

PAULO DE BESSA ANTUNES

DIREITO AMBIENTAL



De acordo com:

- Alterações no Estatuto da Cidade
– Lei 13.699/2018
- Alterações no Estatuto da Metrópole
– Lei 13.683/2018
- Destinação e aplicação dos recursos
de compensação ambiental
– Lei 13.668/2018



DIREITO AMBIENTAL



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de concursos, ciências jurídicas, humanas, exatas, da saúde e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

PAULO DE BESSA ANTUNES

DIREITO AMBIENTAL



- A EDITORA ATLAS se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.
- Nas obras em que há material suplementar *on-line*, o acesso a esse material será disponibilizado somente durante a vigência da respectiva edição. Não obstante, a editora poderá franquear o acesso a ele por mais uma edição.
- Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2019 by

EDITORA ATLAS LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Rua Conselheiro Nébias, 1384 – Campos Elíseos – 01203-904 – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5080-0770 / (21) 3543-0770

faleconosco@grupogen.com.br / www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).

Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

- Capa: Fabricio Vale
Produção digital: Geethik

- Data de fechamento: 28.01.2019

- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

A643d

Antunes, Paulo de Bessa

Direito Ambiental / Paulo de Bessa Antunes. – 20. ed. – São Paulo: Atlas, 2019.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-97-01680-2

1. Direito ambiental – Brasil. I. Título.

18-48398

CDU: 349.6:347.9(81)

Leandra Felix da Cruz – Bibliotecária – CRB-7/6135

A obra *Direito Ambiental* atinge sua 20ª edição, buscando manter o compromisso de atualização constante. Nesta edição foram feitas alterações relevantes no texto, cortando-se excessos para tornar a leitura mais agradável e direta. Preservou-se o essencial, com vistas a propiciar o melhor para os leitores.

Mais uma vez, agradeço a consideração do público leitor com a obra.

O Autor

1 O DIREITO AMBIENTAL

- 1.1 Apresentação
- 1.2 Direito ambiental: conceito
 - 1.2.1 A vertente econômica do Direito Ambiental
 - 1.2.2 A vertente humana do Direito Ambiental
- 1.3 Autonomia do direito ambiental
- 1.4 Princípios do direito ambiental
 - 1.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana
 - 1.4.2 Princípio do desenvolvimento
 - 1.4.3 Princípio democrático
 - 1.4.4 Princípio da precaução
 - 1.4.5 Princípio da prevenção
 - 1.4.6 Princípio do equilíbrio
 - 1.4.7 Princípio da capacidade de suporte
 - 1.4.8 Princípio da responsabilidade
 - 1.4.9 Princípio do poluidor pagador
 - 1.4.10 Conclusão
- 1.5 Fontes do direito ambiental
 - 1.5.1 Fontes materiais
 - 1.5.1.1 Movimentos populares
 - 1.5.1.2 Descobertas científicas
 - 1.5.1.3 Doutrina jurídica
 - 1.5.2 Fontes formais
- 1.6 Relações do direito ambiental com outros ramos do direito
- 1.7 Metodologia do direito ambiental

2 A ORDEM CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE

§ 1ª AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E O MEIO AMBIENTE

- 2.1 Introdução
- 2.2 O período republicano
- 2.3 A Constituição de 1988
 - 2.3.1 Aspectos gerais da Constituição de 1988
 - 2.3.2 O artigo 225 da CF de 1988
 - 2.3.2.1 Conceito normativo de meio ambiente
 - 2.3.2.2 Direito Ambiental e direitos humanos
 - 2.3.3 Direito Ambiental e indisponibilidade de direitos
 - 2.3.3.1 O estreitamento do conceito de indisponibilidade de direitos
 - 2.3.3.2 A “indisponibilidade” de direitos no Direito Ambiental
 - 2.3.4 A equivalência entre dano ambiental e valor econômico
 - 2.3.4.1 Transação em matéria ambiental
 - 2.3.4.2 A conciliação em ações ambientais
- 2.4 Aplicabilidade das normas
- 2.5 A integração de conceitos exteriores ao direito na Constituição

§ 2ª COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL

- 2.6 Introdução
 - 2.6.1 Competência federal
 - 2.6.1.1 Omissões inconstitucionais
 - 2.6.2 Competência estadual
 - 2.6.3 Competência municipal
 - 2.6.3.1 Exercício da competência comum mediante a edição de leis próprias
 - 2.6.4 A questão da aplicação da norma mais restritiva
 - 2.6.5 LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011
 - 2.6.6 Conclusão

3 SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICA AMBIENTAL

§ 1ª SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTAL

- 3.1 O papel de cada um dos poderes da República
 - 3.1.1 Atribuições do Ministério Público
- 3.2 O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA
 - 3.2.1 A PNMA como LC

- 3.3 Órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
 - 3.3.1 Cooperação administrativa
 - 3.3.1.1 Comissões multipartes
 - 3.3.1.2 Delegabilidade de atribuições
 - 3.3.2 Conselho de Governo
 - 3.3.3 O Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama
 - 3.3.3.1 Os órgãos do Conama
 - 3.3.3.2 Competência Recursal do Conama
 - 3.3.3.3 O Conama e a delegação de competências
 - 3.3.3.4 Composição do Conama, separação de poderes e autonomia do Ministério Público
 - 3.3.3.5 Ministério do Meio Ambiente – MMA
 - 3.3.4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama
 - 3.3.4.1 Atribuições do Ibama
 - 3.3.5 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes
- § 2º PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL
- 3.4 O poder de polícia
 - 3.4.1 Conceito normativo de poder de polícia
 - 3.4.2 Ordem pública do meio ambiente
 - 3.4.3 A fiscalização ambiental
 - 3.4.3.1 A fiscalização como expressão do poder de polícia
 - 3.4.3.2 Limites da fiscalização
 - 3.4.3.3 Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-parques
- 3.5 O licenciamento ambiental
 - 3.5.1 Introdução
 - 3.5.2 Cooperação administrativa e licenciamento ambiental
 - 3.5.3 O licenciamento ambiental como processo administrativo
 - 3.5.3.1 Natureza e alcance da Licença Prévia
 - 3.5.3.2 Localização do estudo prévio de impacto ambiental no processo de licenciamento ambiental
 - 3.5.4 O licenciamento federal
 - 3.5.4.1 Procedimento
 - 3.5.4.2 Responsabilidade pela emissão das licenças ambientais
 - 3.5.4.3 O sistema estabelecido pela LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011
 - 3.5.4.4 Intervenção de órgãos externos no licenciamento ambiental
 - 3.5.4.5 Conflitos entre os diferentes órgãos intervenientes no licenciamento ambiental
 - 3.5.5 Itinerário para o licenciamento
 - 3.5.5.1 Licenciamento de petróleo
 - 3.5.5.2 Licenciamento ambiental para empreendimentos elétricos de pequeno porte
 - 3.5.5.3 Licenciamento de portos
- 3.6 Zoneamento
 - 3.6.1 Zoneamento ambiental
 - 3.6.1.1 Zoneamento federal
 - 3.6.1.2 Zoneamento estadual
 - 3.6.1.3 Zoneamento municipal
 - 3.6.1.4 Zoneamento ambiental urbano
 - 3.6.1.5 Zonas de Uso Industrial (ZUI)
 - 3.6.1.6 Direito de pré-ocupação e realocização
 - 3.6.1.7 Posição dos tribunais
 - 3.6.1.8 Zona de Uso Estritamente Industrial (ZEI)
 - 3.6.1.9 Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI)
 - 3.6.1.10 Zona de Uso Diversificado (ZUD)
 - 3.6.2 Zoneamento agrícola
 - 3.6.3 Zoneamento costeiro

4 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 4.1 Introdução
 - 4.1.1 Violação do princípio da reserva de lei
- 4.2 Infrações administrativas: sanções
 - 4.2.1 Autuação
 - 4.2.1.1 Autuação de advertência
 - 4.2.1.2 Multas
 - 4.2.1.3 Demais sanções administrativas
 - 4.2.1.4 Prazos prescricionais
- 4.3 Infrações administrativas contra o meio ambiente
 - 4.3.1 Infrações contra a fauna
 - 4.3.2 Infrações contra a flora
 - 4.3.3 Infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais
 - 4.3.4 Infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural
 - 4.3.5 Infrações administrativas contra a administração ambiental

- 4.3.6 Infrações cometidas exclusivamente em Unidades de Conservação
- 4.3.7 Aspectos relevantes do processo administrativo
- 4.3.8 Destinação dos bens e animais apreendidos
- 4.3.9 A conversão da multa em serviços ambientais

5 A PROTEÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

- 5.1 Introdução
- 5.2 O Poder Judiciário
 - 5.2.1 O STF e o STJ na proteção ambiental
 - 5.2.2 A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a proteção ambiental
 - 5.2.3 A Justiça dos Estados e a proteção ambiental
- 5.3 O Ministério Público
 - 5.3.1 A base constitucional da atuação do Ministério Público
- 5.4 Defensoria Pública
- 5.5 Principais meios judiciais de proteção ambiental
 - 5.5.1 Ação civil pública
 - 5.5.1.1 Competência para o processamento e julgamento das ações civis públicas
 - 5.5.1.2 Prescrição
 - 5.5.1.3 Legitimidade ativa
 - 5.5.1.4 Ministério Público como parte legítima da ACP
 - 5.5.2 Mandado de segurança coletivo
 - 5.5.3 Ação popular
 - 5.5.4 Desapropriação
 - 5.5.5 Tombamento

6 RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS

- 6.1 Introdução
- 6.2 A responsabilidade ambiental na Constituição Federal
- 6.3 As responsabilidades ambientais
 - 6.3.1 Culpa como fundamento da responsabilidade
 - 6.3.2 A responsabilidade por risco
 - 6.3.2.1 Responsabilidade por risco em matéria ambiental
 - 6.3.3 Responsabilidade de instituições financeiras
 - 6.3.4 Responsabilidade ambiental das instituições de crédito imobiliário
 - 6.3.5 Crédito rural e meio ambiente: responsabilidade
 - 6.3.6 A tarifação da responsabilidade ambiental
- 6.4 Responsabilidade civil e excludentes de responsabilidade ambiental na jurisprudência majoritária do STJ
 - 6.4.1 Introdução ao tema
 - 6.4.2 Risco
 - 6.4.2.1 Teoria do Risco Integral na visão do STJ: síntese
 - 6.4.2.2 Renascimento da teoria do risco integral
 - 6.4.2.3 Responsabilidade objetiva e atividades de grande impacto
 - 6.4.3 Doutrina nacional e responsabilidade ambiental por risco integral
 - 6.4.4 Exclusão de responsabilidade ambiental
 - 6.4.5 A inexistência da exclusão da responsabilidade como estímulo ao comportamento antiambiental
- 6.5 O conceito de dano
 - 6.5.1 O dano ambiental
 - 6.5.1.1 Dano moral ambiental
- 6.6 Reparação do dano ambiental
 - 6.6.1 A apuração do dano ambiental

7 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

§ 1º IMPACTO AMBIENTAL

- 7.1 Definições de impacto, meio ambiente e de impacto ambiental
 - 7.1.1 Conceitos normativos de meio ambiente e impacto ambiental

§ 2º BASES CONSTITUCIONAIS

- 7.2 A legislação ordinária
 - 7.2.1 Áreas críticas de poluição e avaliação de impactos ambientais
 - 7.2.2 A avaliação dos impactos ambientais prevista na Lei nº 6.803/1980
 - 7.2.3 O estudo de impacto ambiental na Lei nº 6.938/81

§ 3º NATUREZA JURÍDICA DO EIA

- 7.3 Natureza jurídica do eia
 - 7.3.1 Formalidades do estudo de impacto ambiental
- 7.4 O EIA e a administração pública
 - 7.4.1 Publicidade
 - 7.4.2 Vinculação da Administração ao EIA

§ 4º REQUISITOS DO EIA

- 7.5 Requisitos de conteúdo
 - 7.5.1 Alternativas tecnológicas e de implantação
 - 7.5.2 Impactos ambientais gerados na fase de implantação e na fase de operação
 - 7.5.3 Área geográfica a ser diretamente atingida
 - 7.5.4 Consideração de planos e programas governamentais
 - 7.5.5 Impactos sociais e humanos
- 7.6 Requisitos técnicos
- 7.7 Requisitos formais
 - 7.7.1 Equipe técnica habilitada
 - 7.7.1.1 Independência da equipe técnica
 - 7.7.2 Informação incompleta
 - 7.7.3 Despesas
 - 7.7.3.1 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental
 - 7.7.4 O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA
- 7.8 Audiência pública
 - 7.8.1 Convocação
 - 7.8.2 Realização da audiência
 - 7.8.3 Função da audiência

8 A PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMBIENTE URBANO

- 8.1 Introdução
- 8.2 Preceitos constitucionais
- 8.3 Instrumentos da política urbana
 - 8.3.1 Instrumentos com imediata repercussão ambiental
 - 8.3.1.1 Direito de preempção
 - 8.3.1.2 Transferência do direito de construir
 - 8.3.1.3 Concessão de uso especial
 - 8.3.1.4 Estudo de Impacto de Vizinhança
 - 8.3.2 Plano Diretor e gestão democrática da cidade
 - 8.3.2.1 Elaboração democrática das normas do Plano Diretor
 - 8.3.2.2 Obrigatoriedade do Plano Diretor
 - 8.3.2.3 Gestão democrática da cidade
- 8.4 Aplicação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, em áreas urbanas
 - 8.4.1 Legislação aplicável
- 8.5 Transporte urbano e meio ambiente
- 8.6 Conclusão

9 DIVERSIDADE BIOLÓGICA

§ 1ª INTRODUÇÃO AO TEMA

- 9.1 O Brasil e a perda da diversidade biológica
 - 9.1.1 Amazônia
 - 9.1.2 Mata Atlântica
- 9.2 Diversidade biológica e atividade econômica
- 9.3 A proteção do conhecimento tradicional associado
 - 9.3.1 Direitos das comunidades indígenas e das comunidades locais
 - 9.3.1.1 Comunidades indígenas
 - 9.3.2 Comunidades locais
 - 9.3.3 Experiência brasileira de utilização do conhecimento tradicional associado
 - 9.3.3.1 Carta de São Luís do Maranhão
 - 9.3.4 Registro do conhecimento tradicional associado
 - 9.3.4.1 Registro do Patrimônio imaterial e dos conhecimentos tradicionais associados

§ 2ª PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA (PRINCIPAIS DOCUMENTOS)

- 9.4 Principais documentos internacionais assinados pelo Brasil
 - 9.4.1 Convenção sobre Diversidade Biológica
 - 9.4.1.1 Objetivos da CDB
 - 9.4.1.2 Soberania e diversidade biológica
 - 9.4.1.3 Medidas de proteção da diversidade biológica
 - 9.4.1.4 Utilização sustentável de componentes da diversidade biológica
 - 9.4.1.5 Acesso a recursos genéticos
 - 9.4.1.6 Acesso à tecnologia e sua transferência
 - 9.4.2 Agenda 21
 - 9.4.3 Convenção de RAMSAR
 - 9.4.3.1 Indicação pelas partes de áreas a serem incluídas na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional
 - 9.4.4 Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção – Cites
 - 9.4.4.1 Relação entre a Cites e outras convenções internacionais e a legislação nacional
 - 9.4.4.2 Procedimentos necessários ao comércio internacional de espécies (espécies integrantes dos Anexos I, II e III da Cites)
 - 9.4.4.3 Não incidência das normas da Cites

§ 3º ACESSO À DIVERSIDADE BIOLÓGICA NO BRASIL

- 9.5 O quadro jurídico do acesso à biodiversidade
 - 9.5.1 Conceitos normativos
 - 9.5.2 Patrimônio genético
 - 9.5.2.1 Inaplicabilidade das normas e vedação de acesso
 - 9.5.2.2 Gestão do patrimônio genético
 - 9.5.2.3 Repartição de benefícios
 - 9.5.2.4 Cláusulas contratuais cogentes
- § 4º POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE
- 9.6 Princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade
 - 9.6.1 Princípios referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados
- 9.7 Diretrizes da política nacional da biodiversidade
- 9.8 Componentes da política nacional da biodiversidade

10 A VEGETAÇÃO NATIVA E SUA PROTEÇÃO LEGAL

- 10.1 Os diversos tipos de floresta
 - 10.1.1 Floresta boreal
 - 10.1.2 Floresta temperada
 - 10.1.3 Floresta tropical
 - 10.1.3.1 Florestas brasileiras
- 10.2 A legislação brasileira de proteção florestal
 - 10.2.1 Lei nº 12.651/2012
 - 10.2.2 Constituição de 1988
 - 10.2.3 Política florestal dos Estados
 - 10.2.4 O regime jurídico das florestas
 - 10.2.4.1 O conceito jurídico de floresta
 - 10.2.5 Áreas de preservação permanente pelo efeito da Lei nº 12.651/2012
 - 10.2.6 Florestas de Preservação Permanente por interesse social
 - 10.2.7 Áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente (normas de regularização de ilícitos passados)
- 10.3 O exercício do direito de propriedade em áreas florestadas
 - 10.3.1 Contorno jurídico da propriedade florestal
 - 10.3.2 As limitações decorrentes da condição de bem de interesse comum
 - 10.3.3 Reserva (florestal) legal
 - 10.3.3.1 Conceito normativo de reserva (florestal) legal
 - 10.3.3.2 A reserva legal como interesse dos habitantes do país
 - 10.3.3.3 A reserva (florestal) legal como obrigação e regime de proteção
 - 10.3.3.4 Proteção florestal e desapropriação
- 10.4 O Supremo Tribunal Federal e o Código Florestal
- 10.5 A floresta, os desmatamentos e a utilização de fogo
 - 10.5.1 Desflorestamento e queimadas
 - 10.5.2 Regime legal da utilização do fogo
 - 10.5.2.1 Proibição do uso de fogo
 - 10.5.2.2 Ordenamento e suspensão temporária do emprego de fogo
 - 10.5.2.3 Redução gradativa do emprego de fogo

11 ESPAÇOS TERRITORIAIS (ÁREAS) ESPECIALMENTE PROTEGIDOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

- 11.1 Introdução
- 11.2 Fundamentos constitucionais dos ETEPs e das UCs
 - 11.2.1 A separação constitucional entre legislação sobre conservação da natureza e proteção de florestas
 - 11.2.1.1 Competências constitucionais: previsão de lei especial para a criação de Unidades de Conservação
 - 11.2.2 Áreas protegidas diretamente pela Constituição Federal
 - 11.2.3 Patrimônio Nacional
- 11.3 Os diferentes espaços territoriais especialmente protegidos
 - 11.3.1 Turismo e áreas protegidas
 - 11.3.1.1 Unidades de Conservação, Código Florestal e a aplicação da legislação especial
 - 11.3.2 Breve histórico da legislação
- 11.4 As unidades de conservação
 - 11.4.1 Unidades de conservação e direitos de propriedade constitucional
 - 11.4.1.1 Princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e ao direito de propriedade
 - 11.4.1.2 Criação de unidades de conservação e vinculação
 - 11.4.1.3 Conceitos normativos aplicáveis às unidades de conservação
 - 11.4.1.4 Objetivos do SNUC
- 11.5 Reserva Nacional de Cobre e seus associados
 - 11.5.1 Órgãos integrantes do SNUC
 - 11.5.2 As unidades de conservação: seus diferentes tipos e funções
 - 11.5.2.1 Unidades de proteção integral
 - 11.5.2.2 Unidades de uso sustentável

- 11.5.3 Reserva da biosfera
 - 11.5.3.1 Regulamentação
 - 11.5.3.2 Criação, implantação e gestão das unidades de conservação
- 11.5.4 Conservação *ex-situ*
- 11.6 A exigibilidade legal da compensação ambiental: delimitação dos danos
 - 11.6.1 As intervenções aptas a gerar a compensação ambiental
 - 11.6.1.1 A natureza dos danos capazes de gerar compensação ambiental
 - 11.6.1.2 O impacto significativo e não mitigável
- 11.7 A exigibilidade da compensação ambiental: aspectos formais
 - 11.7.1 Termo inicial (*dies a quo*) para a exigência da compensação ambiental
 - 11.7.2 Implantação do empreendimento: conceito
 - 11.7.2.1 Compensação ambiental e empreendimentos já implantados
 - 11.7.2.2 Extensão da compensação ambiental em relação ao volume de recursos investidos pelo empreendedor
- 11.8 Ampla defesa e compensação ambiental
- 11.9 Execução da Compensação ambiental

12 BIOSSEGURANÇA

- 12.1 Objetivos, conceitos e proibições da lei de biossegurança
- 12.2 Estrutura administrativa de biossegurança
 - 12.2.1 Conselho Nacional de Biossegurança
 - 12.2.1.1 Atribuições e competências
 - 12.2.1.2 Composição
 - 12.2.2 A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio
 - 12.2.2.1 Composição da CTNBio
 - 12.2.2.2 Funcionamento da CTNBio
 - 12.2.2.3 Competência da CTNBio
 - 12.2.3 Comissão Interna de Biossegurança
 - 12.2.4 Registro de OGM
- 12.3 Responsabilidade civil, administrativa e penal

13 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

- 13.1 Introdução
- 13.2 Abrangência
- 13.3 Conceitos normativos
- 13.4 Concepção geral
- 13.5 Instrumentos
- 13.6 Diretrizes
- 13.7 Competências
- 13.8 Classificação dos resíduos sólidos
- 13.9 Planos de resíduos sólidos
- 13.10 Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos
- 13.11 Plano de gerenciamento de resíduos sólidos
- 13.12 Responsabilidades dos geradores e dos poderes públicos
 - 13.12.1 Responsabilidade compartilhada
 - 13.12.2 Embalagens
 - 13.12.3 Logística reversa
- 13.13 Resíduos perigosos
 - 13.13.1 Seguro e áreas órfãs
- 13.14 Instrumentos econômicos
- 13.15 Proibições
- 13.16 Regulamentação: Decreto nº 7.404/2010
 - 13.16.1 Introdução
 - 13.16.2 Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos
 - 13.16.3 Responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e do poder público
 - 13.16.4 Responsabilidade dos consumidores e coleta seletiva
 - 13.16.5 Logística reversa
 - 13.16.5.1 Acordos setoriais
 - 13.16.5.2 Termos de compromisso
 - 13.16.5.3 Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa
 - 13.16.5.4 Diretrizes aplicáveis à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos
 - 13.16.5.5 Participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis
 - 13.16.6 Planos de resíduos sólidos
 - 13.16.6.1 Planos de resíduos sólidos elaborados pelo poder público
 - 13.16.6.2 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos
 - 13.16.7 Resíduos perigosos
 - 13.16.7.1 Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos
 - 13.16.7.2 Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR

- 13.16.8 Educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos
- 13.16.9 Condições de acesso a recursos técnicos, econômicos e financeiros
- 13.16.10 Instrumentos econômicos
- 13.16.11 Infrações administrativas

14 SANEAMENTO BÁSICO

- 14.1 Introdução
- 14.2 Diretrizes e política federal de saneamento básico
 - 14.2.1 Conceitos normativos aplicáveis
- 14.3 Titularidade dos serviços públicos de saneamento básico
 - 14.3.1 Prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico
 - 14.3.1.1 Decisão do Supremo Tribunal Federal
- 14.4 Planejamento
- 14.5 Regulação
 - 14.5.1 Aspectos técnicos e ambientais
 - 14.5.2 Participação de órgãos colegiados no controle social
- 14.6 Política federal de saneamento básico
- 14.7 Regulamento da lei (Decreto nº 7.217/2010): aspectos ambientais
 - 14.7.1 Esgotamento sanitário
 - 14.7.2 Resíduos sólidos
 - 14.7.3 Águas pluviais urbanas
 - 14.7.4 Serviços públicos de saneamento básico e recursos hídricos
 - 14.7.5 Licenciamento ambiental

15 REGIME JURÍDICO DOS RECURSOS HÍDRICOS

§ 1ª DIREITO DOS RECURSOS HÍDRICOS

- 15.1 A importância das águas
- 15.2 A água nas constituições brasileiras
 - 15.2.1 As águas nas Constituições anteriores a 1988
 - 15.2.1.1 Constituição imperial
 - 15.2.1.2 Período republicano
 - 15.2.2 As águas na Constituição de 1988
 - 15.2.2.1 Domínio da União
 - 15.2.2.2 Domínio dos Estados
 - 15.2.2.3 Competência legislativa
 - 15.2.2.4 Mudança de concepção
- 15.3 O regime jurídico dos recursos hídricos
 - 15.3.1 Água: sua definição
 - 15.3.2 Conceitos básicos do Código de Águas
 - 15.3.2.1 Outros conceitos importantes
 - 15.3.3 Legislação extravagante de proteção aos recursos hídricos
- 15.4 O valor econômico dos recursos hídricos
 - 15.4.1 Desapropriação de recursos hídricos
 - 15.4.2 Obrigação de conservação da qualidade das águas
 - 15.4.2.1 A regulamentação administrativa das águas
- 15.5 As águas submetidas ao regime jurídico de utilização “privada”
 - 15.5.1 Normas gerais estabelecidas pelo CC brasileiro
 - 15.5.1.1 Regime de prescrição
 - 15.5.2 Normas do Código de Águas referentes ao aproveitamento de águas comuns e particulares
- 15.6 A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH
 - 15.6.1 Princípios gerais da PNRH
 - 15.6.1.1 Objetivos
 - 15.6.2 Instrumentos
 - 15.6.2.1 Outorga de direito de uso de recursos hídricos
 - 15.6.2.2 Cobrança pela utilização dos recursos hídricos
 - 15.6.2.3 Administração dos recursos hídricos
 - 15.6.3 Infrações e penalidades
- 15.7 Agência de água
 - 15.7.1 Organizações civis de recursos hídricos
 - 15.7.2 Agência Nacional de Águas – ANA
 - 15.7.2.1 Apresentação
 - 15.7.2.2 Competências da ANA
 - 15.7.3 Estrutura administrativa da Agência Nacional de Águas – ANA
 - 15.7.3.1 Diretoria: composição
 - 15.7.3.2 Atividades vedadas aos dirigentes
 - 15.7.3.3 Atribuições da diretoria

§ 2ª POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

- 15.8 Âmbito de aplicação e definições
- 15.9 Objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens
- 15.10 Princípios fundamentais da Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB
- 15.11 Poder de polícia
- 15.12 Instrumentos da PNSB
 - 15.12.1 Plano de Segurança da Barragem
 - 15.12.2 Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)
- 15.13 Sanções
- 15.14 Política Nacional de Irrigação
 - 15.14.1 A Política Nacional de Irrigação – aspectos gerais
 - 15.14.2 Licenciamento ambiental
- 15.15 Poluição hídrica por óleos
- 15.16 A Convenção Marpol
 - 15.16.1 Conteúdo dos Anexos
- 15.17 A Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000
 - 15.17.1 Objetivos e definições da lei
 - 15.17.1.1 Glossário da Lei nº 9.966/2000
 - 15.17.2 Classificação das substâncias quanto ao perigo ou nocividade
 - 15.17.2.1 Sistemas de prevenção, controle e combate da poluição
 - 15.17.3 Descarga em águas jurisdicionais nacionais de óleo, substâncias nocivas ou perigosas e lixo
 - 15.17.3.1 Ressarcimento de custos de combate à poluição
 - 15.17.4 Poder de polícia em matéria de poluição por óleo
 - 15.17.4.1 Repartição das atribuições de polícia
 - 15.17.5 Infrações administrativas
 - 15.17.5.1 Responsabilidade
- 15.18 Alijamento em águas sob jurisdição nacional
 - 15.18.1 Definições
 - 15.18.2 Proibição de alijamento
 - 15.18.2.1 Bens alijados no mar

16 MINERAÇÃO

- 16.1 A mineração nas constituições brasileiras
 - 16.1.1 Constituições anteriores
 - 16.1.2 A mineração na Constituição de 1988
 - 16.1.2.1 Disposições constitucionais
 - 16.1.2.2 Breve análise das disposições constitucionais à luz do artigo 225, § 2º
- 16.2 O código de mineração
 - 16.2.1 Classificação das jazidas minerais
 - 16.2.2 O Código de Minas e a proteção do meio ambiente
- 16.3 Mineração em terras indígenas
- 16.4 Mineração e meio ambiente
 - 16.4.1 Licenciamento das atividades de mineração
 - 16.4.2 Estudos de impacto ambiental e atividades de mineração
 - 16.4.2.1 Ilegalidades existentes na Resolução nº 9/90 do Conama
 - 16.4.2.2 A extinção das classes minerais e os estudos de impacto ambiental
 - 16.4.2.3 Atividades com repercussões ambientais em áreas indígenas
 - 16.4.3 Obrigação de recuperação ambiental da área degradada
 - 16.4.4 Cavernas
 - 16.4.4.1 Proteção ao patrimônio espeleológico

17 CONTROLE DE PRODUTOS TÓXICOS

§ 1º PRODUTOS TÓXICOS EM GERAL

- 17.1 Introdução
- 17.2 Controle de produtos perigosos
 - 17.2.1 Convenções internacionais
 - 17.2.1.1 Convenção de Basileia
 - 17.2.1.2 Convenção de Roterdã
 - 17.2.1.3 Convenção de Estocolmo
 - 17.2.2 Normas internas
 - 17.2.2.1 Asbestos (amianto)
 - 17.2.2.2 Quadro legal sobre a matéria
 - 17.2.2.3 Competência concorrente e amianto
 - 17.2.2.4 Doença ocupacional e indenização
 - 17.2.2.5 Conclusão
 - 17.2.3 Ascarel
 - 17.2.3.1 Portaria Interministerial nº 19, de 29 de janeiro de 1981 (Ministério do Interior, da Indústria e do Comércio e das Minas e Energia)

	17.2.3.2	Resolução Conama nº 6, de 15 de junho de 1988
17.2.4		Ascarel em juízo
17.2.5		Mercúrio
	17.2.5.1	O controle dos metais pesados no Brasil
	17.2.5.2	Limite legal de concentração de mercúrio na água
17.2.6		Benzeno
17.2.7		Cloro
	17.2.7.1	Importância do Cloro
	17.2.7.2	A Regulamentação legal da produção de cloro no Brasil
	17.2.7.3	Ampliação e modificação de indústrias já instaladas
	17.2.7.4	Penalidades
17.2.8		Pilhas e baterias
	17.2.8.1	Aspectos gerais
	17.2.8.2	Definição de pilhas e baterias
	17.2.8.3	Obrigações
17.3		Transporte de produtos tóxicos
	17.3.1	Condições de transporte
17.4		Transporte de produtos perigosos entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
	17.4.1	Acordo de alcance parcial para a facilitação do transporte de produtos perigosos
	17.4.1.1	Embalagens
	17.4.1.2	Vículos
	17.4.2	Normas técnicas
17.5		Transporte ferroviário
	17.5.1	Aplicabilidade do regulamento
§ 2ª AGROTÓXICOS		
17.6		Regime legal dos agrotóxicos
	17.6.1	Antecedentes legislativos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989
	17.6.1.1	Decreto nº 24.414, de 12 de abril de 1934
17.7		A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989
	17.7.1	Repartições de Competências Administrativas no Interior da Administração Federal
	17.7.1.1	Competências dos Ministérios da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente
	17.7.1.2	Competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
	17.7.1.3	Competências do Ministério da Saúde
	17.7.1.4	Competências do Ministério do Meio Ambiente
	17.7.1.5	Competências do Ministério do Trabalho e Emprego
	17.7.2	Definição legal de agrotóxico, seus componentes e afins
17.7.3		Controle de qualidade, inspeção e fiscalização dos agrotóxicos
	17.7.3.1	Controle de qualidade
	17.7.3.2	Inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins
	17.7.3.3	Atribuições da fiscalização
	17.7.4	Registro de pessoas física e jurídica
	17.7.5	Alerta de organizações internacionais e seus reflexos no Brasil
	17.7.6	Registro do produto
	17.7.6.1	Produtos para exportação
17.8		Responsabilidade
	17.8.1	Responsabilidade criminal
	17.8.2	Responsabilidade administrativa
	17.8.2.1	Infrações
17.9		Comercialização dos agrotóxicos
	17.9.1	Receituário agrônômico
	17.9.2	Embalagem, fracionamento e rotulagem
	17.9.3	Destinação final dos agrotóxicos

18 POLÍTICA ENERGÉTICA E MEIO AMBIENTE

18.1		Introdução
18.2		Política energética nacional
	18.2.1	Princípios e objetivos da política energética nacional
	18.2.2	Conselho Nacional de Política Energética
	18.2.2.1	Finalidade e composição
	18.2.2.2	Funcionamento do CNPE
18.3		O Petróleo na Política Energética Nacional
	18.3.1	A Exploração e Produção (E&P) de petróleo no Brasil
	18.3.2	Regime legal do petróleo no Brasil
	18.3.2.1	Dispositivos constitucionais
	18.3.2.2	Glossário da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997
	18.3.2.3	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
	18.3.2.4	Exploração e produção (aspectos ambientais)

- 18.4 Política Nacional de Conservação de Energia
 - 18.4.1 Penalidades
 - 18.4.2 Regulamentação da Política Nacional de Conservação de Energia
 - 18.4.2.1 Composição e atribuições do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE
 - 18.4.3 Energia renovável: iniciativa energética
- 18.5 Política Nacional de Mudanças Climáticas
 - 18.5.1 Introdução
 - 18.5.2 A Política Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC
 - 18.5.2.1 Redução de emissões de GEE?

19 ENERGIA NUCLEAR

§ 1ª A ENERGIA NUCLEAR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- 19.1 Competências em matéria nuclear
 - 19.1.1 Competências da União
 - 19.1.1.1 Administrativa
 - 19.1.1.2 Legislativa
 - 19.1.2 As competências dos Estados e dos Municípios em matéria nuclear
 - 19.1.3 Análise da estrutura de competências
 - 19.1.4 Inserção da atividade nuclear na ordem econômica
- 19.2 Tratamento democrático do problema nuclear na Constituição de 1988
- 19.3 O Brasil na comunidade nuclear internacional

§ 2ª OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR

- 19.4 Acidentes nucleares na utilização pacífica da energia nuclear
 - 19.4.1 *Three Mile Island*
 - 19.4.2 Chernobyl
 - 19.4.3 Goiânia
- 19.5 Fukushima
 - 19.5.1 Jurisprudência

§ 3ª REJEITOS NUCLEARES

- 19.6 Os rejeitos nucleares: breve definição
- 19.7 Alguns aspectos internacionais do problema
- 19.8 O problema no Brasil
 - 19.8.1 O Césio 137
 - 19.8.2 Destinação final de rejeitos radioativos
 - 19.8.2.1 Responsabilidade pelos rejeitos radioativos
 - 19.8.2.2 Tipos de depósitos de rejeitos radioativos
 - 19.8.2.3 Responsabilidade civil

§ 4ª RESPONSABILIDADE CRIMINAL EM MATÉRIA NUCLEAR

- 19.9 A responsabilidade criminal em matéria nuclear
 - 19.9.1 Os crimes previstos na Lei nº 6.453/77
 - 19.9.1.1 Os tipos legais previstos na Lei nº 6.453/77
 - 19.9.2 A utilização do Código Penal
 - 19.9.3 Lei de Crimes Ambientais

20 TERRAS INDÍGENAS

§ 1ª LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Terras indígenas – Introdução

- 20.1 Os primeiros contatos com o colonizador
 - 20.1.1 O Regimento de Tomé de Souza
 - 20.1.2 A escravização dos indígenas
- 20.2 O índio nas Constituições Brasileiras
 - 20.2.1 Dispositivos da Constituição de 1988
 - 20.2.1.1 Dispositivos específicos
 - 20.2.2 Conclusão
- § 2ª AS TERRAS INDÍGENAS, A EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E O CONSENTIMENTO PRÉVIO LIVRE E INFORMADO
- 20.3 Histórico da legislação
 - 20.3.1 Do período colonial até o século XIX
 - 20.3.2 O período republicano
- 20.4 As terras indígenas na Constituição de 1988
 - 20.4.1 Antecedentes
 - 20.4.2 Direitos adquiridos sobre as terras indígenas
 - 20.4.3 Classificação das terras indígenas pelo Estatuto do Índio
 - 20.4.4 A extração de madeira nas terras indígenas
 - 20.4.5 Terras indígenas e soberania nacional
- 20.5 A demarcação das terras indígenas
 - 20.5.1 O Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996
- 20.6 Direito de propriedade, terras indígenas e etnogênese

- 20.7 Gestão Territorial de Terras indígenas
 - 20.7.1 Objetivos da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas
- 20.8 A Exploração de Recursos Naturais em Terras Indígenas: O Consentimento prévio livre e informado
 - 20.8.1 Bases legais do Consentimento Prévio Livre e Informado
 - 20.8.1.1 Em nível internacional
 - 20.8.1.2 Convenção Sobre Diversidade Biológica – Decreto legislativo nº 2/1994
 - 20.8.1.3 Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas
 - 20.8.2 Brasil
 - 20.8.3 O tema no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos
 - 20.8.3.1 O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos
 - 20.8.3.2 Decisões do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos
 - 20.8.3.3 Decisões Judiciais
 - 20.8.4 Instituições de Fomento Econômico e o Consentimento Prévio Livre e Informado
 - 20.8.5 Conclusões
- § 3ª A LEGISLAÇÃO PENAL E OS INDÍGENAS
 - 20.9 Aspectos gerais
 - 20.10 Legislação penal específica (Lei nº 6.001/73)
 - 20.10.1 Principiologia em relação ao agente indígena
 - 20.10.2 Crimes praticados contra os indígenas e suas comunidades
 - 20.10.2.1 Crimes previstos no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73)
 - 20.10.2.2 Genocídio (Lei nº 2.889/56)
 - 20.10.2.3 Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/89)
 - 20.10.2.4 Lavra garimpeira (Lei nº 7.805/89)
 - 20.10.2.5 Crimes praticados pelos índios

Referências bibliográficas

Nota da Editora: as alterações na organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, estabelecidas pela Medida Provisória 870/2019, não foram incorporadas ao conteúdo da obra tendo em vista que, até o fechamento desta edição, as novas estruturas regimentais que constam nos Decretos regulamentadores não estavam em vigor (início previsto para 30.01.2019).

O DIREITO AMBIENTAL

1.1 APRESENTAÇÃO

O Direito Ambiental é um dos mais recentes setores do Direito moderno e, com toda a certeza, é um dos que têm sofrido as mais relevantes modificações, crescendo de importância na ordem jurídica internacional e nacional. Como em toda novidade, existem incompreensões e incongruências sobre o papel que ele deve desempenhar na sociedade, na economia e na vida em geral. A sua implementação não se faz sem dificuldades das mais variadas origens, indo desde as conceituais até as operacionais.

A função primordial do Direito Ambiental é organizar a forma pela qual a sociedade se utiliza dos recursos ambientais, estabelecendo métodos, critérios, proibições e permissões, definindo o que pode e o que não pode ser apropriado economicamente (ambientalmente). Não satisfeito, vai além. Ele estabelece *como* a apropriação econômica (ambiental) pode ser feita. Assim, não é difícil perceber que o Direito Ambiental é um regulador da atividade econômica, pois ela se faz sobre a base de uma infraestrutura que consome recursos naturais.

O surgimento do Direito Ambiental como disciplina jurídica denota que as relações entre o Homem (*antropo*) e o mundo que o envolve vêm se modificando de forma muito acelerada e profunda. O Direito Ambiental é um dos mais marcantes instrumentos de intervenção em tal realidade. Thornton e Beckwith (1997, p. 2) nos chamam a atenção para o fato de que uma definição de Direito Ambiental vai depender muito da definição de meio ambiente, pois uma é subordinada à outra. Todavia, muitas vezes as definições de meio ambiente são extremamente amplas e, portanto, pouco operacionais. Einstein – o genial físico –, definiu ambiente como tudo que não seja eu. Ora, se adotarmos um conceito tão amplo como o de Einstein, tudo estará compreendido no Direito Ambiental e, portanto, ele seria uma espécie de Pandireito capaz de abarcar toda e qualquer atividade humana, o que, evidentemente, é um despropósito. É claro que, ao tratarmos de Direito Ambiental, não estamos falando de toda e qualquer atividade humana. Falamos fundamentalmente daquelas atividades que afetam as águas, a fauna, as florestas, o solo e o ar em especial. Normalmente, as leis que tratam desses temas definem padrões de lançamento de substâncias químicas, de partículas, padrões de qualidade, proteção de espécies animais e vegetais. Certamente, muitas zonas de interseção com diversos outros campos do direito existem. Daí, a definição de limites é essencial para que o Direito Ambiental possa cumprir a sua principal missão, que é servir como marco regulatório e normativo das atividades humanas em relação ao meio ambiente.

O objetivo deste capítulo, portanto, é o exame da Teoria do Direito Ambiental como parte da Teoria Geral do Direito, de forma a destacar o que ela tem de comum e de singular, indicando de forma clara qual o significado e papel do Direito Ambiental na ordem jurídica contemporânea. A importância de investigar as peculiaridades do Direito Ambiental e das normas jurídicas destinadas à proteção do meio ambiente pode ser avaliada pelo fato de que sempre houve normas voltadas para a tutela da natureza. Tal proteção, quase sempre, fazia-se através de normas de direito privado que protegiam as relações de vizinhança, ou mesmo por normas de Direito Penal ou Administrativo, que sancionavam o mau uso dos elementos naturais ou a utilização de forma prejudicial a terceiros. Entretanto, os novos tempos demandam outra concepção de proteção jurídica da natureza. É por isso que o Direito Ambiental não se confunde com as formas de proteção jurídica dos bens naturais que o antecederam, sendo de fato um setor específico da ordem jurídica.

As diferenças fundamentais entre a proteção jurídica dos bens ambientais feitas no passado e a tutela conferida pelo Direito Ambiental são:

- modificação ontológica da tutela conferida aos bens naturais;
- flexibilização dos conceitos de direito público e direito privado;
- flexibilização dos conceitos de direito interno e direito internacional;
- integração entre diversas áreas do conhecimento humano na aplicação da ordem jurídica;
- consideração do desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente e com a integração das populações nos benefícios gerados pelo desenvolvimento.

1.2 DIREITO AMBIENTAL: CONCEITO

Metodologicamente, só se pode saber o que é o Direito Ambiental após se ter conhecimento do que é (i) Direito e o que é (ii) meio ambiente ou ambiente.

Miguel Reale (1973), em conhecida formulação, aduzia que o Direito é interação tridimensional de norma, fato e valor.

“A integração de três elementos na experiência jurídica (o axiológico, o fático e técnico-formal) revela-nos a precariedade de qualquer compreensão do Direito isoladamente como fato, como valor ou como norma, e, de maneira especial, o equívoco de uma compreensão do Direito como pura forma, suscetível de albergar, com total indiferença, as infinitas e conflitantes possibilidades dos interesses humanos” (REALE, 1993, p. 701-702).

O *fato* que se encontra à base do Direito Ambiental é a própria vida humana, que necessita de recursos ambientais para a sua reprodução, a excessiva utilização dos recursos naturais, o agravamento da poluição de origem industrial e tantas outras mazelas causadas pelo crescimento econômico desordenado, que fizeram com que tal realidade ganhasse uma repercussão extraordinária no mundo normativo do *dever ser*, refletindo-se na *norma* elaborada com a necessidade de estabelecer novos comandos e regras aptos a dar, de forma sistemática e orgânica, um novo e adequado tratamento ao fenômeno da deterioração do meio ambiente. O *valor* que sustenta a norma ambiental é o reflexo no mundo ético das preocupações com a própria necessidade de sobrevivência do Ser Humano e da manutenção das qualidades de salubridade do meio ambiente, com a conservação das espécies, a proteção das águas, do solo, das florestas, do ar e, enfim, de tudo aquilo que é essencial para a vida, isto para não se falar da crescente valorização da vida de animais selvagens e domésticos.

É também no campo do *valor* que se manifestam com intensidade os chamados conflitos de uso dos recursos ambientais, pois as diferentes perspectivas axiológicas tendem a identificar, em um mesmo bem, utilidades diversas e que nem sempre são coincidentes. Ao contrário, a evolução normativa do Direito Ambiental demonstra que é, precisamente, em função de marcantes divergências axiológicas que se faz necessária a intervenção normativa com vistas à racionalização do conflito e a sua solução em bases socialmente legítimas.

O Direito Ambiental é, portanto, a *norma* que, baseada no *fato* ambiental e no *valor ético* ambiental, estabelece os mecanismos normativos capazes de disciplinar

as atividades humanas em relação ao meio ambiente. Há uma questão relevante e altamente complexa, que é a *medida de equilíbrio* que cada uma das três diferentes dimensões do direito deve guardar em relação às demais. Com efeito, a gravidade da chamada “crise ecológica” – ou uma determinada percepção dela – pode induzir a uma supervalorização do aspecto ético – com riscos da abstração nele encerrada – sobre o normativo e o fático, gerando situações juridicamente espinhosas e de insegurança. É como afirma Dworkin (2002, p. 313), “*não se pode definir os direitos dos cidadãos de modo que possam ser anulados por supostas razões de bem-estar geral*”.

O Direito Ambiental tem sido entendido de forma extremamente ampla e, de certa maneira, “imperialista”, pois se pretende que, ante os seus aspectos peculiares, outros valores constitucionalmente tutelados cedam passagem, haja vista que, muitas vezes, parte-se de uma ideia de que o *ambiente é tudo que não seja eu*, conforme o conceito de Einstein. O corte é claramente autoritário, pois em sociedade democrática somente a atuação de saída dos processos regulares de direito é legítima. Infelizmente, o discurso da hecatombe ambiental tem servido de base para muitos procedimentos que não se sustentam do ponto de vista democrático, como já tem decidido o STF (STF. RE – Recurso Extraordinário 157905 – SP – São Paulo. DJU 25.09.1998, p. 20. Relator: Ministro Marco Aurélio).

É elementar que o Direito Ambiental deve ser visto como *direito* – com todas as limitações que tal instrumento tem para atuar como elemento de equilíbrio entre as diferentes tensões que existem no fato ambiental – e não como estrutura cabalística capaz de dar solução a problemas para além do jurídico.

O tratamento jurídico do meio ambiente se faz em diferentes áreas do Direito e por diferentes instrumentos que, nem sempre, são de “Direito Ambiental”. Talvez este fato seja um dos mais relevantes no contexto, pois nem toda norma que, direta ou indiretamente, se relaciona a uma questão ambiental pode ser compreendida no universo do Direito Ambiental. Ao mesmo tempo, a amplitude – crescente – do chamado ambiente faz com que muitas províncias jurídicas se especializem e se torne cada vez mais difícil tratá-las dentro de um enorme “guarda-chuva” designado Direito Ambiental. Existe um direito da proteção da diversidade biológica, um direito da proteção dos mares, um direito referente aos produtos tóxicos, outro sobre espécies ameaçadas de extinção e daí por diante, e isso ocorre tanto no direito internacional como no direito interno. Cada um destes diferentes segmentos vem solidificando uma principiologia própria, normas próprias e padrões aplicativos e operacionais específicos. O tratamento só se justifica na medida em que possamos identificar alguns pontos de contato, coordenação e coerência entre todos esses segmentos da ordem jurídica. Vê-se que não é pouco comum que se pretenda atribuir ao domínio do Direito Ambiental questões que dificilmente poderão ser consideradas “ambientais”, tais como a participação feminina nas questões públicas e outras correlatas (Declaração do Rio – Princípio 20).

A doutrina jurídica se baseia em classificação e subdivisão do Direito em “ramos”, o que sem dúvida é reflexo do pensamento positivista. Como entender o componente ambiental do Direito Ambiental? O Direito Ambiental é um direito da natureza? Esta é uma questão importante e que merece alguma reflexão preliminar (ANTUNES, 2015). Certamente, a *natureza* é parte importante do meio ambiente, talvez a mais importante delas. Mas o meio ambiente não é só a natureza. Meio ambiente é natureza mais atividade antrópica, mais modificação produzida pelo Ser Humano sobre o meio físico de onde retira o seu sustento. Não se deve, contudo, imaginar que o Homem não é parte do mundo natural, ao contrário, ele é parte essencial, pois dotado de uma capacidade de intervenção e modificação da realidade externa que lhe outorga uma posição extremamente diferente da ostentada pelos demais animais. Um dos fundamentos da atual “crise ecológica” é, sem dúvida, a concepção de que o *humano* é externo e alheio ao *natural*. Averte-se que, no entanto, o conceito de natureza é vago, como bem registrado por Michel Prieur (1984, p. 5) ao afirmar que: *Se existe um conceito vago, é aquele de natureza*.

A palavra *natureza* é originada do latim *Natura*, de *nato*, nascido. Os seus principais significados são: (a) *conjunto de todos os seres que formam o universo; e (b) essência e condição própria de um ser*. Whitehead (1994, p. 7), em conhecida obra dedicada ao estudo da natureza, afirma que

“a natureza é aquilo que observamos pela percepção obtida através dos sentidos. Nessa percepção sensível, estamos cômicos de que algo que não é pensamento e que é contido em si mesmo com relação ao pensamento. Essa propriedade de ser autocontido em si mesmo em relação ao pensamento está na base da ciência natural. Significa que a natureza pode ser concebida como um sistema fechado cujas relações mútuas prescindem da expressão do fato de que se pensa acerca das mesmas”.

Ao tomarmos consciência da natureza como realidade que nos é externa, damos início ao mundo da cultura. É apenas por intermédio do mundo da cultura que sobrevivemos às dificuldades do mundo exterior, tal a nossa fragilidade perante o mundo natural.

“É óbvio que esse mundo não é nenhuma exceção às regras biológicas que regem a vida de todos os demais organismos. No entanto, no mundo humano encontramos uma característica nova que parece ser a marca distintiva da vida humana. O círculo funcional do homem não é só quantitativamente maior; passou também por uma mudança qualitativa. O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao ambiente” (Cassirer 2001, p. 47).

Não devemos esquecer também que *Natureza* é um conceito político que tem servido de inspiração para filósofos e reformadores políticos. O Estado da *Natureza* é um marco teórico que tem sustentado diferentes Teorias de Filosofia Política e Social. Para Rousseau, o *estado de natureza* não caracteriza um período da história humana marcado por inconveniências a serem superadas pela constituição da sociedade civil. Aqueles para os quais o estado de natureza constituía uma etapa que precisava ser necessariamente ultrapassada para que a humanidade pudesse estabelecer formas de convivência mais adequadas ao conjunto dos indivíduos, como é, por exemplo, o caso de Locke e Hobbes, essa passagem implicava perdas em termos da limitação da liberdade e do julgamento e execução pelos próprios indivíduos da “lei da natureza”. Mas o estabelecimento da sociedade civil através de um pacto acordado por toda a comunidade trazia ganho suficiente – em termos de preservação da vida, da liberdade, da propriedade, da igualdade, dos bens e da segurança e do respeito às leis que deveriam submeter igualmente a todos – para ser amplamente adotado. O caminho aberto pela sociedade civil é para eles, portanto, o que leva às conquistas mais caras à civilização e a formas mais adequadas de convivência entre os homens. Para estes pensadores e filósofos políticos, o estado de natureza era um período de selvageria fundamentalmente insatisfatório, onde os aspectos negativos dificultavam demasiadamente – quando não inviabilizavam – a vida em coletividade.¹ O Homem sobrevive às intempéries e às diferentes condições climáticas que lhes são desfavoráveis culturalizando a natureza, transformando-a em menos hostil, mediante uma evolução que o leva às cidades que refletem a expressão máxima da cultura como atividade humana, como observado por Aristóteles.²

Essas considerações tornam evidente que a cidade é uma realidade natural e que o homem é, por natureza, um animal político (*politikón zôon*). E aquele que, por natureza e não por mero acidente, não faz parte de uma cidade é ou um ser degradado ou um ser superior ao homem; ele é como aquele a quem Homero censura por ser “sem clã, sem lei e sem lar”,³ um tal homem é, por natureza, ávido de combates, e é como uma peça isolada no jogo de damas. É evidente, assim, a razão pela qual o homem é um animal político em grau maior que as abelhas ou todos os outros animais que vivem reunidos. Dizemos, de fato, que a natureza nada faz em vão, e o homem é o único entre todos os animais a possuir o dom da fala. Sem dúvida, os sons da voz (*phonê*) exprimem a dor e o prazer e são encontrados nos animais em geral, pois sua natureza lhes permite experimentar esses sentimentos e comunicá-los uns aos outros. Mas quanto ao discurso (*lógos*), ele serve para exprimir o útil e o nocivo e, em consequência, o justo e o injusto. De fato, essa é a característica que distingue o homem de todos os outros animais: só ele sabe discernir o bem e o mal, o justo e o injusto, e os outros sentimentos da mesma ordem; ora, é precisamente a posse comum desses sentimentos que engendra a família e a cidade.

A cidade, portanto, é por natureza anterior à família e a cada homem tomado individualmente, pois o todo é necessariamente anterior à parte; assim, se o corpo é destruído, não haverá mais nem pé nem mão, a não ser por simples analogia, como quando se fala de uma mão de pedra, pois uma mão separada do corpo não será melhor que esta. Todas as coisas se definem sempre pelas suas funções e potencialidades; por conseguinte, quando elas não têm mais suas características próprias, não se deve dizer mais que se trata das mesmas coisas, mas apenas que elas têm o mesmo nome (homônima). É evidente, nessas condições, que a cidade existe naturalmente e que é anterior aos indivíduos, pois cada um destes, isoladamente, não é capaz de bastar-se a si mesmo e está [em relação à cidade] na mesma situação que uma parte em relação ao todo; o homem que é incapaz de viver em comunidade, ou que disso não tem necessidade porque basta-se a si próprio, não faz parte de uma cidade e deve ser, portanto, um bruto ou um deus.

Tem sido recorrente, na Ciência Política, a utilização da natureza sempre que se busca um modelo alternativo de organização social. Filósofos como Rousseau,

Locke, Hobbes sustentavam a existência de um “estado da natureza” como base teórica para as críticas sociais que produziam. A natureza como conceito político e filosófico encontra as suas origens na Grécia Antiga, pois foi através da observação da natureza que os primeiros filósofos buscaram estabelecer leis universais capazes de explicar os diferentes fenômenos físicos e, sobretudo, a sociedade. Modernamente, o conceito político de natureza foi resgatado por *Henry David Thoreau*, filósofo e humanista norte-americano que pode ser considerado o pai do ecologismo moderno, diante da importante crítica que traçou à sociedade moderna e o seu apego exagerado à acumulação de riquezas sem uma base ética sólida, privilegiando o imediato e material em detrimento do mais distante e despretenso, cuja seguinte passagem é bem representativa: “Se alguém andar na mata por amor a ela, a metade de cada dia, ele está em perigo de ser encarado como um vadio, mas se ele passa o dia todo como um especulador, destruindo a floresta e desmatando a terra antes da época própria, então ele é visto como um cidadão empreendedor. Como se uma cidade não tivesse interesse em suas florestas, além de derrubá-las”.⁴

Meio ambiente compreende o humano como parte de um conjunto de relações econômicas, sociais e políticas que se constroem a partir da apropriação dos bens naturais que, por serem submetidos à influência humana, transformam-se em recursos essenciais para a vida em quaisquer de seus aspectos. A construção teórica da natureza como *recurso* é o seu reconhecimento como base material da vida em sociedade. Como demonstrado por Thoreau, todo o conflito sobre os bens naturais é um conflito sobre o papel que a eles atribuímos para a nossa vida. Conflito entre o mero utilitarismo e o desfrute das belezas cênicas que muitas vezes serve como descanso para a alma.

Assim, o Direito que se estrutura com vistas a regular as atividades humanas sobre o meio ambiente somente pode ser designado como Direito Ambiental. Nos primórdios do Direito Ambiental como disciplina universitária, outras designações foram ensaiadas, contudo não lograram se firmar em função das fragilidades teóricas sobre as quais se apoiavam.

A *Declaração do Rio*, que foi proclamada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, embora não tenha utilizado a expressão Direito Ambiental, demonstrou uma preferência inequívoca pelo termo *ambiental*, em relação à ecologia ou natureza, por exemplo, como demonstra o Princípio 11 do importante documento.⁵

Nos primórdios de nossa disciplina no Brasil, ela era conhecida como Direito Ecológico, como consta dos trabalhos de Sérgio Ferraz (1972) e Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1997). O desenvolvimento dos estudos sobre a disciplina conduziu a maioria dos autores à utilização da expressão *Direito Ambiental*, por ser mais abrangente e mais capaz de assimilar as nuances da matéria em questão. *A experiência prática tem demonstrado que muitos e diferentes problemas acabam sendo absorvidos pelo Direito Ambiental, ainda que não se refiram direta e unicamente às questões estritamente ecológicas. Aliás, uma das grandes dificuldades em nossa disciplina é, efetivamente, estabelecer-lhe limites de abrangência que evitem os desvios da tentativa de ela se transformar em Pandireito. Sabemos que a proteção jurídica compreendida pela legislação ambiental estende-se a horizontes mais vastos do que a natureza considerada em si própria. A este respeito, é conveniente lembrar a lição de Rodgers (1977, p. 1): “O Direito Ambiental não é preocupado só com o ambiente natural – as condições físicas da terra, ar, água. Ele abraça também o ambiente humano – a saúde, o social e outras condições afetando o lugar do ser humano na Terra”.*

A produção nacional, bem representada pelo Professor Paulo Affonso Leme Machado (MACHADO, 2005, p. 148-149), nas primeiras edições de seu *Direito Ambiental Brasileiro*, não chegou a apresentar uma definição de Direito Ambiental, preferindo, em sua obra, fornecer ao leitor uma metodologia para que este compreenda o conteúdo e o significado do Direito Ambiental. Para o consagrado autor, o Direito Ambiental é um direito de proteção à natureza e à vida, dotado de instrumentos peculiares que se projetam em diversas áreas do Direito, sobretudo no Direito Administrativo. Posteriormente, o consagrado mestre evoluiu em sua concepção e nos fornece a seguinte definição:

“O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o meio ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito do solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade de instrumentos jurídicos de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação”.

Entendo que o Direito Ambiental pode ser definido como um direito que tem por finalidade regular a apropriação econômica dos bens ambientais, de forma que ela se faça levando em consideração a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico e social, assegurando aos interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, bem como padrões adequados de saúde e renda. Ele se desdobra em três vertentes fundamentais, que são constituídas pelo: (i) *direito ao meio ambiente*, (ii) *direito sobre o meio ambiente* e (iii) *direito do meio ambiente*. Tais vertentes existem, na medida em que o direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais. Mais do que um ramo autônomo do Direito, o Direito Ambiental é uma concepção de aplicação da ordem jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. O Direito Ambiental tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica que devem ser compreendidas harmonicamente. Evidentemente que, a cada nova intervenção humana sobre o ambiente, o aplicador do Direito Ambiental deve ter a capacidade de captar os diferentes pontos de tensão entre as três dimensões e verificar, no caso concreto, qual delas é a que se destaca e que está mais precisada de tutela em um dado momento.

A doutrina nacional se divide em duas correntes básicas: (i) uma que privilegia o chamado ambientalismo social ou socioambientalismo (SANTILLI, 2005) e (ii) outra mais voltada para o preservacionismo. O socioambientalismo busca conciliar a convivência humana – sobretudo populações menos favorecidas – com a proteção de ambientes naturais; já a vertente preservacionista tem uma visão de santuário das áreas protegidas e se encontra reunida em torno do grupo Planeta Verde com forte base de sustentação no Ministério Público.

Certamente, não se pode pensar o Direito Ambiental de forma rígida e dogmática, pois isto é uma contradição em seus próprios termos. É da própria natureza do Direito Ambiental que ele seja examinado de forma flexível e maleável. A relevância do chamado socioambientalismo e a sua compreensão jurídica é que, efetivamente, ele busca localizar o Ser Humano no centro do Direito Ambiental, o que, em minha opinião, corresponde ao comando de nosso legislador constitucional ao definir o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos princípios basilares de nosso ordenamento jurídico. Equívoca-se o socioambientalismo ao pretender que, *necessariamente*, as populações tradicionais protejam o meio ambiente, pois a prática tem demonstrado que populações tradicionais também podem ser promotoras de degradação ambiental quando as pressões econômicas se tornam irresistíveis.

1.2.1 A vertente econômica do Direito Ambiental

Economia e ecologia têm muita coisa em comum, pois têm origem na palavra *oikos*, casa. No entanto, tal relação óbvia não tem tido aceitação entre as partes envolvidas, existindo sempre a irreal dicotomia entre “desenvolvimento e meio ambiente”. Fato é que as relações entre economia e ecologia têm sido muito tensas e, especialmente no Direito Ambiental, elas não têm tido a atenção que merecem. No particular, é relevante a observação de Christopher D. Stone (1995, p. 150) no sentido de que é vergonhoso pensarmos que o pensamento econômico é intrinsecamente oposto ao ambiental. A doutrina relevante de Direito Ambiental no Brasil ainda voltou a sua atenção para a vertente econômica do Direito Ambiental, fazendo com que muita incompreensão reine em tão importante área. Mais uma vez não posso deixar de recorrer à constatação de Stone no sentido de que: existe uma desafortunada desconfiança mútua entre ambientalistas e economistas (STONE, 1995, p. 151). A ideia que me dirige nesta seção é a de demonstrar cabalmente que o Direito Ambiental não pode, sequer, ser imaginado sem uma consideração profunda de seus aspectos econômicos, pois dentre os seus fins últimos se encontra a regulação da apropriação econômica dos bens naturais.

A Constituição de 1934 introduziu em nosso meio jurídico os primeiros mecanismos constitucionais de atuação positiva do Estado na ordem econômica. O ano de 1934 marca o início do modelo de intervenção econômica e do federalismo cooperativo que passa a dotar a União de novos poderes para, mediante a execução de programas específicos, alavancar a atividade econômica. A Constituição de 1934 foi concebida sobre o conceito de intervenção econômica. Foi naquela Carta que teve início o nosso Direito Econômico, que está contido no direito público, a sua característica mais marcante: a interdisciplinaridade. O Direito Econômico é um

polo, ao redor do qual circulam o Direito Tributário, o Direito Administrativo, o Direito Financeiro, o Direito Ambiental e inúmeros outros.

Direito Econômico é o *direito considerado em suas consequências econômicas* (MONCADA, 1988, p. 12). Para o Direito Econômico, o relevante é a eficácia, isto é, a capacidade de produzir alterações na ordem econômica como consequência das medidas implementadas. Ele é, assim como o Direito Ambiental, um direito de organização que não se submete apenas às forças do mercado, muito embora não possa desconsiderá-las.

O Direito Econômico está intimamente ligado à intervenção do Estado sobre a ordem econômica que em seus aspectos ambientais se faz mediante a utilização de mecanismos jurídicos próprios e que pertencem ao campo do Direito Ambiental. O Direito Ambiental como parte do Direito Econômico vai além do mero poder de polícia, haja vista que orienta as forças produtivas em uma determinada direção, no caso concreto, a utilização racional dos recursos ambientais. A intervenção econômica se diferencia do poder de polícia, na medida em que este último se limita à proibição de atividades, condutas ou comportamentos de particulares.

A intervenção econômica, segundo Eros Roberto Grau (1991), possui três modalidades principais: a) participação, absorção; b) direção; c) indução.

A *participação* e a *absorção* indicam que o Estado ou está atuando como agente econômico através de suas entidades criadas especificamente para tal fim, ou está atuando mediante a atividade de empresas que, por um motivo ou por outro, foram incorporadas ao patrimônio público. *Direção* é o processo pelo qual o Estado dirige um determinado empreendimento econômico, assumindo as responsabilidades essenciais do mesmo. *Indução* é um mecanismo pelo qual o Estado cria incentivos ou punições para a adoção de determinados comportamentos econômicos ou cria condições favoráveis para que se desenvolvam empreendimentos privados em determinadas regiões, ou mesmo que determinadas atividades econômicas possam ser realizadas mediante medidas especiais de política econômica.

Para o Direito Ambiental, a *indução* é o instrumento mais importante, haja vista que somente através dele é que se podem tomar medidas com vistas a impedir que danos ambientais significativos se concretizem. A indução se faz, essencialmente, com a adoção dos chamados mecanismos de incentivo econômico.

A proteção do meio ambiente é um dos princípios basilares de nossa ordem econômica constitucional, estando prevista no artigo 170, inciso VI. Ao mesmo nível do princípio da proteção ao meio ambiente, a Constituição reconhece outros princípios, tais como (i) *soberania nacional*; (ii) *propriedade privada*, (iii) *função social da propriedade*, (iv) *livre-concorrência*, (v) *defesa do consumidor*; (vi) *redução das desigualdades regionais e sociais*, (vii) *busca do pleno emprego* e (viii) *tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País*.

A inclusão do “*respeito ao meio ambiente*” como um dos princípios da atividade econômica e financeira é medida de enorme importância, pois ao nível mais elevado de nosso ordenamento jurídico está assentado que a licitude constitucional de qualquer atividade fundada na livre iniciativa está, necessariamente, vinculada à observância do respeito ao meio ambiente ou, em outras palavras, à observância das normas de proteção ambiental vigentes. Relevante anotar que as dificuldades ocasionadas por uma legislação ambiental extremamente fragmentária, com competências legais e administrativas mal definidas, fizeram com que o Poder Constituinte derivado determinasse um “princípio” que se expressa em tratamento diferente em função do impacto ambiental produzido pela atividade. O Constituinte, no particular, reconheceu uma grave externalidade negativa da norma constitucional, que é a proliferação de um conjunto de normas que, antes de proteger o meio ambiente, dificultam a pequena atividade econômica com onerosidade excessiva e, muitas vezes, desproporcional. Tal princípio, contudo, não tem sido observado, visto que os órgãos ambientais tratam igualmente as empresas, independentemente do padrão de tecnologia que adotem com vistas à redução dos impactos. O artigo 174 e seu § 3º referem-se diretamente ao meio ambiente quando tratam da organização de cooperativas de garimpeiros, que deverão levar em conta a proteção ao meio ambiente. Também no artigo 176 podem ser contempladas normas de natureza ambiental. Os capítulos da política urbana (arts. 182/183) e da política agrícola e fundiária (arts. 184/191) guardam enorme proximidade com a matéria ambiental, sendo certo que a própria função social da propriedade ficou submetida à necessidade de preservação ambiental, havendo quem fale em uma função socioambiental da propriedade.

O desenvolvimento brasileiro, como regra, sempre se fez com pouco respeito ao ambiente, pois calcado na exploração intensiva de produtos primários, sem qualquer preocupação mais profunda quanto à sua conservação. A partir da década de 80 do século XX, sobretudo após a edição da Lei da PNMA, começou a se formar uma nova maneira de pensar as relações entre a atividade econômica e o meio ambiente. Isto se dá, principalmente, com a introdução do conceito de sustentabilidade e a constatação de que recursos naturais não são infinitos. Essa mudança de concepção, contudo, não é linear e, sem dúvida, podemos encontrar diversas contradições e dificuldades na implementação de políticas industriais que levem em conta o fator ambiental e que, mais do que isso, estejam preocupadas em assegurar a sustentabilidade da utilização de recursos ambientais.

A concepção do desenvolvimento sustentado tem em vista a tentativa de conciliar a conservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento econômico. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi a primeira norma legal federal construída sobre a base da proteção ambiental como elemento essencial para o desempenho da atividade econômica, e mais: compreende a própria proteção ao meio ambiente como atividade de natureza econômica, como deixa ver o seu artigo 2º.

Como Direito Econômico, o Direito Ambiental é dotado de instrumentos específicos que não se confundem com os demais postos. Esses instrumentos estão previstos tanto na CF quanto na legislação ordinária, merecendo destaque aqueles que estão previstos na Lei nº 6.938/81, como instrumentos da PNMA. Entre os diversos instrumentos, os que merecem mais atenção são, por exemplo, os seguintes: (i) a Avaliação Ambiental Estratégica e (ii) o Zoneamento Econômico Ecológico, cujas finalidades, em linhas gerais, estão relacionadas com a realização de diagnósticos antecipados das consequências ambientais decorrentes da possível implantação de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente em determinados meios físicos.

O estabelecimento de *preços* pela utilização dos recursos ambientais e a criação de incentivos para a utilização menos intensiva de recursos ambientais também são instrumentos importantes, pois condicionam a ação do agente econômico em busca de uma atividade menos agressiva em relação ao ambiente na qual ele está inserido.

1.2.2 A vertente humana do Direito Ambiental

O conteúdo econômico do Direito Ambiental já foi exaustivamente demonstrado. Nesta etapa, cumpre demonstrar o seu conteúdo humanístico. O primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que a sua construção prática demonstra que ele, em grande medida, é originado de movimentos reivindicatórios e de protestos contra más condições de vida, poluição, falta de saneamento e tantas outras. No contexto brasileiro que de certa forma reproduz o internacional, há um amálgama que funde ações políticas com medidas judiciais e legislativas, criando uma base bastante rica e fértil para a produção de regras ambientais.

Em inúmeras ocasiões, os Tribunais têm sido provocados a dar seu veredicto sobre situações que, do ponto de vista das ações judiciais, são lesivas ao meio ambiente. É certo, ademais, que muitas vezes os litígios judiciais são a única forma de impedir medidas ilegais até mesmo do Poder Público, como muito bem observado por Farber e Findley (1998, p. 2) fora do processo político, o único controle sobre os órgãos ambientais é o judicial.

Atualmente, vivemos uma “*era dos direitos*” (BOBBIO, 1992) com recursos escassos, na qual as diferentes parcelas da população postulam direitos de forma cada vez maior e que resultam em normas cada vez mais atributivas de garantias processuais e direitos substantivos, ainda que muitas vezes os orçamentos públicos previstos para a concretização das novas realidades normativas nem sempre sejam capazes de torná-las efetivas.

O *caput* do artigo 225 da CF define o direito ao meio ambiente equilibrado como um “*direito de todos*”, logo, subjetivamente exigível por toda e qualquer pessoa. No particular, averbe-se que há forte tendência teórica de incluir os animais irracionais como “*sujeitos*” (SINGER, 2004) (POSNER, 2004) de direito e, portanto, devendo ser compreendidos no conceito de “*todos*” formulado pela Constituição, com o qual não estamos de acordo.

É imperioso perceber que, mesmo com forte conteúdo econômico, não se pode entender claramente o Direito Ambiental como um tipo de relação jurídica que privilegie a atividade produtiva em detrimento dos valores propriamente humanos. A conservação e sustentabilidade dos recursos ambientais (recursos econômicos) são instrumentos para garantir um bom padrão de qualidade de vida para os indivíduos. O fator econômico deve ser compreendido como *desenvolvimento, evolução, melhora contínua* e não como simples *crescimento ou acúmulo*. O *desenvolvimento* se distingue do *crescimento* na medida em que pressupõe uma harmonia entre os seus diferentes *elementos constitutivos*.

No regime constitucional brasileiro, o artigo 225 da CF impõe a conclusão de que o *direito ao ambiente* prístino é um dos direitos humanos fundamentais. É, o

meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, portanto, é res communes omnium (coisa comum a todos), interesse comum, tutelável judicialmente por meio de ação popular, como se pode ver do artigo 5º da CF em seu inciso LXXIII. Uma consequência lógica da identificação do direito ao ambiente como um direito humano fundamental, conjugada com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é que no centro de gravitação do Direito Ambiental se encontra o Ser Humano. Entretanto, a concepção ora esposada encontra acirrada oposição em parte significativa do pensamento contemporâneo que tem buscado identificar uma igualdade essencial entre todos os seres vivos. Tais correntes encontram muita repercussão no Direito Ambiental, sobretudo nos países mais desenvolvidos nos quais problemas básicos já tenham sido superados. Há, inclusive, a construção de um chamado *Direito dos Animais*, merecedor de uma *Declaração Universal dos Direitos dos Animais*, que, contudo, penso não fazer parte da disciplina Direito Ambiental, não se confundindo com esse último. Uma boa mostra do pensamento que serve de base para os “direitos animais” pode ser encontrada na seguinte passagem de Singer (2004, p. 24):

“Normalmente, isso significa que, se tivermos de escolher entre a vida de um ser humano e a vida de outro animal, deveríamos escolher salvar a vida do ser humano; mas pode haver casos especiais em que o inverso é verdadeiro, porque o ser humano em questão não possui as capacidades de um ser humano normal”.

Pretende-se que o Direito Ambiental represente a ruptura do antropocentrismo na ordem jurídica. Sustenta-se que, ao proteger a vida, em especial a vida animal e vegetal, o Direito Ambiental teria reconhecido novos sujeitos de direito que, conjuntamente com o ser humano, passariam a ocupar o núcleo central do mundo jurídico. Em meu ponto de vista, tal raciocínio é primário, pois deixa de considerar uma questão essencial e inafastável, que é o fato de que o Direito positivado é uma construção humana para servir propósitos humanos. O fato de que o direito esteja evoluindo para uma posição na qual o respeito às formas de vida não humanas seja uma obrigação jurídica cada vez mais relevante não é suficiente para deslocar o eixo ao redor do qual a ordem jurídica circula. A obrigação jurídica de respeito aos animais e às demais formas de vida é principalmente a expressão de um movimento de “humanização” dos animais cujas dimensões crescentes têm implicado o aumento do arco protetivo, nesse sentido o STJ garantiu o direito de ex-companheiro visitar animal de estimação após dissolução da união estável.

A ONU, pela da Resolução nº 37/7, de 28 de outubro de 1982, proclamada pela Assembleia Geral, afirmou que: “Toda forma de vida é única e merece ser respeitada, qualquer que seja a sua utilidade para o homem, e, com a finalidade de reconhecer aos outros organismos vivos este direito, o homem deve se guiar por um código moral de ação”.

O Direito Ambiental, quando confere proteção aos bens naturais, o faz na função de mediador entre os diferentes agentes econômicos e das respectivas visões axiológicas sobre o destino a ser dado aos elementos naturais quando parte do tráfico econômico e jurídico. Na medida em que se reconhece uma carga axiológica mais densa, menor é a utilização econômica legalmente consentida para o bem considerado em si mesmo. Ao afastar determinados bens da apropriação direta pela atividade econômica e com o estabelecimento de medidas que sejam capazes de garantir tal afastamento – legitimidade extraordinária para a proteção dos bens ambientais –, está propiciando um equilíbrio na competição no mercado entre os agentes econômicos, além de assinalar de forma bastante clara o nível de valor cultural e espiritual que determinado bem possui na sociedade. Processualmente, os interesses difusos e o sistema de legitimidade que lhes asseguram tutela é a forma encontrada pela sociedade para permitir que um conflito de uso relevante possa ser racionalmente mediado.

O Direito brasileiro reconhece à natureza um elevado nível de tutela positivamente fixado. Isto ocorre tanto em relação à norma constitucional, quanto em relação à legislação ordinária. Relembre-se que os incisos I, II e VII do artigo 225 da CF falam em: “Proteger e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico dos ecossistemas”, “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País”, “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica [...]”.

Observe-se que há uma obrigação social, legal e constitucional para com a tutela dos processos ecológicos essenciais que, a toda evidência, só reflexamente pode ser vinculada ao sujeito de direito, entendido como tal o ser humano. Há obrigação do Estado de empenho para com a preservação das espécies da flora e da fauna, não se cogitando imediatamente das suas necessidades ou utilidades imediatas. O direito, igualmente, age com um poder geral de cautela, pois prefere determinar que alguns bens sejam protegidos e “congelados”, ainda que não tenham utilidade imediata. Cria-se, portanto, uma reserva de valor que poderá vir a ser utilizada – ou não – em um futuro não especificado.

O reconhecimento de tutela a bens jurídicos que não estejam *diretamente* vinculados à pessoa humana é um aspecto de grande importância para que se possa medir o real grau de codependência entre o homem e o mundo que o cerca, do qual ele é parte integrante e, sem o qual, não logrará sobreviver. A atitude de respeito e proteção às demais formas de vida ou aos sítios que as abrigam é uma prova de compromisso do ser humano com a própria raça e, portanto, consigo mesmo.

1.3 AUTONOMIA DO DIREITO AMBIENTAL

A autonomia dos chamados “ramos” do Direito é sempre problemática e deve ser considerada antes uma questão de natureza acadêmica e periférica e não deve impressionar aqueles que pretendam estudar as diferentes manifestações setoriais do fenômeno jurídico. O mesmo se passa com a autonomia do Direito Ambiental. Se é verdade que as diferentes manifestações do Direito, como fenômeno normativo, possuem peculiaridades, também não é menos verdade que ele busca certo grau de harmonia e coerência entre os seus diferentes setores. No caso específico do Direito Ambiental, é relevante considerar que, em função do elevado nível de influência exercido por saberes não jurídicos e por situações extraleais, possui especificidades que o distinguem dos “ramos tradicionais” do Direito. Em primeiro lugar, há que se observar que a relação do Direito Ambiental com os demais ramos do Direito é *transversal*, isto é, as normas ambientais tendem a se incrustar em cada uma das demais normas jurídicas, obrigando que *se leve em conta* a proteção ambiental em cada um dos demais “ramos” do Direito. Uma norma de direito público que determine a administração, a realização de estudos de impacto ambiental para a implementação de certas atividades está situada no direito administrativo ou no Direito Ambiental? Uma norma que tipifica crimes contra o meio ambiente é uma norma criminal ou ambiental? No caso, o importante é ter em vista que a proteção ambiental pode ocorrer mediante a tutela conferida por normas dos mais diferentes campos do Direito.

O desenvolvimento que o Direito Ambiental vem demonstrando ao longo dos anos, certamente, já é suficientemente amadurecido para que se possa reconhecer a sua autonomia em face de outros ramos do Direito. Tal autonomia, todavia, não o transforma em um “superdireito”, imune às influências da ordem jurídica. Ressalte-se que os conceitos fundamentais do Direito são válidos em qualquer um dos diferentes “ramos” do Direito. O conceito de sujeito de Direito é válido tanto para o Direito Penal quanto para o Direito Tributário ou o Direito Civil, assim como para o Direito Ambiental. O Direito Ambiental, contudo, não se situa em *paralelo* a outros “ramos” do direito, pois é direito de *coordenação* e, nessa condição, é um direito que sugere aos demais setores do universo jurídico o respeito às normas que o formam, dado que o seu fundamento de validade é emanado diretamente da norma constitucional. Sua principal característica é a transversalidade, exprimindo um valor que deve ser refletido nos demais ramos jurídicos.

1.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece em seu artigo 4º que diante de omissão legislativa, o juiz decidirá o caso de acordo com “a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. O CPC, muito embora não mencione expressamente os princípios gerais de Direito, determina em seu artigo 140 que “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”, daí resultando evidente que os princípios são parte integrante do ordenamento jurídico. Logo, os princípios gerais de Direito formam o último recurso a ser empregado pelo aplicador da norma com vistas a dar solução a um caso concreto. Tem sido reconhecido que os princípios jurídicos sempre tiveram papel relevante na ordem jurídica, qual seja o de dotar o sistema de unidade, coerência e harmonia, servindo de *guia para o intérprete*. Admite-se que, modernamente, o constitucionalismo e a nova hermenêutica têm lhes reconhecido plena normatividade, equivalente à de norma jurídica (PADILHA. 2010, p. 238), conforme admitido na doutrina jurídico-ambiental.

Há, todavia, mesmo da doutrina ambiental, quem identifique – na atual quadra – uma hipertrofia dos princípios em “seara ambiental”, como é o caso de SARLET e FENSTERSEIFER (2014, p. 18), que afirmam ser a matéria inspiradora de cuidados, pois, como o verificado em outros “campos sensíveis”, há excessos de

“perfil fundamentalista”, o que acarreta “uma dose de voluntarismo que procura se legitimar mediante invocação genérica – e, por vezes, mesmo *panfletária* – do discurso dos princípios”. Por utilização panfletária dos princípios entende-se a busca de soluções para casos concretos de forma a inviabilizar a atividade econômica ou a negar eficácia a atos administrativos emitidos por agências ambientais. Poder-se-ia dizer que o *principismo* é a doença infantil do Direito Ambiental, pois buscando sempre a posição mais radical como se fosse, por si só sinônimo de maior legitimidade e legalidade, ou até mesmo de maior eficiência para a proteção ambiental.

Entretanto, o recurso aos princípios jurídicos é uma tarefa que está longe de ser simples e tranquila, pois não há, sequer, um consenso doutrinário sobre quais os princípios aplicáveis ao Direito Ambiental e, certamente, alguns deles são amplamente aceitos, ainda que se encontre forte divergência quanto ao seu significado. Assim, a aplicação de princípios é altamente problemática e, como se demonstrará, somente deve ser feita em último caso, quando inexistente norma e/ou precedente judicial.

1.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

O ser humano, conforme estabelecido em nossa Constituição e na Declaração do Rio – embora esta não tenha força obrigatória –, é o centro das preocupações do Direito Ambiental, que existe em função do ser humano e para que ele possa viver melhor na Terra. A relação com os demais animais deve ser vista de uma forma caridosa e tolerante, sem que se admitam a crueldade, o sofrimento desnecessário e a exploração interesseira de animais e plantas. Mas, evidentemente, não se pode perder de vista o fato de que o homem se encontra em posição superior aos demais animais, haja vista a sua capacidade de raciocínio, transformação consciente da natureza etc. Como afirmado por Sófocles: “*Há muitas maravilhas neste mundo, mas a maior de todas é o homem*”.

1.4.2 Princípio do desenvolvimento

O grau maior de proteção ambiental é uma razão direta do maior nível de bem-estar social e renda da população. Por isso as principais declarações internacionais sobre meio ambiente sempre enfatizam a necessidade de desenvolvimento econômico, o qual deverá ser sustentável. Nesse particular, é bem significativo o chamado Relatório Brundtland, do qual destaco a seguinte passagem:

“Mas isto não basta. A administração do meio ambiente e a manutenção do desenvolvimento impõem sérios problemas a todos os países. Meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados; estão inevitavelmente interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental. Esses problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1998, p. 40).

Qualquer análise que se faça do estado do meio ambiente no Brasil – e, nisso, nada temos de diferente dos demais países do mundo – demonstrará que os principais problemas ambientais se encontram nas áreas mais pobres e que as grandes vítimas do descontrole ambiental são os mais desafortunados. De fato, há uma relação perversa entre condições ambientais e pobreza. Assim, parece óbvio que a qualidade ambiental somente poderá ser melhorada com melhor distribuição de renda.

A propósito, o Brasil é signatário da Declaração sobre o *Direito ao Desenvolvimento* que, no § 1º do artigo 1º, dispõe: “O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”.

Tal disposição deve ser interpretada conjuntamente com o § 1º do artigo 2º, que define: “A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento”.

Há ainda que considerar que o conceito de desenvolvimento tem alguns elementos-chave como aquele que determina: “Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento e devem assegurar, *inter alia*, igualdade de oportunidade para todos, no acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição equitativa da renda. Medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças sociais”.

A Declaração prossegue afirmando em seu artigo 9º que: “Todos os aspectos do direito ao desenvolvimento estabelecidos na presente Declaração são indivisíveis e interdependentes, e cada um deles deve ser considerado no contexto do todo”.

O princípio do desenvolvimento, como anteriormente demonstrado, materializa-se no direito ao desenvolvimento sustentável, que se encontra presente em diferentes textos normativos nacionais e internacionais. Há, evidentemente, uma zona de fricção entre o princípio do desenvolvimento e o chamado *princípio da precaução*, como será adiante demonstrado. Compreender e harmonizar ambos os princípios é essencial para que se possa alcançar um nível ótimo de proteção ambiental.

1.4.3 Princípio democrático

O Direito Ambiental tem uma das suas principais origens nos movimentos reivindicatórios dos cidadãos. Logo, a democracia é uma de suas bases mais caras e consistentes. O princípio democrático encontra a sua expressão normativa especialmente nos *direitos à informação* e à *participação*. Tais direitos estão, expressamente, previstos no texto da CF e em diversas leis esparsas.

O Direito Ambiental, em seus aspectos regulatórios, depende da Administração Pública, que tem no princípio da publicidade administrativa um dos seus alicerces.

O princípio democrático assegura aos cidadãos o direito de, na forma da lei ou regulamento, participar das discussões para a elaboração das políticas públicas ambientais e de obter informações dos órgãos públicos sobre matéria referente à defesa do meio ambiente e de empreendimentos utilizadores de recursos ambientais e que tenham significativas repercussões sobre o ambiente, resguardado o sigilo industrial. No sistema constitucional brasileiro, tal participação faz-se por várias maneiras diferentes, das quais merecem destaque: (i) o dever jurídico de proteger e preservar o meio ambiente; (ii) o direito de opinar sobre as políticas públicas, por meio de:

- a) participação em audiências públicas, integrando órgãos colegiados etc.;
- b) participação mediante a utilização de mecanismos judiciais e administrativos de controle dos diferentes atos praticados pelo Executivo, tais como as ações populares, as representações e outros;
- c) as iniciativas legislativas que podem ser patrocinadas pelos cidadãos. A materialização do princípio democrático faz-se por meio de diversos instrumentos processuais e procedimentais.

As *iniciativas legislativas* são:

- *Iniciativa Popular*, prevista no artigo 14, inciso III, da CF;
- *Plebiscito*, previsto no artigo 14, inciso I, da CF; e
- *Referendo*, previsto no artigo 14, inciso II, da CF.

Direito de informação. O artigo 5º, XXXIII, da CF. A Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, é especificamente voltada para assegurar o direito à informação em questões de meio ambiente. Além dessa lei voltada especificamente para a informação ambiental, aplica-se Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Trata-se de uma norma geral e, portanto, aplicável à União, aos Estados e aos Municípios, bem como às organizações não governamentais que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Direito de petição. Previsto na alínea *a* do inciso XXIV do artigo 5º da CF. É a possibilidade que o cidadão tem de acionar o Poder Público para que este, no exercício de sua autotutela, ponha fim a uma situação de ilegalidade ou de abuso de poder. Exemplo: exigir que o Estado puna o possuidor de um depósito clandestino de produtos tóxicos.

Estudo prévio de impacto ambiental. É exigência constitucional prevista no § 1º, inciso IV, do artigo 225 da CF, para toda *instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente*. O EIA deve ser tornado público. O EIA deve ser submetido à audiência pública. É importante frisar que a exigência de EIA só é legal nas hipóteses em que o órgão ambiental demonstre a potencialidade de um impacto negativo a ser causado ao meio ambiente. A exigência da avaliação ambiental prévia não se confunde com a exigência de prévio EIA.

Medidas judiciais fundadas no princípio democrático:

Ação popular. É ação constitucional, cuja finalidade é anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade da qual o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ela tem sido muito utilizada e tem obtido resultados bastante satisfatórios.

Ação civil pública. É ação constitucional (artigo 129, III) que somente pode ser proposta por determinadas pessoas jurídicas ou pelo Ministério Público, que são dotados de legitimação extraordinária para a tutela dos interesses protegidos pela norma processual constitucional.

Ações de Constitucionalidade, inconstitucionalidade e arguição de violação de preceito fundamental. Peculiaridades muito próprias do sistema judicial brasileiro fizeram com que um grande número de legitimados pudesse se dirigir ao STF com vistas a discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas de proteção ao meio ambiente.

Há, seguramente, um déficit de aplicação do princípio democrático na prática administrativa do Direito Ambiental brasileiro, notadamente no licenciamento ambiental, o qual transforma a participação de terceiras partes interessadas em mera assistência privilegiada, sem que as suas opiniões sejam, efetivamente, levadas em consideração, ou sem que elas possam estabelecer mecanismos formais de solução de conflitos.

1.4.4 Princípio da precaução

É entre os princípios do Direito Ambiental aquele objeto das mais acirradas polêmicas e debates, com grande repercussão nos foros judiciais, na imprensa e em toda a sociedade.

O princípio da precaução tem origem no Direito alemão e, certamente, é uma de suas principais contribuições ao Direito Ambiental. Foi na década de 70 do século XX que o Direito alemão começou a se preocupar com a necessidade de avaliação prévia das consequências sobre o meio ambiente dos diferentes projetos e empreendimentos que se encontravam em curso ou em vias de implantação. Daí surgiu a ideia de precaução. Na sua formulação original, o princípio estabelecia que a *precaução* era desenvolver em todos os setores da economia processos que reduzissem significativamente as cargas ambientais, principalmente aquelas originadas por substâncias perigosas. Outras formulações do princípio foram sendo construídas e, em pouco tempo, o *Vorsorgeprinzip* se expandiu para o direito internacional e para diversos direitos internos, inclusive o brasileiro. Apesar disso, é importante ressaltar que *não existe* um consenso internacional quanto ao seu significado. Contudo, é possível identificar nas diferentes visões alguns pontos comuns, por exemplo: “*O banimento total pode não ser uma resposta proporcional ao risco potencial em todos os casos*”, como ressaltado no documento da Unesco elaborado sobre a matéria (UNESCO, 2005).

Ante a inexistência de um consenso a respeito do conteúdo concreto do princípio da precaução, há tendência à adoção de *uma definição negativa do princípio*, ou definição do *que ele não é*:

Para evitar mal-entendidos e confusões, é útil refletir sobre o que o PP não é. O PP não é baseado em “risco zero”, mas pretende alcançar riscos ou riscos mais baixos ou mais aceitáveis. Não é baseado em ansiedade ou emoção, mas é uma regra de decisão racional, baseado na ética, que tem como objetivo usar o melhor dos “sistemas de ciências” de processos complexos para tomar decisões mais sábias. Finalmente, como qualquer outro princípio, o PP em si não é um algoritmo de decisão e, portanto, não pode garantir a consistência entre os casos. Assim como em casos judiciais legais, cada caso será um pouco diferente, tendo os seus próprios fatos, incertezas, circunstâncias e tomadores de decisão e o elemento de julgamento não pode ser eliminado (Unesco, 2005, p. 16).

Desnecessário dizer que, ao se estabelecer a *precaução como princípio*, ela não pode ser interpretada como uma cláusula geral, aberta e indeterminada. É preciso que se defina o que se pretende prevenir e qual o risco a ser evitado. Isto, contudo, só pode ser feito diante da análise das diferentes alternativas que se apresentam para a implementação ou não de determinado empreendimento ou atividade. A precaução, inclusive, deve levar em conta os riscos da não implementação do projeto proposto.

Um bom exemplo é o DDT, que vem sendo fortemente combatido desde a publicação de *Silent Spring* de Rachel Carson (1994), em função de alegados danos à saúde humana e ao meio ambiente, poderemos ver que a sua virtual eliminação causou danos muito maiores do que a continuidade de seu uso de forma adequada, conforme tem sido reconhecido por pesquisadores da área médica quando relacionados com os problemas de malária:

O controle sistemático de combate aos vetores da doença iniciou-se na Amazônia, em 1945, nas localidades de Breves e Santa Mônica, Pará. Em setembro de 1947, já havia sido utilizado em outras localidades do estado, no estado do Amazonas e em Guaporé (atual Rondônia) e Amapá, territórios federais na época. Segundo Roberts, o reaparecimento da malária na América do Sul deve-se ao fato de os países terem deixado de utilizar DDT nos programas de controle. Os dois únicos países onde a malária não reapareceu foram Venezuela e Equador, devido ao fato de o DDT não ter sido proibido. Alguns malariologistas argumentam que a aplicação dentro de residências, que seria prejudicial à saúde humana, não é convincente. E que em vários países o uso de inseticidas organoclorados é o único meio economicamente viável de controle, assim como para a leishmaniose. Seus escassos orçamentos para as campanhas de saúde não possibilitariam substituir satisfatoriamente os inseticidas organoclorados, tendo em vista os preços mais elevados de possíveis alternativas (D'AMATO, TORRES e MALM, 2002).

Outro aspecto do Princípio da Precaução que tem sido muito pouco ressaltado é que prevenir riscos ou danos implica *escolher* quais os riscos ou danos pretendemos prevenir e quais os que aceitamos correr. Se feita racionalmente a escolha, escolheremos o risco menor em preferência ao maior. Contudo, nem sempre as escolhas são feitas racionalmente, pois a *percepção* do risco nem sempre guarda alguma relação com o *risco real* e, muitas vezes, a escolha é feita com base na percepção e não no risco real.

O grande lançamento internacional do Princípio da Precaução ocorreu com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, que ficou conhecida como Rio 92. Na oportunidade, foi proclamada a Declaração do Rio que, muito embora não seja juridicamente vinculante para os seus signatários, tem gozado de enorme prestígio e servido de inspiração para grande parte das normas que foram produzidas posteriormente.

O Princípio da Precaução foi redigido como o princípio número 15 da Declaração do Rio da seguinte maneira:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Vários documentos internacionais dotados de força obrigatória têm expressamente assumido o Princípio da Precaução como um de seus fundamentos. Permite-se citar alguns: *Protocolo de Cartagena*: É um documento internacional que encontra suas origens na CDB, cujo objetivo fundamental é estabelecer normas de biossegurança no que se refere à transferência, à manipulação e ao uso dos organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, decorrentes do movimento transfronteira. Tal documento foi promulgado pelo Decreto 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. *Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes*. Tal Convenção, promulgada pelo Decreto 5.472, de 20 de junho de 2005, estabelece em seu artigo 1º que: “*Tendo presente o Princípio da Precaução consagrado no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o objetivo da presente Convenção é proteger a saúde humana e o meio ambiente dos poluentes orgânicos persistentes*”. Esta mesma Convenção, na sua Parte IV, reconhece que a utilização das melhores técnicas disponíveis para prevenir a liberação de poluentes orgânicos persistentes deve levar em conta uma análise custo-benefício quando da aplicação de medidas de precaução e prevenção.

O conceito de melhores técnicas disponíveis não está dirigido a uma técnica ou tecnologia específica, mas deve levar em conta as características técnicas da instalação em questão, sua localização geográfica e as condições ambientais locais. As técnicas apropriadas de controle para reduzir liberações das substâncias químicas relacionadas na Parte I são em geral as mesmas. Na determinação das melhores técnicas disponíveis, consideração especial deve ser dada, em geral ou em casos específicos, aos seguintes fatores, tendo em mente os prováveis custos e benefícios de uma medida e as considerações de precaução e prevenção.⁶

O artigo 1º refere-se à abordagem da precaução, o que claramente indica uma forma de compreender o problema, não uma norma jurídica cogente. “De acordo com a *abordagem de precaução* [grifo PBA] contida no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o objetivo do presente Protocolo é de contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana e enfocando especificamente os movimentos transfronteiriços”. Observa-se que o Protocolo “encoraja” as Partes a levarem em consideração os avanços científicos com vistas à proteção do meio ambiente e da saúde humana:

As Partes são encorajadas a levar em consideração, conforme o caso, os conhecimentos especializados, os instrumentos disponíveis e os trabalhos realizados nos fóruns internacionais competentes na área dos riscos para a saúde humana.

Verifica-se, sem grande dificuldade, que a comunidade internacional tem oscilado na adoção do *nomen juris* princípio da precaução, abordagem de precaução e considerações de precaução, sendo certo que a denominação *princípio* tem sido adotada preferentemente em documentos em força obrigatória.

Uma primeira exegese do texto do princípio nº 15 da Declaração do Rio nos indica que:

- (i) O critério da precaução não é um critério (princípio) definido pela ordem internacional, mas, ao contrário, é um princípio que se materializa na ordem interna de cada Estado, na exata medida das capacidades dos diferentes Estados. Ou seja, a aplicação de tal princípio deve levar em conta o conjunto de recursos disponíveis, em cada um dos Estados, para a proteção ambiental, considerando as peculiaridades locais. Em outras palavras, as medidas adotadas para prevenir a poluição atmosférica em Hamburgo não são as mesmas necessárias para uma pequena cidade no interior da Costa Rica.
- (ii) A dúvida sobre a natureza nociva de uma substância não deve ser interpretada como se não houvesse risco. A dúvida, entretanto, não se confunde com a mera opinião de leigos ou “impressionistas”. A dúvida, para fins de que se impeça uma determinada ação, é fundada em análises técnicas e científicas, realizadas com base em protocolos aceitos pela comunidade internacional. O que tem ocorrido é que, muitas vezes, uma opinião isolada e sem a necessária base científica tem servido de pretexto para que se interrompam projetos e experiências importantes. Dúvida é um elemento fundamental no avanço da ciência, pois sem ela ainda acreditaríamos na quadratura da Terra. Todo conhecimento científico é sujeito à dúvida. O que não admite a dúvida é o dogma religioso que pertence a um domínio diferente da vida humana, que é o campo da fé. É evidente que, se do ponto de vista científico existir uma dúvida – que não se confunde, repita-se, com um palpite –, as medidas de precaução deverão ser tomadas.

O princípio não determina a paralisação da atividade, mas que ela seja realizada com os cuidados necessários, até mesmo para que o conhecimento científico possa avançar e a dúvida ser esclarecida.

Em termos práticos, como se deve proceder diante de uma fundada incerteza quanto aos efeitos que uma determinada intervenção sobre o meio ambiente pode acarretar? Como deve ser aplicado o princípio da precaução? Em primeiro lugar, há que se consignar que o princípio da precaução encontra uma expressão concreta nos sete incisos do § 1º do artigo 225 da CF, ou seja, naqueles incisos existem determinações para que o Poder Público e o legislador ordinário definam meios e modos para que a avaliação dos impactos ambientais seja realizada e que sejam evitados – tanto quanto possível – danos ao meio ambiente. Fora dessas circunstâncias, a aplicação do princípio da precaução não pode ocorrer de forma imediata e sem uma base legal que a sustente.

A expressão normativa do princípio da precaução se materializa nas diversas regras que determinam a avaliação dos impactos ambientais dos diferentes empreendimentos capazes de causar lesão ao meio ambiente, ainda que potencialmente. *Não há qualquer previsão legal para uma aplicação genérica do princípio da precaução, sob o argumento de que os superiores interesses da proteção ambiental assim o exigem*. De fato, é muito comum que, na ausência de norma específica para o exercício de uma determinada atividade, a administração pública se socorra de uma equivocada interpretação dos Princípios da Precaução para criar obstáculos a tal atividade, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos valores do trabalho e da livre-iniciativa e frustrando os *objetivos fundamentais da República*, quais sejam, garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e erradicar a pobreza e marginalização (CF, art. 3º, III). Juridicamente, o princípio da precaução, como *mero princípio setorial*, não pode se sobrepor, por exemplo, aos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), dos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa (CF, art. 1º, IV). Isso para não se falar na impossibilidade de sobreposição de outros princípios setoriais, tais como o da legalidade (CF, art. 37), com os quais deve se harmonizar, visto que hierarquicamente nivelados.

A única aplicação *juridicamente legítima* que se pode fazer do princípio da precaução é aquela que leve em consideração as leis existentes no País e que determine a avaliação dos impactos ambientais de uma certa atividade, conforme a legalidade infraconstitucional existente. Infelizmente, tem havido uma forte tendência a se considerar que o princípio da precaução é um superprincípio que se sobrepõe aos princípios fundamentais da República, tal como estabelecidos pela própria CF, o que, evidentemente, é uma grave ruptura da legalidade constitucional e prova de precário conhecimento jurídico. Ante a possível existência de conflito entre uma norma legal expressa e um princípio setorial, há que prevalecer a norma positivada, salvo se ela se apresentar maculada pela inconstitucionalidade. Observe-se que, no caso, não se trata propriamente da prevalência de um princípio setorial, mas de uma afronta à Constituição, o que é uma preliminar inafastável.

O princípio da precaução tem sido prestigiado pelo legislador brasileiro que, em muitas normas positivadas, determina uma série de medidas com vistas à avaliação dos impactos ambientais reais e potenciais gerados pelos diferentes empreendimentos. Ainda que extremamente relevante – o que é reconhecido por toda a doutrina brasileira e pelo nosso ordenamento jurídico –, o princípio da precaução não é dotado de normatividade capaz de fazer com que ele se sobreponha aos princípios da legalidade (um dos princípios setoriais reitores da administração pública) e, especialmente, aos princípios fundamentais da República, repita-se. A aplicação do princípio da precaução somente se justifica constitucionalmente quando observados os princípios fundamentais da República e ante a inexistência de norma capaz de determinar a adequada avaliação dos impactos ambientais. Fora de tais limites, a aplicação do princípio da precaução se degenera em simples arbítrio.

1.4.5 Princípio da prevenção

É princípio próximo ao da precaução, embora com este não se confunda. *O princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos* e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis. Com base no princípio da prevenção, o licenciamento ambiental e, até mesmo, os estudos de impacto ambiental podem ser realizados e são solicitados pelas autoridades públicas. Pois tanto o licenciamento quanto os estudos prévios de impacto ambiental são realizados com base em conhecimentos acumulados sobre o meio ambiente. O licenciamento ambiental, na qualidade de principal instrumento apto a prevenir danos ambientais, age de forma a evitar e, especialmente, minimizar e mitigar os danos que uma determinada atividade causaria ao meio ambiente, caso não fosse submetida ao licenciamento ambiental.

É importante deixar consignado que a prevenção de danos, tal como presente no princípio ora examinado, não significa – em absoluto – a eliminação de danos. A existência de danos ambientais originados por um empreendimento específico é avaliada em conjunto com os benefícios que são gerados pelo mencionado empreendimento e, a partir de uma análise balanceada de uns e outros, surge a opção política consubstanciada no deferimento ou indeferimento do licenciamento ambiental. As condicionantes estabelecidas para a implantação do projeto, de certa maneira, indicam as condições técnicas e políticas mediante as quais o administrador estabelece a ponderação entre os diferentes interesses em jogo. Este mecanismo de valoração é mais claramente definido na aplicação do chamado princípio do equilíbrio, que será examinado adiante.

O Poder Judiciário tem decidido matérias que são claramente a aplicação do princípio da prevenção, muito embora tenha dele tratado sob o *nomen iuris* de princípio da precaução. É uma confusão justificável, tendo em vista a novidade da matéria; contudo, é importante que se alerte para os efeitos negativos que tal troca de denominação possa vir a causar para uma adequada aplicação do Direito. Diversas são as decisões que incorrem no mesmo equívoco. Diga-se, entretanto, em sua defesa, que a própria doutrina nacional ainda não se estabilizou no sentido de reconhecer a diferença entre ambos os princípios.

1.4.6 Princípio do equilíbrio

Pelo princípio que ora se examina, os aplicadores da política ambiental e do Direito Ambiental devem pesar as consequências previsíveis da adoção de uma determinada medida, de forma que esta possa ser útil à comunidade e não importar gravames excessivos aos ecossistemas e à vida humana. Por meio do mencionado princípio, deve ser realizado um balanço entre as diferentes repercussões do projeto a ser implantado, isto é, devem ser analisadas as consequências ambientais, as consequências econômicas, as sociais etc. A legislação ambiental deverá ser aplicada de acordo com o resultado da aplicação de todas essas variantes.

As medidas capazes de assegurar maior proteção do meio ambiente, como se percebe facilmente, dependem do grau de consciência social em relação à necessidade de que se dê ao meio ambiente atenção prioritária. Não se pode, licitamente, esquecer que rotineiramente são apresentadas dicotomias absolutamente falsas entre progresso e proteção ambiental. *Princípio do equilíbrio é o princípio pelo qual devem ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, buscando-se adotar a solução que melhor concilie um resultado globalmente positivo.*

É uma versão ambiental do conhecido exame de custo/benefício que, em última análise, informa toda e qualquer atividade humana realizada conscientemente.

1.4.7 Princípio da capacidade de suporte

Em edições anteriores desta obra denominei o presente princípio como *princípio do limite*, contudo reflexão mais aprofundada levou-me a alterar-lhe o nome para *princípio da capacidade de suporte*. Justifico a opção. Efetivamente a obrigação que o Poder Público tem de fixar limites para o lançamento de matéria ou energia no ambiente não se explica por si só. Ao contrário, encontra-se condicionada por diferentes e complexos fatores, o que é suficiente para retirar-lhe a ideia de que explicitavam princípios jurídicos de DA. Ao contrário, a existência do princípio é que implica a fixação de limites que, no entanto, não existem em si mesmos e, isto sim, estão condicionados às condições ambientais e outras de diferentes naturezas, seja tecnológica, seja econômica.

O *princípio da capacidade de suporte* tem assento constitucional no inciso V do § 1º do artigo 225 da CF. A primeira manifestação objetiva de tal princípio se dá quando a Administração Pública estabelece padrões de qualidade ambiental que se concretizam em limites de emissões de partículas, de limites aceitáveis de presença de determinados produtos na água etc.

Tais padrões devem, necessariamente, levar em consideração a capacidade de suporte do ambiente, isto é, o limite de matéria ou energia estranha que o ambiente pode suportar sem alterar suas características básicas e essenciais. A Administração Pública tem a obrigação de fixar padrões de emissões de matérias poluentes, de ruído, enfim, de tudo aquilo que possa implicar prejuízos aos recursos ambientais e à saúde humana. A violação dos limites fixados, sem uma justificativa técnica plausível, deve ser sancionada. A fixação dos limites é de extrema importância, pois será a partir deles que se estabelecerá uma presunção que permite à Administração impor coercitivamente as medidas necessárias para que se evite, ou pelo menos se minimize, a poluição e a degradação. Há que se observar, entretanto, que o limite último é a chamada capacidade de suporte do corpo receptor. Os padrões são fixados de forma a, em tese, resguardar a qualidade ambiental. Dependendo do grau de saturação de um corpo receptor, pode ocorrer que o limite esteja acima ou abaixo daquilo que, efetivamente, pode ser suportado pelo ambiente.

Assim, o princípio da capacidade de suporte estabelece uma presunção *iuris tantum* cuja consequência é a transferência do ônus da prova para que o empreendedor demonstre o cumprimento do padrão legal, ou que a sua ultrapassagem não esteja causando danos ao meio ambiente, às pessoas ou aos seus bens.

Há uma importante questão a ser examinada, que é a de saber qual o parâmetro a ser adotado quando da ocasião da fixação dos padrões. O tema é importante e controverso, pois muitas vezes os limites são determinados de acordo com a capacidade industrial e tecnológica de reduzir a poluição. Fixam-se limites cuja base de cálculo leva em consideração o nível tecnológico atual e não o potencial de agressão da atividade que está sendo limitada. A fixação de parâmetros de forma que estes possam estimular o desenvolvimento tecnológico, com vistas ao alcance de índices mais baixos de emissão de partículas, mais elevados de pureza da água e do ar, é um importante elemento para que se alcance a modernização tecnológica e a ampliação dos investimentos em pesquisas de proteção ambiental. Os limites devem ser estabelecidos em função das necessidades de proteção ambiental e da melhor tecnologia disponível, sem custos excessivos. É destituída de sentido a fixação de padrões de emissão e de lançamentos de efluentes em níveis absolutamente idênticos para áreas densamente industrializadas e para outras que não possuem qualquer grau de industrialização. Parâmetros rígidos e idênticos estimulam a concentração industrial e tendem a agravar os níveis de poluição.

Melhor tecnologia disponível, em países cujo nível de desemprego é elevado e nos quais a preparação técnica dos trabalhadores é ainda deficiente, é um critério que deverá levar em consideração fatores de ordem política e econômica extremamente importantes. Uma tecnologia que proteja o meio ambiente de forma adequada, mas que traga como consequência a redução de um grande número de empregos, não pode ser tida como a melhor tecnologia disponível, haja vista que não considera todos os fatores que, necessariamente, estão envolvidos no problema. Melhor tecnologia disponível, em minha opinião, deve ser aquela que, no conjunto, atenda às diferentes necessidades identificadas no projeto.

O princípio da capacidade de suporte tem reconhecimento normativo no direito positivo brasileiro. A Resolução Conama nº 382, de 26 de dezembro de 2006: *estabelece que os limites máximos de emissões de poluentes atmosféricos em seu conjunto estão ligados à capacidade de suporte do ambiente no qual eles são lançados.* De fato, os incisos I e IV do artigo 2º da Resolução dispõem que: “para o estabelecimento dos limites de emissão de poluentes atmosféricos são considerados os seguintes critérios mínimos: I – o uso do limite de emissões é um dos instrumentos de controle ambiental, cuja aplicação deve ser associada a critérios de capacidade de suporte do meio ambiente, ou seja, ao grau de saturação da região onde se encontra o empreendimento; [...] IV – possibilidade de diferenciação dos limites de emissão, em função do porte, localização e especificidades das fontes de emissão, bem como das características, carga e efeitos dos poluentes liberados; [...]”.

A capacidade de suporte é definida normativamente como “a capacidade da atmosfera de uma região receber os remanescentes das fontes emissoras de forma a serem atendidos os padrões ambientais e os diversos usos dos recursos naturais”.

É importante observar que a Resolução desmente a afirmação muito comum em DA que somente poderão ser fixados padrões mais restritivos. Ao contrário, o princípio da capacidade de suporte expressamente admite que padrões menos restritivos de emissões sejam autorizados, desde que, tecnicamente, fique comprovado que a sua adoção não implicará prejuízos ao meio ambiente ou à saúde humana. O § 2º do artigo 6º da Resolução estabelece que: “o órgão ambiental licenciador poderá, mediante decisão fundamentada, a seu critério, estabelecer limites de emissão menos restritivos que os estabelecidos nesta Resolução para as fontes fixas de emissões atmosféricas, nas modificações passíveis de licenciamento em fontes já instaladas e regularizadas, que apresentem comprovados ganhos ambientais, tais como os resultantes da conversão de caldeiras para o uso de gás, que minimizam os impactos ambientais de fontes projetadas originalmente com outro(s) insumo(s), notadamente óleo combustível e carvão”.

Tal circunstância é confirmada pelo artigo 7º, parágrafo 1º, ao tratar de instalações já em operação: “As fontes fixas existentes, por já estarem em funcionamento ou com a licença de instalação requerida antes da publicação desta Resolução, deverão ter seus limites de emissão fixados pelo órgão ambiental licenciador, a qualquer momento ou no processo de renovação de licença, mediante decisão fundamentada. § 1º O órgão ambiental licenciador poderá estabelecer valores menos restritivos que os limites máximos de emissão estabelecidos nesta Resolução, considerando as limitações tecnológicas e o impacto nas condições locais, de acordo com o disposto na Resolução Conama nº 05, de 15 de junho de 1989”.

1.4.8 Princípio da responsabilidade

Qualquer violação do Direito implica a sanção do responsável pela quebra da ordem jurídica. A CF Brasileira estabelece, no § 3º do artigo 225, a responsabilidade por danos ao meio ambiente, embora não defina o caráter subjetivo ou objetivo dela. Esta questão restou delegada para a legislação ordinária que a definiu como objetiva. Um ponto que julgo mereça ser ressaltado é o fato de que a responsabilidade, no sistema jurídico brasileiro, decorre de lei, contrato ou ato ilícito. A responsabilidade ambiental se divide em: (i) civil, (ii) administrativa e (iii) penal.

1.4.9 Princípio do poluidor pagador

O reconhecimento de que o mercado nem sempre age tão livremente como supõe a teoria econômica, principalmente pela ampla utilização de subsídios ambientais, a saber, por práticas econômicas que são utilizadas em detrimento da qualidade ambiental e que diminuem artificialmente preços de produtos e serviços, fez com que se estabelecesse o chamado Princípio do Poluidor Pagador, que foi introduzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, mediante a adoção, aos 26 de maio de 1972, da Recomendação C(72) 128, do Conselho Diretor, que trata de princípios dos aspectos econômicos das políticas ambientais (OECD, 1972). O PPP parte da constatação de que os recursos ambientais são escassos e que o seu uso na produção e no consumo acarretam a sua redução e degradação. Ora, se o custo da redução dos recursos naturais não for considerado no sistema de preços, o mercado não será capaz de refletir a escassez. Assim sendo, são necessárias políticas públicas capazes de eliminar a falha de mercado, de forma a assegurar que os preços dos produtos reflitam os custos ambientais.

A – Princípios dirigentes. A) Alocação de custos: O Princípio Poluidor Pagador 2. Os recursos ambientais são em geral limitados e o seu uso em atividades de produção e consumo pode levá-los à deterioração. Quando o custo desta deterioração não é adequadamente levado em conta no sistema de preços, o mercado falha em refletir a escassez de tais recursos no nível nacional e no internacional. Medidas públicas são, então, necessárias para reduzir a poluição e para alcançar uma melhor alocação de recursos, assegurando que os preços dos bens dependentes da qualidade e da quantidade de recursos ambientais reflitam mais proximamente a sua escassez relativa e que os agentes econômicos envolvidos ajam de acordo... 4. O princípio a ser usado para a alocação dos custos da prevenção e das medidas de controle da poluição que sirvam para encorajar o uso racional dos escassos recursos ambientais e para evitar distorções no comércio e no investimento é o assim chamado “Princípio Poluidor Pagador”. Este princípio significa que o poluidor deve suportar os custos de realização das medidas acima mencionadas decididas pelas autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja em um estado aceitável. Em outras palavras, os custos destas medidas devem estar refletidos no custo dos bens e serviços que causam poluição na produção e/ou consumo. Estas medidas não devem ser acompanhadas por subsídios que criem significativas distorções no comércio e investimento internacionais (OECD, 1972).⁷

O elemento que diferencia o PPP da responsabilidade é que ele busca afastar o ônus do custo econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais. Ele não pretende recuperar um bem ambiental que tenha sido lesado, mas estabelecer um mecanismo econômico que impeça o desperdício de recursos ambientais, impondo-lhes preços compatíveis com a realidade.

Os recursos ambientais como água, ar, em função de sua natureza pública, sempre que forem prejudicados ou poluídos, implicam um custo público para a sua recuperação e limpeza. Este custo público, como se sabe, é suportado por toda a sociedade. Economicamente, este custo representa um subsídio ao poluidor. O PPP busca, exatamente, eliminar ou reduzir tal subsídio a valores insignificantes (ARAGÃO, 1997, p. 34). O PPP, de origem econômica, transformou-se em um dos princípios jurídicos ambientais mais importantes para a proteção ambiental.

1.4.10 Conclusão

Os diferentes princípios aplicáveis ao Direito Ambiental giram em torno de um princípio constitucional básico, que é o *princípio da dignidade da pessoa humana*, e devem ser compreendidos e, sobretudo, aplicados à luz daquele que é um dos próprios fundamentos da CF e da própria República.

Os princípios do Direito Ambiental são extremamente importantes, visto que a proteção do meio ambiente se faz de forma dinâmica e não meramente estática. Não raro, surgem situações que não encontram tratamento legislativo ou regulamentar, mas que, no entanto, demandam uma ação administrativa ou judicial capaz de prover soluções, ainda que parciais, para as questões concretamente formuladas. É estreme de dúvidas que, em tais oportunidades, a principiologia particular do Direito Ambiental avulta em importância. Contudo, há que ser repelida a hipertrofia dos princípios de Direito Ambiental que, por ser caracterizada por uma aplicação aleatória e assistemática de princípios ainda mal definidos e sobre os quais não existe um consenso doutrinário e judicial, acaba se transformando em arbitrariedade, visto que significa o abandono de conceitos legais.

Os princípios de Direito Ambiental não existem em si mesmos, de forma autônoma e desvinculada da ordem jurídico-constitucional; ao contrário, eles só encontram existência no interior da Ordem Constitucional, na qual devem ser interpretados em harmonia com os demais princípios da própria CF e, o que é muito importante, subordinados aos princípios fundamentais que regem a República Brasileira.

1.5 FONTES DO DIREITO AMBIENTAL

As fontes do Direito são sempre um tema extremamente problemático em todas as áreas do Direito. Embora seja dotado das peculiaridades que têm sido vistas ao longo deste capítulo, não se pode deixar de considerar que, também para o Direito Ambiental, a matéria é extremamente importante.

1.5.1 Fontes materiais

1.5.1.1 Movimentos populares

As fontes materiais do Direito Ambiental são múltiplas e, na realidade, guardam relações bastante complexas entre si. Dentre as fontes materiais do Direito Ambiental, podemos encontrar o movimento dos cidadãos por uma melhor qualidade de vida; contra os riscos efetivos decorrentes da utilização de determinados produtos e práticas etc. Enfim, é extremamente variada a relação das fontes materiais de nossa disciplina. Doravante, faremos uma pequena exposição das principais

O movimento dos cidadãos em defesa da qualidade de vida e do meio ambiente ganhou maior expressão social e política a partir de 1960, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. No Brasil, esse movimento teve seu início na década de 70 do século XX, no Estado do Rio Grande do Sul, que, desde então, vem se mantendo em posição vanguardista na proteção ambiental. Não se pode esquecer, contudo, que, na mesma década, no Estado do Acre, tiveram início as atividades que ficaram conhecidas como “empate”. Por tais movimentos, os seringueiros impediam a derrubada de florestas, visando a assegurar a preservação dos seringais e, consequentemente, de seu modo tradicional de produção e vida. É importante observar que a prática adotada pelos seringueiros deu margem ao nascimento de um modelo específico de unidade de conservação, as reservas extrativistas.

Este movimento teve a sua maior liderança em Chico Mendes que, com coragem e alto espírito de abnegação, soube defender a causa de seus iguais. Lamentavelmente, o grande líder foi assassinado covardemente. Sua saga, entretanto, serve de luz para todos aqueles que estão empenhados em defender o meio ambiente e a melhoria das condições de vida de nossa população.

Em 1971, foi fundada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan). Anteriormente, no Rio Grande do Sul, já existia a União Protetora da Natureza, cuja fundação remonta ao ano de 1955. O primeiro ato de impacto nacional promovido pela Agapan ocorreu quando o estudante de arquitetura Carlos Alberto Dayrell subiu em um pé de Tipuana, no centro de Porto Alegre, para evitar fosse este derrubado por uma obra que a Prefeitura planejava desenvolver (construção de um viaduto); isto se deu no ano de 1977. A manifestação foi vitoriosa, pois a Prefeitura precisou mudar os planos para a construção do viaduto e não derrubou a árvore.

Outras lutas importantes desenvolvidas pela Agapan foram contra a Riocell (na época, denominada Boregaard), contra o polo petroquímico de Triunfo, contra as usinas termelétricas de Candiota e de Jacuí. O movimento dos cidadãos em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, no Rio Grande do Sul, é diretamente responsável pela elaboração de diversas leis protetoras do meio ambiente. Dentre essas, pode ser destacada a Lei nº 7.747/82, que proíbe a produção e comercialização de agrotóxicos no Rio Grande do Sul.

“Ainda estamos em cima da árvore”,

homenagem a Carlos Alberto Dayrell. O texto a seguir é de autoria grupal. Foi lido pela *Agapan* quando do recebimento do título de cidadão honorário de Porto Alegre pelo Eng. Agrônomo *Carlos Alberto Dayrell*, em 28 de abril de 1998:

Há quase três décadas, o estudante e associado da Agapan – Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – subiu em uma árvore em frente à Faculdade de Direito da UFRGS, impedindo que ela e outras fossem desnecessariamente derrubadas para a construção de uma via elevada. A multidão solidária que presenciou aquele ato e milhões de pessoas que dele tiveram conhecimento no mundo inteiro compreenderam a novidade radical e o imenso significado daquele gesto exemplar. O acontecimento, manchete na imprensa local, nacional e mundial, foi um dos símbolos que consagraram o surgimento do ambientalismo como uma nova tomada de consciência da realidade e como a bandeira de uma nova ética universal, a impor limites ao industrialismo selvagem e ao consumismo predatório da civilização industrial contemporânea. Na época de Dayrell a agressão à natureza começou a ser percebida como parte da opressão política e da repressão ideológica promovida pelas ditaduras militares na América Latina e pela guerra fria. A descoberta das possibilidades e da necessidade do desenvolvimento de relações de solidariedade com o mundo natural e humano faziam parte de uma mesma busca de liberdade. Além disso, a problemática ecológica introduzia questionamentos que não se enquadravam na visão de mundo das concepções políticas vigentes naquele período de radicalização do conflito entre as ideologias de esquerda e direita. A novidade ecológica era recebida como uma entrada de ar fresco, uma ampliação dos horizontes da condição humana e do seu sentido. Os problemas colocados por uma obra como *Os Limites do Crescimento* (1968) derrubavam o dogma fundamental do capitalismo e também dos países ditos comunistas: a necessidade e a possibilidade do crescimento econômico e do aumento contínuo da produção e do consumo como condição do desenvolvimento econômico e social. A 1ª Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, junho de 1972), com a participação lamentável da representação brasileira – que convidou os poluidores do mundo a virem desenvolver o Brasil – representava o reconhecimento oficial da problemática ecológica. A atuação pioneira da Agapan, fundada em 27 de abril de 1971, em Porto Alegre, através da figura de José Lutzenberger, encontrava uma ressonância na mídia local e nacional e junto aos meios universitários. Pensadores e líderes ambientalistas perceberam que harmonizar civilização industrial e natureza era um desafio que exigiria uma revolução cultural, econômica e social sem precedentes. *O Fim do Futuro – Manifesto Ecológico Brasileiro* (1976), escrito por José Lutzenberger, então presidente da Agapan, foi a primeira e única obra a traduzir em termos de contexto cultural brasileiro, uma resposta global e abrangente ao desafio ecológico. A imprensa brasileira dava uma cobertura intensa e permanente às questões ambientais. Paralelamente, desde o início dos anos 70, a administração pública, pressionada pelos ambientalistas, começou a se ocupar da questão ambiental, criando secretarias, ministérios, conselhos, comissões, gerando legislação ambiental e órgãos de controle de poluição, nos âmbitos federal, estadual e municipal. A Agapan lançou campanhas contra a poda de árvores, o uso de agrotóxicos, a energia nuclear, a devastação da Amazônia e numerosos outros temas, obtendo vitórias sucessivas em termos de legislação e apoio da opinião pública. O gesto de Dayrell ao subir naquela árvore simbolizou a nova tomada de consciência de uma época. Hoje os tempos são outros. Vimos o fim dos governos militares no Brasil e América Latina, ao que seguiu a distensão do conflito entre capitalismo e comunismo. A ascensão do neoliberalismo e a normalização democrática da política brasileira diluíram a dimensão política da questão ambiental. Atualmente, a ideologia consumista e predatória da civilização industrial – com seus *shopping centers*, seus produtos descartáveis, seu lixo e seus estragos irreversíveis na saúde pública e na natureza – triunfa como uma nova religião. Os meios de comunicação de massa promovem uma verdadeira lavagem cerebral confundindo o consumismo com a própria felicidade. O vocabulário ambientalista foi apropriado pelos governos, pela mídia, pela indústria; o “verdismo” virou moda e até grife. As estratégias de *marketing* e publicidade lançam uma cortina de fumaça verde sobre a realidade, impedindo uma compreensão pública mais efetiva da problemática ambiental e das mudanças necessárias para solucioná-la. A realidade antiecológica, opressora e devastadora, justamente denunciada pelo protesto de Dayrell ao subir na árvore, continua a existir com mais força até do que em tempos passados. A realização da Rio 92 foi a culminância de um processo de confraternização ambientalista mundial e de ecologização da opinião pública, que teve lugar apesar dos poderes da civilização industrial ali presentes. As dificuldades encontradas para a assinatura de convenções e as posições intransigentes da maioria dos países industrializados na defesa dos interesses econômicos em detrimento da biodiversidade foram nuvens negras no céu azul dos ecologistas ali reunidos. Vivemos atualmente o paradoxo da aparente consagração definitiva das teses do movimento ecológico sem as esperadas e necessárias transformações na ideologia do consumismo ilimitado e suas contrapartidas nos planos político, econômico, tecnológico e comunicacional-informacional. Decorridas quase três décadas de ambientalismo, as lideranças culturais, políticas, científicas e tecnológicas brasileiras, presas a paradigmas pré-ecológicos ultrapassados (ironicamente explicáveis pela Teoria da Dependência, elaborada por Fernando Henrique Cardoso) ainda não deram respostas ao desafio de propor modelos alternativos de desenvolvimento que incorporem criativamente a dimensão ecológica no que ela tem de mais radical. O chamado “desenvolvimento sustentável” é o discurso oficial de governos e empresariado que corresponde ao conceito sociológico de “modernização conservadora” (expressão utilizada por Hélio Jaguaribe) ou seja, é uma reação paliativa ao desafio ecológico que não atende efetivamente às demandas tecnológicas, econômicas, políticas e culturais que se apresentam. Entretanto, apesar de desafiarem poderosos interesses econômicos e políticos, as ideias do movimento ecológico continuam a provocar uma irresistível trajetória de transformações pontuais em praticamente todos os campos da cultura. Estas vão desde reformulações teóricas em diversos campos do conhecimento, da ética à filosofia, das artes às ciências humanas e naturais, inclusive apresentando inovações tecnológicas

– como na agricultura, onde a perspectiva agroecológica vem ganhando terreno dia a dia em todos os lugares do mundo. Mesmo assim, o gesto exemplar de Dayrell deve ser reinterpretado. Quando aconteceu, a compreensão da problemática ambiental era mais simples e estava muito mais ao alcance do grande público. Pode-se dizer que respondia à problemática instaurada pela Revolução Industrial. Hoje temos uma nova complexidade que vem no bojo da revolução biológica em curso. A biotecnologia, os organismos transgênicos, o patenteamento de seres vivos e todas as implicações econômicas daí derivadas apresentam uma complexidade cuja compreensão ainda está muito longe do domínio público. O atual sistema econômico, por ser intrinsecamente incapaz de refutar os questionamentos trazidos pelo paradigma ecológico, realiza apenas modificações de fachada nos processos industriais poluentes – e ainda cria novos problemas no campo biológico – sem qualquer alteração na ideologia do consumo ilimitado. Nós, ecologistas, não temos soluções prontas, imediatas e tranquilizadoras que assegurem a preservação da biodiversidade essencial à manutenção da vida no Planeta. Da mesma forma, não podemos isoladamente garantir a adoção de um novo imperativo ético de solidariedade com as gerações futuras. Assim, após quase três décadas de movimento ecológico, o gesto de Dayrell continua a ser um símbolo de valor permanente tanto para a Agapan como para os ambientalistas do Brasil e do Mundo. *Obrigado, Dayrell*. Disponível em: <<http://www.agirazul.com/eds/ed13/dayrell1.htm>>. Acesso em: 19 set. 2015.

1.5.1.2 Descobertas científicas

As descobertas científicas desempenham um importante papel na construção do Direito Ambiental. Questões como o aquecimento global, que gerou o Protocolo de Quioto; o Protocolo de Montreal sobre a proteção da camada de ozônio, as convenções sobre produtos perigosos e tantas outras são diretamente fundadas em descobertas científicas significativas. Tais descobertas exercem o papel de chamar a atenção para questões cruciais que demandam uma regulamentação jurídica. Muitas vezes, princípios científicos são incorporados ao mundo jurídico também.

1.5.1.3 Doutrina jurídica

A doutrina é uma importante fonte material do Direito Ambiental, pois, através dela, muitas mudanças legislativas e interpretativas têm sido adotadas nos mais diversos países. Merece destaque, no particular, a elaboração doutrinária dos princípios do Direito Ambiental que, cada vez mais, tornam-se fundamentais na elaboração de leis e na aplicação judicial das normas de proteção ao meio ambiente. No Brasil, é bastante comum que decisões judiciais cite expressamente a doutrina elaborada por juristas nacionais e estrangeiros.

1.5.2 Fontes formais

As fontes formais do Direito Ambiental não se distinguem ontologicamente daquelas que são aceitas e reconhecidas como válidas para os mais diversos ramos do Direito. Consideram-se fontes formais do DA: a Constituição, as leis, os atos internacionais firmados pelo Brasil, as normas administrativas originadas dos órgãos competentes e a jurisprudência.

O papel desempenhado pela CF como fonte de Direito Ambiental é óbvio, dispensando maiores comentários. Observe-se, contudo, que, devido ao sistema federal adotado pelo Brasil, existem várias Constituições estaduais que devem ser obedecidas e seguidas em seus âmbitos específicos de competência. Tais Constituições, evidentemente, devem se adequar ao modelo definido pela CF, sob pena de inconstitucionalidade (STF – ADI 1505/ES. Relator: Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. *DJU* 04/03/2005).

As leis brasileiras sobre proteção ambiental podem ser federais, estaduais ou municipais, cada uma dentro de uma determinada esfera de atribuição e competência. A CF define um modelo para que cada lei de um ente federativo seja válida em determinada esfera. Os atos internacionais ratificados pelo Brasil integram o Direito brasileiro com a hierarquia de lei.

As normas administrativas são muito importantes em Direito Ambiental. Argumenta-se que não é possível que o Congresso legisle com a velocidade necessária para acompanhar determinadas áreas científicas nas quais a evolução é extremamente rápida, motivo pelo qual as normas administrativas devem ter o seu poder ampliado. Se, por um lado, este é um aspecto da realidade objetiva, por outro, é ele muito perigoso, pois o Executivo tende a exorbitar de suas atribuições, seja para ampliar a “proteção” ambiental à custa de direitos e garantias individuais, mediante a imposição de restrições às atividades de particulares que não encontram referência na lei; seja pela inobservância de normas e parâmetros legais, em prejuízo da boa qualidade ambiental. Aqui, não há como se afastar a incidência do princípio da legalidade estabelecido na CF, ou seja, as normas administrativas não podem ultrapassar os limites fixados pela lei, sob pena de invalidade formal.

A jurisprudência é um fator fundamental na construção do Direito Ambiental, mesmo em um sistema como o nosso, que privilegia o direito legislado. Este fato tem sido ressaltado por quase todos os autores que se dedicam ao estudo da proteção legal do Meio Ambiente. Com efeito, muitos dos contornos básicos do Direito Ambiental foram construídos em litígios judiciais, transportando-se para o mundo legislativo.

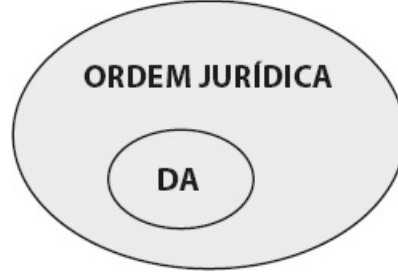
1.6 RELAÇÕES DO DIREITO AMBIENTAL COM OUTROS RAMOS DO DIREITO

O Direito Ambiental é um dos “ramos” da ordem jurídica que mais fortemente se relaciona com os demais. Este fato, indiscutível por si só, é uma consequência lógica da *transversalidade* (STJ, MS 021580, Relator: Min. SÉRGIO KUKINA, 19/02/2015), que é, como sabemos, a característica mais marcante do Direito Ambiental. *Transversalidade* significa que o Direito Ambiental penetra os diferentes ramos do direito positivo, fazendo com que todos, indiferentemente de suas bases teleológicas, assumam a preocupação com a proteção do meio ambiente. É muito difícil que se consiga conceber o Direito Ambiental independentemente das normas próprias do Direito Administrativo, visto que a Administração Pública, pelo exercício do poder de polícia ambiental, desempenha um papel essencial na imensa maioria das questões ambientais. A imposição de multas, a interdição de atividades, a oposição de embargos administrativos não podem fugir dos cânones básicos do Direito Administrativo, tais como a observância do princípio da legalidade, da proporcionalidade, da impessoalidade e de outros que lhes são relacionados (STF, DI-MC 1823/DF, Relator: Min. Ilmar Galvão, Pleno, *DJU* 16/10/1998). O mesmo se diga em relação ao Direito Constitucional.

Quanto à defesa de direitos “privados” sobre o meio ambiente, o direito de vizinhança tem exercido um importante papel, sobretudo no que se refere à garantia de tranquilidade e sossego das pessoas. No Direito Penal, encontram-se diversas normas de defesa da saúde e da ambiência humana (Muito embora a tutela penal ambiental objetive proteger bem jurídico de indiscutível valor social, sabido que toda intervenção estatal deverá ocorrer com estrita observância dos postulados fundamentais do Direito Penal, notadamente dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação do princípio da insignificância (ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela) reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, permitindo a afirmação da atipicidade material nos casos de perturbações jurídicas mínimas ou leves, consideradas também em razão do grau de afetação da ordem social que ocasionem. (STJ, AgRg no REsp 1263800/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, *DJe* 21/08/2014).

Também as normas de Direito Tributário podem ser utilizadas em defesa do meio ambiente. No particular, não se deve esquecer que o Direito Ambiental se utiliza das taxas para o pagamento de licenciamento ambiental e para controle ambiental, além de outras.

O Direito Ambiental mantém intensas relações com os principais ramos do Direito Público e do Direito Privado, influenciando os seus rumos na medida em que carrega para o interior dos núcleos tradicionais do Direito a preocupação com a tutela jurídica do meio ambiente. Esta é a chave da compreensão das relações do Direito Ambiental com os demais ramos do Direito: o Direito Ambiental penetra nos demais “ramos” do Direito, fazendo com que eles assumam uma “preocupação” com os bens jurídicos tutelados pelo Direito Ambiental.



1.7 METODOLOGIA DO DIREITO AMBIENTAL

Tem sido reconhecida como uma das características fundamentais do Direito Ambiental a sua interdisciplinaridade. Não se pode pensar a proteção jurídica do meio ambiente sem se considerarem as informações e os dados fornecidos ao aplicador do Direito por outras áreas do conhecimento humano. Não se concebe a proteção de florestas sem que se saibam as condições de suporte de determinado ecossistema, as condições econômicas das populações que vivem naquele ecossistema. Enfim, o Direito Ambiental somente pode oferecer solução jurídica se ela estiver coordenada e integrada com as questões que permeiam o problema de fundo a ser enfrentado pelo Direito. Dentre esses vários conhecimentos que influenciam a construção do Direito Ambiental, podem ser destacados a Biologia, a Química, a Meteorologia, as Ciências Sociais etc. Muitas vezes, o jurista recorre a conceitos de outras ciências para dar solução a um problema que, aparentemente, estava alicerçado em questão puramente jurídica. A metodologia do Direito Ambiental, portanto, não pode se restringir à análise dogmática da norma jurídica, muito embora esta seja essencial.

Em matéria de Direito Ambiental, as fronteiras entre os diversos segmentos do conhecimento humano são cada vez menores. Na análise de uma medida a ser tomada pelo aplicador da lei em matéria ambiental, necessariamente, estão presentes considerações não jurídicas, pois, como tem sido visto ao longo de todo este capítulo, é necessário que se observem critérios que não são apenas jurídicos.

Observe-se que as normas de Direito Ambiental, muitas vezes, necessitam de preenchimento feito por portarias e outros atos administrativos, cujo conteúdo é fornecido por disciplinas não jurídicas. Decorre daí a imperiosa necessidade de que o jurista, ao tratar de questões ambientais, tenha conhecimento de disciplinas que não são a sua, ou que busque tal conhecimento onde ele se encontra disponível.

A metodologia jurídico-ambiental é eclética e construída caso a caso, pois somente em uma análise casuística que, no entanto, é iluminada pela lei, pela principiologia e pela jurisprudência, se poderá chegar à solução considerada justa.

-
- ¹ José Sávio Leopoldi, *Rousseau – estado de natureza, o “bom selvagem” e as sociedades indígenas*. Disponível em: <http://publique.rdc.pucrio.br/revistaalceu/media/alceu_n4_Leopoldi.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2007.
 - ² Disponível em: <<http://www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc>>. Acesso em: 19 maio 2007.
 - ³ *Iliada*, ix, 63.
 - ⁴ THOREAU, Henry David, *Life without principle*. Disponível em: <<http://thoreau.eserver.org/life1.html>>. Acesso em: 12 set. 2015.
 - ⁵ Os Estados adotarão *legislação ambiental* eficaz. As normas ambientais, e os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de meio ambiente a que se aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão ser inadequadas para outros, em particular para os países em desenvolvimento, acarretando custos econômicos e sociais injustificados.
 - ⁶ Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_5472_2005.htm>. Acesso em: 13 jun. 2007.
 - ⁷ Disponível em: <<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0132>>. Acesso em: 17 nov. 2018.

A ORDEM CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE

§ 1º AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E O MEIO AMBIENTE

2.1 INTRODUÇÃO

A principal fonte formal do Direito Ambiental é a Constituição da República. A CF de 1988 trouxe imensas novidades em relação às que a antecederam, notadamente na defesa dos direitos e garantias individuais e no reconhecimento de nova gama de direitos, dentre os quais se destaca o direito meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nas Constituições anteriores as referências aos *recursos ambientais* eram feitas de maneira não sistemática, com pequenas menções aqui e ali, sem que se pudesse falar na existência de um contexto constitucional de proteção ao meio ambiente.

A Constituição Imperial de 1824 não fez qualquer referência aos recursos naturais, sendo, portanto, irrelevante para o nosso estudo. É curioso observar, no entanto, que, na ocasião de sua promulgação, o País era essencialmente exportador de produtos primários não manufaturados e, portanto, inteiramente dependente dos bens naturais. A concepção predominante, no entanto, era a de que o Estado não deveria se imiscuir nas atividades econômicas, ou melhor, fazia-o por abstenção, havendo uma menção às Câmaras Municipais (art. 169), determinando que lei decretasse suas competências para a “formação das posturas policiais” e “todas as suas particulares e úteis atribuições”, o que foi feito pela Lei de 1ª de outubro de 1828.

Quanto ao meio ambiente, a identificação das competências legislativas era atribuída aos municípios que as exerciam mediante a expedição das chamadas *posturas*. Naquele regime jurídico constitucional, as municipalidades tinham competências amplas (art. 66 e parágrafos).

2.2 O PERÍODO REPUBLICANO

Na primeira fase do regime político que sucedeu o Império do Brasil, conforme foi muito bem observado por Machado Horta (1992, p. 271), “[...] o tema ambiental se confundia com a autorização conferida à União para legislar sobre defesa e proteção da saúde ou com a proteção aos monumentos históricos, artísticos e naturais, às paisagens e aos locais particularmente dotados pela natureza [...]”. À mudança do regime político ocasionada pela proclamação da República correspondeu uma nova Constituição. Os municípios, no novo regime, perderam o alto índice de autonomia legislativa que detinham no regime constitucional anterior. As províncias foram transformadas em Estados e, de alguma forma, buscou-se atribuir-lhes um determinado grau de autonomia. Isto, entretanto, não se concretizou de forma plena, pois a federação que foi estabelecida era altamente centralizadora. Esta característica, como se sabe, persistiu – em maior ou menor grau – nas diferentes Cartas republicanas. A CF de 1891, em seu artigo 34, nº 29, atribuía competência legislativa à União para legislar sobre as *suas minas e terras*. Em tese, aos Estados estava reservada a competência para legislar sobre as minas e terras que não pertencessem à União.

Em 1934, como fruto da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista de 1932 – ocorrida em São Paulo –, foi elaborada uma nova CF, que, dentro do espírito da época, tinha características intervencionistas na ordem econômica e social. A CF de 1934, em seu artigo 5º, inciso XIX, já atribuía à União competência legislativa sobre “*bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, água, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração*”.

As competências legislativas federais foram muito ampliadas e, principalmente, deve ser anotado que elas cresceram nas áreas que modernamente são classificadas como *infraestrutura*, isto é, atividades necessárias para o desenvolvimento econômico. De alguma forma, a CF de 1934 estimulou o desenvolvimento de uma legislação infraconstitucional preocupada com a proteção ambiental, dentro de uma abordagem de conservação de recursos econômicos. Um bom exemplo é o Código de Águas de 1934, cujos objetivos primordiais estavam relacionados à produção de energia elétrica. O mesmo se pode dizer em relação ao antigo Código Florestal (1934), que buscou estabelecer mecanismos para a utilização industrial das florestas. Ambos os diplomas legais continham normas visando à proteção dos recursos. A Constituição de 1937 dispunha, em seu artigo 16, inciso XIV, competir privativamente à União legislar sobre “*os bens de domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua exploração*”.

O próprio regime democrático de 1946 não alterou substancialmente as competências legislativas da União em temas referentes à infraestrutura e, consequentemente, ambientais. Os textos anteriores foram, praticamente, repetidos. Na CF de 1946, em seu artigo 5º, inciso XV, alínea I, constava a competência da União para legislar sobre “*riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca*”.

Com a implantação do regime político de 1964, e a exacerbação dos poderes do Executivo federal, que passou a exercê-los de forma discricionária e autoritária, mediante a imposição de uma ditadura cívico-militar, houve uma hipertrofia dos Poderes da União que, como se viu, não eram pequenos. A CF de 1967, em seu artigo 8º, XII, atribuiu as seguintes competências para a União: “*organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente a seca e as inundações*”. Outras competências estavam previstas entre aquelas titularizadas pela União. Nos termos da Carta de 1967, competia à União explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão, os serviços e as instalações de energia elétrica de qualquer origem ou natureza, mantendo a característica de que a infraestrutura era uma matéria federal. Aqui, como é fácil perceber, tratava-se de uma competência administrativa que, necessariamente, trazia consigo a competência legislativa. Quanto à competência legislativa, propriamente dita, a Carta de 1967 estabelecia que a União era dotada das seguintes potestades legislativas: (i) direito agrário; (ii) normas gerais de segurança e proteção da saúde; (iii) águas e energia elétrica; (iv) jazidas, minas e outros recursos minerais; (v) metalurgia; (vi) florestas, caça e pesca; (vii) regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial e lacustre.

A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, manteve as competências. Houve, entretanto, uma pequena mudança no que diz respeito às competências legislativas em relação à energia, que foi subdividida em elétrica, térmica, nuclear ou de qualquer natureza. Um balanço geral das competências constitucionais em matéria ambiental demonstra que o tema, até a Constituição de 1988, mereceu tratamento apenas tangencial e que a principal preocupação do constituinte sempre foi com a infraestrutura para o desenvolvimento econômico.

2.3 A CONSTITUIÇÃO DE 1988

2.3.1 Aspectos gerais da Constituição de 1988

Além de ser dotada de um capítulo próprio para o meio ambiente, a CF de 1988, ao longo de diversos outros artigos, trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro com o meio ambiente. Tais normas, do ponto de vista do Direito Constitucional, podem ser agrupadas como normas de (i) garantia, (ii) competência, (iii) gerais e (iv) específicas (HORTA, 2002, p. 271). Conforme já foi examinado nos itens precedentes, as Constituições que antecederam à atual Carta deram ao tema meio ambiente um tratamento esparso e com enfoque voltado para a infraestrutura da atividade econômica, e a sua regulamentação legislativa teve por escopo priorizar a atividade produtiva, independentemente da conservação dos recursos naturais. A Constituição de 1988 não desconsiderou o meio ambiente como elemento indispensável e que servira de base para o desenvolvimento da atividade de infraestrutura econômica. Ao contrário, houve um aprofundamento das relações entre o meio ambiente e a infraestrutura econômica, pois, nos termos da Constituição de 1988, é reconhecido pelo constituinte originário que se faz necessária a proteção ambiental de forma que se possa assegurar uma adequada fruição dos recursos ambientais e um nível elevado de qualidade de vida às populações. A Constituição não desconsiderou que toda a atividade econômica se faz pela utilização de recursos ambientais. O legislador constituinte estabeleceu um mecanismo mediante o qual as tensões entre os diferentes usuários dos recursos ambientais sejam amenizadas dentro de uma perspectiva de utilização sustentável.

A fruição do meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado foi erigida em direito fundamental. A adequada compreensão do capítulo e dos dispositivos constitucionais voltados para o Meio Ambiente é essencial e exige uma atenção toda especial para disciplinas não jurídicas. Conceitos pertencentes à Geografia, à Ecologia, à Mineralogia etc. passam a desempenhar um papel na interpretação da norma constitucional que era completamente impensável antes de 1988. Esse é, provavelmente, o maior desafio que o artigo 225 lança ao jurista.

Vê-se, com clareza, que há, no contexto constitucional, um sistema de proteção ao meio ambiente que ultrapassa as meras disposições esparsas. Aqui reside a diferença fundamental entre a Constituição de 1988 e as que a precederam. Em 1988, buscou-se estabelecer uma harmonia entre os diferentes dispositivos voltados para a defesa do Meio Ambiente. A norma constitucional ambiental é parte integrante de um complexo mais amplo e podemos dizer, sem risco de errar, que ela faz a interseção entre as normas de natureza econômica e aquelas destinadas à proteção dos direitos individuais. A correta interpretação das normas ambientais existentes na Constituição da República deve ser feita, como já foi dito, com a análise das diferentes conexões materiais e de sentido que elas guardam entre si e, principalmente, com outras áreas do Direito. A tarefa não é trivial, pois é elevado o número de normas ambientais existentes na CF. A Constituição possui 22 artigos que, de uma forma ou de outra, relacionam-se com o meio ambiente, além de parágrafos e incisos diversos. Sistematizá-los e harmonizá-los é uma tarefa que ainda está por ser feita.

2.3.2 O artigo 225 da CF de 1988

O capítulo do Meio Ambiente da CF é o centro nevrálgico do sistema constitucional de proteção ao meio ambiente e é nele que está muito bem caracterizada e concretizada a proteção do meio ambiente como um elemento de interseção entre a ordem econômica e os direitos individuais. O artigo 225 da CF determina que “[t]odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O primeiro destaque é o vocábulo “*todos*”, que dá início ao capítulo. “*Todos*”, tal como presente no artigo 225, tem o sentido de qualquer indivíduo que se encontre em território nacional. “*Todos*” quer dizer todos os seres humanos. Aqui há uma evidente ampliação do rol dos direitos constitucionalmente garantidos, pois, diferentemente dos direitos eleitorais e os de controle da probidade administrativa, não se exige a condição de cidadão. Vê-se que, quando se trata da definição de direitos e obrigações, a CF estabelece claramente o destinatário da garantia ou do comando. Assim é que os direitos e as garantias individuais definidos no artigo 5º não se destinam a toda e qualquer pessoa; os seus destinatários são os *brasileiros e os estrangeiros residentes no País*. Um estrangeiro que esteja simplesmente de passagem pelo País, em tese, não é destinatário do artigo 5º da CF. Mesmo no interior das disposições contidas no artigo 5º é possível identificar limitações ao exercício de alguns direitos e garantias. A ação popular constitucional, por exemplo, só pode ser proposta por *cidadão* que, no caso, é o eleitor em dia com as suas obrigações eleitorais. O artigo 225, ao se utilizar da expressão “*todos*”, buscou estabelecer que mesmo os estrangeiros não residentes no País e outros que, por motivos diversos, tenham tido suspensos os seus direitos de cidadania, ainda que parcialmente, são destinatários da norma atributiva de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A leitura irracional e apressada do vocábulo tem levado à interpretação de que “*todos*” teria como destinatário todo e qualquer ser vivo. A hipótese não se justifica. A Constituição tem como um de seus princípios reitores a dignidade da pessoa humana e, portanto, a ordem jurídica nacional tem como seu centro o indivíduo humano. A proteção aos animais e ao meio ambiente é estabelecida como uma consequência de tal princípio e se justifica na medida em que é necessária para que o indivíduo humano possa ter uma existência digna em toda plenitude. Relevante notar que aos animais foi dada uma dignidade inexistente no direito anterior que é a expressa proibição constitucional de tratamento cruel, o que implica elevadíssimo patamar de tutela, como reconhecido pelo STF (STF, ADI 1856/RJ).

A promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da “*farra do boi*” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. – A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da CF vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. – Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que façam periclitare todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“*gallus gallus*”) (Ministro Celso de Mello). Na mesma linha está a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.299, de 08 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. “*Vaquejada – Manifestação cultural – Animais – Crueldade manifesta – Preservação da fauna e da flora – Inconstitucionalidade. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.*” (ADI 4983/CE, Relator Ministro Marco Aurélio, 06/10/2016).

No particular, há que se observar que a Emenda Constitucional 96/2017 introduziu o § 7º no artigo 225 estabelecendo uma exceção para a vaquejada que foi considerada como atividade cultural. É matéria polêmica que ainda deverá ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A vaquejada é, certamente, uma tradição cultural. Todavia, pairam dúvidas relevantes relativas à sua compatibilidade com a vedação de maus-tratos aos animais.

2.3.2.1 Conceito normativo de meio ambiente

Nesta altura é necessário definir meio ambiente. Para Robert Reichardt (KADE, 1975, p. 184): “*Definimos o ambiente de uma dada população de seres humanos como o sistema de constantes espaciais e temporais de estruturas não humanas, que influencia os processos biológicos e o comportamento dessa população. No ‘ambiente’ compreendemos os processos sociais diretamente ligados a essas estruturas, como sejam o trajeto regular dos suburbanos, ou o desvio comportamental em correlação direta com a densidade da população ou com as condições habitacionais. Excluímos, no entanto, os processos que se desenvolvem principalmente no exterior do sistema social. É evidente que tal distinção, em certa medida, é arbitrária, pois num sistema social cada elemento se acha vinculado a todos os outros*”.

Já José Lutzemberger (1976, p. 9) afirmava que: “*A evolução orgânica é um processo sinfônico. As espécies, todas as espécies, e o Homem não é uma exceção, evoluíram e estão destinadas a continuar evoluindo conjuntamente e de maneira orquestrada. Nenhuma espécie tem sentido por si só, isoladamente. Todas as espécies, dominantes ou humildes, espetaculares ou apenas visíveis, quer nos sejam simpáticas ou as consideremos desprezíveis, quer se nos afigurem como úteis ou mesmo nocivas, todas são peças de uma grande unidade funcional. A natureza não é um aglomerado arbitrário de fatos isolados, arbitrariamente alteráveis ou*

dispensáveis. Tudo está relacionado com tudo. Assim como numa sinfonia os instrumentos individuais só têm sentido como partes do todo, é função do perfeito e disciplinado comportamento de cada uma das partes integrantes da maravilhosa sinfonia da evolução orgânica, onde cada instrumento, por pequeno, fraco ou insignificante que possa parecer, é essencial e indispensável”.

O conceito normativo de meio ambiente consta do artigo 3º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. A referida Lei, estabelecida no regime constitucional anterior, foi firmada com base no artigo 8º, inciso XVI, alíneas *c*, *h* e *i*, da Carta de 1967, tendo sido recebida pela atual Constituição, fato que foi confirmado pelas suas sucessivas reformas. ALC nº 140/2011, conforme nos dá conta o seu artigo 20, demonstra que as partes da Lei nº 6.938/81 foram recebidas como LC, o que já havíamos indicado em edições anteriores deste livro, haja vista que a LC nº 140/2011 modificou trechos da Lei da PNMA.

Muitas são as definições encontradas para o termo. Iara Verocai (1992, p. 133-135) apresenta uma enorme quantidade de definições; dentre essas, merecem destaque as seguintes:

- a) *A soma das condições externas e influências que afetam a vida, o desenvolvimento e, em última análise, a sobrevivência de um organismo* (The World Bank).
- b) *O conjunto do sistema externo físico e biológico, no qual vivem o homem e os outros organismos* (PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).

A Lei da PNMA define meio ambiente:

Meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

A CF de 1988 elevou o meio ambiente à condição de direito de todos e bem de uso comum do povo, modificando o conceito jurídico de meio ambiente, tal como ele estava definido pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Em razão da alta relevância do bem jurídico tutelado, a CF estabeleceu a obrigação do Poder Público e da Comunidade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Foram criadas duas situações distintas: a primeira, de (i) não promover degradação; a segunda, de (ii) promover a recuperação de áreas já degradadas. A Constituição fez uma escolha clara pela conservação que, necessariamente, tem que ser interpretada de maneira dinâmica. A Constituição criou a obrigação de zelo para com o meio ambiente. Não se olvide, contudo, que o conceito de uso comum de todos rompe com o tradicional enfoque de que os bens de uso comum só podem ser bens públicos. Não, a CF estabeleceu que, mesmo sob a égide do domínio privado, podem ser fixadas obrigações para que os proprietários assegurem a fruição, por todos, dos aspectos ambientais de bens de sua propriedade. A fruição, contudo, é mediata, e não imediata. O proprietário de uma floresta permanece proprietário da mesma, pode estabelecer interdições quanto à penetração e permanência de estranhos no interior de sua propriedade. Entretanto, está obrigado a não degradar as características ecológicas que, estas sim, são de uso comum, tais como a beleza cênica, a produção de oxigênio, o equilíbrio térmico gerado pela floresta, o refúgio de animais silvestres etc. Aqui há uma importante contribuição do legislador ordinário brasileiro que, desde 1934, considera as florestas de interesse comum de todos (art. 1º).

Os artigos 219 e 225, § 4º, da CF estabeleceram o conceito jurídico de *patrimônio nacional*, cujo conteúdo não foi definido. Contudo, há que se observar que, no contexto específico da proteção ambiental, tal conceito não se confunde com o de propriedade pública, como tem sido reiteradamente decidido pelo STF. (RE 134.297/SP. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 13/6/1995. Primeira Turma. DJU 22/09/1995. p. 30.597).

2.3.2.2 Direito Ambiental e direitos humanos

A proteção ao meio ambiente é uma evolução dos direitos humanos. A profunda e estreita relação entre direitos humanos e proteção ao meio ambiente tem sido reconhecida pelo STF, assim como tem sido reconhecida pela Corte Constitucional que a proteção ao meio ambiente, ou a alegação de que a ação administrativa se faz em defesa do meio ambiente, não pode ser feita sem a observância dos direitos e das garantias individuais. (STF. MS 22.164/SP – Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 30.10.1995. Tribunal Pleno. DJU 17/11/1995. p. 39.206).

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, acrescentou alguns artigos à nossa CF que, em princípio, poderão influenciar na decisão das questões jurídico-ambientais. Refiro-me, especificamente, à inclusão do § 3º do artigo 5º. Chamo a atenção para o fato de que a doutrina, por ampla maioria, bem como algumas decisões do STF têm considerado que o artigo 225 da nossa Constituição é, em um dos seus múltiplos aspectos, uma extensão do artigo 5º.

2.3.3 Direito Ambiental e indisponibilidade de direitos

Como sabemos “os conceitos [jurídicos] devem servir às necessidades humanas” (POSNER, 2009), contudo, em não raras oportunidades, o Direito Ambiental se torna refém de seus próprios conceitos. É o que ocorre com a aplicação do conceito de indisponibilidade de direitos ao Direito Ambiental, sem uma visão crítica. Na verdade, estamos diante de um fenômeno que foi identificado como uma “imperfeição estrutural” (FRAGA, 1995, p. 177) das normas de Direito Ambiental, fazendo com que elas não se harmonizem entre si e, de fato, impliquem verdadeiras perplexidades diante dos casos concretos, exigindo que o intérprete se afaste de dogmas e tire as conclusões necessárias dos fatos que se apresentam no mundo real.

A adoção do conceito de indisponibilidade de direitos gera dificuldades para que os conflitos ambientais possam ser resolvidos pelos chamados métodos alternativos, tais como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Penso que insistir na impossibilidade da adoção de solução alternativa de conflitos em matéria ambiental é uma negação explícita dos princípios democráticos e da participação que informam o direito ambiental, “que [é] poder-dever a toda a coletividade, por imperativo constitucional” (Desembargador Federal Souza Prudente, TRF da 1ª Região, AC 199838000216247, 6ª Turma, e-DJF1 06/05/2008, p. 423).

2.3.3.1 O estreitamento do conceito de indisponibilidade de direitos

Indisponíveis são aqueles direitos cujo titular não pode, por ato de manifestação de vontade, transferir, alienar, extinguir ou modificar, devendo exercê-los na forma que a lei determinar. Contudo, tal indisponibilidade vem sendo temperada, desde longa data. Ela é conceito *histórico*, portanto, mutável, como vem sendo afirmado pelo STF (HC 93250/MS. Julgamento: 10/6/2008, 2ª Turma). Francisco Amaral (2006, p. 250), a propósito, sustenta: “Essa indisponibilidade não é, porém, absoluta, admitindo-se, por exemplo, acordo que tenha por objeto direito da personalidade, como ocorre no caso da cessão do direito de imagem para fins de publicidade, ou ainda a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano (rim, pulmão, sangue, material genético), em vida ou *post mortem*, para fins de transplante e tratamento, ou ainda o corte e a venda de cabelos”.

Note-se que a evolução recente da jurisprudência tem admitido inclusive a mudança de sexo (STJ, REsp 737.993/MG, 4ª Turma, DJe 18.12.2009). Não se pode deixar de incluir no exame da matéria o “direito a alimentos”, o qual a doutrina tem entendido que “[se] pode deixar de exercer, mas não se pode renunciar” (QUEIROGA, 2004, p. 306), chegando o tema a merecer verbete da Súmula da jurisprudência predominante no STF (Súmula 379), todavia, paulatinamente as cortes judiciais têm admitido a renunciabilidade do direito a alimentos (STJ, AgRg no Ag 1.044.922/ SP, 4ª Turma. DJe 02/08/2010). É certo, igualmente, que desde há muito os alimentos são transacionáveis (Lei nº 5.478, de 25/07/1968, art. 5º), sendo a transação viável “em qualquer fase processual” (STJ, REsp 1.021.299/ES, 3ª Turma, DJe 16/09/2008). Mais remotamente, os direitos trabalhistas, desde o advento da Consolidação das Leis do Trabalho, com a criação das Juntas de Conciliação e Julgamento, sempre foram considerados transacionáveis, e também que, desde lá para cá, criou-se inclusive uma *conciliação prévia* (CLT, art. 625-A, e STF ADI 2139 MC, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio. Pleno, julgado em 13/05/2009, DJe-200. “Processo objetivo – Petição inicial. A petição inicial do processo objetivo deve ser explícita no tocante à causa de pedir. Jurisdição trabalhista – Fase administrativa. A CF em vigor, ao contrário da pretérita, é exaustiva quanto às situações jurídicas passíveis de ensejar, antes do ingresso em juízo, o esgotamento da fase administrativa, alcançando, na jurisdição cível-trabalhista,

apenas o dissídio coletivo”). Veja-se, também, que a matéria previdenciária, considerada como indisponível, é hoje tranquilamente transacionável como deixa claro a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Chame-se a atenção para o fato de que a conciliação, a transação ou a desistência, no caso, abrangem tanto os direitos previdenciários, como os próprios direitos econômicos do Estado.

Se examinarmos a questão referente aos contratos de concessão de serviços públicos, matéria tratada pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, veremos que uma das *cláusulas essenciais* de tais contratos é o estabelecimento da *previsão de solução amigável das divergências contratuais*. Para concluir, o CTN admite como uma das formas legítimas de extinção do crédito tributário a transação e a remissão, tal como disposto em seu artigo 156, III e IV. Ora, considerando-se que, em matéria de direito tributário, os institutos de direito privado não podem ser alterados pela lei tributária, mantendo a sua natureza tal qual estabelecida pelas normas de direito privado, indiscutível, portanto, que mesmo em área tão sensível como a arrecadação do Estado, é possível a negociação e, portanto, a “disposição” de direitos.

2.3.3.2 A “indisponibilidade” de direitos no Direito Ambiental

O artigo 225 da CF é o principal núcleo normativo da proteção ao meio ambiente no direito brasileiro, de sua leitura se pode perceber que a indisponibilidade é uma exceção expressamente definida na própria CF. De fato, pelo § 5º o constituinte originário determinou a indisponibilidade das “*terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais*”. Cuida-se, obviamente, de uma exceção, pois impede que os Estados alienem tais terras ou façam quaisquer transações que importem em sua alienação e dos bens de valor ambiental nelas contemplados, haja vista que imóveis por determinação legal. Por outro lado, em outros pontos do mesmo artigo constitucional, admite-se que se possam suprimir bens de valor ambiental, desde que mediante lei e admite-se (CF, art. 225, § 1º, III), igualmente, que a recuperação ambiental não se faça de forma integral, mas por uma presunção estabelecida por solução técnica (CF, art. 225, § 2º).

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, em sua redação originária, atribuiu ao Conama competência para “*homologar acordos*”.

Não se esqueça de que a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, admite a *arbitragem* administrativa quando da existência de divergência quanto à utilização de recursos hídricos. Mais recentemente, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, foi bastante clara ao estabelecer a possibilidade de *acordos* entre as partes *para a definição de responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida dos produtos*. No caso, a lei fala em *natureza contratual*, o que denota uma clara intenção de consensualidade na medida. Em assim sendo, parece-me bastante claro que as normas e os fatos admitem, expressamente, que o interesse da proteção ao meio ambiente pode ser objeto de acordos de vontade entre as partes. Não bastassem as razões jurídicas acima expostas, não se pode olvidar a chamada “*força normativa dos fatos*” (Ministro Eros Grau, STF ADI 3.689/PA. Julgamento: 10/5/2007, Plenário, DJe-047, 28/06/2007).

2.3.4 A equivalência entre dano ambiental e valor econômico

Caso se faça exame das responsabilidades penais e administrativas em matéria ambiental, constatar-se-á que a imposição de sanções, até mesmo pecuniárias, exemplifica o equivalente entre o dano sofrido pelo meio ambiente e o dano a ser causado ao infrator. Releva notar que, mesmo em sede penal, reconhece-se que as infrações penais cometidas contra o meio ambiente podem ser objeto de *transação penal ou de suspensão condicional do processo*, e, em alguns casos, são tidas como ambientalmente insignificantes (STJ, REsp 182.847, 6ª Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJU 5/4/1999, p. 160).

A Lei nº 9.985/2000 estabeleceu a chamada *compensação ambiental* sempre que determinado projeto ou empreendimento a ser implantado, com base em estudo prévio de impacto ambiental, possa vir a causar danos às unidades de conservação que se encontrem na sua área de influência. A *compensação ambiental*¹ é um *equivalente monetário*, fixado por critérios legalmente definidos, *do bem ambiental danificado*. Como tenho sustentado (ANTUNES, 2015-a), os danos ambientais podem ser (i) recuperáveis, (ii) mitigáveis ou (iii) compensáveis.

A Lei, em sua redação originária, estabeleceu que os danos às unidades de conservação têm equivalência monetária igual a, no mínimo, 0,5% do valor total dos investimentos, os quais deverão ser empregados para “*apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral*”. Do ponto de vista do presente trabalho, não há dúvida, pelo menos para o autor, de que a lei, expressamente, admitiu a possibilidade de que parcela de bem ambiental fosse trocada por equivalente monetário, constituindo-se em disponibilidade *ex vi lege*, a ser examinada pelo órgão ambiental no âmbito do licenciamento ambiental. O STF ao examinar a ADI nº 3.378-6 declarou parcialmente inconstitucional a expressão, “*não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento*” sem, todavia, impugnar a opção legislativa de troca de parcela do bem ambiental por pecúnia. A Corte Constitucional entendeu que a compensação deve corresponder à totalidade do dano identificado pelo Estudo Prévio de Impacto Ambiental. É interessante observar que o Tribunal de Contas da União, examinada a aplicação de recursos da compensação ambiental, taxativamente, entendeu que a verba de compensação não tem natureza pública, cabendo ao Estado, por meio de seu órgão de controle ambiental, apenas indicar a aplicação a ser feita pela parte interessada. Assim, um direito indisponível e mais: em área especialmente protegida, foi tornado disponível, conforme critérios fixados pelo EIA.

Contrariamente ao que tem sido apregoado, *questões* ambientais são essencialmente negociáveis, como claramente estabelecido pelo Resolução nº 237/97 do Conama (art. 10. [...] I – [...] com a *participação do empreendedor* [...]. § 2º [...] com a *concordância do empreendedor* e do órgão ambiental competente), pois todas as intervenções sobre o meio ambiente implicam opções entre possibilidades diversas, privilegiando este ou aquele aspecto, conforme uma tomada de decisão, em grande parte discricionária. Não é excessivo relembrar os termos do artigo 2º da PNMA, cujo “*objetivo [é] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana*”, destacando-se “*os seguintes princípios*”, (i) “*ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo*”; (ii) “*racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar*”; (iii) “*planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais*”; (iv) “*proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas*”; (v) “*controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras*”; (vi) “*incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais*”.

A PNMA, no inciso I, do artigo 2º define o meio ambiente como “*patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo*”. Posteriormente, e persistindo na mesma concepção, a CF de 1988 definiu que o meio ambiente ostenta a condição de “bem de uso comum do povo”, o que, de certa forma, fortalece e reafirma a ideia de indisponibilidade do direito ao meio ambiente. Entretanto, se faz necessário que se veja que o próprio artigo 225 da CF admite claramente a possibilidade de recategorização das Unidades de Conservação, “*sendo a alteração e a supressão permitidas*” o que “*somente [ocorrerá] através de lei*”. É totalmente desnecessário reafirmar que a hipótese tratada pela Norma Fundamental é aplicável quando a nova categoria de Unidade de Conservação implicar nível menor de proteção ambiental. Imagine-se a hipótese de transformação de um Parque em Área de Proteção Ambiental, em tal caso, a Unidade de Conservação passa do grupo de proteção integral para o grupo de uso sustentável. Logicamente, grande parte da área cuja utilização, no regime de parque, era indireta, no novo regime jurídico poderá sujeitar-se à utilização direta, ou seja, a lei determinou que fossem “alienadas” parcelas de “direito indisponível”. Aliás, no particular existe um exemplo concreto que é o da Lei nº 11.686, de 2 de junho de 2008, que transformou o Parque Nacional dos Pontões Capixabas em Monumento Natural dos Pontões Capixabas, ainda que ambas as Unidades de Conservação pertençam ao grupo de proteção integral. Considere-se, ademais, que o artigo 225 da CF, dada a sua condição de um dos direitos individuais mais caros à coletividade, tem aplicação imediata, como tem sido reconhecido por boa parte dos autores; ainda assim, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, em seu artigo 55 determina que “[a]s unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento...”

Outro exemplo do que tem sido afirmado sobre a irrenunciabilidade é o das chamadas áreas de preservação permanente que, expressamente, podem ser suprimidas, *em função de um interesse público de natureza não ambiental*. Veja-se que a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que revogou o Código Florestal, estabeleceu toda uma série de exceções à proibição de supressão das áreas de preservação permanente, conforme disposto em seu artigo 8º, frise-se que tal

possibilidade de mais amplamente reconhecida pelo STF para decidir a Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.540, sendo importante observar que a reserva legal somente se impõe para os “*espaços territoriais especialmente protegidos*”, não se aplicando para as áreas merecedoras de proteção genérica.

O próprio licenciamento ambiental é um instrumento administrativo para definir o grau de “*poluição*” ambiental tido como aceitável pela sociedade. Ora, o licenciamento ambiental é “[o] procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso” (Resolução Conama 237/1997, art. 1º, I), que permitirá, em concreto, a utilização dos recursos ambientais e, portanto, à sua disposição.

2.3.4.1 Transação em matéria ambiental

A *transação* (CC, art. 840) é um dos mecanismos mais aptos a solucionar conflitos ambientais, pois ela pressupõe a existência de insegurança quanto à real extensão dos direitos das partes, haja vista que implica “concessões mútuas”, com vistas a “prevenir ou terminar litígios”. O CC, no entanto, limita a transação aos casos nos quais a controvérsia gire em torno de “*direitos patrimoniais de caráter privado*” (art. 841), o que, em tese, cria um obstáculo intransponível para a sua adoção em questões ambientais. Contudo, a prática judicial tem demonstrado que as transações têm sido admitidas em matéria ambiental, com bastante frequência. Em primeiro lugar, não há qualquer dúvida ou controvérsia quanto à possibilidade de *transação penal*, mesmo em se tratando de crimes contra o meio ambiente. Como assinalado acima, a dificuldade surge quando se fala em transação “civil”. Sem aderir a um simples praxismo, não há que se desconsiderar que o mundo prático e as decisões judiciais são capazes de produzir direito. Nesse sentido, é relevante trazer à colação a decisão proferida no Recurso Especial nº 299.400, STJ, 2ª Turma, Relator Ministro Peçanha Martins, Relatora designada Ministra Eliana Calmon, DJU 02/08/2006, p. 229: “1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos difusos. 2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor solução na composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. 3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra”.

A propósito, não se pode deixar de dizer que a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de forma ampla reconhece o valor econômico do bem ambiental água, determinando a cobrança pelo seu uso, bem como a ampla arbitralidade administrativa das questões relativas aos conflitos de uso, muito embora não deixe de afirmar a natureza de bem público da água.

Na linha da decisão acima, diversas outras têm sido proferidas no sentido de admitir a transação judicial em Ações Cíveis Públicas ajuizadas com objetivo de proteção ao meio ambiente. Curiosamente, é muito comum que um dos legitimados a tomar o Termo de Ajustamento de Conduta, impugne tais termos quando firmados pelos demais legitimados sem a sua presença. É interessante o caso no qual o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública (TRF da 2ª Região [TRF 2]. AC – Apelação Cível – 427.003. 6ª Turma Especializada. Data Decisão: 2/3/2009, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon), em face de particular, sendo certo que ambas as partes firmaram Termo de Ajustamento de Conduta, submetendo-o à homologação pelo magistrado da Vara Federal Única de Resende, Estado do Rio de Janeiro; tal procedimento levou o feito à extinção, com julgamento de mérito, com base no artigo 269, III do CPC (1973). O Instituto Chico Mendes de Diversidade Biológica, inconformado por não ter participado da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, apelou da sentença suscitando-lhe a nulidade, ante a sua não intervenção, a qual, em seu entendimento, era obrigatória.

No que interessa ao presente trabalho, vale observar que a autarquia ambiental, dentre outros argumentos, afirmou que: “*O laudo de vistoria dá conta de que a construção do imóvel foi realizada em área de preservação permanente, com violação da legislação ambiental, além da transformação de um curso d’água em canal hidráulico, com construção de garagem, piscina e churrasqueira, de modo a ocupar o leito original do curso d’água. O termo de ajustamento de conduta encontra-se evadido de diversas inconsistências, não ensejando a reparação integral do dano ambiental causado no local*”. Acrescentando, ainda que: “[n]ão houve comprovação da reparação dos danos ambientais – demolição das construções irregularmente realizadas –, tampouco alguma prova técnica a embasar a afirmação de que a demolição poderia causar danos mais graves do que aqueles já causados. Ademais, ainda que o suposto curso d’água seja intermitente (mero canal de escoamento de águas pluviais), tal circunstância é suficiente para configurar área de preservação permanente. O julgamento foi assim ementado: “3. O objetivo do compromisso de ajustamento de conduta é readaptar e conformar a conduta do degradador ou potencial degradador ao ordenamento jurídico em vigor, afastando o risco de dano ou recompondo os danos já causados. 4. Houve expressa limitação à legitimidade para firmar o termo de ajustamento de conduta, eis que somente é atribuído tal poder aos órgãos públicos legitimados ao ajuizamento da ação civil pública (e não a todos os legitimados para ajuizamento da ação civil pública). Buscou a lei evitar que determinadas pessoas jurídicas (notadamente as de direito privado) pudessem firmar compromisso de ajustamento de conduta com os potenciais ou efetivos degradadores, ainda que presentes os requisitos exigidos para a propositura da ação civil pública, como no exemplo das associações. Como se trata de acordo em sentido estrito, tendo como objeto direitos e bens indisponíveis, é perfeitamente legítima e constitucional tal limitação... 8. A expressão “ajustamento de conduta”, tal como empregada pelo legislador ao se referir ao TAC, é emblemática, eis que ‘o instituto se propõe unicamente a fazer com que as pessoas físicas e jurídicas possam se adequar ao que determina a legislação’. 9. Daí a impossibilidade de se confundir o compromisso de ajustamento de conduta com a transação, este instituto típico do Direito Civil, relacionado aos interesses disponíveis”.

Por outro lado, a simples existência da apelação do ICMBio demonstra que, do ponto de vista da autarquia ambiental, os danos causados ao meio ambiente não foram totalmente recuperados, o que significaria, no contexto da presente discussão, que parte deles foi renunciada, pois coerentemente com a tese da indisponibilidade dos direitos difusos, o Termo de Ajustamento de Conduta teria que cobrir toda a extensão dos danos. Sem entrar no mérito da extensão da recuperação, fato é que ocorreu uma clara divergência quanto à própria recuperação ambiental entre dois legitimados; ressalte-se, ademais, que o Acórdão entendeu desnecessária a participação de todos os legitimados e, especificamente, do ICMBio. Nem se diga que isto ocorreu por a transação ter sido firmada com o Ministério Público Federal, pois há decisão no mesmo sentido, porém sendo apelante o *Parquet Federal* da qual se destaca: “*É preciso ressaltar que a previsão legal estabelece a possibilidade de intervenção do MPF. Desta forma, apesar de aconselhável, desejável, a intervenção do MPF é desnecessária na elaboração do referido TAC. Logo, sua ausência não acarreta, portanto, nulidade do mesmo, por não haver dispositivo legal que imponha tal presença*” (Desembargador Federal Reis Friede, TRF da 2ª Região, Apelação Cível 415974; 7ª Turma Especializada; Relator Desembargador Federal Reis Friede, DJU 06/10/2008, p. 196).

Não se desconhece, todavia, orientação diversa no que se refere à obrigatoriedade de intervenção dos legitimados, ainda que minoritária: “[s]entença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que os órgãos ambientais federais – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ICMBio – sejam citados, para integrarem a lide, manifestando-se sobre os termos do ajustamento de conduta firmado entre as partes, em busca da preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações” (CF, art. 225, caput) (Desembargador Federal Souza Prudente, TRF 1ª Região, AC 200438020037440, 6ª Turma, e-DJF 1, 09/02/2009, p. 98). Veja-se, a propósito, o artigo 178, I do Código de Processo Civil.²

Ora, é exatamente a divergência de concepção sobre a extensão dos danos a serem recuperados que possibilita a elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta, o qual se transforma em transação ao ser homologado judicialmente. A minha experiência em questões como a ora tratada leva-me a considerar pequena a possibilidade de que uma parte particular, ou mesmo pública, firme Termo de Ajustamento de Conduta para a recuperação de danos inexistentes, ou que não lhe possam ser imputados.

A doutrina da irrenunciabilidade de direitos implica que o Termo de Ajustamento de Conduta, ao ser firmado, corresponda à totalidade do dano ambiental que, em tese, seria objeto de recuperação por força da decisão judicial, pois do contrário, parte do suposto “direito” teria sido renunciada. Aqui, não posso deixar de assinalar que, lamentavelmente, tenho a impressão de que *retornamos ao conceito do direito concreto de Ação*, haja vista que ao ajuizamento de uma demanda corresponderia uma inevitável sentença de procedência e, em sendo assim, o Termo de Ajustamento de Conduta nada mais seria do que a antecipação daquilo que o magistrado decidiria. Ora, a transação, ou a sua necessidade, surge da incerteza quanto ao resultado da demanda, fazendo com que as partes tenham preferência, elas próprias, em darem contornos aos seus direitos. Nos Termos de Ajustamento de Conduta é exatamente o que ocorre, ainda que de forma imperfeita. Pode ocorrer que as

partes desistam de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta, em função de divergência quanto à extensão ou mesmo existência de determinado dano ao meio ambiente, haja vista que o ente público entendia relevante o dano e, por outro lado, a parte privada o entendia inexistente, muito embora admitisse firmar um Termo de Ajustamento de Conduta limitado, com vistas a evitar o processo judicial e os custos dele decorrentes; ajuizada a Ação Civil Pública, esta após longa tramitação foi julgada improcedente; assim, o direito que era irrenunciável, transformou-se em direito inexistente.

Na verdade, inúmeros são os julgados que, no caso concreto, são obrigados a conceder prazos, diminuir exigências e tantas outras questões que, na prática, implicam uma adequação do direito “em tese” existente, ao direito concretamente possível e exercitável.

A título de exemplo, cite-se a decisão da Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator Desembargador Eduardo Braga. São Paulo, 14/10/2010. Voto nº 14 738, Agravo de Instrumento nº 990.10.107594-6/Marília.)

Decisão que determinou o prosseguimento da execução judicial, fixando prazo de 60 dias para paralisação espontânea das atividades empresariais da agravante, sob pena de interdição. Reunião de ações envolvendo as mesmas partes, havendo recursos com pendência de julgamento e ainda, deferimento de liminar em outra ação civil pública, anulando o procedimento de licença prévia das novas instalações da agravante, para onde se transferiria. Impedimento e paralisação da transferência, que culminaria no cumprimento de acordo havido entre as partes, para que tal transferência se fizesse em 18 meses. Concordância do agravado [MP] para que novo cronograma de transferência se faça, com a concessão do prazo de mais 6 meses para tanto. Provimento do Agravo de Instrumento, para ficar sem efeito a r. decisão agravada, devendo o MM. Juízo “a quo” designar audiência de conciliação [...].

O que tem caracterizado o direito ambiental para a doutrina, unanimemente, é o seu caráter interdisciplinar e a sua transversalidade, o que significa dizer que a preocupação com o meio ambiente e sua proteção devem se fazer presentes em qualquer ramo do Direito; por outro lado, todo e qualquer instituto jurídico que possa ser utilizado de maneira a assegurar mais eficiência para a proteção do meio ambiente não deve ser desprezado. Do contrário, as tão propaladas transversalidade e interdisciplinaridade não serão nada mais, nada menos do que letra morta. Aliás, tal concepção encontra amparo na CF que estabeleceu a “eficiência” como um dos princípios norteadores da atividade da administração pública (CF, art. 37).

Boa parte da doutrina (LEITE e AYALA, 2010, p. 256) mostra-se perplexa com a possibilidade de transação em matéria ambiental e, de forma contraditória, cria construções cerebrinas bastante afastadas da realidade dos fatos, chegando a sustentar que “[o] compromisso de ajustamento deve ser homologado judicialmente” (LEITE e AYALA, 2010, p. 258). Ora, a homologação judicial de um Termo de Ajustamento de Conduta, caso inexistente a Ação Civil Pública é uma contradição, pois qual seria o sentido de que um documento válido como título executivo extrajudicial fosse levado a juízo para a homologação e ser, por essa via, transformado em um título executivo judicial? Por outro lado, quando as partes transigem nos autos da Ação Civil Pública, necessariamente, o feito deverá ser encerrado por uma sentença de mérito. Por outro lado, em evidente desprestígio ao rol de entes públicos legitimados à celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, sustentam os mesmos autores que “o compromisso de ajustamento deve-se (sic) submeter à apreciação do Ministério Público, quando não efetivado pelo Parquet”. Cuida-se, evidentemente, de uma opinião respeitável a qual, porém, não encontra amparo na lei, nem na jurisprudência, como já visto. O fato é que a Lei da Ação Civil Pública não colocou nenhum dos legitimados para a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta em posição superior aos demais. A supervisão ministerial, no sentido de controle da legalidade, somente se legitima nas Ações Cíveis Públicas nas quais ele não funciona como parte autora, ocasião em que intervirá obrigatoriamente no feito como fiscal da ordem jurídica.

O que se pode fazer com os Termos de Ajustamento de Conduta é executá-los judicialmente, dispensando-se a fase de conhecimento, desde que eles tenham sido redigidos de forma a assegurar que a obrigação seja (i) certa, (ii) líquida e (iii) exigível (TJRJ, Ação Rescisória, Órgão Especial, 0021026-45.2006.8.19.0000 – Relator Des. Nametala Machado Jorge – Julgamento: 22/10/2007), sob pena de nulidade da execução (CPC, art. 803). Infelizmente, parcela considerável dos Termos de Ajustamento de Conduta é redigida de forma pouco clara, sem que as obrigações sejam certas líquidas e exigíveis. Cláusulas tais como “fica obrigado a fazer reflorestamento”, “recuperar danos” e outras semelhantes desnaturam os principais elementos dos títulos executivos extrajudiciais, pois extremamente abstratas. É necessário que o reflorestamento seja definido, de acordo com projeto, cronogramas e desembolsos, de forma que possa, se for o caso, ser executado judicialmente; o mesmo se diga em relação à recuperação de danos.

2.3.4.2 A conciliação em ações ambientais

A Ação Civil Pública é, ainda, o grande instrumento para a defesa judicial do meio ambiente, sendo que o Ministério Público é o grande ator em tais ações que, em sua imensa maioria, são por ele ajuizadas. Diz-se que a Ação Civil Pública é indisponível e obrigatória, “o Ministério Público não tem discricionariedade para deixar de agir” (JATAHY, 2008, p. 348), fazendo com que ele dê prosseguimento às demandas propostas pelos demais legitimados, salvo casos excepcionais, (Desembargador Vasco Della Giustina, STJ, RESP 199900016319, 3ª Turma, DJe 15/09/2010). Essa concepção tem acarretado uma discussão muito acirrada sobre a possibilidade de conciliação nas Ações Cíveis Públicas, com grandes consequências práticas para o meio ambiente.

O revogado CPC, em seu artigo 331, determinava que o juiz da causa “designará audiência preliminar” sempre que a matéria versar “sobre direitos que admitam transação”. Como amplamente demonstrado acima, os direitos referentes à proteção ao meio ambiente são tidos como indisponíveis e, portanto, não sujeitos ao regime de transação; no mesmo sentido, os artigos 447 e seguintes do CPC de 1973. Por outro lado, como igualmente acima demonstrado, as transações se constituem em realidade candente nas Ações Cíveis Públicas, as quais se materializam, inúmeras vezes em Termos de Ajustamento de Conduta que foram considerados como “fórmula eficaz e ponderada de solução do conflito” (Des. Cristina Tereza Gaulia, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000025-53.2007.8.19.0037). A jurisprudência oscila entre a impossibilidade de conciliação em Ação Civil Pública, “[c]onquanto o recorrente consigne a imperiosidade da realização de audiência de conciliação, atualmente denominada audiência preliminar, em verdade, ela evidencia-se desnecessária quando a controvérsia envolver direitos indisponíveis” (STJ, REsp 200100613601, Ministro Franciulli Netto 2ª Turma, DJU 14/03/2005, p. 244), até uma obrigação do magistrado “tent[á-la] a qualquer tempo” (STJ, REsp 199600701601, 2ª Turma, Ministro Peçanha Martins, DJU 22/03/1999, p. 162).

Na verdade, “a força normativa dos fatos” (STF, ADI 3689/PA, Relator: Min. Eros Grau, Julgamento: 10/05/2007, Tribunal Pleno. DJe 047. 28/06/2007, publicação: 29/6/2007) tem feito com que muitos doutrinadores que, igualmente, atuam no mundo do direito real e concreto, tenham se curvado à realidade e reconhecido, ainda que com reticências, que a “indisponibilidade” e a “obrigatoriedade” nem sempre andem de braços dados com as melhores opções para a defesa do meio ambiente. Dada a importância do autor, faça-se a seguinte transcrição:

a desistência da ação somente é admissível nas hipóteses em que tal providência convier à adequada proteção do meio ambiente e o prosseguimento da demanda comprometer a própria tutela do bem ou direito protegido (MIRRA, 2004, p. 241).

O ilustre autor assim arremata a argumentação:

Portanto, no âmbito da ação civil pública ambiental admite-se, sim, a desistência da demanda proposta por qualquer um dos legitimados ativos, mesmo reconhecida a sua indisponibilidade [?!], mas na medida em que tal providência convenha ao interesse público, não se concebendo, entretanto, por mera vontade individual e injustificada do demandante (MIRRA. 2004, p. 242).

Assim, parece evidente que a incerteza é a tônica quanto à questão, fato que reputo extremamente negativo, pois o recurso ao Judiciário e à busca de composição entre as partes passa a ser integrante do problema, e não de sua solução, como é o desejável e racional. Espera-se que o novo CPC venha a dar um tratamento adequado à matéria, de forma que se evitem delongas e transtornos injustificados para as partes e que, no final das contas, se possa dar mais efetividade à proteção do meio ambiente.

2.4 A APLICAÇÃO DAS NORMAS

Uma das questões centrais da vida do Direito, provavelmente a mais importante, é aquela que diz respeito à aplicação e eficácia das normas jurídicas. Em matéria ambiental, o problema não é diferente. Provavelmente seja mais grave.

A CF, com o objetivo de tornar efetivo o exercício do *direito ao meio ambiente sadio*, estabeleceu uma gama de incumbências para o Poder Público, arroladas nos incisos I/VII do § 1º do artigo 225 que se constituem em direitos públicos subjetivos, exigíveis pelo cidadão a qualquer momento.

Ante o jurista, coloca-se a questão de saber qual a natureza das normas constitucionais pertinentes ao meio ambiente. Um correto equacionamento da questão é fundamental para que a Lei seja adequadamente aplicada e para que o cidadão e a coletividade, *como titulares do direito ao meio ambiente sadio*, possam exigir do Estado e dos particulares em geral a proteção devida ao meio ambiente.

Inicialmente, cumpre observar que o *caput* do artigo 225 instituiu um Direito de ampla abrangência econômica e social. Todo o conjunto de normas do artigo 225 estabelece um rol de ações e abstenções que devem, desde logo, ser observadas pela Administração, ou pelos particulares. Verifica-se, de plano, que muitos incisos e parágrafos do artigo 225 não demandam posterior regramento em nível infraconstitucional, enquanto outros necessitam de adensamento em Lei específica, sendo de eficácia contida. Tal situação torna problemática a aplicação imediata e *in totum* do capítulo ambiental de nossa Carta Política, ainda que se possa entender que o artigo 225 é uma extensão do artigo 5º, pois, sem dúvida, o meio ambiente pode ser entendido como um “direito individual”; logo, nos termos do § 1º do artigo 5º, cuja eficácia é plena, a matéria, contudo, não é tão simples.

Saber quais das normas são de eficácia plena e quais são de eficácia contida é uma tarefa jurídica complexa e de relevância fundamental para que o Direito Ambiental possa, efetivamente, ter uma existência concreta. Maria Helena Diniz sustenta que:

São plenamente eficazes as normas constitucionais que forem idôneas, desde sua entrada em vigor; para disciplinarem as relações jurídicas ou o processo de sua efetivação, por conterem todos os elementos imprescindíveis para que haja a possibilidade da produção imediata dos efeitos previstos, já que, apesar de suscetíveis de emenda, não requerem normação subconstitucional subsequente (DINIZ, 1989, p. 99).

O artigo 225 é complexo em sua estrutura e, portanto, compõe-se de normas de variado grau de eficácia. De fato, no interior do citado artigo existem normas que explicitam um direito da cidadania *ao meio ambiente sadio* (art. 225, *caput*), normas que dizem respeito ao *direito do meio ambiente* (art. 225, § 1º, I) e normas que explicitam *um direito regulador da atividade econômica em relação ao meio ambiente* (art. 225, § 1º, V).

Essas dificuldades ainda não foram devidamente enfrentadas pela doutrina. Não temos dúvidas em afirmar que as normas que consagram o *direito ao meio ambiente sadio* são de eficácia plena e não necessitam de qualquer norma subconstitucional para que operem efeitos no mundo jurídico e que, em razão disso, possam ser utilizadas perante o Poder Judiciário, mediante todo o rol de ações de natureza constitucional, tais como a ação civil pública e a ação popular.

Veja-se que, após definir o *direito ao meio ambiente*, a CF, no § 1º do artigo 225, estatui que: “*Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:*”.

A partir do parágrafo, segue uma série de incisos. Em tais incisos estão contidos os comandos para o legislador ordinário e para o administrador. Tais comandos são de natureza obrigatória e não podem ser descurados pelos destinatários. É exatamente através da obediência aos comandos constitucionais que o *direito ao meio ambiente* pode se tornar um elemento da vida real. Os instrumentos são constitucionais, são as ferramentas com as quais o direito se materializará.

Na qualidade de *instrumentos*, não se pode admitir que os incisos do § 1º do artigo 225 sirvam para impedir a fruição do direito estabelecido no *caput*. Ocorre, entretanto, que alguns dos incisos são problemáticos quanto à sua materialização. O exemplo mais significativo é aquele que nos é fornecido pelo inciso IV, que se apresenta como o mais problemático, na medida em que se refere expressamente à necessidade de lei. Lei, nessa altura, deve ser compreendida como ato normativo, regulamento. É desnecessária a normação por meio de lei formal, pois a própria Constituição fixou os limites da exigibilidade dos Estudos de Impacto Ambiental. É evidente que os Estudos de Impacto Ambiental significam uma interferência na esfera privada dos agentes econômicos e, portanto, somente poderiam ser criados por lei formal. Ocorre que a própria Constituição reconheceu e recepcionou o instituto que lhe é antecedente e, mais do que isso, definiu as condições em que este deverá ser exigido. Assim sendo, a norma está plenamente apta a gerar resultados jurídicos, a ser exercitada plenamente, a ser eficaz.

As demais normas jurídicas contidas nos parágrafos restantes do artigo 225 possuem natureza diversa daquela do parágrafo inaugural do capítulo constitucional do meio ambiente. Em verdade, não há uma unidade conceitual ou material entre os cinco parágrafos finais do capítulo. Devido à grande disparidade entre os temas contidos no parágrafo, não será possível examiná-los todos neste capítulo. O exame dos diferentes conteúdos está espalhado ao longo dos diversos capítulos do presente trabalho.

2.5 A INTEGRAÇÃO DE CONCEITOS EXTERIORES AO DIREITO NA CONSTITUIÇÃO

O § 1º do art. 225 da CF integrou toda uma série de conceitos não jurídicos ao Direito Ambiental Constitucional. Como exemplo,

posso citar: O inciso I estabelece obrigações para o Poder Público e, em contrapartida, estabelece um *direito subjetivo público* oponível ao Estado, de forma que o cidadão possa exigir que o Estado atue ativamente na área da proteção ao meio ambiente. A preservação é uma obrigação cujos sujeitos passivos são os diversos órgãos públicos especialmente voltados para a referida tarefa ou para aqueles que tenham promovido ou estejam promovendo atividades ambientalmente impactantes. Contudo, há que se observar que somente os processos ecológicos essenciais devem ser preservados; os demais estão submetidos às regras de conservação. Existe uma obrigação de, na medida do possível, *repristinar* as realidades ambientais anteriores. O Estado deve se empenhar em estabelecer processos que permitam a recuperação de ecossistemas degradados, quaisquer que sejam as origens da degradação.

Observe-se, contudo, que processos ecológicos essenciais é uma expressão que soa incoerente e contraditória, pois, como se sabe, a interação e o equilíbrio são as características fundamentais da vida em natureza. O que me parece é que o constituinte pretendeu resguardar uma estrutura natural mínima capaz de assegurar a reprodução e o desenvolvimento de determinados padrões de ecossistemas.

Não se pode, concretamente, falar em desenvolvimento sustentado sem que o fator humano desse desenvolvimentismo tenha logrado atingir um nível capaz de assegurar o seu florescimento pleno em condições de ampla dignidade. O equilíbrio ecológico não se consegue com uma participação igualitária entre todos os seres vivos na imensa roda que é o desenrolar da vida em todas as formas pelas quais esta se manifesta. Ao contrário, os papéis são diversificados e, praticamente, impossíveis de ser quantificados.

Ecossistema, em definição acadêmica, é um conceito complexo que, para Roger Dajoz (1983, p. 279), é composto pelo biótopo mais a biocenose: “A noção de biocenose é inseparável da noção de biótopo. Dá-se esse nome ao espaço ocupado pela biocenose. O biótopo é uma área ‘geográfica de superfície e volumes variáveis submetida a condições cujas dominantes são homogêneas’ (Pères, 1961). Para Davis (1960), o biótopo é uma extensão mais ou menos bem delimitada contendo recursos suficientes para poder assegurar a conservação da vida”.

Como se sabe, o termo “ecossistema” foi originalmente proposto por Tansley, visando a dar uma definição para a interação entre os seres vivos e os elementos físicos que dotam de peculiaridades os locais onde estes habitam. O ecossistema é a unidade funcional básica da natureza. Para Tansley, os termos anteriormente propostos pelos cientistas para designar a unidade básica da natureza não eram suficientemente adequados.

Ante a importância fundamental do conceito, julgamos extremamente importante agregar mais alguns conceitos e definições sobre o ecossistema. Eugene Odum (1988, p. 9) afirma que: “Os organismos vivos e o seu ambiente não vivo (abiótico) estão inseparavelmente inter-relacionados e interagem entre si. Chamamos de sistema ecológico ou ecossistema qualquer unidade (biosistema) que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre

partes vivas e não vivas”.

O ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia, pois inclui tanto os organismos quanto o ambiente abiótico; cada um desses fatores influencia as propriedades do outro e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a conhecemos na Terra. Esse nível de organização deve ser nossa primeira preocupação se quisermos que a nossa sociedade inicie a implementação de soluções holísticas para os problemas que estão aparecendo agora em relação ao bioma e à biosfera.

A complexidade dos ecossistemas e das múltiplas interações existentes em seu interior demonstra ao jurista a total impossibilidade da adoção dos métodos tradicionais do direito para a compreensão dessa nova realidade que, originariamente exterior, penetra avassaladoramente no universo do direito, assentando-se na própria Constituição. Vê-se, claramente, que o jurista deverá buscar na moderna ecologia os conceitos básicos para a proteção ambiental desejada pela sociedade.

§ 2º COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA AMBIENTAL

2.6 INTRODUÇÃO

Um dos problemas jurídico-constitucionais mais complexos em matéria de proteção ambiental é a repartição de competências entre os entes da federação. Isso tem sido reconhecido pelos estudiosos do tema, não sem uma certa perplexidade, como nos dá mostra Freitas (FREITAS, 1993, p. 31-32): *“em que pesem as dificuldades para discernir o que é interesse nacional, regional ou local, assunto ainda pouco enfrentado pela doutrina e pelos Tribunais, o certo é que a repartição de poderes atende mais aos interesses da coletividade. Evidentemente, só com o tempo as dúvidas serão aclaradas”*.

Em obra posterior, o mesmo autor (2000, p. 80) insiste na questão das evidentes dificuldades decorrentes dos aspectos relacionados com competências, senão vejamos: *“A prática vem revelando extrema dificuldade em separar a competência dos entes políticos nos casos concretos. Há – é inegável – disputa de poder entre órgãos ambientais, fazendo com que, normalmente, mais de um atribua a si a mesma competência legislativa e material”*.

Essas observações, adequadas, por certo, ainda não têm encontrado eco nos ambientes judiciais que, em diversas vezes, não demonstram capacidade de esclarecer os comandos constitucionais referentes às competências. É verdade, como se verá, que o STF tem dado à questão um tratamento bastante coerente, muito embora extremamente centralizadora.

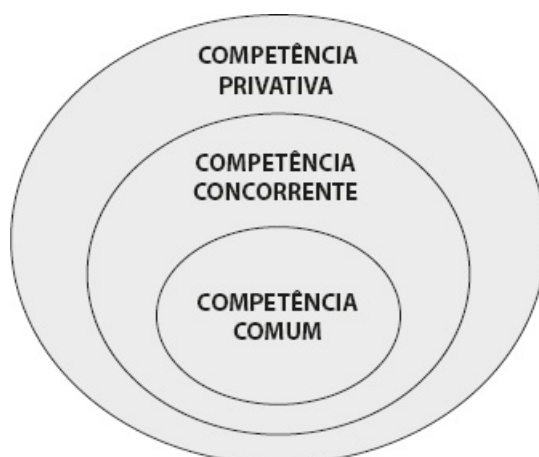
Machado (2005, p. 108), com a inegável autoridade e experiência na matéria que lhe é reconhecida, aponta questão que, com frequência, tem sido esquecida por legisladores e administradores: *“leis infraconstitucionais não podem repartir ou atribuir competências, a não ser que a própria CF tenha previsto essa situação, como o fez expressamente no art. 23, parágrafo único, quando previu que a competência comum estabelecendo normas de cooperação será objeto de LC”*.

O decano do direito ambiental brasileiro tocou em uma das questões mais delicadas e críticas: a indistintável tendência legislativa e mesmo regulamentar em “atribuir” competência e definir repartições de forma flagrantemente antagônica ao texto constitucional.

É relevante consignar que a proteção ao meio ambiente, considerada em si mesma, não é necessariamente democrática, ainda que o Direito Ambiental, tal como concebido modernamente, tenha uma origem democrática. É perfeitamente possível que se proteja o meio ambiente com métodos ditatoriais (DIAMOND, 2005), como foi o caso de Juan Balaguer na República Dominicana; o grande desafio para a nossa sociedade é proteger o meio ambiente em um regime democrático, federalista e constitucional.

Uma das questões cruciais é a repartição das competências administrativas que, em termos práticos, se desdobra na fiscalização e no licenciamento ambiental. Nesses dois pontos estão as maiores dificuldades para as atividades econômicas e, principalmente, os conflitos entre os diferentes entes administrativos, tanto no nível das diferentes esferas administrativas como, não raras vezes, dentro de um mesmo nível político administrativo, visto que não são raras as divergências entre agências de controle ambiental, institutos de florestas e agências de águas de um mesmo Estado, Município ou da União.

Rotineiramente, o poder de polícia sobre determinada atividade integra as atribuições da pessoa de direito público interno dotada de competência legislativa no assunto, visto que o poder de polícia é uma decorrência da competência. À competência legislativa corresponderá uma competência administrativa específica. A definição das competências é importante para saber quais são as entidades responsáveis pela fiscalização da atividade. O sistema federativo adotado por nosso País, contudo, cria situações que não são juridicamente claras. Aliás, esse é um tema recorrente em todos os países que adotam o chamado modelo do federalismo cooperativo. A primeira dificuldade concreta para compreender a questão é que a Constituição utiliza, indistintamente, da expressão *meio ambiente* e de vocábulos, de elementos que, em tese, constituem o meio ambiente. Assim, a Constituição fala em meio ambiente e em recursos hídricos, florestas, ecossistemas etc. Ora, a Constituição reconhece *uma competência para legislar sobre minas e outra para legislar sobre meio ambiente*; reconhece uma competência para energia nuclear e outras para meio ambiente. Por certo, são temas intimamente correlacionados e cujo tratamento deve ser feito em conjunto, sob pena de esvaziamento das competências constitucionais e insegurança jurídica, com a consequente fragilização ambiental. Parece-me, e esse tem sido o entendimento do STF, que as competências privativas se sobrepõem às competências concorrentes – quando os temas se tangenciarem –, o que significa, na prática, o estabelecimento de um regime federal muito centralizado e centralizador. Ora, ao legislar sobre *minas*, por exemplo, a União exerce toda a competência sobre a matéria, inclusive a ambiental, adotando-se o critério de que o acessório segue o principal, ou seja, a competência concorrente somente será exercida na medida em que se conforme ao padrão federal definido em sede de competência exclusiva. Nenhuma norma estadual ou municipal poderá, a título de proteção ambiental, chegar ao ponto de inviabilizar a atividade tal qual definida pela União no uso exclusivo de suas atribuições. Esse é um parâmetro que deve ser seguido em toda e qualquer matéria que, tratada na competência privativa da União, tenha repercussão ambiental (competência concorrente). É possível se afirmar que a competência privativa exerce um direito de preempção sobre a competência concorrente e mesmo a comum, sempre que entre elas se identifique um ponto de contato. O que aqui se explicita, por certo, não é um desejo pessoal do autor, mas a forma pela qual a prática judicial e administrativa tem solucionado as questões: com maior centralização.



As competências legislativas ambientais estão *aparentemente* muito repartidas pela CF, sendo certo que tanto a União como os Estados-Membros e os Municípios

possuem-na, em tese, ainda que de forma e grau diferentes. Há uma verdadeira *balcanização* de competências. A repartição de competências legislativas, feita com espírito que, à primeira vista, se passa por descentralizador, muito embora não o seja, implica a existência de um sistema legislativo complexo e que, nem sempre, funciona de modo integrado, como seria de se esperar e que tende a operar como uma força centrípeta. Tal fato é devido a toda uma gama de circunstâncias que variam desde interesses locais e particularizados até conflitos interburocráticos e, sem dúvida, chegam até as dificuldades inerentes ao próprio sistema federativo tripartite. Com efeito, ainda não se logrou uma clara demarcação do campo de atividade dos diversos órgãos ambientais, vez que as competências não estão claramente definidas, pois a repartição de competências é muito vaga. Esse fato, como é óbvio, resulta altamente prejudicial ao meio ambiente e para aqueles que utilizam bens ambientais para atividades econômicas, estabelecendo um eficiente regime de incerteza jurídica.

2.6.1 Competência federal

A CF, em seu artigo 22, determina competir *privativamente* à União legislar sobre: águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais e atividades nucleares de qualquer natureza. Os itens acima citados estão amplamente relacionados com o meio ambiente. Formam, portanto, parte significativa da legislação ambiental e, na prática, desmentem aqueles que acreditam que a Constituição de 1988 é descentralizadora. Tal quantidade de competências privativas, quando mesclada com as concorrentes, gera uma teia que muito pouco, ou quase nada, resta para os demais entes federativos. A União, na forma do artigo 23 da CF, tem competência *comum* com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a flora e a fauna; registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. A competência comum é uma verdadeira “armadilha”, visto que, na prática, a atribuição de todos acaba se transformando na atribuição de ninguém. Ademais, a competência comum não é complementada pela indispensável fonte de recursos para a sua implementação, gerando uma dependência de Estados e municípios em relação ao poder federal. Veja-se, ademais, que a competência comum despreza o princípio da *subsidiariedade* (Pontifício Conselho de Justiça e Paz, 2005, p. 235), sendo articulada sem nenhum critério claro ou, minimamente, compreensível. Não há, na Constituição, um critério fundado na possibilidade de uma prestação de serviço mais adequada ou de maior proteção ao meio ambiente.

O artigo 24 da CF determina competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do meio e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Por incrível que possa parecer, verifica-se, mais uma vez e sem muita dificuldade, que diversas das matérias que integram a competência privativa da União estão, concomitantemente, arroladas nas competências comum e concorrente dos diversos formadores da Federação. Água, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais e atividades nucleares de qualquer natureza integram a competência legislativa privativa da União. Ocorre que a proteção do meio ambiente, o combate à poluição, a preservação de florestas, da flora e da fauna, a exploração de recursos hídricos, estão incluídos na competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do meio e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Essa notória superposição legislativa e de competências ainda não foi esclarecida, pois não existe uma lei que delimite claramente o conteúdo da competência de cada uma das entidades políticas que constituem a Federação brasileira. A Resolução nº 237 do Conama, ainda que sem a necessária base legal, tentou enfrentar o problema. Diante do quadro normativo acima descrito, o papel desempenhado pela União se avulta, pois, dado que à União compete estabelecer os *princípios gerais* da legislação ambiental, as suas normas servem de referencial para Estados e Municípios, que, não raras vezes, não produzem legislação própria e acabam aplicando diretamente a legislação federal, o que não me parece juridicamente válido, embora aconteça na prática cotidiana. De fato, a experiência tem demonstrado que, não poucas vezes, os municípios e os Estados chegam a aplicar, por intermédio de suas fiscalizações, normas criminais previstas na Lei nº 9.605!

A competência definida no artigo 22 da Constituição, ou seja, a *competência privativa*, somente pode ser exercida pela própria União, a menos que ela, mediante LC, autorize os Estados-Membros a legislar sobre questões específicas incluídas nas matérias contempladas no parágrafo único. *A competência privativa é competência legislativa que só pode ser exercida pelos Estados mediante autorização dada por LC federal para casos específicos. O STF já tem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a legislação local enquanto não for editada a LC determinada pela própria Constituição: “Esta Corte, em pronunciamentos reiterados, assentou ter, a Constituição do Brasil, conferido exclusivamente à União a competência para legislar sobre trânsito, sendo certo que os Estados-Membros não podem, até o advento da LC prevista no parágrafo único do artigo 22 da CF/88, legislar a propósito das matérias relacionadas no preceito. 2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente”* (ADI 2432/RN, Relator: Min. Eros Grau, Pleno, DJU 26/08/2005, p. 5. Republicação: DJU 23/09/2005, p. 7).

A LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011, veio tentar solucionar os problemas referentes à repartição das competências administrativas, sobretudo no que diz respeito ao licenciamento e à fiscalização ambiental. É interessante observar que todas as críticas que haviam sido formuladas antes da entrada em vigor da LC nº 140/2011, aparentemente, foram assumidas pelo Executivo Federal, pois evidentemente que uma determinada matéria não pode ser, concomitantemente, tratada por LC e por mera Resolução administrativa, como é o caso da Resolução nº 237/97 do Conama. Perderam-se incríveis 14 anos entre a Resolução e a LC e 23 anos entre a Constituição e a LCP nº 140/2011, para que se constatasse o óbvio.

2.6.1.1 Omissões inconstitucionais

Todo o problema – ou pelo menos a parte mais importante dele – jurídico-constitucional relativo à repartição de competências tem uma origem bem demarcada nas omissões do Congresso Nacional que não disciplina, por leis próprias, as matérias relativas à repartição de competências e, com isso, reforça o seu próprio papel político em detrimento da autonomia dos Estados e dos municípios.

Tem circulado nos meios políticos e jurídicos a expressão *Pacto Federativo*. Vejamos do que se trata. Por *pacto federativo* tem sido entendido um amplo acordo entre os entes federados quanto ao exercício das competências de cada um. Apenas, *en passant*, deve ser lembrado que *pacto federativo*, de fato, é o que consta da própria Constituição, que deveria, simplesmente, ser cumprido. Para a implementação de tal pacto, chegou-se a criar “comissões tripartites”, nas quais estão representados o Ibama, os órgãos estaduais de meio ambiente e os órgãos municipais. Tanto as comissões tripartites quanto o chamado pacto federativo são mecanismos que, como concebidos, fortalecem a centralização.

O *pacto federativo* está contido na CF e só nela. O que é urgente, sob meu ponto de vista, é o duplice reconhecimento do Estado de Direito e do Federalismo, de forma que possamos sair do verdadeiro atoleiro no qual patina, sem esperança de sair, a implementação do federalismo ambiental no Brasil.

Em primeiro lugar, há que se observar que o artigo 24 da CF, em seus quatro parágrafos, estabelece caber à União produzir a legislação geral e que a competência geral da União não suprime a competência suplementar dos Estados. Acrescenta a Constituição que, na inexistência de norma federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência plena e que, na superveniência de lei federal sobre normas gerais, cessa a eficácia da norma estadual naquilo que contrariar a lei federal sobre normas gerais. Nesses quatro parágrafos, está a essência do chamado “federalismo cooperativo”. Entretanto, no estágio em que a matéria se encontra, de fato, não podemos falar em um federalismo cooperativo, pelo simples fato de que não existe uma lei federal sobre normas gerais. O que se tem verificado é uma forte tendência da União a criar “políticas nacionais”, nem sempre com amparo constitucional e que, não raras vezes, têm sido recebidas pelo ordenamento jurídico como se “normas gerais” fossem. Na verdade, as “políticas nacionais” implicam, do ponto de vista prático e, sobretudo, político, a submissão dos Estados à “política federal” vigente. A política nacional, em matéria contemplada na competência concorrente, é o centralismo avançado sobre o espaço político reservado aos Estados e aos municípios, com a tolerância, aceitação e, às vezes, por requerimento dos próprios Estados que, destituídos de recursos, se submetem à constante e firme invasão do poder federal sobre áreas constitucionalmente reservadas a Estados e municípios.

Como já foi visto, há a necessidade constitucional de que se elabore uma lei sobre normas gerais para que as competências concorrentes possam ser exercidas de forma harmônica e conforme o desejo do legislador constituinte. O artigo 61 da CF determina a titularidade ativa para a iniciativa de lei que, no caso concreto, está deferida a qualquer membro do Congresso Nacional e ao Presidente da República. Entretanto, passadas décadas da elaboração da “Constituição Cidadã”, nem o Poder Legislativo nem o Poder Executivo usaram o seu poder-dever de dar iniciativa a projeto de lei versando sobre tema tão crucial para a nossa combatida federação. Na verdade, tal iniciativa não é exercida, pois implicaria uma real diminuição dos poderes federais, o que não atende aos interesses – seja do Executivo, seja do Legislativo – federais, que permanecem com um alto poder de pressão e barganha sobre estados e municípios.

Em regime federativo, como se sabe, cabe ao Poder Judiciário decidir as questões relativas às inconstitucionalidades de leis e atos normativos federais e estaduais em face da CF e daquelas dos Estados. Ao STF é deferida a elevada atribuição de, ao declarar as inconstitucionalidades em face da CF, estabelecer o perfil jurídico constitucional da relação entre os diversos integrantes da Federação, fazendo com que ele seja o ponto de equilíbrio da própria União. Isso pode ser feito por diversos meios, dentre os quais se destaca a Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja por ação ou omissão.

Quem se dedicar ao exame das muitas matérias compreendidas na competência concorrente entre Estados, União e Distrito Federal verificará que existe uma tendência à centralização que, sem dúvida alguma, tem sido sustentada pelo STF em função do fato de que “*não há em nosso ordenamento jurídico*” uma lei federal sobre normas gerais, o que acaba acarretando que, na prática, toda e qualquer lei federal seja considerada uma “lei geral”. De fato, não tem havido um questionamento efetivo quanto aos limites impostos ao poder de legislar da União e, principalmente, de invadir a competência dos Estados. São praticamente inexistentes as declarações de inconstitucionalidade de leis federais por “*invasão da competência dos estados*”, muito embora a possibilidade teórica exista.

Se formos compulsar o artigo 24, VI, da CF, veremos que legislar sobre florestas é matéria que integra a competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da União. Nesse sentido, a Lei nº 12.651/2012 é lei geral. Entretanto, a compreensão que o STF tem dado à capacidade dos Estados de suplementar a legislação federal é muito restritiva, limitando-se a admitir o preenchimento de lacunas relativas às realidades locais (ADI 1.086 MC/SC. Medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator: Min. Ilmar Galvão. Julgamento: 01/08/1994. Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJU 16/09/1994, p. 42.279. “...Estudo prévio de impacto ambiental. Diante dos amplos termos do inc. IV do § 1º do art. 225 da Carta Federal, revela-se juridicamente relevante a tese de inconstitucionalidade da norma estadual que dispensa o estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais. Mesmo que se admitisse a possibilidade de tal restrição, a lei que poderia viabilizá-la estaria inserida na competência do legislador federal, já que a este cabe disciplinar, através de normas gerais, a conservação da natureza e a proteção do meio ambiente (art. 24, inc. VI, da CF, não sendo possível, ademais, cogitar-se da competência legislativa a que se refere o § 3º do art. 24 da Carta Federal, já que esta busca suprir lacunas normativas para atender a peculiaridades locais, ausentes na espécie...”).

O STF, evidentemente, *só pode julgar com base no quadro normativo vigente* e, efetivamente, inexistindo a norma sobre normas gerais – aliás, a ser produzida pela União –, devem ser consideradas gerais aquelas que a União entender que gerais são. Há alguns poucos exemplos nos quais as leis estaduais foram mantidas, liminarmente, com base no exercício da competência concorrente (ADI 1.278 MC/SC – Medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator: Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. DJU 14/06/2002, p. 126. “Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade – Liminar. O deferimento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo impugnado, requisitos reveladores da relevância da matéria versada na inicial. Isto não ocorre relativamente à Lei do Estado de Santa Catarina nº 1.179/94, no que disciplinou a pasteurização do leite de cabra. A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente – inciso XII do artigo 24 da CF”).

Uma das possíveis soluções para o grave problema apontado é o ajuizamento, perante o STF, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

De fato, o que se vem observando em matéria de proteção ao meio ambiente, com a crescente centralização e a inércia do Executivo e do Legislativo, é um verdadeiro escândalo constitucional neste País no qual não existem escândalos. Efetivamente, os Governadores dos Estados possuem legitimidade para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e, no particular, até onde é do conhecimento deste autor, não o fizeram e, portanto, acabam agindo de forma a contribuir para a crescente diminuição das competências estaduais e subalternizando o próprio papel dos Estados para os quais foram eleitos como dirigentes máximos. Assim, e cada vez mais, o legislador estadual se transforma em um legislador de ninharias sem relevância nenhuma, como o caso dos *pitbulls* no Rio de Janeiro (Lei nº 3.205, de 9 de abril de 1999), matéria que poderia ser disciplinada por uma portaria do Chefe de Polícia, sem qualquer problema.

É nesse quadro de amplo e constante avanço da centralização e da subalternização das leis estaduais que floresce o Direito Ambiental brasileiro que, cada vez mais, se transforma no *direito ambiental federal*. Grande parcela de culpa deve ser atribuída aos próprios Estados que, em função de recursos econômicos escassos, acabam aceitando o jogo proposto pelos poderes federais, que é o de afunilar tudo para Brasília, com a decretação da supremacia dos órgãos federais sobre os dos Estados.

Seria muito importante que um dos legitimados à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade fosse ao STF questionar a inconstitucionalidade por omissão no que se refere à lei sobre normas gerais. Sabemos que o STF não terá condições de compelir, seja o Legislativo, seja o Executivo, a agir. Entretanto, a simples declaração de mora poderá surtir um efeito extraordinário, assim como se poderá, em tese, permitir que os Estados legislem sem que fiquem submetidos a que se tenha por norma geral algumas metragens estabelecidas por leis federais, como tem sido feito.

2.6.2 Competência estadual

A competência dos Estados-Membros da Federação para atuar em matéria ambiental está prevista nos artigos 23 e 24 da CF. No artigo 23, como já vimos, existe uma atribuição de cooperação administrativa entre os diversos componentes da Federação. Já o artigo 24 afirma uma competência legislativa própria para os Estados. Ele não trata do meio ambiente como um bem *unitário*, mas, ao contrário, subdivide-o em diversos “setores” que, integrando-o, estão tutelados por normas legais estaduais. Assim, os Estados podem legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; responsabilidade por dano ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Observadas as normas gerais federais, cada Estado pode estabelecer as suas próprias normas de tutela ambiental, criando sistemas estaduais de proteção ao meio ambiente. Esse é um caminho interessante para a proteção do meio ambiente, pois a maior proximidade entre o bem a ser tutelado e a agência de controle ambiental é bastante positiva e possibilita mais efetividade na tutela almejada. Evidentemente que o estabelecimento de sistemas estaduais de proteção ao meio ambiente encontra fortes obstáculos em questões de natureza econômico-financeira. Como se vê, é ampla a possibilidade que os Estados têm para legislar sobre meio ambiente. A prática do federalismo cooperativo, no entanto, vem bloqueando os poderes locais no que tange à possibilidade de exercerem as suas competências: “*Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 2º, 4º e 5º da Lei nº 10.164/94, do Estado do Rio Grande do Sul. Pesca Artesanal. Inconstitucionalidade formal. 1. A Constituição do Brasil contemplou a técnica da competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados-Membros especificá-las. 2. É inconstitucional lei estadual que amplia definição estabelecida por texto federal, em matéria de competência concorrente. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente*” (ADI 1.245/RS. Relator: Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. DJU 26/8/2005, p. 5).

Não se pode deixar de observar que a Lei nº 10.165/2000 levou ao paroxismo o extremamente confuso quadro de repartição de competências entre os diferentes entes federativos, ao admitir a repartição de receitas oriundas da Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental devida ao Ibama.

2.6.3 Competência municipal

Os Municípios, pela Constituição de 1988, foram elevados à condição de integrantes da Federação. Na forma do artigo 23 da CF, os Municípios têm competência administrativa para defender o meio ambiente e combater a poluição. Contudo, os Municípios não estão arrolados entre as pessoas jurídicas de direito público interno

encarregadas de legislar sobre meio ambiente. No entanto, seria incorreto e insensato dizer-se que os Municípios não têm competência legislativa em matéria ambiental.

O artigo 30 da CF atribui aos Municípios competência para legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e estadual no que couber; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Parece claro, na minha análise, que o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam um elo fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o problema. É através dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de *agir localmente, pensar globalmente. Na verdade, entender que os Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da CF.*

2.6.3.1 Exercício da competência comum mediante a edição de leis próprias

O problema mais grave no que se refere ao exercício da competência comum, em meu modo de ver, é a necessidade de que os Municípios se equipem com uma legislação adequada, com previsão dos tipos administrativos e das sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento das normas de tutela ambiental, ou que, na inexistência dessas, exista, no mínimo, convênio específico. Muitas são as razões jurídicas que determinam que assim seja. Senão, vejamos.

A imposição e arrecadação de multas por parte dos entes públicos está plenamente submetida ao *princípio da legalidade* e, evidentemente, não pode dele se afastar. É importante observar, com Marçal Justen Filho (2005, p. 398), que um dos principais aspectos que norteiam a necessidade da legalidade das sanções administrativas é o de dar ao cidadão a possibilidade de escolha quanto à conduta a adotar, tendo em vista o conhecimento das penalidades que, em tese, poderá estar sujeito.

“Mas o princípio da legalidade propicia a certeza e previsibilidade da ilicitude, proporcionando a todos a possibilidade de ordenar suas condutas futuras. Tipificar legislativamente a ilicitude e sua sanção equivale a atribuir ao particular a possibilidade de escolha entre o lícito e o ilícito. A supressão da legalidade das infrações elimina garantias do particular em face do Estado e atenta contra princípios fundamentais [...]”

Com efeito, o fato de existir uma competência comum entre União, Estado e Municípios para proteger o meio ambiente não desonera o Município da obrigação de ter uma legislação própria para que possa fielmente desincumbir-se de suas obrigações constitucionais.

Diferente não é, por exemplo, a opinião de José Afonso da Silva (SILVA, 2004, p. 80). Senão, vejamos:

“Quer isso dizer que não se recusa aos Municípios competência para ordenar a proteção do meio ambiente, natural e cultural. Logo, é plausível reconhecer, igualmente, que na forma do art. 30, II, entra também a competência para suplementar a legislação federal e a estadual na matéria. Isso é reconhecido em leis federais, bastando lembrar, além do já transcrito § 1º do art. 5º da Lei 7.661, de 1988, que reconhece aos Municípios costeiros a possibilidade de instituir, mediante lei, os respectivos Planos de Gerenciamento Costeiro, o art. 2º da Lei 6.938, de 1981, que diz que os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, poderão elaborar normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente”.

Analisando-se a doutrina especificamente municipalista, da qual nos dá um excelente exemplo o Professor José Nilo de Castro (CASTRO, 1999, p. 193-194), veremos que, majoritariamente, ela assim tem entendido o tema:

“É indispensável, no âmbito municipal, a competência por cooperação com a União, Estado e outros Municípios, mediante convênio ou consórcio administrativo. A figura da cooperação associativa prescreveu-a também o Decreto-lei nº 200/67, art. 10, § 1º, b. E no exercitamento da competência comum, que é competência administrativa, a cooperação associativa tem universo maior e mais propício para ações integradas [...]. Inegavelmente, cabe ao Município, como Poder Público, dispor sobre regras de direito, legislando em comum com a União e o Estado, com fundamento no art. 23, VI, CF. Portanto, quando um Município, através de lei, mesmo que se lhe reconheça conteúdo administrativo, em se tratando da competência comum, disciplinar esta matéria, fá-lo-á no exercício da competência comum, peculiarizando-lhe a ordenação pela compatibilidade local, em consideração a esta ou àquela vocação sua [...]”.

Portanto, a compatibilização entre a competência constitucional dos Municípios para darem combate à poluição e proteger o meio ambiente com o princípio da legalidade somente ocorre com a existência de uma legislação municipal própria sobre o assunto e, principalmente, com a sua aplicação aos casos concretos. Quanto ao particular, o STF já se pronunciou da seguinte forma: *“Federação ... Lei estadual que confere aos municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos, no Estado, o que vale por excluir, a propósito de tais bens do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de proteção e guarda e a consequente responsabilidade não apenas do Estado, mas também da própria União, incluídas na competência comum dos entes da Federação, a qual substantiva incumbência de natureza qualificadamente irrenunciável. 2. A inclusão de determinada função administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades federativas: donde a previsão, no parágrafo único do art. 23 CF, de LC que fixe normas de cooperação (v., sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos, a Lei 3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios...”* (ADI 2.544 MC/RS. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento: 12.6.2002. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJU 08/11/2002, p. 21).

Por oportuno, vale trazer à colação outra decisão do STF que indica que a competência para legislar sobre trânsito é exclusiva da União (ADI 1.032, ADIMC 1.704, ADI 532, ADI 2.101 e ADI 2.064), assim como é a competência para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança (ADIMC 874), Veja também o RE 227384/SP, Relator Min. Moreira Alves. Julgamento: 17/6/2002. Tribunal Pleno. DJU 09/08/2002, p. 68).

2.6.4 A questão da aplicação da norma mais restritiva

Um dos temas mais presentes e debatidos quando se trata de repartição de competências em matéria ambiental é a chamada *“prevalência da norma mais restritiva”*. A primeira indagação para compreender o problema é a seguinte: Qual é o conceito de *mais restritivo*? Aparentemente, *mais restritivo* significa a menor intervenção ambiental quando comparadas as normas que estejam em um suposto conflito positivo. Normalmente, afirma-se que a norma a ser aplicada é aquela considerada mais restritiva, pois, em tese, se estaria privilegiando a maior proteção ao meio ambiente. Ocorre que o critério do mais restritivo, ainda que pudesse ser justificado ambientalmente, o que nem sempre é verdade, precisa encontrar uma legitimidade jurídica, visto que é de aplicação de lei que se trata.

Do ponto de vista puramente ambiental, nem sempre a intervenção mais suave sobre o meio ambiente é a melhor ou a mais necessária. Muitas vezes, em função de intervenções muito pequenas sobre o meio ambiente, surgem situações de profundo desequilíbrio ambiental. Não há qualquer base legal ou constitucional para que se aplique a norma mais restritiva. A ordem jurídica, como se sabe, organiza-se em uma escala hierárquica, encimada pela CF, que, dentre outras coisas, dispõe sobre a competência dos diversos organismos políticos e administrativos que formam o Estado. *Pouco importa que uma lei seja mais restritiva e, apenas para argumentar, seja mais benéfica para o meio ambiente, se o ente político que a produziu não é dotado de competência para produzi-la.* A questão central que deve ser enfrentada é a que se refere à competência legal do órgão que elaborou a norma. Naturalmente, espera-se que os diferentes entes políticos produzam boas leis, na esfera de suas competências.

O Brasil é organizado politicamente sob a forma de Estado Federal com três níveis de governo. Cada um desses níveis tem uma esfera de atribuição própria que

deve ser respeitada pelos demais níveis de governo e, evidentemente, por cada um deles em relação às suas próprias atribuições. Assim, um governo não deve dispor além, muito menos aquém, de suas prerrogativas constitucionais. Hipoteticamente raciocinando, o Estado do Rio de Janeiro poderia proibir instalações nucleares em seu território. Ora, como a União permite instalações nucleares no Brasil, é evidente que a lei estadual seria mais restritiva e, portanto, admitindo-se a tese que vem sendo debatida, a lei local deveria prevalecer sobre a lei federal. *O raciocínio peca, todavia, devido ao fato de que os Estados não têm competência em matéria nuclear*: Os contrários à tese que estou defendendo poderão argumentar que a energia nuclear é uma competência exclusiva da União e, portanto, o exemplo não caberia. Diriam que, em se tratando de competência concorrente, aí sim a aplicação da norma “mais restritiva” encontra o seu *locus* privilegiado de existência.

Embora o canto de Circe seja sedutor, não devemos nos deixar levar por ele, pois as consequências podem ser trágicas. Reconheço que a nossa *Constituição Cidadã* não é nenhum exemplo de coerência e de clareza. Ao contrário, ela é bastante complexa e pouco clara. No tema obscuridade, a repartição de competências nada de braçada, pois é de longe a principal dificuldade para o nosso federalismo dito “cooperativo”. A força avassaladora que a União detém, seja do ponto de vista dos recursos econômicos, seja do ponto de vista do arsenal de competências legislativas e administrativas que lhes foram outorgadas pela própria Constituição, faz com que a própria União defina quais são os limites de sua *legislação geral*. Assim, os Estados devem – como rotina – conformar-se com a produção de normas cosméticas e de pouca relevância prática. Não havendo uma definição clara sobre o conceito de norma geral, esta será aquilo que a União quiser que seja.

A restrição que o Estado está autorizado legitimamente a opor a uma atividade submetida à competência concorrente não pode ir ao ponto de descaracterizar as normas federais. Trocando em miúdos, um Estado não pode, por exemplo, proibir em seu território um produto que esteja autorizado pela União, ainda que sob o pretexto de estar exercendo a sua competência concorrente em matéria de proteção ao meio ambiente. (RE 286.789/RS. Recurso Extraordinário. Relator: Min. Ellen Gracie. Segunda Turma. DJU 08/04/2005, p. 38). Vale observar que, em sede normativa, o conceito de *mais restritivo* encontra guarida no § 2º do artigo 5º da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro). Enquanto não declarada a inconstitucionalidade de tal norma, evidentemente, ela há que ser observada.

Como já foi visto acima, a Resolução Conama nº 382, de 26 de dezembro de 2006, estabelece expressamente a possibilidade de que, em certas circunstâncias, possa haver a ultrapassagem dos padrões de emissão de particulado, conforme consta do artigo 6º, § 2º, haja vista que o órgão ambiental licenciador poderá, mediante decisão fundamentada, a seu critério, estabelecer limites de emissão “menos restritivos” que os estabelecidos na Resolução. O mesmo raciocínio é válido para as disposições da Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011 do CONAMA, vez que o artigo 6º estabelece que excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental competente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução, desde que observados determinados requisitos.

2.6.5 LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011

A CF, em seu artigo 23, estabelece ser da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (i) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e (ii) preservar as florestas, a fauna e a flora, determinando que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Estas determinações constitucionais são uma das expressões do chamado “federalismo cooperativo”, que, em tese, é o modelo adotado pela República Federativa do Brasil. Por tal modelo, busca-se um equilíbrio entre os diferentes entes federativos, de forma que eles possam exercer suas autonomias constitucionais e que as diferentes ações da administração pública sejam realizadas de forma a assegurar a economia de recursos financeiros, técnicos e administrativos com vistas a alcançar maior eficiência administrativa. Contudo, passar do retórico ao prático é algo bastante complexo, especialmente em matéria ambiental de difícil execução.

Após muitos anos da promulgação da CF de 1988 e um lustro depois da edição da Emenda Constitucional nº 53 de 2006, que deu nova redação ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição, finalmente veio a lume a LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011, que cuidou de regulamentar tal cooperação. Muito embora não se possa negar a importância da lei, fato é que ela não soluciona todos os problemas.

Em primeiro lugar, cumpre observar que o Congresso Nacional entendeu que a Lei nº 6.938/1981, deve ser considerada como LC, posição que já havíamos sustentado em edições anteriores deste livro. Por outro lado, a matéria tratada pela LC antes de sua edição, no que diz respeito a licenciamento ambiental, estava disciplinada por Resolução do Conselho Nacional, o que mostra que a Resolução Conama nº 237/97 não era o instrumento jurídico hábil para dispor sobre a matéria, como também já foi afirmado em edições anteriores deste livro.

A LC nº 140/2011 repartiu as competências administrativas entre a União, os Estados e os Municípios, que ficaram assim definidas:

União	Estados	Municípios
• formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a PNMA; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; • promover ações relacionadas à PNMA nos âmbitos nacional e internacional; • promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à PNMA; • promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; • promover a articulação da PNMA com as de	• executar e fazer cumprir em âmbito estadual, a PNMA e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; • formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente; • promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente; • promover o desenvolvimento de estudos e	• executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; • formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente; • promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente; • promover o desenvolvimento de

Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras; - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional; - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União; - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: (i) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; (ii) localizados ou desenvolvidos no mar territorial na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; (iii) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; (iv) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (v) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; (vi) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97, de 9 de junho de 1999; (vii) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou (viii) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da	pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente; - prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima; - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os - zoneamentos de âmbito nacional e regional; - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida aos Estados; - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º da LC nº 140/2011; - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (ii) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do artigo 7º; e (iii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado;	estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente; - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente; - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais; - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município; - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: (i) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou (ii) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, aprovar: a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e b) a supressão e o manejo de
--	--	---

Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento; • aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e (ii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; • controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados; • controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas; • proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI do artigo 7º da LC nº 140/2011;	• elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies <i>in situ</i>; • controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas; • aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; • exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e • exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do artigo 7º.	vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município. • elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies <i>in situ</i>; • controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do artigo 7º; • aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
• exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional; • gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais; • exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e • exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.		

2.6.6 Conclusão

Diante do que foi exposto, entendo que tanto a União quanto os Estados e Municípios são dotados de amplas competências ambientais, muito embora a prática judicial tenha reduzido em muito a capacidade legislativa dos Estados e dos Municípios. Este fato é, em si próprio, bastante complexo, pois a prática tem demonstrado que os três níveis da administração pública *não agem* coordenadamente. Muito pelo contrário, é rotineira a tomada de medidas contraditórias e até mesmo antagônicas entre eles. Isto faz com que reine, entre empreendedores e a população em geral, a mais completa perplexidade. Também não se pode deixar de consignar que, em diversas oportunidades, as competências ambientais têm servido de escudo para ações políticas de retaliação entre autoridades públicas de partidos diferentes. É bastante comum que prefeitos de um partido determinem embargos “ambientais” de obras licenciadas pelos órgãos estaduais ou federais, bem como o contrário, em todas as três esferas da Administração Pública, com evidente prejuízo para a credibilidade do sistema. Assim, vivemos muito mais em um federalismo *competitivo* do que em um federalismo *cooperativo*. É urgente que seja elaborada a LC federal sobre normas gerais e que os entes federativos descubram suas vocações específicas para que a proteção ao meio ambiente possa se fazer de forma harmônica e integrada, como é o espírito da PNMA que, lamentavelmente, ainda não vingou.

-
- ¹ Matéria tratada na Lei nº 13.668/2018.
- ² Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social.

SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICA AMBIENTAL

§ 1º SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTAL

O Sistema Nacional do Meio Ambiente [SISNAMA] é o conjunto de órgãos e instituições *vinculadas ao Poder Executivo* que, nos níveis federal, estadual e municipal, são encarregados da proteção e melhoria da qualidade ambiental, conforme definido em lei. *Além do Sisnama*, cuja estruturação é feita com base na lei da PNMA, outras instituições nacionais têm importantes atribuições relativas à proteção do meio ambiente. Por política ambiental devemos entender todos os movimentos articulados pelo poder público com vistas a estabelecer os mecanismos capazes de promover a utilização de recursos ambientais de forma a mais eficiente possível, considerando como elementos primordiais a capacidade de suporte do meio ambiente, a conservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis. A política ambiental está inserida no contexto do desenvolvimento econômico e social, sendo indissociável deles.

A política ambiental é ação eminentemente executiva, muito embora não seja a ela limitada. Por diversos meios e modos, cada um dos diferentes poderes da República acaba exercendo um papel importante, seja na formulação, seja na implementação de políticas públicas ambientais.

3.1 O PAPEL DE CADA UM DOS PODERES DA REPÚBLICA

Cada um dos diferentes Poderes da República tem uma tarefa específica a desempenhar na proteção ao meio ambiente e na implantação de políticas ambientais. Contudo, o papel mais relevante é o do Executivo, que é o responsável pela formulação das diferentes políticas ambientais. Em uma sociedade democraticamente organizada, a divisão dos Poderes políticos é um importante elemento para a proteção dos cidadãos contra o abuso de poder. “... *O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional...*” (STF – MS 23.452/RJ. Relator: Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno. DJU: 12.5.2000, p. 20).

Ao Executivo competem as tarefas de definição dos usos possíveis dos recursos ambientais, bem como a forma pela qual eles serão utilizados, estabelecendo políticas setoriais de energia, recursos hídricos, florestas e outras. Fazer cumprir e implementar as políticas definidas é, igualmente, uma atribuição típica e essencial do Executivo. Os mecanismos de licenciamento ambiental, incentivos econômicos e financeiros, estabelecimento de penalidades e outros, são instituídos em função das metas contempladas pela política de utilização dos recursos ambientais.

Ao Legislativo compete a elaboração de leis, a fixação dos orçamentos das agências ambientais e o controle político das atividades desempenhadas pelo Executivo. O Legislativo estabelece as grandes linhas a serem observadas pelo Executivo, mediante a produção das leis específicas. Ao Judiciário, compete a revisão de todos os atos administrativos praticados pelo Executivo que tenham repercussão sobre o meio ambiente e o controle da constitucionalidade das normas elaboradas pelos demais Poderes. Também é relevante a função desempenhada pelo Judiciário no que diz respeito à cobrança da implementação das definições da política ambiental posta em lei. É através do Judiciário que os cidadãos interessados poderão contra-arrestar decisões administrativas que não se enquadrem nas normas constitucionais e legais. Também é por meio do Judiciário que os cidadãos poderão exigir que sejam cumpridas as normas vigentes.

O Ministério Público, cuja função é eminentemente ativa, tem por tarefa a integral fiscalização dos atos e procedimentos dos Poderes Públicos para, em caso de violação da legalidade, acioná-los judicialmente. Não é mais novidade para ninguém que o Ministério Público tem exercido um forte protagonismo nas questões ambientais, sendo um relevante ator na implementação concreta de algumas políticas ambientais. Isto ficou mais claro com o artigo 178, I, do Código de Processo Civil.

O sistema constitucional brasileiro atribui ao Congresso Nacional competências fundamentais para a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido pelo artigo 48 da CF. A competência legislativa da União em matéria ambiental é extremamente vasta. O Congresso Nacional, especialmente em matéria de energia nuclear, é dotado de competência, independentemente de sanção do Presidente da República. Pertence, ainda, à competência exclusiva do Congresso Nacional “*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa*”. Integram, também, as competências privativas do Congresso Nacional as de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Os incisos que demonstram mais claramente as atribuições congressuais em matéria de proteção ao meio ambiente são os de números XIV, XVI e XVII. Pelas normas contidas em tais incisos, o Congresso possui atribuição para “*aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares; autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais*”. E ainda, aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

É fácil constatar que o Congresso possui atribuições de três ordens distintas. A primeira delas é a de: (i) sustar a execução ou a vigência de atos normativos que não estejam em sintonia com a Constituição e com as leis votadas pelo próprio Congresso Nacional. O Congresso não tem usado dessa sua prerrogativa fundamental. Outra categoria de atribuição do Congresso Nacional é: (ii) a de permitir a supervisão de órgãos e agências do Executivo.

A maior omissão do Congresso Nacional está na total inoperância com que tem enfrentado a chamada questão nuclear. A vigente Constituição outorga ao Congresso os maiores poderes em matéria nuclear. Relembre-se do conteúdo da norma constitucional: “*aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares*”. Também no artigo 225, § 6º, estabelece uma importante atribuição do Legislativo em matéria nuclear, cabendo-lhe o poder-dever de, mediante lei, estabelecer a localização das usinas nucleares brasileiras. O Congresso Nacional jamais votou qualquer lei *especificamente* voltada para a localização das usinas nucleares Angra II e III.

Dentre outras atividades relacionadas com a atividade nuclear, cuja regulamentação depende de lei, está aquela contemplada no § 3º do artigo 177 da CF, que diz respeito ao *transporte e à utilização de materiais radioativos no território brasileiro*. Merece ser observado que, apenas em 2001, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.308, de 20 de novembro de 2001, que dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências.

O regime constitucional brasileiro estabelece que nenhuma ameaça ou lesão a direito poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Essa norma

constitucional, integrante do rol dos direitos e garantias individuais, estabelece um amplo sistema de revisão judicial de todo e qualquer ato administrativo exarado por quaisquer dos níveis político-administrativos do Estado brasileiro.

Os diplomas legais mais importantes para que o cidadão exerça o controle da administração são: (i) a ação popular, a (ii) ação civil pública e a (iii) lei de improbidade administrativa. ACF de 1988 deu um grande impulso ao papel desempenhado pelo Poder Judiciário na defesa do meio ambiente e da qualidade de vida.

O desempenho do Poder Judiciário em nosso tema está intimamente ligado ao tipo de demandas que lhe são propostas, seja pelo Ministério Público, seja pelos demais legitimados à propositura das ações civis públicas.

J. William Futrell (CAMPBELL-MOHN, BREEN e FUTRELL, 1993, p. 45) afirma, com razão, que os tribunais desempenham o vital papel de assegurar o poder de participação popular efetiva em uma democracia gerida por burocracias complexas.

A questão da separação de poderes e a participação do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas é tema controverso. A separação de poderes é um dos mais importantes dogmas do regime democrático, tal como ele tem sido compreendido nos países ocidentais. O STF, seguidamente, tem se pronunciado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário impedir possa o Executivo dar seguimento e implementar as políticas públicas definidas pela Administração. Veja-se a seguinte decisão do STF. “2. Art. 1º da Lei 9.494/97, c/c art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/92: configuração de grave lesão à ordem pública. Pedido de suspensão de tutela antecipada deferido em parte. 3. *A decisão impugnada no presente pedido de suspensão concedeu antecipação de tutela para sobrestar o processo administrativo de desapropriação, até que se providenciasse a exclusão das áreas destacadas do imóvel expropriando e transferidas para outras matrículas.* 4. *Existência de grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, dado que a decisão impugnada no presente pedido de suspensão impede a Administração de executar uma política pública, qual seja, a implementação da reforma agrária.*” (STF. STA-ED – Emb. Decl. na suspensão de tutela antecipada 85/PE. Relator Ministra Ellen Gracie. DJU: 11/10/2007, p. 38).

No entanto, a inércia com a qual o Executivo tem implementado determinadas questões tem feito com que muitas Cortes ultrapassem os limites da separação de poderes e, efetivamente, passem a avançar em áreas tipicamente executivas.

O exemplo mais completo de separação de poderes em matéria ambiental, na minha opinião, é o caso TVA vs. Hill, que cuidava da construção de barragens, ou outras obras de grande porte, e seus impactos sobre espécies listadas como ameaçadas de extinção. Nos Estados Unidos, a proteção de espécies, ao contrário do Brasil, é feita por lei e, portanto, expressa uma inequívoca manifestação de vontade do Congresso em preservar a diversidade biológica. No contexto do Direito Administrativo americano, o Congresso delega ao Executivo, no caso representado pelo Secretário do Interior e pelo Secretário de Comércio, a autoridade para incluir espécies na lista de animais ameaçados, cabendo ao *Fish and Wildlife Service* administrar o ESA e zelar pelas espécies tuteladas pela lista. A EPA é responsável pela administração de outras leis, tais como a National Environment Policy Act, o Clear Water Act ou o Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), por exemplo.

O ESA, à época da decisão do caso TVA vs. Hill, em sua seção 7, ostentava a seguinte redação:

Os departamentos federais e agências [...] com a assistência do Secretário, deverão utilizar as suas autoridades na prossecução dos objectivos da [a] lei através da realização de programas para a conservação de espécies ameaçadas [...] e pela adopção das medidas necessárias para assegurar que as ações autorizadas, financiadas ou realizadas por eles não ponham em causa a existência e continuação de tais espécies ameaçadas de extinção.

A seção 7, como se vê do texto legal, proibia qualquer ação que pudesse pôr em risco a existência de espécies ameaçadas de extinção. Se deixarmos de lado a questão ambiental e olharmos a decisão sob o prisma do Direito Constitucional – que é a forma atual como tem sido olhado o caso TVA vs. Hill pelos juristas norte-americanos –, veremos que ela encerra uma lição de separação de Poderes e de isenção do Judiciário perante as pressões do Executivo. Vale notar que importantes obras de Direito Ambiental não trazem mais o caso TVA vs. Hill como matéria de estudo, por considerá-lo superado. A chave constitucional da decisão TVA vs. Hill se encontra na seguinte passagem do voto do Justice Burger: Pode parecer curioso para alguns que a sobrevivência de um número relativamente pequeno de um peixe de três polegadas dentre os incontáveis milhões de espécies existentes pudesse requerer a paralisação permanente de uma barragem virtualmente completa, para a qual o Congresso gastou mais de 100 milhões de dólares. O paradoxo não é minimizado pelo fato de que o Congresso continuou a apropriar grandes somas de dinheiro público para o projeto, mesmo após os Comitês de Apropriações do Congresso terem tido ciência do aparente impacto sobre as espécies ameaçadas. Podemos concluir, no entanto, que o ESA requer explicitamente este resultado.

Se formos um pouco mais adiante na decisão, veremos que em uma outra passagem do voto o Juiz Burger afirma claramente que o desejo do Congresso era: “*parar e reverter a tendência de extinção das espécies a qualquer custo*”. Ante tão clara concepção da Corte, de fato, não havia outra decisão possível que não fosse a de determinar a paralisação das obras. Entendeu a Suprema Corte que, diante do expresse mandamento legal não arriscar, não pôr em perigo às espécies, não havia qualquer margem de discricionariedade para o Executivo que deveria se limitar a cumprir o comando que o Legislativo havia acionado. No particular, há que se verificar que a discricionariedade administrativa já havia sido exercida com a inclusão do *snail darter* na relação de animais a serem protegidos. Vale observar que, no caso brasileiro, algumas decisões judiciais de Cortes Regionais Federais têm sido tomadas em aparente conflito com os expressos termos da norma constitucional – haja vista que deram ao Texto Fundamental uma interpretação bastante alargada e, em geral, privilegiando a ação Executiva em detrimento da letra constitucional. Refiro-me ao caso do § 6º do artigo 225 da Constituição, que determina ao Executivo que se muna de autorização do Congresso Nacional para localizar usinas nucleares, sem o que não poderão operar. No caso TVA vs. Hill, a Suprema Corte entendeu que a mera apropriação de recursos para uma atividade não indicava que o Congresso estivesse revogando uma norma que claramente determinava o não molestamento de espécies definidas em uma relação elaborada pelo Executivo.

A interpretação que o TRF2 (AG – 151.046. DJU: 24/04/2007) tem dado ao § 6º do artigo 225, conforme mostra o aresto a seguir transcrito, é:

“[...] IV – De fato, a Constituição da República exige a autorização do Congresso Nacional para a instalação de usinas nucleares. Estabelece, também, que lei federal deverá determinar o local em que as mesmas deverão ser instaladas. V – Cumpre registrar, todavia, que o planejamento para a efetivação do empreendimento Angra III iniciou-se muito antes da ordem constitucional atual. Registre-se, também, que, consoante a CF/67, emendada em 1969, a autorização para instalações nucleares se dava sob a forma de decreto presidencial. Desta maneira, no ano de 1975, nos exatos termos constitucionais, o então Presidente da República, através do Decreto nº 75.870, autorizou a estruturação de uma terceira unidade de usina nuclear (fl. 85). VI – Verifica-se, assim, que o empreendimento em testilha foi iniciado ao tempo da Constituição anterior, que dispensava as exigências de autorização do Congresso Nacional para a construção de usinas nucleares, bem como a disposição sobre a localização das mesmas. VII – Deve-se afirmar, desta maneira, que não há que se falar em caducidade do Decreto nº 75.870/75 em confronto aos preceitos da nova ordem constitucional. E isso porque, analisando a jurisprudência do Pretório Excelso, quando o texto constitucional pretender assumir efeito retrospectivo, deve assim se manifestar expressamente. VIII – Outrossim, ainda que se admita a imprescindibilidade de cumprimento de tais requisitos, entende-se que os mesmos não devem vincular o início do procedimento de licenciamento ambiental. E isso porque é neste procedimento onde serão realizados todos os estudos necessários para a efetivação de empreendimento considerado poluidor, estudos estes imprescindíveis ao Congresso Nacional no momento em que for avaliar se deve ou não autorizar o funcionamento do referido empreendimento. IX – Caso contrário, o Congresso Nacional estaria sem qualquer referencial para emitir sua decisão, seja sobre a aprovação da construção da usina, seja sobre o local em que a mesma deverá ser construída [...]”

Sem pretender polemizar com a decisão, aliás proferida em sede de Agravo, parece-me evidente que se avançou em uma interpretação da norma constitucional muito além daquela que seria razoável, sobretudo em caso da magnitude do decidido. Ao revogar a Ordem constitucional anterior, o Constituinte de 1988 dispôs de forma inteiramente diversa sobre energia nuclear. Caso ele entendesse existente algum direito adquirido a ser mantido na nova ordem constitucional, no que se refere à instalação das usinas nucleares, certamente teria feito a ressalva, como fez para diversas outras questões nas disposições constitucionais transitórias. TVA vs. Hill, no particular, é uma lição de independência judiciária e não intervenção sobre a vontade do Congresso até o ponto de descaracterizá-la, como ocorreu na decisão brasileira apresentada. Não há que se confundir planejamento com instalação e muito menos autorização para planejamento com autorização para instalação. Além

disso, no caso concreto, ante a não implementação da autorização, haja vista que nada foi construído, não me parece razoável que tal interpretação possa persistir contra expressa disposição constitucional. Há, indiscutivelmente, um custo envolvido; contudo, em primeira análise, parece que o Congresso, assim como o norte-americano, não se importou com os custos, pois achou que outros valores superavam o mero custo financeiro.

O poder do Executivo Americano para elaborar as listas de espécies ameaçadas, sob a doutrina Chevron [Chevron USA v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 (1984)], tem sido amplamente reconhecido, e o Poder Judiciário deve aceitá-lo com base em deferência ao poder discricionário do Executivo, desde que a ação executiva tenha sido razoável. Assim, a Suprema Corte reconhece que o Congresso delegou a atribuição de formar a lista para o Executivo (Chevron Step 1) e que a escolha foi razoável e não exorbitante (Chevron Step 2). Cabe, segundo a doutrina Chevron, ao Executivo definir as questões de políticas públicas a serem aplicadas, segundo a determinação do Congresso, tal como expressas em lei.

TVA vs. Hill teve como uma de suas consequências uma modificação no texto da seção 7 do ESA com a substituição da expressão “do not jeopardize” por “is not likely to jeopardize”, ou seja, provavelmente não prejudique, não arrisque. A norma, portanto, tornou-se muito mais abstrata e ampliou o poder discricionário do Executivo para avaliar as medidas a serem tomadas em cada caso que, conforme a doutrina Chevron, devem ser respeitadas pelos tribunais desde que sejam razoáveis.

TVA vs. Hill é um marco judiciário extraordinário e demonstra claramente o que é uma Corte independente e, ao mesmo tempo, é uma aula sobre separação de poderes. Não há dúvida de que a decisão, se analisada sob o prisma de danos ambientais concretos, custo e benefício, investimentos realizados e a serem realizados, é extremamente exagerada e absurda. Por outro lado, se o Tribunal tivesse resolvido “legislar” e dar uma interpretação à norma que, evidentemente, não era possível, teria dado ao Executivo a possibilidade de, simplesmente, não cumprir a determinação do Legislador que, exagerada, por certo, era aquela mesmo. Seguramente, todo o sistema de proteção de espécies estaria colocado sob uma discricionariedade absoluta do Executivo, o que não era o desejo do Congresso.

3.1.1 Atribuições do Ministério Público

As atribuições do Ministério Público em matéria de proteção ao meio ambiente datam de longo tempo, já a lei de proteção aos animais outorgava a nobre missão ao MP (Decreto nº 4.645, de 10 de junho de 1934, art. 2º, § 3º). A Lei nº 6.938/81, desde a sua primeira versão, já determina competir ao Ministério Público promover a responsabilização daqueles que fossem responsáveis por danos ao meio ambiente. Posteriormente, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, veio a atribuir funções a serem desempenhadas pelo Ministério Público na proteção de todo e qualquer interesse difuso. Tanto a Lei nº 7.347/85 como diversos outros diplomas legais têm atribuído ao MP funções extrajudiciais. Tais funções implicam que o *parquet* é dotado de legitimidade para celebrar transações e termos de compromisso e ajustamento de conduta com agentes degradadores do meio ambiente, de molde que os mesmos se enquadrem em condutas ambientalmente sadias. As atribuições do Ministério Público se dividirão em conformidade com as competências constitucionais.

[...] Assim, figurando como autor da ação o Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competência para a causa é da Justiça Federal. 3. *Não se confunde competência com legitimidade das partes. A questão competencial é logicamente antecedente e, eventualmente, prejudicial à da legitimidade. Fixada a competência, cumpre ao juiz apreciar a legitimação ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda, consideradas as suas características, as suas finalidades e os bens jurídicos envolvidos.* 4. À luz do sistema e dos princípios constitucionais, nomeadamente o princípio federativo, é atribuição do Ministério Público da União promover as ações civis públicas de interesse federal e ao Ministério Público Estadual as demais. Considera-se que há interesse federal nas ações civis públicas que (a) envolvam matéria de competência da Justiça Especializada da União (Justiça do Trabalho e Eleitoral); (b) devam ser legitimamente promovidas perante os órgãos Judiciários da União (Tribunais Superiores) e da Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais); (c) sejam da competência federal em razão da matéria – as fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional (CF, art. 109, III) e as que envolvam disputa sobre direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) sejam da competência federal em razão da pessoa – as que devam ser propostas contra a União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, ou em que uma dessas entidades figure entre os substituídos processuais no polo ativo (CF, art. 109, I); e (e) as demais causas que envolvam interesses federais em razão da natureza dos bens e dos valores jurídicos que se visa tutelar [...]”.

Observe-se, contudo, que a ação do Ministério Público não pode ser substituída da ação a ser desenvolvida pelo Executivo.

3.2 O SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – SISNAMA

As origens do Sisnama remontam à criação da SEMA pelo Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973 (revogada), logo após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972, realizada em Estocolmo. Outro momento que marca os antecedentes do Sisnama foi o II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, no qual as questões ambientais mereceram atenção.

A SEMA foi criada no âmbito do Ministério do Interior; como órgão autônomo, e diretamente subordinada ao Ministro de Estado. A SEMA deveria ter a sua orientação voltada para a *conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais*, foi extinta pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que resultou da aprovação da Medida Provisória nº 34, de 23 de janeiro de 1989.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu, através de seu artigo 6º, o Sisnama. A PNMA tem os seus objetivos estabelecidos pelo artigo 2º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. A norma legal determina que a PNMA tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar ao País condições de desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Como não é difícil perceber, cuida-se de norma muito abrangente. Em primeiro lugar, ela visa à preservação [*rectius*: conservação] do meio ambiente. Preservação tem o sentido de perenizar, de perpetuar, de salvaguardar os recursos naturais. Além dos objetivos traçados pelo artigo 2º da Lei nº 6.938/81, o seu artigo 4º estabelece uma lista mais ampla de objetivos, a saber:

- a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
- a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
- o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
- o estabelecimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional dos recursos ambientais;
- a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
- a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos.

As boas condições ambientais, nos termos da lei, constituem-se em um importante elemento indutor do desenvolvimento socioeconômico. Servem, também, como meio indispensável para a segurança nacional e proteção da dignidade humana. Estes três últimos elementos somente podem ser compreendidos sob a ótica do *desenvolvimento sustentado*. A PNMA, portanto, deve ser compreendida como o conjunto dos instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e econômicos

destinados à promoção do desenvolvimento sustentável da sociedade e economia brasileiras. A implementação da PNMA se faz a partir de princípios que são estabelecidos pela própria CF e pela legislação ordinária.

O artigo 2º da Lei nº 6.938/81, em seus incisos I a X, estabelece os princípios legais que devem reger a PNMA. Tais princípios, obviamente, estão submetidos aos princípios gerais do Direito Ambiental. A conclusão é óbvia, pois a PNMA é uma importante parcela do Direito Ambiental positivo brasileiro.

Os princípios estabelecidos na lei são os seguintes:

- I) *ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;*
- II) *racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;*
- III) *planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;*
- IV) *proteção dos ecossistemas, com a preservação das áreas representativas;*
- V) *controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;*
- VI) *incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;*
- VII) *acompanhamento do estado da qualidade ambiental;*
- VIII) *recuperação de áreas degradadas;*
- IX) *proteção de áreas ameaçadas de degradação; e*
- X) *educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente.*

Nem todos os tópicos arrolados no artigo 2º são verdadeiros *princípios jurídicos ambientais*. De fato, a maioria dos incisos acima transcritos representa uma orientação prática à ação governamental que decorre dos princípios do Direito Ambiental.

O princípio do meio ambiente como *Direito Humano Fundamental* deve ser considerado como um princípio implícito na PNMA, pois, embora não seja expressamente mencionado na lei, é um princípio constitucional e, portanto, presente nas normas de natureza infraconstitucional.

O princípio democrático encontra-se presente na principiologia estabelecida pela Lei nº 6.938/81 através da norma contida no inciso X do artigo 2º. Essa é uma das normas mais importantes da PNMA. Lamentavelmente, o preceito legal tem sido muito pouco observado, pois a educação ambiental e a capacitação dos cidadãos para a defesa ativa do meio ambiente restam como objetivos a serem alcançados.

O *princípio da capacidade de suporte*, igualmente, está presente na PNMA (incisos II, III e V do artigo 2º).

A Lei nº 6.938/81, em seu artigo 9º, estabeleceu uma série de instrumentos cuja finalidade é a de viabilizar a consecução dos objetivos da PNMA instituídos no artigo 4º. Tais instrumentos são:

- o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
- o zoneamento ambiental;
- a avaliação de impactos ambientais;
- o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
- os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
- criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevantes interesses ecológicos e extrativistas;
- o Sistema Nacional de Informações sobre o meio ambiente;
- o Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental;
- as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;
- a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama;
- a garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
- o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais;
- instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros.

Os instrumentos acima mencionados encontram a sua base constitucional no conjunto de normas jurídicas que se encontram presentes no artigo 225 da CF, especialmente no § 1º e seus incisos. Nesse ponto, é desnecessário examinar cada um individualmente, pois isso será feito ao longo de todo o presente trabalho.

3.2.1 APNMA como LC

Como se sabe, não há hierarquia entre LC e Lei Ordinária, haja vista que elas possuem atribuições normativas diferentes. A LC deriva diretamente da Constituição, tratando matérias que a própria Constituição determinou fossem objeto de LC. Como se pode ver, os artigos 20 e 21 da LC nº 140/2011 revogaram dispositivos constantes dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Lei nº 6.938/81	Lei nº 7.804/89	LCP nº 140/2011
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras	Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –	Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. § 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação,

licenças exigíveis.	Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. § 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação.	ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. § 2º (Revogado) § 3º (Revogado) § 4º (Revogado)
	§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação do Ibama. § 3º O órgão estadual do meio ambiente e o Ibama, este em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido. § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, o licenciamento previsto no <i>caput</i> deste artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.	
Art. 11. Compete ao Ibama propor ao Conama normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio Conama.	Art. 11. Compete ao Ibama propor ao Conama normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio Conama. § 1º A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pelo Ibama, em caráter supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes. § 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos e entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.	Art. 21. Revogam-se os §§ 2º, 3º e 4º do art. 10 e o § 1º do art. 11 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

A sequência legislativa acima nos traz uma interessante questão. A Lei nº 6.938/81 foi inicialmente editada como lei ordinária, com o advento da CF de 1988, o artigo 23 determinou que a colaboração administrativa entre os entes federados fosse regida segundo normas estabelecidas por LC. No entanto, somente em 5 de dezembro de 2011, foi editada a LC nº 140, a qual, expressamente, revogou artigos da PNMA. Assim, parece que determinados artigos da Lei nº 6.938/81 foram recebidos pela nova Constituição como LC. Contudo, a Lei nº 7.804/89 – que não tem caráter de LC – não poderia ter alterado a PNMA, caso o entendimento seja no sentido de sua recepção como LC, por outro lado, se consideramos que a Lei nº 6.938/81 não continha aspectos de LC, as alterações produzidas pela LCP 140 seriam inválidas, haja vista que LC não altera lei ordinária. A propósito, vale trazer a colação a seguinte passagem de decisão proferida pelo STF: “A recepção de lei ordinária como LC pela Constituição posterior a ela só ocorre com relação aos seus dispositivos em vigor quando da promulgação desta, não havendo que se pretender a ocorrência de efeito repristinatório, porque o nosso sistema jurídico, salvo disposição em contrário, não admite a repristinação (art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao CC)” (STF: AI 235.800-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 25.5.1999, Primeira Turma, DJ de 25.6.2000).

3.3 ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

O Sisnama é integrado por um órgão superior; por um órgão consultivo e deliberativo; por um órgão central; um órgão executor; diversos órgãos setoriais; órgãos seccionais e órgãos locais. Cada um desses órgãos possui atribuições próprias. Compete-lhes precipuamente o exercício do poder de polícia em matéria

ambiental.

A fiscalização das atividades degradadoras do meio ambiente por parte dos órgãos integrantes do Sisnama tem se revelado hipertrofiada e pouco eficiente. A Lei da PNMA estruturou o Sisnama em sete níveis político-administrativos, o que por si só já demonstra a inequívoca vocação cartorial e burocrática. O Sisnama, na forma da lei, é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

Os órgãos formadores do Sisnama são:

- Órgão Superior: o Conselho de Governo;
- Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conama;
- Órgão Central: o MMA;
- Órgãos Executores: (i) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais renováveis – Ibama; e o (ii) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes;
- Órgãos Setoriais: órgãos da Administração Federal, direta, indireta ou fundacional voltados para a proteção ambiental ou disciplinamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais;
- Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades estaduais responsáveis por programas ambientais ou pela fiscalização de atividades utilizadoras de recursos ambientais;
- Órgãos Locais: as entidades municipais responsáveis por programas ambientais ou responsáveis pela fiscalização de atividades utilizadoras de recursos ambientais.

3.3.1 Cooperação administrativa

Com vistas ao aprimoramento de um sistema com evidentes dificuldades de articulação, foi editada a LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011, a qual buscou disciplinar a articulação entre os órgãos do Sisnama, mediante a criação de instrumentos de cooperação.

Conforme estabelecido pelo artigo 4º da LC nº 140/2011, os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação institucional: (i) consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor; (ii) convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o artigo 241 da CF; (iii) Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal; (iv) fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; (v) delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos na LC nº 140/2011; (vi) delegação da execução de ações administrativas de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos na LC nº 140/2011.

A LCP 140/2011 estabelece que os convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos de colaboração poderão ser firmados por prazo indeterminado. Há uma grande quantidade de instrumentos de cooperação firmados entre os diferentes entes federativos, tais instrumentos permanecem em vigor, salvo na hipótese em que contenham cláusulas manifestamente contrárias aos termos da LC.

3.3.1.1 Comissões multipartes

A LC estabeleceu um mecanismo colegiado com vistas a dirimir controvérsias entre os entes federados e acelerar as medidas de cooperação: são as comissões multipartes, a seguir examinadas:

- Comissões Tripartites Nacional: formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.
- Comissões Tripartites Estaduais: formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.
- Comissões Bipartites do Distrito Federal: formada, paritariamente, por representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e descentralizada entre esses entes federativos.

3.3.1.2 Delegabilidade de atribuições

A LC, claramente, estabeleceu a delegabilidade das atribuições de cada ente federativo no que concerne ao poder de polícia ambiental. Foram estabelecidos apenas dois requisitos para a delegação: (i) existência de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e (ii) disponha de conselho de meio ambiente.

Conforme o parágrafo único do artigo 5º, órgão capacitado é aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Contudo, merece ser sublinhado que, não sendo a delegação uma obrigação, mas uma mera possibilidade, não há qualquer impedimento legal para que o órgão deselegante estabeleça requisitos adicionais para o ato de delegação. É muito comum que medidas judiciais sejam ajuizadas com vistas à anulação de licenciamentos ambientais, em função de que o licenciamento no caso concreto seria atribuição do órgão federal de meio ambiente: “o pedido formulado na exordial é a declaração de nulidade do licenciamento ambiental do empreendimento Terminal Portuário – Distrito do Açu, concedido pelo INEA, pretendendo que este seja dado pelo Ibama, bem como o ressarcimento pelos danos ao causados pela construção do referido Terminal.” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região; CC 201202010071591; 6ª Turma Especializada; Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama; E-DJF2R – 30/07/2012, p. 263-264). Normalmente, entre os órgãos ambientais há acordo quanto à delegação de competência, muito embora terceiras partes nem sempre concordem com os entendimentos entre os órgãos ambientais, gerando a disputa judicial.

A LC nº 140/2011 repartiu as competências administrativas entre a União, os Estados (Distrito Federal) e os Municípios que ficaram assim definidas:

União	Estado	Municípios
• formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a PNMA; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições; • promover ações relacionadas à PNMA nos âmbitos nacional e internacional; • promover a integração de programas e	• executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a PNMA e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;	• executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente; • exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política Nacional do Meio Ambiente; • promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionadas à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; • promover a articulação da PNMA com as de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras; • organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); • elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional; • definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; • promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; • controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; • exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União; • promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: (i) localizados	• formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Estadual de Meio Ambiente; • promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente; • promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; • organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente; • prestar informações à União para a formação e atualização do Sinima; • elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional; • definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; • promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; • controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; • exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados; • promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º da LC nº 140/2011; • promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos	• formular, executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Municipal de Meio Ambiente; • promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental; • articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente; • promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; • organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente; • prestar informações aos Estados e à União para a formação em atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente; • elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais; • definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; • promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente; • controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente, na forma da lei; • exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município; • observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: (i) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou (ii) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); • observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, aprovar: (a) a
---	---	---

ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; (ii) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; (iii) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; (iv) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (v) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; (v) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97, de 9 de junho de 1999; (vii) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); ou (viii) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento; - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e (ii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies <i>in situ</i>; - controlar a introdução no país de espécies exóticas potencialmente invasoras que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas; - aprovar a liberação de exemplares de espécies exótica da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos; - controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos deles derivados; - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas; - proteger a fauna migratória e as espécies inseridas na relação prevista no inciso XVI do	localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); - aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: (i) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em áreas de Proteção Ambiental (APAs); (ii) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e (iii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado; - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies <i>in situ</i>; - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX do art. 7º; - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre; - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e - exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7º.	supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e (b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
---	--	--

artigo 7º da LC nº 140/2011;		
• exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional; • gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais; • exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos; e • exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, de produtos perigosos.		

3.3.2 Conselho de Governo

O Conselho de Governo é órgão integrante da Presidência da República e é encarregado do assessoramento imediato ao Presidente da República, conforme determinação que se continha na Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. A reorganização da estrutura administrativa da Presidência da República ocorrida em razão das disposições contidas na Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, manteve o Conselho de Governo como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República. O Conselho de Governo é constituído por todos os Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado Geral da União, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental.

3.3.3 O Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama

O Conama foi criado pelo artigo 6º, inciso II, da Lei nº 6.938/81 com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O Conama, portanto, é uma entidade dotada de poder regulamentar em razão de expressa determinação legal.

A competência legal do Conama está estabelecida no artigo 8º da Lei nº 6.938/81. Nos termos da lei, compete ao Conama:

- estabelecer, mediante proposta do Ibama, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo Ibama;
- determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
- homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental;
- determinar, mediante representação do Ibama, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
- estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;
- estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.

Outras atribuições legais do Conama:

- Órgão Consultivo e deliberativo do SNUC;
- Definir atividades de interesse social e utilidade pública para fins de supressão de vegetação.

O Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, com nova redação dada pelo Decreto nº 3.942, de 27 de setembro de 2001, em seu artigo 7º, regulamentou tal competência assim:

- I – estabelecer, mediante proposta do Ibama, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto;*
- II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;*
- III – decidir, após o parecer do Comitê de Integração de Políticas Ambientais, em última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo Ibama;*
- IV – determinar, mediante representação do Ibama, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;*
- V – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes;*
- VI – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos;*
- VII – assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais;*
- VIII – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;*
- IX – estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação;*

- X – acompanhar a implementação do SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000;*
- XI – propor sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais;*
- XII – incentivar a instituição e o fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;*
- XIII – avaliar a implementação e a execução da política ambiental do País;*
- XIV – recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, previsto no art. 9º, inciso X, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;*
- XV – estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;*
- XVI – promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;*
- XVII – elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional de Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do Sisnama, sob a forma de recomendação;*
- XVIII – deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando ao cumprimento dos objetivos da PNMA; e*
- XIX – elaborar o seu regimento interno”.*

Determina o § 1º do artigo 7º que: “*As normas e os critérios para o licenciamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras deverão estabelecer os requisitos necessários à proteção ambiental*”. Disposição, em minha opinião, totalmente redundante, pois o objetivo do licenciamento é o de “estabelecer os requisitos necessários para a proteção ambiental”.

As penalidades previstas no inciso IV do artigo 7º somente serão aplicadas nos casos previamente definidos em ato específico do Conama, assegurando-se ao interessado a ampla defesa.

Uma importante inovação é a constante do § 3º do artigo 7º, que estabelece que: “na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, o Conama levará em consideração a capacidade de autorregeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros genéricos mensuráveis”. Isso implica que o elemento mais importante a ser considerado seja a capacidade de suporte ambiental e não o parâmetro em si próprio. Prevalece, em minha opinião, a capacidade de suporte sobre o parâmetro, abrindo-se espaço para o controle ambiental pela qualidade e não meramente por limites estabelecidos sem qualquer base científica.

3.3.3.1 Os órgãos do Conama

O Conama é composto pelos seguintes órgãos:

- Plenário;
 - Câmara Especial Recursal;
 - Comitê de Integração de Políticas Ambientais;
 - Câmaras Técnicas;
 - Grupos de Trabalho; e
 - Grupos Assessores.
- *Plenário:* O Plenário do Conama reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada três meses, no Distrito Federal, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos dois terços de seus membros. As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora do Distrito Federal, sempre que *razões superiores*, de conveniência técnica ou política, assim o exigirem. O Plenário do Conama reunir-se-á em sessão pública, com a presença de pelo menos a metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples dos membros presentes no Plenário, cabendo ao Presidente da sessão, além do voto pessoal, o de qualidade. O Presidente do Conama será substituído, nos seus impedimentos, pelo Secretário-Executivo do Conama e, na falta deste, pelo Conselheiro representante do MMA. A atividade dos membros do Conama é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das despesas de deslocamento e estadia.
- *Câmara Especial Recursal:* A Câmara Especial Recursal é a instância administrativa do Conama responsável pelo julgamento, em caráter final, das multas e outras penalidades administrativas impostas pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes.

As decisões da Câmara têm caráter terminativo.

- A Câmara Especial Recursal tem a seguinte composição: (a) MMA, que a preside; (b) Ministério da Justiça; (c) Instituto Chico Mendes; (d) Ibama; (e) entidade ambientalista; (f) entidades empresariais; e (g) entidades de trabalhadores.
- É de se lamentar que a Câmara Especial Recursal, cuja função é extremamente importante, do ponto de vista do controle da legalidade, não tenha em sua composição um integrante da Advocacia Geral da União – AGU.

3.3.3.2 Competência Recursal do Conama

O Conama, por força da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, não detém mais competência recursal, uma vez que o inciso XIII do artigo 79 da mencionada Lei revogou expressamente o “inciso III do *caput* do art. 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981”. Por se tratar de matéria processual, a norma tem vigência imediata. Discute-se, contudo, a legalidade da norma, haja vista que a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, tem por escopo regular a legislação tributária e, seguramente, as multas ambientais não se enquadram no conceito de tributo, que são as taxas, as contribuições e os impostos. Lembre-se que permanece vigente a LC nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que nos incisos I e II do artigo 7º que determina: que o primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: I – excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; II – a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.

3.3.3.3 O Conama e a delegação de competências

A separação de poderes entre o Executivo e o Legislativo, bem como o consequente controle judicial de legalidade, acrescidos da grande complexidade da vida atual, sobretudo em matérias para as quais seja requerido um elevado grau de informação técnico-científica, tem acarretado um deslocamento, cada vez maior, para o Poder Executivo de atribuições regulatórias específicas. Esse fenômeno se consubstancia na criação das chamadas “agências regulatórias”, tais como a ANEEL e tantas outras. O Conama não ostenta explicitamente a condição de agência regulatória, muito embora a sua função normativa seja evidente. A Lei 6.938/81, como visto, expressamente delegou algumas atribuições ao Conselho, assim como o fez a Lei do SNUC e o Código Florestal. Assim, inicialmente está colocada a questão de saber quais os limites da delegação feita pelo Legislativo para o Executivo e, em um segundo momento, se o órgão de execução das decisões do Conama, no caso os integrantes do Sisnama, está agindo dentro dos limites fixados pelo Conselho. Tem sido entendido pelos Tribunais Superiores que as competências das agências reguladoras prevalecem em relação a normas editadas por entes federados, mesmo sob a forma de lei quando invadem competência federal delegada às agências,

sobretudo quando se tratar de matéria técnica. Está claro, contudo, que as agências reguladoras, no exercício de suas regulares atribuições legais, não estão autorizadas à ultrapassagem dos limites fixados pela lei, como tem sido decidido pelos Tribunais Superiores ((i) STJ – AgRg na MC 11870/RS; Relator: Ministro Luiz Fux. 1ª Turma. *DJU* 16/11/2006, p. 216. (ii) STJ – REsp 676.172/RJ. Relator: Ministro José Delgado. 1ª Turma. *DJU* 27/6/2005, p. 253).

É importante que se observe, também, que as agências reguladoras atuam sobre serviços públicos concedidos ou autorizados, o que não ocorre com o CONAMA e, que não dispõe sobre concessão ou autorização de serviços públicos, muito embora possa dispor sobre aspectos ambientais da prestação de alguns serviços. Portanto, cada ato emanado do Conama deverá ser examinado em duas etapas distintas: (i) saber se houve delegação legislativa para o ato especificamente considerado e (ii) examinar se a delegação foi exercida dentro de limites razoáveis.

3.3.3.4 Composição do Conama, separação de poderes e autonomia do Ministério Público

O Conama, curiosamente, não tem a sua composição definida em lei, visto que, na primeira versão da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 7º, havia a previsão da composição do Conselho, com a indicação de seus membros. Infelizmente, as Leis nºs 7.804 e 8.028 expungiram do universo jurídico a composição legal do Conama. Agora, a composição do Conselho é fixada por um mero decreto, baixado segundo a competência constitucional do Presidente da República. Há, contudo, figuras esdrúxulas, que são os 3 (três) “conselheiros convidados”, visto que, no caso específico do Ministério Público e do Legislativo, tais figuras violam inteiramente a separação dos Poderes prevista no artigo 2 da Constituição e a autonomia funcional do Ministério Público.

O Ministério Público é dotado de atribuições essenciais para as funções jurisdicionais do Estado, exercendo-as em todos os juízos brasileiros perante os quais desempenha as suas funções institucionais, dentre as quais se destacam aquelas indispensáveis ao controle da legalidade dos atos praticados pelos próprios juízes, além de promover a defesa judicial de diversos interesses e direitos socialmente relevantes. Veja-se a determinação contida no artigo 127 da CF: “*O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis*”. A CF foi mais além ao estabelecer um rol das chamadas funções institucionais do Ministério Público que se constituem em conjunto de *atividades típicas* do MP e que desenharam o perfil da instituição. É o artigo 129 da CF, que explicita a referida relação, dela constando: (i) promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; (ii) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; (iii) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (iv) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; (v) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; (vi) expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da LC respectiva; (vii) exercer o controle externo da atividade policial, na forma da LC mencionada no artigo anterior; (viii) requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; (ix) *exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedadas a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas*.

Conforme se pode perceber do § 5º do artigo 128 da CF, leis complementares da União e dos Estados estabelecerão “a organização, as atribuições” de cada um dos Ministérios Públicos. “*A questão pertinente ao Ministério Público Especial junto ao tribunal de Contas Estadual: uma realidade institucional que não pode ser desconhecida. Consequente impossibilidade constitucional de o Ministério Público Especial ser substituído, nessa condição, pelo Ministério Público comum do Estado-Membro. Ação Direta julgada parcialmente procedente*” (ADI 2.068, Relator Ministro Celso de Mello, *DJU* 16/5/2003).

Pelo que se percebe do texto constitucional, as funções institucionais do Ministério Público não se constituem em *numerus clausus*, ao contrário, poderão ser ampliadas, desde que compatíveis com a finalidade da própria instituição. Entretanto, a CF, *a priori*, definiu algumas atividades que *não poderão* ser conferidas ao Ministério Público, a saber: (a) representação jurídica e (b) consultoria jurídica de entidades públicas.

Essas são vedações institucionais, entretanto, a CF define *uma vedação específica para os membros do Ministério Público*. Vejamos o teor: “Art. 128. O Ministério Público abrange: [...] § 4º – [...] II – as seguintes vedações: [...] d) *exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério*”. Função, como se sabe, é qualquer encargo atribuído pelo Poder Público a um cidadão, seja remunerado ou não. Trata-se de um conceito mais amplo do que o de cargo (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 3º). É indiscutível que o exercício de mandato de conselheiro do Conama se constitui em função pública relevante, conforme é admitido em sede normativa (Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, art. 6º, § 4º). Resulta daí inteiramente contrário ao sistema constitucional que rege as elevadas funções do Ministério Público a presença do *Parquet* no Conama, seja em que condição for.

Em sede doutrinária, os autores que versaram especificamente sobre o papel constitucional do Ministério Público, com destaque para Mazzilli (1998, p. 53) sustentam tese idêntica.

A vedação só tem duas exceções, uma de caráter permanente (uma função de magistério) e outra transitória, aliás, já vencida (para os optantes a que se refere o art. 29, § 3º, do ADCT). Tem havido controvérsia sobre a participação de membros do Ministério Público em comissões ou organismos estatais. Não raro por imposição de leis municipais, estaduais e federais, há previsão da participação de membros do Ministério Público em conselhos de defesa de direitos humanos, comissões de trânsito, conselhos de entorpecentes, enfim, em órgãos administrativos diversos. As próprias leis orgânicas do Ministério Público são as primeiras a, erroneamente, prever sua participação em organismos administrativos. Inexiste vedação para o exercício de algumas funções administrativas da própria instituição (para os assessores do procurador-geral, o corregedor-geral, os conselheiros), mas há vedação à participação do membro do Ministério Público em conselhos ou organismos estatais, porque isso importa o exercício de outra função pública.

A participação em Conselhos, *data venia*, não se confunde com “função institucional”, visto que a capacidade de decisão do Ministério Público e a sua independência funcional restam prejudicadas ao participar do colegiado, pois é uma prática elementar em qualquer regime democrático que os conselheiros se submetam às decisões dos colegiados que integram. Ora, não se pode admitir que o MP, por integrar o conselho, se exonere de suas funções de fiscalização da legalidade, o que gera uma incompatibilidade entre ambas as funções, ou seja, a de “fiscal da ordem jurídica” e a de conselheiro. Não se pretende dizer que os conselhos ajam ilegalmente, o que se afirma é que a independência de um e de outro fica tolhida. A esse respeito, veja-se a Resolução nº 5 de 20 de março de 2006 do CNMP.

É importante observar que qualquer nova função institucional do Ministério Público, ou mesmo instrumento de atuação, conforme definido pela Lei Orgânica do Ministério Público, somente poderá ser atribuída *por lei*. Lei, no caso, há que ser tomada em seu sentido formal, pois aqui se trata de definições extremamente relevantes para a ordem jurídica democrática. Caso se pudesse cogitar do deferimento de atribuições ao Ministério Público pela via do Decreto Presidencial, de fato, as cláusulas de independência e autonomia funcionais restariam como letra morta. Acresce, ainda, o fato de que, para se evitar uma contradição lógica, a nova função não poderá implicar, seja a que título for, que o membro do *parquet* passe a exercer uma função pública distinta ou adicional àquela que já exerce normalmente.

A LC n 75/93 reservou a exclusiva competência para definir as condições de atuação dos integrantes do MP da União em órgãos externos. Ou seja, a Lei define os órgãos de atuação externos à instituição do Ministério Público, e o Procurador-Geral estabelece, observadas as diretrizes legais, os critérios da atuação. *Aqui, não se pode deixar de reconhecer uma tendência da instituição em se espalhar pelo interior da Administração e do próprio governo, de forma inteiramente contrária ao espírito que rege o perfil constitucional do MP que, para o bem e para o mal, está intimamente vinculado ao modelo organizativo da magistratura.*

É evidente que mesmo a interpretação conforme a Constituição não dá margem para que se admita que, por decreto, se disponha sobre atribuições do Ministério Público, tendo em vista a mais completa incompatibilidade com o sistema constitucional. Assim, para se salvar os termos da LC e de toda uma legislação que lhe é subjacente, há que se fulminar o decreto. Conforme a lição do Ministro do STF Roberto Barroso (2004, p. 189):

Na interpretação conforme a Constituição, órgão jurisdicional declara qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a CF. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que determinado preceito infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer delas

No que concerne ao Ministério Público dos Estados, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não é dotada de disposições semelhantes àquelas constantes da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Há, entretanto, em seu artigo 25, a atribuição para que o Ministério Público delibere sobre a sua participação em conselhos estatais diversos, inclusive nos voltados para a defesa do meio ambiente. A Lei merece ser examinada com critério, pois, para que o Ministério Público “delibere” sobre sua participação, são necessários alguns requisitos básicos: (i) que o Conselho exista; (ii) que haja uma vaga destinada ao Ministério Público. Não existe a possibilidade de que o MP “crie” uma vaga para si em qualquer Conselho. Além do mais, por uma questão de respeito ao regime federativo e à própria estrutura organizacional do Ministério Público, o MP dos estados só é dotado de atribuições no plano estadual, a menos que uma lei nacional defina de forma diversa.

Quando deparamos com um setor que lida diretamente com a liberdade humana, como o da execução das penas privativas da liberdade, por exemplo, veremos que as funções que o Ministério Público deve desempenhar estão expressamente previstas na Lei, como, aliás, é a determinação constitucional, como já foi visto. De fato, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, estabelece em seus artigos 67 e seguintes todo um rol de atribuições para o Ministério Público. Diferente não é quando se trata de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Também no chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, a participação do Ministério Público nos diferentes conselhos encontra expressa previsão legal.

No caso da proteção das crianças e adolescentes, a amplíssima participação do Ministério Público está perfeitamente prevista em lei e, o que é bom, de forma bastante minuciosa. Em campo diametralmente oposto do espectro legislativo, podemos ver que na hipótese de defesa da concorrência e do livre mercado a intervenção do Ministério Público junto ao CADE, como não poderia deixar de ser, está prevista em lei, reservando-se ao *parquet* uma atuação muito importante naquele Conselho Administrativo; contudo, houve revogação da lei do CADE pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que não mais destina assento ao Ministério Público junto ao CADE.

O Conama foi criado pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a PNMA. Ele, em princípio, é um órgão consultivo e deliberativo do Sisnama. Muito embora o Conama não possa ser enquadrado como consultoria jurídica, é evidente o seu papel normativo para determinadas matérias técnicas e, portanto, de produção de documentos legais que, como todos sabemos, em termos de Direito Ambiental, são extremamente importantes e relevantes, basta que se vejam as atribuições legais do Conselho, conforme definidas pelo artigo 8º da PNMA. A maioria das atribuições, em princípio, parecem-me *incompatíveis* com as funções do Ministério Público. É incompatível com a função do MP, por exemplo, decidir sobre penalidades administrativas impostas pelos órgãos do Sisnama, visto que cabe ao próprio *parquet* velar pela legalidade da Administração, o que o deixa em uma posição, no mínimo, incômoda. As demais funções, *ça va sans dire*, nada têm a ver com as funções institucionais do Ministério Público. Tendo em vista a semelhança de regime constitucional, convém anotar que o CNJ concreto, proibiu os magistrados de exercerem funções na chamada Justiça Desportiva (Resolução CNJ nº 10, de 19 de dezembro de 2005).

3.3.3.5 Ministério do Meio Ambiente – MMA

3.3.3.5.1 Antecedentes

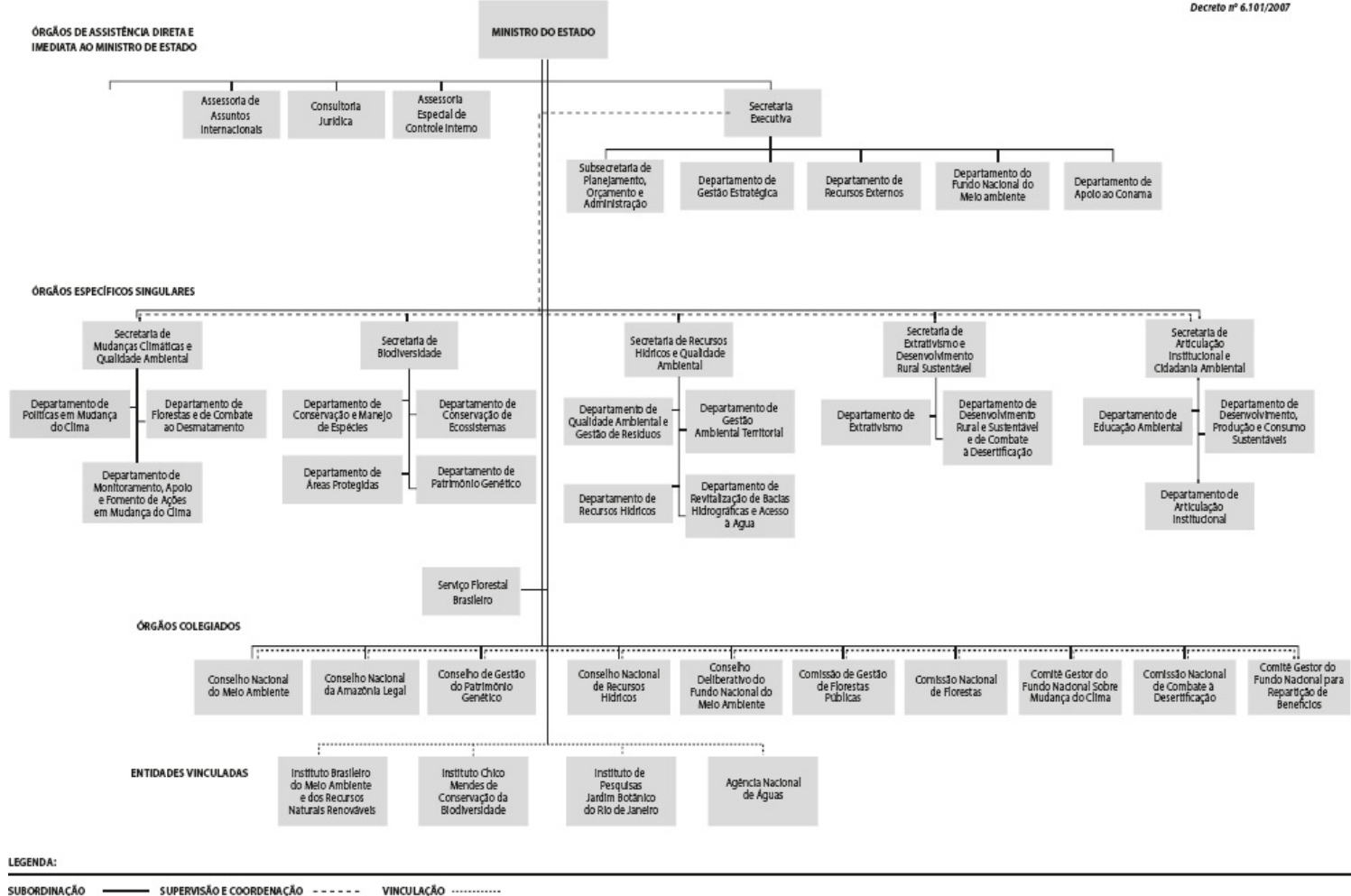
A primeira estrutura administrativa criada no Brasil Republicano para a proteção do que posteriormente seria o “meio ambiente” foi o Serviço Florestal do Brasil criado pelo Decreto nº 4.421, de 28 de dezembro de 1921, que era “uma seção especial”, cujos objetivos eram “conservação, beneficiamento, reconstituição, formação e aproveitamento das florestas”. Dentre as atribuições do Serviço Florestal estavam as seguintes: (i) promover e auxiliar a conservação, criação e guarda das florestas protetoras; (ii) estabelecer e propagar os conhecimentos relativos à silvicultura, mediante investigações e demonstrações; (iii) práticas em hortos florestais, convenientemente situados, executar, a título de experiência e demonstração, em florestas-modelo, convenientemente escolhidas; (iv) estudar e vulgarizar os processos de conservação, por meios químicos, das madeiras, quer quando aplicadas aos vários fins a que se destinam, quer quando depositadas e em transporte; (v) organizar a estatística florestal, e para esse fim: (vi) determinar, depois de completos os reconhecimentos, as regiões em que devam ser estabelecidas as reservas florestais; (vii) estudar e propor ao Governo as melhores situações para o estabelecimento de parques nacionais, isto é, de florestas típicas das diversas regiões do país, que conservem, quanto possível, todos os característicos da fauna e flora indígena; (viii) pôr em prática e fazer cumprir todas as medidas de proteção e de polícia florestal que forem decretadas de acordo com a lei; (ix) divulgar em publicações, ou por quaisquer outros meios de instrução, ideias e trabalhos de utilidade referentes às florestas, considerando-as principalmente sob o ponto de vista econômico.

Das autarquias que contribuíram diretamente para a construção do MMA, a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – Sudepe foi criada pela Lei Delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962, no âmbito do Ministério da Agricultura. Já a Superintendência da Borracha – Sudhevea, entidade com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, técnica e financeira, sob a jurisdição do Ministério da Indústria e do Comércio, foi criada pela Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967. Também de 1967 é a criação do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal – IBDF, conforme o Decreto-lei nº 289, de 28 de fevereiro.

O MMA resultou da transformação da Secretaria do Meio Ambiente em Ministério por força do artigo 21 da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992. Por sua vez, o MMA foi transformado pela Lei nº 8.746, de 9 de dezembro de 1993, em MMA e da Amazônia Legal. Houve uma ligeira alteração nas atribuições e na estrutura básica do Ministério transformado para aquelas que passaram a ser atribuídas ao novo Ministério.

As atribuições do atual MMA são de:

- planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao meio ambiente;
- formulação e execução da PNMA;
- articulação e coordenação das ações de política integrada para a Amazônia Legal, visando à melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas;
- articulação com os ministérios, órgãos e entidades da Administração Federal, de ações de âmbito internacional e de âmbito interno, relacionadas com a política nacional integrada para a Amazônia Legal;
- preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis;
- implementação de acordos internacionais nas áreas de sua competência.



Organograma do MMA conforme Decreto nº 9.085/2017.

Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/institucional/organograma>>. Acesso em: 24 nov. 2018.

3.3.4 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama

O Ibama foi criado pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, resultante da aprovação da Medida Provisória nº 34, de 1989, a partir da extinção dos antigos órgãos encarregados dos problemas ambientais brasileiros. Para a criação do Ibama, foram extintas a SEMA, criada pelo Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973, e a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – Sudepe, autarquia federal vinculada ao Ministério da Agricultura, criada pela Lei Delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962. O Ibama foi criado sob a forma de autarquia federal de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao MMA, com a finalidade de assessorá-la na formação e coordenação, bem como executar e fazer executar a PNMA e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais.

A criação do Ibama teve o mérito de congregar, em um único organismo, diversas entidades que não conseguiram jamais atuar em conjunto. Antes da existência do Ibama, havia pelo menos quatro órgãos voltados para as questões ambientais. Deve ser ressaltado, entretanto, que nenhum deles possuía força política ou econômica para desempenhar adequadamente as suas tarefas. O Ibama, sem dúvida, foi um grande progresso em relação à situação anterior. É lógico, contudo, que remanescem problemas muito graves. O mais importante deles é, sem dúvida, a falta de uma definição clara quanto às tarefas a serem desenvolvidas pelo Instituto, pois existe uma evidente superfetação de atribuições. É de se considerar, ademais, que as competências de planejamento, gestão, fiscalização e execução são muito diferenciadas entre si e, não poucas vezes, geram conflitos muito graves no interior de um mesmo órgão. Embora vitoriosa, faz-se necessária uma revisão da iniciativa que levou à criação do Ibama. A experiência que foi acumulada nos mostra que órgãos de controle ambiental não devem se confundir com órgãos encarregados da gestão de unidades de conservação, ou mesmo de pesquisa científica.

Os órgãos setoriais integrantes do Sisnama são os órgãos ou entidades federais, da administração direta ou indireta, cujas atividades sejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou à disciplina da utilização dos recursos naturais. Muitos são os órgãos que podem ser catalogados na condição de órgãos setoriais do Sisnama. É de se observar que o verdadeiro labirinto legal e regulamentar em que se constitui a legislação brasileira de proteção ao meio ambiente levou a que o Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, que regulamentou a Lei nº 6.938/81, utilizasse uma denominação diversa daquela contida na lei. Com efeito, o artigo 3º, V, do decreto denomina como *órgãos seccionais* os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta ou indireta, bem como os órgãos e entidades da Administração Pública dos Estados-Membros da Federação. Houve, evidentemente, uma clara impropriedade no decreto, pois os órgãos setoriais foram suprimidos do Sisnama e confundidos com os órgãos seccionais.

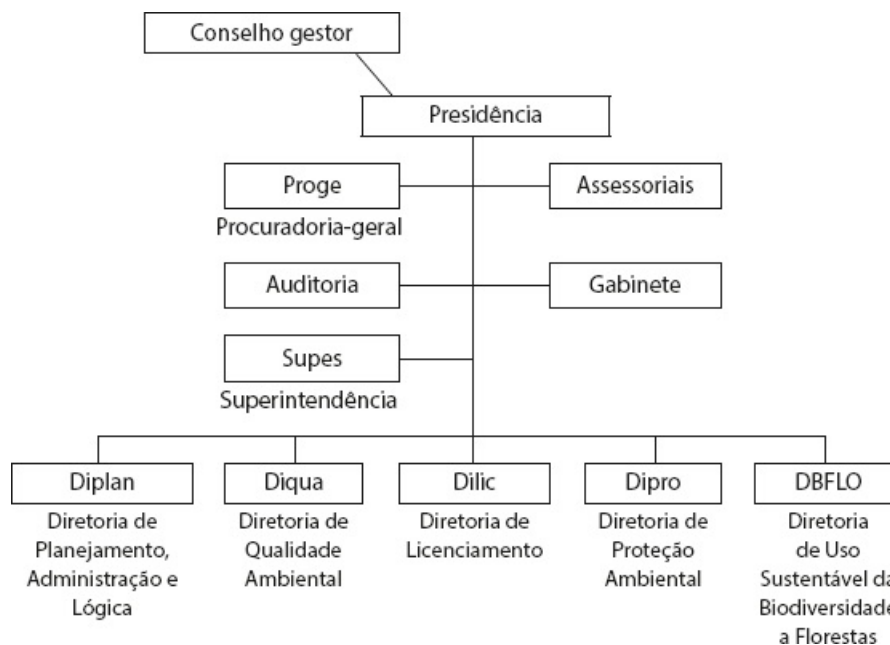
O artigo 12 do revogado Decreto nº 99.200 determina que a coordenação dos órgãos seccionais federais, quanto à PNMA, compete ao MMA.

Órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos, e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. Tais órgãos são de extraordinária importância para o Sisnama, pois a eles compete a maior parte da atividade de controle ambiental. Cada Estado deverá organizar a sua agência de controle ambiental de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu interesse peculiar. A grande dificuldade dos órgãos seccionais é que, quase sempre, os mesmos são destituídos de recursos necessários para o seu adequado funcionamento.

Os órgãos locais são os órgãos municipais de controle ambiental. Tais órgãos somente existem nos Municípios mais ricos, naqueles que são dotados de mais recursos financeiros. Na grande maioria das vezes, o controle ambiental em âmbito local é inexistente ou realizado pelo órgão estadual ou federal.

3.3.4.1 Atribuições do Ibama

A nova redação do artigo 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, deu as seguintes atribuições ao Ibama: (i) exercer o poder de polícia ambiental; (ii) executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do MMA; e (iii) executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente.



3.3.5 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes

A Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, fruto da conversão da Medida Provisória nº 356, de 2007, criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, que é organizado sob a forma de autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira, vinculada ao MMA, com as seguintes finalidades: (i) *executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União*; (ii) *executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União*; (iii) *fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental*; (iv) *exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União*; e (v) *promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam permitidas*.

Foi mantido o poder de polícia ambiental do Ibama, em caráter supletivo.

§ 2º PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

3.4 O PODER DE POLÍCIA

A utilização dos recursos ambientais é atividade submetida ao poder de polícia do Estado. É o exercício do poder de polícia que servirá de parâmetro para os limites de utilização legítimos, segundo a ordem jurídica vigente. O poder de polícia é um poderoso instrumento de harmonização de direitos individuais, fazendo com que eles sejam exercidos com respeito ao direito de terceiros. Contudo, a sua legitimidade depende da estrita observância das normas legais e regulamentares, sendo necessário que o agente da autoridade atue dentro dos contornos estabelecidos pela regra de direito. O Estado tem por objetivo assegurar a igualdade jurídica entre os diversos membros da sociedade. Dessa forma, ao Estado cumpre organizar a vida em sociedade e prestar determinados serviços básicos de saúde, educação, segurança e justiça. Ele deve assegurar aos indivíduos a liberdade para a realização de seus projetos pessoais e privados, desde que não produzam danos à esfera privada de terceiros.

O poder de polícia tem suas origens na própria formação do Estado moderno tal como concebido na Europa Ocidental. A necessidade concreta de ordenar e regulamentar os diversos aspectos da vida social impôs à Administração o exercício de práticas que passaram a ser conhecidas como *atividades de polícia, exercidas sob um poder político centralizado*. Não há uma origem precisa para o vocábulo “polícia” (SCHIERA, 1984, p. 313). Marcello Caetano (1986, p. 1145) observa que a palavra *polícia* hoje tem significado diferente daquele que ostentava até o século XIX. Conforme lembrado pelo jurista português, a Revolução Francesa substituiu o “Estado de Polícia”, sinônimo de arbítrio, pelo “État de Droit”, fundado na lei e em princípios jurídicos claros e definidos previamente. O poder de polícia é a faculdade que o Estado possui de intervir na vida social, com a finalidade de coibir comportamentos nocivos para a vida em comunidade. O moderno poder de polícia é uma decorrência do próprio Estado de Direito e está, *ipso iure*, submetido ao princípio fundamental da legalidade, sem o qual não alcança legitimidade constitucional. Não se pode estabelecer uma exigência de polícia sem que haja uma base constitucional e legal para a sua imposição. Esse é um elemento de grande tensão no Direito Ambiental, pois a Administração Pública Ambiental, muitas vezes, confunde a existência de princípios jurídicos – por exemplo, o princípio da precaução – com proibições sem uma base normativa clara. Princípios jurídicos, como já foi visto neste livro, servem fundamentalmente para estabelecer critérios para a formulação de normas ou ante a inexistência destas últimas para o preenchimento das chamadas lacunas jurídicas. O administrador está prioritariamente submetido à legalidade.

O poder de polícia, como atuação estatal demarcadora do conteúdo de direitos privados, é exercido no sentido de evitar a prática de danos a terceiros. Indiscutivelmente, o poder de polícia é um balizamento de direito imposto pelo Estado aos cidadãos e que se dirige fundamentalmente à liberdade individual e à propriedade privada, fixando os marcos nos quais esses direitos são concretamente exercidos. Hely Lopes Meirelles (1987, p. 78) sustentava que o conceito de poder de polícia se vinha alargando dia a dia, de forma a abranger maior gama de atividades particulares que, de uma forma ou de outra, mediata ou imediatamente, interferiam nos diversos interesses dos grupos que constituem o tecido social. As restrições e limitações impostas pelo Poder Público ao cidadão – aqui deve ser observado que as limitações atingem, indistintamente, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas – decorrem da lei e são, portanto, *vinculadas, isto é, são tomadas com base em preceito formal de lei*.

Não pode ser esquecido, a propósito, o fato de que o Estado, em qualquer uma de suas manifestações de soberania, tem a indeclinável obrigação de fundamentar todos os seus atos em preceito contido em uma lei formal (CF, arts. 93, IX, e 129, VIII). A *vinculação* da Administração ao Direito escrito e positivado é uma garantia do cidadão e da sociedade, servindo de barreira para que o administrador não ultrapasse os limites do mandato que lhe foi outorgado pela comunidade, ou seja, exercer a atividade administrativa nos estreitos limites da norma legal.

3.4.1 Conceito normativo de poder de polícia

É no CTN que está o conceito normativo de poder de polícia (artigo 78). Ele é uma atividade indelegável exercida pelo Estado, (STF – ADI 1.717/DF – Relator: Min. Sydney Sanches. *DJU* 28/03/2003. É atuação estatal, preventiva ou repressiva, visando a coibir *danos sociais*. É importante observar a particularidade específica da ação policial do Estado, pois, agindo em relação aos danos sociais, tudo aquilo que for do interesse privado é imune à atividade de polícia, bem entendido que não pode a atividade privada prejudicar a ordem pública em quaisquer de seus aspectos. Por ser atividade *vinculada*, o Estado não pode, no uso de seu poder de polícia, imiscuir-se na intimidade privada dos cidadãos nem no seu domicílio (STF – RE-AgR 331.303/PR. Min. Sepúlveda Pertence, *DJU* 12/03/2004, p. 42).

A atividade de *polícia* se subdivide em dois grandes grupos: (i) Polícia Administrativa e (ii) Polícia Judiciária. A polícia administrativa é constituída por uma gama de intervenções do Poder Público para disciplinar a ação dos particulares, objetivando prevenir atentados à ordem pública.

O ato de polícia é autoexecutório, resguardados os direitos constitucionais de inviolabilidade do domicílio; por exemplo, isso significa a desnecessidade de que o Poder Executivo recorra ao Poder Judiciário a fim de obter autorização para agir em casos concretos, desde que a infração seja atual. O Estado age por meios coativos que são postos à sua disposição pela lei; contudo, o limite da coação legítima é balizado pela própria lei. A execução dos atos de polícia é atribuição da autoridade de polícia, que é sempre uma autoridade pública.

A autoridade administrativa tem o poder-dever de promover a regulamentação a ser posta em prática pelo pessoal de polícia, isto é, pelos agentes responsáveis pelo cumprimento e observância da ordem emanada da autoridade competente, nos exatos termos em que esta tenha sido proferida, atentando-se para o fato de que o pessoal de polícia não está obrigado a dar cumprimento à determinação manifestamente ilegal. Devem, contudo, ser observados alguns pontos fundamentais. Embora autoexecutório, o ato de polícia não pode ser exercido sem observância da legalidade e da proporcionalidade entre a infração eventualmente cometida e a sanção administrativa aplicada ao caso concreto. A *proporcionalidade* é requisito essencial para a validade do ato de polícia (STF – ADI-MC 1976/DF. Min. Moreira Alves. Tribunal Pleno. *DJU*: 24.11.2000, p. 189). Assim, não pode a autoridade pública interditar toda uma fábrica se apenas um de seus fornos polui a atmosfera e a sua interdição é suficiente para fazer cessar a agressão ambiental (GASPARINI, 1988, p. 103). O importante é que se estabeleça uma real equivalência entre dano e pena. A aplicação proporcional de uma sanção é, provavelmente, o elemento mais difícil dentre todos aqueles que se fazem necessários para a adequada manutenção da ordem pública ambiental (TRF – 4ª REGIÃO. AC 16413/RS. 4ª Turma. *DJU*: 21/03/2001. Juíza Sílvia Goraieb).

Claro está que o ato de polícia, em termos de proteção ao meio ambiente, não foge ao regramento geral dos atos administrativos, uma vez que ele é, apenas, uma espécie em um universo mais amplo. Por isso, é indispensável que o ato de polícia seja praticado pela autoridade competente, ou seja, aquela dotada de atribuição legal; que seja revestido de forma adequada, ainda, de proporcionalidade, da sanção e da legalidade dos meios. Evidentemente que a ordem de polícia, a regulamentação de polícia, deve ser emanada da autoridade competente e baseada em norma legal. A Constituição de 1988 estabelece, ainda, como pressuposto para a validade dos atos administrativos a impessoalidade, a moralidade e a eficiência, requisitos necessários para a validade dos atos de polícia.

3.4.2 Ordem pública do meio ambiente

Uma das principais atribuições do Direito Ambiental é fixar parâmetros normativos capazes de assegurar que a utilização dos recursos ambientais não viole um mínimo necessário para a sustentabilidade dos recursos e para que não se criem danos para a saúde, os bens e demais direitos de terceiros. A *ordem pública* do meio ambiente é o respeito pelos cidadãos e pelas instituições públicas e privadas aos parâmetros estabelecidos pela norma ambiental. Se os níveis ambientais legalmente estabelecidos estiverem sendo observados, a ordem pública ambiental estará, em princípio, sendo cumprida. Contudo, não há uma garantia absoluta que o respeito aos padrões ambientais não implique em danos a terceiros, ou mesmo ao meio ambiente. Assim, o respeito da ordem pública ambiental necessita de, no mínimo, dois requisitos: (i) adequação da atividade aos parâmetros normativamente fixados e (ii) inexistência de danos a terceiros ou ao ambiente.

A polícia do meio ambiente, no intuito de assegurar a obediência às normas ambientais, pode ser preventiva ou repressiva. A atuação preventiva ou repressiva faz-se mediante a utilização de medidas de polícia ambiental. O conceito de polícia do meio ambiente é, essencialmente, um conceito jurídico-administrativo que se referencia à atuação dos órgãos ambientais e à função de fiscalização e controle por eles exercidos. No particular, não se pode deixar de registrar que a Lei nº 9.605/98, ao estabelecer um grande elenco de crimes ambientais, os quais com muita frequência se confundem com os ilícitos administrativos, tem gerado uma atuação inteiramente anômala, que é a polícia judiciária tentando se substituir aos órgãos de controle ambiental, promovendo atividades de “fiscalização” e controle inusitadas.

O direito de fiscalizar instalações industriais para verificar a sua adequação às normas de proteção ao meio ambiente é inerente à atividade de órgãos ambientais que tenham concedido a licença ou autorização ambiental (LC 140/2011, art. 17), salvo em casos nos quais estejam sendo cometidos crimes. Tanto a polícia judiciária como a polícia militar não exercem a função de fiscalização ambiental. Infelizmente, a lei de crimes ambientais criminalizou grande parte dos ilícitos administrativos, por exemplo, operar sem licença. Esse fato, por si só, não tem o condão de estabelecer uma permissão para que a polícia passe a exercer um “controle” sobre a existência ou não de licenças válidas nas empresas que estejam operando.

3.4.3 A fiscalização ambiental

A fiscalização ambiental é uma das atividades mais relevantes para a proteção do meio ambiente, pois é por meio dela que danos ambientais podem ser evitados e, se consumados, reprimidos. No entanto, nem sempre a fiscalização é exercida com a observância das normas próprias, do respeito aos cidadãos e de forma isenta. Um dos motivos mais importantes para que isso ocorra é que, simplesmente, as regras de fiscalização são desconhecidas pelo público e, não raras vezes, até pelos próprios fiscais. A fiscalização federal, como regra, é a mais bem estruturada e, portanto, será o principal objeto de nosso exame. Para que se possa compreender os seus mecanismos, é necessário que se examinem os termos da Lei nº 10.410/2002. Pela Lei, o cargo de analista ambiental tem as seguintes atribuições: (i) regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; (ii) monitoramento ambiental; (iii) gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; (iv) ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; (v) conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e (vi) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais, conforme o artigo 4º.

3.4.3.1 A fiscalização como expressão do poder de polícia

A grande “visibilidade” das fiscalizações ambientais tem feito com que, não raras vezes, órgãos sem a devida atribuição atuem “em defesa” do meio ambiente. Também não se pode esquecer que, em certas ocasiões, maus servidores públicos “fiscalizam” atividades que não estão arroladas dentre as suas atribuições, sob o argumento de que há uma competência comum para a proteção do meio ambiente. Alguns tribunais, inclusive o STJ (AGRESP 200401790140, Ministro Humberto Martins, *DJE*: 15/5/2009), davam sustentação a tal tese, fazendo com que a fiscalização ambiental fosse realizada de forma “lotérica”. Sempre nos posicionamos contra tal entendimento, haja vista que ele significa a mais absoluta incerteza para o cidadão que, sem dúvida, fica sem saber qual é o órgão responsável pela atividade, dando margem à corrupção e outras práticas altamente questionáveis. Felizmente, a LC nº 140/2011 deu um tratamento racional à questão ao dispor que a competência fiscalizatória é corresponsiva à competência para licenciamento, como determinado pelo artigo 17 da LC nº 140/2011. Assim, o ente que não detenha a competência para licenciamento, somente poderá atuar uma atividade que não esteja em sua esfera de atribuição para licenciar, quando o órgão dotado da mencionada atribuição tenha se quedado inerte.

3.4.3.2 Limites da fiscalização

Qualquer atividade administrativa está submetida aos princípios e preceitos constitucionais, não podendo ser exercida ao arrepio da CF. Para tal, há que se

observar precipuamente o *caput* do artigo 37 da CF, em especial os princípios de *legalidade*, *publicidade* (STJ – MS 9744/DF. Ministro José Delgado. 1ª Seção. DJU: 4/4/2005, p. 158) e *impressoalidade*. A fiscalização deve agir dentro dos estreitos limites do respeito aos direitos e garantias individuais, inclusive daqueles referentes à privacidade do domicílio (artigo 5º, XI, da CF).

No caso específico da legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000 estabelece em seu artigo 3º que: “No exercício da ação fiscalizadora, observado o disposto no art. 5º, XI, da CF, ficam asseguradas às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial. Parágrafo único – O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função”.

Assim, expressamente, o legislador determinou à fiscalização a observância dos preceitos constitucionais. Logo, por força de expressa determinação legal, a fiscalização somente poderá ingressar em estabelecimentos, sem o consentimento do proprietário, nas hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, salvo isso apenas com determinação judicial (STF – HC 82.788/RJ. Min. Celso de Mello. 2ª Turma. DJU: 2/6/2006, p. 43).

Outra questão que merece reflexão é a possibilidade de fiscalização que seja iniciada com base em denúncia “informal”. Tal denúncia informal, ou anônima, é hoje amplamente difundida, tendo virado um mecanismo de perseguição e intimidação, quando não de chantagem. Importante observar que a LC nº 140, no § 1º do artigo 17, admitiu a denúncia de “qualquer pessoa legalmente identificada”, o que joga por terra, pelo menos em matéria ambiental, a chamada “denúncia anônima”, a qual, não poucas vezes, é um instrumento de chantagem e perseguição. Parece-me evidente que a pessoa “legalmente identificada”, em casos excepcionais, poderá solicitar que a autoridade ambiental mantenha em sigilo a identidade do denunciante.

Há que se ver que as infrações administrativas tipificadas no Decreto nº 6.514/2008, em grande medida são meras cópias dos crimes tipificados pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o que implica a adoção pelo Ibama de um procedimento padronizado de “*comunicação de crime*” às autoridades policiais e ao Ministério Público sempre que é lavrado um auto de multa em razão de uma atividade de fiscalização.

3.4.3.2.1 Fiscalização pelo Ibama

A fiscalização efetivada pelo Ibama é regida pelas normas contidas no Regulamento Interno da Fiscalização (RIF) do Ibama aprovado pela *Portaria Ibama nº 11, de 10 de junho de 2009*.

A existência de norma procedimental para a atividade fiscalizatória é fundamental, pois fiscalização sem regras claras e predefinidas é algo que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. Infelizmente, a grande maioria dos Estados e dos Municípios não possui regulamentos internos de fiscalização, exercendo-a de forma aleatória e arbitrária. A fiscalização realizada pelo Ibama é feita de forma descentralizada, por setores próprios, sendo supervisionada e avaliada pela Coordenação-Geral de Fiscalização Ambiental (CGFIS), dentro do planejamento estratégico formulado pela Diretoria de Proteção Ambiental (Diproem) em consonância com as diretrizes gerais do Ibama.

Conforme o disposto no artigo 7º da LC nº 140/2011, as atribuições de fiscalização do Ibama são basicamente as seguintes:

- exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
- localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
- localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;
- localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
- localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
- localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
- de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97, de 9 de junho de 1999;
- destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); ou
- que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

a) Do agente de fiscalização

Somente *servidor público* especialmente designado possui autoridade legal para lavrar autos de infração e demais documentos inerentes à ação fiscalizatória, bem como adotar as medidas administrativas decorrentes de seu poder de polícia. No particular, merece ser observado que o STJ tem adotado conceito amplo de servidor público, nele incluindo aqueles sob contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (REsp 200401810061, 2ª Turma, DJU 21/3/2006, p. 103, Ministro Castro Meira).

No caso específico da fiscalização ambiental procedida pelo Ibama, não se aplica a condição geral de servidor público, sendo necessária a condição de servidor do quadro efetivo do Ibama, como aproveitamento em curso próprio para a função de agente de fiscalização ambiental. E mais: designação por Portaria específica expedida pelo presidente do órgão para o exercício da função.

Entretanto, em algumas oportunidades, lamentavelmente, a fiscalização do Ibama vem sendo realizada por pessoas estranhas aos quadros da autarquia (TRF 2ª Região. Desembargador Federal Guilherme Calmon, Apelação/ Reexame Necessário 2008.51.01.020999-0. 6ª Turma Especializada).

Há decisões judiciais (TRF 1ª Região, AGA 200701000441406, 8ª Turma, *e-DJFI* 06/06/2008. p. 664) que admitem a atuação fiscalizatória do analista ambiental, tendo em vista que a estruturação legal da carreira admite, em tese, a função. Contudo, tais decisões foram proferidas antes da entrada em vigor das normas administrativas que regulamentaram a atividade de agente de fiscalização. A Portaria nº 11/2009 do Ibama deve ser considerada legal e não exorbitante, haja vista que definiu os requisitos necessários para o servidor do quadro efetivo possa exercer, com vantagens para a administração e para a ordem democrática, a importante missão de agente de fiscalização.

b) Atribuições e deveres da fiscalização

O Regulamento Interno da Fiscalização organizou as atribuições da fiscalização, previstas em lei, de forma a racionalizar a ação administrativa do Ibama. Por óbvio, somente a lei pode dar à fiscalização as suas atribuições e competências.

A fiscalização ambiental está subordinada à *Diretoria de Proteção Ambiental*, à qual compete (Portaria nº 11/2009 do Ibama): (a) estabelecer, de acordo com as diretrizes gerais definidas pelo Ibama, o Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental com os objetivos estratégicos atinentes às ações de monitoramento, auditoria e fiscalização voltadas à proteção ambiental; (b) promover e orientar, no âmbito nacional e de acordo com as normas e orientações gerais, as ações de proteção, monitoramento, auditoria e fiscalização ambientais; (c) envidar esforços para a busca das condições gerais, políticas, humanas, materiais e financeiras necessárias à execução das ações estabelecidas no Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental; (d) estabelecer condições mínimas, humanas e logísticas, para a atividade fiscalizatória federal nas grandes frentes de proteção ambiental, como flora, fauna, pesca, biopirataria, biossegurança, poluição e degradação, efetivo cumprimento de licenciamento, bem como nas ações supletivas de proteção de unidades de conservação federais; (e) quantificar, qualificar e requerer os recursos humanos

necessários à execução dos Planos Nacionais Anuais de Proteção Ambiental; (f) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento e execução das ações de fiscalização; (g) estabelecer listagem anual de Agentes Ambientais Federais lotados em todos os estados da Federação, Distrito Federal e sede nacional com cronograma para sua incorporação em operações de caráter nacional a serem executadas pela CGFIS, em sintonia com o planejamento estratégico estadual dos setores de fiscalização das unidades descentralizadas.

Junto à Diretoria de Proteção Ambiental funciona a Coordenação-Geral de Fiscalização (CGFIS) que é dotada das seguintes atribuições: (a) promover, orientar, coordenar e fazer executar, em todo o País, o Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, observadas as normas e orientações gerais e específicas; (b) buscar, junto ao setor competente, as condições materiais para aquisição, manutenção, recuperação, distribuição, controle, uso adequado e racional dos equipamentos, veículos, barcos, aeronaves, armas, uniformes e demais instrumentos necessários à execução das ações de fiscalização em todo o País; (c) zelar pela padronização e qualidade do trabalho executado pelos Agentes Ambientais Federais e dirigentes do Órgão atuantes na fiscalização; (d) supervisionar as ações estabelecidas nos planos de fiscalização, em âmbito nacional; (e) selecionar Agentes Ambientais Federais para compor o Grupo Especial de Fiscalização (GEF) destinado a executar ação fiscalizatória, em caráter especial, em qualquer estado da Federação; (f) decidir pelo acionamento do Grupo Especial de Fiscalização (GEF); (g) selecionar servidores do Ibama para comporem Grupo de Informações de Fiscalização (GIF) para, em caráter sigiloso e especial, efetuar atividades precursoras de busca de dados e informações úteis para ação fiscalizatória em qualquer Estado da federação; (h) supervisionar o controle de informações sobre o efetivo de Agentes Ambientais Federais, quantificando-os e envidando esforços para sua qualificação dentro da política de elevação da qualidade do serviço prestado pelo Órgão; (i) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento e execução das ações de fiscalização; (j) zelar para que os Agentes Ambientais Federais cumpram os princípios e obrigações estabelecidos no Regulamento Interno da Fiscalização; (k) decidir pelo recolhimento dos equipamentos, armamento e respectivo registro e cautela, sob a responsabilidade do Agente Ambiental Federal, e seu afastamento da operação, em casos de grave desrespeito às normas do Regulamento Interno da Fiscalização, à execução operacional, à autoridade hierarquicamente superior ou ao Coordenador Operacional; (l) afastar da atividade fiscalizatória o Agente Ambiental Federal durante o período que estiver respondendo à Sindicância Punitiva ou ao Processo Disciplinar decorrente de ação que infrinja o disposto no RIF; (m) designar equipe de fiscalização para apuração de infrações ambientais, através do formulário denominado Ordem de Fiscalização; (n) designar servidores do Grupo de Informações de Fiscalização (GIF) para atividade estabelecida no art. 16 do RIF mediante formulário denominado Ordem de Busca de Informações; (o) propor plano nacional de distribuição dos veículos, aeronaves, barcos, equipamentos, armas e demais instrumentos empregados nas ações fiscalizatórias.

Junto aos órgãos descentralizados do Ibama funcionam as Coordenações de Fiscalização e Operações (COFIS) às quais compete: (a) supervisionar, promover, orientar, fazer executar, de acordo com as normas e orientações gerais e específicas estabelecidas pela CGFIS, as ações de fiscalização de responsabilidade do setor de fiscalização das unidades descentralizadas; (b) planejar, coordenar e executar, ou delegar essa responsabilidade, de acordo com as normas e orientações gerais e específicas estabelecidas pela CGFIS, as ações fiscalizatórias que envolvam dois ou mais estados da Federação; (c) acionar e coordenar diretamente a ação fiscalizatória executada pelo Grupo Especial de Fiscalização (GEF); (d) determinar a apuração das infrações ambientais; (e) designar equipe de fiscalização para apuração de infrações ambientais, por meio do formulário denominado Ordem de Fiscalização; (f) requerer os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à execução das atividades; (g) receber e analisar os formulários e demais documentos lavrados em decorrência da ação fiscalizatória executada por Agentes Ambientais Federais sob sua coordenação imediata, providenciando o seu encaminhamento para autuação em processo administrativo; (h) zelar pela observância dos dispositivos previstos no RIF atinentes à formulação de Auto de Infração, Parecer Técnico e demais formulários, bem como por sua boa qualidade, com vistas à devida instrução dos processos administrativos resultantes da ação fiscalizatória; (i) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento e execução das ações de fiscalização; (j) decidir pelo afastamento de Agente Ambiental Federal, ou outro integrante participante da ação fiscalizatória, da operação em casos de grave desrespeito às normas do RIF, à execução operacional, à autoridade hierarquicamente superior ou ao Coordenador Operacional; (k) zelar para que os Agentes Ambientais Federais cumpram os princípios e as obrigações estabelecidos no RIF; (l) afastar da atividade fiscalizatória o Agente Ambiental Federal durante o período que estiver respondendo a Sindicância Punitiva ou Processo Disciplinar decorrente de ação que infrinja o disposto no RIF.

Ao nível das Superintendências Estaduais do Ibama existe um Coordenador do setor de fiscalização ao qual compete: (a) planejar, promover, orientar, coordenar e fazer executar, no âmbito da sua área de atuação, e de acordo com as normas e orientações gerais e específicas, as ações fiscalizatórias executadas pelos Agentes Ambientais Federais sob seu comando direto e pelas unidades avançadas de sua jurisdição; (b) supervisionar, promover, orientar, fazer executar, de acordo com as normas e orientações gerais e específicas estabelecidas pela CGFIS, as ações fiscalizatórias sob sua responsabilidade; (c) determinar a apuração das infrações ambientais de competência do Ibama; (d) designar equipe de fiscalização para apuração de infrações ambientais, através do formulário denominado Ordem de Fiscalização; (e) designar servidores, após consulta à COIN, para atividade estabelecida no art. 16 do RIF mediante formulário denominado Ordem de Busca de Informações; (f) fazer executar as ações estabelecidas nos planos de fiscalização, no âmbito de sua jurisdição; (g) fazer executar ações estabelecidas no Plano Anual Nacional de Proteção Ambiental, dentro ou fora de sua jurisdição, quando determinado pela CGFIS; (h) qualificar, quantificar e requerer os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à execução das atividades; (i) consolidar e remeter à chefia imediata e à CONOF os relatórios mensais e anuais das atividades de fiscalização, assim como outras informações solicitadas; (j) controlar e distribuir aos Agentes Ambientais Federais sob sua coordenação os formulários e demais documentos inerentes à fiscalização, bem como equipamentos destinados à modernização da atividade fiscalizatória; (k) receber e analisar os formulários e demais documentos lavrados em decorrência da ação fiscalizatória, providenciando o seu encaminhamento para autuação em processo administrativo; (l) zelar pela observância dos dispositivos previstos no RIF atinentes à formulação de auto de infração, parecer técnico e demais formulários, bem como por sua boa qualidade, com vistas à devida instrução dos processos administrativos resultantes da ação fiscalizatória; (m) encaminhar ao Ministério Público informações e documentos acerca de infrações identificadas no exercício da ação fiscalizatória e que sejam também tipificadas como crime; (n) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento e execução das ações fiscalizatórias; (o) coordenar a distribuição, o controle e o uso adequado e racional dos equipamentos, armas e demais instrumentos empregados nas ações fiscalizatórias; (p) promover, junto ao setor competente, a manutenção, recuperação, distribuição, controle, uso adequado e racional dos veículos e barcos; (q) decidir pelo afastamento de Agente Ambiental Federal, ou outro integrante participante da ação fiscalizatória, da operação em casos de grave desrespeito às normas do RIF, à execução operacional, à autoridade hierarquicamente superior ou do Coordenador Operacional; (r) zelar para que os Agentes Ambientais Federais cumpram os princípios e as obrigações estabelecidos no RIF; (s) afastar da atividade fiscalizatória o Agente Ambiental Federal durante o período que estiver respondendo a Sindicância Punitiva ou Processo Disciplinar decorrente de ação que infrinja o disposto no RIF.

As Unidades avançadas do Ibama devem proceder às ações de fiscalização, no âmbito de suas circunscrições, reportando-se ao Coordenador da Superintendência Estadual.

c) Obrigações dos agentes ambientais federais

Os Agentes Ambientais Federais, no desempenho de suas atribuições, estão obrigados a: (a) conhecer a estrutura organizacional do Ibama, seus objetivos e competências como Órgão executor da PNMA; (b) obedecer rigorosamente aos princípios, deveres, proibições, responsabilidades e obrigações relativas ao servidor público civil da União, estabelecidos em leis e normas vigentes, destacando-se as obrigações referentes à ética no serviço público, comunicando a autoridade competente, se for o caso, para apuração de responsabilidades por desrespeito às normas e leis; (c) respeitar a estrutura hierárquica do Órgão, cumprindo com disciplina as determinações estabelecidas pela autoridade competente, pelo Coordenador Operacional ou pelo Chefe de Equipe Fiscalizatória; (d) aplicar técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizatória, adquiridos nos cursos de capacitação ou aperfeiçoamento; (e) identificar-se previamente, sempre que estiver em ação fiscalizatória; (f) abordar as pessoas de forma educada e formal, quando das ações fiscalizatórias; (g) cumprindo seu papel de educador e multiplicador de informações, orientar a comunidade em geral sobre a legislação ambiental vigente e sobre direitos e deveres referentes a prazos e documentos a serem apresentados resultantes de ação fiscalizatória; (h) aplicar as sanções previstas na legislação vigente, mediante a constatação de ilícitos ambientais; (i) preencher os formulários de fiscalização com atenção, de forma concisa e legível, ou mediante uso de equipamento digital, circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e enquadramento legal específico, evitando a perda do impresso, quando for o caso, ou provocando a nulidade da autuação; (j) atuar

ostensivamente mediante o uso do uniforme e veículo oficial identificado, conforme decisão da autoridade competente ou do Coordenador Operacional; (k) submeter-se às necessidades do exercício da atividade fiscalizatória, atuando em locais, dias e horários necessários, ainda que peculiares, à execução adequada dos trabalhos práticos; (l) atender aos prazos estabelecidos pela autoridade hierarquicamente superior, Coordenador Operacional ou Chefe de Equipe Fiscalizatória para a adoção dos procedimentos pertinentes, inclusive quanto à entrega de formulários lavrados e demais documentos das atividades de fiscalização, ainda que mediante solução eletrônica; (m) apresentar à autoridade hierarquicamente superior ou ao Chefe de Equipe Fiscalizatória o Relatório de Autuação, Parecer Técnico, bem como dados complementares dos fatos ocorridos, preferencialmente com fotos, descrição e localização exata do ilícito ambiental; (n) participar de cursos, atualizações, treinamentos e encontros que visem ao aperfeiçoamento das suas funções; (o) zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos veículos, barcos, equipamentos, armas e demais instrumentos empregados nas ações fiscalizatórias em geral e, em específico, aqueles que lhes forem confiados; (p) conhecer e adestrar-se no manuseio de armas de fogo mediante processo de capacitação específico concebido e dirigido pela CGFIS ou por esta autorizado; (q) zelar pelo sigilo das informações quando do planejamento e execução das ações fiscalizatórias; (r) manter a discrição e portar-se de forma compatível com a função que exerce; (s) apresentar-se limpo, com o uniforme padrão em bom estado, não sendo permitido o uso de vestimentas, acessórios e objetos incompatíveis com o mesmo; (t) comunicar ao superior imediato os desvios praticados e irregularidades detectadas no exercício da ação fiscalizatória; (u) abster-se de aceitar favorecimentos que impliquem o recebimento de benefícios para hospedagem, transporte, alimentação, salvo em situações de emergência e que não tenham sido previstas no planejamento operacional; (v) abster-se em aceitar presentes e brindes de qualquer espécie cuja doação seja motivada por sua condição de Agente Ambiental Federal; (x) abster-se do consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de entorpecentes durante o serviço, considerando-se todos os turnos quando em operação de fiscalização, ou trabalhar sob seus efeitos; (y) devolver todo material, uniformes, armamento, acessórios e equipamentos que caracterizem atividade de fiscalização, que lhes tenham sido fornecidos pelo Órgão, ao afastar-se dessa atividade ou ser excluído de Portaria de designação para atividade fiscalizatória.

d) A fiscalização ambiental federal

A norma de regência busca fazer com que a fiscalização ambiental não se faça por espasmos ou demanda, mas, antes, seja parte de um planejamento estratégico, o qual deve estar fundado em princípios capazes de dar à atividade de fiscalização maior grau de eficiência, segurança jurídica e certeza. A fiscalização federal se pretende atividade majoritariamente preventiva e não repressiva e deverá *“criar condições, mediante ações eficientes executadas pelos Agentes Ambientais Federais e conduzidas pelos dirigentes do Órgão, para se promover a dissuasão aos potenciais infratores ambientais”*.

A fiscalização tem início pela expedição de Ordem de Fiscalização ou Ordem de Busca de Informações cuja emissão é da atribuição do (i) Diretor de Proteção Ambiental; (ii) Coordenador Geral de Fiscalização Ambiental; (iii) Coordenador de Operações de Fiscalização (COFIS); (iv) o Superintendente do Ibama no Estado; (v) Chefe da Divisão Técnico-Ambiental; (vi) o responsável pelo Núcleo de Controle e Fiscalização das Superintendências, designado para tal função. (artigo 14 Portaria Ibama nº 11/2009, alterado pela Portaria Ibama nº 35, de 26 de dezembro de 2013). Agente Ambiental Federal Coordenador Operacional, (ii) a indicação dos demais Agentes Ambientais Federais e outros integrantes da missão, (iii) a meta a ser cumprida, a (iv) área de abrangência para a ação, os (v) instrumentos e condições materiais a serem empregados, o (vi) período e demais informações necessárias.

É importante observar que a equipe de fiscalização deve ser integrada por, no mínimo, dois agentes públicos, sendo ao menos um destes Agente Ambiental Federal.

As ações fiscalizatórias são: (i) execução de plano de fiscalização previamente estabelecido; (ii) cumprimento de determinação superior; (iii) cumprimento de determinação judicial ou do Ministério Público; (iv) atendimento à denúncia; (v) ação supletiva decorrente de omissão ou ilegalidade, identificadas a partir de monitoramento sobre órgãos do Sisnama, quando se tratar de fato de interesse local; (vi) iniciativa própria do Agente Ambiental Federal.

A ação fiscalizatória de iniciativa do Agente Ambiental Federal limita-se aos casos de flagrante de infração ambiental ou risco iminente de dano ambiental que requeiram intervenção imediata, desde que não se traduza a ação em risco desmedido à integridade física do Agente e não comprometa ação fiscalizatória planejada. Quando não se tratar de flagrância, o agente ambiental deverá se limitar a comunicar o fato ao seu superior imediato.

Em se tratando de ilícito ambiental que não esteja na esfera direta de competência da União, por ser de interesse local, *“deverá o Agente Ambiental Federal envolver a autoridade ambiental competente para promover sua apuração imediata mediante processo administrativo próprio”*.

e) Fiscalização e produção de provas

A atividade de fiscalização, muito embora de natureza eminentemente preventiva, necessita produzir provas das constatações efetivadas durante as diligências, de modo que os autos de constatação e infração emitidos possam ter consistência jurídica e as penalidades efetiva e corretamente aplicadas. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Grande parte da ineficiência da fiscalização é demonstrada pelo pequeno índice de pagamento de multas os quais refletem, dentre outras coisas, uma fiscalização malfeita e apressada, sem a produção da necessária prova técnica. O Ibama (SALOMON, 2011) é o recordista de baixo rendimento no recolhimento de multas aplicadas.

Todos os elementos de informação que forem coligidos durante a ação fiscalizatória deverão constar em relatório próprio, de acordo com as normas vigentes para procedimento de apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e, “sempre que possível”, reforçadas com parecer técnico que contenha ao menos os itens a seguir: (i) número do auto de infração e demais termos; (ii) fotografias, preferencialmente coloridas e datadas; (iii) manifestação técnica sobre o objeto da infração e danos verificados, emitida por Analista Ambiental ou Especialista de nível superior, com habilitação adequada, e, preferencialmente, por outro integrante da equipe que não o Agente Ambiental Federal autuante; (iv) coordenadas geográficas, no formato grau, minuto e segundo, *Datum* oficial do IBGE-SAD 1969 ou Sirgas 2000; (v) nos casos de infração em que o dano seja medido em unidade de área (km², hectare, alqueire e outros), deverá ser confeccionado o polígono delimitando a área de abrangência do dano; (vi) em todos os demais casos deverá ser indicado o local da infração, definido por um par de coordenadas geográficas; (vii) nos casos em que a infração puder ser verificada via sensoramento remoto, o parecer técnico deverá conter ao menos duas imagens, ser houver, uma anterior e outra posterior ao fato, ambas datadas e com a grade de coordenadas; (viii) quando houver indicativo A4 de desmatamento gerado pelo Sistema de Detecção em Tempo Real (DETER), o mesmo deverá ser anexado ao parecer técnico. Registre-se que o laudo técnico é essencial, pois é dele que decorrerá a prova cabal da materialidade da ação nociva. Ademais, dado que a apuração judicial dos fatos é sempre lenta, somente um laudo contemporâneo aos eventos poderá servir de base para decisões futuras.

3.4.3.2.2 Fiscalização pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade

A fiscalização sob atribuição do Instituto Chico Mendes está regulamentada pela Portaria ICMBio nº 95, de 5 de setembro de 2012. Conforme disposto no artigo 1º do RIFICMBio, as ações de fiscalização promovidas pelo ICMBio serão executadas com base nas orientações e princípios estabelecidos neste regulamento, em consonância com a legislação pertinente, tendo como áreas de abrangência as Unidades de Conservação Federais e respectivas zonas de amortecimento.

Elas serão planejadas e executadas pelas unidades descentralizadas e serão coordenadas, avaliadas e supervisionadas pela Diretoria responsável do ICMBio.

A área de atuação do ICMBio para as ações de fiscalização previstas no RIFICMBio é restrita às unidades de conservação federais e respectivas zonas de amortecimento. Vale notar, também, que a fiscalização do ICMBio não exclui a do Ibama, nem dos demais órgãos integrantes do Sisnama.

a) Obrigações da fiscalização

Conforme o disposto no artigo 5º do RIFICMBio, são obrigações dos Chefes das Unidades Descentralizadas: (a) Manter atualizados os conhecimentos referentes à Instituição, legislação, procedimentos e tecnologias relacionadas às ações fiscalizatórias; (b) Planejar, promover, orientar, coordenar e fazer executar as ações de fiscalização no âmbito da sua área de atuação e de acordo com as normas e orientações gerais e específicas; (c) Manter sistematizadas as informações e documentos

referentes às ações de fiscalização; (d) Quantificar, especificar e solicitar os recursos humanos, materiais e financeiros necessários à execução das atividades de fiscalização; (e) Designar equipe para realizar ações fiscalizatórias de caráter preventivo e para apuração de infrações ambientais no âmbito da sua competência; (f) Receber e analisar os formulários e demais documentos lavrados em decorrência das ações de fiscalização na sua área de atuação, providenciando o seu encaminhamento para autuação em processo administrativo, conforme norma própria; (g) Consolidar e remeter à CGPRO informações e relatórios definidos em normas e orientações, bem como quaisquer outros porventura solicitados; (h) Promover a manutenção, recuperação, distribuição, controle, uso adequado e racional dos equipamentos e materiais empregados nas ações de fiscalização na sua área de atuação; (i) Controlar e distribuir formulários e demais documentos inerentes à fiscalização que lhe forem atribuídos; (j) Autorizar, sempre que possível, a participação dos Agentes de Fiscalização sob sua chefia em ações realizadas em outras Unidades; (k) Incentivar, apoiar e requisitar a participação dos Agentes de Fiscalização em cursos, atualizações, treinamentos e encontros que visem ao aperfeiçoamento das ações de fiscalização; (l) Orientar os Agentes de Fiscalização para que cumpram os princípios e obrigações estabelecidos neste regulamento; (m) Comunicar à CGPRO e/ou demais autoridades competentes os desvios praticados e irregularidades detectadas no exercício da ação de fiscalização; e (n) Zelar pelo sigilo das informações relativas às ações de fiscalização.

O Agente de Fiscalização está obrigado a (art. 6º do RIFICMbio): (a) Manter atualizados os conhecimentos referentes à Instituição, legislação, procedimentos e tecnologias relacionados à ação fiscalizatória; (b) Executar, no âmbito da sua área de atuação e de acordo com as normas e orientações gerais e específicas, as ações de fiscalização; (c) Participar de operações de fiscalização fora de sua unidade de lotação, sempre que convocado pela CGPRO ou recrutado por outras Unidades Descentralizadas; (d) Atender às peculiaridades da ação fiscalizatória, atuando em locais, dias e horários próprios à atividade de fiscalização, de acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto; (e) Apresentar-se uniformizado na execução das ações de fiscalização do ICMBio, salvo motivo justificado; (f) Identificar-se previamente no exercício da atividade de fiscalização; (g) Atuar em ação de fiscalização sempre em equipe; (h) Buscar testemunhas ao constatar ilícitos ambientais; (i) Preencher os formulários de fiscalização de forma concisa e legível, circunstanciando os fatos com informações objetivas; (j) Apresentar à chefia da Unidade onde estiver ocorrendo a ação ou ao coordenador da equipe o relatório das atividades de fiscalização, acompanhado dos devidos formulários, em prazo máximo de 3 (três) dias após o término da ação fiscalizatória; (k) Receber, mediante assinatura do Termo de Recebimento, os formulários e demais materiais controlados da fiscalização, passando a responder por sua guarda e utilização; (l) Devolver todo o material controlado ao afastar-se da atividade de fiscalização, em decorrência de exoneração, cessão, redistribuição, aposentadoria, licença e outros tipos de afastamentos previstos em legislação; (m) Primar pela manutenção e pelo uso adequado e racional de todo patrimônio que lhe for confiado; (n) Participar de cursos, atualizações, treinamentos e encontros que visem ao aperfeiçoamento das ações fiscalizatórias, aplicando no exercício da atividade as técnicas, procedimentos e conhecimentos adquiridos; (o) Orientar a comunidade em geral sobre a prevenção de ilícitos, assim como divulgar a legislação ambiental vigente; (p) Adotar conduta pautada no respeito aos direitos humanos, com vistas a minimizar a ocorrência e a intensidade de conflitos durante a ação fiscalizatória, somente fazendo uso da força, inclusive de cunho verbal, em resposta proporcional à ação prévia por parte do abordado, observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência; (q) Comunicar à chefia imediata, à CGPRO e/ou demais autoridades competentes os desvios praticados e irregularidades detectadas no exercício da ação de fiscalização; e (r) Guardar o sigilo das ações de fiscalização.

O Regimento da Fiscalização definiu os padrões a serem utilizados quando do preenchimento dos formulários, com vistas a garantir exigibilidade da imputação. Dessa forma, “[o] preenchimento dos formulários deverá ser efetuado utilizando-se letra de forma legível ou por meio de equipamento eletrônico específico”. E “[a] assinatura do autuante deverá obrigatoriamente estar acompanhada de seu nome completo, matrícula e número da portaria de designação como Agente de Fiscalização, todos legíveis, ou carimbo contendo essas informações”.

Um elemento da maior importância é a atividade prática da fiscalização, a qual se divide em: (i) *De Ordem*: por determinação ou solicitação superior, tipificadas como (art. 7º do RIFICMbio): (a) rotina: ações cotidianas de fiscalização; (b) emergencial: situações atípicas à rotina, que exige atendimento imediato; (c) demanda externa: encaminhada por outros órgãos públicos ou pela sociedade de modo geral, incluindo determinações judiciais, solicitações do ministério público e atendimento a denúncias diversas, formais e informais; (d) precursora: não ostensiva, de caráter reservado, objetivando levantamento de informações relacionadas a ilícitos ambientais e (ii) *De ofício*: por dever de ação do Agente de Fiscalização diante da ocorrência de ilícito ambiental, de competência de apuração pelo ICMBio, sem que haja prévio conhecimento ou determinação.

É relevante observar que a “[a]ção de fiscalização será iniciada com a designação da equipe de fiscalização pelo chefe da Unidade Descentralizada”. A equipe de fiscalização “será composta pelo mínimo de 3 (três) Agentes de Fiscalização do ICMBio”. Para que a equipe atue é necessário que exista uma formalização “por meio de Ordem de Fiscalização, onde deverão constar os elementos para o cumprimento da ação fiscalizatória, período, nome dos membros da equipe e coordenador”. Sem tal designação, como regra, a fiscalização deve ser tida por clandestina e realizada sem a devida autorização, portanto, nulos os atos por ela produzidos.

3.4.3.2.3 Fiscalização e exercício de profissões regulamentadas

A Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002 instituiu uma carreira no serviço público federal e não dispôs sobre o exercício de uma profissão. Por sua vez, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”, não estabeleceu um conceito normativo de *carreira*, ainda que dela tenha tratado em várias ocasiões. Contudo, é certo que, doutrinariamente, o vocábulo *carreira* encontra sua definição muito bem sedimentada, chegando a ser consensual entre os especialistas. O conceituado José Cretella Júnior (1967, p. 187) assim define *carreira*: “*Carreira significa, entre outras coisas, corrida, caminho, estrada, curso, percurso, espaço percorrido, viagem. O cargo de carreira pressupõe, desde logo, uma possibilidade de marcha, de caminho continuado, de acesso ou promoção*”. Cargo de carreira é aquele ocupado pelo servidor público estatutário que lhe permite acesso a cargos superiores. O cargo de carreira se contrapõe ao cargo isolado que não pressupõe uma estrutura hierárquica de promoção funcional do servidor público. O servidor de carreira é, portanto, um servidor profissional do Estado.

Pela Lei, ao cargo de analista ambiental competem as seguintes atribuições: (i) regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; (ii) monitoramento ambiental; (iii) gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; (iv) ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; (v) conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e (vi) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais, tudo como estabelecido pelo artigo 4º. É evidente que as atribuições dos analistas, por extremamente técnicas, devem ser exercidas por analistas que tenham em sua formação profissional básica a habilitação para o seu exercício. Veja-se que o artigo 11 determina que: “O ingresso nos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente referidos no art. 1º desta Lei ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, no padrão inicial da classe inicial”. Acrescente-se que na hipótese do artigo 4º, parágrafo único, o concurso realizar-se-á obrigatoriamente por áreas de especialização. O cargo de analista especificamente exige formação superior.

Ocorre que muitas das atribuições do cargo de analista ambiental são incluídas nas atribuições de determinadas profissões, por exemplo, as de Engenheiro ou Biólogo, fazendo com que os cargos de analista ambiental que desempenhem funções incluídas no rol das profissões regulamentadas só possam ser preenchidos por profissionais devidamente habilitados. Imensa repercussão haverá na fiscalização ambiental, haja vista que o fiscal deverá ter a habilitação requerida para a atividade, não bastando a mera investidura no serviço público ou a designação para a fiscalização. Igual posição é assumida por Moraes (2006, p. 118):

A fiscalização é uma necessidade inerente à existência do Estado, portanto, é uma função cujos cargos estão classificados como Carreira de Estado, ou seja, indissociável à sua própria concepção e existência. Nesse sentido, essas funções devem ser ocupadas, através de concurso público, por pessoas que possuam a qualificação técnica estipulada em lei, sob pena de nulidade dos atos praticados, em face de violação ao referido dispositivo constitucional.

Merece atenção o parágrafo único do artigo 6º, que determina: “O exercício das atividades de fiscalização pelos titulares dos cargos de Técnico Ambiental deverá ser precedido de ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual estejam vinculados e dar-se-á na forma de norma a ser baixada pelo Ibama ou pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, conforme o Quadro de Pessoal a que pertencerem.”

Assim, somente em situações excepcionais poderá a função de fiscalização ambiental ser atribuída a técnico ambiental, uma vez que, originariamente, a fiscalização é atribuição do analista ambiental.

3.4.3.3 Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-parques

O Decreto Federal nº 6.515, de 22 de julho de 2008 instituiu, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, os Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-Parques. Tais programas têm por “*objetivo de desenvolver ações de cooperação federativa na área ambiental*”. Conforme disposto no § 2º do artigo 1º do decreto: “os Programas serão destinados, prioritariamente, para as atividades de prevenção e defesa contra crimes e infrações ambientais, bem como para a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora, conforme previsto neste Decreto e no ato formal específico de adesão dos entes federativos interessados.”

Os Programas de Segurança devem ser orientados pelos seguintes princípios e diretrizes: (i) cooperação ambiental; (ii) solidariedade federativa; (iii) planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; (iv) proteção de áreas ameaçadas de degradação e de espaços territoriais a serem protegidos e seus componentes; (v) prevenção contra crimes e infrações ambientais; (vi) emprego de técnicas adequadas à preservação ambiental; e (vii) qualificação especial para gestão de conflitos.

3.5 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3.5.1 Introdução

Todas as atividades capazes de alterar negativamente as condições ambientais estão submetidas ao controle ambiental, que é uma atividade geral de polícia exercida pelo Estado. O controle ambiental tem sido confundido com o licenciamento ambiental, o que do ponto de vista teórico e prático é incorreto. O controle ambiental é um poder-dever estatal de exigir que as diferentes atividades humanas sejam exercidas com observância da legislação de proteção ao meio ambiente, independentemente de estarem licenciadas ou não. O licenciamento ambiental é uma modalidade de controle ambiental específica para atividades que, devido às suas dimensões, sejam potencialmente capazes de causar degradação ambiental.

O *licenciamento ambiental* é, juntamente com a fiscalização, a principal manifestação do poder de polícia exercido pelo Estado sobre as atividades utilizadoras de recursos ambientais. O licenciamento ambiental, segundo a conceituação da Cetesb, é: “um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, e que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.”³

Tal definição corresponde, em linhas gerais, àquela estabelecida pela Resolução Conama nº 237/97 (art. 1º, I).

Em síntese, como afirma Farias (2007, p. 37), “trata-se de um mecanismo cuja função é enquadrar as atividades causadoras de impacto sobre o meio ambiente, o que pode ser feito por meio de adequação ou de correção de técnicas produtivas e do controle da matéria-prima e das substâncias utilizadas”.

O licenciamento ambiental se materializa nos *Alvarás ambientais*, que podem ser de vários tipos diferentes. A Administração pode conceder *licenças ou autorizações* para que pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, exerçam as atividades que utilizam os recursos ambientais.

É importante que o leitor fique atento para as diferenças entre licença administrativa e licença ambiental. A *licença administrativa*, que possui caráter de *definitividade*, só podendo ser revogada por interesse público ou por violação das normas legais (STF – RE 106931/PR. Min. Carlos Madeira. 2ª Turma. *DJU*: 16/5/1986, p. 8188), sendo que, na primeira hipótese, a revogação far-se-á mediante indenização (STF – RMS 2810. Min. Mario Guimarães. Pleno. *DJU*: 24/12/1956, p. 2465.); importante ressaltar que somente será legal a revogação precedida pela ampla defesa e o contraditório, haja vista que a licença, em tese, concede direitos ao seu titular; já a *autorização* expedida a título *precário* é revogável a qualquer momento pelo poder autorizante, mediante um juízo de conveniência e oportunidade. As licenças e autorizações ambientais têm as suas origens imediatas nas licenças e autorizações administrativas e com estas mantêm uma relação intensa e, por vezes, conflitante. Assim, não há que se confundir a licença ambiental com a autorização ambiental. As duas modalidades de alvarás são perfeitamente válidas. Ocasionalmente existirão em que a hipótese será de concessão de licença ambiental; em outras, a questão será resolvida mediante autorização ambiental. A LC nº 140/2011, expressamente, e em várias passagens, reconhece a existência das “autorizações ambientais”. Este fato tem enorme repercussão jurídica que ainda não foi devidamente analisado pela doutrina e jurisprudência.

Ao longo dos anos temos sustentado a tese de que há uma diferença clara entre as licenças de direito ambiental e as licenças administrativas, havendo uma natureza especial para a licença ambiental. Da mesma forma, temos afirmado que a licença ambiental não é uma mera autorização, como muitas vezes, equivocadamente, tem sido asseverado, até mesmo por decisões judiciais. Aparentemente, o passar dos anos tem dado razão ao nosso ponto de vista. Muito embora o licenciamento ambiental federal não defina claramente a diferença entre as licenças e as autorizações ambientais, ao nível dos Estados é cada vez maior o número daqueles que, expressamente, reconhecem as diferenças entre os conceitos normativos de licença ambiental e autorização ambiental. Assim, parece que é chegada a hora de que se reconheça que o licenciamento ambiental não é atividade discricionária e que a licença ambiental não é, de forma nenhuma, uma autorização concedida em caráter precário.

Outro aspecto que deve ser mencionado é o referente às sanções aplicadas pela polícia administrativa, as quais possuem uma imensa gama de formas, variando em sua intensidade em consonância com a gravidade da lesão produzida. As principais são:

- multa;
- interdição de atividade;
- fechamento do estabelecimento;
- demolição;
- embargo de obra;
- destruição de objetos;
- inutilização de gêneros;
- proibição de fabricação ou comércio de produtos;
- vedação de localização de indústria ou comércio em determinadas áreas.

3.5.2 Cooperação administrativa e licenciamento ambiental

A LC nº 140/2011, muito embora não tenha trazido “novidades” para a regulamentação jurídica da cooperação entre entes federativos para a proteção do meio ambiente, pois de certa forma é uma repetição de normas constantes na Resolução Conama nº 237/1997; fato que é demonstrativo do baixo nível de segurança e técnica jurídica das normas ambientais. Ademais, nenhum jurista sério pode entender que uma matéria pode ser tratada seja por LC, seja por uma simples Resolução do Conama. O fato é que a LC está aí e, certamente, muitos atos jurídicos que foram praticados com base em norma anterior merecerão revisão, sobretudo aqueles que importaram em aplicação de penalidades e restrições, fundadas em resolução que, como se comprovou posteriormente, versava matéria reservada à LC. A Resolução nº 237/97 do Conama, até aqui a principal norma de licenciamento ambiental, tem merecido os mais diferentes tratamentos judiciais.

Atualmente, não há um grande empreendimento que não passe por sérios questionamentos quanto ao licenciamento ambiental.

Diante da edição da LC 140/2011 e de seu regulamento (Decreto Federal nº 8.437/2015), várias questões passaram a ficar mais claramente estabelecidas e, espera-se, haverá maior estabilidade jurídica.

3.5.3 O licenciamento ambiental como processo administrativo

Como já foi visto acima, a utilização dos recursos ambientais não é inteiramente livre, pois demanda uma autorização especial do estado que é feita por meio do procedimento administrativo de licenciamento ambiental, o qual se dá sempre que uma atividade ou empreendimento seja considerado efetiva ou potencialmente poluidor, ou seja capaz de causar degradação ambiental. O licenciamento ambiental, de mero processo administrativo e rotineiro, acabou se transformando no centro de quase toda a polêmica em torno do meio ambiente que, por um motivo, ou por outro, acaba se reduzindo a uma discussão sobre o licenciamento ambiental e suas formalidades.

A natureza jurídica do licenciamento ambiental tem sido pouco estudada pela doutrina jurídica especializada, isso talvez se justifique devido ao fato de que o licenciamento, além dos aspectos jurídicos, tem uma conotação técnica muito acentuada e, por conta disso, não pode ter regras jurídicas muito amarradas e peremptórias. Por outro lado, as normas jurídicas que disciplinam o licenciamento ambiental não podem ser abertas demais. Há, portanto, uma enorme tensão entre o princípio da legalidade e o informalismo; tal tensão encontra solução normativa nos incisos VI e IX do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.784/1999, fato é que matéria tão relevante para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento da atividade econômica não pode ficar ao sabor de normas puramente administrativas, fazendo-se necessária a edição de uma lei para disciplinar o licenciamento ambiental federal.

Não se deve perder de vista que o requerimento de licença ambiental visa, por parte do empreendedor, à obtenção de um Alvará concedido pelo Estado que o habilite ao exercício de uma determinada atividade utilizadora de recursos ambientais. Nesse sentido, o Licenciamento Ambiental é atividade diretamente relacionada ao exercício de direitos constitucionalmente assegurados, tais como o direito de propriedade e o direito de livre iniciativa econômica que deverão ser exercidos com respeito ao meio ambiente. Assim, indiscutivelmente, o Alvará de Licença Ambiental servirá de limitador concreto para o exercício da atividade econômica que somente será lícita se respeitados os limites da Licença Ambiental concedida. Penso que diante de tais circunstâncias não resta dúvida de que a postulação de uma licença ambiental é, simultaneamente, a postulação para o exercício de direitos constitucionalmente assegurados, motivo pelo qual se lhe deve aplicar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aliás, se examinarmos o conjunto de normas que regem o licenciamento ambiental, veremos que, muito embora de forma assistemática, existe uma tímida aplicação do contraditório e da ampla defesa. Contudo, ante o crescimento da atividade econômica e, conseqüentemente, a demanda por mais licenciamentos, começa a ficar evidente que a estrutura normativa que serve de arcabouço para os procedimentos de licenciamento ambiental necessita de profunda revisão, de forma a assegurar a efetiva participação comunitária nos licenciamentos, como forma, inclusive, para dar-lhes grau maior de legitimidade.

Como se sabe, o processo de licenciamento ambiental é levado ao conhecimento do público desde o seu início, haja vista que existe determinação para que o simples requerimento de licença seja publicado na imprensa e tornado público. Evidentemente que tal norma não é ociosa. O fundamento para a sua existência é que qualquer cidadão legitimamente interessado poderá acompanhar o processo de licenciamento ambiental, com vistas a controlar-lhe a legalidade e, se for o caso, requerer o que for de direito. Infelizmente, não existem regras que estabeleçam as formas pelas quais a participação se dará e a publicação, tal como tem sido a sua prática, se torna mais um procedimento burocrático, destituído de qualquer valor prático, haja vista que não dá início a uma participação mais ampla no licenciamento, bem como há necessidade de maior clareza na atuação do Estado no processo de licenciamento que, em grande parte das vezes, é obscura e enigmática.

Também indica a natureza contraditória e processual do licenciamento ambiental o artigo 11 da Resolução Conama nº 001/86, que determina sejam o EIA e o RIMA colocados à disposição da comunidade. Por fim, as audiências públicas, ainda que de caráter meramente consultivo, indicam a prevalência do contraditório no licenciamento ambiental, uma vez que a comunidade interessada a ser atingida pelo empreendimento poderá levar as razões de seu descontentamento ao órgão ambiental. Muitos outros exemplos poderiam ser apontados. Entretanto, a legislação própria tem vacilado no sentido de aprofundar o caráter contraditório do processo de licenciamento ambiental que, lamentavelmente, ainda conta com normas pouco claras. É verdade que, timidamente, o Ibama tem reconhecido o licenciamento ambiental como processo e não como mero procedimento, como é o caso da IN Ibama nº 184, de 17 de julho de 2008, com nova redação dada pela Instrução Normativa nº 14/2011 que trata do licenciamento ambiental federal, que em seu artigo 7º expressamente se refere à “*instauração do processo de licenciamento*”.

A professora Odete Medauar reconhece a natureza processual do licenciamento ambiental, classificando-o como processo administrativo de outorga (MEDAUAR, 1996, p. 199). O reconhecimento do licenciamento como processo administrativo e não como mero procedimento implica a admissão do direito de apresentar recursos, formular defesas específicas, apresentar pareceres técnicos e análises que se façam necessárias para a defesa dos direitos e interesses em jogo. Por outro lado, implica a adoção de prazos mais estáveis e peremptórios tanto para os interessados como para a própria administração. Há uma evidente impropriedade técnica nas definições normativas que têm insistido em classificar o licenciamento ambiental como mero procedimento, impropriedade que, aliás, é desmentida por normas que asseguram um determinado grau de contraditório às partes interessadas.

No licenciamento, são discutidos direitos extremamente importantes tanto para o empreendedor como para as comunidades situadas na área de influência do empreendimento e, evidentemente, tais direitos não podem sofrer menoscabo. Por outro lado, o estabelecimento de regras claras no processo de licenciamento ambiental, com a definição precisa da participação do público e de prazos, por exemplo. É importante que o processo de licenciamento ambiental seja capaz de incorporar as diferentes tensões envolvidas no caso concreto, evitando-se que liminares e outras medidas judiciais tomadas com base em processos administrativos mal conduzidos sejam capazes de paralisar empreendimentos necessários que muitas vezes são prejudicados em função de licenciamentos ambientais conduzidos de forma equivocada, apressada e, portanto, ilegítima.

O sistema federal de licenciamento ambiental é ligeiramente mencionado na Lei da PNMA, com a especificação das licenças ambientais no Decreto Federal 99.274/1990. Há, igualmente, como é o caso do petróleo, de licenças criadas por Resolução do Conama. O sistema está construído, pois, fundamentalmente, em Resoluções Administrativas do Conama, o que acarreta uma evidente fragilidade normativa, em detrimento da segurança jurídica para as partes interessadas, sem que disso resulte maior proteção ao meio ambiente. É importante frisar que não existe um sistema nacional de licenciamento ambiental, haja vista que as normas aplicáveis podem variar em conformidade com os diferentes estados e municípios que, no caso concreto, estejam outorgando determinada licença ambiental.

O licenciamento ambiental ocorre perante a Administração Pública e, dessa forma, está submetido aos princípios reitores da Administração Pública tipificados em nossa CF. No caso específico dos licenciamentos federais, havendo lacunas nas normas específicas, há que se aplicar a Lei nº 9.784/1999 conforme disposto no seu artigo 69.

O licenciamento ambiental que não observe, em sua tramitação, os princípios fundamentais da Administração Pública é licenciamento ambiental passível de revisão judicial. O Direito Administrativo, como se sabe, é um dos principais vetores do Direito do Estado, visto que rege as relações entre os diferentes órgãos da própria Administração e entre a Administração e os particulares. Para o Ministro Eros Roberto Grau (1991, p. 28): “O Direito Administrativo, ao mesmo tempo em que é concebido como provedor da defesa do indivíduo contra o Estado, apresenta como princípio fundamental o da supremacia do interesse público, e isto ocorre sem que, em regra, seja questionada a dissociação entre interesse público – interesse cujo titular é o Estado – e interesse social – cujo titular é a sociedade”.

O Direito Administrativo e, sobretudo, o processual administrativo, é fundamental no licenciamento ambiental, pois a observância da legalidade é indispensável para a validade dos licenciamentos. A proteção ambiental se faz no interior do Estado Democrático e com a utilização dos instrumentos da ordem jurídica democrática que são postos à sua disposição. Não pode haver incompatibilidade entre proteção ambiental e Estado de Direito, pois a primeira subordina-se ao segundo.

Não se desconhece que existe forte tendência, certamente influenciada por leitura apressada de obras jurídicas não elaboradas com base em nossa estrutura

normativa, a qual busca aplicar indistintamente princípios jurídicos abstratos e pouco claros, em contraposição às normas positivadas. Certamente, o recurso aos princípios jurídicos só tem sentido ante a inexistência de norma positiva sobre o tema abordado. Princípios como os da presunção de legalidade do ato administrativo e outros não contradizem o princípio da precaução. A mera invocação da cautela ou da precaução não é motivo juridicamente relevante para que se desconsiderem atos administrativos que, em princípio, foram praticados de acordo com a lei.

A PNMA, no inciso IV do artigo 9º, estabelece que o licenciamento é um de seus instrumentos. O artigo 10 da mesma norma determina quais as medidas básicas que devem tomadas para o licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores. O licenciamento ambiental é um dos diferentes procedimentos de controle ambiental, adotados pelo Estado, cujo objetivo é assegurar que as atividades a ele submetidas gerem o menor impacto ambiental possível. O procedimento e licenciamento ambiental têm origem a requerimento do interessado, ou de ofício, e se encerra com a concessão ou a negativa do Alvará respectivo, isto é, uma licença ou autorização ambiental, conforme o caso.

A licença ambiental não é uma licença de Direito Administrativo, haja vista que possui algumas diferenças marcantes em relação à licença administrativa. As licenças de direito administrativo, uma vez concedidas, passam a integrar o patrimônio jurídico de seu titular como direito adquirido. Em tais circunstâncias, somente poderão ser revogadas pela infração às normas legais. Celso Antônio Bandeira de Mello (1991, p. 23) afirma, sobre a licença, que: “Uma vez cumpridas as exigências legais, a Administração não pode negá-la”.

O licenciamento ambiental, como regra, é constituído por um conjunto de licenças que se sucedem no tempo, na medida em que tenham sido cumpridas as condicionantes apostas à licença. A redução da licença ambiental à condição de simples autorização é um elemento grave de instabilidade econômica, haja vista que grande parte dos empreendimentos submetidos ao regime de licenciamento ambiental demanda investimentos elevados, os quais nem sempre possuem retorno rápido. Assim, a instabilidade das licenças ambientais atua como um desincentivo à atividade econômica, o que prejudica toda a sociedade. O licenciamento a prazo determinado tem a grande vantagem de evitar que se cristalizem situações nas quais os padrões de emissões e de lançamento de efluentes já tenham sido superados tecnologicamente e que possam ser substituídos por outros, inclusive sem prejuízo econômico para o empreendedor.

A questão referente aos direitos outorgados pela licença para o seu titular pode ser assim resumida: No prazo de validade da licença, a modificação de padrões de emissões e de lançamento de efluentes não é oponível ao titular de uma licença válida e que esteja sendo cumprida de acordo com as determinações nela contidas. Encerrada a licença, cabível a exigência de modificação dos padrões, com vistas ao cumprimento dos novos índices. Entretanto, a exigibilidade dos novos padrões não é uma questão meramente jurídica, dependendo de inúmeros outros fatores que necessitam ser levados em consideração pelas autoridades ambientais. Passo a examinar alguns: (i) padrão construtivo. É comum que as instalações industriais sejam projetadas e construídas de forma a possibilitar a implantação da tecnologia escolhida à época da construção. Isso implica em que, nem sempre, as plantas industriais possam ser adaptadas facilmente às tecnologias mais modernas; (ii) dificuldades econômicas da empresa etc. Resulta daí que a negociação é o melhor caminho para assegurar o aprimoramento dos padrões efetivos de proteção ambiental.

O sistema de licenciamento ambiental é essencialmente preventivo e não pode se esgotar na mera concessão das licenças, como tem ocorrido na prática. O acompanhamento das licenças concedidas e as performances ambientais são objetivos a alcançar. O excesso de atividades submetidas ao regime de licenciamento, bem como as inúmeras dificuldades burocráticas envolvidas nos procedimentos de licenciamento ambiental fazem com que a parte mais importante, isto é, o controle do desempenho, conforme os termos determinados na licença, simplesmente não acontece.

O licenciamento ambiental é procedimento administrativo complexo que se desenrola em diversas etapas e, em não poucas vezes, perante diferentes órgãos públicos pertencentes a níveis políticos administrativos diversos, o que é motivo de enorme complexidade, sobretudo em função da inexistência de normas claras que regulem as interfaces entre todos eles. Existe, até mesmo, uma previsão constitucional para a adoção de determinados procedimentos obrigatórios a serem observados para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Veja-se a obrigatoriedade constitucional de estudo prévio de impacto ambiental para o licenciamento de atividades potencial ou efetivamente causadoras de significativo impacto sobre o meio ambiente.

ALC nº 140/2011, em boa hora, veio estabelecer mecanismos para que os diferentes entes federativos possam exercer suas atribuições constitucionais de forma harmônica e cooperativa (artigo 13).

Os três níveis federativos guardam competências de licenciamento ambiental, porém, tais competências não serão mais exercidas de forma superposta, ou contraditória, fazendo com que o licenciamento ambiental se transforme em verdadeiro “guessing game”, tais as incertezas que o informam. A própria LC, como já foi visto acima, estabeleceu uma ampla possibilidade de delegação de competências e uma repartição que, muito embora reproduza os critérios contidos na Resolução Conama nº 232/97, avançou na solução de complexas questões referentes ao licenciamento na zona costeira que, não se sabe por que, estava sendo transferido por meio de decisões judiciais cujas fundamentações jurídicas não se sustentavam e, não poucas vezes, estavam em contradição direta com o texto legal contido na Lei da PNMA, cujo exemplo mais claro é a célebre decisão do Rio Itajaí-Açu (STJ, REsp – Recurso Especial 588.022, 1ª Turma, DJU 5/4/2004, p. 217), cujo conteúdo é centralizador.

E, na prática, transferia para o Ibama todos os licenciamentos na zona costeira e mais: atribui ao órgão estadual de meio ambiente competência supletiva em matéria de licenciamento ambiental, o que afronta literal disposição da antiga redação do artigo 10 da Lei nº 6.938/81. A LC nº 140/2011 deu tratamento a matéria e, de forma muito clara, conforme consta de seus artigos 2º e 15. Assim, a supletividade está claramente definida e, espera-se, diminuam as inúmeras demandas civis públicas ajuizadas com o único fundamento da incompetência do órgão licenciador e que pouco benefício trazem para a proteção ambiental, principalmente em função dos efeitos negativos, tais como (i) aumento da centralização federativa; (ii) transferência para o Ibama do licenciamento de toda uma série de questões de pouquíssima relevância nacional ou regional, sem que o órgão tenha atribuição ou capacidade técnica institucional para delas cuidar, dispersando os esforços do órgão de controle ambiental federal. No que diz respeito à Zona Costeira, da mesma forma, a LC dispôs adequadamente, dispondo o parágrafo único do artigo 7º.

3.5.3.1 Natureza e alcance da Licença Prévia

A LP conforme definido na maior parte da legislação brasileira, tanto federal quanto dos Estados e Municípios é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação. Logo, não autoriza qualquer intervenção sobre o meio ambiente, obra ou atividade que possa vir a comprometer os atributos ambientais de qualquer local ou região e, por si só, “não representa agressão ao meio ambiente, pois se trata de ato administrativo que permite o detalhamento do projeto de construção da obra”. (TRF 1ª Região. AGRSLT – Agravo Regimental na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela 00388264720114010000, Relator Desembargador Federal Olindo Menezes. Corte Especial. e-DJFI: 20/03/2012, p. 11). Em outras palavras, o que se aprova é um projeto conceitual a ser detalhado na fase de obtenção da Licença de Instalação, conforme as condicionantes estabelecidas na própria LP.

Portanto, a primeira função básica da LP é aprovar a localização. Note-se que aqui se cuida de macrolocalização, pois a microlocalização das unidades a serem construídas será definida nas condicionantes e nos estudos para a obtenção da LI, em especial no Plano Básico Ambiental [PBA].

A concepção do projeto é a segunda função básica da LP que, em linhas gerais, é o que se pretende construir, os seus aspectos mais amplos – que serão detalhados no projeto executivo – a serem submetidos às condicionantes apostas na licença prévia. Por sua vez, a viabilidade ambiental (terceira função básica) é a possibilidade de que o projeto seja implementado sem que dele resultem agressões ao meio ambiente maiores do que os benefícios resultantes de sua consecução. A viabilidade ambiental não se confunde com a “poluição zero”, pois de todo projeto a ser implantado haverá algum grau de dano ambiental, o qual, como se sabe, divide-se em (i) recuperável, (ii) mitigável e (iii) compensável. Veja-se que a própria lei do SNUC estabeleceu uma presunção de dano compensável quando os empreendimentos – precedidos de estudo prévio de impacto ambiental (caso presente) – deverão arcar com a compensação ambiental.

É relevante anotar que o licenciamento ambiental é um procedimento dinâmico e que a LP é apenas uma medida vestibular que, após uma concordância geral com a (i) localização, (ii) viabilidade ambiental e (iii) concepção, abre caminho para o detalhamento do projeto sobre o território e dos requisitos de conservação

ambiental que deverão ser atendidos.

A matéria relativa à concessão de LP pelas autoridades ambientais já mereceu apreciação pelo STF, conforme se vê da decisão do Eminentíssimo Ministro Sepúlveda Pertence (ACO 876 MC, Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 18/12/2006, publicado em *DJ* 01/02/2007, p. 148), que para concessão da Licença Prévia basta que os esclarecimentos porventura solicitados sobre os estudos apresentados sejam considerados satisfatórios pelo órgão licenciador, pois nesse momento do procedimento de licenciamento são estabelecidos os requisitos básicos e as condicionantes a serem atendidas nas próximas fases de implementação do empreendimento.

3.5.3.2 *Localização do estudo prévio de impacto ambiental no processo de licenciamento ambiental*

3.5.3.2.1 O marco jurídico

A CF, em seu artigo 225, § 1º, IV, estabelece que incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, “*para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade*”. Do ponto de vista constitucional, a questão se divide em três aspectos relevantes: (i) o poder público deve estabelecer o conceito de obra ou instalação capaz de causar *significativa* degradação ambiental; (ii) verificar se o empreendimento em questão é potencialmente capaz de produzir a significativa degradação ambiental; e (iii) se presente a segunda condição, cabe exigir do empreendedor a apresentação de EIA.

A norma constitucional é clara e não admite outra interpretação: os estudos de impacto ambiental devem ser exigidos *antes da instalação* de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. A *Constituição não exige*, e nem é o seu papel fazê-lo, que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental seja apresentado logo no *início* do processo de licenciamento ambiental, ou seja, antes mesmo da concessão de LP.

A Lei Federal nº 6.938/81, em seu artigo 9º, estabelece os instrumentos da PNMA e, expressamente, dá ao licenciamento ambiental a condição de seu instrumento, conforme a redação do inciso IV. Decorre daí que o Decreto Federal nº 99.274/90, ao regulamentar a Lei nº 6.938/81, estabeleceu uma tripartição no licenciamento ambiental que se faz mediante a concessão de três licenças distintas que são outorgadas *de acordo com as diferentes etapas de planejamento da atividade pretendida. De acordo com o artigo 19 do Decreto Federal nº 99.274/90: A LP é concedida na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; Já a LI autoriza o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e a LO, autoriza, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.*

Pela norma regulamentadora (Decreto 99.274/90), a LP corresponde à fase preliminar, momento em que ainda não existem elementos suficientes para a realização do estudo prévio de impacto ambiental, dentre os quais, por exemplo, o Projeto Básico do empreendimento a ser desenvolvido e, muito menos, existe uma relação de estudos requeridos pelos órgãos técnicos, tais como sondagens, levantamentos de solo, água, flora e fauna e tantos outros.

Em nível procedimental, a Resolução Conama nº 01/86 define as hipóteses exemplificativas nas quais o estudo prévio de impacto ambiental é exigível e, no que tange ao licenciamento ambiental propriamente dito, é determinado que: os órgãos ambientais *devem compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente (artigo 4º)*. Veja-se, ademais, que o artigo 9º da Resolução Conama 001/86 determina que o EIA deva analisar o projeto que, como se sabe, só é plenamente definido após a concessão da LP. Mesmo a Resolução Conama 237/1997, que deu tratamento mais completo ao licenciamento ambiental – aplicável aos órgãos federais ou aos Estados e Municípios que não tenham tratado do tema em normas próprias –, não alterou as condições básicas acima descritas e, nem poderia, haja vista que não lhe caberia contrariar a Constituição ou a lei, ou mesmo o decreto presidencial.

O Conama pela Resolução nº 237 (art. 10), estabeleceu, apenas, que o processo de licenciamento ambiental deverá contemplar determinadas etapas que deverão ser condizentes com o planejamento do projeto a ser implantado. Logo, não há qualquer exigência no sentido de que o EIA deva anteceder a LP. Ele deve ser anterior à implantação do projeto ou atividade.

3.5.4 O licenciamento federal

O licenciamento ambiental federal é efetivado perante o Ibama e vem crescendo de importância gradativamente, com um esvaziamento dos entes federativos, que veem os seus órgãos ambientais extremamente diminuídos. A edição da LC nº 140/2011, pode significar uma mudança de tendência, eis que ela busca ampliar a descentralização administrativa, mediante a adoção de mecanismos de cooperação entre os diferentes entes federativos.

O licenciamento ambiental é atividade tipicamente administrativa, sendo certo que, no âmbito federal, o artigo 7º da LC nº 140/2011 assim determinou:

- promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades;
- localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
- localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;
- localizados ou desenvolvidos em TIs;
- localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs;
- localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
- de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97/1999;
- destinados a pesquisar, lavar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da CNEN;
- que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento;
- aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União.

É necessário que se atente para o fato de que o licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento (art. 7º, parágrafo único).

A relação acima tem dado margem a que os órgãos federais licenciem diversas atividades, das quais podem ser destacadas as seguintes: Usinas Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas, Mineração, Linhas de Transmissão, Usinas Termelétricas, Ferrovias, Hidrovias, Pontes, Portos, Dragagens, Dutos, Empreendimentos Militares, Exploração de Calcário Marinho, Nuclear. Com exceção daquelas atividades que, por lei, estão claramente incluídas na competência federal para licenciamento, não é simples a identificação do órgão competente para o processo de concessão de licença. Vários critérios têm sido tentados. Contudo, as contradições legislativas são de tal ordem que a norma é a imprecisão:

“As próprias normas são contraditórias. Algumas utilizam a localização do empreendimento ou da atividade como critério para definir a competência.

O que se tem observado é que a amplitude das normas vigentes até a edição de LC nº 140/2011 fazia com que, na prática, existisse uma preempção do Ibama sobre os órgãos estaduais, como marca indelével de uma tendência centralizadora.

No dia 23 de abril de 2015, foi publicado o Decreto Federal nº 8.437, que veio regulamentar justamente o artigo 7º, *caput*, inciso XIV, alínea “h” e parágrafo único, da LC nº 140/2011, para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento deverá ser conduzido pela União.

No artigo 3º do Decreto nº 8.437/2015 estabelece-se que as seguintes atividades e empreendimentos serão licenciados pelo órgão ambiental federal:

- I – **rodovias federais:** a) implantação; b) pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a duzentos quilômetros; c) regularização ambiental de rodovias pavimentadas, podendo ser contemplada a autorização para as atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração, ampliação de capacidade e melhoramento; e d) atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração e melhoramento em rodovias federais regularizadas;
- II – **ferrovias federais:** a) implantação; b) ampliação de capacidade; e c) regularização ambiental de ferrovias federais;
- III – **hidrovias federais:** a) implantação; e b) ampliação de capacidade cujo somatório dos trechos de intervenções seja igual ou superior a duzentos quilômetros de extensão;
- IV – **portos organizados**, exceto as instalações portuárias que movimentem carga em volume inferior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano;
- V – **terminais de uso privado e instalações portuárias** que movimentem carga em volume superior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano;
- VI – **exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos** nas seguintes hipóteses: a) exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição sísmica, coleta de dados de fundo (*piston core*), perfuração de poços e teste de longa duração quando realizadas no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (*offshore*); b) produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação de sistemas de produção e escoamento, quando realizada no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (*offshore*); e c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (*offshore*) ou terrestre (*onshore*), compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento; e
- VII – **sistemas de geração e transmissão de energia elétrica**, quais sejam: a) usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos megawatts; b) usinas termelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos megawatts; e c) usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades *offshore* e zona de transição terra-mar.

Vale ressaltar que, em relação à implantação e pavimentação e ampliação de rodovias federais, a competência ambiental federal não se aplica nos casos de contornos e acessos rodoviários, anéis viários e travessias urbanas. Da mesma forma em relação às ferrovias federais, a competência federal não se aplica nos casos de implantação e ampliação de pátios ferroviários, melhoramentos de ferrovias, implantação e ampliação de estruturas de apoio de ferrovias, ramais e contornos ferroviários.

O Decreto Federal nº 8.437/2015 estabeleceu que os processos de licenciamento e autorização ambiental das atividades e empreendimentos, classificados na tipologia, iniciados em data anterior à publicação do Decreto (23/04/2015), terão sua tramitação mantida perante os órgãos originários até o término da vigência da licença de operação, cuja renovação caberá ao ente federativo competente. Caso o pedido de renovação da licença de operação tenha sido protocolado no órgão ambiental originário em data anterior à 23/04/2015, a renovação caberá ao referido órgão. Já os pedidos de renovação posteriores à data da publicação do Decreto serão realizados pelos entes federativos competentes, nos termos do Decreto Federal nº 8.437/2015.

A CF de 1988 adotou *federalismo cooperativo*, deixando claro que os diferentes integrantes da federação, embora autônomos, devem partilhar responsabilidades em relação à proteção do meio ambiente. Tais responsabilidades vão desde a competência legislativa até a competência de implementação ou de execução (MILARÉ, 2005, p. 541). Contudo, há que se observar que, ainda que esse tenha sido um comando do Constituinte originário ao legislador, tanto o complementar quanto o originário, o Legislador, contudo, não observou o determinado pelo autor do pacto fundante.

Em nível constitucional, o licenciamento ambiental – parcela do poder de polícia administrativo-ambiental – é tratado como matéria de competência comum dos entes da federação, disciplinada pelo artigo 23, inciso VI, da CF. O licenciamento ambiental é atividade administrativa com caráter essencialmente tutelar e, assim, compreende-se no âmbito de competência de implementação, e, portanto, na chamada competência comum e como tal exercida pelos três níveis federativos. A PNMA ainda que elaborada em regime constitucional diverso, busca dar organicidade ao relacionamento político institucional entre os diferentes entes políticos federados, articulando-os em um regime de colaboração recíproca com a formulação de um modelo capaz de integrá-los com vistas a racionalizar esforços, poupar recursos e aumentar a eficiência da proteção ao meio ambiente, mediante a adoção de ações descentralizadas. Em princípio, do ponto de vista administrativo, tal articulação se encontra perfeitamente compatível com os princípios presentes no *caput* do artigo 37 da CF, no que se refere à eficiência administrativa.

É com vistas a alcançar a eficiência que a Lei nº 6.938/81, em seu artigo 10, definiu uma repartição de competências ambientais para o licenciamento, as quais foram revogadas com a nova redação do artigo, dada pela LC nº 140/2011. A LC manteve o critério que anteriormente fora adotado como critério geral: a fixação da competência dos estados para o licenciamento ambiental. É verdade que a LC, assim como a antiga redação da Lei da PNMA, admite que o Ibama possa exercer o licenciamento ambiental em caráter supletivo, ou seja, excepcionalmente, condição na qual deve ser compreendido o licenciamento de caráter nacional ou regional. Admitiu-se, também, que os estados possam agir supletivamente aos municípios. A “estadualização” do licenciamento ambiental corresponde à salutar medida de descentralização administrativa e de consequente economia de recursos públicos e privados. Todavia, com a publicação do Decreto nº 8.437/2015, identificamos uma busca pela centralização do licenciamento ambiental em âmbito federal.

A LC nº 140/2011 estabelece ampla delegabilidade do licenciamento ambiental. Assim, mesmo nos casos nos quais o licenciamento seja de empreendimentos de caráter regional, ou nacional, não há qualquer obstáculo para a sua realização pelo órgão estadual, ou pelos órgãos municipais, conforme a hipótese, desde que observadas as regras para a delegação.

Como se observa, trataram referidos diplomas sobre normas federais básicas para a uniformização do licenciamento ambiental em todo o território nacional, referendando a descentralização de sua outorga, que ficou entregue fundamentalmente aos órgãos estaduais. Posteriormente, a Constituição de 1988, recepcionando a Lei nº 6.938/81, deixou claro que os diversos entes da Federação compartilham responsabilidades sobre a condução das questões ambientais, tanto no que tange à competência legislativa, quanto no que diz respeito à competência dita implementadora ou de execução (competência administrativa).

Assim, integrando o licenciamento o âmbito da competência de implementação, os três níveis de governo estão habilitados a licenciar empreendimentos com impactos ambientais, cabendo, portanto, a cada um dos entes integrantes do sistema nacional do meio ambiente, promover a adequação de sua estrutura administrativa com o objetivo de cumprir essa função, que decorre diretamente da Constituição.

Em nível federal, as principais diretrizes quanto ao licenciamento ambiental se encontram no Decreto nº 99.274/1990, que vem sendo complementado por uma grande quantidade de Resoluções, Portarias e Instruções Normativas além de outras normas administrativas.

O Conama deverá fixar os critérios básicos a serem observados no processo de licenciamento ambiental, nos quais deverá ser exigido que conste dos estudos ambientais:

- o diagnóstico ambiental;

- descrição da ação proposta e suas alternativas;
- identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos.

ALC nº 140/2011 veio corroborar o nosso entendimento sobre a matéria ao determinar que a atuação supletiva é a substituição de um órgão por outro, de acordo com previsão expressa, que pode ser: (i) excessiva demora na concessão da licença ambiental; (ii) inexistência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no ente federativo competente para o licenciamento.

ALC criou, ainda, a chamada *ação subsidiária* que é uma forma de apoio técnico, financeiro e científico para o desempenho das competências administrativas em matéria ambiental.

3.5.4.1 Procedimento

O procedimento-padrão de licenciamento ambiental compreende a concessão de duas licenças preliminares e a licença final que o encerra. Essas licenças são (Decreto nº 99.274/1990):

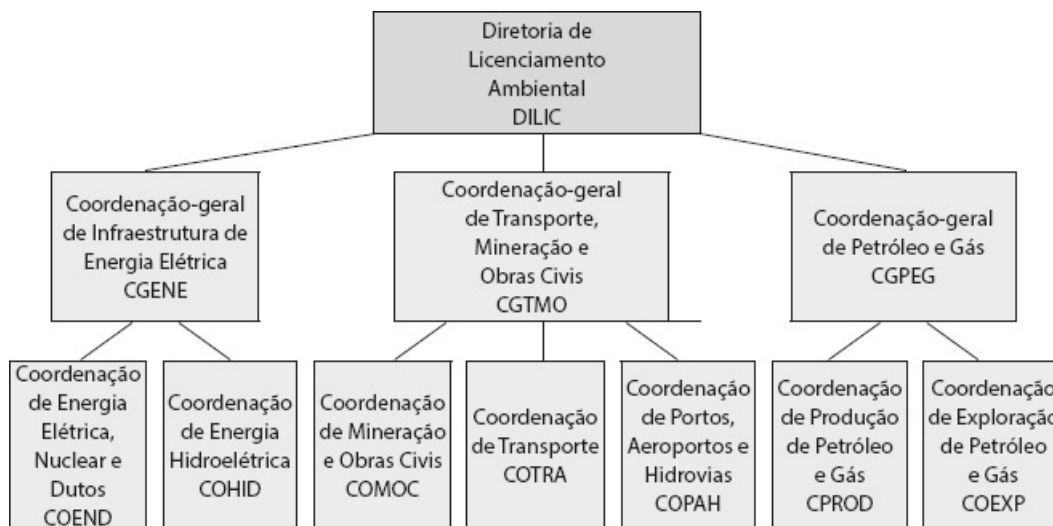
- I – LP, na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais do uso do solo.
- II – LI, autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado.
- III – LO, autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação.

Penso que não existe uma obrigação para que as licenças sejam concedidas em sequência. Muitas vezes, não há a necessidade concreta de que uma ou outra licença seja concedida. Nem sempre há a necessidade de uma LP, por exemplo. Em diversas hipóteses, serão necessárias outras licenças diferentes.

3.5.4.2 Responsabilidade pela emissão das licenças ambientais

A grande polêmica relacionada à concessão de licenças ambientais que, seguidamente, tem acarretado o ajuizamento das mais diversas ações judiciais em face de servidores dos órgãos ambientais implicou a elaboração da Lei nº 11.516/2007, que em seu artigo 13 estabelece que a responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de parecer técnico conclusivo visando à emissão de licença ambiental prévia por parte do Ibama será exclusiva de órgão colegiado do referido Instituto, estabelecido em regulamento.

Com isso, o legislador buscou afastar a responsabilidade individual do servidor público e diluí-la entre os diferentes membros do colegiado que emitiram o parecer técnico que deu embasamento à emissão da licença ambiental. A medida responde a uma situação de fato na qual os órgãos administrativos chegaram à quase paralisação no que diz respeito à emissão de licenças, tendo em vista o potencial “risco” para os funcionários que as assinassem.



3.5.4.3 O sistema estabelecido pela LC nº 140, de 8 de dezembro de 2011

As grandes dificuldades existentes no processo de licenciamento ambiental, decorrentes, em grande parte, de uma incompreensão da Lei nº 6.938/81, acarretaram que, muitas vezes, fossem exigidas dos empreendedores diferentes licenças ambientais. Tal situação, evidentemente, não poderá prosseguir, em razão dos seus elevados custos e de sua irracionalidade latente. A ausência da LC tratada no artigo 23 da CF fazia com que todas as questões se tornassem mais complexas e a insegurança jurídica fosse uma característica marcante de nosso sistema legal de proteção ao meio ambiente.

ALC determinou a repartição para o licenciamento ambiental.

Federal	Estadual	Municipal
• exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União; • promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: (i) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; (ii) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; (iii) localizados ou desenvolvidos	• exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados; • promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,	• exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município; • observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos: (i) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio

em terras indígenas; (iv) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (v) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; (vi) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97, de 9 de junho de 1999; (vii) destinados a pesquisar, lavar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); ou (viii) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento; • aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessionais em: (i) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e (ii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União.	ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º; • promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); • aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessionais em: (i) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (ii) imóveis, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º; e (iii) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado.	Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou (ii) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); • observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas na LC, aprovar: (i) a supressão e o manejo de vegetação, de floresta e formações rurais, sucessionais em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e (ii) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessionais em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
---	---	--

O Licenciamento ambiental deverá ser feito em apenas um nível federativo, tal como determinado pelo artigo 13 da LC nº 140/2011, cabendo aos demais entes federativos interessados manifestarem-se sem efeito vinculante, observados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Aqui cabe uma indagação: qual o efeito da norma ora examinada sobre o artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 que disciplina o SNUC? Como se sabe, o mencionado artigo 36 determina em seu § 3º que os gestores das unidades de conservação devem dar o seu *nihil obstat* para projetos que possam afetar as unidades de conservação por eles geridas. Ora, a LC, acertadamente, determinou que o parecer de ente federativo diverso daquele que está licenciando uma atividade não tem efeito vinculante – consequência lógica do regime federativo –, assim, o parecer oferecido por uma unidade de conservação integrante de outra esfera administrativa não obriga àquela que está licenciando, o que modera os efeitos do poder de veto que passa a ser aplicável apenas quando a Unidade de Conservação afetada e o órgão licenciador forem do mesmo nível federativo.

3.5.4.4 Intervenção de órgãos externos no licenciamento ambiental

A intervenção de órgãos externos ao sistema ambiental nos procedimentos de licenciamento ambiental é tema complexo e tem gerado muita controvérsia. Como sabemos, o licenciamento ambiental é procedimento administrativo complexo, no qual pode ser necessária a intervenção de diversos órgãos públicos além daqueles responsáveis diretamente pelo licenciamento ambiental. Normalmente a intervenção dos órgãos externos tem por objetivo resguardar bens que poderão ser afetados negativamente pelo empreendimento em implantação. Os órgãos externos, em princípio, não estão autorizados a emitir opiniões sobre os impactos ambientais, especificamente aqueles que dizem respeito ao meio biótico. Contudo, devido ao fato de que o conceito de meio ambiente é extremamente amplo, há uma tendência de os órgãos externos ao sistema de licenciamento ambiental ampliarem o seu nível de participação e seguidamente, opinarem sobre questões que se situam em um “limbo”, ou zona cinzenta, sem que se saiba exatamente onde começa a atribuição de cada órgão. Para dar solução a tais problemas, foi editada a Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011. Em 23 de março de 2015, foi publicada a Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS nº 60, de 24 e março de 2015, que revogou expressamente a Portaria nº 419/2011 para passar a disciplinar a matéria. Logo após foram publicadas outras três Instruções Normativas relevantes:

- **IN MC/FCP nº 01, de 25 de março de 2015**, que estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares nos Processos de licenciamento ambiental dos quais participe.
- **IN IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015**, que estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.
- **IN FUNAI nº 02, de 27 de março de 2015**, que estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, quando instada a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

3.5.4.4.1 Normas gerais

Para os fins de aplicação da Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/ MS nº 60/2015 foram adotadas as seguintes definições (art. 2º):

- estudos ambientais: estudos referentes aos aspectos ambientais relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida;

- bens culturais acautelados em âmbito federal: a) bens culturais protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961; b) bens tombados nos termos do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; c) bens registrados nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; e d) bens valorados nos termos da Lei nº 11.483/2007;
- Ficha de Caracterização da Atividade – FCA: documento apresentado pelo empreendedor, em conformidade com o modelo indicado pelo Ibama, em que são descritos: a) os principais elementos que caracterizam a atividade ou o empreendimento; b) a área de localização da atividade ou empreendimento, com as coordenadas geográficas e o *shapefile*; c) a existência de intervenção em terra indígena ou terra quilombola, observados os limites definidos pela legislação; d) a intervenção em bem cultural acautelado, considerada a área de influência direta da atividade ou do empreendimento; e) a intervenção em unidade de conservação, compreendendo sua respectiva zona de amortecimento; f) as informações acerca da justificativa da implantação do projeto, de seu porte, da tecnologia empregada, dos principais aspectos ambientais envolvidos e da existência ou não de estudos, entre outras informações; e g) a existência de municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária;
- licença ambiental: procedimento administrativo pelo qual o Ibama estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental;
- licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o Ibama licencia a localização, instalação, ampliação e operação de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, consideradas as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;
- órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental: o órgão e as entidades públicas federais (Fundação Cultural Palmares – FCP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e Ministério da Saúde), incumbidos da elaboração de parecer sobre temas de sua competência, nos processos de licenciamento ambiental conduzidos pelo Ibama;
- Projeto Básico Ambiental – PBA: conjunto de planos e programas identificados a partir da elaboração dos estudos ambientais, com cronograma executivo, plano de trabalho operacional e definição das ações a serem desenvolvidas nas etapas de implantação e operação da atividade ou empreendimento e ainda monitoramento de indicadores ambientais;
- regiões endêmicas de malária: compreende os municípios localizados em áreas de risco ou endêmicas de malária, identificados pelo Ministério da Saúde;
- Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID: documento que identifica e delimita o território quilombola a partir de informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas e antropológicas, conforme disposto em Instrução Normativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA;
- termo de referência (TR): documento elaborado pelo Ibama que estabelece o conteúdo necessário dos estudos a serem apresentados em processo de licenciamento ambiental e que contempla os conteúdos apontados pelos Termos de Referência Específicos;
- termos de referência específico (TRE): documentos elaborados pelos órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos no licenciamento ambiental que estabelecem o conteúdo necessário para análise dos impactos afetos a cada órgão ou entidade;
- terra indígena: a) áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União; b) áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios isolados, publicada no Diário Oficial da União; e c) demais modalidades previstas no art. 17 da Lei nº 6.001/1973;
- terra quilombola: as áreas ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, que tenha sido reconhecida pelo Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, devidamente publicado.

Cabe ao Ibama, no início do procedimento de licenciamento ambiental, conforme constar da Ficha de Caracterização da Atividade – FCA, solicitar informações ao empreendedor sobre possíveis interferências em terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária, com vistas a identificar a necessidade de intervenção de outros órgãos no licenciamento ambiental. Havendo omissão das informações solicitadas na FCA, o Ibama deverá informá-la às autoridades competentes para a apuração da responsabilidade do empreendedor, na forma da legislação em vigor.

A Portaria estabeleceu uma presunção de interferência nos seguintes casos: (i) em terra indígena quando a atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em terra indígena ou apresentar elementos que possam gerar dano socioambiental direto no interior da terra indígena, respeitados os limites do Anexo I da Portaria; (ii) quando a atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em terra quilombola ou apresentar elementos que possam gerar dano socioambiental direto no interior da terra quilombola, respeitados os limites do Anexo I da Portaria; (iii) quando a área de influência direta da atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se numa área onde for constatada ocorrência de bens culturais acautelados; (iv) quando a atividade ou empreendimento localizar-se em municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária.

O termo de referência do estudo ambiental exigido pelo Ibama para o licenciamento ambiental deverá trazer as exigências de informações ou de estudos específicos referentes à interferência da atividade ou empreendimento em terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais acautelados e em municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária; assim como deverá ser dada especial atenção aos aspectos locais e de traçado da atividade ou empreendimento, bem como as medidas para a mitigação e o controle dos impactos a serem consideradas pelo Ibama quando da emissão das licenças pertinentes.

3.5.4.4.2 Procedimentos e prazos

A intervenção dos órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental para a definição do conteúdo do TR, de que trata o art. 4º da Portaria, deverá observar os termos de referência específicos constantes de Anexo e mais:

- o Ibama encaminhará, em até 10 (dez) dias consecutivos, a partir do requerimento de licenciamento ambiental, a solicitação de manifestação dos órgãos e entidades envolvidos, disponibilizando a Ficha de Caracterização Ambiental em seu sítio eletrônico oficial;
- os órgãos e entidades envolvidos deverão manifestar-se ao Ibama no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento da solicitação de manifestação.

Admite-se que, em casos excepcionais devidamente justificados e, a pedido do órgão ou entidade envolvido, o Ibama poderá prorrogar em até 10 (dez) dias o prazo para a entrega da manifestação; uma vez expirado o prazo estabelecido aqui mencionado, o Termo de Referência será considerado consolidado, dando-se prosseguimento ao procedimento de licenciamento ambiental.

Os órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental deverão apresentar ao Ibama manifestação conclusiva sobre o Estudo Ambiental exigido para o licenciamento, nos prazos de até 90 (noventa) dias no caso de EIA/RIMA e de até 30 (trinta dias) nos demais casos, a contar da data do recebimento da solicitação, considerando:

- Fundação Nacional do Índio: FUNAI – a avaliação dos impactos provocados pela atividade ou pelo empreendimento em terras indígenas e a apreciação da adequação das propostas de medidas de controle e de mitigação decorrentes desses impactos.
- Fundação Cultural Palmares – avaliação dos impactos provocados pela atividade ou empreendimento em terra quilombola, bem como apreciação da

adequação das propostas de medidas de controle e de mitigação decorrentes desses impactos.

- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN – a avaliação dos impactos provocados pela atividade ou pelo empreendimento nos bens culturais acautelados de que trata esta Portaria e a apreciação da adequação das propostas de medidas de controle e de mitigação decorrentes desses impactos.
- Ministério da Saúde – Avaliação e recomendação acerca dos impactos sobre os fatores de risco para a ocorrência de casos de malária, no caso de atividade ou empreendimento localizado em áreas endêmicas de malária.

No período antecedente a emissão das licenças de instalação e operação, é facultado ao Ibama solicitar manifestação dos órgãos e entidades envolvidos, quanto ao cumprimento das condicionantes das licenças expedidas anteriormente, bem como quanto aos estudos, planos e programas pertinentes à fase do licenciamento em curso, os quais terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da solicitação do Ibama, para oferecer resposta.

Iphan	Funai	F. C. Palmares	Centro Tamar	Ministério da Saúde	Gestor Unidade de Conservação da Instrução Normativa
Portaria nº 28 de 31/1/2003	IN Funai nº 02, de 27/03/2015	Decreto nº 4.887, de 20/11/2003	Resolução Conama nº 10, de 24/10/1996		ICMBio nº 7, de 5/11/2014
IN IPHAN nº 01, de 25/03/2015		IN nº 57, de 20/10/2009			Resolução Conama nº 428, de 17/12/2010
		Portaria nº 98, de 26/11/2007			
		Instrução Normativa MC/FCP nº 01, de 25/03/2015			

3.5.4.4.3 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN

Normas aplicáveis:

Portaria nº 28, de 31 de janeiro de 2003: Resolve que os empreendimentos hidrelétricos dentro do território nacional para a renovação da licença ambiental de operação devem prever a execução de projetos de levantamento, prospecção, resgate e salvamento arqueológico.

IN IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015: Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

Portaria Interministerial nº 69, de 23 de janeiro de 1989: Aprova normas comuns sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar.

Portaria nº 007, de 1º de dezembro de 1988: Estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios previstos na Lei nº 3.924/1961.

Portaria nº 187, de 11 de junho de 2010: Dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado, a imposição de sanções, os meios de defesa, o sistema recursal e a forma de cobrança dos débitos decorrentes das infrações.

3.5.4.4.4 Fundação Cultural Palmares

A Fundação Cultural Palmares é uma entidade instituída pelo governo federal em 1988, cujos objetivos estatutários são promover e preservar a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade racial e com a valorização das manifestações de matriz africana, mediante a formulação e implantação de políticas públicas que potencializam a participação da população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País. Dentre as principais atividades da Fundação Cultural Palmares está a identificação e regularização dos quilombos de acordo com expressa determinação constitucional. A matéria é importante, pois as comunidades quilombolas podem ser enquadradas como “populações tradicionais” e, portanto, albergadas pela CDB.

Legislação aplicável:

Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 – Regulamenta a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes dos quilombos.

IN nº 57, de 20 de outubro de 2009 – Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007 – Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares, também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, Mocambos, Quilombos, dentre outras denominações congêneres.

IN MC/FCP nº 01, de 25 de março de 2015 – Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural Palmares nos Processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

3.5.4.4.5 Gestor de Unidade de Conservação

A Lei do SNUC estabelece no § 3º do artigo 36 que:

quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração [...].

No âmbito federal, o Instituto Chico Mendes regulamentou a matéria mediante a expedição da IN ICMBio nº 7, de 5 de novembro de 2014.

O órgão gestor da unidade de conservação afetada poderá vetar um determinado projeto caso entenda que ele é capaz de gerar impactos inadmissíveis na área protegida.

Norma aplicável:

Resolução Conama nº 428, de 17 de dezembro de 2010 – *Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.*

3.5.4.4.6 Centro de Tartarugas Marinhas – Centro Tamar

O Centro destinado ao estudo e a proteção das tartarugas marinhas, Centro Tamar, com o desmembramento do Ibama, passou a integrar a estrutura administrativa do ICMBio e, nas hipóteses nas quais os empreendimentos a serem implantados estejam próximos a áreas nas quais se encontrem quelônios, deverá ser ouvido, como fator de validade do licenciamento ambiental. Diferentemente da hipótese da oitiva do órgão gestor de unidades de conservação, aqui não há poder de veto.

Norma aplicável:

Resolução Conama nº 10, de 24 de outubro de 1996 – Regulamenta o licenciamento ambiental em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas.

3.5.4.5 Conflitos entre os diferentes órgãos intervenientes no licenciamento ambiental

Diante da grande quantidade de órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental é bastante comum que entre eles se estabeleçam conflitos interadministrativos não referentes às atribuições legais de cada um deles, bem como sobre o mérito das intervenções. Figure-se a hipótese de que o órgão gestor de uma unidade de conservação vete a implantação de determinado projeto, por supostos danos irreversíveis à unidade de conservação sob sua tutela e que, contrariamente, o órgão licenciador entenda que o impacto é mitigável. Quando se tratar de uma controvérsia entre órgãos de diferentes níveis político-administrativos, o nosso regime jurídico não possui um mecanismo institucional apto a dirimir a controvérsia que, assim, sai do nível técnico e passa para o campo das diversas pressões políticas, com prejuízo para todas as partes envolvidas.

No âmbito federal, felizmente, existe a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal CCAF que, embora pouco acionada, pode desempenhar papel importantíssimo na solução de controvérsias entre órgãos federais em licenciamentos ambientais, a legislação aplicável, no caso é formada pelo (i) Decreto nº 7.392/2010 (artigo 18) e (ii) pela Portaria AGU nº 1.281/2007 (artigo 2º).

3.5.5 Itinerário para o licenciamento

A Resolução Conama nº 237/97 estabeleceu um roteiro mínimo a ser observado nos processos de licenciamento ambiental, roteiro este composto por oito etapas: I – Definição pelo órgão ambiental, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários para o começo do processo de licenciamento. II – Requerimento da licença ambiental, acompanhado da documentação definida no item I – deve ser dada publicidade ao requerimento de licença. III – Análise pelo órgão ambiental. IV – Possibilidade de formulação de pedidos de esclarecimentos pelo órgão ambiental – uma única vez, podendo haver renovação caso os esclarecimentos não sejam satisfatórios. V – Audiência pública, se for o caso. VI – Novos esclarecimentos ao órgão ambiental se, da audiência pública, surgir a necessidade. VII – Emissão de parecer técnico conclusivo e, se for o caso, parecer jurídico. VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido, com a devida publicidade.

Uma medida extremamente importante foi a definida no § 1º do artigo 10, que determina que os requerimentos de licenças ambientais devem vir instruídos com certidão emitida pelo Poder Público municipal, demonstrando que o empreendimento se encontra em conformidade com o zoneamento municipal. Merece aplauso o artigo 14 da Resolução nº 237/97, ao definir prazo para a tramitação dos processos de licenciamento ambiental, evitando-se, dessa forma, os processos que nunca chegavam ao fim. Estabeleceu-se, também, a prorrogação automática das licenças quando estas não forem renovadas no prazo regulamentar, por culpa exclusiva da administração (art. 18, § 4º).

Quanto ao mais, foram mantidos os instrumentos e institutos anteriormente vigentes.

3.5.5.1 Licenciamento de petróleo

O regime jurídico da exploração e produção de petróleo no Brasil foi extremamente modificado com a quebra do monopólio da Petrobrás. Com as modificações constitucionais e legais, que permitiram o ingresso de diversas outras companhias no negócio do petróleo, houve um aumento expressivo do movimento econômico gerado pela atividade, em especial no estado do Rio de Janeiro, que é o maior produtor nacional de petróleo e gás natural.

Logicamente que o aumento da produção, sobretudo com o ingresso de novas áreas produtoras, implica em ampliação do potencial de risco e danos, o que exige medidas de proteção mais apuradas.

A Lei nº 9.478/1997, em seu artigo 1º, IV, determina que: “Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos: [...] IV – proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia [...]”. Os objetivos gerais da política nacional de petróleo têm, na Agência Nacional de Petróleo – ANP, o seu principal garante. É importante observar, também, que a ANP não é estranha às responsabilidades ambientais decorrentes do negócio do petróleo. Assim é que o artigo 8º, IX, da Lei nº 9.478/97, determina, *in verbis*: “Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, cabendo-lhe: [...] IX – fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do meio ambiente [...]”. Nos termos da lei, não há dúvida de que a ANP é dotada de competências ambientais específicas quanto à atividade do setor petrolífero e de gás natural. Penso que, no caso concreto, caso não exista uma coordenação muito clara e precisa entre o Conama, o Ibama e a ANP, poderemos, em breve tempo, estar diante de conflitos interadministrativos muito sérios e relevantes para o meio ambiente e para o prosseguimento das atividades econômicas.

Uma característica bastante interessante é que a legislação que instituiu a ANP admite que os próprios contratos de concessão estabeleçam obrigações de natureza ambiental para serem cumpridas pelas concessionárias, conforme determinado pelo artigo 44, I. O Conama buscou dar tratamento normativo à exploração de petróleo mediante a edição da Resolução nº 23, de 7 de dezembro de 1994, que regulamenta a atividade que denominou como Exproper (Exploração, Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural). O Conama, pela resolução citada, instituiu um conjunto de procedimentos específicos para o licenciamento das atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.

O artigo 2º da Resolução nº 23, de 7 de dezembro de 1994, considera atividade de exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural:

- i) a perfuração de poços para identificação das jazidas e suas extensões;
- ii) a produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica;
- iii) a produção efetiva para fins comerciais.

Nas hipóteses em que a atividade de Exproper se realize em terras indígenas, deverá ser ouvida a autoridade indigenista.

O licenciamento de Exproper possui características próprias e é assim definido:

- i) Licença Prévia para Perfuração – LPper, autorizando a atividade de perfuração e apresentando, o empreendedor, para a concessão deste ato, Relatório de Controle Ambiental – RCA das atividades e a delimitação da área de atuação pretendida;
- ii) Licença Prévia de Produção para Pesquisa – LPpro, autorizando a produção para pesquisa da viabilidade econômica da jazida, apresentando, o empreendedor, para a concessão deste ato, o Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA;
- iii) Licença de Instalação – LI, autorizando, após a aprovação do EIA ou RAA e contemplando outros estudos ambientais existentes na área de interesse, a instalação das unidades e sistemas necessários à produção e ao escoamento;
- iv) Licença de Operação – LO, autorizando, após a aprovação do Projeto de Controle Ambiental – PCA, o início da operação do empreendimento ou das unidades, instalações e sistemas integrantes da atividade, na área de interesse.

O procedimento de licenciamento é feito mediante a utilização dos seguintes instrumentos:

- i) Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo RIMA, de acordo com as diretrizes gerais fixadas pela Resolução/Conama/nº 1, de 23 de janeiro de 1986;
- ii) Relatório de Controle Ambiental – RCA, elaborado pelo empreendedor, contendo a descrição da atividade de perfuração, riscos ambientais, identificação dos impactos e medidas mitigadoras;
- iii) Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, elaborado pelo empreendedor, contendo plano de desenvolvimento da produção para a pesquisa pretendida, com avaliação ambiental e indicação das medidas de controle a serem adotadas;
- iv) Relatório de Avaliação Ambiental – RAA, elaborado pelo empreendedor, contendo diagnóstico ambiental da área onde já se encontra implantada a atividade, descrição dos novos empreendimentos ou ampliações, identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas mitigadoras a serem adotadas, considerando a introdução de outros empreendimentos;
- v) Projeto de Controle Ambiental – PCA, elaborado pelo empreendedor, contendo os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI, com seus respectivos documentos.

Para a perfuração, são necessárias as seguintes licenças:

- I – Licença Prévia para Perfuração – LPper, que deverá ser instruída com os seguintes documentos: (i) Requerimento de Licença Prévia para Perfuração – LPper; (ii) Relatório de Controle Ambiental – RCA; (iii) autorização de desmatamento, quando couber, expedida pelo Ibama; (v) Cópia da publicação do pedido de LPper.
- II – Licença Prévia de Produção para Pesquisa – LPpro, que deverá ser instruída com os seguintes documentos: (i) Requerimento de Licença Prévia de Produção para Pesquisa – LPpro; (ii) Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA; (iii) autorização de desmatamento, quando couber, expedida pelo Ibama; (iv) cópia da publicação do pedido de LPpro.
- III – LI, que deverá ser instruída com os seguintes documentos: (i) Requerimento de LI; (ii) Relatório de Avaliação Ambiental – RAA ou Estudo de Impacto Ambiental – EIA; (iii) Outros estudos ambientais pertinentes, se houver necessidade; (iv) Autorização de desmatamento, quando couber, expedida pelo Ibama; (v) Cópia da publicação de pedido de LI.
- IV – LO: (i) Requerimento de LO; (ii) Projeto de Controle Ambiental – PCA; (iii) cópia da publicação de pedido de LO.

Vale ressaltar que a Portaria MMA nº 422/ 2011 trouxe regras específicas para o licenciamento ambiental federal de atividades e empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar. Há disposições sobre o licenciamento da pesquisa sísmica (Capítulo II da Portaria), licenciamento da perfuração de poços (Capítulo III da Portaria), licenciamento da produção, escoamento de petróleo e gás natural (Capítulo IV da Portaria) e do licenciamento do teste de longa duração (Capítulo IV da Portaria).

3.5.5.2 Licenciamento ambiental para empreendimentos elétricos de pequeno porte

A Resolução Conama nº 279/2001 aplica-se ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos, com pequeno potencial de impacto ambiental, dentre os quais a Resolução destaca:

- i) usinas hidrelétricas e sistemas associados;
- ii) usinas termelétricas e sistemas associados;
- iii) sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e subestações);
- iv) usinas eólicas e outras fontes alternativas de energia.

Muito embora o artigo 1º da Resolução extrapole as competências legais do Conama ao estabelecer que: “os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução aplicam-se em qualquer nível de competência”, matéria de atribuição exclusiva dos entes federativos, pois diz respeito à sua organização interna, a Resolução é meritória, pois facilita procedimentos e processos, diminuindo a burocratização tão característica dos licenciamentos ambientais no Brasil.

Vale ressaltar que a Resolução Conama nº 462/2014 estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre.

3.5.5.2.1 Glossário da Resolução Conama nº 279/2001

A Resolução adotou os seguintes conceitos (art. 2º):

- i) Relatório Ambiental Simplificado – RAS: os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação.
- ii) Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: é o documento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e compensatórias e os programas ambientais propostos no RAS.
- iii) Reunião Técnica Informativa: Reunião promovida pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor, para apresentação e discussão do Relatório Ambiental Simplificado, Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e demais informações, garantidas a consulta e participação pública.
- iv) Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas elétricos, pequenos ramais de gasodutos e outras obras de infraestrutura comprovadamente necessárias à implantação e operação dos empreendimentos.

O Relatório Ambiental Simplificado é uma modalidade de avaliação ambiental, cabível quando o impacto ambiental não tiver a característica de *significativo*, que é a condição constitucional que determina a exigibilidade dos estudos prévios de impacto ambiental. É óbvio que cabe aos órgãos ambientais definir aquilo que se deve ter como, em tese, efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Esse, aliás, é um critério que tem sido adotado desde a Resolução nº 001/86 do Conama.

Ora, se houve a definição de empreendimentos como capaz de causar pequeno impacto ambiental, não há qualquer obrigatoriedade constitucional para que tais empreendimentos sejam precedidos de EIA, pois não caracterizada a efetiva ou potencial *significativa* degradação do meio ambiente.

Deve ser levado em consideração, ademais, que cabe ao órgão ambiental fazer o enquadramento da atividade pretendida dentro dos parâmetros da Resolução nº 279/2001. O empreendedor limita-se a solicitar o enquadramento. Caso este não seja concedido pelo órgão ambiental, o licenciamento seguirá os procedimentos gerais e, considerando-se que a atividade é efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, exigível o EIA.

3.5.5.2.2 Procedimentos

O requerimento de LP deve ser instruído com o Relatório Ambiental Simplificado, que deverá atender, pelo menos, ao conteúdo do Anexo I da Resolução, assim como o registro na Agência Nacional de Energia – ANEEL, quando couber, e pareceres dos órgãos envolvidos. Um elemento importante na Resolução Conama nº 279/2001 é que o § 1º do artigo 3º exige, acompanhando o requerimento de LP, “a declaração de enquadramento do empreendimento” à Resolução, firmada pelo responsável técnico pelo RAS e pelo responsável principal do empreendimento. Essa é uma medida importante, pois elimina análises, muitas vezes, desnecessárias e, ao mesmo tempo, firma a responsabilidade do empreendedor e seus prepostos. É igualmente importante a obrigatoriedade de apresentação do cronograma físico-financeiro a partir da Concessão da Licença de Instalação, destacando-se a data de início das obras.

A expedição da LP condiciona-se à apresentação, quando couber, da outorga de direito de utilização dos recursos hídricos ou da declaração da reserva de disponibilidade hídrica, feitas pelo órgão competente. O requerimento da Licença de Instalação deverá vir acompanhado da comprovação do atendimento das condicionantes da Licença Prévia, do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, e outras informações, quando couber. A LI somente será expedida após a comprovação, quando couber, da Declaração de Utilidade Pública do empreendimento.

3.5.5.2.3 Prazos

O prazo para emissão da LP e da LI é de até 60 dias, contados a partir da data em que o requerimento tenha dado entrada no órgão. Caso sejam necessários estudos ambientais complementares, o prazo para a entrega do Alvará de Licença é suspenso enquanto tais estudos estiverem sendo realizados. Tal suspensão, de 60 dias, poderá ser prorrogada pelo órgão ambiental mediante solicitação fundamentada do empreendedor. Caso os estudos não sejam apresentados no prazo estipulado, o procedimento de licenciamento é arquivado. A Resolução nº 279/2001, em péssima técnica redacional, usa o termo “cancelado”. Ora, só haveria cancelamento se o protocolo fosse alterado, como se o procedimento administrativo nunca houvesse existido, o que não é o caso.

O § 4º do artigo 6º determina que: *A Licença de Instalação perderá sua eficácia caso o empreendimento não inicie sua implementação no prazo indicado pelo empreendedor conforme cronograma apresentado, facultada sua prorrogação pelo órgão ambiental mediante provocação justificada.*

Aplica-se aos empreendimentos que já se encontravam em licenciamento ambiental na data da publicação da Resolução e, desde de que possam ser enquadrados nos seus pressupostos, o licenciamento ambiental simplificado, quando requerido pelo empreendedor.

A LO será emitida pelo órgão ambiental competente no prazo máximo de 60 dias após seu requerimento, desde que tenham sido cumpridas todas as condicionantes da LI, no momento exigíveis, antes da entrada em operação do empreendimento, verificando-se, inclusive, quando for o caso, por meio da realização de testes pré-operacionais necessários, previamente autorizados.

3.5.5.2.4 Reunião técnica informativa

O artigo 8º define a possibilidade da realização de Reunião Técnica Informativa, seja por iniciativa própria do órgão ambiental, ou por solicitação de entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 pessoas maiores de 18 anos. A reunião técnica é uma simplificação da Audiência Pública, prevista para os licenciamentos nos quais o estudo prévio de impacto ambiental é exigido. Assim como a Audiência Pública, não há obrigatoriedade de sua realização, se não for convocada por quem de direito. Todavia, a sua realização é medida salutar. Atendidas as formalidades legais e uma vez convocada, a Reunião Técnica Informativa deve ocorrer em até 20 (vinte) dias após a data de publicação, o mesmo ocorrendo com a publicação do requerimento das licenças pelo empreendedor. Na Reunião Técnica Informativa, é obrigatória a presença do empreendedor, das equipes responsáveis pela elaboração do Relatório Ambiental Simplificado e do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e de representantes do órgão ambiental competente. É assegurado a qualquer cidadão o direito de se manifestar, por escrito, no prazo de 40 dias da publicação do requerimento de licença, cabendo ao órgão ambiental juntar as manifestações ao processo de licenciamento ambiental e considerá-las na fundamentação da emissão da licença ambiental.

3.5.5.2.5 Publicidade

As publicações deverão ser feitas em *Diário Oficial* e em jornal de grande circulação ou outro meio de comunicação amplamente utilizado na região onde se pretende instalar o empreendimento. Delas devem constar: i) a identificação do empreendedor; ii) o local de abrangência; iii) o tipo de empreendimento; e iv) o endereço e telefone do órgão ambiental competente.

Cabe ao empreendedor encaminhar cópia das publicações ao Conselho de Meio Ambiente competente.

A divulgação por meio de rádio, quando determinada pelo órgão ambiental competente ou a critério do empreendedor, deverá ocorrer por, no mínimo, três vezes ao dia durante três dias consecutivos em horário das 6h às 20h.

3.5.5.3 Licenciamento de portos

A matéria está tratada pela Portaria MMA nº 424, de 28 de outubro de 2011. Em primeiro lugar deve-se considerar que existe a presunção de legalidade dos atos administrativos, muito embora esteja bastante claro que o titular do MMA não detém competência legal para dispor sobre licenciamento ambiental, como é a conclusão lógica da simples leitura do inciso I do artigo 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a PNMA.

Assim, de acordo com a **lei hoje vigente**, compete ao Conama, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Admite-se que decreto editado pelo Chefe do Executivo Federal pudesse disciplinar a matéria**, haja vista o disposto no artigo 84, IV, da CF: É interessante observar que o Termo de Referência (TR), anexo à Portaria, se utiliza da expressão “deste Decreto”, talvez por erro de revisão, o que denota que o próprio Executivo não tem segurança em regular a matéria por mera Portaria Ministerial.

Vale ressaltar que, como já explicado em momento anterior, o Decreto Federal nº 8.437/2015, estabelece ser de competência da União o licenciamento de portos organizados, exceto as instalações portuárias que movimentem carga em volume inferior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 t/ano; e de terminais de uso privado e instalações portuárias que movimentem carga em volume superior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 t/ano.

Feitas essas considerações iniciais, passo a examinar a Portaria MMA nº 424/2011.

3.5.5.3.1 Âmbito de aplicação

Apenas os procedimentos de licenciamento ambiental realizados pelo Ibama ou a regularização ambiental de Portos ou Terminais Portuários que **deveriam ter sido licenciados** pelo Ibama. Contudo, os órgãos estaduais de meio ambiente, na falta de legislação local que trate do tema, se assim entenderem, poderão aplicar a Portaria subsidiariamente.

O objetivo da norma é a chamada “regularização ambiental” de portos e terminais portuários já implantados e que não ostentem licenças ambientais. Percebe-se que a Portaria parte do conceito de que os Portos e Terminais Portuários estariam sujeitos a uma única licença ambiental para todo o complexo. Entretanto, a prática tem demonstrado que, em muitas oportunidades, os Portos e Terminais Portuários podem necessitar de várias licenças ambientais, em função do grande número de atividades capazes de causar impacto ambiental. **A Portaria deve ser interpretada no sentido de que todas as atividades que necessitem licença ambiental devem ser regularizadas e são, portanto, regularizáveis.**

Estão excluídos da norma os terminais e Portos em implantação e as atividades de dragagem para quaisquer portos e terminais portuários. A regularização ambiental terá início por iniciativa do Ibama que intimará aos portos e terminais portuários que estejam operando sem licenças ambientais para que firmem Termo de Compromisso, no prazo de 120 dias contados da expedição da Portaria, assinando-se prazo de 720 dias para a apresentação de Relatório de Controle Ambiental. Importante ressaltar que a assinatura do TC suspende a aplicação das sanções administrativas que já tenham sido aplicadas pelo Ibama e impede a aplicação de novas que tenham por base a ausência de licenciamento ambiental. Quando o empreendimento, de alguma forma, afetar Unidade de Conservação.

O estudo ambiental necessário para o processo de regularização ambiental é o Relatório de Controle Ambiental, o qual deverá observar Termo de Referência padrão. Para os licenciamentos em curso de portos e terminais portuários em operação sem licenças, tal como descritos no artigo 1º da Portaria, ela poderá ser aplicada imediatamente, passando os prazos e exigências a serem observados assim como definidos na própria Portaria.

Como o artigo 6º da Portaria autoriza o funcionamento normal do Porto ou das instalações Portuárias, os embargos que tenham sido aplicados em função da falta de licenciamento ambiental ficam automaticamente suspensos e sem efeito, desde que o processo de regularização ambiental esteja em curso (artigo 6º).

As Licenças de Operação serão expedidas após a análise do RCA, cujo prazo será de 180 dias. O RCA a ser exigido pelo IBAMA deverá ter conteúdo (artigo 7º) conforme especificado na própria. Portaria. Há previsão da possibilidade de abertura de Consulta Pública, a ser instaurada por despacho motivado do IBAMA, ocasião na qual terceiras partes interessadas, em prazo de até 30 dias poderão oferecer manifestação escrita sobre o processo de regularização ambiental (artigo 5º).

3.5.5.3.2 Compensação ambiental

Expressamente foi excluída a cobrança de compensação ambiental dos Portos e terminais Portuários que se achavam instalados e em operação antes da entrada em vigor da Lei nº 9.985/2000 que instituiu o SNUC (artigo 9º). A Portaria estabeleceu procedimento a ser praticado antes do início do processo de regularização ambiental, sempre que um Porto ou Terminal Portuário afete Unidades de Conservação que é a manifestação do órgão responsável pelo funcionamento da UC, não se fazendo distinção entre o nível federativo ao qual a UC esteja vinculada (artigo 10).

Em linha de coerência com o decidido em relação à compensação ambiental, somente se deveria exigir a oitiva de órgão gestor de UC no caso de Portos e Terminais Portuários que tenham sido implantados após a entrada em vigor da Resolução nº 13/90 do Conama que estabeleceu a necessidade da oitiva dos conselhos gestores. Vale ressaltar que a Resolução Conama nº 13/90 foi revogada pela Resolução Conama nº 428, de 17 de dezembro de 2010. Em todo caso, dadas as circunstâncias de fato, o órgão gestor, em tese, não poderá vetar a implantação do empreendimento.

3.6 ZONEAMENTO

Os principais conflitos ambientais dizem respeito aos usos concomitantes do espaço geográfico, sejam o solo, o espaço aéreo ou as águas. Eles ocorrem, pois de fato, geralmente, existem concepções diferentes quanto à utilização de uma parcela do espaço geográfico e, na falta de regras claras que destinem determinada região para um ou vários usos específicos, o conflito se estabelece. Todavia, eles *não se limitam aos usos contemporâneos*, visto que, em diversas oportunidades, *os usos passados* têm repercussão sobre os usos presentes e mesmo futuros. O zoneamento, nesse contexto, é medida de ordem pública cujo objetivo é arbitrar e definir os usos possíveis, mediante a adoção de regras.

Assim como o licenciamento ambiental, o zoneamento é um importante instrumento institucional para a prevenção de danos ambientais e de controle das atividades potencialmente poluidoras, sendo um instrumento da PNMA,

O zoneamento tem origem em sociedades industrializadas e urbanizadas. Foi nos direitos norte-americano e inglês que a questão se colocou primeiramente. No Direito norte-americano, o termo *zoning* é definido como (BLACK, 1991, p. 1.114):

“a determinação e aplicação em cada um dos distritos, tendo a ver com os desenhos arquitetônicos e estruturais de prédios, determinando usos e as construções que podem haver no interior de cada distrito determinado. A divisão do solo em zonas e dentro das zonas, as regulações tanto de natureza do uso da terra e as dimensões físicas dos usos, incluindo os gabaritos e as áreas mínimas”.

Para o Professor Diogo Figueiredo Moreira Neto (1977, p. 87):

“Zoneamento não é mais que uma divisão física do solo em microrregiões ou zonas em que se promovem usos uniformes; há, para tanto, indicação de certos usos, exclusão de outros e tolerância de alguns. A exclusão pode ser absoluta ou relativa”.

Na mesma linha, o Professor José Afonso da Silva (1981, p. 291) afirma que: “Zoneamento – constitui um procedimento urbanístico, que tem por objetivo regular o uso da propriedade do solo e dos edifícios em áreas homogêneas no interesse coletivo do bem-estar da população”.

O ex-Ministro do STF, Professor Eros Roberto Grau (1983, p. 98), sustenta que: “Zoneamento é a divisão de um território – municipal – a partir de determinados critérios”.

Existe zoneamento quando são estabelecidos critérios legais e regulamentares para definição de usos permitidos. Tais usos, uma vez estabelecidos, tornam-se *obrigatórios*, tanto para o particular, quanto para a Administração Pública, constituindo-se em limitação administrativa incidente sobre o direito de propriedade. Os critérios a serem utilizados para o zoneamento são fixados unilateralmente pela Administração Pública, através de ato próprio, ou mediante obrigatória consulta à população interessada. O estabelecimento de zonas especiais destinadas a fins específicos integra o poder discricionário da Administração Pública, conforme desde há muito vem sendo reconhecido pelo STF (“*Não sai de sua órbita constitucional a lei municipal que propõe o zoneamento urbano, com faculdade ao prefeito de incluir, conforme a conveniência da cidade, este ou aquele logradouro público*” (RE – Embargos – Embargos no Recurso Extraordinário. 51.972. ADJ: 14/11/1963, p. 1165. Relator Ministro Cândido Motta).

Quando o zoneamento se impuser sobre propriedade privada, não poderá vedar os usos preexistentes, sob pena de violação de direitos adquiridos (“Estabelecimento industrial para exploração de pedreira regularmente licenciado pela municipalidade – Lei posterior do município, alterando o zoneamento da cidade. Não pode o poder público, *manu militari*, interromper o funcionamento do estabelecimento industrial, regularmente licenciado de acordo com os usos conformes, sob pena de se ferir direito adquirido. Recurso Extraordinário conhecido e provido” STF – RE: 92.845/SP – São Paulo – DJU: 19/9/1980, p. 7206. Relator: Ministro Cunha Peixoto).

Merece ser observado que, uma vez que ele tenha sido estabelecido, toda e qualquer atividade a ser exercida na região submetida a uma norma de zoneamento passa a ser *vinculada*, isto é, não poderão ser admitidas pela Administração Pública atividades que contrariem as normas estabelecidas para o zoneamento. Os particulares têm, portanto, o direito de exigir que se faça cumprir o zoneamento. Por exemplo, se residimos em uma região classificada como exclusivamente residencial, temos o direito de exigir judicialmente que a prefeitura não conceda alvará para a localização de uma boate, ou outra atividade que possa implicar

incômodo para a vizinhança. Somente por meio de hierarquia superior ou igual àquele que tenha estabelecido o zoneamento é que se poderá alterá-lo.

O zoneamento é contemporâneo do urbanismo e, de fato, foi com o planejamento das modernas cidades industriais que ele surgiu. A propósito, vale recordar a lição de Gaston Bardet (1990, p. 18), que afirma: “*Foi na Inglaterra, berço da grande indústria, onde a miséria dos guetos dos trabalhadores amedrontou os mais realistas, que se multiplicaram normalmente as reações contra a cidade monstruosa*”. Desde 1816, o industrial Robert Owen observava “*a atenção que se consagra à máquina morta, à falta de consideração pela máquina viva*”. As oposições que encontrou fizeram-no compreender que a grande cidade e a sua economia são um mal, não somente para a classe trabalhadora, como para a sociedade inteira, e que “*a moradia sã e barata não é um produto normal da sociedade capitalista*” (Catherine Bauer). Na verdade, hoje nós sabemos perfeitamente que atrás da fábrica vêm os operários, atrás das cidades vem o crescimento das populações etc. A economia industrial e de escala é essencialmente urbana. As estatísticas mais modernas indicam um número cada vez maior de pessoas vivendo em cidades, muitas vezes em condições extremamente precárias, muito embora os números estejam em diminuição, com uma melhoria relativa da qualidade de vida das populações.

“O Brasil conseguiu reduzir o número de pessoas que vivem em favelas em 16% desde 2000, de acordo com o relatório State of the World’s cities 2010/2011, divulgado ontem pela Divisão de Habitação da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o documento, cerca de 10,4 milhões de pessoas tiveram suas condições de vida melhoradas nos últimos dez anos. Apesar da evolução, o desempenho é inferior à média de progresso da América Latina, que teve uma redução de 19,5% no número de habitantes de favelas, segundo a Agência Brasil.

O relatório indica que a parcela de brasileiros que mora em áreas urbanas carentes passou de 31,5% para 26,4%, devido principalmente às políticas sociais e econômicas, à diminuição na taxa de natalidade e à redução na migração do campo para a cidade. Mesmo assim 54,6 milhões ainda vivem em moradias consideradas inadequadas no país. Em todo o mundo, um total de 227 milhões de pessoas conseguiu deixar as favelas na última década.

Os países mais populosos da América Latina – Argentina, México, Colômbia e Brasil – contabilizaram 79% do avanço nas condições de vida dos moradores das favelas por causa de um acesso maior a saneamento e água. Mesmo com o bom desempenho brasileiro, Argentina e Colômbia foram os países mais bem-sucedidos, já que reduziram em 40% sua população residente em favelas. A República Dominicana também é citada como bom exemplo, por reduzir em 30% o número de pessoas que vivem em moradias precárias”.⁴ O Direito brasileiro, especialmente após a Constituição de 1988, ultrapassou o conceito puramente urbanístico de zoneamento, passando a adotá-lo para uma grande variedade de atividades econômicas distintas.

O zoneamento é utilizado no direito ambiental como instrumento da PNMA. Como instrumento jurídico, o zoneamento ingressou em nosso direito positivo como ferramenta de proteção à saúde humana, tal qual ocorreu em outras nações. Atribui-se à Lei nº 5.027/1966, que instituiu o *Código Sanitário do Distrito Federal*, a condição de um dos diplomas legais pioneiros na matéria. O artigo 6º da referida lei determinou a divisão do território do Distrito Federal em três áreas: a área metropolitana; as áreas dos núcleos satélites; e área rural.

Em cada uma dessas áreas foram estabelecidos usos permitidos e critérios para a autorização de atividades no interior de cada uma das zonas delimitadas.

3.6.1 Zoneamento ambiental

O zoneamento é uma importante intervenção estatal na utilização de espaços geográficos e no domínio econômico, organizando a relação espaço-produção, alocando recursos, interditando áreas, destinando outras para estas e não para aquelas atividades, incentivando e reprimindo condutas etc. Ele é o resultado de uma arbitragem feita pelo poder público, de forma a definir a convivência entre os diferentes interesses de uso dos espaços geográficos, reconhecendo e legitimando os conflitos entre os diversos agentes. Ele busca estabelecer um padrão de convivência para os usuários de um mesmo espaço. O principal instrumento de planejamento (zoneamento) urbano é o Plano Diretor elaborado pelos municípios.

3.6.1.1 Zoneamento federal

As bases constitucionais para o zoneamento são bastante amplas. A primeira, evidentemente, decorre do poder de polícia do Estado. O artigo 21, inciso IX, da CF, fornece uma primeira referência do poder-dever da União em relação ao zoneamento. A União pode, ainda, conforme permissivo contido no artigo 43 da Constituição de 1988, articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Também poderá a União estabelecer os zoneamentos definidos na Lei do SNUC, de acordo com mandamento constitucional contido no artigo 225, § 1º, III, muito embora não se trate de uma competência exclusiva ou privativa da União. O zoneamento, no entanto, deve ter por base uma lei, pois como instrumento de planejamento deve se adaptar ao disposto no artigo 174, § 1º, da CF.

3.6.1.2 Zoneamento estadual

Os Estados (art. 25, § 3º, CF), poderão, mediante LC, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Observe-se que, ao município, não compete concordar ou discordar de sua inclusão em um dos instrumentos de gestão urbanísticas acima mencionados. Compete-lhe, única e exclusivamente, a eles se integrar da forma mais ampla possível (“... Ao primeiro exame, discrepa do § 3º do artigo 25 da CF norma de Carta de Estado que submete a participação de município em região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião à aprovação prévia da câmara municipal. Liminar deferida para suspender a eficácia do preceito em face do concurso da relevância da argumentação jurídico-constitucional, da conveniência e do risco de manter-se com plena eficácia o preceito, obstaculizada que fica a integração e realização das funções públicas de interesse comum” STF – ADI 1841 MC/RJ. Relator: Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. DJU 28/8/1998, p. 2.)

Mesmo a manifestação plebiscitária da população diretamente interessada foi declarada inconstitucional pelo STF [...] 2. Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 216, § 1º. Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, para criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Impugnação em face do art. 25, § 3º, da CF. Previsão de plebiscito, para inteirar-se o processo legislativo estadual, em se tratando de criação ou fusão de municípios, ‘ut’ art. 18, § 4º, da Lei Magna federal, não, porém, quando se cuida da criação de regiões metropolitanas. 4. Relevância dos fundamentos da inicial e *periculum in mora* caracterizados. Cautelar deferida, para suspender, *ex nunc*, a vigência do § 1º do art. 216 da Constituição do Estado do Espírito Santo. 5. Ação direta de inconstitucionalidade procedente. Declarada a inconstitucionalidade do § 1º do art. 216, da Constituição do Estado do Espírito Santo” ADI 796/ES – Relator: Min. Néri da Silveira. Tribunal Pleno. DJU: 17/12/1999, p. 2).

3.6.1.3 Zoneamento municipal

Aos Municípios estão reservadas as mais importantes tarefas em matéria de zoneamento, visto que a utilização do solo é matéria de interesse predominantemente local e, portanto, contemplada entre as competências municipais. No âmbito da política urbana, os Municípios têm a tarefa de editar os *planos diretores*, que são obrigatórios para cidades com mais de 20.000 habitantes. O *plano diretor* é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É através dele que as cidades podem projetar o desenvolvimento e fixar critérios jurídico-urbanísticos para a ocupação racional do solo. Até mesmo no setor agrário, a atividade municipal, igualmente, é importante, pois os planos diretores é que irão fixar as regiões voltadas para a atividade agrícola, delimitando a utilização do solo municipal. O estabelecimento de zonas urbanas e de zonas rurais, como é óbvio, é da maior importância para a proteção ambiental.

3.6.1.4 Zoneamento ambiental urbano

O zoneamento urbano alcançou grande desenvolvimento desde a sua criação e não se limita mais às clássicas funções de separar a indústria da população em geral, como forma de reduzir os impactos da industrialização com referência à sociedade. Não. Hoje, o zoneamento urbano é muito mais complexo e,

constantemente, são criados novos instrumentos de intervenção urbanística.

3.6.1.5 Zonas de Uso Industrial (ZUI)

As zonas industriais podem ter origem “espontânea” ou “induzida” pelo Poder Público. As zonas industriais formadas “espontaneamente” são aquelas que se criam em função da existência de capitais, mercados e capacidade técnica em certas regiões que estimulam a implantação de indústrias, e os melhores exemplos brasileiros são a cidade e o Estado de São Paulo. As zonas industriais induzidas são aquelas cuja localização é determinada pela Administração Pública e é resultado de políticas de incentivos fiscais e outros mecanismos empregados pelo Estado para a atração de investimentos. Como exemplo pode ser citado o polo petroquímico de Camaçari, ou outras regiões construídas especificamente para abrigar indústrias.

No Direito brasileiro, a definição legal da necessidade de mecanismos para combate à poluição nas zonas industriais teve início com o Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispôs sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais, e, em seu artigo 1º, determinou que “as indústrias instaladas ou as que fossem ser instaladas em território nacional ficavam obrigadas a promover medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos causados pela poluição e contaminação do meio ambiente.” É importante observar que a norma não reconheceu nem poderia reconhecer o “direito adquirido” a poluir. “Inicialmente, deve ser afastado o argumento que versa sobre o longo lapso temporal que o Impetrante mantém o empreendimento, pois não há direito adquirido a poluir, em assim sendo, no momento em que averiguada a ocorrência de um dano ao meio ambiente, cumpre, ao órgão fiscalizador, tomar as medidas previstas em lei, com o fim de impedir a continuidade da agressão, independentemente do período de tempo em que a mesma vinha sendo perpetrada. 3. Sobre a vigência de licenciamentos para o exercício da atividade, também não merece prosperar o argumento do Impetrante. Isto porque o órgão Impetrado agiu no exercício de competência (atribuição) concorrente, conferida pela CF.” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 200851110002991, Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrland, 8ª Turma Especializada, E-DJF2R: 24.3.2010. p. 358-359).

O artigo 4º do mencionado decreto-lei estabeleceu que nas áreas críticas, será adotado esquema de zoneamento urbano, objetivando, inclusive, para as situações existentes, viabilizar alternativa adequada de nova localização, nos casos mais graves, assim como, em geral, estabelecer prazos razoáveis para a instalação dos equipamentos do controle de poluição.

O Decreto-lei foi posteriormente revisto pela Lei nº 6.803/1980, que manteve e aprofundou as determinações referentes à organização da ocupação do solo urbano com finalidades industriais e de combate à poluição. O importante § 3º do artigo 1º da Lei nº 6.803 determina que “As indústrias ou grupos de indústrias já existentes, que não resultarem confinadas nas zonas industriais definidas de acordo com a lei, serão submetidas à instalação de equipamentos especiais de controle e, nos casos mais graves, à realocação”.

A norma estabeleceu um importante padrão a ser observado e que, desde a sua edição, vem se desenvolvendo e aprofundando. A atividade industrial, conforme o teor da norma, deve se realizar dentro de condições capazes de, concomitantemente, assegurar o prosseguimento da produção e o menor nível possível de incômodos a terceiros. O parágrafo estabeleceu uma solução: instalação de equipamentos especiais de controle, que se se revelarem insuficientes para preservar as condições de salubridade ambiental, poderá ser seguida da realocação da indústria. Essa segunda solução, entretanto, é complexa, pois envolve recursos financeiros, transferência de empregos, existência de áreas livres e muitas outras questões que não são triviais.

Foi a partir da instituição de áreas críticas de poluição que se iniciou um processo mais sistemático e coerente de delimitação de espaços urbanos para proteção ambiental. Nessas áreas, as zonas destinadas à instalação de unidades industriais devem ser definidas em esquema de zoneamento que seja capaz de compatibilizar as atividades industriais com a proteção do meio ambiente. As categorias básicas definidas pela legislação são as seguintes: zona de uso estritamente industrial; zona de uso predominantemente industrial; e zonas de uso diversificado.

As zonas industriais, independentemente da categoria em que estejam classificadas, podem, ainda, ser: não saturadas; em vias de saturação; e saturadas.

3.6.1.6 Direito de pré-ocupação e realocação

Como já foi dito, a indústria é um indutor de crescimento populacional, atraindo grande quantidade de pessoas para o seu entorno, gerando aglomerações urbanas que muitas vezes crescem sem o devido planejamento e controle. Todo esse conjunto de circunstâncias pode acarretar a absoluta impossibilidade técnica de manter a instalação industrial no local onde se encontra situada e, concomitantemente, assegurar níveis mínimos de salubridade. É a clássica situação na qual a indústria acaba se transformando em uma espécie de “ilha”, cercada pelos mais diferentes tipos de atividades não industriais que se transformam em risco para os seus moradores e, ao mesmo tempo, passam a ser um risco para a própria indústria.

Uma abordagem inicial da questão se focava na questão de que a população deveria ter que conviver com a indústria, visto que a fábrica tinha chegado primeiro à região. Quase sempre se colocava a questão de se saber se existia, ou não, para a instalação industrial, o direito adquirido a permanecer no local em que se encontrava, retirando-se a comunidade do entorno da instalação. A esse “direito” se dá o nome de direito à pré-ocupação, visto que a fábrica estava localizada antes daqueles que ocuparam o seu entorno. Coerentemente com essa lógica, argumentava-se que os problemas não teriam sido causados pela instalação industrial, mas, ao contrário, por aqueles que se dirigiram para o mencionado entorno.

Não é necessário frisar que, no caso, qualquer dos polos da discussão está utilizando argumentos extremamente simplistas e que não servem para resolver a questão, como a realidade nos demonstra a cada dia. Enfrentar o problema em termos de um direito de pré-ocupação é fugir das questões centrais envolvidas na questão.

Tanto o Decreto-lei nº 1.413/75 como a Lei nº 6.803/80 apresentam um importante conceito jurídico, que é o do não reconhecimento ao direito adquirido de pré-ocupação do solo. Qual o significado do preceito? O que a lei pretende afirmar, e afirma, é que uma empresa, mesmo que regularmente licenciada e autorizada em determinado local, pode ser transferida desse local para outro, desde que as condições de convivência entre a comunidade e ela se tornem absolutamente insuportáveis em razão da poluição produzida pela unidade industrial. Chamo a atenção para o fato de que o mero incômodo da vizinhança não é suficiente para determinar uma medida tão drástica. Isso é possível na medida em que o licenciamento ambiental, em realidade, é feito mediante a concessão de licenças administrativas, por prazo certo. No fim do prazo da licença, caso as condições ambientais tenham se agravado de forma crítica, em tese, seria possível o início de um processo de realocação. Ao mesmo tempo, e compreendendo as imensas dificuldades referentes a uma eventual realocação de instalações industriais, o artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 6.803/80, estabelece que os projetos destinados à realocação de indústrias e à redução da poluição ambiental, em especial aqueles em zonas saturadas, terão condições de financiamento a serem definidos pelos órgãos competentes.

Há, portanto, uma obrigação legal e oponível ao Poder Público no sentido de que os organismos oficiais de crédito forneçam créditos capazes de viabilizar efetivamente o combate à poluição industrial. É importante que se observe que, não raras vezes, quando ocorre o cercamento de uma indústria, a própria indústria pode passar a ter interesse em se realocar, em função dos riscos que a sua presença em meio a uma comunidade pode representar. Há que se exigir que o Poder Público, em qualquer uma de suas esferas, aja de forma eficiente para impedir que a desorganização urbana acabe resultando em prejuízo para as populações mais desfavorecidas e, até mesmo, para a própria arrecadação municipal, visto que, muitas vezes, diante de uma convivência impossível com comunidades que praticamente invadem áreas industriais, muitas fábricas chegam a se mudar de município, gerando o fenômeno conhecido como desindustrialização.

3.6.1.7 Posição dos tribunais

A jurisprudência brasileira, inicialmente, não havia se conscientizado da importância das normas jurídicas relativas ao combate à poluição industrial e da importância do zoneamento ambiental no contexto. É de imperiosa necessidade que o sistema de zoneamento seja respeitado e implementado como condição para a garantia de uma boa qualidade do meio ambiente, bem como para a proteção da saúde humana e o adequado desempenho das atividades produtivas. Não poucas

vezes, os tribunais brasileiros, ao se tratar de poluição industrial, não se pode esquecer o “direito de pré-ocupação”, isto é, caso a instalação industrial estivesse fixada na região antes das populações que se consideram prejudicadas pela poluição, não se poderá determinar a realocação ou mesmo a interdição da atividade poluidora. “*Pode aquele que, voluntariamente, se aproxima de uma fonte poluidora, já consolidada pelo tempo, exigir sua paralisação? Aproximou-se por quê?*” (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, AC nº 45.501-1, Relator Juiz Schalcher Ventura, Meio Ambiente nos Tribunais. Rio de Janeiro: Esplanada, 1992, p. 30 ss.).

A tese do direito de pré-ocupação não é uma criação brasileira e tem obtido acolhida em alguns julgados realizados em outros países, como demonstra Francis Caballero (1981, p. 261).

A industrialização é um fenômeno essencialmente urbano. A expansão da industrialização e a construção de fábricas atraem grandes contingentes de população das áreas rurais para as cidades e, mais especificamente, para o seu entorno, pois é nesses locais que se encontram as maiores possibilidades de trabalho e emprego. Tal deslocamento de população, na direção campo-cidade, faz-se em razão da necessidade de trabalho para aqueles que irão ser os operários das indústrias e das oportunidades de prestação de serviços para a indústria e seus operários para aqueles que se estabelecem no setor de serviços. É da própria lógica industrial a construção de aglomerados em torno das fábricas, caso não haja uma observância estrita das normas de zoneamento.

A existência de instalações industriais é um fator de atração de população. A liberdade de escolha de locais para habitar, reservada aos operários e àqueles que prestam serviços à população que vive no entorno da instalação industrial, é, praticamente, inexistente, pois a ela se dirigem em busca de sua sobrevivência. É de extrema crueldade sustentar-se que aqueles que precisam viver de seu trabalho não devem opor-se às condições ambientalmente negativas às quais estão submetidos em seu dia a dia. Além de cruel, é antijurídico opor-se o pretensão do direito de poluir ao direito humano fundamental à boa saúde e ao meio ambiente sadio. O Poder Público Municipal tem uma parcela relevante, senão a maior, de culpa, pois não impede a construção de habitações em locais de risco, sejam eles o entorno de fábricas, sejam encostas de morros ou margem de rios.

A propósito da construção social da vida dos pobres nas cidades, veja-se a lição de Gaston Bardet (1990, p. 46):

O afluxo das populações operárias para as cidades modernas levou à noção, contemporânea e desumana, de subúrbios exclusivamente operários. A necessidade de pôr ordem igualmente levou a considerar as zonas ditas industriais separadas das zonas residenciais, bem como preservar as pequenas casas de campo da vizinhança indesejável dos prédios de aluguel [...] Esse espírito separatista, excelente no que diz respeito a descartar os elementos nocivos, é catastrófico em consequência de sua má aplicação, que contribuiu para acentuar o isolamento da classe operária em zonas desfavoráveis.

Os tribunais brasileiros evoluíram muito no sentido de compreender mais profundamente o significado das normas jurídicas de combate à poluição industrial e, certamente, decisões como aquela, que foi examinada acima, atualmente, são amplamente minoritárias e não possuem mais qualquer importância como precedente judicial. Os tribunais têm enfrentado questões as mais diversas e, em geral, têm atendido plenamente às necessidades de proteção ambiental. Passaremos a apresentar alguns exemplos que julgamos significativos.

Especificamente quanto à realocação de empresa poluidora, é muito significativo o seguinte acórdão proferido pelo extinto Tribunal de Alçada Cível de São Paulo: “1 – Não importa que a ré tenha transferido, após a propositura da ação, a maior parte de sua maquinaria para outro local, porque têm os autores interesse em que a situação existente no momento da propositura não seja restabelecida. Quanto à queima do material, não importa que não tenha sido provada a nocividade dos gases exalados, uma vez que a simples emissão de odores fétidos é incômodo suficiente que viole os deveres de vizinhança e que deve ser reprimido. O valor da multa diária deve ser suficientemente elevado para tornar efetiva a sanção, compensando plenamente eventual resultado da atividade industrial, realizada com infração à ordem judicial. De nada adiantaria fixar multa ínfima se, exercendo as atividades vedadas, a apelante colhesse lucros superiores ao valor da pena” (ANTUNES, 1995, p. 112).

Outra importante decisão proferida pelo mesmo Tribunal de Alçada Cível de São Paulo é a seguinte: “O funcionamento de fábrica em bairro considerado residencial, que funciona ininterruptamente vinte e quatro horas por dia, emanando fumaça e ruídos noturnos excedentes ao máximo permitido de decibéis, deve ter reduzida a sua jornada de trabalho, como limitação das atividades industriais” (ANTUNES, 1995, p. 113).

Evidentemente que não caberia ao Tribunal determinar a realocação de empresa, pois tal ato é tipicamente administrativo, entretanto, dentro do seu limite de competência, a Corte assegurou a tranquilidade do sono dos habitantes da região.

Porém, a jurisprudência mais recente vem determinando que os municípios arquem com a responsabilidade de impedir as “invasões” e tem determinado que, ao colocar infraestrutura no local, à municipalidade cabe arcar com os prejuízos sofridos pelos terceiros. Todos os paradigmas apresentados reconhecem que a simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo sem ser repelida pelo Município, não constitui desapropriação indireta. Não é o caso dos autos. Concretizada a invasão, o Município assumiu para si a responsabilidade de oferecer condições de infraestrutura de esgoto e luz para que a população assentada fosse atendida em suas necessidades. 3. A Súmula nº 70/ TJ estatui que ‘os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença’. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido” (STJ – RESP – 235773/RJ. 1ª Turma. DJU 27/3/2000, p. 76. Relator: Ministro José Delgado).

É importante considerar que o CC brasileiro de 2002, ao tratar do direito de vizinhança, deu um tratamento bastante interessante à matéria, haja vista o disposto nos artigos 1.277, 1278 e 1279.

3.6.1.8 Zona de Uso Estritamente Industrial (ZEI)

As zonas de uso estritamente industrial se destinam à localização de estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações e radiações podem causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, segundo as determinações legais.

As zonas de uso estritamente industrial devem-se localizar em áreas que sejam dotadas das seguintes características:

- elevada capacidade de assimilação de elementos e proteção ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo;
- favoreçam a instalação de infraestrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança;
- mantenham em seu entorno anéis verdes de isolamento capazes de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais.

Nas zonas estritamente industriais, é proibido o estabelecimento de toda e qualquer atividade não essencial às suas funções básicas ou capaz de sofrer efeitos danosos em decorrência.

3.6.1.9 Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI)

São zonas destinadas, principalmente, à instalação de indústrias cujos processos, submetidos a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não causam incômodos sensíveis às demais atividades urbanas nem perturbam o repouso noturno das populações.

Devem ser instaladas em áreas que tenham capacidade de dotação de uma infraestrutura adequada e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e segurança; deverão, ainda, dispor, em seu interior, de área de proteção ambiental que minimize os efeitos da poluição em relação aos outros usos.

3.6.1.10 Zona de Uso Diversificado (ZUD)

São zonas destinadas à localização de estabelecimentos industriais cujo processo produtivo seja complementar das atividades do meio urbano ou rural em que se situem e com elas se compatibilizem, independentemente do uso de métodos especiais de controle de poluição, não ocasionando, em qualquer caso, inconvenientes à

saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas.

3.6.2 Zoneamento agrícola

O zoneamento *agrícola* ou *agrário* é uma transposição, para a área rural e a atividade agrícola, das disposições de zoneamento originalmente concebidas para as regiões urbanas. Atualmente, o zoneamento agrário tem luz própria e não está mais submetido às influências do zoneamento urbano.

A Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) foi a primeira lei brasileira a dispor sobre o zoneamento agrícola. O artigo 43 do referido diploma legal estabeleceu a competência do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, atual INCRA para a realização de estudos de zoneamento homogêneo do ponto de vista socioeconômico e das características da estrutura agrária.

O estabelecimento de zoneamento agrícola tem por finalidade a definição de:

- as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação dos minifúndios e dos latifúndios;
- as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, em que não ocorrem tensões nas estruturas demográficas e agrárias;
- as regiões já economicamente ocupadas em que predomine economia de subsistência e cujos lavradores e pecuaristas careçam de assistência adequada;
- as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de desbravamento, povoamento e colonização de áreas pioneiras.

A lei determina algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração para a caracterização das áreas prioritárias, quais sejam:

- posição geográfica das áreas, em relação aos centros econômicos de várias ordens, existentes no País;
- o grau de intensidade de ocorrência de áreas em imóveis rurais acima de mil hectares e abaixo de cinquenta hectares;
- o número médio de hectares por pessoa ocupada;
- as populações rurais, seu incremento anual e a densidade específica da população agrícola;
- a relação entre o número de proprietários e o número de rendeiros, parceiros e assalariados em cada área.

Em 1991, foi promulgada a Lei nº 8.171. A lei, em seu artigo 19, inciso III, dispõe que é de atribuição do Poder Público *“realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como para a instalação de novas hidrelétricas”*.

3.6.3 Zoneamento costeiro

A costa brasileira, por força de expressa disposição constitucional (art. 225, § 4º), é um espaço territorial submetido a regime especial de proteção.

Justifica-se essa determinação constitucional, pois desde os primórdios da colonização portuguesa tem sido muito intensa a pressão exercida sobre os ecossistemas costeiros. Relembre-se que a maior parte da população brasileira está assentada ao longo do litoral; dos 17 Estados que são banhados pelo mar, 14 possuem suas capitais no litoral. A enorme extensão do litoral brasileiro (7.367 km) faz com que ali se encontre toda uma grande variedade de ecossistemas.

Em obediência à norma constitucional que determinou um regime especial de tutela para a costa, o legislador ordinário estabeleceu o sistema de gerenciamento costeiro.

Em realidade, o gerenciamento costeiro não é de simples administração, pois nele devem envolver-se os três níveis da Administração Pública, o que nem sempre ocorre com harmonia e facilidade. Assim como nas demais áreas do Direito Ambiental, a proteção da zona costeira está envolvida em uma superposição de atribuições administrativas e legislativas que é bastante problemática.

A Lei nº 7.661/1988, atualmente regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.300/2004, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências, em seu artigo 2º determina que, subordinando-se aos princípios e tendo em vista os objetivos genéricos da PNMA, fixados respectivamente nos arts. 2º e 4º, o PNGC visará especificamente a orientar a utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. A Zona Costeira é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano.

Inicialmente, há que se observar que a Lei que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro é norma que, expressamente, se subordina à PNMA e que, portanto, deve haver compatibilidade entre a sua aplicação e a Lei nº 6.938/81. A Lei do PNGC, definitivamente, busca a racionalização na utilização dos recursos existentes na Zona Costeira. Recursos, como se sabe, são os bens ambientais utilizados de forma econômica. A Lei nº 7.661/88, portanto, é norma que busca dar racionalidade à utilização dos recursos existentes na *zona costeira*. Isso significa que a regra geral estabelecida pela lei é a utilização de tais recursos, desde que observados os critérios de racionalidade e sustentabilidade ambiental que são normativamente definidos no próprio texto legal. O PNGC, logo, não é uma norma com vistas ao congelamento dos recursos existentes no litoral; pelo contrário, o desiderato explícito da lei é o de possibilitar a plena utilização dos recursos contidos em nosso litoral. Merece ser destacado que o “PNGC visará especificamente orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, *de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural*”.

Um exemplo foi o projeto Rio Mar, desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha como um de seus objetivos específicos a ocupação racional da orla marítima da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, visando ser mais uma tentativa de reduzir até níveis toleráveis a invasão das praias por barraqueiros, camelôs, comércio clandestino, prostituição e outros males que, lamentavelmente, assolam nossas praias.

O mencionado projeto estava baseado na construção de quiosques para acomodar o comércio e possibilitar a construção de facilidades sanitárias etc. A complexa questão das competências constitucionais, como sempre, transformou a questão da ocupação das áreas de praia em verdadeiras batalhas judiciais voltadas para a modesta questão referente à construção e utilização de quiosques. (TRF – 2ª Região – AG – 118.162/ RJ. 1ª Turma. *DJU* 4/10/2004. p. 271. Relator: Juiz Carreira Alvim). Esse é um modelo que tem se reproduzido em diferentes Estados da federação com as motivações mais variadas. No Nordeste, por exemplo, a grande questão que tem surgido é a da chamada carcinicultura, que tem sido objeto de litígios judiciais (TRF – 5ª Região. AG – 55076 – CE. 2ª Turma: *DJU* 27/10/2004. p. 874. Relator: Desembargador Federal Petrúcio Ferreira); já no Rio Grande do Sul, debateu-se a construção de plataforma para pesca mar adentro (TRF – 4ª Região. AC – Apelação Cível – 406.081-RS. 3ª Turma. *DJU* 3/7/2002, p. 356. Relator: Juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz).

O atual modelo de ocupação das praias brasileiras é completamente caótico e, certamente, mereceria uma norma geral capaz de disciplinar a matéria de forma ampla e definitiva. O PNGC, em sua existência, não conseguiu servir de instrumento apto a resolver as complexas questões decorrentes da ocupação do litoral brasileiro. Conforme tal lei, nos termos de seu artigo 3º, I e III, o PNGC tem por objetivo assegurar a conservação das praias e de monumentos que integrem o patrimônio histórico, natural e cultural da nação. Isso, entretanto, deve ser feito levando-se em consideração *o grau de urbanização de cada uma das regiões*. Tal, contudo, não ocorreu. Ao contrário, as praias, cada vez mais, se assemelham a “mercados persas”, nos quais acontece de tudo um pouco.

-
- ¹ STJ – REsp 440.002/SE; Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. 1ª Turma. *DJU*: 06/12/2004, p. 195.
 - ² Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br/institucional/organograma/>>. Acesso em: 25 nov. 2009.
 - ³ Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/onde_fazer/define_licenciamento.asp>. Acesso em: 21 set. 2007.
 - ⁴ Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=984298&tit=Numero-de-moradores-de-favelas-cai-16>>. Acesso em: 4 ago. 2011.

INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 9.605/1998, chamada impropriamente Lei de Crimes Ambientais, não definiu as infrações administrativas contra o meio ambiente, limitando-se a adoção de uma fórmula geral contida em seu artigo 70.

Foi com base em tal fórmula aberta que se editou o Decreto nº 6.514/2008. É relevante anotar que a fórmula adotada pelo artigo é o reflexo de uma curiosa oscilação existente nas normas ambientais de caráter punitivo, pois o legislador, em alguns casos, adotou o critério da reserva legal para definir as punições e as próprias condutas ilícitas, e, em outros, utilizou-se de fórmulas abertas e abstratas como a contida no artigo 70.

Infrações Ambientais					
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos)	Lei nº 11.105, de 24 de março 2005 (Biossegurança)	Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (experimentação científica com animais)	Lei do SNUC	Política Nacional do Meio Ambiente	Poluição por óleo
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos: I – derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso; II – iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; III – (VETADO)	Art. 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes	Art. 18. Qualquer pessoa que execute de forma indevida atividades reguladas por esta Lei ou participe de procedimentos não autorizados pelo CONCEA será passível das seguintes penalidades administrativas: I – advertência; II – multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – suspensão temporária; IV – interdição definitiva para o exercício da atividade regulada nesta Lei.	Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei.	Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em infração punível com multa de: I – R\$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física; II – R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa; III – R\$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte; IV – R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte;	Art. 25. São infrações, punidas na forma desta Lei: I – descumprir o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º; Pena – multa diária; II – descumprir o disposto nos arts. 9º e 22: Pena – multa; III – descumprir o disposto nos arts. 10, 11 e 12: Pena – multa e retenção do navio até que a situação seja regularizada; IV – descumprir o disposto no art. 24: Pena – multa e suspensão imediata das atividades da empresa transportadora em situação irregular. § 1º Respondem pelas infrações previstas neste artigo, na medida de sua ação ou omissão:

IV – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; V – perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; VI – fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos; VII – infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes; VIII – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções.				V – R\$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte. Parágrafo único. Revogado.	I – o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o represente; II – o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou operado pelo proprietário; III – o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo; IV – o comandante ou tripulante do navio; V – a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar; VI – o proprietário da carga. § 2º O valor da multa de que trata este artigo será fixado no regulamento desta Lei, sendo o mínimo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). § 3º A aplicação das penas previstas neste artigo não isenta o agente de outras sanções administrativas e penais previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em outras normas específicas
---	--	--	--	---	--

					que tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pelas perdas e danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado.
					Art. 26. A inobservância ao disposto nos arts. 15, 16, 17 e 19 será punida na forma da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.

Há uma *natureza bifronte* em relação às infrações administrativas ambientais: (i) expressa previsão legal, e (ii) remissão às normas administrativas, em fórmula geral, como é o caso do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998.

O Decreto nº 6.514/2008 estabelece as bases para a imputação de responsabilidades administrativas por atos e omissões lesivas ao meio ambiente (§ 3º, art. 225, da CF). Dado que a Lei nº 9.605/1998, *não dispõe* sobre tipos administrativos, o Decreto nº 6.514/08 assemelha-se em muitos aspectos aos chamados regulamentos autônomos. Como se sabe, quanto aos regulamentos autônomos, a competência do Executivo limita-se à auto-organização de seus serviços, desde que não importem em aumento de despesa pública (art. 84, VI, *a*, da CF), conforme Maria Sylvania Zanella Di Pietro (2008, p. 83-84). Há, todavia, posicionamento diverso do ora esposto, como é o caso de Nicolao Dino de Castro e Costa Neto (2003, p. 384):

É importante registrar que as infrações administrativas integram o chamado direito administrativo sancionador, o qual guarda muita semelhança com o direito penal. Aliás, o artigo 79 da Lei nº 9.605/98 determina a aplicação subsidiária dos preceitos dos Códigos Penal e de Processo Penal à matéria regida pela Lei nº 9.605/98 e, conseqüentemente, ao Decreto nº 6.514/2008. No caso das sanções estabelecidas pelo Decreto nº 6.514/08, a sua repercussão sobre a esfera individual do infrator é de elevadíssima monta e, seguramente, ultrapassa em muito a constrição deambulatoria da Lei nº 9.605/98. Relembre-se que há previsão de multas que chegam a atingir a soma de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

4.1.1 Violação do princípio da reserva de lei

A Administração Pública está submetida aos princípios constitucionais do artigo 37 da CF, entre os quais se destaca o da *legalidade administrativa*; por ele, a Administração somente pode atuar com base na lei e com a finalidade de alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Quando a Administração tem necessidade de punir algum ato praticado contra as normas administrativas, tal princípio se desdobra em outro princípio que é o da *reserva legal*.

O Decreto nº 6.514/2008 é inaugurado (art. 2º) com a reprodução do texto do artigo 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Ele revela técnica legislativa pobre, assim como o texto da lei. Ademais, traz um tipo administrativo aberto, o que contradiz o princípio da legalidade administrativa previsto no *caput* do artigo 37 da CF.

Não se discute da necessidade de estabelecer limites à atividade pública e particular com vistas a garantir a salubridade ambiental. O ponto da discussão está no *método* utilizado para a definição das restrições. O Decreto nº 6.514/2008, a partir de uma suposta autorização genérica contida no artigo 70 da Lei nº 9.605/98, simplesmente repetiu, em grande parte, os *tipos penais* existentes na lei e atribuiu-lhes a *condição de tipos administrativos*, a propósito veja-se decisão do STJ (RMS 21.274/GO, Relatora Ministra Denise Arruda, 1ª Turma, DJU 16/10/2006, p. 292).

O procedimento escolhido pela administração faz com que a simples prática de um ilícito administrativo, em tese, se transforme em prática de ilícito penal. Aliás, deve ser registrado que a expressão *crime ambiental* se vulgarizou de tal forma que até os órgãos ambientais têm feito a confusão entre um e outro ilícito, muitas vezes com objetivos de marketing político. No caso da imposição de sanções administrativas a particulares, deve ser acrescentado ao princípio da legalidade o da *reserva de lei*. Isso porque o poder administrativo não pode agir autonomamente, salvo nas restritíssimas hipóteses estabelecidas pela CF (art. 84, VI), conforme já foi visto acima. Ademais, é curial que o poder regulamentar não pode ir além ou aquém da norma legal. Ora, ainda que o meu raciocínio possa parecer *naïf* (*ingênuo*), *não me convence a tese de que o poder regulamentar tenha a amplitude de transformar um solitário artigo de lei em mais de uma dezena de ilícitos administrativos* contemplados pelo Decreto nº 6.514/2008.

As infrações administrativas previstas no Decreto nº 6.514/08 têm evidente caráter penal (sancionador), e nem poderia ser diferente, haja vista que o mencionado decreto pretende “regulamentar” uma norma penal que, em essência, é penal, muito embora trate de outras matérias também. Lucas Rocha Furtado (2007, p. 145), ex-Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União, sobre o tema entende que:

Afirmar que ninguém, vale dizer que os particulares somente podem ser obrigados a fazer ou a deixar de fazer algo em função da lei tem o mesmo sentido que afirmar que a Administração Pública somente pode intervir no âmbito de atuação dos particulares impondo-lhes obrigações, condicionando-lhes o exercício de atividades, limitando-lhes o exercício de direitos, por exemplo, ao se utilizar de lei.

Inexplicavelmente, algumas leis ambientais federais (Lei nº 11.105/2005, art. 21) têm repetido um padrão que *não se sustenta em uma ordem jurídica democrática: a instituição de tipos administrativos abertos*. Houve, no particular um evidente retrocesso, pois se examinarmos a lei que instituiu a PNRH (Lei nº 9.433/1997), veremos que ela estabeleceu, o tipo administrativo conforme consta de seus artigos 49 e 50. Aqui foi aplicado corretamente o princípio da legalidade administrativa. Merece ser ressaltado que o antigo Decreto nº 3.179/1999 já havia sido declarado ilegal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Remessa *Ex Officio* em MS nº 2000.39.00.000430-4/PA, Relatora: Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues.

A dúplice face da administração no trato da questão que, do ponto de vista jurídico é idêntica, demonstra que uma das duas soluções encontradas é juridicamente inadequada. Do nosso sistema constitucional decorre que o equívoco reside no artigo 70 da Lei nº 9.605/98.

Para concluir a crítica que ora se faz, mesmo correndo o risco de uma repetição enfadonha, cumpre assinalar que a doutrina mais moderna e mais de acordo com a realidade de uma Constituição democrática tem afirmado que, “os tipos devem ser claros, suficientemente densos, dotados de um mínimo de previsibilidade quanto aos seus conteúdos” (OSÓRIO, 2000, p. 2010), “dentre as possíveis consequências da cláusula constitucional do devido processo legal, destaca-se a ideia de que as normas sancionadoras não podem ser excessivamente vagas, pois devem ser redigidas com a suficiente clareza e precisão, dando justa notícia a respeito de seu conteúdo proibitivo” (OSÓRIO, 2000, p. 211). Analistas mais apressados do artigo 70 poderiam argumentar que o legislador estabeleceu uma cláusula geral e

que, em tese, teria deixado ao administrador definir concretamente as hipóteses, estas sim típicas, nas quais a cláusula geral restaria violada. Não se sustenta o argumento, pois “*não é possível uma lei sancionadora delegar em sua totalidade, a função tipificadora à autoridade administrativa* [no caso, o Chefe da Administração pela via do decreto], pois isso equivaleria uma insuportável deterioração da normalidade legal sancionadora, violentando-se a garantia de legalidade” (OSÓRIO, 2000, p. 218).

Heraldo Garcia Vitta (2003, p. 91), com inteira razão, afirma que “pouco valeria o princípio da legalidade se o administrador pudesse impor penalidades administrativas sem que houvessem sido definidos, com antecedência e de maneira exaustiva, os comportamentos que são pressupostos de sanções. Do mesmo modo, o referido princípio seria inócuo se, acaso, o administrador pudesse determinar as infrações por atos subalternos da lei, ficando ao Legislativo, apenas a enumeração das respectivas penalidades”.

4.2 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS: SANÇÕES

As infrações administrativas, na forma do artigo 3º do Decreto nº 6.514/2008 podem ser punidas com as seguintes sanções: (i) advertência; (ii) multa simples; (iii) multa diária; (iv) apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; (v) destruição ou inutilização do produto; (vi) suspensão de venda e fabricação do produto; (vii) embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas; (viii) demolição de obra; (ix) suspensão parcial ou total das atividades; e (x) restritiva de direitos.

Antes de examinar detalhadamente cada uma das sanções aplicáveis, julgo conveniente afirmar que, do meu ponto de vista, *encontra base legal, no que diz respeito à punição das pessoas jurídicas*, haja vista que o artigo 3º da Lei nº 9.605/98 taxativamente determina que: “*as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei*”. Contudo, o legislador acrescentou uma ressalva que é a seguinte: “*nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade*”. Parece-me evidente que, no caso, a penalização administrativa, com base na Lei nº 9.605/98 e no decreto que a regulamenta, somente pode ocorrer quando comprovado que aqueles indicados no artigo 3º tenham deliberadamente agido em contravenção à norma legal com o objetivo de, de alguma forma, favorecer a pessoa jurídica.

Há uma evidente lacuna no que se refere à penalização da pessoa física (*reticius*: natural). Tal lacuna, todavia, somente pode ser preenchida por lei formal, pois ao direito repugna a aplicação analógica de sanções, sejam elas penais ou administrativas (STF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, RHC 70.743/DF, 1ª Turma, DJU 01/07/1994, p. 17.498).

No particular é importante acrescentar o fato de que a CF literalmente estabelece que as “*pessoas físicas ou jurídicas*” serão responsabilizadas pelas condutas lesivas ao meio ambiente. Logo, a lei deveria definir as sanções para ambas. Contudo, não o fez, como uma leitura do texto legal, do ponto de vista, claramente demonstra. Se estivéssemos tratando de norma que não fosse de natureza sancionatória, tranquilamente, poderíamos admitir a hipótese da interpretação extensiva. Contudo, este não é o caso. Esclarecido esse ponto de vista preliminar, cumpre passar ao exame exegético da norma. No particular, há importante orientação normativa da Advocacia-Geral da União que dispõe o seguinte: “1. A penalidade de multa simples aplicada em razão de infração administrativa ambiental não tem por fundamento hipótese legal prevista como crime; 2. As multas são aplicadas pelo IBAMA única e exclusivamente com base nos artigos 70 e 72 da Lei nº 9.605/98, regulamentados, até 23 de julho de 2008, pelo Decreto nº 3.179/99, e a partir daí pelo Decreto nº 6.514/08; 3. A competência para a aplicação de multa em razão da prática de conduta descrita nos artigos 29/69-A da Lei nº 9.605/98 é privativa do Poder Judiciário, por se tratar de matéria de natureza penal. Por outro lado, os artigos 70 e 72 da Lei nº 9.605/98 c/c o Decreto nº 6.514/08 definem as infrações administrativas ambientais; 4. Enfim, a previsão legal para o enquadramento da ação/omissão dos autuados como infração ambiental tem natureza administrativa, não havendo falar-se em apuração de crime/contravenção penal pela Administração Ambiental (Orientação Jurídica Normativa nº 09/2010/PFE/Ibama)”.

- *Advertência*

A advertência é a penalidade administrativa mais branda e é, de certa forma, inerente à ação administrativa advertir os particulares que estejam praticando algum ato em desacordo com as normas regulamentares aplicáveis à atividade especificamente considerada. Na verdade, toda ação fiscalizatória deveria ser iniciada com a medida educativa de advertência.

- *Multas (simples e diária)*

Multa é a sanção pecuniária imposta ao particular pela administração pela inobservância de normas administrativas que regem determinadas atividades submetidas ao poder de polícia. As multas incidem diretamente no patrimônio do particular e, portanto, estão submetidas ao princípio da legalidade e, igualmente, ao princípio da reserva legal. A Lei nº 9.605/98 dispõe amplamente sobre multas e elevou-as a valores extremamente significativos, podendo atingir sem os diferentes agravantes a soma de R\$ 50 milhões. O Ibama, em seu sítio na Internet, informa ter imposto um montante de R\$ 3,25 bilhões durante o ano de 2008, isto, no entanto, não significa que as multas tenham sido efetivamente recolhidas.

A multa simples deve ser aplicada na hipótese das infrações que se esgotam em si mesmas, nas *infrações instantâneas*, como por exemplo, o corte sem autorização de uma árvore. Já a multa diária tem cabimento quando a infração cometida é de natureza continuada, como por exemplo, a operação de uma atividade em desacordo com os padrões legalmente aplicáveis. Normalmente, quando a infração da natureza da ora mencionada é praticada, determina-se a paralisação da fonte irregular, até que ela seja capaz de operar dentro dos padrões admissíveis. Na hipótese na qual a determinação de paralisar não tenha sido observada, a cada novo dia de operação corresponderá uma nova multa.

- *Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.*

A apreensão é o ato pelo qual a administração pública retira do comércio o produto que esteja sendo comercializado fora dos devidos parâmetros legais e administrativos. Pense-se no exemplo da posse ilegal de animal silvestre. Quantas pessoas não têm um papagaio em casa, por exemplo? Tecnicamente, trata-se de uma infração às normas de posse e guarda de animais silvestres que, para efeitos legais, são de propriedade do Estado brasileiro, conforme consta do artigo 1º da Lei de Proteção à Fauna, também conhecida, equivocadamente, como Código de Caça (Lei nº 5.197/1967). Ao julgar caso em que foram apreendidos dois papagaios que viviam em uma residência por 25 anos, o STJ entendeu que “*Após 25 anos de convivência, sem indício de terem sido maltratados e afastada a caracterização de espécie em extinção, é desarrazoado determinar a apreensão de dois papagaios para duvidosa reintegração ao seu habitat. 4. Registre-se que, no âmbito criminal, o art. 29, § 2º, da Lei 9.065/1998 expressamente prevê que, “no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”* (STJ, REsp 200801836879/ REsp 1084347, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 30/9/2010).

- *Destruição ou inutilização de produto*

É ato administrativo material mediante o qual a administração destrói ou torna inútil para a atividade a qual se destina o produto produzido em infração às normas administrativas. É medida extrema e somente deve ser tomada pela administração mediante a possibilidade de ampla defesa para o possível infrator que deverá ter a oportunidade de provar a origem legal de seu produto. A medida somente poderá ser adotada após uma avaliação prévia do produto apreendido, sua quantificação e identificação e com a ciência do possível infrator das normas administrativas que deverá dar ciência dos termos acima mencionados. A medida tem como um de seus principais objetivos desincentivar a prática da atividade. Quando se tratar de produto perecível, uma vez que este tenha sido destruído e, a final, não comprovada a infração que deu origem à destruição ou inutilização, deverá haver indenização ao proprietário.

Suspensão de venda ou fabricação do produto

A penalidade está prevista no artigo 72 da Lei nº 9.605/98, é penalidade grave, pois impõe severas restrições à atividade econômica do autuado. Não há previsão de prazo para a duração de tão drástica medida, pelo que se depreende que ela deve perdurar enquanto persistirem as condições de desobediência aos preceitos legais que regem a venda e a fabricação do produto retirado do mercado. É importante que a fiscalização produza laudo técnico demonstrando as razões necessárias para que a sanção seja aplicada, sob pena de agir com excesso de poder. É medida a ser adotada para produtos considerados perigosos ou potencialmente lesivos à saúde da coletividade.

Embargo de obra ou atividade e de suas respectivas áreas

É medida que tem por finalidade paralisar obra ou atividade que estejam sendo realizadas em desacordo com as normas legais. É importante que se observe que o embargo de obra ou atividade só é legítimo se procedido pelo órgão que detém o poder de polícia sobre a obra ou atividade em questão. Parece-me ilegal que, sob o pretexto de exercício de competência supletiva, por exemplo, admita-se que o órgão federal de controle ambiental embargue obra ou atividade devidamente licenciada por órgão estadual ou municipal que esteja atuando regularmente e, portanto, exercendo o seu natural poder de polícia. Em relação ao tema veja-se a seguinte decisão: “[...] 2. Se a atividade em desenvolvimento causa impacto exclusivamente na localidade do empreendimento agrícola, é de se reconhecer a competência do órgão ambiental estadual para licenciar tal atividade econômica. 3. Concedida, pelo órgão estadual competente, autorização para a implementação de atividade potencialmente poluidora (instalação de sistema de irrigação para plantio de mudas de cana-de-açúcar), ainda que por meio de instrumento formalmente inadequado (termo de compromisso), não cabe ao IBAMA interferir na atividade que já é monitorada pelo órgão estadual, sob pena de vulnerar o princípio da segurança jurídica, abalando a confiança do administrado na intangibilidade de que se revestem os atos da Pública Administração. 4. Por mais que se reconheça ao IBAMA competência supletiva para conceder licenças e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras do meio ambiente mesmo em áreas eminentemente a cargo de órgãos ambientais estaduais, sua atuação não tem o condão de suprimir ou de sobrepujar a competência do órgão estadual. TRF-1 – AGA: 34519 TO 2008.01.00.034519-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2008, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 10/10/2008 e-DJF1 p.173)

Em frontal divergência, permito-me trazer à colação a seguinte decisão: *Constitucional e administrativo. Danos ao meio ambiente. Construção em área de preservação permanente. Exercício do direito em desatenção ao princípio da função socioambiental da propriedade. Obrigação de reparar os prejuízos causados aos recursos naturais. Responsabilidade objetiva. Nulidade do auto de infração. Não ocorrência. Termo de embargo. Obra concluída. Não manutenção da sanção. Com efeito, não se pode confundir a definição da competência para processar o licenciamento com a competência para fiscalizar e coibir danos ao meio ambiente. Ademais, a existência de licenças emitidas por órgãos estaduais ou municipais não tem o condão de afastar ou prejudicar a atuação do Ibama* (TRF 4. Apelação Cível nº 2003.72.00.005795-9/SC. Relator: Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz.)

No que diz respeito ao embargo, há que se observar que a Lei nº 12.651/2012, Código Florestal, em seu artigo 51 estabelece que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento irregular deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. Todavia, o embargo deverá restringir-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.

Demolição de obra

Tal qual o embargo, a demolição de obra somente é legítima quando praticada pelo órgão detentor do poder de polícia específico sobre a obra ilegal. A medida só é legítima após o suposto infrator ter exercido o direito de defesa no âmbito administrativo, não restando mais qualquer etapa a ser vencida. Superadas as preliminares da ampla defesa, a Administração pode agir de ofício, sendo desnecessário o recurso ao Poder Judiciário, haja vista que os atos administrativos são dotados de autoexecutoriedade (FURTADO, 2007, p. 274). No particular, merece ser real o fato de que existem recentes decisões judiciais negando legitimidade ativa à Administração para a propositura de ações demolitórias, quando não há resistência do particular à ação administrativa.

Se não há pretensão resistida, não há que se falar em regular constituição da lide, como é da tradição das decisões de nossos tribunais, como se pode ver na seguinte decisão: “Correto o julgado recorrido ao fixar a ausência de uma das condições da ação – Interesse de agir – Porquanto, à míngua de qualquer obstáculo imposto pela autarquia federal (INSS), não se aperfeiçoa a lide, doutrinariamente conceituada como um conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida”. (STJ REsp 147186/MG. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. 6ª Turma. DJU 6/4/1998, p. 179).

Suspensão parcial de obra ou atividade

A suspensão parcial de obra ou atividade é a que atinge apenas uma parcela do empreendimento e não implica paralisação do complexo de atividades desenvolvidas. É medida que se adéqua à proporcionalidade do dano que esteja sendo causado pelo empreendimento. É a hipótese de paralisação de uma chaminé que esteja emitindo material particulado em desacordo com os padrões legais, sem que as demais de uma mesma indústria sejam paralisadas, desde que se encontrem operando conforme as determinações legais e regulamentares.

Evidentemente somente pode ser aplicada para atividades que estejam acontecendo de forma irregular.

Caracterização de negligência ou dolo

A negligência e o dolo são manifestações da conduta subjetiva do agente autor da infração que a Administração Pública pretende punir. São, portanto, manifestações de *culpa*. Sabemos que a culpa não se presume, logo, no caso dos cometimentos das infrações previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 72 da Lei nº 9.605/1998, caberá à Administração demonstrar que o ato praticado pelo autuado teve por base uma conduta não conforme com as regras elementares de cuidado. A negligência é a falta de zelo, de interesse e a desatenção às medidas necessárias para evitar danos ao meio ambiente. Já o dolo é a conduta cuja finalidade é o resultado negativo para o meio ambiente. Há que se observar que, ainda que grande parte da doutrina admita que o ilícito administrativo é objetivo (MACHADO, 2009, p. 322) notadamente o ilícito administrativo ambiental, a lei é expressa ao determinar a apuração da culpa. Quanto ao particular, vale o recurso a lição Wellington Pacheco Barros (2008, p. 242-243), “é possível concluir-se que a aferição de qualquer infração administrativa ambiental exige que a administração ambiental demonstre, dentre outras características, que o infrator agiu com dolo ou culpa, matéria que diz respeito com a subjetividade do agente. Isso significa que não se está diante de uma responsabilidade civil, forma autônoma de responsabilização, cuja aferição se opera de forma objetiva necessitando apenas a comprovação do nexo entre o dano e sua respectiva autoria. Mas de uma análise sobre uma infração a um dispositivo legal em que se comina uma pena.”

Com efeito, Paulo Affonso Leme Machado e os demais que sustentam a tese da objetividade da responsabilidade administrativa ambiental, laboram em equívoco na medida em que se olvidam do fato de que a reparação civil, na qual se admite e festeja a responsabilidade objetiva, não se confunde com a responsabilidade pela infração de normas administrativas. É relevante notar que as críticas do Professor Paulo Affonso Leme Machado, expressando entendimento pessoal, *de lege ferenda*, reconhecem a subjetividade necessária para o apenamento administrativo, tal como disposto na lei: “ao utilizar as expressões ‘negligência ou dolo’, esse parágrafo específico desvia-se do sistema adotado na Lei da PNMA (Lei 6.938/81), em seu art. 14 § 3º uma volta no tempo e um desserviço aos objetivos da própria Lei 9.605/98”. Não posso concordar com o ilustre professor, pois a Lei nº 6.938/81 estabelece uma política a ser adotada pela Administração e trata de responsabilidade civil, não administrativa; já a Lei nº 9.605/98 é lei penal e, portanto, dotada de princípios próprios do Direito Penal. Retrocesso, na verdade, é olvidar-se a separação entre as esferas civis, penais e administrativas e pretender que elas sejam tratadas igualmente. No particular, o STJ mudou sua posição, passando a admitir a responsabilidade administrativa subjetiva: “Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano” (REsp 1.251.697/PR, Rel.

4.2.1 A autuação

A autuação deve ser feita pelo agente da administração pública, *legalmente* investido na função pública e com designação específica para fiscalização. A sua atuação deve ser ostensiva, salvo em casos especiais, com a utilização de uniforme e caracterização. Em contexto de legalidade estrita, como é o da aplicação do direito administrativo sancionatório, faz-se necessário que haja prévia previsão legal das sanções a serem aplicadas ao infrator, assim como se faz necessário que os motivos e fundamentos que impliquem o agravamento das sanções a serem aplicadas pela autoridade administrativa estejam, igualmente, previstos na norma. Contudo, também nesse ponto, a Lei nº 9.605/98 deixa a desejar, pois o capítulo VI que cuida da infração administrativa simplesmente não é dotado de tal previsão legal. A lei, no particular, é coerente, haja vista que se não traz em seu bojo as infrações, não teria sentido trazer a previsão de seu agravamento.

O que a Lei nº 9.605/98 contempla são as condições de aplicação e agravamento da multa penal (art. 6º) que não se confunde com a multa administrativa, portanto, não sendo passível de regulamentação pela autoridade administrativa. Não se desconhece que o artigo 6º da Lei nº 9.605/98 se utiliza do vocábulo *autoridade* que, em tese, poderia ser tanto a autoridade judiciária quanto a administrativa. Todavia, leitura atenta do Capítulo II da Lei, dedicado à aplicação da pena, demonstra que, de fato, é de *pena criminal* que se cuida. Uma interpretação sistemática do capítulo, por mais que se queira aproveitá-lo para aplicação em sede administrativa, demonstra-se esforço vão.

O artigo 6º não fala em criminoso, mas em infrator, o que, em tese, é favorável à legalidade do artigo ora comentado. Entretanto, na sequência do capítulo são utilizadas expressões tais como: *crime*; *crime culposo*; *código penal*; *a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal*; *sentença penal condenatória*; *prática de crime* e tantas outras que, em meu ponto de vista *não há como se aplicar* o capítulo analogicamente às infrações administrativas. Admite-se, por amor à argumentação, que se pudesse aplicar analogicamente a Lei nº 9.784/99 que disciplina o processo administrativo federal; entretanto, a lei recém-mencionada é lacônica ao tratar do assunto (art. 68) e, expressamente, determina prevalecer a lei que rege o processo específico (art. 69).

4.2.1.1 Autuação de advertência

Determina a norma que a advertência *poderá* ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração, no caso das infrações de menor “lesividade” ao meio ambiente. Na realidade a advertência *deverá* ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração, haja vista que a advertência meramente verbal por parte da fiscalização não gera qualquer efeito jurídico concreto. *A mera reprimenda não se confunde com advertência*. Menor lesividade é conceito normativo, firmado pelo valor da multa que, neste caso, não poderá ser aplicada imediatamente, haja vista que a advertência tem por uma de suas funções basilares dar ao particular a possibilidade de sanar o erro de sua conduta. Caso o prazo deferido pela fiscalização não seja atendido, aí sim, será lavrada a multa respectiva.

Uma vez sanada a irregularidade, no prazo assinado pela autoridade, o processo administrativo terá seguimento. Ora, se com mera advertência houve o atendimento do mandamento legal e a irregularidade foi superada, parece-me despropositado que se dê prosseguimento ao processo administrativo, haja vista que dele não resultará nenhum benefício para a administração ou para o meio ambiente.

A administração não deve praticar atos inúteis e dos quais os únicos resultados previsíveis sejam danos à esfera jurídica de terceiros administrados. Alexandre de Moraes (2000, p. 304), a propósito definiu o princípio da eficiência administrativa: “*é aquela que impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social.*”

A advertência é pena aplicável a ilícitos administrativos de menor envergadura e é uma modalidade de constituição em mora do particular. Não há que se falar em advertência em hipóteses que, por sua gravidade, merecem outra punição. Uma vez aplicada a sanção de advertência, a norma veda nova imposição durante o período de três (3) anos após a lavratura de auto de infração no qual conste a penalidade de advertência. É discutível a legalidade da norma, haja vista que, na hipótese de ocorrência de uma nova infração de natureza pequena, pelo particular, não se lhe poderá aplicar a penalidade correspondente – advertência – mas se deverá agravá-la independentemente da situação de fato. Não há previsão de tal situação na lei, não podendo o poder regulamentar criá-la *sponte sua*. Registre-se que a reabilitação criminal ocorre no prazo de 2 anos (art. 94 do Código Penal) e que a reabilitação administrativa em hipóteses de contratação com o Poder Público é igualmente de dois anos (art. 87 da Lei nº 8.666/1993).

4.2.1.2 Multas

Conforme determinação contida no artigo 8º do Decreto nº 6.514/2008, “*a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão-mdc, estêreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado*”. Buscou-se estabelecer uma proporcionalidade entre o dano causado – medido pelas unidades aplicáveis a mensuração de cada um dos recursos ambientais e o valor a ser imputado ao infrator. Ficou para o órgão ambiental definir os parâmetros aplicáveis, o que deverá ser feito por portaria. Contudo, não há previsão legal.

As multas devem ter os seus valores corrigidos, tal como determinado pelo artigo 9º do Decreto nº 6.514/2008, sendo estabelecido o valor entre o valor mínimo de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

O artigo 9º reproduz, em termos, o artigo 75 da Lei nº 9.605. O capítulo mencionado na Lei nº 9.605/1998 é o das infrações administrativas. O que a norma determina é que o Executivo, mediante instrumentos próprios, corrija o valor da imposição pecuniária, de forma a evitar que a penalidade não sofra corrosão inflacionária e, após longo período, se transforme em soma pouco significativa.

O Executivo, no entanto, não fez a correção dos valores, o que me parece uma contrariedade ao texto legal. Aqui, de certa forma, *há um incentivo econômico* à prática do ilícito. O que a Lei determina é que o Executivo publique tabelas com a correção das multas e os valores que passarão a ser exigidos. É hipótese diferente da correção da multa já aplicada e ainda não paga. Justifica-se, portanto, o protesto de grupos ambientalistas quanto aos valores, muitas vezes, irrisórios de multas ambientais. Não se deve esquecer que, na ocasião da edição de Lei nº 9.605/1998, os valores das multas eram muito relevantes e, portanto, aptos a exercer o caráter simbólico e intimidatório.

Uma questão que remanesce é a de saber se os valores constantes da lei podem ou não ser corrigidos. Explico-me: o valor máximo de R\$ 50 milhões não poderia ser corrigido, pois fixado em lei. Penso que não é a melhor interpretação, pois se assim o fosse, a determinação de atualização seria letra morta e, em tese, todas as multas poderiam atingir o teto de R\$ 50 milhões. Assim, os valores foram fixados à época da edição da lei e, conforme exposto acima, devem manter ao longo do tempo a mesma expressão econômica. O fundamental é que exista uma atualização geral e que ela seja publicada pela Administração pública para que todos possam dela ter conhecimento prévio.

A multa diária é aplicável às chamadas infrações continuadas e não às instantâneas, isto é, aquelas que se consumam em um único ato. A inobservância de tal circunstância implica nulidade da sanção aplicada. O agente autuante deverá lavrar o auto e, nele, indicar o valor da multa-dia a ser aplicada ao agente do ilícito.

O valor atribuído à multa-dia deve ser estabelecido na forma dos critérios definidos no Decreto nº 6.514, cingindo-se à uma faixa que não poderá ser inferior ao mínimo definido pelo artigo 9º, nem superar dez por cento do valor da multa simples máxima cominada para a infração.

Não se aplicará a multa diária após a apresentação, pelo autuado, dos documentos aptos a comprovar a regularização da situação que deu margem à lavratura do auto de infração. Todavia, constatada a inexistência da informação, restaura-se a aplicação da multa diária; aqui merece ser destacado que, evidentemente, a prestação de informações inverídicas é uma infração autônoma.

Ressalte-se que a celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerra a contagem da multa diária, a qual deverá ser consolidada na

data. Penso que o *dies a quo* deverá ser o da publicação, e não o da mera celebração, haja vista que os efeitos legais e o conhecimento de terceiros se dão *após* a publicação, dada a natureza de documento oficial ostentada pelo termo de compromisso.

Segundo o estipulado pelo artigo 11 do Decreto nº 6.514, a prática de nova infração pelo mesmo agente, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado no julgamento especificado no artigo. 124, implica: (i) aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou (ii) aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta. O artigo 11 não encontra amparo na Lei nº 9.605/98 que, ao tratar das infrações administrativas, limitou-se ao que consta dos artigos 70 e seguintes, nada dispondo sobre reincidência. Os artigos 6º até o 24 da Lei nº 9.605/1998 estabelecem critérios para aplicação de penas judiciais e não administrativas e, como é óbvio, não é possível a aplicação da analogia para restrição de direitos. E mais, não é jurídico que se considere para fins de reincidência a data de emissão do auto de infração, haja vista que somente após a decisão administrativa é que se poderá considerar alguém como infrator da legislação ambiental, isso caso não haja medida judicial contestando a imposição da penalidade.

Ademais, a majoração de multas (em triplo) para o cometimento da “mesma infração” (*rectius*: infração à mesma norma legal) e em dobro em caso de cometimento de outra infração (*rectius*: infração à norma diversa) não consta do Capítulo VI da Lei nº 9.605/98, havendo, portanto, extrapolação dos termos da lei.

O agravamento da pena não é aplicado imediatamente pela autoridade administrativa que, conforme consta do decreto deverá dar início a procedimento apuratório próprio com vistas a determinar a imposição da penalidade decorrente do agravamento da pena; a prática administrativa, no entanto, não tem observado tal circunstância. Há que consignar que, aparentemente, existe contradição entre o *caput* do artigo 11 e o artigo 21 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos após a lavratura do auto de infração. Parece-me existir uma elevada dose de incoerência entre o reconhecimento da prescrição de uma infração no prazo de cinco anos e a imposição de penalidade pela prática de nova infração no mesmo período. Além do mais, e como já dito anteriormente, persiste a questão referente à reabilitação que é tranquilamente admitida em sede penal e não há porque a resistência em reconhecê-la no âmbito administrativo.

É relevante anotar que o agravamento não se aplica às penas de multa e que, além disso, a sua aplicação somente pode ocorrer quando devidamente instruído o novo procedimento com o antigo auto de infração. Em realidade com todo o processo que implicou aplicação da sanção que servirá de base para o agravamento. Relembre-se, todavia, que o já mencionado capítulo VI da Lei nº 9.605/98 não trata do agravamento de penalidades administrativas, o que, em minha opinião, gera o mesmo vício de legalidade acima já comentado.

O § 3º do artigo 11 do Decreto nº 6.514/2008, como tantos outros, é inteiramente óbvio e desnecessário, pois, evidentemente, após o julgamento da nova infração não se poderá aplicar qualquer agravamento, pelo simples fato que a atividade julgadora já se encerrou. Já o § 4º denota a natureza autoritária do Decreto nº 6.514, pois é uma ampla inversão de qualquer princípio de julgamento justo. Como se pode ler de seus incisos, a autoridade agravará a pena, notificará a parte para dizer sobre o agravamento e depois fará a aplicação do agravamento. Logicamente, o itinerário deveria ser (a) intimar a parte sobre a *possibilidade* de agravamento da penalidade, (b) requerer que ela, querendo, se manifestasse sobre o agravamento e (c) em seguida decidir. Determina o artigo 12 que: *O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos pelo Decreto, havendo necessidade de efetivo pagamento da multa, não se levando em consideração a celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta ou outra forma de compromisso de regularização da infração ou composição de dano, salvo se deste também participar o órgão ambiental federal.*

O artigo é o reconhecimento explícito, cabal e indiscutível de que os componentes da federação brasileira ainda estão muito distantes de praticarem o *federalismo cooperativo* previsto em nossa Constituição. De fato, não há qualquer integração entre os diferentes agentes de fiscalização ambiental que, não raras vezes, competem entre si, sendo bastante comum a aplicação simultânea de multas federais, estaduais e municipais para uma mesma conduta. Há, inclusive o curioso caso de uma tentativa de sequestro de multa imposta por órgão estadual, em favor do Ibama, sob o argumento que o valor da multa havia sido irrisório. Vejamos a hipótese.

Certamente, entre os casos ambientais de maior repercussão encontra-se o derramamento de óleo ocorrido no dia 16 de julho de 2000 nos rios Birigui e Iguaçu no Estado do Paraná. O episódio aconteceu devido ao rompimento de um oleoduto que originou um grande vazamento de óleo para os rios em questão. Tal fato se registrou no mesmo ano de outro significativo vazamento de óleo na Baía de Guanabara, logo no dia 18 de janeiro. Ambos os vazamentos ocorreram em instalações de propriedade da Petrobras que, então, era presidida pelo Sr. Henri Phillipe Reichstul. Ambos os vazamentos foram levados ao Poder Judiciário pelos órgãos competentes.

O vazamento de óleo no Paraná deu margem ao ajuizamento de uma (i) ação civil pública com vistas à reparação dos danos ao meio ambiente, que foi precedida de uma medida cautelar de busca e apreensão com vistas a “sequestrar” em favor do Ibama, a multa aplicada à Petrobras pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e de (ii) uma ação penal movida em desfavor da Petrobras e de Henri Phillipe Reichstul e outro, com base no artigo 54 da Lei nº 9.605/98. A medida cautelar em questão chegou a obter liminar que determinava o sequestro dos valores pagos pela empresa ao órgão ambiental paranaense. Contudo, ante o seu evidente caráter vanguardista, a liminar foi cassada, pois julgada juridicamente impossível pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) (2). Fundava-se a demanda no fato de que a multa aplicada pelo IAP, 50 milhões de reais, era valor insignificante, tendo em vista que a empresa era reincidente em danos ambientais. O Tribunal assim decidiu a questão (2) TRF – 4ª Região/AG – 116170 – PR. 4ª Turma. DJU 01/10/2003, p. 569. Relator: Juiz Amaury Chaves de Athayde. “...1. Configura-se a competência da justiça federal comum (e não da justiça do trabalho) quando o pedido a ser conhecido e julgado abrange providências com repercussão laboral meramente reflexas (ausente a identificação com o meio ambiente do trabalho). 2. Em sendo pretérita a tradição do numerário que interessa, a par de já ter sido julgado, por sentença, juridicamente impossível o pedido de sequestro de multa administrativa paga a órgão estadual, descabe o deferimento de liminar.”

O Decreto nº 6.514 buscou fazer prevalecer o princípio da subsidiariedade e, de certa forma, privilegiar a autoridade de nível mais local. Outro elemento que resulta inescusável da norma é o reconhecimento por parte do Executivo de conflito de atribuições entre as diversas esferas do poder público que, com grande frequência, atuam sem coordenação e buscam, concomitantemente, exercer a competência comum contemplada no artigo 23 da CF. Há uma curiosa possibilidade: no caso de aplicação de uma triplice multa, ou seja, (a) pelo órgão federal, (b) pelo estadual e pelo (c) municipal, a multa seria paga por escalas assim caso a multa federal fosse de R\$ 50 milhões, a estadual de R\$ 20 milhões e a municipal de R\$ 10 milhões; a administração federal receberia R\$ 20 milhões e as demais os valores da face da multa. O sentido puramente arrecadatório é indiscutível. Em um regime de repartição de competências constitucionais, não há como se sustentar uma triplice e simultânea competência, pois se assim fosse, não teria sentido a repartição prevista na Constituição. A LC nº 140, em casos tais como acima descritos, determina deva prevalecer a sanção aplicada pelo órgão responsável pelo licenciamento da atividade, conforme o § 3º do artigo 17.

Segundo determinação do artigo 13 (Decreto 6.514) deverão reverter ao Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA vinte por cento dos valores arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, podendo o referido percentual ser alterado, a critério dos órgãos arrecadadores. O artigo 73 da Lei nº 9.605/1998 estabelece que: “Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador”. Há divergência entre a norma regulamentar e o texto legal. Com efeito, a lei determina que o produto da arrecadação das multas seja destinado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Fundo Naval e a outros fundos de natureza estadual ou municipal “correlatos”, conforme dispuser o órgão arrecadador. Assim, o decreto fez uma restrição em desfavor do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo Naval que não consta da Lei. Poder-se-ia argumentar que a Lei ao determinar a destinação dos recursos arrecadados com as multas estaria invadindo competência da Administração, diante do princípio da separação de poderes; contudo, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo 73 da Lei nº 9.605/1998, motivo pelo qual o poder regulamentar não poderia estabelecer percentual dos valores arrecadados e, muito menos, retirar o Fundo Naval do rol dos beneficiários dos recursos.

4.2.1.3 Demais sanções administrativas

A apreensão de animais é sanção administrativa prevista no inciso IV do artigo 72 da Lei nº 9.605/1998.

Embargo de obra ou atividade é a sua paralisação por determinação da autoridade administrativa, em razão de dano ambiental relevante ou de descumprimento reiterado de ordem administrativa ou mesmo judicial. É medida gravíssima que deve ser aplicada guardada a proporção com o ilícito praticado. Daí o decreto estabelecer que o embargo de obra ou atividade aplicado determinado pela autoridade ambiental deve se limitar ao local ou locais nos quais efetivamente a infração foi cometida. É medida baseada no princípio da proporcionalidade, uma vez que o montante da pena deve guardar uma relação proporcional com a dimensão do ilícito praticado.

A pena, administrativa ou judicial, é uma retribuição equivalente ao ilícito causado. Tal equivalência se faz por sua dosagem adequada, devidamente caracterizada nos tipos e nas sanções decorrentes de sua violação. Desconsiderar a medida da retribuição é, de fato, praticar vingança, o que é repellido pela ordem jurídica democrática. Observe-se que o embargo, dado aos transtornos que causa aos embargados, deve ser aplicado de forma minimalista, até mesmo porque a paralisação de atividades, seguramente implica prejuízo para os embargados, prejuízo que só se justifica se a atividade paralisada, de fato, for ilegal ou danosa. Como atividade administrativa, o embargo é abrangido pelo contido no § 6º do artigo 37 da CF, devendo a Administração responder pelos prejuízos causados na vigência do embargo, caso este seja declarado ilegal pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário.

A Lei nº 9.605/1998, ao estipular a pena de embargo, não definiu prazo máximo para a sua duração, concluindo-se que ele deve ser aplicado até que a atividade se regularize ou corrija o erro apontado. A norma reconhece a possibilidade de paralisação das atividades por prazo indeterminado, sujeito a evento futuro e incerto que é a apresentação da documentação que comprove a regularidade da atividade sancionada, ou a sua regularização pela autoridade ambiental.

A autoridade, no caso, é a própria autoridade embargante ou a que lhe seja superior em grau de recurso. “Relativamente ao pedido de suspensão do embargo às atividades, registre-se que, considerando-se a legalidade do ato que aplicou tal penalidade, a cessação da mesma dependerá de decisão administrativa prolatada após a demonstração perante o órgão fiscalizador ambiental, por parte do autuado, de que a pendência está regularizada, nos termos do art. 15-B do Decreto nº 6.514/08” (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 200851010232251, AC – Apelação Cível, Relatora Desembargadora Federal Maria Alice Paim Lyard– 454877, 6ª Turma Especializada, e-DJF2R 19/8/2011, p. 438-439).

Importante ressaltar que, em muitas oportunidades, o Termo de Compromisso (TC) ou mesmo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) têm sido utilizados como instrumentos aptos para o levantamento dos embargos administrativos.

O desmatamento irregular e as queimadas mereceram importante destaque no decreto, haja vista que a imposição genérica de embargos não se aplica aos casos, haja vista a existência de norma especial.

O desmatamento e as queimadas são dois dos principais problemas ambientais brasileiros e, em princípio, a sua realização somente é permitida mediante controle e supervisão dos órgãos ambientais que disciplinaram a matéria por meio de normas regulamentares. A autorização para supressão de vegetação e utilização de fogo, em áreas rurais é de atribuição dos órgãos ambientais estaduais, conforme disposto na LC nº 140/2011; entretanto, quando se tratar de licenciamento ambiental, a autorização deve ser concedida pelo órgão responsável pelo licenciamento (artigo 12) nos demais casos observando-se o seguinte:

Autorização para supressão de vegetação		
União	Estados	Municípios
Art. 7º São ações administrativas da União: [...] XV – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União; e	Art. 8º São ações administrativas dos Estados: [...] XVI – aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em: a) florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º. c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado.	Art. 9º São ações administrativas dos Municípios: [...] XV – observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta LC, aprovar: a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs). b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.

A norma ora em comento determina a paralisação de toda e qualquer atividade que esteja sendo realizada na área objeto de queimada ou desmatamento irregular, excetuando-se as chamadas atividades de subsistência. Há uma dúvida, pois no artigo 15-A do Decreto Federal nº 6.514/2008: A determinação é no sentido de que o embargo atinja apenas as áreas de prática do ilícito. Verifica-se que o artigo 16 do mesmo diploma adotou conceito alargado da área de prática do ilícito que, parece, confunde-se com toda a propriedade ou posse na qual esteja se verificando o desmatamento ou a queimada irregular.

A ressalva feita para as chamadas “áreas de subsistência”, muito embora louvável, não se sustenta. Que se promovam medidas educativas, explicativas e outras capazes de impedir que os pequenos agricultores promovam atos irregulares, porém, “passar a mão na cabeça”, como tem sido a tradição, não me parece a medida mais adequada, pois acaba funcionando como estímulo e, o que é pior, os pequenos agricultores acabam fazendo o papel da ponta de lança do desmatamento, pois eles dão início, depois repassam a terra já desmatada para produtores com maior capacidade econômica.

O § 1º do artigo 16 determina que o agente autuante *comprove* os elementos que levaram à imposição da sanção. A medida é adequada, pois autos de infração redigidos e documentados inadequadamente levam à sua inevitável nulidade. *Importante observar que, não sendo mata nativa, ou área de preservação permanente ou de mata nativa, não se aplica a sanção de embargo da atividade.*

Outra modalidade é o embargo de áreas submetidas à concessão florestal, conforme o disposto na Lei nº 11.284/2006, que dispõe sobre o serviço florestal brasileiro e sobre a concessão florestal. Tenho tal convicção devido ao fato de que a norma, explicitamente, faz referência ao chamado PMFS, que é um instrumento típico da concessão florestal. Não que não se possa fazê-lo em florestas particulares, ao contrário, ele deve ser feito. Aumenta a minha convicção a menção ao Termo de Responsabilidade de Manutenção da Floresta. Pelo que se depreende, a simples existência do PMFS não é suficiente para a autorização de intervenções na floresta, necessário se faz que o órgão gestor expressamente autorize o início dos trabalhos. As atividades que estavam sendo realizadas ao arrepio da lei, embargadas que estejam, devem ser imediatamente recuperadas pelo autor do ilícito. A determinação é lógica e é uma consequência natural do princípio geral de responsabilidade, segundo o qual aquele que causa dano a outrem deve ressarcir o prejuízo causado. Em termos ambientais, isto significa repristinar a situação e revertê-la ao *status quo ante*.

Há sanção própria para aqueles que não obedeçam às determinações administrativas que impliquem embargos de obras ou atividades. A primeira sanção é a constante do inciso I do artigo 18 do Decreto nº 6.514/2008 que determina a suspensão da atividade que originou a infração. Parece-me uma redundância e, ao

mesmo tempo, se a administração não se a utilizar já estava embargada e o embargo não foi cumprido, a suspensão da atividade é um *bis in idem* e nada diz que a nova determinação será observada. A hipótese prevista no inciso II, esta sim, é medida efetiva, pois é o cancelamento do registro, licenças e autorizações relativas ao empreendimento ou atividade. Muito embora as licenças tenham um caráter de definitividade, elas não podem sobreviver à ilegalidade praticada pelo seu titular. Também o “confisco” dos produtos é medida adequada, pois incide diretamente nos frutos econômicos do agente, o que, sem dúvida, é o melhor caminho para penalizar uma empresa ou indivíduo.

A demolição administrativa de obras irregularmente construídas é uma prerrogativa do Estado, no caso representado pela autoridade ambiental (“Ação Civil pública. Ambiental. Interesse de agir. Provimento em parte. I – A demolição de obra irregular por violação a norma ambiental, constitui sanção de natureza administrativa, cuja competência para sua aplicação é privativa da Administração, descabendo a substituição desta pelo Judiciário. II – Ainda que a demolição se cuidasse de prerrogativa inserida no campo da exigibilidade, seria necessária a sua aplicação em procedimento administrativo regular, o que não restou aqui demonstrado, para, em havendo resistência do particular, ser ativada a jurisdição para a sua execução” TRF 5ª Região. AC 318899 – PB. Quarta Turma. Relator Desembargador Federal Edilson Nobre Decisão unânime).

A medida funda-se na chamada autoexecutoriedade do ato administrativo, o que significa que a administração não está obrigada a se dirigir ao Poder Judiciário em busca de uma autorização prévia para o legítimo exercício dos poderes que lhes são inerentes. Evidentemente que a autoexecutoriedade dos atos administrativos está compreendida dentro dos limites do Estado de direito democrático, ou seja, a ação administrativa deve ser precedida de regular processo administrativo no qual seja conferida às partes privadas os direitos de ampla defesa, contraditório e as demais garantias inerentes à defesa dos cidadãos. Uma vez encerrado o processo administrativo, a administração tem o poder-dever de dar execução à decisão. O único óbice que pode paralisar a ação administrativa é a interposição de alguma medida judicial e que, em tal medida, tenha sido concedida uma liminar ou uma antecipação de tutela que determine a interrupção da ação administrativa. Diante do regime constitucional de separação de poderes albergado por nossa Constituição, a só existência de processo judicial não tem o condão de inibir à ação administrativa. E, portanto, não deve impressionar ao administrador. Logicamente que a demolição administrativa é medida resultante da resistência do infrator em, ele próprio, demolir o irregularmente construído. Somente após a intimação do particular para que ele promova os atos às suas próprias expensas é que a administração se legitima para, por seus próprios meios, exercer os atos materiais de demolição do irregularmente edificado. Contudo, relevante notar que a administração deverá buscar do próprio infrator o ressarcimento dos custos incorridos que, como todo custo administrativo, deve ser comprovado e registrado.

A demolição, contudo, não deve ser aplicada quando dela decorrerem danos ambientais maiores do que aqueles que se pretenda coibir. Mesmo parecendo surpreendente, o parágrafo retrata uma realidade bastante rotineira em matéria ambiental. Não poucas vezes são realizadas construções ou implantados equipamentos e empreendimentos que, ainda que iniciados irregularmente, com o passar dos anos – em decorrência muitas vezes da própria inércia da administração – dão base ao surgimento de ecossistemas novos e próprios que, se forem desfeitos para a reconstituição, acarretarão um novo dano ao ambiente, o que é inteiramente contraditório e sem qualquer sentido lógico ou prático. Aliás, o Decreto nº 6.514, no particular, reflete decisões judiciais sobre o tema: *“Várias circunstâncias inibem seja determinada a demolição da edificação como medida reparatória do meio ambiente, mesmo considerando haver sido ela construída em área de preservação permanente (300 metros a partir da linha preamar média), a saber: (a) está ela situada em loteamento de há muito urbanizado e ocupado; (b) o histórico de ocupação da área revela que a implantação do loteamento ocorreu no ano de 1991, atendendo, presumivelmente, as regras urbanísticas e ambientais vigentes à época, dentre as quais, importante que se registre, não se inscrevia a Resolução nº 303 do Conama, que empresta sustentação jurídica à tese da associação autora, e que foi editada somente em 13/5/2002; (c) o pleito desatende o princípio da proporcionalidade, porquanto grandes seriam os prejuízos financeiros para a construtora, sem qualquer garantia da possibilidade de recuperação efetiva da área, mediante a reconstituição da cobertura vegetal primitiva – restingas, e, ainda que assim não fosse, não há um dimensionamento do impacto ambiental em face da ausência da flora originária naquela porção de terra em que edificado o empreendimento; (d) não há evidências de ameaça ao equilíbrio ecológico, fim último das regras de direito ambiental, pois é pouca e imprecisa a repercussão ambiental da supressão de cobertura vegetal realizada pela recorrida; e, ainda, há notícia nos autos de que, em frente ao empreendimento, remanesce importante e significativa área de preservação devidamente delimitada e identificada com placas alertando para a sua condição jurídico-ambiental, o que minimiza qualquer temor de descompensação ambiental na região”* (TRF 4ª Região, AC – 200372000041850 – SC 3ª Turma, DJU 4/10/2006, p. 713, Relator: Des. Fed. Luiz Carlos de Castro Lugon).

A transferência das despesas referentes à ação administrativa para o particular é justa, pois não se pode pretender que toda a sociedade seja onerada com as despesas causadas por ato ilícito de terceiro. Caso a despesa não seja reembolsada espontaneamente pelo infrator, ela deverá ser inscrita como dívida ativa do ente público e cobrada mediante o processo de execução fiscal, também aplicável às dívidas de natureza não tributária.

As sanções restritivas de direito são aquelas arroladas pelo Decreto nº 6.514/2008 que, como é comum no diploma, em alguns casos reproduzem e, em outros, inovam em relação à Lei nº 9.605/98. De fato, a questão referente ao prazo para a vigência das sanções analisadas não está clara, pois a lei só fala no prazo de vigência da proibição de contratar com a administração, atribuindo-lhe um período máximo de 3 (três) anos. O Executivo fixou em 1 (um) ano o período máximo para a vigência da penalidade nos casos dos incisos I a IV. Artigo 20 do Decreto 6.514/2008 Contudo, a realidade é que se está diante de uma lacuna legal, pois sem a previsão legal da duração da pena, falta atribuição ao Executivo para atribuir prazos, máximos ou mínimos, quando o legislador não o fez. Seria a hipótese de inaplicabilidade da norma? É uma questão que deverá, sem dúvida, ser submetida ao Judiciário. Nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.938/81, cabe ao Conama a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 9.605/98. Observe-se, por fim, que o § 2º, artigo 20, do Decreto Federal nº 6.514/2008 não encontra amparo na lei, pois assim não está previsto. Veja-se que, mesmo a sanção penal, correspondente à restrição de direitos, tem prazo máximo de 10 (dez) anos e a nossa Constituição não admite penas indeterminadas ou perpétuas, como parece ser a vontade do Executivo no caso ora em exame.

4.2.1.4 Prazos prescricionais

Inicialmente, permito-me trazer à colação as seguintes reflexões de François Ost (2005, p. 153):

“Só há memória sobre um fundo de esquecimento”, escreve Pierre Vidal-Nequet, “este esquecimento ameaçador e, contudo, necessário”. Se o esquecimento, ao contrário da memória, apresenta uma natureza ambígua, é que a memória, também ela, é necessária (já dissemos a que ponto ela era constitutiva do social) e perigosa. No capítulo VII de O Processo, Kafka tem esta frase terrível: “o Tribunal nunca esquece nada”; que sinal mais revelador de uma sociedade virtualmente totalitária que um tribunal que nunca esquece nada? Mas uma memória infalível não é apenas ameaçadora, é também ineficaz: um personagem de Borges, denominado Funes Memorioso, é dotado de uma tal memória universal (“Eu sozinho tenho mais recordações do que podem ter tido todos os homens desde que o mundo é mundo”): insone e febril, ele é capaz de reconstituir, uma a uma todas as lembranças e todas sensações de cada dia (operação que, de resto, lhe toma um dia inteiro); ela é, em contrapartida, incapaz de formular uma ideia geral – de fato ele não pensa, ou muito pouco porque “pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo sobrecarregado de Funes não havia senão detalhes, quase imediatos”.

Em boa hora a Administração Pública reconheceu uma obviedade que é a incidência de prescrição em qualquer relação jurídica salvo nas hipóteses nas quais expressamente tenha havido uma exclusão legal. A prescrição é instituto jurídico que tem por finalidade resguardar a segurança jurídica e, de nenhuma forma, a sua aplicação nas questões ambientais tem a consequência de deixar o bem jurídico meio ambiente sem a devida tutela, como parece ser a tese daqueles que sustentam a imprescritibilidade em matéria ambiental.

O fato objetivo é que os interessados e, notadamente, a Administração devem diligenciar tempestivamente para que a punição ou recuperação dos danos causados ao meio ambiente seja providenciada por quem de direito. O que é inadmissível e, do meu ponto de vista, antijurídico é a perpetuação de situações abertas e sem a devida solução, como é o caso da tese da imprescritibilidade dos danos ao meio ambiente. Importante observar que não há qualquer norma legal que seja capaz de nos induzir à conclusão de que a tutela do meio ambiente não sofre os efeitos do tempo. Um bom exemplo da tese da imprescritibilidade do dano ambiental nos é dado por Édis Milaré (2007, p. 1047):

No primeiro caso, ou seja, de ação civil pública veiculadora de pretensão reparatória de dano ambiental coletivo, não conta nosso ordenamento com disciplina específica em matéria prescricional. Tudo conduz, portanto, à conclusão de que se inscreve no rol das ações imprescritíveis. De todo o estabelecimento de um prazo para o ajuizamento da ação tendente à composição da lesão ambiental resulta por completo inadequado o sistema da prescrição.

Não posso concordar com a concepção. Édis Milaré sustenta o núcleo de seu pensamento no fato de que “*é claro que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é um direito patrimonial*”. Contudo, é necessário observar que a prescrição não é instituto voltado para a defesa patrimonial, mas para a tutela da segurança das relações jurídicas. O direito do Estado de punir o homicida é sujeito à prescrição e não se está a falar de direitos patrimoniais, por suposto. Os casos de imprescritibilidade são expressos nas leis e na própria Constituição, por serem excepcionais. Na mesma linha, do ora criticado, se encontra Hugo Nigro Mazzilli (2007, p. 574):

a luta pelo meio ambiente hígido é um metadireito, suposto que antecede à própria ordem constitucional. O direito ao meio ambiente hígido é indisponível, embora seja patrimonialmente aferível.

Compreende-se e se louva a justa preocupação dos ilustres publicistas anteriormente citados, todavia, o direito não se coaduna com argumentos abstratos, genéricos e que não encontram sustentáculo em normas jurídicas. O Estado dispõe de todos os meios para exercer o seu poder de polícia e deve fazê-lo; caso não o faça, que seja responsabilizado. Finalmente, há que se contestar o argumento de que a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado implicaria, *tout s*, imprescritibilidade. Fábio Ulhoa Coelho (2003, p. 371) tratou do assunto assim:

a indisponibilidade do direito implica a irrenunciabilidade, mas não a imprescritibilidade. A independência dos dois atributos pode notar-se pelas inúmeras combinações que entre eles se estabelecem, e também pela dificuldade de se encontrar exemplo de direito simultaneamente irrenunciável e imprescritível.

A prescrição é instituto geral do direito, incidindo em todas as suas diferentes áreas, mediante normas próprias. Não havendo no setor jurídico específico normas próprias, aplicável aquilo que é determinado pelo CC, o que decorre da interpretação do direito como *sistema* e não como mero amontoado inorgânico de normas, princípios e conceitos. Quanto ao particular, permito-me relembrar a lição de Arnaldo Rizzardo (2007, p. 608-609):

“O CC, no Título IV do Livro III da Parte Geral, disciplina a prescrição e a decadência, dispondo no art. 189 que a violação do direito traz para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. O marco para o início do prazo prescricional é o momento da transgressão ou violação. Tão logo verificado o fato que atingiu e feriu o direito, oportuniza-se o exercício da demanda cabível, que perdura por certo tempo, não sendo indefinido ou eterno. Se não vier a ação cabível em lapso de tempo que a própria lei assinala, consolida-se a transgressão, e reverte-se em direito a favor do transgressor. Fica o direito desprovido da ação que o protegia, e que era garantida para a sua restauração”.

Prossegue o autor (2007, p. 615):

“A principal finalidade está em imprimir certeza às relações jurídicas, o que se consegue pelo longo decurso de tempo. Com efeito, se passados vários anos de inércia, incute-se na comunidade a convicção de inexistência de direito. A busca da estabilidade, constitui o fator preponderante para justificar tanto a prescrição como a decadência. Não é possível suportar uma perpétua situação de incerteza ou insegurança. Todas as pessoas buscam estabilidade e certeza. Depois de um certo tempo, há que preponderar uma situação de fato sobre uma situação de direito. O fato se sobrepõe ao direito. Mostra-se inconcebível que, passados numerosos anos, ainda vá uma pessoa atrás de pretensos direitos ou bens. Se perpétuo ou reservado indefinidamente o direito de reclamar, desapareceria a estabilidade de toda a espécie de relações. Ficariam enfraquecidos os direitos, e ver-se-ia o devedor em constante ameaça de cobrança de uma dívida, mesmo que passadas décadas de anos”.

Em linhas gerais, a concepção é perfeitamente aplicável aos ilícitos praticados contra o meio ambiente. Há, contudo, que se estabelecerem algumas peculiaridades. A prescrição, como resultado da incidência do tempo sobre as relações jurídicas, assemelha-se à coisa julgada que, igualmente, desempenha o papel de pôr uma pá de cal sobre o passado. Tanto uma quanto outra desempenham o papel social e legal de estabilizar relações consolidadas. Pois bem, a *res iudicata*, como se sabe, incide sobre as relações jurídicas ambientais, como expressamente resulta da Lei da Ação Civil Pública e da Lei de Ação Popular. Nem se argumente que não haverá coisa julgada caso a demanda tenha julgamento de improcedência por falta de prova. Na verdade, não se cuida aqui de inexistência de coisa julgada, pois caso não tenha logrado produzir prova, não houve uma questão de fato deduzida em juízo. O elemento crucial que deveria ser examinado pelo magistrado não restou provado, abrindo-se, portanto, nova possibilidade para a perseguição da reparação perante o Poder Judiciário. Cuida-se de uma situação excepcional e altamente favorável aos autores, o que se constitui em uma imensa vantagem para a proteção ambiental. Contudo, conjugar-se a hipótese acima descrita com a ausência de prescrição colocaria a Administração ou aqueles encarregados de proteger o meio ambiente em uma posição de tal vantagem processual que caberia a pergunta: O princípio da isonomia está sendo observado?

Ademais, a tese de imprescritibilidade antes favorece à Administração e não o meio ambiente. Com efeito, como sabemos a gestão dos bens ambientais é pública, haja vista que os diferentes órgãos de controle ambiental disciplinam e estabelecem normas – com base em lei – para a utilização dos recursos ambientais e, além do mais, são dotados de poder de polícia para fazer cumprir as normas de proteção ambiental. A não incidência da prescrição é, *ipso facto*, a leniência da inércia administrativa, com a indolência do administrador em cumprir suas funções.

Acresce que existem situações de ilícitos ambientais que, infelizmente, se prolongaram no tempo e o seu desfazimento implicaria enormes transtornos para a coletividade. Pense-se em uma cidade como Petrópolis na qual a sua principal avenida está às margens de um rio. De fato, se a situação se consolidou, como de fato ocorreu, isto foi devido à inércia da própria administração que não pode se valer de sua inércia para surpreender à sociedade e obrigar a que todos se realoquem.

A prescrição não fulmina o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que continuará existindo, independentemente de ser acionável judicial ou administrativamente. Por outro lado, há que se observar que o princípio da *actio nata* determina que o dever de reparação nasce com o conhecimento da lesão e esta, em questões ambientais, nem sempre é imediata, fato que por si só amplia em muito a possibilidade de que o causador do dano seja acionado.

Observe-se que o novo CC (art. 1.228, § 1º) se referiu à necessidade de conservação do meio ambiente e, portanto, o tema não lhe é estranho. Evidente que tema de tão ampla relevância não teria passado alheio ao legislador que, se assim entende-se, teria estabelecido a regra de imprescritibilidade. O estabelecimento dos prazos prescricionais para as infrações administrativas contra o meio ambiente foi medida extremamente acertada, muito embora ela decorresse naturalmente do Decreto-lei nº 4.597/1942, sendo, portanto juridicamente desnecessária. Contudo, dado que boa parte da doutrina, equivocadamente, sustentava a imprescritibilidade dos danos ao meio ambiente, a fixação da norma é relevantíssima. A prescrição penal dos chamados crimes ambientais tem sido aceita tranquilamente por nossos tribunais e não causa qualquer espanto (STJ, REsp 850110/SP. Relatora Ministra Laurita Váz, 5ª Turma. Julgamento: 22/4/2008).

Os motivos comumente apontados como justificadores da imprescritibilidade dos danos ao meio ambiente são, quase sempre, de natureza metajurídica e, datíssima vênua, revelam desconhecimento do que seja prescrição e como ela opera. Em primeiro lugar há que se observar que por força do chamado princípio da *actio nata*, repita-se, o prazo prescricional somente começa a fluir quando o lesado tem conhecimento do dano que lhe foi causado (art. 189, Cód. Civil). O mesmo CC estabelece um prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na hipótese de a lei não fixar prazo menor (art. 205). O prazo é bastante largo e não há porque não aplicá-lo em matéria de danos ao meio ambiente. Há um receio infundado no sentido de que eventuais danos futuros não serão indenizados ou reparados, dado que a sua gestação poderia ter sido em período de tempo há mais de dez anos no passado. A preocupação é legítima, porém juridicamente infundada. Lesões cuja origem seja complexa como, por exemplo, doenças causadas por exposição ou ingestão de produtos químicos, radioativos ou outros perigosos somente terão o seu prazo prescricional iniciado quando elas forem de conhecimento da vítima. Isto é, quando a vítima tiver elementos que demonstrem, ainda que indiciariamente, relação

entre o evento ocorrido e o surgimento da lesão. Assim, se alguém foi exposto a produto perigoso durante 20 anos e a lesão somente começou a se manifestar sob a forma de doença no 21º ano, é a partir dele que a prescrição começa a correr. Aliás, a matéria é pacífica em nossas cortes superiores (STJ, Relator Ministro Humberto Martins, AgRg no REsp 931896/ES, 2ª Turma, DJU 3/10/2007. p. 194).

O decreto, obviamente, só cuida da prescrição do direito da fazenda em apurar e exigir responsabilidade administrativa, não cuidando da responsabilidade civil do causador do dano ambiental e nem poderia fazê-lo, pois essa é matéria reservada à lei. É importante observar que o *caput* do artigo se refere à *administração* que deve ser tomada em sentido amplo e não apenas no sentido da administração ambiental. Administração, aqui, é o Estado e qualquer um de seus agentes.

O *dies a quo* foi fixado em três hipóteses (a) como o da prática do ato que tenha infringido às normas ambientais, no caso de infração instantânea, isto é, aquela que se consuma com a sua prática, (b) quando da prática de infrações que se repetem no tempo, as permanentes ou continuadas, o termo inicial será o dia de sua cessação. A ciência da administração, neste caso, não tem o mesmo efeito que a ciência do lesado tem para fins de contagem do termo inicial do prazo prescricional. Isto porque compete à administração pública exercer o poder de polícia, não se podendo punir o particular pela inércia administrativa. Vigê o mesmo sistema da prescrição em matéria penal. Não se cogita da aplicação do *“in dubio pro ambiente”*, pois no caso, o beneficiário da ação é a administração e não o ambiente abstratamente considerado. O princípio *in dubio pro ambiente* é de aplicação restrita aos casos de incerteza quanto ao resultado de determinadas medidas a serem adotadas pelo administrador e mesmo pelo Poder Judiciário. É uma latinização do princípio da prevenção que não pode se generalizar para a imposição de sanções administrativas pela prática de fatos pretéritos que foram fulminados pela prescrição administrativa. Há, ainda, a hipótese (c) de que é a demarcação do *dies a quo* quando da lavratura do auto de infração, penso que o decreto padece de vício no particular, pois o dia a ser considerado é o da *ciência do auto de infração pelo interessado*.

A prescrição em matéria de ilícito administrativo ambiental está contemplada na Lei nº 9.873/1999. De acordo com o artigo 1º da norma em questão *“prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor; contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”*. Acrescenta o § 1º do artigo que: *“Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”* Na hipótese em que o ilícito administrativo também ostente a condição de ilícito penal, conforme o § 2º, *“a prescrição rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal”*.

Do ponto de vista prático, a pretensão punitiva da administração, será na maior parte das hipóteses previstas no Decreto nº 6.514/2008, regulada pela norma penal, haja vista que é muito grande a coincidência entre tipos penais e tipos administrativos ambientais. Pense-se na hipótese do crime previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98: *“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”* ao qual é cominada a pena de *“detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente”*. Tal tipo penal corresponde ao tipo administrativo contemplado no artigo 66 do decreto ora comentado, o qual estabelece: *“Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes”*.

Ora, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prescreve *“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”*. Assim, no caso concreto, será aplicada a prescrição do Código Penal tanto para os processos em andamento quanto para os paralisados que terão redução de prazo para dois anos.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 9.605/98 estabelece em seu artigo 79 determina que: *“Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.”* Tal disposição, do meu ponto de vista, é aplicável ao decreto regulamentador da Lei e, portanto, devendo ser observada, quando for o caso, a pena aplicada em concreto.

4.3 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA O MEIO AMBIENTE

As infrações administrativas contra o meio ambiente estão arroladas, principalmente, no Decreto nº 6.514/2008. A seguir serão feitos breves comentários aos principais artigos do decreto.

4.3.1 Infrações contra a fauna

Art. 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Multa de:
I – R\$ 500,00 (quinhentos reais) por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção;
II – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES.
§ 1º As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária.

O artigo corresponde ao artigo 29 da Lei nº 9.605/98.

A prática dos atos mencionados no *caput*, em princípio não é proibida, nem punível, desde que o agente seja dotado da devida permissão administrativa. Observe-se que os animais da fauna silvestre ou nativa são de propriedade do Estado (*rectius*: União), a autorização deve ser concedida por órgão federal, ou pelos dos estados e municípios, desde que exista convênio com a entidade federal responsável pela proteção da fauna. Contudo, a simples existência da autorização não é suficiente para impedir a prática da infração, pois a atuação em desacordo com o documento autorizativo é infração administrativa.

Chama-se a atenção para o fato de que a norma protege todo e qualquer animal silvestre, nativo ou em rota de migração, pouco importando o seu grau de vulnerabilidade, muito embora, seja outorgada proteção especial para os animais relacionados nas chamadas listas de espécies ameaçadas de extinção, ou listas vermelhas. Observe-se que não há uma gradação, nem definição da categoria na qual o animal deva estar incluído. A menção específica à Convenção Cites é desnecessária, pois a norma foi incorporada ao direito interno brasileiro mediante a expedição do Decreto nº 76.623/75.

O texto do § 1º, do artigo 24 reforça a necessidade da caracterização da subjetividade para a aplicação da pena de multa, haja vista que na hipótese em exame, é imperiosa a apuração do objetivo “vantagem pecuniária” por parte do agente.

Não possui qualquer correspondente na lei, restando, portanto, duvidosa a sua legalidade.

§ 2º Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.
§ 3º Incorre nas mesmas multas:
I – quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.
§ 4º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605, de 1998.
§ 5º No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.
§ 6º Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.
§ 7º São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste Decreto, todos os organismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.
§ 8º A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada infração, nos termos deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa ao meio ambiente.
§ 9º A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) quando a contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

A norma, com redação pouco clara, pretende proibir a circulação, com finalidades comerciais, de ovos, larvas, espécimes e quaisquer produtos deles derivados cuja origem não possa ser rastreada até um criadouro oficialmente registrado perante as autoridades competentes. Não há, portanto, obrigatoriedade para que o comerciante tenha uma autorização própria e específica, mas que ele adquira os produtos em fontes legitimadas legalmente. Cuida-se de aplicação analógica de norma em *bonan partem*. A medida é salutar, pois é imensa a quantidade de pessoas que possuem pássaros e outros animais silvestres como animais de estimação e, com toda segurança, a criminalização da conduta em nada resultará em benefício dos animais e, pelo contrário, pode significar imensos prejuízos para as pessoas e para os próprios animais.

Art. 25. Introduzir espécime animal silvestre, nativo ou exótico, no País ou fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível:
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:
I – R\$ 200,00 (duzentos reais), por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção;
II – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.
§ 1º Entende-se por introdução de espécime animal no País, além do ato de ingresso nas fronteiras nacionais, a guarda e manutenção continuada a qualquer tempo.
§ 2º Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza espécime da fauna silvestre sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível.

2-3

O artigo busca reprimir duas condutas distintas (I) a simples introdução no país de animal silvestre, nativo ou exótico e (ii) a introdução de animal fora de seu *hábitat* natural, ambas sem a devida análise técnica fornecida por parecer, quando exigível. Pelo conteúdo da norma, um animal nativo que se encontre no exterior somente pode retornar ao Brasil, após parecer técnico que demonstre que ele não acarreta perigo para as espécies aqui existentes. É medida de segurança sanitária bastante importante, pois a estada de animais no exterior pode, em tese, implicar contágio de doenças para a fauna brasileira.

Quanto ao (ii), o objetivo da norma é evitar a ocorrência das chamadas espécies invasoras que, de fato, se constituem em problema grave, pois uma espécie ao ser introduzida em *hábitat* no qual ela não haja predador natural pode caracterizar alteração ecológica negativa, ou mesmo a transmissão de doenças desconhecidas para os demais animais. Não há uma proibição de introdução de espécies fora de seu *hábitat* natural; o que a norma determina é que isso somente ocorra após a elaboração de parecer técnico que garanta que a introdução não terá efeitos deletérios para as demais espécies que habitem o determinado local, conforme regulamentado pela autoridade ambiental. O § 1º equipara a guarda e a manutenção continuada com a introdução de espécie no País, o que se justifica, pois o tipo previsto em (I), resume-se à mera introdução no território nacional, não exigindo a ocorrência de nenhum dano.

Art. 26. Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente:
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de:
I – R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção; ou
II – R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Exportar é enviar para o exterior, no caso, com finalidades comerciais. A norma não coíbe diretamente a exportação das peles e couros dos animais que menciona. A proibição diz respeito ao produto “em bruto”. É na verdade medida de proteção comercial, pois uma vez manufaturados a pele e o couro, com a entrada de recursos mais significativos no País, a norma não se aplica. A autoridade competente, no caso, é a ambiental e a aduaneira. Ambas as autorizações são necessárias. A norma não tem qualquer conteúdo ambiental.

Art. 27. Praticar caça profissional no País:
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de:
I – R\$ 500,00 (quinhentos reais), por indivíduo capturado; ou
II – R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da CITES.

A caça é uma das atividades humanas mais antigas. Inicialmente, ela era praticada com o objetivo de alimentação e sobrevivência. O homem, em sua natureza primitiva é carnívoro. Na medida em que os excedentes agrícolas e de caça foram se tornando mais relevantes, a caça perdeu o seu sentido de atividade realizada para a sobrevivência humana e se tornou um “esporte” praticado pelos mais afortunados. Na verdade, a caça tem sido ao longo dos séculos uma das atividades humanas mais elitizadas e “exclusivas”. É interessante observar que as primeiras áreas protegidas do Ocidente foram florestas dedicadas exclusivamente ao exercício da caça pela aristocracia e a nobreza.

Interesses de natureza econômica e mesmo o “puro lazer”, aliados à maior letalidade e eficiência das armas, levaram a caça a atingir níveis extremamente elevados, com impacto direto nas populações animais, fazendo com que ela passasse a ser amplamente combatida até mesmo com o estabelecimento de uma convenção internacional contra o tráfico de espécies ameaçadas de extinção (Decreto nº 3.607/00 – Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – Cites) da qual o Brasil é signatário. Vários países adotaram a restrição, como é o caso do Brasil que não admite a caça profissional (Lei nº 5.197/67 – Art. 2º).

Estes fatos fizeram com que, em muitos países, as espécies protegidas por normas legais, passassem a desfrutar de um inequívoco aumento populacional, gerando problemas relacionados com os conflitos de uso do solo entre os animais protegidos e as populações rurais.

Concomitantemente, há todo um processo político para a defesa dos “direitos dos animais” que, hodiernamente, já contam com uma “Declaração de Direitos” que foi proclamada em assembleia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978. A Declaração não se volta especificamente para a caça, mas diz respeito à proibição de crueldade contra os animais. Ressalte-se que, como declaração, não é obrigatória para os Estados. No Brasil, os animais silvestres pertencem ao Estado, não havendo um direito de caça esportiva indiscriminado, pois este deve ser regulamentado pelo governo federal, no caso representado pelo IBAMA. No Estado do Rio Grande do Sul, tradicionalmente é aberta uma temporada de caça, sendo estabelecidos critérios para o exercício da atividade. Pessoalmente, considero a caça uma barbaridade e não estaria disposto a participar de uma caçada. No entanto, entendo que a atividade necessita ser regulamentada, pois assim determina a legislação brasileira, inclusive a nossa Lei de Crimes Ambientais (art. 29).

Art. 28. Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade excedente.

O artigo não possui correspondente na Lei nº 9.605/1998. A Lei nº 5.197/1967 também não trata do assunto. Trata-se de norma mal redigida e, claramente, fora dos objetivos do decreto que é a proteção administrativa do meio ambiente e exorbitante da lei. A infração, em tese, é aperfeiçoada pelo ato de comércio de produtos, instrumentos e objetos que “*impliquem*” a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre. Implicar, como se sabe é: “v.t. e v.i. Embaraçar, envolver, enredar: implicar alguém numa acusação. Dar a entender: a amizade implica sinceridade. Tornar necessário, indispensável. Produzir como consequência; acarretar. Ser incompatível, não se harmonizar; implicar com alguém. Lógica. Envolver uma implicação formal, material. V.pr. Comprometer-se, enredar-se: não te implique em negócios escusos”.¹

Como se vê, o artigo, sem qualquer base legal pretende punir o comerciante que comercialize produtos, instrumentos e objetos que possam ser utilizados para a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre. Entretanto, toda uma série de produtos pode ser utilizada para tal; porretes, cola, caixas, cordas etc. e, tais coisas não demandam licença para serem comercializadas, especialmente licença da autoridade ambiental.

O comércio é atividade lícita e, em princípio, que não demanda maiores regulamentações, salvo em casos específicos. O comércio de armas, de motosserras e outros já possui a regulamentação adequada, inclusive com a cominação de sanções para a inobservância dos dispositivos de restrição ao livre comércio. Por outro lado, dificilmente o artigo pode ser enquadrado na generalidade do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998 pois, seguramente, não se constitui em “*ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente*”, salvo com verdadeiro malabarismo exegético.

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.

A norma tutela a higidez física e “psicológica” dos animais, haja vista que não tolera o tratamento cruel. Contudo, não há uma definição clara de maus-tratos aos animais, muito embora a lei de proteção aos animais nos dê um excelente indicativo. O STF, por exemplo, tem julgado como inconstitucionais as leis estaduais que “legalizam” a “briga de galos”. (STF – Relator Ministro César Peluso ADI 3776/RN. Tribunal Pleno, *DJU* 29/6/2007).

Antes da decisão recém mencionada, o STF já havia se manifestado pela via do Recurso Extraordinário sobre a chamada “farra do boi”, pseudomanifestação cultural que se realizava no estado de Santa Catarina. (STF. Relator Ministro Marco Aurélio RE 153.531 – SC, *DJU* 13/3/1998). Mais recentemente foi julgada inconstitucional a chamada Vaquejada, Lei nº 15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural (STF – ADI 4983). Como já foi referido em outra parte deste livro, houve a introdução do § 7º ao artigo 225 da Constituição Federal que incluiu a vaquejada entre as atividades de natureza cultural.

--

Art. 30. Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio em águas jurisdicionais brasileiras:
Multa de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No Brasil, vige a proibição de pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras, (Lei nº 7.643/1987). A lei, bastante rigorosa em seus termos, estabeleceu inclusive um tipo penal (artigo 2º).

A mais recente relação de espécies ameaçadas divulgadas pelo MMA classifica o grau de ameaça dos cetáceos. A relação se baseia em critérios técnicos mais desenvolvidos do que os anteriormente utilizados, pois categorizou de forma hierárquica o nível de ameaça às diferentes espécies integrantes de nossa fauna silvestre, o que não era feito anteriormente. A escala é a seguinte: (i) criticamente em perigo; (ii) em perigo e, (iii) vulnerável. A categoria vulnerável não significa que o animal esteja sofrendo uma ameaça imediata, mas um risco a médio prazo que poderá ser evitado, desde que tomadas as medidas adequadas.

A Baleia Franca é o cetáceo que possui o maior grau de proteção legal no Brasil, tendo sido criada uma APA com a finalidade específica de sua defesa (Decreto de 14 de setembro de 2000).

O IBAMA “regulamentou” o artigo 1º da Lei nº 7.643/1987, conforme a Portaria nº 117, de 26 de dezembro de 1996, posteriormente alterada pela Portaria nº 24, de 8 de fevereiro de 2002, como forma de coibir o molestamento de cetáceos. O artigo 2º da norma determina o seguinte: “Art. 2º É vedado a embarcações que operem em águas jurisdicionais brasileiras: (a) aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos de Ordem *Mysticeti*; cachalote, *Physeter macrocephalus*, e orca, *Orcinus orca*) com motor engrenado a menos de 100m (cem metros) de distância do animal mais próximo, devendo o motor ser obrigatoriamente mantido em neutro, quando se tratar de baleia jubarte *Megaptera novaeangliae*, e desligado ou mantido em neutro, para as demais espécies; (b) reengrenar ou religar o motor para afastar-se do grupo antes de avistar claramente a(s) baleia(s) na superfície a uma distância de, no mínimo, de 50 m (cinquenta metros) da embarcação; (c) perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 30 (trinta) minutos, ainda que respeitadas as distâncias supraestipuladas; (d) interromper o curso de deslocamento de cetáceo(s) de qualquer espécie ou tentar alterar ou dirigir esse curso; (e) penetrar intencionalmente em grupos de cetáceos de qualquer espécie, dividindo-o ou dispersando-o; (f) produzir ruídos excessivos, tais como música, percussão de qualquer tipo, ou outros, além daqueles gerados pela operação normal da embarcação, a menos de 300m (trezentos metros) de qualquer cetáceo; (g) despejar qualquer tipo de detrito, substância ou material a menos de 500m (quinhentos metros) de qualquer cetáceo, observadas as demais proibições de despejos de poluentes previstas em Lei; (h) aproximar-se de indivíduo ou grupo de baleias que já esteja submetido à aproximação de, no mesmo momento, de pelo menos, duas outras embarcações.

Há, portanto, uma legislação bastante abrangente para a defesa dos Cetáceos em águas jurisdicionais brasileira. Tal legislação vem sendo observada e cumprida e implementada de forma consistente. Os encalhes de baleia nas praias são fatos que se repetem em razão de diversos fatores que, ainda, não foram adequadamente identificados e que demandam estudos mais profundos. É evidente que eles podem ter motivações naturais ou antrópicas que somente poderão ser identificadas na base do caso a caso. Há que considerar que, em função da crescente proteção aos Cetáceos, o número de espécimes da espécie tende a aumentar o que, logicamente, implicará – em tese – um número maior de indivíduos sujeitos a atingirem as praias.

A importância dos valores envolvidos na questão (i) respeito à vida animal, (ii) mobilização do sentimento público de solidariedade; (iii) cumprimento da legislação brasileira; (iv) manutenção da atividade econômica da indústria do petróleo e muitos outros, não permite que, oportunisticamente, se passe a apontar culpados por um evento trágico, sem a menor base factual, técnica ou científica.

Art. 31. Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular:
Multa de R\$ 500,00 a R\$ 5.000,00 (mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.

A norma tem como destinatário as chamadas unidades de conservação atípicas, pois não previstas na Lei nº 9.985/2000. O ilícito administrativo é de natureza formal, pois relacionado única e exclusivamente com a manutenção de livros adequados para o registro do acervo faunístico da instituição.

No sistema jurídico brasileiro, os animais silvestres são propriedade do Estado (art. 1º da Lei nº 5.197/1967).

Contudo, é importante observar que, nos termos da LC nº 140/2011, os criadouros de fauna silvestre, conforme o estipulado nos incisos XVIII e XIX do artigo 8º, estão submetidos à aprovação dos órgãos estaduais de controle ambiental, caso haja necessidade de apanha de animais silvestres, a regulamentação permanece com a União. A LC, assim, transferiu o controle dos criadouros para os órgãos estaduais que deverão estabelecer normas próprias sobre a matéria, admitindo-se transitoriamente a utilização das normas que haviam sido baixadas pelo Ibama.

Jardim Zoológico, conforme o disposto na Lei nº 7.173/1983 é “qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública”. O Jardim Zoológico é atividade exercida mediante autorização do Poder Público Federal. O Jardim Zoológico é mero depositário dos animais da fauna silvestre que integrem o seu plantel, devendo possuir registro junto ao IBAMA que concederá licença para a atividade, observados critérios técnicos.

Os livros de registro, cuja ausência ou irregularidade dá azo à imposição de sanções administrativas, são uma exigência legal capitulada no artigo 14 da Lei nº 7.173/83. Os livros de registro são aqueles regulamentados pela IN nº 4/2002 do Ibama.

Por sua vez, a IN Ibama nº 2/2001, dispôs sobre as categorias de Jardim Zoológico, Criadouro Comercial de Fauna Silvestre e Exótica, Criadouro Conservacionista, Criadouro Científico e Mantenedouro de Fauna Exótica, nos quais manutenção de animais silvestres e exóticos em cativeiro é permitida na forma da lei e cuja relação de animais sob a responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas que respondem pelas categorias é parte integrante dos processos de registro junto ao Ibama, determinando a necessidade de que tais atividades possuam ficha de controle e identificação de plantel, a qual deve conter: (i) a categoria de registro, (ii) número do registro Ibama, (iii) nome do proprietário, (iv) responsável técnico, (v) localização, (vi) nome científico, (vii) nome popular, (viii) identificação individual, (ix) origem de cada espécime, (x) tipo, (xi) identificação individual, (xii) número, (xiii) sexo, (xiv) assinatura do responsável ou proprietário e (xv) local e data.

A IN Ibama nº 07/2015, baixada para instituir e normatizar “as categorias de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro, define, no âmbito do Ibama, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas”, dispôs sobre (art. 3º): (i) centro de triagem de fauna silvestre; (ii) centro de reabilitação da fauna silvestre nativa; (iii) comerciante de animais vivos da fauna silvestre: estabelecimento comercial, de pessoa jurídica, com finalidade de alienar animais da fauna silvestre vivos, sendo vedada a reprodução; (iv) comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre: estabelecimento comercial varejista, de pessoa jurídica, com finalidade de alienar partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre; (v) criadouro científico para fins de conservação; (vi) criadouro científico para fins de pesquisa; (vii) criadouro comercial; (viii) mantenedouro de fauna silvestre; (ix) matadouro, abatedouro, e frigorífico; (x) jardim zoológico.

Por meio da IN nº 07/2015, art. 5º, foram estabelecidos os critérios para a autorização das atividades mencionadas. *Crerios esses que não se aplicam aos*: (i) empreendimentos que utilizam, exclusivamente, espécimes da fauna doméstica; (ii) empreendimentos que utilizem, exclusivamente, peixes, invertebrados aquáticos, exceto os classificados como jardins zoológicos; (iii) criações de insetos para fins de pesquisa ou de alimentação animal, desde que já existentes na área do empreendimento, exceto quando se tratar de espécies da fauna silvestre brasileira pertencentes à lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, ou de espécie pertencente à lista estadual da Unidade da Federação em que se localiza o empreendimento; (iv) criações de invertebrados terrestres considerados pragas agrícolas,

vetores de doenças ou agentes de controle biológico; (v) meliponicultores que mantenham menos de cinquenta abelhas nativas, conforme resolução Conama nº 346/2004; (vi) restaurantes, bares, hotéis e demais estabelecimentos que revendam carne ou produtos alimentares de origem na fauna silvestre, desde que mantidas as notas fiscais que comprovem a sua aquisição legal; (vii) estabelecimentos que produzam, vendam ou revendam artigos de vestuário, calçados e acessórios cujas peças contenham no todo ou em parte couro ou penas de animais silvestres criados ou manejados para fins de abate, desde que mantidas as notas fiscais que comprovem a sua aquisição legal, ou ainda, a partir de importações devidamente registradas nos sistemas de controle do comércio exterior; (viii) atividade que atue exclusivamente na importação e exportação de fauna silvestre nativa e exótica, ou ainda de suas partes, produtos e subprodutos.

Todavia a inexigibilidade das autorizações não dispensa a atividade ou empreendimento da inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do licenciamento ambiental, quando exigível pelo órgão competente, nem de outros atos administrativos necessários para a sua implantação e funcionamento.

Foram estabelecidas as seguintes definições para fins de aplicação da norma (art. 2º da IN Ibama 07/2015): “(i) *animal de estimação ou companhia*: animal proveniente de espécie da fauna silvestre nativa, nascido em criadouro comercial autorizado para tal finalidade, mantido em cativeiro domiciliar, sem finalidade de abate, de reprodução, uso científico, uso laboratorial, uso comercial ou de exposição; (ii) *espécie*: conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre si, capazes de originar descendentes férteis, incluindo aqueles que se reproduzem por meios assexuados; (iii) *espécime*: indivíduo vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, unidade de uma espécie; (iv) *fauna doméstica*: conjunto de espécies da fauna cujas características biológicas, comportamentais e fenotípicas foram alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornando-as em estreita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas diferente da espécie silvestre que os originou; (v) *fauna silvestre exótica*: conjunto de espécies cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e suas águas jurisdicionais, ainda que introduzidas, pelo homem ou espontaneamente, em ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas e excetuadas as migratórias; (vi) *fauna silvestre nativa*: todo animal pertencente a espécie nativa, migratória e qualquer outra não exótica, que tenha todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras; (vii) *parte ou produto da fauna silvestre*: pedaço ou fração originário de um espécime da fauna silvestre que não tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua característica, forma ou propriedade primária, por exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura, ovo, asa, pele, pelo, pena, pluma, osso, chifre, corno, sangue, glândula, veneno, entre outros; (viii) *subproduto da fauna silvestre*: pedaço ou fração originário de um espécime da fauna silvestre beneficiado a ponto de alterar sua característica, forma ou propriedades primárias.”

Art. 32. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

A norma se destina àquele que exerce o comércio de animais silvestres, não devendo se confundir com comerciantes de produtos manufaturados derivados de animais silvestres, tais como sapatos, bolsas e outros. A declaração de estoque tem por objetivo dificultar a comercialização clandestina de animais silvestres que é uma das grandes fontes internacionais de dinheiro ilícito. A declaração dos valores deve ser entendida como as notas fiscais referentes à comercialização dos animais.

Art. 33. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus-tratos:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao uso de imagem para fins jornalísticos, informativos, acadêmicos, de pesquisas científicas e educacionais.

A norma tutela a imagem dos animais, impedindo que ela seja explorada comercialmente. Observe-se que a norma diz respeito à imagem de animal “mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus-tratos”. Não há tutela no que se refere à exploração comercial de imagens de animais silvestres em liberdade, ou regularmente mantidos em cativeiro. O parágrafo único excepciona o uso de imagens para fins jornalísticos, acadêmicos, educacionais ou científicos etc. Há que se considerar, contudo, que os direitos de imagem são de natureza civil, tutelados por normas próprias e que escapam ao poder regulamentar. Aqui, foi criada uma forma anômala de propriedade intelectual.

Art. 34. Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de domínio público:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Degradação é conceito normativo previsto na Lei nº 6.938/1981 (art. 3º, II) que é a promoção de alterações adversas no meio ambiente. A norma, inexplicitamente, tutela apenas os açudes, viveiros ou estações de aquicultura de domínio público.

Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida:

Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II – pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida;

IV – transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente;

V – captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem

VI – deixa de apresentar declaração de estoque.

O tipo administrativo corresponde ao artigo 34 da Lei nº 9.605/1998. A pesca submete-se ao poder de polícia, sendo-lhe aplicável a Lei nº 11.959/2009. Como norma geral, a pesca é permitida, submetendo-se às regras de polícia, com vistas a proteger os recursos pesqueiros, a segurança da navegação e o exercício de outras atividades. Pesca é *“toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros”*. A pesca pode ser exercida nas *“águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil, excetuando-se as áreas demarcadas como unidades de conservação da natureza de proteção integral ou como patrimônio histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para a segurança nacional e para o tráfego aquaviário”*. Assim, como se vê, podem ser definidas áreas de exclusão para a pesca; do mesmo modo, a Administração pode estabelecer exclusão temporária para o exercício da atividade pesqueira, mediante o estabelecimento do chamado período de defeso que é: *“a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes”*.

As hipóteses legais de proibição da pesca estão tipificadas no artigo 6º da Lei nº 11.959/2009. Logo, o exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória, periódica ou permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção: (i) de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados; (ii) do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros; (iii) da saúde pública; (iv) do trabalhador.

Há, ainda, proibição do exercício da atividade pesqueira (i) em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente; (ii) em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não permitidos pelo órgão competente; (iii) quando sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente; (iv) em quantidade superior à permitida pelo órgão competente; (v) em locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas, com distância estabelecida em norma específica; (vi) em locais que causem embaraço à navegação; (vii) mediante a utilização de: (a) explosivos; (b) processos, técnicas ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante ao de explosivos; (c) substâncias tóxicas ou químicas que alterem as condições naturais da água; (d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios. Também estão proibidos o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de espécimes provenientes da atividade pesqueira ilícita.

A proibição de pesca não se presume, devendo ser claramente estabelecida e devidamente divulgada para conhecimento de todos, indicando períodos, locais e espécies cuja pesca é proibida.

O inciso II do art. 34 da Lei nº 9.605/98 estabelece punição para quem *“pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos”*; assim como no inciso precedente, há que existir norma estabelecendo a quantidade de pesca admitida em cada época ou região, bem como os utensílios cuja utilização não é admitida para a atividade de pesca.

Os incisos III e IV do art. 35 do Decreto nº 6.514/2008 são semelhantes e dizem respeito ao exercício de atividades comerciais e industriais com a pesca sem a devida autorização legal. Assim quem *“transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida”*, bem como quem *“transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente”*, está sujeito à imposição das sanções administrativas.

Em nível administrativo, a IN Ibama nº 202, de 22 de outubro de 2008, dispôs sobre normas, critérios e padrões para a exploração com finalidade ornamental e de aquariofilia de peixes nativos ou exóticos de águas marinhas e estuarinas.

É permitida, nas águas jurisdicionais brasileiras, exceto nos bancos e ilhas oceânicas, a captura, o transporte e a comercialização de exemplares vivos das espécies nativas relacionadas no Anexo I da IN, com a utilização dos seguintes petrechos: (i) tarrafas: (a) tamanho pequeno (até dois metros de diâmetro e malha de um centímetro); (b) tamanho grande (até três metros de diâmetro e malha de três centímetros), (ii) puçás ou jererês, (iii) hastes não perfurantes para desalojar os peixes de suas tocas ou abrigos. Os exemplares vivos de espécies nativas que não tenham sido não listadas no Anexo I da IN não podem ser explorados para fins ornamentais e de aquariofilia, salvo quando as suas espécies tenham regulamentação federal própria permitindo a sua utilização para tal finalidade. Já os espécimes vivos de peixes de espécies não listadas no Anexo I da IN poderão ser explorados para fins ornamentais e de aquariofilia, desde que não ocorram naturalmente no território nacional ou que tenham origem em cultivo devidamente registrado no órgão competente, acompanhados de comprovante de origem. Admite-se que exemplares vivos de espécies nativas não listadas no Anexo I da IN sejam utilizadas para fins didáticos, educacionais ou expositivos, desde que o uso seja autorizado pela Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Ibama do estado onde se realizará a exposição.

É permitida a exposição em restaurantes, para fins de consumo alimentar, de exemplares vivos de espécies não listadas no Anexo I da IN, respeitada a legislação que regulamenta o seu uso.

Na forma do § 6º do artigo 2º: *“A captura e a comercialização de exemplares cuja espécie conste ou passe a constar em listas oficiais de espécies sobre-explotadas, ameaçadas de sobre-explotação, de extinção, ou no Apêndice I da Convenção Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, mesmo que permitidos por esta IN, devem obedecer às normas estabelecidas pelas legislações específicas”*.

As embarcações utilizadas na captura de peixes marinhos e estuarinos, para ornamentação e aquariofilia, deverão estar devidamente autorizadas pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR. Em tal caso, a tripulação das embarcações poderão capturar peixes marinhos e estuarinos na quantidade máxima de 5 kg (cinco quilogramas) de pescado mais 1 (um) exemplar por viagem e por pescador, se destinado exclusivamente ao consumo próprio. As embarcações, contudo, não poderão conduzir petrechos de pesca não relacionados nos incisos I, II e III do artigo 1º da IN, exceto linha e anzol.

Os utensílios que caracterizam a captura de peixes vivos marinhos, estuarinos e o acondicionamento a bordo, para fins de ornamentação e aquariofilia são: (a) reservatórios com renovação constante de água para manutenção dos exemplares capturados; (b) pequenos tanques redes, recipientes e sacos plásticos com furos, destinados ao acondicionamento dos peixes durante a coleta dos exemplares; (c) recipientes plásticos de tamanhos variados, com furos, utilizados para o confinamento dos exemplares de forma individual; (d) cinto de lastro; (e) nadadeiras; (f) máscaras de mergulho; (g) válvulas (estágios I e II) para respiração artificial; e (h) cilindros e compressores de ar para respiração artificial.

Durante o processo de captura de peixes nativos de águas marinhas e estuarinas para fins ornamentais e de aquariofilia é proibido: (i) uso de substâncias químicas, anestésicas, tóxicas ou que causem irritações; (ii) perfuração do exemplar para descompressão; (iii) retirada e/ou ações que acarretem danos físicos aos corais, moluscos; (iii) equinodermos, crustáceos, esponjas, algas e outros seres pertencentes ao substrato marinho; e (iv) revolvimento de substrato.

No que tange à exportação e à importação de peixes para fins ornamentais e de aquariofilia somente poderão ser realizadas mediante Autorização de Exportação (Anexo II) ou de Importação (Anexo III) de que trata a IN, emitida pela Superintendência Estadual do Ibama e assinada pelo seu representante legal. As exportações de espécimes de peixes nativos não reproduzidos em cativeiro terão cotas anuais por espécie, por empresa ou cooperativa de pescadores, conforme especificação constante do Anexo I da IN.

Compete à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas – DBFLO/Ibama controlar as exportações das espécies citadas no *caput* do artigo 5º, verificando se as cotas de exportação, estabelecidas no Anexo I da IN, foram atingidas, através das efetivações realizadas via Sistema de informações do BACEN – Sisbacen.

Às empresas detentoras de cotas cabe a responsabilidade de informar à DBFLO/Ibama o cancelamento de Registros de Exportação previamente efetivados pelo Ibama, para a atualização das cotas utilizadas. Observe-se que as autorizações são concedidas pelo prazo máximo de 1 ano, expirando compulsoriamente no dia 31 de dezembro do ano de sua emissão, sendo obrigatórios os seguintes procedimentos: (i) Cabe ao interessado, quando houver finalidade comercial protocolizar solicitação de exportação ou importação, acompanhada dos seguintes documentos: (a) Registro Geral de Pesca-RGP emitido pela SEAP/PR dentro do prazo de validade; (b)

Cadastro Técnico Federal-CTF/Certificado de Regularidade do Ibama; (c) Licenciamento ambiental (quando necessário); (d) Relação das espécies, discriminadas pelo nome científico e, para as exportações, as quantidades de cada espécie. (ii) Compete ao interessado, quando não houver finalidade comercial protocolizar solicitação de exportação ou importação, acompanhada da relação das espécies discriminadas pelo nome científico e, para as exportações, as quantidades de cada espécie. (iii) Cabe às Superintendências do Ibama: (a) analisar a solicitação, levando em conta a finalidade, a documentação apresentada e as espécies e quantidades solicitadas; (b) elaborar parecer técnico, considerando as espécies solicitadas e a documentação apresentada, devendo, verificar o efetivo pagamento das taxas; e, (c) emitir a Autorização e enviar cópia à Coordenação Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros – CGFAP, da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas – DBFLO do Ibama.

É permitida, com fins de ornamentação e de aquaríofilia, a importação das espécies de peixes de águas marinhas e estuarinas de acordo com as orientações contidas no Anexo IV dessa IN. No prazo de até 60 dias anteriores ao vencimento da autorização, poderá o interessado requerer nova autorização, caso o Ibama não se manifeste conclusivamente sobre o pedido até a expiração autorização anterior, fica a mesma automaticamente renovada por mais um ano ou até posterior deliberação do órgão ambiental.

Quando a autorização de exportação de espécies nativas for solicitada no segundo semestre do ano, observar-se-ão os limites de cotas proporcionais à quantidade de meses restantes para o encerramento do ano.

As Autorizações de Exportação ou Importação tratadas no artigo 5º da IN não se aplicam às espécies que constem ou passem a constar dos Apêndices da Convenção Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES.

A exportação ou importação internacional de peixes cuja espécie conste ou passe a constar nos Apêndices da CITES deverão ser realizadas mediante autorização própria para cada transação, conforme instituído na IN Ibama nº 140/2006.

Quanto ao transporte interestadual de espécies de peixes de águas marinhas e estuarinas para fins ornamentais e de aquaríofilia, em todo o seu percurso, esse deve ser realizado juntamente com a Guia de trânsito de peixes com fins ornamentais e de aquaríofilia – GTPON, constante no Anexo V da IN. O transporte internacional com fins comerciais prescinde da GTPON, todavia a carga deve se fazer acompanhar de cópia impressa do Registro de Exportação (RE) ou da Licença de Importação (LI) do BACEN, efetivados no Sisbacen, Siscomex ou outros sistemas que venham a substituí-los.

É dispensada a GTPON para o transporte interestadual de até 10 espécimes de peixes de águas marinhas e estuarinas com fins ornamentais ou de aquaríofilia, por pessoa física, desde que não haja objetivo comercial; devendo o interessado acompanhar a carga em todo o trajeto do transporte. O transporte internacional deverá ser autorizado pelo Ibama, conforme o estabelecido no art. 5º da IN, não se dispensando os documentos obrigatórios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, bem como das autoridades estaduais ou municipais pertinentes.

A IN Interministerial MMA/MPA nº 001, de 3 janeiro de 2012, é a norma que define critérios e padrões para a exploração de peixes nativos ou exóticos de águas continentais com finalidade ornamental ou de aquaríofilia, tendo sido baixada por ato conjunto dos Ministros de Estado da Pesca e Aquicultura e do MMA.

Estão fora do campo de incidência da IN Interministerial: (i) a exposição em restaurantes, para fins de consumo alimentar de peixes vivos; e (ii) a exposição de peixes vivos em zoológicos, mostras ou similares com finalidade didática, educacional ou científica.

O artigo 2º da IN estabeleceu os seguintes conceitos: (i) Ornamentação: utilizar organismos vivos ou não, para fins decorativos, ilustrativos ou de lazer; e (ii) Aquaríofilia: manter ou comercializar, para fins de lazer ou de entretenimento, indivíduos vivos em aquários, tanques, lagos ou reservatórios de qualquer tipo.

São permitidos a captura, o transporte e a comercialização de exemplares vivos de peixes nativos das espécies listadas no Anexo I da IN Interministerial. Os exemplares vivos de espécies nativas não listadas no Anexo I da IN Interministerial não poderão ser explorados para fins ornamentais e de aquaríofilia, salvo aqueles cujas espécies possuam regulamentação específica que permita a utilização para tais fins. A identificação das espécies não descritas cientificamente e permitidas no Anexo I da IN Interministerial, será ser realizada com base nos exemplares de referência, conforme número de registro e Museu, Universidade ou Instituto de Pesquisa onde se encontrem depositados, e nas fichas constantes nos sítios eletrônicos do IBAMA e do Ministério da Pesca e Aquicultura para fins de orientação a comerciantes e consumidores. Os espécimes vivos de espécies não listadas no Anexo I da IN Interministerial poderão ser explorados para fins ornamentais e de aquaríofilia, desde que: (i) não ocorram naturalmente no território nacional; e (ii) sejam provenientes de cultivo devidamente registrado no órgão competente, acompanhados de comprovante de origem; por sua vez, a captura e a comercialização de exemplares cuja espécie conste ou passe a constar de listas oficiais de espécies sobre-explotadas, ameaçadas de sobre-explotação ou de extinção, ou nos Anexos da Convenção Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES, deverão obedecer também às normas ali estabelecidas, mesmo que permitidas pela IN.

São proibidos durante o processo de captura de peixes nativos de águas continentais para fins ornamentais e de aquaríofilia: (i) o uso de substâncias químicas, anestésicas, tóxicas ou que causem irritações; (ii) as ações que acarretem danos ambientais ou à fauna aquática; e (iii) o revolvimento de substrato.

O transporte interestadual de espécies de peixes de águas continentais para fins ornamentais e de aquaríofilia, em todo o seu percurso, deve estar acompanhado da Guia de trânsito de peixes com fins ornamentais e de aquaríofilia – GTPON, constante no Anexo II da IN Interministerial; no entanto, será dispensada a GTPON para o transporte interestadual de até 40 espécimes, sem objetivo comercial, de peixes de águas continentais com fins ornamentais ou de aquaríofilia, por pessoa física, em tal caso, o interessado deverá acompanhar a carga em todo o trajeto do transporte. Em se tratando de transporte internacional com fins comerciais não há necessidade de GTPON, devendo a carga estar acompanhada da cópia impressa do Registro de Exportação-RE ou da Licença de Importação-LI do BACEN, efetivado no Sistema de Informações do BACEN-Sisbacen, no Sistema Integrado do Comércio Exterior-Siscomex ou outros sistemas que venham a substituí-los. Para o transporte internacional, deve ser solicitada licença de exportação ou importação, por meio do Sistema de Emissão de Licenças para a importação ou exportação de flora e fauna – Cites. No caso de exportação ou importação de peixes cujas espécies constem ou passem a constar nos Anexos da Cites, deverá haver uma autorização própria para cada transação, de acordo com o estabelecido pela IN Ibama nº 140/2006, cujas solicitações devem ser feitas pelo Siscites.

É permitida, para fins de ornamentação e de aquaríofilia, a importação das espécies de peixes de águas continentais constantes do Anexo III da IN Interministerial, sendo proibida a importação das espécies constantes.

O inciso VI estabelece como infração administrativa a prática daquele que “*deixa de apresentar declaração de estoque*”. A declaração de estoque é documento.

Art. 36. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria.

A norma corresponde ao artigo 35 da Lei nº 9.605/1998.

Especial atenção foi dada à proibição da pesca mediante a utilização de explosivos, substâncias tóxicas ou proibidas pelas autoridades competentes. É importante observar que, atualmente, a proibição da pesca é atividade feita em colaboração entre o MMA e o MAPA do pelo Decreto nº 6.981/2009.

Pescar com explosivos é fazer detonações no mar ou em águas continentais, com vistas a atordoar ou matar peixes e outros animais aquáticos, a fim de facilitar a captura. É método tipicamente predatório, pois não há qualquer seleção em relação ao animal “pescado”, atingindo toda a vida aquática indistintamente. Ainda é prática comum. A norma proíbe e pune a utilização de qualquer substância que cause efeitos semelhantes ao da explosão. A outra modalidade interdita é a da utilização de substância tóxica. É comum a utilização de elementos químicos que causam anestesiamento do pescado, facilitando-lhe a captura. É método tradicional indígena de pesca. Além dos dois “sistemas” anteriormente vistos, a norma trata de qualquer outra metodologia que tenha sido proibida pela autoridade administrativa.

Art. 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:
Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação.
Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

A pesca é atividade submetida ao poder de polícia do Estado, tendo como um dos principais agentes o MAPA.

Ao MAPA compete dispor sobre (i) política nacional pesqueira e aquícola, abrangendo produção, transporte, beneficiamento, transformação, comercialização, abastecimento e armazenagem; (ii) fomento da produção pesqueira e aquícola; (iii) implantação de infraestrutura de apoio à produção, ao beneficiamento e à comercialização do pescado e de fomento à pesca e aquicultura; (iv) organização e manutenção do Registro Geral da Pesca; (v) sanidade pesqueira e aquícola; (vi) normatização das atividades de aquicultura e pesca; (vii) fiscalização das atividades de aquicultura e pesca no âmbito de suas atribuições e competências; (viii) *concessão de licenças, permissões e autorizações para o exercício da aquicultura e das seguintes modalidades de pesca no território nacional, compreendendo as águas continentais e interiores e o mar territorial da Plataforma Continental, da Zona Econômica Exclusiva, áreas adjacentes e águas internacionais, excluídas as Unidades de Conservação federais e sem prejuízo das licenças ambientais previstas na legislação vigente*: (1) pesca comercial, compreendendo as categorias industrial e artesanal; (2) pesca de espécimes ornamentais; (3) pesca de subsistência; (4) pesca amadora ou desportiva; (ix) autorização do arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca e de sua operação, observados os limites de sustentabilidade estabelecidos em conjunto com o MMA; (x) operacionalização da concessão da subvenção econômica ao preço do óleo diesel instituída pela Lei nº 9.445, de 14 de março de 1997; (xi) pesquisa pesqueira e aquícola; e (xii) fornecimento ao MMA dos dados do Registro Geral da Pesca relativos às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e aquicultura, para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Cabe ao MAPA e ao MMA, em conjunto e sob a coordenação do primeiro, nos aspectos relacionados ao uso sustentável dos recursos pesqueiros: (i) fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, com base nos melhores dados científicos e existentes, na forma de regulamento; e (ii) subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca e aquicultura.

O exercício da pesca pode se dar de diversas maneiras, conforme estabelecido pela Lei nº 11.959/2009. A pesca pode ser: (i) comercial, subdividindo-se em: (a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; (b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial; ou (ii) não comercial: (a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; (b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; (c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

O pescador pode ser amador ou profissional, sendo “*amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a pesca sem fins econômicos*” (art. 2º, inciso XXI, Lei nº 11.959/2009) e pescador profissional “*a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica*” (art. 2º, inciso XXII, Lei nº 11.959/2009).

A *atividade pesqueira* é constituída por todos os processos de pesca, exploração e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros e o seu exercício somente pode ser realizado mediante prévio ato autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas: (i) a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais; (ii) a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das populações com saberes tradicionais; (iii) a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos.

A administração, nos termos do artigo 25 da Lei nº 11.959/2009, exerce o poder de polícia sobre a atividade pesqueira mediante a expedição dos seguintes atos administrativos: (i) *concessão*: para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à exploração de recursos pesqueiros; (ii) *permissão*: para transferência de permissão; para importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital; para construção, transformação e importação de embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para pesquisa; para o exercício de aquicultura em águas públicas; para instalação de armadilhas fixas em águas de domínio da União; (iii) *autorização*: para operação de embarcação de pesca e para operação de embarcação de esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a realização de torneios ou gincanas de pesca amadora; (iv) *licença*: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; (v) *cessão*: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, dos Estados e do Distrito Federal, para fins de aquicultura.

Para a obtenção de concessão, permissão, autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira, o interessado deve estar previamente cadastrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira.

O poder de polícia sobre a atividade pesqueira e a consequente fiscalização abrange as fases de pesca, cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos.

Aquicultura. O registro da atividade de aquicultura está regulado pela IN nº 6/2011, do MAPA.

Os conceitos normativos definidos pela IN são: (i) aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo, sendo classificada como: (a) comercial: quando praticada com finalidade econômica, por pessoa física ou jurídica; (b) familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei nº 11.326/2006; (c) ornamental: quando praticada para fins de aquaríofilia ou de exposição pública, com fins comerciais ou não. (ii) aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, exerce a aquicultura com fins comerciais; (iii) Registro de Aquicultor: documento emitido em caráter individual e preliminar, em modelo adotado pelo MPA, considerado como instrumento comprobatório da primeira fase de inscrição do interessado junto ao RGP; (iv) Licença de Aquicultor: documento emitido em caráter individual, em modelo adotado pelo MPA, considerado como instrumento comprobatório da fase conclusiva de inscrição do interessado junto ao RGP, na categoria de Aquicultor, que o permite exercer a atividade de aquicultura; (v) unidade de aquicultura: conjunto de estruturas destinadas à aquicultura, caracterizando um empreendimento único, delimitado ou facilmente passível de delimitação, localizado em uma mesma propriedade, posse, cessão ou domínio. (vi) formulário de requerimento do Registro de Aquicultor: formulário contendo informações necessárias para o cadastro do aquicultor e da atividade; (vii) formulário de requerimento da Licença de Aquicultor: formulário contendo informações sobre a unidade de aquicultura, bem como dados técnicos do cultivo.

Devem se inscrever no RGP, na categoria de Aquicultor, para o exercício da aquicultura, desde que atendidos os demais requisitos estabelecidos na IN: (i) a pessoa física em pleno exercício de sua capacidade civil, brasileira, nata ou naturalizada; (ii) a pessoa estrangeira portadora de autorização para o exercício profissional no País; e (iii) a pessoa jurídica regularmente registrada. A inscrição de pessoa física ou jurídica no RGP, na categoria de Aquicultor, é feita em duas etapas que se complementam, sendo o Registro de Aquicultor a primeira etapa e a Licença de Aquicultor a conclusiva. Elas podem ser realizadas separadamente ou em conjunto, de acordo com a apresentação da documentação exigida nos artigos 7º e 8º da IN. O Registro e a Licença de Aquicultor não podem ser transferidos

para terceiros.

Conforme redação dada pela IN MPA nº 16/2013, o Registro de Aquicultor tem validade por tempo indeterminado, condicionado à posse pelo interessado do número do protocolo ou documento similar que comprove o requerimento de licença ambiental junto ao Órgão Ambiental competente. Após a obtenção da primeira licença de aquicultor não será necessária a manutenção do Registro de Aquicultor, devendo apenas atualizá-lo quando necessário.

Já a Licença de Aquicultor terá validade de um ano, contado a partir da data de expedição, devendo a renovação ser requerida até trinta dias antes da data do seu vencimento.

O Registro de Aquicultor e a Licença de Aquicultor serão cancelados: (i) a pedido do interessado; (ii) nos casos de óbito do interessado; (iii) por decisão judicial; (iv) por infração à legislação vigente, a pedido do órgão fiscalizador competente; (v) quando não renovados em até 12 (doze) meses após a data de vencimento. O Registro e a Licença de Aquicultor serão suspensos de ofício, quando houver descumprimento a qualquer dispositivo da IN. Evidentemente, há que se assegurar ao titular do Registro ou da Licença, o direito à ampla defesa.

Não é exigível o Registro e Licença de Aquicultor para: (i) exposições com finalidades educativas; (ii) aquicultura com fins de subsistência; (iii) aquicultura praticada para fins de aquarofilia ou de exposição pública, quando sem fins comerciais; (iv) restaurantes, peixarias e similares, que mantenham organismos aquáticos vivos para o abate e consumo direto, excetuando o pesque-pague.

Permissionamento de embarcações. A IN Interministerial nº 10/2011, alterada pelas IN MMA/MAPA nº 14/2014 e 01/2015, aprovou as normas gerais e a organização do sistema de permissionamento de embarcações de pesca para acesso e uso sustentável dos recursos pesqueiros, com definição das modalidades de pesca, espécies a capturar e áreas de operação permitidas.

A IN estabeleceu os seguintes conceitos: (i) *Embarcação de Pesca*: aquela que, permissionada e registrada junto à Autoridade Marítima e ao Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP, opera com exclusividade em uma ou mais das seguintes atividades: pesca, aquicultura, conservação, processamento e transporte de pescado, conforme disposto nos incisos I a VI, do art. 10, da Lei nº 11.959/2009; (ii) *Pesca*: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros; (iii) *Pesca Comercial*: aquela praticada com fins comerciais; (iv) *Pesca Comercial Artesanal*: aquela praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta – AB menor ou igual a 20; (v) *Pesca Comercial Industrial*: aquela praticada por pessoa física ou jurídica, envolvendo pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações com qualquer AB; (vi) *Permissão Prévia de Pesca*: ato administrativo discricionário e precário, condicionado ao interesse público, pelo qual é permitido ao interessado adquirir, construir, substituir ou importar uma Embarcação de Pesca, transformar suas características estruturais ou mudar de Modalidade de Permissionamento, sem prejuízo da obrigatoriedade de obtenção das licenças de construção ou importação junto aos órgãos competentes, conforme o caso, e da autorização de pesca para fins de operação; (vii) *Autorização de Pesca*: ato administrativo discricionário e precário, condicionado ao interesse público, pelo qual é permitido ao proprietário ou arrendatário, detentor de permissão prévia de pesca dentro do prazo de validade, operar com Embarcação de Pesca, devidamente identificada, na pesca de determinada(s) Espécie(s) Alvo, definida(s) em uma Modalidade de Permissionamento prevista nesta IN; (viii) *Autorização de Pesca Complementar*: ato administrativo discricionário e precário, condicionado ao interesse público, concedido de forma concomitante e complementar à Autorização de Pesca, pelo qual é permitido ao proprietário ou arrendatário operar com embarcação na atividade de Pesca de Espécie(s) Alternativa(s), devidamente identificadas na Modalidade de Permissionamento; (ix) *Registro de Embarcação de Pesca*: inscrição no RGP dos dados relativos à propriedade, posse, características estruturais e Modalidade de Permissionamento de uma Embarcação de Pesca, armazenados no Sistema Informatizado do RGP – SisRGP, módulo integrante do Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura – SINPESQ; (x) *Modalidade de Permissionamento*: conjunto de informações relativas ao Método, a Modalidade de Pesca, com a(s) respectiva(s) espécie(s) a ser(em) capturada(s), incluindo a Fauna Acompanhante Previsível, a(s) Espécie(s) de Captura Incidental e a(s) Área(s) de Operação, componentes da Permissão Prévia de Pesca ou da Autorização de Pesca e da Autorização de Pesca Complementar; (xi) *Método de Pesca*: conjunto de Modalidades de Pesca distintas, que utiliza Petrechos de Pesca com características físicas e operacionais semelhantes; (xii) *Modalidade de Pesca*: processo ou forma de extração, coleta ou captura de recursos pesqueiros realizados em conformidade com as características estruturais e operacionais da Embarcação de Pesca e seus equipamentos, assim como dos Petrechos empregados nas operações de Pesca; (xiii) *Petrecho de Pesca*: instrumento, aparelho, utensílio, ferramenta ou objeto utilizado(s) nas operações de Pesca; (xiv) *Espécie(s) Alvo*: espécie(s) de interesse comercial, objeto principal da Permissão Prévia de Pesca e da Autorização de Pesca, sobre a qual é direcionado o esforço de Pesca; (xv) *Espécie(s) Alternativa(s)*: espécie(s) de interesse comercial, distinta(s) da(s) Espécie(s) Alvo, cuja pesca é permitida pela Autorização de Pesca Complementar, podendo ocorrer durante a temporada de Pesca da Espécie(s) Alvo, assim como durante o defeso dessa(s) Espécie(s) Alvo, observado o ordenamento definido em norma específica; (xvi) *Área de Operação*: área correspondente à ocorrência natural da(s) Espécie(s) Alvo ou a definida em regulamentação, especificada nas Autorizações de Pesca, respeitadas as áreas de restrição de Pesca, previstas em legislação específica; (xvii) *Fauna Acompanhante Previsível*: conjunto de espécies passíveis de comercialização, capturadas naturalmente durante a pesca da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou profundidade, cuja captura não pode ser evitada, observado o ordenamento definido em norma específica; (xviii) *Espécies de Captura Incidental*: conjunto de espécies não passíveis de comercialização, capturadas incidentalmente durante a pesca da(s) Espécie(s) Alvo, as quais coexistem na mesma área de ocorrência, substrato ou profundidade, cuja captura deve ser evitada por estarem protegidas por legislações específicas ou Acordos Internacionais, as quais, quando capturadas, devem ser liberadas vivas ou descartadas na área de pesca ou desembarcadas para fins de pesquisa quando autorizadas em norma específica e sua ocorrência registrada nos Mapas de Bordo; (xix) *Defeso*: paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução ou recrutamento, assim como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentais.

Haja vista que a pesca é atividade submetida ao poder de polícia do Estado, as modalidades listadas a seguir necessitam de prévia autorização para que possam ser praticadas legalmente: (i) *Linha*: o que se realiza com o emprego de linha simples, com ou sem o auxílio de caniços ou varas, ou múltipla com anzóis ou garateias encastoados, do tipo espinhel, cuja operação requeira o auxílio de Embarcação de Pesca; (ii) *Emalhe*: o que se realiza com o emprego de rede de espera não tracionada, à deriva ou fundeada, cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o auxílio de Embarcação de Pesca; (iii) *Arrasto*: o que se realiza com o emprego de rede de arrasto tracionada, com recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de Embarcação de Pesca; (iv) *Cerco*: o que se realiza com o emprego de rede de cerco, com recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de Embarcação de Pesca; (v) *Armadilha*: o que se realiza com o emprego de Petrechos dos tipos covos ou potes, cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o auxílio de Embarcação de Pesca; (vi) *Outros*: qualquer outra Modalidade de Pesca não mencionada nos incisos anteriores, cuja operação requeira o auxílio de Embarcação de Pesca.

As Modalidades de Pesca e os Petrechos a serem utilizados em cada Método descrito no parágrafo anterior deverão observar as restrições previstas nas normas de ordenamento, definidas no âmbito do sistema de gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros, de que trata o Decreto nº 6.981/2009, e a Instrução Normativa MPA/MMA nº 05/2015.

A pesca de Espécie Alternativa durante o período de defeso da Espécie-Alvo, somente será permitida quando requerida pelo interessado e autorizada pelo MAPA ou quando prevista em norma de ordenamento específica, definida no âmbito do sistema de gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros.

Para a concessão de Autorização de Pesca na Modalidade de Permissionamento qualificada como Diversificada Costeira, deverão ser observadas as seguintes condições: (i) Embarcação de Pesca não motorizada com AB inferior ou igual 2,0; (ii) Na ausência da informação sobre a AB, a embarcação deverá possuir comprimento total inferior ou igual a 8,0 metros. Nas hipóteses em que a Embarcação de Pesca for motorizada, a potência do motor não poderá ultrapassar 18 HP; a Modalidade de Permissionamento Diversificada Costeira não poderá contemplar (i) prática de arrasto tracionado; e (ii) captura de espécies sob controle de esforço de pesca.

A concessão de Permissões Prévias de Pesca e de Autorizações de Pesca, inclusive nos casos de substituição de embarcação já permissionada, fica condicionada aos critérios e condições previstas nas normas específicas de cada Modalidade de Permissionamento, definidas, para cada caso, no âmbito do sistema de gestão

compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros, de que tratam o Decreto nº 6.981/2009, e a Portaria Interministerial MPA/MMA nº 05/2015. Em sendo o caso da Modalidade de Permissionamento que contemple frota que atue sobre espécies com controle de esforço, a nova embarcação somente receberá a Permissão Prévia de Pesca ou a Autorização de Pesca se, com vistas à recuperação dos estoques, apresentar as seguintes características: (i) compatibilidade, em termos de características físicas e operacionais, com a pescaria que irá realizar; (ii) respeitar o poder de pesca da embarcação desativada e o limite de esforço de pesca para a modalidade, com base nos parâmetros definidos nas normas de ordenamento específicas de cada pescaria ou modalidade de permissionamento; (iii) assegure maior eficiência no aproveitamento do pescado capturado, com vistas à redução das perdas.

Art. 38. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de espécies aquáticas, oriundas de produto de pesca para ornamentação.
§ 1º Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida.
§ 2º A multa de que trata o <i>caput</i> será aplicada em dobro se houver dano ou destruição de recife de coral.

O artigo *não possui correspondente na Lei nº 9.605/1998*. Contudo, a modalidade importar está compreendida no tipo previsto no artigo 31 da Lei nº 9.605/1998: Importar é trazer do exterior para o Brasil; já exportar é fazer o movimento inverso. A importação e a exportação são atividades que estão submetidas ao poder de polícia do Estado, no caso presente tal controle é multifacetado, nele intervindo a (i) autoridade ambiental, (ii) a fazendária e (iii) a sanitária. A norma tutela as águas jurisdicionais brasileiras que são conceito normativo estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 9.966/2000.

A norma tutela a fauna aquática e não apenas marinha em dois aspectos relevantes (i) a introdução de espécies exóticas sem a competente autorização do órgão de controle ambiental e (ii) a retirada de espécimes da fauna aquática do território nacional sem o conhecimento e a autorização das autoridades ambientais. Busca-se, assim, assegurar higidez do meio ambiente aquático, mantendo o equilíbrio das espécies autóctones. Além da importação e da exportação, a norma visa impedir que espécies exóticas sejam introduzidas no meio ambiente sem o efetivo controle da autoridade ambiental. Mesmo que o interessado possua a licença ambiental específica para a atividade, a norma equipara a não observância dos estritos termos da licença com a sua ausência pura e simples.

A introdução de espécies aquáticas nas águas jurisdicionais brasileiras foi regulamentada pela Portaria nº 145-N/1998 do IBAMA. Em realidade, as normas estabelecidas pela Portaria vão além de introdução de espécies, pois se destinam também à *“reintrodução e transferência de peixes, crustáceos, moluscos e macrófitas aquáticas para fins de aquicultura, excluindo-se as espécies animais ornamentais”* (artigo 1º).

Quanto ao tema, há ainda a Portaria IBAMA nº 5/2008, que cuida da chamada lagostim-vermelha. Por tal Portaria, o Ibama houve por bem *“não autorizar, em todo território nacional, a introdução, reintrodução, importação, comercialização, cultivo e transporte de indivíduos vivos da espécie Procambarus clarkii”*.

A pena administrativa aplicada é a multa; todavia, parece-me que a multa, no caso, é inaplicável, pois hipótese de incidência, data vênua, não guarda qualquer relação com o *caput* do tipo administrativo. De fato, as condutas puníveis são: (i) importar; (ii) exportar *“quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida”*. Assim, inteiramente sem sentido a punição ao “produto da pescaria”, pois não é disso que se trata. Pesca não se confunde com importação ou exportação.

O § 1º, art. 38, do Decreto nº 6.514/2008 determina ser aplicada a mesma pena àquele que *“introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida”*. A pena é, igualmente, inaplicável haja vista que introdução de espécies nativas ou exóticas não é pescaria. Já o § 2º estabelece critério para a majoração da pena administrativa que é a existência de dano ou destruição de recife e coral. Assim, caso a espécie introduzida cause dano ou destruição de recifes de coral, duplica-se a penalidade. Contudo, de meu ponto de vista, permanece inaplicável a pena, pois ela está condicionada ao produto da pesca que, como já foi assinalado, não é o caso.

Art. 39. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime do produto.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I – utiliza, comercializa ou armazena invertebrados aquáticos, algas, ou recifes de coral ou subprodutos destes sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida; e
II – fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.
Art. 40. A comercialização do produto da pesca de que trata esta Subseção agravará a penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies sobre-explotadas ou ameaçadas de sobre-exploração, conforme regulamento do órgão ambiental competente, com o acréscimo de:
I – R\$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobre-exploração; ou
II – R\$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobre-explotadas.

A norma não tem correspondente na Lei nº 9.605/1998.
A subseção na qual está inserido o artigo 40 está voltada para a proteção dos recursos pesqueiros, determinando uma série de condutas ilícitas e que, portanto,

devem ser reprimidas pela autoridade administrativa. O artigo, na verdade, é uma agravante a ser aplicada aos demais casos de comercialização em desconformidade com as normas legais sempre que a espécie for (i) sobre-explotada ou (ii) ameaçada de sobre-explotação, conforme definido pela autoridade competente. É importante que se ressalte que, no caso, a norma se aplica apenas à comercialização e não a qualquer outra etapa do ciclo econômico do pescado.

A autoridade competente para a definição das espécies sobre-explotadas ou em vias de sobre-explotação é bifronte; pois nos termos do Decreto nº 6.981/2009, há gestão compartilhada entre o MAPA e o MMA sobre os recursos pesqueiros, cabendo a ambos ministérios conjuntamente fixar “as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento, em conformidade com as peculiaridades de cada unidade de gestão”, dispondo sobre: “I – os regimes de acesso; II – a captura total permitível; III – o esforço de pesca sustentável; IV – os períodos de defeso; V – as temporadas de pesca; VI – os tamanhos de captura; VII – as áreas interditadas ou de reservas; VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; e IX – a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques” (art. 4º).

O critério da norma é econômico, pois não foi usada a expressão *ameaçado de extinção* ou *em ameaça de extinção*. É lógico que a sobre-explotação tem como consequência o risco à própria espécie, contudo o poder regulamentar deu ênfase ao aspecto econômico, o que me parece um despropósito.

Art. 41. Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente:

Multa: R\$ 1.000,00 (mil reais).

Os comandantes das embarcações têm por obrigação legal fornecer informações aos diferentes órgãos de controle da pesca no que se refere aos locais nos quais as embarcações estão atuando, a quantidade e qualidade do pescado e tantas outras informações quantas sejam necessárias, o que se faz pelo preenchimento de mapas fornecidos pelas autoridades administrativas. Tais mapas são importantíssimos, pois é mediante o seu adequado preenchimento que boa parte das estatísticas pode ser produzida.

Art. 42. Para os efeitos deste Decreto, considera-se pesca todo ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

Parágrafo único. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

A Lei nº 9.605/1998 assim definiu, em seu artigo 36, a atividade de pesca para fins penais:

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

A definição de pesca é aquela contemplada pelo inciso III do artigo 2º da Lei nº 11.959/2009:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura; ... III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros. [...]

Como se vê, a norma administrativa regulamentada foi a constante da Lei nº 11.959/2009, que em seu artigo 33 assim determina:

Art. 33. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas na forma da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e de seu regulamento.

Ora, analisando-se sistematicamente o conjunto de artigos acima, verifica-se que o parágrafo único do artigo 42 foi além do disposto, seja na Lei nº 9.605/1998, seja na Lei nº 11.959/2009. Ademais, o parágrafo pune os chamados atos preparatórios, o que me parece antijurídico. De fato, o parágrafo único, sem base legal, pois alterou completamente o sentido de “ato tendente”, vez que considera a mera detenção de petrechos de pesca como infração administrativa desde que o “infrator” esteja na área de pesca ou dirigindo-se a ela. Em um ônibus, de táxi, de avião? Como se sabe, atos preparatórios não são puníveis, pois sequer podem ser tidos por tentativa de prática de ato ilícito (TRF1ª Região, RCCR 200132000132923, RCCR – Recurso CRIMINAL – 200132000132923, 3ª Turma, DJU 20/1/2006, p. 47).

4.3.2 Infrações contra a flora

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida.

A Lei nº 9.605/1998 não possui correspondente exato, possuindo, no entanto, artigos que podem ser considerados “regulamentados” pelo decreto, quais sejam:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade; Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade; Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa

O artigo do Decreto faz uma mescla dos tipos penais, de molde a definir um tipo administrativo. Os três tipos penais, bem como o administrativo, têm como núcleo os verbos *destruir* ou *danificar*, que, para efeito da aplicação da sanção, foram considerados iguais pelo legislador.

Art. 44. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem

permissão da autoridade competente:
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou R\$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.

A Lei nº 9.605/1998 assim dispõe:

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente: Pena – detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

O ilícito administrativo é o corte de árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida. A aplicação do tipo não é simples, demandando que previamente à aplicação de qualquer sanção seja examinado: (i) se a área é de preservação permanente e (ii) se o espécime cortado é parte de espécie especialmente protegida e (iii) se havia autorização válida.

Outra questão complexa decorre da aplicação do Decreto por órgãos de controle ambiental dos estados e dos municípios. Muitas vezes ocorre a utilização do Decreto nº 6.514 para punir infração à legislação local. Em não poucas oportunidades a legislação local estabelece áreas de preservação permanente que não encontram equivalente no antigo, nem no novo Código Florestal, como é o caso da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (artigo 268), que estabelece como área de preservação permanente a Baía de Guanabara. Em tais hipóteses, o agente autuante somente poderá considerar de preservação permanente as áreas arroladas nas leis federais de regência. É importante observar que o ilícito é “*cortar árvores*”. Chamo a atenção para o fato, pois o decreto se utiliza muito de vocábulos como “floresta”, “floresta nativa”, “demais formas de vegetação” e outros semelhantes. Assim, o ilícito é bastante específico e a penalidade somente pode ser aplicada quando houver corte ilegal de *árvore* em área de preservação permanente e não uma genérica “supressão de vegetação”. Equipara-se ao corte em área de preservação permanente aquele feito em árvore pertencente a “espécie especialmente protegida”. Com relação à proteção especial de espécie, a matéria é complexa, pois como se sabe existem diversos níveis de proteção das espécies, estejam elas em extinção ou não. Há espécies que são protegidas localmente, porém não nacionalmente. Como proceder? Havendo divergência entre a lista local e a nacional, penso que o melhor critério é adotar a lista local, pois esta indica com mais precisão se a espécie está, ou não, localmente ameaçada.

Art. 45. Extrair de florestas de domínio público ou áreas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Multa simples de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou fração.

O tipo corresponde ao artigo 44 da Lei nº 9.605/1998:

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

O bem jurídico tutelado é a *riqueza mineral do subsolo* e do solo das florestas de domínio público. Note que a norma não protege *Unidade de Conservação*, mas *floresta de domínio público*, que é conceito mais amplo. A atividade proibida é a extração mineral que está submetida, no caso em tela, à dupla regulamentação: (i) da autoridade mineral e (ii) da autoridade ambiental.

Os produtos minerais, oriundos do subsolo, são bens de propriedade da União, haja vista que, nos termos de nossa CF, a propriedade do solo é distinta da propriedade do subsolo. No caso mencionado no artigo, a norma se bifurca na proteção das (i) florestas de domínio público e das (ii) áreas de preservação permanente, estas últimas de domínio público ou privado. A norma, contida no artigo ora comentado, deve ser vista como ênfase da necessidade de autorização para a extração mineral, uma vez que, independentemente da natureza do regime dominial aplicável ao solo, a exploração do subsolo somente poderá ocorrer licitamente com a necessária autorização do Agência Nacional de Mineração.

A equiparação para fins de aplicação de sanções administrativas entre florestas de domínio público e áreas de preservação permanente é descabida, pois o regime jurídico de ambas é diverso.

Art. 46. Transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em carvão, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, sem licença ou em desacordo com as determinações legais:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico de carvão – MDC.

O tipo penal mais próximo do administrativo é o previsto no artigo 45 da Lei nº 9.605/1998. O ilícito se resume em transformar madeira, de origem nativa, em carvão para qualquer utilização sem a necessária autorização ou sem a obediência do autorizado. A utilização do carvão vegetal é matéria submetida a grande regulamentação, muito embora nem sempre haja o cumprimento das normas relativas. O agente do ilícito é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que promove a transformação da madeira, qualquer que seja o meio utilizado, em contravenção às normas aplicáveis.

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1º Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.
§ 2º Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.
§ 3º Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da

fiscalização.

§ 4º Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie.

O tipo do Decreto nº 6.614/2008 tem correspondência no artigo 46 da Lei nº 9.605/1998: O ilícito administrativo bem como o penal transferem para o particular a obrigação de fiscalizar a comercialização de produtos madeireiros, haja vista que determinam competir ao adquirente ou possuidor “exigir” que o entregador da mercadoria apresente a licença outorgada pela “autoridade competente”. Caso a mercadoria já tenha sido paga e a licença não seja exibida, cabe ao adquirente arcar com o prejuízo, mesmo em face da mercadoria a ser entregue? Devolve a carga? Penso que a atividade é estatal, pois integrante do poder de polícia, o qual é de prerrogativa do estado.

Pela leitura do *caput* do artigo 47 percebe-se que os destinatários da norma são (i) o comerciante, habitual ou eventual, ou (ii) a indústria. A circulação dos diferentes produtos vegetais encontra-se amplamente regulamentada, o que demonstra por si só que o tema é polêmico e sujeito a diversas formas de pressão política, social e econômica. A vasta regulamentação, entretanto, não foi capaz de pôr fim aos fenômenos das queimadas e do desmatamento de nossas florestas, em especial a Floresta Amazônica. A norma determina que o adquirente exija do vendedor ou do transportador o Documento de Origem Florestal (DOF) do produto adquirido e exigem, ainda, que o adquirente fique com uma das vias do documento, como forma de provar a origem legal do produto adquirido. É importante observar, contudo, que não cabe ao adquirente checar a legalidade do DOF que lhe é apresentado; evidentemente que certificar-se da legalidade do que se está adquirindo é relevante, contudo, não pode o Estado transferir ao particular as suas funções de controle e investigação e apenas-lo caso ela não faça as vezes de fiscal, como parece ser o objetivo do artigo e seus parágrafos.

Na verdade, o procedimento de apenar o particular por falhas do poder público vem se tornando uma constante em nossa legislação ambiental. Observe-se que a norma acarreta, para o particular autuado, o dever de produzir uma “prova negativa”, pois o tipo é lavrado nos seguintes termos: “sem exigir”, logo, cabe ao autuado provar que “exigiu” e, se “exigiu” os documentos e estes não foram apresentados, a compra é ilegal. O que se observa é que criou uma presunção de ilegalidade para os produtos de origem florestal transportados e comercializados. Trata-se, efetivamente, de uma confissão de incapacidade do poder público em controlar a circulação comercial de produtos de origem florestal. O § 2º clarifica o fato de que cabe ao particular “confirmar” a legalidade da documentação apresentada pelo vendedor ou transportador dos produtos de origem florestal.

Os §§ 3º e 4º indicam que a sanção deve ser aplicada mediante a confirmação do volume do produto licenciado e aquele em poder do autuado. Claro está que a diferença entre um e outro é que servirá de base para a aplicação da sanção, quando for o caso. É preciso observar que tal quantificação deve ser feita mediante a elaboração de laudos, os mais detalhados possíveis, com especificações amplas, de forma a permitir uma rápida identificação do ilícito. Laudos pouco claros ou precisos, diante do rigor matemático da norma, implicam nulidade.

Em uma única penada, o Poder regulamentar desconstituiu alguns dos elementos fundamentais de nossa ordem jurídica, tais como (i) a presunção de inocência, (ii) a presunção de legalidade dos documentos públicos e (iii) transferiu para o particular o poder de polícia ambiental.

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente.

Não há uma correspondência perfeita com os tipos penais previstos na Lei nº 9.605/1998, aproximando-se do artigo 48. O objetivo da norma é permitir que as áreas degradadas, nas quais haja possibilidade biológica de regeneração natural possam cumprir seu destino. A regeneração ocorre em diferentes estágios que, em nosso sistema legal, estão disciplinados normativamente, em especial no que tange à mata atlântica. A norma, ora comentada, contudo, dirige-se especialmente às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente, ou especialmente protegidas, inclusive RFL, nas quais tenha havido uma designação de área a ser deixada em regeneração natural. Tal designação deve constar de ato formal do poder público, sob pena de inaplicabilidade do artigo.

Art. 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:

Multa de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare ou fração.

Parágrafo único. A multa será acrescida de R\$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no *caput* se der em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

A Lei nº 9.605/1998 não possui tipo penal exatamente igual ao administrativo, contudo os artigos 38, 38 A e 50, aparentemente, serviram como base para a “regulamentação” administrativa. Cuida-se de norma assemelhada à constante do artigo 44 do decreto. Observe-se que o tipo administrativo faz referência a floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passível de autorização para exploração ou supressão. Inicialmente, cumpre registrar que o decreto não possui uma definição de *preservação*, ou de *especial preservação*. Em norma de direito sancionatório, cuida-se de problema relevante, pois não se pode dar aos termos um grau de elasticidade com tanta amplitude que o cidadão não saiba exatamente qual é a conduta vedada. O termo *especial preservação* é claramente inadequado, pois o que o poder regulamentar quis dizer foi especial *proteção*. *Conservação* e *Preservação* dizem respeito à forma pela qual serão apropriados economicamente os recursos naturais. *Conservação* é a utilização dos recursos ambientais de forma racional e sustentável; já a *preservação* é a utilização indireta dos recursos naturais, sem um uso econômico imediato. Assim, não faz qualquer sentido se falar em preservação especial, como faz o decreto.

A Lei do SNUC define preservação como: “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais”. Por sua vez, a Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 3º, II, estabelece que a Área de Preservação Permanente é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Já o artigo 4º da Lei nº 12.651/2012 estabelece o rol das áreas passíveis de serem enquadradas como de preservação permanente. As áreas mencionadas não se enquadram no conceito de “especial preservação”, haja vista que constam de descrição genérica e não específica, o que asseguraria a ideia de “especialização”.

O essencial para que uma área se caracterize como de preservação permanente é a adição da localização geográfica com a função ambiental, não bastando a simples a localização geográfica, isto porque as leis não possuem palavras ociosas e novo Código Florestal reproduziu, no particular, o que já se fazia presente na

legislação por ele revogada. Código se utilizou da partícula **com**, cujo significado é inequivocamente de adição, ou seja, as áreas de preservação permanente são isto mais aquilo.

O artigo 6º do Código Florestal estabeleceu a possibilidade de que o poder público, mediante a edição de ato próprio, defina outras áreas de preservação permanente, além daquelas criadas por lei. A declaração de imunidade ao corte, tratada pelo artigo 70, II do Novo Código Florestal, também, é vinculada, como decorre de simples leitura do texto legal.

A supressão em áreas de preservação permanente é permitida, desde que observados os ditames constantes do Código Florestal (artigo 7º). De tudo o que foi examinado acima, parece-me evidente que o artigo é mal redigido e se utiliza de conceito inapropriado, “especial preservação”, o qual não encontra base legal, haja vista que mesmo o artigo 4º do Código Florestal estabelece as áreas de preservação permanente e estabelecer um regime de proteção. Contudo, com vistas ao aproveitamento da norma, admite-se que ela se destina aos bens tutelados pelos artigos 4º e 70, II do Novo Código Florestal. *Ressalte-se, entretanto, que somente as florestas e demais formas de vegetação nativas estão albergadas pelo dispositivo*. Há, ainda, outra questão relevante que é a utilização da expressão “*não passíveis de autorização para exploração ou supressão*”. Ora, se o artigo se refere aos bens tutelados pelo artigo 4º do Código Florestal, áreas de preservação permanente criadas por ato do poder público, não há dúvida que eles são passíveis de autorização para supressão, basta uma simples leitura do § 1º do artigo 8º do Código Florestal, assim, a hipótese não se aplicaria. Permaneceria apenas o caso da exploração econômica que, em regra, não é admissível em áreas de preservação permanente.

Por fim, o Parágrafo único estabelece que: “*a multa será acrescida de R\$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica*”. Isto é, haverá um acréscimo da multa caso a floresta ou outra forma de vegetação nativa objeto de especial preservação for vegetação primária ou secundária no estado avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

Bioma Mata Atlântica é aquele tratado pela Lei nº 11.428/2006 (artigo 2º). Observe-se que a Lei da Mata Atlântica outorga uma proteção especial aplicável as formas de vegetação constantes do artigo 2º, não se justificando, portanto, a existência de uma nova “especial preservação” dentro de um regime de proteção especial.

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

§ 1º A multa será acrescida de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica.

§ 2º Para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação.

O artigo 50 inaugura uma sequência de artigos voltados para a proteção florestal. Há muita repetição e redundância, pois pretendem prever todas as hipóteses de danos florestais. Contudo, é relevante notar que a norma só tutela espécies nativas ou espécies nativas plantadas. E mais, não basta que as espécies sejam nativas ou nativas plantadas, necessita-se que elas sejam objeto de especial proteção. A especial proteção mereceu definição normativa, sendo aquelas que “tenham regime jurídico próprio e especial de conservação, conforme definido pela legislação”. O conceito não ajuda muito, pois se utiliza de conceitos indeterminados para determinar conceitos indeterminados.

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

O mesmo em relação ao artigo anterior.

Art. 51-A. Executar manejo florestal sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em PMFS ou em desacordo com a autorização concedida:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

No Brasil, a utilização das florestas nativas e formações sucessoras, públicas ou privadas, somente pode ser executada mediante a utilização do chamado manejo florestal sustentável, o qual deverá ser aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, em geral um órgão pertencente à administração dos estados. Uma vez concedida a autorização para a implantação do Plano de Manejo Florestal Sustentado, as suas determinações deverão ser observadas, sob pena de que o responsável pela atividade florestal incorra em infecção administrativa.

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

A Lei nº 9.605/1998 não tem um tipo penal exatamente igual à infração administrativa, sendo a infração penal mais aproximada aquela que consta do artigo 50-A.

O núcleo da ação é o desmatar mediante a utilização de corte raso. Segundo o Instituto Ambiental do Paraná, *corte raso “é a eliminação de toda e qualquer vegetação existente sobre uma área. Normalmente um corte raso é feito para plantar outra cultura, seja agrícola ou florestal ao que chamamos de conversão, ou seja, estamos fazendo uma conversão de uma área que tinha floresta para plantar nela soja, milho, reflorestamento etc. Sinônimos: supressão, roçada”*.² O corte raso, como se depreende da norma, depende de autorização do órgão de controle ambiental, em alguns casos específicos, normalmente para pequenos agricultores ou em casos de interesse ou utilidade pública.

Os bens jurídicos protegidos são as florestas e demais formações nativas; não se aplicando a norma à vegetação exótica. É importante observar que, em se

Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal obrigatória.

O decreto se utiliza das expressões “*reserva legal*” e “*reserva florestal averbada*”. Não se discute que a reserva legal é uma obrigação *propter rem* e, portanto, parte integrante da própria propriedade florestal. Contudo, é igualmente indiscutível que ela necessita estar averbada no registro geral de imóveis, haja vista que não se pode presumir a sua localização no interior da área de determinado imóvel rural. Assim, não havendo averbação, não há reserva legal, para as finalidades do artigo. Há, isto sim, a necessidade de que o proprietário a averbe. Vale ressaltar que o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) dispõe que o registro da Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural (“CAR”) desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4º).

Art. 54. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.
Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular de que trata o § 1º do art. 18 e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito.

A norma procura evitar a “receptação” de produtos florestais provenientes de áreas que tenham sido embargadas. O parágrafo único estabelece uma condicionante que é a prévia divulgação pública das áreas que tenham sofrido a aplicação da sanção administrativa de embargo. A medida é correta, pois não se pode exigir que o particular verifique a cada momento a origem dos produtos que adquire que, evidentemente, gozam de uma presunção relativa de legalidade. A divulgação dos embargos tem por objetivo desconstituir a presunção de legalidade, haja vista que, a publicação gera uma presunção de conhecimento público do embargo.

Art. 55. Deixar de averbar a reserva legal:
Penalidade de advertência e multa diária de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva legal.
§ 1º O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma das alternativas previstas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
§ 2º Durante o período previsto no § 1º, a multa diária será suspensa.
§ 3º Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1º nos cento e vinte dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração, na forma estipulada neste Decreto.
§ 4º As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental.

O Decreto não define o sujeito ativo da infração administrativa, limitando-se a “deixar de averbar a reserva legal”. Tal infração, contudo, é *própria*, pois a averbação da reserva legal é obrigação do proprietário do imóvel, dada a sua natureza *propter rem*. Contudo, não raras vezes, os órgãos ambientais e o próprio Ministério Público têm “exigido” que a averbação seja procedida por terceiros, como ocorre com bastante frequência na implantação de reservatórios e linhas de transmissão. Tem sido prática comum exigir-se que os empreendedores de tais empreendimentos firmem termos de compromisso ou de ajustamento de conduta, responsabilizando-se pela averbação, sob pena de não obterem as licenças ambientais pretendidas.

A prática é reprovável. Cabe ao órgão ambiental exigir que o proprietário, ou o possessor, cumpra com os encargos relativos à averbação da RFL, pois dele é a obrigação, da qual somente se exonera pela perda da propriedade.

Como explicitado *supra*, Código Florestal estabeleceu que o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 56. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 1.000,00 (mil reais) por unidade ou metro quadrado.

A norma corresponde ao artigo 49 da Lei nº 9.605/1998.

Luiz Régis Prado (2011, p. 235), assim se manifestou sobre o tipo penal, as quais, guardadas as proporções se aplicam ao tipo administrativo:

Por plantas ornamentais entendem-se as que decoram, adornam embelezam ou enfeitam um local, como begônias, lírios, tulipas, orquídeas, samambaias entre outras. Essa incriminação (inclusive com a forma culposa) não deveria passar – quando muito – de infração administrativa. Há evidente exagero do legislador [...]

Cuida-se de mais uma das normas inacreditáveis de nossa legislação de proteção ao meio ambiente. Não há a menor dúvida que falece ao Poder Executivo Federal a competência para a definição de ilícito administrativo em logradouro público, pois como se sabe, cabe ao Município zelar pela ordem urbana, dentro da qual, certamente, se encontra a proteção dos logradouros públicos; por outro lado, não há qualquer sentido, bom-senso ou juridicidade em transformar em infração administrativa danos à propriedade privada, pois as normas administrativas existem para proteger o bem público e à coletividade, jamais o bem privado que merece proteção ampla em nossos direitos penal e civil.

Logradouro público é a rua, a avenida, o beco, a travessa, o caminho enfim qualquer via aberta à livre circulação do público na qual estejam localizadas plantas

ornamentais, isto é com finalidades decorativas e de embelezamento do local. As condutas puníveis são (i) destruir, (ii) danificar, (iii) lesar e (iv) maltratar.

Art. 57. Comercializar, portar ou utilizar em floresta ou demais formas de vegetação, motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), por unidade.

A motosserra é aparelho utilizado para o corte de madeiras e árvores; normalmente o motor é alimentado por gasolina ou outro combustível. É um aparelho relativamente pequeno e, portanto, de fácil transporte e manuseio. Devido a velocidade com a qual opera e a facilidade de manipulação que proporciona, ela faz com que a derrubada de árvores seja, atualmente, uma operação muito simples. Em função das circunstâncias mencionadas, as motosserras estão submetidas à regulamentação administrativa, no âmbito federal, assim como muitos estados possuem normas legais para a comercialização das motosserras.

O artigo 51 da Lei nº 9.605/1998 não contempla o verbo portar. A imputação de portar motosserra é excessiva e pune administrativamente um ilícito abstrato, pois o portador pode ser um mero detentor da motosserra, não sendo razoável que se atribua pena por detenção muitas vezes meramente accidental. Também não é razoável que se exija do mero detentor a posse dos documentos relativos ao aparelho. A obrigação legal para o registro de motosserra está prevista no Código Florestal, conforme o disposto em seu artigo 69. A matéria, administrativamente, está regulada pela Portaria Normativa Ibama nº 149, de 30 de dezembro de 1992.

Art. 58. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

A norma visa a impedir a propagação de fogo e incêndios em decorrência da utilização das chamadas queimadas que são, como se sabe, uma prática agropastoril milenar e cuja utilização moderna é cada vez mais problemática, seja em motivo da destruição da diversidade biológica, seja pela contribuição para a emissão de gases de efeitos estufa (GEE) para a atmosfera.

O antigo artigo 27 do Código Florestal revogado (Lei nº 4.771/1965) foi regulamentado pelo Decreto nº 2.661/1998. Ao regulamentar o Código Florestal revogado, o decreto estabeleceu que é vedado o emprego do fogo: (i) nas florestas e demais formas de vegetação; (ii) para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de (a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais; (b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável; (iii) numa faixa de: (a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica; (b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica; (c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações; (d) cinquenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades de Conservação; (e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio; (iv) no limite da linha que simultaneamente corresponda: (a) à área definida pela circunferência de raio igual a seis mil metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem de aeródromos públicos; (b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial de aeródromo público, dela distanciando no mínimo dois mil metros, extremamente, em qualquer de seus pontos. O Decreto permanece vigente, pois compatível com o Novo Código Florestal.

O decreto admite a chamada “queima controlada”, conforme as normas e condições estabelecidas por ele estabelecidas. A queima controlada é o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos. Ela, contudo, somente pode ser praticada mediante a expedição de prévia autorização a ser obtida pelo interessado junto ao órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, com atuação na área onde se realizará a operação.

É condição para a obtenção da autorização para a queima controlada que o interessado (i) defina as técnicas, os equipamentos e a mão de obra a serem utilizados; (ii) faça o reconhecimento da área e avalie o material a ser queimado; (iii) promova o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo; (iv) prepare aceiros de no mínimo três metros de largura, ampliando a faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível assim determinarem; (v) providencie pessoal treinado para atuar no local da operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos; (vi) comunique formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, hora do início e do local onde será realizada a queima; (vii) preveja a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação; (viii) providencie o oportuno acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. O aceiro deverá ter sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do poder público e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.

Uma vez que o interessado tenha protocolizado o requerimento de Queima Controlada, o órgão competente do Sisnama, no prazo máximo de quinze dias, deverá expedir a autorização correspondente; ficando o interessado autorizado a realizar a queima, conforme comunicado, salvo se se tratar de área sujeita à realização de vistoria prévia a que se refere o artigo 7º do decreto.

A vistoria prévia é obrigatória em áreas: (i) que contenham restos de exploração florestal; (ii) limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecido em ato do poder público.

A Autorização de Queima Controlada é específica e transitória, devendo conter apenas o suficiente à realização da operação de emprego do fogo, dela constando, expressamente, o compromisso formal do requerente, sob pena de incorrer em infração legal, de que comunicará aos confrontantes a área e a hora de realização da queima, nos termos em que foi autorizado. Admite-se a “revalidação” da Autorização de Queima Controlada concedida anteriormente para a mesma área, para os mesmos fins e para o mesmo interessado, ficando dispensada nova apresentação dos documentos previstos já apresentados, salvo os comprovantes de comunicação aos confrontantes, de que trata o inciso VI do art. 4º.

Os órgãos integrantes do Sisnama poderão estabelecer escalonamento regional do processo de Queima Controlada, com base nas condições atmosféricas e na demanda de Autorizações de Queima Controlada, para controle dos níveis de fumaça produzidos. Também poderão determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou município quando: (i) constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; (ii) a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos como parâmetros; (iii) os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte. A Autorização de Queima Controlada será suspensa ou cancelada pela autoridade ambiental nos seguintes casos: (i) em que se registrarem risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; (ii) de interesse e segurança pública; (iii) de descumprimento das normas vigentes.

Art. 59. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

O tipo corresponde ao artigo 42 da Lei nº 9.605/1998. A norma objetiva proteger o ambiente contra o fogo.

O balão cuja produção, venda, transporte ou sultura é interdita é aquele apto a provocar incêndio. Em tese, todo balão, por ter bucha inflamável, é capaz de provocar incêndio; contudo, parece que a intenção do legislador, no caso seguida pelo poder regulamentar, foi reprimir os balões de grande porte. De qualquer forma, há necessidade de uma opinião técnica para que se possa determinar a capacidade do balão provocar incêndio.

Os seguintes dados merecem reflexão: “No ano passado, cerca de dois mil incêndios em áreas florestais do Rio foram ocasionados por balões. Em 2008, os números também são alarmantes. Devido ao grande número de acidentes já registrados neste ano, principalmente nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros decidiu antecipar a operação para reprimir a ação dos balões, que estava prevista para a segunda quinzena de junho, para domingo passado (25)”. Segundo o coronel Vânius de Amorim, comandante do Primeiro Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros, no ano passado, os bombeiros atenderam a 8.485 incêndios apenas em vegetação. “Desses 8.485, cerca de 25% foram provocados por balões, o que dá uma faixa de 2 mil a 2.150 incêndios, localizados principalmente na área do grande Rio, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí”, explicou em entrevista à CBN.”³ O mesmo quadro, infelizmente, se reproduz nos demais estados e cidades do País.

Art. 60. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando:

I – ressaldados os casos previstos nos arts. 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio; e

II – a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

O artigo estabelece uma majorante genérica a ser adicionada às penalidades aplicadas aos infratores quando (i) o agente se utilizar de fogo ou (ii) provocar incêndio ou, ainda, nos (iii) casos nos quais a vegetação prejudicada esteja incluída em lista de espécies ameaçadas de extinção.

A redação do inciso II é inadequada, pois *vegetação* é conceito genérico e não há *vegetação* ameaçada de extinção, o que existe é *espécie ameaçada* de extinção. Também aqui existe um problema. As listas de espécies ameaçadas de extinção têm sido aprimoradas e o conceito “espécies ameaçadas de extinção” abrange uma gama de subconceitos tais como “em risco”, “vulneráveis” e outros.⁴

Art. 60-A. Nas hipóteses previstas nos arts. 50, 51, 52 e 53, em se tratando de espécies nativas plantadas, a autorização de corte poderá ser substituída pelo protocolo do pedido junto ao órgão ambiental competente, caso em que este será instado pelo agente de fiscalização a fazer as necessárias verificações quanto à real origem do material.

O artigo expressa mais uma patética confissão de incapacidade da administração em atender às demandas dos cidadãos. Com efeito, a simples apresentação de um protocolo não pode se substituir à autorização administrativa que, em tese, é concedida após a análise do pedido. O “direito de protocolo” não possui qualquer base legal e tem sido rejeitado por nossos tribunais. (STJ – ROMS – 27641 – SP, 2ª Turma, DJU 14/10/2008).

Admissível seria o direito de protocolo, caso a atividade já se encontrasse aprovada, o que não é a hipótese do artigo (STJ – REsp – 77.154-RJ. 1ª Turma. DJU 26/8/1996, p. 29.642). Toma-se o silêncio da administração como aprovação. Tal preceito contraria os princípios da legalidade e da eficiência administrativa que estão insculpidos no *caput* do artigo 37 da CF, acrescente-se que os artigos 48 e 49 da Lei de Processo Administrativo, expressamente estabelecem o dever de decidir.

4.3.3 Infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o *caput* serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

A poluição, no direito brasileiro, possui conceito normativo que nos é trazido pelo artigo 3º, inciso III e alíneas da Lei nº 6.938/1981. Como se pode ver do texto legal, o conceito é bastante amplo, vez que é “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente” prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas para as atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. O primeiro ponto que chama a atenção é que o conceito de poluição somente se perfaz a partir da existência de uma degradação da qualidade ambiental, ou seja, para que exista poluição é necessário que ocorra uma “alteração adversa do meio ambiente”. Portanto, o legislador admitiu como lícita a alteração do meio ambiente que não seja capaz de produzir alteração negativa. O julgamento quanto à nocividade, ou não, de uma alteração antrópica do ambiente é matéria que tem dado azo a muita discussão, restando altamente controversa. Há necessidade de que a poluição a ser combatida tenha origem em uma ação antrópica, vinculada por nexo de causalidade a determinado autor, não se admitindo que alterações adversas anteriores ao fato em questão sejam esgrimidas em desfavor do eventual réu ou autuado (STJ, REsp 200600597046, REsp – Recurso Especial – 840011, 1ª Turma, 20/9/2007.)

O decreto, no entanto, não está voltando para a poluição juridicamente irrelevante, ou seja, aquela incapaz de causar alteração adversa do meio ambiente, esta é imune ao ordenamento jurídico, seja de origem antrópica, seja de origem natural. O artigo do Decreto reproduz, com pequenas variações, o artigo 54 da Lei nº 9.605/98.

Assim como na maioria dos ilícitos administrativos ambientais, há uma forte vinculação do ilícito administrativo com o ilícito penal, o que me parece extremamente infeliz, haja vista que o ilícito penal exige uma conduta subjetiva para o seu aperfeiçoamento⁵.

O tipo administrativo não reprime a produção de qualquer poluição. A poluição que o decreto reprovou, nisto fazendo coro com a Lei nº 9.605/98 é aquela “em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade”. É importante ressaltar que o parágrafo único do artigo, acertadamente, exige a produção de laudo técnico elaborado pelo *órgão ambiental*. A expressão *órgão ambiental*, no caso concreto, deve ser entendida em termos, haja vista que os laudos devem ser produzidos por profissionais com a qualificação necessária para identificar e quantificar a poluição ilícita. Assim, caso a matéria diga respeito, por exemplo, a poluição por óleo, o laudo não poderá ser produzido por advogado ou contador. Este fato é importante, pois os órgãos ambientais, em geral, organizam os seus servidores em cargos de carreira compostos por técnicos ou analistas ambientais, o que não lhes atribui competência para o exercício das profissões regulamentadas, por exemplo, de Biólogo, Engenheiro, Químico ou outras. A qualificação profissional do agente público que tenha lavrado o Auto de Infração é uma condição de sua validade jurídica.

As decisões acima enumeradas, em grande parte voltadas para a matéria penal, demonstram que a exigência de laudo técnico para a condenação é essencial. Em sede administrativa, há algumas decisões judiciais que dispensam o rigor da produção do laudo técnico⁶: A decisão merece comentário. Em primeiro lugar, há que se relembrar que o texto normativo expressamente determina a elaboração de laudo técnico quando a infração que, em tese, tenha sido cometida seja a de poluição. Justifica-se a exigência normativa, haja vista que o tipo administrativo se refere a *níveis tais* que sejam capazes de danos à saúde, mortandade de animais etc. O tipo não exige que a mortandade de animais ou os danos à saúde tenham ocorrido, mas que o fato potencialmente possa causá-los. Logo, sem uma prova técnica, em princípio, dificilmente haverá a caracterização necessária para o apenamento.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, no caso concreto do tipo do artigo 61 sofre uma mitigação, vez que exigido o laudo técnico; uma vez presente o laudo técnico, aí sim, o ônus da prova é carreado para o particular que deverá desconstituí-lo. Esta é uma conclusão que, do meu ponto de vista, encontra respaldo no artigo 36 da Lei de Processo Administrativo Federal que assim dispõe: “*Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei*”. Em conclusão, parece-me absolutamente indispensável a existência de laudo técnico, também em sede administrativa, para que se possa caracterizar o ilícito.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente autuante;
III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
IV – dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, efluentes, carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;
V – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;
VI – deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar a lei ou ato normativo;
VII – deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível; e
VIII – provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da biodiversidade.
IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos;
X – lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
XI – queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade;
XII – descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;
XIII – deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
XIV – destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;
XV – deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade;
XVI – não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e
XVII – deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2º do art. 39 da Lei no 12.305, de 2010.
§ 1º As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação.
§ 2º Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência.
§ 3º No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2º, poderá ser aplicada a penalidade de multa, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 4º A multa simples a que se refere o § 3º pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
§ 5º Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.
§ 6º As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX.

O artigo 62 estabelece uma lista de condutas consideradas nocivas ao meio ambiente para as quais serão aplicadas penalidade iguais àquelas contempladas no artigo 61, mera continuação do 61, o que demonstra a pobreza da técnica redacional, indica situações específicas de poluição, as quais se constituem em subtipos do *caput* do artigo 61.

Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana é o resultado de conduta que, mediante a imposição de alterações adversas, inviabilizam a localização permanente de seres humanos. A ocupação humana, no caso vertente, deve ser entendida como a habitação ou residência permanente, bem como o exercício de atividades econômicas constantes. É a poluição contemplada no artigo 3º, III, *b*, da Lei nº 6.938/1981.

Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que provoque, de forma recorrente, significativo desconforto respiratório ou olfativo devidamente atestado pelo agente autuante, nesta hipótese o bem jurídico tutelado é a qualidade do ar, a qual deve ser mantida em níveis tais que permitam que as populações habitem permanentemente em determinada região sem que sejam obrigadas a deslocamento em razão da redução do padrão de qualidade atmosférica ou que aí permaneçam. O tipo não exige que a retirada da população seja permanente, contudo, se faz necessário que a retirada da população seja uma medida ordenada pela defesa civil ou mesmo pela autoridade ambiental, após análise dos riscos envolvidos.

A forma recorrente de *significativo* desconforto respiratório ou olfativo pode ser identificada pela presença no ar de componentes químicos ou partículas em suspensão que sejam aptos a prejudicar o exercício normal e regular da respiração de pessoas saudáveis, independentemente da idade. A melhor fórmula para a identificação é a análise química do ar, identificando-se e quantificando-se os elementos geradores do problema. Aqui é importante ter em vista o velho direito de vizinhança que faz clara separação entre o mau uso da propriedade, capaz de causar danos a terceiros, e o mero incômodo de vizinhança.

A poluição atmosférica tratada pelo inciso II é tema relevante e que, cada vez mais tem gerado preocupação na sociedade. Como sabemos, a grande sensibilização para a questão da poluição atmosférica ocorreu em Londres, no ano de 1952, com o chamado “grande smog”. O acontecimento ocorreu em função de uma inversão térmica que se iniciou no dia 3 de dezembro de 1952 e, em poucos dias, acarretou forte recrudescimento das taxas de internações e mortes em função de problemas respiratórios. “O cheiro do fumo penetrava nos edifícios pelas portas e janelas abertas.”

Todas as grandes cidades do mundo enfrentam ou já enfrentaram problemas com poluição atmosférica, notadamente aquela causada por veículos automotores, as chamadas fontes móveis. A poluição atmosférica, contudo, não se restringe aos fatores decorrentes da circulação de veículos automotores. Muitas outras atividades são responsáveis pela turbacão da qualidade do ar, tais como indústrias, estradas não pavimentadas, aparelhos de ar condicionado, cigarros etc.

Um dos problemas mais complexos, em tal matéria, é o fato de que normas locais, dificilmente, conseguem dar conta do problema, pois o ar, assim como a água, não respeita fronteiras políticas e uma atividade realizada aqui, poderá causar problemas acolá. Muitos documentos do Direito Internacional estão voltados para disciplinar a chamada poluição transfronteiriça ou à longa distância.

No Direito interno, o combate à poluição atmosférica é um dos campos mais propícios à existência de normas federais, pois as normas estaduais não são suficientemente capazes de impedir que “outros estados” sejam prejudicados por emissões locais. A União, contudo, tem sido omissa no particular e, até hoje, não existe uma lei federal apta a regular a qualidade do ar em nível nacional. As normas existentes são meramente de caráter regulamentar e, portanto, capazes de gerar polêmicas tais como a noticiada no início deste artigo. De fato, o Estado de São Paulo, ao exercer as suas competências ambientais, fica tolhido pela atribuição da ANP em dispor sobre “combustíveis” que, no caso sob exame, é uma norma cujo caráter ambiental é inequívoco.

A primeira norma brasileira (federal) que tratou do tema, ainda que genericamente, foi o Decreto-lei nº 1.413/1975 que instituiu as chamadas áreas críticas de poluição. Logo depois, a Lei nº 6.803/1980 estabeleceu as diretrizes para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. No artigo 9º da lei, ficou estabelecido que o licenciamento das atividades industriais deveria ser feito com o “atendimento das normas e padrões ambientais definidos pela SEMA”. Logo em seu primeiro inciso, foi dada ênfase à emissão de gases e vapores.

Desde 1967, o antigo estado da Guanabara já praticava o controle da qualidade do ar, com a instalação de estações de monitoramento. Aliás, neste particular, o estado Rio de Janeiro, como demonstra relatório elaborado pela Feema, é exemplar:

O Estado do Rio de Janeiro, não só vem atendendo as ações previstas em todas as fases do Proconve, como também é o único estado que implantou o programa de I/M veicular; que vem sendo realizado desde julho de 1997, conforme preconiza a Resolução Conama 07. Quanto à parcela de emissões oriundas de veículos a diesel, encontra-se em execução o Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta, onde estão sujeitas ao programa todas as empresas transportadoras de cargas e de passageiros, que utilizam óleo diesel como combustível automotor e atuam no Estado do Rio de Janeiro. Em termos de controle das emissões de fontes, embora as novas fases do Proconve estabeleçam limites mais restritivos para emissões de poluentes, a partir de 2009, principalmente para os percussores de ozônio, a frota de veículos vem ao longo dos anos apresentando uma tendência de crescimento acentuada, ou seja, tais medidas isoladamente não serão suficientes para garantir a redução ou, tendência de estabilização do teor de poluentes oriundos de fontes móveis. Dentre as alternativas existentes, não podemos deixar de mencionar a necessidade urgente de melhoria da modal de transporte público e da matriz energética. O que mostra que a solução do problema não depende apenas do sistema de meio ambiente, mas de ações compartilhadas entre vários setores da sociedade, que direta ou indiretamente podem impulsionar prioridades políticas no que tange ao controle da qualidade do ar.

A nossa legislação federal nasceu com cerca de dezessete anos de atraso em relação à *Clean Air Act* dos Estados Unidos, país cuja primeira norma nacional data de 1963 e, tal como a brasileira, não determinava nenhuma redução de material a ser lançado na atmosfera. A Alemanha, desde muito tempo possui as suas *Luft und Luftreinhaltung Gesetze*, sendo certo que o princípio da precaução ingressou no direito alemão, pela via da regulação da qualidade do ar, isto nas décadas de 1970 e 1980 do século passado.

A regulação do enxofre tem sido muito importante, pois foi através do controle da chuva ácida que mecanismos de licenças negociáveis foram introduzidos. Ainda que as licenças negociáveis não sejam uma panaceia, elas permitiram uma efetiva redução do enxofre na atmosfera, muito embora haja forte crítica quanto aos motivos reais que levaram aos resultados:

Aparentemente, esse sistema respeitava as preconizações de Ronald Coase, deixando funcionar o jogo do mercado. E o “Acid Rain” conheceu verdadeiro sucesso: o objetivo previsto – redução de 40% nas emissões de SO₂, em relação à situação de 1980 – foi alcançado e mesmo ultrapassado. Se examinarmos mais de perto, porém, não seria correto atribuir esse êxito ao mercado.

Em primeiro lugar, o fortalecimento da regulamentação, somado a um controle contínuo dos poluentes que saíam das chaminés, levou um bom número de empresas exploradoras a antecipar os trabalhos de adequação às normas. Além disso, a indústria do carvão desenvolveu produtos com baixo teor de enxofre, menos emissores de SO₂, que se tornaram competitivos. Esses dois fenômenos explicavam em grande parte a forte baixa das emissões, com o comércio de autorizações no mercado intervindo apenas marginalmente. Porém, os efeitos colaterais não eram desprezíveis. O poder calorífico inferior do novo carvão com menos enxofre o levava a ser consumido em maior quantidade, o que aumentava mecanicamente as emissões de um outro poluente: o dióxido de carbono! Mas os defensores da não intervenção do Estado retiveram apenas isto: o mercado das cotas é eficaz – portanto, pode ser generalizado.⁷

Apesar da inexistência de uma lei federal, a qualidade do ar no Brasil tem melhorado. As medidas de controle da poluição atmosférica têm obtido resultado, ainda que a atividade industrial tenha se ampliado. Em Cubatão – situação-limite – a emissão de poluentes teve queda de 98,8% nos últimos 25 anos, segundo dados da Cetesb. Dois foram os fatores que deram margem a tal resultado: (a) maiores investimentos em tecnologia e (b) fiscalização mais adequada e atuante.

Normas federais:

RESL-Conama-382-2006 Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. **RESL-Conama-354-2004** Dispõe sobre os requisitos para adoção de sistemas de diagnose de bordo – OBD nos veículos automotores leves objetivando preservar a funcionalidade dos sistemas de controle de emissão. – **RESL-Conama-299-2001** Estabelece procedimentos para elaboração de relatório de valores para o controle das emissões dos veículos novos produzidos e/ou importados. **RESL-Conama-297-2002** Estabelece os limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, motocicletas e veículos similares novos. **RESL-Conama-418-2009** Estabelece critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV, para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, determina novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. – **RESL-Conama-15-1995** Estabelece, para o controle da emissão veicular de gases, material particulado e evaporativa, nova classificação dos veículos automotores, a partir da data que indica. – **RESL-Conama-8-1990** Estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes do ar (padrões de emissão) para processos de combustão externa em fontes novas fixas de poluição com potências nominais totais até 70 MW (setenta megawatts) e superiores. – **RESL-Conama-3-1990** Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR – Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar. – **RESL-Conama-8-1993** Em complemento à Resolução Conama nº 18, de 6 de maio de 1986, estabelecer os Limites Máximos de Emissão de poluentes para os motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e importados, conforme Tabela 1. – **RESL-Conama-5-1989** Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – Pronar. – **RESL-Conama-4-1989** Dispõe sobre níveis de emissão de hidrocarbonetos por veículos com motor a álcool, e dá outras providências – RESL-Conama-3-1989. Dispõe sobre níveis de emissão de aldeídos no gás e escapamento de veículos automotores. – **RESL-Conama-18-1986** Institui, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve, e dá outras providências.

A constatação dos odores desagradáveis, de acordo com a norma ora comentada ficou a cargo da capacidade olfativa da fiscalização e não de uma constatação técnica. Medida semelhante já foi declarada ilegal no Estado de São Paulo, como nos deixa ver a seguinte ementa: *Administrativo – Direito ambiental – regulamento – Padrões de qualidade ambiental – Adoção de critérios inseguros – Decreto 8.468/76 do Estado de São Paulo – Ilegalidade (Lei Federal 6.938/81). – O Decreto 8.468/76 do Estado de São Paulo, incidiu em ilegalidade, contrariando o sistema erigido na Lei Federal 6.938/81, quando adotou como padrões de medida de poluição ambiental, a extensão da propriedade e o olfato de pessoas credenciadas* (Ministro Humberto Gomes de Barros).

Existem equipamentos capazes de comprovar a presença de substâncias geradoras de maus odores no ar e a administração deve usá-los apara dar segurança às suas atuações.

Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade é atitude gravíssima, merecedora de severo juízo de reprovação.

Relevante lembrar que o veto ao artigo 59 do Projeto de Lei que deu origem Lei nº 9.605:

Art. 59 – Produzir, sons, ruídos ou vibrações em desacordo com as prescrições legais ou regulamentares, ou desrespeitando as normas sobre emissão e imissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades: Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

A matéria referente à produção de ruídos deixou de ter uma regulamentação ambiental específica de nível emissão federal, ficando adstrita a normas locais e estaduais, bem como à segurança e saúde do trabalho. O STJ (REsp 200800870873, REsp – 1.051.306, 2ª Turma, DJe 10/9/2010, p. 257) entendeu possível a persecução civil, com vistas a coibir o ruído excessivo, pelo Ministério Público; contudo, entendendo que a hipótese seria de lançamento de energia em desacordo com os padrões vigentes. É fato que muitos municípios e estados possuem padrões de decibéis, os quais deverão ser observados, sendo punível a ultrapassagem. Todavia, para o enquadramento dentro do conceito de poluição como ilícito, com a devida vênia, o excesso de energia sonora deve ser apto a produzir os efeitos nocivos contemplados no artigo 61.

A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a “sadia qualidade de vida”, referida no art. 225, caput, da CF. 4. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. 5. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir; duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica. 6. Nos termos da Lei 6.938/81 (Lei da PNMA), também é poluição a atividade que lance, no meio ambiente, “energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (art. 3º, III, alínea “e”), exatamente a hipótese do som e ruídos” (Ministro Herman Benjamin).

Ademais, o artigo 62 corresponde, aproximadamente, aos parágrafos do artigo 54 da Lei nº 9.605/98 que indicam aumento de pena específico. O inciso I do artigo denota poluição gravíssima, vez que a área se tornou imprópria para ocupação humana. Contudo, “ocupação humana” é conceito muito amplo, pois vários usos diversos podem indicar ocupação humana. Não está claro, mas a norma sugere que o termo ocupação humana tem o significado de habitação humana. Se o raciocínio ora desenvolvido for verdadeiro, a norma terá dificuldade de aplicação perante os tribunais judiciais, pois tipos devem ser claros e não deixar margem para ambiguidades.

Interrupção de abastecimento público de água. É um dos principais delitos de poluição que, infelizmente, ocorre com regularidade. Refiro-me especialmente ao caso do Rio Paraíba do Sul que, frequentemente, sofre derramamentos de produtos químicos perigosos em suas águas com a consequência de paralisação do abastecimento de água de muitas cidades e localidades. Contudo, o problema se reitera, pois as medidas são sempre paliativas e não enfrentam a questão seriamente.

Art. 63. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou fração.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão ambiental competente.

O artigo parece-me absolutamente redundante e desnecessário, embora reproduza o artigo 55 da Lei nº 9.605/98. Efetivamente, a regulamentação da atividade minerária é de atribuição da Agência Nacional de Mineração. Nisto reside a especificidade normativa da atividade. No que se refere à regulamentação ambiental da mineração, data vênia, bastaria enquadrá-la no artigo 66 do Decreto e teríamos menos normas a serem cumpridas, facilitando o trabalho de todos, inclusive dos próprios órgãos ambientais. Por fim, acrescente-se que o Código de Mineração dispõe de uma gama de artigos capazes de impedir o início de atividades minerárias sem as necessárias licenças (art. 63).

Art. 64. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias referidas no <i>caput</i>, descarta de forma irregular ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quádruplo.
Art. 65. Deixar, o fabricante de veículos ou motores, de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos na legislação:
Multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Esta é mais uma norma inteiramente deslocada do contexto do decreto, pois é norma cuja finalidade é a proteção do consumidor que adquiriu veículo ou motor dotado de equipamento de controle de ruídos ou de emissões. A garantia é matéria de direito civil ou o do consumidor e, data vênia, nada tem a ver com a tutela do meio ambiente.

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:
I – constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e
II – deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

A norma pune a mera desobediência às obrigações de licenciar ou buscar autorização do órgão *ambiental competente*. Isto implica que o tipo não poderá ser aplicado, por exemplo, no caso da falta de *licença de construir* ou de Alvará do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Tutela-se, portanto, o poder de polícia dos órgãos ambientais. A parte final do *caput* é contraditória, pois se a licença foi concedida e está sendo observada, a atividade não pode contrariar regulamentos ou normas legais pertinentes. Caso a licença tenha sido concedida em desacordo com o ordenamento jurídico, data vênia, o empreendedor somente poderá ser responsabilizado se, após prévia apuração, ficar comprovado que ele participou ativamente da concessão irregular da licença. Qualquer outro raciocínio é violar o princípio da proteção da confiança.

Atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras são aquelas definidas previamente pela Administração, mediante ato próprio, como tal e, portanto, submetidas a licenciamento ambiental. Atualmente, as atividades que demandam licenciamento ambiental são aquelas mencionadas no anexo da Resolução Conama 237/97.

É necessário observar, igualmente, que muitas atividades estão em funcionamento antes da entrada em vigor da exigência de licenciamento ambiental. Essas atividades não estão submetidas ao rigor do artigo, salvo se foram intimadas pela Administração para se licenciarem ambientalmente. No âmbito federal as licenças exigíveis, como regra, são a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). Pois a Licença Prévia (LP) não autoriza o início de atividades.

Art. 67. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

A norma tutela a higidez dos ecossistemas, punindo aquele que propague ou dissemine doença ou praga capazes de causar danos aos ecossistemas. O artigo tem inspiração no artigo 61 da Lei nº 9.605/98, muito embora não lhe reproduza fielmente o texto, ante a retirada dos termos pecuária e agricultura. A ausência dos vocábulos talvez possa ser explicada por uma reconhecida dificuldade do MMA com as atividades de pecuária e agricultura.

Art. 68. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O artigo é mais um daqueles inteiramente apartados das normas legais e evidentemente, eivados de subjetivismo incompatível com a aplicação de normas sancionatórias em regime democrático. A redação é péssima, sob qualquer ângulo que seja examinada. Pode-se inferir que o decreto pretende impedir a circulação de veículo automotor que não esteja em acordo com as *exigências ambientais*. O que são exigências ambientais? Exigências legais previstas na legislação ambiental? Qual é legislação ambiental? A de proteção à qualidade do ar e relativa aos padrões de emissão?

O conceito de veículos automotores é definido no Código de Trânsito Brasileiro (artigo 96) que dispõe amplamente sobre o tema, dividindo-os em várias espécies e categorias. Quanto diferentes tipos de meios de transporte com propulsão a motor, a Lei nº 6.938/81, em seu artigo 8º outorga ao Conama a competência privativa para estabelecer normas e padrões nacionais para o controle de poluição para veículos automotores, embarcações e aeronaves. O artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro, determina que os veículos devem atender às normas relativas à emissão de poluentes.

O Código de Trânsito Brasileiro ao estabelecer a obrigatoriedade de observância dos padrões de emissão de poluentes, definiu um ilícito administrativo que, no entanto, não tem previsão na Lei nº 9.605/98, haja vista o caráter genérico do artigo 70, tantas vezes mencionado neste trabalho. A jurisprudência, contudo, tem admitido que os Estados em sua legislação complementar estabeleçam parâmetros a serem observados pelos veículos e mantida as penalidades aplicadas em função da desobediência das normas: *“Inócu a discussão sobre a falibilidade do método Ringelmann, quando este foi escolhido no exercício do poder discricionário do administrador, dentro da competência legislativa suplementar do Estado”* (STJ, REsp 125018/RJ. 1ª Turma, DJU 28/5/2001, p. 151.) Há, inclusive, manifestação expressa do STJ quanto a possível violação do artigo 8º da Lei da PNMA: *“Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que as normas regulamentadoras dos índices toleráveis de produção de fumaça causada por veículos automotores, editadas pelo estado do Rio de Janeiro, não violam o art. 8º, inc. IV, da Lei 6.938,*

Parece-me que, nos termos em que a questão está colocada, a autoridade de trânsito terá atribuição para impor sanções aos violadores da norma que determina a observância da legislação de controle ambiental, especificamente no que se refere à emissão de poluentes por veículos automotores e, igualmente, a autoridade ambiental estadual, desde que disponha de norma própria. Quanto ao órgão federal de controle ambiental, entendo que o artigo ora comentado não é suporte legal suficiente para que lhe seja conferida a necessária atribuição.

Art. 69. Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de Veículos ou Motor – LCVM expedida pela autoridade competente:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e correção de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.
Art. 70. Importar pneu usado ou reformado em desacordo com a legislação:
Multa de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), por unidade.
§ 1º Incorre na mesma multa quem comercializa, transporta, armazena, guarda ou mantém em depósito pneu usado ou reformado, importado nessas condições.
§ 2º Ficam isentas do pagamento da multa a que se refere este artigo as importações de pneumáticos reformados classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900, procedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao amparo do Acordo de Complementação Econômica nº 18.

Os pneus abandonados são uma importante fonte de problemas ambientais e de saúde humana, haja vista que neles podem se acumular detritos e resíduos dos mais diversos, bem como podem servir de base para o acúmulo de água parada, formando focos de diversas doenças, dentre as quais a dengue que, hoje em dia, é endêmica em muitos estados brasileiros. A norma do artigo 70, contudo, dificilmente pode ser enquadrada como norma de controle ambiental, ostentando uma característica de comércio internacional. O Conama editou a Resolução nº 258/1999, mediante a qual buscou disciplinar a importação de pneus usados. Tal Resolução foi substituída pela Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009. De fato, o grande problema em relação à matéria é que não existe uma norma nacional sobre a destinação final de resíduos sólidos, ficando a matéria, até aqui, sujeita a legislação estadual que tem dado tratamento ao tema, haja vista que vários estados têm leis sobre resíduos sólidos. No âmbito federal, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (“PNRS”), que será tratada no Capítulo IX, Parte IV, deste livro. Vale adiantar, neste momento, que os pneus são resíduos obrigatoriamente sujeitos ao sistema de logística reversa, de acordo com o artigo 33, inciso II, da PNRS. Importante observar que o mesmo STJ tem entendimento que a proibição de importação de pneus como medida de comércio internacional é perfeitamente válida e legal (REsp 157318/CE, 1ª Turma, DJU 8/6/1998, p. 33.)

Art. 71. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas na legislação:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, e correção da irregularidade.

Ver anotações ao artigo 68.

4.3.4 **Infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural**

O primeiro ponto a ser examinado no que se refere à existência de normas de proteção ao ordenamento urbano e ao patrimônio cultural é que, por exemplo, no que se refere ao ordenamento urbano, a competência para dele dispor é basicamente dos municípios, conforme disposto no artigo 30 da CF, o que acarreta que a fiscalização em tais casos é fundamentalmente municipal, conforme determinado pela LC nº 140/2011(artigo 17). Em meu entendimento, a aplicação direta pelos municípios dos dispositivos do presente decreto é problemática, uma vez que é de se esperar que o município tenha suas normas próprias para o exercício de suas atribuições constitucionais. Por outro lado, no que se refere ao ordenamento urbano, a União goza de determinadas prerrogativas, tal como determinado pelos artigos 182 e 183. Tais prerrogativas têm se materializado na edição de normas gerais que devem ser observadas por estados e municípios, merecendo destaque as seguintes: (i) Lei nº 6.766/1979; (ii) Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e (iii) Decreto-lei nº 25/1937.

É evidente por si mesmo que o Decreto nº 6.514/2008, no particular, foi além da Lei nº 9.605/98.

Art. 72. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A norma é mera reprodução do tipo penal contido no artigo 62 da Lei nº 9.605/98. Assim, como em diversas oportunidades, o ilícito penal foi transformado em ilícito administrativo, com consequência graves para a apuração de ambos, como se pode ver do seguinte trecho: “A denúncia imputou ao paciente a prática, em tese, das condutas subsumidas nos artigos 38 e 60 da Lei nº 9.605/98, embasando-se, principalmente, em auto de infração lavrado e posteriormente cancelado pelo IBAMA, o que mitigou o conteúdo dos outros documentos referidos na peça vestibular; o Termo de Embargo e Interdição, o Termo de Inspeção e o Relatório de Fiscalização. III – No caso analisado, o auto de infração que subsidiou a denúncia, além de ter sido emitido por órgão diverso daquele com atribuição para expedir a licença reputada necessária, foi cancelado. A licença de instalação foi expedida e sucessivamente renovada pela FEEMA, órgão com atribuição para expedi-la, havendo, ainda, a adaptação do projeto às necessidades do empreendimento. IV – Outrossim, noticiado nos autos a prolação de a sentença DA LAVRA DA MM. Juíza Federal da 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, em ação civil pública, na qual não restou reconhecida nulidade na licença expedida pela FEEMA relativamente ao empreendimento questionado”. (TRF da 2ª Região, HC 200602010091050, HC – 4717, 1ª Turma Especializada, DJU 19/4/2007, p. 110.)

Destruir, inutilizar ou deteriorar é retirar do mundo físico, tornar imprestável para o uso a que se destina e causar alteração que modifique as características do bem tutelado. A norma aplica-se a bem imóvel que tenha merecido especial proteção por parte do poder público, nele compreendidos os três poderes; contudo, não

se infere do artigo que os bens tutelados sejam apenas aqueles de valor ambiental ou cultural, especialmente quando se trata do inciso I, restando uma perigosa abrangência. O inciso II é mais preciso no que diz respeito ao bem jurídico tutelado. É de se observar, contudo, que museu, biblioteca e pinacoteca são universalidades, não se confundindo com o mero somatório de quadros, livros ou objetos. Assim, o dano deve ser à universalidade e não meramente a um dos seus componentes.

Art. 73. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A norma reproduz o artigo 63 da Lei nº 9.605/98, devendo ser observado que ela não se refere a bem tombado, mas, pura e simplesmente, a edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Em primeiro lugar, é indiscutível que os bens tombados estão tutelados pelo artigo ora comentado, de acordo com o disposto no artigo 17 do Decreto-lei nº 25/1937.

É importante considerar que, muitas vezes, os entes públicos se utilizam de conceito amplíssimo que deve ser protegido pela desapropriação e não por outros mecanismos, como já decidido pelo STF: “Tombamento. Parágrafo 1º do artigo 216 da CF. – A única questão constitucional invocada no recurso extraordinário que foi prequestionada foi a relativa ao par. 1. do artigo 216 da Carta Magna. Às demais falta o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356). – No tocante ao par. 1. do art. 216 da CF, não ofende esse dispositivo constitucional a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que há um conceito amplo e um conceito restrito de patrimônio histórico e artístico, cabendo a legislação infraconstitucional adotar um desses dois conceitos para determinar que sua proteção se fará por tombamento ou por desapropriação, sendo que, tendo a legislação vigente sobre tombamento adotado a conceituação mais restrita, ficou, pois, a proteção dos bens, que integram o conceito mais amplo, no âmbito da desapropriação. Recurso extraordinário não conhecido” (STF: RE 182782/RJ, Julgamento: 14/11/1995, 1ª Turma, DJU 9/2/1996, p. 2092, Ement. V. 01815-08, p. 1489).

Todavia, mesmo que a proteção não encontre amparo constitucional, dada a existência de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o apenado deverá buscar a anulação da imposição sancionatória perante o Poder Judiciário. Por fim, deve ser realçado que a alteração do aspecto ou da estrutura dos bens protegidos relacionados no *caput* do artigo somente se constitui em ato ilícito se não forem autorizadas pela autoridade detentora do poder de polícia sobre o bem, ou praticada em desacordo com a licença ou autorização concedida.

Art. 74. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

O artigo reproduz o artigo 64 da Lei nº 9.605/1998.

O tipo administrativo, assim como o penal, comporta duas condutas diversas e uma contradição, como se demonstrará. Existe o (i) solo não edificável, isto é, aquele no qual a edificação é proibida e existe o (ii) solo edificável mediante autorização da autoridade pública. Ambos não se confundem, pois no solo não edificável a autoridade não poderá emitir licença ou autorização, haja vista a proibição legal. O solo edificável mediante autorização é o solo em geral, pois a polícia edilícia se faz presente sobre qualquer construção ou projeto.

Promover construção em solo não edificável significa construir ou fornecer meios ou estímulo para que alguém construa em solo não edificável, ou seja, em área na qual não é permitida a edificação, seja por força de restrição legal ou administrativa, seja por força de dificuldades construtivas. O artigo, contudo, não tutela todo e qualquer solo não edificável; ao contrário, o seu objeto de tutela é bastante específico. A limitação é de construção em solo não edificável em razão de seu valor artístico, paisagístico, ecológico, turístico, cultural, religioso, etnográfico ou seu entorno sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a autorização; desnecessário dizer que deve haver um reconhecimento formal e oficial da existência dos valores presentes na norma. Sem o reconhecimento formal o tipo não se aperfeiçoa.

Área de entorno é conceito aberto e muitas vezes se confunde com o conceito de zona de amortecimento. Dado o caráter punitivo da norma, quando se tratar de *unidade de conservação urbana* deve ser aplicado o conceito contido na Lei nº 9.985/2000 (artigo 2º, XVIII), salvo se existente outro na legislação estadual ou municipal específica.

Acrescente-se que o artigo 25 da Lei do SNUC assim determina que, à exceção das Áreas de Proteção Ambiental e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, todas as unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Os usos permitidos nas zonas de amortecimento deverão ser fixados pelo gestor da unidade de conservação, com cuidado para não esvaziar o conteúdo econômico de tais áreas, sob pena de indenização. Os limites da zona de amortecimento devem ser fixados no ato de criação da unidade de conservação ou posteriormente.

Há Resolução do CONAMA (Resolução nº 428/2010) sobre as zonas de amortecimentos, cuja finalidade, no entanto, é a aplicação no âmbito do licenciamento ambiental. No caso específico de imóveis tombados, o Decreto-lei nº 25/1937 (artigo 18) estabelece que sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto.

É relevante assinalar que o conceito de vizinhança não se confunde com o de contiguidade, como tem sido admitido pelos tribunais brasileiros. (TRF da 4ª Região, AC 9004113738, 3ª Turma, DJU 11/3/1998, p. 445).

O chamado entorno é conceito que não se encontra previsto no Decreto-lei nº 25/37, que se utiliza do termo *vizinhança*, determinado que as construções que nela sejam edificadas não impeçam a visão do bem tombado. Importante observar que, em não raras oportunidades, situações de fato, tornam a norma inaplicável: “*Evidencia-se dos autos a existência de uma coletividade assentada urbanisticamente nos montes Guararapes, antes mesmo ou independentemente de seu tombamento, determinando o respeito as situações existentes pelas limitações administrativas ao direito de propriedade. 2. A tolerância da administração pública, no tocante a existência de centenas de construções e vias públicas naquele sítio, é incompatível com a pretensão de demolir edificação de prédio direcionada para as encostas do morro, já totalmente tomado por casebres*” (STJ. REsp 33599/PE, 2ª Turma, DJU 7/11/1994, p. 30015).

Art. 75. Picar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia ou monumento urbano:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em dobro.

O artigo reproduz o artigo 65 da Lei nº 9.605/1998, antes das alterações promovidas pela Lei nº 12.408/2011. A *grafitagem* foi retirada do *caput* do ilícito penal, ficando claro pelo § 2º a excludente de ilicitude penal quando realizada com finalidade artística e mediante a devida autorização de quem de direito, contudo, permanece como ilícito administrativo. Nos dias atuais a *grafitagem* é considerada expressão artística tipicamente urbana e, de fato, não merecia estar enquadrada como crime. Da mesma forma, deve ser retirada do rol dos ilícitos administrativos.

O artigo não é o pichar, mas a conspurcação de edificação alheia ou monumento urbano pelo meio de tais ações.

Grafite⁸ ou graffiti (do italiano graffiti, plural de graffito, “marca ou inscrição feita em muro”) é o nome dado às inscrições feita em parede, desde o Império Romano.

Considera-se grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para esta finalidade – normalmente em espaço público.

Street art, arte urbana, grafite, não pode ser confundida com pichação, como muitos ainda insistem equiparar. O grafite é uma arte muito mais complexa, muito popular entre os jovens de todo o mundo, uma vertente radical que usa os muros e fachadas das cidades para expôr sua arte.

A arte do grafite generalizou-se pelo mundo a partir do movimento de contracultura de maio de 1968, quando os muros de Paris foram palco de inscrições de caráter poético político. Dentre os grafiteiros, o mais célebre foi Jean Michel Basquiat que no final dos anos 1970, despertou a atenção da imprensa novaiorquina, sobretudo pelas mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan.

4.3.5 **Infrações administrativas contra a administração ambiental**

Art. 76. Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art. 17 da Lei 6.938, de 1981:
Multa de:
I – R\$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física;
II – R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se microempresa;
III – R\$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
IV – R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; e
V – R\$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.

A Lei nº 6.938/1981 em seu artigo 17 criou o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, sendo o registro em tais órgãos obrigatórios. As atividades que devem se cadastrar perante o Cadastro Técnico Federal são as seguintes, conforme IN Ibama nº 06, de 15 de março de 2013, com nova redação dada pela Instrução Normativa nº 11/2018.

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS				
CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Pessoa jurídica	Pessoa física
Extração e Tratamento de Minerais	1 – 1	Pesquisa mineral com guia de utilização	Sim	Sim
	1 – 2	Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento	Sim	Sim
	1 – 3	Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento	Sim	Não
	1 – 4	Lavra garimpeira	Sim	Sim
Extração e Tratamento de Minerais	1 – 7	Lavra garimpeira – Decreto nº 97.507/1989	Sim	Sim
	1 – 5	Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural	Sim	Não
Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos	2 – 1	Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração	Sim	Não
	2 – 2	Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares	Sim	Não
Indústria Metalúrgica	3 – 1	Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos	Sim	Não
	3 – 2	Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Sim	Não
	3 – 3	Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro	Sim	Não
	3 – 4	Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Sim	Não
	3 – 5	Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas	Sim	Não
	3 – 6	Produção de soldas e anodos	Sim	Não
	3 – 7	Metalurgia de metais preciosos	Sim	Não

	3 – 12	Metalurgia de metais preciosos – Decreto nº 97.634/1989	Sim	Não
	3 – 8	Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas	Sim	Não
	3 – 9	Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Sim	Não
	3 – 10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia	Sim	Não
	3 – 11	Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície	Sim	Não
Indústria Mecânica	4 – 1	Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície	Sim	Não
Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	5 – 1	Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores	Sim	Não
	5 – 2	Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática	Sim	Não
	5 – 4	Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática – Lei nº 12.305/2010: art. 33, V	Sim	Não
	5 – 3	Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos	Sim	Não
Indústria de Material de Transporte	6 – 1	Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios	Sim	Não
	6 – 2	Fabricação e montagem de aeronaves	Sim	Não
	6 – 3	Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes	Sim	Não
Indústria de Madeira	7 – 1	Serraria e desdobramento de madeira	Sim	Não
	7 – 2	Preservação de madeira	Sim	Não
	7 – 3	Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada	Sim	Não
	7 – 4	Fabricação de estruturas de madeira e móveis	Sim	Não
Indústria de Papel e Celulose	8 – 1	Fabricação de celulose e pasta mecânica	Sim	Não
	8 – 2	Fabricação de papel e papelão	Sim	Não
	8 – 3	Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada	Sim	Não
Indústria de Borracha	9 – 1	Beneficiamento de borracha natural	Sim	Não
	9 – 3	Fabricação de laminados e fios de borracha	Sim	Não
	9 – 4	Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex	Sim	Não
	9 – 5	Fabricação de câmara de ar	Sim	Não
	9 – 6	Fabricação de pneumáticos	Sim	Não
	9 – 7	Recondicionamento de pneumáticos	Sim	Não
Indústria de Couros e Peles	10 – 1	Secagem e salga de couros e peles	Sim	Não
	10 – 2	Curtimento e outras preparações de couros e peles	Sim	Não
	10 – 3	Fabricação de artefatos diversos de couros e peles	Sim	Não
	10 – 4	Fabricação de cola animal	Sim	Não
Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos	11 – 1	Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos	Sim	Não
	11 – 2	Fabricação e acabamento de fios e tecidos	Sim	Não
	11 – 3	Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos	Sim	Não
	11 – 4	Fabricação de calçados e componentes para calçados	Sim	Não
Indústria de Produtos de Matéria Plástica	12 – 1	Fabricação de laminados plásticos	Sim	Não
	12 – 2	Fabricação de artefatos de material plástico	Sim	Não

Indústria do Fumo	13 – 1	Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo	Sim	Não
Indústrias Diversas	14 – 1	Usinas de produção de concreto	Sim	Não
	14 – 2	Usinas de produção de asfalto	Sim	Não
Indústria Química	15 – 1	Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos	Sim	Não
	15 – 17	Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – PI nº 292/1989: art. 1º	Sim	Não
	15 – 20	Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – Lei nº 9.976/2000	Sim	Não
	15 – 21	Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos – Resolução CONAMA nº 463/2014/ Resolução CONAMA nº 472/2015	Sim	Não
	15 – 2	Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira	Sim	Não
	15 – 23	Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira – Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, XIV	Sim	Não
	15 – 3	Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo	Sim	Não
	15 – 4	Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira	Sim	Não
	15 – 5	Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos	Sim	Não
	15 – 6	Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos	Sim	Não
	15 – 7	Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais	Sim	Não
	15 – 8	Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos	Sim	Não
	15 – 9	Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas	Sim	Não
	15 – 10	Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes	Sim	Não
	15 – 11	Fabricação de fertilizantes e agroquímicos	Sim	Não
	15 – 12	Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários	Sim	Não
	15 – 13	Fabricação de sabões, detergentes e velas	Sim	Não
	15 – 14	Fabricação de perfumarias e cosméticos	Sim	Não
	15 – 15	Produção de álcool etílico, metanol e similares	Sim	Não
Indústria de Produtos Alimentares e Bebida	16 – 1	Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares	Sim	Não
	16 – 2	Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal	Sim	Não
	16 – 15	Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal – Instrução Normativa nº 7/2015: art. 3º, IX	Sim	Não
	16 – 3	Fabricação de conservas	Sim	Não
	16 – 4	Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados	Sim	Não
	16 – 5	Beneficiamento e industrialização de leite e derivados	Sim	Não
	16 – 6	Fabricação e refinação de açúcar	Sim	Não
	16 – 7	Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais	Sim	Não
	16 – 8	Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação	Sim	Não
	16 – 9	Fabricação de fermentos e leveduras	Sim	Não

	16 – 10	Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais	Sim	Não
	16 – 11	Fabricação de vinhos e vinagre	Sim	Não
	16 – 12	Fabricação de cervejas, chopes e maltes	Sim	Não
	16 – 13	Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais	Sim	Não
	16 – 14	Fabricação de bebidas alcoólicas	Sim	Não
Serviços de Utilidade	17 – 1	Produção de energia termoeleétrica	Sim	Sim
	17 – 59	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “f”, “k”	Sim	Não
	17 – 60	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XIV	Sim	Não
	17 – 57	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Decreto nº 7.404/2010: art. 36	Sim	Não
	17 – 58	Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos – Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VIII	Sim	Não
	17 – 4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas	Sim	Não
	17 – 61	Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, I	Sim	Não
	17 – 62	Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, II	Sim	Não
	17 – 63	Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, III	Sim	Não
Serviços de Utilidade	17 – 64	Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “g”	Sim	Não
	17 – 65	Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, “h”	Sim	Não
	17 – 66	Disposição de resíduos especiais: Protocolo de Montreal	Sim	Não
	17 – 5	Dragagem e derrocamentos em corpos d’água	Sim	Não
	17 – 67	Recuperação de áreas degradadas	Sim	Sim
	17 – 68	Recuperação de áreas contaminadas	Sim	Não
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	18 – 1	Transporte de cargas perigosas	Sim	Sim
	18 – 74	Transporte de cargas perigosas – Lei nº 12.305/2010	Sim	Não
	18 – 14	Transporte de cargas perigosas – Resolução CONAMA nº 362/2005	Sim	Não
	18 – 83	Transporte de cargas perigosas – Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, “g”	Sim	Sim
	18 – 2	Transporte por dutos	Sim	Não
	18 – 3	Marinas, portos e aeroportos	Sim	Não
	18 – 4	Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos	Sim	Não
	18 – 5	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos	Sim	Não
	18 – 80	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos – Lei nº 12.305/2010	Sim	Não
	18 – 7	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos	Sim	Não
	18 – 8	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Decreto nº 97.634/1989	Sim	Não
	18 – 10	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Protocolo de Montreal	Sim	Sim
	18 – 13	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 362/2005	Sim	Não
	18 – 17	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Convenção de Estocolmo / PI nº 292/1989	Sim	Não

	18 – 64	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 463/2014 / Resolução CONAMA nº 472/2015	Sim	Não
	18 – 66	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Lei nº 7.802/1989	Sim	Não
	18 – 79	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Decreto nº 875/1993	Sim	Não
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	18 – 81	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos – Resolução CONAMA nº 401/2008	Sim	Não
	18 – 6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo	Sim	Não
Turismo	19 – 1	Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos	Sim	Não
Uso de recursos naturais	20 – 60	Silvicultura – Lei nº 12.651/2012: art. 35, §§ 1º, 3º	Sim	Sim
	20 – 61	Silvicultura – Lei no 12.651/2012: art. 35, § 1º	Sim	Sim
	20 – 2	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais	Sim	Sim
	20 – 63	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais – Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II	Sim	Sim
	20 – 23	Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, VII	Sim	Não
	20 – 25	Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, X	Sim	Não
	20 – 5	Utilização do patrimônio genético natural	Sim	Sim
	20 – 6	Exploração de recursos aquáticos vivos	Sim	Sim
	20 – 54	Exploração de recursos aquáticos vivos – Lei nº 11.959/2009: art. 2º, II	Sim	Sim
	20 – 21	Importação ou exportação de fauna nativa brasileira	Sim	Sim
	20 – 22	Importação ou exportação de flora nativa brasileira	Sim	Sim
	20 – 26	Introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura	Sim	Sim
	20 – 35	Introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente	Sim	Sim
	20 – 37	Uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente	Sim	Não
Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	21 – 51	Formulação de produtos biorremediadores – Resolução CONAMA nº 463/2014	Sim	Não
	21 – 66	Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle – Lei nº 7.802/1989	Sim	Não
Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	21 – 5	Experimentação com agroquímicos – Lei nº 7.802/1989	Sim	Não
	21 – 47	Aplicação de agrotóxicos e afins – Lei nº 7.802/1989	Sim	Sim
	21 – 46	Controle de plantas aquáticas – Resolução CONAMA nº 467/2015	Sim	Sim
	21 – 35	Geração de energia hidrelétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Sim
	21 – 36	Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Sim
	21 – 34	Transmissão de energia elétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	21 – 37	Distribuição de energia elétrica – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	21 – 33	Estações de tratamento de água – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	21 – 30	Operação de rodovia – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	21 – 31	Operação de hidrovía – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	21 – 32	Operação de aeródromo – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não

	21 – 40	Comércio exterior de resíduos controlados – Decreto nº 875/1993	Sim	Não
	21 – 41	Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista – Lei nº 12.305/2010	Sim	Não
	21 – 45	Importação de pneus e similares – Resolução CONAMA nº 416/2009	Sim	Sim
	21 – 43	Importação de veículos automotores para uso próprio – Lei nº 8.723/1993	Sim	Sim
	21 – 44	Importação de veículos automotores para fins de comercialização – Lei nº 8.723/1993	Sim	Não
	21 – 42	Importação de eletrodomésticos – Resolução CONAMA nº 20/1994	Sim	Não
	21 – 3	Utilização técnica de substâncias controladas – Protocolo de Montreal	Sim	Sim
	21 – 49	Transporte de produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 36	Sim	Sim
	21 – 50	Armazenamento de produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 35, § 2º	Sim	Não
	21 – 67	Comércio atacadista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 37	Sim	Não
	21 – 68	Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais – Lei nº 12.651/2012: art. 37	Sim	Não
Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	21 – 48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal – Lei nº 12.651/2012: art. 34	Sim	Não
	21 – 64	Exportação de carvão vegetal de espécies exóticas – Instrução Normativa IBAMA nº 15/2011: art. 2º, § 1º	Sim	Não
	21 – 69	Comercialização de recursos pesqueiros – Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31	Sim	Não
	21 – 70	Revenda de organismos aquáticos vivos ornamentais – Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31	Sim	Não
	21 – 52	Centro de triagem de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, I	Sim	Não
	21 – 54	Centro de reabilitação de fauna silvestre nativa – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, II	Sim	Não
	21 – 71	Revenda de animais vivos de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, III	Sim	Não
	21 – 72	Comércio de partes, produtos e subprodutos de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, IV	Sim	Não
	21 – 56	Criação científica de fauna silvestre para fins de conservação – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, V	Sim	Sim
	21 – 55	Criação científica de fauna silvestre para fins de pesquisa – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, VI	Sim	Não
	21 – 53	Manutenção de fauna silvestre – Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, VIII	Sim	Sim
	21 – 57	Importação ou exportação de fauna silvestre exótica – Portaria IBAMA nº 93/1998: art. 3º	Sim	Sim
	21 – 59	Manejo de fauna sinantrópica – Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006: art. 4, § 2º	Sim	Sim
	21 – 58	Manejo de fauna exótica invasora – Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006: art. 4, § 2º	Sim	Sim
Atividades sujeitas a	21 – 60	Criação de passeriformes silvestres nativos – Instrução Normativa IBAMA nº 10/2011	Não	Sim
	21 – 62	Manutenção de área passível de Ato Declaratório Ambiental – Lei nº 6.938/1981: art. 17-O	Sim	Sim
Atividades sujeitas a	22 – 1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos – Lei nº 6.938/1981: art.	Sim	Não

controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 – Obras civis	22 – 2	10 Construção de barragens e diques – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	22 – 3	Construção de canais para drenagem – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	22 – 4	Retificação do curso de água – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 – Obras civis	22 – 5	Abertura de barras, embocaduras e canais – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	22 – 6	Transposição de bacias hidrográficas – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	22 – 7	Construção de obras de arte – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não
	22 – 8	Outras obras de infraestrutura – Lei nº 6.938/1981: art. 10	Sim	Não

O ilícito administrativo é formal, devendo as empresas de tipologia acima efetuarem o respectivo registro no órgão federal de controle ambiental.

Art. 77. Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

O artigo 69 da Lei nº 9.605/1998 é o que mais se aproxima do tipo administrativo. Obstar é impedir que a Ação fiscalizadora se realize plenamente, que verifique *in loco* a existência ou não de ilícitos ambientais. Contudo, existe uma enorme zona de incerteza no que diz respeito aos limites da atividade de fiscalização, notadamente quando se trata de fiscalização em domicílio do particular. Matéria bastante assemelhada foi decidida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (AG 200602010045075, AG – Agravo de instrumento – 146210, 7ª Turma Especializada, DJU 24/10/2007, p. 122).

Quanto ao tema, o STF (HC 82788, 2ª Turma, 12/4/2005) decidiu que a circunstância de a administração estatal achar-se investida de poderes excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária não a exonera do dever de observar, para efeito do legítimo desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e pelas leis da República, sob pena de os órgãos governamentais incidirem em frontal desrespeito às garantias constitucionalmente asseguradas aos cidadãos em geral e aos contribuintes em particular.

Assim, a ação de *obstar* a fiscalização somente pode ser considerada ilícito administrativo nos casos em que a autoridade ambiental pretenda realizar a atividade de fiscalização (i) mediante prévia notícia ao fiscalizado, (ii) mediante a existência de uma ordem judicial, (iii) para evitar a prática de um crime ou (iv) diante de perigo iminente (CF, artigo 5º, XI).

Dificultar deve ser compreendido em outro contexto. Dificultar é atrapalhar, prejudicar a atividade legal de fiscalização, estabelecer embaraços etc. A fiscalização se realiza, porém inadequadamente, sem que haja culpa da administração.

A ação fiscalizatória tutelada pelo tipo administrativo é aquela realizada pelos órgãos de controle ambiental dotados da competência para a fiscalização da atividade, conforme o estabelecido na LC nº 140/2011, não sendo razoável que o tipo tutele a ação de outros agentes, haja vista que ela ocorre de forma completamente aleatória, o que impede o direito de defesa do particular.

Art. 78. Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele encarregado, na coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização:
Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais) por hectare do imóvel.

O artigo pode ser considerado um subtipo ou extensão do tipo contido no artigo precedente, devendo ser aplicadas todas as considerações acima no que se refere à legalidade da ação fiscalizatória. Contudo, existem peculiaridades no tipo que merecem ser analisadas. Como se sabe, o auto de infração ambiental deve ser redigido de forma clara e precisa, indicando os elementos do ilícito cometido, até mesmo para propiciar o direito de defesa do suposto infrator. Um dos elementos fundamentais para a adequada caracterização do ilícito ambiental é o local no qual ele teria ocorrido. Modernamente, a identificação do local é feita pelo chamado georreferenciamento.

O georreferenciamento, conforme definição da Associação Brasileira de Georreferenciamento e Geomática é “uma técnica aprimorada de descrição de imóveis rurais e urbanos, voltada para o controle tanto do cadastro de imóveis rurais e urbanos como dos direitos a eles relativos; visando a identificação de lotes urbanos e terras devolutas Federais e Estaduais, com finalidade de combater a superposição de áreas e as fraudes decorrentes”. Igualmente, *georreferenciamento ou georreferenciação*º de uma imagem ou um mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica é tornar suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. Os pontos de controle são locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, tais como interseções de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, entre outros. A obtenção das coordenadas dos pontos de controle pode ser realizada em campo (a partir de levantamentos topográficos, GPS – Sistema de Posicionamento Global), ou ainda por meio de mesas digitalizadoras, ou outras imagens ou mapas (em papel ou digitais) georreferenciados.

No Brasil, a Lei nº 10.267/01 torna obrigatório o georreferenciamento do imóvel na escritura para alteração nas matrículas, como mudança de titularidade, remembramento, desmembramento, parcelamento, modificação de área e alterações relativas a aspectos ambientais, respeitando os prazos previstos. A mesma lei criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, que terá base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.

Há que se registrar que a Lei nº 10.267/2001 não deu qualquer atribuição ao órgão ambiental federal, no caso ao IBAMA, para a “coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização”. Assim, a coleta de dados georreferenciados só pode ser concebida no bojo de uma ação fiscalizatória com vistas à adequada identificação do local no qual tenha sido praticada alguma infração ambiental. Contudo, no caso de apuração de infração, evidentemente que a Ação deve ser do próprio órgão de controle ambiental, a menos que *lei* delegue a atividade para particular, sob pena de nulidade do ato praticado sem a observância de tais cuidados.

Qualquer outra informação sobre georreferenciamento deverá ser buscada junto ao INCRA.

Art. 79. Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas:
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O embargo de obra ou atividade é uma sanção administrativa prevista no inciso VII do artigo 72 da Lei nº 9.605/1998. O embargo é sanção grave que implica a paralisação da obra ou atividade enquanto ele não for suspenso pela autoridade administrativa ou judicial. Ele pode ser parcial ou total. Embargo *parcial* é aquele que se limita a determinado aspecto da obra ou atividade embargada, notadamente aquele no qual foi constatada a prática do ilícito. Total é o embargo que paralisa toda a obra ou atividade.

A decretação do embargo deve observar o disposto nos artigos 15-A, 15-B, 16 e 17 do decreto ora sob análise. Observe-se que a penalidade estabelecida pelo artigo deve ser considerada em conjunto com aquelas estabelecidas pelo artigo 18. A decretação do embargo, quando competente o fiscal, tem efeito imediato, devendo ser observado pelo embargado. Há que se registrar, todavia, que o embargo pode ter o caráter de medida cautelar, com vistas a impedir que, no que na visão da autoridade ambiental, seja uma infração grave capaz de causar dano ao ambiente.

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental.
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 81. Deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando <i>aplicável</i>, naquele determinado pela autoridade ambiental:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omissão, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:
Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 83. Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental:
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

4.3.6 Infrações cometidas exclusivamente em Unidades de Conservação

Art. 84. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Excetua-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade. § 2º Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.
Art. 85. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos com vistas à criação de unidade de conservação:
Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras formas de vegetação nativa nas áreas definidas no <i>caput</i> .
Art. 86. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1º A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2º Excetua-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de material biológico.
Art. 87. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta for exigível: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008)
Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo as áreas de <i>proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural</i> .
Art. 88. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de *proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural*.

A CF e o CC determinam a proteção dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais o direito à imagem é um dos mais relevantes, merecendo tutela específica. A Lei do SNUC possui norma própria determinando seja autorizada pela Administração a utilização de imagens de unidades de conservação. A medida é salutar, pois coíbe a utilização econômica de imagens de bens públicos sem que o estado aufera o necessário benefício; a matéria, como se vê, não guarda qualquer relação com proteção ambiental, antes resguardando interesses patrimoniais do Estado contra a exploração comercial por terceiros não autorizados; contudo, a norma precisa ser interpretada com razoabilidade, pois muitas vezes, as imagens, ainda que feitas por terceiros, sem que tenham remunerado a unidade de conservação, podem ser um importante fator de divulgação. A Lei do SNUC, em seu artigo 33 determina que “A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto APA e RPPN, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento”.

A norma, como se vê, não determina a punição administrativa daquele que explorar comercialmente a imagem de unidade de conservação e o fez adequadamente, pois a questão se resolve no campo da indenização civil, não da punição administrativa.

A exploração de bens e serviços de Unidades de Conservação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, tendo o uso de imagem sido tratado pelo artigo 27.

Art. 89. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 1º A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de proteção integral.
§ 2º A multa será aumentado ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.
§ 3º O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.
Art. 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Plano de Manejo é o instrumento técnico que estabelece as condições de uso das diferentes UCs, descrevendo as atividades permitidas, os locais nos quais elas poderão ser realizadas etc. É, portanto, um instrumento extremamente importante e ao qual é necessário que se dê uma ampla divulgação, sob pena de restar letra morta. Ele deve ser elaborado mediante consultas à comunidade, sobretudo os proprietários das terras submetidas ao regime especial, quando se tratar de UC de uso sustentável. Observe-se que a obediência aos ditames do Plano de Manejo depende de uma précondição que é a sua publicidade. Infelizmente, não tem sido dada a necessária publicidade aos Planos de Manejo e estes, em grande parte das vezes, permanecem como uma grande incógnita. Há uma questão relevante que não tem sido observada pela doutrina que é o zoneamento das áreas de proteção ambiental que, como sabemos, em sua maioria são constituídas por áreas privadas. Normalmente são estabelecidos zoneamentos os quais contemplam, por exemplo, zonas de conservação da vida silvestre (ZCVS) que não admitem atividades econômicas ou de lazer. Certamente tais zonas são relevantes intervenções na propriedade privada e, portanto, se faz necessário que os proprietários sejam ouvidos quando da instituição do zoneamento. Além do mais, necessário que se averbe à margem do registro da propriedade a restrição de origem ambiental.

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:
Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade competente.
Art. 93. As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta Subseção, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.

As UCs são a materialização do mandamento constitucional que determina ao Poder Público que delimite os espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Isto poderá (*rectius*: deverá) ser feito pelas três esferas do Poder Público, havendo UCs Federais, Estaduais e Municipais. No âmbito federal, Unidades de Conservação são aquelas definidas como tal pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Elas se dividem em (i) UCs de proteção integral e (ii) UCs de uso sustentável. As unidades de conservação são o “*espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção*”, portanto, elas não se confundem, por exemplo, com as áreas de preservação permanente ou com a RFL.

As UCs de Proteção Integral têm por objetivo legal preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei nº 9.985/2000; já as UCs de Uso Sustentável têm por finalidade compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O grupo de unidades de proteção integral é composto por: (i) Estação Ecológica; (ii) Reserva Biológica; (iii) Parque Nacional; (iv) Monumento Natural, e (v) Refúgio de Vida Silvestre. Cada uma das diferentes unidades de proteção integral tem o seu objetivo e o seu contorno jurídico definido na lei. O grupo das UCs de Uso Sustentável é composto por: (i) Área de Proteção Ambiental; (ii) Área de Relevante Interesse Ecológico; (iii) Floresta Nacional; (iv) Reserva Extrativista; (v) Reserva de Fauna; (vi) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e (vii) Reserva Particular do Patrimônio Natural.

O artigo 91 do Decreto nº 6.514/2008 pune o dano causado às diferentes modalidades unidades de conservação, não estabelecendo limites para o dano infringido.

Dano, como se sabe, é o ato ilícito capaz de gerar prejuízo ao meio ambiente, pois ser reparado pelo seu causador. Penso que o dano à unidade de conservação deva ser compreendido como o ato ilícito capaz de pôr em risco ou debilitar gravemente os atributos que deram origem à instituição da Unidade de Conservação concretamente considerada. Não deve ser considerado dano à unidade de conservação aquele causado às instalações utilizadas como *meio* para o funcionamento da referida unidade. O dano causado ao estacionamento de um Parque Nacional é dano ao patrimônio público, e não dano à unidade de conservação. Os danos causados à sede da APA de Petrópolis, situada em zona urbana à beira da estrada União e Indústria, são dano ao patrimônio público.

O artigo 92 do Decreto nº 6.514/2008 estabelece como tipo administrativo o ato de “*penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível*”. Penetrar, no caso, deve ser entendido como invadir, entrar sem consentimento da autoridade responsável pela manutenção da UC. Neste particular, duas questões devem ser observadas (i) a UC deve estar demarcada e os seus limites devem ser acessíveis ao público em geral que deverá ter meios de saber se está ou não “penetrando” em uma UC ocorra, estará havendo uma aplicação de responsabilidade objetiva e, no particular, como a pena é de multa, o § 2º do artigo 3º do decreto determina que ela somente seja aplicada após a advertência do infrator para cessar a atividade e que se apure a “negligência ou dolo”, em outras palavras, a culpabilidade e, ainda (ii) que a UC seja daquelas de proteção integral, pois nas de uso sustentável, muitas vezes a pesca, por exemplo, é permitida. Note-se que a ausência de licença para porte dos equipamentos mencionados no artigo já é, em si mesma, uma infração administrativa.

Uma questão tormentosa é a que diz respeito às chamadas áreas de entorno de UCs. Em primeiro lugar há que se consignar que nem toda UC é dotada de entorno, ou zona de amortecimento. Isto significa que as zonas de amortecimento devem ser demarcadas e definidas por ato próprio, e jamais por um ato genérico que defina arbitrariamente a área de entorno. Assim, sem eficácia a Resolução nº 13/90 do Conama, cuja constitucionalidade, mesmo antes da Lei do SNUC já era bastante discutível. “*Penal. Crimes contra o meio ambiente. Tipicidade. I – Nulidade de decisão revogando recebimento da denúncia que se declara. Precedentes. II – Circunstâncias de imputadas ações sobre a flora em terras particulares a justificarem exame de ofício. III – Precário o grau de determinação do conteúdo da lei, deficiente a descrição da conduta, a interpretação a daí se extrair não pode ser de maior restrição à esfera da liberdade. Caráter excessivamente genérico da definição legal que não pode ser empregado para como delito enquadrar a conduta em si do proprietário em terras particulares. IV – A mera conduta de ocupação de área sem prévia autorização da autoridade ambiental supostamente exigida não configura crime, não se entevendo dano no sentido do artigo 40 mas conduta de outra natureza, não havendo previsão de crime com semelhante descrição de conduta. V – Delitos que exigem a elementar da unidade de conservação criada, que por sua vez submete-se ao regime da Lei 9.985/2000 que em obediência à Constituição expressamente estabelece a criação em terras públicas ou que como tal venham a se tornar por desapropriação e quando admite a abrangência ao domínio privado ressalva os direitos dos proprietários e os limites constitucionais. VI – Recurso provido para anular-se a decisão revogando o recebimento da denúncia e de ofício concedido ‘Habeas Corpus’ para trancamento do processo criminal*” (TRF da 3ª Região, RSE 200261240011464, RSE – Recurso em Sentido Estrito – 4026, 2ª Turma, DJU 2/2/2007, p. 338).

Vale ressaltar que a Resolução Conama nº 13/1990 foi expressamente revogada pela Resolução Conama nº 428, de 17 de dezembro de 2010.

4.3.7 Aspectos relevantes do processo administrativo

O agente da fiscalização ao constatar a prática de uma infração às normas administrativas de tutela do meio ambiente deverá lavrar o respectivo auto e comunicar ao infrator ciência da autuação, de modo que ele possa se defender adequadamente ao ilícito que lhe foi imputado. Observe-se que para a imposição de sanções administrativas aos particulares estabeleceu-se, em princípio, que o Auto de Infração goza de presunção de veracidade do contido na autuação. Tal situação, por óbvio, não implica veracidade absoluta da ação administrativa e, ao particular, é dado o direito de produzir as provas que julgue necessárias para a sua defesa.

Por sua vez, a autoridade administrativa tem o poder-dever de requisitar (*rectius*: determinar) a realização das provas que julgue necessárias para a formação de sua convicção quanto aos fatos que lhe forem apresentados e confirmar ou reformar a decisão impugnada. Dois elementos sobressaem: (I) o parecer técnico para esclarecer questões complexas e que demandem uma análise mais profunda e, sobretudo, especializada. O parecer poderá ser solicitado de órgãos estranhos à administração que, no entanto, não estão obrigados a fornecê-los sem a respectiva remuneração, ou a existência de convênios entre os órgãos solicitantes e o solicitado; (ii) a contradita é a informação prestada pela autoridade autuante que, por ela, poderá defender a prática do ato impugnado pelo recorrente. Como se pode depreender do regulamento, a autoridade deverá especificar as situações de fato que deram margem à autuação e não fazer, o que tem sido muito comum, uma listagem, de leis e normas, como se isto fosse suficiente para justificar a autuação. O fiscal autuante, *data venia*, não exerce função jurídica, não lhe cabendo “interpretar” normas legais. O bom fiscal relata fatos que no seu entendimento são infracionais. Fiscais que interpretam normas só existem em regimes ditatoriais.

A fixação do prazo para a elaboração do parecer é medida importante, pois impede que as demandas administrativas se prolonguem indefinidamente.

Assim como no processo civil, a autoridade processante tem ampla liberdade para examinar a pertinência das provas que as partes pretendem produzir e, a partir de sua análise, deferi-las ou indeferi-las. Como decorre de nossa principiologia constitucional, qualquer decisão quanto ao particular deve ser fundamentada, com vistas a possibilitar às partes o direito de ampla defesa. Sempre que a matéria versar sobre interpretação jurídica de uma determinada situação de fato – o que ocorre na maioria dos casos dos quais tenho conhecimento – antes de prolatada a decisão pela autoridade administrativa, deverá ser emitido parecer jurídico, com vistas a subsidiar a decisão a ser proferida. O parecer não é vinculante, o que significa que a autoridade administrativa não está adstrita a seguir-lhe os termos. Contudo a prudência determina que, em casos que tais, a opinião da procuradoria seja observada. A parte tem o direito de expor o seu ponto de vista sobre a prova produzida nos autos, analisando-as e ressaltando os aspectos que julgarem mais favoráveis aos seus interesses. As alegações finais devem ser apresentadas por escrito e de forma articulada.

A autoridade julgadora é dotada de amplo poder de revisão e não está, de forma nenhuma, vinculada às decisões tomadas pela autoridade autuante. Contudo como se verifica, o artigo 123 do Decreto nº 6.514/2008 está endereçado diretamente às hipóteses de multa. Todavia, o parágrafo único, guarda uma redação bastante peculiar e que merece reprovação. Com efeito, determina-se que o interessado apresente razões finais quando o julgamento – em tese ainda não realizado – implique em majoração da multa imposta. Da forma como o parágrafo está redigido, o leitor é levado a acreditar que o julgamento já foi decidido previamente, o que causa revolta ao sentimento jurídico e afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Observe-se que a Lei nº 9.605/1998, em seus artigos 70 e 71, dispõe de algumas regras gerais sobre o processo administrativo para a apuração de infrações cometidas contra a ordem pública do meio ambiente, pelas quais se considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

É relevante assinalar que a Lei nº 11.941/2009, em seu artigo 79, inciso XIII, revogou o inciso III do *caput* do art. 8º da Lei nº 6.938/1981. Tal disposição é extremamente discutível ante o teor dos artigos 1º, 3º e 7º da LC nº 95/1998.

Assim, os artigos ora em comento deixaram de ter eficácia jurídica, tendo em vista que a competência recursal do Conama foi expungida do mundo jurídico.

Como já foi sustentado por diversas vezes na presente obra, a Lei nº 9.605/98 não dispôs sobre infrações administrativas contra a legislação do meio ambiente, limitando-se a criar uma fórmula genérica contemplada no artigo 70. Contudo, no que se refere ao processo administrativo para o apenamento de infrações, a lei foi relativamente generosa e, nos artigos 71 ss., tratou da matéria de forma bastante razoável, pelo menos no que diz respeito aos recursos e as penalidades aplicáveis. Como se sabe, no âmbito federal, existe a Lei nº 9.789/1999 (processo administrativo federal). Contudo, é importante que se ressalte que, ante o princípio da especialidade, a Lei nº 9.605/98, no que se refere ao processo administrativo de apuração de infração e aplicação de sanções, tem prevalência sobre a norma geral que deverá ser aplicada subsidiariamente. Colocada tal questão, cabe assinalar que, nos termos da Lei nº 9.784/99, cabem recursos administrativos das decisões de *mérito e de legalidade*. Assim, há uma ampla gama de possibilidades de revisão da decisão de “primeira instância”, contudo, a norma não definiu uma instância administrativa autônoma capaz de assegurar isenção para a análise dos recursos, o mesmo ocorrendo com a Lei nº 9.605/98. Trata-se de uma inexplicável aversão brasileira ao contencioso administrativo e uma inadequada compreensão da possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos. Fato é que urge a criação de instrumentos administrativos autônomos diante dos órgãos executivos para o exame dos recursos administrativos. Timidamente temos os conselhos de contribuinte,

no âmbito fazendário, que pouco a pouco vêm adquirindo mais autonomia mais, infelizmente, ainda estão longe do desejável.

Um bom exemplo a ser seguido é o da EPA norte-americana que é dotada de um corpo de juízes administrativos, nomeados pelo Presidente da República e que decidem questões relevantes.¹⁰ Resguarda-se a *judicial review*, na medida em que as suas decisões podem ser revistas pelo Judiciário em casos de ilegalidade.

De acordo com o modelo geral estabelecido na Lei (9.784/99), encaminha-se o recurso a autoridade que proferiu a decisão recorrida para que ela, no prazo de 5 (cinco) dias, remeta-o ao superior hierárquico, a quem caberá o exame da revisão. Como regra, os recursos administrativos independem de caução ou pagamento de custas administrativas, prevalecendo o princípio da gratuidade. Após a vigência da Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004, que estabeleceu as chamadas súmulas vinculantes, cabe à autoridade, quando alegada pelo recorrente a violação de súmula, expor suas razões no sentido de defender o ato praticado. O artigo 57 da Lei nº 9.784 determina que o “*recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa*”. Aqui, lei deve ser entendida como lei formal, haja vista que não é juridicamente possível que ato regulamentar subtraia direitos concedidos em lei aos particulares.

As partes legítimas para a interposição de recursos são as seguintes: (i) *os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo*; (ii) *aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida*; (iii) *as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos*; (iv) *os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos*.

O Decreto nº 6.514/2008 outorgou às partes o prazo da Lei nº 9.605/98, o que é correto, ante a especialidade da matéria, maior do que o legal para a interposição de recurso administrativo. Observe-se que existe uma determinação no sentido de que a autoridade administrativa que proferiu a decisão recorrida exerça, inicialmente, o juízo de retratação e que, somente após a expressa manutenção da decisão recorrida, é que o arrazoado seguiria para a autoridade superior. Veja-se que, infelizmente, o revisor está sendo vinculado à cadeia de comando daquele que proferiu a decisão, havendo relação hierárquica e profissional entre ambos, o que não consulta aos melhores interesses da aplicação da lei.

O parágrafo 2º do artigo 127 do Decreto nº 6.514/2008 deve ser interpretado restritivamente, pois a única interpretação possível em regime democrático é que as autoridades encarregadas de examinar recursos serão designadas pela direção do órgão ambiental previamente, com vistas a assegurar o princípio do juízo natural, mesmo que na esfera administrativa.

O Decreto nº 6.514/2008 dotou os administradores dos órgãos ambientais do poder de definir a “alçada”, a partir da qual, haverá o chamado “recurso de ofício”, ou o reexame administrativo necessário da decisão desfavorável à Administração. Trata-se de prática tradicional em nossa administração pública. Há, evidentemente, uma forte desconfiança em relação às autoridades administrativas de menor hierarquia. O recurso de ofício não é fundamentado, limitando-se a devolver todo o conhecimento da matéria à autoridade superior designada. Não se pode deixar de observar, ademais, que o sistema adotado demonstra uma inconsistência e, concomitantemente, denuncia a fragilidade do sistema de revisão e recursos administrativos que, do meu ponto de vista, devem ser dotados de maior independência e distanciamento do administrador.

A regra é que os recursos administrativos não sejam dotados de efeito suspensivo e que as decisões neles proferidas tenham aplicação imediata, O § 1º do artigo 128 do Decreto nº 6.514/2008 admite a hipótese de que, em havendo justo e fundado receio de que a decisão possa resultar em prejuízo ou dano de difícil reparação, seja o recurso dotado de efeito suspensivo, impedindo-se a imediata entrada em vigor da decisão recorrida. Relembre-se, contudo, que para as hipóteses de aplicação de penalidade de multa, a regra é o recebimento do recurso administrativo com *efeito suspensivo*.

A autoridade superior tem ampla capacidade de reforma da decisão proferida na instância administrativa *a quo*; contudo, não se trata, evidentemente, de aplicação de juízo discricionário, haja vista que toda e qualquer decisão administrativa deve ser fundamentada em razões de fato e de direito. Contudo, há uma margem de discricionariedade administrativa na aplicação de penalidades; de fato, muitas vezes, a apenação de uma determinada atividade pode ter consequências econômicas, sociais e políticas mais nocivas do que a própria prática que se pretende coibir. Assim, é relevante que a autoridade superior exerça um exame do custo/benefício de uma determinada medida, antes de decidir o recurso administrativo que lhe foi submetido. No campo ora examinado, a matéria está inteiramente submetida aos desígnios do princípio da legalidade administrativa. No caso de improvimento do recurso administrativo, a decisão recorrida será “confirmada” pela instância *ad quem*. A modificação deve ser entendida como a reforma parcial da decisão de primeiro grau. A amplitude da reforma parcial é muito grande, pois por ela podem ser reduzidos valores de penalidades, diminuídos os prazos de penas restritivas de direitos etc.

A *anulação* ocorre nas hipóteses de ilegalidade no conteúdo da decisão recorrida. Já a revogação é aplicável nos casos de conveniência e oportunidade administrativa. Pelo teor do § 1º do artigo 129 do Decreto nº 6.514/2008, verifica-se que a hipótese do artigo é aplicável apenas para os chamados “recursos de ofício”, haja vista que o requerimento de revisão deve ser interposto “*mediante declaração na própria decisão*”. Tal parágrafo é coerente com o que se lhe segue, haja vista que determina a possibilidade de uma alçada até a qual não se aplica a remessa para revisão de ofício.

A Lei nº 9.784/99 estabelece em seu artigo 60 que o “*recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes*”. Trata-se do recurso voluntário interposto pela parte interessada pela reforma da decisão ou quaisquer uns dos demais legitimados administrativamente. Desnecessário dizer que, para que se possa garantir que terceiras partes interessadas possam recorrer da decisão, imprescindível que a mesma seja publicada no órgão oficial, pelo menos sob a forma de extrato, no qual se possa identificar claramente a demanda administrativa decidida. Ademais, é importante observar que a lei de informações ambientais (Lei nº 10.650/2003) assegura a todos o direito de conhecer o conteúdo dos processos administrativos que tratam de questões referentes a proteção do meio ambiente, desde que resguardado o sigilo industrial.

Nos processos administrativos não vige o princípio da defesa técnica, nem o da indispensabilidade do advogado. Assim, qualquer um poderá postular perante a Administração, seja em causa própria, seja defendendo o interesse de terceiros, neste último caso desde que munido da competente procuração.

O Decreto nº 6.514/2008 admitiu como terceira instância recursal o Conama – Conama. De acordo com o disposto na Lei nº 9.784/99, esta é a última instância administrativa, dela não cabendo, em princípio, nenhum novo recurso administrativo. Contudo, a praxe administrativa tem admitido a interposição de recursos administrativos perante o Chefe do Executivo que, como se sabe, goza da prerrogativa de revisão geral de todos os atos administrativos.

Todavia, entende-se que o Conama deixou de *ser uma terceira instância com a revogação do inciso III do artigo 8º da Lei Federal nº 6.938/1981, que previa a competência do Conama para decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA*. Tal revogação se deu pela Lei nº 11.941/2009.

Como se depreende do artigo 131 do Decreto nº 6.514/2008, ele estabeleceu um rol menor de hipóteses de não conhecimento dos recursos administrativos do que aquelas previstas na lei de processo administrativo federal. Logicamente que, quando cabível, a autoridade administrativa deverá aplicar a lei, com vistas a não restringir direitos dos administrados. Recursos fora de prazo são aqueles interpostos além da data fatal determinada pela lei. Para que se possa saber qual é a data fatal, necessário se faz que se utilize o critério legal *para a contagem dos prazos*. Como o decreto não define um critério específico para as infrações ambientais, aplicável o previsto na Lei nº 9.784/99 (artigos 66 e 67), pelos quais os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. O prazo é prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Já os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. A suspensão de prazos só por motivo de força maior.

A expressão *órgão ambiental* utilizada pelo decreto deve ser interpretada em sentido restrito, isto é, deve ser a entidade dotada de personalidade jurídica que seja legalmente competente para a apreciação da matéria. Não se deve tomar a expressão no sentido da repartição especificamente considerada. Nada impede que o interessado protocole o seu recurso perante o Ibama de Petrópolis, mesmo que a decisão tenha sido proferida pelo Ibama do Rio de Janeiro, desde que a petição de interposição tenha os elementos necessários à identificação da repartição, penso não haver qualquer problema em protocolá-lo em “outro” local.

Vale destacar a necessidade de publicidade dos atos administrativos. Para tal, a administração deverá se valer das normas contidas na Lei nº 9.784/99 que são as seguintes:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 1º A intimação deverá conter: I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II – finalidade da intimação; III – data, hora e local em que deve comparecer; IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V – informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. § 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. § 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. § 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

No que se refere aos processos administrativos relativos à imposição de sanções, há que se ressaltar que a eles se aplica o artigo 65 da Lei nº 9.784/99 que estabelece que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, não se aplicando a *reformatio in pejus*.

4.3.8 Destinação dos bens e animais apreendidos

No âmbito federal, a matéria foi regulamentada pela IN Ibama nº 19/2014 (art. 1º). A IN Ibama 19/2014, em seu artigo 2º, estabeleceu o seguinte glossário:

(i) destinação imediata: destinação de animais ou bens apreendidos no momento da ação fiscalizatória, sem que haja manifestação prévia da autoridade julgadora competente, e que deverá ser confirmada por esta no âmbito dos autos do processo administrativo correspondente; (ii) destinação mediata: destinação de animais ou bens apreendidos em momento posterior à ação fiscalizatória; (iii) destinação sumária: destinação de animais ou bens apreendidos em momento anterior ao da confirmação da apreensão por meio do julgamento, por parte da autoridade julgadora competente, no âmbito do processo administrativo correlato; pode se dar imediatamente (destinação sumária imediata), ou de modo mediato (destinação sumária mediata), ambas em circunstâncias específicas que justifiquem a medida excepcional, respectivamente, com ratificação posterior ou mediante manifestação prévia da autoridade julgadora competente; (iv) embarcação: instrumento utilizado na prática de infração ambiental, que tenha ou não sido fabricado ou alterado em suas características para essa finalidade, que possibilite o transporte humano, animal ou de carga, por via aquática; (v) equipamento: instrumento utilizado na prática de infração ambiental, em geral de fabricação mais complexa, e de uso não relacionado diretamente com o transporte humano, animal ou de carga, tais como dragas, máquinas de escavações e de terraplanagem, tratores; (vi) instrumento utilizado na prática de infração ambiental: bem, objeto, maquinário, aparelho, petrecho, equipamento, veículo, embarcação, aeronave etc., que propicie, possibilite, facilite, leve a efeito ou dê causa à prática da infração ambiental, tenha ou não sido alterado em suas características para essa finalidade, seja de fabricação ou uso lícito ou ilícito; (vii) madeiras sob risco iminente de perecimento: as que estejam acondicionadas a céu aberto ou as que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, quando inviável o transporte e a guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão; (viii) petrecho: instrumento utilizado na prática de infração ambiental, em geral de fabricação simples e uso conjunto com outros petrechos de mesma finalidade, a exemplo dos petrechos de pesca (anzóis, arpões, redes, molinetes, físgas, aparelhos de respiração artificial etc.), petrechos para derrubada de vegetação (correntes, machados, facões, serras, motosserras etc.), petrechos para a captura e manutenção de animais da fauna silvestre (alcapões, gaiolas, apitos, armadilhas, estilingues, armas, transportadores etc.); (ix) produto ou subproduto perecível: aquele que, por sua natureza ou composição, necessita de condições especiais para sua conservação, sob pena de perecimento; (x) produto ou subproduto não perecível: aquele que, por sua natureza ou composição, não necessita de condições especiais para sua conservação; (xi) veículo de qualquer natureza: instrumento utilizado na prática de infração ambiental, que tenha ou não sido fabricado ou alterado em suas características para essa finalidade, que possibilite o transporte humano, animal ou de carga, por via terrestre ou aérea.

Determina o artigo 3º da IN que constatada a prática de infração administrativa ambiental, o agente atuante apreenderá os animais, os produtos e os instrumentos utilizados na prática da infração, lavrando-se, no ato de fiscalização, o respectivo Termo de Apreensão, conforme determina a Lei nº 9.605/1998, e o seu regulamento (Decreto nº 6.514/2008). O § 4º do artigo 4º da IN Ibama 19/2014 estabelece que, “*se for o caso, o agente deverá isolar e individualizar, no Termo de Apreensão, o registro dos animais ou dos bens apreendidos por meio da identificação do tipo de marcação (lacres, anilhas, tatuagem, placas, gravação etc.) e da transcrição dos dados do sistema de marcação ou outra referência única no Termo*”. O comando é fundamental, pois é mediante a sua adequada aplicação que a autoridade assegura que está atuando nos exatos limites da lei e que, simultaneamente, assegura ao suposto infrator o direito de reaver os seus bens caso o auto de infração não seja confirmado pela autoridade superior ao agente atuante. A crítica que se faz é à expressão “se for o caso”, pois entendemos que, todos os bens apreendidos deverão ser isolados e individualizados, com a referência a lacres ou marcação adotada no Termo de Apreensão, bem como devem ser indicados características, detalhes, estado de conservação, dentre outros elementos que distingam o bem apreendido.

A avaliação dos bens apreendidos deverá, sempre que possível, ser feita em conformidade com o valor de mercado, o qual poderá ser “*afetado em pesquisa*” por qualquer meio de divulgação de comercialização de bens de mesma natureza, tais como, classificados de jornais, sítios de comercialização na rede mundial de computadores, informações obtidas junto a estabelecimentos comerciais, dentre outros. Não há obrigação no sentido de que a identificação do valor dos bens seja feita no próprio auto, contudo, “*deverá ocorrer na primeira oportunidade e ser certificada nos autos do processo*”.

O artigo 21 da IN traz norma inteiramente transbordante da legalidade, como se demonstrar: “*quando identificado que o bem apreendido estiver gravado com ônus de alienação fiduciária, a sanção de perdimento aplicada deve ser comunicada ao credor fiduciário para, se quiser, promover a execução necessária para reaver as parcelas ainda não quitadas pelo devedor.*” Como se vê, o Ibama foi além de suas tamancas. Com efeito, a alienação fiduciária é um instituto legal regulado por lei própria, sendo certo que o proprietário do bem não é o seu detentor. A alienação fiduciária de bens móveis é regida pela Lei nº 4.728/1965.

Logo, a IN jamais poderia determinar o perdimento de bem que não pertence ao suposto praticante da infração, haja vista que o bem alienado fiduciariamente não é de propriedade do “infrator”, que apenas possui a posse direta do bem. É, evidentemente, o titular do domínio e da posse indireta, terceiro estranho à relação jurídico-administrativa entre o Ibama e o suposto infrator, não podendo sofrer-lhe as consequências. Ademais, carece de qualquer sentido ou juridicidade a parte final do artigo 21 que, em “liberalidade” admite que o proprietário possa executar o devedor quanto às parcelas não quitadas do financiamento. Lembre-se que, na forma do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei Federal nº 13.043/2014:

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Vê-se, e (TRF da 2ª Região, AG 200802010207412, AG – Agravo de Instrumento – 172488, 6ª T. Especializada, DJU 19/3/2009, p. 169) “*Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação cautelar de busca e apreensão. Apelação. Efeito suspensivo. Nos estritos termos do art. 3º, § 5º, do Decreto-lei nº 911/69, não é possível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a busca e apreensão, e consolidou a propriedade e a posse dos bens alienados nas mãos do credor fiduciário. A hipótese excepcional de risco de lesão grave e de difícil reparação, (art. 558, caput e pará. único, do*

CPC) não restou suficientemente comprovada. Não bastam alegações genéricas de fim das atividades empresariais, risco para a segurança dos trabalhadores e ao meio ambiente, sem qualquer respaldo probatório nem tampouco previsão legal [...]”.

Nos casos em que a autoridade julgadora decidir por não confirmar a apreensão ou não aplicar a penalidade de perdimento, deverá determinar que o bem seja restituído ao proprietário. Na impossibilidade de restituição, o Ibama deverá indenizar o proprietário, conforme o disposto no parágrafo único do art. 105 do Decreto nº 6.514, de 2008. A norma é inspirada nas determinações do artigo 25 da Lei nº 9.605/1998. O artigo e seus incisos estabelecem os mecanismos pelos quais os bens e animais (CC, artigo 82) apreendidos que, após a aplicação da pena de perdimento, passam ao domínio do órgão de controle ambiental, deverão ser utilizados para dar-lhes destinação adequada, haja vista que, em regra, não interessa ao Estado amealhar bens, muitas vezes, de complexa manutenção.

A administração ambiental, ao confirmar as decisões administrativas de perdimento de bens apreendido, deve dar-lhes destino adequado, de forma a desincentivar as ações ilícitas e praticadas em desfavor do meio ambiente. Em princípio a decisão administrativa é autoexecutória e não há necessidade de que o Estado se socorra do Poder Judiciário para implementá-la. Obviamente, na hipótese de que o Judiciário, de alguma maneira, reverta o administrativamente determinado, o suposto infrator deverá ser indenizado dos danos nos quais venha a incorrer em razão efetivação da decisão administrativa.

Os bens acima aludidos poderão ser vendidos ou doados, conforme determinação legal. Doação é contrato pelo qual uma pessoa, no caso o Estado, por liberalidade transfere, no todo ou em parte, seu patrimônio, bens e vantagens para o de outra. É necessário para que a doação se efetive que haja a aceitação por parte do donatário e que haja a tradição dos bens e direitos. No caso tratado pelo artigo a doação é formal, devendo ser escrita em “termo” (artigo 137, Decreto nº 6.514/2008).

Os bens perecíveis serão doados, conforme norma contida no inciso I do artigo 134 do Decreto nº 6.514/2008. O CC brasileiro (art. 86) não contempla a categoria de bens perecíveis, devendo ser entendido que, na realidade, bens perecíveis são bens consumíveis, os quais deverão ser doados para que se evite a sua deterioração ou gastos com a conservação. Muito embora a norma não determine para quem deva ser efetivada a doação, parece-me evidente que a medida só se justifica quando o beneficiário é uma instituição beneficente reconhecida, ou quando se tratar de escola ou hospital público, estabelecimentos penitenciários e outros similares.

No que tange ao inciso II do artigo 134 do Decreto nº 6.514/2008, doação de madeiras, por exemplo, há decisão do STJ (REsp 200500351030, REsp – Recurso Especial – 730034, 2ª Turma, DJe 21/5/2010) no sentido de que:

“[...] 13. Por isso, é imperioso achar uma solução harmoniosa entre o direito de propriedade dos recorridos e o art. 25, § 2º, da Lei nº 9.605/98. 14. Esta conciliação é simples e far-se-á da seguinte forma: (i) a regra é a aplicação do art. 25, § 2º, da Lei nº 9.605/98, independentemente de autorização judicial; (ii) havendo fundada dúvida sobre a dominialidade dos bens apreendidos e não sendo caso de os proprietários ou terceiros de boa-fé estarem diretamente relacionados com a prática da infração (penal ou administrativa), a alienação deverá ser onerosa, com o depósito dos valores líquidos auferidos (descontadas as despesas de apreensão, transporte, armazenagem e processamento da venda) em conta bancária à disposição do juízo, cuja destinação final (se à União ou a quem ela determinar, se aos proprietários da terra) será aferida após incidente processual cabível; e (iii) na hipótese de inviabilidade (técnica, de fato ou por ausência de compradores) da alienação onerosa, o órgão ambiental poderá doar, de imediato, os bens apreendidos, conforme disposto no art. 25, § 2º, da Lei nº 9.605/98, garantindo-se aos prejudicados o direito de indenização em face dos criminosos. 15. Recurso especial parcialmente provido para que, na espécie, diante de suas peculiaridades, a origem determine a aplicação das fórmulas (ii) e (iii) logo acima expostas, conforme a hipótese em concreto”.

O inciso III do artigo 134 do Decreto Federal nº 6.514/2008 determina que os produtos ou subprodutos da fauna, quando não perecíveis, serão destruídos ou doados. O inciso cogita de bens manufaturados, os quais em geral possuem valor econômico. A destruição é uma medida eficiente, pois retira o produto do mercado e os riscos de sua reintrodução, ainda que por via de desvios de instituições que receberam as doações. No que se refere às doações, estas devem ser realizadas mediante a adoção de cláusulas bastante específicas que impeçam a venda, revenda, doação, cessão ou qualquer movimentação que possa vir a ser praticada pelo donatário.

Conforme o disposto no inciso IV do artigo 134 do Decreto nº 6.514/2008, “os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações”. Isto significa que a Administração, goza de um juízo discricionário no que diz respeito ao destino a ser dado aos “petrechos” que tenham sido utilizados para a prática do ilícito ambiental. É importante observar que, se no caso concreto, os “petrechos” utilizados para a prática do ilícito administrativo sejam os mesmos dos quais se valeu o infrator para a prática de crime ambiental, prevalecerá a decisão judicial quanto ao destino que lhes deverá ser dado.

A Administração dispõe das seguintes alternativas para o caso de produtos: (i) destruição; (ii) inutilização; (iii) doação; e (iv) venda ou leilão.

A destruição pode ser efetivada por qualquer meio de retire o bem do mundo físico, devendo ser registrada e testemunhada, de forma que não resem dúvida quanto ao fato de que ela foi efetivamente concretizada. O auto de destruição deverá ser anexado ao processo administrativo. Há regulamentação administrativa estabelecida pela IN IBAMA nº 19/2014, sobre a matéria. De acordo com as disposições contidas no artigo 62, os bens apreendidos poderão ser destruídos ou inutilizados quando a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias ou possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Para que se proceda à destruição ou inutilização devem ser observados os seguintes requisitos (art. 62 da IN nº 19/2014 do IBAMA): (i) não houver uso lícito ou outra forma de destinação para o bem apreendido; (ii) manifestação da área técnica competente que ateste as situações previstas no *caput* do artigo 62 da IN; (iii) avaliação pecuniária dos bens; e (iv) decisão da autoridade competente. A destruição ou inutilização de bem deve ser precedida da lavratura de Termo de Destruição ou Inutilização, o qual conterá: (i) contendo a descrição detalhada dos bens, (ii) seu valor, (iii) suas características e condições anterior e posteriormente à e (iv) justificativa para a adoção da medida. Excepcionalmente, admite-se a destruição ou inutilização de bem apreendido antes da decisão confirmatória do auto de infração, em tais hipóteses, Termo de Destruição ou Inutilização deverá ser lavrado por dois servidores do IBAMA, sendo pelo menos um Agente Ambiental Federal. Em tais casos, o Termo deverá justificar a adoção da medida extrema. A medida deverá ser convalidada pela autoridade hierarquicamente superior.

A utilização pode ocorrer quando o utensílio utilizado para a prática do ilícito puder ser útil para as atividades rotineiras da Administração. É o caso do veículo 4 × 4 utilizado para transportar ilegalmente espécimes da fauna silvestre que, ante a evidente utilidade para a Administração, poderá ser utilizado. *A utilização não transfere a propriedade do bem, o qual somente passará a integrar o patrimônio público após a aplicação da pena de perdimento.* É altamente desaconselhável que a utilização de “petrechos” se faça sob a modalidade de designação de servidor como fiel depositário, notadamente quando os equipamentos em questão forem barcos, veículos, aviões e outros.

A doação é liberalidade praticada pela Administração Pública que, no entanto, não pode ser efetivada com base em mera discricionariedade administrativa. De fato, mesmo para doar, a Administração deve observar regras e procedimentos estabelecidos no artigo 25 da Lei nº 9.605/1998.

A Lei nº 8.666/1993 (artigo 17) que rege as licitações públicas, determina que a doação é uma forma de alienação de patrimônio público e, como tal, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Nas hipóteses de doação que serão examinadas, inclui-se a de doação, bem como a alienação onerosa ou mesmo destruição, de bens que não pertencem à União, pois ainda não incorporados ao patrimônio nacional. É evidente que, sem entrar no mérito da discussão relativa à constitucionalidade dos casos, parece isento de dúvidas que o Estado deve ressarcir ao particular quando não provada a prática de infração administrativa, bem como responsabilizar pessoalmente ao agente público que tenha dado azo à alienação do patrimônio particular, sem que tenha sido comprovada a responsabilidade administrativa do cidadão, na hipótese de que o procedimento administrativo tenha concluído pela inexistência da infração administrativa (CF art.

37). Superadas as alegações preliminares, passa-se ao exame da norma administrativa que rege os procedimentos de doação de bens apreendidos para entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente. Os artigos 40 e seguintes da IN nº 19/2014, do Ibama estabelecem os procedimentos aplicáveis.

De acordo com a regra (art. 40 da IN nº 19/2014 do Ibama), os órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais, de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar, social e ambiental, bem como as entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente, deverão ser cadastradas no Ibama para fins de recebimento de bens apreendidos em doação. Tal cadastro deve conter pelo menos as seguintes informações (art. 41 da IN nº 19/2014 do Ibama): (i) nome do órgão ou entidade, com respectivo CNPJ, telefone, endereço, endereço de correio eletrônico para comunicações oficiais; (ii) objetivos, competência, finalidade institucionais ou objetivos sociais e estatutários; (iii) abrangência geográfica de atuação do órgão ou entidade e existência, se for o caso de atuação nacional ou regional, de mais de uma unidade gestora; (iv) quais as espécies ou os tipos de bens de seu interesse, indicando a quantidade compatível com a sua necessidade, demanda e capacidade de utilização ou consumo; (v) a necessidade dos bens indicados para a consecução dos objetivos do órgão ou entidade; (vi) nome e número perante o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do representante legal com competência para a assinatura do Termo de Doação.

Em relação à *doação sumária de produtos perecíveis*, o artigo 51, § 3º, da IN: “No caso de produtos perecíveis considerados próprios para o consumo humano, de acordo com as normas sanitárias específicas, o agente autuante deverá proceder à doação sumária, preferencialmente, a órgãos ou entidades que visem propiciar a segurança alimentar das comunidades envolvidas, mesmo que essas não estejam cadastradas perante o IBAMA”.

O artigo 67 determina que os bens apreendidos não integram o patrimônio do Ibama, o que é óbvio, pois se integrassem estaríamos diante de confisco. Caso seja decretado o perdimento do bem, aí sim eles poderão ser incorporados ao patrimônio da autarquia.

Em se tratando do Ibama, a utilização se fará na forma da IN nº 19, de 19 de dezembro de 2014, que em seu artigo 65 admite a utilização do bem, antes da decisão definitiva quanto ao Auto de Infração desde que a autoridade administrativa (i) demonstre a relevância do interesse público; e (ii) declare não haver outro meio disponível para a consecução da respectiva ação. Em sendo o bem apreendido veículo de qualquer natureza ou embarcação, é admitida a sua utilização para o deslocamento do material apreendido até local adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental.

A venda de bens e animais apreendidos observará o procedimento do leilão disposto na Lei nº 8.666/1993. A venda de instrumentos utilizados na prática da infração que tenham sido alterados em suas características para essa finalidade, ou cujo fabrico vise à prática de infrações ambientais, somente poderá ser procedida após a sua descaracterização ou reciclagem, de modo que não mais possam ser utilizados para esse fim.

Assim, nos termos do artigo 17 da Lei de Licitações Públicas, deverá ser feita a avaliação dos bens previamente à venda, sendo os bens vendidos em leilão. Quando se tratar do IBAMA, aplicável a IN nº 19/2014, que determina em seu artigo 52 que a venda far-se-á por leilão, na forma da Lei de Licitações.

O artigo 53 da IN admite a possibilidade de realização do leilão “antes da decisão que confirme o auto de infração e a medida de apreensão, quando se tratar de venda de animais domésticos e exóticos apreendidos conforme previsto no art. 103 do Decreto nº 6.514/2008, bem como de produtos ou subprodutos perecíveis ou madeiras sob risco iminente de perecimento quando não forem doados por qualquer impedimento.” De qualquer forma, a venda dos será precedida de avaliação e decisão motivada da autoridade competente que conclua que a venda é viável econômica e operacionalmente, levando-se em conta a natureza dos animais apreendidos e o risco de perecimento. A hipótese ora tratada não é a regra e deve ser utilizada homeopaticamente pela Administração. Se, no entanto, no julgamento administrativo de impugnação ao Auto de Infração, for dado provimento ao inconformismo, o proprietário dos animais deverá ser indenizado pelo valor constante da avaliação contida no Termo de Apreensão. Não há dúvida, contudo, de que poderá haver contestação ao valor da avaliação, seja administrativa, seja judicialmente.

Todos os custos operacionais incorridos pela Administração para depósito, remoção, transporte, beneficiamento, bem como os encargos legais correrão à conta do adquirente.

A realização da praça será precedida de: (i) avaliação econômica do bem; (ii) discriminação da quantidade e da qualidade dos bens, bem como a menção do local em que se encontram depositados e o seu estado de conservação; (iii) publicidade, por meio de: (a) jornal de grande circulação na cidade onde ocorrerá o leilão, uma vez; (b) Diário Oficial da União – DOU, uma vez; e (c) na página oficial do Ibama na rede mundial de computadores – Internet.

A avaliação do valor econômico do bem apreendido se faz segundo critérios estabelecidos, a saber: a avaliação econômica do bem observará o preço médio constante da tabela do sistema Documento de Origem Florestal – DOF no caso de madeira, e, nos demais casos, o preço previsto nas pautas de valores utilizados pela Administração Pública federal, estadual e municipal, ou o preço praticado no mercado ou valor obtido a partir de parecer técnico do Ibama (art. 57, parágrafo único da IN nº 19/2014 do Ibama).

É vedado a infrator punido com sanção restritiva de direitos prevista no art. 72, inciso XI, da Lei nº 9.605/1998, participar do processo licitatório, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da ocorrência da infração ambiental, desde que a decisão homologatória da sanção seja irreversível no âmbito administrativo. É vedado ao infrator que teve os bens apreendidos, coautores e partícipes, participar do processo licitatório.

Determina o § 3º do artigo 30 da IN IBAMA nº 19/2014 que: sendo a soltura inviável ou não recomendável, os animais silvestres da fauna nativa brasileira apreendidos serão entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados, conforme determina o § 1º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998.

De acordo com o artigo 23 da IN IBAMA nº 19/2014, os animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, madeiras, petrechos, equipamentos, embarcações ou veículos de qualquer natureza apreendidos pelo Ibama em razão da prática de infrações ambientais deverão ser destinados nos termos da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/ 2008.

Acompanhando os termos da Lei e do Decreto, estabelece a IN as seguintes modalidades de destinação: (i) no caso de animais silvestres: a) soltura em seu *habitat* natural; b) cativeiro (jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas), desde que confiados a técnicos habilitados; (ii) no caso de animais domésticos e exóticos: a) venda ou leilão; b) doação; (iii) no caso de produtos, inclusive madeiras, subprodutos, instrumentos e demais bens apreendidos: a) venda ou leilão; b) doação; c) inutilização ou destruição.

Sendo a soltura inviável ou não recomendável, os animais silvestres da fauna nativa brasileira apreendidos serão entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados, conforme determina o § 1º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998.

A IN Ibama nº 23/2014, estabelece as diretrizes e os procedimentos para a destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados por autoridade competente ou entregues voluntariamente pela população, bem como para o funcionamento dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do Ibama – Cetas.

A Resolução Conama nº 457/2013, dispõe sobre o depósito e a guarda provisórios de animais silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, como também oriundos de entrega espontânea, quando houver justificada impossibilidade das destinações previstas no §1º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998. Tal Resolução revogou expressamente a Resolução Conama nº 384/2006, que tratava da questão.

Conforme dispõe o artigo 24 da IN nº 19/2014, a destinação poderá ser procedida sumariamente, após a apreensão e antes da decisão que confirme o auto de infração e a respectiva apreensão, levando-se em conta a natureza dos animais e dos bens apreendidos, o risco de perecimento e as circunstâncias em que se deu a apreensão. Após a decisão que confirme o auto de infração, de caráter irreversível no âmbito administrativo, os bens e os animais que não tenham sido objeto de destinação sumária não mais retornarão ao infrator, podendo ser doados ou leiloados, ou, excepcionalmente e nos casos de bens, inutilizados ou destruídos.

A apreensão de bens e animais pelo Ibama somente se aperfeiçoa por meio do trânsito em julgado no âmbito do processo administrativo de apuração da infração administrativa ambiental correspondente, assegurado ao interessado o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Se constatado durante a instrução processual que o petrecho, o equipamento, o veículo ou a embarcação, de posse ou utilização lícita, identificado no Termo de Apreensão, não foi utilizado como instrumento na prática da infração ambiental, será revogado o respectivo termo, restituindo-se o bem ao proprietário mediante decisão da autoridade julgadora competente, independentemente da confirmação do respectivo auto de infração.

O Termo de Doação de bens apreendidos vedará a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos da flora e da fauna,

instrumentos, petrechos, veículos e embarcações. A autoridade responsável pela destinação poderá, excepcionalmente, autorizar a transferência dos bens doados quando tal medida for considerada mais adequada à execução dos fins institucionais dos beneficiários.

A propósito deve ser observada a seguinte tendência judicial (TRF da 1ª Região, REO 9001089240, REO – Remessa *Ex Officio* – 9001089240, 4ª Turma, DJU 18/2/1991, p. 2164) “...1. Sendo desproporcional a infração fiscal (dano ao erário) e a sanção econômica imposta ao infrator, apresenta-se injustificável a perda do veículo. 2. Pacífica a Jurisprudência Do extinto TFR, no sentido de ser impertinente a imposição da pena de perdimento...”

E mais (TRF da 1ª Região, AMS 200540000068204, AMS – Apelação em Mandado de Segurança – 200540000068204, 5ª Turma, e-DJF1 9/3/2012, p. 118). “...1. Na sentença, foi indeferido o pedido de ordem para liberação de toda a madeira transportada e mesmo da parte excedente da quantidade constante das guias florestais. Deferiu-se, entretanto, ordem de liberação dos caminhões transportadores, ao fundamento de que não pode haver apreensão de veículo como medida coercitiva do pagamento de multa, nem a interdição de estabelecimento com a mesma finalidade... 3. É indevida a apreensão de toda carga, quando divisível, se parte dela estava coberta por guia florestal. Mas, não houve recurso da impetrante e a remessa oficial, mesmo no mandado de segurança, segundo a jurisprudência, só favorece a entidade pública. 4. Quanto à apreensão dos caminhões, a lei ambiental não prevê como simples medida cautelar ou probatória, mas como pena. Estão sujeitos, os veículos transportadores de madeira desacompanhada de guia florestal, em tese, à pena de perdimento. 5. No caso sob exame, há a peculiaridade de que a madeira transportada sem guia florestal é menos de 30% (trinta por cento) da carga total. 6. Há antiga e reiterada jurisprudência relacionada com o crime de contrabando ou descaminho – em que há semelhante pena de perdimento do veículo transportador – no sentido de que se afasta essa pena quando a quantidade e valor da mercadoria transportada é desproporcional ao valor do veículo. 7. Aqui, quase trinta por cento da carga completa de cada caminhão, talvez não seja, exatamente, caso de aplicar essa orientação jurisprudencial. Todavia, deve-se considerar, conforme já foi dito, que houve excesso na apreensão de toda a madeira, questão que não é mais suscetível de discussão. 8. Mantida a liberação dos veículos, já consumada, restará compensada, de certa forma, a injustiça que consistiu na apreensão da parte de madeira coberta por guia florestal...”

Os órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais, de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar, social e ambiental, bem como as entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente, conforme previsto no art. 135 do Decreto nº 6.514/2008, deverão ser cadastradas no Ibama para fins de recebimento de bens apreendidos em doação. Assim, o donatário deverá demonstrar ao doador, mediante a exibição de seus estatutos, que a entidade (*rectius*: pessoa jurídica) não distribui lucro entre os seus dirigentes, bem como não remunera seus administradores (TRF da 1ª Região, AMS 199701000406927, AMS – Apelação em Mandado de Segurança – 199701000406927. Relator: Juiz Lourival Gonçalves de Oliveira. 4ª turma, DJU 20/6/2001, p. 57). A utilidade pública não se presume e deve ser comprovada por uma declaração formal mediante documento expedido por autoridade pública federal, estadual ou municipal, a qual juntamente com os demais documentos deverá ficar anexada ao processo de doação.

A autoridade competente para a doação é aquela que apreendeu os bens, devendo haver autorização expressa para a doação. Evidentemente que, se por hipótese a apreensão for anulada, deverá haver a restituição dos bens ou indenização equivalente para o proprietário.

O parágrafo único do artigo 135 do Decreto nº 6.514/2008 estabelece uma restrição para a doação de “*produtos da fauna não perecíveis*”, os quais deverão ser doados para instituições científicas, culturais ou educacionais. Observe-se que, aqui, não se estabeleceu a limitação de doação para órgãos e entidades públicas ou beneficentes, contudo, os beneficiários só poderão ser instituições científicas, culturais ou educacionais. Os mesmos cuidados acima descritos devem ser tomados pelo Administrador.

Como se sabe, o ilícito ambiental deve ser combatido em função do mal que gera para a coletividade, contudo, não se deve onerá-la com os custos de combater a ilegalidade. Assim, determina o Decreto que o próprio infrator arque com os custos referentes às atividades relativas à apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente. A norma é específica e, portanto, somente deve ser aplicada quando os produtos ou substâncias constarem de relação própria, ou, na inexistência dela, quando o órgão ambiental, mediante a expedição de laudo técnico firmado por profissional habilitado demonstrar o perigo ou a nocividade do produto ou substância. Uma vez demonstrada a nocividade de certo produto ou substância, todas as medidas destinadas a neutralizá-los ou destruí-los serão cobradas daquele que delas tenha a posse ou a propriedade – não se aplicando a norma no caso e mera detenção por empregados, por exemplo.

As medidas adotadas pela Administração deverão ser indenizadas pelo infrator, sendo os valores inscritos na dívida ativa, caso o ressarcimento não se faça voluntariamente. Não se esqueça, ademais, que as diferentes autoridades sanitárias, também são dotadas de atribuição para determinar a destruição de produtos tóxicos ou perigosos.

4.3.9 A conversão da multa em serviços ambientais

O Programa de Conversão de Multas Ambientais¹¹ é um programa federal, instituído pelo MMA, cujo objetivo é facilitar que o valor das multas ambientais seja aplicado diretamente em atividades de melhoria das condições de salubridade do ambiente brasileiro. Tal programa tem origem na Lei nº 9.605, de 1998 que, no parágrafo 4º do artigo 72 admite a possibilidade. A conversão da multa será aplicada pela autoridade responsável pela sua aplicação e poderá ser feita em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

O Decreto nº 9.179, de 23 de outubro de 2017 deu amplo tratamento matéria ao determinar nova redação para os artigos 139 e seguintes do Decreto 6.514/2008. Assim, foi instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais emitidas por órgãos e entidades da União integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. Por meio de tal programa a autoridade ambiental federal competente para a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, observado o disposto no § 4º do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998. Os Estados e Municípios poderão, por meio de normas próprias podem replicar o programa em seus âmbitos de atuação.

Os serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, são as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos que contemplem, no mínimo, uma das seguintes atividades: (i) recuperação: a) de áreas degradadas para conservação da biodiversidade e conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente; b) de processos ecológicos essenciais; c) de vegetação nativa para proteção; e d) de áreas de recarga de aquíferos; (ii) proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre; (iii) – monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais; (iv) – mitigação ou adaptação às mudanças do clima; (v) manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos; (vi) – educação ambiental; ou (vii) – promoção da regularização fundiária de unidades de conservação.

Com exceção dos assentamentos de reforma agrária, territórios indígenas, quilombolas e unidades de conservação – menos áreas de proteção ambiental –, os serviços a serem executados que demandem recuperação da vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Os projetos a serem realizados poderão ser selecionados por meio de chamada pública à qual poderão manifestar interesse órgãos e entidades, públicas ou privadas, sem fins lucrativos.

A conversão da multa poderá ser requerida pelo autuado até o momento de apresentação de suas alegações finais no processo administrativo. Todavia, em meu entendimento, o prazo pode ser estendido, pois a própria lei de execução fiscal¹² – dívida já inscrita – admite o cancelamento da inscrição da dívida antes da decisão judicial de primeira instância, logo em sede administrativa não há qualquer impedimento para o seu cancelamento e, muito menos, para a conversão. A conversão, entretanto, não pode ser aplicada para a recuperação do dano que tenha dado origem ao auto de infração.

O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no inciso I do *caput* do art. 142-A do Decreto nº 6514/2008 deverá ser instruído com projeto, elaborado em conformidade com as diretrizes emanadas do órgão emissor da multa.

A conversão, conforme escolha do autuado poderá ser feita (i) pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e recuperação da

qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a VII do *caput* do art. 140 do Decreto 6.514/2008 ; ou (ii) – pela adesão a projeto previamente selecionado pelo órgão federal emissor da multa, na forma estabelecida no art. 140-A, observados os objetivos previstos nos incisos I a VII do *caput* do art. 140 do Decreto nº 6.514/2008. Ressalte-se que a conversão não isenta o autuado de reparar o dano que tenha originado a autuação.

Uma vez admitida a conversão, a autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o valor da multa consolidada o desconto de: (i) – trinta e cinco por cento, na hipótese prevista no inciso I do *caput* do art. 142-A do Decreto nº 6.514/2008; ou (ii) sessenta por cento, na hipótese prevista no inciso II do *caput* do art. 142-A do mesmo decreto.

A concessão da conversão será decidida juntamente com o julgamento do órgão de infração. Uma vez deferido o requerimento de conversão, as partes celebrarão termo de compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado ou de sua cota-parte no projeto escolhido pelo emissor da multa. O Termo de Compromisso terá como cláusulas obrigatórias: (i) as seguintes – nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e de seus representantes legais; (ii) o serviço ambiental objeto da conversão; (iii) o prazo de vigência do compromisso, que será vinculado ao tempo necessário à conclusão do objeto da conversão que, em função de sua complexidade e das obrigações pactuadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de dez anos, admitida a prorrogação, desde que justificada; (iv) a – multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações pactuadas; (v) os efeitos do descumprimento parcial ou total do objeto pactuado; (vi) – reparação dos danos decorrentes da infração ambiental, caso existentes; e (vii) – foro competente para dirimir litígios entre as partes. Neste ultimo caso, não vejo impedimento para que as partes estipulem a previsão de mecanismos de auto composição do litígio,

No que se refere à conversão prevista no inciso I do *caput* do art. 142-A do Decreto 6.514/2008, o termo de compromisso conterá: (i) a descrição detalhada do objeto; (ii) – o valor do investimento previsto para sua execução; (iii) – as metas a serem atingidas; e (iii) – o anexo com plano de trabalho, do qual constarão os cronogramas físico e financeiro de implementação do projeto aprovado. Quando se tratar da conversão prevista no inciso II do *caput* do art. 142-A do Decreto 6.514/2008, o termo de compromisso: (i) será instruído com comprovante de depósito integral ou de parcela em conta garantia em banco público, observado o previsto no § 3º do art. 143, referente ao valor do projeto selecionado ou à respectiva cota-parte de projeto, nos termos definidos pelo órgão federal emissor da multa; (ii) conterá a outorga de poderes do autuado ao órgão federal emissor da multa para a escolha do projeto a ser apoiado; (iii) contemplará a autorização do infrator ao banco público, detentor do depósito do valor da multa a ser convertida, para custear as despesas do projeto selecionado; (iv) preverá a inclusão da entidade selecionada como signatária e suas obrigações para a execução do projeto contemplado; e (v) estabelecerá a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado ou pelo órgão federal emissor da multa, do valor depositado na conta garantia.

É relevante anotar que a assinatura do termo de compromisso suspende a exigibilidade da multa, em contrapartida, o multado abdica do direito de recorrer da penalidade. O processo administrativo, todavia, não se encerra enquanto às medidas contidas no termo de compromisso estiverem em cumprimento. Somente após a aprovação pelo órgão ambiental das medidas implementadas é que o processo administrativo será encerrado e arquivado.

No IBAMA a matéria foi tratada pela IN 06/2018 de título executivo extrajudicial.

- ¹ Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/implicar/>>. Acesso em: 16 abr. 2012.
- ² Disponível em: <<http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=5>>. Acesso em: 30 mar. 2012.
- ³ Disponível em: <<http://www.sidneyrezende.com/noticia/12759>>. Acesso em: 25 abr. 2009.
- ⁴ A Fundação Biodiversitas que tem trabalhado, fortemente, na matéria, traz informações sobre a lista por ela produzida, e que tem sido adotada pelo MMA, no seu site: <http://www.biodiversitas.org.br/f_ameaca/>. Acesso em: 25 mar. 2009.
- ⁵ Veja-se a dramaticidade da situação decidida pelo TRF da 2ª Região (INQ – Inquérito – 367, Plenário, *DJU* 2/5/2008, p. 413-414).
- ⁶ TRF da 2ª Região, AC 200351020087195, AC – Apelação Cível – 388.572, 5ª T Especializada, e-*DJF2R* 24/3/2011, p. 145-146. Desembargador Federal Luiz Paulo S. Araújo Filho
- ⁷ Antunes, Paulo de Bessa. Disponível em: <<https://www.oeco.org.br/colunas/paulo-bessa/19798-algo-alem-dos-avioes-de-carreira/>>.
- ⁸ Disponível em: <<http://bethccruz.blogspot.com.br/2009/03/grafiteiro-artista-de-vanguarda-street.html>>. Acesso em: 28 mar. 2012.
- ⁹ Disponível em: <<http://dicionario.sensagent.com/georeferenciamento/pt-pt/>>. Acesso em: 2 abr. 2012.
- ¹⁰ Disponível em: <<http://www.epa.gov/oalj/>>. Acesso em: 13 jan. 2009.
- ¹¹ Todos os artigos mencionados, salvo expressa informação em contrário, são do decreto 6.514/2008.
- ¹² Lei nº 6.830/1988 – Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

A PROTEÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

5.1 INTRODUÇÃO

Uma das maiores dificuldades para os leigos em Direito é compreender a estrutura do Poder Judiciário brasileiro e das instituições que têm sua existência em função da prestação jurisdicional, tais como o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Militar, assim como a própria advocacia. De fato, há uma verdadeira perplexidade sobre o tema. Mesmo entre os profissionais do direito, não raras vezes, há ausência de clareza sobre a matéria. Não é difícil perceber que, sem uma prévia e correta compreensão da estrutura judiciária brasileira, é muito difícil que se possa buscar a proteção judicial do meio ambiente.

5.2 O PODER JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário é um dos Três Poderes existentes no Estado brasileiro e tem por finalidade dirimir conflitos com base no sistema legal, com vistas a evitar ameaças ou lesões de direitos (CF, art. 2º c/c o art. 5º, XXXV) e assegurar um mínimo de convivência pacífica entre os membros da sociedade. A estrutura organizacional do Poder Judiciário brasileiro está contemplada nos artigos 92 e seguintes da CF. Em obediência à estrutura federativa do Estado brasileiro, o Poder Judiciário está assim constituído:

- *Supremo Tribunal Federal;*
- *Superior Tribunal de Justiça;*
- *Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais;*
- *Tribunais e Juízes do Trabalho;*
- *Tribunais e Juízes Eleitorais;*
- *Tribunais e Juízes Militares;*
- *Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.*

O STF e o STJ têm jurisdição sobre todo o território nacional, cabendo ao STF examinar as ofensas à Constituição e ao STJ examinar as ofensas à lei federal. O Poder Judiciário Brasileiro se divide em (i) *comum* e (ii) *especializado*. A Justiça comum é constituída pela Justiça Federal e pela Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Já a Justiça especializada é composta pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Militar (Estadual ou Federal). Uma vez que o Brasil é uma Federação, o Poder Judiciário poderá ser Federal ou Estadual e o seu conjunto é conhecido como Poder Judiciário Nacional (STF. ADI 3367/DF. Relator: Ministro Cezar Peluso. Julgamento: 13/4/2005. Tribunal Pleno. DJU 17/3/2006, p. 4. "... 1 [...] 3. Poder Judiciário. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado-membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados-membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça".

O Poder Judiciário Federal é integrado pela Justiça Federal e pelas Justiças especializadas. O Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, embora seja mantido pela União Federal, é considerado como se estadual fosse, especialmente em razão de suas competências.

5.2.1 O STF e o STJ na proteção ambiental

O STF é o principal tribunal do sistema judiciário brasileiro, competindo-lhe, fundamentalmente, a guarda da CF, nos termos dos artigos 102 e seguintes da própria CF. Cabe, ainda, ao STF, processar e julgar ações entre os Estados ou entre os Estados e a União Federal. Tais causas, não é preciso dizer, poderão versar sobre matéria ambiental. Contudo, o papel ambiental mais importante desempenhado pelo STF é o julgamento das ações diretamente constitucionais, bem como a violação de preceito fundamental. Por meio do citado mecanismo, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma norma jurídica com validade *erga omnes* e "manter" ou "suspender" um texto legal.

Já o STJ tem uma atuação de natureza recursal diversa, pois ao mencionado tribunal compete a guarda da legislação federal infraconstitucional. A matéria ambiental que pode ser tratada pelo STJ, em geral, chega-lhe pela via de recursos contra as decisões dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça. O STJ tem proferido inúmeras decisões em matéria ambiental, notadamente quanto a questões envolvendo competências processuais. O tribunal tem desempenhado um papel muito relevante em matéria ambiental, muito embora com decisões controversas.

5.2.2 A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a proteção ambiental

À Justiça Federal compete processar e julgar as causas nas quais existam interesses da União, de suas autarquias, de suas fundações ou empresas públicas. Compete, ainda, à Justiça Federal processar e julgar as causas que tenham por fundamento os tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. No campo criminal, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União e das entidades que lhe sejam vinculadas. Compete, ainda, à Justiça Federal julgar as causas sobre direitos indígenas. Bem se vê, portanto, que a Justiça Federal desempenha um importante papel no interior da problemática concernente à proteção judicial do meio ambiente. A proteção da fauna silvestre, dos parques nacionais, dos rios interestaduais, do mar, das reservas indígenas etc. está constitucionalmente definida como área de competência da Justiça Federal.

A Justiça do Trabalho, em situações específicas, pode também ser um importante instrumento de proteção ambiental. Como se sabe, a Justiça do Trabalho, por força do artigo 114 da Constituição de 1988, tem por competência processar e julgar dissídios entre empregados e empregadores e, também, aqueles originários do cumprimento de suas próprias decisões. Ocorre que o artigo 200, VIII, da Constituição determina que compete ao Sistema Único de Saúde "*colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho*". O meio ambiente do trabalho pode ser urbano ou rural e, muitas vezes, cláusulas não econômicas são incluídas nos dissídios coletivos ou acordos trabalhistas com o intuito de promover melhorias em condições ambientais ou de saúde. O cumprimento de tais cláusulas

deverá ser buscado perante a Justiça do Trabalho. O STF, em acórdão de lavra do Ministro Marco Aurélio, para nossa felicidade, consagrou a tese que venho defendendo, desde há muito, de que existe competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações civis públicas, sobretudo quando envolverem questões relativas à saúde do trabalhador (RE nº 206.220-MG. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 16/3/1999. 2ª Turma. DJU 17/9/1999, p. 58. “*Competência. Ação civil pública. Condições de trabalho. Tendo a ação civil pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho*”).

5.2.3 A Justiça dos Estados e a proteção ambiental

Todas as causas que não tenham a União ou uma de suas entidades em polo passivo ou ativo, e que não sejam decorrência de relação de trabalho, deverão ser processadas e julgadas perante a Justiça dos Estados. É um universo extremamente vasto e importante.

5.3 O MINISTÉRIO PÚBLICO

A Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de atribuições bastante amplo para o Ministério Público em matéria de proteção ambiental. Em linhas gerais, tais atribuições são originárias do regime jurídico que ora se passa a examinar.

5.3.1 A base constitucional da atuação do Ministério Público

Já se tornou lugar-comum afirmar que a CF de 1988 atribuiu ao Ministério Público papel de grande relevância na proteção dos chamados interesses difusos. De fato, a vigente CF brasileira foi bastante positiva ao atribuir funções ao Ministério Público. Os artigos 127/130 da CF moldaram o perfil do *parquet* como um importante instrumento de expressão da sociedade.

A organização constitucional do Ministério Público no Brasil não encontra paralelo em nenhum outro país do mundo. O nível de independência e autonomia que foi deferido ao MP pelo constituinte é absoluto. O Ministério Público e seus integrantes somente se encontram submetidos à lei e à própria consciência.

Sem dúvida alguma, é no artigo 127 da CF que se encontra o cerne das atribuições ministeriais. Em razão de suas atribuições básicas, conforme estatuídas no *caput* do artigo 127, decorrem as funções institucionais estabelecidas ao longo do artigo 129. Estas, em realidade, se constituem em um conjunto de atribuições pelas quais são criados instrumentos para que o Ministério Público possa exercer os misteres ao seu encargo.

Dentre as diversas *funções institucionais* mencionadas no artigo 129, encontram-se o exercício da ação civil pública e do inquérito civil. As funções institucionais estabelecidas na CF são exercidas na forma da legislação de menor hierarquia, notadamente pelas Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Atualmente existe grande número de leis que tratam da ação civil pública e do inquérito civil.

Hoje, o Direito brasileiro consagra, no mínimo, cinco ações civis públicas *típicas*, que são aquelas previstas nas leis:

- a) Lei nº 7.347/85;
- b) Lei nº 7.853/89 (*integração social do deficiente físico*);
- c) Lei nº 7.913/89 (*responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários*);
- d) Lei nº 8.069/90 (*Estatuto da Criança e do Adolescente*);
- e) Lei nº 8.078/90 (*Código de Defesa do Consumidor*);
- f) Lei nº 12.852/2013 (*Estatuto da Juventude*);
- g) Lei nº 13.146/2015 (*Estatuto da Pessoa com deficiência*).

Penso que os dispositivos constantes de todas as leis mencionadas são complementares e podem ser aplicados em processos judiciais versando matéria ambiental.

O Ministério Público é, no Brasil, o principal autor de ações civis públicas e desempenha um papel de extraordinária relevância quanto ao particular. O Ministério Público, em razão disso, passou a desempenhar um tipo de advocacia *pro bono* quando acionado por pessoas e associações preocupadas com os problemas ambientais.

5.4 DEFENSORIA PÚBLICA

A Lei nº 7.347/85 sofreu alteração para que se incluísse entre os legitimados à propositura da Ação Civil Pública a defensoria pública que, desde então, consta no inciso II do artigo 5º como um dos titulares da Ação, inclusive com a possibilidade de celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Penso, no entanto, que o novel legitimado não pode extrapolar os limites do mandato que lhe foi outorgado pela CF (art. 134). Assim, parece claro que a legitimidade da Defensoria Pública, em matéria de ação civil pública, somente se faz presente quando a medida judicial tiver por base a defesa de interesses de *necessitados*. Não há uma legitimidade ampla como aquela do Ministério Público. Sobre o tema o STJ tem entendido que: “A Defensoria Pública tem legitimidade ativa *ad causam* para propor ação civil pública com o objetivo de defender interesses individuais homogêneos de consumidores lesados em virtude de relações firmadas com as instituições financeiras (STJ. AgRg no REsp 1000421/SC. Ministro João Otávio Noronha. 4ª Turma. DJe 1/6/2011)”.

Ainda sobre o tema, a matéria foi decidida em Repercussão Geral que entendeu legítima a propositura de ação civil pública por parte da Defensoria Pública, conforme estabelecido pelo Recurso Extraordinário (RE) 733433, com repercussão geral reconhecida que atingiu 23 casos que estavam sobrestados.

5.5 PRINCIPAIS MEIOS JUDICIAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

5.5.1 Ação civil pública

O presente tópico não pretende ser uma análise exaustiva da ação civil pública, mas, apenas e tão somente, servir de apresentação sumária do tema. A ação civil pública é importante instrumento de tutela do meio ambiente, mas, a toda evidência, não é um instituto que integre o Direito Ambiental. A lei da ação civil pública, igualmente, não criou qualquer direito. É, apenas, norma de processo, e é dessa maneira que deve se enfocada.

Para que se possa compreender o objeto da ação civil pública é necessário que se tenha em mente que são diversas as matérias tuteladas pela Lei nº 7.347/85.

A Lei nº 7.347/1985, tem por finalidade, sem prejuízo da ação popular disciplinada pela Lei nº 4.717/1965, reger as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico. Vale notar que, com o advento da Constituição de 1988, o campo de abrangência da lei que ora se examina foi bastante ampliado, vez que, por força do artigo 129, III, estabeleceu-se a possibilidade de propositura de ações civis públicas para a defesa de outros interesses difusos.

O objeto da ação civil pública está contido no artigo 1º da Lei nº 7.347/85. Muito embora a Lei nº 7.347/85 vise a regulamentar uma ação de “*responsabilidade*”, ela não contém qualquer dispositivo acerca da liquidação dos danos, logo os ressarcimentos devem ser buscados mediante a utilização do CPC.

Dentre os bens jurídicos tutelados pela lei, o meio ambiente é um dos que merecem maior destaque. Normativamente, meio ambiente, como se sabe, está conceituado no inciso I do artigo 3º da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a PNMA. Nos termos da norma jurídica recém-citada, o meio ambiente é o *conjunto de*

condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Por força de expressa disposição constitucional, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservá-lo e defendê-lo (CF, art. 225).

De todas as hipóteses de cabimento das ações civis públicas, esta é aquela que permite a maior ampliação do instrumento processual ora sob análise. Evidentemente que a amplitude do permissivo contido no inciso é função do entendimento que se tenha dos próprios interesses difusos. O nosso posicionamento é no sentido de considerar que os interesses difusos revestem-se da característica de serem um prolongamento e uma extensão dos direitos humanos fundamentais. Nessa condição possuem um caráter de garantia e tutela de determinados padrões de condição de vida e não podem ser confundidos com qualquer reivindicação de grupos. Isso porque os interesses difusos não se confundem com postulações corporativas.

Existe uma certa tendência doutrinária em considerar que o simples choque de interesses entre grupos sociais que formulam reivindicações conflitantes entre si é suficiente para configurar um choque de interesses difusos. Não é assim. Não se pode falar em interesse difuso quando a postulação é contrária ao próprio sistema constitucional de garantia dos direitos humanos em qualquer uma de suas dimensões.

O objetivo que deve guiar o intérprete é o de compatibilizar a reivindicação eventualmente formulada por um grupo com um interesse geral da sociedade. Se a postulação não trazer em seu bojo um interesse geral da sociedade, presente e futura, não há que se falar em interesse difuso, mas, ao contrário, de interesse corporativo, não tutelado pela ação civil pública.

5.5.1.1 Competência para o processamento e julgamento das ações civis públicas

Parece-nos que o legislador não foi muito feliz ao tratar do presente assunto, senão vejamos:

- a) a lei determina que a ação seja proposta perante o juízo com jurisdição sobre o local do dano;
- b) a lei determina que o juiz do local terá competência funcional para processar e julgar o feito.

Em minha opinião há uma contradição nos termos com os quais o legislador quis abordar o tema ora examinado. A hipótese prevista na letra *a* é, a toda evidência, de competência territorial. Como é de conhecimento de todos, é competência relativa, portanto, prorrogável. Quanto à letra *b*, esta não tem qualquer relação com a competência territorial. Juridicamente, há um erro grosseiro de conceituação, pois, de fato, o legislador misturou e confundiu os institutos da competência territorial e da competência funcional. Vale trazer à colação a lição de Humberto Theodoro Junior (1984, 176):

Há que se distinguir a competência de foro da competência do juiz. Foro é o local onde o juiz exerce as suas funções. Mas no mesmo local podem funcionar vários juizes com atribuições iguais ou diversas, conforme a organização judiciária. Se tal ocorrer, há que se determinar, para uma mesma causa, primeiro qual o foro competente e, depois, qual o juiz competente. Foro competente, portanto, vem a ser a circunscrição territorial (Seção Judiciária ou Comarca) onde determinada causa deve ser proposta. E juiz competente é aquele, entre os vários existentes na mesma circunscrição, que deve tomar conhecimento da mesma para processá-la e julgá-la.

Longe de pretender doutrinar sobre tema de tão grave indagação, socorro-me da lição de Athos Gusmão Carneiro (1983, p. 92): “Diferentes ‘funções’ ou atribuições dentro de um mesmo processo podem caber a diferentes juizes. No âmbito criminal, temos exemplo expressivo nos processos por crimes de competência do tribunal do júri, pois pode caber a um juiz de vara criminal comum instruir o processo, ao juiz da vara privativa do júri proferir a sentença de pronúncia e presidir o júri, aos jurados responderem aos quesitos, ao juiz fixar a pena, e, por fim, ao juiz das execuções criminais apreciar os incidentes surgidos durante a execução da pena. Trata-se nessa hipótese, de competência funcional ‘horizontal’ tramitando o processo no mesmo grau de jurisdição. No cível, o critério de competência funcional encontra maior aplicação no plano ‘vertical’, na também chamada competência ‘hierárquica’, ou competência recursal. São de ordem pública, e assim interrogáveis – competência absoluta –, os critérios de competência funcional, atributivos da competência a um juiz para praticar determinados atos ou para conhecer de uma causa em primeira instância, e a outras, juizes para conhecê-la em segunda instância”.

O Estado brasileiro é organizado sob a forma de República Federativa, com separação de Poderes. Isso implica que os Poderes se organizam de forma independente, devendo manter harmonia em suas relações. A República brasileira, na forma da Constituição de 1988, é constituída pela união dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Dessa forma, e em decorrência dos princípios federativos adotados pela CF, o Poder Judiciário, embora seja um dos Poderes nacionais, divide-se em Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. A propósito, vale frisar que as justiças especializadas (Trabalho, Eleitoral e Militar) são, em geral, federais, à exceção da última, que também pode ser estadual. A Justiça Federal, propriamente dita, é justiça comum. Verifica-se, portanto, que há uma organização dual na Justiça brasileira. A Lei nº 7.347/85, como é óbvio, existe para ser aplicada pelo Poder Judiciário, seja federal ou estadual e não apenas por um de seus “braços”.

No âmbito da Justiça dos Estados, o *local do dano* é uma Comarca, salvo nos casos em que o dano possa ter ocorrido em mais de uma Comarca. Caso o dano tenha se verificado em mais de uma Comarca, deverão ser aplicadas as normas do CPC sobre conexão, prevenção etc.

Há que ser considerada a eventualidade da existência de dano que, por suas dimensões excepcionais, ultrapasse os limites de uma única Comarca e que, nesse caso, se reproduza em várias localidades que, juridicamente, podem ser Comarcas diversas. Ora, em minha opinião, deve ser considerado que, em se tratando de matéria de competência relativa, o ajuizamento poderá ocorrer em qualquer uma das Comarcas nas quais o evento danoso tenha produzido consequências. Evidentemente que, se ajuizado mais de um processo visando à reparação do dano, em Comarcas diferentes ou em mais de uma Vara da mesma Comarca, prevalecerá a competência daquela que primeiro tenha tido conhecimento dos fatos (mediante despacho citatório exarado pelo órgão judicial), por força da prevenção. Do ponto de vista estritamente prático, recomenda-se seja o feito ajuizado na Comarca do local onde o dano tenha sido iniciado, onde o evento lesivo se verificou, desconsiderando-se repercussões em outras Comarcas. Tal recomendação tem por objetivo facilitar a produção de provas. Daí poderá haver uma repercussão socialmente mais eficaz para o processo. Galeno de Lacerda (1986, p. 40) e Hugo Nigro Mazzilli (1988, p. 40) têm entendimento no mesmo sentido.

Quando se tratar de ação civil pública que tenha por finalidade a tutela de bem jurídico cuja titularidade é da União Federal ou de uma de suas autarquias ou empresas públicas, a competência, em nossa opinião, é, evidentemente, federal. Tais casos não demandam maiores indagações, se o dano ocorrer nas capitais ou em cidades que sejam sede de juízo federal.

Importante observar que, com a finalidade de evitar a multiplicação de ações, o legislador determinou que:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

5.5.1.2 Prescrição

A prescrição é um dos assuntos mais árdios e dos mais importantes para o direito ambiental e, talvez em função disso, tem sido pouco tratada pela doutrina mais abalizada. A grande importância do tema está situada na órbita do *direito processual* e não propriamente na do direito qualificado como “*material*”. Ela se constitui em defesa do réu que, se acolhida, importa *julgamento com resolução do mérito*, conforme determinação do CPC (art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição). Em geral, sustenta-se que, devido aos valores tutelados pelo

direito ambiental, não se poderia falar em prescrição, visto que aqueles, por não terem caráter patrimonial, estariam imunes à sua incidência. Aduz-se que a prescrição recai sobre direitos patrimoniais e que, em direito ambiental, apenas parcialmente se pode falar em direitos patrimoniais, visto que os bens tutelados, em sua essência, não possuem valor econômico.

A fim de bem expor a posição acima mencionada, permito-me, nesta altura, transcrever um breve texto do excelente Edis Milaré (2005, p. 962-963) que, na minha opinião, bem ilustra o conjunto das concepções negadoras da prescrição em matéria ambiental, *in verbis*: “Conforme salientamos alhures, o Direito enxerga o dano ambiental sob dois aspectos distintos: a) o dano ambiental coletivo, dano ambiental em sentido estrito ou dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, como patrimônio coletivo, e b) o dano ambiental individual ou dano ambiental pessoal, sofrido pelas pessoas e seus bens. Assim é porque um mesmo fato pode ensejar ofensa a interesses difusos e individuais, como ocorre, por exemplo, com a contaminação de um curso de água por carreamento de produto químico nocivo. Ao lado do dano ecológico puro ou coletivo identificado, poderão coexistir danos individuais em relação aos proprietários ribeirinhos que tenham suportado perda de criações ou se privado do uso comum da água contaminada [...]. De fato, o estabelecimento de um prazo para o ajuizamento da ação tendente à composição da lesão ambiental resulta por completo inadequado para o sistema de prescrição.

O tema, por complexo, não será examinado em toda a sua profundidade nesta sede, buscarei dar uma ideia geral do nível dos debates sobre a matéria e, na medida do possível, externar uma concepção pessoal. Em primeiro lugar penso que o aludido *caráter difuso* do dano ambiental não deve nos impressionar. Os chamados interesses difusos têm como uma de suas mais importantes características básicas a sua quase completa fluidez e plasticidade, um caráter gelatinoso, que resulta de situações fundamentalmente fáticas. Conforme Mancuso (1988, p. 105): “são interesses metaindividuais que, não tendo atingido o grau de agregação e organização necessário à sua aferição institucional, junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade civil como um todo (v. g., o interesse à pureza do ar atmosférico), podendo por vezes concernir a certas coletividades de conteúdo numérico indefinido (v. g., os consumidores). Caracterizam-se pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por uma intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no tempo e no espaço”.

Diante de uma abrangência tão ampla e de seu caráter evidentemente *aberto*, o problema da legitimidade ativa, evidentemente, tem uma grande importância. As dificuldades para tutelar judicialmente tais *interesses foram resolvidas no direito brasileiro com a Lei nº 7.347/85, que instituiu a Ação Civil Pública que, posteriormente, foi constitucionalizada*. Tal lei processual estabeleceu mecanismos de substituição processual capazes de romper com os rígidos limites do artigo 18 do CPC. A Lei foi uma construção prática capaz de dar solução a problemas de *legitimidade ativa* no que concerne à busca pela reparação de danos causados a bens que não estavam diretamente vinculados à esfera jurídica de particulares e, portanto, estes últimos não podiam perseguir em juízo, pela falta de legitimidade ativa. Posso citar, por exemplo, a obrigação de que o ar fosse mantido limpo, ou de que os rios não fossem poluídos. Não se deve esquecer, contudo, que nas hipóteses individuais, o direito de vizinhança foi amplamente utilizado no direito brasileiro e com expressivo sucesso, nas questões de ruído excessivo, iluminação, fumaça etc. Evidentemente que *os direitos de vizinhança não são suficientes para resolver problemas de natureza coletiva*, visto que terceiros não podem defender em nome próprio direito alheio.

Os *interesses difusos* não excluem nem são antagônicos às questões patrimoniais. Aliás, se analisarmos as questões referentes aos danos morais veremos que, inicialmente, eles não eram indenizáveis, visto que se alegava que a dor não tinha preço. Com isso, seguramente, os causadores de tal espécie de dano ficavam inteiramente imunes à força do direito. A evolução da matéria chegou ao ponto de que a proteção da intimidade e a possibilidade de indenização de danos morais se transformaram em matéria constitucional. Veja-se que já se fala em *dano moral ambiental* (RODRIGUERO, 2004), com repercussão inclusive na jurisprudência. “*Ação Civil pública. Poluição ambiental, corte de árvore. Falta de autorização judicial. Construção sem licença. Ressarcimento dos danos. Dano moral. Fixação do valor. Recurso provido. Embargos de declaração. Acolhimento. Poluição ambiental. Ação civil pública formulada pelo Município do Rio de Janeiro. Poluição consistente em supressão da vegetação do imóvel sem a devida autorização municipal. Cortes de árvores e início de construção não licenciada, ensejando multas e interdição do local. Dano à coletividade com a destruição do ecossistema, trazendo consequências nocivas ao meio ambiente, com infringência às leis ambientais, Lei Federal 4.771/65, Decreto Federal 750/93, artigo 2º, Decreto Federal 99.274/90, artigo 34 e inciso XI, e a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, artigo 477. Condenação à reparação de danos materiais consistentes no plantio de 2.800 árvores, e ao desfazimento das obras. Reforma da sentença para inclusão do dano moral perpetrado à coletividade. Quantificação do dano moral ambiental razoável e proporcional ao prejuízo coletivo. A impossibilidade de reposição do ambiente ao estado anterior justifica a condenação em dano moral pela degradação ambiental prejudicial à coletividade. Provimento do recurso*” (TJRJ. Apelação Cível 2001.001.14586. Relatora: Des. Maria Raimunda T. Azevedo. Julgamento: 7/8/2002. 2ª Câmara Cível).

Ao contrário, a patrimonialização, em determinada medida, é a única forma possível de fazer com que as lesões que tenham sofrido não resem completamente impunes.

Entretanto, gostaria de ressaltar que o meu ponto central é o de que não existe uma relação direta entre não patrimonialidade e direitos difusos. Aliás, se observarmos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a norma mais completa para a defesa dos interesses difusos, veremos que a maioria dos direitos por ele tutelados são de natureza patrimonial, ainda que a defesa do consumidor seja considerada como integrante do rol de “interesses difusos”. “*Ação civil pública. Entidades de saúde. Aumento das prestações. Legitimidade ativa. 1. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa dos consumidores de planos de saúde. 2. Antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, o País sempre buscou instrumentos de defesa coletiva dos direitos, ganhando força seja com a Lei nº 7.347/87, seja alcançando dimensão especial com a disciplina constitucional de 1988. Sedimentados os conceitos centrais, não há razão que afaste o presente feito do caminho da ação civil pública. O instituto autor é entidade regularmente constituída e tem legitimidade ativa para ajuizar a ação civil pública de responsabilidade por danos patrimoniais causados ao consumidor. 3. Recurso especial conhecido e provido*” (STJ. REsp 72994/SP. Relator: Ministro Nilson Naves. Relator para Acórdão: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 3ª Turma. DJU 17/9/2001, p. 159).

O problema que os direitos difusos buscaram resolver não guarda qualquer relação com a natureza patrimonial ou não patrimonial dos bens. A existência de dificuldade para a quantificação de valor econômico de um bem não significa, em si, que ele não possa ter um valor econômico definido. Especialmente porque se tais bens não têm preço, certamente têm custos e os custos são ressarcíveis e indenizáveis. Da mesma forma, o fato de que para determinados indivíduos, considerados pessoalmente, certos bens e pessoas sejam incomensuráveis, isso não implica que *socialmente* não se atribuam valores a bens “sem preço” como a vida humana, por exemplo. Diariamente são fixadas indenizações civis pelo “evento morte”, “danos à saúde” e “invalides” e chega-se mesmo a estabelecer valores por perda de determinadas *partes do corpo humano*; da mesma forma, nada impede a incidência da prescrição de ações que visem a obter reparações por tais perdas.

Aliás, a compensação ambiental estabelecida pelo artigo 36 da lei do SNUC é a criação de um equivalente pecuniário para o dano ambiental. Se examinarmos os *bens ambientais*, veremos, sem muita dificuldade, que eles, desde muito, possuem valor redutível à pecúnia em nosso direito. O velho Código de Águas instituído pelo Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, em diversos de seus artigos previa a quantificação pecuniária do uso das águas. Naquela norma era admissível que, em razão de interesse relevante da agricultura ou da indústria, as águas fossem “inquinadas”, cabendo uma indenização em favor dos lesados (arts. 111 e 112). Havia, também, a previsão da possibilidade de desapropriação de águas, o que demonstra a redutibilidade à pecúnia de seu “valor” (art. 32). A legislação mais moderna sobre recursos hídricos é bastante clara ao definir que a água é um bem que possui valor econômico (Lei nº 9.433/ 1997, art. 1º), chegando a estabelecer a obrigação de que o usuário da água deve pagar um preço pelo bem considerado em si mesmo.

Um outro elemento importante para que se possa compreender a questão é que o meio ambiente, no direito brasileiro, ostenta a condição de bem de uso comum, conforme definição do artigo 225 da CF. Isso implica que os valores ambientais podem e devem ser usufruídos por todos da forma mais ampla possível. Isso, entretanto, só é possível no interior da ordem jurídica, visto que em todo e qualquer caso de violação de tal “*bem comum*”, o aparato repressivo do Estado poderá ser acionado por qualquer indivíduo que se sinta prejudicado, mediante os mecanismos processuais próprios. Do ponto de vista prático, o meio ambiente é considerado *patrimônio público*, conforme disposto na Lei nº 6.938, de 31 de julho de 1981 (art. 2º).

5.5.1.2.1 A prescrição e seus principais elementos

As sociedades e os indivíduos não podem viver eternamente presos ao peso de seus passados, seja para lamentá-lo, seja para exaltá-lo.

No mundo do direito, a prescrição é um dos mecanismos aptos a evitar que o passado continue a dominar o presente, fazendo com que o último possa se desenvolver sem os pesos do que ficou para trás. Sem a existência da prescrição, as violações de direito praticadas no passado permaneceriam constantemente puníveis e abertas, impedindo a consolidação de situações de fato. Se considerarmos, com Reale, que direito é fato, norma e valor, a não consolidação de situações de fato impediria a consolidação do próprio direito, visto que um dos seus elementos fundantes não teria como se expressar adequadamente. É na interação desses três elementos que se poderão estabelecer os critérios para que situações pretéritas possam ser “esquecidas” pela ordem jurídica. Entretanto, o critério para o esquecimento é, obviamente, axiológico em sua raiz mais profunda. Para que o esquecimento opere efeitos, normalmente, são fixados prazos que resultam de uma valoração social que considera o fato em si, a sua importância no contexto de uma sociedade e a quantidade de tempo que se fixa como necessária para que o esquecimento se manifeste juridicamente. O que se busca estabelecer é uma regra de equivalência que seja socialmente aceita e, portanto, capaz de assegurar padrões desejáveis de estabilidade social, com força para afastar o “rancor” e o “ressentimento” da vida social, que se perpetuariam caso não houvesse o mecanismo legal do esquecimento.

Prescrição é a repercussão causada na ordem jurídica pelo decurso do tempo, operando os efeitos acima enunciados. Ela pode significar a *perda* ou a *aquisição* de determinados direitos, conforme seja a situação especificamente considerada. “*De fato, dentro do instituto da prescrição, o personagem principal é o tempo*” (RODRIGUES, 2002, p. 324). Ela se divide em duas grandes: (i) extintiva e (ii) aquisitiva. Ambas possuem enorme importância no mundo jurídico. Pela primeira é determinada a perda do direito de ação em face do devedor da obrigação, muito embora o próprio direito não se perca; já pela segunda, o sujeito ativo adquire direitos em face da inércia de terceiros, é o caso do *usucapião*. Tanto em uma, como na outra, o lapso temporal é uma medida de política legislativa e, portanto, poderá sofrer variações de acordo com as opções do legislador em cada caso concreto. Da mesma forma, o legislador poderá determinar as hipóteses excepcionais de imprescritibilidade, visto, que, para nós, vale “*a regra geral de não haver em nosso sistema direitos imprescritíveis*” (PEREIRA, 2004, p. 685). A Constituição Brasileira reconhece a imprescritibilidade dos crimes de racismo e terrorismo, por exemplo. Um outro exemplo que se poderia considerar de imprescritibilidade é o tratado pelo *caput* do artigo 231 e § 4º da Constituição.

Efetivamente, a construção do instituto da prescrição extintiva de direitos é uma importante evolução pela qual passou o direito romano, visto que antes da sua institucionalização pelo direito pretoriano as ações eram perpétuas e a parte passiva permanecia indefinidamente sujeita a vir a ostentar a condição de réu em uma ação judicial, não importando a época na qual a “violação” do direito tivesse sido praticada.

No direito brasileiro a matéria está regulada, em termos gerais, pelo CC, ainda que leis especiais possam prever prazos e situações especiais de prescrição. Para nós a prescrição requer, ainda, a inércia do titular. Isto é, a prescrição se constitui sobre uma base dúplice: (i) decurso de tempo e (ii) inércia do titular. Para as questões que estão sendo abordadas neste texto, avulta a inércia do titular. Digo isso porque os negadores da prescrição em matéria ambiental, de maneira geral, negligenciam o aspecto subjetivo na sua construção. Muitas vezes, a negação da possibilidade de existência do lapso prescricional é feita de forma tão genérica que se torna difícil compreender-lhe os fundamentos jurídicos (FIORILLO, 2004, p. 348).

Entendo que a *prescrição incide nas lesões causadas ao meio ambiente*, visto que, como tenho sustentado ao longo de todo o presente livro, o direito ambiental está inserido na ordem jurídica constitucional e a prescrição é um dos pilares do valor segurança jurídica que não pode ser relegado a segundo plano, devendo ser harmonizado com os demais valores constitucionalmente relevantes, como é o caso da proteção ao meio ambiente. Compreende-se que, muitas vezes, situações individuais complexas e graves possam fazer com que o intérprete perca a noção de conjunto do sistema jurídico e da própria aplicação da justiça. Nesses casos, é conveniente relembrar a lição de Mary Douglas: “Justiça não tem nada a ver com casos isolados” (1986, p. 124).

Acrescento, por exemplo, que as *Bases Generales Del Medio Ambiente* (19.300) do Chile admitem a prescrição de uma forma tecnicamente correta:

Art. 63. La acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño.

Conforme sustentei anteriormente, a doutrina e a jurisprudência¹ brasileiras admitem tranquilamente que a prescrição *somente começa a correr com o conhecimento da lesão do direito*.

O importante da manutenção da possibilidade teórica da ocorrência da prescrição é assegurar que o equilíbrio jurídico não seja quebrado, garantindo a existência do preceito de justiça que, ante a existência da responsabilidade objetiva, sofre uma transmutação significativa. Romper a barreira prescricional seria, no caso concreto, estabelecer um nível insuportável de falta de isonomia, com graves reflexos para a vida do direito e, reflexamente, para a atividade econômica.

5.5.1.3 Legitimidade ativa

O artigo 5º da Lei nº 7.347/85 estabelece o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações civis públicas. Com efeito, estabelece o artigo 5º da Lei nº 7.347/85:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública;

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V – a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

O artigo 5º é, provavelmente, aquele que apresenta a mais importante inovação contida na lei da ação civil pública. É aquele que rompe mais formalmente com a tradição individualista que informa o sistema processual civil brasileiro. Queremos nos referir, em especial, à norma contida no artigo 18 do CPC.

A regra contida na *lei de ritos* é que apenas o titular de um direito subjetivo pode pleitear esse mesmo direito perante o Poder Judiciário. Nessas hipóteses, a parte processual se confunde com a parte material. A *legitimatatio ad causam* tradicionalmente existente em matéria de processo civil está, destarte, vinculada à relação existente entre o titular do direito dito material e a demanda. À exceção à regra se dá o nome de *substituição processual*, figura essa que não se confunde com a da *representação*, pois, como se sabe, o representante age em nome do representado e não em nome próprio. O CPC de 1973 já contemplava algumas hipóteses nas quais a figura do substituto processual se fazia presente, bem como o próprio CC brasileiro, o Código Comercial e, em matéria de defesa do patrimônio público, em sentido amplo, a Lei de Ação Popular e a legislação de combate à poluição causada por óleo e a própria Lei nº 6.938/81.

5.5.1.4 Ministério Público como parte legítima da ACP

A ação civil pública definida pelas diversas leis que a regulamentam é uma das principais, senão a principal área de atuação do Ministério Público no campo do processo civil; isso não implica que, no âmbito civil, a única ação que pode ser proposta pelo Ministério Público seja a ação civil pública e, muito menos, que a ação civil pública sirva para amparar processualmente toda e qualquer pretensão do Ministério Público. O *parquet*, na ação civil pública, pode ser autor ou fiscal da ordem jurídica. Possui, ainda, o poder de realizar investigações prévias à própria propositura da ação judicial, mediante a instauração de inquérito civil. Tais atribuições fazem

com que, *ipso iure*, o Ministério Público seja a presença mais marcante no que se refere à defesa dos interesses difusos. Atualmente, a concepção de que o processo penal é o “reino do Ministério” é um pouco menos verdadeira.

As ações civis públicas são o principal instrumento de ação do Ministério Público no âmbito da jurisdição civil. O Ministério Público, apesar das imensas dificuldades de recursos financeiros e materiais, vem propondo diversas ações civis públicas e tem obtido alguns êxitos significativos. É interessante observar que, apesar de a lei conferir uma amplíssima legitimação ativa para a propositura das ações civis públicas, tem sido o Ministério Público o maior ajuizante desse tipo de demandas judiciais. Contam-se em algumas centenas os números de ações civis públicas propostas perante os diversos juízos existentes em nosso País.

A Lei nº 7.347/85 teve a grande virtude de ampliar os vínculos entre a sociedade e o Ministério Público. Assim é na medida em que os membros do *parquet*, que se têm dedicado à proteção jurídica do meio ambiente e de outros interesses difusos, têm logrado obter o respeito e a consideração da população que, não sem pouca frequência, acorre às curadorias e procuradorias em busca de auxílio.

Como autor, o Ministério Público busca a condenação do poluidor ou degradador do meio ambiente. Há, portanto, um objetivo teleológico. O Ministério Público, nessas hipóteses, não busca, como já foi dito antes, a realização abstrata da Justiça, mas a sua concretização em uma condenação. Para atingir o seu objetivo ele pode valer-se de todos os instrumentos existentes na legislação processual brasileira.

Uma importante questão que está colocada na ordem do dia é a da repartição de atribuições entre os ramos federal e estadual do Ministério Público. Pode o Ministério Público dos Estados ajuizar feitos perante a Justiça federal? Muita controvérsia tem surgido sobre o tema. Com o devido respeito, as opiniões que se têm apresentado sobre a matéria não estão alicerçadas no melhor critério técnico, sendo fundamentalmente corporativistas. Felizmente, o STF tem conseguido dar racionalidade à questão: *Ementa: Reclamação – Alegado desrespeito a decisão proferida pelo STF em sede de fiscalização abstrata – Ministério Público do Trabalho – Ilegitimidade para atuar, em sede processual, perante o STF – Princípio da unidade institucional do Ministério Público (CF, ART. 127, § 1º) – Recurso não conhecido. O Ministério Público do Trabalho não dispõe de legitimidade para atuar, em sede processual, perante o STF, eis que a representação institucional do Ministério Público da União, nas causas instauradas na Suprema Corte, inclui-se na esfera de atribuições do Procurador-Geral da República, que é, por definição constitucional (CF, art. 128, § 1º), o Chefe do Ministério Público da União, em cujo âmbito se acha estruturado o Ministério Público do Trabalho. Precedentes (STF. Rcl 5873 AgR/ES. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento: 9/12/2009. Tribunal Pleno. DJe-027, divulg. 11/2/2010, public. 12/2/2010).*

A possibilidade de litisconsórcio ativo entre os Ministério Público Federal e dos Estados-membros, em nossa opinião é, evidentemente, *inconstitucional*, perante o artigo 127, § 1º, da CF. Assim é porque, se o MP é *uno e indivisível*, não pode *dividir-se em duas entidades autônomas* e que se unem em determinados momentos para a propositura de uma demanda judicial. A cooperação e integração entre os diversos segmentos do MP são absolutamente desejáveis. Entretanto, a sua realização deve ser administrativa e não judicial.

A hipótese chegou a ser prevista no § 2º do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, que veio a ser, posteriormente, vetada. Esse parágrafo tratava de um *litisconsórcio facultativo* entre o *parquet* federal e os estaduais. Entretanto, o artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor acabou por inserir o § 5º do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, objeto de veto, prevendo a mesma possibilidade. Assim, pela aplicação subsidiária desta última lei às causas que envolvem os direitos e interesses dos consumidores (art. 90 do Código de Defesa do Consumidor), a discussão continua atual.

Em meu entendimento, até por coerência, é de ser afastada a hipótese de litisconsórcio facultativo entre Ministério Público Federal e Estadual. Só podem litisconsorciar-se entidades diferentes, a teor do que dispõe o artigo 113 do CPC, “duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II – entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”. Se o Ministério Público é um só – *uno e indivisível* –, essa possibilidade é logicamente impossível. Aliás, todas as normas jurídicas contidas no CPC que cuidam do instituto do litisconsórcio referem-se a *pessoas diferentes*. João Batista de Almeida também se posiciona no mesmo sentido:

Ministério Público tanto pode ser o Federal como o Estadual. Funciona o primeiro se a ação for de competência da Justiça Federal [...] Funciona o segundo se a ação for de competência da Justiça Estadual (1991, p. 150).

Idêntica é a posição de Vicente Greco Filho, que aponta a violação do sistema federativo pela subversão das competências dos ramos autônomos do MP (1981, p. 377). A defesa da possibilidade de litisconsórcio ativo entre ramos do Ministério Público, em realidade, faz-se, muito mais, em razão de interesses corporativos do que em razão de concepções jurídicas que tenham qualquer consistência teórica ou mesmo legal. O STJ teve a oportunidade de apreciar dois recursos, tendo se pronunciado taxativamente pelo não cabimento do litisconsórcio entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados.

Administrativo. Processual civil. Ação civil pública. Competência da Justiça Estadual. Litisconsórcio Ativo. Órgãos do Ministério Público Federal e Estadual. Inadmissibilidade. Em sede de ação civil pública, na qual se discute questão administrativa do âmbito da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, assunto cujo exame compete à Justiça Estadual, não há como se conceder a admissão do MP Federal no polo ativo da demanda, e litisconsórcio com o MP Estadual. Recurso desprovido (STJ. ROMS nº 4.146/CE. Relator: Min. Vicente Leal. 6ª Turma. j. 23/10/1995. DJU 26/2/1996, p. 336).

Processual civil. Ação civil pública. Sociedade de Economia Mista Estadual (Concessionária de Serviços de Telefonia). Competência da Justiça Estadual. I – Reconhecida a falta de interesse do Ministério Público Federal, para atuar no polo ativo da ação como litisconsórcio facultativo do autor, Ministério Público Estadual, em ação que este aforou contra sociedade de economia mista do estado, correta a declaração de incompetência da Justiça Federal, com remessa dos autos à Justiça Comum para apreciação da lide. II – Recurso não conhecido (STJ. REsp nº 151.855/PE. Relator: Min. Waldemar Zveiter. 3ª Turma. j. 12/5/1998. DJU 29/6/1998, p. 167).

No mesmo sentido vai a pacífica jurisprudência do STF, que reconhece apenas a legitimidade do Chefe do *Parquet* Federal para atuar perante a Corte Constitucional, o que demonstra a impossibilidade do pretendido litisconsórcio.

“[...] o Ministério Público do Estado de São Paulo não possui legitimidade para propor originariamente Reclamação perante esta Corte, já que ‘incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, nos termos do art. 46 da LC 75/93’ (Rcl 4453 MC-AgR-AgR/SE, de minha relatoria, DJe 059, 26/3/2009). 2. Entretanto, a ilegitimidade ativa foi corrigida pelo Procurador-Geral da República, que ratificou a petição inicial e assumiu a iniciativa da demanda. 3. Entendimento original da relatora foi superado, por maioria de votos, para reconhecer a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público Estadual para propor reclamação. [...] (STF. Rcl. 7358/SP. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Julgamento: 24/2/2011. Tribunal Pleno. DJe-106, divulg. 2/6/2011, public. 3/6/2011).

Como se sabe, o Ministério Público pode desempenhar papéis diferentes no interior de uma ação civil pública. Passemos a examinar tais papéis.

A função de *custos legis* é uma função exercida pelo Ministério Público nas causas em que ele não for o autor. Em tal função, o Ministério Público deve ficar atento para que a lei se aplique corretamente, fiscalizando as partes e o próprio juiz da causa.

A função mais tradicional do Ministério Público, no âmbito do processo civil, é a de fiscal da ordem jurídica. Isto é, compete ao *parquet* exercer a fiscalização da correta aplicação da lei, em cada um dos diversos feitos judiciais nos quais estejam presentes as condições estabelecidas na legislação processual, em especial nos casos do artigo 178 do CPC (art. 178). O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na CF e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. É importante observar que a LC nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União –, trouxe uma importante modificação no particular, pois, nos termos do artigo 6º, inciso XV, do citado diploma, *cabe ao próprio Ministério Público dizer de seu interesse em ingressar no feito*. Senão vejamos:

Por força do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, o *parquet* intervirá em todas as ações nas quais não tenha sido o autor. Em sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público, a sua não realização implica nulidade do processo. A intervenção do Ministério Público é material e não apenas formal. A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica implica que este seja intimado das provas a serem produzidas pelas partes. Deverá ser intimado dos documentos e perícias constantes dos autos. Deverá, também, ser intimado das assentadas, das decisões interlocutórias e da sentença. Ou seja, o Ministério Público deverá ter conhecimento de *tudo o que consta dos autos*. Nenhum prazo correrá contra o Ministério Público, caso este não tenha sido intimado pessoalmente. Na hipótese em que as partes cheguem a algum tipo de acordo ou transação, o Ministério Público deverá ser intimado de seus termos e esta somente poderá ser homologada pelo órgão judicial após a manifestação do representante do Ministério Público. Caso o Ministério Público discorde dos termos nos quais foi lavrado o acordo ou transação, poderá recorrer da decisão homologatória.

O Ministério Público, na função de fiscal da ordem jurídica, será responsável subsidiário pela execução da decisão condenatória, quando a associação vencedora não o tenha feito em até 60 dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 15 da Lei nº 7.347/85).

5.5.1.4.1 Posição do STJ

A propósito do tema, veja-se a decisão do STJ, proferida em questão de ordem, na qual se discutia a possibilidade de o Ministério Público dos Estados sustentar oralmente perante a Corte. A Primeira Seção, por maioria, decidiu que o Ministério Público dos Estados não pode fazer sustentação oral no STJ como parte (impetrante de MS), devendo ser representado como parte pública autônoma pelo Subprocurador-Geral da República que se senta à direita do ministro presidente na sessão de julgamento. “A questão foi suscitada pelo Min. Hamilton Carvalhido [...] Lembrou, também, que a Corte Especial já se pronunciou nesse sentido nos EREsp 445.664-AC, *DJ* 30/10/2008, ao decidir que somente o MPF, por meio dos Subprocuradores-Gerais da República, tem legitimidade para atuar nas causas de competência do STJ, e nessa atuação está compreendida a sustentação oral. Note-se que, no citado julgamento, a Corte Especial anulou o processo pela duplicidade de atuação do MP. Observou o Min. Teori Albino Zavascki a dificuldade em admitir a manifestação do MP no mesmo processo e no mesmo julgamento por dois diferentes órgãos, ainda que possa haver opiniões diferentes entre eles. Não se poderia desconhecer o princípio da unidade do MP, o qual resulta na vinculação da própria instituição pela palavra de qualquer dos seus integrantes. Por esse motivo, ao seu ver, não vale o argumento de que um atua como representante do MP na função de parte e o outro na de *custos legis*, pois, mesmo quando atua como parte, o MP não se despe da sua função institucional de defensor da ordem pública conferida pela art. 127 da CF/1988, o que significa que, em qualquer de seus pronunciamentos, inclusive como parte, o MP é sempre *custos legis*. Por outro lado, a Min. Eliana Calmon afirmou que, no *mandamus*, o MP é parte autônoma e como parte somente pode falar uma vez. Entretanto, ressaltou ter compromisso com essa posição só em mandado de segurança e manifestou ainda ter dúvidas sobre a legitimidade de o MP impetrar o mandado de segurança. QO no MS 14.041-DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgada em 9/9/2009” (STJ, Informativo 206).

5.5.2 Mandado de segurança coletivo

O mandado de segurança coletivo é uma inovação processual trazida ao sistema processual brasileiro pela Constituição de 1988. Trata-se de uma ação constitucional prevista nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da CF, regulamentada pela Lei nº 12.016/2009.

Os pressupostos gerais para a impetração do mandado de segurança coletivo são aqueles que estão contidos no inciso LXIX do artigo 5º da CF, que trata do mandado de segurança. O detalhe é fornecido pela alínea *b* do inciso LXX, que dispõe sobre mandado de segurança impetrado por “*organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados*”.

Ocorre que, para que se configure a legitimidade para ajuizamento do mandado de segurança coletivo, necessário se faz que as associações obtenham de seus membros a expressa autorização para o ingresso em juízo, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 5º da CF.

José Afonso da Silva (2004, p. 396-397) espousa a opinião que:

O requisito de direito líquido e certo será sempre exigido quando a entidade impetra o mandado de segurança coletivo na defesa do direito subjetivo individual. Quando o sindicato usá-lo na defesa do interesse coletivo de seus membros e quando os partidos políticos forem impetrá-lo na defesa do interesse coletivo difuso exige-se menos a ilegalidade e a lesão do interesse do que o que o fundamento.

É possível figurar-se a hipótese de um sindicato de trabalhadores em usinas de metalurgia que, no dissídio coletivo da categoria, logrou inserir cláusulas de proteção de meio ambiente do trabalho, tais como a instalação de filtros antipoluição, plantio de árvores no terreno da indústria e outras. Tais cláusulas, por exemplo, não estão sendo cumpridas pela empresa. O sindicato tem, evidentemente, direito líquido e certo de exigir judicialmente que tais cláusulas sejam implementadas pela empresa. Daí ser cabível o mandado de segurança coletivo.

5.5.3 Ação popular

A ação popular constitucional está prevista no artigo 5º, LXXIII, da Constituição. Veja-se que a norma constitucional capitulou, expressamente, o meio ambiente dentre os bens jurídicos passíveis de tutela por meio da ação popular. Vale lembrar, contudo, que a lei ordinária já incluía o meio ambiente entre os bens jurídicos protegidos pela referida ação.

A ação popular é um dos mais tradicionais meios de defesa dos interesses difusos do Direito brasileiro. O autor popular, cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos, age em nome próprio na defesa de um bem da coletividade. A ação popular é um instituto jurídico constitucional a ser exercitado pelo cidadão e não por associações ou pessoas jurídicas ou, ainda, pelo Ministério Público. Tal circunstância, entretanto, não impede que vários cidadãos litisconsorciem-se para a propositura de um único processo.

5.5.4 Desapropriação

O artigo 216 da CF estabelece que:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...].

O inciso V do referido artigo inclui dentre os bens que formam o patrimônio:

[...] os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

O § 1º determina que:

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

É inegável, portanto, que o meio ambiente está arrolado no interior do conceito de patrimônio cultural brasileiro, inclusão esta que não se choca com o *caput* do artigo 225 da CF. Destarte, razoável e lógico que a desapropriação seja mais um dos vários instrumentos de Direito Ambiental. A desapropriação, *in casu*, não poderá

afastar-se do princípio geral estabelecido no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição. A desapropriação com finalidade de proteção do meio ambiente, utilidade pública, deverá ser precedida de indenização em dinheiro, conforme preceitua a CF.

5.5.5 Tombamento

Embora não se trate de uma medida judicial de proteção ao meio ambiente, entendi que seria conveniente a colocação do tema *tombamento* no interior do presente capítulo, tendo em vista que a matéria guarda estreita relação com a defesa judicial do meio ambiente, sobretudo em razão da ampla possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos.

O tombamento é a declaração de valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais que, por tal motivo, mereçam a preservação pelo Poder Público. O tombamento é ato administrativo de exclusiva atribuição do Poder Executivo, seja este federal, estadual ou municipal. Isso não quer dizer que o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário não possam, em concreto, declarar que determinados bens mereçam proteção especial do Estado. O que ocorre é que, em tais casos, *ipso iure*, não se pode falar em *tombamento*. O que poderá haver é a proteção em decorrência de lei ou de decisão judicial. Não haverá, porém, tombamento, que é ato administrativo típico.

Após efetuada a declaração da existência dos valores anteriormente referidos, deve ser o bem inscrito em livro próprio – o *livro tombo*. No Brasil, esse instituto jurídico (o tombamento) tem sede constitucional no § 1º do artigo 216. Hely Lopes Meirelles (1989, p. 484-485) sustenta que o tombamento não é uma forma adequada para a proteção do meio ambiente, conforme deixa ver a seguinte passagem:

Ultimamente o tombamento tem sido utilizado para proteger florestas nativas. Há equívoco neste procedimento. O tombamento não é o instrumento adequado para a preservação da flora e da fauna. As florestas são bens de interesse comum e estão sujeitas ao regime legal especial estabelecido pelo Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15/9/1965), que indica o modo de preservação de determinadas áreas florestadas [...]. O mesmo ocorre com a fauna, que é regida pela Lei da Fauna (Lei nº 5.197, de 3/1/1967), os quais indicam como preservar as espécies silvestres e aquáticas [...]. Portanto, a preservação das florestas e da fauna silvestre há de ser feita com a criação de parques nacionais, estaduais e municipais ou de reservas biológicas, como permite expressamente o Código Florestal (art. 5º).

A questão fundamental que deve ser examinada na matéria em foco é a seguinte: quais as consequências que o ato de tomar um bem ambiental poderá acarretar para o proprietário do mesmo, caso este se encontre submetido ao regime jurídico de Direito Privado e tenha um proprietário? É a partir dessa indagação que se poderá examinar a pertinência ou não do tombamento. Como se sabe, o tombamento implica um regime de controle bastante estrito do Estado sobre o bem tombado, ainda que o mesmo permaneça sob o mesmo regime jurídico que detinha antes do tombamento. Ora, o tombamento, muitas vezes, implica esvaziamento do valor econômico do bem e, nesse caso, haverá verdadeira desapropriação indireta e, em assim sendo, o proprietário deverá ser indenizado.

Outra questão que nos parece extremamente complexa é que, com o tombamento, a área ambiental tombada passará ao regime de supervisão e controle do patrimônio histórico, o que é, evidentemente, um contrassenso.

¹ “O prazo prescricional da ação não está sujeito ao arbítrio das partes. A cada ação corresponde uma prescrição, fixada em lei. A prescrição definida no art. 27 do CDC é especial em relação àquela geral das ações pessoais do art. 177 do CC/16. Não houve revogação, simplesmente, a norma especial afasta a incidência da regra geral (LICC, art. 2º, § 2º). A prescrição da ação de reparação por fato do produto é contada do conhecimento do dano e da autoria, nada importa a renovação da lesão no tempo, pois, ainda que a lesão seja contínua, a fluência da prescrição já se iniciou com o conhecimento do dano e da autoria” STJ. REsp 304724/RJ. 3ª Turma. *DJU* 22/8/2005, p. 259. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros.

RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS

6.1 INTRODUÇÃO

Aquele que causa um dano a terceiro deve arcar com os custos do malefício causado, de forma proporcional ao sofrimento ou prejuízo imposto ao terceiro. Em termos de proteção ambiental, existem diferentes modalidades de responsabilidades ambientais. Primeiramente, as responsabilidades por lesões ao meio ambiente se dividem em três grandes grupos:

- i) penal;
- ii) civil;
- iii) administrativa.

Embora a Constituição Federal tenha mencionado no § 3º do artigo 225 a existência de uma tríplice responsabilidade ambiental, no âmbito da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, ela não é unitária, como pretende boa parte da doutrina e da jurisprudência. Na verdade, muito embora o discurso ambiental esteja fundado em holismo e unitarismo, o fato é que as políticas públicas de proteção ao meio ambiente se fazem por leis específicas, as quais estabelecem sistemas próprios de responsabilidade que, em muitos casos, se apartam do modelo estabelecido pela Lei da PNMA que deve ser concebido como um modelo geral, dada a natureza de lei geral ostentada pela PNMA, ficando claro que, havendo uma lei especial, esta deve se aplicar ao caso concreto, afastando-se a lei geral.

6.2 A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de *status* constitucional. A Constituição estabeleceu uma tríplice responsabilização a ser aplicada aos causadores de danos ambientais, conforme se pode observar do artigo 225, § 3º, da CF. A responsabilidade é bastante abrangente e pode ser aplicada a: (i) pessoas físicas e (ii) pessoas jurídicas, e se subdivide em (i) penal; (ii) administrativa e (iii) civil.

Muito embora a Constituição não defina se o regime de responsabilidade é objetivo ou subjetivo, a lei da PNMA definiu-o como objetivo e, portanto, independente de culpa, como se depreende do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

No âmbito internacional, a Declaração do Rio, em seu Princípio nº 13, determina que:

Cada Estado deverá estabelecer sua legislação nacional no tocante a responsabilidades e indenizações de vítimas da poluição e de outras formas de agressão ao meio ambiente. Além disso, os Estados deverão cooperar na busca de uma forma expedita e mais determinada de desenvolver a legislação internacional adicional referente a responsabilidades e indenizações por efeitos adversos de dano ambiental causado por atividades dentro de sua jurisdição ou controle a áreas fora de sua jurisdição.

O CC, em seu artigo 927, instituído pela Lei nº 10.406/2002, deu um novo tratamento geral para atividades que, por sua natureza, possam implicar risco para terceiro, diferindo do CC de 1916.

6.3 AS RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS

Embora muito se tenha escrito sobre responsabilidade ambiental, o fato é que ainda estamos longe de compreendê-la em todas as suas dimensões. O meio ambiente é tema cujas fronteiras não estão bem delineadas e, conseqüentemente, os seus limites jurídicos também não. Por uma opção metodológica e, de certa maneira, seguindo a organização constitucional, a responsabilidade ambiental decorrente da atividade nuclear não será examinada neste capítulo, embora não se possa, em tese, afastá-la do presente tema.

6.3.1 Culpa como fundamento da responsabilidade

A primeira ideia que deve ser associada à de responsabilidade é a da *compensação equivalente* pelo dano sofrido. Tal compensação, contudo, tem passado por diferentes etapas e concepções e, por isso, sua evolução não é linear. Conforme aponta o Professor Caio Mário da Silva Pereira (1990, p. 6):

Na origem [do Direito Romano], porém, a ideia predominante é a vingança privada, no que, aliás, não se distanciam as civilizações que o precederam.

José Cretella Jr. (1980, p. 6-7) aponta que responsabilidade indica o cognato resposta, ambos alicerçados na raiz *spond* do verbo latino *respondere*, que significa responder. A responsabilidade é um dos temas mais importantes e fundamentais do Direito; de fato, é um dos elementos mais marcantes para que se julgue a eficácia ou ineficácia de um sistema jurídico, bem como as finalidades sociais deste. O ingresso da culpa no Direito moderno foi uma consequência do Cristianismo, pois o antigo Direito Romano não conheceu a noção de culpa. É certo que a chamada Lei Aquiliana introduziu no Direito Romano alguns princípios que poderiam ser tidos como precursores da moderna noção de culpa. Contudo, a influência ideológica da Igreja é que foi determinante para que, a partir da noção de pecado, fizesse-se necessária a indagação quanto à intenção culpável de alguém.

Na modernidade, com o desenvolvimento da noção de sujeito, da vontade livre e soberana, o conceito jurídico de culpa tornou-se mais importante, pois, como se sabe, um dos alicerces essenciais da construção jurídica do sujeito é, precisamente, a manifestação livre de vontade e, portanto, do subjetivismo psicológico.

O responsável pelo dano tem o dever de repará-lo o mais amplamente possível. Reparar o dano significa a busca de determinado valor que se possa ter como “equivalente” ao dano causado. A doutrina jurídica tem reconhecido que: [...] *mesmo uma pequena inadvertência ou distração obriga o agente a reparar o dano sofrido pela vítima* (GONÇALVES, 1988, p. 176).

A reparação visa fazer com que o lesado, através do recebimento de uma indenização, seja recolocado no *status quo ante*, como se a lesão não houvesse ocorrido. Essa é uma concepção teórica, pois, na maior parte das vezes, é impossível a reconstrução da realidade anterior: *e. g.*, morte de uma pessoa, destruição de

uma obra de valor histórico, artístico ou paisagístico; extinção de uma espécie animal etc. Existem bens que são *únicos e*, nessa qualidade, são insubstituíveis. Não há indenização capaz de substituí-los. Em termos de reparação de danos ambientais, não raras vezes, questões similares colocam-se com extrema dramaticidade.

Tradicionalmente, como já foi visto acima, o fundamento da responsabilidade é a culpa. O Código Napoleão, que é considerado como o grande monumento da ordem jurídica liberal, consagra amplamente a culpa como o elemento central de toda responsabilidade. É o *Code Civil* o reconhecimento e o coroamento de uma nova racionalidade que se afirmou, tendo como seu epicentro o indivíduo e a sua vontade que, desde então, ocupam o papel central na cena jurídica. O consagrado historiador do Direito, Franz Wieacker (1980, p. 386), assim resumiu a importância do CC de 1804:

Todos [...] foram ultrapassados pelo enorme impacto formal e de conteúdo do Code Civil de 1804. Também o grande CC da França nasceu da crença jus racionalista na lei. No entanto, a sua estrutura interna e a sua imagem do Direito foram sobretudo promovidas pela revolução e pelo brilho da grandeza napoleônica. A codificação francesa já não constitui um resultado do absolutismo esclarecido, mas, nos seus primórdios, a própria obra duma nação revolucionária e, mais tarde, do seu grande tribuno, o primeiro cônsul Bonaparte. A emoção da soberania popular agora recém-reconquistada e a participação do citoyen também influenciam decisivamente a sua expressão espiritual.

É, sem dúvida, unânime, entre os principais historiadores do Direito, o reconhecimento do papel fundamental desempenhado pelo CC francês na construção da racionalidade burguesa e do moderno direito burguês. John Glissen (1988, p. 536) ensina-nos que:

Colocamos o Code Civil de 1804 no centro de nossa exposição histórica, desenvolvendo, por um lado, a evolução de cada instituição civil desde a época romana até 1804 e, por outro, a sua evolução desde então. Uma vez que ainda está, em larga medida, em vigor, quer na Bélgica, quer em França – e, indiretamente, em muitos outros países –, o Código continua a ser uma etapa importante da história do Direito, mas, embora ponto de suspensão depois de quinze séculos de evolução desde a época romana, o Code não foi um ponto de paragem [...]

A ordem jurídica do capitalismo, como se sabe, está fundada na possibilidade que cada indivíduo goza de participar do mercado na qualidade de vendedor ou de comprador de mercadorias. Em outras palavras, do ponto de vista do Direito, cada indivíduo pode trocar produtos com os demais integrantes da sociedade. A economia de mercado necessita, para a sua reprodução, de uma rápida circulação de bens e produtos. A circulação, entretanto, não é aleatória, pois as trocas fazem-se entre equivalentes. O Direito, através de sua normatização, cria mecanismos capazes de reduzir todos os bens a um denominador comum, que é a livre expressão da vontade no mercado. Assim, os integrantes da sociedade, independentemente de sua posição social ou econômica, igualam-se no momento em que podem expressar *livremente* suas vontades.

O princípio da troca equivalente é o princípio fundamental das relações jurídicas que se dão entre os diversos sujeitos de Direito. No próprio Direito Penal, o princípio do qual falamos é essencial. A fixação de penas predeterminadas para os crimes implica o reconhecimento de uma certa equivalência entre um ato nocivo praticado pelo criminoso e o castigo que lhe é imposto pela sociedade: a pena. A responsabilidade civil fundada na culpa é, igualmente, um instrumento de equivalências.

A culpa é a violação de um dever jurídico. Tradicionalmente, pode ser dividida em contratual ou extracontratual, esta última também conhecida como aquiliana. A culpa contratual surge da violação de um dever estabelecido em contrato. A sua origem, portanto, é a inobservância de uma regra estabelecida pela própria vontade das partes. A culpa aquiliana funda-se na inobservância de um dever legal preexistente a qualquer ato privado, a qualquer manifestação de vontade das partes diretamente envolvidas.

Para que a culpa possa ser imputada a alguém, é necessário que o seu ato, o ato danoso a outrem, o ato lesivo, tenha sido praticado sem que se tenham tomados os necessários cuidados para evitá-los. Trata-se daquilo que se tornou conhecido como a diligência do “bom pai de família”, ou seja, dos cuidados razoavelmente exigíveis de uma pessoa. É a violação de um dever por inexperiência, negligência, sem nenhuma intencionalidade e tampouco por caso fortuito que causa danos a terceiro; obriga ao ressarcimento (PARISI e RINOLDI, 1989, p. 48-49).

No direito brasileiro, a responsabilidade é um antigo instituto jurídico. O CC brasileiro sofreu grande influência da doutrina contida no Código Napoleão, fundando a responsabilidade na ideia de culpa e em todos os conceitos ideológicos subjacentes à referida subjetivação. A matéria, no Código, está tratada ao longo de dois artigos; no artigo 43, está regulada a responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito público. O outro artigo de nosso CC dedicado ao assunto é o 927.

A responsabilidade civil fundada em culpa, do ponto de vista da estrutura econômica, corresponde a uma determinada etapa do desenvolvimento, na qual não existiam as produções em grande escala, a máquina a vapor, as comunicações por telégrafo e as vias férreas trouxeram uma grande modificação na escala produtiva, pois os acidentes passaram a fazer parte da rotina da atividade industrial e produtiva, muito mais do que anteriormente. Esse conjunto de fatos implicaram profundas transformações no Direito em geral.

O Código Napoleão, em sua estrutura fundamental, bem como os demais códigos que seguiram o seu modelo, é incapaz de regular as relações industriais. A sua concepção é a do capitalismo comercial e de uma grande base agrária. Os seus institutos são orientados para uma realidade produtiva de unidades pequenas e quase sempre familiares. A industrialização ocorrida no século XIX, em suas repercussões jurídicas, levou ao surgimento de toda uma série de setores especializados do Direito, setores estes que passaram a não estar submetidos às normas do Direito comum (civil). Nas palavras de François Ewald (1987, p. 225): “*As categorias do Direito Civil eram insuficientes para resolver os problemas postos pela industrialização*”.

6.3.2 A responsabilidade por risco

O abandono da culpa como fundamento da responsabilidade não se fez de uma forma linear e sem maiores complicações político-ideológicas e técnico-jurídicas. Isso porque, no regime jurídico da responsabilidade por culpa, existe toda uma necessidade de que a vítima prove a culpa do causador do dano, uma vez que culpa não se presume. Processualmente, cabe àquele que reivindica a reparação fazer a prova para que, finalmente, possa ser indenizado. Essa circunstância torna bastante complexo e difícil o trabalho a ser desenvolvido pelo autor da demanda, beneficiando o réu. Não basta que se prove o fato; é necessário, também, que se prove a ação culposa de seu causador; que se prove que o causador do dano não agiu com a prudência de um *bom pai de família*.

A culpa, ex-grande estrela dos códigos civis modernos, não impressiona mais. A redução da importância da culpa é fenômeno que se verifica em todo o mundo industrializado, como uma das consequências da própria industrialização. O estado moderno, diante das repercussões da industrialização, fez algumas opções políticas, visando a mitigar-lhe os efeitos sociais. O já citado François Ewald (s.d., p. 49) sustenta que a instituição de um regime de responsabilidade fundada no risco teve por finalidade a realização de uma tríplice liberação. A (i) liberação jurídica, afastando o exame de causalidade subjetiva dos danos; (ii) a liberação metafísica, pois a responsabilidade fundava-se em preceitos estabelecidos em lei, nada mais. E, por fim, (iii) uma liberação política, pois a responsabilização não mais se confundia com um ato caridoso, mas como imposição legal e, portanto, expressando uma vontade social.

A atividade industrial possui algumas características que eram absolutamente desconhecidas pelo antigo regime; tais características é que levaram à institucionalização de um novo regime legal, cujas características são inéditas.

6.3.2.1 Responsabilidade por risco em matéria ambiental

Muito embora exista uma cláusula geral de responsabilidade subjetiva no Direito brasileiro, o parágrafo único do artigo 927 do CC admite que a responsabilidade objetiva possa decorrer em função do risco da atividade.

Existe julgado do STJ (REsp 442586/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. 1ª Turma. DJU 24/2/2003, p. 196) considerando a responsabilidade ambiental derivada do *risco integral*. Penso ser importante chamar a atenção para o fato de que a responsabilidade por risco integral não pode ser confundida com a responsabilidade

derivada da só existência da atividade. Explico-me melhor: não se pode admitir que um empírico que tenha sido vitimado por fato de terceiro passe a responder por danos causados por este terceiro, como se lhes houvesse dado causa. Responsabilidade por risco integral não pode ser confundida com responsabilidade por fato de terceiro, que somente tem acolhida em nosso Direito quando expressamente prevista em lei. Conforme a adequada lição de Vénosa (2005, p. 79), *in verbis*:

A responsabilidade emerge com o ato danoso das pessoas enumeradas. No entanto, os terceiros somente podem, em princípio, ser responsabilizados se o ato foi praticado por culpa do autor material do dano ou do autor direto, ao menos nas hipóteses em que estamos tratando.

As diferentes hipóteses deverão ser examinadas de forma casuística, visto que enorme gama de possibilidades impede, *ipso facto*, a construção abstrata de uma teoria geral aplicável.

6.3.2.1.1 Poluidor indireto e responsabilidade objetiva

No caso em que a poluição seja imputada indiretamente a um determinado agente, torna-se possível a aplicação da responsabilidade objetiva? O cerne da questão está centrado no *conceito de poluidor indireto*. De fato, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a PNMA, estabelece que:

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV – *poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;*

A definição de poluidor indireto é um dos temas mais controversos do Direito Ambiental brasileiro e, seguramente, não há um consenso doutrinário ou jurisprudencial quanto à extensão do conceito. Existem algumas decisões judiciais emanadas do STJ que, em meu entendimento, *dão ao conceito de poluidor indireto uma abrangência bastante grande* (REsp 604725/PR. Relator: Ministro Castro Meira. 2ª T. DJU 22/8/2005, p. 202). No mesmo sentido é a seguinte decisão: REsp 467212/RJ. Relator: Ministro Luiz Fux. 1ª Turma. DJU 15/12/2003, p. 193. O STJ entende que o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a responsabilidade é solidária entre o poluidor direto e indireto (REsp 1079713. Relator: Ministro Herman Benjamin. 2ª Turma. DJe 31/8/2009).

Ao nível dos tribunais de segunda instância, sejam federais, sejam estaduais, as decisões marcham no mesmo sentido daquelas acima já apontadas, senão vejamos a seguinte decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Paraná, *in verbis*: “Na ação civil pública, que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, pode o juiz, nos próprios autos, determinar o cumprimento da prestação devida, ou cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária (artigo 11 da Lei 7.347/85). A ação, por danos ao meio ambiente, pode ser proposta contra o responsável direto, contra o responsável indireto, ou contra ambos (artigo 3º, IV, da Lei 6.898/91), em litisconsórcio passivo facultativo. Proposta contra o responsável direto, descabe denunciação da lide ao provável culpado pela lesão ambiental, desde que o regime da reparação do dano ambiental transite no âmbito da responsabilidade objetiva (artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81). 4. Se a pretensão indenizatória está aprisionada aos limites dos gastos efetuados para a recomposição ecológica, e essa recomposição ocorreu naturalmente, sem qualquer despesa adicional, injurídico condenar a poluidora em causa de pedir diversa da constante da peça de ingresso (artigo 128 do CPC) (Apelação Cível nº 71230-3, de Cambé – Vara Cível. Apelantes: 1. Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. 2. Ministério Público do Estado do Paraná. Apelados: 1. Município de Cambé. 2. Ministério Público do Estado do Paraná. 3. Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. Relator: Airvaldo Stela Alves – Juiz Convocado).

Em igual sentido é a decisão do TRF da 4ª Região, cuja ementa se passa a transcrever: ...1. A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável direto, o responsável indireto ou contra ambos, pelos danos causados ao meio ambiente, por se tratar de responsabilidade solidária, a ensejar o litisconsórcio facultativo. 2. A omissão do Poder Público no tocante ao dever constitucional de assegurar proteção ao meio ambiente não exclui a responsabilidade dos particulares por suas condutas lesivas, bastando, para tanto, a existência do dano e nexos com a fonte poluidora ou degradadora. Agravo parcialmente provido (AG 9604633430/ SC. 3ª Turma. DJU 29/9/1999. p. 640. Relatora: Juíza Vivian Josete).

Em meu ponto de vista, a *excessiva* ampliação do conceito de poluidor indireto pode implicar uma verdadeira *indução à não responsabilização* dos proprietários de atividades poluentes que, de uma forma ou de outra, se encontrem vinculados a cadeias produtivas maiores, haja vista que a responsabilidade se transferirá automaticamente para aquele que detenha maiores recursos econômicos, como é o caso, por exemplo, dos aterros industriais destinados à guarda e destinação final de resíduos sólidos; o que, para a proteção ambiental, é a pior solução possível, pois implicaria maior degradação ambiental e a inviabilização prática do sistema de disposição final de resíduos sólidos. Contudo, a mudança da orientação jurisprudencial, até onde se sabe, ainda é uma mera aspiração. Ressalte-se o fato de que a ambiguidade dos termos da lei é um convite à insegurança e à proliferação de decisões imprevisíveis.

A imposição de responsabilidade por danos tem como um de seus fundamentos estabelecer uma pressão econômica sobre o causador do dano, de forma que a atitude preventiva seja mais racional do ponto de vista econômico do que deixar à sorte a prevenção de danos. Assim, se faz necessário que aquele que tenha investido na prevenção de danos possa ter a sua responsabilidade reduzida em relação àquela do agente que não se preocupa com medidas preventivas. Com efeito, estabelecer a mesma obrigação de reparação independentemente do nível concreto de culpa envolvido é, em minha opinião, incentivar o descompromisso com a prevenção, pois qualquer que seja a medida preventiva adotada, ela terá pouca repercussão na diminuição dos efeitos financeiros que possam recair sobre o poluidor indireto.

6.3.2.1.1.1 Concepção maximalista de poluidor indireto: Responsabilidade objetiva da Administração por omissão?

A orientação da 2ª Turma do STJ (REsp 1071741/SP. 2ª Turma. DJe 16/12/2010) tem sido no sentido de assumir concepção maximalista da responsabilidade ambiental, conforme deixa ver o seguinte trecho de aresto: “4. Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação *in integrum*, da prioridade da reparação *in natura*, e do *favor debilis*, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ. 5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da CF, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microsistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um *standard* ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional. 6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da PNMA (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). 7. Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação ‘os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, designados para as atividades de fiscalização’, além de outros a que se confira tal atribuição. 8. Quando a autoridade ambiental ‘tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade’ (art. 70, § 3º, da Lei 9.605/1998). 11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer ‘pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). 12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer; quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar; quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 13. A Administração é solidária, objetiva e

ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. 14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência). 15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do CC), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC)..." (Ministro Herman Benjamin).

A decisão, é desnecessário dizer, é relevantíssima e merece comentário. Reconhece o Tribunal, com razão, que a responsabilidade ambiental (civil) no Brasil é de natureza objetiva e solidária. Contudo, a responsabilidade ambiental se manifesta de diferentes formas, dependendo da área do Direito Ambiental que esteja sendo tratada, dependendo do sujeito passivo da obrigação ambiental e de uma série de outros fatores que restaram intocados no bem lançado Acórdão. Com efeito e com o devido respeito, a Corte legislou, inclusive, em matéria constitucional.

É princípio elementar do direito constitucional que a Constituição é una e deve ser interpretada harmonicamente, não havendo contradição entre os seus diferentes artigos, como tem decidido com frequência o STF (ADI 2650/DF. Julgamento: 24/08/2011; Pleno; DJe-218 16/11/2011; Public. 17/11/2011):

Esse problema hermenêutico deve ser evitado por intermédio de interpretação que dê a mesma solução para ambos os casos, sob pena de, caso contrário, se ferir, inclusive, a isonomia entre os entes da federação. O presente caso exige, para além de uma interpretação gramatical, uma interpretação sistemática da Constituição, tal que se leve em conta a sua integralidade e a sua harmonia, sempre em busca da máxima da unidade constitucional, de modo que a interpretação das normas constitucionais seja realizada de maneira a evitar contradições entre elas (Ministro Dias Toffoli).

Ora, a CF dispõe da seguinte maneira sobre a responsabilidade da administração e sobre a responsabilidade ambiental:

Responsabilidade ambiental da administração na Constituição	
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.	Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Como se depreende do contraste entre os dois mandamentos constitucionais, resulta claro que a interpretação harmônica e integradora entre ambos só pode ser uma: as entidades integrantes da administração pública responderão por danos ao meio ambiente, na forma da responsabilidade especificamente determinada pela própria Constituição para a responsabilidade da Administração que, nos termos constitucionais, é regida por normas próprias, não se confundindo com o regime estabelecido pela Lei nº 6.938/1981, haja vista que tratada pela CF. Tal responsabilidade, quando decorrente de omissão, como reconhecido pelo Acórdão, é subjetiva. Com efeito, a moderna Teoria Constitucional não comporta a afirmação de que:

[...] a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da CF, enfrenta **duas exceções principais**. Primeiro, **quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal**, em microsistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, **quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional**.

Como se admitir que uma lei ordinária ou complementar possa estabelecer exceções a uma regra prevista diretamente no texto constitucional, sem qualquer reserva de possível exceção? Como se admitir que a presença de um padrão a ser oposto à Administração pública mais rigoroso do que aquele previsto na própria Constituição? Com o devido acatamento, ousamos discrepar do Acórdão. Averte-se que, no caso concreto, *sequer a responsabilidade estabelecida pelo § 3º do artigo 225 da CF é necessariamente objetiva*, a objetivação da responsabilidade foi uma opção do legislador ordinário. Assim, cuida-se de uma verdadeira anomalia pretender se impor, à Administração Pública, um regime de responsabilidade diverso daquele expressamente contemplado na Carta Política, como parece ser a concepção que fundamenta o Acórdão ora examinado.

Não existe uma única responsabilidade ambiental no direito brasileiro, isto porque a proteção ao meio ambiente se faz por meio de normas legais de natureza setorial, cada qual definindo um regime peculiar de responsabilidade. A Lei nº 6.938/1981 é aplicável apenas às hipóteses nas quais não exista uma norma específica de responsabilidade. Resumidamente, podemos encontrar no direito brasileiro as seguintes modalidades de responsabilidades ambientais:

Lei nº 6.766/1979	Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato <i>inter vivos</i>, ou por sucessão causa mortis, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado. Art. 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.
Lei nº 6.938/1981	Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...]

	V – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
Lei no 9.966/2000	Art. 21. As circunstâncias em que a descarga, em águas sob jurisdição nacional, de óleo e substâncias nocivas ou perigosas, ou misturas que os contenham, de água de lastro e de outros resíduos poluentes for autorizada não desobrigam o responsável de reparar os danos causados ao meio ambiente e de indenizar as atividades econômicas e o patrimônio público e privado pelos prejuízos decorrentes dessa descarga. [...] Art. 23. A entidade exploradora de porto organizado ou de instalação portuária, o proprietário ou operador de plataforma ou de navio, e o concessionário ou empresa autorizada a exercer atividade pertinente à indústria do petróleo, responsáveis pela descarga de material poluente em águas sob jurisdição nacional, são obrigados a ressarcir os órgãos competentes pelas despesas por eles efetuadas para o controle ou minimização da poluição causada, independentemente de prévia autorização e de pagamento de multa. Parágrafo único. No caso de descarga por navio não possuidor do certificado exigido pela CLC/69, a embarcação será retida e só será liberada após o depósito de caução como garantia para pagamento das despesas decorrentes da poluição. Art. 25. São infrações, punidas na forma desta Lei: [...] § 1º Respondem pelas infrações previstas neste artigo, na medida de sua ação ou omissão: I – o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o represente; II – o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou operado pelo proprietário; III – o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo; IV – o comandante ou tripulante do navio; V – a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar; VI – o proprietário da carga.
Lei nº 11.105/2005	Artigo 2º, § 4º: “As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação”.
Lei nº 7.802/2008	Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, o transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: (a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida; (b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas; (e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente; (f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos. Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar ou prestar serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além da multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3

Lei nº 12.305/2010	(três) anos, além da multa de 50 (cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR. Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. § 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. [...] Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; [...] Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução. [...] Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: I – investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos: (a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada; (b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; II – divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; III – recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33; IV – compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não incluídos no sistema de logística reversa. [...] Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: I – adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; II – estabelecer sistema de coleta seletiva; III – articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; IV – realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; V – implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; VI – dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. [...] Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento.
----------------------------------	---

Como se pode ver, o direito brasileiro consagra, mesmo em matéria ambiental, um amplo leque de normas sobre responsabilidade, as quais deverão se aplicar preferencialmente àquela prevista na Lei nº 6.938/1981 sempre que o fato que tenha dado origem à obrigação esteja disciplinado em norma própria. Penso já ser tempo para que, à semelhança do que se contém no CTN, crie-se um sistema de responsabilidade claro e inequívoco, inclusive com a hipótese de exoneração de responsabilidade, mediante denúncia espontânea, como forma de que se descubram os inúmeros “esqueletos ambientais” que existem em nosso País. À guisa de complementação, ver o fato de que, por exemplo, a Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Chile), Lei nº 19.399, de 1º de março de 1994, com as emendas da Lei nº 20.417, de 13 de novembro de 2010, estabelece o seguinte:

Artículo 51. Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del CC.

6.3.2.1.2 A inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova é medida excepcional e não deve ser adotada sem que exista uma forte razão para tal. A Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/1985 – não dispõe expressamente sobre a matéria. Contudo, há que se observar que o Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078/1990, em seu artigo 117, determinou a inclusão do artigo 21 na Lei da Ação Civil Pública, mediante o qual é aplicável à Ação Civil Pública o Título III do Código de Defesa do Consumidor. *A matéria da inversão do ônus da prova não está tratada em tal Título.* Na verdade, a inversão do ônus da prova é matéria tratada nos direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O atual Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, § 1º, que nos casos em que haja previsão legal ou “peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Todavia, o § 2º do mesmo artigo estabelece que a inversão do ônus da prova “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça fez editar a súmula 618 que estabelece que “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

Há importante decisão do STJ (REsp 1060753/ SP. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. DJe 14/12/2009), a qual faz uma mescla de princípio da precaução com a inversão do ônus da prova em matéria de execução fiscal. Muito embora a decisão da Corte tenha sido bastante apropriada para o caso concreto, o caminho do seu raciocínio poderá acarretar relevantes consequências práticas, a se confirmar tendência hoje existente. Colho a seguinte passagem da ementa: “*O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. 4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da Internet. 5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano*”.

Sabe-se que em matéria de execução fiscal, qualquer que seja a matéria de fundo, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado desconstituí-la mediante a produção de prova adequada. Veja-se que, muito embora a origem da dívida seja uma possível infração à legislação de proteção ao meio ambiente, no caso concreto, a legislação ambiental é irrelevante para o deslinde do fato, pois o que se discute é a aptidão do fato para degradar o meio ambiente. Desnecessário, portanto, o recurso aos princípios do Direito Ambiental para dirimir a controvérsia, haja vista que a inversão do ônus da prova decorre da legislação processual e não das normas próprias de proteção ao meio ambiente.

6.3.3 Responsabilidade de instituições financeiras

O Rio de Janeiro sediou, nos dias 14 e 15 de março de 2002, a 4ª Reunião Anual da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se realizou no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Compareceram ao evento cerca de 350 representantes de diversas instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como dirigentes de diversos organismos internacionais dedicados à proteção ambiental e organizações não governamentais, como os Amigos da Terra e a União Internacional para a Conservação da Natureza, dentre outras.

O tema é extremamente novo e provocativo, embora seja visível que ele venha crescendo em importância a cada dia que passa. Entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Em primeiro lugar, é necessário que fique bem claro que riscos ambientais são riscos financeiros. Vários exemplos demonstram a veracidade da assertiva. Vejamos o caso do polêmico Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco. Como se sabe, há mais de 150 anos existem projetos com o objetivo de retirar uma pequena quantidade de água do Rio São Francisco e levá-la para o semiárido nordestino, como forma de amenizar a seca na região. O Governo Federal decidiu implementar um dos diversos projetos para a transposição das águas, programando investimentos de cerca de R\$ 3 bilhões, ou seja, o equivalente aos gastos governamentais nos dois últimos anos de seca rigorosa. O projeto nada mais era do que um conjunto de canais e bombas que, em caso de necessidade, faria a transposição de cerca de 3% da vazão do rio para as regiões mais duramente afetadas pela seca. Logo, não se tratava de uma retirada constante das águas do rio, porém de uma simples retirada em caso de necessidade extrema, a ser decidida por um conselho gestor, com participação comunitária. Teríamos, no caso, um aumento da segurança hídrica dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O desenvolvimento do projeto foi paralisado por força de uma liminar em ação civil pública que determinou a interrupção do procedimento de licenciamento ambiental, com a virtual suspensão do projeto até a próxima mudança de governo, ou enquanto perdurarem os efeitos da medida liminar. É indiscutível que a paralisação do projeto, do ponto de vista financeiro, implica uma enorme perda de recursos e, portanto, prejuízos. Posteriormente, em função de modificações no projeto original, a obra finalmente teve o seu início, não sem antes ter passado por inúmeras e complexas medidas judiciais que implicaram em fortíssimos riscos financeiros para o empreendimento.

As questões básicas referentes à transposição do Rio São Francisco foram resolvidas pelo STF (ACO 876 MC-AgR/BA, Julgamento: 19/12/2007, Tribunal Pleno, DJe-142) tempos depois: “*Agravo regimental. Medida liminar indeferida. Ação civil originária. Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Periculum in mora não evidenciado. 1. Como assentado na decisão agravada, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção da Bahia, AATR – Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, GAMBA – Grupo Ambientalista da Bahia, IAMBIA – Instituto de Ação Ambiental da Bahia, Associação Movimento Paulo Jackson – Ética, Justiça e Cidadania, PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e da AEABA – Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia, não detêm legitimidade ativa para a ação prevista no art. 102, I, “f”, da CF. 2. A Licença de Instalação levou em conta o fato de que as condicionantes para a Licença Prévia estão sendo cumpridas, tendo o Ibama apresentado programas e planos relevantes para o sucesso da obra, dos quais resultaram novas condicionantes para a validade da referida Licença de Instalação. A correta execução do projeto depende, primordialmente, da efetiva fiscalização e empenho do Estado para proteger o meio ambiente e as sociedades próximas. 3. Havendo, tão somente, a construção de canal passando dentro de terra indígena, sem evidência maior de que recursos naturais hídricos serão utilizados, não há necessidade da autorização do Congresso Nacional. 4. O meio ambiente não é incompatível com projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo como patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar que o meio ambiente pode ser palco para a promoção do homem todo e de todos os homens. 5. Se não é possível considerar o projeto como inviável do ponto de vista ambiental, ausente nesta fase processual qualquer violação de norma constitucional ou legal, potente para o deferimento da cautela pretendida, a opção por esse projeto escapa inteiramente do âmbito desta Suprema Corte. Dizer sim ou não à transposição não compete ao Juiz, que se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger o meio ambiente. 6. Agravos regimentais desprovidos (Ministro Menezes Direito)*”.

Outro exemplo bastante ilustrativo da situação é o da implantação de uma grande planta siderúrgica no Estado de Santa Catarina, cujos investimentos previstos montam a aproximadamente US\$ 420 milhões. Também nesse caso, em função de dificuldades de licenciamento ambiental, o projeto evoluiu em ritmo muito aquém do previsto no planejamento financeiro. Se considerarmos que, em face da expressividade dos valores envolvidos, existe uma engenharia financeira dando suporte ao projeto, com a participação de uma ou mais instituições de investimento, todo o planejamento delas, bem como a expectativa de retorno ficam prejudicados seriamente.

Mais recentemente, nas questões referentes ao desmatamento da Amazônia e à importância da concessão de crédito pelas instituições financeiras, foram ajuizadas diversas ações civis públicas pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de examinar se o crédito rural concedido atendia às determinações legais¹.

Os exemplos apresentados demonstram que, obviamente, as instituições financeiras, ao concederem os créditos para investimentos em projetos industriais, agrícolas ou outros, necessariamente, devem considerar a variável ambiental como um potencial elemento de risco para os seus negócios. Quanto maior o risco

ambiental, maior o risco do investimento. Inversamente, se os riscos ambientais forem reduzidos, menores serão os riscos financeiros do negócio. Há que se considerar que, da análise de risco ambiental, pode resultar uma considerável variação da taxa de juros. Além do risco do investimento, as instituições financeiras devem considerar que é crescente a tendência a responsabilizar os agentes financeiros por danos causados pelos mutuários. Há que se considerar que a Lei nº 6.938/81 (PNMA) criou a figura do *poluidor indireto*, que é todo aquele responsável indiretamente pela degradação ambiental (art. 3º, IV). Na esfera penal, a Lei nº 9.605, em seu artigo 2º, determina que incorre nas penas cominadas aos crimes ambientais “quem de qualquer forma” concorre para a sua prática. Por força de lei, portanto, há uma solidariedade passiva do agente financiador do empreendimento que degradou o meio ambiente.

A Lei da Política Nacional de Biossegurança estabelecida pela Lei nº 11.105/2005, estabelece no § 4º de seu artigo 2º que:

As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação.

É importante que se considere, ademais, que a responsabilidade ambiental vem ganhando contornos próprios. Veja-se, por exemplo, a chamada responsabilidade pós-consumo, amplamente tratada pela Lei nº 12.305/2010. Essa é uma aplicação prática da chamada “*deep pocket doctrine*” (“doutrina do bolso profundo”), muito utilizada nos Estados Unidos e que, certamente, começará a ganhar notoriedade em nossas cortes judiciais.

Deep Pocket doctrine é um jargão forense que busca dar solução para os casos nos quais existem muitas responsabilidades solidárias e dificilmente se pode chegar à definição sobre “quão responsável é cada responsável”. Os tribunais, com vistas a não deixar que a vítima permaneça sem os devidos ressarcimentos, escolhem aquele que é o mais saudável financeiramente e transferem para ele toda a responsabilidade econômica decorrente da indenização. Essa tendência está bastante cristalizada em nossa jurisprudência, pois os tribunais seguidamente negam denunciação da lide em questões ambientais, afirmando que a discussão entre os possíveis responsáveis é matéria privada e que não pode retardar a reparação dos danos ao meio ambiente e o pagamento das respectivas indenizações.

É crescente o número de instituições financeiras que tem demonstrado preocupação com questões ambientais. A iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente conta com a colaboração de cerca de 200 instituições financeiras de todo o mundo². As instituições financeiras criaram um mecanismo denominado princípios do Equador, mediante o qual são estabelecidos critérios voluntários para a concessão de crédito, aos quais aderiram 70 instituições com duas associadas.

Aos 28 de fevereiro de 2008, o CMN expediu a Resolução nº 3.545. Tudo se iniciou com a revogada Circular Bacen nº 736/1982, editada há mais de 35 anos, na parte destinada ao crédito industrial e programas especiais, que dispunha que:

A liberação da última parcela do crédito, nos financiamentos de destilaria, somente poderá ser efetivada contra a apresentação, pelo mutuário, de comprovante emitido pelo órgão estadual de controle do meio ambiente atestando a conclusão da implantação do projeto de tratamento de efluentes.

Do mesmo modo, a Circular Bacen nº 1.268/1987, tem em suas disposições sobre crédito rural o seguinte:

o assessoramento técnico a nível de carteira e o técnico incumbido de elaborar o plano ou projeto devem verificar a adequação do empreendimento às exigências de defesa do meio ambiente.

O mesmo se diga em relação à Circular Bacen nº 1.351/1988, que dispunha sobre crédito agroindustrial que:

1 – O agente financeiro deve observar a legislação específica sobre controle da poluição do meio ambiente na concessão de financiamento a: a) projetos com atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras; b) empreendimentos capazes de causar degradação ambiental. 2 – O agente financeiro deve exigir do mutuário o compromisso expresso de: a) observar a legislação específica sobre controle da poluição do meio ambiente [...].

Talvez a resolução mais “ousada” sobre meio ambiente fosse aquela que tenha instituído plano de conversão da dívida externa para fins ambientais (Resolução Bacen nº 1.840, de 16 de julho de 1991).

Evidentemente que seria enfadonho e despropositado fazer uma relação de todas as circulares e resoluções do Conselho Monetário Nacional que determinam que as instituições de crédito façam observar a legislação de proteção ao meio ambiente. Em dever de justiça para com o Conselho Monetário Nacional, há que se registrar que, tão logo a Lei nº 6.938/81 entrou em vigor, o CMN já se manifestava sobre questões de controle ambiental, dentro das condições específicas de concessão de crédito.

A Resolução Bacen nº 3.545, portanto, não é “uma novidade”, quando muito, será um “aperfeiçoamento” de normas já presentes em nosso ordenamento jurídico. O curioso é que a Resolução é específica para o “Bioma Amazônia”, quando na verdade a lei que trata de restrições a financiamentos (6.938/81) é dirigida para todos os “biomas”. Mostra-se indubitável a observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE.

A Resolução tem como destinatários as instituições oficiais de crédito ou os bancos privados que sejam agentes financeiros de créditos públicos. A Resolução deverá ser observada “*obrigatoriamente a partir de 1ª de julho de 2008, e facultativamente a partir de 1ª de maio de 2008* para a concessão de crédito rural ao amparo de recursos de qualquer fonte para atividades agropecuárias nos municípios que integram o Bioma Amazônia, ressalvado o contido nos itens 14 a 16 do MCR 2-1. A norma estabeleceu os seguintes condicionamentos para a concessão dos créditos: (a) apresentação, pelos interessados, de: 1 – Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR vigente; 2 – declaração de que inexistem embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel; e 3 – licença, certificado, certidão ou documento similar comprobatório de regularidade ambiental, vigente, do imóvel onde será implantado o projeto a ser financiado, expedido pelo órgão estadual responsável [...]” Caso tais documentos não existam, poderá ser apresentado um atestado de recebimento da documentação exigível para fins de regularização ambiental do imóvel, emitido pelo órgão estadual responsável, ressalvado que, nos Estados onde não for disponibilizado em meio eletrônico, o atestado deverá ter validade de 12 (doze) meses.

Uma grande novidade que, no entanto, deve ser vista com muito cuidado é a quase transferência para o agente financeiro de um papel de fiscalização que, francamente, não é da atribuição de tais instituições:

verificação, pelo agente financeiro, da veracidade e da vigência dos documentos referidos na alínea anterior, mediante conferência por meio eletrônico junto ao órgão emissor, dispensando-se a verificação pelo agente financeiro quando se tratar de atestado não disponibilizado em meio eletrônico.

O item c, também, é bastante polêmico, pois impõe uma punição ao mutuário em caso de “*embargo do uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel, posteriormente à contratação da operação, nos termos do § 11 do art. 2º do Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999*”. Ora, o embargo não significa que a atividade seja ilegal; ele significa que ela foi embargada, nada mais. Quantos embargos ilegais existem? Em tal hipótese poderá haver a suspensão da “*liberação de parcelas até a regularização ambiental do imóvel e, caso não seja efetivada a regularização no prazo de 12 (doze) meses a contar da data da autuação, o contrato será considerado vencido antecipadamente pelo agente financeiro*”.

A Resolução está destinada apenas aos grandes proprietários, sendo excluídos expressamente a turma do Pronaf ou de produtores rurais que disponham, a qualquer título, de área não superior a 4 (quatro) módulos fiscais que deverá providenciar declaração atestando a existência física de reserva legal e área de preservação permanente, conforme previsto no Código Florestal, e a inexistência de embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel.

6.3.4 Responsabilidade ambiental das instituições de crédito imobiliário

O jornal *O Estado de S. Paulo* de 10 de abril de 2002 noticiou o fechamento de uma empresa na cidade de Bauru, em função de alegada contaminação de solo derivada de suas atividades com chumbo. No fim do ano de 2001, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo verificou grave contaminação do solo na área do Conjunto Residencial Barão de Mauá, no Parque São Vicente, município de Mauá. Em tal localidade existem 50 edifícios de apartamentos, servindo de residência para cerca de 5 mil pessoas. Acresce o fato de que mais 22 edifícios estão em fase de construção. No Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, também existem casos graves de contaminação do solo. Um dos mais antigos é o da Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, que é uma área pobre na Baixada Fluminense na qual uma comunidade se instalou sobre área que havia sido utilizada como depósito de produtos organoclorados (pó de broca – BHC), resultando daí inúmeros casos de doenças graves e morte na população local. No local, funcionava a antiga fábrica de BHC do extinto Serviço Nacional de Malária. O TRF da 2ª Região, em voto de lavra do eminente Desembargador Federal Dr. André Fontes, julgou procedente a ação movida pela comunidade em face da União e outros (TRF 2ª Região. Apelação Cível 103083. 6ª Turma. DJU 27/1/2005: “... I – A União possui legitimidade passiva e responsabilidade exclusiva em relação à ocorrência do evento danoso, uma vez que este ocorreu devido à inobservância do dever de cuidado por um órgão do Ministério da Saúde, nomeadamente o Instituto de Malariologia. II – Não há que falar em responsabilidade solidária de outros entes da Federação, da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), e da extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA), tampouco em responsabilidade regressiva de servidor público federal, sem a demonstração cabal de suas respectivas condutas culposas, ao se omitirem diante do dever de cuidado. III – Em razão do dano infecto, originado de um ilícito ambiental passado, cujos efeitos se protraem no tempo, é possível a responsabilização objetiva da União, por meio da aplicação do § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81 e ainda que assim não fosse, estaríamos diante da chamada culpa *in re ipsa* e do desrespeito, por parte da União, ao princípio da precaução e ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV – Mesmo que se discuta sobre a natureza objetiva ou subjetiva do critério de responsabilização, no caso sob análise, não restam dúvidas sobre a responsabilidade da União, uma vez que o abandono do produto químico em questão resultou ilícito civil, do qual decorreram efeitos naturalísticos, que causaram diversos danos passíveis de ressarcimento. V – Recurso parcialmente provido, para condenar a União a reparar o dano moral por eles sofridos, bem como a indenizá-los, em numerário que possibilite suas transferências para novas moradias”).

A repetição de tais situações tem por base o fato de que se tem verificado uma “desindustrialização”, em decorrência da transferência de empresas para outras regiões. Muitos são os fatores para que assim seja, dentre eles se destacam: urbanização desordenada, fazendo com que plantas industriais fiquem “ilhadas” por residências; incentivos fiscais oferecidos por outros Estados e Municípios; decisões corporativas que implicam o fechamento de determinadas unidades industriais etc. e, obviamente, falta de controle da qualidade do solo.

Em decorrência, muitas áreas industriais têm se transformado em áreas residenciais. Infelizmente, conforme foi visto, nem sempre o solo sobre o qual elas estão instaladas foi submetido à necessária auditoria.

Do ponto de vista da responsabilidade legal, parece-me que, em tese, tanto o antigo proprietário do terreno como o adquirente são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados aos terceiros de boa-fé que tenham adquirido as unidades habitacionais postas à venda no mercado. As instituições de crédito imobiliário que tenham financiado os projetos habitacionais podem ser incluídas no rol dos responsáveis solidários? A resposta é complexa. Permito-me um breve exame de algumas decisões judiciais sobre responsabilidade ambiental antes de expressar o meu ponto de vista.

A chave para que se possa responder à questão acima encontra-se no conceito legal de *poluidor indireto*. Com efeito, a Lei nº 6.938/1981, que instituiu a PNMA, em seu artigo 3º, IV, define que poluidor é toda aquela pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, pela degradação ambiental. O Poder Judiciário, desde o ano de 1988, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vem entendendo que: “O poluidor que causa dano ao ambiente tem definição legal e é aquele que proporciona, *mesmo indiretamente*, degradação ambiental. E o poluidor é sujeito ao pagamento de indenização, além de outras penalidades” (TJSP. 5ª Câmara Cível. Ap. nº 96.536-1. 7/4/1988). Ao longo dos anos, tal tendência vem se consolidando no STJ que tem se posicionado no sentido de que a mera alegação de que uma empresa tenha causado dano ao meio ambiente é suficiente para que a mesma seja admitida como ré em uma demanda judicial. Veja-se o seguinte aresto, cujo relator foi o Ministro José Delgado: REsp 232187/SP: DJU 8/5/2000, p. 67. *É parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública a pessoa jurídica ou física apontada como tendo praticado o dano ambiental. A Ação Civil Pública deve discutir, unicamente, a relação jurídica referente à proteção do meio ambiente e das suas consequências pela violação a ele praticada. Incabível, por essa afirmação, a denúncia da lide. Direito de regresso, se decorrente do fenômeno de violação ao meio ambiente, deve ser discutido em ação própria.* Além disso, o STJ vem entendendo que o simples fato de que uma empresa exerça atividades em uma área duramente atingida pela poluição é suficiente para que ela seja solidariamente responsável pela degradação ambiental, em princípio, cabendo-lhe, apenas, a ação de regresso contra aqueles que sejam os reais responsáveis pela degradação ambiental: RES 18567/SP. Relatora a Ministra Eliana Calmon. DJU 2/10/2000, p. 154. *A solidariedade entre empresas que se situam em área poluída, na ação que visa preservar o meio ambiente, deriva da própria natureza da ação. Para correção do meio ambiente, as empresas são responsáveis solidárias e, no plano interno, entre si, responsabiliza-se cada qual pela participação na conduta danosa.* Do voto da ilustre Ministra, merece ser ressaltado o seguinte trecho: *A solidariedade é um traço que identifica a ação civil pública como um instrumento que se dirige contra todos aqueles que estejam ligados por uma base comum, como por exemplo: as empresas que se situam na área industrial que sofreu poluição, solidariedade esta que, após a perícia, pode ser descartada em termos de responsabilidade patrimonial.*

É necessário que se faça a adequada correlação entre as decisões acima, com relação jurídica de compra e venda de imóveis. A aquisição de uma unidade habitacional que esteja construída sobre terreno contaminado é, efetivamente, a aquisição de um produto com defeito oculto, ou vício redibitório. Conforme seja o nível da contaminação verificada, tal defeito pode chegar ao ponto de tornar a coisa imprestável para a finalidade a qual se destina (habitação). Tal situação encontra previsão legal no CC (arts. 441 ss.) e no próprio Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 8º e 18). O reconhecimento judicial da responsabilidade do agente financeiro pelos defeitos ocultos de unidades habitacionais é tranquilo e não causa a menor dúvida entre os tribunais. Assim é que o STJ, ao decidir o REsp nº 51.169/ RS, relator o Ministro Ari Pargendler, entendeu que: *A obra iniciada mediante financiamento do Sistema Financeiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro pela respectiva solidez e segurança.*

Do conjunto de decisões judiciais que foram arroladas, resta estreme de qualquer dúvida o fato de que existe a responsabilidade solidária entre o agente financeiro, o construtor de imóvel e o incorporador, por empreendimentos construídos sobre terrenos contaminados ou em áreas que, por força de lei ou outro ato normativo, sejam consideradas como *non aedificandi*. Ao credor, cabe escolher qual dos devedores prefere executar com vistas a satisfazer o crédito que lhe é devido. A tendência à responsabilização das instituições financeiras é crescente, pois, como se sabe, tais instituições são mais sólidas e possuem uma estrutura capaz de arcar com custos de forma mais completa do que, em geral, as construtoras e incorporadoras imobiliárias.

Retomando a questão que foi colocada antes, não tenho qualquer dúvida em sustentar que, no caso concreto, é aplicável a figura do poluidor indireto que, conjugada com os chamados vícios redibitórios, em tese, induzem à responsabilização dos agentes financeiros em função de imóveis construídos sobre terrenos contaminados.

6.3.5 Crédito rural e meio ambiente: responsabilidade

Um importantíssimo caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Refiro-me à Apelação Cível nº 25.408, na qual foi apelante o Banco do Brasil e apelado o Ministério Público do Estado do Mato Grosso. A questão deduzida em juízo foi a seguinte: O MP do Estado do Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública (nº 8/99) em face do Banco do Brasil, objetivando compeli-lo a se abster de conceder qualquer financiamento agropecuário, empréstimo, incentivo financeiro de qualquer natureza ou que promova a securitização ou repactuação de empréstimos e financiamentos em favor de proprietários de imóveis rurais de área igual ou superior a 100 hectares que não comprovem, mediante certidão do registro de imóveis, que procederam à averbação da reserva prevista no artigo 44 da CF e, por certidão do órgão ambiental, que a vegetação da referida área encontra-se preservada ou em processo de recuperação, nos termos do artigo 99 da Lei nº 8.171/91. A ação civil pública tramitou perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, tendo sido julgada procedente, na forma do pedido, conforme

sentença lavrada pelo Juiz de Direito José Zuquim Nogueira.

O TJMT reformou *in totum* a decisão de primeiro grau, proferindo acórdão assim ementado: *Ação Civil Pública – Ministério Público – Procedência em 1ª grau – Financiamentos ou incentivos rurais – Exigência no cumprimento da Legislação Ambiental – Inexistência de obrigatoriedade – Sucumbência – Aplicação da Lei nº 7.347/85 – Recurso Provido: Inadmissível, especialmente quando não vem olvidando o Banco-apelante que nenhuma exigência legal protetiva do meio ambiente, responsabilizá-lo por uma possível ocorrência de dano ambiental. Embora digna de encômios, a atuação brilhante do representante do Ministério Público, não se pode deixar de reconhecer a gravidade da situação ambiental no país, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação civil pública* (Foi relator o Desembargador Benedito Pereira do Nascimento).

O TJMT, em síntese, entendeu que não cabe, ao agente financeiro, ao conceder empréstimo para a agricultura, verificar se estão sendo cumpridas as normas referentes à proteção e manutenção da RFL, tal como definidas no Código Florestal e na Lei de Política Agrícola. A 2ª Turma do STJ tem entendido que a RFL deve ser cumprida e que ela integra a própria propriedade florestal, conforme se pode ver da seguinte ementa: *Direito ambiental – Limitação à propriedade rural – reserva florestal – Exegese do art. 99 da Lei nº 8.171/91 – Obrigação de recomposição da área na proporção de 1/30, considerada a área total da propriedade. Não se trata, a reserva florestal, de servidão, em que o proprietário tem de suportar um ônus, mas de uma obrigação decorrente de lei, que objetiva a preservação do meio ambiente, não sendo as florestas e demais formas de vegetação bens de uso comum, mas bens de interesse comum a todos, conforme redação do art. 1º da CF. A única finalidade do art. 99 da Lei nº 8.171/91 foi a de estabelecer um prazo maior, que não o imediato, para que os proprietários procedessem à recomposição da área de floresta, não alterando em nada as demais disposições legais caracterizadoras do dever de recomposição de área de reserva legal, que se for feita a passos curtos jamais atingirá a finalidade da lei, no tocante à preservação do meio ambiente, que não pode ser visto como o conjunto de pequenas partes, mas o próprio todo. Recurso não concedido, porquanto não violado pelo aresto a quo o art. 99 da Lei nº 8.171/91*” (REsp 237.690/MS, REsp 1999/0101680-0, relator Ministro Paulo Medina).

A decisão do Tribunal Estadual, com todo o respeito, parece ter feito tábula rasa da determinação contida no artigo 12 da Lei nº 6.938/1981. É importante observar que a ACP movida pelo MPMT *não tinha por escopo que o Banco do Brasil fizesse controle ambiental*, mas, única e exclusivamente, que ele exigisse a comprovação da averbação da RFL. Ora, se os órgãos financiadores públicos estão obrigados a exigir o licenciamento ambiental e o cumprimento de padrões do Conama, com muito mais razão devem exigir o cumprimento da lei. Veja-se, em complemento, que o financiamento público somente pode ser concedido se no projeto constar previsão de melhoria da qualidade do meio ambiente. No caso concreto, evidentemente que é a recuperação das áreas de RFL, onde ela for inexistente. Acrescente-se o fato de que a perda de financiamentos públicos é uma penalidade a ser aplicada pelo Conama, por Resolução própria, àqueles que desrespeitam a legislação de proteção ao meio ambiente (art. 14, III, da Lei nº 6.938/81).

No caso em tela, o financiamento que, em tese, seria concedido pelo Banco do Brasil, está catalogado como *crédito rural*, cuja regulamentação está a cargo da Lei nº 4.829/1965. Ora, como se sabe, o *sistema nacional de crédito rural* é integrado pelo Bacen, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste por suas carteiras próprias.

Segundo o disposto no artigo 3º da Lei nº 4.829/65, o crédito rural tem os seguintes objetivos:

I – estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; II – favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e comercialização de produtos agropecuários; III – possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios; IV – incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo.

Ele é, portanto, *uma política pública* que, na forma do artigo 1º, “*será distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do povo*”. Ainda que muito anterior à CF de 1988, em linhas gerais o crédito rural atende aos ditames do artigo 225 de nossa CF, pois busca aprimorar o padrão de vida das populações rurais e a adequada defesa do solo (*rectius*: meio ambiente). A RFL é, como se sabe, um instrumento absolutamente necessário para a defesa do solo e, portanto, o financiamento a ser concedido com base na Lei nº 4.829/65 não pode deixar de levá-la em consideração. O crédito rural tem, evidentemente, uma natureza pública.

O TJMT, *data venia*, equivocadamente, entendeu que o MPMT estava exigindo que o concedente do crédito rural exercesse a função de órgão de controle ambiental ou de responsável pelo dano causado por terceiro. Em meu entendimento, tal não foi o pedido da ACP, mas, pura e simplesmente, que o Banco, ao celebrar o mútuo, exigisse certidão de averbação da RFL ou prova de que ela estava submetida a procedimento de recuperação. O pedido encontra, em minha opinião, ressonância em nossa ordem jurídica e, certamente, a matéria voltará a ser enfrentada pelos nossos tribunais. As instituições bancárias que atuam com crédito rural não devem tomar a decisão do egrégio TJMT como uma tendência definitiva de nossa jurisprudência, pois, conforme tentei demonstrar, o conjunto de normas legais sobre o assunto aponta em direção inversa àquela adotada pela egrégia Corte de Justiça do Estado do Brasil Central.

No que tange ao crédito rural, merece destaque a Resolução nº 4.107, de 28 de junho de 2012 do BACEN que “*altera as disposições do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), de que trata o Capítulo 10 do Manual de Crédito Rural (MCR), para aplicação a partir da Safra 2012/2013*” que em seu artigo 2º inclui entre os beneficiários do Pronaf: (i) pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou em regime de parceria com outros pescadores igualmente artesanais; (ii) aquicultores que se dediquem ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e que explorem área não superior a 2 (dois) hectares de lâmina d’água ou ocupem até 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanque rede; (iii) silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; (iv) extrativistas que exerçam o extrativismo artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores; (v) integrantes de comunidades quilombolas rurais; (vi) povos indígenas e (vii) demais povos e comunidades tradicionais, desde que atendidas determinadas condições.

Também a Política Nacional de Irrigação instituída pela Lei nº 12.757, de 11 de janeiro de 2013 no § 1º do artigo 23 estabelece que “[a]s instituições participantes do sistema nacional de crédito rural de que trata a Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, somente financiarão a implantação, a ampliação e o custeio de projetos de irrigação que detenham outorga prévia do direito de uso dos recursos hídricos.”

6.3.6 A tarificação da responsabilidade ambiental

A objetivação da responsabilidade, contudo, não é a única grande transformação pela qual passou o ancião instituto jurídico. O desenvolvimento das atividades comerciais e industriais, bem como o aumento das somas de capital envolvido em tais atividades, implicaram novas e importantes alterações na realidade jurídica da responsabilidade.

O reconhecimento do risco como fundamento da culpa é a negação da teoria do acidente, do acaso, da área tão falada pelos especialistas. A partir do momento em que a legislação reconhece o risco como fundamento da indenização, está, concomitantemente, reconhecendo a existência de uma previsibilidade na ocorrência de sinistros, de uma inevitabilidade dos mesmos, de uma rotina de acidentes. Esse fato tem evidentes consequências econômicas decorrentes do aumento dos custos das atividades perigosas em face da necessidade de pagamento das indenizações às vítimas.

Essas circunstâncias dão início a um processo contraditório, no qual, ao mesmo tempo em que se ampliam os campos de incidência da responsabilidade *por risco*, surge uma *limitação nos valores indenizatórios*. Uma responsabilidade dita *tarifada*. Carlos Alberto Bittar (1985, p. 89) aponta, com propriedade, o fato de que tais limitações *destinam-se a conciliar a necessidade da indenização com a viabilização econômica das atividades empresariais* [...] A conciliação da qual fala o ilustre professor é sempre feita em favor das atividades empresariais e contra os interesses dos cidadãos.

Há, portanto, uma tendência nítida para que sejam criados mecanismos legais que permitam ao agente da atividade industrial uma certa dose de certeza de seus custos. Uma previsão estatística de seus custos em razão de inevitáveis acidentes. Sob o aspecto puramente econômico, é indiscutível que existe uma necessidade premente de que se possa estabelecer, com a maior precisão possível, todo o montante de custos envolvidos em uma atividade industrial ou comercial.

Grande parte das atividades econômicas de elevado investimento e alto potencial de sinistros é grandemente tutelada por leis que preveem a limitação da responsabilidade do empreendedor (BITTAR, 1989, p. 86). Vários são os critérios utilizados para a fixação dos limites indenizatórios.

Dentre as leis que preveem a tarifação dos valores indenizatórios, as principais são:

Lei nº 6.367/1976, e Lei nº 6.195/1974, que tratam de acidentes de trabalho urbano e rural;

Lei nº 2.681/1912, sobre acidentes ferroviários;

Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica);

Lei nº 6.453/1977 sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras providências.

No Direito brasileiro, existem diversas leis que adotaram critérios para o estabelecimento de mecanismos de tarifação da responsabilidade. A motivação é, evidentemente, a mesma que se fez presente em outros setores do Direito positivo: o elevado investimento, o elevado nível de risco da atividade e, igualmente, a necessidade que o empreendedor tem de prever o montante aproximado de seu risco. Exemplificativamente, passo a examinar as linhas gerais do sistema adotado no caso de poluição marinha.

6.4 RESPONSABILIDADE CIVIL E EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ

6.4.1 INTRODUÇÃO AO TEMA

Como nos lembra Karl Popper (2006, p. 9), “É impossível prever todas as consequências não desejadas de nossas ações. A ciência natural é, aqui, nossa maior esperança: seu método é a correção dos erros”. Como se examinará adiante, a jurisprudência majoritária do STJ em matéria de responsabilidade civil ambiental, parte de uma lógica equivocada, a qual admite que o cidadão tem a obrigação de prever todas as possíveis consequências negativas de suas ações, pouco importando o que tenha dado causa ao resultado negativo. As excludentes de responsabilidade, assim, não fazem parte do repertório do STJ quando se trata de responsabilidade ambiental. Este tópico tem por objetivo examinar as chamadas excludentes de responsabilidade civil em matéria de danos ao meio ambiente, tal como interpretadas pela jurisprudência majoritária do STJ. Uma excelente visão da totalidade da jurisprudência do importante tribunal pode ser vista em SOARES e ALVARENGA (2010). O tema, em nossa opinião, tem merecido pouca atenção por parte dos acadêmicos e, sobretudo, por parte dos legisladores; aliás, observe-se que não há tradição acadêmica brasileira de crítica às decisões judiciais, realidade que precisa ser mudada, pois os tribunais, formados por seres humanos, são falíveis. A crítica acadêmica, de fato, atende a duas necessidades prementes: (i) possibilita o aprimoramento da jurisprudência e (ii) corresponde a prática de uma sociedade democrática, na qual todos os Poderes são sujeitos a críticas. Boa parte da doutrina e da jurisprudência brasileira (TJMG – AC 10439110065125001/MG, Relator: Desembargador Amorim Siqueira. 9ª Câmara Cível. Publicação: 02/12/2013: “Para o dano ambiental se aplica a teoria do risco integral, logo, é objetiva a responsabilidade e não se admite a incidência das excludentes de força maior, caso fortuito e fato de terceiro”) e TJSP – Apl 90933507420098260000/SP. Relator: Desembargador Ricardo Dip. 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público. Publicação: 16/05/2014: “Para a teoria do risco integral basta que se comprovem a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a atividade desenvolvida. Ou seja, o dever de reparar é fundamentado pela só existência da atividade da qual adveio o prejuízo. Não se cogita das causas do infausto. Não se investiga a culpa do dono da atividade. Não são invocáveis as tradicionais excludentes da responsabilidade civil” (TJSP – AC 0003947-05.2007. Des. Renato Nalini), inspirada pelo STJ, tem tratado do tema com base em teoria jurídica estabelecida no fim do século XIX (teoria do risco integral), cujo objetivo, naquela quadra, era o de oferecer resposta interpretativa a questões que não encontravam base normativa clara, eis que presente o dogmatismo da culpa como pressuposto da responsabilidade, ainda que aqui e ali o direito indicasse casos de responsabilidade objetiva. Após mais de 100 anos houve notável desenvolvimento dos estudos sobre o tema dos riscos e, conseqüentemente, uma produção legislativa mais apta a enfrentar as questões da vida moderna. Curiosamente, tal jurisprudência tem sido influenciada por um conjunto caótico de informações articuladas pela mídia e por organizações não governamentais que nos fazem crer que a sociedade e a humanidade se encontram à beira do juízo final e, portanto, as questões que lhe são submetidas são tratadas como se nelas se decidisse o futuro da vida sobre a Terra – ainda que as decisões sejam tomadas muitos e muitos anos depois de os fatos terem ocorrido. Se por um lado isso reflete uma maior abertura do Tribunal para a sociedade, por outro, revela que ele tem sido pouco seletivo na informação que recolhe e tem se amoldado às pressões de opinião pública, imprensa e organizações ambientalistas, sem qualquer análise crítica. Veja-se o seguinte caso: “Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio *habitat* do ser humano. Também a atividade degradadora contínua não se sujeita a prescrição: a permanência da causação do dano também elide a prescrição, pois o dano da véspera é acrescido diuturnamente. Em matéria ambiental, de ordem pública, por um lado, pode o legislador dar novo tratamento jurídico a efeitos que ainda não se produziram; de outro lado, o Poder Judiciário pode coibir as violações a qualquer tempo. A consciência jurídica indica que não existe o direito adquirido de degradar a natureza. É imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo, em matéria ambiental. Afinal, não se pode formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das gerações atuais, como futuras” (STJ – REsp 1.421.027/RJ (2012/0218893-7). Relator: Ministro Raul Araújo).

No caso concreto tratava-se de derramamento de óleo ocorrido na Baía de Guanabara em 2000 e decidido pelo STJ em 2014. A prática do direito brasileiro, todavia, não evoluiu no sentido de perceber que a própria noção de risco (base da teoria do risco integral) se transformou significativamente e, atualmente, não cabe mais falar em risco genericamente considerado, mas, ao contrário, em diferentes riscos, havendo que se fazer uma escolha entre riscos aceitáveis (FISCHOFF et al., 1981).

A responsabilidade por danos ao meio ambiente, como se sabe, no direito brasileiro tem *status* constitucional, conforme o disposto no § 3º do artigo 225 da CF (CF) que estabelece as normas gerais de responsabilidade ambiental, seja civil, administrativa ou penal. Ainda que, em nossa opinião, não se possa extrair do texto constitucional o caráter objetivo da responsabilidade civil ambiental – pois, quando a CF quis estabelecer a responsabilidade objetiva em temas de grandes impactos ambientais, assim o fez –, fato é que a lei da PNMA (“PNMA”), indiscutivelmente, atribui-lhe objetividade, conforme o disposto no § 1º do artigo 14, “é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

A PNMA, contudo, restringe-se ao texto supratranscrito, nada tratando sobre os limites da responsabilidade, das suas excludentes e tudo aquilo que se pode considerar relevante para que a matéria seja amplamente tratada e as dúvidas interpretativas reduzidas ao máximo possível. É verdade que o artigo 3º, IV, da PNMA nos permite entender que a responsabilidade ambiental é solidária, podendo ser atribuída a uma imensa gama de pessoas, “poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. Todavia, a lei mais não disse.

Na verdade, a lei, criada na época do regime militar não precisava dizer mais nada, pois naquele regime a imposição de responsabilidade era uma questão política, e não jurídica. Curiosamente, o regime democrático promoveu diversas alterações na PNMA, muito embora não tenha proporcionado qualquer mudança nas normas relativas à responsabilidade, tornando-as mais claras. Na verdade, o regime democrático – pelo ativismo judicial – estabeleceu um regime de responsabilidade confuso. “Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem” (REsp 1071741. Relator: Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma. DJe 16/12/2010).

Assim, conforme a interpretação judicial, qualquer um, independentemente de sua ação ou omissão concreta, pode ser enquadrado na amplíssima categoria de poluidor, direto ou indireto. Como será demonstrado adiante, a nossa legislação parou no tempo, o que acarretou um avanço do STJ em matéria claramente legislativa.

Doutrinária e judicialmente, a responsabilidade civil objetiva ambiental tem sido considerada ilimitada, “*Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador; da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental*” (REsp 1071741/SP. 2ª Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. DJe 16/12/2010).

Além disso, a responsabilidade ambiental, fundada na teoria do risco integral, não admite a possibilidade de invocação de excludentes por parte do causador do dano. “*A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no código civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade*” (STJ – AgRg no REsp 1412664/SP. 4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo, DJe 11/03/2014).

Com efeito, a responsabilidade civil “ilimitada” é um mito, pois, como é lógico e evidente, a responsabilidade *sempre* estará limitada à capacidade de pagamento do devedor. Este tópico busca demonstrar que a atual interpretação judicial do tema é, ao contrário do que possa parecer, um forte instrumento de desincentivo às medidas concretas de proteção ambiental, pois trata igualmente aqueles que investem na proteção ambiental e os que não o fazem. À base de tal construção doutrinária encontram-se elementos de senso comum, sem a necessária base científica para a tomada de decisão, bem como um discurso romântico e antimoderno que identifica no progresso tecnológico e científico um mal em si mesmo.

6.4.2 Risco

Como nos lembra a falecida antropóloga Mary Douglas (1994, p. 22), a palavra risco adquiriu nova proeminência. Segundo ela, uma explicação popular é a de que os riscos derivados da tecnologia cresceram grandemente em todo o mundo. Todavia, ela nos adverte que outros riscos decresceram, “*pelo menos se as figuras para mortalidade e morbidez significam alguma coisa*”. A nossa sociedade se considera em risco, por vários motivos, dentre os quais merece destaque a chamada crise ecológica, justificada por Sarlet e Fernsterseifer (2014, p. 78), como: “*A ação ou omissão humana está na origem da atual crise ambiental. Dito de outro modo, são justamente as práticas inconsequentes e irresponsáveis dos seres humanos, nas mais diversas áreas de atuação, tanto privadas quanto públicas que nos conduziram ao atual estado de risco existencial*”.

A “crise ambiental” está presente em boa parte da doutrina jurídica que a considera tão grave que pode chegar a dar base para a *aplicação retroativa da norma legal*, justificada pela urgência do estado pré-apocalíptico do mundo.

As garantias individuais não podem impor-se, a priori, diante das garantias pro bonum omnium, mais do que simples princípios de índole coletiva. Bem diferente, apenas excepcionalmente, danos pretéritos, provocados em situação de absoluta falta de previsibilidade de seus efeitos e, por conseguinte, capazes de romper o nexo causal, cederiam ao dever privado de recomposição, restando para o poder público, antes, solidariamente responsável pela deficiência da legislação caduca, responder isoladamente pela restauração das crateras dos rios e de suas margens, do dano, em resumo, um preço alto que tenha legado para o futuro. Um preço alto ao pacto intergeracional, o que requer exame atento da situação presente de responsabilização do passado sob o olhar do futuro. Ao ambiente caberão apenas desculpas e recuperação, jamais o legado da morte e da destruição (SAMPAIO, 2010, p. 172).

O risco, nos dias de hoje, é visto como negativo, muito embora já tenha sido considerado positivo (BECK, 2013, p. 25). Assim, cria-se um caldo de cultura no sentido de induzir-nos a acreditar que o ser humano tem uma aversão inata ao risco. Isto não é verdade. Se Cristóvão Colombo e Santos Dumont tivessem aversão ao risco talvez as coisas fossem diferentes. Caso ambos esperassem ter certeza dos resultados de suas ações, *não teriam feito o que fizeram. Parece, portanto, que o risco é inerente à vida humana*. A questão, presente inclusive na jurisprudência examinada neste artigo, é que tem sido feita uma escolha de determinados riscos, em detrimento de outros. A construção de hidrelétricas sem reservatório na Amazônia é uma opção entre dois riscos: (i) perda de diversidade biológica; e (ii) geração de energia. Do ponto de vista do risco da geração de energia – com consequências ambientais graves –, *a opção pelas hidrelétricas a “fio d’água” é a que traz mais riscos para a sociedade como um todo, pois inclusive contribui para o aumento de térmicas, com o consequente aumento de gases de efeito estufa (GEE)*. Assim, *as excelentes intenções de evitar riscos podem ampliar “outros” riscos. Um bom exemplo é o caso do DDT. Rachel Carson em seu conhecido livro Primavera silenciosa (2010) fez uma dura crítica da utilização do produto, devido aos graves problemas de saúde humana. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde (2011) assim se posiciona sobre o banimento total do produto:*

Espera-se que haverá um papel contínuo para o DDT no controle da malária até que alternativas igualmente econômicas sejam desenvolvidas. Um deslocamento prematuro para alternativas menos eficazes ou mais caras para DDT, sem um reforço das capacidades (humanas, técnicas e financeiras) dos Estados-Membros não será apenas insustentável, mas também terá um impacto negativo sobre a carga da doença em países endêmicos. Esta declaração de posição resume as questões que envolvem o uso de DDT para fins de controle de vetores.

Logo, o risco não é uma categoria neutra que se aplica a toda e qualquer circunstância. A construção do risco, como ressaltado pioneiramente por Mary Douglas, é, antes de tudo, social, ainda que não só. A dificuldade de lidar com o risco do ponto de vista jurídico, sobretudo em processos judiciais, é que a lógica do processo judicial é casuística e, portanto, restrita ao caso decidido, não observando o contexto social mais amplo. No caso brasileiro, as deficiências judiciais para tratar do tema são agravadas pela inacreditável morosidade do Judiciário que decide questões relativas a “sobrevivência da humanidade” muitos e muitos anos depois dos fatos. Retirar conclusões gerais aplicáveis a toda e qualquer hipótese é, por incrível que pareça, “um risco”.

6.4.2.1 Teoria do Risco Integral na visão do STJ: síntese

A Teoria do Risco Integral, ainda que apresentada como se moderna fora, é teoria jurídica velha, pois estabelecida no fim do século XIX, como muito bem ressaltado pela excelente síntese produzida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (REsp 1.373.788/SP, 3ª Turma, DJe 20/05/2014). Conforme anotado pelo Ministro, a teoria do risco integral teve origem na busca de solução para questões relativas a acidentes de trabalho que se intensificavam na França do fim do século XIX. A teoria foi estabelecida para dar solução a casos concretos em período no qual o Código Napoleão reinava soberano, não existindo a chamada legislação extravagante.

Saleilles, em 1897, lidera o movimento em favor da responsabilidade objetiva... propugnando pela substituição da ideia de culpa pela de causalidade objetiva, através de uma nova interpretação da palavra faute contida no art. 1.382 do CC francês. O argumento é de que ela se refere apenas ao próprio fato causador do dano sem qualquer indagação do elemento psicológico. Critica a ideia de culpa, qualificando-a como falsa e humilhante e sugerindo que, em atenção à dignidade humana, cada um assuma os riscos de sua atividade, transformando, em síntese, faute em fait [...]

Após ampla análise do adelgaçamento da noção de culpa, sugere o seu banimento completo do domínio da responsabilidade civil, já que “somos responsáveis não apenas pelos nossos atos culposos, mas pelos nossos atos que causarem dano injusto e anormal a outrem”. A noção de culpa deve ser substituída pela de risco, pois “quem cria um risco deve, se esse risco vem a verificar-se à custa de outrem, suportar as consequências [...]”

Surgiu, assim, na França, no final do século XIX, um novo fundamento para a responsabilidade civil, que foi a teoria do risco [...] Como a liberdade de iniciativa capitalista, necessária ao progresso econômico, continha uma grande dose de risco inerente à própria atividade, o titular do empreendimento, que objetivava o seu lucro pessoal, deveria responder pelo risco de sua atividade (ubi emolumentum, ibi onus).

6.4.2.2 Renascimento da teoria do risco integral

O CC de 2002, em seu artigo 927, parágrafo único, estabelece que: “[h]averá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Isso fez com que a jurisprudência dominante em matéria ambiental passasse a compreender como de risco integral e “cláusula geral” a responsabilidade: “O CC de 2002 foi além dessa orientação, pois, embora mantendo a responsabilidade civil subjetiva, em seu art. 186, estatuiu, em seu parágrafo único do art. 927, a inovadora cláusula geral de risco, consagrando de forma ampla a responsabilidade objetiva. A teoria do risco como cláusula geral de responsabilidade civil restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo único do art. 927 do CC... Essa norma, a par de estatuir uma cláusula geral de responsabilidade civil, manteve os casos de responsabilidade objetiva pelo risco acolhidos por leis especiais já aludidos” (REsp 1373788/SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3ª Turma. DJe 20/05/2014).

No particular, há que se registrar que a responsabilidade por risco integral – sem qualquer exclusão – é uma exceção, dependente de lei que assim o determine (ANTUNES, 2014, p. 496). A título de exemplo deve ser citada a Lei nº 10.744, de 9 de outubro de 2003, relativa à assunção pela União de responsabilidade civil decorrente de atos terroristas.

O direito brasileiro não tem se dedicado ao estudo do risco e de suas repercussões na ordem jurídica, com exceção dos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, cuja influência para o moderno desenvolvimento da matéria tem sido muito relevante (LEITE, 2012). A teoria do risco integral, recuperada pela jurisprudência dominante do STJ, é, em nossa opinião, e como se espera demonstrar, um retrocesso que tem como pano de fundo a concepção de que a sociedade moderna é um mal em si mesmo. “Hoje todos acreditam no mito sugerido da malignidade radical do mundo e da ‘sociedade’” (POPPER, 2006, p. 30). Um bom exemplo do que se fala é a afirmação de José Rubens Morato Leite e Germana Parente Neiva Belchior: “Se lidar com o risco certo e em potencial, utilizando a expressão de Beck, já era difícil no paradigma anterior, imagina gerir riscos imprevisíveis, em abstrato, em virtude das incertezas científicas” (2012, p. 19). Ora, uma das características do racionalismo é que não podemos ter a certeza como meta (POPPER, 2006, p. 15). Relembre-se, todavia, que os riscos são percebidos diferentemente pela sociedade (ROBBINS et al., 2014, p. 90).

A percepção do risco não é uma função universal do cérebro, mas em vez disso está localizada na cultura, pode estar enraizada em instituições (como as organizações ambientais ou agências do governo), e está ligada às prioridades concorrentes de gestão ambiental. A percepção do risco é profundamente política.

Aliás, uma bela alegoria da tentativa de prever o futuro – e do seu fracasso –, como forma de evitar riscos indesejáveis, nos é dada por Philip K. Dick³ no seu extraordinário conto *Minority Report*:

“Cada relatório foi diferente”, Anderton concluiu. “Cada um era único. Mas dois deles concordaram sobre um ponto. Se eu fosse deixado livre, eu mataria Kaplan. Isso criou a ilusão de um relatório da maioria. Na verdade, isso é tudo o que era – uma ilusão. ‘Donna’ e ‘Mike’ previram o mesmo evento – mas em dois caminhos de tempo totalmente diferentes, ocorrendo em situações totalmente diferentes. ‘Donna’ e ‘Jerry’, o chamado relatório da minoria e metade do relatório da maioria, estão incorretos. Dos três, ‘Mike’ estava correta – uma vez que nenhum relatório veio depois dele, para invalidá-lo. Isso resume tudo”.

Ao se tentar evitar os riscos de homicídios, com base em certezas, criou-se a falta de liberdade, restando provado ao final que a previsão não dera certo. O renascimento da teoria do risco integral na jurisprudência ambiental majoritária do STJ corresponde a uma forma de apropriação jurídica do chamado “discurso ambiental” (HANNIGAN, 2014, p. 72-99) pela maioria do Tribunal: “Não se trata, conforme entendem alguns juristas, da objetivação da responsabilidade civil fundada na teoria do risco criado, modalidade que admitiria excludentes fundadas na culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Na verdade, está-se diante de uma objetivação com a adoção da teoria do risco integral, pois, se o porvir depende de cautela extrema das atuais gerações, para que possa existir qualidade de vida e até mesmo condições mínimas de subsistência num planeta submetido a intenso maltrato, é evidente que toda norma ambiental há de ser interpretada de modo a se atingir os desígnios constitucionais” (AREsp 414617. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Publicação: 24/11/2014).

6.4.2.2.1 Um caso exemplar

A adoção da centenária Teoria do Risco integral às questões ambientais é bastante firme no STJ, merecendo exame o Recurso Especial nº 1.373.788/ SP, bem relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que se encontra excelentemente construído e, por isso mesmo, é um bom exemplo de supervalorização da responsabilidade objetiva – com a negativa de aplicação de excludentes –, sendo certo que a matéria poderia ter sido resolvida dentro dos marcos tradicionais da responsabilidade objetiva, sem o recurso à negativa de excludentes. De fato, no caso concreto cuidava-se de ação indenizatória movida por “jovem que sofreu graves queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural”. Conforme estabelecido na ementa da decisão, “A colocação de placas no local indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil”, acrescentando-se que é irrelevante a “eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima”. Conforme consta do relatório da decisão: *A polêmica devolvida ao conhecimento desta Corte situa-se em torno da responsabilidade civil da empresa recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido decorrentes de queimaduras sofridas pelo contato com resíduos tóxicos depositados em terreno pertencente à demandada. Com efeito, o Tribunal de origem, reformando a sentença que julgara improcedente o pedido indenizatório, condenou a parte recorrente a indenizar a parte recorrida pelos danos morais advindos das queimaduras sofridas pelo autor; decorrentes do contato com resíduos tóxicos que se encontravam expostos a céu aberto na propriedade da ré, arbitrando quantum indenizatório no montante de 200 salários mínimos nacionais...*

O recurso da empresa sustentou (i) a inexistência de provas acerca da ocorrência do evento danoso; (ii) a ausência de nexo de causalidade, por não haver relação entre a conduta da ré e o suposto dano do autor; (c) a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente que adotou todas as providências necessárias ao acautelamento e afastamento de terceiros não autorizados, entre outras coisas. O autor narrou, desde a petição inicial, que, no dia 8 de outubro de 1995, quando contava com doze anos de idade, na parte da manhã, em um terreno de propriedade da parte requerida, localizado atrás da Chácara Planalto, no Município de Sertãozinho, no Estado de São Paulo, estava caminhando por uma estrada a fim de recolher seu gado, quando pisou em uma terra vermelha que lhe causou queimaduras de terceiro grau, permanecendo sob cuidados médicos por sete dias, sendo submetido a diversos curativos e pequenas intervenções cirúrgicas. Prossegue o relatório: *A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, sob o fundamento de que “o episódio envolvendo o autor não decorreu de conduta dolosa nem culposa das requeridas, mas sim de caso fortuito ou força maior; já que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o local dos fatos era destinado ao depósito de materiais perigosos e nocivos para a saúde de outrem”. O acórdão recorrido, revisando os fundamentos da indigitada sentença, asseverou que a simples existência de placas de sinalização e cerca não torna lícito o despejo de material tóxico no meio ambiente, contaminando o solo e o lençol freático de maneira a colocar em perigo toda comunidade em seu entorno, e asseriu que aquele que joga resíduos industriais no terreno responde pelo prejuízo que causou e causar enquanto houver dano a quem quer que seja.*

Conforme realçado na própria decisão do STJ, *A modalidade que apresenta peculiaridades mais marcantes é exatamente a teoria do risco integral, que interessa neste momento. Constitui uma modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g., culpa da vítima; fato de terceiro, força maior). Essa modalidade é excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado, como ocorre com o dano nuclear (CF, art. 21, XXIII, letra “c”, e Lei 6.453/77). O mesmo ocorre como o dano ambiental (CF/88, art. 225, caput e § 3º, e Lei 6.938/81, art. 14, § 1º), em face da crescente preocupação com o meio ambiente.*

No caso em questão, não há dúvida de que a empresa praticou ato ilícito, destinação dos produtos tóxicos sem a adequada proteção. Esse fato já seria suficiente para fazer surgir o dever de indenizar. Também o fato de que a propriedade não estava adequadamente guardada, como demonstrado, indica que o proprietário assumiu os riscos daí derivados. E, por fim, o fato de que a vítima era menor à época dos fatos certamente é um elemento em favor da indenização, visto que o recurso a uma “modalidade excepcional” em caso relativamente simples é medida que, em nossa opinião, contribui para banalizar a aplicação de má teoria que, por excepcional, somente deve ser utilizada em casos igualmente excepcionais. Não se deve deixar de considerar no caso concreto que o feito demorou cerca de 20 anos para ser decidido pelo STJ.

6.4.2.3 Responsabilidade objetiva e atividades de grande impacto

A história da responsabilidade objetiva, na era industrial e pós-industrial, nos demonstra que ela é uma resposta que busca equilibrar os riscos gerados por atividades socialmente desejadas e os benefícios sociais por elas gerados. Em direito brasileiro uma das primeiras normas que tratou da responsabilidade objetiva – culpa presumida na linguagem da época – foi a relativa ao transporte ferroviário (Decreto Federal nº 2.861/1912). No particular, será visto mais adiante como o STJ modificou a jurisprudência relativa aos acidentes ferroviários, como forma de coibir os chamados “surfistas ferroviários”. Posteriormente, várias normas foram incorporadas ao direito brasileiro, inclusive a recente lei sobre responsabilidade civil objetiva pela prática de ilícitos administrativos (corrupção) (Lei Federal nº 12.846/2013). Com exceção da responsabilidade civil objetiva pela prática de atos de corrupção, a característica principal das normas é de estarem voltadas para atividades econômicas de grande porte.

A teoria do risco integral que vem sendo adotada pelas Cortes não encontra qualquer base legal, sendo uma construção cerebrina, em grande parte informada por uma concepção catastrófica da utilização dos recursos ambientais, superdimensionando as responsabilidades civis em qualquer caso, como se o superdimensionamento, por si só, pudesse garantir mais proteção ao meio ambiente.

De fato, há uma forte tendência no STJ (AREsp 476067, Relator: Ministro Humberto Martins, DJe 02/05/2014) reproduzindo texto a tratar as questões ambientais como se estivessemos às portas do juízo final ecológico, mesmo quando o caso concreto diz respeito à construção de um muro de 50 metros, em um condomínio residencial:

O ritmo dendroclasta prossegue, conforme noticia a imprensa internacional, após constatar o que ocorre com a Floresta Amazônica, última grande mata nativa tropical do planeta. Hoje, pese embora a negativa oficial, as fotos dos satélites não escondem o destino melancólico da última rain forest do mundo. Foi por isso que o constituinte de 1988, num assomo de lucidez, conferiu tratamento diferencial e significativo ao meio ambiente. Ao convertê-lo em “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, alterou a tosca e insuficiente concepção ecológica do Estado brasileiro. Este se vê obrigado a exercer “o dever de defendê-lo e preservá-lo”, defender e preservar o meio ambiente, mas não o fará só. Incumbiu desse dever a própria coletividade, integrada pelo povo e pelas sociedades particulares, às quais o Estado deve assegurar condições de criação, funcionamento e subsistência. Por que o constituinte de 1988 se viu obrigado a destinar ao meio ambiente um tratamento tão singular? Foi alertado pela verdade científica de que a continuidade do maltrato, a insensibilidade e a inconsequência, conjugados com a ganância da sociedade de consumo, tornariam realidade próxima a ameaça remota de esgotamento dos recursos naturais. A propósito, James Lovelock, o formulador da hipótese Gaia, alerta que o mundo está irremediavelmente comprometido pelo aquecimento global e que talvez não haja possibilidade de retorno. O que está em jogo não é apenas a qualidade de vida, senão a própria sobrevivência no Planeta. Quando da realização da Eco-92, o então Presidente Gorbachev afirmou que a humanidade teria trinta anos para mudar seus hábitos de consumo. Senão, a Terra poderia continuar a existir, mas prescindiria da espécie humana para isso.

Um bom castigo para a “ganância da sociedade de consumo” é a inexistência da exclusão de responsabilidade, pois casos fortuitos, força maior ou fato de terceiros são a prova da “vingança de Gaia” e, portanto, devem impor ao degradador do meio ambiente ônus pesados pelo sacrilégio que perpetraram. Na verdade, estamos diante de uma manifestação do chamado pós-modernismo que tem sido bastante forte na atualidade jurídica brasileira, com a magistratura avançando em conceitos de natureza técnica e científica, os quais nem sempre domina, ostentando, em muitos casos, “uma erudição superficial” (SOKAL e BRICMONT, 2014, p. 18). Isso tem feito com que se crie uma corrente jurisprudencial inteiramente dissociada da realidade, gerando custos inaceitáveis para o País e, o que é pior, sem que os problemas ambientais graves sejam resolvidos.

6.4.3 Doutrina nacional e responsabilidade ambiental por risco integral

As decisões tomadas pelo STJ, com base na teoria do risco integral, não encontram ressonância tranquila na produção doutrinária especializada que, no particular, se encontra dividida, conforme se passa a demonstrar. Uma das posições mais extremadas em relação à inexistência das excludentes de responsabilidade é a sustentada por Norma Sueli Padilha (2010, p. 284), para quem,

a mera existência do risco gerado pela atividade deve conduzir à responsabilização e, havendo mais de uma causa para o dano, todas serão consideradas eficientes para produzi-lo (equivalência das condições para aferição do liame causal). Basta que o dano esteja ligado à existência do “fator de risco”, pois este deve ser considerado a causa do dano. O que importa é o fato risco, não uma causa perfeitamente identificada e vinculada a uma atividade perigosa.

Parece claro que a prestigiada autora raciocina com o conceito de dano e risco como fatores equivalentes. Assim, a existência de um dano ambiental qualquer em área de influência de atividade-risco é equivalente a um dano concreto, resulta daí que o agente da atividade será responsável pelo evento danoso, “o que importa é o fato risco, não uma causa perfeitamente identificada e vinculada a uma atividade perigosa”. Assim, dispensa-se até mesmo a relação causa-efeito para que se impute a responsabilidade. Também com posição assemelhada se acha o respeitado Édis Milaré (2009, p. 964), para quem:

Em outras palavras, com a teoria do risco integral, o poluidor, na perspectiva de uma sociedade solidarista, contribui – nem sempre de maneira voluntária – para com a reparação do dano ambiental, ainda que presentes quaisquer das clássicas excludentes da responsabilidade ou cláusula de não indenizar. É o poluidor assumindo todo o risco que sua atividade acarreta: o simples fato de existir a atividade produz o dever de reparar; uma vez provada a conexão causal entre dita atividade e o dano dela advindo. Segundo esse sistema, só haverá exoneração de responsabilidade quando: a) o dano não existir; o dano não guardar relação de causalidade com a atividade da qual emergiu o risco.

Todavia, há concepções mais moderadas sobre a existência de exclusões de responsabilidade, como aquela do consagrado Professor Paulo Affonso Leme Machado (2012, p. 424) que admite a exclusão de responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito e força maior, sendo certo que “[q]uem alegar o caso fortuito e a força maior deve produzir a prova de que era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato necessário – terremoto, raio, temporal, enchente”. No mesmo diapasão segue Annelise Steigleder: “Finalmente, há uma posição intermediária, que nos parece a mais correta, admite apenas a força maior e o fato de terceiro como causas excludentes, eis que consistem em fatos externos, imprevisíveis e irresistíveis, nada tendo a ver com os riscos intrínsecos ao estabelecimento ou atividade” (STEIGLEDER, 2004, p. 212).

A Professora Maria Luiza Machado Granziera (2009, p. 550) deu um excelente tratamento à questão ao escrever:

Há que se analisar a questão à luz do risco ao qual a atividade causadora de dano expôs a sociedade e o meio ambiente... Se não ficar claramente evidenciado que o fato ocorrido estava totalmente fora da previsão e do controle do empreendedor e que nenhum ato seu colaborou para a realização do dano, é cabível a sua responsabilização.

Parece, portanto, razoável que “um empreendimento que tenha sido vitimado por fato de terceiro passe a responder por danos causados por este terceiro, como

se lhes houvesse dado causa (ANTUNES, 2014, p. 496). O fato não é discutiível, é como tema tão relevante e com repercussões tão graves não pode ficar relegado a ser disciplinado por opiniões doutrinárias ou por criação de direito novo por parte do Judiciário, como tem sido o caso, necessitando reformulação legislativa para a matéria seja tratada amplamente.

6.4.4 Exclusão de responsabilidade ambiental

Diferentemente da orientação que vem prevalecendo nas decisões majoritárias do STJ, a exclusão de responsabilidade ambiental em determinados casos é a regra, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Como será visto adiante, a posição adotada pela elevada Corte de justiça brasileira não encontra paralelo nos países que têm demonstrado alto grau de preocupação com o meio ambiente. A União Europeia, mediante a expedição da Diretiva 2004/35/CE⁴ do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril de 2004 (“Diretiva 2004/35”), estabeleceu normas relativas à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais.

Um dos elementos mais importantes da Diretiva 2004/35 é a definição clara de danos ambientais que, na forma do artigo 2º, 1, são:

a) Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos, isto é, quaisquer danos com efeitos significativos adversos para a consecução ou a manutenção do estado de conservação favorável desses habitats ou espécies. O significado de tais efeitos deve ser avaliado em relação ao estado inicial, tendo em atenção os critérios do Anexo I.

Os danos causados às espécies e habitats naturais protegidos não incluem os efeitos adversos previamente identificados que resultem de um acto de um operador expressamente autorizado pelas autoridades competentes nos termos das disposições de execução dos nos 3 e 4 do artigo 6º ou do artigo 16º da Diretiva 92/43/CEE ou do artigo 9º da Diretiva 79/409/CEE, ou, no caso dos habitats e espécies não abrangidos pela legislação comunitária, nos termos das disposições equivalentes da legislação nacional em matéria de conservação da natureza;

b) Danos causados à água, isto é, quaisquer danos que afectem adversa e significativamente o estado ecológico, químico e/ou quantitativo e/ou o potencial ecológico das águas em questão, definidos na Diretiva 2000/60/CE, com exceção dos efeitos adversos aos quais seja aplicável o nº 7 do seu artigo 4º; c) Danos causados ao solo, isto é, qualquer contaminação do solo que crie um risco significativo de a saúde humana ser afetada adversamente devido à introdução, direta ou indireta, no solo ou à sua superfície, de substâncias, preparações, organismos ou micro-organismos.

É interessante observar que a Diretiva estabelece um regime de responsabilidade bipartido, ou seja, há (i) responsabilidade objetiva e (ii) responsabilidade subjetiva, conforme seja a origem do dano. Assim, o artigo 3º ao definir o âmbito de aplicação determina que:

1. A presente diretiva é aplicável: a) Aos danos ambientais causados por qualquer das atividades ocupacionais enumeradas no Anexo III e à ameaça iminente daqueles danos em resultado dessas atividades; b) Aos danos causados às espécies e habitats naturais protegidos por qualquer atividade ocupacional distinta das enumeradas no Anexo III, e à ameaça iminente daqueles danos em resultado dessas atividades, sempre que o operador agir com culpa ou negligência.

Tal bipartição é relevantíssima, pois como visto anteriormente, a responsabilidade objetiva – sobretudo na interpretação do STJ: risco integral –, quando aplicada a pequenos empreendimentos e atividades, pode ter o efeito colateral de “jogar fora a criança com a água do banho”. Logo, repartir a responsabilidade, conforme a dimensão da atividade e do impacto causado, é medida da mais elementar justiça e proporcionalidade. Merece ser ressaltado que o artigo 4º expressamente prevê as hipóteses de exclusão de responsabilidade:

1. A presente diretiva não abrange danos ambientais nem ameaças iminentes desses danos, causados por: a) Atos de conflito armado, hostilidades, guerra civil ou insurreição; b) Fenômenos naturais de caráter excepcional, inevitável e irresistível; 2. A presente diretiva não se aplica aos danos ambientais, nem a ameaças iminentes desses danos, que resultem de incidentes relativamente aos quais a responsabilidade ou compensação seja abrangida pelo âmbito de aplicação de alguma das Convenções Internacionais enumeradas no Anexo IV, incluindo quaisquer posteriores alterações dessas convenções, em vigor no Estado-Membro em questão.

No que diz respeito aos custos de prevenção e reparação de danos ao ambiente, o artigo 8º da Diretiva 2004/35 estipula que:

3. Não é exigido ao operador que suporte o custo de ações de prevenção ou de reparação executadas por força da presente diretiva, se este puder provar que o dano ambiental ou a ameaça iminente desse dano: a) Foi causado por terceiros e ocorreu apesar de terem sido tomadas as medidas de segurança adequadas; ou b) Resultou do cumprimento de uma ordem ou instrução emanadas de uma autoridade pública que não sejam uma ordem ou instrução resultantes de uma emissão ou incidente causado pela atividade do operador.

Nestes casos, os Estados-Membros devem tomar as medidas adequadas para permitir ao operador recuperar os custos incorridos. 4. Os Estados-Membros podem permitir que o operador não suporte o custo das ações de reparação executadas por força da presente diretiva se ele provar que não houve culpa nem negligência da sua parte e que o dano ambiental foi causado por: a) Uma emissão ou um acontecimento expressamente permitidos e que respeitem integralmente uma autorização emitida ou conferida nos termos das disposições legislativas e regulamentares nacionais de execução das medidas legislativas adotadas pela Comunidade, especificadas no Anexo III, tal como se aplicam à data da emissão ou do acontecimento; b) Uma emissão, atividade ou qualquer forma de utilização de um produto no decurso de uma atividade que o operador prove não serem consideradas susceptíveis de causarem danos ambientais de acordo com o estado do conhecimento científico e técnico no momento em que se produziu a emissão ou se realizou a atividade.

Uma das leis mais duras em matéria de responsabilidade civil ambiental é a chamada CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980)⁵ dos Estados Unidos, que constantemente é emendada e atualizada, a qual estabelece um regime de exclusão de responsabilidade, em seu § 9.607, após definir na alínea (a) a relação dos responsáveis pelas ações de descontaminação, na alínea (b) (defesas) exclui as responsabilidades em caso de

(1) act of God, (2) ato de guerra (3) ação ou omissão de uma terceira parte que não seja empregado ou agente do defendente, ou aquele cuja ação ou omissão ocorra no âmbito de uma relação contratual, direta ou indiretamente existente, com o réu (exceto onde o único acordo contratual surge de uma tarifa publicada e aceitação para o transporte por uma transportadora comum por via férrea), se o réu estabelece por uma preponderância das evidências de que (a) exerceu o devido cuidado em relação à substância perigosa em causa, tendo em consideração as características de tal substância perigosa, à luz de todos os fatos e circunstâncias relevantes, e (b) ele tomou precauções contra previsíveis atos ou omissões de qualquer terceiro e as consequências que poderiam previsivelmente resultar de tais ações ou omissões, ou (4) qualquer combinação dos parágrafos acima.

Na Argentina, também se admite a exclusão da responsabilidade ambiental conforme estabelecido pelo artigo 29 da Política Ambiental Nacional, de acordo com a tradição jurídica ocidental. No Chile, a responsabilidade ambiental é subjetiva, muito embora se admita a presunção de responsabilidade nas hipóteses de infração às normas administrativas de proteção ao meio ambiente. No Peru,⁶ vigora regime que reconhece uma bipartição da responsabilidade ambiental em (i) objetiva e (ii) subjetiva, conforme a natureza do dano e que, evidentemente, reconhece excludentes de responsabilidade dentre as quais merece destaque o caso de que o dano ambiental tenha sido causado por uma ação ou omissão “não contrária à normativa aplicável”. Assim, a jurisprudência majoritária do STJ está praticamente solitária – orgulhosamente solitária – na adoção de teoria que, na prática, afasta toda e qualquer excludente de responsabilidade em relação aos danos ambientais.

Ainda que tímida e amplamente minoritárias, existem decisões do STJ que admitem a exclusão de responsabilidade em matéria ambiental, e.g.: “A excludente de

responsabilidade civil consistente no fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita, dada a abrangência do artigo acima transcrito. Desse modo, só poderá ser reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor; e não se possa atribuir a este qualquer participação na consecução do dano” (REsp 1381211/TO. Relator: Ministro Marco Buzzi. 4ª Turma. DJ: 19/09/2014).

6.4.5 A inexistência da exclusão da responsabilidade como estímulo ao comportamento antiambiental

O artigo 225 da CF determina que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. O mesmo artigo, após estabelecer o direito de todos, determinou uma obrigação exigível do poder público e da coletividade, o “dever de defendê-lo e preservá-lo”. Assim, do ponto de vista constitucional e, na medida de suas possibilidades, todas as pessoas naturais e jurídicas devem agir de forma a defender e preservar o ambiente. No âmbito da aplicação da responsabilidade civil ambiental, parece evidente que a indenização de danos causados ao meio ambiente e a terceiros não é extensível às hipóteses de, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, pois esta última estaria agindo de forma contrária à proteção ambiental. Assim, conforme a precisa observação de Michael Faure (2007, p. 88), a responsabilidade civil tem como uma de suas funções o desencorajamento dos comportamentos antissociais e, em muitos casos, indenizar as vítimas é estimular tal comportamento. No particular, a jurisprudência sobre acidentes ferroviários do STJ (REsp 160051/RJ. Relator: Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. 3ª Turma. DJ: 17/02/2003, p. 268) é bastante elucidativa ao rechaçar a indenização aos chamados “surfistas ferroviários”. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, “A pessoa que se arrisca em cima de uma composição ferroviária, praticando o denominado ‘surf ferroviário’, assume as consequências de seus atos, não se podendo exigir da companhia ferroviária efetiva fiscalização, o que seria até impraticável”.

Assim, indenizar aqueles que tenham se colocado em áreas de risco, notadamente com as invasões em áreas destinadas à indústria é, *ipso facto*, colocar-se contra o mandamento constitucional que atribui a todos a obrigação de proteger o meio ambiente, bem como estimular comportamentos irresponsáveis, desnaturando a função da responsabilidade civil. Assim, sendo certo que a indenização das vítimas é uma das funções essenciais da responsabilidade civil, daí não decorre que todas as vítimas devam ser indenizadas.

6.5 O CONCEITO DE DANO

Não se pode, com toda certeza, avançar no presente capítulo sem que se faça uma breve incursão pelo conceito jurídico de dano, que é o pressuposto indispensável para a construção de uma teoria jurídica da responsabilidade ambiental. É evidente que, para a correta compreensão do assunto ora examinado, é fundamental uma definição de *dano* para que, a partir daí, se defina o *dano ambiental*. A toda evidência, não se pode definir qual o ressarcimento devido se o dano a ser reparado não estiver suficientemente classificado, especificado e quantificado. Com efeito, sem a existência do dano, inexistente responsabilidade.

O dano é o prejuízo injusto causado a terceiro, gerando obrigação de ressarcimento. A ação ou omissão de um terceiro é essencial. Desnecessário dizer que, no conceito, somente se incluem as alterações negativas, pois não há dano se as condições forem alteradas para melhor, sem prejuízo. É a variação, moral ou material, negativa que deverá ser, na medida do possível, mensurada de forma que se possa efetivar o ressarcimento. Posta nestes termos, a questão parece simples. Contudo, é nessa aparente simplicidade que se encontram as mais significativas dificuldades do Direito Ambiental. A noção de dano, originariamente, tinha um conteúdo eminentemente patrimonial, na medida em que não se considerava prejuízo a um valor de ordem íntima, uma vez que esta não tem conteúdo econômico imediato.

A ressarcibilidade do dano não é, contudo, uma matéria tranquila. Entende-se que só é ressarcível o dano que preencha três requisitos, a saber: (i) certeza, (ii) atualidade e (iii) subsistência.

6.5.1 O dano ambiental

Dano ambiental é dano ao meio ambiente, que na forma da lei é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Como se vê, cuida-se de um conceito abstrato que não se confunde com os bens materiais que lhe dão suporte. Embora uma árvore seja um recurso ambiental, não é o meio ambiente. Dano ambiental, portanto, é a ação ou omissão que prejudique as diversas condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permita, abrigue e reja a vida, em quaisquer de suas formas.

O meio ambiente é um bem jurídico autônomo e unitário, que não se confunde com os diversos bens jurídicos que o integram. O bem jurídico meio ambiente não é um simples somatório de flora e fauna, de recursos hídricos e recursos minerais. Ele resulta do somatório de todos os componentes que, isoladamente, podem ser identificados, tais como florestas, animais, ar etc. Esse conjunto de bens adquire uma particularidade jurídica que é derivada da própria integração ecológica de seus elementos componentes. Os múltiplos bens jurídicos autônomos que se agregam e transfiguram para a formação do bem jurídico meio ambiente encontram tutela tanto no Direito público, como no Direito privado, e o mesmo se dá com o conjunto.

Meio ambiente é, portanto, um *bem communes omnium*, de natureza imaterial. Uma coisa comum a todos, que pode ser composta por bens pertencentes ao domínio público ou ao domínio privado. A propriedade dos bens materiais e individualizados que compõem o meio ambiente pode ser pública ou privada, com exceção do ar atmosférico, que é inapropriável. A fruição do bem jurídico meio ambiente é sempre de todos, da sociedade. Por outro lado, o dever jurídico de proteger o meio ambiente também é de toda a coletividade, podendo ser exercido pelo indivíduo, pelas associações, pelo Ministério Público ou pelo próprio Estado contra os proprietários individuais e contra o próprio Estado.

Os Tribunais brasileiros têm debatido muito a matéria, dando ênfase à necessidade de comprovação do dano, haja vista que, salvo determinação legal, não há que se falar em dano presumido, devendo a sua ocorrência ser comprovada. Há antiga decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos, na Apelação Cível nº 88.556.787, que entendeu: “A simples alegação de dano ao meio ambiente não autoriza a concessão de liminar suspensiva de obras e serviços públicos prioritários e regularmente aprovados pelos órgãos técnicos competentes”.

Tal orientação foi confirmada pelo STJ em decisão de lavra da Ministra Eliane Calmon, da qual se destaca o seguinte: “Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido” (REsp nº 1.140.549/MG (2009/0175248-6), 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

A aprovação pela administração de uma determinada obra, portanto, no entendimento da extinta Corte, gera uma presunção *iuris tantum* de adequação desta às exigências ambientais. Tal presunção só pode ser desfeita através de um amplo processo probatório e não nos estreitos limites de uma medida liminar, haja vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Acontece que nem mesmo a infração, por parte das indústrias, de normas de Zoneamento urbano, tem sido considerada como causadora de danos ambientais, potenciais ou atuais, exigindo-se do autor que prove, *além do risco*, o próprio dano. No caso, o Tribunal admite um “perigo socialmente aceitável”. A esse respeito, o TJRJ, na Ap. nº 1.171, julgada pela sua 5ª Câmara Cível, sentenciou que: “A pura infração de normas de zoneamento urbano não importa necessariamente a configuração de dano, atual ou potencial, ao meio ambiente. A condenação da empresa a abster-se da atividade industrial não pode repousar na simples existência de riscos [...]”.

Pelo que se viu das decisões judiciais acima comentadas, observa-se que a concepção até aqui predominante em nossos Tribunais é a de que os danos ambientais devem ser atuais e concretos. Ou seja, a atuação judicial é fundamentalmente *posterior* ao dano causado. A simples burla de formas legais, como é o caso de normas de zoneamento, não é suficiente para que, judicialmente, caracterize-se o dano ao ambiente, sendo apenas uma infração administrativa.

6.5.1.1 Dano moral ambiental

A existência de acidentes que impliquem danos ao meio ambiente tem acarretado a construção de uma recente jurisprudência a qual reconhece a existência de dano moral ambiental (*rectius*: dano moral em razão de acidentes ambientais). Há decisões⁷ que admitem tal espécie de dano coletivo e individual. Não há dúvida de

que, em análise casuística, é ampla a possibilidade de que acidentes ambientais possam, de fato, acarretar dano moral para terceiros; contudo, há que se rejeitar que tais danos morais sejam presumidos, pois, como se sabe, danos devem ser provados, sobretudo aqueles de natureza subjetiva.

6.6 REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

O artigo 225, § 3º, da CF determina que *condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados*.

O dispositivo constitucional aponta a existência de tríple responsabilidade, administrativa, civil e penal. As sanções penais e administrativas têm a característica de um castigo que é imposto ao poluidor. Já a reparação do dano reveste-se de um caráter diverso, pois através dela busca-se uma recomposição daquilo que foi destruído, quando possível. Relembre-se de que o direito brasileiro não reconhece os chamados “danos punitivos”, muito embora, os danos morais coletivos venham exercendo função assemelhada.

A grande dificuldade, evidentemente, não está nas sanções penais e administrativas, mas na *obrigação de reparar o dano*. Em que consiste tal obrigação? A prática judicial brasileira ainda não nos oferece uma resposta segura.

6.6.1 A apuração do dano ambiental

Por muito que se tenha falado sobre o assunto, a realidade é que, até hoje, não existe um critério para a fixação do que, efetivamente, constitui o dano ambiental e como este deve ser reparado. A primeira hipótese a ser considerada é a da *repristinação do ambiente* agredido ao seu *status quo ante*. Esta pode ser conseguida por (i) intervenção humana ou por (ii) regeneração natural. Contudo, nem sempre se pode garantir que a regeneração ocorrerá. É o caso, por exemplo, de extinções de espécies como externalidade de danos ambientais.

Essas questões estão longe de obter uma resposta consensual ou simples. A adoção de um valor arbitrado para significar a espécie destruída tem a desvantagem de estabelecer um macabro sistema pelo qual aqueles que possuem recursos financeiros poderão pagar uma soma para compensar a área ou espécie prejudicada. Por outro lado, esse mecanismo tem como lado positivo a fixação de algum critério objetivo a ser imposto ao poluidor.

Há mecanismos econômicos que têm sido utilizados como critérios de valoração ambiental, com vistas a monetarizar as perdas ambientais.

Outro critério que vem sendo adotado é o da compensação, hoje com expressa previsão legal na Lei do SNUC. Isto é, à degradação de uma área deve corresponder a recuperação de uma outra, no caso da Lei do SNUC, adota-se um equivalente financeiro a ser aplicado em unidades de conservação. O que se percebe, de fato, é que os critérios de reparação do dano ambiental são sempre discutíveis e falhos, assim, os mecanismos preventivos devem ser privilegiados e os eventuais danos ambientais inevitáveis devem ser admitidos somente após criteriosa análise do tipo custo/benefício que possa assegurar que a intervenção sobre o meio ambiente será globalmente positiva, considerados todos os aspectos envolvidos na questão.

- ¹ Disponível em: <<http://www.prpa.mpf.gov.br>>. Acesso em: 8 ago. 2011.
- ² Disponível em: <<http://www.unepfi.org/about/index.html>>. Acesso em: 8 ago. 2011.
- ³ Disponível em: <<http://cwanderson.org/wp-content/uploads/2011/11/Philip-K-Dick-The-Minority-Report.pdf>>. Acesso em: 6 jan. 2015.
- ⁴ Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0035&from=PT>>. Acesso em: 5 jan. 2015.
- ⁵ Disponível em: <<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title42-chap103.htm>>. Acesso em: 5 jan. 2015.
- ⁶ PERU, Lei Geral do Ambiente Ley nº 28611. “*Artículo 142. De la responsabilidad por daños ambientales 142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. [...] Artículo 144. De la responsabilidad objetiva La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva a producir. Artículo 145. De la responsabilidad subjetiva La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente. Artículo 146. De las causas eximentes de responsabilidad No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos: a) Cuando concurren una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley; b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible; y, c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y omisión no contraria a la normativa”.*- ⁷ *Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Instalação de estação de tratamento de esgoto a céu aberto. Corsan. Responsabilidade objetiva por violação de normas sanitárias. Mau cheiro. Condições insalubres. Dano moral ambiental individual. Configuração. Manutenção do quantum. Honorários advocatícios mantidos. Precedentes. – Serviço público e direito subjetivo ao saneamento básico.* (Desembargador Leonel Pires Ohlweiler) (TJRS – AC 70046226064/RS. Julgamento: 01/12/2011. 9ª Câmara Cível. *Diário da Justiça*: 14/12/2011).

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

§ 1º IMPACTO AMBIENTAL

O Capítulo Constitucional dedicado ao meio ambiente determina a exigência de EIA para a “*instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente*”. A colocação do tema em sede constitucional é suficiente para dizer de sua importância. Determina, ainda, a CF seja dada publicidade ao EIA. Penso que, no particular, a exigência deveria ser de estudos ambientais para atividades que pudessem causar danos ao ambiente, todavia, a esta altura, o tema já está consolidado, não sendo prudente modificar o texto constitucional.

O EIA é uma das diferentes modalidades de estudos utilizadas para o exame dos diferentes custos de um projeto, estando voltada para os chamados custos ambientais, os quais são caracterizados pelos impactos positivos e negativos advindos da implantação do empreendimento. Analisar custos de implantação de projetos é uma prática antiga; de fato, o empreendedor de um projeto busca avaliar se os benefícios compensarão os custos a serem alcançados. Se os benefícios forem maiores que os custos, diz-se que o referido projeto é viável economicamente. Desde a década de 50 do século XX, vem se desenvolvendo uma metodologia de análise de custos de projetos que ficou conhecida como *avaliação social de projetos*. Trata-se de uma evolução da análise custo-benefício que considera ademais das repercussões para o empreendedor público ou privado, as repercussões sobre o meio social no qual o projeto se inserirá.

Para a avaliação social, é extremamente importante a análise das externalidades dos projetos. Elas são os resultados não desejados advindos da implementação de um dado projeto (CONTADOR, 1988, p. 245). As externalidades podem ser positivas ou negativas. Positivas são aquelas que redundam em benefícios não previstos quando da planificação do projeto. Negativas são as externalidades que implicam a criação de problemas insuspeitados quando do planejamento e da implementação do projeto. Dentro das externalidades, as ambientais avultam pela importância e complexidade.

Os EIAs representam evolução das análises do tipo custo/benefício, cujos objetivos básicos podem ser resumidos como uma análise custo/benefício do projeto, tomando-se como parâmetro a repercussão sobre o meio ambiente.

Estabelecidas as preliminares, os capítulos que se seguem pretendem examinar os elementos que compõem os estudos de impacto ambiental do ponto de vista jurídico.

7.1 DEFINIÇÕES DE IMPACTO, MEIO AMBIENTE E DE IMPACTO AMBIENTAL

O primeiro aspecto que deve ser considerado na conceituação de impacto ambiental é o próprio significado semântico do termo. O vocábulo “impacto” deriva do termo latino *impactu*. O *Dicionário Aurélio Eletrônico* fornece os seguintes significados para o substantivo masculino impacto:

- a) encontro de projétil, míssil, bomba ou torpedo, com o alvo; choque, colisão;
- b) colisão de dois ou vários corpos;
- c) abalo moral causado nas pessoas por um acontecimento chocante ou impressionante;
- d) impressão muito forte, muito profunda, causada por motivos diversos. O vocábulo “ambiente” é definido pelo *Aurélio Eletrônico* como:

Ambiente [Do lat. *ambiente*.] Adj. 2 g. 1. Que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os lados; envolvente: – V. meio. S. m. 2. Aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas; meio ambiente. 3. Lugar, sítio, espaço, recinto. 4. Meio. 5. V. meio. 6. O conjunto de condições materiais e morais que envolve alguém; atmosfera: 7. Arquit. *Âmbiência*.

Em italiano, a definição de *Impatto* (ZINGARELLI, 1990, p. 890) é a seguinte:

Urto. Atto e modo col quale un corpo in movimento, come bomba, missile, proiettile, aeromobile e sim. urta contro q.c. trasformando gran parte della sua energia cinetica in lavoro di deformazione della propria struttura e di quella o di quelle dell'altro... Urto... Influenza...

Já, *Ambiente* (ZINGARELLI, 1990, p. 70) é definido como:

Che sta attorno, che circonda. Complesso degli condizioni esterne all'organismo in cui si svolge vita vegetale e animale. Complesso degli esterne materiali, sociali, culturali e sim nelle'ambito delle quali si sviluppa, vivere e opera un essere umano [...]

Em francês, a definição de *Impact* fornecida pelo *Dicionário Robert* (1988, p. 521) tem o seguinte conteúdo:

Point d'impact. collision, heurt: endroit où le projectile vient frapper et, par ext. trace qu'il laisse [...] Effet produit, action exercée [...]

Já *Environnement* (ROBERT, 1988, p. 368) é:

Entourage habituel [...] Ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines [...]

O consagrado *Black's Law Dictionary* (1991, p. 369-370) define *Environment* da seguinte forma:

The totality of physical, economic, cultural, aesthetic, and social circumstances and factors which surround and affect the desirability and value of property and which also effect the quality of people's life. The surrounding conditions, influences or forces which influence or modify.

O conceito de meio ambiente, como se pôde ver antes, é um conceito que implica o reconhecimento de uma totalidade. Isto é, meio ambiente é um conjunto de ações, circunstâncias, de origem culturais, sociais, físicas, naturais e econômicas que envolve o homem e todas as formas de vida. É um conceito mais amplo do que o de natureza, o qual em sua acepção tradicional limita-se aos bens naturais que existem independentemente da ação humana. Daí ser possível falar-se em meio

ambiente urbano, meio ambiente do trabalho etc.

Impacto é choque, modificação brusca causada por força exterior que tenha colidido com um objeto. Sinteticamente: o impacto ambiental é uma modificação brusca causada no meio ambiente. O EIA somente examina os *impactos ambientais antrópicos*. A análise, contudo, poderá incluir a contribuição humana para a ocorrência de impactos ambientais naturais, como ocorre com a atual discussão sobre mudanças climáticas globais. Certamente, o impacto ambiental causado por circunstâncias naturais pode ter repercussões ambientais e econômicas extraordinárias, *e. g.*, erupções vulcânicas.

Uma nuvem de cinzas provocada pela erupção de um vulcão na Islândia no final de semana deve atingir o norte da Grã-Bretanha e do Oceano Atlântico na manhã de terça-feira, de acordo com informações do centro de meteorologia britânico. O Met Office alerta que isso não significa que o espaço aéreo será fechado, mas existe a possibilidade de atrasos e transtornos. (...) Muitos aviões não puderam decolar, já que as autoridades alegaram que as aeronaves não funcionariam com segurança em meio à nuvem de cinzas. Na ocasião, o espaço aéreo foi fechado por vários dias em diversos países. O geofísico Pall Einarsson, da Universidade da Islândia, adverte que a erupção atual não chegará nem perto da escala registrada no ano passado. “Aquele era um vulcão incomum, uma distribuição de cinzas incomum e um padrão de meteorologia incomum, que conspiraram para dificultar a vida na Europa”. As cinzas vulcânicas do Grimsvotn são maiores do que as do Eyjafjallajökull, e, portanto, caem mais rápido no solo¹

O impacto ambiental pode ser (i) positivo e (ii) negativo. Normalmente, o direito ambiental está mais voltado para o impacto ambiental negativo, pois é ele que será capaz de gerar o dano ambiental e, conseqüentemente, a responsabilidade. O EIA deve indicar todos os impactos ambientais, positivos e negativos, como forma de propiciar ao administrador os instrumentos necessários para a correta avaliação do empreendimento.

O EIA busca estabelecer forma de empreender com a proteção dos ecossistemas, os quais semanticamente, assim se definem:²

Ecossistema [De eco-1 + sistema.] S. m. 1. Conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os micro-organismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico.

A Constituição Brasileira fala de meio ambiente e de ecossistemas. É certo, contudo, que, nos termos de nossa CF, a proteção dos ecossistemas é um dos instrumentos capazes de assegurar a efetividade do *direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado*. Logo, ecossistemas são partes integrantes do meio ambiente, embora não contenham todo o meio ambiente. Ao contrário, nele estão contidos.

7.1.1 Conceitos normativos de meio ambiente e impacto ambiental

Os *conceitos normativos* são essenciais para o Direito, sobretudo em função das grandes vinculações entre o direito ambiental e o conhecimento científico, bem como devido à forte especialização e setorização das regras de proteção ao meio ambiente, o que implica muitas possibilidades de insegurança e conflitos. Contudo, a simples existência de conceitos normativos não é suficiente para que se possa assegurar uma certeza jurídica absoluta. Mesmo no Direito privado muitas áreas de incerteza permanecem. O próprio conceito de boa e má-fé, essencial para a teoria dos contratos, não possui definição normativa.

No Direito positivo brasileiro, o conceito de meio ambiente está estabelecido na Lei nº 6.938/1981 em seu artigo 3º, I como *o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas*.

É de se acrescentar, ademais, que a própria Lei nº 6.938/81 estabelece, em seu artigo 2º, inciso I, que o meio ambiente deve ser considerado *como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo*. A noção de patrimônio público deve ser compreendida como instrumento que possibilita a defesa do meio ambiente através de mecanismos de direito público. Não se trata, porém, do fato de que tenha havido uma desapropriação dos bens ambientais que se encontrem submetidos a regimes jurídicos de direito privado. Na verdade, não se cuida de um “direito”, mas de um “interesse”.

A doutrina jurídica brasileira não chegou a estabelecer uma análise crítica do conceito legal de meio ambiente. Entretanto, algumas análises têm sido feitas. Doravante, passo a apresentar algumas. Roberto Armando Ramos de Aguiar (1994, p. 36) sustenta que:

O conceito de meio ambiente é totalizador. Embora possamos falar em meio ambiente marinho, terrestre, urbano etc., essas facetas são partes de um todo sistematicamente organizado onde as partes, reciprocamente, dependem umas das outras e onde o todo é sempre comprometido cada vez que uma parte é agredida.

Observe-se que o conceito legal de meio ambiente está mais voltado para os aspectos biológicos, físicos e químicos, significando uma relação harmoniosa entre partes, não se confundindo com os bens considerados em si mesmos. O conceito estabelecido é mais amplo do que o contido na legislação ordinária, pois conjuga conceitos técnicos, sociais e políticos.

O conceito normativo de impacto ambiental não é simples. A Resolução nº 1/86, do Conama, em seu artigo 1º estabeleceu que:

Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II – as atividades sociais e econômicas;

III – a biota;

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V – a qualidade dos recursos ambientais.

A Resolução nº 237/1997, do Conama, em seu artigo 1º, IV, estabeleceu um novo conceito, que é o de impacto regional e que tem por finalidade definir os parâmetros para o licenciamento de atividades poluidoras que tenham características próprias. “*Administrativo. Projeto de carcinicultura. Licença ambiental. Ação visando assegurar a exploração de atividade de carcinicultura, com base em licença expedida pelo órgão ambiental estadual – SUDEMA. É vedada a instalação de projeto de carcinicultura em área do domínio da União, salvo aforada antes de 1997, e em manguezais. Em ‘Zona Costeira’ depende de licenciamento pelo órgão competente (Curtis e Terence Trennephol, ‘Licenciamento Ambiental’ – Resolução Conama nº 312/2002). Projeto instalado em ‘Zona Costeira’, mas em terreno próprio e não em manguezais. A ‘Zona Costeira’ (faixa marítima de 11,1 km e faixa terrestre de 20 km) é patrimônio nacional, não quer dizer propriedade da União. Inexistência de impacto ambiental regional ou nacional. Competência do órgão ambiental estadual para o licenciamento*” (TRF da 5ª Região. AG 200705000153548. Relator: Desembargador Federal Ridalvo Costa. 3ª Turma. DJ: 29/8/2007, p. 871, nº 167).

O impacto regional foi assim definido:

É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados.

Deve ser observado, contudo, que a LC nº 140/2011, ao tratar das ações administrativas da União, especificamente no que diz respeito ao licenciamento ambiental não tratou mais de atividades regionais, *in verbis*:

Art. 7º São ações administrativas da União: [...] XIV – promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: (a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; (b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; (c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; (d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela

União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); (e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; (f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto na LC nº 97, de 9 de junho de 1999; (g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou (h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conama (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

As alterações desfavoráveis à saúde são óbvias por si próprias. Todo projeto que acarrete repercussão negativa sobre a saúde dos indivíduos de uma determinada comunidade é impactante. A segurança deve ser entendida como segurança social contra riscos decorrentes da inadequada localização de materiais tóxicos, alteração significativa nas condições de fixação do solo, possibilidade de enchentes, desabamentos etc. Não se pode deixar de mencionar os riscos de ampliação de índices de criminalidade e outros que afetam desfavoravelmente a segurança. Quanto ao bem-estar, este deve ser compreendido como um conjunto de condições que definem um determinado padrão de qualidade de vida que deve ser aferido levando-se em conta as condições peculiares de cada comunidade especificamente considerada.

As atividades sociais e econômicas dizem respeito ao emprego, ao modo de produção da riqueza e dos bens, guardando-se como referencial as populações que vivem em uma determinada região. Os projetos de intervenção no meio ambiente serão socialmente nocivos se, em sua execução, implantação e funcionamento, implicarem desagregação social, descaracterização de comunidades, deslocamentos indesejados, desapossamento de bens.

Efeitos desfavoráveis sobre a biota são aqueles que dizem respeito, diretamente, às condições de vida animal e vegetal na região considerada.

Alteração das condições estéticas e sanitárias são as transformações que produzam alterações de natureza paisagística ou visual ou mesmo olfativa, que potencialmente possam resultar em doenças para os membros de uma coletividade. Quanto à qualidade dos recursos ambientais, o projeto a ser implantado não poderá trazer alterações qualitativas aos recursos, tais como enfraquecimento genético de espécies, diminuição de padrões de concentração de determinados elementos etc.

§ 2º BASES CONSTITUCIONAIS

A CF, no que foi seguida pelas Constituições Estaduais e pela maioria das Leis orgânicas Municipais, no que diz respeito às avaliações de impactos ambientais, tomou a parte pelo todo. Explico-me: o inciso IV do § 1º do artigo 225 determina a obrigatoriedade de realização prévia de estudos de impacto ambiental para a implantação de projeto ou atividade capaz de causar significativa degradação ambiental. A medida é louvável e não se está a criticar os estudos de impacto ambiental. Todavia, o legislador constituinte teria andado melhor se tivesse determinado a realização de avaliações ambientais previamente à implantação de projetos, programas ou empreendimentos capazes de causar degradação ambiental. Como sabemos, o estudo prévio de impacto ambiental é, apenas, mais uma modalidade de avaliação ambiental como (i) prévias, (ii) concomitantes ou (iii) posteriores à implantação, operação ou desmobilização dos empreendimentos, atividades ou programas capazes de impactar negativamente ao ambiente.

No Brasil, a obrigatoriedade do estudo prévio de impacto ambiental para a implantação de obras ou atividades potencial ou efetivamente causadores de significativa degradação ambiental é uma imposição constitucional.

A constitucionalização dos Estudos de Impacto Ambiental não foi acompanhada de uma legislação ordinária apta a concretizar a determinação constitucional no plano da prática diária e administrativa. Fato é que a norma constitucional é aberta e necessita que o Poder Executivo defina critérios capazes de estabelecer, com segurança, qual é o conceito de atividade que efetiva ou potencialmente possa ser causadora de *significativa* degradação ambiental. Infelizmente, a matéria permanece, em âmbito federal, regulada por ato administrativo de escala subalterna, que são as resoluções do Conama.

A necessidade de Estudos de Impacto Ambiental está prevista no inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF, que determina caber ao Poder Público *exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade*.

No particular, o direito brasileiro vive uma situação curiosa, pois uma norma constitucional foi “regulamentada” por uma mera resolução, ou resoluções, do Conama, o que me parece não ser exatamente o determinado pelo Constituinte que usou a expressão “na forma da lei”. Dado que os estudos prévios de impacto ambiental incidem diretamente na esfera de direitos e garantias individuais, seja o direito ao meio ambiente equilibrado, seja o direito ao empreendedorismo empresarial, penso que, no caso, o ideal seria a existência de uma lei definindo diretrizes mínimas para o enquadramento de uma obra ou atividade no conceito de causadora de significativa degradação ambiental, remetendo ao Executivo a implementação de tais diretrizes. É importante considerar que a jurisprudência do STF³ não tem considerado as regulamentações administrativas como aptas a dispor diretamente sobre matéria constitucional.

No que concerne aos impactos ambientais, a CF, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 42/2003, estabeleceu que o exame dos impactos ambientais deve ser “diferenciado”, considerando-se os produtos, serviços e seus processos de elaboração e prestação (art. 170, VI). Assim, o inciso IV do § 1º do artigo 225 deve ser lido e compreendido em harmonia com o artigo 170, VI, significando que o administrador não pode estabelecer exigências ambientais, notadamente no que se refere à análise de impactos ambientais que desconsiderem o porte dos empreendimentos e suas repercussões sobre o ambiente. Cuida-se da adoção de critério de maior proteção ambiental, sem custos excessivos.

Ademais, os estudos prévios de impacto ambiental são *modalidades de avaliação de impactos constitucionais*. Do meu ponto de vista, melhor teria andado o constituinte se tivesse determinado a avaliação dos impactos ambientais das obras e atividades capazes de causar significativa degradação ambiental, deixando ao administrador definir qual forma de avaliação seria necessária para o caso concreto.

Merece ser ressaltado que não há que se falar em realização de EIA para atividade instalada antes da exigência regulamentar, conforme já foi decidido pelo STJ: *1. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental revela exigência administrativa que não se coaduna com o funcionamento de empresa instalada há mais de 3 (três) décadas, conjurando, a um só tempo, a evidência do direito e o periculum in mora (art. 273 do CPC). 2. Deveras, sobressai carente de prova inequívoca a ação que visa à referida exigência legal instituída após 1 (uma) década da instalação da empresa, por isso que, in casu, através de cognição exauriente e no curso da lide, prova técnica, sob contraditório, encerra meio pertinente à aferição da verossimilhança da alegação. 3. É defeso ao juiz, em nome do “poder geral de cautela”, deferir medida antecipatória satisfativa, porquanto diversos os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional referida. É que a tutela cautelar reclama aparência (fumus boni juris) e a tutela satisfativa evidência (prova inequívoca conducente à verossimilhança da alegação). 4. A fungibilidade dos requisitos viola o art. 273 do CPC, tanto mais que, in casu, a tutela antecipada visa à estagnação das atividades da empresa, caso não apresente o Estudo Prévio, sendo certo que a atividade resta exercida por 37 (trinta e sete) anos. 5. Recurso especial provido (REsp 200501147867. REsp 766236. Ministro Francisco Falcão. 1ª Turma. DJe 04/08/2008).*

7.2 A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA

7.2.1 Áreas críticas de poluição e avaliação de impactos ambientais

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, produziu muitos reflexos no direito interno de diversos países, em função da Declaração lá proclamada. Muito embora a Declaração de Estocolmo não tivesse força obrigatória para os signatários, não se constituindo mais do que uma *simples afirmação de princípios, não um tratado* (MELLO, 1974, p. 667), os seus efeitos são incontáveis. No âmbito do direito brasileiro, é possível apontar, como uma das principais influências da

Declaração, o início de uma legislação de proteção ao meio ambiente moderna e baseada em uma principiologia própria de direito ambiental.

A legislação tutelar do meio ambiente que antecede à Conferência de Estocolmo é, de fato, constituída por normas e princípios de direito administrativo, pois não estava imbuída dos conceitos básicos do direito ambiental, em especial a noção de utilização sustentável dos recursos ambientais.

A história legislativa do estudo de impacto ambiental no Brasil tem início na década de 70 do século XX, pela edição do Decreto-lei nº 1.413/1975, que introduziu em nosso direito o zoneamento das áreas críticas de poluição. O texto legal estabeleceu um sistema inteiramente novo no interior do universo jurídico brasileiro, pois, em decorrência da norma contida no artigo 1º do Decreto-lei nº 1.413/75, possibilitou-se uma base legal para o licenciamento ambiental. Observe-se que o decreto-lei, ao dispor sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais, alterou, profundamente, toda uma série de concepções jurídicas até então vigentes e indiscutíveis. Em primeiro lugar, chamo a atenção para o fato de que o decreto-lei estabeleceu um claro marco temporal:

- antes do Decreto-lei nº 1.413/75; e
- depois do Decreto-lei nº 1.413/75.

As empresas que viessem a ser instaladas após a data de expedição do decreto-lei deveriam possuir antipoluição. Para tal, fazia-se necessária a avaliação prévia dos impactos ambientais causados pela atividade. Ainda que sem um maior rigor metodológico e sem uma imposição legal clara e precisa, não resta dúvida de que, para o direito brasileiro, foi esse o marco fundamental para a obrigatoriedade jurídica das avaliações de impacto ambiental.

A segunda observação a ser feita é quanto às *indústrias que já se encontravam instaladas quando da edição do decreto-lei*. Elas estavam em pleno funcionamento e, presumidamente, cumprindo a legislação vigente no País. Contudo, isso não era suficiente para eximi-las da fiscalização ambiental e da obrigatoriedade de cumprirem as novas exigências de ordem pública ambiental. O mecanismo utilizado pelas entidades de controle ambiental para a verificação das condições de funcionamento das ditas instalações é o da *auditoria ambiental*, isto é, a *avaliação do impacto ambiental* é feita *a posteriori*.

A regulamentação do Decreto-lei nº 1.413/75 foi feita pelo Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975. O seu artigo 1º estabeleceu o conceito normativo de poluição:

Para as finalidades do presente Decreto, considera-se poluição industrial qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia ou de substâncias sólida, líquida ou gasosa, ou combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretamente, de:

I – prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II – criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;

III – ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais.

Os artigos 2º e 4º do Decreto nº 76.389/75 estabeleceram critérios gerais a serem observados pelos órgãos públicos quando da concessão de financiamentos de atividades potencialmente poluidoras do ambiente. Foi determinado expressamente que: *Os órgãos e entidades gestoras de incentivos governamentais, notadamente o CDI, a Sudene, a Sudam e os bancos oficiais considerarão explicitamente, na análise de projetos, as diferentes formas de implementar política preventiva em relação à poluição industrial, para evitar agravamento da situação nas áreas críticas, seja no aspecto de localização de novos empreendimentos, seja a escolha do processo, seja quanto à exigência de mecanismos de controle ou processo antipoluentes, nos projetos aprovados.*

À então SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) competia fixar padrões gerais de qualidade ambiental visando a evitar e corrigir os feitos danosos da poluição industrial. O artigo 4º do decreto estabelece que: *Os Estados e os Municípios, no limite de suas respectivas competências, poderão estabelecer condições para o funcionamento das empresas, inclusive quanto à prevenção ou correção da poluição industrial e da contaminação do meio ambiente, respeitados normas e padrões fixados pelo Governo Federal (Decreto nº 76.389, de 3/10/1975).*

Um importante critério operacional foi estabelecido pelo parágrafo único do artigo 4º, que determinou que: *Observar-se-á sempre, no âmbito dos diferentes níveis de Governo, a orientação de tratamento progressivo das situações existentes, estabelecendo-se prazos razoáveis para as adaptações a serem feitas e, quando for o caso, proporcionando alternativa de nova localização, com apoio do setor público.*

Sem reconhecer o “direito adquirido de poluir”, o decreto foi sensível a realidades que não poderiam ser mudadas de uma hora para outra. Estabeleceu-se, portanto, um canal de negociação entre governo e indústria, com a finalidade de, em prazo razoável, alterar situações ambientalmente inaceitáveis. A última opção é a da realocização das empresas que não pudessem diminuir de forma eficaz a poluição produzida. Um importante resultado da norma acima mencionada foi a realocização das instalações industriais do Curtume Carioca, que se situavam no Bairro da Penha, na Cidade do Rio de Janeiro, e que, em razão da alta densidade populacional da região, não tinha mais condições de permanecer naquele local. Após um longo processo de negociação entre governo, população e indústria, foi decidida a realocização da fábrica na Zona Oeste da cidade.

7.2.2 Avaliação dos impactos ambientais prevista na Lei nº 6.803/1980

Marco de grande importância para o tema ocorreu com a edição da Lei nº 6.803/1980. Foi através dela que se estabeleceu de forma clara e precisa a necessidade da avaliação do impacto ambiental dos empreendimentos industriais. É importante observar que, nos termos da lei referida, *a avaliação é prévia*. Assim é que o artigo 10, § 3º, da lei determinou que *Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento do zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o parágrafo anterior será precedida de estudos especiais de alternativas e de avaliações de impactos, que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada.*

Observe-se que a avaliação de impacto prevista no § 3º do artigo 10, necessariamente, deveria contemplar alguns itens previamente definidos no artigo 9º:

O licenciamento para implantação, operação e ampliação, de estabelecimentos industriais, nas áreas críticas de poluição, dependerá da observância do disposto nesta lei, bem como ao atendimento das normas e padrões ambientais definidos pela SEMA, pelos organismos estaduais e municipais competentes, notadamente quanto às seguintes características dos processos de produção:

I – emissão de gases, vapores, ruídos, vibrações e radiações;

II – riscos de explosão, incêndios, vazamentos danosos e outras situações de emergência;

III – volume e qualidade de insumos básicos, de pessoal e de tráfego gerados;

IV – padrões de uso e ocupação do solo;

V – disponibilidade nas redes de energia elétrica, água, esgoto, comunicações e outros;

VI – horários de atividade.

A autoridade licenciante para tais empreendimentos é a estadual, sem embargo de outras licenças exigíveis.

7.2.3 O estudo de impacto ambiental na Lei nº 6.938/81

A Lei nº 6.938/81 marca uma mudança qualitativa no sistema legal de proteção ambiental, pois busca criar um sistema estruturado e organicamente coerente de medidas a serem adotadas para o alcance dos objetivos fixados naquele texto normativo. A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), por força da Lei nº 6.938/81, foi

elevada à condição de um dos instrumentos da PNMA. É de se observar, contudo, que a Lei da PNMA não desceu a minúcias quanto às formalidades que deveriam compor a Avaliação de Impacto Ambiental. Registre-se, por oportuno, que, não tendo sido revogada a Lei nº 6.803/80, as exigências contidas nos artigos 9º e 10 daquele diploma legal permaneceram vigentes.

A regulamentação do assunto não foi feita por decreto, mas por resolução do Conama [que foi criado pela própria Lei nº 6.938/81]. A referida regulamentação, entretanto, não se deu em apenas um ato normativo, ao contrário, demandou a edição de diversas resoluções do Conama, que guardam um grande lapso temporal entre si e, de certa maneira, tratam de assuntos variados, demonstrando que houve muita resistência à implantação do novo sistema.

A resolução mais importante no campo das avaliações de impacto ambiental é a Resolução nº 1/1986. Essa resolução buscou regulamentar inteiramente o assunto, muito embora diversos temas pertinentes remanescessem carentes de regramento. Veja-se que, tal qual o exemplo francês, foi longo o lapso de tempo decorrido entre o estabelecimento da norma que exige os estudos prévios de impacto ambiental e a sua regulamentação.

É curioso que a Resolução nº 1/86 fez uma inovação no instituto definido pelo artigo 9º, III, da Lei nº 6.938/81, pois a Avaliação de Impacto Ambiental passou a ser efetivada através da realização de EIA e dos respectivos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA. Posteriormente, a denominação Estudo de Impacto Ambiental acabou se popularizando de tal maneira que se inseriu na própria Constituição.

§ 3º NATUREZA JURÍDICA DO EIA

7.3 NATUREZA JURÍDICA DO EIA

No sistema jurídico brasileiro, o estudo de impacto constitucional tem a natureza jurídica de *instituto constitucional, constituindo-se em instrumento da PNMA* (Lei nº 6.938/1981, art. 9º, III). *O que isto significa na prática?* Na condição de instrumento constitucional, ele, em tese, está colocado acima da PNMA, surgindo aí uma contradição, pois ao mesmo tempo ele tem uma previsão constitucional que a PNMA não possui.

O estudo prévio de impacto ambiental é uma informação técnica posta à disposição da administração, com vistas a subsidiar o licenciamento ambiental de obra ou atividade capaz de potencial ou efetivamente causar *significativa degradação ambiental*.

A PNMA é um dos principais instrumentos jurídicos para a implementação das diretrizes constitucionais para a promoção do desenvolvimento sustentado. É nesse contexto que os estudos de impacto ambiental estão incluídos. Dentre todos os instrumentos previstos na PNMA ele é um dos mais complexos. A complexidade é primeiramente (i) *técnica*, em função do conjunto de disciplinas que devem ser utilizadas para a realização de um estudo de impacto ambiental adequado, (ii) *jurídica*, pois o papel legal desempenhado pelo EIA não é trivial. Existe, também, uma grande complexidade (iii) *política*, que é ocasionada pela participação popular nos processos de licenciamento e, ainda, há uma complexidade (iv) *institucional*, em função do papel desempenhado pelo EIA como instrumento para a tomada de decisão e em função dos diversos órgãos públicos que, conforme seja a natureza e localização do projeto, deverão intervir no licenciamento ambiental.

O inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF estabelece que é dever da Administração Pública *exigir, na forma da lei, o Estudo Prévio de Impacto para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente*.

Aqui está um dos pontos mais controversos da questão. O Poder Público não pode exigir o EIA de forma aleatória, visto que a CF estabelece alguns critérios para que tal exigência seja válida e legal. O primeiro deles é que o EIA é exigível na *forma da lei*. Ora, qual seria a extensão do vocábulo “lei” no caso concreto? A doutrina, em sua maioria, tem entendido que lei, na hipótese, tem o sentido de norma jurídica e *não lei formal*.

O EIA é exigível de forma vinculada, no interior do processo de licenciamento de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, ou seja, está submetido aos princípios gerais da Administração Pública, em especial o da *legalidade*. Caso o legislador quisesse autorizar a exigência de EIA sem previsão legal, não teria se utilizado da expressão, na forma da lei. Parece-me bastante evidente que, uma vez que o capítulo constitucional do meio ambiente é uma extensão dos direitos e garantias constitucionais, não há como deixar de assinalar que a limitação do exercício de direitos somente se faz com base em uma expressa autorização legal. Ainda que a prática administrativa e judiciária venha admitindo a regulamentação da exigência do EIA por meras resoluções administrativas, sou de opinião de que já é tempo para dar um novo tratamento ao tema. Marçal Justen Filho (2005, p. 139), com propriedade, adverte para o fato de que o vocábulo “lei” é utilizado constitucionalmente de forma a identificar várias espécies de atos estatais, conforme consta do artigo 59 da própria Constituição, não cabendo para explicitar atos de outra índole, como, por exemplo, as resoluções administrativas. “Ou seja, o princípio da legalidade significa, em grande parte dos casos, a insuficiência da previsão constitucional para a validade da atividade administrativa. A Constituição é o conjunto de normas fundamentais, mas é insuficiente para disciplinar a atividade administrativa.”

Há que se observar, por imperioso, que há Estados que legislaram sobre a exigência de estudos prévios de impacto ambiental, por meio da edição de leis formais, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 1.356/1988).

Uma outra questão crucial é a seguinte: a CF estabelece que o Estudo de Impacto Ambiental deve ser exigido quando se tratar de licenciar *obra ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente*. O conceito, no entanto, é aberto e somente pode ser preenchido através da edição de atos normativos, sejam legais ou regulamentares. *A contrario sensu*, se a atividade não se incluir entre aquelas que possam *efetiva ou potencialmente* ser agentes de *significativa degradação*, o Estudo de Impacto Ambiental será inexigível. Observe-se que não há *dispensa* (STF. RE 631753 AgR/RJ. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 7/6/2011. 1ª Turma. DJe-119. “... I – O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.086/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou que a previsão, por norma estadual, de dispensa ao estudo de impacto ambiental viola o art. 225, § 1º, IV, da CF. II – Agravo regimental improvido”) do estudo de impacto ambiental, ele sempre será exigível se a obra ou atividade causar impacto negativo significativo. Ocorre que as atividades humanas são múltiplas e, diuturnamente, surgem novos projetos industriais, novos produtos e situações que, dificilmente, podem ser antecipadas por atos normativos e legais. Essas questões são importantíssimas, seja para a atividade econômica, seja para a proteção do meio ambiente e da saúde humana, e dependem da adequada definição da natureza jurídica dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental. O Poder Executivo é o único autorizado a, mediante critérios fixados legalmente, definir se uma atividade é ou não causadora de significativo impacto ambiental. É importante observar que as listas de atividades potencialmente poluidoras devem ser examinadas com cuidado, pois não é raro que, em função da tecnologia adotada, uma atividade concreta possa estar aquém ou além do padrão na qual tenha sido classificada. Evidentemente que, em tais casos, a produção de estudos técnicos deverá ser levada em consideração para a sua real classificação (TRF da 4ª Região. AC – Apelação Cível/PR. Juiz Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. 3ª Turma. DJU 3/9/2003, p. 511. “... 1. Não há necessidade de estudo de impacto ambiental para mera limpeza de canais de escoamento e, *in casu*, a pretensão de nulidade de todas as autorizações, bem como a paralisação das obras de desassoreamento dos canais, deixa ao desamparo as populações vizinhas, que sofrem riscos de calamidades decorrentes das cheias, como a proliferação de doenças como a dengue e a leptospirose, além de danos em residências, móveis e utensílios. 2. A aplicação da Resolução nº 237/97 do Conama deve ser feita com razoabilidade à luz do que dispõe o art. 225 da Constituição, sem esquecer que a obra que necessita de estudo de impacto ambiental/ relatório de impacto ambiental, é predicada pela ‘significativa degradação do meio ambiente’. 3. Verificando a situação concreta, limpeza e desassoreamento de canais vintenarios, operação que deveria ocorrer periodicamente, anualmente quiçá, não se mostra necessário o EIA/RIMA a cada operação de limpeza, o que seria uma demasia, pelo seu alto custo e complexidade, daí a conclusão de que as autoridades avaliaram bem a situação, ao dispensá-los, neste caso. 4. Não podem, todavia, ser realizadas obras novas, como o canal entre os balneários ST Etienne e Albatroz, no balneário Matinhos, o do Rio da Onça e o ligando o Balneário Monções ao canal do Guaraçu, bem como o próprio alargamento do canal do Guaraçu sem os devidos EIA/RIMAs, no qual se discuta também a opção de ‘não fazer’. 5. A despeito da função institucional dos órgãos ambientais-réus, Ibama e IAP, de fiscalizarem tudo o quanto se refira ao meio ambiente, degradação ou restauração, fica mantida a condenação de todos os réus, no que se refere ao cumprimento do Plano de

Recuperação Ambiental, inclusive com a promoção da desocupação das áreas invadidas ou irregularmente ocupadas. 6. Parcialmente providos os recursos e a remessa oficial, afastada a condenação em honorários advocatícios, por incabíveis na espécie”).

7.3.1 Formalidades do estudo de impacto ambiental

O Estudo de Impacto Ambiental é parte integrante do processo de licenciamento ambiental de obras ou atividades capazes de causar significativa degradação ambiental. Alguns autores, como, por exemplo, o Ministro Antônio Benjamim (s.d.), entendem-no como *limite da discricionariedade administrativa, na medida em que, para tais estudiosos, a administração estaria vinculada aos resultados do Estudo de Impacto Ambiental*. Essa é uma questão que examinarei mais adiante. Do ponto de vista da forma, o EIA deve, na medida do possível, atentar para as prescrições legais e regulamentares. Entretanto, há que se observar que o EIA não está disciplinado em lei e, portanto, as suas formalidades não são obrigatórias (Lei nº 9.784/1999, art. 22), até mesmo porque o processo administrativo se rege pela adoção de formas simples (Lei nº 9.784, 29/01/1999, art. 2º). Com efeito, a prática administrativa e judiciária tem demonstrado que, não raras vezes, um vício formal pode implicar a anulação de uma licença ambiental. A solução não é, obviamente, a mais adequada. É importante que a administração busque aproveitar todos os atos que tenham sido praticados no processo de licenciamento, pois ele, como se sabe, é extremamente caro e difícil, não tendo sentido a anulação de seus atos se, substancialmente, não estão evitados de vícios ou outros elementos que possam pôr em dúvida a lisura da concessão da licença (Lei nº 9.784/1999, art. 55). A judicialização extremada das questões ambientais tem levado a que, seguidamente, sejam privilegiadas as questões meramente de forma, em detrimento do próprio conteúdo dos EIA.

O *licenciamento*, como se sabe, é uma espécie do gênero processo administrativo e deve se reger pelas normas gerais a este último aplicáveis. A vinculação do processo administrativo se dá na medida em que o administrador não pode exigir do administrado medidas sem a adequada previsão legal. Nada mais.

As conclusões do EIA não obrigam a Administração, até mesmo porque seria sem sentido que a administração ficasse tolhida em sua ação administrativa por força de um documento que, embora constante do processo de licenciamento, é, na maioria das vezes, de produção privada. Elas são um importantíssimo instrumento de auxílio na tomada de decisão e não mais do que isso. Caso o EIA fosse vinculante para a Administração, *data venia*, não haveria sentido na própria existência do licenciamento, pois, uma vez que o EIA tivesse concluído que uma licença deveria ser dada, a Administração não poderia negá-la, por exemplo. O EIA não é um instrumento capaz de impor ao administrador uma determinada conduta – positiva ou negativa – com relação à concessão de uma licença ambiental.

O EIA simplesmente analisa os impactos que podem ser previstos e oferece ao administrador uma síntese, considerando-os em uma matriz da qual resultará uma opinião sobre a viabilidade ambiental ou não do projeto analisado, sugerindo medidas mitigadoras para os impactos prováveis.

Os impactos identificados pelo EIA são os impactos mínimos do projeto, nada impede que a administração identifique outros impactos, ocasião em que poderá solicitar complementação de estudos. Contudo, dada a estrutura do procedimento de licenciamento ambiental, tem sido hábito a exigência do EIA na fase de licença prévia, o EIA acaba sendo uma peça de ficção, pois não corresponde ao processo que será implantado, pois no planejamento prévio não é possível o detalhamento do projeto, momento a partir do qual será possível a identificação real dos impactos. Logicamente, sempre que a Administração demonstrar discordância com o EIA deverá fazê-lo de forma fundamentada. Na hipótese de negativa da concessão de uma licença, a fundamentação deve ser coerente, sob pena de violação a direitos subjetivos (TRF 2ª Região. AG. 200002010086683/RJ. 3ª Turma. DJU 29/3/2001. Relatora: Juíza Virginia Procópio de Oliveira Silva. “Agravado de instrumento. Tutela antecipada. Relatório de Impacto Ambiental – EIA/ RIMA I. Em havendo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e Estudo de Impacto Ambiental – EIA favoráveis às obras dos autos, é de se considerar verossímeis as alegações da parte autora e confirmar o provimento antecipatório de tutela jurisdicional já obtido na 1ª Instância. II – Agravado a que se nega provimento. Agravado regimental prejudicado”). O empreendedor, este sim, vincula-se à análise contida no EIA, bem como aos padrões e tecnologias neles examinados, salvo se a modificação posterior for no sentido de diminuir o impacto sobre o meio ambiente.

O EIA é procedimento essencialmente técnico, devendo guardar coerência técnica. *A sobreposição de uma excessiva formalidade ao conteúdo material do EIA, como vem sendo entendido em muitos fora, é uma distorção grave. A finalidade precípua dos EIA é informar e examinar todas as alternativas para a implementação ou a não implementação de um projeto. Desde que isto esteja contemplado e que os princípios contidos no artigo 37 da CF estejam contemplados no estudo, não há qualquer motivo racional para não o aproveitar.*

7.4 O EIA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Depois de tudo o que foi dito acima, resta uma pergunta: qual é o papel desempenhado pelo EIA em relação à Administração Pública? A partir da promulgação da CF de 1988, ficou implicitamente determinado que o licenciamento ambiental fosse realizado mediante a adoção de um procedimento complexo, no qual intervêm diversos atores, que são: a administração pública (muitas vezes por órgãos diversos), a equipe técnica multidisciplinar, o postulante ao licenciamento ou empreendedor e a população, através da participação na audiência pública.

O EIA, como já foi visto, é um instituto jurídico de nível constitucional. Nessa condição, o seu objetivo máximo é o de integrar como elemento técnico o mecanismo jurídico administrativo apto a assegurar a efetividade do direito consagrado no artigo 225 da CF. Tal direito, como se sabe, *depende da utilização pelo Poder Público* dos instrumentos constitucionais previstos nos diversos incisos do § 1º do artigo 225, além de outros que possam ser criados pelo legislador ordinário.

A Administração Pública tem o dever de exigir dos empreendedores que realizem, às suas próprias expensas, os estudos ambientais. Necessário, contudo, que tal exigência seja feita através de ato formal e respaldada em motivação técnica que demonstre ser a atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. O ato formal exigido para o caso é o chamado *termo de referência (TR)*. O TR é o instrumento que balizará as exigências da administração para um determinado licenciamento. Normalmente, é um documento negociado entre empreendedor e órgão ambiental.

O *termo de referência* é um balizamento estabelecido pela Administração Pública para a equipe técnica multidisciplinar que irá trabalhar na elaboração do estudo de impacto ambiental ou de outros estudos ambientais. Através do termo de referência, a Administração Pública mostrará ao empreendedor quais são os elementos que ela julga devam ser privilegiados na análise a ser realizada pelos técnicos. Cuida-se do estabelecimento de aspectos cuja observação deverá ser mais acurada, mais detalhada. O termo de referência é a bússola que irá orientar o trabalho da equipe técnica. Entretanto, é necessário que se diga que o trabalho dos técnicos não deverá limitar-se ao termo de referência.

O *termo de referência* é um instrumento que serve tanto para a Administração Pública como para o empreendedor. Assim é, na medida em que a complexidade de determinados estudos exige que a própria Administração Pública se prepare para examiná-los e, nesse sentido, o termo de referência serve como um orientador na constituição das equipes que serão encarregadas de oferecer um parecer conclusivo sobre o estudo de impacto ambiental.

É importante observar que o *termo de referência* estabelece critérios mínimos a serem observados pelo elaborador do Estudo de impacto ambiental; entretanto, a ênfase da investigação a ser procedida pela equipe técnica multidisciplinar será sobre os elementos constantes no termo de referência. A Administração Pública não poderá rejeitar um Estudo de Impacto Ambiental sob o argumento de que faltaram análises específicas sobre determinado ponto se tais análises não foram solicitadas no termo de referência nem são daquelas obrigatórias.

A exigência de estudos de impacto ambiental, ou de qualquer outra forma de avaliação de impacto ambiental, é medida tipicamente administrativa e, portanto, praticada apenas pelo Poder Executivo. O Estado do Espírito Santo tinha em sua Constituição uma norma curiosa que determinava competir à Assembleia Legislativa o exame dos Estudos de Impacto Ambiental antes da concessão da licença ambiental. Cuidava-se, evidentemente, de norma exótica e despropositada que, em boa hora, foi declarada inconstitucional pelo STF (STF. ADI 1505/ES. Ação direta de inconstitucionalidade. Relator: Ministro Eros Grau. Tribunal Pleno. DJU 4/3/2005, p. 101. “1. É inconstitucional preceito da Constituição do Estado do Espírito Santo que submete o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – ao crivo de comissão

permanente e específica da Assembleia Legislativa. 2. A concessão de autorização para desenvolvimento de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente consubstancia ato do Poder de Polícia – ato da Administração Pública – entenda-se ato do Poder Executivo. 3. Ação julgada procedente para declarar inconstitucional o trecho final do § 3º do artigo 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo”).

Da mesma forma, entendeu o STF que não cabe ao Constituinte dos Estados dispensar os estudos prévios de impacto ambiental por norma constitucional, face à determinação da CF, *sempre que presente a efetiva ou potencial significativa degradação do meio ambiente* (ADI 1086/SC. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Tribunal Pleno. Julgamento: 10/8/2001. DJU 10/8/2001, p. 2. “... *A norma impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob enfoque*”).

7.4.1 Publicidade

A publicidade dos EIAs e RIMA é obrigatória por mandamento constitucional, sendo realizada conforme a determinação regulamentar. A Resolução nº 1/86 do Conama, no particular, determina que:

Art. 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive o período de análise técnica.

§ 1º Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação.

§ 2º Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente ou o Ibama ou, quando couber, o Município determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA.

Com isso busca-se dar publicidade ao estudo de impacto ambiental e ao seu relatório. Da mesma forma, e compreendida no processo, deve ser considerada a Audiência Pública, que é mais uma forma de levar ao conhecimento do público os elementos do estudo de impacto ambiental.

Podemos afirmar que, nos casos de atividades ou instalações, potencial ou efetivamente causadoras de *significativa – assim definida em ato próprio* – poluição ou degradação ambiental, o licenciamento ambiental que não tenha sido precedido de EIA é anulável. A questão crucial, portanto, é definir as atividades que podem se enquadrar no tipo constitucional aberto como efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental. Evidentemente que, em cada caso concreto, a Administração Pública deverá declarar se a atividade pode ou não ser enquadrada na categoria. Esse enquadramento deverá ser feito de forma fundamentada mediante ato administrativo próprio, repita-se.

7.4.2 Vinculação da Administração ao EIA

A matéria referente à vinculação da Administração Pública aos resultados do EIA tem sido bastante controversa. Poucos autores, dentre os quais merece ser citado como exemplo Passos de Freitas (1993, p. 62), *têm a correta compreensão de que o EIA não é vinculante para a Administração: “Permito-me, com a devida vênia, divergir de tal posicionamento. Observo que inexistente qualquer comando legal a ordenar tal vinculação ao administrador”*.

A plena limitação da discricionariedade administrativa pelo EIA seria, de fato, atribuir ao estudo um papel que nem a Constituição, nem a lei, lhe atribuem, é evidente, pois, como é fácil de se perceber, que os Estudos de Impacto Ambiental servem apenas e tão somente para oferecer uma análise técnica dos efeitos que decorrerão da implantação do projeto. Vale observar que o EIA deve ser abrangente, e, uma vez que os elementos tenham sido fornecidos aos administradores, caberá ao governo realizar um balanço entre todas as opções, consideradas, inclusive, aquelas de natureza socioeconômica.

§ 4º REQUISITOS DO EIA

A validade do EIA depende do preenchimento de requisitos de ordem formal e material. Infelizmente, os referidos requisitos não se encontram organizados e sistematizados em um único diploma legal; ao contrário, estão distribuídos ao longo de diversas Resoluções do Conama, sem que haja uma organicidade entre elas; da mesma forma ocorre com as normas estaduais e municipais que tratam do assunto.

Os requisitos de conteúdo estão previstos na Resolução nº 1/86, em seus artigos 5º e 9º. Já os requisitos formais estão na própria Resolução nº 1/86 e na Resolução nº 1/88, essencialmente.

7.5 REQUISITOS DE CONTEÚDO

Requisitos de conteúdo são aqueles que dizem respeito aos aspectos materiais que devem estar presentes nas Avaliações de Impactos Ambientais – AIA, expressas em estudo de impacto ambiental e em seus Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA. O sistema jurídico brasileiro, fundado no princípio da legalidade, impede que os aspectos e questões que, necessariamente, devem estar contidos em estudos e relatórios de impacto ambiental sejam aleatórios, ou feitos sem a existência prévia de uma norma legal. Assim sendo, a legislação ambiental brasileira estabelece um conteúdo material mínimo que deve estar presente em todas as avaliações de impacto ambiental, que devem ser submetidas ao Poder Público para fins de licenciamento de uma atividade ou empreendimento. Nada impede, contudo, que a equipe técnica responsável pelo EIA avance na análise de assuntos que não são formalmente exigidos pelas normas legais, desde que a exigência seja motivada em necessidades ambientais claramente explicitadas. Evidentemente que, em tais casos, as informações colhidas servirão como novos subsídios para o órgão licenciante. Observe-se, contudo, que dada a vinculação do empreendedor ao EIA, as informações que lhe sejam desfavoráveis devem ser consideradas.

O artigo 5º da Resolução do Conama nº 1/1986, estabelece que o estudo de impacto ambiental deverá obedecer às seguintes diretrizes gerais: (i) contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; (ii) identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade; (iii) definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; (iv) considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

Observe-se que, no caso, trata-se de diretrizes que deverão ser observadas no EIA. O órgão ambiental, em meu entendimento, poderá adotar as diretrizes da forma que julgue mais conveniente, não estando obrigado a adotar uma Fórmula ou forma, previamente determinada. O que a norma busca é ter a informação, não especificando a maneira pela qual ela se incorporará ao EIA.

É de se considerar que, quando da determinação da realização do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual, federal ou municipal, conforme o caso, poderá determinar as diretrizes adicionais que, em razão das peculiaridades do projeto e características ambientais da área, façam-se necessárias, indicando, inclusive, os prazos para que os estudos sejam concluídos. Assim sendo, o órgão licenciante, quando formular a exigência de que seja feito um EIA, deverá indicar imediatamente quais são os estudos complementares necessários. Ultrapassada essa fase, a agência ambiental não poderá formular outras exigências para o empreendedor, salvo pedidos de esclarecimentos para questões já anteriormente suscitadas. Aqui, opera-se uma preclusão administrativa. Assim é na medida em que os EIA são estudos de longa duração, complexos e caros, e, evidentemente, compete à Administração Pública expor, claramente, aquilo que deseja saber sobre um projeto determinado.

Exigências técnicas, pouco claras ou sem base legal devem ser evitadas, pois somente serão evitadas a todas as partes envolvidas, inclusive para a Administração Pública, visto que o Poder Judiciário poderá invalidar as exigências ilegais. A norma deve ser a “não surpresa”.

A determinação regulamentar é no sentido de que o órgão licenciante e a própria equipe que se encarregará de realizar o trabalho utilizem uma determinada abordagem filosófica no desenvolvimento do estudo de impacto ambiental. A abordagem requerida pela legislação brasileira é interdisciplinar e abrangente. Deve prever todas as hipóteses suscitadas pelo projeto. Como se materializam as determinações do artigo 5º? Passemos a examinar o que é desejado pela norma legal.

7.5.1 Alternativas tecnológicas e de implantação

O estudo de impacto ambiental deve examinar todas as opções tecnológicas para que a finalidade do empreendimento proposto possa ser alcançada. Exemplificativamente, se o projeto a ser implantado tem por finalidade a geração de energia elétrica para uma determinada região, é necessário que a equipe técnica examine todas as possibilidades de geração elétrica disponíveis. Assim sendo, deverão ser vistas as consequências da geração hidrelétrica, termelétrica, eólica etc. Nesse ponto, a análise prende-se ao aspecto tecnológico, isto é, se a tecnologia disponível atende, do ponto de vista da qualidade do produto final, à demanda concreta. A análise tecnológica implica, necessariamente, o exame de outros fatores envolvidos no projeto. Dentre todos os fatores factíveis de exercer influência na implementação de um projeto, obviamente, avulta o fator econômico. A relação comparativa entre os custos dos diversos projetos e a análise dos benefícios eventualmente gerados por cada uma das opções é fundamental na definição da alternativa tecnológica a ser adotada. Não há como dissociar a análise tecnológica do custo da tecnologia. Um elemento importante que não pode ser descuidado é aquele que determina a opção pela melhor tecnologia disponível, isto é, em geral, os projetos devem ser implantados com a utilização dos aparelhos e tecnologias que sejam os mais *eficientes* em termos de proteção ambiental.

Nem a equipe técnica nem o órgão licenciante estão adstritos a examinar, apenas, a opção tecnológica oferecida pelo empreendedor. É possível que um projeto seja inviável com a utilização de uma determinada opção tecnológica e perfeitamente viável se for adotado outro caminho técnico. O mesmo deve ser dito quanto à localização. O local pretendido, muitas vezes, pode não ser o adequado e a equipe técnica deve dizê-lo claramente, inclusive sugerindo outra localização.

Cumprido lembrar que as exigências para a indicação de alternativas locais para empreendimentos e instalações não estão claramente definidas em nosso ordenamento jurídico. Na verdade, em nível federal, a matéria encontra-se regulada, apenas, pela Resolução Conama nº 1/86, que no artigo 5º, I estipula que o *estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de PNMA, e que também deverá obedecer às seguintes diretrizes gerais: contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto.*

Ressalte-se que, como se depreende da Resolução nº 1/86, *não há qualquer sanção administrativa para a não realização dos estudos de análise locacional.* Contudo, há uma tendência judicial a determinar a realização de novos estudos ambientais sempre que requisitos formais dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental não sejam observados, motivo pelo qual o tema será devidamente aprofundado nesta exposição. Lembre-se, aliás, que aqui estamos diante de “diretrizes gerais”.

Os estudiosos do Direito Ambiental, notadamente aqueles que se dedicam aos pormenores do licenciamento ambiental, têm dedicado pouca atenção ao relevantíssimo tema das alternativas tecnológicas e locais para a implantação e o desenvolvimento de projetos. É ocioso dizer que, mesmo em sede normativa, o tema tem papel secundário, muito embora seus aspectos práticos sejam muito significativos, pois uma má escolha local pode implicar a não realização de um projeto e, por consequência, em enormes prejuízos para os empreendedores.

A escolha da localização de um empreendimento industrial deve levar em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos: (i) facilidade de acesso a mercados/centros de distribuição; (ii) facilidades de acesso a fornecedores e recursos necessários para funcionamento do empreendimento; (iii) bom relacionamento com a comunidade e autoridades governamentais; (iv) competitividade da localização em relação às demais alternativas analisadas; (v) considerações ambientais (legais e ecológicas); (vi) facilidade de relacionamento com demais empresas do mesmo grupo econômico; (vii) abundância e capacitação profissional da mão de obra necessária para a implementação da atividade; (viii) atratividade do local; (ix) situação tributária, disponibilidade de crédito e incentivos para a implementação da atividade; (x) boa infraestrutura de transportes; (xi) existência de utilidades e serviços.

Pelo que se pode ver, a escolha de uma boa alternativa local é, apenas, parcialmente, feita pelo empreendedor, pois existem fatores objetivos que, obrigatoriamente, devem ser contemplados sob pena da inviabilização do próprio negócio. Resulta claro, portanto, que a chamada alternativa local de um empreendimento não é uma escolha arbitrária a ser tomada pelas empresas sem considerações bastante profundas. Na verdade, a opção por determinada localização para um empreendimento, frequentemente, é decisiva para o sucesso ou o fracasso da atividade que envolvem fatores políticos, econômicos e ambientais (ecológicos e socioambientais).

Como se viu, a variável ecológica é uma das componentes de uma matriz mais ampla que deve ser levada em consideração para que se possa, com segurança, tomar a decisão de investir. A questão que necessita ser esclarecida, portanto, é qual o peso relativo que deve ser atribuído à variável ecológica na composição dos elementos que levam à tomada de decisão de investir, isso do ponto de vista privado. Para a autoridade ambiental, a equação se soluciona com atribuição de pesos para a variante ambiental, de forma a considerar que, no âmbito das ponderações necessárias, o investimento a ser feito é ambientalmente justificável. É imperioso sublinhar que a variável ecológica, assim como as demais, está subordinada ao contexto legal específico, sendo limitada pela legislação aplicável. Não há que se falar em limitações ecológicas se a legislação expressamente não determinar a impossibilidade da realização da atividade. Tem sido frequente o recurso aos chamados princípios do Direito Ambiental como limitadores de implantação de empreendimentos, contudo, o recurso aos princípios só se mostra legítimo nas hipóteses nas quais não existe norma legal.

As diferentes atividades a serem implantadas têm características que, naturalmente, impõem limitações adicionais para a escolha de uma alternativa local adequada. Existem exemplos clássicos que merecem ser mencionados neste capítulo. Pense-se na implantação de uma (i) usina hidrelétrica; além de todas as considerações acima mencionadas, há uma limitação natural, que é a existência de potenciais hidrelétricos capazes de, em tese, gerar a quantidade de energia nova que se pretende lançar no mercado; o mesmo se diga em relação à (ii) atividade de mineração que, obviamente, somente poderá ser instalada em locais nos quais existam os jazimentos que se pretenda explorar. Uma mina de ferro somente pode estar localizada em região na qual reconhecidamente existam jazidas de ferro.

Em linhas gerais, portanto, as alternativas locais se dividem em dois grandes grupos que necessitam ser respeitados e observados para que o empreendimento que se pretende desenvolver não parta de uma premissa local inadequada ou inconveniente. A localização de um empreendimento, portanto, se subdivide em (a) macrolocalização e (b) microlocalização.

A macrolocalização leva em conta os aspectos físico-geográficos, mas, sobretudo, considera os fatores de natureza econômica e tecnológica, ou seja, é necessário para que uma determinada região seja considerada adequada para a implantação de um empreendimento que ela esteja (a) próxima de seu mercado consumidor, (b) que a infraestrutura necessária para a sua implantação esteja presente, (c) que exista mão de obra apta a trabalhar no empreendimento, (d) que os aspectos tributários tornem a região competitiva.

É importante realçar que entre a macrolocalização e a microlocalização existe um grau de interação e interferências recíprocas que, não em raras oportunidades, farão que uma tenha repercussão direta sobre a outra, chegando a ser uma condicionante.

A microlocalização corresponde ao espaço geográfico, ao território, que será ocupado pelo empreendimento. As suas limitações serão basicamente de ordem legal, haja vista que as instalações deverão ser implantadas em local sem restrições legais para a atividade. A microlocalização de um empreendimento deve observar as normas municipais de zoneamento e uso e ocupação do solo, além de outras normas legais aplicáveis. O empreendimento deve ser compatível com a destinação que o Município deu ao local onde se pretende instalá-lo.

No que diz respeito à alternativa tecnológica, há que se considerar, ainda, o fato de que muitas das atividades de infraestrutura são passíveis de concessão pública, o que limita a alternativa tecnológica, pois se um leilão de energia foi feito para a implantação de energia solar, não adianta nada que a melhor opção seja energia eólica, por exemplo. Aliás, a matéria diz respeito à política energética, que não é matéria de atribuição do órgão de controle ambiental. Outra questão é a que se refere à localização; no regime de propriedade privada, o domínio do solo é um elemento intransponível no que se refere à possibilidade de localização de um

projeto. Penso que, concretamente, a única possibilidade de não localização de um projeto em determinado local é uma vedação legal ou regulamentar.

Questão polêmica é a da chamada *opção zero*, isto é, a análise dos efeitos produzidos pela não realização do empreendimento. Trata-se, evidentemente, de comparar a situação ecológica atual da região em que se pretende implantar determinado projeto com a situação futura. Não se trata, contudo, apenas disso. Deve ser analisada, igualmente, a situação econômico-social da área de influência do projeto nas hipóteses de realização e de não realização do empreendimento. Aqui é preciso lembrar que a legislação brasileira, em matéria ambiental, tem como um de seus objetivos assegurar condições de desenvolvimento socioeconômico. Parece-nos, portanto, que a opção zero somente deve ser considerada como a mais adequada quando o projeto causar grandes impactos ambientais, sem possibilidade de mitigação aceitável, e que os seus resultados econômico-sociais sejam desprezíveis. Deve ser lembrado que, no regime constitucional brasileiro, a regra ambiental não é a da intocabilidade do meio ambiente, mas, ao contrário, a regra é a utilização equilibrada. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais se afirma a extraordinária importância da Avaliação de Impactos Ambientais. Se a regra fosse a da intocabilidade, seriam desnecessários os estudos de impacto, vez que os projetos não seriam implantados.

7.5.2 Impactos ambientais gerados na fase de implantação e na fase de operação

A avaliação dos impactos ambientais derivados da fase de implantação e de operação do projeto não se constitui matéria de fácil análise. O impacto da fase de implantação é de curto prazo e não exige maior esforço de investigação, muito embora os seus efeitos possam ser duradouros. O impacto ambiental gerado na fase de implantação é, ainda, bastante visível, de imediato reconhecimento. A sua caracterização, portanto, é menos problemática do ponto de vista tecnológico e científico. Normalmente ela está relacionada com obras civis, movimentação de caminhões, presença de operários em número excessivo etc.

A questão torna-se complexa quando se trata dos impactos ambientais decorrentes da fase de operação, principalmente devido ao fato de que os EIA são exigidos na fase preliminar de planejamento, para a concessão da LP. Ora, na fase de preliminar de planejamento, o projeto não se encontra acabado e, portanto, não há como se ter uma previsão segura dos impactos a serem gerados, pois não há uma definição clara dos equipamentos que serão utilizados pela planta industrial. Normalmente, são utilizados modelos matemáticos, que buscam realizar simulações das situações que ocorrerão quando o empreendimento estiver em pleno funcionamento. Apesar da sofisticação do método, não raro, a natureza apresenta surpresas que os melhores modelos matemáticos têm dificuldade de prever.

7.5.3 Área geográfica a ser diretamente atingida

A análise dos impactos ambientais ao longo do tempo será uma função da verificação de tais impactos em uma determinada área geográfica, a chamada área de influência do projeto. A definição da área de influência é uma das tarefas mais inglórias em matéria de estudos ambientais. A enorme inter-relação entre todos os componentes da biosfera faz com que muitos atos praticados localmente possam repercutir globalmente. O fenômeno da poluição transfronteíra, das chuvas ácidas e outros demonstram a dificuldade da abordagem do tema. Obviamente que a resolução não pretende o impossível, mas apenas e tão somente que se faça um estudo cientificamente sério e dentro de limites razoáveis. O referencial da bacia hidrográfica é razoável e somente precisará ser ultrapassado em circunstâncias específicas e peculiares. Paulo Affonso Leme Machado (1992, p. 136) sugere um critério casuístico bastante útil: *A possibilidade de se registrarem impactos significativos é que vai definir a área chamada de influência do projeto.*

Contudo, é importante registrar que a área de influência direta, bem como a área de influência indireta são definidas pelo EIA, salvo se o termo de referência determinar diferentemente.

7.5.4 Consideração de planos e programas governamentais

Com o planejamento urbano e industrial que hoje é cada vez mais uma presença na atividade humana, não se pode deixar de considerar o projeto a ser implantado em integração com todo o planejamento governamental para a região na qual este deverá ser localizado. Assim sendo, pode ocorrer que a região esteja planejada para ser uma área de residências, impedindo a implantação da atividade industrial.

7.5.5 Impactos sociais e humanos

A Resolução nº 1/86 do Conama não exige, explicitamente, a análise dos impactos sociais e humanos do projeto proposto. O entendimento da necessidade da realização de tal análise decorre de uma compreensão holística das ciências ambientais e, evidentemente, do próprio Direito Ambiental. O conjunto de disposições legais contidas na Lei nº 6.938/81 é suficiente para demonstrar que, efetivamente, os impactos sociais e humanos dos projetos a serem implantados devem ser examinados pelo EIA, sob pena de necessidade de complementação do estudo. Além de instituto constitucionalmente previsto, o estudo de impacto ambiental é um dos instrumentos da PNMA. Assim, ele tem por desiderato o alcance dos objetivos fixados para a PNMA. Como se sabe, o artigo 2º, da Lei nº 6.938/81 determina que, dentre os seus objetivos estão os de *recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e a proteção da dignidade humana*. Necessário, portanto, que as repercussões sociais e humanas dos projetos sejam bem examinadas no estudo.

Não bastassem os argumentos acima expendidos, é de se acrescentar que a própria Lei nº 6.938/81, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente (i) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou (ii) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas.

Ora, se a avaliação dos impactos ambientais, em última análise, tem por finalidade a pesquisa e o descobrimento das repercussões geradas por um projeto especificamente considerado, e que, no próprio conceito de poluição, estão incorporadas as perturbações sensíveis da atividade social e econômica, não se pode deixar de incluir nas análises dos impactos tudo aquilo que seja repercussão na vida social e econômica da população da área de influência do projeto.

Necessário se faz que o aspecto *qualidade de vida* seja examinado de forma muito clara e precisa. A implantação de projetos e a utilização de recursos ambientais devem ser realizadas com vários objetivos e, dentre estes, não pode faltar o da geração de empregos e da utilização de mão de obra local, sempre que possível.

7.6 REQUISITOS TÉCNICOS

O artigo 6º da Resolução nº 1/86 do Conama determina quais são as alternativas técnicas mínimas que deverão ser desenvolvidas no EIA. O primeiro requisito é o diagnóstico da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existentes antes da implementação do projeto, de modo a caracterizar a situação ambiental da área. Trata-se, portanto, de um inventário ambiental da região. Há determinação normativa de que, no curso do aludido inventário, sejam considerados três parâmetros, que são: (i) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; (ii) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico-econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente; (iii) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos.

Não são poucas as exigências contidas no primeiro inciso do artigo 6º. A primeira providência a ser tomada é uma ampla investigação sobre a base física na qual deverá ser instalado o projeto proposto, para que se saiba de sua compatibilidade com a instalação projetada. Esse é um exame preliminar. Em determinados momentos, é possível que se verifique que o lençol freático não comporta o projeto, embora haja compatibilidade do projeto com o regime de ventos da região etc. Além das repercussões sobre o meio físico, devem ser examinadas as suas repercussões sobre a vida animal e vegetal existentes na região na qual se pretende executá-lo. É uma análise ampla. Muitas vezes, um projeto poderá tornar inviável a sobrevivência de uma espécie animal ou vegetal; poderá afetar as características

básicas de vida de animais e vegetais. Esses elementos devem ser sopesados, e propostas alternativas capazes de viabilizar a vida devem ser apresentadas para exame. A questão grave que se coloca é quando, por exemplo, tornar-se factível a extinção de uma determinada espécie animal ou vegetal em razão do projeto. Nesse caso, é necessário que se faça uma dura opção entre os eventuais benefícios compreendidos pelo projeto e os danos ambientais, cuja quantificação é extremamente difícil, senão impossível. Nesses casos, o projeto deverá prever e prover os meios que se façam necessários para que se evite uma perda irreparável em termos ambientais.

O que deve estar contido no EIA é uma exposição clara e precisa dos impactos. Caberá à sociedade avaliar quais as opções a serem tomadas diante do caso concreto. O EIA, na medida do possível, não deve formular juízos de valor, uma vez que esta não é a sua finalidade. O que deve estar contido no EIA é a mais ampla pluralidade de alternativas e situações possíveis. Os julgamentos de valor devem ser feitos pelas autoridades governamentais e pela sociedade.

Por fim, faz-se necessária uma análise cultural do projeto, ou seja: como o empreendimento irá repercutir na vida social de uma determinada localidade. Não se pode admitir a destruição de localidades inteiras, de modos de vida e de cultura, sob o pretexto do “progresso”. A história recente do Brasil bem demonstrou tristes exemplos de destruição de comunidades inteiras para a construção de barragens e outros empreendimentos de grande porte. Felizmente, de algum tempo para cá, está se organizando um forte movimento de cidadãos em defesa de suas comunidades, que já logrou conquistar algumas vitórias contra a destruição de seus valores culturais. Já é antiga uma importante decisão do TRF da 4ª Região que determinou a paralisação das obras de construção de uma barragem, pois estas não haviam sido precedidas do EIA (AI nº 92.04.03619-2/PR, rel. Juiz Vladimir Passos, *DJU*, seção II, 14/4/1992, p. 9483). Algumas outras decisões no mesmo sentido já vêm sendo tomadas por diversas Cortes brasileiras.

O inciso II do artigo 6º determina seja analisada a natureza do impacto a ser produzido pelo projeto. Nessa análise deverão estar incluídas também as alternativas para os impactos. Deverão ser analisados os impactos positivos e os negativos que, eventualmente, serão produzidos. Esses impactos deverão ser dimensionados em curto, médio e longo prazo. Deverão, ainda, ser estudados quais os impactos que permanecerão perenes e quais aqueles outros que somente se manifestarão ao longo de certo lapso de tempo.

A caracterização dos impactos ambientais como algo negativo *em si* deve ser rejeitada por ser preconceituosa e pouco útil para o desenvolvimento social e a própria proteção ambiental. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, possui um belíssimo exemplo de impacto ambiental positivo que nos é dado pelo Aterro do Flamengo. Como se sabe, a construção do Aterro do Flamengo foi feita com pedras e terra retiradas do desmonte do Morro de Santo Antônio, situado no Centro da cidade. Construiu-se o aterro, com belíssimos jardins e monumentos, área de recreação para milhares de pessoas, solucionou-se, à época, o problema de trânsito da Zona Sul da cidade para o Centro e, por fim, estabeleceu-se uma nova urbanização para a área do Morro de Santo Antônio. Como se vê, portanto, a retomada de um pedaço da Baía de Guanabara e o desmonte do Morro de Santo Antônio foram amplamente compensados. Um outro exemplo positivo de impacto ambiental nos é trazido pelo Elevado do Joá, também na cidade do Rio de Janeiro; trata-se da construção de estrada que, margeando o mar, incorporou-se de tal maneira à montanha que circunda que, de fato, passou a integrar o complexo ecológico da região.

A conclusão do EIA deverá apontar, quando viáveis, as providências capazes de diminuir ou cancelar os efeitos dos impactos ambientais negativos. Na análise de tais providências, deverá constar, inclusive, um exame do material técnico necessário para implementar as medidas, avaliando a eficiência destes. Há, ainda, a necessidade de que se preveja um sistema de acompanhamento e monitoramento permanente das repercussões ambientais do projeto que se pretenda implantar.

7.7 REQUISITOS FORMAIS

Requisitos formais são aqueles que dizem respeito à forma jurídica pela qual o EIA/RIMA deve ser expresso em sua integralidade e, igualmente, quais os preceitos legais que não podem ser olvidados, sob pena de nulidade do estudo. Os requisitos formais do EIA são fundamentais e não devem ser desprezados por aqueles que militam em defesa do meio ambiente. A experiência prática tem demonstrado que, em muitas oportunidades, a violação de requisitos formais é uma preliminar para a posterior violação de requisitos de conteúdo do EIA. A forma, aqui, milita em defesa do meio ambiente. A defesa dos requisitos formais da legislação de proteção ambiental é, quase sempre, o primeiro passo em defesa do meio ambiente considerado em si próprio.

O EIA deve ser escrito em vernáculo, as folhas numeradas em sequência, conter a fonte das informações apresentadas, conter as memórias de cálculo dos estudos, indicar os *softwares* e modelos matemáticos rodados, ser firmado por equipe técnica habilitada e ser disponível para a coletividade.

7.7.1 Equipe técnica habilitada

A equipe técnica exigida para a realização de estudos de impacto ambiental é multidisciplinar. Essa exigência decorre da própria natureza do EIA que, como se viu, engloba conhecimentos de várias ciências. Os integrantes da equipe técnica, portanto, devem ser profissionais das diversas áreas envolvidas no projeto cujo licenciamento se pretende.

7.7.1.1 Independência da equipe técnica

Penso que a primeira formalidade a ser examinada é aquela contida no artigo 7º da Resolução nº 1/86 do Conama. Tal artigo, como se sabe, diz respeito à independência da equipe técnica responsável pelo EIA. Com efeito, o artigo 7º da Resolução nº 1/86 determina que o EIA deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

No sistema atual de licenciamento ambiental, a independência deve ser considerada em termos, pois os estudos de impacto ambiental, como regra, são encomendados pelo empreendedor e por ele estipendiados. Assim, a independência só pode ser técnica e decorre não da Resolução em si, mas do dever de responsabilidade técnica dos profissionais.

O tema da independência técnica, contudo, não é fácil e tem suscitado inúmeras polêmicas. Antônio Inagê Assis de Oliveira (S/d, p. 38), profundo conhecedor que é da legislação ambiental brasileira, leciona que

Com o desenvolvimento do sistema de licenciamento, cedo se verificou que os órgãos ambientais, por melhor aparelhados que fossem, apenas com o conhecimento de seus técnicos, não teriam condições de proceder ao estudo de avaliação de impacto ambiental de certas atividades ou empreendimentos de maior sofisticação técnica ou elevado porte.

Prossegue o autor:

Esse problema não poderia ser resolvido simplesmente com a contratação de novos técnicos especialistas na matéria versada, inclusive por óbices administrativos, mas principalmente pela relativa ociosidade a que estariam destinados, cumprida a tarefa específica. A princípio foi tentada a utilização de consultores independentes, logo inviabilizada pelo elevado montante de recursos necessários [...]

O papel da equipe técnica é, claramente, o de fornecer ao órgão licenciante um parecer prévio sobre o projeto. Tal parecer, muito mais que um aconselhamento, é, obviamente, um laudo técnico cujas repercussões são muito importantes.

7.7.1.1.1 Revogação do artigo 7º da Resolução nº 1/86 do Conama

A prática administrativa demonstrou que as excelentes intenções demonstradas pelo Conama, ao elaborar a Resolução nº 1/86, no concreto, revelaram-se irreais.

A Resolução Conama nº 237/1997, em seu artigo 11, alterou o sistema anteriormente vigente, no que se refere à apresentação dos estudos ambientais para efeito de licenciamento ambiental, dispondo em seu artigo 11 que *os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente*

habilitados, às expensas do empreendedor. Na forma do parágrafo único do mencionado artigo o empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações prestadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

A nova regulamentação apenas reconhece uma prática que já existia, isto é, a remuneração da equipe técnica pelo empreendedor. Na vigência do sistema anterior, qualquer empresa idônea de consultoria, contratada para a elaboração do EIA/RIMA, deveria ser remunerada. Tal remuneração, obviamente, só poderia ser feita pelo empreendedor. Pelo novo sistema, a própria empresa licencianda poderá elaborar o EIA/RIMA e levá-lo à apreciação do órgão licenciador. Certamente, existe uma diminuição de custos, sem qualquer prejuízo para a qualidade dos estudos, pois a responsabilidade técnica permanece a mesma. Observe-se que a natureza pública do EIA/RIMA não foi suprimida e, portanto, permanecem vigentes todas as implicações quanto à veracidade e à seriedade das informações constantes do documento.

7.7.1.1.2 Responsabilidade dos autores do EIA

A Lei nº 9.605/1998 (artigo 69-A) tipifica como conduta criminalmente punível “*elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão*” estabelecendo a pena de reclusão de “3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.” Por sua vez, o Decreto nº 6.514/2008, em seu artigo 82 estabelece penalidade administrativa para aquele que elabore ou apresente informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental, determinando a imposição de multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

7.7.2 Informação incompleta

A Lei nº 9.605/1998, desde a inclusão do artigo 69-A passou a ter incidência direta sobre o licenciamento ambiental e, sobretudo, na elaboração dos estudos ambientais, qualquer que seja a modalidade. Assim, se faz necessário saber exatamente quando o órgão ambiental considera que um estudo ambiental esteja encerrado e o que se deve entender por informação incompleta. O tipo penal em questão, data vênua, tem sido um instrumento de inquietação para toda uma gama de profissional e, com todo respeito, os seus benefícios para a qualidade dos estudos ambientais ainda não foi comprovado.

A avaliação ambiental é essencial para a implantação de projeto ou empreendimento utilizador de recursos ambientais. O papel do EIA é ainda mais relevante dada a sua natureza constitucional desempenhando atividade fundamental no licenciamento ambiental de atividades capazes de causar, potencial ou efetiva, significativa degradação ambiental.

O EIA é um procedimento que, além de seu aspecto constitucional, tem natureza (i) técnica e (ii) institucional. A conciliação de todos os seus aspectos nem sempre é facilmente resolvida, pois ao lidar com dados científicos, o EIA não é capaz de afirmar certezas absolutas, dado que a natureza da ciência é evolutiva, com a superação de estágios cognitivos passados e a criação de novos que se fazem à base das pesquisas e estudos que se renovam. Por outro lado, o mundo institucional e jurídico se faz à base de proposições que tendem à verdade, pelo menos a verdade jurídica, criada pela coisa julgada que é imutável, ainda que possa ser discutível ou mesmo inconveniente.

Assim, é da natureza do EIA e de sua análise pelos órgãos ambientais, o constante questionamento e a sua modificação na medida em que surgem demandas por parte da sociedade nas audiências públicas e dos próprios órgãos de controle ambiental. É importante ressaltar que o EIA é apresentado ao órgão ambiental na fase de requerimento da LP e, portanto, na fase preliminar de planejamento do projeto, em momento meramente conceitual, no qual as definições do empreendimento ainda se encontram em fase embrionária.

Com muita frequência é comum que, em função de aspectos econômicos, os projetos sofram alterações entre a LP e a concessão da LI, no que se denomina na praxe administrativa como alteração de projeto. Em muitos casos, a alteração de projeto demanda complementações ao EIA para que haja uma adaptação ao projeto “concreto” que se busca implantar e não mais ao “projeto conceitual” que fora licenciado.

É importante observar que a CF não determina que o EIA seja posicionado antes desta ou daquela licença, mas antes da implantação do empreendimento ou projeto (STF. ACO 876 MC/BA; Relator: Min. Sepúlveda Pertence; Julgamento: 18/12/2006; DJU 1º/2/2007, p. 148.) O tema tem sido muito suscitado perante as nossas cortes judiciais e já chegou a merecer decisão do STF, a qual com invulgar felicidade examinou o tema em profundidade. Na oportunidade, o então Ministro Sepúlveda Pertence foi ao âmago da questão:

Cumprer ressaltar que somente com a Licença de Instalação é que o empreendedor poderá realizar ato de construção propriamente dito. É dizer, qualquer alteração efetiva no meio ambiente somente ocorrerá após a emissão dessa licença, com observância dos requisitos básicos e condicionantes expressos nos procedimentos ultrapassados. Portanto, a concessão de Licença Prévia, por si só, não importa em risco de degradação do meio ambiente. Aliás, caso o órgão ambiental competente verifique violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença, bem como a superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, poderá – por meio de decisão motivada – alterar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, e ainda suspender ou cancelar uma licença expedida (art. 19 da Resolução 237/97)(42). Não há, é certo, limitação temporal para o exercício desse poder, em virtude do evidente realce concedido à questão ambiental em nossa ordem jurídica.”

Por todos os motivos anteriormente descritos e por tantos outros, não se deve supervalorizar o papel do EIA no contexto do licenciamento ambiental, haja vista que ele é um instrumento da política ambiental, não sendo o único. O EIA por mais técnico e correto que seja não é vinculante para a administração pública. Matéria bastante semelhante já foi submetida ao crivo judicial, destacando-se os seguintes pontos de decisão proferida pelo TRF da 4ª Região AC 200671010038018; Relator Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 3ª Turma, DE 4/11/2009:

10. Nulidade do licenciamento ambiental prévio. Argui o Ministério Público que o EIA realizado não contemplou todas as informações arroladas nos arts. 5º e 6º da Resolução Conama nº 001/86, acarretando a nulidade do estudo e da Licença Prévia emitida. A nulidade afirmada, no entanto, não se verifica. Os arts. 5º e 6º da Resolução Conama nº 001/86, de fato, contém uma série de parâmetros que devem nortear a realização do Estudo de Impacto Ambiental, como as alternativas de localização do projeto, os impactos na implantação e operação da atividade, a delimitação da área impactada pelo empreendimento e a consideração dos projetos governamentais previstos ou implementados. Para isto, a norma estabelece que o EIA deverá ser integrado pelas atividades de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, contendo o levantamento dos recursos ambientais antes do empreendimento (meios físico, biológico, socioeconômico); de análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, com a projeção das prováveis alterações relevantes; das medidas mitigadoras dos impactos negativos; e da elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento de tais impactos. Tratando-se de estudo ambiental necessário à concessão da Licença Ambiental apenas prévia, entretanto, não se exige que tais estudos sejam exaurientes, infensos a modificações, detalhamentos e complementações mesmo posteriores à concessão da licença.

A mutabilidade do EIA é intrínseca à sua natureza, dado que se trata de um estudo prospectivo e projetivo das alterações ambientais a serem causadas, no futuro, pelo empreendimento. A própria norma reconhece a necessidade de um estudo probabilístico, ao determinar a necessidade de “projeção das prováveis alterações” ambientais a serem causadas (Resolução Conama nº 001/86, art. 6º). Assim, pretender a definitividade de um estudo cujo ethos é a virtualidade de alterações ambientais futuras, em face de obras ainda não empreendidas, não condiz com o espírito da norma. A interpretação defendida na inicial que, à hipótese de incidência “alterações e complementações do EIA”, liga a consequência jurídica “nulidade do EIA” revela-se, nestes termos, a menos indicada.

A definitividade pretendida é mesmo um contrassenso normativo, na medida em que se está, na fase da licença prévia, apenas tentando projetar, embora da

forma mais detalhada e abrangente possível, as alterações ambientais a serem causadas por obra futura, e a forma de evitá-las, mitigá-las ou compensá-las. A própria CF, no artigo 225, § 1º, inciso IV, dispõe que incumbe ao Poder Público exigir o EIA que deve ser prévio, de qualquer modo, à instalação da obra, como se constata: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento) [...] Sabe-se que o licenciamento ambiental é ato uno, de caráter complexo, em cujas etapas intervêm vários agentes, e deverá ser precedido de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, sempre que constatada a existência, ainda que potencial, de significativo impacto ambiental (MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: RT, 2001. p. 360).

O procedimento administrativo de licenciamento ambiental, dada a amplitude da tutela constitucional do meio ambiente, prevê a possibilidade de a Administração Pública, através de seu órgão ambiental, solicitar do empreendedor esclarecimentos e complementações dos estudos ambientais que deram início ao licenciamento do empreendimento, podendo mesmo haver a reiteração das solicitações de complementação dos estudos sempre que os esclarecimentos não forem satisfatórios (Resolução Conama nº 237/97, art. 10, IV). Há, também, possibilidade de serem solicitados esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental, decorrentes das audiências públicas, de acordo com o disposto no art. 10, VI, da mesma Resolução Conama nº 237/97. A oportunidade de a Administração exigir complementações do empreendedor é igualmente prevista no mesmo artigo 10, § 2º, da Resolução Conama 237/97, que preconiza que “No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental – EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência dos esclarecimentos já prestados, conforme os incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação”. A previsão normativa de sucessivos pedidos de complementação do EIA, portanto, evidencia o caráter dinâmico dos estudos ambientais e das licenças ambientais concedidas pela Administração Pública. A exigência de complementações e de incorporação de novas condicionantes ambientais é insita à natureza do estudo ambiental e do licenciamento ambiental. Assim, vê-se que o procedimento de licenciamento ambiental comporta diversas etapas e diversas possibilidades de complementações e saneamentos dos EIAs inicialmente apresentados, sem que tais deficiências e esclarecimentos impliquem, necessariamente, a invalidade dos estudos ambientais prévios.

Não exige a legislação ambiental, como se vê, que o EIA, documento inicial do licenciamento ambiental, represente estudo definitivo, inenunciável a revisões. Ao contrário, espera-se mesmo que, de seu exame, surjam novas indagações a serem respondidas para que seja possível o licenciamento ambiental. Novos questionamentos sobre o EIA inicialmente apresentado surgem como decorrência do seu exame pelo órgão ambiental e pelos demais participantes do licenciamento ambiental. De fato, a legislação pertinente em nenhum momento determina que eventuais pedidos de complementação e solicitação de esclarecimentos devam acarretar a invalidade do EIA prévio e a necessidade de sua reelaboração completa. É lícito, portanto, concluir que a existência de complementações nos EIAs previamente apresentados para o licenciamento ambiental não traz como consequência jurídica a sua nulidade e a necessidade de sua completa reelaboração, fazendo tábula rasa do quanto já empreendido nos estudos ambientais. A constatação de deficiências no estudo ambiental prévio determina que, caso procedentes e relevantes tais incompletudes, os estudos deverão ser acrescidos, complementados ou esclarecidos, no bojo do licenciamento ambiental e não completamente reelaborados, desconsiderando-se in totum o EIA inicialmente trazido ao órgão ambiental. Admitir a conclusão contrária é admitir que haverá, no curso do licenciamento ambiental, diversas reelaborações completas dos EIAs e nulidade das licenças já concedidas, uma para cada oportunidade de esclarecimentos e saneamento de deficiências, o que comprometeria, de forma definitiva, a necessária efetividade da atuação administrativa no licenciamento ambiental...”

Assim, não se devem considerar os estudos ambientais finalizados antes de sua aprovação final pelo órgão de controle ambiental. A mera entrega deles não é apta para gerar consequências penais ou administrativas.

7.7.3 Despesas

Foi com o intuito de viabilizar a independência técnica que o artigo 8º da Resolução nº 1/86 do Conama determinou que as despesas deveriam correr todas por conta do proponente do projeto. O espírito da norma é o de impedir que a sociedade arque com as despesas de exame de um projeto cujos benefícios individuais são bastante claros.

7.7.3.1 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental

A Lei nº 6.938/81, por seu artigo 17, I, estabeleceu o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Já o Conama, pela Resolução nº 1/1988, visou a disciplinar o registro de técnicos que, eventualmente, venham a compor equipes técnicas com a finalidade de elaborar projetos para a realização de EIAs. O artigo 2º da Resolução acima mencionada determina que a SEMA e os órgãos ambientais, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta resolução, somente aceitarão, para fins de análise, projetos técnicos de controle da poluição ou estudo de impacto ambiental, cujos elaboradores sejam profissionais, empresas ou sociedades civis regularmente registradas no Cadastro de que trata o art. 1º.

Prossegue a Resolução, determinando o prazo de validade do registro, que será de dois anos, competindo aos cadastrados promover a renovação dos registros.

Pelo artigo 5º da Resolução estabeleceu-se que para fins de cadastramento, serão exigidos das pessoas físicas e jurídicas interessadas tão somente os dados necessários à sua caracterização jurídica e responsabilidade legal, bem como avaliação da capacidade técnica e da eficácia dos serviços oferecidos, dados esses a serem coletados através de formulário próprio, cabendo à declarante responder sob as penas da lei, em qualquer tempo, pela veracidade das informações apresentadas. Já o artigo 6º dispõe que a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal não implicará, por parte da SEMA e perante terceiros, certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

O tema tratado na Resolução nº 1/88 é extremamente polêmico. Com efeito, a matéria diz respeito ao exercício profissional e, efetivamente, a referida resolução estabeleceu uma limitação ao exercício profissional de várias categorias. Pelo sistema adotado no Brasil, quando se tratar de profissões regulamentadas, o registro será exigido nos órgãos pertinentes. Ou seja, o registro deverá ser feito junto aos organismos encarregados pela fiscalização de cada uma das diferentes profissões. Nem o Ibama nem o Conama possuem atribuições para controlar o exercício de atividades profissionais de qualquer profissão. Pelos termos da resolução, se um advogado oferecer parecer acerca de um EIA, o órgão ambiental somente poderá aceitá-lo se o profissional estiver cadastrado junto ao Cadastro Técnico Federal. Ora, somente a Ordem dos Advogados do Brasil tem poderes para fiscalizar o exercício da profissão de Advogado, e o bacharel não precisa inscrever-se em nenhum outro órgão para exercer sua profissão.

7.7.4 O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

Muitas vezes, há confusão entre EIA e RIMA. O EIA é o conjunto de pesquisas que se fazem necessárias para avaliar o impacto ambiental de um determinado empreendimento. O RIMA é parte integrante do EIA e tem por finalidade fazer com que conceitos técnicos e científicos sejam acessíveis à população em geral.

Deve ser dada a mais ampla divulgação ao RIMA; admite-se, apenas, o sigilo de natureza industrial. O RIMA é um resumo do EIA e deve conter todas as informações contidas naquele, de forma simplificada e acessível.

7.8 AUDIÊNCIA PÚBLICA

As audiências públicas como parte integrante do processo de licenciamento ambiental, em nível federal, estão regulamentadas pela Resolução Conama nº 9/1987. Tal Resolução foi a que estabeleceu as linhas básicas a serem observadas nas audiências públicas.

A finalidade legal das audiências públicas é a de assegurar que a comunidade afetada seja ouvida sobre o projeto, manifestando sua opinião, sem caráter deliberativo. Busca-se com a audiência que os cidadãos indaguem sobre dúvidas quanto ao EIA – já distribuído previamente – e aos impactos nele previstos. Para a Administração, ela tem a função de ser um momento no qual poderá ser feita a aferição das repercussões junto à sociedade, do projeto proposto. Sugestões e críticas podem, e devem ser feitas, assegurando que os administradores possam saber exatamente qual é a opinião popular sobre o projeto.

A Lei nº 9.784/1999, que instituiu no âmbito da Administração Pública Federal o processo administrativo para a defesa de direitos perante a administração, admite em seu artigo 32 a realização de audiências públicas como parte do processo instrutório. Tal norma é, evidentemente, aplicável ao licenciamento ambiental. Posteriormente, a Lei nº 11.105/2005 (Biossegurança), também dispôs sobre audiências públicas, conforme o contido no artigo 15 e seu parágrafo. Especificamente no que diz respeito ao acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica a Lei nº 13.123/2015 disciplina a matéria.

Assim, existe na legislação brasileira uma ampla previsão de participação no processo deliberativo das questões ambientais, mais particularmente no licenciamento ambiental.

Tem havido uma tendência à impugnação de audiências públicas e medidas judiciais com vistas a impedir-lhes a realização. *“A solicitação de esclarecimentos e complementações a Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA tem expressa previsão na Resolução Conama nº 237/97 (art. 10, inciso IV), como medida prévia à realização de audiências públicas (art. 10, inciso V), competindo ao Ibama aferir a sua necessidade, com vistas na completa instrução do procedimento de licenciamento ambiental. Demonstrada, objetivamente, essa necessidade, obstáculos de ordem material e/ou de política governamental, nem mesmo o poder discricionário do órgão ambiental, não têm o condão de impedir a sua realização, em homenagem ao interesse maior da sociedade, na busca da elucidação de todas as questões pertinentes ao aludido licenciamento ambiental”* (TRF da 1ª Região. AC 200133000057790, 6ª Turma, DJU 3/5/2004).

7.8.1 Convocação

A audiência pública pode ser convocada de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou, ainda, por convocação de 50 cidadãos. *A convocação de ofício não é obrigatória*, pois a Resolução nº 9/87 do Conama estabelece que ela será feita sempre que o órgão ambiental *“julgar necessário”*. Muito embora o órgão ambiental não esteja obrigado a realizar a convocação da audiência pública, ele está obrigado a, mediante edital ou anúncio na imprensa local, abrir prazo de, no mínimo, 45 dias para que os interessados, se assim o desejarem, solicitem a realização da *public hearing*.

A convocação da audiência pública pelo *parquet* ou pelo grupo de 50 cidadãos é um direito subjetivo público que não pode ser obstruído pelos órgãos licenciadores. O não atendimento do requerimento dá margem à impetração de mandado de segurança por ser hipótese de direito líquido e certo. É importante observar que, se a audiência pública tiver sido convocada e não realizada, a licença concedida poderá ser anulada, conforme o artigo 1º, § 3º.

No caso de ter sido apresentada a solicitação da audiência pública, o órgão licenciador deverá, mediante edital, fixar data e local para a sua realização e, ainda, fazer comunicação escrita, através de correspondência, àqueles que tenham realizado a solicitação.

7.8.2 Realização da audiência

A audiência deve ser realizada de forma a permitir que os cidadãos possam dela participar efetivamente. Dependendo da complexidade do projeto a ser examinado, poderá ser realizada mais de uma audiência. Encerrada a audiência, desta deverá ser lavrada uma ata circunstanciada na qual constem todos os incidentes e, principalmente, deverão ser anexados todos os documentos nela produzidos ou encaminhados pela sociedade para consideração pelo órgão licenciante.

A abrangência do projeto, a sua extensão geográfica, a localização dos solicitantes e outros fatores a serem estabelecidos, caso a caso, poderão determinar a realização de audiências públicas em locais diferenciados.

7.8.3 Função da audiência

A audiência pública não possui caráter decisório. É atividade de natureza consultiva. Ela é, entretanto, um ato oficial e que, nessa condição, deve ter os seus resultados levados em consideração pelo órgão licenciante. Cabe, no entanto, observar que o artigo 5º da Resolução nº 9/87 vem sendo pouco explorado. Determina o artigo mencionado que a ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e o parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. Qual o alcance dessa norma? Penso que aqui se estabeleceu um dever de levar em conta a manifestação pública. Esse dever se materializa na obrigação jurídica de que o órgão licenciante realize um reexame, em profundidade, de todos os aspectos do empreendimento que tenham sido criticados, fundamentadamente, na audiência pública. *“1. O objetivo da audiência de EIA/ RIMA é possibilitar a participação popular em assuntos relacionados ao meio ambiente, e dar concretude ao comando do artigo 225, IV, da CF, o qual, por sua vez, deriva de um princípio maior, o Republicano, insculpido no artigo 1º da Carta Maior. 2. Iniciada a audiência pública em 17/12/2008, compareceram mais de 300 participantes, o que inviabilizou o prosseguimento da mesma no local designado, porquanto vários outros interessados permaneceram fora do recinto. 3. Redesignada a audiência para o dia 24 de janeiro de 2008, em local mais amplo, com publicação no Diário Oficial do Estado, no Jornal ‘O Estado de S. Paulo’ e em jornais locais, além de informes na Rádio Capital e na Rádio local ‘Z’, compareceram mais de 600 pessoas, com lista de 483 pessoas das quais 55 se manifestaram, com tendo a audiência se estendido por cerca de 7 horas. 4. Foi exatamente o adiamento da audiência que possibilitou a ampla participação popular e o extenso debate que, como dantes afirmado, se estendeu por quase 7 horas, garantindo total legitimidade ao processo. 5. O simples fato de a legislação não prever o desdobramento da audiência não significa que ela não possa ocorrer. É o interesse público quem dita tais regras. O que a legislação veda é a surpresa, a surdina, simulacro de audiência visando burlar o interesse da coletividade”*. (TRF da 3ª Região. 3ª T; AC 00045385720084036100; AC – Apelação Cível – 1564005; e-DJF3 Judicial 1, data:15/07/2011, p. 503).

-
- ¹ Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/05/110523_vulcao_islandia_dg.shtml>. Acesso em: 13 ago. 2011.
 - ² *Dicionário Aurélio Eletrônico*.
 - ³ STF – MI-AgR 304/DF, Min. Moreira Alves. Tribunal Pleno. *DJU* 13/8/1993. p. 15675. EMENT, V. 1712-01

A PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMBIENTE URBANO

8.1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade tem por objetivo disciplinar os artigos 182 e 183 de nossa CF, com vistas a regular o uso da propriedade urbana em benefício da coletividade, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e, também, do equilíbrio ambiental. O artigo 2º da lei estabelece as diretrizes (*rectius*: princípios) norteadoras da política urbana, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

É importante realçar que o meio ambiente urbano é regido pelas normas especiais do Estatuto da Cidade, complementadas pelos diferentes Planos Diretores dos Municípios que tenham população superior a 20 mil habitantes. Os princípios são os seguintes: (i) *garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações*; (ii) *gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano*; (iii) *cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social*; (iv) *planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente*; (v) *oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais*; (vi) *ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição da população a riscos de desastres*; (vii) *integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência*; (viii) *adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência*; (ix) *justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização*; (x) *adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais*; (xi) *recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos*; (xii) *proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico*; (xiii) *audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população*; (xiv) *regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais*; (xv) *simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais*; (xvi) *isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social*; (xvii) *estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais*; (xviii) *tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento*; (xix) *garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados*.

8.2 PRECEITOS CONSTITUCIONAIS

A Constituição Brasileira possui dois artigos especialmente voltados para o estabelecimento de uma disciplina para a ocupação do solo urbano e para as políticas públicas cujo objetivo é assegurar uma ocupação racional e socialmente justa dos territórios de nossas cidades. Tais artigos são: (i) artigo 182 e (ii) artigo 183.

Em sede constitucional, foi estabelecido que a Política de Desenvolvimento Urbano é executada, fundamentalmente, pelo Poder Público Municipal, de acordo com as diretrizes gerais que tenham sido fixadas em lei. Tal política tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O “instrumento básico” da política de desenvolvimento urbano é o plano diretor, que possui caráter obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes. Ele é fundamental, pois é quem definirá quando a propriedade privada estiver, ou não, cumprindo com as suas funções sociais, mediante o atendimento das “exigências fundamentais” de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.

Há necessidade premente de uma norma infraconstitucional para regular a aplicação dos preceitos constitucionais do § 4º do artigo 182, que estipula que “é facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I – parcelamento ou edificação compulsórios; II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais”. O chamado IPTU progressivo somente foi considerado constitucional após a edição da Emenda Constitucional 29/2000, conforme a Súmula 668 do STF (É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana).

Usucapião urbana. A CF, em seu artigo 183, estabeleceu a possibilidade da usucapião urbana, assim definida: “Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” (Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da CF. Pedido indeferido com fundamento em exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento em norma

hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso provido. 1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m². Pretensão da parte autora de usucapir porção de 225 m², destacada de um todo maior, dividida em composesse. 2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal. 3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 da CF, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote). 4. Recurso extraordinário provido (STF. RE 422349/RS – Min. Dias Toffoli, Pleno, *DJe-153*, 05-08-2015).

O próprio texto constitucional definiu os contornos, mínimos, a serem observados pelo legislador ordinário ao dispor sobre a matéria. Assim sendo, determinou o Constituinte que: (i) *o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil*; (ii) *o direito de concessão de uso não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez*; (iii) *os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião*.

8.3 INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

O artigo 4º do Estatuto da Cidade estabelece um conjunto de instrumentos a serem utilizados pelo Poder Público para a implementação e efetivação da política urbana. Tais instrumentos, entretanto, não se constituem em *numerus clausus*, podendo ser acrescentados outros àqueles exemplificados. Os instrumentos dividem-se em: (i) ações de planejamento, seja no nível nacional, estadual, municipal, metropolitano, de microrregiões ou aglomerações urbanas; (ii) planejamento municipal – que mereceu destaque especial – com as seguintes ações: plano diretor; disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; zoneamento ambiental; plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamento anual; gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos de desenvolvimento econômico e social; (iii) institutos tributários e financeiros: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; contribuição de melhoria; incentivos e benefícios fiscais e financeiros; (iv) institutos jurídicos e políticos: desapropriação; servidão administrativa; limitações administrativas; tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; instituição de unidades de conservação; instituição de zonas especiais de interesse social; concessão de direito real de uso; concessão de uso especial para fins de moradia; parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; usucapião especial de imóvel urbano; direito de superfície; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; transferência do direito de construir; operações urbanas consorciadas; regularização fundiária; assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos; referendo popular e plebiscito; demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; legitimação de posse; (v) estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

O Estatuto da Cidade teve o cuidado de procurar evitar a superposição de institutos jurídicos, institucionais ou técnicos, pois explicitamente determinou que “*os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria*”.

8.3.1 Instrumentos com imediata repercussão ambiental

8.3.1.1 Direito de preempção

O artigo 25 define os contornos do direito de preempção do Poder Público Municipal. Por tal direito é conferida “ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares”.

O direito de preempção, para ser legalmente exercido pelo Poder Público municipal, demanda a existência de determinadas condições legais bem caracterizadas e absolutamente necessárias para que ele possa ser exercido. Em primeiro lugar, faz-se necessário que haja uma lei municipal (em sentido formal), diretamente emanada do Plano Diretor, à qual cabe delimitar as áreas em que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Assim, nós poderíamos definir o direito de preempção como o direito de preferência que é outorgado ao Poder Público municipal, por lei própria, com delimitação espacial e temporal e com definição do objetivo do exercício da preferência. A declaração do direito de preempção não obsta que se realizem transações entre particulares no imóvel declarado sujeito à sua incidência. Dentro do prazo legal, o Poder Público poderá exercê-lo.

O direito de preempção somente será exercido quando o Poder Público necessitar de áreas para: (i) regularização fundiária; (ii) execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; (iii) constituição de reserva fundiária; (iv) ordenamento e direcionamento da expansão urbana; (v) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; (vi) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; (vii) criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; (viii) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

O proprietário deve notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o Município, no prazo máximo de 30 dias do recebimento da notificação, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. À notificação deve ser anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, na qual deverão constar preço, condições de pagamento e prazo de validade. Compete ao Município fazer publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. Uma vez decorrido o prazo, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Tão logo seja concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. Caso a alienação seja processada em condições diversas da proposta apresentada, é nula de pleno direito. O Município poderá, nos casos de venda fora da proposta apresentada, adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

É desnecessário dizer que o exercício do direito de preempção deve ser feito mediante o pagamento em dinheiro e que, igualmente, as verbas a ele destinadas estejam previstas em rubrica orçamentária própria.

8.3.1.2 Transferência do direito de construir

Uma das questões mais tormentosas que têm estado bastante presentes na vida de todas as áreas urbanas é a resultante do conflito entre o estabelecimento de determinados padrões urbanísticos e a limitação ao direito de construir. Não raras vezes, projetos já autorizados e licenciados têm sofrido enormes dificuldades para chegarem a bom termo, tendo em vista o estabelecimento de padrões diferentes daqueles vigentes à época da concessão das licenças ou autorizações. A Transferência do Direito de Construir, em princípio, parece ser uma boa alternativa para a questão, pois por seu intermédio é possível compatibilizar o desenvolvimento harmônico da cidade com a preservação de direitos individuais, em especial com o direito de propriedade.

Na forma do artigo 35, a lei municipal, baseada no Plano Diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para as seguintes finalidades: (i) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; (ii) preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; (iii) servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

8.3.1.3 Concessão de uso especial

A MProv nº 2.220/ 2001 estabeleceu importantes normas ambientais. A Concessão de uso especial tem expressa previsão constitucional. Nos termos do artigo 1º da MProv nº 2.220/2001, “[a]quele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural”, nova redação dada pela Lei nº 13.465/2017. A MProv admite, ademais, a concessão de uso especial coletiva para as populações de baixa

renda, nos locais nos quais não se pode identificar o possuidor individual.

O artigo 5º da MProv estabelece que é facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de concessão de uso tratado pelos artigos 1º e 2º em outro local, quando a ocupação do imóvel ocorrer, dentre outras, em área de interesse para a preservação ambiental e para a proteção de ecossistemas naturais. A medida é muito importante, pois não raras vezes se estabelece uma contraposição entre os chamados “interesses sociais” e os de preservação ambiental, com a ocupação de encostas de morros, faixas marginais de proteção e outras áreas ambientalmente sensíveis e incapazes de assegurar moradias adequadas para as pessoas. O Poder Público, agora, tem os instrumentos legais adequados para providenciar a desocupação de áreas extremamente perigosas e ambientalmente sensíveis e, ao mesmo tempo, conceder direito de uso de bens públicos para aqueles que necessitam ter uma habitação adequada.

8.3.1.4 Estudo de Impacto de Vizinhança

A lei estabeleceu, em seu artigo 36, uma importantíssima inovação denominada EIV. O EIV deverá estar previsto em lei municipal que definirá as atividades para cuja implantação o mencionado estudo se fará necessário, com vistas à obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

O EIV, assim como o EIA, é um aperfeiçoamento das análises de custo/benefício de um determinado empreendimento. De acordo com o determinado no artigo 37, *o EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades*. O conteúdo mínimo do EIV deverá contemplar as seguintes questões: (i) adensamento populacional; (ii) equipamentos urbanos e comunitários; (iii) uso e ocupação do solo; (iv) valorização imobiliária; (v) geração de tráfego e demanda por transporte público; (vi) ventilação e iluminação; e (vii) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

O EIV deve ser disponível para a consulta por parte dos interessados.

O artigo 38 determina que a *elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental*. O EIV, conforme se pode facilmente verificar, é uma evolução do Estudo de Impacto Ambiental – sendo ambos espécies de AIAs – previstas na Constituição para todas as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Infelizmente, o legislador deixou passar uma ótima oportunidade para disciplinar adequadamente a avaliação de impactos em atividades urbanas, especialmente as atividades não industriais. Todos aqueles que militam na área da proteção ao meio ambiente sabem que os estudos de impacto ambiental têm uma vocação eminentemente industrial, ou, no mínimo, de projetos que signifiquem intervenção em ambiente não urbanizado. No entanto, à míngua de outras normas, o EIA passou a ser exigido pelos órgãos ambientais para a implantação de *shopping centers*, condomínios e outros empreendimentos semelhantes. Tais Estudos de Impacto, de acordo com os seus termos de referência, normalmente, têm por objetivo investigar os assuntos relacionados como conteúdo mínimo do EIV. Penso que o EIV é um instrumento mais do que suficiente para que se avaliem os impactos gerados por uma nova atividade a ser implantada em área urbana – não se tratando de atividade industrial. O EIV nada mais é do que um EIA para área urbanas e, *data venia*, creio ser completamente destituída de lógica ou razão a obrigatoriedade de ambos os estudos.

8.3.2 Plano Diretor e gestão democrática da cidade

O instrumento jurídico mais importante para a vida das cidades é o Plano Diretor, pois é dele que se originam todas as diretrizes e normativas para a adequada ocupação do solo urbano. É segundo o atendimento das normas expressas no Plano Diretor que se pode avaliar se a propriedade urbana está, ou não, cumprindo com a sua função social tal qual determinado pela CF. Assim é que determina o artigo 39 do Estatuto da Cidade: *“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor; assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas”*, observadas as diretrizes previstas no artigo 2º do próprio Estatuto da Cidade. O Plano Diretor é lei formal, não podendo ser substituído por decreto ou outro ato administrativo de qualquer natureza. Como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, ele é parte integrante e indissociável do processo de planejamento municipal. Tanto o plano plurianual como as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Isso, entretanto, ainda não vem se realizando na prática. Não é pouco comum que normas de diversas hierarquias contrariem, frontalmente, as diretrizes do Plano Diretor municipal.

O Plano Diretor não pode se limitar às áreas de expansão urbana do município, pois deve abranger todo o território municipal, inclusive as áreas rurais, quando houver. Com vistas a manter-se atualizado, o Plano Diretor deve ser submetido a um processo de ampla revisão a cada dez anos.

8.3.2.1 Elaboração democrática das normas do Plano Diretor

O estatuto da cidade definiu preceitos de participação cidadã, mínimos, a serem observados quando da elaboração dos Planos Diretores dos diferentes Municípios, a saber: (i) promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; (ii) publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; (iii) acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

8.3.2.2 Obrigatoriedade do Plano Diretor

A existência do Plano Diretor é obrigatória para cidades: (i) com mais de 20 mil habitantes; (ii) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (iii) onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4º do artigo 182 da CF; (iv) integrantes de áreas de especial interesse turístico; (v) inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; (vi) incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

O conteúdo mínimo do Plano Diretor deve contemplar o seguinte: (i) a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do artigo 5º do Estatuto da Cidade; (ii) disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 do estatuto; (iii) sistema de acompanhamento e controle.

8.3.2.3 Gestão democrática da cidade

O Estatuto estabeleceu uma relação de instrumentos com vistas a assegurar a gestão democrática da cidade. Tais instrumentos são, a saber: (i) órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; (ii) debates, audiências e consultas públicas; (iii) conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; (iv) iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

O legislador assegurou uma enorme variedade de instrumentos aptos a assegurar a participação cidadã em todos os aspectos da vida urbana. Não se deve esquecer, contudo, que, em face da autonomia constitucional dos Estados e dos Municípios em relação à União, estes deverão estabelecer, em leis próprias, os mecanismos de participação que deverão guardar simetria com os estabelecidos em âmbito federal.

Diante da importância crucial que os orçamentos públicos desempenham na vida de qualquer coletividade, o artigo 44 determinou que: *“No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.”* O artigo merece reflexão, pois determina uma condição prévia para a aprovação do plano plurianual que não encontra amparo na CF, seja na forma procedimental, seja na imposição de limitações ao exercício da soberania popular por meio de seus representantes. Acredito que a matéria será submetida à apreciação do STF para decidir quanto à sua constitucionalidade.

O artigo 45, igualmente, apresenta questões de constitucionalidade que não são simples. Assim é que determina o mencionado artigo: *“Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.”* O controle dos órgãos administrativos, na forma da CF, pode ser exercido por duas vias: (i) interna e (ii) externa. O controle interno se faz pelos órgãos de controle do próprio Poder em questão; já o controle externo se faz pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. É indiscutível que o Ministério Público, igualmente, exerce um importante papel no controle da legalidade dos Poderes. A participação popular no controle dos diferentes atos administrativos se faz por meio da representação aos Poderes Públicos, ou pela ação popular. Como compatibilizar os preceitos constitucionais com a norma contida no artigo 45 é uma questão que, em minha opinião, está aberta.

8.3.2.3.1 Loteamento fechado

Uma tendência que tem se verificado em muitas cidades é a construção dos chamados “loteamentos fechados”, que não são condomínios, haja vista que as “áreas” comuns são públicas e doadas à municipalidade, nem loteamentos clássicos, pois implicam um determinado grau de controle de circulação e acesso. O campo permanece sem uma legislação de regência, muito embora as Cortes de Justiça tenham admitido a hipótese, desde que sem caráter obrigatório para a associação. Normalmente, o mecanismo funciona com a constituição de uma associação de moradores que congregue a maioria dos adquirentes de lotes dos loteamentos fechados e tais associações se encarregam de prover alguns serviços para os moradores, com ênfase para a segurança. *“Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de taxa condominial. Precedentes da Corte. 1. Nada impede que os moradores de determinado loteamento constituam condomínio, mas deve ser obedecido o que dispõe o art. 8º da Lei nº 4.591/64. No caso, isso não ocorreu, sendo a autora sociedade civil e os estatutos sociais obrigando apenas aqueles que o subscreverem ou forem posteriormente admitidos. 2. Recurso especial conhecido e provido”* (STJ – REsp 623274/RJ. Relator Ministro Carlos Alberto Direito. 3ª Turma. DJ 18/6/2007, p. 254). Por fim, não se pode deixar de considerar que o não pagamento das cotas é uma forma de enriquecimento ilícito, pois há o aproveitamento de um serviço custeado por terceiros.

8.4 APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, EM ÁREAS URBANAS

A revogação da Lei nº 4.771/1965, pela Lei nº 12.651/2012, não encerrou a polémica referente à aplicação em áreas urbanas de uma lei geral federal de proteção de florestas. A questão, inicialmente, foi suscitada pelo parágrafo único do artigo 2º do Código revogado, o qual determinava: “Art. 2º – [...] *Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.*” A Lei nº 12.651, de 25/2012, em seu artigo 4º também dispôs sobre áreas urbanas, verbis: “Art. 4º *Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I – as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; (b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; (c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: (a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; (b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; V – as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; VII – os manguezais, em toda a sua extensão; VIII – as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; IX – no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; X – as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.*

Como se sabe, o conceito normativo de área de preservação permanente constava do inciso II do § 2º do artigo 1º do Código Florestal revogado, o qual passo a reproduzir: “*Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.*” Como se pode perceber da leitura do dispositivo legal as áreas de preservação permanente (APP) se dividiam em duas grades categorias, a saber: (i) **aquelas estabelecidas pelo próprio Código Florestal** e (ii) **aquelas estabelecidas por ato do poder público**. É importante observar que a existência das áreas de preservação permanente demanda outros requisitos além daqueles estipulados nos artigos 2º e 3º do revogado Código Florestal, há a necessidade de que as áreas contempladas pelos dispositivos legais tenham a “*função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas*”.

A regulamentação trazida pela lei nº 12.651/2012 estabeleceu, no inciso II do artigo 3º, o seguinte conceito normativo: “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, **com a função ambiental** de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Na essência não houve alteração significativa em relação ao direito precedente.

Em assim sendo, os requisitos para que uma área possa ser declarada de preservação permanente são: (i) estar incluída na relação do artigo 4º da Lei nº 12.651/2012 ou (ii) ser objeto de ato do poder público (art. 6º) e (iii) exercer *função ambiental* de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Além da identificação da APP, é necessário que se verifique se o Município é ou não dotado de Plano Diretor, pois ele é o instrumento que, em essência, apresenta os instrumentos para a proteção ambiental em áreas urbanas.

Logo, a discussão sobre a aplicação do artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, em áreas urbanas é complexa e implica a harmonização de diferentes instrumentos jurídicos em diferentes níveis federativos.

8.4.1 Legislação aplicável

A resposta à indagação quanto a legislação aplicável passa, necessariamente, pela identificação da competência legislativa em relação ao assunto. *É por meio de normas urbanísticas que se protege o meio ambiente urbano*, como se pode inferir das disposições contidas na CF. Compete à União estabelecer normas gerais sobre urbanismo e política urbana, tal como definido pelos artigos 182 e 183 da CF. No uso de suas competências constitucionais, o legislador ordinário editou a Lei nº 10.257/2001, conhecida como *Estatuto das Cidades*, a qual é norma geral aplicável aos Municípios, que deverão observá-la quando da elaboração e implementação de suas normas próprias.

O Estatuto, em seu artigo 2º, estabelece que a “política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: [...] IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos

negativos sobre o meio ambiente; [...] VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição da população a riscos de desastres; VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; [...] XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”.

Acrescente-se que as competências da União, em matéria e direito urbanístico, são aquelas definidas pela CF e pelo artigo 3º do Estatuto das Cidades. Assim, em princípio, não se poderia pensar em normas de proteção ambiental urbanas no Código Florestal. Tal raciocínio é reforçado pelo artigo 7º da LC nº 95/1998, que determina: “Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: I – excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; II – a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva; IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”

Assim, parece claro que somente o Plano Diretor pode dispor sobre proteção ambiental de áreas urbanas. Ainda ao nível federal, e plenamente recepcionada pela Constituição vigente, existe a Lei nº 6.766/1979, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.932/2004, que estabeleceu no inciso III do artigo 4º o seguinte: “Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo menos, os seguintes requisitos: [...] III – ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.”

É importante ressaltar que a alteração da Lei nº 6.766/1979, ocorreu na data de 3 de agosto de 2004, pelo advento da Lei nº 10.932, ou seja, foi posterior à entrada em vigor da nova redação do artigo 2º do Código Florestal, em especial do parágrafo único, a qual foi atribuída pela Lei nº 7.803/1989. Aqui, há uma importante questão a ser observada, que é a aplicação da lei no tempo. Com efeito, determina a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

Assim, tem-se que tanto o Estatuto da Cidade quanto a Lei nº 10.932/04 são posteriores à nova redação dada ao artigo 2º do Código Florestal pela Lei nº 7.803/89 e, ainda que tais normas *regularam inteiramente a proteção ambiental em áreas urbanas*, motivo pelo qual é ineficaz o parágrafo único do artigo 2º do Código Florestal, quando se tratar de área urbana, assim definida em Plano Diretor. Aliás, a própria definição conceitual de área de preservação permanente indica que ela não se compatibiliza com áreas urbanas.

Parece evidente que o Código Florestal tem uma destinação específica, que é a de servir para regular as atividades florestais e rurais, não se destinando às áreas urbanas. “Contudo, o exame do Código Florestal revela que o legislador quis se ocupar, preferencialmente do meio ambiente natural, com destaque para seus aspectos florísticos, em face do qual a intervenção humana surge apenas como aspecto incidental [...] o primeiro dado a inferir-se é que as normas contidas no Código Florestal visam a proteção do meio ambiente natural como tal, acentuando as consequências da atuação sobre ele, dos processos socioeconômicos humanos”. (MAGRI, BORGES, 1996. p. 72) .

Aliás, o regramento da propriedade urbana, tal como definido no Estatuto da Cidade, indica que ela deve atender a uma função social, dentre a qual se encontra a de edificar, sob pena de desapropriação, compreendendo-se na função social as necessidades do cidadão quanto à qualidade de vida; logo, a defesa do meio ambiente urbano.

A Lei nº 12.651/2012, embora posterior às normas acima descritas, não possui força normativa suficiente para afastar as competências próprias dos municípios, nem para se sobrepor às normas constantes do Estatuto da Cidade.

O STF (RE 413815/SC. Julgamento: 3/2/2010. DJe-038, divulg. 2/3/2010) em decisão do Ministro Dias Toffoli, entendeu válida lei municipal que versava sobre a matéria objeto deste opinamento: “[...] **Desta forma, quando, posteriormente, a Lei 1.138/96 [do município de Siderópolis] restringiu as áreas de proteção ambiental, não atentou contra qualquer artigo do Código Florestal, o qual continua em plena vigência e dando o suporte necessário para que as áreas ambientais que devam ser preservadas continuem imunes a quaisquer tipos de exploração**” (folha 731) não tem o condão de preencher o requisito do prequestionamento, a viabilizar a análise do recurso extremo. No sentido dessa conclusão, cite-se o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Celso de Mello, nos autos do RE nº 294.267/RJ-AgR, Segunda Turma, DJ de 4/3/05, que bem aborda a questão: “[...] **Ressalte-se que, haveria vício na Lei nº 1.138/96 se ela tivesse afirmado que as nascentes de rios e olhos d’água, lençóis freáticos, vegetação remanescente de mata atlântica existentes no município de Siderópolis não eram mais áreas de preservação permanente, pois, nesse caso, ela estaria violando dispositivos da lei federal em vigor. Porém, não foi isso que o diploma municipal determinou, não havendo razão para declaração incidental de inconstitucionalidade, ou sucessivamente, ilegalidade, como requer o apelante**”.

8.5 TRANSPORTE URBANO E MEIO AMBIENTE

O Brasil é hoje um país com elevado nível de urbanização e, consequentemente, com aglomerados populacionais bastante significativos e que demandam infraestrutura para que os serviços básicos possam ser oferecidos às populações residentes nas cidades. Juntamente com o saneamento (ou a falta dele), os transportes são, dos serviços Básicos, aqueles que podem impactar mais fortemente o meio ambiente, dependendo da opção de política pública adotada em todos os níveis da administração pública. O Brasil, na década de 50 do século XX fez a opção de construir a sua industrialização com base no automóvel e no transporte individual, agora, muitos anos depois, tal industrialização está cobrando o preço ambiental.

A Lei Federal nº 12.587/2012 muito embora não seja voltada precipuamente para a proteção do meio ambiente, estabeleceu algumas disposições relevantes para a matéria.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana busca contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do *Sistema Nacional de Mobilidade Urbana*, que é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.

Os modos de transporte urbano foram classificados pela lei em (i) *motorizados* e (ii) *não motorizados*. Tais modos de transporte *quanto ao objeto* podem ser: (i) de passageiros; (ii) de cargas.

No que diz respeito às suas características, eles podem ser: (i) coletivo e (ii) individual; no que se refere à sua *natureza* podem ser: (i) público e (ii) privado. A *infraestrutura de mobilidade urbana* foi caracterizada como: (i) vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias; (ii) estacionamentos; (iii) terminais, estações e demais conexões; (iv) pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas; (v) sinalização viária e de trânsito; (vi) equipamentos e instalações; e (vii) instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. Veja-se que, em princípio, tais atividades podem ser enquadradas na alínea *b*, do inciso IV do § 2º do artigo 1º do Código Florestal revogado, admitindo-se, quando for o caso, a supressão de vegetação de preservação permanente.

É importante observar que um dos objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, conforme o inciso II do artigo 5º é o “desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais.” O legislador determinou que a Política Nacional de Mobilidade Urbana seja orientada pelas seguintes diretrizes: (i) integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos; (ii) *prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado*; (iii) integração entre os modos e serviços de transporte urbano; (iv) *mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade*; (v) incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao *uso de energias renováveis e menos poluentes*; (vi) priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; (vii) integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional; (ix) garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária do serviço. Penso que, no caso concreto, a implantação de políticas de mobilidade urbana deverá considerar prioritariamente os elementos acima arrolados, sob pena de questionamentos. Lembre-se que um dos objetivos da política ora examinada é o de *promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades*”.

Um importante instrumento com claras repercussões ambientais é o estabelecido pelos incisos I, II e VII do artigo 23 que estabelece como instrumentos de gestão, postos à disposição dos entes federativos, respeitadas as competências constitucionais de cada um deles, que são os seguintes: (i) restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados; (ii) estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle; (iii) monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição.

O Plano de Mobilidade Urbana, como definido em lei, é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes nela dispostos a saber: (i) os serviços de transporte público coletivo; (ii) a circulação viária; (iii) as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas; (iv) a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; (v) a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; (vi) a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; (vii) os polos geradores de viagens; (viii) as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; (ix) as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; (x) os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e (xi) sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Nos municípios com população acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido. Observe-se que, nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

A integração do Plano de Mobilidade Urbana ao plano diretor municipal estará em elaboração até 14 de abril de 2015. Após tal data surge o impedimento de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até o atendimento da exigência legal. Apesar do tempo transcorrido, a questão tem sido relegada a segundo plano.

Observe-se que, no que concerne ao licenciamento ambiental e urbanístico, os impactos dos novos empreendimentos ou atividades na mobilidade urbana deverão ser contemplados nos EIVs e nos Estudos Ambientais exigíveis.

8.6 CONCLUSÃO

O Estatuto da Cidade é uma norma jurídica que veio estabelecer os princípios gerais a serem adotados para a boa gestão da vida urbana. Este capítulo não se preocupou em realizar a análise integral do Estatuto, levando em conta os aspectos ambientais da norma. É evidente, contudo, que gerir cidades é produzir impactos sobre o meio ambiente – positivos ou negativos. Como um todo, a lei é positiva. É verdade que ela é muito mais uma consolidação de práticas administrativas que vêm sendo implementadas em diversas urbes brasileiras. As questões referentes à constitucionalidade de algumas normas serão dirimidas pela nossa mais elevada corte, fazendo uma adaptação da norma aos termos da CF vigente.

DIVERSIDADE BIOLÓGICA

§ 1º INTRODUÇÃO AO TEMA

A percepção de que o mundo natural perece em função da atividade humana é fenômeno antigo e acompanha a história da humanidade. Para o pensamento ocidental, uma das primeiras constatações foi feita por Platão em seu célebre diálogo *Crítion*, no qual ele lamenta, acadamente, o estado de degradação ambiental do mundo que lhe era contemporâneo (ANTUNES, 2015, p. 26). Mesmo sociedades tidas como “primitivas” e paradisíacas foram responsáveis pela extinção de espécies. Paul R. Ehrlich (2000, p. 242) demonstra que os Maori, em menos de 1.000 anos de presença na Nova Zelândia, promoveram a extinção de cerca de 13 espécies de Moa (pássaro sem asas), em função de caça intensiva e destruição de vegetação. Há suspeitas de que a aparição do Homem no continente americano causou a extinção, de pelo menos, duas espécies de mamíferos (DIAMOND, 2000, p. 45). Pesquisas arqueológicas demonstram que mesmo comunidades pré-históricas poderiam ter levado inúmeros animais à extinção. Não seria exagerado dizer que a convivência “natural” do Ser Humano com outros animais é predatória.

Como quer que seja, o fim da megafauna foi a mais importante extinção de animais do planeta desde a época dos dinossauros, podendo ser considerada importante por ter sido contemporânea do ser humano e, portanto, possivelmente relacionada à ação deste. Entretanto, seria mesmo correto atribuir ao homem essa destruição, ou seria apenas nossa consciência pesada a sugerir tais hipóteses? Não sabemos, mas o estudo da megafauna extinta por essa ligação umbilical com o ser humano promete continuar a concentrar a atenção dos pesquisadores do passado pré-histórico e a gerar novos conhecimentos coevolucionários entre humanos e animais (FUNARI e NOELLI, 2002, p. 57).

O mundo natural tem servido, principalmente, como paradigma para a crítica dos modelos políticos vigentes e para a construção de outros. Os atuais problemas referentes à perda de diversidade biológica não são diferentes. É importante que não percamos de vista que, em grande parte da discussão sobre perda de diversidade biológica, existe uma arrogância humana, na medida em que nos consideramos capazes de produzir danos irreversíveis à Terra. Veja-se lúcida e perspicaz anotação de Gould (GOULD, 1993, p. 46-47):

Esta declaração de nossa impotência poderia ser contestada se nós, apesar de termos chegado tarde, tivéssemos hoje algum poder sobre o futuro do planeta. Mas não temos poder nenhum, apesar da imagem distorcida que fazemos de nossa própria força. Não temos, na prática, nenhum poder sobre a Terra, em termos de escala de tempo geológico de nosso planeta. Toda a megatonelagem de todos os nossos arsenais nucleares soma apenas um décimo de milionésimo da força do asteroide de dez quilômetros que pode ter desencadeado a extinção em massa do Cretáceo. Ainda assim a Terra sobreviveu àquele choque e, com a extinção dos dinossauros, abriu-se o caminho para a evolução dos mamíferos maiores, entre eles os seres humanos. Tememos o aquecimento global, mas nem mesmo o mais radical dos modelos fala de uma Terra tão quente quanto a que havia em muitas etapas prósperas e felizes do passado pré-humano.

Há que ser considerado, porém, que essa é nada mais, nada menos, do que a prova irrefutável de que a atual discussão se faz no interior de quadros políticos, econômicos e sociais bastante definidos (ANTUNES, 2015).

Evitar a perda de diversidade biológica, em uma escala geológica de tempo, por exemplo, é absolutamente impossível para os limites da capacidade do Homem (MAYR, 1998, p. 540).

A perda de diversidade biológica como consequência da própria evolução é um fenômeno corriqueiro e não deve impressionar (DARWIN, s/d). A extinção, ou melhor, as extinções ocorrem de tempos em tempos e são parte da história da Terra e do próprio Universo. Leakey e Lewin (1999) falam de cinco extinções em massa antes da nossa era – causadas por razões naturais – e de uma sexta extinção em massa, que é a de nosso tempo, causada por fatores humanos, motivo que a torna diferente de todas as que a precederam. Entretanto, como foi salientado, a simples presença humana implica um fator qualitativamente diferente de extinção, com ritmos particulares. Se observarmos a questão do ponto de vista puramente biológico, o Ser Humano está, em suas condições próprias, lutando pela sobrevivência, assim como as demais espécies. A questão é se a luta que está sendo desenvolvida pode, ou não, assegurar uma sobrevivência em longo termo, ou se é meramente imediatista. Os mesmos autores estimam que 30 bilhões de espécies tenham existido sobre a face da Terra desde a aparição dos primeiros organismos multicelulares. Como afirmou John Maynard Keynes, “*a longo prazo todos estaremos mortos*”. Acredita-se que, atualmente, existam cerca de 30 milhões de espécies vivas, o que significa que cerca de 99,99% de todas as espécies já foram extintas. Os números, certamente, são impressionantes. Não deve ser esquecido, entretanto, que há enorme controvérsia sobre a quantidade real de espécies existentes sobre o planeta, assim como do ritmo da marcha da extinção. Ao que parece, as informações disponíveis encontram-se muito mais no terreno especulativo do que em um campo de segurança e certeza. A variação para o número de espécies existentes em nosso planeta demonstra quão pouco seguros são os cálculos até aqui utilizados. A própria definição de espécie é altamente controversa. Parte-se de um patamar mínimo de 3 milhões de espécies e chega-se a um número de 100 milhões; desnecessário dizer que o grau de variação é excessivo. Sabe-se que foram descritas cerca de 1,7 milhão de espécies, das quais um pouco mais de 1 milhão são de insetos, 250.000 de plantas superiores e cerca de 4.500 mamíferos (SMITH, DAILY, e EHRLICH, 1998, p. 126). Uma crítica bastante severa quanto aos métodos de calcular o número de espécies, bem como a taxa de extinção, pode ser encontrada em Lomborg (2001). Na contramão, ele afirma nunca terem existido tantas espécies como agora.

É importante ficar atento para o fato de que, ao falarmos de perda de diversidade biológica, estamos falando de determinadas espécies e não de outras, pois é claro que a morte é parte da própria vida. De fato, todo o nosso discurso, por social, está pleno de um receio de perda da vida em sociedade tal qual a conhecemos e, portanto, ao lutarmos pela conservação da diversidade biológica, de fato, estamos lutando pela nossa sobrevivência em um horizonte visível de tempo. A luta pela conservação da diversidade biológica encerra, portanto, um receio da própria extinção da sociedade que a contém. A questão da proteção da diversidade biológica contra as perdas deve ser enfocada, portanto, do ponto de vista social, pois do ponto de vista científico existe um relativo grau de certeza de que a extinção é o destino final (HAWKING, 1989, p. 121-149). O raciocínio que vem sendo desenvolvido neste parágrafo não tem por finalidade diminuir ou reduzir o significado que a perda de diversidade biológica tem para a nossa sociedade concreta no tempo presente. Ao contrário, dando-lhe a dimensão histórica precisa, fica mais fácil entender-lhe o significado, bem como perceber as suas limitações sociais. Gould (1993, p. 46), analisando o problema da conservação de uma determinada espécie, afirmou: “*Não resolvemos proteger os esquilos vermelhos do monte Graham porque estamos preocupados com a estabilidade planetária num futuro distante que*

provavelmente não vai nos incluir. Estamos tentando preservar populações e certos meios ambientes porque o conforto e a decência presentes de nossas vidas, bem como das vidas das espécies que conosco compartilham o planeta, dependem desta estabilidade.” O mesmo autor acrescenta: “[...] estou disposto a empregar todas as minhas energias na defesa das espécies, mas não podemos lutar pela preservação de todo e qualquer gene, a menos que encontremos algum modo de abolir a própria morte (porque muitos organismos individuais apresentam mutações singulares)”.

Parece ser relevante deixar consignado que, efetivamente, diante do incalculável número de micro-organismos e insetos, a maior preocupação com a perda da diversidade biológica está voltada para a extinção de animais superiores que, *ipso facto*, passam a se constituir em uma elite biológica que recebe um grau maior de proteção *vis-à-vis* aos demais seres vivos. Isso corresponde ao simples fato de que é o Homem quem define, concretamente, o que não deve ser protegido e conservado.

A perda da diversidade biológica é decorrente de múltiplos fatores. Um primeiro fator que tem sido destacado é o chamado consumo excessivo e não sustentável realizado pelas populações que se encontram nos chamados países de primeiro mundo e parcelas mais favorecidas dos países do terceiro mundo e das economias de transição. Durning (1990, p. 184) sustenta que *“a maior parte das ameaças ao meio ambiente que, pouco a pouco, avultam por sobre o mundo, desde a contaminação da água do subsolo à mudança no clima, é subproduto da riqueza”*. A afirmação deve ser tomada em termos, pois a pobreza é eticamente insustentável e, certamente, é fundamental que as populações e países mais pobres possam aumentar o seu padrão de desenvolvimento. É indiscutível que o maior avanço nos mecanismos de proteção ambiental encontra-se nos países com maior nível de renda e, portanto, de consumo. Aliás, a proteção do meio ambiente e, portanto, da diversidade biológica somente se torna uma questão central quando ultrapassados certos níveis de renda e consumo, ou seja, que a população passe a “viver” em harmonia com o meio ambiente e não “morrer” em harmonia com o meio ambiente.¹ A pressão causada pela pobreza sobre os recursos naturais não deve ser menosprezada. Relembre-se a assertiva de Flavin (2000, p. 5): *“Considerados há muito como questões distintas, confiadas a órgãos governamentais independentes, os problemas ecológicos e sociais são, na realidade, interligados e se reforçam mutuamente”*. Veja-se o exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Em pouco mais de 100 anos, aproximadamente, a sua população cresceu cerca de 134%, enquanto a população que habita em favelas apresentou um crescimento da ordem de 463%;² chega-se a falar em 1/3 da população da região metropolitana habitando em favelas. Não é difícil avaliar a pressão à qual a diversidade biológica é submetida em função da situação. Além do quadro da pressão urbana que, em maior ou menor escala, existe nos países em desenvolvimento, há que se considerar as pressões agrícola, pecuária e madeireira, que são consideráveis. Outro aspecto que não pode ser desprezado é que a pressão da pobreza se faz sentir nos orçamentos públicos, que passam a incluir prioridades que não estão relacionadas com a proteção da diversidade biológica.

Um aspecto da perda da diversidade que não tem merecido a mesma atenção da comunidade internacional é o que diz respeito à perda da diversidade cultural entre os diferentes povos, em especial das chamadas populações indígenas e comunidades locais. Funari e Noelli (2002, p. 66) sustentam que: *“O desaparecimento das línguas nativas está ocorrendo em todo o mundo dado o processo de globalização, com 95% das línguas vivas em risco de extinção por causa da morte de seus falantes e do abandono da língua nativa em favor de línguas dominantes, como o inglês, o francês, o espanhol, o português, o hindi e o chinês”*.

A perda da diversidade biológica deve ser enfocada sob duplice aspecto: i) perda de diversidade de flora e fauna; e ii) perda de diversidade cultural. Ambos os aspectos são indissociáveis e não podem ser tratados separadamente, sob pena de a questão restar mal compreendida. Se considerarmos somente as populações indígenas brasileiras, veremos que existem cerca de 217 etnias que se expressam em, aproximadamente, 170 línguas.

As relações entre a necessidade de desenvolvimento econômico e a destruição das áreas florestais é bastante evidente; igualmente evidentes são as relações entre a destruição das florestas e a pobreza, tanto é assim que o Banco Mundial aponta que a área ocupada por florestas nos países em desenvolvimento foi reduzida à metade em aproximadamente um século. Esse quadro, contudo, não é recente. Ao contrário, a pressão humana sobre as florestas e seus diversos recursos é tão antiga quanto a própria existência dos seres humanos. Como observa Perlin (1992, p. 31):

Os sumerianos, que estabeleceram a primeira sociedade urbana há mais de quatro mil anos no Crescente Fértil, usavam o signo cuneiforme “gis”, que determinava os tipos de madeiras e objetos de madeira, em palavras que significavam “projeto [de um edifício]”, “modelo” e “arquétipo”. “Architékton”, que na Grécia clássica chegou a significar “chefe de obras” e da qual nós derivamos a palavra “arquiteto”, significa literalmente “principal trabalhador em madeira”.

O próprio Banco Mundial reconhece o papel econômico desempenhado pela exploração florestal e, igualmente, reconhece o negativo papel que desempenhou em matéria de desenvolvimento florestal, pois grande parte de seus financiamentos voltados para a utilização econômica das florestas serviu de agente indutor da destruição e degradação florestal e ambiental. Desde a sua criação, o Banco Mundial financiou mais de 94 projetos florestais (MIKESELL e WILLIANS, 1992. p. 165). Esses projetos custaram 2,5 bilhões de dólares americanos. A proteção ambiental, contudo, não fazia parte das preocupações deles. Um dos exemplos mais gritantes de política equivocada é o do chamado Polonoroeste, em Rondônia, Brasil. Com financiamento do Banco Mundial, foi promovida uma grande devastação ambiental e gerados inúmeros problemas sociais de difícil solução. O projeto de colonização iniciado em 1982 foi considerado um fracasso pelo presidente do Banco Mundial, Barber Conable, em 1987. Foi a partir da constatação de políticas ambientalmente desastrosas e da própria pressão da opinião pública internacional que o Banco Mundial assumiu o compromisso de não conceder financiamentos para projetos florestais sem que rigorosos estudos de impacto ambiental fossem realizados previamente.

9.1 O BRASIL E A PERDA DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em contexto peculiar e mítico, segundo o qual aqui havia uma espécie de paraíso terrestre pronto para fornecer-lhes tudo aquilo que necessitavam e desejavam, de forma tranquila e permanente. As populações locais eram vistas como remanescentes do éden ou, no mínimo, como os bons selvagens que provavam a existência do “estado da natureza”, tão caro a Hobbes, Locke e Rousseau. As populações autóctones existentes no Brasil *“foram uma revelação para os portugueses”* (SKIDMORE, 1998. p. 30). A revelação foi de tal ordem que os preconceitos e visões distorcidas que, desde o início, marcaram as relações dos ocidentais com as populações autóctones, permanecem como um pano de fundo, por exemplo, para as modernas questões referentes à proteção da diversidade biológica. A diferença em relação a todos os modos de vida, até então conhecidos, fez com que as populações autóctones, não sem uma enorme carga de incompreensões, fossem consideradas como povos sem história (TRIGGER, 1992. p. 13).

O universo mítico povoava a ideia dos europeus sobre o Novo Mundo e, de certa forma, ainda povoa, visto que eles nunca conseguiram compreender os povos autóctones que habitavam nesta parte do planeta, uma vez que os preconceitos ainda estão presentes, o que se pode demonstrar em toda plenitude nos primeiros relatos de viagens elaborados por diferentes viajantes, ao entrar em contato com as novas terras e povos. Mesgravis e Pinsky (2002, p. 9) afirmam que, em linhas gerais, os relatos descreviam o novo continente como tendo *“clima agradável, natureza exuberante, habitantes cordiais e inocentes – descrições paradisíacas”*. A visão mítica e paradisíaca da terra e de seus habitantes, no entanto, não foi suficiente para impedir que o Frei Bartolomé de Las Casas (1997, p. 35) escrevesse:

Todas as coisas que nas Índias sucederam, desde o seu maravilhoso descobrimento e desde que para elas foram espanhóis para ficar algum tempo, e depois no seguimento disso até aos dias de hoje, em toda sorte admiráveis têm sido essas coisas, e tão inacreditáveis a quem as não viu, que parecem ter obscurecido e silenciado e muitas delas posto no olvido todas quantas, por mais façanhas, nos séculos passados se viram e ouviram no Mundo. Entre estas estão as matanças e estragos de gentes inocentes, e os despovoamentos de aldeias, províncias e reinos que nessas Índias se têm perpetrado, e todas as outras não de menor espanto.

Os europeus, ao chegarem ao Novo Mundo, não foram capazes de reconhecer, nos habitantes autóctones, o “outro” como titular de direitos e detentor de personalidade e dignidade. O discurso da revelação do paraíso mítico não incorporou o fato de que as novas terras eram habitadas por pessoas de carne e osso e, como tal, portadoras de virtudes e defeitos. É sobre essa forma de ver o Novo Mundo que se construiu a concepção de proteção das florestas que, aos olhos dos

europeus – e da cultura ocidental –, eram inabitadas, despovoadas de “iguais” e, portanto, aptas para serem tratadas, única e exclusivamente, desde a ótica do colonizador.

Uma consequência inesperada da chegada dos europeus à América foi a constituição, por múltipla miscigenação, de populações rurais não indígenas, com as origens mais diversas, que estabeleceram modos de vida os mais diferenciados. Refiro-me às populações caipira, caícaras, cabocla, sertaneja e gaúcha, bem como as ribeirinhas da Amazônia. O processo de miscigenação, assim como a introdução de novos colonos brancos, gerou um conjunto muito diferenciado de populações tradicionais que, conjuntamente, com os indígenas, jogam um papel muito relevante na proteção da diversidade biológica mediante o domínio de técnicas e saberes denominados conhecimentos tradicionais

A enorme extensão territorial do Brasil faz com que o país tenha uma imensa quantidade de espécies de flora e fauna, cuja variabilidade ainda não foi suficientemente estudada ou contabilizada. O foco principal, naquilo que se refere à proteção da diversidade biológica na imensidão territorial de nosso país, tem sido dirigido para a Amazônia e a Mata Atlântica, havendo um princípio de conscientização quanto ao pantanal e um quase-abandono de biomas como o Cerrado e a Caatinga.

9.1.1 Amazônia

A colonização do Brasil, durante muitos anos, limitou-se às terras costeiras. A penetração na Amazônia somente se fez muito mais tarde. A região amazônica somente começou a ser colonizada pelos portugueses na segunda década do século XVII. Desde aquela época, já existiam ideias distorcidas e mirabolantes sobre a região. Uma das mais extravagantes foi a de Estácio da Silveira, que desejava lá produzir cana-de-açúcar. Fato é que a Amazônia permaneceu, durante muitos anos, completamente à margem da sociedade nacional. Antes do século XIX, os portugueses haviam se limitado a fundar algumas cidades e consolidar a posse do território. A presença indígena permaneceu predominante pelo menos até 1850. O primeiro grande “ciclo econômico” ocorrido na Amazônia teve início no século XIX, foi o chamado ciclo da borracha, cuja primeira fase ocorreu entre os anos 1890-1911. Nessa primeira fase, ocorreram diversos episódios politicamente significativos, tendo como elemento principal a incorporação do Acre ao território nacional, cuja sátira foi tão bem elaborada por Márcio de Souza, em seu conhecido *Galvez, Imperador do Acre*. Foi somente no século XX que, efetivamente, a região foi “incorporada” ao restante do país.

Em relação ao assunto objeto de nosso estudo, o momento mais importante para a sua compreensão é a década de 70 do século XX, quando foi planejado um grande projeto de ocupação da Amazônia, cujos vetores principais foram a rodovia transamazônica e a perimetral norte. Ambos os projetos viários foram abandonados à própria sorte. Foi também na década de 70 que se estabeleceu um amplo esquema de incentivos fiscais para a “colonização” da Amazônia e para a construção da Zona Franca de Manaus. Esse conjunto de medidas teve, logicamente, impacto sobre a cobertura vegetal da área, com repercussões negativas. Merece registro, igualmente, a grande expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia e a consequente transferência de enormes contingentes populacionais para a região, que, por falta de alternativas, passaram a se dedicar às atividades garimpeiras, com graves resultados tanto para o meio ambiente como para as populações nativas da região. Um exemplo de política fracassada na região foi o chamado Polonoroeste, que, embora contasse com aportes de capital do Banco Mundial, não conseguiu promover integração social de milhares de agricultores que se dirigiram para áreas não povoadas do Estado de Rondônia, e mais, gerou enormes danos ao meio ambiente. Um dos problemas mais graves da atualidade amazônica é o resultante das queimadas.

9.1.2 Mata Atlântica

A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que primeiro foi encontrado pelo colonizador português e, em função disso, foi sobre seus domínios que se desenvolveram as principais atividades econômicas ao longo dos mais de 500 anos de existência do país.

É relevante considerar que a Mata Atlântica é o primeiro ponto de contato do colonizador português e foi sobre ele que se realizou a principal parcela da vida do país nesses anos todos de existência. De fato, houve uma impressionante redução das áreas florestadas em função das atividades econômicas praticadas no Brasil. Quanto ao que foi destruído e por que foi, nós já temos informações suficientes. A grande questão é tentar compreender a importância do que ainda existe em pé e, principalmente, definir meios e modos que nos possibilitem ampliar a área protegida. Dentro desse contexto, a existência de recursos econômicos, financeiros e institucionais é um elemento imprescindível para que qualquer projeto possa ter a mínima chance de êxito. Um dos principais geradores de recursos para a proteção da diversidade biológica é o ICMS ecológico, pois ele ataca *diretamente* a questão central dos necessários recursos econômicos. Capobianco (2001) aponta uma enorme dificuldade para a caracterização da Mata Atlântica, em função do seu aspecto “colcha de retalhos”, devido ao fato da descontinuidade de sua cobertura. Isso faz com que, na opinião daquele especialista, a área da Mata Atlântica seja reduzida artificialmente. O mencionado autor pretende, com a sua lógica, ampliar a área a ser submetida ao regime de proteção legal. Tem havido uma saudável disputa pelos recursos do ICMS ecológico entre municípios potencialmente destinatários. Os critérios de redistribuição de parcela dos recursos tributários em função de ampliação de áreas protegidas foi uma iniciativa paranaense que se espalhou por muitos estados.

A Mata Atlântica possui um valor ecológico inestimável, pois ainda possui cerca de 20.000 espécies de plantas, quase metade endêmica, sendo a segunda maior floresta tropical do país. Tal valor, entretanto, não pode ser desvinculado do enorme valor social que ela possui. Não se desconhece que a maioria da população brasileira está situada nas regiões abrangidas pela Mata Atlântica, sendo, portanto, bastante perceptível a pressão antrópica exercida sobre a floresta. Com efeito, a maioria da população brasileira está localizada na área de domínio da Mata Atlântica, decorrendo daí que o bioma é diretamente responsável pela produção de água, estabilização do clima, qualidade de solo etc.

É curioso observar que, muito embora as maiores cidades estejam situadas em áreas que originariamente integravam a mata atlântica, existe uma infinita quantidade de pequenas comunidades que vivem no interior da mata atlântica e que realizam suas atividades econômicas a partir dos produtos do interior da mata. Diegues (2002) aponta a existência das seguintes populações tradicionais: (i) caícaras; (ii) jangadeiros; (iii) sertanejos/vaqueiros; (iv) açorianos; (v) caipiras; (vi) varjeiros; (vii) quilombolas; (viii) pastoreio; (ix) pescadores; e (x) sitiantes.

Deve ser observado, ademais, que 73% da mata atlântica se encontram submetidos ao regime de propriedade privada, o que torna a gestão e o manejo ambientais extremamente complexos. A existência de uma parcela tão grande de Mata Atlântica submetida ao regime de direito privado, obrigatoriamente, faz com que a gestão ambiental de tal bioma leve em consideração tal realidade inafastável. É importante, portanto, que a Administração Pública se perceba como mais um agente na gestão do bioma e não como o agente. A torrencial quantidade de decisões judiciais determinando o respeito ao regime de propriedade privada para o estabelecimento de áreas protegidas – como será demonstrado adiante – confirma a impossibilidade de que tais realidades sejam ignoradas, como tem sido a prática administrativa. Esse fato tem significado um estímulo ao desmatamento, tendo em vista o clima de desconfiança dos proprietários privados em relação a possíveis medidas administrativas sobre áreas submetidas ao regime de propriedade privada. Capobianco demonstra que no período compreendido entre os anos de 1990-1995 os Estados do RS, SC, PR, MS, GO, SP, RJ e ES sofreram uma perda de 5,76% em relação a 1990. O Estado do Rio de Janeiro, no mencionado período, chegou a perder 13,13% de sua cobertura vegetal, que não ultrapassava 20% do território fluminense. É importante que se observe que, embora espécies extintas não possam ser “ressuscitadas”, é perfeitamente possível a reversão das taxas de desmatamento.

9.2 DIVERSIDADE BIOLÓGICA E ATIVIDADE ECONÔMICA

O principal documento internacional para estabelecer quadros legais para o desenvolvimento de atividades econômicas que se relacionam com a diversidade biológica é a CDB. Ela foi firmada em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro; é um documento-chave para assegurar a proteção dos ecossistemas e, concomitantemente, promover o tão almejado desenvolvimento sustentável. Este trabalho pretende ser uma contribuição ao debate sobre o palpitante tema. O meu objetivo é fazer uma análise geral da CDB, do ponto de vista do direito interno. A quantidade de artigos e documentos que têm sido produzidos sobre a CDB, no âmbito internacional, é impressionante. Em contrapartida, a produção brasileira sobre o tema é muito

pequena, quase inexistente. Não sei explicar o motivo capaz de justificar tal situação. É curioso, pois a produção acadêmica, no Direito Ambiental brasileiro, tem se mostrado muito ampla e diferenciada. Contudo, a diversidade biológica não tem sido contemplada com a preocupação de nossos juristas. Existem, é verdade, trabalhos sobre unidades de conservação e áreas protegidas; temas que, mediatamente, remetem à diversidade biológica. A maioria, entretanto, utilizando um enfoque preservacionista que, em minha opinião, não corresponde ao espírito da CDB, que é conservacionista.

O tema referente aos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica, atualmente, ocupa o nodal de toda problemática do acesso à biodiversidade. Tanto a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI quanto a Organização Mundial do Comércio (OMC) têm dedicado muita atenção às intensas e nem sempre tranquilas conexões entre o TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights*) e a CDB, especialmente naquilo que concerne à necessária proteção legal do conhecimento tradicional associado à diversidade biológica.

O nosso país é um dos principais atores em todas as discussões que foram mencionadas, pois, além de ser o maior detentor de diversidade biológica do mundo, possui também um expressivo número de comunidades locais e populações indígenas que são detentoras de imensos conhecimentos tradicionais sobre os seus *hábitats*. Não bastasse isso, nós nos encontramos em um estágio muito promissor em termos de moderna biotecnologia.

O papel privilegiado que o Brasil ocupa no cenário internacional em função da sua enorme biodiversidade faz com que o nosso país seja um importante ator no cenário internacional referente ao tema. A enorme quantidade de riquezas potenciais que podem estar presentes em nossa flora e fauna é de tal envergadura que se chega a compará-la, não sem certo exagero, com o cartel dos países produtores de petróleo. Há estimativa de que o patrimônio existente no Brasil possa chegar à casa dos dois trilhões de dólares americanos. Indiscutivelmente, tais valores são sempre questionáveis e dependem imensamente da perspectiva do analista, sem falar na existência de pessoas dispostas a pagar tal preço.

O Brasil é um país de proporções continentais: seus 8,5 milhões km² ocupam quase a metade da América do Sul e abarcam várias zonas climáticas – como o trópico úmido no Norte, o semiárido no Nordeste e áreas temperadas no Sul. Evidentemente, estas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas: a Floresta Amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo; o Pantanal, maior planície inundável; o Cerrado de savanas e bosques; a Caatinga de florestas semiáridas; os campos dos Pampas; e a floresta tropical pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões km², que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos.

A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras: o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta abundante variedade de vida – que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra – eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos (ou de maior biodiversidade).³

Não se pode deixar de considerar, no entanto, que a megadiversidade biológica ostentada pelo Brasil não é suficiente para fazer com que possamos existir em um regime de “autarquia ambiental”, desligados e presunçosamente achando que não dependemos de germoplasma oriundo de outros países. Existe uma troca constante entre plantas e países que formam as bases de toda a moderna agricultura, assim como de outras atividades que dependam da diversidade biológica. Merece ser destacado o fato de que, não obstante a condição privilegiadíssima que o Brasil ostenta em matéria de Diversidade Biológica, isso não o faz menos interdependente. A cana-de-açúcar foi importada da Guiné; o café, da Etiópia; o arroz, das Filipinas; a soja, da China; o cacau, do México etc., o mesmo sendo válido para a silvicultura, para os animais de corte, piscicultura, enfim. À megabiodiversidade brasileira não corresponde um mesmo nível de autonomia no que diz respeito à produção de alimentos, por exemplo. Outra questão que não pode ser negligenciada é que a diversidade biológica somente possui valor se existente a tecnologia para explorá-la. Logo, para que o Brasil realize o valor que, em tese, está em sua imensa biodiversidade, necessariamente, terá que se associar com aqueles que possuam as tecnologias adequadas. Essa é uma parceria obrigatória, pois, sem tecnologia, a diversidade biológica é incapaz de gerar benefícios e renda para os países que a detêm. Não se deve descurar do fato de que a pesquisa em moderna biotecnologia é altamente intensiva em capitais e cérebros. Para que o setor se expanda, os três segmentos são igualmente necessários. É certo, inclusive, que modelos computacionais podem modelar moléculas para servir em pesquisas.

Assim sendo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do tecnológico ou econômico, o Brasil precisa se credenciar para desempenhar o papel que, por direito próprio, detém em todos os aspectos do acesso à diversidade biológica. Modestamente, este trabalho busca ser parte do processo de compreensão das questões que foram mencionadas. É mais um elemento posto à mesa das discussões e dos debates. Ante a novidade do tema, é uma obra aberta e que espera poder ser criticada por aqueles que se interessam pela matéria.

9.3 A PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

A proteção do Conhecimento Tradicional Associado, no Direito brasileiro, encontra amparo constitucional. Em função disso, o legislador ordinário fez editar a Lei nº 13.123/2015 que trata da proteção dos conhecimentos tradicionais relativos ao patrimônio genético, regulamentado pelo Decreto nº 8.772/2016.

O chamado conhecimento tradicional associado, nos termos da Lei brasileira, pode ser dividido em dois grandes grupos: (i) origem identificável e (ii) origem não identificável. Ele é a informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético. No que se refere à identificação de sua origem, é considerado não identificável aquele conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional.

O conceito normativo não é de simples compreensão, ou mesmo de singela aplicação. O sujeito de direito que se pretende tutelar não é uma pessoa física ou jurídica, mas uma comunidade que vive de forma tradicional ou diferente da sociedade envolvente. Nesse particular, é importante que sejam incorporados os conceitos constantes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre as populações tradicionais.⁴

É importante observar que a Lei nº 13.123/2015, não se utiliza mais do conceito de “prática individual” como critério capaz de identificar o conhecimento tradicional, como fazia a MP 2.186. Todavia, vale registrar que, ainda que a norma falasse em prática individual, esta deveria ser compreendida no contexto cultural da comunidade tradicional. É possível – e mesmo muito frequente – que um determinado indivíduo em uma comunidade seja o único a exercer funções de Pajé ou Xamã, ou outra qualquer. Mesmo assim, estamos diante de uma atividade coletiva, pois tal indivíduo é fruto de uma atitude coletiva, de um conhecimento coletivo, de uma tradição. E mais: a sua prática será transmitida a terceiro que, a tempo e hora, irá sucedê-lo em sua função social.

É importante que não se confundam comunidades tradicionais com comunidades pobres e marginalizadas em geral, embora, em muitos momentos, as duas condições possam estar presentes em um mesmo agrupamento social. Os pequenos produtores rurais, necessariamente, não ostentam a condição de comunidade tradicional, para os efeitos da aplicação das normas da CDB, muito embora tenham sido incorporados ao rol dos detentores de conhecimentos tradicionais, por meio de norma interna. Igualmente, penso que a definição não pode ser aplicada para comunidades urbanas. Sem perder de vista que a minha opinião possa ser tida por reducionista, parece-me que a CDB objetiva a proteção da diversidade biológica em ecossistemas não urbanizados e as suas regras de tutela e proteção de conhecimentos tradicionais dirigem-se às populações que, aos olhos dos “seres urbanos”, praticam um modo de vida “tradicional”.

É desnecessário dizer que as comunidades locais e indígenas não se constituem em um sujeito de direito ordinário; para o modelo vigente de ordenamento jurídico, tais agrupamentos sociais não possuem personalidade jurídica própria. Podemos dizer que se trata de uma comunidade que se constitui sobre a existência de laços culturais. A grande dificuldade, *ça va sans dire*, é a de estabelecer meios e modos que sejam capazes de conferir proteção coletiva, dentro de um sistema legal que é, fundamentalmente, individualista. Todavia, em um contexto de proteção aos direitos humanos, há amplo reconhecimento da capacidade postulatória de tais comunidades e, em termos brasileiros, no que diz respeito aos povos indígenas, tal capacidade decorre da própria Constituição, não havendo qualquer motivo para que tal situação seja negada às demais comunidades tradicionais.

A proteção jurídica do conhecimento tradicional associado é uma resposta às reivindicações formuladas por Organizações Não Governamentais [ONGs] e pelas próprias comunidades tradicionais que se sentiam ameaçadas em seus direitos de utilização de plantas, drogas e práticas com finalidades medicinais e culturais, diante

do processo de globalização e, em especial, pelos avanços da biotecnologia e das atividades de bioprospecção, assim como pela crescente utilização de ritmos, motivos e diferentes manifestações de origem autóctone, na florescente indústria cultural.

O artigo 7º, III, da revogada MPov 2.186 falava em comunidade local, cuja definição é a seguinte: “*grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas*”. Tal definição foi substituída pela constante do artigo 2º, IV, da Lei 13.123/2015 que define comunidade tradicional como “grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Note-se que o agricultor tradicional é a “pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e conserva a diversidade genética, incluído o agricultor familiar.”

A proteção dos conhecimentos tradicionais reveste-se de urgência, pois várias são as ameaças que sobre eles pairam. Posso identificar, liminarmente, as seguintes: (i) acelerado processo de urbanização e abandono das áreas rurais por parte das comunidades locais e populações indígenas; (ii) ampliação da utilização de produtos industrializados, fazendo com que aqueles produzidos localmente fiquem relegados ao segundo plano; e (iii) natureza oral de tais conhecimentos, que faz com que eles tendam a se perder no tempo e na memória. Estas são ameaças de natureza cultural. Um outro aspecto a ser considerado é aquele que diz respeito à proteção dos conhecimentos tradicionais em face de sua utilização comercial *não autorizada* pelos seus detentores.

A proteção dos conhecimentos tradicionais associados é uma forma *sui generis* de proteção de propriedade intelectual, em modalidade coletiva e reconhecendo outras características de propriedade inventiva. O artigo 8º da revogada MPov. 2.186 estabelecia proteção para os “conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita [...]”.

Merece destaque o fato de que o § 1º do artigo 8º expressamente reconhecia “o direito de populações indígenas, de comunidades tradicionais e de agricultores tradicionais de participar da tomada de decisões, no âmbito nacional, sobre assuntos relacionados à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético do País”. Tal norma é consistente com os princípios legais aplicáveis à concessão de consentimento prévio livre e informado (artigo 9º) para a utilização econômica de informações derivadas de conhecimento tradicional. A proteção do conhecimento tradicional, como obra intelectual coletiva, se faz, essencialmente, pelo seu depósito em banco de dados – haja vista que os modelos tradicionais de proteção à propriedade intelectual são de difícil aplicação na hipótese concreta; do ponto de vista das manifestações culturais, o conhecimento tradicional, é considerado como parte do patrimônio cultural nacional. Em função das notórias dificuldades para a identificação do conhecimento tradicional, a lei admite as seguintes formas de reconhecimento: (i) publicações científicas; (ii) registros em cadastros ou bancos de dados; ou (iii) inventários culturais. Naturalmente, há necessidade de que cada uma dessas formas de reconhecimento seja devidamente regulamentada e validada, pois elas próprias podem ser controversas.

Na hipótese de utilização econômica do conhecimento tradicional, há necessidade de que se comprove a obtenção do consentimento prévio livre e informado da comunidade que o detenha. Tal comprovação deve ser feita segundo os mecanismos estabelecidos no § 1º do artigo 9º, da Lei nº 13.123/2015 a saber: (i) assinatura de termo de consentimento prévio; (ii) registro audiovisual do consentimento; (iii) parecer do órgão oficial competente; ou (iv) adesão na forma prevista em protocolo comunitário. Evidentemente que tais hipóteses somente são aplicáveis ao conhecimento tradicional cuja origem seja identificável. Em relação às atividades agrícolas, vale notar que o “acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional local ou crioula ou à raça localmente adaptada ou crioula para atividades agrícolas compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado não identificável que deu origem à variedade ou à raça e não depende do consentimento prévio da população indígena, da comunidade tradicional ou do agricultor tradicional que cria, desenvolve, detém ou conserva a variedade ou a raça”, ou seja, em tais hipóteses não incidem direitos econômicos ou intelectuais (morais).

Os direitos assegurados às populações indígenas, às comunidades tradicionais e aos agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado são os seguintes: (i) ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e conservação de patrimônio genético, em qualquer forma de publicação, utilização, exploração e divulgação, (ii) ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional associado em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações, (iii) perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, nos termos da lei; (iv) participar do processo de tomada de decisão sobre assuntos relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à repartição de benefícios decorrente desse acesso, na forma do regulamento (v) usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, observados os dispositivos das Leis nºs 9.456, de 25 de abril de 1997, e 10.711, de 5 de agosto de 2003; e (vi) conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver, melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado.

9.3.1 Direitos das comunidades indígenas e das comunidades locais

9.3.1.1 Comunidades indígenas

Ao se tratar dos direitos das comunidades indígenas, no contexto da CDB, não se pode deixar de levar em consideração que elas são regidas por normas constitucionais específicas e por leis próprias. No nível constitucional, o artigo 231 rege a matéria. “*São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.*” Em complemento, o § 2º do mencionado artigo atribui aos indígenas o “usufruto exclusivo” das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas.

O instituto do usufruto constitucional indígena impõe de forma muito clara que toda e qualquer atividade que possa ser realizada em terras indígenas, necessariamente, deve ter o consentimento prévio dos indígenas que as habitam, e mais: eles devem participar do rendimento econômico da coisa. É importante frisar que o § 6º do artigo 231 fulmina com nulidade e extinção “*os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras [...] ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes*”. Juridicamente, a diversidade biológica é acessória em relação às terras, aos rios e aos lagos e, portanto, o acesso a ela não pode se fazer, em terras indígenas, sem a consideração das disposições constitucionais próprias.

Há, ainda, em favor dos indígenas, o conjunto de normas tutelares constantes do Estatuto do Índio, instituído pela Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Com efeito, os indígenas, em seus negócios com terceiros não indígenas, são regidos pelo parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 6.001/73, não se lhes aplicando normas mais desfavoráveis, quando cotejadas com outras mais protetoras para os silvícolas. Não desconheço que concepções respeitáveis tendem a interpretar que a Constituição de 1988 teria revogado a Lei nº 6.001/1973, e que, em função disso, os indígenas não estariam mais submetidos à órbita da FUNAI. O argumento é importante, mas não impressiona. Tê-lo por jurídico seria levar ao caos toda a política indigenista nacional e, na prática, implicaria um abandono dos índios à sua própria sorte. A FUNAI, com todas as dificuldades que encontra para exercer o seu papel, é, seguramente, legalmente responsável pela proteção aos indígenas, e a Lei nº 6.001/73 continua vigente até que, expressamente, seja revogada por novo diploma legal. “*Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto no art. 6º do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável. Precedentes. II – O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por legislação própria – Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 – cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo STF*” (RMS 26212/DF. Ministro Ricardo Lewandowski. Julgamento: 3/5/2011. 1ª Turma. DJe-094, divulgação 18/5/2011, publicação: 19/5/2011).

O usufruto indígena, tratado no artigo 24 da Lei nº 6.001/73, em minha opinião recebido pela CF de 1988, compreende “o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de *todas as utilidades existentes nas terras* (grifei) ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades”. Parece-me que não subsiste dúvida de que o patrimônio genético integra o conjunto de bens submetidos ao usufruto indígena, não obstante o seu caráter imaterial, motivo pelo qual é devida remuneração aos indígenas pela sua utilização.

9.3.2 Comunidades locais

Comunidade local é uma designação muito mais genérica e ampla do que comunidades indígenas ou populações indígenas. Acredito, no entanto, que o ordenamento jurídico brasileiro possui alguns instrumentos normativos capazes de nos auxiliarem a compreendê-lo e, principalmente, dar a solução jurídica que a matéria exige e merece seja dada. O § 1º do artigo 216 da CF identifica os seguintes grupos: (i) culturas populares; (ii) indígenas; (iii) afro-brasileiros e (iv) outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A Constituição, como se vê, admitiu um pluralismo cultural e étnico em nosso país.

O § 5º do artigo 216 determina o tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, sendo certo que o artigo 68 do ADCT reconheceu a propriedade das terras ocupadas por remanescentes de quilombos, cabendo ao Estado emitir os títulos respectivos. É crucial observar que os remanescentes de quilombos foram formalmente reconhecidos pela MProv nº 2.186-14, como depositários de conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica.

Quilombos identificados⁵

QUADRO GERAL POR REGIÃO			
Nº	UF	CRQs (Certidões)	Nº CRQs (Comunidade)
1	NORTE	255	319
2	NORDESTE	1.362	1.657
3	CENTRO-OESTE	120	122
4	SUDESTE	304	351
5	SUL	154	158
TOTAL POR ANO:		2.195	2.607

Informações atualizadas até 10/09/2015.

A identificação de quilombos está regulada pelo Decreto nº 4.887/2003. Vale observar que tramita no STF ação declaratória de inconstitucionalidade do decreto (ADI 3.239).

Outro grupo que pode ser enquadrado como comunidade local para efeito de repartição de benefícios decorrentes do acesso à diversidade biológica é o constituído pelas *populações tradicionais* que habitam nas *florestas nacionais* ou nas *reservas extrativistas*.

O Ibama, desde 1992 mantém o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais – CNPT, que foi criado pela Portaria Ibama nº 22, de 10 de fevereiro de 1992. A proteção das populações tradicionais é uma das principais preocupações da Agenda 21 e da própria CDB. O Ibama, antecipando-se aos dois documentos internacionais, mas agindo dentro de seu espírito, estabeleceu o mecanismo para catalogação e registro das comunidades tradicionais. Posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC, ficou bastante claro, pela instituição das chamadas *unidades de uso sustentável*, que têm como finalidade legal a compatibilização entre a conservação da natureza e o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, o reconhecimento explícito das populações que *vivem* em unidades de conservação e que, em função disso, praticam um modo de vida compatível com a própria conservação da natureza. As populações tradicionais, dessa forma, podem ser definidas como aquelas que, em princípio, encontram seus *hábitats* em florestas nacionais, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, ou seja, os grupos que são conhecidos como povos da floresta, caçaras ou outros que, reconhecidamente, tenham uma forma de vida peculiar e característica, distinguindo-os da comunidade nacional. No contexto do presente trabalho, é muito relevante deixar anotado que a Lei do SNUC, em diversos artigos, faz menção expressa a populações tradicionais. Desde o Decreto nº 96.944/1988, foi estabelecida a obrigação legal de proteger as comunidades indígenas e as populações envolvidas no processo de extrativismo.

A comunidade indígena e a comunidade local que criem, desenvolvam, detenham ou conservem conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético têm garantidos os seguintes direitos: (i) ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações; (ii) impedir terceiros não autorizados de: (a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conhecimento tradicional associado; (b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado; (iii) perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, cujos direitos são de sua titularidade.

O conhecimento tradicional associado, devida às suas peculiares características pode ser detido por apenas um indivíduo ou um pequeno grupo no interior de uma comunidade e, ainda assim, merecerá a proteção legal. Pretende-se, com isso, proteger o conhecimento de xamãs, curandeiros e outros indivíduos que, em tese, detêm conhecimentos tradicionais associados. A norma, *in casu*, reconhece o caráter social e coletivo dos conhecimentos tradicionais associados, pois inadmitte que, em comunidades locais ou indígenas, haja uma apropriação individual das práticas coletivas, mesmo nas hipóteses em que elas assumem uma expressão individualizada.

Uma matéria jurídica relevante é aquela que diz respeito à aplicação do § 2º do artigo 231 da CF, pois a norma nele contida determina que as terras indígenas, embora de propriedade da União, estão sob o regime de usufruto exclusivo em favor dos indígenas quanto às riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Penso que, em se tratando de acesso ao patrimônio genético existente em terras indígenas, cabe à União, por intermédio do Conselho de Gestão e do próprio órgão responsável pela proteção aos indígenas, exercer o controle dos contratos, mas não lhe compete qualquer percepção de *royalties*, pois o usufruto é exclusivo dos indígenas, o que restaria subvertido caso a União recebesse qualquer valor decorrente da utilização de terras indígenas.

9.3.3 Experiência brasileira de utilização do conhecimento tradicional associado

Em nosso país, algumas experiências de acesso e utilização de conhecimentos tradicionais associados vêm sendo desenvolvidas com extraordinário êxito. É verdade, contudo, que são poucos os casos concretos. A tendência, com a definição de regras claras, é que elas sejam ampliadas e se multipliquem. Não se deve olvidar, no entanto, que o elemento mais importante em toda e qualquer experiência que envolva o acesso aos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica é que se assegure a sua *sustentabilidade*. Sustentabilidade esta que deve ser, ao mesmo tempo, *social* e *ambiental*. Sustentabilidade social é aquela que faz do acesso um instrumento para fortalecimento dos laços sociais e culturais de uma comunidade tradicional ou indígena, que desenvolve a sua autoestima, que documenta e registra práticas e costumes, que protege língua e cultura; sustentabilidade ambiental se traduz na utilização racional dos recursos da diversidade biológica, de forma que eles não sejam superutilizados e passem a viver em regime de escassez.

São conhecidos dois casos bastante significativos de acesso aos recursos genéticos por intermédio de conhecimentos tradicionais associados. O primeiro deles (i) é o desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – Embrapa, com os índios Krahô (“*Projeto conservação e uso de recursos genéticos na Terra Krahô*”);⁶ o segundo (ii) é o desenvolvido pela empresa de cosméticos Natura®, que produz uma linha de produtos com base em óleos e essências originários de comunidades indígenas da Amazônia.

9.3.3.1 Carta de São Luís do Maranhão

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI promoveu no mês de dezembro de 2001, na cidade de São Luís do Maranhão, o seminário denominado “*A sabedoria e a ciência do Índio e a Propriedade Industrial*”, com o objetivo de debater o tema dos conhecimentos tradicionais associados ao acesso aos recursos genéticos. O evento mereceu grande divulgação na imprensa e, certamente, foi muito importante no contexto das discussões sobre a proteção aos conhecimentos tradicionais. Como tive a oportunidade de observar, “não se deve esquecer que a proteção dos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica é um tema que diz respeito não apenas às populações indígenas, mas igualmente às populações extrativistas, comunidades ribeirinhas, remanescentes de quilombos e outras comunidades”.⁷

O encontro promovido pelo INPI, embora extremamente significativo, não teve o condão de contemplar toda a gama de comunidades e interesses envolvidos nas questões referentes à proteção legal do conhecimento tradicional.

Aliás, a bem da verdade, é importante que se diga que o INPI, em louvável iniciativa, buscou “abrir o debate sobre a matéria”. Isso foi realizado com muita competência. Entre as comunidades locais e as populações indígenas existe uma diferença de *status* legal muito significativa, pois as populações indígenas gozam de uma legislação própria que lhes é muito favorável, merecendo destaque os preceitos constitucionais específicos. De qualquer forma, o encontro elaborou um documento que, em linhas gerais, está de acordo com o conjunto de reivindicações que tem sido formulado pelas comunidades locais e populações indígenas, das mais diferentes latitudes, sobre o tema.

O documento, denominado Carta de São Luís do Maranhão, lembra que o Brasil é uma sociedade pluriétnica constituída, dentre outros, por 220 povos⁸ indígenas que falam 180 línguas, ocupando cerca de 12% do território nacional, com uma população de 360 mil indígenas, aproximadamente. A Carta de São Luís possui 16 pontos, dentre os quais merecem destaque: (i) reivindicação no sentido de que as comunidades indígenas participem do CGEN; (ii) recomendação para que a matéria referente ao acesso ao patrimônio genético seja regulada por lei; (iii) reivindicação de participação dos indígenas nas diferentes organizações internacionais nas quais os temas de diversidade biológica e acesso ao patrimônio genético sejam debatidos; (iv) reivindicação de que seja aprovado pela Organização das Nações Unidas o projeto de Declaração sobre os Direitos Indígenas; (v) oposição ao patenteamento que “provenha da utilização dos conhecimentos tradicionais”; (vi) reivindicação de que sejam criados mecanismos para punir o furto da biodiversidade brasileira; (vii) recomendação de que o governo federal crie um fundo, gerido por uma organização indígena, com vistas à capacitação e ao treinamento de profissionais indígenas na área dos conhecimentos tradicionais; (viii) recomendação da realização do II Encontro de Pajés sobre a CBD e Conhecimentos Tradicionais; (ix) criação de um Comitê Indígena para acompanhamento dos processos de discussão e planejamento da produção dos Conhecimentos Tradicionais; (x) reivindicação de que os Conhecimentos Tradicionais sejam reconhecidos como saber e ciência, com tratamento equitativo em relação à ciência ocidental, com o estabelecimento de uma política de ciência e tecnologia que reconheça a importância deles; (xi) criação de um sistema *sui generis* de proteção aos conhecimentos tradicionais que seja universalmente reconhecido; e (xii) criação de um Banco de Dados e registros sobre os conhecimentos tradicionais.

A Carta de São Luís do Maranhão foi entregue à Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, como parte da fundamentação da proposta formulada pelo Governo brasileiro, no sentido de que deve ser conferida proteção legal, com reconhecimento internacional, aos conhecimentos tradicionais. No atual estágio dos debates, está-se formando um consenso internacional no sentido de que devem ser estabelecidos mecanismos jurídicos que contemplem, na medida do possível e conforme o caso, um modelo de proteção legal para os conhecimentos tradicionais, pois permitiriam um acréscimo de renda para as comunidades locais e indígenas e, principalmente, o reconhecimento da contribuição cultural que elas têm dado para toda a humanidade.

9.3.4 Registro do conhecimento tradicional associado

Conhecimento tradicional é expressão muito ampla e abrangente e que, por isso, pouco esclarecedora. O folclore, certamente, é parte dos conhecimentos tradicionais, embora *não seja todo* o conhecimento tradicional. Também não se pode confundir o conhecimento tradicional das populações indígenas com aquele das comunidades locais.

O acesso à diversidade biológica, como um importante elemento da moderna atividade econômica, necessita que um de seus aspectos mais relevantes seja suficientemente desenvolvido e resolvido. O aspecto ao qual me refiro é a relação entre os conhecimentos tradicionais associados e a equitativa repartição dos benefícios derivados do acesso aos segredos da diversidade biológica, em função do domínio de tais conhecimentos. Essa é uma conclusão lógica do artigo 8º, *j*, da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB.

O conhecimento tradicional associado tem uma definição normativa que já foi vista neste texto, não havendo necessidade de voltar a examiná-la nesta altura. Wolff (2001, p. 19) informa que, desde os anos 1980, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e a Unesco estabeleceram um *Grupo de Especialistas para a Proteção de Expressões de Folclore na Propriedade Industrial*. A expressão “folclore” gerou protestos de vários países até que, no Fórum Mundial de Proteção do Folclore, realizado em 1997 conjuntamente pelas duas Organizações Internacionais, adotou-se também o termo “conhecimento tradicional”.

Conhecimento Tradicional		
Conhecimentos Indígenas	Conhecimento de Comunidades Locais	Folclore

O secretariado da CDB tem feito uma divisão dos Conhecimentos Tradicionais que leva em consideração o campo de incidência específico de cada conhecimento determinado. A tabela a seguir demonstra como é a classificação adotada.

Componentes do Conhecimento Tradicional⁹

Tecnologias e <i>know-how</i> (identificação, caracterização e supervisão de ecossistemas e espécies)	Tecnologias para conservação <i>in situ</i>	Tecnologia para uso sustentável de diversidade biológica
CT sobre sistemas locais	Conhecimentos e tecnologias tradicionais para conservação <i>in situ</i>	Usos espirituais e culturais
CT sobre função do ecossistema		Técnicas tradicionais de produção de medicamentos
CT sobre territórios e <i>habitats</i>		Tratamento dos recursos naturais com o uso de conhecimentos e tecnologias autóctones
Taxonomias tradicionais		Metodologia para avaliação da diversidade biológica, inclusive valores econômicos, tais como

		a existência de valores religiosos, éticos e culturais
Usos tradicionais e atuais CT para determinar espécies e categorias do RG e normas de população através do tempo		
CT – Conhecimento Tradicional		
RG – Recursos Genéticos		

A Organização das Nações Unidas – ONU declarou o ano de 1993 como “Ano Internacional dos Povos Indígenas Mundiais”. Tal declaração seguiu-se à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, na qual as organizações representativas dos povos indígenas e comunidades locais foram bastante expressivas e desempenharam papel de grande importância.

O ano de 1993 foi marcado pela realização, na Nova Zelândia, da Primeira Conferência Internacional sobre Direitos de Propriedade Intelectual e Cultural dos Povos Indígenas, que contou com a participação de cerca de 150 delegados de 14 países diferentes (DOUSCAS, 1995, p. 4). Ao término da Conferência, foi proclamada uma declaração que afirmou a insuficiência dos modelos oficiais de proteção da propriedade intelectual para assegurar os direitos dos povos indígenas. Reivindicou-se, na oportunidade, que cabia aos povos indígenas estabelecer suas próprias definições para os seus direitos de propriedade intelectual. Dentre as recomendações, originadas na Conferência, merecem destaque as seguintes: (i) desenvolver um código de ética que assegure que, quando houver utilização, por meio de qualquer mídia, de um conhecimento tradicional, não sejam violadas regras costumeiras de respeito de tal conhecimento tradicional; (ii) estabelecer regras apropriadas para: (a) preservar e monitorar a utilização comercial de conhecimentos tradicionais que se encontrem em domínio público; (b) assessorar os povos indígenas na preservação de sua herança cultural; (c) fomentar mecanismos de consultas obrigatórias para a elaboração de qualquer nova legislação que afete a cultura dos povos indígenas e os seus direitos de propriedade intelectual.

Quando se trata da produção dos chamados fármacos, argumenta-se que o desenvolvimento de novos produtos depende de um conhecimento prévio das qualidades das plantas ou dos animais que serão utilizados para a sua elaboração. Busca-se, assim, o princípio ativo, através de técnicas diferentes. A essas atividades se dá o nome de bioprospecção. Os conhecimentos tradicionais podem ser importantes, pois se dispensa a bioprospecção puramente aleatória, cuja chance de êxito é praticamente insignificante (BASTOS JR., 2001, p. 208), e se passa a realizar a bioprospecção racional, com critérios técnicos e científicos para a procura de possíveis plantas com valor para atividades econômicas. Bastos Jr., analisando as diferentes formas de bioprospecção, informa que “*o método que indiscutivelmente oferece melhores condições de êxito é aquele que se utiliza da etnobotânica – conhecimento das propriedades medicinais das plantas e ervas, ancestralmente adquiridos pelas populações locais*”. O mesmo autor assinala que, por meio dos conhecimentos de etnobotânica, a possibilidade de êxito, por amostras, aumenta em índices ente 50 e 75%, reduzindo os custos de pesquisa. Prakash adota uma postura muito mais otimista, pois estima que a possibilidade de êxito na prospecção de novos princípios ativos pode passar da média de 10.000 (dez mil) testes, por resultado positivo, para um por dois (PRAKASH, 1999, p. 823). Não se deve deixar passar em branco o fato de que não mais do que cerca de apenas 4% do germoplasma utilizado no desenvolvimento de novas espécies provêm de espécies selvagens ou coletadas *in situ* (DUTFIELD, 2000, p. 6). De qualquer forma, mesmo que os números estejam sub ou supervalorizados, fato é que não se pode mais desconhecer a importância da etnobotânica para a bioprospecção.

O reconhecimento dos conhecimentos tradicionais encontra-se em diferentes estágios nos diversos países. Existe uma tendência à construção de um quadro legislativo que seja capaz de contemplar a proteção dos conhecimentos tradicionais. Verifica-se que, indiscutivelmente, os sistemas jurídicos das comunidades tradicionais estão ganhando uma relevância que, anteriormente, não possuíam. Como será visto, a experiência australiana de reconhecimento judicial do direito aborígene é muito importante e marca uma nova perspectiva em relações interétnicas. Deliberadamente, não examinarei questões referentes ao Canadá e Estados Unidos, pois tais países possuem particularidades quanto ao tema que demandariam a elaboração de trabalhos específicos.

9.3.4.1 Registro do Patrimônio imaterial e dos conhecimentos tradicionais associados

Uma das questões mais complexas relacionadas com a proteção da diversidade biológica é aquela que diz respeito ao acesso aos benefícios decorrentes da utilização do patrimônio genético para fins comerciais, por aqueles que detêm conhecimentos tradicionais associados a tal patrimônio. Um dos fatores mais importantes para a dificuldade de enfrentamento do tema é o fato de que o “conhecimento tradicional associado” necessita estar devidamente catalogado e registrado para que possa ser provado e, consequentemente, defendido e remunerado. Não são poucas as discussões sobre o tema. Os diferentes debates e concepções sobre proteção da propriedade intelectual têm encontrado muitas dificuldades em enquadrar a proteção dos conhecimentos tradicionais associados dentro dos esquemas legais oficialmente reconhecidos nos diferentes direitos internos e mesmo no direito internacional.

Em função das dificuldades anteriormente apontadas, a comunidade internacional evoluiu para o reconhecimento de uma modalidade *sui generis* de proteção. Vários mecanismos foram desenvolvidos por diferentes países para assegurar a proteção de seus conhecimentos tradicionais associados. No caso brasileiro, quando da edição da revogada MPProv nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que trata do acesso e justa repartição dos benefícios associados ao patrimônio genético, não foi feita qualquer referência ou consideração ao Decreto Federal nº 3.551/2000. A norma, simplesmente, desconsiderou a existência da forma de registro “*sui generis*” do patrimônio imaterial, dentro do qual, sem dúvida, incluem-se os conhecimentos tradicionais associados, como pretendo demonstrar. É fato que a MPProv, acertadamente, considerou que o conhecimento tradicional associado é parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, motivo pelo qual deveria ter o seu registro no órgão próprio para tal. É evidente que o órgão registrário não deve se imiscuir nas questões de acesso ao patrimônio genético, assim como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não se imiscui com a utilização dos dados que nele são registrados.

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

O registro de bens culturais, como parte do patrimônio imaterial da nação, é uma decorrência e aprofundamento da proteção legal estabelecida pelo Decreto-lei nº 25/37, que cuida da proteção legal do patrimônio histórico, artístico, cultural, paleontológico material. A proteção do patrimônio imaterial é igualmente importante e estava sendo negligenciada por muitos e muitos anos.

O Decreto nº 3.551/2000, por seu artigo 1º, instituiu o “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro”. Tal registro é constituído obrigatoriamente por quatro livros, que são os seguintes:

- I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
- II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social;
- III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
- IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.

A inscrição em qualquer um dos livros de registro deve ter como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a

identidade e a formação da sociedade brasileira. Quanto a isso devo acrescentar que, assim como no caso do tombamento, não há qualquer impedimento legal para que os Estados e os Municípios criem registros de seu patrimônio imaterial específico e com importância local ou regional. O próprio decreto admite, no § 3º do artigo 1º, a possibilidade de abertura de outros livros, “para a inscrição de bens culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro do artigo 1º.”

Os livros I e II, em minha opinião, podem perfeitamente servir como um registro *sui generis* para o conhecimento tradicional associado. E, em tal condição, servirem de garantia do reconhecimento de que determinados conhecimentos tradicionais são obra da produção cultural desta ou daquela.

A instauração do procedimento administrativo de registro pode ser requerida por: i) Ministro de Estado da Cultura; ii) Instituições vinculadas ao Ministério da Cultura; iii) Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; iv) Sociedades ou associações civis.

Os requerimentos de abertura do procedimento administrativo de registro, acompanhados de documentação técnica, deverão ser encaminhados ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que os submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para apreciação e deliberação. Procedente o requerimento de registro, após decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título de “Patrimônio Cultural do Brasil”.

Uma vez registrado o bem, o Ministério da Cultura deve garantir: (i) documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo; e (ii) ampla divulgação e promoção.

Dado o caráter imaterial do bem registrado, sujeitando-se a alterações decorrentes da mudança de sua ambiência cultural, determina o artigo 7º que se proceda a uma reavaliação decenal da sua classificação como “Patrimônio Cultural do Brasil”. Na hipótese de a revalidação ser negada, o registro será mantido, como referência cultural de seu tempo. Naquilo que diz respeito à proteção “*sui generis*” do conhecimento tradicional associado, não há qualquer prejuízo, pois o registro permanece.

O Registro do Patrimônio Imaterial, tal como estabelecido na legislação própria, possui limitações bastante evidentes, se observado do ponto de vista da proteção de direitos de propriedade intelectual – quaisquer que sejam as suas naturezas. É lógico que somente mediante *lei* seria possível definir um regime de proibição geral e de exclusividade de utilização de tal patrimônio. Isso, no entanto, possui aspectos muito controversos e de difícil solução pela ordem jurídica ocidental.

De qualquer forma, a matéria é mais complexa, pois práticas e costumes associados ao conhecimento tradicional e às diferentes manifestações de expressão cultural dificilmente são *exclusividade* desta ou daquela comunidade local ou indígena, pois, se assim fosse, conceitos de unidade cultural, nações e pertinência a uma mesma linha civilizacional não teriam qualquer sentido. Não se esqueça, igualmente, das enormes dificuldades para definir a diferença entre uma influência legítima – e mesmo inevitável – de uma determinada tradição cultural sobre outra e a utilização deliberada de formas de arte, diferentes formas de expressões culturais e conhecimento tradicionais por terceiros, com o objetivo de obtenção de lucro; é uma linha muito tênue – se é que existe tal linha – e que não será facilmente identificada.

Naquilo que diz respeito, por exemplo, ao conhecimento tradicional associado à utilização de determinadas plantas ou substâncias de natureza medicinal, existe um outro problema bastante complexo que se origina no fato de que, em geral, a utilização de uma determinada terapia em comunidades indígenas encontra-se associada a rituais místicos e espirituais diretamente relacionados com a utilização da planta medicinal. Khalil (1998, p. 242) apresenta uma interessante visão sobre o tema:

*So it can be seen that knowledge had some sacredness around it. The traditional healers, for instance, were not wizards or witches, but medical practitioners who used the medium of psychoanalysis to treat patients.*¹⁰

Não se discute, evidentemente, o papel que o ritual desempenha no aspecto psicológico de pessoas doentes nem na própria cultura de uma sociedade, principalmente por meio do sentido de pertinência a um grupo. Do ponto de vista cultural, impõem-se as seguintes questões: (i) Qual a importância da substância como elemento curativo? (ii) Qual a importância dos rituais? (iii) A proteção jurídica a ser concedida aos detentores de tais conhecimentos poderá ser seccionada, se o seu detentor entende que eles formam um conjunto único?

É indiscutível que, dada a complexidade do tema e as múltiplas interpretações que podem ser dadas à matéria, faz-se necessário um consenso internacional sobre o assunto, de forma que se possam estabelecer patamares de proteção que sejam suficientemente adequados para estabelecerem uma equitativa repartição dos benefícios, sem que se criem obstáculos intransponíveis para a circulação de conhecimentos, bens e mercadorias.

O caminho para o registro *sui generis* dos conhecimentos tradicionais, em minha opinião, deve ser a criação de um banco de dados que não deveria ficar vinculado ao INPI, pois tantas são as especificidades do tema que, dificilmente, um órgão vocacionado para a ciência e tecnologia teria condições de atender às expectativas sociais. O desenvolvimento e o aprofundamento do modelo proposto pelo Decreto nº 3.551/2000 parece-me o mais adequado e factível. Poder-se-ia criar um livro específico para os conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica e a participação do MMA, da FUNAI e do próprio INPI no procedimento de registro.

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial foi disciplinado pela Portaria nº 200, de 18 de maio de 2016 do IPHAN. Tal Portaria faz uma importante consolidação de definições adotadas pela UNESCO, tais como:

Patrimônio Imaterial – “[...] são os usos, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes são inerentes – que as comunidades, os grupos e em alguns casos os indivíduos reconheçam como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é recriado constantemente pelas comunidades e grupos em função de seu entorno, sua interação com a natureza e sua história, infundindo-lhes um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana” (Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial/UNESCO – 2003).

Salvaguarda – “[...] entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não formal – e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos” (Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial/UNESCO – 2003).

Referência Cultural – São os sentidos e valores, de importância diferenciada, atribuídos aos diversos domínios e práticas da vida social (festas, saberes, modos de fazer, lugares e formas de expressão, etc.) e que, por isso mesmo, se constituem em marcos de identidade e memória para determinado grupo social (Manual de Aplicação do INRC, 2000).

Detentores – denominação dada às comunidades, grupos, segmentos e coletividades que possuem relação direta com a dinâmica da produção, reprodução de determinado bem cultural imaterial e/ou seus bens culturais associados, e para os quais o bem possui valor referencial, é parte constituinte da sua memória e identidade. Os detentores possuem conhecimentos específicos sobre esses bens culturais e são os principais responsáveis pela sua transmissão para as futuras gerações e continuidade da prática ao longo do tempo.

O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial está calcado em três macroprocessos que são (i) (Identificação de Bens Culturais de Natureza Imaterial, (ii) Reconhecimento de Bens Culturais de Natureza Imaterial (iii) – Apoio e Fomento a Bens Culturais de Natureza Imaterial.

A Identificação de Bens Culturais de Natureza Imaterial visa a produzir conhecimento e documentação – textual, sonora, visual e audiovisual – sobre o patrimônio imaterial por meio da utilização de instrumentos e metodologias específicas, objetivando a salvaguarda de bens culturais e o subsídio de políticas públicas. Este macroprocesso se divide em três processos que são a saber: (i) identificar Bens Culturais de Natureza Imaterial, (ii) Aplicar o Inventário Nacional de Referências Culturais e, (iii) Aplicar o Guia de Pesquisa e Documentação para o INDL.

O processo é constituído pelo conjunto de atividades que compõem a realização de processo de identificação por meio da metodologia do INRC. Além do que já está previsto no próprio instrumento, ele inclui também as atividades técnicas de análise, acompanhamento, avaliação de produtos, mobilização, participação em ações

devolutivas, já descritos no processo de identificar bens culturais de natureza imaterial, além de suporte técnico para capacitação no uso da metodologia. Já o Reconhecimento de Bens Culturais de Natureza Imaterial objetiva reconhecer e valorizar bens e práticas culturais como patrimônio cultural brasileiro por meio de instrumentos, processos e procedimentos normatizados. O Reconhecimento se faz por meio de quatro processos, a saber: (i) Registro de bens culturais de natureza imaterial, (ii) revalidação de bens de natureza cultural registrados, (iii) inclusão de línguas e (iv) apoio a candidaturas às Listas da Convenção UNESCO de 2003.

§ 2º PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA (PRINCIPAIS DOCUMENTOS)

Uma das principais características do chamado Direito Internacional do Meio Ambiente é uma enorme proliferação de Tratados, Convenções e Protocolos internacionais, multilaterais e bilaterais voltados para a proteção ambiental. Outra característica marcante é a segmentação dos temas. Explica-se essa segunda característica na medida em que é muito mais simples se alcançar consensos internacionais sobre temas predeterminados do que sobre temas muito genéricos, tais como proteção da vida marinha, proteção da fauna silvestre etc. O presente capítulo, como de resto todo o conjunto do presente trabalho, está voltado, fundamentalmente, para o Direito Interno. Não obstante isso, penso ser extremamente relevante que sejam apresentadas algumas das principais questões que estão relacionadas à proteção internacional do meio ambiente, pois, de uma forma ou de outra, elas acabam tendo uma enorme repercussão no Direito brasileiro.

9.4 PRINCIPAIS DOCUMENTOS INTERNACIONAIS ASSINADOS PELO BRASIL

Os documentos a seguir relacionados estão organizados de forma restritiva, isto é, só foram indicados aqueles que, diretamente, têm relação com a proteção da diversidade biológica.

Atos Multilaterais Assinados pelo Brasil no Campo da Proteção Ambiental¹¹

Título	Data	Promulgação	
		Decreto nº	Data
Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América	12/10/1940	58.054	23/3/1966
Convenção Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico	14/5/1966	65.026	20/8/1969
Convenção relativa às Zonas Úmidas de Importância Internacional, particularmente como <i>hábitats</i> das aves aquáticas	2/2/1971	1.905	16/5/1996
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outros Materiais (London Convention) (LC-72)	29/12/1972	87.566	16/9/1982
Convenção para o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção	3/3/1973	76.623	17/11/1975
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, 1973 (Marpol)	2/11/1973	2.508	4/3/1998
Protocolo de 1978 Relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, 1973 (Marpol PROT-78 ou Marpol 73/78)	17/2/1978	2.508	4/3/1998
Emenda ao artigo XI da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção	22/6/1979	133	24/5/1991
Protocolo de Emendas à Convenção Relativa às Zonas Úmidas de Importância Internacional, particularmente como <i>Hábitats</i> das Aves Aquáticas	3/12/1982	1.905	16/5/1996
Emenda ao artigo XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Extinção	20/4/1983	92.446	7/3/1986
Protocolo Adicional à Convenção Internacional para Conservação do Atum e Afins do Atlântico (CICAA)	10/7/1984	97.612	4/4/1989
Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio	22/5/1985	99.280	6/6/1990
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio	16/9/1987	99.280	6/6/1990
Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito	22/3/1989	875	19/7/1993
Ajuste ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio	20/6/1990	181	24/7/1991
Emenda ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio	29/6/1990	2.699	30/7/1998
Convenção Internacional para Prevenção, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo (OPRC-90)	30/11/1990	2.870	10/12/1998
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima	9/5/1992	2.652	1º/7/1998

Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais (Ata de Montevideú)	13/5/1992	2.544	13/4/1998
CDB (Rio-92)	5/6/1992	2.519	16/3/1998
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens Utilizados na Defesa e Proteção do Meio Ambiente	27/6/1992	652	15/9/1992
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio	25/11/1992	2.679	17/7/1998
Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Afetados por Seca e/ou Desertificação, principalmente na África	15/10/1994	2.741	20/8/1998
Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas	1º/12/1996	3.842	13/6/2001
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima	11/12/1997	5.445	12/5/2005
Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos VIII e IX à Convenção de Basileia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito	27/2/1998	4.581	27/1/2003
Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (PIC)	10/9/1998	5.360	31/1/2005
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da CDB	29/1/2000	5.705	16/2/2006
Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul	22/6/2001	5.208	17/9/2004
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes	22/5/2001	5.472	20/6/2005
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, aprovadas em Montreal, em 17 de setembro de 1997, ao Término da Nona reunião das Partes, e, em Pequim, em 3 de dezembro de 1999, por Ocasião da Décima Primeira Reunião das Partes	17/9/1997 e 3/12/1999	5.280	22/11/2004

O *site* do Ministério das Relações Exteriores¹² indica todos os atos internacionais praticados pelo Brasil em matéria ambiental.

9.4.1 Convenção sobre Diversidade Biológica

Dentre os instrumentos legais gerados na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992, a CDB é das mais importantes. Apesar de toda a importância da Convenção, é relevante deixar consignado que os Estados Unidos ainda não a ratificaram. Esse fato, na prática, enfraquece sobremaneira o acordo internacional, tornando bastante problemática a sua implementação, tendo em vista a importância política e econômica do mencionado país. É desnecessário dizer, ademais, que os termos da CDB não são obrigatórios para aqueles que não aderiram aos seus termos.¹³ Registre-se, ainda, que a CDB deu origem ao Protocolo, de Cartagena sobre Biossegurança, de 24 de maio de 2000, tema que seguramente será uma das questões dominantes no cenário internacional nos próximos anos; e, ainda, o Protocolo de Nagoya⁶ sobre repartição de benefícios.

A CDB está em plena vigência no Brasil, pois foi promulgada pelo Decreto nº 2.519/1998, que *promulga a CDB, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992*, após a sua aprovação pelo Congresso Nacional, mediante a expedição do Decreto Legislativo nº 2/1994.

O elemento mais importante a ser destacado, com a incorporação da CDB ao direito interno brasileiro, é que o Estado brasileiro se obrigou a implementar diversas medidas previstas na Convenção. É bom que se diga – a bem da verdade – que o Brasil vem dando cumprimento às determinações contidas na CDB, não obstante as dificuldades que daí surgem. Diversas são as ações legais e institucionais que vêm sendo tomadas para a integral aplicação da CDB. A entrada em vigor da CDB, no Brasil, não significa que as normas nela contidas serão aplicadas por si mesmas. Ao examinarmos os principais pontos da CDB, não será difícil perceber que ela estabelece normas a serem seguidas pelos Estados, seja em suas relações internacionais, seja na ordem interna. Trata-se de uma “convenção quadro” que define medidas legislativas, técnicas e políticas a serem adotadas pelos Estados-Partes. Ao analisarmos a legislação ambiental brasileira pós-Rio 92, facilmente se constata que o Brasil vem elaborando as normas definidas na CDB e, portanto, nos limites de sua capacidade técnica e econômica, está cumprindo fielmente as obrigações que assumiu perante a Comunidade Internacional. Prova disso é a legislação que será examinada posteriormente. É preciso que se reconheça, contudo, que há ainda muito por se fazer, especialmente no que concerne ao tema central deste trabalho.

9.4.1.1 Objetivos da CDB

Os objetivos da CDB estão estabelecidos em seu artigo 1º e são os seguintes: (i) conservação da diversidade biológica; (ii) a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias e mediante financiamento adequado.

A tradução dos objetivos da CDB, em minha opinião, é a de que ela visa a estabelecer – pelo menos em tese – um fluxo contínuo de informações, tecnologia e recursos genéticos. É evidente, no entanto, que tal fluxo não se faz de forma linear, pois muitas são as dificuldades para que ele seja implementado.

A conservação da diversidade biológica é uma aspiração de todos. Contudo, desde a elaboração da CDB, a diversidade biológica vem diminuindo, pois a sua conservação não é meramente uma questão de desejo. É, sobretudo, uma questão de recursos financeiros. A repartição justa e equitativa dos benefícios do acesso deve ser feita com a consideração das diferentes variáveis do processo, ou seja, a variável econômica dos investimentos, de sua escassez etc. A transferência adequada de tecnologia é outro ponto sensível, pois é totalmente onírico acreditar que ela possa ser feita de forma eficiente se não houver um sistema de patentes muito bem consolidado e implementado.

9.4.1.2 Soberania e diversidade biológica

O artigo 3º da CDB estabelece a forma pela qual os Estados exercerão o direito soberano de explorar seus próprios recursos naturais. Este deve ser exercido em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de Direito Internacional. Tal exploração deve ser realizada segundo as políticas ambientais adotadas por cada um dos Estados-Partes da CDB. Há uma soberania solidária e responsável em relação aos demais países da comunidade internacional, na medida em que os Estados têm a obrigação de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da sua jurisdição nacional. Dado o fato de que a diversidade biológica é um interesse de toda a humanidade, está claro que o *direito soberano dos Estados* não inclui o de destruí-la. Ela deve ser utilizada à luz do conceito de desenvolvimento sustentável.

A CDB expressamente reconhece que, sendo certo que a diversidade biológica ultrapassa fronteiras nacionais, a sua exploração não pode implicar danos além-fronteira. Está estabelecido, portanto, um princípio de solidariedade e responsabilidade entre as nações para a conservação de uma “preocupação comum” da humanidade e, portanto, dos Estados. O reconhecimento de que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos afasta de plano a ideia de que a diversidade biológica existente em cada um dos Estados é um *patrimônio comum* da Humanidade. Se aceita a tese do patrimônio comum, a consequência lógica seria o estabelecimento de algum mecanismo internacional que se encarregasse de geri-lo. Não há, portanto, uma gestão internacional sobre a diversidade biológica de cada um dos países.

9.4.1.3 Medidas de proteção da diversidade biológica

A CDB determina que os Estados-Partes desenvolvam uma série de medidas com vistas à preservação da diversidade biológica. Tais medidas devem ser adotadas dentro das limitações econômicas, financeiras e institucionais de cada um dos Estados-Partes.

As medidas institucionais a serem adotadas são: (i) desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para esse fim estratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, entre outros aspectos, as medidas estabelecidas nessa Convenção concernentes à Parte interessada; e (ii) integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes.

Medidas de monitoramento e identificação: (i) identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua conservação e sua utilização sustentável, levando em conta a lista indicativa de categorias constante no Anexo I da CDB; (ii) monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras técnicas, os componentes da diversidade biológica identificados em conformidade com a letra (i) acima, prestando especial atenção aos que requeiram urgentemente medidas de conservação e aos que ofereçam o maior potencial de utilização sustentável; (iii) identificar processos e categorias de atividades que tenham ou possam ter sensíveis efeitos negativos na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica e monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras e outras técnicas; (iv) manter e organizar, por qualquer sistema, dados derivados de atividades de identificação e monitoramento em conformidade com os itens (i), (ii) e (iii) anteriores.

Quanto à conservação *in situ*, na medida do possível e conforme o caso, deve ser providenciado o seguinte: (i) estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica; (ii) desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica; (iii) regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização sustentável; (iv) promover a proteção de ecossistemas, *hábitats* naturais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural; (v) promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes às protegidas, a fim de reforçar a proteção dessas áreas; (vi) recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies ameaçadas, mediante, dentre outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras estratégias de gestão; (vii) estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde humana; (viii) impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, *hábitats* ou espécies; (ix) procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes; (x) em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas; (xi) elaborar ou manter em vigor a legislação necessária e/ou outras disposições regulamentares para a proteção de espécies e populações ameaçadas; (xii) quando se verificar um sensível efeito negativo à diversidade biológica, em conformidade com o artigo 7º, regulamentar ou administrar os processos e as categorias de atividades em causa; (xiii) cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação *in situ* a que se referem os itens (i) a (xii), particularmente aos países em desenvolvimento.

Quanto à conservação *ex situ*, na medida do possível e conforme o caso, e principalmente a fim de complementar medidas de conservação *in situ*: (i) adotar medidas para a conservação *ex situ* de componentes da diversidade biológica, de preferência no país de origem desses componentes; (ii) estabelecer e manter instalações para a conservação *ex situ* e pesquisa de vegetais, animais e micro-organismos, de preferência no país de origem dos recursos genéticos; (iii) adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies ameaçadas e para sua reintrodução em seu *hábitat* natural em condições adequadas; (iv) regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de *hábitats* naturais com a finalidade de conservação *ex situ*, de maneira a não ameaçar ecossistemas e populações *in situ* de espécies, exceto quando forem necessárias medidas temporárias especiais *ex situ* de acordo com a alínea (iii); (v) cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação *ex situ* a que se referem as alíneas (i) a (iv) e com o estabelecimento e a manutenção de instalações de conservação *ex situ* em países em desenvolvimento.

9.4.1.4 Utilização sustentável de componentes da diversidade biológica

A CDB estabelece que as Partes Contratantes, na medida do possível e conforme o caso, devem: (i) incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos no processo decisório nacional; (ii) adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos na diversidade biológica; (iii) proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável; (iv) apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida; (v) estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos.

9.4.1.5 Acesso a recursos genéticos

Os recursos genéticos pertencem ao domínio eminente de cada Estado que, no entanto, não deve negar acesso aos demais, desde que obedecidas as leis de cada país detentor de mencionados recursos. Devem ser observados os seguintes procedimentos: (i) em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional; (ii) cada Parte Contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras Partes Contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos da CDB; (iii) para os propósitos da CDB, os recursos genéticos providos por uma Parte Contratante, a que se referem os artigos 15, 16 e 19, são apenas aqueles providos por Partes Contratantes que sejam países de origem desses recursos ou por Partes que os tenham adquirido em conformidade com essa Convenção; (iv) o acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no artigo 15; (v) o acesso aos recursos genéticos sujeita-se ao *consentimento prévio fundamentado* da Parte Contratante provedora, salvo se for estipulado ou de outra forma determinado pela mencionada

parte; (vi) cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras Partes Contratantes com sua plena participação e, na medida do possível, no território da parte provedora do acesso aos recursos genéticos; (vii) cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com os artigos 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos artigos 20 e 21, para *compartilhar de forma justa e equitativa* os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve ser feita de comum acordo.

9.4.1.6 Acesso à tecnologia e sua transferência

Esse é um dos temas mais complexos da CDB, pois ele busca fazer com que o acesso aos recursos genéticos implique, de alguma forma, uma troca entre os mencionados recursos e o desenvolvimento tecnológico do país provedor, mediante um procedimento de acesso e transferência de tecnologia.

A Convenção, como se vê, está estruturada dentro de uma concepção de que há dois fluxos distintos e paralelos, conforme o seguinte quadro:

Tecnologia	Recursos Genéticos	Acesso aos Recursos	Recursos Financeiros
Norte-Sul	Sul-Norte	Norte-Sul	Norte-Sul

- as Partes da CDB reconhecem que tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia como a sua transferência entre Partes Contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos da Convenção, por isso se comprometem, conforme o disposto no artigo 16, a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas tecnologias;
- o acesso à tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o § 1º do artigo 16, devem ser permitidos e/ ou facilitados em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em condições de concessão e preferenciais quando de comum acordo, e, caso necessário, em conformidade com mecanismo financeiro estabelecido nos artigos 20 e 21 da CDB. *No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual.* Mantendo-se compatibilidade com os §§ 3º, 4º e 5º do artigo 16;
- cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as demais Partes Contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que proveem recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as disposições dos artigos 20 e 21, de acordo com o Direito internacional e conforme os §§ 4º e 5º do artigo 16;
- cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o § 1º do artigo 16, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 16;
- as Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação da CDB, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional *para garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos da Convenção.*

9.4.1.6.1 Gestão da biotecnologia e distribuição de seus benefícios

Um dos aspectos mais complexos da CDB é o que diz respeito à gestão da biotecnologia. Como se sabe, o tema tem suscitado muita polêmica. As determinações contidas na CDB são as seguintes: (i) cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para permitir a participação efetiva, em atividades de pesquisa biotecnológica, das Partes Contratantes, especialmente países em desenvolvimento, que proveem os recursos genéticos para essa pesquisa, e se possível nos países provedores de recursos genéticos; (ii) cada Parte Contratante deve adotar todas as medidas possíveis para promover e antecipar acesso prioritário, em base justa e equitativa das Partes Contratantes, especialmente países em desenvolvimento, aos resultados e benefícios derivados de biotecnologia baseada em recursos genéticos providos por essas Partes Contratantes. Esse acesso deve ser definido de comum acordo; (iii) as Partes devem examinar a necessidade e as modalidades de um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em especial, a concordância prévia fundamentada, no que respeita à transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo modificado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica; (iv) cada Parte Contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, sob sua jurisdição, provedora dos organismos a que se refere o § 3º, à Parte Contratante em que esses organismos devam ser introduzidos, todas as informações disponíveis sobre a utilização e as normas de segurança exigidas por essa Parte Contratante para a manipulação desses organismos, bem como todas as informações disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos desses organismos específicos.

9.4.1.6.2 Relações entre diversidade biológica e produção de medicamentos

As relações entre a produção de produtos farmacêuticos e a preservação da diversidade biológica são intensas e profundas, muito embora nem sempre sejam claramente colocadas e, principalmente, compreendidas. Na verdade, a indústria farmacêutica é, seguramente, um dos ramos industriais mais fortemente interessados na conservação da diversidade biológica e na sua utilização racional, pois, conforme será demonstrado adiante, ela pode servir de matéria-prima para a pesquisa de importantes princípios ativos. Há uma tendência bastante generalizada de confundir a produção de medicamentos, realizada por laboratórios que fazem investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento, com a elaboração de poções mágicas a partir de extratos vegetais. Em realidade, entre uma planta e um medicamento que seja produzido com base em um dos *princípios ativos* nela existentes, há uma longa jornada a ser percorrida. Em primeiro lugar, há que se considerar que menos de 1% (um por cento) das plantas floreadas foi pesquisado cientificamente para o conhecimento de suas propriedades químicas (SHELDON e BALICK, Michael. *Etnobotany and the Search for Balance between Use and Conservation*. In: SWANSON, 1998. p. 46) . Em contrapartida, o conhecimento tradicional sobre as qualidades terapêuticas das plantas é muito vasto, pois *“thousands of years of direct dependence on plants has required the revision and perpetuation of a significant body of information regarding the value of individual species and their habitats”*,¹⁴ A questão que se coloca, portanto, é a de compatibilizar as pesquisas científicas com o conhecimento tradicional, tudo isso com vistas a proporcionar avanços na produção de novos medicamentos eficientes e seguros. A indústria farmacêutica, conforme nos relembra Aylward (1998. p. 103), data do século XIX e, até aquela época, a maioria dos remédios derivava diretamente da natureza, especialmente das plantas. Desde então, tem havido uma variação muito grande entre a pesquisa baseada em estudos sobre plantas e pesquisas com produtos químicos sintéticos. É necessário que se observe, no entanto, que, entre o início das pesquisas para um novo produto farmacêutico e a sua efetiva comercialização, o tempo gasto é de, aproximadamente, 14 anos, com custos que superam, em muito, a centenas de milhões de dólares americanos. O volume de recursos necessários para a produção de um novo medicamento, seja do ponto de vista econômico, seja dos pontos de vista científicos e tecnológicos (a indústria farmacêutica é uma das mais fortemente conhecimento-intensivas), faz com que somente poucos países possam pertencer a um “clube” muito fechado, pois somente grandes empresas podem suportar os custos e os riscos de pesquisa que se prolongam por mais de uma década, sem que haja qualquer segurança de que o produto delas resultantes será efetivo e seguro e terá aceitação no mercado. Alguns países em desenvolvimento têm buscado estabelecer uma indústria

farmacêutica autotone, mas, nesses mesmos 30 anos, eles foram responsáveis por apenas 20 novos medicamentos, ou seja, cerca de 1% da produção total (AYLWARD, 1998).

Do ponto de vista prático, a patente de um medicamento tem a duração de cerca de seis anos, entre sua concessão e o término de sua validade, período no qual os investimentos devem ser recuperados, sob pena de o produto ser um fracasso comercial, ainda que possa ser um excelente produto nos aspectos medicinais. A manutenção dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual, por intermédio das patentes, é extremamente importante para que os investimentos continuem a ser gerados e novos medicamentos produzidos. Qualquer pressão para que os mecanismos de proteção da propriedade intelectual referente aos medicamentos sejam enfraquecidos criará seguramente uma redução de investimentos privados em novos produtos. A indústria farmacêutica, no entanto, tem se mostrado um “*alvo fácil*” (AYLWARD, 1998, p. 98) para o corte de custos com saúde. E tais dificuldades econômicas e incertezas – aliadas aos baixíssimos investimentos governamentais na pesquisa de novos medicamentos – fizeram com que o ritmo de novas descobertas tenha diminuído e que a maioria dos medicamentos que atualmente estão entrando em uso tenha sido descoberta há quase 20 anos. Um outro fator ao qual não tem sido dada a necessária atenção é que as universidades utilizam muito mais recursos genéticos oriundos dos países em desenvolvimento do que as indústrias (PRAKASH, 1999, p. 823). Merece, ademais, ser ressaltado que a maioria dos medicamentos atualmente em uso não possui mais patentes válidas.

É bastante significativo o fato de que os grandes laboratórios farmacêuticos de pesquisa se dediquem também ao lançamento de genéricos.

9.4.2 Agenda 21

A Agenda 21 é um conjunto de metas e objetivos que visam a estabelecer orientações para a comunidade internacional durante o século XXI. É um documento que surgiu no contexto da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. O capítulo 15 da Agenda 21 trata da Conservação da Diversidade Biológica. De fato, cada um dos capítulos da Agenda 21 busca definir um conjunto de ações e atividades a serem cumpridas na ordem internacional que se materializarão em tratados e convenções específicos. A Agenda 21 é uma declaração política firmada pelos Estados e não tem força obrigatória, muito embora os seus signatários venham desenvolvendo toda uma série de ações para a sua implementação. A Agenda 21, em seu item 15.2, proclama que:

Os bens e serviços essenciais de nosso planeta dependem da variedade e variabilidade dos genes, espécies, populações e ecossistemas. Os recursos biológicos nos alimentam e nos vestem, e nos proporcionam moradia, remédios e alimento espiritual. Os ecossistemas naturais de florestas, savanas, pradarias e pastagens, desertos, tundras, rios, lagos e mares contêm a maior parte da diversidade biológica da Terra. Os campos agrícolas e os jardins também têm grande importância como repositórios, enquanto os bancos de genes, os jardins botânicos, os jardins zoológicos e outros repositórios de germoplasma fazem uma contribuição pequena mas significativa. O atual declínio da diversidade biológica resulta em grande parte da atividade humana, e representa uma séria ameaça ao desenvolvimento humano.

Dentre os objetivos da Agenda 21, está bastante caracterizada a importância das comunidades locais e indígenas, naquilo que concerne à produção dos conhecimentos tradicionais associados. Assim é que em 15.4 está disposto que os diferentes atores do cenário internacional devem levar em “consideração as populações indígenas e suas comunidades”.

Especificamente sobre a repartição dos benefícios decorrentes do acesso à diversidade biológica, a Agenda 21 estabelece como objetivo (15.4.d) o de adotar as medidas apropriadas para a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da pesquisa e desenvolvimento, bem como do uso dos recursos biológicos e genéticos, inclusive da biotecnologia, entre as fontes desses recursos e aqueles que os utilizam.

Os Estados signatários da Agenda 21 igualmente assumem o compromisso de (15.4.g):

reconhecer e fomentar os métodos tradicionais e os conhecimentos das populações indígenas e suas comunidades, enfatizando o papel específico das mulheres, relevantes para a conservação da diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos biológicos, e assegurar a esses grupos oportunidade de participação nos benefícios econômicos e comerciais decorrentes do uso desses métodos e conhecimentos tradicionais.

O mesmo tema é reenfatizado no item 15.5.e da Agenda 21, dessa vez como comprometimento de elaboração de uma legislação nacional apta a assegurar a proteção dos conhecimentos tradicionais e a sua remuneração adequada, *in verbis*:

em conformidade com a legislação nacional, adotar medidas para respeitar, registrar, proteger e promover uma maior aplicação dos conhecimentos, inovações e práticas das comunidades indígenas e locais que reflitam estilos de vida tradicionais e que permitam conservar a diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos biológicos, com vistas à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes, e promover mecanismos que promovam a participação dessas comunidades, inclusive das mulheres, na conservação e manejo dos ecossistemas.

9.4.3 Convenção de RAMSAR

É uma Convenção internacional que antecede à própria CNUMAD, pois foi realizada em 1971. Os primeiros sete Estados que dela participaram foram: (i) Austrália; (ii) Finlândia; (iii) Grécia; (iv) Irã; (v) Noruega; (vi) África do Sul e (vii) Suécia. O objetivo da referida Convenção é o de estabelecer mecanismos de cooperação internacional com vistas à proteção de áreas úmidas, bem como de aves aquáticas que tenham importância internacional. Ela entrou em vigor no ano de 1975.

A Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como *Hábitat de Aves Aquáticas*, concluída em Ramsar, Irã, a 2 de fevereiro de 1971, foi ratificada pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo nº 33, de 1992, tendo sido promulgada pelo Decreto nº 1.905/1996.

O Preâmbulo da Convenção de Ramsar está firmado sobre a premissa da interdependência entre o Homem e o Meio Ambiente e considera a importância das funções ecológicas fundamentais das zonas úmidas enquanto reguladoras dos regimes de água e enquanto *hábitats* de uma flora e fauna características, especialmente de aves aquáticas.

É importante ressaltar que a Convenção considera que as zonas úmidas constituem um recurso de grande valor econômico, cultural, científico e recreativo, cuja perda seria irreparável. A Convenção, portanto, é celebrada com o objetivo de assegurar a interrupção do processo de degradação das áreas úmidas com importância internacional. É importante ressaltar que a Convenção de Ramsar reconhece que as aves aquáticas, em suas migrações sazonais, atravessam fronteiras e, em tal condição, devem ser consideradas como um recurso internacional.

A Convenção expressa a confiança de que a conservação de zonas úmidas, da sua flora e da sua fauna, pode ser assegurada com políticas internacionais conjuntas de longo alcance, através de ação internacional coordenada.

Como toda Convenção internacional, a Convenção de Ramsar define um glossário básico, de forma que a matéria tratada não deixe margem a dúvidas ou gere conflitos de interpretação. Para os efeitos da Convenção de Ramsar: (i) *Zonas Úmidas*: são áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade na maré baixa; (ii) *Aves Aquáticas*: são pássaros ecologicamente dependentes de zonas úmidas.

9.4.3.1 Indicação pelas partes de áreas a serem incluídas na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional

As Partes Contratantes deverão indicar as zonas úmidas existentes em seus territórios, que deverão constar da Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional. Tais áreas devem ter os seus limites descritos pormenorizadamente e delimitados no mapa, podendo incorporar áreas ribeirinhas ou trechos de litorais

adjacentes às zonas úmidas e ilhas ou porções de água marítima que possuam mais de seis metros de profundidade na maré baixa e que estejam situadas dentro da área de zona úmida, principalmente onde estas tenham, ainda, importância como *habitat* de aves aquáticas.

A indicação de áreas para integrar a Lista não pode ser aleatória, mas, pelo contrário, deve seguir critérios de escolha que se baseiem em sua importância internacional pelos seus aspectos ecológicos, botânicos, zoológicos, imunológicos ou hidrológicos. O primeiro critério a ser utilizado quando da escolha de uma área para ser incluída como integrante da lista é o da importância ecológica em qualquer estação do ano.

A indicação de uma área como integrante da Lista não retira do país, dentro do qual ela esteja situada, os direitos de soberania inerentes à sua condição de soberania nacional.

As Partes integrantes da Convenção têm o direito de adicionar à Lista outras zonas úmidas situadas no seu território, bem como aumentar os limites das que já estão incluídas na Lista, ou, por motivo de interesse nacional urgente, anular ou restringir os limites das zonas úmidas já incluídas na Lista. Para que assim procedam, devem informar a realização de tais alterações, em curto prazo, ao organismo ou ao governo encarregado das funções de *bureau* permanente, conforme especificado no artigo 8º da Convenção. Como forma de mitigação dos direitos estipulados no artigo 2,6 da Convenção, cada Parte Contratante deverá levar em conta a sua responsabilidade, no plano internacional, para a conservação, orientação e exploração racional da população migrante de aves aquáticas, tanto ao designar as zonas úmidas de seu território a serem inscritas na Lista, como ao exercer o seu direito de modificar a inscrição.

Áreas Brasileiras Incluídas na Convenção¹⁵

Sítios	UF	Data da inclusão
Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses	MA	30/11/1993
Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense	MA	29/02/2000
Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz e Baixios do Mestre Alvaro e Tarol	MA	29/02/2000
Parque Nacional do Araguaia – Ilha do Bananal	TO	04/10/1993
Parque Nacional da Lagoa do Peixe	RS	24/05/1993
Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense	MT	24/05/1993
Reserva de desenvolvimento Sustentável Mamirauá	AM	04/10/1993
Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal	MT	06/12/2002
Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro	MS	28/05/2009
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos	BA	02/02/2010
Parque Estadual do Rio Doce	MG	26/02/2010
Parque Nacional do Cabo Orange	AP	02/02/2013
Reserva Biológica Atol das Rocas	RN	11/12/2015
Parque Nacional do Viruá	RR	22/03/2017
Parque Nacional de Anavilhanas	AM	22/03/2017
Reserva Biológica do Guaporé	RO	22/03/2017
Estação Ecológica do Taim	RS	22/03/2017
Estação Ecológica de Guaraqueçaba	PR	05/06/2017
Lund-Warming/APA Carste de Lagoa Santa	MG	05/06/2017
APA Cananéia – Iguape – Peruíbe	SP	04/09/2017
APA Estadual de Guaratuba	PR	21/09/2017
Parque Nacional de Ilha Grande	MS/PR	30/09/2017
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha	PE	25/01/2018
Rio Negro (Sítio Ramsar Regional)	AM	19/03/2018
Estuário do Amazonas e seus Manguezais (Sítio Ramsar Regional)	AP até CE	19/03/2018
Rio Juruá	AM	29/09/2018
Estação Ecológica Taimã	MT	21/10/2018

As Obrigações com relação às áreas incluídas na lista são (i) elaborar e executar os seus planos de modo a promover a conservação das zonas úmidas incluídas na Lista e, na medida do possível, a exploração racional daquelas zonas úmidas do seu território; (ii) tomar as medidas necessárias para ser informada com a possível brevidade sobre as modificações das condições ecológicas de qualquer zona úmida situada no seu território e inscrita na Lista que se modificar ou esteja em vias de se modificar, devido ao desenvolvimento tecnológico, poluição ou outra intervenção humana. As informações dessas mudanças serão transmitidas sem demora à organização ou ao governo responsável pelas funções do *bureau* especificadas no artigo 8º; (iii) promover a conservação de zonas úmidas e de aves aquáticas, estabelecendo reservas naturais nas zonas úmidas, quer estas estejam ou não inscritas na Lista, e providenciar a sua proteção apropriada; (iv) em caso de anulação ou diminuição dos limites de uma zona úmida incluída na Lista, em função de interesse nacional urgente, a Parte Contratante providenciar a compensação, na medida do possível, da perda de recursos da zona úmida e em especial criar novas reservas naturais para as aves aquáticas e para a proteção dentro da mesma região ou em

outra, de uma porção apropriada do *hábitat* anterior; (v) incentivar a pesquisa e o intercâmbio de dados e publicações relativas às zonas úmidas e à sua flora e fauna; (vi) empreender esforços pela sua gestão para aumentar a população das aves aquáticas nas zonas úmidas apropriadas; (vii) promover a formação do pessoal competente para estudo, gestão e proteção das zonas úmidas.

9.4.4 Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção – Cites

Um dos elementos mais importantes dentro do contexto da perda de diversidade biológica é o tráfico internacional de espécies da flora e da fauna silvestre ameaçadas de extinção. A importância do assunto é de tal ordem que a comunidade internacional dedicou-lhe a “convenção sobre o comércio internacional das espécies da flora e fauna selvagem em perigo de extinção”, firmada aos 3 de março de 1973, aprovada pelo Brasil mediante o Decreto Legislativo nº 54/1975, e promulgada pelo Decreto nº 76.623/1975. O quadro normativo da inserção da Cites no Direito interno brasileiro é complementado, ainda, pelas seguintes disposições legais: (i) Decreto Legislativo 21/1985, (ii) Decreto Legislativo nº 35/1985, (iii) Decreto nº 92.446/1986, e (iv) Decreto nº 3.607/2000.

A Convenção é seguida de três anexos que se destinam a definir as espécies que, de uma forma ou de outra, estão sob a sua tutela. O conteúdo dos anexos é o seguinte:

Anexo I: Todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou possam ser afetadas pelo comércio.

O comércio de qualquer espécime de tais espécies deve estar submetido à regulamentação “particularmente” rigorosa, com vistas a assegurar que elas não sejam mais ameaçadas em sua sobrevivência, e somente deve ser autorizado em situações excepcionais.

Anexo II:

- a) todas as espécies que, embora atualmente não se encontrem necessariamente em perigo de extinção, possam vir a estar em tal condição, a menos que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito à regulamentação rigorosa, a fim de evitar exploração incompatível com sua sobrevivência; e*
- b) outras espécies que devam ser objeto de regulamentação, a fim de permitir um controle eficaz do comércio dos espécimes de certas espécies a que se refere o subparágrafo a do presente parágrafo.*

Anexo III: Todas as espécies que qualquer das partes declare sujeitas, nos limites de sua competência, à regulamentação para impedir ou restringir sua exploração e que necessitam da cooperação das outras partes para o controle do comércio.

As partes integrantes da Cites somente podem permitir o comércio de espécimes de espécies incluídas nos Anexos I, II e III com a observância das disposições contidas na Convenção.

9.4.4.1 Relação entre a Cites e outras convenções internacionais e a legislação nacional

A condição de parte signatária da Cites não impede o direito soberano de adoção de: (i) medidas internas mais rígidas com referência às condições de comércio, captura, posse ou transporte de espécimes de espécies incluídas nos anexos I, II e III, ou proibi-los inteiramente; ou (ii) medidas internas que restrinjam ou proíbam o comércio, a captura, a posse ou o transporte de espécies não incluídas nos anexos I, II ou III.

As disposições da Cites não afetam as disposições de qualquer medida interna ou obrigações das partes derivadas de qualquer tratado, convenção ou acordo internacional referentes a outros aspectos do comércio, da captura, da posse ou do transporte de espécimes que estejam em vigor, ou que entrem em vigor posteriormente para qualquer das partes, incluídas as medidas relativas à alfândega, saúde pública ou quarentenas vegetais ou animais. Da mesma forma, não afetam as disposições ou obrigações emanadas de qualquer tratado, convenção ou acordo internacional celebrados ou que venham a ser celebrados entre Estados e que criem uma união ou acordo comercial regional, que estabeleça ou mantenha um controle aduaneiro comum externo e elimine controles aduaneiros entre as partes respectivas, na medida em que se refiram ao comércio entre os Estados-Membros dessa união ou acordo.

Um Estado-parte da presente convenção que seja também parte de outro tratado, convenção ou acordo internacional vigente, quando entrar em vigor a presente convenção e em virtude de cujas disposições se protejam as espécies marinhas incluídas no anexo II, ficará isento das obrigações que lhe impõem as disposições da presente convenção com referência aos espécimes de espécies incluídas no anexo II capturados tanto por barcos matriculados nesse Estado e de conformidade com as disposições desses tratados, convenções ou acordos internacionais.

Sem prejuízo das disposições dos artigos III, IV e V, para qualquer exportação de um espécime capturado de conformidade com o § 4º do presente artigo, somente será necessário um certificado de uma autoridade administrativa do Estado de introdução, assegurando que o espécime foi capturado de acordo com as disposições dos tratados, convenções ou acordos internacionais pertinentes.

Nenhum dispositivo da presente convenção prejudicará a modificação e o desenvolvimento progressivo do direito do mar pela Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, convocada de acordo com a Resolução nº 2.750 C (XXV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, nem as reivindicações e teses jurídicas presentes ou futuras de qualquer Estado no que se refere ao Direito do Mar e à natureza e extensão da jurisdição costeira e da bandeira do Estado.

9.4.4.2 Procedimentos necessários ao comércio internacional de espécies (espécies integrantes dos Anexos I, II e III da Cites)

O Anexo I da Cites é integrado pelas espécies que são consideradas ameaçadas de extinção e, portanto, potencialmente afetadas pelo comércio, necessitando que a sua comercialização seja submetida a controle estrito das Autoridades Administrativas, o que se faz mediante a concessão de Licença ou Certificado.

A exportação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo I da Cites somente pode ser autorizada pela expedição e apresentação prévia de Licença de Exportação, que somente será concedida após o atendimento dos seguintes requisitos: (i) emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação não prejudicará a sobrevivência da espécie; e (ii) verificação, pela Autoridade Administrativa, se o transporte não causará danos ao espécime, se foi concedida a Licença de Importação e se é legal sua aquisição.

A importação de qualquer espécime de uma espécie incluída no Anexo I da Cites somente será autorizada mediante a concessão e apresentação prévia de Licença de Exportação ou Certificado de Reexportação e de Licença de Importação, a qual somente será concedida uma única vez, atendidos os seguintes requisitos: (i) emissão de parecer, pela Autoridade Científica, atestando que a exportação não prejudicará a sobrevivência da espécie; (ii) verificação, pela Autoridade Administrativa, se o transporte não causará danos ao espécime, se foi concedida a Licença de Importação e se é legal sua aquisição. Deve, ainda, ser providenciado para que o espécime não seja utilizado para fins comerciais. Igualmente, deve ser assegurado que o importador, o exportador ou reexportador, conforme o caso, dispõem de instalações adequadas para a recepção do espécime vivo. As atividades comerciais acima mencionadas somente poderão ser praticadas caso não haja ameaça à sobrevivência da espécie.

O Anexo II da Cites compõe-se de espécies que, embora não se encontrem em perigo de extinção, necessitam de cuidados especiais para que não atinjam tal condição. Daí a necessidade de que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito à regulamentação rigorosa, podendo ser autorizada a sua comercialização, pela Autoridade Administrativa, somente mediante a concessão de Licença ou emissão de Certificado. Tanto a importação, a exportação e a reexportação demandarão a emissão de licenças e certificados, que deverão atestar as condições sanitárias do receptor dos espécimes de espécies, o não prejuízo para as espécies da comercialização do espécime. A Autoridade Administrativa deverá certificar a legalidade da atividade e, também, que as condições de transporte não são prejudiciais ao espécime.

A autoridade administrativa poderá estabelecer cotas tanto para importação como para exportação de espécimes de espécies contempladas no Anexo II da Cites.

Conforme determina o artigo 10 do Decreto, “as espécies incluídas no Anexo III da Cites por intermédio da declaração de qualquer país são aqueles cuja exploração necessita ser restrita ou impedida e que requer a cooperação no seu controle, podendo ser autorizada sua comercialização, mediante concessão de Licença ou Certificado, pela Autoridade Administrativa”. Uma vez que a espécie seja incluída no Anexo III, as transações comerciais internacionais somente poderão ser autorizadas mediante a concessão e apresentação prévia de licenças de importação, exportação e/ou reexportação, conforme o caso.

9.4.4.3 Não incidência das normas da Cites

As disposições do Capítulo II do Decreto nº 3.607/2000, não são aplicáveis nas hipóteses seguintes: (i) trânsito ou transbordo de espécimes no território de país que seja signatário da Convenção, enquanto os espécimes permanecerem sob o controle aduaneiro; (ii) quando a Autoridade Administrativa do país de exportação ou de reexportação verificar que um espécime foi adquirido antes de a Convenção entrar em vigor; (iii) espécimes que sejam objetos pessoais ou de uso doméstico, exceto nos casos previstos no § 3º do artigo 7º da Convenção; (iv) empréstimo, doação ou intercâmbio sem fim comercial entre cientistas ou instituições científicas registradas junto às Autoridades Administrativas dos respectivos países; e (v) espécimes que fazem parte de zoológico, circo, coleção zoológica ou botânica ambulantes, desde que sejam obedecidos os seguintes requisitos: (a) o exportador ou importador registre todos os pormenores sobre os espécimes junto à Autoridade Administrativa; (b) os espécimes estejam incluídos nos incisos II e IV do artigo 16 do Decreto nº 3.607/2000; e (c) a Autoridade Administrativa verifique se o transporte não causará dano ao espécime.

§ 3º ACESSO À DIVERSIDADE BIOLÓGICA NO BRASIL

O acesso aos benefícios decorrentes da utilização da biodiversidade é uma das questões mais complexas em diversos setores da vida internacional, haja vista a possibilidade de geração de valor econômico. Não se deve, contudo, deixar de anotar a perspicaz observação de DUTFIELD (2000, p. 2) no sentido de que: “*Na ausência de um mercado, é muito difícil calcular o seu valor econômico como incentivo na moderna criação de plantas.*” Esse é, apenas, o aspecto da moderna agroindústria. Entretanto, há que se considerar que questões relacionadas com a produção de itens farmacêuticos, igualmente, estão extremamente vinculadas com o acesso à biodiversidade. O meu objetivo, neste capítulo, é analisar a legislação federal referente ao acesso à diversidade biológica. Examinarei, fundamentalmente, os mecanismos legais e institucionais criados pela MProv nº 2.186-16/2001, revogada pela Lei nº 13.123/2015.

9.5 O QUADRO JURÍDICO DO ACESSO À BIODIVERSIDADE

A CF, em seu artigo 225, § 1º, II, e § 4º, define as regras básicas a serem observadas pelo legislador ordinário. As normas constitucionais brasileiras formam o arcabouço jurídico básico que serve de suporte para a adesão brasileira aos termos da CDB que foi incorporada ao nosso direito interno pelo Decreto nº 2.519/1998.

A Lei ampliou e deu mais estabilidade jurídica aos assuntos que eram tratados pela revogada MProv nº 2.186-16/2001. Assim, o artigo 1º da lei determinava que o seu campo de aplicação é: (i) o acesso ao patrimônio genético do País, bem de uso comum do povo encontrado em condições *in situ*, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantido em condições *ex situ*, desde que encontrado em condições *in situ* no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva; (ii) ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, relevante à conservação da diversidade biológica, à integridade do patrimônio genético do País e à utilização de seus componentes; (iii) ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a conservação e a utilização da diversidade biológica; (iv) à exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado; (v) à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, para conservação e uso sustentável da biodiversidade; (vi) à remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos, vivos ou mortos, de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio genético; e (vii) à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados.

A lei foi criada com vistas a tentar dar solução a diversos problemas criados pela própria MProv nº 2.186-16/2001 que *não* estabelecia normas referentes ao exercício dos direitos de propriedade material ou imaterial incidentes sobre o componente do patrimônio genético acessado ou sobre o local de sua ocorrência, ou seja, tanto o titular do produto resultante da utilização do patrimônio genético quanto o titular do conhecimento tradicional associado, gerando um clima de instabilidade muito grande na matéria que, diga-se de passagem, ainda não foi totalmente superado.

A questão relativa aos direitos de propriedade intelectual foi expressamente tratada no § 1º do artigo 1º que, expressamente, determina que “o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado será efetuado sem prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado acessado ou sobre o local de sua ocorrência”, quanto ao acesso ao patrimônio genético existente na plataforma continental deverão ser observadas as normas contidas na Lei nº 8.617/1993.

9.5.1 Conceitos normativos

A lei estabeleceu uma série de conceitos normativos – a serem utilizados em harmonia com os constantes na CDB (Lei nº 13.123/2015) – que são os seguintes (art. 2º): (i) patrimônio genético – informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos; (ii) conhecimento tradicional associado – informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético; (iii) conhecimento tradicional associado de origem não identificável – conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional; (iv) comunidade tradicional – grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição; (v) provedor de conhecimento tradicional associado – população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional que detém e fornece a informação sobre conhecimento tradicional associado para o acesso; (vi) consentimento prévio informado – consentimento formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários; (vii) protocolo comunitário – norma procedimental das populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios de que trata esta Lei; (viii) acesso ao patrimônio genético – pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético; (ix) acesso ao conhecimento tradicional associado – pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias, tais como feiras, publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras formas de sistematização e registro de conhecimentos tradicionais associados; (x) pesquisa – atividade, experimental ou teórica, realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis; (xi) desenvolvimento tecnológico – trabalho sistemático sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para exploração econômica; (xii) cadastro de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado – instrumento declaratório obrigatório das atividades de acesso ou

remessa do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado; (xiii) remessa – transferência de amostra de patrimônio genético para instituição localizada fora do País com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária; (xiv) autorização de acesso ou remessa – ato administrativo que permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e a remessa de patrimônio genético; (xv) usuário – pessoa natural ou jurídica que realiza acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado ou explora economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado; (xvi) produto acabado – produto cuja natureza não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado seja um dos elementos principais de agregação de valor ao produto, estando apto à utilização pelo consumidor final, seja esta pessoa natural ou jurídica; (xvii) produto intermediário – produto cuja natureza é a utilização em cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na condição de insumo, excipiente e matéria-prima, para o desenvolvimento de outro produto intermediário ou de produto acabado; (xviii) elementos principais de agregação de valor ao produto – elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico; (xix) notificação de produto – instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o usuário declara o cumprimento dos requisitos da Lei e indica a modalidade de repartição de benefícios, quando aplicável, a ser estabelecida no acordo de repartição de benefícios; (xx) acordo de repartição de benefícios – instrumento jurídico que qualifica as partes, o objeto e as condições para repartição de benefícios; (xxi) acordo setorial – ato de natureza contratual firmado entre o poder público e usuários, tendo em vista a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da exploração econômica oriunda de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável; (xxii) atestado de regularidade de acesso – ato administrativo pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado cumpriu os requisitos da Lei; (xxiii) termo de transferência de material – instrumento firmado entre remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso, que indica, quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado e que estabelece o compromisso de repartição de benefícios de acordo com as regras previstas na Lei; (xxiv) atividades agrícolas – atividades de produção, processamento e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas; (xxv) condições *in situ* – condições em que o patrimônio genético existe em ecossistemas e *habitats* naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham desenvolvido suas características distintivas próprias, incluindo as que formem populações espontâneas; (xxvi) espécie domesticada ou cultivada – espécie em cujo processo de evolução influenciou o ser humano para atender suas necessidades; (xxvii) condições *ex situ* – condições em que o patrimônio genético é mantido fora de seu *habitat* natural; (xxviii) população espontânea – população de espécies introduzidas no território nacional, ainda que domesticadas, capazes de se autopropagarem naturalmente nos ecossistemas e *habitats* brasileiros; (xxix) material reprodutivo – material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução sexuada ou assexuada; (xxx) envio de amostra – envio de amostra que contenha patrimônio genético para a prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil; (xxxi) agricultor tradicional – pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e conserva a diversidade genética, incluindo o agricultor familiar; (xxxii) variedade tradicional local ou crioula – variedade proveniente de espécie que ocorre em condição *in situ* ou mantida em condição *ex situ*, composta por grupo de plantas dentro de um táxon no nível mais baixo conhecido, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, incluindo seleção natural combinada com seleção humana no ambiente local, que não seja substancialmente semelhante a cultivares comerciais; e (xxxiii) raça localmente adaptada ou crioula – raça proveniente de espécie que ocorre em condição *in situ* ou mantida em condição *ex situ*, representada por grupo de animais com diversidade genética desenvolvida ou adaptada a um determinado nicho ecológico e formada a partir de seleção natural ou seleção realizada adaptada por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional.

O parágrafo único do artigo 2º estende o conceito de patrimônio genético ao “micro-organismo que tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental”.

A norma legal admite uma multiplicidade de direitos de propriedade incidentes sobre o mesmo bem jurídico. O patrimônio genético, por exemplo, é claramente imaterial e não se confunde com os bens materiais individuais ou coletivos.

O artigo 2º determina a existência do regime de autorização da União para acesso ao patrimônio genético existente no país. A matéria, portanto, está submetida ao poder de polícia da União, logo, o uso, a comercialização e o aproveitamento para quaisquer fins estão submetidos à fiscalização, a restrições e repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos na Medida Provisória e no seu regulamento.

O patrimônio genético, mal comparando, é o *software* do meio ambiente, pois mais importante que o próprio *hardware*, embora um não viva sem o outro.

9.5.2 Patrimônio genético

O patrimônio genético é a Informação de origem genética contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições *in situ*, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções *ex situ*, desde que coletados em condições *in situ* no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.

Ele não é, portanto, um conjunto de bens materiais, pois é uma informação, um conjunto de bens imateriais. A norma estabelece que tal conjunto de informações, mesmo que ainda não tenham sido reveladas, é de propriedade do Estado brasileiro e que, em função de tal regime de titularidade, os benefícios econômicos e outros que possam dele advir devem ser repartidos entre o Estado e os outros intervenientes no processo de seu desvendamento.

Uma questão que ainda não está muito clara é aquela que diz respeito à competência legislativa sobre patrimônio genético, pois, salvo melhor juízo, os artigos da CF não se referem ao tema. É certo, no entanto, que o artigo 225, § 1º, II, determina que compete ao Poder Público “*preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas pesquisa e à manipulação de material genético*”. O comando contido na norma *supra* tem por finalidade assegurar que todos usufruam de uma sadia qualidade ambiental. Em princípio, o legislador constituinte entendeu que a conservação do patrimônio genético é, reflexamente, uma questão ambiental. Em meu entendimento, esse fato desloca a competência sobre a matéria para o artigo 24 da CF, por se tratar de competência em matéria ambiental, logo, concorrente. Em abonoamento a esse entendimento, é possível verificar-se que alguns Estados-Membros da Federação já estão legislando sobre a matéria de forma bastante abrangente. Entretanto, como será visto, a matéria não é tão simples, pois existem assuntos de Direito Comercial, de propriedade intelectual, terras indígenas e outros que se imbricam no tema. A questão central, em meu entendimento, é que, em vez de se estabelecerem disputas por competências, os entes federados *devem colaborar entre si* para dar o melhor encaminhamento possível à questão.

9.5.2.1 Inaplicabilidade das normas e vedação de acesso

A Medida Provisória não se aplica em duas hipóteses: (i) patrimônio genético humano; e (ii) intercâmbio e difusão de componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado praticado entre si por comunidades indígenas e comunidades locais para seu próprio benefício e baseados em prática costumeira. É inadmissível o acesso ao patrimônio genético quando a sua utilização se fizer com o objetivo de realização de práticas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas.¹⁶ É uma consequência lógica da CDB, pois ela visa ao desenvolvimento sustentável e à promoção humana.

9.5.2.2 Gestão do patrimônio genético

O artigo 6º da Lei nº 13.123/2015 criou, no âmbito do MMA, sob a presidência de seu representante, o CGEN – cuja composição e funcionamento são definidos em regulamento –, de caráter deliberativo e normativo, formado por representantes de órgãos e entidades da Administração Pública Federal com competência sobre

as diversas ações referentes ao acesso à biodiversidade.

Atribuições do Conselho de Gestão: (i) coordenar a implementação de políticas para a gestão do patrimônio genético; (ii) estabelecer: a) normas técnicas; b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa; c) diretrizes para elaboração do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios; d) critérios para a criação de base de dados para o registro de informação sobre conhecimento tradicional associado; (iii) acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado; (iv) deliberar sobre: a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético, mediante *anuência prévia de seu titular*; b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante *anuência prévia de seu titular*; c) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético à instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos termos do regulamento; d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado à instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos termos do regulamento; e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento ou de instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins: i.a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado; ii.a remeter amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior; f) credenciamento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de componente do patrimônio genético; (v) dar *anuência* aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios quanto ao atendimento dos requisitos previstos na Medida Provisória e no seu regulamento; (vi) promover debates e consultas públicas sobre os temas relacionados ao acesso à biodiversidade; (vii) funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição credenciada e dos atos decorrentes da aplicação da Lei de acesso à biodiversidade; (viii) aprovar seu regimento interno.

A atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecimento e que não esteja associada à bioprospecção, sempre que envolva a participação de pessoa jurídica estrangeira, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pela política nacional de pesquisa científica e tecnológica, na forma da legislação específica.

Ao Presidente do Conselho de Gestão compete firmar, em nome da União, Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. Tal atribuição poderá ser delegada ao titular de instituição pública federal de pesquisa e desenvolvimento ou instituição pública federal de

9.5.2.3 Repartição de benefícios

Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos, de forma justa e equitativa, entre as partes contratantes, conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente. A regra definida no artigo 25 é de intervenção do Estado nos contratos, pois estabelece a possibilidade de que normas regulamentares possam definir o percentual a ser deferido, como cláusulas obrigatórias para eles. Deve ser anotado que, nas hipóteses em que a União não seja parte contratante, deve ser-lhe assegurada a participação nos benefícios, na forma de regulamento específico.

9.5.2.3.1 Benefícios

A Lei estabeleceu uma relação de benefícios que, legalmente, devem resultar da concessão de acesso à Diversidade Biológica e ao conhecimento tradicional associado. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo, desenvolvido a partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, podem ser, dentre outros, os seguintes: i) divisão de lucros; ii) pagamento de *royalties*; iii) acesso e transferência de tecnologias; iv) licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e v) capacitação de recursos humanos.

Não há qualquer obrigatoriedade legal de que todos os benefícios sejam conferidos simultaneamente, assim como também não há obrigatoriedade legal de que os benefícios sejam os contidos na norma legal. O artigo 25 tem, claramente, caráter exemplificativo. Qualquer benefício estabelecido livremente entre as partes contratantes é válido e legal. O importante é que, após a celebração do contrato, haja uma melhoria concreta auferida por aquele que cede o acesso à diversidade biológica. Não se desconhece, contudo, que o próprio conceito de melhoria é passível de críticas diversas. Aqui, como de resto em qualquer relação contratual equânime, necessário se faz que haja benefícios recíprocos.

O artigo 26 estabeleceu a regra de que a exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de *royalties* obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. Essa norma, evidentemente, só é aplicável no caso de o acesso ser concedido a empresa sediada no Brasil, pois dificilmente será aplicável a empresas sediadas no exterior.

Uma modalidade de benefício importante se refere à parcela dos lucros e dos *royalties* devidos à União, resultantes da exploração econômica de processo ou produto desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, bem como o valor das multas e indenizações. O montante constituído por tais valores será destinado: i) ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797/1989; ii) ao Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923/1932; e iii) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo Decreto-lei nº 719/1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172/1991. Tais recursos devem ser utilizados exclusivamente na conservação da diversidade biológica, incluindo a recuperação, criação e manutenção de bancos depositários, no fomento à pesquisa científica, no desenvolvimento tecnológico associado ao patrimônio genético e na capacitação de recursos humanos associados ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao uso e à conservação do patrimônio genético.

9.5.2.4 Cláusulas contratuais cogentes

O legislador determinou de forma bastante positiva que os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios devem ser escritos de forma bastante objetiva, bem como conter determinadas cláusulas legais. A primeira delas é indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de um lado, o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária.

O artigo 28 estabelece que no Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios devem constar, dentre outras, as seguintes cláusulas essenciais que disponham sobre: i) objeto, seus elementos, quantificação da amostra e uso pretendido; ii) prazo de duração; iii) forma de repartição justa e equitativa de benefícios e, quando for o caso, acesso à tecnologia e transferência de tecnologia; iv) direitos e responsabilidades das partes; v) direito de propriedade intelectual; vi) rescisão; vii) penalidades; viii) foro no Brasil.

Cláusulas essenciais são aquelas sem as quais o contrato pode ser nulo ou anulável. Portanto, é extremamente importante que elas sejam observadas, sob pena de que o contrato resulte em letra morta. Estabelece o parágrafo único do artigo 28 que: “quando a União for parte, o contrato referido no caput deste artigo reger-se-á pelo regime jurídico de direito público”.

O parágrafo único do artigo 28, em minha opinião, é um elemento extremamente complicador para que a União possa intervir como parte em Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, isso porque o legislador determinou que tais contratos são de direito público. Ora, em tal condição,

os mencionados contratos devem ser regidos pela Lei nº 8.666/1993. Ante os estritos termos da norma legal, *data venia*, não vejo como afastar o procedimento licitatório da lavratura dos contratos de que ora falamos, *ainda que não seja com a adoção da modalidade de dispensa de licitação*.

A MProv deveria ter estabelecido um procedimento legal a ser utilizado quando da celebração dos contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, respeitando as especificidades do caso. Os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios serão submetidos a registro no Conselho de Gestão e só terão eficácia após sua anuência. A não observância dos preceitos legais cogentes gera a nulidade de pleno direito dos contratos celebrados.

9.5.2.4.1 Processo administrativo

Um dos pontos de maior destaque do Decreto nº 5.459/2005 é o fato de que ele estabeleceu um processo administrativo para a imposição de sanções àqueles que violarem as normas de proteção ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, assegurando-se aos particulares a ampla defesa e o contraditório. Aqui é preciso chamar a atenção para o fato de que as determinações contidas na Lei nº 9.784/1999, que rege o processo administrativo perante a administração federal, são plenamente aplicáveis.

§ 4º POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE

9.6 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE

O Decreto nº 4.339/2002, *institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade*. Tal decreto merece atenção, pois é a primeira vez, em toda a legislação de proteção à diversidade biológica e ao meio ambiente, que se estabelece uma *política nacional* por decreto. Na verdade, o decreto que ora se comenta deveria ser uma lei; tal, no entanto, não foi possível. Esse fato gerou o impasse que propiciou tratar de matéria tão significativa por meio de um decreto.

A PNB tem como objetivos geral a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Do conjunto dos objetivos traçados podemos identificar que a PNB busca a conservação da diversidade biológica e não a preservação da variabilidade das espécies. Isso implica que a política adotada pelo país tem em vista o manejo e utilização das espécies existentes sob a jurisdição nacional. Desnecessário dizer que o centro do objetivo da política estabelecida é o ser humano, pois a própria norma determina um objetivo geral de promoção de forma integrada da conservação da “biodiversidade” e da “utilização sustentável de seus componentes”. Tais objetivos, conforme se verá, são contraditados pelos princípios da Política Nacional da Biodiversidade, que, salvo melhor juízo, são extremamente confusos e equívocos.

Os princípios e diretrizes da PNB formam um conjunto bastante confuso e pouco claro, pois misturam elementos de direito internacional com declarações de princípios quanto ao direito interno, bem como inovam em relação à própria CDB, como se pode ver pela leitura do Preâmbulo da mencionada Convenção. Exemplo de inovação em relação à CDB é o definido pelo *Princípio I*, que dispõe: “*a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo respeito independentemente de seu valor para o homem ou potencial para uso humano*”. Em realidade, a CDB não reconhece um valor intrínseco da diversidade biológica, independentemente de seu valor para o ser humano; muito ao contrário, todo o conjunto de normas contido na CDB está firmemente construído sobre o valor da diversidade biológica como um instrumento de desenvolvimento econômico capaz de aliviar o sofrimento e a pobreza de países que, embora ricos em diversidade biológica, carecem de recursos econômicos para explorá-la adequadamente. É, igualmente, curioso que o decreto faça uma declaração sobre a obrigatoriedade de países desenvolvidos aportarem recursos para a utilização da diversidade biológica brasileira (!) (“Princípio IV – a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são uma preocupação comum à humanidade, mas com responsabilidades diferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às tecnologias pertinentes para atender às necessidades dos países em desenvolvimento”).

O Princípio V limita-se a ser uma reprodução desnecessária do *caput* do artigo 225 da CF, o mesmo se diga em relação ao Princípio X que é uma reprodução do inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF. Outro aspecto extremamente lamentável da principiologia é o rarefeito domínio de uma terminologia básica, e universalmente aceita, no que se refere ao conceito de conservação e utilização sustentável de recursos (“Princípio XVI – a gestão dos ecossistemas deve buscar o equilíbrio apropriado entre a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, e os ecossistemas devem ser administrados dentro dos limites de seu funcionamento. Conservação e utilização sustentável são expressões sinônimas e implicam administração (*rectius*: manejo) dentro dos limites de seu funcionamento que é o reconhecimento da capacidade de suporte”).

O outro princípio que poderia ser classificado como de natureza antropológica é o Princípio XI, que declara que o homem faz parte da natureza e está presente nos diferentes ecossistemas brasileiros há mais de dez mil anos, e todos estes ecossistemas foram e estão sendo alterados por ele em maior ou menor escala. Trata-se, evidentemente, de uma obviedade que reconhece que o Ser Humano, para a sua sobrevivência, necessita alterar o meio ambiente, pois, em qualquer uma de suas múltiplas atividades, consome recursos ambientais e naturais e, portanto, altera os ecossistemas dos quais retira os elementos para a sua reprodução. Aliás, o “reconhecimento” estabelecido pelo Princípio XI serve como antessala para o Princípio XIV, que afirma “[o] valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco, incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético.”

Veja-se que, passadas as declarações bombásticas, o decreto “caiu na real” e foi paulatinamente reconhecendo o importante papel econômico da proteção da diversidade biológica (“Princípio XVII – os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto econômico, objetivando: a) reduzir distorções de mercado que afetam negativamente a biodiversidade; b) promover incentivos para a conservação da biodiversidade e sua utilização sustentável; e c) internalizar custos e benefícios em um dado ecossistema o tanto quanto possível”). Tal “princípio” é claramente contraditório com o Princípio I, que afirma um “valor intrínseco” para a “biodiversidade”. Veja-se que a definição de intrínseco que se encontra contemplada no Princípio XIV, na realidade, implica um valor socialmente reconhecido e, portanto, variável segundo determinadas condições políticas, históricas, econômicas etc. Tal contradição mostra a impossibilidade de estabelecimento de uma política que busca conciliar vertentes contraditórias e, em alguns casos, antagônicas, levando a uma confusão teórica extremamente nociva para o estabelecimento de uma política de acesso à diversidade biológica que possa redundar em efetivo progresso para o nosso país, tema constante do Princípio XV (“Princípio XV – a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade devem contribuir para o desenvolvimento econômico e social e para a erradicação da pobreza”). O Princípio VIII, de maneira inexplicável, admite que, mesmo em caso de risco sério e irreversível para o meio ambiente, o Poder Público limite-se a aumentar custos para evitar a degradação (!), *in verbis*: “Onde exista evidência científica consistente de risco sério e irreversível à diversidade biológica, o Poder Público determinará medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental.” Com todo o respeito que os formuladores da PNB merecem, na hipótese de haverem os riscos mencionados no princípio ora comentado, a medida adequada é impedir a atividade, jamais estabelecer “medidas eficazes em termos de custo”, como proposto no princípio. O que há, conforme confirmado em outro princípio (“Princípio IX – a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo da poluição, com o devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais”), é uma inadequada compreensão da natureza econômica do princípio do poluidor pagador.

9.6.1 Princípios referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados

Tendo em vista as peculiaridades referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica, a Política Nacional da Biodiversidade estabeleceu um subconjunto de princípios diretamente direcionados para o tema. Assim é que os mencionados princípios dispõem: *XII – a manutenção da diversidade cultural nacional é importante para pluralidade de valores na sociedade em relação à biodiversidade, sendo que os povos indígenas, os quilombolas e as outras comunidades locais desempenham um papel importante na conservação e na utilização sustentável da biodiversidade brasileira; XIII – as ações relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade deverão transcorrer com consentimento prévio informado dos povos indígenas, dos quilombolas e das outras comunidades locais.*

9.7 DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE

O número 4 do Anexo ao Decreto nº 4.339/2002 estabelece as seguintes diretrizes a serem observadas na implantação da PNB i) estabelecimento de cooperação com outras nações, diretamente ou, quando necessário, mediante acordos e organizações internacionais competentes, no que respeita a áreas além da jurisdição nacional, em particular nas áreas de fronteira, na Antártida, no alto-mar e nos grandes fundos marinhos e em relação a espécies migratórias, e em outros assuntos de mútuo interesse, para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica; ii) o esforço nacional de conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica devem ser integrados em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes de forma complementar e harmônica; iii) investimentos substanciais são necessários para conservar a diversidade biológica, dos quais resultarão, conseqüentemente, benefícios ambientais, econômicos e sociais; iv) é vital prevenir, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica; v) a sustentabilidade da utilização de componentes da biodiversidade deve ser determinada do ponto de vista econômico, social e ambiental, especialmente quanto à manutenção da biodiversidade; vi) a gestão dos ecossistemas deve ser descentralizada ao nível apropriado e os gestores de ecossistemas devem considerar os efeitos atuais e potenciais de suas atividades sobre os ecossistemas vizinhos e outros; vii) a gestão dos ecossistemas deve ser implementada nas escalas espaciais e temporais apropriadas e os objetivos para o gerenciamento de ecossistemas devem ser estabelecidos a longo prazo, reconhecendo que mudanças são inevitáveis; viii) a gestão dos ecossistemas deve se concentrar nas estruturas, nos processos e nos relacionamentos funcionais dentro dos ecossistemas, usar práticas gerenciais adaptativas e assegurar a cooperação intersetorial; ix) criar condições para permitir o acesso aos recursos genéticos e para a utilização ambientalmente saudável destes por outros países que sejam Partes Contratantes da CDB, evitando-se a imposição de restrições contrárias aos objetivos da Convenção.

9.8 COMPONENTES DA POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE

À semelhança de um projeto acadêmico financiado pelo Banco Mundial, ou outro organismo internacional de crédito, a PNB é constituída por “componentes”. Tais “componentes”, em número de 7 (sete), nada mais são do que os objetivos do que seria uma política nacional de diversidade biológica. Diante dos termos quase caóticos do decreto que está sendo analisado, não há um conjunto de objetivos a serem atingidos pela implementação de políticas públicas sobre o tema. O que é lamentável sob todos os aspectos. Veja-se que os componentes devem ser tratados “como os eixos temáticos” da PNB. Afinal, quais são os “componentes” da Política Nacional da Biodiversidade? Passemos a eles: Componente 1 – Conhecimento da Biodiversidade: congrega diretrizes voltadas à geração, sistematização e disponibilização de informações que permitam conhecer os componentes da biodiversidade do país e que apoiem a gestão da biodiversidade, bem como diretrizes relacionadas à produção de inventários, à realização de pesquisas ecológicas e à realização de pesquisas sobre conhecimentos tradicionais; Componente 2 – Conservação da Biodiversidade: engloba diretrizes destinadas à conservação *in situ* e *ex situ* de variabilidade genética, de ecossistemas, incluindo os serviços ambientais, e de espécies, particularmente daquelas ameaçadas ou com potencial econômico, bem como diretrizes para implementação de instrumentos econômicos e tecnológicos em prol da conservação da biodiversidade; Componente 3 – Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade: reúne diretrizes para a utilização sustentável da biodiversidade e da biotecnologia, incluindo o fortalecimento da gestão pública, o estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos, e o apoio a práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, considerando não apenas o valor econômico, mas também os valores sociais e culturais da biodiversidade; Componente 4 – Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos sobre a Biodiversidade: engloba diretrizes para fortalecer os sistemas de monitoramento, de avaliação, de prevenção e de mitigação de impactos sobre a biodiversidade, bem como para promover a recuperação de ecossistemas degradados e de componentes da biodiversidade sobre-explotados; Componente 5 – Acesso aos Recursos Genéticos e aos Conhecimentos Tradicionais Associados e Repartição de Benefícios: alinha diretrizes que promovam o acesso controlado, com vistas à agregação de valor mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, e a distribuição dos benefícios gerados pela utilização dos recursos genéticos, dos componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados, de modo que sejam compartilhados, de forma justa e equitativa, com a sociedade brasileira e, inclusive, com os povos indígenas, com os quilombolas e com outras comunidades locais; Componente 6 – Educação, Sensibilização Pública, Informação e Divulgação sobre Biodiversidade: define diretrizes para a educação e sensibilização pública e para a gestão e divulgação de informações sobre biodiversidade, com a promoção da participação da sociedade, inclusive dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, no respeito à conservação da biodiversidade, à utilização sustentável de seus componentes e à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado à biodiversidade; Componente 7 – Fortalecimento Jurídico e Institucional para a Gestão da Biodiversidade: sintetiza os meios de implementação da Política; apresenta diretrizes para o fortalecimento da infraestrutura, para a formação e fixação de recursos humanos, para o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia, para o estímulo à criação de mecanismos de financiamento, para o fortalecimento do marco legal, para a integração de políticas públicas e para a cooperação internacional.

- 1 MOTTA, Ronaldo Seroa. Desafios ambientais da economia brasileira. IPEA: textos para discussão nº 509, 1997. Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br/pub/td/t.pdf>>.
- 2 *Segundo pesquisa crescimento das favelas é galopante, O Estado de S. Paulo*, 14/12/2001.
- 3 Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- 4 **Artigo 1º**
 1. A presente convenção aplica-se:
 - a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;
 - b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.
 2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos a que se aplicam as disposições da presente Convenção.
 3. A utilização do termo “povos” na presente Convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.
- 5 Disponível em: <<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/QUADRO-GERAL.pdf>>. Acesso em: 7 out. 2015.
- 6 Disponível em: <<http://www.kraho.org/projetos.html>>.
- 7 ANTUNES, Paulo de Bessa. A Necessária Proteção do Conhecimento Tradicional, *Gazeta Mercantil*.
- 8 A palavra *povos*, no contexto do documento, não tem o significado que lhe é atribuído no Direito Internacional.
- 9 Fonte: UNEP/CDB/COP 19, 1996, p. 11. Disponível em: <<http://www.humboldt.org.co/biocomercio/html/dpi-biodiv.htm>>.
- 10 *Então pode ser visto que o conhecimento tinha algo de sagrado envolvendo-o. Os curandeiros tradicionais, por exemplo, não eram feiticeiros ou feiticeiras, mas praticantes da medicina que tratavam seus pacientes por meio da psicanálise.*
- 11 Disponível em: <<http://www2.mre.gov.br/dai/meamb.htm>>. Acesso em: 20 ago. 2011.
- 12 Disponível em: <<https://concordia.itamaraty.gov.br/pesquisa-avancada>>. Acesso em: 23 nov. 2018
- 13 Atualmente, a CDB é formada por 196 partes, contando com 168 assinaturas (7/10/2015). Disponível em: <<http://www.cbd.int/convention/parties/list/>>. Acesso em: 7 out. 2015.
- 14 *Milhares de anos de dependência direta das plantas exigiu a revisão e perpetuação de um corpo significativo de informação referente ao valor de espécies individuais e seus habitats.*
- 15 Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zonas-umidas-convencao-de-ramsar/s%C3%ADtios-ramsar.html>>. Acesso em: 23 nov. 2018
- 16 O Brasil é signatário da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição, promulgada pelo Decreto nº 77.374, de 1º/4/1976.

A VEGETAÇÃO NATIVA E SUA PROTEÇÃO LEGAL

A conservação das florestas é uma das questões fundamentais para a humanidade e as demais formas de vida; consequentemente, é um tema essencial do direito ambiental. Indiscutivelmente, a matéria remete-nos às graves questões da biodiversidade e do aquecimento global, assim como aos problemas relacionados ao desenvolvimento econômico dos países em vias de desenvolvimento. Nos dias atuais, as questões florestais desempenham um relevante papel dentre os temas da agenda internacional. Yves Bergeron et al. (BARRÈRE, 1992. p. 81). Assim sintetizaram o importante papel desempenhado pelas florestas,

As relações entre a imperiosa necessidade de desenvolvimento econômico e o avanço sobre as áreas florestais é evidente; igualmente evidentes são as relações entre o avanço sobre as florestas e a pobreza, tanto é assim que o Banco Mundial aponta que a área ocupada por florestas nos países em desenvolvimento foi reduzida à metade em aproximadamente um século (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 10). Esse quadro, contudo, não é recente. Ao contrário, a pressão humana sobre as florestas e seus diversos recursos é tão antiga quanto a própria existência dos seres humanos. Como observa Perlin (1992, p. 31): “Os sumerianos, que estabeleceram a primeira sociedade urbana há mais de quatro mil anos no Crescente Fértil, usavam o signo cuneiforme ‘gis’, que determinava os tipos de madeiras e objetos de madeira, em palavras que significavam ‘projeto [de um edifício]’, ‘modelo’ e ‘arquétipo’. ‘Architékton’, que na Grécia clássica chegou a significar ‘chefe de obras’ e da qual nós derivamos a palavra ‘arquiteto’, significa literalmente ‘principal trabalhador em madeira’.”

O próprio Banco Mundial reconhece o papel econômico desempenhado pela exploração das florestas e, igualmente, reconhece o negativo papel que desempenhou em matéria de desenvolvimento florestal, pois grande parte de seus financiamentos voltados para a utilização econômica das florestas serviu de agente indutor da destruição e degradação florestal e ambiental. Desde a sua criação, o Banco Mundial financiou 94 projetos florestais. Esses projetos custaram 2,5 bilhões de dólares americanos. A proteção ambiental, contudo, não fazia parte das preocupações deles. Um dos exemplos mais gritantes de política equivocada é o do chamado Polonoeste em Rondônia, Brasil. Com financiamento do Banco Mundial, foi promovida uma grande devastação ambiental e gerados inúmeros problemas sociais de difícil solução. O projeto de colonização iniciado em 1982 foi considerado um fracasso pelo presidente do Banco Mundial, Barber Conable, em 1987 (MIKESELL e WILLIAMS, 1992. p. 165). Foi a partir da constatação de políticas ambientalmente desastrosas e da própria pressão da opinião pública internacional que o Banco Mundial assumiu o compromisso de não conceder financiamentos para projetos florestais sem que rigorosos estudos de impacto ambiental fossem realizados previamente. Devido ao importantíssimo papel desempenhado pelo Banco Mundial como agente de fomento econômico, é de se esperar que o seu comprometimento seja efetivo e verdadeiro, o que trará significativas alterações no quadro global de proteção dos recursos ambientais.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, dedicou boa parte de seus trabalhos ao exame da situação das florestas mundiais. As questões florestais estão contempladas no item 9 da agenda 21. A Rio 92 estabeleceu diversos princípios para o manejo das florestas. As florestas são um dos principais temas do direito ambiental, como já foi sublinhado, em razão da importância que têm para a preservação da vida em todas as suas formas. A matéria florestal, no ordenamento jurídico brasileiro, está contemplada em dois instrumentos legais básicos (i) a Lei nº 12.651, de maio de 2012 e (ii) na Lei 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) e, devido ao fato de que a competência para a proteção das florestas é concorrente, a diversas normas estaduais. Especificamente em relação às florestas nacionais, aplica-se a (iii) Lei nº 11.284/2006.

Pierre Merlin (1988, p.304) e outros definem *floresta* como “*formação vegetal espontânea ou produzida, caracterizada pela predominância de árvores e pela fraca iluminação do sol. Por extensão, uma vasta superfície [...] plantada de árvores em formação cerrada*”.

O documento elaborado pela UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza; pelo PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; e pelo WWF – Fundo Mundial para o Meio Ambiente, *Cuidando do Planeta Terra* (1991, p. 136), classifica as florestas em:

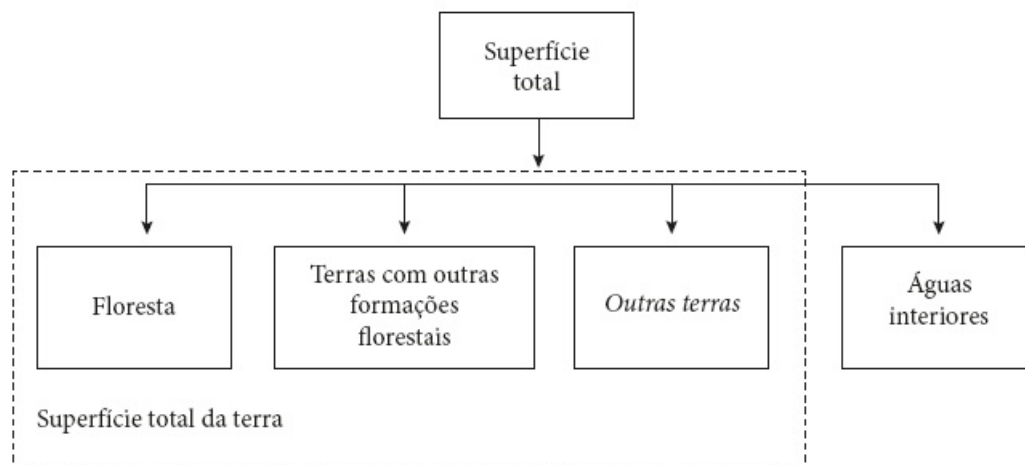
Florestas		
Natural	Modificada	Plantada
Floresta onde as árvores jamais foram cortadas ou não foram abatidas durante os últimos 250 anos.	Florestas onde as árvores têm sido abatidas nos últimos 250 anos para a obtenção de madeira ou para o cultivo migratório; e que retêm a cobertura de árvores ou arbustos nativos. O crescimento de novas árvores pode derivar inteiramente da recuperação natural ou ser suplementado por “plantação de enriquecimento”. A floresta modificada inclui muitas variações, desde florestas que têm sido seletivamente abatidas até aquelas que foram enormemente modificadas.	Floresta na qual todas, ou a maioria das árvores (51% ou mais da biomassa da madeira), foram plantadas ou semeadas.

Merece menção a importante classificação da cobertura de terra feita pela FAO:¹

Tipo de cobertura de terra	Definição

Superfície total	Superfície total (do país) incluindo a superfície coberta pelos corpos de águas interiores, porém excluindo as águas territoriais de alto-mar.
Floresta	Terras com outras formações florestais Outras terras Águas interiores Terra com uma cobertura de copa (ou seu grau equivalente de espessura) com mais de 10 por cento da área e uma superfície superior a 0,5 hectares (ha). As árvores deveriam atingir uma altura mínima de 5 metros (m) em sua <i>madurez in situ</i> . <i>Podem ser formações florestais densas, onde árvores de diversos tamanhos e formações florestais arbustivas cobrem grande parte do terreno; ou formações florestais abertas, com uma cobertura de vegetação contínua onde a cobertura de copa ultrapassa 10 por cento. Dentro da categoria de floresta estão incluídos todos os talhões naturais jovens e todas as plantações estabelecidas para fins florestais, que ainda devem crescer até atingir uma densidade de copa de 10 por cento ou uma altura de 5 m. Também se incluem nela as áreas que normalmente formam parte da floresta, mas que estão temporariamente sem árvores, por causa da intervenção do homem ou por causas naturais, mas que eventualmente voltarão a transformar-se em floresta. Inclui: viveiros florestais e hortos porta-sementes que formam parte integral da floresta; caminhos florestais, trilhas, guarda-fogos e outras pequenas áreas abertas; florestas que integram parques nacionais, reservas da natureza e outras áreas protegidas que sejam de interesse espiritual, cultural, histórico ou científico; corta-ventos e faixas de proteção formadas com</i>
Floresta	árvores, com uma superfície superior a 0,5 ha e uma largura mais de 20 m; plantações utilizadas principalmente para fins florestais, incluindo as plantações de seringueira e talhões de alcornoque; Exclui: Terras utilizadas primordialmente para práticas agrícolas.
Terras com outras formações florestais	Estas abrangem terras onde a cobertura de copa (ou seu grau de espessura equivalente) tenha entre 5 e 10 por cento de árvores capazes de atingir uma altura de 5 m em sua <i>madurez in situ</i> ; ou terras com uma cobertura de copa com mais de 10 por cento (ou seu grau de espessura equivalente) onde as árvores não são capazes de atingir uma altura de 5 m em sua <i>madurez in situ</i> (por ex. <i>árvores anãs ou diminuídas</i>); ou aquelas onde a cobertura arbustiva abrange mais de 10 por cento
Outras terras	Terras não classificadas como florestais ou terras com outras formações florestais especificadas acima. Inclui terras agrícolas, pradarias naturais e artificiais, terrenos com construções, terras improdutivas etc.
Águas interiores	Superfície ocupada por rios, lagos e represas importantes.

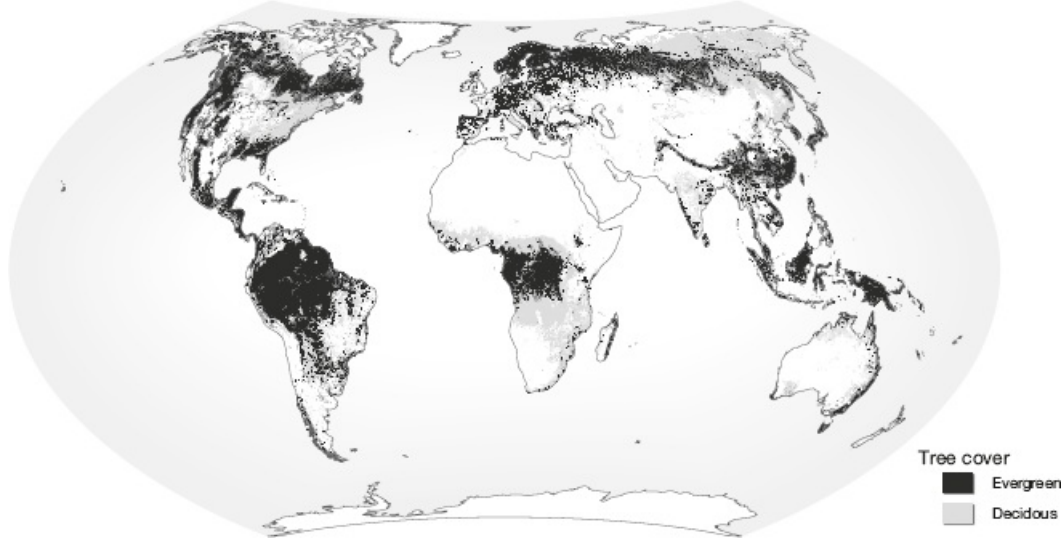
Classificação da terra, nível geral



Obs.: A definição de floresta aplicada no FRA 2000 requer uma mínima cobertura florestal e ser muito diferente da definição legal de floresta (ou terra com outras formações).

O Direito brasileiro, embora não reconheça as florestas tal como definidas no documento internacional que acaba de ser mencionado, estabelece que, na forma do art. 2º da Lei nº 12.651/2012 as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, sendo os direitos exercidos conforme as limitações legalmente previstas.

10.1 OS DIVERSOS TIPOS DE FLORESTA



10.1.1 Floresta boreal

Os países que possuem as maiores coberturas florestais do mundo são:

- Rússia;
- Brasil;
- Canadá;
- Estados Unidos; e
- Zaire.

Embora as florestas tropicais sejam o maior repositório de biodiversidade existente na Terra, pois abrigam mais da metade das espécies vegetais e animais da terra, elas não chegam a ocupar mais do que 7% do planeta. A principal floresta mundial, em extensão, é a floresta boreal, que ocupa uma área de mais de 6 bilhões de hectares, isto é, uma área equivalente a 25% da superfície terrestre que ainda permanece coberta de matas. O Canadá e a Rússia possuem aproximadamente 70% desse tipo de floresta. As florestas boreais situam-se no extremo norte da Europa, da Ásia e da América do Norte. Da mesma forma que as florestas tropicais, a floresta boreal está passando por um grave risco de sobrevivência. Tal situação, entretanto, tem ocupado pouco espaço na mídia. É preciso observar que a pressão para a preservação das florestas boreais não se faz com a mesma intensidade que a efetivada em relação às florestas tropicais. Parece evidente que, em grande parte, tal fato é devido à circunstância de que são os países do chamado primeiro mundo os detentores das enormes áreas de floresta boreal. A atividade econômica nas florestas boreais é extremamente grande e os países que as detêm não parecem dispostos a abrandar o ritmo de sua exploração. Além da atividade madeireira, há um risco que tem sido negligenciado, mas que não pode ser relegado a segundo plano, que é aquele decorrente de testes e depósitos de artefatos nucleares, naufrágios de submarinos nucleares no oceano Ártico etc. Muitos são os fatores que ameaçam as florestas boreais. Ela está submetida a ameaças diretas e indiretas. As ameaças diretas são as mesmas que se encontram presentes em todas as áreas florestais, ou seja, a pressão para a extração de madeira e recursos econômicos ocasionada por uma incorreta compreensão da utilização das florestas. A expansão urbana desordenada é, também, um fator de ameaça à floresta boreal. É na Rússia que se encontram as maiores ameaças à floresta boreal, pois o fim do regime soviético e o estabelecimento de uma economia completamente desorganizada têm feito pressão para que a madeira seja explorada de forma não sustentável. Em verdade, o corte de madeiras nas terras siberianas tem sido feito em ritmo avassalador e, evidentemente, todavia exige uma resposta da comunidade internacional. Questões estratégicas, têm feito com que os problemas ora referidos fiquem em segundo plano na agenda internacional.

10.1.2 Floresta temperada

As florestas temperadas são as maiores vítimas da poluição industrial. O fato de a maioria dessas florestas estar situada na região mais industrializada do planeta faz com que elas sejam vítimas de uma grande pressão urbana, vítimas das chuvas ácidas e outras mazelas da civilização industrial.

Roger Dajoz (1983, p. 390) fornece-nos uma breve síntese dos ecossistemas abrangidos pelas florestas temperadas: “A fauna nelas é muito diversificada. Os vertebrados arborícolas são os esquilos e os leirões entre os mamíferos, os pica-paus e as picanilhas entre as aves. Os mamíferos terrestres são veados, corços e javalis; os roedores (ratos, arganazes) são numerosos e caçados pelos pequenos carnívoros (raposas, doninhas). O urso encontra-se em raros lugares. As aves insetívoras e as aves de rapina noturnas são abundantes [...]”.

A Europa praticamente não possui mais florestas naturais. Ao longo dos vários séculos em que esse continente tem sido habitado por seres humanos, o seu ecossistema vem sendo fortemente modificado. A Europa é, sem dúvida, um dos melhores exemplos da construção social da natureza, isto é, de uma natureza que foi intensamente modificada pelo homem, de forma a atender aos seus objetivos políticos e econômicos. Na América do Norte, embora com menor intensidade, a modificação das florestas produzidas pela atividade humana, em especial após o encontro de civilizações que se deu com a chegada dos europeus ao continente americano, também foi espetacular. É de se ressaltar que os povos aborígenes, antes da chegada do colonizador europeu, exerciam atividades capazes de modificar a feição natural de seus territórios. A diferença fundamental se dá na escala e no manejo da modificação humana. A diferença é, essencialmente, cultural, de concepção acerca do valor das florestas e seus recursos em cada civilização.

A situação economicamente privilegiada dos países situados na zona temperada tem propiciado que suas florestas apresentem um relativo crescimento nos últimos anos. Assim é porque os governos dos países ricos têm patrocinado projetos de reflorestamento, e o aumento da consciência preservacionista entre a população tem servido como freio à derrubada de matas. Tal conjunto de ações, contudo, não tem conseguido recuperar todas as áreas que, secularmente, vêm sendo degradadas e destruídas. O reflorestamento, em geral, é feito com poucas espécies da flora e, consequentemente, a recomposição do ecossistema nunca é perfeita. Há, também, o gravíssimo perigo de que se realize um reflorestamento uniforme e de pequeno ou nenhum valor ecológico.

O fato é que, enquanto se constata uma ampliação das áreas florestais nos países ricos, paralelamente, amplia-se a pressão sobre as florestas tropicais em busca da madeira e de outros recursos. A ética da ampliação dos espaços florestais dos países do primeiro mundo não pode se dissociar de uma ação profunda em defesa da floresta tropical. Defesa essa que não pode passar ao largo da modificação dos hábitos de consumo do primeiro mundo, pois é para atender tais hábitos que, em grande parte, é patrocinada a destruição das florestas tropicais. Pouco importa que se amplie a floresta na Europa ou no Japão se, na Malásia, por exemplo, a destruição das florestas segue em um ritmo alucinante. Essa ética também não pode se dissociar da premente necessidade de uma nova ordem econômica internacional que seja capaz de alterar o perfil da distribuição internacional de riqueza entre as nações.

10.1.3 Floresta tropical

É, sem dúvida, a principal depositária mundial da biodiversidade. As florestas tropicais encontram-se situadas nas regiões mais pobres do mundo e, por isso, são ecossistemas extremamente pressionados; a pressão sobre as florestas tropicais tem várias origens. Independentemente da ordem de sua importância, podemos destacar: i) pressão migratória exercida por populações marginalizadas; ii) pressão exercida pela criação de gado; iii) pressão exercida por madeiras; iv) pressão exercida pelo narcotráfico; v) pressão exercida pelo tráfico de animais; vi) pressão exercida por conflitos armados; vii) pressão exercida pela necessidade de divisas fortes; viii) pressão exercida pelo garimpo de metais preciosos.

O elevado nível de pobreza encontrado nos países do “terceiro mundo” tem gerado um movimento de concentração urbana e de expansão de fronteira agrícola que vem efetuando uma destruição constante das florestas tropicais. O caso brasileiro é bastante exemplificativo quanto ao particular.

A Mata Atlântica, que cobria a costa brasileira desde Santa Catarina ao Rio Grande do Norte, é hoje um arremedo daquilo que foi, pois foi reduzida a 7% de seu tamanho quando da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A extração de madeira para a exportação, a destruição de florestas para a implantação de regiões agrícolas e a construção de cidades foram fatais para a Mata Atlântica. Esse processo, com pequenas alterações, tem se verificado em todas as regiões tropicais.

A falta de equidade nas relações de comércio internacional tem feito com que determinadas regiões de floresta tropical estejam, praticamente, condenadas à morte, se o sistema internacional de trocas não for modificado rapidamente. A floresta tropical da Malásia é o melhor e mais triste exemplo:

As florestas de Bornéu estão encolhendo ano a ano. O alto preço da madeira e o uso da exploração mecanizada estão causando destruição em um ritmo assustador. É muito provável que dentro de poucas décadas todas as áreas acessíveis da selva tenham sido abatidas pelos madeireiros (MACKINNON, 1988, p. 26).

Não pode deixar de ser mencionado, *en passant*, que, além do problema especificamente florestal, existem outros problemas mais graves, que são aqueles vivenciados pelos milhões de pessoas que habitam no interior das florestas e, rapidamente, estão perdendo a sua característica de povos tradicionais, com gravíssimas consequências culturais e sociais.

10.1.3.1 Florestas brasileiras

O Brasil possui vastas áreas de florestas, e tais florestas se constituem em muitos ecossistemas bastante diversos entre si e portadores de grande riqueza genética e de alta complexidade ecológica. A Constituição Brasileira, em seu artigo 225, § 4º, estabeleceu que a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica constituem patrimônio nacional. Dessa forma, a Constituição deu um destaque especial para tais ecossistemas. Isso não quer dizer, contudo, que as mencionadas florestas gozem de um *status* jurídico superior aos demais ecossistemas florestais. Houve, ao que parece, uma supervalorização de alguns modelos em relação aos demais. Tal supervalorização é muito mais retórica do que efetiva. Aliás, seria profundamente incoerente estabelecer uma superproteção jurídica para a Mata Atlântica e abandonar-se, por exemplo, os cerrados. O próprio § 4º do artigo 225, como é facilmente constatável, preocupou-se mais com o meio ambiente litorâneo do que com o conjunto do meio ambiente nacional. Justifica-se o fato em razão de que a imensa maioria da população brasileira habita a área costeira e que, portanto, a pressão maior se faça sentir no litoral.

Apesar de todos os problemas acima mencionados, a CF é um instrumento jurídico capaz de assegurar, pelo menos em tese, a proteção jurídica de que as nossas florestas necessitam.

Os principais ecossistemas florestais brasileiros são: (i) Floresta Amazônica; (ii) Cerrado; (iii) Mata Atlântica; e (iv) Caatinga. Cada um exerce uma função de suma importância e, sem dúvida, não se pode estabelecer uma escala hierárquica entre eles. Em razão de sua importância internacional, passo a fazer uma singela análise das questões referentes à Floresta Amazônica.

A Amazônia brasileira possui cerca de 40% da floresta tropical remanescente em todo o mundo. A quantidade total de espécies vegetais ou animais existentes na Amazônia é incalculável. Assim como as demais parcelas da Floresta Amazônica, a Amazônia brasileira é vítima de pressões extremamente severas sobre os seus ecossistemas. O Brasil é o país que possui mais florestas tropicais e, com certeza, um maior número de espécies animais e vegetais do que qualquer outro país do mundo. Essa circunstância impõe ao nosso país uma grave responsabilidade internacional com a preservação da Hileia Amazônica; por outro lado, a comunidade internacional, igualmente, deve assumir suas responsabilidades para com o Brasil e cooperar construtivamente de forma que o país possa ter acesso aos recursos financeiros e à tecnologia que serão capazes de assegurar a sobrevivência da Amazônia, pois não haverá preservação da Amazônia sem preços internacionais justos e boas condições de vida para o amazônida.

A vasta extensão da Amazônia brasileira ainda não foi ferida de morte. Essa é uma importante constatação feita por analistas internacionais independentes, e que merece registro: “[...] Com aproximadamente 90% de suas matas ainda em pé, a Amazônia brasileira permanece relativamente intacta tanto em face de padrões nacionais quanto internacionais” (RYAN, 1992, p. 29).

Na Amazônia brasileira, a expansão econômica da década de 1970 do século XX, simbolizada pela construção da Transamazônica, acarretou uma acelerada destruição da floresta para a criação de gado e mesmo para áreas de garimpo. É importante observar que os governos de então foram os fundamentais e mais importantes indutores do processo, pois, através de toda uma série de incentivos fiscais, estimularam a destruição ambiental.

Tem havido uma diminuição no ritmo de destruição da Floresta Amazônica brasileira (MYERS, 1992, p. 350) em razão do fim de incentivos fiscais para projetos agropecuários na região amazônica. O problema das queimadas não se encontra solucionado, embora o seu ritmo seja menor do que nas décadas de 1970 ou 1980.

O correto manejo da Floresta Amazônica pode ser um importantíssimo fator de desenvolvimento para o Brasil e para os demais países da região amazônica. Necessário se faz que a sociedade brasileira, contudo, tenha um projeto de longo prazo para o manejo amazônico e não se deixe seduzir por ganhos fáceis e imediatos que levarão, inexoravelmente, à destruição daquele que é, provavelmente, o maior tesouro biológico do mundo.

Historicamente, têm sido atribuídas qualidades ambientais à Amazônia que ela, evidentemente, não possui. A primeira dessas qualidades é a de “pulmão” do mundo. A concepção é equivocada e tem se prestado a manipulações políticas. Certamente que é muito importante o papel desempenhado pela Amazônia dentro do contexto ecológico internacional. Entretanto, sabemos que a maior parte do oxigênio que respiramos é produzida pelos oceanos.

10.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO FLORESTAL

10.2.1 Lei nº 12.651/2012

Com a revogação da Lei nº 4.771/1965, a principal norma federal para a proteção das florestas é a Lei nº 12.651/2012. Embora possuindo inegável valor na vida econômica nacional foi apenas em 1934 que as florestas mereceram menção constitucional.

É importante observar que, nos termos do § 3º do artigo 5º da Carta de 34, a competência da União para legislar sobre florestas não excluía a possibilidade de os Estados legislar complementares e supletivamente. Aos Estados foi atribuída a competência para, atendendo às peculiaridades locais, suprir a legislação federal naquilo que ela fosse insuficiente ou lacunosa. Os Estados, contudo, estavam impedidos de dispensar as exigências da legislação federal.

A Carta outorgada de 1937 estabelecia, em seu artigo 16, XIV, que era competência privativa da União legislar sobre os bens do domínio federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua exploração. Por sua vez, o artigo 18, alínea a, determinava que independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta as regule, quanto a riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia

hidroelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração.

A Constituição democrática de 1946, em seu artigo 5º, XV, alínea I, dispunha competir à União legislar sobre as riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca. De acordo com o artigo 6º da CF de 1946, os Estados eram dotados de competência legislativa supletiva ou complementar, conforme o caso. Tanto na Constituição de 1967, como na de 1969, o artigo 8º, XVII, alínea h, dispunha que competia à União legislar sobre: jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas; caça e pesca.

10.2.2 Constituição de 1988

A Constituição de 1988 é a que deu tratamento mais abrangente à matéria, merecendo destaque o § 4º do artigo 225, que estabelece que a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica são parte do *patrimônio nacional*. Há, ainda, uma menção expressa à flora no inciso VII do § 1º do artigo 225. O conceito de patrimônio expresso no texto Constitucional não pode e não deve ser confundido com o conceito de patrimônio existente no Direito Civil. Manuel Andrade (1983, p. 205), com a sua habitual proficiência, assim expõe a doutrina tradicional:

Num primeiro e mais amplo sentido, o patrimônio vem a ser [...] o conjunto de relações jurídicas (direitos e obrigações) com valor econômico, isto é, avaliável em dinheiro, de que é sujeito ativo e passivo uma dada pessoa – singular ou coletiva (patrimônio global). Numa fórmula mais sintética mas pouco explícita, podemos defini-lo como o resultado jurídico-econômico da atividade de uma pessoa.

Evidentemente que as florestas e demais formas de vegetação que se encontram no interior do território brasileiro podem integrar o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, bem como podem, obviamente, integrar o patrimônio jurídico de pessoas naturais. O comando constitucional não teve o condão de proceder a desapropriações dos bens que se encontravam no interior do patrimônio de pessoas distintas da União. Não, os bens florestais permaneceram sob a titularidade que ostentavam antes da promulgação da CF de 1988. A norma constitucional foi estabelecida com o sentido de realçar a proteção legal dos bens instituídos como patrimônio nacional e reafirmar o dever de todos no sentido de atuar visando à preservação ambiental, como forma de assegurar o exercício do direito previsto no artigo 225, *caput*. Houve, com efeito, uma reafirmação da Soberania e do domínio eminente do Estado sobre os bens existentes em seu território.

Quanto à competência legislativa relativa às florestas, o artigo 24, VI, da CF, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna³, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Na forma do artigo 24, § 1º, compete à União legislar sobre normas gerais. Quanto às competências administrativas, conforme determina o artigo 23, VII, da CF existe competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para preservar as florestas, a fauna e a flora.

No atual quadro jurídico constitucional brasileiro, portanto, a Lei nº 12.651/2012 tem a natureza de lei geral, limitando-se a estabelecer os princípios gerais que devem ser observados pelos Estados em sua legislação.

10.2.3 Política florestal dos Estados

Como já foi visto, no atual regime constitucional, a Lei nº 12.651/2012 é uma lei cuja finalidade é o estabelecimento de princípios legislativos gerais que devem ser observados pelos Estados-Membros da federação, podendo cada um deles estabelecer sua própria política florestal.

10.2.4 O regime jurídico das florestas

O artigo 2º da Lei nº 12.651/2012 estabelece que: as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Sendo certo que na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições legais são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869/1973 – CPC (revogada), sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/1981, e das sanções administrativas, civis e penais. E mais: as obrigações previstas na lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

O direito revogado se utilizava da expressão “uso nocivo da propriedade”, a qual foi substituída por “uso irregular da propriedade” que, em essência, tem o mesmo conteúdo. Vilson Rodrigues Alves (1992, p. 295) assim trata o assunto: “*A nocividade é a lesão, ou a probabilidade – de acordo com a iminência e não com a eventualidade do dano – da lesão à segurança pessoal, à segurança material, ao sossego...*”

Ao leitor atento não passará despercebido que, na singeleza da redação do texto legal, diversas questões de alta indagação jurídica estão contidas. Como já foi dito acima, a primeira questão suscitada deriva da circunstância de que a Lei nº 12.651/2012 *não define o conceito jurídico normativo de floresta*. A segunda questão é a que diz respeito aos *bens de interesse comum a todos os habitantes do País*. E, por fim, temos o fato de que o parágrafo único estabelece que as ações ou omissões contrárias às disposições do Novo Código Florestal constituem-se em uso irregular da propriedade. A Lei nº 12.651/2012, *ipso iure*, estabelece um regime especial de propriedade especificamente voltado para as florestas e demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade para as terras que revestem. Passemos ao exame das questões anteriormente apontadas.

Merece ser ressaltado que a Lei nº 12.651/2012 não está voltada, apenas, para a proteção das florestas. Os bens jurídicos protegidos são (i) as florestas; (ii) as demais formas de vegetação úteis às terras que revestem; (iii) as terras propriamente ditas; (iv) os recursos hídricos; e (v) diversidade biológica.

10.2.4.1 O conceito jurídico de floresta

Etimologicamente, segundo o *Dicionário Aurélio*,⁴ *floresta* pode ser definida da seguinte forma:

Verbetes: floresta [Do fr. ant. forest, hoje forêt, com infl. de flor.] S. f.

1. *Formação arbórea densa, na qual as copas se tocam; mata.*
2. *Grande quantidade de coisas muito juntas; aglomerado, conglomerado; mata.*
3. *Fig. Confusão, labirinto, dedalo.*

Para o *Webster's Dictionary* (s.d., 718), o vocábulo *forest* significa, principalmente, “*uma grande extensão de terra coberta com árvores e arbustos; uma mata*”. Em francês, o *Dicionário Robert* (1988, p. 440) define *forêt* da seguinte forma: “*vasta extensão de terreno coberta de árvores; conjunto destas árvores*. Na língua de Dante, floresta é definida pelo Zingarelli (1983, p. 750) como: “*grande extensão de terreno coberta de árvores*”.

O *Dictionnaire de l'Urbanisme et de l'Aménagement* (MARLIN e CHOUAY, 1988, p. 304), em seu verbete sobre florestas, assim as define:

formação vegetal espontânea ou manejada, caracterizada pela predominância de árvores e pela fraca iluminação do solo. Por extensão, um vasto espaço (muitas centenas de hectares) plantado de árvores em formação cerrada [...]. Biologicamente, a floresta se apresenta como um tipo de organismo no qual se encontram associadas as ações do clima, do solo, do subsolo, dos vegetais, dos animais e mesmo do homem. O delicado equilíbrio de seus componentes é rompido, se um dentre eles assumir um papel muito importante.

O já tantas vezes citado Osny Duarte Pereira (1950, p. 148), relembrando a definição de Guyot, afirma: “*É um imóvel plantado de árvores, onde a madeira (material lenhoso ou outras substâncias tiradas da árvore, tais como resinas e casca) constitui a produção principal.*” Embora não se possa afirmar que a produção principal de toda e qualquer floresta seja a de madeira, a definição que acaba de ser apresentada tem uma grande importância, à medida que, diferentemente das que foram anteriormente apresentadas, coloca em destaque o papel econômico desempenhado pela floresta. Esse é um aspecto fundamental, pois somente através de uma adequada compreensão das funções econômicas desempenhadas pelas florestas é que, efetivamente, assegura-se a sua preservação. O manejo sustentado das florestas é, sem dúvida alguma, um dos principais objetivos de toda a legislação de proteção florestal. É preciso que se tenha claro que o atual nível de desenvolvimento tecnológico não possibilita o encerramento das atividades madeireiras. A utilização econômica das florestas é, ainda, uma das atividades econômicas que não podem ser dispensadas.

Os três conceitos apresentados acima, por serem mais precisos, permitem que se possa ter um maior grau de segurança jurídica no trato com as diversas questões florestais. Na literatura jurídica brasileira, Hely Lopes Meirelles (1993, p. 476) foi o autor que primeiro perquiriu um conceito próprio de floresta. Para ele, floresta é “*a forma de vegetação, natural ou plantada, constituída por um grande número de árvores, com o mínimo espaçamento entre si*”.

O Direito comparado, tal qual o Direito brasileiro, não fornece muitas definições normativas de floresta, embora sejam inúmeras as leis voltadas para o tema. Um bom exemplo do que vem de ser dito é a legislação florestal federal norte-americana, que, embora extensa, não define o conceito jurídico de floresta. Michel Prieur (1991, p. 279), preocupado com o problema da definição jurídica de florestas, afirma: “*nenhuma definição jurídica de floresta pode ser dada*”.

Portanto, o Direito deverá se socorrer dos conceitos originários da biologia, da ecologia, da agronomia e de tantas quantas sejam as ciências voltadas para o estudo das florestas. Qualquer procedimento diferente tornaria absolutamente impossível a aplicação da legislação florestal. Há que se fazer uma *juridicização* de conceitos científicos. Evidentemente que as ciências dedicadas ao estudo das florestas não podem trabalhar com uma definição *genérica* de floresta. Ao contrário, cada uma das diferentes modalidades de floresta terá sua própria definição. O Cerrado não será definido nos mesmos termos em que é definida a Floresta Amazônica, sendo esta diferente da Mata Atlântica. Enfim, o aplicador da lei florestal deverá ter presente qual o tipo de floresta que, no caso concreto, está necessitando de proteção legal.

Não há, portanto, um conceito jurídico genérico que seja capaz de definir as florestas como um todo. Existem, contudo, conceitos jurídicos específicos para cada tipo de floresta concretamente determinado. Tais conceitos serão vistos adiante.

10.2.5 Áreas de preservação permanente pelo efeito da Lei nº 12.651/2012

O primeiro grande grupo de espaços territoriais tratado pela Lei nº 12.651/2012 é o constituído pelas áreas de preservação permanente por imposição legal. Este grupo foi estabelecido pelo artigo 4º sendo assim formado, em zonas rurais ou urbanas: i) faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.

E, também, as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas. Ainda as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto no § 1º; bem como as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;— as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive. À relação acima acrescentem-se as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; os manguezais, em toda a sua extensão; as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. Também são de preservação permanente em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

Importante ressaltar que o previsto no inciso III do artigo 4º^s deve ser aplicada conforme definido na licença ambiental. Não se exigirá faixa de áreas de preservação permanente nos entornos das acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.

Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água perene e intermitente excluídos os efêmeros, que delimitem as áreas da faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada pelos respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo inciso I do artigo 4º.

A relação é longa, merecendo exame minucioso, principalmente em razão de uma terminologia técnica que é empregada e que é pouco conhecida pelos juristas. O primeiro ponto que merece ser observado de preservação permanente é o espaço territorial, coberto ou não por vegetação nativa, ou seja: coberto ou não por flora nativa. Flora é, evidentemente, um conceito mais amplo que o de floresta. O Dicionário Aurélio assim define o vocábulo *flora*:

Verbetes: flora [De Flora, deusa das flores.] S. f. 1. Bot. O conjunto das espécies vegetais de uma determinada localidade: 2. Conjunto de plantas que servem para determinado fim: [Dim. irreg.: flórlula].

Sendo certo que a Lei nº 12.651/2012 é legislação (norma) geral e que, por força constitucional, limita-se a estabelecer normas gerais, os Estados poderão estabelecer, em sua legislação própria, outros critérios para que se definam locais nos quais a flora será considerada de preservação permanente. Tal situação já foi objeto de discussão judicial e de decisão que considerou constitucional lei do Estado do Rio Grande do Sul voltada para a preservação das florestas (ANTUNES, 1995, p. 90).

a) Reconhecimento judicial da legislação estadual sobre florestas

O pleno exercício da competência suplementar dos Estados-Membros da Federação tem sido reconhecido pelos tribunais de nosso país, conforme nos dá mostra o seguinte aresto do STJ: *Conflito de Normas – Inexistência – Norma Especial que se Compatibiliza com Preceito Geral Contido na Norma Federal. O disposto no artigo 19, § 1º, da Lei Estadual nº 10.561/91 não conflita com o preceito contido no artigo 21, parágrafo único, do Código Florestal. Trata-se aquela de lei especial, compatível com o tratamento genérico da norma federal. Recurso improvido* (REsp nº 246.531/MG. 1ª Turma. Data da decisão: 13/3/2001. DJU 11/6/2001. p. 108. Relator Garcia Vieira).

O TRF da 4ª Região, com jurisdição sobre o Estado do Paraná, já teve a oportunidade de examinar o tema, tendo decidido que: *Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Florestas. Plano de Exploração. Código Florestal. Competência. Regulação. Constitucionalidade. Lei Estadual nº 7.989/85. Art. 8º, inc. 17, da CR/1988. Remessa Oficial Provida. A Constituição (art. 8º, inc. 17) está respeitada pelo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) quando este explicita que a preservação das florestas pode ser objeto também de legislação local, suprimindo eventuais omissões. 2. Sentença Reformada* (REO 8904198534. 2ª Turma. DJU 1º/4/1992. p. 7679, relator(a) JUIZ OSVALDO ALVAREZ). *Constitucional. Direito Florestal. A preservação das florestas deixou de ser objeto de competência legislativa privativa da União Federal a partir da CF de 1988, que deste modo recepcionou a Lei Estadual nº 7.989, de 1985. Apelação e Remessa “Ex Officio”*

b) Proteção das encostas e das elevações

Outro aspecto importante que se pode observar na instituição das florestas de preservação permanente pelo *só efeito* do Código é o voltado para a proteção das encostas e das elevações. A lei fala em proteção das florestas e demais formas de vegetação que se encontrem no topo dos morros, montes, montanhas e serras.

Morro é definido pelo *Dicionário Geológico-Geomorfológico* (GUERRA, 1993, p. 299) como: “Monte pouco elevado, cuja altitude é aproximadamente de 100 a 200 metros. Termo descritivo para o geomorfológico e muito usado pelos topógrafos. “Monte, para o mesmo dicionário (p. 298), é definido como: “Grande elevação do terreno, sem se considerar a sua origem. Apenas se leva em conta o aspecto topográfico, ao descrever-se a região onde aparecem este tipo de acidente de relevo. O termo genérico de monte se aplica, de ordinário, às elevações que surgem na paisagem como formas isoladas [...]”.

Já montanha (GUERRA, 1993, p. 297) é: “Grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros e constituída por um grande agrupamento de morros [...]”.

O conceito normativo de *morro* ou *monte* é estabelecido pela Resolução Conama nº 4/1985, e é o seguinte: “*Morro ou monte – elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre 50 (cinquenta) e 300 (trezentos) metros e encostas com declividade superior a 30% (aproximadamente 17º) na linha de maior declividade; o termo “monte” se aplica, de ordinário, à elevação isolada na paisagem.*”

O conceito normativo de *montanha* está estabelecido pela alínea *i* do artigo 2º da Resolução Conama nº 4/85, nos seguintes termos: “*Grande elevação do terreno, com cota em relação à base superior a 300 (trezentos) metros e frequentemente formada por agrupamentos de morros.*”

A proteção legal estende-se às encostas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declividade. Aqui, mais uma vez, é necessário que nos socorramos com o vocabulário técnico, indispensável para a compreensão da norma jurídica. Assim sendo, *encosta* (GUERRA, 1993, p. 148) é “[*d]eclive nos flancos de um morro, de uma colina ou de uma serra. São estes declives de quando em vez interrompidos em sua continuidade, apresentando rupturas (rupturas de declives), cuja origem pode estar ligada à erosão diferencial, à estrutura, às diferenciações de meteorização, às variações de níveis de base etc.*”

Protegidos estão, também, as bordas de chapadas e tabuleiros. *Chapada* (GUERRA, 1993, p. 90) é definida da seguinte maneira: “[*d]enominação usada no Brasil para as grandes superfícies, por vezes horizontais, e a mais de 600 metros de altitude que aparecem na Região Centro-Oeste do Brasil [...]*.” Por sua vez, *tabuleiro* (GUERRA, 1993, p. 404) é forma topográfica de terreno que se assemelha a planaltos, terminando geralmente de forma abrupta [...]. O conceito normativo de *tabuleiro* ou *chapada* está contido na alínea *q* do artigo 2º, XI da Resolução nº 303/2002, do Conama.⁶

A finalidade do estabelecimento de flora de preservação permanente nos locais acima mencionados é a de evitar a erosão dos terrenos e a destruição dos solos, preservando a integridade dos acidentes geográficos. Evitam-se, igualmente, as enchentes e inundações nos terrenos mais baixos, uma vez que a vegetação ajuda a fixar a água da chuva no solo e funciona como uma verdadeira barreira natural.

As florestas e demais formas de vegetação acima tipificadas são consideradas de preservação permanente e foram instituídas como reservas ecológicas (Resolução Conama nº 4/85, art. 2º, IV/VI, confirmado na Resolução 303/2002). Deve ser observado que a Lei nº 12.651/2012 não trouxe conceitos normativos dos vocábulos acima mencionados, portanto, permanecem válidas as definições estabelecidas pelo Conama até que venham a ser substituídas, se for o caso. Cabe crítica, pois reserva ecológica é conceito que não se encontra presente na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

c) Proteção das restingas

O simples efeito da vigência da Lei nº 12.651/2012 fez com que as restingas, sempre que fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangue, fossem juridicamente elevadas à condição de vegetação de preservação permanente que nos termos da lei é depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.

A definição científica é mais completa; assim é que, para o *Dicionário Geológico* (GUERRA, 1993, p. 372), as restingas foram definidas como: “*Ilha alongada, faixa ou língua de areia, depositada paralelamente ao litoral, graças ao dinamismo destrutivo e construtivo das águas oceânicas*”.

Nos termos do artigo 3º, XIII da Lei nº 12.651/2012, manguezal é o [e]cossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluviomarina, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina.

O estabelecimento das restingas como áreas de preservação permanente é fundamental, pois os manguezais são essenciais à formação da vida marinha e se constituem em abrigo e fonte de alimentação para os seres marinhos. Outras importantes funções são exercidas pelos manguezais. Eugene P. Odum (1988, p. 551), sinteticamente, define a função desempenhada por estes importantes ecossistemas:

Davis, que estudou a ecologia dos manguezais, pensa que eles são importantes, não só para ampliar as costas e formar ilhas, mas também para proteger aquelas da excessiva erosão que, de outro modo, se produziria com as violentas tempestades tropicais. Tem se demonstrado que os detritos de folhas dos mangais constituem para os seres aquáticos uma das principais fontes de energia.

Por estarem situados no litoral ou em áreas sujeitas à influência das marés, os manguezais são bens pertencentes ao patrimônio da União, em razão do que determina o artigo 20 da CF, em seus incisos IV e VII. Como é do conhecimento do leitor, os terrenos de marinha têm a sua definição legal estabelecida pelo artigo 2º do Decreto-lei nº 9.760/1946.

10.2.6 Florestas de Preservação Permanente por interesse social

O artigo 6º da Lei nº 12.651/2012 estabelece que o Chefe do poder Executivo, qualquer que seja o nível federativo, poderá declarar áreas de interesse social para os fins de proteção ambiental, conforme *verbis*:

Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:

I – conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha;

II – proteger as restingas ou veredas;

III – proteger várzeas;

IV – abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;

V – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;

VI – formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

VII – assegurar condições de bem-estar público;

VIII – auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.

IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

10.2.7 Áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente (normas de regularização de ilícitos passados)

A Lei nº 12.651/2012 com o objetivo regularizar e acomodar situações pretéritas estabeleceu um conjunto de disposições relativas às áreas de preservação permanente que não vinham sendo respeitadas pelos proprietários ou possuidores antes de 22 de julho de 2008, data da edição do Decreto nº 6.514/2008 que define as infrações administrativas praticadas em desfavor do meio ambiente.

De acordo com a norma, admite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, “exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, conforme alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.727/2012. O artigo 61-A da Lei definiu uma “escadinha” de recomposição:

Recomposição	
Área do Imóvel Rural	Recomposição
Até 1 Módulo Fiscal	5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água
1 módulo fiscal até 2 módulos fiscais	8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito regular, independente da largura do curso d’água
Maior do que 2 módulos fiscais até 4 módulos fiscais	15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d’água
Maiores do que 4 módulos fiscais	20 (vinte) metros, e máximo 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular
Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de	5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal
	8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais
Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de	5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal
	8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais
	15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais
	30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais
Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de	30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais
	50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais

A recomposição acima mencionada poderá ser feita com a adoção, conjunta ou isolada, dos seguintes métodos: (i) condução de regeneração natural de espécies nativas; (ii) plantio de espécies nativas; (iii) plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas; (iv) plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do *caput* do art. 3º da Lei nº 12.651/2012.

Outra regra de transição é a estabelecida pelo artigo 61-B mediante a qual os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, tiveram assegurado que a exigência de recomposição, nos termos da Lei nº 12.651/2012, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: (i) 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; e (ii) 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais.

No que tange aos assentamentos do Programa de Reforma Agrária a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo ou no entorno de cursos d’água, lagos e lagoas naturais deve observar as exigências estabelecidas no art. 61-A, respeitados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Incra.

Na caso implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.(artigo 5º do Código Florestal).

Nas áreas rurais consolidadas nos locais constantes dos incisos V, VIII, IX e X do art. 4º da Lei nº 12.651/2012 será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. O pastoreio extensivo, contudo, deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo. A manutenção das culturas e da infraestrutura, nas hipóteses mencionadas, condiciona-se à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água, conforme definido pelos órgãos de assistência técnica rural. Permite-se, nas Áreas de Preservação Permanente, previstas no inciso VIII do art. 4º da Lei nº 12.651/2012, dos imóveis rurais de até 4 (quatro) módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas as situações de risco de vida.

10.3 O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM ÁREAS FLORESTADAS

10.3.1 Contorno jurídico da propriedade florestal

O primeiro ponto para a correta compreensão do problema é uma questão que vem sendo amplamente esquecida: aquela que define os contornos jurídicos da propriedade florestal. Esta, evidentemente, não se confunde com a propriedade tal como estabelecida no CC brasileiro, pois a Lei nº 12.561/2012 é lei especial e, portanto, os seus institutos, quando dispuserem inteiramente sobre uma matéria, devem prevalecer sobre o direito comum, no caso o direito civil. Fato é que, após a CF de 1988, a subordinação do direito civil aos princípios constitucionais está mais clara e, obviamente, o direito civil ganhou o *status* de ser “mais um ramo do direito”, perdendo a condição de “o direito”, como tende a vê-lo o pensamento jurídico do século XIX. Neste sentido, o “direito comum” é o próprio direito constitucional.

Pelo teor do *caput* do artigo 2º, fica claro que a propriedade florestal está regida pelas limitações gerais existentes em nosso ordenamento jurídico, isto é, respeitando as normas de vizinhança, as normas constitucionais referentes ao desempenho da função social da propriedade, tal como definidas pela CF que, no caso florestal, manifestam-se pelos institutos próprios que se encontram presentes na Lei de florestas. A propriedade florestal, portanto, é uma propriedade especial, que não se confunde com a propriedade em geral, que, diante das diferentes regras jurídicas que lhe são aplicáveis, nada mais é do que uma hipótese teórica, pois o que existe na atualidade jurídica são “propriedades”. Quanto ao tema, aliás, há que se registrar que, desde o momento em que a Constituição definiu que a propriedade deve desempenhar a sua função social para que, legitimamente, possa continuar a ser exercida, não se pode mais – com fundamento jurídico – pensar no direito de propriedade com base no CC, eis que este espelha, pura e simplesmente, o aspecto referente à propriedade civil que não é mais uma cláusula geral, pois este papel é deferido à propriedade tal qual esta se encontra regrada pela CF, ou seja, se existente uma “propriedade em geral”, esta é aquela subordinada ao conceito jurídico constitucional de função social. A propriedade florestal, tal como definida por nosso ordenamento jurídico, possui quatro limitações principais que são: i) as Áreas de Preservação Permanente; ii) Áreas de uso restrito; iii) as Reservas Legais; iv) corte somente com autorização do Poder Público.

Tanto umas como as outras integram o próprio conteúdo do direito de propriedade florestal. A propriedade florestal que não possua, por exemplo, a Reserva Legal, é juridicamente inexistente como tal, pois destituída de um dos elementos essenciais para a sua caracterização legal e constitucional. Não há, portanto, limitações ao direito de propriedade, mas a definição de como esse instituto jurídico é perante o Código Florestal. A ideia de limitação ao direito de propriedade é errônea, pois em sua essência admite o conceito dos anos 1800 de que a propriedade é um direito ilimitado. Em realidade, inexistem limitações ao direito de propriedade. O que existe é que o direito de propriedade somente tem existência dentro de um determinado contexto constitucional e somente é exercido no interior desse mesmo contexto. A função social da propriedade, tal como exercida na própria Constituição, não possui conteúdo concreto. A Função Social, na hipótese florestal, é inteiramente diferente da função social exercida pela propriedade imobiliária urbana, por exemplo.

Deve ser ressaltado que o Código Florestal, em sua redação primitiva, já considerava que as *ações e omissões contrárias* às suas disposições são consideradas *uso nocivo da propriedade*. Há que se considerar que o *uso nocivo da propriedade*, tal como estabelecido pelo Código Florestal, não se confunde com o uso nocivo da propriedade que impera no direito de vizinhança, embora seja dele derivado. Isso não quer dizer, entretanto, que alguns dos institutos presentes neste último não possam ser utilizados pelos intérpretes da Lei de Florestas. A utilização do instituto deve ser compreendida no referencial histórico no qual ele foi inserido no Código e *interpretado* de acordo com a *época presente*, ou seja, ele foi plenamente recepcionado pela Carta de 88, que possui um amplo leque de normas jurídicas com o objetivo de proteção ambiental. A aplicação pós-88, portanto, somente pode ser feita com o objetivo de *retirar do uso nocivo da propriedade* presente no Código Florestal as mais amplas consequências para proteger o meio ambiente e, por conseguinte, os “vizinhos” da propriedade, no caso os habitantes do país. Noção essa que está plenamente compatível com o *caput* do artigo 225 da CF, que estabelece o “direito de todos” ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A *vizinhança prejudicada* não se limita àqueles que estão próximos, mas se alarga a todos os que sofrem as consequências da inexistência de florestas. Isso se torna claro na medida em que o próprio artigo 1º do Código estabeleceu a noção de interesse dos habitantes do país como um dos alicerces da *forma* de propriedade que está sendo examinada. O conceito de *uso irregular* não é substancialmente diverso daquele outrora existente.

O atual estágio de desenvolvimento do Direito brasileiro, com todo o arcabouço jurídico constitucional de proteção ao meio ambiente, não só permite, mas, principalmente, impõe, que a interpretação dos institutos previstos na Lei nº 12.651/2012 se faça de forma cada vez mais voltada para a proteção do patrimônio florestal como um conjunto de bens que, simultaneamente, interessa à coletividade e ao titular do domínio. Ambos deverão agir em coordenação, de forma que a ação de um não descaracterize o direito do outro. *O proprietário deve respeitar os “direitos” da coletividade, utilizando-a dentro dos preceitos estabelecidos pela lei de proteção da vegetação.* Julgo importante reafirmar o meu ponto de vista no sentido de que a Reserva Legal não é propriamente uma “limitação” ao direito de propriedade, mas, ao contrário, um dos elementos constitutivos do próprio direito de propriedade florestal e, como tal, condição de sua existência. Finalmente, penso que a Reserva Legal é uma manifestação do domínio eminente e que, em tal condição, não pode ser desrespeitado pelo proprietário, privado ou público, ou por quem quer que seja. Aliás, há reconhecimento legal expresso no sentido da natureza *propter rem* da reserva legal, como já foi exaustivamente visto neste livro.

10.3.2 As limitações decorrentes da condição de bem de interesse comum

Conforme já foi visto acima, a Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 2º, *caput*, considera que as florestas e demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade para as terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País. O artigo 170 da CF determina que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados vários princípios dentre os quais a defesa do meio ambiente. Ressalte-se que a Lei nº 12.651/2012 em seu artigo 70 dispõe que além de suas determinações e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na forma da Lei nº 9.985/2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá i) proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies; ii) declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de portasementes; iii) estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos florestais.

10.3.3 Reserva (florestal) legal

10.3.3.1 Conceito normativo de reserva (florestal) legal

A Reserva (Florestal) Legal é um elemento importante da propriedade florestal, que é constituído por uma área, cujo percentual da propriedade total é definido em lei, variando conforme as peculiares condições ecológicas, em cada uma das regiões geopolíticas do país e que não pode ser utilizada economicamente de forma tradicional, isto é, destinar-se à produção de madeira ou de outra *commodity* que dependa da derrubada das árvores em pé. O conceito normativo de reserva (florestal) legal é fornecido pelo artigo 3º, III da Lei nº 12.651/2012, sendo a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

A área a ser mantida como reserva (florestal) legal depende da região geográfica do país e do bioma nos quais esteja inserida a propriedade florestal em questão. Ela não se confunde com as áreas de preservação permanente que possuem outra destinação legal e ecológica. Averte-se que, muito embora não se possa confundir a reserva (florestal) legal com as áreas de preservação permanente, há possibilidade de que o proprietário faça a adição de uma com a outra para fins de cumprimento da norma legal.

Há possibilidade legal de *cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que sejam observadas as seguintes condições: a) não sejam convertidas novas áreas par o uso alternativo do solo; b) a área a ser computada esteja conservada ou em processo de*

recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e c) o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

A reserva (florestal) legal deverá ser averbada no Registro de Imóveis para conhecimento de terceiros, a sua não averbação, no entanto, não exonera o proprietário da obrigação de respeitá-la, pois ela não se constitui pela averbação, que é um simples registro que declara a existência da Reserva Legal e que não a constitui, de forma alguma.

A Reserva Legal caracteriza-se por ser necessária ao uso sustentável dos recursos naturais. Como se sabe, uso sustentável dos recursos naturais pode ser descrito como i) aquele que assegura a reprodução continuada dos atributos ecológicos da área explorada, tanto em seus aspectos de flora como de fauna. É sustentável o uso que não subtraia das gerações futuras o desfrute da flora e da fauna, em níveis compatíveis com a utilização presente; ii) recursos naturais são os elementos da flora e da fauna utilizáveis economicamente como fatores essenciais para o ciclo produtivo de riquezas e sem os quais a atividade econômica não pode ser desenvolvida.

10.3.3.2 A reserva legal como interesse dos habitantes do país

A Lei nº 12.651/2012, utilizando-se e mantendo a já tradicional e primorosa noção de “interesse comum a todos os habitantes do País”, que à época de sua criação foi bastante inovador, pois definiu uma situação jurídica bastante interessante e criativa, capaz de dar legitimidade ativa a qualquer cidadão em defesa das florestas. Como é óbvio, o *interesse* estabelecido não se constitui em direito de propriedade ou mesmo desapropriação. Ele é a coincidência da vontade da coletividade, e de cada indivíduo, em ter uma condição de vida digna e sob condições ambientais que, sob o regime de 88, chamaríamos de “ecologicamente equilibrada”, com a norma legal que o assegura, ao menos parcialmente, ao estabelecer a obrigação da manutenção da Reserva Legal. Observe-se que a MProv nº 1.956-53/2000, ainda que mantendo o *caput* do artigo 1º da Lei nº 4.771/1965 (revogada), foi responsável por profundas alterações no artigo, vez que laborou a introdução de inúmeros parágrafos, muitos deles contraditórios e capazes de esvaziar o próprio conteúdo do conceito jurídico da Reserva Legal. Entretanto, a modificação legal efetuada pela MProv, no particular, teve o mérito de propiciar a criação de um conjunto de conceitos normativos que, à época, era perfeitamente apto a possibilitar ao intérprete um caminho seguro para a adequada aplicação do revogado código florestal.

A Lei nº 12.651/2012 foi bastante minuciosa ao disciplinar a reserva (florestal) legal, conforme consta do artigo 12 e seguintes. Pelas normas legais, resta claro que foi estabelecida uma obrigação geral, e em tal condição não onerosa, que determina que, em todo imóvel rural, deve ser assegurado que uma parcela da área deve ser retirada da atividade econômica e mantida como *reserva legal*. A onerosidade da restrição somente se justifica quando ela é instituída de tal forma que apenas um, ou poucos proprietários, deve arcar com o encargo estabelecido sobre a sua propriedade. A reserva legal atinge todos os proprietários de áreas florestadas, ou mesmo que tenham sido desflorestadas. Ela nada mais é do que a aplicação concreta de um princípio geral estabelecido pelo artigo 2º da Lei nº 12.651/2012, que determina serem as florestas um interesse comum de todos os habitantes do País. A abrangência da norma contida no novo código florestal é extremamente ampla, pois ela oferece uma tutela que, *verbi gratia*, é mais alargada do que aquela fornecida pela Ação Popular, que somente contempla o cidadão. No caso presente, até mesmo o estrangeiro é sujeito ativo de tal interesse, condição que lhe assegura o acesso aos remédios jurídicos aptos a tornar efetiva a sua defesa. A norma é sábia, vez que o bem tutelado é a sanidade das terras, a higidez do ar, enfim, aquilo que o texto constitucional de 1988 chamou como “meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Merece ser ressaltado, ademais, que o *caput* do artigo 225 da CF acolhe expressamente o artigo 2º da Lei nº 12.651/2012, pois estendeu o direito ao meio ambiente equilibrado a “todos”; veja-se que aqui, em tese, qualquer indivíduo que esteja em território brasileiro, ainda que não o habite em caráter permanente, é sujeito ativo do aludido direito. O revogado código florestal (Lei nº 4.771/1965), elaborado sob a égide da Constituição de 1946 – e com ela inteiramente compatível – realizou uma verdadeira antecipação da norma que seria insculpida na Constituição de 1988, embora se utilizasse da noção de interesse e não da de direito, como hodiernamente consta de nossa Lei Maior (ANTUNES, 2015). É preciso ter clareza que o conceito que se encontrava presente no revogado código florestal (Lei nº 4.771/1965) e, também, na Lei nº 12.651/2012, é extremamente importante, haja vista que ele mesmo materializa o princípio da coordenação entre sociedade e indivíduo. Por ele, a sociedade não se sobrepõe ao indivíduo e, muito menos, este se sobrepõe àquela. Pelo princípio da coordenação, não existem sacrifícios individuais em benefício da coletividade, nem sacrifícios coletivos em benefício do indivíduo. Uns e outros têm igualmente repartidos as cargas e os benefícios ambientais. Em última análise, o *interesse* estabelecido pelo artigo 2º da Lei nº 12.651/2012 é, também, do proprietário das terras que, no particular é, concomitantemente, sujeito passivo e ativo, pois se beneficia, na condição de habitante do País – todos no texto do artigo 225 –, dos benefícios decorrentes da reserva (florestal) legal. A legitimação de qualquer “habitante do país” para a propositura de ações ambientais visando coibir o mau uso (uso irregular) da propriedade, antes da Carta de 88, decorria da noção de interesse estabelecida pelo artigo 1º da Lei nº 4.771/1965.

É importante frisar que a reserva (florestal) legal não se confunde com áreas de preservação permanente que, uma vez existentes na propriedade, devem ser mantidas intocadas por força dos comandos contidos no artigo 4º da Lei nº 12.651/2012.

10.3.3.3 A reserva (florestal) legal como obrigação e regime de proteção

A reserva (florestal) legal é uma obrigação que recai diretamente sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de sua pessoa ou da forma pela qual tenha adquirido a propriedade; desta forma, ela está umbilicalmente ligada à própria coisa, permanecendo aderida ao bem. O proprietário ou possuidor, para se desonerar da obrigação, necessita, apenas, renunciar à coisa, mediante a utilização de qualquer uma das formas legais aptas para transferir a propriedade. O revogado código florestal (Lei nº 4.771/1965), no particular, não inovou em nosso Direito. Com efeito, o Direito Civil brasileiro desde há muito reconhece obrigações de tal natureza. Um exemplo bastante corriqueiro é aquele presente no antigo artigo 1.197 do CC brasileiro (1916), no CC de 2002 constante do artigo 576; ela também se faz presente em inúmeros institutos jurídicos que regem as relações de vizinhança, conforme bem assinalado por Carlos Alberto Bittar (1990, p. 41), para quem:

Nas obrigações propter rem [...] decorre o vínculo da lei em função de direitos reais, facultando-se a uma pessoa exigir do titular certa prestação, o qual se safa, no entanto, ao despir-se do direito, como nas hipóteses de construção e conservação de marcos divisórios e de tapumes divisórios, em que se impõe aos proprietários a colaboração para a sua edificação ou manutenção; de divisão da coisa comum, em que cada condômino deve colaborar para as despesas de conservação ou de divisão; de pagamento da dívida na hipoteca pelo adquirente do bem, para a sua liberação etc.

O CTN, igualmente, reconhece a existência de obrigações da mesma natureza, conforme deixam ver os seus artigos 130 e 131.

Tanto a obrigação de natureza civil como a de natureza tributária são transmissíveis com o próprio bem (BALEIRO, 1985, p. 482). No caso do revogado código florestal (Lei nº 4.771/1965), não resta dúvida de que a obrigação é de natureza civil e é na legislação civil que a mesma deve ser investigada, inclusive quanto às suas peculiaridades jurídicas mais proeminentes. Ressalte-se, entretanto, que os institutos do Direito civil deverão ser “*lidos*” com os olhos da proteção ambiental e de como ela é tratada em nossa Constituição. É no Direito das Obrigações que o intérprete deve buscar socorro para a adequada compreensão do instituto jurídico em questão.

Efetivamente, a reserva (florestal) legal é uma característica da propriedade florestal que se assemelha a um ônus real que recai sobre o imóvel e que obriga o proprietário e todos aqueles que venham a adquirir tal condição, quaisquer que sejam as circunstâncias. Trata-se de uma obrigação “*in rem*”, “*ob*” ou “*propter rem*”, ou seja, uma obrigação real ou mista (GOMES, 1998, p. 21). Convém lembrar as palavras de Orlando Gomes sobre a matéria, *in verbis*: “[as obrigações reais] Caracterizam-se pela *origem e transmissibilidade automática*. Consideradas em sua origem, verifica-se que provêm da existência de um direito real, impondo-se ao seu titular. Esse cordão umbilical jamais se rompe. Se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo.” O ilustre Professor Orlando Gomes não está solitário em sua concepção, sendo uma das mais abalizadas vozes de uma corrente amplamente majoritária sobre o tema. Apenas para reforçar o argumento, vale trazer à colação a opinião do professor Caio Mário da Silva Pereira (1976, p. 44-45), que é a seguinte:

Mas, se há uma relação jurídico-real, em que se insere, adjeto à faculdade de não ser molestado, o direito a uma prestação específica, este direito pode

dizer-se ad rem, e a obrigação correspondente é propter rem. Não falta quem lhe pretenda atribuir autonomia. Mas parece-nos em vão, pois que o direito que visa a uma prestação certa é de crédito, e a obrigação respectiva é estrita. A obligatio propter rem somente incorpa-se quando é acessória a uma relação jurídico-real ou se objetiva numa prestação devida ao titular do direito real, nesta qualidade (ambulat cum domino). E o equívoco dos que pretendem definir a obrigação propter rem como pessoal é o mesmo dos que lhe negam existência, absorvendo-a na real...

É importante consignar que a discussão teórica acima apresentada encontrou ressonância legislativa e, felizmente, hoje é expressamente o reconhecimento não só da reserva (florestal) legal, bem como das áreas de preservação permanente como obrigação “real”, não remanescendo mais qualquer dúvida em relação à matéria.

10.3.3.3.1 Regime de proteção da reserva (florestal) legal

A Lei nº 12.651/2012 estabeleceu um conjunto de normas estruturando um regime normativo de proteção da reserva (florestal) legal. Definiu-se que a reserva (florestal) legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Contudo, não há proibição de sua exploração econômica, desde que mediante a utilização de manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão ambiental que, no caso, em princípio deverá ser o estadual, observadas as condicionantes do artigo 20 da Lei.

Conforme o disposto no artigo 18, “a área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei”. Far-se-á a inscrição da reserva (florestal) legal no CAR mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo, no caso deverá ser o Executivo estadual. Quando se tratar de posse, a área de reserva (florestal) legal será assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão ambiental, sendo o documento dotado de força de título executivo extrajudicial, o qual deverá contemplar, no mínimo: (i) a localização da área de reserva (florestal) legal; e (ii) as obrigações assumidas pelo possuidor perante o órgão ambiental. O § 4º em disposição discutível determina que o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato”.

10.3.3.3.2 Regime de utilização da reserva (florestal) legal

A reserva (florestal) legal está submetida a regime de utilização controlada e não de intocabilidade, como é o caso das áreas de preservação permanente, como regra. A Lei nº 12.651/2012 admite o manejo, dito sustentável, conforme se depreende do artigo 20 no manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial.”

Conforme o disposto no artigo 21, “é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes”, desde que observados, (i) os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; (ii) a época de maturação dos frutos e sementes; (iii) técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Observe-se que a administração deverá, o quanto antes, regulamentar a utilização das áreas de reserva (florestal) legal, sob pena de impedir o livre exercício do direito de propriedade.

A Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 22, estabelece os critérios que deverão orientar a atividade regulamentar, quando se tratar de utilização comercial quais sejam: (i) não descaracterização da cobertura vegetal e inexistência de prejuízo para a conservação da vegetação nativa da área; (ii) garantia de manutenção da diversidade das espécies; (iii) condução do manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas.

Quando se tratar de manejo sustentável para exploração florestal eventual sem finalidades comerciais, destinado ao consumo no próprio imóvel, é desnecessária a autorização dos órgãos de controle ambiental, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.

Na prática, conforme se percebe do artigo 24, o regime de manejo da reserva (florestal) legal é idêntico ao das demais áreas fora da reserva: “No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e 23”.

- Extinção da reserva (florestal) legal

Dado que a reserva (florestal) legal é atributo de *imóvel rural*, a transformação do uso do solo de rural para urbano tem o condão de extingui-la, observadas determinadas condições. Dessa forma, de acordo com o disposto no artigo 19 da Lei nº 12.651/2012 a inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da CF. Isso significa que, enquanto não ocorrer o parcelamento do solo, a área de reserva (florestal) legal deverá ser mantida pelo proprietário ou posseiro, contudo, a obrigação se extingue concomitantemente com o registro do parcelamento do solo para fins urbanos. Há vista que a lei não estabeleceu restrição, qualquer finalidade urbanística deve ser compreendida como abrangida pelo permissivo legal, desde que observadas as diretrizes do plano diretor do município. A lei não dispôs sobre aqueles municípios que não estejam obrigados a possuir plano diretor, em tais casos, ainda que não exista a obrigação constitucional da existência de plano diretor, é de toda conveniência que o município disponha de lei de uso do solo. Acrescente-se que, na forma do artigo 25, II, as municipalidades estão autorizadas a transformar as áreas de reserva (florestal) legal em *áreas verdes urbanas*. Considere-se que não há qualquer exigência legal no sentido de que as reservas (florestais) legais transformadas em áreas verdes urbanas tenham as mesmas dimensões que ostentavam quando vinculadas aos antigos imóveis rurais. A disposição contida no inciso II do artigo 25 deve ser combinada com aquela contida no inciso III, de forma que os projetos tenham assegurada a existência de áreas verdes, conforme as necessidades tipicamente urbanas.

10.3.3.3.3 Prazos para recomposição da reserva legal

O estabelecimento de prazos legais para que o proprietário – ou mesmo o posseiro – faça respeitar a Reserva Legal e, por força disto, faça o reflorestamento da área degradada, é uma medida que, em minha opinião, é puramente protelatória e de duvidosa constitucionalidade. Ora, se a própria Lei nº 12.651/2012, reconhece, em seu artigo 2º, que existe um *interesse* comunitário de que a propriedade florestal seja explorada *nos termos da própria lei* e, em consequência disto, tenha estabelecido que a inobservância de suas normas se constitui em uso irregular da propriedade e, portanto, em um atentado ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o estabelecimento de prazos para que se cumpra uma determinação legal e constitucional de extrema importância deve ser considerado como medida excepcional e interpretada restritivamente.

10.3.3.3.4 A delimitação, pela autoridade pública, da área a ser preservada

Argumento que, à primeira vista, impressiona é aquele que afirma que a Reserva Legal deve ser delimitada pela autoridade competente e que, na inexistência da ação administrativa, o particular não está obrigado a promover o reflorestamento e a recomposição da reserva (florestal) legal, enquanto a autoridade pública não fizer a referida delimitação. O revogado Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), na redação original do artigo 16, em meu entendimento, não condicionava a ação de reflorestar à existência da norma administrativa específica. Penso que esta seja a conclusão lógica do fato de que à autoridade administrativa foi outorgada a missão de delimitar a extensão da reserva (florestal) legal, *em taxas mínimas*, conforme definido pela lei. Observe-se, ademais, que, se o proprietário não obteve do Poder

Público a delimitação geográfica da área a ser mantida como reserva (florestal) legal e, igualmente, não obteve a definição dos percentuais de sua propriedade que devem ser considerados como reserva (florestal) legal, isto não o desonera da obrigação de manter a reserva (florestal) legal. Ao contrário, ante a omissão da administração – que deverá ser constituída em mora –, o próprio proprietário pode *sponte sua* definir a área e o percentual – respeitado o percentual mínimo – a serem averbados como reserva (florestal) legal. Isso para que não se torne sujeito passivo de uma possível medida judicial com o objetivo de evitar o prosseguimento da utilização danosa da propriedade. Outra conclusão seria totalmente contrária à letra e ao espírito de toda a legislação de proteção ambiental, inclusive das normas constitucionais. A reserva (florestal) legal, por seus atributos ecológicos, não pode deixar de estar presente na propriedade florestal, pois como venho argumentando ao longo deste trabalho, ela é parte da própria propriedade florestal. A delimitação da reserva (florestal) legal, pela autoridade administrativa, é um mero reconhecimento físico, nada mais. *Mutatis mutandi*, a hipótese se assemelha à das terras indígenas, a demarcação administrativa não é constitutiva, mas meramente declaratória.

A questão parece-me extremamente simples. A reserva (florestal) legal é estabelecida por ato do proprietário que determina a sua averbação junto ao Registro de Imóveis. À administração pública compete, única e exclusivamente, verificar a existência de atributos ecológicos nas áreas que deverão ser averbadas pelo proprietário e delimitar-lhes os contornos. É um ato administrativo vinculado, no qual o administrador limita-se a verificar o preenchimento das condições legais. É da própria natureza do ato mencionado a vinculação, pois o sistema constitucional brasileiro inadmitte a intervenção do Estado na propriedade privada de forma discricionária. Caso o ato de delimitação da reserva (florestal) legal fosse um ato administrativo discricionário, estaríamos diante de uma desapropriação indireta. É da própria natureza da propriedade florestal a existência da reserva (florestal) legal, inclusive como condição de exploração da dita propriedade. Não há exploração legal de propriedade florestal que não tenha averbada a reserva (florestal) legal.

- O regime de localização da reserva (florestal) legal na Lei nº 12.651/2012

De acordo com o artigo 14 da Lei nº 12.651/2012, localização da área de reserva (florestal) legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios: (i) plano de bacia hidrográfica; (ii) Zoneamento Ecológico-Econômico; (iii) formação de corredores ecológicos com outra reserva (florestal) legal, com Área de Preservação Permanente, com UC ou com outra área legalmente protegida; (iv) áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e (v) áreas de maior fragilidade ambiental.

Cabe ao órgão estadual integrante do Sisnama e, ou instituição por ele habilitada aprovar a localização da reserva (florestal) legal após a inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme o art. 29 da Lei nº 12.651/2012.

10.3.3.3.5 Percentuais que devem ser mantidos como reserva legal

A matéria até 2012 estava regida pelo artigo 16 do revogado Código Florestal (Lei nº 4.771/1965), na forma da redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 1.956-53, de 23 de agosto de 2000, em seu *caput*, estabelecia como *regra geral* a possibilidade da supressão das florestas e outras formas de vegetação nativas desde que não estivessem classificadas como áreas de preservação permanente, não estivessem submetidas ao regime de utilização limitada ou protegidas por legislação específica. Esta regra geral, entretanto, somente era aplicável desde que fossem observadas as áreas de Reserva Legal mínimas definidas nos incisos I até IV do artigo.

Na Amazônia Legal, o percentual de reserva (florestal) legal foi definido em 80% para as áreas de floresta; nas áreas de cerrado existentes na Amazônia Legal, definiu-se o percentual de 35%. Tal percentual, entretanto, pode ser subdividido em um índice de, no mínimo, 20% na *própria* propriedade e os restantes 15% poderiam ser constituídos por *compensação em outra área* incluída na mesma microbacia e que deveria ser averbada no registro de imóveis.

O percentual de 20% era o padrão geral aplicável às demais regiões do País, seja às florestas ou outras formas de vegetação, mesmo nas regiões de campos gerais.

- O regime da Lei nº 12.651/2012

Uma importante inovação introduzida pela Lei nº 12.651/2012 foi a possibilidade, contemplada pelo artigo 15, do cômputo das áreas de preservação permanente para a integralização do percentual (cálculo) reserva (florestal) legal do imóvel, desde que: (i) o benefício previsto no artigo 15 não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; (ii) a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente; e (iii) o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

É relevante consignar que regime de proteção da área de preservação permanente não se altera. Admite, o § 2º do artigo 15 que o proprietário ou possuidor de imóvel com reserva (florestal) legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR, disciplinado pelo artigo 29 da Lei, cuja área exceda o mínimo exigido pela lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres. O cômputo de área tratado pelo artigo 15 é aplicável a todas as modalidades de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação.

a) Regime condominial

O artigo 16 da Lei nº 12.651/2012 admite a instituição da reserva (florestal) legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 12 em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual na forma do artigo 15, em princípio é o órgão estadual. Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 16, “no parcelamento de imóveis rurais, a área de Reserva Legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes”.

b) Áreas consolidadas em áreas de reserva (florestal) legal

A Lei nº 12.651/2012 tem como uma de suas principais características o pragmatismo e a consolidação de situações anteriormente consolidadas, ainda que transbordantes da legalidade então vigente. Assim, o artigo 66, em linha de coerência com a orientação geral da lei estabelece que: o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente: I – recompor a Reserva Legal; II – permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal; III – compensar a Reserva Legal.

A data de 22 de julho de 2008 corresponde ao dia de edição do Decreto nº 6.514/2008, o qual define as infrações administrativas contra o meio ambiente. Relembre-se que o artigo 55 do decreto estabelece que:

Deixar de averbar a reserva legal: Penalidade de advertência e multa diária de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva legal. § 1º O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na forma das alternativas previstas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. § 2º Durante o período previsto no § 1º, a multa diária será suspensa. § 3º Caso o autuado não apresente o termo de compromisso previsto no § 1º nos cento e vinte dias assinalados, deverá a autoridade ambiental cobrar a multa diária desde o dia da lavratura do auto de infração, na forma estipulada neste Decreto. § 4º As sanções previstas neste artigo não serão aplicadas quando o prazo previsto não for cumprido por culpa imputável exclusivamente ao órgão ambiental. § 5º O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para averbar a localização, compensação ou desoneração da reserva legal, contados da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental competente ou instituição habilitada. § 6º No prazo a que se refere o § 5º, as sanções previstas neste artigo não serão aplicadas.

Devido à sua natureza *propter rem*, a obrigação é transmitida ao sucessor no caso de alienação do domínio ou posse do imóvel rural. A recomposição da reserva (florestal) legal deve ser promovida conforme os critérios definidos pelo órgão de controle ambiental, com o alargado prazo de até 20 (vinte) anos para a sua conclusão, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.

Admite a norma que a recomposição possa ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros: (i) o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional; (ii) a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada. Uma vez que o proprietário ou possuidor tenha aderido ao programa de recomposição da reserva (florestal) legal, ser-lhe-á assegurado o direito à sua exploração econômica.

No que tange à *compensação* tratada no inciso III do *caput* do artigo, ela deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: (i) aquisição de Cota de Reserva Ambiental – CRA; (ii) arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal; (iii) doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; (iv) cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. As áreas utilizadas para compensação deverão: (i) ser equivalentes em extensão à área da reserva (florestal) legal a ser compensada; (ii) estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; (iii) se forem localizadas em outro do estado da federação, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados, no caso o receptor da área. Importante observar que o § 7º estabelece m critério geral a ser observado para a definição das áreas prioritárias tratadas pelo § 6º, ou seja, elas deverão favorecer, (i) a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, (ii) a criação de corredores ecológicos, (iii) a conservação de grandes áreas protegidas e (iv) a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

Na hipótese de compensação devida por imóveis públicos, a compensação poderá ser efetivada mediante: (i) concessão de direito real de uso ou (ii) doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detenha reserva (florestal) legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária. A expressão *suficiente* contida na lei deve ser entendida como *equivalente*.

c) Averbação de reserva (florestal) legal

A Lei nº 12.651/2012 ao tratar da averbação de reserva (florestal) legal, no meu modo de ver, complicou uma situação que era relativamente simples. A reserva (florestal) legal deveria ser averbada junto à matrícula do imóvel, como determinado pela Lei nº 6.015/1973: “Art. 167 – No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos [...] II – a averbação: [...] 22. da reserva legal”.

O tratamento dado a matéria pela novel legislação, com todo o respeito, é de constitucionalidade discutível, como se verá adiante. Com efeito, o artigo 236 da CF determina que:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1ª Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2ª Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3ª O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Assim, em princípio, o registro público de imóveis é atividade exercida pelos registradores, por força de mandamento constitucional, logo parece estar em contradição com o texto constitucional a norma que admite a averbação da reserva (florestal) legal no órgão de controle ambiental, dispensando o proprietário de fazê-lo junto ao respectivo registro imobiliário. Com efeito, determina o artigo 18 da Lei nº 12.651/2012:

Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei... § 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato.

d) Reserva (florestal) legal e incidência do tempo

A reserva (florestal) legal passou por muitas alterações legislativas, fato que naturalmente gerou graves questões relativas à aplicação da lei no tempo. A Lei nº 12.651/2012, acertadamente, disciplinou a matéria reconhecendo de forma cabal as situações pretéritas, como se pode ver do artigo 68 que assim dispõe:

os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

O § 1º do artigo, com a finalidade de evitar dúvidas, estabelece que o proprietário ou possuidor de imóveis rurais “*poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos*”. Também foi facultado aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais situados na Amazônia Legal e seus “herdeiros necessários” (sic) que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental – CRA e outros instrumentos congêneres previstos na lei. Não faz qualquer sentido jurídico a limitação aos “herdeiros necessários”, haja vista a injuridicidade de exclusão das outras formas legais de sucessão, por violação ao princípio da isonomia constitucional.

e) RFL e os reservatórios de hidrelétricas

O regime tradicional de propriedade foi incapaz de assegurar a reprodução das características ambientais essenciais das áreas submetidas a atividade madeireira ou agrícola, vindo a lei a dar solução para a questão com a instituição, repita-se, da RFL. As diferentes atividades econômicas no país e, especialmente, a expansão da chamada fronteira agrícola estavam potencialmente nos conduzindo a um nível de desflorestamento inaceitável, haja vista que não existia qualquer obrigação legal para que o proprietário rural destinasse parcela de sua propriedade para as finalidades de reprodução das características ambientais relevantes. A solução encontrada pelo legislador se alicerça em dois pilares fundamentais (i) a elevação das florestas ao *status* de interesse nacional e (ii) a instituição da RFL. Assim, *ex vi lege*, foi criada uma *obrigação para o proprietário rural*, no sentido de que ele mantenha determinado percentual de sua propriedade apto a assegurar a reprodução dos elementos ecossistêmicos fundamentais.

Reserva (florestal) legal	
Lei nº 4.771/1965	Lei nº 12.651/2012

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.	Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
--	---

Uma interpretação meramente semântica do dispositivo legal demonstra que é da *própria essência do conceito* de reserva (florestal) legal a sua *aderência a uma propriedade ou posse rural*. Da mesma forma, a finalidade de sua instituição é bastante óbvia: manutenção no **interior da área agrícola** de parcela pristina capaz de assegurar a reprodução das condições ecológicas originárias que foram suprimidas para ceder vez à atividade agrícola ou de silvicultura. É importante ressaltar no presente contexto que o legislador não deu qualquer outra função à reserva (florestal) legal, bem como não determinou que ela fosse observada em outro tipo de atividade que não a rural ou agrícola. Anote-se que, devido à sua *especialidade*, não é lícito presumir que o legislador tenha tido a intenção de atribuir ao instituto uma abrangência maior do que aquela que expressamente consta da lei (CC, art. 1.231). A reserva (florestal) legal se justifica como instituto jurídico aplicável ao solo com vocação agrícola, pois como se depreende de sua definição normativa é área que, obrigatoriamente, deve ser mantida hígida com vistas a assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e a reabilitação dos processos ecológicos nas áreas que foram desflorestadas com vistas à implantação de atividades agrícolas ou rurais. Relembrem-se os precisos termos da definição: “*localizada no interior de uma propriedade ou posse rural*”. Permito-me ressaltar a expressão anteriormente sublinhada para reafirmar que não há reserva legal que não esteja “*localizada no interior de uma propriedade ou posse rural*”. Não é a simples existência de uma floresta que dá origem à imposição da obrigação *propter rem* de manutenção da reserva (florestal) legal, até mesmo porque não há que se falar em *reserva florestal*, se a área é toda florestada, a reserva somente se justifica quando parcela significativa do imóvel não é florestada ou será desflorestada para a atividade rural. A conclusão é lógica e se impõe por si própria.

Estabelecida a necessidade da existência de uma propriedade rural para que se possa falar em Reserva Legal ou reserva (florestal) legal, há que se observar, contudo, que a propriedade rural não é um conceito arbitrário ou aleatório a ser utilizado pelo administrador público quando da identificação de área na qual é exigível a reserva (florestal) legal. Para que a exigência seja feita com base legal, se faz necessário que o conceito normativo de propriedade ou posse rural ou agrícola seja preenchido inteiramente. Aqui, poderíamos falar em verdadeira tipicidade do conceito. Como se sabe, o *conceito normativo de propriedade rural*, por força do veto presidencial aos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, *deve ser buscado no Estatuto da Terra*, instituído pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que em seu artigo 4º, I, define *imóvel rural*: “*O prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.*” Como se vê, o legislador se utilizou de uma concepção teleológica para a classificação do imóvel e não de uma classificação geográfica, como poderia parecer em princípio. Penso que, da definição deve ser extraída uma consequência relevante: *A mera localização de um imóvel em área rural não o transforma em rural automaticamente*. A natureza jurídica de imóvel rural exige que ele tenha como destinação a “*exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial*”. Permito-me afirmar que esta é uma consequência inteiramente lógica e racional, pois o terreno destinado à instalação de um hospital em área rural não se transforma em rústico, haja vista que não é destinado à exploração extrativa agrícola, mas à saúde pública. O mesmo se diga de escolas, postos de gasolina e toda e qualquer outra atividade, inclusive as atividades e bens vinculados a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, desde sempre, estão afetadas apenas e tão somente ao mencionado fim. Analisando o conceito de imóvel rural, o saudoso agrarista Rafael Augusto de Mendonça Lima (1977, p. 33), com a tradicional precisão:

O que importa é a possibilidade de exploração agrícola (destinação), podendo encontrar-se o imóvel, quer no ambiente rural, quer dentro do perímetro urbano.

A Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, em seu artigo 6º, conceitua de forma diferente o imóvel rural, valendo o conceito, no entanto, só para os efeitos de incidência do imposto territorial rural.

[...]

Desta forma, o imóvel com mais de um hectare, que for utilizado para qualquer fim, que não agrícola, não será imóvel rural...

Não é raro que muitas das propriedades desapropriadas sejam divididas, permanecendo parcelas relevantes dos imóveis que foram desapropriados e alagados em posse e propriedade dos titulares originais do imóvel que sofreu a expropriação. Também não é raro que as áreas alagadas correspondam à totalidade das áreas destinadas à reserva (florestal) legal. Em tais hipóteses como será e por quem deve ser cumprida a exigência de manutenção da reserva (florestal) legal? Como já foi visto, o imóvel alagado perde a sua característica de imóvel rural, transformando-se em um bem público federal vinculado ao serviço público concedido de geração, transmissão e distribuição de energia.

A Lei nº 12.651/2012 deu a matéria tratamento igual àquele que venho sustentando já há vários anos. Assim, o § 7º do artigo 12 dispõe taxativamente:

não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.

Ademais, deve ser registrado que a área remanescente ao processo expropriatório permanece integrando o patrimônio do mesmo titular da antiga propriedade. Por força do alagamento, indiscutivelmente, criou-se uma nova realidade física que, *ex vi lege*, deverá ter outra área destinada à reserva (florestal) legal. A obrigação, no entanto, permanece com o proprietário, não havendo qualquer norma legal que a transfira para o expropriante.

f) Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O Decreto nº 7.830/2012, instituiu o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural e estabeleceu normas para os Programas de Regularização Ambiental. Posteriormente, o Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014, estabeleceu normas complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal e instituiu o Programa Mais Ambiente Brasil. Ambos os decretos vieram a permitir que, efetivamente, o CAR pudesse ser implementado⁷. Administrativamente, é ainda aplicável a IN MMA nº 2, de 6 de maio de 2014, que dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e define os procedimentos gerais do CAR.

Decreto nº 7.830/2012

O Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) é um sistema eletrônico de âmbito nacional destinado ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais. Já o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima), obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

O Sicar tem como objetivos: (i) receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos; (ii) cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação nativa, às áreas de interesse social, às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às áreas consolidadas e às Reservas Legais; (iii) monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a

compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais; (iv) promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território nacional; e (v) disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na Internet.

O CAR é uma base de dados que deve contemplar: (i) as informações sobre o proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a respectiva planta georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e da localização das Reservas Legais.

10.3.3.4 Proteção florestal e desapropriação

Uma questão que é extremamente debatida é aquela suscitada pelo estabelecimento de áreas de preservação permanente e as suas repercussões no patrimônio dos titulares do domínio das respectivas áreas. É grande o número de decisões judiciais que, em muitas hipóteses, determinam o pagamento de indenizações em razão do estabelecimento de áreas de preservação. Entendem os tribunais que, em várias hipóteses, verifica-se um esvaziamento econômico do bem privado, que este perde toda a sua importância anterior. Em verdade, para o particular, torna-se um estorvo. É evidente que a simples declaração de que uma área está submetida ao regime especial de proteção florestal não é suficiente para que o referido espaço passe a integrar o domínio público. Para que se possa compreender melhor o tema ora abordado, passemos a examinar como os autores classificam a desapropriação indireta.

O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello (1992, p. 385-386) assim define a desapropriação indireta:

É a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração ao patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. Ocorrida esta, cabe ao lesado recurso às vias judiciais para ser plenamente indenizado, do mesmo modo que o seria caso o Estado houvesse procedido regularmente.

O jurista Hely Lopes Meirelles (1993, p. 507-508) assim define a desapropriação indireta:

Não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio em lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível [...].

Para o Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1992, p. 283), o “instituto” pode ser assim definido:

Na realidade, não se trata de uma modalidade de desapropriação, mas de um ato ilícito da Administração, que se omite no cumprimento de dois requisitos constitucionais inarredáveis da desapropriação: declaração e indenização. Dá-se quando o Estado se apossa da propriedade particular e a utiliza efetivamente no interesse público. A afetação decorrente integra, irreversivelmente, o bem esbulhado, ao domínio público, cabendo, porém, ao espoliado, pleitear a indenização que, por se tratar de ato ilícito, há de ser a mais ampla possível [...].

A desapropriação indireta, portanto, é uma gentil construção doutrinária e jurisprudencial sobre o apossamento, puro e simples, de bens privados. É lamentável que a repetição de tal fato tenha se verificado tantas vezes que se tornou uma prática rotineira.

A criação de Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais é uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico que grava com a intocabilidade toda a área na qual se tenha estabelecido o parque. Essa circunstância faz com que os proprietários de terras da referida área não possam mais explorar economicamente o seu bem, esvaziando-lhe o conteúdo econômico e, portanto, retirando-lhe qualquer utilidade que não seja a de lazer. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem, seguidamente, mantido entendimento nesse sentido (ANTUNES, 1995, p. 92). Também o STJ tem entendido que:

As limitações administrativas, quando superadas pela ocupação permanente, vedando o uso, gozo e livre disposição da propriedade, desnatura-se conceitualmente, materializando verdadeira desapropriação. Impõe-se, então, a obrigação indenizatória justa e em dinheiro, espancando mascarado confisco (ANTUNES, 1995, p. 92-93).

Concordo, em tese, com a orientação jurisprudencial e doutrinária. Contudo, faz-se necessário lembrar que o momento atual é de valorização dos bens naturais e que, atualmente, está sendo desenvolvida uma poderosa indústria turística e de pesquisas científicas que, dependendo da forma de conservação a qual uma determinada região está sendo submetida, podem ser praticadas perfeitamente. Muitas vezes, é o próprio estabelecimento de áreas de preservação que irá servir de suporte para a valorização econômica de um bem. É necessário que os tribunais estejam atentos para o fato e que a análise do esvaziamento econômico leve em consideração as novas formas de atividade econômica. Evidentemente que o limite entre a “limitação administrativa” do direito de propriedade e o esvaziamento desse mesmo direito é extremamente tênue e precisa ser examinado em cada caso concreto.

10.4 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CÓDIGO FLORESTAL

A Lei nº 12.651/2012, logo após a sua edição, foi objeto de inúmeras contestações perante o Supremo Tribunal Federal com ajuizamento de inúmeras medidas judiciais diversas que foram propostas Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelos Partidos Socialismo e Liberdade (PSOL) e Progressista (PP). A Corte julgou constitucionais os principais dispositivos impugnados pelos autores das medidas judiciais. Um resumo geral das decisões pode ser visto no quadro abaixo.

Quadro do Novo Código Florestal em Relação às decisões do Supremo Tribunal Federal

TEXTO LEGAL	DISPOSITIVO	INCONSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] VIII – utilidade pública: b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão,	Art. 3, VIII, alínea b	Por maioria inconstitucionalidade do trecho: “Gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais”.	Interpretação conforme: “condicionar à comprovação de ausência de alternativa técnica e locacional para intervenção em APP em casos de utilidade pública e interesse social.”

instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;			
Art. 3º [...] IX – interesse social:	Art. 3º, IX		Interpretação conforme: <i>“condicionar à comprovação de ausência de alternativa técnica e locacional para intervenção em APP em casos de utilidade pública e interesse social.”</i>
Art. 3º [...] XVII – nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água;			Interpretação conforme: <i>“entorno das nascentes e olhos d’água intermitentes consideram-se APP.”</i>
Art. 3º [...] XIX – leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano;	Art. 3º, XIX		Constitucional
Art. 3º [...] Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais com até 4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território.	Art. 3º, parágrafo único.	Por maioria inconstitucional o trecho: “Demarcadas e tituladas”	
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: [...] III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;	Art. 4º, III		Constitucional
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: [...] IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;	Art 4º, IV.		Interpretação conforme: <i>“entorno das nascentes e olhos d’água intermitentes consideram-se APP.”</i>
Art. 4º [...] § 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.	Art. 4º, §1º		Constitucional
Art. 4º [...]	Art. 4º, §4º, §5º e §6º		Constitucional

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. § 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.			
§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que: I – sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; II – esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; III – seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; IV – o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR. V – não implique novas supressões de vegetação nativa.			
Art. 5º – Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. § 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em	Art. 5º		Constitucional

conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de Preservação Permanente.			
§ 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.			
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. § 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. § 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. § 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º.	Art. 7º Art. 7º, § 3º		Constitucional
Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. [...] § 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.	Art. 8º, § 2º		Constitucional
Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25º e	Art. 11		Constitucional

45º, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.			
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: [...] § 4º Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. § 5º Nos casos da alínea a do inciso I, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas. § 6º Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.	Art. 12, §4º a §6º		Constitucional
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: [...] § 7º Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas			

linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.			
--	--	--	--

10.5 A FLORESTA, OS DESMATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO DE FOGO

As queimadas são, certamente, um dos mais graves problemas enfrentados pelas florestas brasileiras, pois, além da diminuição da área florestada, elas causam um enorme aumento da emissão de material particulado, ampliam a poluição atmosférica e contribuem para o aquecimento global. Os incêndios florestais têm várias origens e não se pode, sob pena de odiosa simplificação, atribuir-lhes como causa imediata este ou aquele fator. O tema é extremamente complexo, pois, para que as florestas se queimem, existem causas que vão desde condições culturais, econômicas até condições climáticas mais favoráveis à propagação do fogo. O Brasil, em função de sua grande presença amazônica, da fragilidade dos ecossistemas da Hileia, das características climáticas da região, das dificuldades de acesso à região, das imensas desigualdades sociais e da pobreza reinantes na selva, tem sido alvo frequente de críticas internacionais sobre incêndios florestais na Amazônia. É evidente que todo o esforço deve ser feito no sentido de que não se ampliem as áreas suscetíveis aos incêndios, preservando-se, ao máximo, as imensas riquezas existentes na floresta tropical. Merece ser realçado, entretanto, que as críticas feitas ao país nem sempre são formuladas por aqueles que podem se apresentar como modelos de proteção ambiental. Em realidade, existe todo um jogo de importantes interesses econômicos e políticos que, de forma constante e repetitiva, busca minar as bases da soberania nacional sobre o território amazônico, espalhando a tese – falaciosa – de que o Brasil não é capaz de desempenhar o seu papel na região. Infelizmente, muitos desavisados, ainda que de boa-fé, têm colaborado para o descrédito do país em relação às suas responsabilidades amazônicas.

10.5.1 Desflorestamento e queimadas

Existe na região amazônica o chamado *Arco de Desmatamento*, composto pelos Estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso (norte), Pará (sul), Tocantins, Maranhão (oeste) e Amazonas (sul). No ano de 1998, um grande incêndio florestal no Estado de Roraima, cujas causas ainda não foram determinadas de forma precisa e clara, deu origem à implantação de um programa governamental denominado *Programa de Prevenção e Controle às Queimadas e aos Incêndios Florestais no Arco do Desflorestamento – Proarco*, sob a responsabilidade do Ibama e do MMA.

Na década de 1980, a taxa de desflorestamento da Amazônia chegou ao alarmante índice de mais de 21 mil km²/ano de floresta. No início da década de 90, tais valores sofreram uma acentuada queda, oscilando entre 11.500 e 12.500 km²/ano. No período compreendido entre 1994 e 1995, lamentavelmente, houve um acréscimo do avanço do desflorestamento, atingindo-se a seguinte cifra: 29.059 km²/ano. Verificou-se uma nova redução dos valores de desflorestamento, com os seguintes valores: 18.161 km² em 1996 e 13.037 km² em 1997. O Instituto de Pesquisas da Amazônia – IPAM (1997) constatou que entre 1994 e 1995, realizando pesquisas nas regiões de Paragominas e Santana do Araguaia – PA, Alta Floresta – MT, Ariquemes – RO e Rio Branco – AC, comprovou que em média de 8% a 23% da área de cada uma das propriedades arroladas foram queimadas. O mesmo estudo mostrou que o fogo acidental correspondeu a 48% da área queimada em 1995. Os incêndios florestais, no entanto, não são um privilégio brasileiro ou da região amazônica. A sua ocorrência é bastante comum em todas as regiões do mundo, inclusive nos países do chamado primeiro mundo.⁸ Nos EUA, o número de focos elevou-se de 24.817, no primeiro semestre de 1997, para 28.455 em igual período de 1998, ampliando-se a área atingida de 198.390 hectares para 241.236 hectares. No Canadá, o crescimento foi ainda maior; no mesmo período o número de focos cresceu de 1.313 para 3.148, ampliando-se a área atingida de 9.478 hectares para 580.120 hectares.⁹

10.5.2 Regime legal da utilização do fogo

O revogado código florestal (Lei nº 4.771/1965), em seu artigo 27, proibia a utilização de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. A proibição da utilização de fogo somente foi regulamentada em 1998, mediante o Decreto nº 2.661, de 8 de julho. Tal decreto, por compatível com a Lei nº 12.651/2012.

A Lei nº 12.651/2012 manteve a tradição do código revogado e proibiu a o uso de fogo na vegetação estabelecendo exceções, conforme o artigo 38. As exceções são as seguintes: (i) em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle; (ii) emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo; (iii) atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama.

Na situação prevista em (i), o órgão de controle ambiental estadual deverá exigir que, no licenciamento ambiental, sejam apresentados estudos específicos que contemplem o emprego do fogo e o controle dos incêndios.

O § 2º isentou da proibição da cabeça do artigo as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas, ainda que louvável a intenção do legislador, evidente que mesmo as práticas tradicionais devem estar submetidas a algum tipo de controle para que não se multipliquem sem critério.

§ 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

10.5.2.1 Proibição do uso de fogo

O artigo 1º do decreto em comento estabeleceu a proibição do uso de fogo (Lei 9.605/1998, art. 41) em três hipóteses bem definidas: (i) florestas e demais formas de vegetação; (ii) para a queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável de: (a) aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais; (b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável; (iii) em faixa de: (a) 15 (quinze) metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica; (b) 100 (cem) metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica; (c) 25 (vinte e cinco) metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações; (d) 50 (cinquenta) metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido limpo e não cultivado, de 10 (dez) metros de largura ao redor das Unidades de Conservação; (e) 15 (quinze) metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio; (iv) no limite da linha que, simultaneamente, corresponda: (a) a área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem de aeródromos públicos; (b) a área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial de aeródromo público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos.

As proibições acima anotadas, evidentemente, não dizem respeito às atividades agrícolas ou agropastoris, pois em realidade visam à proteção de atividades técnicas, comerciais e econômicas.

A partir de 9 de julho de 2003, ficou proibida a utilização de fogo, ainda que de forma controlada, para a queima de vegetação contida numa faixa de 1.000 metros do aglomerado urbano de qualquer porte, delimitado a partir de seu centro urbanizado, ou de 500 metros, a partir do perímetro urbano, se superior. A proibição contida no § 3º do artigo 1º do Decreto nº 2.661/98, ao ingressar diretamente na área de domínio municipal, gestão do solo urbano, em minha opinião, encontra dificuldade para se afirmar constitucional. Acrescente-se, ademais, que a matéria é de evidente interesse local.

10.5.2.1.1 Requisitos para a queima controlada

Aqueles que desejarem realizar queima controlada de vegetação deverão, necessariamente, solicitar autorização ao órgão de controle ambiental com atribuição na região. O requerimento de solicitação deverá ser prévio ao início da queima controlada. O requerimento deverá ser instruído com as seguintes informações (Decreto nº 2.661/98): (i) definição das técnicas, equipamentos e mão de obra a serem utilizados no processo de queima controlada; (ii) reconhecimento da área e avaliação do material a ser submetido à queima controlada; (iii) assegurar o monitoramento dos resíduos da vegetação, para limitar a ação do fogo; (iv) preparar aceiros com, no mínimo, três metros de largura, ampliando a referida faixa sempre que as condições ambientais, topográficas, climáticas e o próprio material combustível assim o determinarem; (v) assegurar a presença de uma equipe treinada para atuar no local da queima controlada, devidamente equipada com o material necessário para evitar a propagação do fogo para além da área delimitada; (vi) comunicar formalmente aos vizinhos confrontantes a intenção de realizar a queima controlada, esclarecendo que a operação será confirmada com a fixação de data, horário e local onde será realizada a queima; (vii) que a queima será realizada em época apropriada, considerando-se as condições de temperatura e vento da ocasião; (viii) previsão de acompanhamento de toda a operação de queima, até a sua extinção, com vistas à adoção das medidas adequadas para a contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo.

Os procedimentos acima arrolados são procedimentos mínimos a serem adotados por aquele que pretenda realizar a queima controlada. O órgão ambiental, diante de peculiaridades da área a ser submetida ao fogo, poderá exigir a adoção de outros procedimentos considerados necessários à proteção do meio ambiente e das propriedades de terceiros.

Uma vez que o órgão ambiental examine as informações prestadas pelo interessado, e as considere suficientes, o requerente deverá solicitar a autorização de queima controlada. A autorização é solicitada pelo documento denominado *Comunicação de Queima Controlada*. O requerimento deverá se fazer acompanhar de: (i) comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel onde se realizará a queima; (ii) cópia da autorização de desmatamento, nas hipóteses nas quais ela é exigível; e (iii) comunicação da queima controlada. Admite-se a hipótese de que a queima seja realizada de forma solidária, isto é, os proprietários ou posseiros que tenham terras contíguas poderão realizar uma única queima controlada, desde que a área a ser submetida ao fogo não ultrapasse 500 hectares.

É curioso observar que, pelo parágrafo único do artigo 6º, o interessado tem direito à realização da queima controlada se a Administração Pública não expediu a autorização ou a sua negativa no prazo de 15 dias após a protocolização do requerimento. As exceções limitam-se às áreas sujeitas à vistoria prévia.

10.5.2.2 Ordenamento e suspensão temporária do emprego de fogo

A queima controlada é matéria submetida ao poder de polícia ambiental e, portanto, o órgão ambiental poderá determinar o seu escalonamento regional, desde que as condições atmosféricas e o número de requerimentos de autorizações possam implicar acréscimo considerável de fumaça na região.

As hipóteses de suspensão de queima controlada, estabelecidas pelo artigo 14, são as seguintes: (i) constatação de risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; (ii) a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por instrumentos e meios adequados, oficialmente reconhecidos como parâmetros; (iii) os níveis de fumaça, originados de queimadas, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte. Nesse caso, a queima controlada está sendo realizada pelo interessado.

O artigo 15 admite a suspensão ou o cancelamento da autorização de queima controlada quando: (i) registrarem riscos de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; (ii) interesse e segurança pública; (iii) descumprimento de normas vigentes.

10.5.2.3 Redução gradativa do emprego de fogo

Por incrível que possa parecer, o Código Florestal, datado de 1965, teve regulamentado o seu artigo 27 no ano de 1998, ocasião na qual se estipulou a diminuição gradativa do emprego de fogo. Os artigos 16 e 17 foram elaborados especificamente para as lavouras de cana-de-açúcar que, como se sabe, é um dos setores mais atrasados e recalcitrantes ao adequado cumprimento das normas de proteção ambiental, ressalvadas as exceções usuais.

O artigo 16 do Decreto nº 2.661/1998, estabelece um prazo de 20 anos (!!!!) após a sua publicação para a eliminação do fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização da colheita.

-
- ¹ Disponível em: <<http://www.fao.org/forestry/4222-0dd83a652d950f2fcd7d74272ecdb39db.pdf>>. Acesso em: 8 nov. 2015.
- ² Disponível em: <<https://www.grida.no/resources/7306>>. Acesso em: 8 set. 2017.
- ³ A este respeito deve ser observado que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 121.681, Relatora a Sra. Ministra Rosa Weber decidiu que “embora a fauna não seja descrita na Constituição Federal como bem da União, o interesse federal decorre do artigo 53 da Lei 9.985/2000, que outorgou ao IBAMA o dever de catalogar espécies ameaçadas de extinção em território nacional. A relatora destacou também que a norma confere à União a faculdade de autorizar, em caráter excepcional, a captura de determinados espécimes em risco de extinção destinados a programas de criação em cativeiro ou formação de coleção específica.
- ⁴ *Dicionário Aurélio Eletrônico.*
- ⁵ III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
- ⁶ XI – tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude;
- ⁷ Todos os elementos do CAR podem ser encontrados no site: <<http://www.car.gov.br>>.
- ⁸ Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Grécia registraram a ocorrência de 460 mil incêndios entre 1º de janeiro de 1985 e 31 de dezembro de 1995. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br>>.
- ⁹ Informações atualizadas sobre queimadas no Brasil podem ser encontradas no excelente sítio da Internet: <<http://www.inpe.br/queimadas/>>.

ESPAÇOS TERRITORIAIS (ÁREAS) ESPECIALMENTE PROTEGIDOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

11.1 INTRODUÇÃO

Espaços territoriais especialmente protegidos e unidades de conservação, muito embora sejam conceitos próximos, não devem ser confundidos. Os ETEP englobam as UCs, mas não se limitam a elas. Existem os espaços protegidos genericamente, por exemplo, aqueles contemplados na Lei nº 12.651/2012, como as áreas de preservação permanente, a reserva legal e as áreas de uso restrito, bem como aqueles que dependem do reconhecimento do poder público e, também existem aqueles que têm origem na Lei nº 9.985/2000 (lei do SNUC.)

11.2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS ETEPS E DAS UCS

As bases constitucionais para que o Poder Público possa instituir UCs estão no inciso III do § 1º do artigo 225 da CF que ordena ao poder público que defina, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

A demarcação das áreas protegidas é feita com base no poder de polícia e de delimitação legal do exercício de direitos individuais, em benefício da coletividade de que é dotada a Administração Pública. Utilizo a expressão *delimitação*, visto que, na concepção que adoto, os direitos são exercidos dentro dos contornos legais sob os quais foram inscritos na ordem jurídica. Dessa forma, não há uma *limitação de direitos*, mas o seu exercício, no interior do círculo estabelecido pela própria lei. Sendo assim, a definição de ETEP poderá ser feita mediante leis ou decretos, conforme o caso. Todavia, o caminho legislativo não é o mais indicado, pois estaríamos falando de “*lei de efeitos concretos*”, as quais materialmente são atos administrativos. Por outro lado, o processo legislativo torna mais difícil a oitiva das comunidades interessadas, audiências públicas, contraditório para a defesa dos direitos dos proprietários etc. Por outro lado, nos termos da norma constitucional, a supressão e a alteração de áreas protegidas somente poderão ser feitas *por lei*. A expressão *lei* deve ser entendida em seu sentido formal. O constituinte atribuiu à Administração o dever de demarcar áreas a serem especialmente protegidas, porém não admitiu que essa mesma Administração pudesse promover alterações ou supressões dessas áreas sem o consentimento do Congresso Nacional. A Constituição não proibiu que todas as áreas merecedoras de especial proteção legal pudessem ser utilizadas e exploradas economicamente; contudo, proibiu utilização que alterasse as características e os atributos que deram fundamento à especial proteção. A questão coloca-se, portanto, no modelo de unidade de conservação a ser adotado para cada um dos espaços territoriais que venham a merecer uma especial proteção. Melhor dizendo, a cada modelo de unidade de conservação corresponde um determinado padrão de limitação de atividades econômicas, sociais e recreacionais etc.

Em 1995, o Brasil possuía 34 Parques Nacionais, 23 Reservas Biológicas Federais, 30 Estações Ecológicas, 38 Florestas Nacionais, 15 Áreas de Proteção Ambiental, 4 Reservas Extrativistas e 6 Reservas Ecológicas.¹ Somando-se as áreas federais com as municipais e estaduais, chegar-se-á ao total de 3,7% da superfície do país em áreas protegidas. Tal percentual vem aumentando de forma bastante significativa nos últimos anos, conforme nos demonstra a tabela a seguir:²

Unidades de Conservação do Brasil				
Grupo manejo	Categoria de Manejo	Unidades de Conservação		Área*** (km²)
		Ocorrência*	Mapeadas**	
Proteção Integral	Estação Ecológica	76	63	109.402,74
	Monumento Natural	11	6	477,12
	Parque	190	147	234.720,04
	Refúgio de Vida Silvestre	7	5	1.538,34
	Reserva Biológica	43	36	50.766,67
Total Parcial		327	257	396.904,91
Uso sustentável	Floresta	79	69	267.491,19
	Reserva Extrativista	59	51	117.508,85
	Reserva Particular do Patrimônio Natural	0	0	0
	Reserva de Desenvolvimento Sustentável	12	10	62.446,73
	Reserva de Fauna	0	0	0
	Área de Proteção Ambiental	133	88	226.916,03

Proteção Integral (PI)	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%
Estação Ecológica	19	107.721	2,6%	4	1.303	0,2%	28	11.370	0,6%
Monumento Natural	0	0	0,0%	5	580	0,1%	12	314	0,0%
Parque	45	260.513	6,2%	19	7.549	0,9%	66	48.410	2,4%
Refúgio de Vida Silvestre	1	64	0,0%	3	347	0,0%	5	2.460	0,1%
Reserva Biológica	13	49.271	1,2%	2	70	0,0%	6	82	0,0%

Total PI	78	417.569	9,9%	33	9.849	1,2%	117	62.636	3,1%
----------	----	---------	------	----	-------	------	-----	--------	------

Uso Sustentável (US)	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%
Floresta	58	298.510	7,1%	6	542	0,1%	11	557	0,0%
Reserva Extrativista	71	137.476	3,3%	3	19	0,0%	6	880	0,0%
Reserva de Desenvolvimento Sustentável	20	109.929	2,6%	1	96	0,0%	2	686	0,0%
Reserva de Fauna	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Área de Proteção Ambiental	34	171.908	4,1%	33	52.267	6,3%	68	108.752	5,3%
Área de Relevante Interesse Ecológico	6	446	0,0%	5	198	0,0%	15	79	0,0%
RPPN	55	466	0,0%	76	477	0,1%	160	1.015	0,0%

Total US	244	718.735	17,1%	124	53.599	6,5%	262	111.968	5,5%
----------	-----	---------	-------	-----	--------	------	-----	---------	------

Total PI e US	322	1.136.304	27,1%	157	63.448	7,7%	379	174.604	8,6%
---------------	-----	-----------	-------	-----	--------	------	-----	---------	------

Área de UC considerando sobreposições¹	Amazônia		Caatinga		Cerrado	
	Área (km²)	%	Área (km²)	%	Área (km²)	%
Proteção Integral (PI)	402.071	9,6%	9.687	1,2%	59.350	2,9%
Uso Sustentável (US)	701.820	16,7%	52.848	6,4%	105.574	5,2%
Sobreposição PI e US	13.618	0,3%	162	0,0%	3.265	0,2%
Total de UC no bioma	1.117.509	26,6%	62.697	7,6%	168.189	8,2%

¹ As áreas de sobreposição consideradas foram obtidas a partir dos arquivos com dados espaciais cadastrados e validados no CNUC.

* Área Marinha corresponde ao Mar Territorial mais a Zona Econômica Exclusiva (ZEE).

Obs. 1: A UC que não tem informação georreferenciada disponível é utilizada a área do ato legal para cálculo de área.

Obs. 2: Os dados do CNUC estão em constante atualização. Ao utilizá-los sempre citar a data.

Obs. 3: Área do Bioma foi obtida de IBGE, 2004.

Fonte: CNUC/MMA, disponível em: <www.mma.gov.br/cadastro_uc>. Atualizada em: 17 fev. 2015.

Unidades de Conservação por Bioma

Mata Atlântica			Pampa			Pantanal			Área Continental			Área Marinha*		
1.117.571			178.704			151.159			8.514.085			3.555.796		
Mata Atlântica			Pampa			Pantanal			Área Continental			Área Marinha*		
Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%
39	1.458	0,1%	1	108	0,1%	1	116	0,1%	91	122.075	1,4%	7	138	0,0%
23	509	0,0%	1	0	0,0%	1	3	0,0%	42	1.407	0,0%	2	1	0,0%
230	23.096	2,1%	4	375	0,2%	5	4.285	2,8%	356	344.229	4,0%	39	3.859	0,1%
21	688	0,1%	1	26	0,0%	0	0	0,0%	31	3.585	0,0%	5	183	0,0%

32	2.445	0,2%	4	107	0,1%	0	0	0,0%	57	51.975	0,6%	8	557	0,0%
345	28.196	2,5%	11	616	0,3%	7	4.404	2,9%	577	523.270	6,1%	61	4.738	0,1%
Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%	Nº	Área (km²)	%
31	357	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	104	299.966	3,5%	0	0	0,0%
11	711	0,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	90	139.086	1,6%	21	5.484	0,2%
14	527	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	36	111.237	1,3%	5	55	0,0%
0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
184	79.683	7,1%	3	4.215	2,4%	0	0	0,0%	292	416.824	4,9%	65	44.097	1,2%
20	164	0,0%	1	30	0,0%	0	0	0,0%	47	917	0,0%	4	4	0,0%
466	1.012	0,1%	9	4	0,0%	17	2.544	1,7%	782	5.517	0,1%	1	0	0,0%
726	82.453	7,4%	13	4.249	2,4%	17	2.544	1,7%	1.351	973.548	11,4%	96	49.641	1,4%
1.071	110.649	9,9%	24	4.865	2,7%	24	6.947	4,6%	1.928	1.496.817	17,6%	157	54.379	1,5%

Mata Atlântica		Pampa		Pantanal		Área Continental		Área Marinha*	
Área (km²)	%	Área (km²)	%	Área (km²)	%	Área (km²)	%	Área (km²)	%
21.482	1,9%	589	0,3%	4.404	2,9%	497.583	5,8%	4.633	0,1%
72.807	6,5%	4.223	2,4%	2.544	1,7%	939.815	11,0%	48.031	1,4%
6.592	0,6%	26	0,0%	0	0,0%	23.663	0,3%	104	0,0%
100.881	9,0%	4.838	2,7%	6.948	4,6%	1.461.061	17,2%	52.767	1,5%

Fonte: CNUC/MMA, disponível em: <www.mma.gov.br/cadastro_uc>. Atualizada em: 17 fev. 2015.

11.2.1 A separação constitucional entre legislação sobre conservação da natureza e proteção de florestas

A partir de 1981, ano da edição da PNMA, o ordenamento jurídico brasileiro incorporou grande quantidade de leis de proteção do meio ambiente. Em 1988, com o advento da nova Constituição Federal, o meio ambiente e as políticas ambientais passaram a ocupar local de destaque na nossa ordem jurídica. O artigo 225 de nossa Constituição estabeleceu um complexo normativo que, rapidamente, foi replicado pelas Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Da mesma forma ocorreu com as leis ordinárias federais relacionadas à proteção ambiental. Esse fenômeno legislativo gerou um conjunto de normas que necessita ser adequadamente compreendido, sob pena de inviabilizar o exercício de atividades legítimas e, ao mesmo tempo, ser ineficaz para oferecer a tutela desejada e necessária.

Não há um estudo sistematizado capaz de informar o número total de normas voltadas para a proteção ambiental no Brasil, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados e dos municípios; entretanto, é possível dizer que a quantidade é muito grande e tende a crescer em ritmo acelerado. É evidente que tal circunstância é uma fonte de conflitos de leis, tanto no tempo, como no espaço. Como se sabe, as competências constitucionais em matéria ambiental, do ponto de vista legislativo, são concorrentes e, do ponto de vista da implementação administrativa, são comuns, conforme estabelecido pelos artigos 23 e 24 de nossa CF.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o STF decidiu por meio da ADI 4.717 que é inconstitucional a diminuição, por meio de medida provisória, de espaços territoriais especialmente protegidos. Os ministros, contudo, não declararam a nulidade da norma questionada nos autos, uma vez que os efeitos da medida provisória, posteriormente convertida em lei, já se concretizaram, incluindo a construção de usinas que já estão em funcionamento.

11.2.1.1 Competências constitucionais: previsão de lei especial para a criação de Unidades de Conservação

O artigo 24 da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados para diferentes temas, dentre os quais (i) florestas e (ii) conservação da natureza. No caso específico da conservação da natureza, o *próprio artigo 225, § 1º, III* estabeleceu a obrigação de criação de espaços territoriais a serem “*especialmente protegidos*”, daí resulta claro que *o regime jurídico florestal não se confunde com o regime jurídico das áreas merecedoras de proteção especial*. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no nível da legislação geral federal, possui normas próprias tanto para uma como para outra hipótese, no caso, (i) a Lei nº 12.651/2012 e (ii) a Lei nº 9.985/2000.

Legislação aplicável (Federal)	
Constituição Federal: Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI – florestas (...)	Constituição Federal: Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI – conservação da natureza (...)
	Constituição Federal: Art. 225, § 1º (...) III – espaços territoriais [...] a serem especialmente protegidos [...] vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção .
Lei no 12.651/2012	Lei nº 9.985/2000

Como já foi ampla e reiteradamente decidido pelo STF (RE 344.882/BA, Tribunal Pleno, *DJU* 6/8/2004, p. 22), a Constituição é um todo e deve ser interpretada de forma a assegurar a compatibilidade entre todos os seus comandos, haja vista que a Constituição não pode ser tida como um conjunto caótico de normas: “*Mas, é lugar comum que o ordenamento jurídico e a Constituição, sobretudo, não são aglomerados caóticos de normas; presumem-se um conjunto harmônico de regras e de princípios*” (Ministro Sepúlveda Pertence).

A orientação do STF reflete velha concepção doutrinária que pode ser encontrada em um dos maiores hermeneutas brasileiros e ex-Ministro do STF, Carlos Maximiliano (1981, p. 128): “O Direito não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma em seu lugar próprio”.

Logo, existem *dois sistemas de proteção ambiental, distintos, previstos na Constituição* e materializados pela legislação ordinária, (i) o primeiro voltado para a generalidade dos ecossistemas e biomas, expresso pelo Código Florestal e o (ii) segundo especificamente voltado para áreas merecedoras de proteção especial, o qual se materializa na Lei do SNUC. Como se demonstrará, ambos não podem ser aplicados simultaneamente sobre um mesmo território, prevalecendo a lei especial sempre que o Poder Público tenha, regularmente, instituído uma Unidade de Conservação, qualquer que seja a sua categoria.

Com efeito, repita-se, a *CF expressamente reconhece a existência de dois marcos legislativos bastante distintos no que tange à proteção do meio ambiente*. O (i) primeiro diz respeito à proteção ambiental genérica e o (ii) segundo diz respeito à proteção ambiental de áreas que sejam julgadas merecedoras de tutela especial. Leitura atenta do artigo 24 da CF demonstra que o Constituinte originário estabeleceu a obrigação para o legislador ordinário legislar sobre (i) *florestas* e (ii) sobre *conservação da natureza*.

Como assentado pelo STF: “*A lei, sabemos, não contém palavras inúteis*” (Ministra Cármen Lúcia), com muito mais razão o legislador constituinte não se utiliza de palavras inúteis no Texto Constitucional. De fato, o Constituinte quis estabelecer e estabeleceu regime próprio para as UCs, o qual não se confunde com o regime geral de proteção ambiental. A concepção jurídica adotada pelo documento ora examinado, incidência concomitante de normas jurídicas voltadas para finalidades diversas, implicaria em consequências jurídicas graves para o (i) Estado, que se veria privado do seu poder-dever de organizar o território – juntamente com o Município – mediante a adoção de políticas públicas de ocupação do solo e proteção ao meio ambiente e para o (ii) particular que seria engolfado em um contexto normativo que esvaziaria por completo o conteúdo econômico de sua propriedade, sem qualquer compensação como lhe é devido pela Constituição (RE 716.270/RS, *DJe*-24, divulgação 13/12/2012).

11.2.1.1.1 A solução de conflitos entre leis

Os conflitos entre leis, e mesmo entre artigos constitucionais, devem ser solucionados segundo critérios legais que, no direito brasileiro, estão principalmente – mas não só – estabelecidos pela chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, instituída pelo Decreto-lei nº 4.657/1942, conforme redação dada pela Lei nº 12.376/2010. É importante ressaltar que o Decreto-lei nº 4.657/1942 foi editado como lei de introdução ao CC, muito embora ele fosse entendido pela doutrina jurídica mais abalizada como uma norma de aplicação de normas de direito em geral, motivo pelo qual se justificou a sua mudança de nome.

Conforme disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “*não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue*”, “*a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior*”. E mais: “*a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior*”.

Uma norma especial tem aplicação preferencial em relação à norma geral, como é pacífico na doutrina e na jurisprudência nacionais e internacionais.

O enquadramento legal de um empreendimento é tarefa complexa, tendo em vista que o Estado Brasileiro é organizado em três níveis políticos administrativos, o que demanda do intérprete da norma esforço para definir precisamente o âmbito de competência de cada um dos entes federativos, de forma a se identificar adequadamente o complexo normativo aplicável ao caso concreto. Diante do elevado número de normas voltadas para a proteção ambiental, tal construção hermenêutica se torna fundamental, na medida em que o sistema de controle de constitucionalidade e o federalismo cooperativo adotado pela Constituição Brasileira estabelecem um verdadeiro “condomínio legislativo”, *com uma esfera de poder que deve ser identificada* (STF. ADI 2.903/PB. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 1º/12/2005. Tribunal Pleno. *DJe*-177).

A Constituição da República, nos casos de competência concorrente (CF, art. 24), estabeleceu verdadeira situação de condomínio legislativo entre a União Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal (Raul Machado Horta, ‘Estudos de Direito Constitucional’, p. 366, item nº 2, 1995, Del Rey), daí resultando clara repartição vertical de competências normativas entre essas pessoas estatais, cabendo, à União, estabelecer normas gerais (CF, art. 24, § 1º), e, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, exercer competência suplementar (CF, art. 24, § 2º). Doutrina. Precedentes. Se é certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para, assim, invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais (como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, consubstanciada na LC nº 80/94), não pode ultrapassar os limites da competência meramente suplementar; pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da inconstitucionalidade. A edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal ofende, de modo direto, o texto da Carta Política.

Justifica-se a caracterização jurídica da Lei do SNUC como lei especial a ser aplicada preferentemente às leis gerais de proteção ao meio ambiente, seja pelos aspectos puramente de hermenêutica jurídica, seja pelos aspectos históricos da evolução legislativa da matéria. Com efeito, já a Constituição de 1934 determinava a proteção das chamadas *belezas naturais*. Tal norma foi cumprida pelo legislador ordinário que, ao aprovar o Código Florestal, estabeleceu a possibilidade da criação de parques, com vistas à proteção das belezas naturais. No mesmo sentido andou o revogado Código Florestal estabelecido pela Lei nº 4.771/1965, que em seu artigo 5º determinava ao Poder Público fossem criadas diferentes unidades de conservação.

Constituições Federais				
1934	1937	1946	1967	1988
Art. 10. Compete concorrentemente à União e aos Estados: [...] III – proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte.	Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão	Art. 175. As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público.	Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado. Parágrafo único – Ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as	Art. 225. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,

	equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.		jazidas arqueológicas.	sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
--	---	--	------------------------	--

É imperioso que se observe que a evolução e consequente especialização da matéria se deu com a Constituição de 1988, a qual determinou fossem demarcadas áreas, em todos os estados da federação, merecedoras de especial proteção em razão de seus atributos ambientais. *Surgiu daí a Lei do SNUC que, em seu artigo 60, revogou expressamente os artigos 5ª e 6ª da Lei nº 4.771/1965, esta última, por sua vez revogada pela Lei nº 12.651/2012, o que significa que a matéria ficou inteiramente regulada pela lei especial.* Assim, parece evidente que tanto o legislador constituinte, quanto o legislador ordinário determinaram um regime jurídico especial para as áreas protegidas (UCs) e deliberadamente excluíram a incidência do Código Florestal sobre elas.

- Papel dos planos de manejo
- O papel e a relevância dos planos de manejo das UCs estão definidos pelo Decreto Federal nº 4.340/2002. O STJ (REsp 1.163.524/SC. Recurso Especial 2009/0206603-4. 2ª Turma. Data do Julgamento: 5/5/2011. *DJe* 12/5/2011). Já decidiu que cabe ao Plano de Manejo definir os usos possíveis no interior de Unidade de Conservação, notadamente naquelas da categoria de uso sustentável, haja vista a necessidade de coexistência entre o regime jurídico administrativo e o regime jurídico de direito privado:

Evolução Legislativa			
Decreto nº 4.421, de 28 de dezembro de 1921	Código Florestal de 1934	Código Florestal de 1965	Lei do SNUC
Art. 37. Oportunamente serão creados parques nacionaes em locaes caracterizados por accidentes topographicos notaveis, grandiosos e bellos e encerrando florestas virgens typicas, que serão perpetuamente conservadas. Art. 38. O estabelecimento dos parques será feito em pontos de facil accesso, relativo, e mediante disposições previamente estabelecidas pelo Congresso Nacional.	Art. 9º Os parques nacionaes, estaduaes ou municipaes, constituem monumentos publicos naturaes, que perpetuam em sua composição floristica primitiva, trechos do paiz, que, por circunstancias peculiares, o merecem. § 1º É rigorosamente prohibido o exercicio de qualquer especie de actividade contra a flora e a fauna dos parques. Ver o art. 86. § 2º Os caminhos de acesso aos parques obedecerão a disposições technicas, de fôrma que, tanto quanto possivel, se não altere o aspecto natural da paisagem. Art. 10. Compete ao Ministerio da Agricultura classificar, para os effeitos deste codigo, as varias regiões e as florestas protectoras e remanescentes, localizar os parques nacionaes, e organizar florestas modelo, procedendo para taes fins, ao reconhecimento de toda a area florestal do paiz. Paragrapho unico. A competencia federal não exclue a acção suppletiva, ou subsidiaria, das autoridades locaes, nas zonas que lhes competirem para os mesmos fins, acima declarados, observada sempre a orientação dos serviços federaes, e ficando a classificação de zona e de florestas sujeita à revisão pelas autoridades	Art. 5º O Poder Público criará: a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos; b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive reservando áreas ainda não florestadas e destinadas a atingir aquele fim. Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais. Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes, cuja receita será destinada em pelo menos 50% (cinquenta por cento) ao custeio da manutenção e fiscalização, bem como de obras de melhoramento em cada unidade, é proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos parques e reservas biológicas criados pelo poder público na forma deste artigo. (Redação dada pela Lei no 7.875, de 13.11.1989) (Revogado pela Lei nº 9.985, de 18/7/2000)	Art. 60. Revogam-se os arts. 5º e 6º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5º da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967; e o art. 18 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

	federaes. Quanto á formação de parques e de florestas modelo, ou de rendimento, de accôrdo com este codigo, a acção das autoridades locais é inteiramente livre.	
--	--	--

Nos termos do art. 225 da CF, o Poder Público tem o dever de preservar o meio ambiente. Trata-se de um dever fundamental, que não se resume apenas em um mandamento de ordem negativa, consistente na não degradação, mas possui também uma disposição de cunho positivo que impõe a todos – Poder Público e coletividade – a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender o ambiente ecologicamente equilibrado. 3. Nesse sentido, a elaboração do plano de manejo é essencial para a preservação da Unidade de Conservação, pois é nele que se estabelecem as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (art. 2º, XVII, da Lei nº 9.985/2000). (Ministro Humberto Martins)

A Lei do SNUC é lei especial e, portanto, afasta a aplicação das leis gerais de proteção ao meio ambiente. Como tem sido reiteradamente decidido pelo STF (Ext. 795 EU. Julgamento: 8/8/2001. Tribunal Pleno. DJU 6/4/2001, p. 67), a Lei Especial tem preferência sobre a lei geral. “Tratado bilateral, no Brasil, tem hierarquia de lei ordinária e natureza de lei especial, que afasta a incidência da lei geral de extradição” (Ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido da prevalência da lei especial sobre a lei geral vai a jurisprudência do STJ: “A regra geral do CC não prevalece sobre a norma especial do art. 59 do DL 167/67, que disciplina o financiamento concedido para o implemento de atividade rural” (REsp 908.752/MG, Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: 26/10/2012).

A prevalência do Plano de Manejo em UCs sobre outras normas que, em tese, poderiam incidir em determinada área, sobretudo quando se tratar de UCs que admitam a existência de propriedade privada, como é o caso do presente licenciamento ambiental, é expressamente prevista em lei. Tanto é assim que a Lei nº 12.651/2012, no § 16 do artigo 61-A determina que as APPs localizadas em imóveis inseridos nos limites de UCs de Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação da Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do *caput* do artigo 61-A e dos §§ 1º a 15, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do Sisnama, nos termos do que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

O Plano de Manejo é documento de natureza eminentemente técnica através do qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, fica estabelecido seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Trata-se de ato de prerrogativa exclusiva da Administração Pública que, de acordo com a CF, tem a função de instituir áreas que, diante de suas características naturais, merecem proteção especial do Estado.

Nos termos do que estabelece a Lei Federal nº 9.985/2000, que criou o SNUC. O Plano de Manejo de uma APA, por exemplo, tem como um dos seus principais objetivos a compatibilização com o regime protetivo com o regime dominial privado, preservando-se o caráter econômico da propriedade.

Tem sido bastante comum em questões relativas à proteção do meio ambiente e ao ordenamento das UCs de Manejo estabelecidos pelos órgãos de controle ambiental e administradores de UCs, sob o argumento de que o órgão de controle ambiental teria aceitado estudos incompletos ou que não se utilizaram da melhor técnica de análise disponível. O argumento, entretanto, não impressiona.

O estabelecimento dos Planos de Manejos é procedimento administrativo cuja finalidade é analisar as possíveis repercussões da utilização do território, em área submetida a determinado regime de proteção, compatibilizando os diferentes direitos envolvidos na questão concretamente considerada. A maior ou menor liberalidade no uso do solo, tal como estabelecido pelo Plano de Manejo, obviamente está subordinada à categoria da UC concretamente considerada. Assim, o Plano de Manejo de uma UC do grupo de proteção integral, necessariamente, será menos permissivo do que o Plano de Manejo de uma Área de Proteção Ambiental, ou de qualquer outra UC do grupo de uso sustentável.

Não há que se confundir a confecção de um Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação com uma competição acadêmica em busca da ciência mais perfeita ou do *cutting edge* científico. O que se espera da decisão administrativa é que ela seja razoável e que não ultrapasse os limites do poder administrativo.

11.2.2 Áreas protegidas diretamente pela Constituição Federal

Além da proteção genérica que é definida no inciso III do artigo 225, deve ser considerado que a própria CF, no § 4º do capítulo dedicado ao meio ambiente, criou um regime jurídico especial de proteção para determinadas parcelas do território nacional constituído pela a) Floresta Amazônica brasileira, b) a Mata Atlântica, c) a Serra do Mar, d) o Pantanal Mato-Grossense e e) a Zona Costeira.

À exceção do *cerrado* e da *caatinga* e dos *Pampas*, todos os demais grandes ecossistemas brasileiros foram classificados como patrimônio nacional e mereceram menção expressa pelo legislador constituinte. Desnecessário dizer que, evidentemente, a quase totalidade da população brasileira e de suas atividades econômicas está situada no interior dos ecossistemas incluídos no Texto Constitucional. Logicamente que a presença de menção expressa de tais elementos na própria Constituição tem por finalidade determinar ao legislador ordinário que, em sua produção legislativa, estabeleça critérios capazes de assegurar a sustentabilidade dos mencionados ecossistemas sem que, no entanto, sejam vedadas atividades econômicas, sociais e recreativas lícitas que, rotineiramente, venham sendo praticadas nas regiões especialmente protegidas pelo dispositivo inserido na CF. Penso que essa é a única explicação possível para o conteúdo da norma constitucional, pois o direito ambiental não é um Direito que se oponha às atividades econômicas, ao contrário, é um Direito que tem por finalidade a compatibilização do crescimento econômico com o respeito às formas de vida existentes no planeta Terra, a sustentabilidade dos recursos naturais renováveis e não renováveis, com os direitos humanos fundamentais e, consequentemente, com a melhoria da qualidade de vida, desta e das futuras gerações.

Ainda que não constem da CF, na forma de referência expressa, nem a *caatinga* nem o *cerrado* são alheios ao sistema constitucional de proteção ambiental. É da própria essência do artigo 225 que ecossistemas essenciais, e da magnitude dos dois que foram olvidados, não fiquem apartados da especial proteção da CF. Aliás, o esquecimento dos dois ecossistemas mencionados serve para demonstrar, cabalmente, que a tendência adotada pelo constituinte não foi a mais adequada. Mais importante do que publicar uma lista de bens que merecem ser elevados à categoria de patrimônio nacional é, sem dúvida, estabelecer um contorno preciso dos bens, de forma que possam ser enquadrados em tal categoria jurídica. Com isso, assegura-se que, caso a caso, o conceito possa ser preenchido adequadamente.

11.2.3 Patrimônio Nacional

A CF, em seus artigos 219 e 225, § 4º, se utilizou do conceito jurídico de Patrimônio Nacional, cujo conteúdo ainda não foi precisamente estabelecido pela doutrina jurídica.

Patrimônio, na definição de Karl Larenz (1987, p. 405), é uma conjunção de direitos e relações jurídicas concretas em relação a uma determinada pessoa à qual correspondem. O conceito estabelecido pelo Direito Civil será importante para a compreensão do conceito constitucional, mas não pode ser interpretado de forma estrita. Observe-se, contudo, que na ideia de patrimônio nacional ecológico, que efetivamente foi como a CF tratou os ecossistemas anteriormente mencionados, não está presente o sentido de transferência do domínio privado para o domínio público da União nem a transferência de bens pertencentes aos Estados e Municípios para a União. Na hipótese constitucional, existe uma simples manifestação do domínio eminente da nação sobre os bens existentes em seu território, sem que isso implique o esvaziamento do domínio útil ou do domínio pleno. O conceito deve ser operacionalizado, de fato, como um interesse comum de todos, tal qual o dispositivo existente na Lei e que já foi examinado em outro capítulo.

De fato, a Constituição não determinou uma desapropriação dos bens mencionados no § 6º do artigo 225. O que a Constituição fez foi estabelecer a base normativa capaz de justificar cautelas na utilização do ambiente. Essas cautelas especiais justificam-se e fundamentam-se, na medida em que os bens ambientais estão submetidos a um regime jurídico especial, pois a fruição dos seus benefícios genericamente considerados (que é de toda a coletividade) não pode ser limitada pelos detentores de um dos diversos direitos que sobre eles incidem. Não é, contudo, apenas nesse particular que se manifesta o contorno do direito de propriedade. Uma de suas principais características, certamente, é a obrigatoriedade da manutenção e preservação da função ecológica essencial.

11.3 OS DIFERENTES ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos[ETEP] são áreas que, devido às características ambientais especiais que apresentam, devem permanecer tuteladas. A proteção com objetivos diversos não se enquadra no conceito de ETEP, tal qual se depreende das normas do artigo 225 da Constituição Fderal. O grau de tutela é variável, considerando-se o tipo de proteção legal específico de cada uma das áreas consideradas individualmente e a classificação jurídica que tenha sido estabelecida para cada uma delas. Os ETEP podem ser (i) diretamente criados por lei, em tal circunstância são genéricos e se aplicam indistintamente sobre todas as regiões que ostentem as características definidas na lei. O exemplo mais notável de ETEP definidos em lei são as Áreas de Preservação Permanente (APP) previstas no Código Florestal, ou ainda (ii) criadas por ato do poder público, como no caso das unidades de conservação estipuladas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

É importante observar que as unidades de conservação instituídas sobre propriedade privada são típicas, não se admitindo a existência de Unidades de Conservação cujo modelo não tenha previsão legal.³

A proteção pode variar desde a intocabilidade até o uso diário e relativamente intenso. Uma categoria de espaços territoriais protegidos mais importante são as UCs.

A concepção tradicional de espaços protegidos é a de que tais áreas devem ser constituídas, essencialmente, por grandes regiões que devem permanecer isoladas. Tal concepção, contudo, tem sido alvo de severas críticas, pois, em geral, realiza-se a proteção ambiental sem que se leve em conta a proteção da vida humana que tradicionalmente se encontra no seu interior. Essa questão será examinada mais adiante.

As áreas protegidas estão contempladas em diversos diplomas legais. Isso, evidentemente, traz enormes dificuldades para a compreensão e sistematização do papel que cada uma delas deve desempenhar no interior do SNUC.

Espaços Territoriais Especialmente Protegidos	
Por Força de Lei	Por atos do Poder Público
Lei nº 12.651/2012 (artigos 4º, 10, 11, 11 -A, 12 e 25)	Decreto-Lei nº 25/1937 (artigo 1º) Lei nº 6.001/1971 (artigo 17) Lei nº 9.985/2000 (artigos 8º e 14) Decreto nº 4.887/2003 (artigo 2º) Lei nº 12.651/2012 (artigo 6º e 70, II)

11.3.1 Turismo e áreas protegidas

Este tópico objetiva examinar uma suposta contradição entre a aplicação de diversas normas legais voltadas para a proteção ambiental e a implantação de empreendimentos turísticos. Em meu ponto de vista, a legislação voltada para a atividade turística é perfeitamente harmônica com a legislação de proteção ao meio ambiente.

O primeiro ponto a ser examinado é que a atividade turística é considerada de interesse público, pois expressamente prevista na CF em seu artigo 180, cabendo aos entes políticos federados incentivá-lo como um dos instrumentos para que se alcance o desenvolvimento econômico e social sustentável. Coerentemente com o mandamento constitucional, há uma vasta legislação ordinária dispondo sobre a matéria e, especificamente, sobre as relações entre empreendimentos turísticos e sua implantação com o meio ambiente.

Em nível federal, não se pode esquecer a Lei nº 6.513/1977, que trata das linhas gerais a serem observadas para o incentivo do turismo como atividade econômica e suas relações com a proteção ambiental, principalmente em função do fato de que é condição de sobrevivência da atividade turística a boa qualidade do meio ambiente. Destarte, a Lei estabeleceu as chamadas Áreas Especiais de Interesse Turístico e os Locais de Interesse Turístico. Conforme o disposto no artigo 1º do diploma normativo, consideram-se de interesse turístico as Áreas Especiais e os Locais instituídos na forma da presente Lei, assim como os bens de valor cultural e natural, protegidos por legislação específica, e especialmente: (i) os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; (ii) as reservas e estações ecológicas; (iii) as áreas destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis; (iv) as manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorram; (v) as paisagens notáveis; (vi) as localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de atividades recreativas, desportivas ou de lazer; (vii) as fontes hidrominerais aproveitáveis; (viii) as localidades que apresentem condições climáticas especiais; (ix) outros que venham a ser definidos, na forma da lei.

O motivo é simples. Os seres humanos quando se deslocam com o objetivo de lazer, quase que necessariamente o fazem em direção de locais que (i) sejam belos, (ii) se possa praticar esportes ou atividades culturais, (iii) possam servir de repouso. Nesse contexto, o meio ambiente equilibrado é fundamental. Portanto, já no ano 1977, a Lei tinha uma clara vocação para combinar a atividade da indústria do turismo com a proteção do ambiente natural e cultural. Tal conclusão resulta mais evidente com a leitura do artigo 3º da Lei para o qual [á]reas Especiais de Interesse Turístico são trechos contínuos do território nacional, inclusive suas águas territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural, e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico.

Os objetivos das Áreas de Interesse Turístico estão tipificados no artigo 11 da Lei nº 6.513/1977, sendo os seguintes: (i) promover o desenvolvimento turístico; (ii) *assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural*; (iii) *estabelecer normas de uso e ocupação do solo*; e (iv) orientar a alocação de recursos e incentivos necessários a atender aos objetivos e diretrizes da Lei. Assim, uma área de interesse turístico tem por finalidade legal a integração entre a atividade econômica [turismo] com a proteção do meio ambiente.

É indiscutível que a Lei nº 6.513/1977 de certa forma antecipou as diretrizes que, posteriormente, seriam traçadas pela PNMA estabelecida pela Lei nº 6.938/1981. Aliás, merece ser registrado que o Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, instituído pela Lei nº 10.165/2000, considera pequeno o potencial poluidor da atividade turística, inclusive quando se tratar de parques temáticos. Posteriormente, e já na vigência da Constituição de 1988, a União Federal editou a Lei Federal nº 11.771/2008, mediante a qual se buscou estabelecer as diretrizes de uma Política Nacional de Turismo que fosse capaz de compatibilizar as demandas decorrentes das necessidades econômicas com a urgência do desenvolvimento sustentável, aí incluída a geração intensiva de empregos, como é o caso da atividade turística. Na forma do comando legal, a Política Nacional de Turismo tem por objetivos: (i) democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral; (ii) reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição de renda; (iii) ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico brasileiro; (iv) estimular a criação, a consolidação e a difusão dos

produtos e destinos turísticos brasileiros, com vistas a atrair turistas nacionais e estrangeiros, diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento econômico e social.

11.3.1.1 Unidades de Conservação, Código Florestal e a aplicação da legislação especial

É importante observar que o legislador, atento às potencialidades das UCs para a atividade turística, estabeleceu no Parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.771, que quando se tratar de UCs, o turismo será desenvolvido em consonância com seus objetivos de criação e com o disposto no plano de manejo da unidade. Logo, o legislador estabeleceu de forma clara e inquestionável que o Plano de Manejo é o instrumento técnico – jurídico apto para definir os parâmetros de ocupação do solo a ser utilizado pela atividade turística em UCs. Justifica-se a medida uma vez que as normas gerais devem ceder passo à norma específica e particular. Uma rápida leitura da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos revela que não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, sendo certo que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Vê-se que a CF impôs ao legislador ordinário a obrigação de identificar, em todo o território nacional, áreas que por seus atributos ambientais são merecedoras de *proteção especial*. Uma vez identificadas, tais áreas se constituem em unidades de conservação, as quais se dividem em dois grandes grupos: (i) uso sustentável e (ii) proteção integral. Ora, constituídas as UCs elas passam a se reger pelas normas legais contidas na Lei do SNUC. Se antes da Lei nº 9.985/2000 se poderia, em tese, admitir que o Código Florestal fosse aplicável às Unidades de Conservação; após a Lei do SNUC, *o tema ficou totalmente afastado da lei geral de proteção das florestas e demais formas de vegetação, conforme se percebe do artigo 60 da Lei do SNUC que revogou os arts. 5º e 6º da Lei nº 4.771/1965; o art. 5º da Lei nº 5.197/1967; e o art. 18 da Lei nº 6.938/1981.*

Não há que se falar em convivência entre proteção especial e proteção geral em um mesmo espaço territorial, até mesmo porque elas podem se contradizer. Figure-se a hipótese da existência de APPs no interior de um PN. Em tese poderíamos admitir a construção de usinas nucleares em seu interior, pois a supressão de áreas de preservação permanente é admitida para projetos de energia.

Não bastasse isso, há legislação especial voltada para a atividade turística, como já se viu, a qual especificamente contempla as hipóteses de turismo ecológico, indicando que a atividade deve ser feita, conforme determinado pelo Plano de Manejo da UC. Aliás, no particular há interessante decisão proferida pelo TRF da 2ª Região que, expressamente, admite a atividade turística em APPs

O Poder Público, por imposição constitucional, tem o dever de proteger a flora nacional e adotar as medidas necessárias para impedir a exploração das florestas de preservação permanente. O dever de proteção ambiental, que cabe ao Estado, não o exonera de outro dever: o de respeitar o regime de propriedade. Ainda que se considere que, já à época da compra do imóvel objeto dos autos, seu proprietário estivesse impedido de explorá-lo economicamente, por encontrar-se situado em área de preservação ambiental, certo é que tal situação não retira o valor econômico da cobertura vegetal ali existente e, consequentemente, o direito do desapropriado a justa indenização. Embora desde à época da aquisição da propriedade, o terreno não pudesse ser desmatado, por já pertencer a reserva florestal, o desapropriado teve frustradas outras eventuais pretensões, como usufruir, a seu gosto, de toda a riqueza natural ali existente e beneficiar-se de frutos e rendimentos outros, que a área poderia lhe proporcionar, por exemplo, a exploração do turismo. A jurisprudência vem entendendo que, mesmo em caso de impossibilidade legal de exploração da cobertura vegetal, deve ser considerado o potencial econômico que ela representa para o patrimônio do proprietário. Considerando que a cobertura vegetal significa um plus ao valor da propriedade, decerto há que haver indenização não só pelo imóvel, terra nua, como por sua floresta, apurável em liquidação, razão por que o provimento há de ser parcial. No que respeita aos honorários advocatícios, não há falar-se em sucumbência recíproca, em razão da procedência total do pedido autoral, mantendo-se o percentual de 5% (EAC 198851010209665. EAC – Embargos Infringentes na Apelação Cível 310508. Desembargador Federal Fernando Marques. 3ª Seção. DJU 16/1/2006, p. 65).

11.3.2 Breve histórico da legislação

O primeiro parque nacional brasileiro foi criado no ano de 1937, no antigo Estado do Rio de Janeiro, em Itatiaia. Tal criação se fez com base em dispositivos legais constantes da CF de 1934. Em 1943, mediante a expedição do Decreto Legislativo nº 3/1948, foi aprovada a *Convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos países da América*, que introduziu em nosso sistema jurídico outras categorias de unidades de conservação. Em 1965, surgiu a Lei nº 4.771, que estabeleceu novos critérios para o estabelecimento de áreas protegidas. A grande inovação foi a diferenciação entre áreas que admitiam a utilização e áreas que a inadmitiam. Em geral, a ideia inicial que preside o estabelecimento das unidades de conservação é a da criação de santuários de flora e fauna. Acirradas críticas vêm sendo opostas a tais concepções, pois, não raras vezes, nas áreas destinadas à preservação, existem comunidades tradicionais que são grandemente prejudicadas pelo estabelecimento de áreas nas quais a presença de comunidades humanas não deve ser admitida. Essa situação começa a ser modificada com o estabelecimento de uma nova mentalidade que busca, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente e as populações que habitam no interior das áreas protegidas (KEMPF, 1993, p. xvii).

A preocupação manifestada teve a oportunidade de ser bem examinada pelo 4º Congresso Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, realizado em Caracas, no ano de 1992. No Brasil, uma das respostas que têm sido dada às questões mencionadas é o estabelecimento das chamadas Reservas Extrativistas e outras unidades de conservação e uso sustentável.

11.4 AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidades de conservação são espaços territoriais que, por força de ato do Poder Público, estão destinados ao estudo e preservação de exemplares da flora e da fauna. As UCs podem ser públicas ou privadas. O estabelecimento de unidades de conservação foi o primeiro passo concreto em direção à preservação ambiental.

As UCs no Brasil estão tratadas em lei federal especificamente voltada para o tema e que será o objeto principal deste capítulo.

11.4.1 Unidades de conservação e direitos de propriedade constitucional

A CF estabelece um complexo relacionamento entre diferentes direitos individuais e o direito de proteção ao ambiente, sobretudo com o direito de propriedade privada, dando a esse último um novo papel na proteção ambiental. A propriedade tem sido considerada como um “direito terrível” (RODOTÁ, 1986), pois direito de exclusão.

O Constitucionalismo brasileiro, desde 1934, tem a adotado a fórmula da *propriedade-função*, sem retirar-lhe o caráter de propriedade capitalista (RODOTÁ, 1986, p. 223). A Constituição de 1988 representa uma resposta que a sociedade deu à chamada “crise ambiental” da qual se fez consciente na segunda metade do século XX.

É importante consignar que a chamada função social de propriedade é uma formulação aberta que pode dar margem a múltiplas interpretações que, em não poucas vezes, esvaziam o conteúdo econômico do direito de propriedade, desnaturando-o completamente.

11.4.1.1 Princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e ao direito de propriedade

A Constituição da República é aberta por *princípios fundamentais*, cuja finalidade é servir de base para a elaboração, fundamentação e aplicação dos preceitos constitucionais e, sobretudo, como comando ao legislador infraconstitucional e ao Administrador. Destaque-se aqueles que dizem respeito à (i) *dignidade da pessoa humana*, (ii) *aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa*. Sem esquecer os relativos a (i) garantir uma sociedade livre, justa e solidária, (ii) *promover o*

desenvolvimento nacional, (iii) erradicar a pobreza e promover o bem de todos.

O Administrador, ao dar cumprimento ao inciso II do § 1º do artigo 225 da CF deve levar em conta as questões acima mencionadas e, especialmente, fazê-lo em conformidade com os subprincípios constitucionais especialmente voltados para a Administração Pública, tal como estabelecidos pelo *caput* do artigo 37 da CF. Aqui devem ser destacados os da eficiência administrativa, impessoalidade e legalidade. A Administração deve buscar os seus fins de forma a *causar menos prejuízos para o particular, gastar menos recursos públicos e fazê-lo no menor tempo possível*.

A lei do SNUC (Lei nº 9.985/2000), de forma expressa, estabelece mecanismos capazes de assegurar a participação cidadã na criação de unidades de conservação, bem como de não onerar o indivíduo excessivamente, impondo-lhe o desapossamento de seus bens sem motivos relevantes. Ela determina seja ouvido o público quando da instituição de UCs por parte do poder público, artigo 22, §§ 2º e 3º. Como afirmam Leite e Ferreira (2010, p. 126), “o cidadão deve, nesse sentido, empenhar-se na consecução desse direito fundamental, participando ativamente das ações voltadas para a proteção do meio ambiente”.

A atuação do Estado para a implementação de direitos constitucionalmente assegurados, sobretudo quando se trata de direitos que são, simultaneamente, individuais e coletivos – os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são deles um notável exemplo –, deve ser feita de forma equilibrada e, na justa medida do necessário, sobretudo quando implicam no desequilíbrio entre as cargas sofridas pela coletividade e pelo indivíduo, fazendo com que os ônus recaiam majoritariamente sobre o indivíduo, em benefício da coletividade, ou daquilo que o Estado entende como coletividade. No particular, justifica-se a limitação, especialmente, devido ao fato de que, no caso concreto da definição de áreas a serem especialmente protegidas, a atividade estatal se caracteriza por uma *prestação positiva* e não meramente por uma inação. É da própria natureza da prestação positiva que, caso não seja limitada ao mínimo estritamente necessário, que ela se desdobre em arbítrio acobertado pelo manto da *discrecionalidade administrativa*, fundada em juízos de conveniência e oportunidade que, em última instância, decorrem de um programa político da maioria, ou na *interpretação* de tal programa pelos encarregados de implementá-lo. Relembre-se Larenz (1985, p. 145):

El principio de la proporcionalidad, en su sentido de prohibición de la excesividad, es un principio del Derecho justo que deriva inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de “moderación” y de “medida justa” en el sentido de equilibrio. Negativamente, de los conceptos citados resulta una prohibición de excesividad, que siempre ha regido como exigencia de legislador que debe establecer un Derecho justo. Su consagración como principio de rango constitucional tiene la importancia práctica de que desde ahora tienen que examinar si se ha observado o no tanto los funcionarios de la Administración (en el ámbito de “Administración intervencionista”) como en todo caso los jueces. Reaparece así la función negativa del principio, que está en primer plano de su formulación como “prohibición de excesividad.

A Lei nº 9.985/2000 estabeleceu um conjunto de normas *vinculantes juridicamente* que coíbem a prática do excesso ora mencionados e que, se bem observados, impedem que a criação arbitrária de unidades de conservação, em especial aquelas do grupo de proteção integral, possa redundar em danos sociais maiores do que os benefícios de sua criação. Ao nível do atual debate jurídico, o cerne da proibição de excesso tem se limitado ao aspecto pecuniário da questão, com a firme decisão das Cortes judiciais em determinar o pagamento de indenizações quando da criação de algumas modalidades de unidades de conservação do grupo de proteção integral, sem a transferência do domínio, sem a compensação para o particular. Contudo, penso que os limites interpretativos da Constituição de 1988 possam ser alargados de forma significativa, trazendo como resultado uma diminuição no gasto de recursos públicos e privados, bem como aumentando o grau de segurança jurídica, pressuposto fundamental do Estado de Direito, assentado em bases sólidas.

A proteção do meio ambiente é um dos temas constitucionais nos quais se expressa o chamado *princípio da solidariedade* entre os integrantes da sociedade nacional, assegurando-se a todos a possibilidade de contribuir para o bem comum. Contudo, a sociedade humana, e o Estado que expressa a sua forma organizada, é falha, necessitando, pois, de mecanismos que sejam aptos a coibir os abusos que a Administração pratique contra o particular; da mesma forma como se fazem necessários mecanismos capazes de coibir os abusos do particular contra os direitos e interesses da coletividade. Como se sabe, a não utilização da propriedade de forma a garantir o exercício de sua função social pode dar margem à aplicação da chamada *desapropriação – sanção*, ou seja, aquela com características de pena imposta pela coletividade sobre quem, ao não utilizar adequadamente a sua propriedade, está onerando excessivamente o todo. Todavia, a desapropriação sanção deve ser feita em observância ao chamado devido processo legal, de forma que se possa assegurar ao cidadão o direito de ampla defesa (STF. MS 22164/SP. Tribunal Pleno. Julgamento: 30/10/1995. DJU 17/11/1995, p. 39206).

11.4.1.2 Criação de unidades de conservação e vinculação

O artigo 22 da Lei do SNUC define normas *vinculantes* para a Administração Pública quando do estabelecimento de uma unidade de conservação, à exceção das EEs ou das Reservas Ecológicas, para as quais não há obrigatoriedade de realização da consulta tratada pelo § 2º do artigo 22. Justifica-se a exigência das formalidades legais, pois vigente a cláusula constitucional do devido processo legal e da ampla defesa. Na consulta à comunidade é imprescindível a oitiva dos proprietários cujos domínios possam vir a ser afetados pela nova unidade de conservação, sobretudo quando se tratar de unidades de conservação do grupo de proteção integral. Em não poucas oportunidades, a decretação de unidades de conservação é feita com a “consulta da comunidade”, muito embora os proprietários de imóveis situados no interior da área a ser “protegida” não sejam ouvidos. De fato, há uma tendência da Administração Pública em considerar como “comunidade” a fração mais ativa da população que, normalmente, se agrupa em associações de *advocacy* com grande capacidade de interlocução junto ao poder público, mas que em tantas vezes representam-se a si mesmas. A título de exemplo podemos indicar a criação de diversas áreas de proteção ambiental no Município do Rio de Janeiro (2010, p. 10) para as quais “*não constava na documentação das APAs do Município criadas após o início da vigência do SNUC, estudos técnicos e consulta pública, recomendada pelo parágrafo 2º do artigo 22 da Lei nº 9.985/2000*”.

O STF, de forma bastante afirmativa, tem se posicionado quanto à nulidade da criação de UCs sem a necessária consulta pública e estudos técnicos prévios; por sua vez, o STJ não tem reconhecido a necessidade da realização de (i) estudos técnicos e (ii) consultas públicas prévias ao ato de criação. De fato, o STF, ao julgar o MS 23800 do Mato Grosso do Sul, entendeu que: 1. *Comprovada nos autos a realização de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado com vistas a atender à exigência do § 2º do artigo 22 da Lei 9.985/00.* 2. *Criação do Parque. Manifestação favorável de centenas de integrantes das comunidades interessadas, do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente – Abema.* 3. *Parecer técnico, do MMA, que concluiu pela viabilidade e conveniência da destinação ambiental da área, dada a necessidade de se proteger o ecossistema local, revestido de significativa mata atlântica. Zona de confluência entre o Pantanal, o Cerrado e o Chaco, onde se encontram espécies vegetais raras, ameaçadas de extinção (Ministro Maurício Corrêa).* A Corte Constitucional que, uma vez regulamentado o artigo 22 da Lei nº 9.985/2000, tornou obrigatória [PBA] a realização de (i) estudos técnicos e (ii) consultas públicas previamente à criação dos Parques Nacionais: “*Quando da edição do Decreto de 27.02.2001, a Lei nº 9.985/00 não havia sido regulamentada. A sua regulamentação só foi implementada em 22 de agosto de 2002, com a edição do Decreto nº 4.340/02. O processo de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não pode substituir a consulta exigida na lei. O Conselho não tem poderes para representar a população local. Concedida a segurança, ressalvada a possibilidade da edição de novo decreto* (MS 24184/DF, Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJU 27/2/2004, p. 22).

Mesmo nos casos de ampliação, a Corte Suprema tem sido firme no sentido de que é exigível a realização prévia de (i) estudos técnicos e (ii) consulta pública, sob pena de nulidade do ato de criação ou ampliação: *Unidade de conservação. Estação ecológica. Ampliação dos limites originais na medida do acréscimo, mediante decreto do Presidente da República. Inadmissibilidade. Falta de estudos técnicos e de consulta pública. Requisitos prévios não satisfeitos. Nulidade do ato pronunciada. Ofensa a direito líquido e certo. Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66, §§ 2º e 6º, da Lei nº 9.985/2000. Votos vencidos. A ampliação dos limites de estação ecológica, sem alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não pode ser feita sem observância dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta pública* (MS 24665/DF. Ministro Cezar Peluso, DJU 6/10/2006, p. 33.).

O STF, em decisão que tem sido pouco abordada, manifestou-se no sentido de que a mera existência de decreto criando parque não é suficiente para sua criação:

É que a implantação do Parque Nacional Mapiaguri – assim como a de toda unidade de proteção integral – não se consuma com o simples decreto de criação, e, muito menos, a desapropriação, com a só declaração de utilidade pública das áreas privadas contidas no perímetro. Não custa, aliás, advertir que a criação dessas unidades pode significar tão só limitações administrativas que não impliquem transferência de domínio, nos casos em que não haja esvaziamento do conteúdo econômico do direito de propriedade. E, como essa poderá ser a hipótese, não há falar em previsão orçamentária para expropriação ainda não efetivada (MC/DF 27623, Ministro Cezar Peluso, DJE-210, divulg. 5/11/2008, public. 6/11/2008).

Merece ser afirmado que, infelizmente, tem sido prática muito comum que entes públicos decretem a “criação” de parques – nas três esferas de Poder – e não implementem as medidas necessárias para a real constituição da unidade de conservação, muito embora desenvolvam atividades administrativas como se, de fato, as áreas tivessem sido desapropriadas e o domínio privado houvesse sido transferido para o público. Assim, são estabelecidas proibições para as atividades particulares que ultrapassam os limites do artigo 22-A da Lei do SNUC, praticando um “desapossamento branco” dos proprietários. A medida é, certamente, ilegal e se caracteriza como abuso de poder ou de autoridade, conforme o caso. Veja-se que, segundo dados da *International Union for Conservation of Nature*, a maior parte dos parques brasileiros está ocupada por população permanente, o que implica em uma necessidade de reavaliar a instituição de tais parques, ou pelo menos de implantá-los efetivamente.⁴

11.4.1.2.1 A criação das unidades de conservação

A CF, em seu artigo 225, § 1º, III, não definiu com precisão quais as condições necessárias para a criação de UCs, limitando-se a estabelecer um comando geral para o Poder Público: “*em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos*”. Cuida-se de obrigação de fazer, cujo destinatário é a Administração Pública. Ao mesmo tempo, o Constituinte criou uma *reserva de lei* sempre que se cogite de medidas cujo objetivo seja a “*alteração ou supressão*” das Unidades de Conservação regularmente constituídas e implantadas. Do Texto Constitucional podemos extrair os seguintes requisitos: (i) *ato do poder público*, (ii) *espaço territorial e seus componentes [atributos ecológicos]*, (iii) *proteção especial*. Como foi bem observado por Benjamin (2001, p. 291), os requisitos são exigíveis cumulativamente, não bastando a presença de um deles para que a unidade de conservação possa ser considerada criada e, sobretudo, instalada. Contudo, assim como em outros setores do Direito Ambiental, há uma “disputa” entre Poderes para a criação de Unidades de Conservação, havendo mesmo aquelas criadas por lei, cuja natureza jurídica, no entanto, é de ato administrativo, pois dotada de efeitos concretos, “*carente da necessária generalidade e abstração*” (STF. ADI 3652/RR. Ministro Sepúlveda Pertence. Tribunal Pleno. Julgamento: 18/12/2006. DJU 16/3/2007, p. 377). A solução legislativa, inclusive, não contempla os elementos legais necessários para a instituição de uma unidade de conservação haja vista que a Lei do SNUC determina em seu artigo 22 que: (i) a criação de uma UC deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento; (ii) no processo de consulta, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. Assim, os proprietários eventualmente existentes em região que seja declarada UC ficarão sem o direito de impugnar sua criação.

As UCs são criadas por ato do poder público, de acordo com expressa determinação constitucional, assim, ao administrador não é possível deixar de criar “*em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos*”.

O Constituinte *não deixou margem de discricionariedade ao Administrador* que, uma vez identificados os espaços dignos de proteção, deve estabelecer a unidade de conservação capaz de dar a melhor proteção possível ao ambiente, levando em consideração que o bem de valor ambiental pode estar submetido ao regime de direito público ou de direito privado. Note-se que a compatibilização dos regimes jurídicos público e privado não é simples, motivo pelo qual o legislador ordinário, ao editar a Lei nº 9.985/2000, criou um naipe de variadas unidades de conservação, o qual se divide em dois blocos principais: (i) as do grupo de proteção integral e (ii) as do grupo de uso sustentável. Tanto umas, quanto outras, podem estar sujeitas aos regimes de direito privado ou direito público.

Parece claro que, após realizar os estudos previstos em lei e concluindo que a área merece proteção especial, ao administrador cabe, única e exclusivamente, decretar o regime especial de proteção consistente na instituição de uma unidade de conservação. Daí surge a candente questão do orçamento capaz de materializar concretamente a determinação do Constituinte; dado que os recursos públicos são escassos e necessitam ser divididos por diferentes setores da vida em sociedade, a utilização do regime de direito privado para a proteção do meio ambiente é uma fórmula criativa para, ao mesmo tempo, (i) implementar a obrigação de criar áreas especialmente protegidas, (ii) possibilitar que o cidadão atue ativamente na proteção ambiental e (iii) não criar pressão excessiva sobre os recursos públicos.

Em primeiro lugar, (i) há que se registrar que a relação e UCs postos à disposição do administrador corresponde ao atual nível de compreensão das diferentes modalidades de proteção necessárias para que se possa atingir, simultaneamente, os objetivos de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico que, se assim feito, tem-se por sustentável. Em seguida, há que se compatibilizar os direitos da coletividade em usufruir de um meio ambiente equilibrado com os direitos constitucionais dos indivíduos, relativos à propriedade. Assim, sempre que ecologicamente possível garantir a proteção ambiental sem a violação aos direitos de propriedade pública ou privada, tal fórmula deve ser *obrigatoriamente adotada pela Administração*.

A administração deve instituir a unidade de conservação que, atingindo os objetivos de proteção identificados nos estudos técnicos, seja *a menos onerosa para o contribuinte, com a menor mobilização de recursos técnicos, econômicos e financeiros possíveis*. Essa é uma determinação da CF, como se pode concluir do *caput* de seu artigo 37. Cuida-se de uma técnica elementar de administração pública que busca a obtenção dos melhores resultados para a aplicação de recursos escassos.

A regulamentação da Lei nº 9.985/2000, foi feita pelo Decreto nº 4.340/2002. Tal regulamentação limitou-se aos artigos 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55. O decreto estabeleceu os critérios a serem aplicados para a criação das UCs.

Na forma do artigo 2º do decreto, o ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar i) a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração; ii) a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; iii) a população tradicional residente, quando couber, no caso das Flonas, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e iv) as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas.

11.4.1.3 Conceitos normativos aplicáveis às unidades de conservação

Um fator de indiscutível valor da Lei nº 9.985/2000, é a definição de conceitos normativos aplicáveis às unidades de conservação, pois não há qualquer dúvida de que as denominações que até então vinham sendo aplicadas eram bastante confusas e muito pouco claras. Com efeito, conceitos como Estação Ecológica, Rebio e outros não raras vezes se sobrepunham, acarretando prejuízo para a proteção ambiental.

Em termos legais, *unidade de conservação é espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção*. Já conservação da natureza é definida como

o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

A diversidade biológica é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Os recursos ambientais foram definidos legalmente como: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Foi estabelecido o conceito normativo de “preservação”, que é o *conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das*

espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Existem, igualmente, os seguintes conceitos normativos (Lei nº 9.985/2000): i) proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; ii) conservação *in situ*: conservação de ecossistemas e *habitats* naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características; iii) manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas; iv) uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais; v) uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; vi) uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável; vii) extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis; viii) recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; ix) restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original; x) zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz; xi) plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; xii) zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e xiii) corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.

11.4.1.4 Objetivos do SNUC

O SNUC, na forma do artigo 3º da Lei nº 9.985/2000, é constituído pelo conjunto das UCs federais, estaduais e municipais. Os seus objetivos são os seguintes: i) contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; ii) proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; iii) contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; iv) promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; v) promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; vi) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; vii) proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; viii) proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; ix) recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; x) proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; xi) valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; xii) favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; xiii) proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

A administração do SNUC observará as seguintes diretrizes: i) garantias que assegurem que, no conjunto das unidades de conservação, estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, *habitats* e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; ii) garantias que assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação; iii) garantias que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação; iv) busca de apoio e cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação; v) incentivo às populações locais e às organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; vi) garantia, quando possível, da sustentabilidade econômica das unidades de conservação; vii) permissão de uso das unidades de conservação para a conservação *in situ* de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres; viii) garantia de que o processo de criação e gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais; ix) consideração das condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; x) garantia para as populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação de meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; xi) garantia de alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos; xii) busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; e xiii) proteção de grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.

11.5 RESERVA NACIONAL DE COBRE E SEUS ASSOCIADOS

O esquecido Decreto nº 89,404, de 24 de fevereiro de 1984 instituiu a chamada Reserva Nacional de Cobre e seus associados localizada nos Estados do Pará e no então território federal do Amapá. Tal área foi constituída especificamente para o desenvolvimento de atividades de mineração, sendo certo que pelo artigo 2º do Decreto, “[o]s trabalhos de pesquisa destinados à determinação e avaliação das ocorrências de cobre e seus associados na área [...] caberão, com exclusividade, à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, que os executará com recursos próprios ou oriundos de convênios firmados com o Grupo Executivo para a Região do Baixo Amazonas – GEBAM”.

Conforme definido no Decreto as concessões de lavra no interior da reserva somente poderiam ser outorgadas às empresas que entrassem em acordo com a CPRM. O Decreto nº 89.404/1984 foi revogado pelo Decreto nº 9.142, de 22 de agosto de 2017 que extinguiu a Reserva Natural de Cobre o qual estabeleceu expressamente que tal extinção “**não afasta a aplicação de legislação específica sobre proteção da vegetação nativa, unidades de conservação da natureza, terras indígenas e áreas em faixa de fronteira**”.

Assim, a revogação da RENCA, em termos legais não implicou em nenhuma flexibilização da proteção jurídica da área, pois como foi visto, a RENCA era uma reserva de área para a exploração econômica por parte da CPRM. Assim, a RENCA não é, nem nunca foi uma unidade de conservação, muit embora em seu interior existissem várias unidades de conservação e terras indígenas. Conforme foi apurado, a extinção da RENCA somente admitiria as atividades de mineração em cerca de 15% a 30% da área.⁵

O principal argumento contra a extinção da RENCA foi baseado na suposição de que a reserva estaria tutelada pelo inciso III do § 1º do artigo 225⁶ da Constituição Federal segundo o qual a alteração de espaços territoriais especialmente protegidos *somente pode ocorrer por lei*.⁷ Na verdade, no interior da RENCA existem os seguintes ETEP:

ETEP no interior da RENCA	
Unidade	Criação

Parna Montanhas do Tumucumaque	Dec s/nº de 22 de agosto de 2002
Reserva Extrativista Rio Cajari	Dec nº 99.145 de 12 de março de 1990
Reserva Biológica Estadual Maicuru	Decreto Estadual no. 2610, de 04/12/2006 (Pará)
Floresta Estadual do Paru	Decreto nº 2.608, de 04/12/2006 (Pará)
Floresta Estadual do Amapá	Lei estadual nº1.028, de 12 de julho de 2006 (Amapá)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Rio Iratapuru	Lei ordinária nº 392, de 11 de dezembro de 1997 (Amapá)
Terra Indígena Rio Paru D´Este	Homologada – 03/11/1997 (Pará)
Terra Indígena Waiãpi	Homologada Decreto s/n – 24/05/1996 (Amapá)

A RENCA, muito embora englobe ETEP, não pode se enquadrar em tal categoria, pois não foi instituída com a finalidade específica de proteção ambiental, mas como estoque de minerais para exploração econômica. Após a sua instituição foram, aí sim, criadas diferentes formas de ETEP em seu interior. As pressões conservacionistas, todavia fizeram com que o Decreto nº 9.142, de 22 de agosto de 2017 fosse revogado pelo Decreto nº 9.159, de 26 de setembro de 2017, revigorando-se expressamente o decreto instituidor da RENCA.

11.5.1 Órgãos integrantes do SNUC

Integram o SNUC os seguintes órgãos, a) Órgão consultivo e deliberativo: o Conama, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema; b) Órgão central: o MMA, com a finalidade de coordenar o Sistema; e c) Órgãos executores: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.

O parágrafo único do artigo 7º admite que, excepcionalmente, o SNUC poderá ser integrado, a critério do Conama, por unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista na lei do SNUC e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Trata-se de um reconhecimento da diversidade de situações ecológicas do país, bem como dos diferentes níveis de organização administrativa dos diversos entes federativos, confirmando a tese de que o SNUC é antes federal do que nacional.

11.5.2 As unidades de conservação: seus diferentes tipos e funções

As UCs são divididas em dois grandes grupos, (i) Proteção Integral e (ii) Uso Sustentável. As de Proteção Integral têm por objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria lei que estabeleceu o SNUC. As *de Uso Sustentável* destinam-se à compatibilização entre a conservação da natureza e o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

11.5.2.1 Unidades de proteção integral

O grupo de proteção integral é composto por (i) Estações Ecológicas E (ii) Reservas biológicas; (iii) Parques Nacionais; (iv) Monumento Natural; e (v) Refúgios da Vida Silvestre.

As **Estações Ecológicas** têm como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. São áreas de posse e domínio públicos, no caso de que a sua instituição englobe áreas privadas estas deverão ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

A visitação pública não será autorizada, salvo quando tiver objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica, igualmente, depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

As alterações dos ecossistemas somente serão admitidas nas hipóteses de (i) medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; (ii) manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; (iii) coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; e (iv) pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por intermédio da Resolução nº 02, de 18 de abril de 1996 estabeleceu que “[p]ara fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de *relevante impacto ambiental*, assim considerado pelo órgão ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA,⁸ terá como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o empreendedor.”

*Elas foram consideradas áreas de relevante interesse turístico pelo inciso II do artigo 1º da Lei nº 6.513/1977. Atualmente constam 98 Estações Ecológicas cadastradas no cadastro nacional de unidades de conservação.*⁹

A **Reserva Ecológica** é um tipo de unidade de conservação que não foi mantido pelo SNUC, pois a Lei nº 9.985/2000 delas não trata. Conforme expressamente determinado pelo artigo 55 da lei do SNUC elas devem ser reavaliadas e incluídas na nova classificação estabelecida pelo SNUC. Penso, entretanto, que não houve uma revogação ou cancelamento das Reservas Ecológicas preexistentes ao novo sistema. Em minha opinião, as Reservas Ecológicas que tivessem sido instaladas, na forma da lei, permanecem existentes, devendo contudo ser feita a reclassificação adequada. Os efeitos são, portanto, *ex nunc*, isto é, aquelas Reservas Ecológicas que não foram regularmente instaladas não mais poderão sê-lo, ante a inexistência da modalidade de UC. É uma categoria que tende a desaparecer. Não consta nenhuma cadastrada no cadastro nacional de unidades de conservação¹⁰

A **Reserva Biológica** é uma unidade de conservação cujo objetivo é a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Assim como a EE, ela é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A visitação pública é, igualmente, proibida, salvo aquela que tenha objetivo educacional, conforme definição regulamentar. As atividades de pesquisa científica dependem de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. As Rebios estavam previstas no artigo 5º da Lei nº 4.771/65, que foi expressamente revogado pelo artigo 60 da Lei nº 9.985/2000. Atualmente estão cadastradas 64 Reservas Biológicas no cadastro nacional de unidades de conservação.¹¹

Os **parques**, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação *in situ*. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento

de verdadeiras santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas.

A primeira reserva natural foi estabelecida na França, no ano de 1853, em Fointainebleau. Aquela reserva foi oficializada em decreto de 13 de agosto de 1861. O ato oficial foi consequência de um movimento organizado por um grupo de artistas e intelectuais, cuja finalidade era a de preservação da mencionada área natural. Em 1872 foi criado o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Em 1895 foi criado na atual África do Sul a reserva que daria origem ao Parque Kruger, oficialmente criado em 1926.

No Brasil, o primeiro Parque Nacional foi o de Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro, criado pelo Decreto nº 1.713/1937. O Decreto legislativo nº 3/1948, que aprova a convenção para a proteção da flora e da fauna e das belezas cênicas naturais dos países da América (artigo 1º), estabeleceu que parques nacionais são regiões estabelecidas para a proteção e conservação das belezas cênicas naturais e da flora e fauna de importância nacional das quais o público pode aproveitar-se melhor ao serem postas sob a superintendência oficial.

O regulamento dos Parques Nacionais determina que eles sejam estabelecidos em áreas relativamente extensas nas quais: i) haja um ou mais ecossistemas pouco ou não alterados pela ação do homem, onde as espécies vegetais e animais, os sítios geomorfológicos e os *hábitats* ofereçam interesses especiais dos pontos de vista científico, educativo e recreativo ou onde existam paisagens naturais de grande valor cênico; ii) tenha o Governo Federal tomado medidas para impedir ou eliminar, o mais breve possível, as causas daquelas alterações e para proteger efetivamente os fatores biológicos, geomorfológicos ou cênicos que determinaram a criação do Parque Nacional; iii) dependa a visita de restrições específicas, mesmo para propósitos educativos, culturais ou recreativos.

O **Parque Nacional** tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É, portanto, uma unidade de conservação aberta à visitação pública, mediante normas previamente estabelecidas. É de se observar, contudo, que o seu regime de visitação é, em tese, mais amplo e liberal do que o vigente em outras unidades de conservação integral. Ele é estabelecido em áreas públicas, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

Um dos problemas mais cruciais, que estão relacionados à implantação de unidades de conservação, é o da tensa e difícil relação entre a proteção de determinadas áreas ecologicamente relevantes e as populações que, tradicionalmente, ocupam tais regiões. Faço um parêntese para observar que, aqui, “tradicionalmente” não tem o sentido de ancestralmente ou imemorialmente. Não. Tradicionalmente, refere-se a um modelo de economia não monetarizada, sustentada em formas não diretamente vinculadas ao modelo de mercado e que, não raras vezes, é desenvolvida de forma comunitária. A lei do SNUC admite que somente nas unidades de uso sustentável possam coexistir populações tradicionais e formas jurídicas qualificadas de proteção. Quando não se tratar da criação de unidades de conservação, ou mesmo de “regularização fundiária” de unidades de proteção integral, as populações tradicionais nelas residentes devem ser reassentadas. Para tal, o Decreto nº 4.340/2002, em seus artigos 35/39, estabeleceu os contornos mínimos dos mecanismos capazes de promover o reassentamento de tais populações. Como pretendo demonstrar, o decreto, no particular, está fundado sobre equívocos bastante sérios.

Estabelece o artigo 35 que o *processo indenizatório de que trata o art. 42 da Lei nº 9.985/2000, respeitará o modo de vida e as fontes de subsistência das populações tradicionais*. A definição de população tradicional para fins de indenização e reassentamento é extremamente complexa e, francamente, considerando-se o nível de incerteza e dificuldades em se encontrar uma definição para o vocábulo, dificilmente se poderá chegar a uma conclusão satisfatória quando não se tratar de populações indígenas ou remanescentes de quilombos que, aparentemente, são mais facilmente identificáveis. O Decreto nº 4.340/2002, no artigo 36, determina que: *“Apenas as populações tradicionais residentes na unidade no momento da sua criação terão direito ao reassentamento”*. Em minha opinião, o artigo exprime uma lógica cruel, pois muitas populações pobres podem não se enquadrar no conceito de tradicional e, nesse caso, não teriam direito ao reassentamento. Fazem jus, ao que parece, a uma simples indenização em pecúnia que – certamente pequena – implicará problemas sociais de êxodo rural etc. Há que se considerar, sobretudo, o fato de que áreas destinadas a unidades de conservação – principalmente na Amazônia – são de baixo valor, pois dotadas de pouca infraestrutura, distantes de mercado etc. Certamente que o legislador não pretendeu, com a criação de unidades de conservação, empurrar populações pobres para a condição de miseráveis. Há, ainda, que se observar que o artigo 37 do Decreto nº 4.340/2002 estabelece que *“o valor das benfeitorias realizadas pelo Poder Público, a título de compensação, na área de reassentamento, será descontado do valor indenizatório”*. Ora, os habitantes de áreas que poderão vir a ser instituídas como unidades de conservação – como já foi dito –, em geral, são pessoas pobres que residem em casas extremamente modestas; se tiverem descontados os valores das benfeitorias dos assentamentos, provavelmente serão confiscados de suas moradias, pois pouco ou nada lhes restará de indenização. Por fim, há que se consignar que a propriedade, registrada em cartório e titulada, não é uma característica muito marcante em nosso meio rural. Ao contrário, a regularidade fundiária é, ainda, um horizonte distante. Logo, a maioria das populações deslocadas é constituída por posseiros (BENJAMIN, 2000).

O órgão fundiário, sempre que solicitado pelo órgão executor, deve apresentar, no prazo de seis meses, a contar da data do pedido, programa de trabalho para atender às demandas de reassentamento das populações tradicionais, com definição de prazos e condições para a sua realização. Obviamente que a matéria deve constar da previsão orçamentária do mencionado órgão fundiário, ou do executor, sob pena de o artigo 38 do decreto restar como letra morta.

O artigo 39 do decreto determina que enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de conservação.

A norma não pode ser aplicada em todas as situações, pois, em se tratando de unidades de conservação que serão criadas, a imissão na posse pelo Poder Público somente ocorre após o ajuizamento da ação expropriatória e do depósito da indenização. Ora, o artigo 42 da Lei do SNUC dispõe que as populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.

Em minha opinião, é condição prévia para que se possa imitar a administração integralmente na posse que a indenização tenha sido depositada e que o reassentamento (realocação, nos termos da lei) já esteja encaminhado. Em unidades de conservação que já possuíam populações em seu interior quando de sua criação, penso que a situação é mais complexa, pois existem usos permitidos prévios que não podem ser restringidos sem mais.

Os parágrafos do artigo 39 do Decreto 4.320 estabelecem absurdos jurídicos, pois definem obrigações e direitos para as partes *antes* do ajuizamento da ação expropriatória ou da desapropriação amigável. Tal procedimento não encontra amparo legal ou constitucional. Atualmente estão cadastrados 444 parques no cadastro nacional de unidades de conservação.¹²

Antes da edição da Lei nº 9.985/2000, os **monumentos naturais** não estavam regulamentados no sistema jurídico nacional de forma bastante clara e incisiva. Limitavam-se a uma previsão feita pela convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos países da América que, em seu artigo 13, definia os Monumentos Naturais como as regiões, os objetos ou as espécies vivas de animais ou plantas, de interesse estético ou valor histórico ou científico, aos quais é dada proteção absoluta, com o fim de conservar um objeto específico ou uma espécie determinada da flora ou fauna, declarando uma região, um objeto ou uma espécie isolada monumento natural inviolável, exceto para a realização de investigações científicas devidamente autorizadas, ou inspeções oficiais.

Os Monumentos Naturais foram declarados sítios de relevância ecológica pela Resolução Conama nº 11/1987 declaração absolutamente inócua, pois a relevância ambiental é evidente, pois não haveria sentido em se declarar um monumento natural sem valor ecológico ou ambiental.

A Lei nº 9.985/2000, em seu artigo 12, estabeleceu que o Monumento Natural *“tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica”*. É importante observar que os Monumentos Naturais, na forma do § 1º do artigo 12, podem ser constituídos *“por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários”*. Trata-se, portanto, de uma unidade de conservação que, em tese, pode estar submetida, concomitantemente, ao regime jurídico público e privado. É importante sublinhar, entretanto, que as áreas privadas somente serão consideradas integrantes do Monumento Natural com a aquiescência de seus proprietários; caso esta não exista, a área deverá ser desapropriada, na forma da lei. Atualmente estão cadastrados 56 Monumentos Naturais no cadastro nacional de unidades de conservação.¹³

Os **RVS (Refúgio de vida silvestre)** têm como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies

ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Eles podem ser constituídos por áreas particulares, desde que compatíveis os objetivos da unidade com a utilização do solo e dos recursos naturais do local pelos proprietários. No caso da existência de incompatibilidades entre os objetivos da unidade de conservação e as atividades privadas ou, ainda, inexistindo a concordância do proprietário com as condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do RVS com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei. O regime de visitação está sujeito às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo de cada unidade e, também, aos regulamentos administrativos. Atualmente estão cadastrados 22 Refúgios da Vida Silvestre no cadastro nacional de unidades de conservação.¹⁴

11.5.2.2 Unidades de uso sustentável

As UCs de uso sustentável são constituídas por i) Área de Proteção Ambiental – APA; ii) Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIL; iii) Floresta Nacional – Flona; iv) Reserva Extrativista; v) Reserva de Fauna; vi) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e vii) Reserva Particular do Patrimônio Nacional – RPPN.

11.5.2.2.1 Áreas de proteção ambiental

As **Áreas de Proteção Ambiental** foram introduzidas no Direito brasileiro pela Lei Federal nº 6.902/1981, que em seu artigo 8º determinava que o Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do território nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.

Não é difícil perceber que, nos termos daquela lei, as APAs eram unidades de conservação *estabelecidas em regiões que já se encontravam habitadas*. Em realidade, a instituição de uma APA tem como um de seus objetivos principais o de *assegurar o bem-estar* das populações humanas que nela habitavam. Tal bem-estar deve ser conjugado, evidentemente, com o aprimoramento das condições ambientais existentes no interior da APA. Bem se vê, portanto, que as APAs são consideradas espaços protegidos que, não obstante a ampla proteção legal que lhes são atribuídas, não se constituem em áreas intocáveis. O artigo 9º, inciso VI, da Lei nº 6.938/81 estabelece que as APAs são um dos instrumentos da PNMA.

As APAs podem ser criadas por decreto ou lei, que, necessariamente, deverá conter sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e proibições e restrições de uso de recursos ambientais. *Não há proibição de habitação*, residência e atividades produtivas nas APAs; contudo, estas devem ser orientadas e supervisionadas pela entidade ambiental encarregada de assegurar o atendimento das finalidades da legislação instituidora. Portanto, a criação de uma APA, *de forma alguma, impede o exercício de atividades econômicas*. Ao contrário, se a APA for bem concebida, é possível que o seu estabelecimento se constitua em *estímulo* ao desenvolvimento de atividades econômicas. A única exigência que é feita pelo Poder Público é que as atividades sejam compatíveis com o plano de manejo e que sejam executadas de maneira sustentável. Há que se consignar a existência de uma tendência à criação de APAs mediante a expedição de leis e não meros decretos.

Nas APAs não são permitidas as seguintes atividades, que serão limitadas ou proibidas: i) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; ii) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem sensível alteração das condições ecológicas locais; iii) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; iv) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional.

Considerando o *status* jurídico especial das APAs, as atividades a serem desenvolvidas em seu interior, necessariamente, devem ser precedidas de estudo de impacto ambiental. Em princípio, não deve haver pagamento de indenização pelo simples estabelecimento de APA. Entretanto, na hipótese em que o estabelecimento de uma APA tenha significado, em concreto, a obrigatoriedade do encerramento de uma determinada atividade econômica, aí, sim, deverá ser paga indenização, tendo em vista a verdadeira desapropriação indireta. Isso, entretanto, é matéria de prova judicial. Há que se evitar a utilização da APA como um pretexto para o encerramento de atividades que já estavam em situação pré-falimentar ou mesmo inviabilizadas por outros motivos que nada têm a ver com a APA.

A Lei nº 9.985/2000, em seu artigo 15, estabelece que a APA é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

A definição é, de certa forma, abstrata, pois se utiliza de termos ambíguos e pouco claros, tais como “*área em geral extensa*” ou “*certo grau de ocupação humana*”. Fato é que a APA tem por finalidade, continuando a tradição do regime legal anterior, a garantia da qualidade de vida humana, por suposto; isso implica que ela deve, necessariamente, ser uma área ocupada por seres humanos. O grau é absolutamente irrelevante, no particular. Da mesma forma, a extensão da área é absolutamente irrelevante. O importante é o que se pretende proteger, não a extensão física da área protegida.

Uma questão complexa que se coloca é aquela que diz respeito à compatibilização do objetivo das APAs em *disciplinar o processo de ocupação* que, evidentemente, é “ocupação do solo”, e o artigo 30 da CF, que define as competências municipais quanto à utilização do solo urbano. Penso que estamos em um terreno extremamente delicado, pois, em minha opinião, dificilmente se poderá compatibilizar a existência de APA federais ou estaduais em áreas urbanas, dados os particulares poderes constitucionais atribuídos aos municípios que, *ipso facto*, teriam as suas competências em disciplinar a utilização do solo usurpadas por outros entes federativos. Essa, obviamente, é uma questão em aberto que somente poderá ser dirimida por uma decisão do STF sobre o tema. É evidente, entretanto, que as leis gozam de presunção de constitucionalidade e não se pode, *tout court*, apregoar a inconstitucionalidade da norma que ora está sendo examinada.

As APAs são constituídas em terras públicas ou privadas. Desde que observados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização da propriedade privada localizada em uma APA. Esse não é um tema singelo, pois muitas APAs têm sido declaradas como desapropriação indireta, pois, infelizmente, a Administração Pública, não raras vezes, sob o manto de APA, estabelece, na prática, outras unidades de conservação:

Serra do Mar: Área de proteção ambiental. Desapropriação indireta. Indenização. 1. Os proprietários de imóveis com restrição ao direito de uso por imposição legal têm direito à indenização pelo desfalque sofrido em seu patrimônio, ocupado pelo Poder Público. A ação de desapropriação indireta é de natureza real, não se expõe à prescrição quinquenal (REsp 94152, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 23/11/1998). 2. *As restrições de uso de propriedade particular impostas pela Administração Pública, para fins de proteção ambiental, constituem desapropriação indireta, devendo a indenização ser pleiteada mediante ação de natureza real, cujo prazo prescricional é vintenário* (Precedentes nos REsp: 443.852 e 94.152). 3. *A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos. 4. A limitação administrativa gera obrigação de indenizar quando resulta em prejuízo para o proprietário. A verificação de prejuízo e de sua extensão é questão de prova, obstaculizada pela Súmula 7/STJ. 5. Decidindo o aresto recorrido pela rejeição da prescrição e retorno dos autos, impõe-se o seu retorno ao juízo de origem. 6. Recurso especial desprovido*” (STJ. REsp 591948/SP. Recurso Especial 2003/0176435-1. Ministro Luiz Fux. 1ª Turma. DJU 29/11/2004, p. 237).

É bem verdade que os Tribunais vêm exigindo para a caracterização da desapropriação indireta que ocorra um molestamento efetivo dos direitos dos proprietários e não meramente a instituição da Unidade de Conservação (STJ. REsp 628588/SP; Recurso Especial 2004/0004702-7. Relator: Ministro Luiz Fux; Relator p/ Acórdão: Ministro Teori Albino Zavascki. 1ª Turma. DJ 1/8/2005, p. 327).

Nas áreas, integrantes da APA, que se encontrem sob o regime jurídico de direito privado, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

A APA, no regime do SNUC, deve dispor de um conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, na forma da regulamentação específica. Atualmente estão cadastradas 343 APAs no cadastro nacional de unidades de conservação.¹⁵

A Cidade do Rio de Janeiro é dotada de mais de 90 áreas especialmente protegidas que vão desde o Jardim Botânico, criado em 1808, até Parques e,

predominantemente, APAC que se espelham pelos mais diversos bairros da cidade. Observe-se que, no número acima, não estão incluídas as Áreas de Proteção do Ambiente Cultural – APAC, que estão submetidas à administração da Secretaria da Cultura.

11.5.2.2.2 Área de relevante interesse ecológico

A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Ela pode ser constituída por terras públicas ou particulares que, observadas as limitações constitucionais ao direito de propriedade, podem sofrer restrições de uso. Atualmente estão cadastradas 54 áreas de relevante interesse ecológico¹⁶ no cadastro nacional de unidades de conservação.

Na forma do artigo 16 da Lei nº 9.985/2000, a ARIL é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

Elas podem ser formadas por terras públicas ou privadas. Uma vez que sejam respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de propriedade privada localizada em ARIL. O mesmo comentário feito para as APAs é válido para as ARILs.

11.5.2.2.3 Floresta nacional

a) Titularidade das terras brasileiras

É conveniente que, inicialmente, se faça uma rápida análise sobre o regime dominial das terras brasileiras, visto que, em nosso país, elas eram originariamente públicas e distribuídas pelo Estado para colonização. Como se sabe, a colonização do Brasil foi feita inicialmente pelo chamado *regime de sesmarias*, que consistia na doação, por parte do poder público, de terras para aqueles que tivessem meios para explorá-las economicamente, impondo-se ao donatário a obrigação de cultivá-las. Caso as sesmarias não fossem exploradas adequadamente, as terras retornavam à propriedade da Coroa Portuguesa, conforme disposto na Lei de Sesmarias de D. Fernando I, emitida no ano de 1375. Às terras não exploradas e que retornavam à propriedade da Coroa se dava o nome de terras devolutas (devolvidas).

O mencionado sistema era possível, visto que, em decorrência do regime colonial, todas as terras pertenciam ao Mestrado da Ordem de Cristo, cujo grão-mestre era o próprio rei de Portugal. O regime de Sesmarias chegou ao fim com o Império, que, logo em seus primórdios, reconheceu o chamado *regime de posse*, abolindo as sesmarias. Na verdade, a resolução da mesa da Câmara que aboliu as sesmarias foi o reconhecimento de uma situação de fato que já tinha encontrado algum amparo legal em Alvará de 1795, cujo objetivo central era a tentativa de reestruturação de nosso padrão fundiário. Com a Lei nº 601/1850, o regime de posse foi extinto e somente se admitiu a alienação de terras devolutas por meio da compra e venda. Assim, em princípio, as terras que não foram dadas em sesmaria são consideradas públicas no Brasil, bem como aquelas que, mesmo tendo sido concedidas, não tenham sido objeto da adequada exploração caíram em *comisso*, retornando à titularidade do Estado. O comisso, como se sabe, era uma pena de perdimento em função do seu não aproveitamento econômico.

Logo, como se viu rapidamente, a quantidade de terras públicas no Brasil é muito grande, em razão do regime de colonização adotado. A proteção e utilização de tais bens públicos com fins de proteção ambiental e de utilização sustentável é, de certa forma, uma tradição de nosso direito positivo, como demonstrarei. Entretanto, integra a mesma tradição a necessidade de utilização econômica do bem. A legislação colonial, em seu espírito e letra, é bastante clara ao determinar a tutela do bem florestal, no contexto do desenvolvimento da Colônia.

Já em 1605, conforme informa Wainer (1991, p. 23), foi baixado o Regimento sobre o Pau-Brasil, mediante o qual ficava proibido o corte do Pau-Brasil sem a devida autorização administrativa. Ainda segundo a ilustre autora:

A partir da edição do Regimento, a preocupação com o desmatamento é uma constante e foi inserida no Regimento da Relação e Casa do Brasil, de março de 1609, que foi o primeiro Tribunal brasileiro na cidade de Salvador, com jurisdição em toda a colônia.

Na verdade, o *Regimento do Pau-Brasil* buscava estabelecer os mecanismos pelos quais era admitida *há anos a extração*, muito mais do que funcionar como uma proibição. Sem que haja necessidade de aprofundar o desenvolvimento histórico da legislação, serve a presente apenas para demonstrar que, desde os seus primórdios, a legislação ambiental brasileira, como parece ser evidente com a simples leitura do Regimento do Pau Brasil, a Coroa Portuguesa tinha preocupações em manter a sustentabilidade da exploração da madeira, ainda que os resultados alcançados não tenham sido os desejáveis.

b) Serviço florestal brasileiro

Modernamente, a proteção das florestas começa com o estabelecimento de um regime federal de proteção das florestas no Brasil, com a edição do Decreto nº 4.421/1921, que criou o *Serviço Florestal do Brasil*, no âmbito do Ministério da Agricultura, e que tinha por escopo a *conservação, beneficiamento, reconstituição, formação e aproveitamento* das florestas. Indiscutível, portanto, que à base da criação do *Serviço Florestal* estava o que atualmente chamamos de *manejo* para o desenvolvimento sustentável. Aliás, isso fica muito claro com a simples leitura do artigo 1º do decreto em questão, pois nele está firmemente estabelecido que o termo “florestas” não se restringe às áreas “*atualmente cobertas de vegetação de alto e médio porte*”, mas, também, aquelas nas quais se pretenda desenvolver tal tipo de vegetação “*para defesa da salubridade e aumento da riqueza pública*”. Sem dúvida, o conceito empregado naquela época se adapta perfeitamente aos nossos dias. Vale lembrar, por pertinente, que o vigente Código Florestal, conforme já foi assinalado, não tem uma definição de floresta, sendo, no particular, mais inconsistente que a legislação ora examinada.

Para fins de gestão do patrimônio florestal, o decreto (art. 3º) em questão definiu diferentes categorias de florestas, com destaque especial para as chamadas florestas protetoras cuja função era: (i) beneficiar a higiene e a saúde pública, (ii) garantir a pureza e abundância dos mananciais aproveitáveis à alimentação; (iii) equilibrar o regime das águas correntes que se destinam não só às irrigações das terras agrícolas como também às que servem de vias de transporte e se prestam ao aproveitamento de energia; (iv) evitar os efeitos danosos dos agentes atmosféricos; (v) impedir a erosão do solo; (vi) obstar a deslocação das areias movediças como também os esbarrocamentos, as erosões violentas, quer pelos rios, quer pelo mar; (vii) auxiliar a defesa das fronteiras.

É importante observar que, na forma da tradição legal brasileira, admitia-se que, nas florestas protetoras, nos casos em que houvesse “grande vantagem” para a riqueza nacional, fosse permitida a exploração econômica de seus produtos, mas “sempre com a obrigação de replantio”. As florestas protetoras que não estivessem sob o regime de domínio público deveriam ser identificadas pelo poder público para fins de declaração de utilidade ou necessidade pública, tornando-se passíveis de desapropriação. Em tais casos, os proprietários deveriam ser notificados e, pelo período de um ano, tinham a obrigação de manter intactas as florestas até que se providenciasse o ato de desapropriação. Contudo, a desapropriação deveria ocorrer no prazo de um ano, pois do contrário os proprietários manteriam os seus direitos de usar, gozar e dispor livremente dos bens declarados imprescindíveis, ficando-lhes ainda salvo o direito de indenização pelo tempo em que a sua propriedade estava gravada.

Além das florestas protetoras, o decreto estabeleceu outras categorias que, hodiernamente, poderiam ser chamadas de *unidades de conservação*, tais como (i) *hortos florestais*, (ii) *florestas-modelo*, (iii) *reservas florestais* e (iv) *parques nacionais*. Assim, como se vê, a criação do serviço florestal brasileiro, do ponto de vista jurídico, foi bastante abrangente, chegou-se à instituição de uma polícia florestal voltada para a defesa das florestas protetoras e de estatísticas próprias para as atividades florestais.

Grande destaque deve ser dado ao chamado *Regime Florestal* estabelecido pelo Decreto nº 4.421. Por tal regime se buscava a “*conservação metódica das florestas e a perpétua exploração das mesmas*”. No particular, ressalte-se que o *regime florestal* era obrigatório para todos os terrenos do domínio da União (art. 58).

No regime estabelecido pelo Decreto, *todo e qualquer terreno da União estava submetido ao chamado regime florestal*, ou seja, deveria ser utilizado economicamente, desde que observadas as cautelas devidas. E mais, mesmo as chamadas *florestas protetoras* poderiam ser submetidas ao regime de exploração econômica sempre que dela resultassem *ganhos efetivos para a nação*. Assim, pelo que se pode perceber da norma, o administrador estava obrigado a ponderar os diferentes aspectos envolvidos na possível desafetação de uma floresta protetora, levando em conta critérios ambientais e econômicos. Em sua essência, trata-se de um mecanismo ainda vigente em nosso ordenamento jurídico, muito embora a terminologia empregada tenha sofrido significativa alteração. Manejo e sustentabilidade eram vocábulos inexistentes em 1921, mas, certamente, os conceitos abstratamente considerados já tinham a sua gênese no texto normativo.

c) Código Florestal de 1934

As normas estabelecidas pelo Decreto nº 4.421/1921, vigoraram até o advento do *Código Florestal* aprovado pelo Decreto nº 23.793/1934 (revogado). Efetivamente, com a queda da República Velha, o Brasil entrou em um estágio no qual a intervenção estatal no domínio econômico passou a ser feita de forma mais intensiva e sistemática. Para que o novo modelo intervencionista pudesse ser operacional, foi necessária uma grande mudança nos marcos legais até então existentes no país, com uma ampla modernização normativa. É nesse contexto que surgem o *Código de Águas*, o *Código de Minas* e a própria CF. A característica que unifica e estabelece uma forte identidade entre os referidos diplomas legais é: criar condições legais e institucionais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Em resumo, podemos dizer que o Código de Águas foi criado para produzir energia elétrica; o Código de Minas, para expandir a mineração, e o Código Florestal para estimular a produção madeireira e de produtos florestais. Tudo isso dentro de um contexto que buscava assegurar o acesso perene aos recursos.

O elemento que, inicialmente, chama mais a atenção do Código revogado e que denota de forma cabal o seu conteúdo intervencionista é o artigo 1º do referido diploma legal. De fato, pelo artigo 1º fica bastante claro que as florestas existentes no território nacional, independentemente de seu regime jurídico, *são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, ficando o exercício dos direitos de propriedade com as limitações das leis do Brasil, especialmente do próprio código florestal*.

c.1) Florestas de domínio público: nacionais, estaduais e municipais

É evidente que as diferentes categorias florestais tratadas pelo Código não guardam uma relação direta com o regime dominial do solo e de seus acessórios. Assim, não resta dúvida de que as *florestas protetoras poderão ser públicas ou privadas, assim como as florestas de rendimento*. O Código definiu regimes de exploração – ou não exploração, conforme o caso – das florestas aplicáveis às áreas florestadas que ostentassem determinados valores considerados relevantes para as finalidades estabelecidas no próprio Código. Conforme determinado pelo artigo 2º do Código de 1934, as normas nele contidas eram aplicáveis *“às florestas como às demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem”*. O Código, ao que me parece, buscava permitir a utilização *racional* das florestas, ao mesmo tempo em que estabelecia um forte regime de proteção ao solo, como forma de assegurar a sobrevivência das florestas e evitar a erosão.

Qual a utilização econômica possível para as florestas submetidas ao regime jurídico administrativo? No que se refere às florestas de domínio público, a exploração econômica, *“exploração industrial intensiva”*, nos termos do próprio Código, somente foi autorizada para as *florestas de rendimento*, conforme disposto no seu artigo 36. *As florestas de rendimento de domínio público são as antecedentes imediatas das modernamente chamadas Florestas Nacionais*. Aqui é necessário lembrar que as *florestas de rendimento* eram todas as florestas de domínio público que não estivessem compreendidas nas categorias de (i) *protetoras*, (ii) *remanescentes* ou (iii) *modelo*.

A *exploração intensiva* era aquela que estava restringida apenas pelas normas da própria CF naquilo que se refere aos *produtos florestais* tal como definidos pelo próprio Código. Flona, assim, era o nome atribuído a uma floresta de rendimento que pertencesse à União.

d) Código Florestal de 1965

Assim como o seu antecessor de 1934, a CF de 1965 surgiu em momento de profunda transformação da vida nacional. É, como o seu predecessor, fruto de uma brusca alteração política e foi instituída, assim como o que lhe antecederia, para dinamizar a atividade florestal. Se comparado ao que lhe precedera, o Código de 1965 trouxe diversas e profundas alterações. Aquela que entendo dotada de mais relevância foi a extinção das diferentes categorias florestais. É notável, como já observei, o fato de que o Código não define floresta!!! De fato, o Código foi mais enfático na ampla autorização para a exploração econômica das florestas, conforme o artigo 16 de sua redação original. Embora tenha extinto as diferentes categorias florestais, o Código de 1965 manteve as florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente, dividindo-as em dois grandes grupos: (i) *ex vi lege*, notadamente em função da localização, e (ii) por ato do poder público, quando destinadas à proteção de bens e valores previstos no próprio Código.

d.1) Florestas públicas: nacionais, estaduais e municipais

Seguindo a tradição legal, o Código de 1965 reconheceu à Administração Pública o poder-dever de instituir Florestas públicas “com fins econômicos, técnicos ou sociais” que, na forma da lei, podiam ser instituídas em áreas *não florestadas*, desde que voltadas para o fim especificado em lei. O que a lei objetivava era a possibilidade de criar florestas em áreas mesmo que sem vegetação. Aqui, resta bastante claro que existe uma linha de continuidade com o provecto “regime florestal” estabelecido pelo Decreto 4.421/1921. Isto é, *as florestas públicas, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais são instituídas com fins econômicos, técnicos ou sociais*, mesmo que as áreas nas quais ocorra a sua instituição não sejam florestadas. Portanto, elas *são um instrumento do estado para atuar na área econômica*, com vistas à produção dos chamados “produtos florestais”, conforme a classificação que foi dada em 1921 *aos frutos das florestas* quando apropriados economicamente. Na linguagem moderna, falaríamos em *recursos florestais*. Não havia, portanto, nenhuma obrigação de que as Flonas correspondessem a uma área já plantada. Ao contrário, poderia ocorrer que a Flona fosse instituída exatamente para propiciar o reflorestamento com finalidades econômicas.

O Código de 1965 *reconheceu* em continuidade à tradição legal brasileira, *a existência de áreas destinadas especificamente à proteção e conservação dos valores ambientais*, conforme a alínea *a* do artigo 5º de sua redação primitiva. Com efeito, por força do dispositivo legal mencionado, foi determinado ao poder público que criasse parques nacionais, estaduais e municipais, bem como reservas biológicas, como reservas biológicas com “a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos”. É facilmente perceptível que o objetivo do legislador foi o de criar duas espécies distintas e, seria possível dizer, antagônicas, de áreas florestais públicas. Aquelas constantes da alínea *a* vocacionadas para a conservação e mesmo preservação ambiental; aquelas da alínea *b*, destinadas ao aproveitamento econômico.

O artigo 5º, *b*, do Código Florestal (revogado) foi regulamentado pelo Decreto nº 1.298/1994. Efetivamente, determina o artigo 1º que as Flonas são áreas de domínio público, providas de cobertura vegetal nativa ou plantada, estabelecidas com os seguintes objetivos: (i) promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais; (ii) garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, e dos sítios históricos e arqueológicos; (iii) fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo

Indiscutível, portanto, que as florestas públicas são, em sua essência, a continuidade das chamadas florestas de rendimento pertencentes ao poder público, independentemente da esfera governamental à qual pertençam.

A inadequada colocação das Florestas Nacionais no SNUC

A partir da CF de 1988, os temas ambientais passaram a ter maior relevância no contexto jurídico constitucional, visto que mereceram um capítulo próprio constituído pelo artigo 225. Em tal artigo, a proteção de espaços territoriais foi expressamente prevista, conforme o inciso III do § 1º. Tanto o Código Florestal como diversas outras normas extravagantes anteriores à própria CF existem para dar cumprimento à determinação constitucional. Entretanto, o legislador ordinário entendeu por bem estabelecer uma norma única para disciplinar aquilo que foi por ele denominado *unidades de conservação*.

A lei, com indistigável erro técnico, tratou de diversas categorias que, somente com muito esforço, podem ser consideradas como unidades “com objetivos de conservação”. Cito como exemplo as áreas de proteção ambiental e, obviamente, as Flonas. Ainda que presentes as dificuldades acima apontadas, o fato é que o SNUC buscou dar um nível maior de articulação às diferentes formas jurídicas para a proteção dos recursos naturais, em especial à diversidade biológica. Fato é, no entanto, que o SNUC *não* deu às Flonas nenhum tratamento diferente daquele que já se encontrava presente em nosso ordenamento jurídico, ainda que se utilizando de uma linguagem mais moderna e atualizada.

As Flonas estão contempladas no artigo 40-A, § 1º da Lei do SNUC, tendo sido catalogadas como unidade de conservação de uso sustentável. A definição e as principais características das Flonas foram estabelecidas pelo artigo 17 da Lei do SNUC como uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

Há que se ver, por fundamental, que o chamado uso múltiplo sustentável é um conceito aberto que deve ser preenchido casuisticamente. Será sustentável todo uso que, de uma forma ou de outra, não implica a subtração perene da cobertura vegetal. Conforme a experiência nos ensina, muitas atividades que, à primeira vista, poderiam parecer como não sustentáveis têm sido desenvolvidas com êxito nas mais diversas unidades de conservação. Um exemplo muito importante para que se possa compreender a *amplitude do conceito de sustentabilidade no interior das Flonas* nos é fornecido pelo caso específico da Flona de Carajás. De fato, conforme está definido no decreto de sua instituição, *o parágrafo único do artigo 1º do decreto, expressamente, que a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, o transporte e a comercialização de recursos minerais estão incluídos dentre os objetivos do plano de manejo*.

As principais características das Flonas são as seguintes: elas devem ser constituídas em área de domínio público, e só de domínio público, sendo certo que as áreas particulares que nelas tenham sido incluídas devem ser desapropriadas de acordo com a lei. Admite-se, contudo, que no interior das Florestas Nacionais existam populações tradicionais desde que nelas habitassem quando da criação. Admite-se que nelas se faça visitação pública, que será condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável pela administração. A pesquisa, também, é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento.

As Florestas públicas passaram a ser reguladas pela Lei nº 11.284/2006. Atualmente constam 107 Florestas nacionais no cadastro nacional de unidades de conservação¹⁷.

11.5.2.2.4 Reserva extrativista

a) Histórico da legislação

As Reservas Extrativistas constituem-se em uma das diversas modalidades de unidades de conservação que são reconhecidas pelo Direito brasileiro. A característica especial das Reservas Extrativistas é que estas são um produto direto das lutas dos seringueiros da Amazônia pela preservação de seu modo de vida e pela defesa do meio ambiente. O exemplo e símbolo mais marcante dessa luta foi o seringueiro Chico Mendes, que foi assassinado em defesa de suas ideias (SHOUMATOFF, 1991), relativas à proteção do meio ambiente e das relações de trabalho vigentes na Amazônia Legal.

O Decreto nº 96.944/1988, em seu artigo 1º, estabeleceu o programa *Nossa Natureza*, com a finalidade de definir condições para a utilização e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis da Amazônia Legal. O item VI do artigo 1º do referido Decreto estabeleceu a obrigação jurídica de *proteger as comunidades indígenas e as populações envolvidas no processo de extrativismo*.

Pelo Decreto nº 98.897/1990, foi, finalmente, definido o mecanismo pelo qual seriam criadas unidades de conservação capazes de conciliar a proteção dos ecossistemas amazônicos com o modo e padrão de vida das populações locais. *As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista*.

As reservas extrativistas deveriam ser criadas em espaços de interesse ecológico e social, que são áreas que possuam características naturais ou exemplares da biota que possibilitem a sua exploração autossustentável, sem prejuízo da conservação ambiental.

As populações extrativistas, para a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, deverão firmar contrato com o Estado para a concessão do direito real de uso, cuja concessão é feita a título gratuito. O contrato de uso é intransferível, e a degradação do meio ambiente por parte das populações extrativistas implica a rescisão do mesmo.

b) Novo regime jurídico

Conforme está disposto no artigo 18 da Lei nº 9.985/2000 a Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Elas são de domínio público, com o direito de uso concedido às populações extrativistas tradicionais, conforme o disposto no artigo 23 da Lei nº 9.985/2000 e em seu regulamento, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com a lei. Deve ser criado um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável pela administração de cada Reserva e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade de conservação.

A visitação pública é admitida, uma vez que compatibilizada com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo respectivo.

Quanto à pesquisa científica, esta é permitida e incentivada, sujeitando-se, entretanto, à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento. Nas reservas extrativistas, são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional.

Quanto à exploração comercial de recursos madeireiros, esta é admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no próprio Plano de Manejo da unidade de conservação. Atualmente constam 94 Reservas Extrativistas no cadastro nacional de unidades de conservação.¹⁸

11.5.2.2.5 Reserva de Fauna

A Reserva de Fauna, conforme disposto no artigo 19 da Lei nº 9.985/2000, é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Ela é de posse e domínio públicos, sendo certo que as áreas particulares nela incluídas devem ser desapropriadas de acordo com a lei. A sua visitação pode ser permitida, sempre que compatível com o seu manejo e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão gestor. No seu interior, é proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. É possível a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas, obedecido o disposto nas leis sobre fauna e respectivos regulamentos. Atualmente não consta nenhuma Reserva da Fauna no cadastro nacional de unidades de conservação.¹⁹

11.5.2.2.6 Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Estabelecidas pelo artigo 20 da Lei nº 9.985/2000, as RDS são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Elas têm como objetivo básico preservar a natureza e, concomitantemente, assegurar

as condições e os meios necessários para a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por tais populações. São unidades de conservação criadas em terras de domínio público, motivo pelo qual as áreas particulares que se encontrem em seu interior devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com a lei. A utilização das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será feita de acordo com o disposto no artigo 23 da Lei nº 9.985/2000 e em seu regulamento.

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é gerida por Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade de conservação.

Para a prática de atividades econômicas na RDS, devem ser observadas as seguintes condições: (i) a visitação pública é permitida e incentivada desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; (ii) a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições e às normas previstas em regulamento é incentivada; (iii) deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e (iv) admite-se a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.

Obrigatoriamente, o Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável deverá definir as zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. Atualmente constam 39 Reservas de Desenvolvimento Sustentável no cadastro nacional de unidades de conservação.²⁰

11.5.2.2.7 Reserva Particular do Patrimônio Natural

A RPPN é uma área privada, gravada com perpetuidade pelo proprietário, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O gravame deverá constar de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

Somente são permitidas nas RPPNs as seguintes atividades: (i) pesquisa científica; (ii) visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao proprietário de RPPN para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. Atualmente constam 914 Reservas Particulares do Patrimônio Natural no cadastro nacional de unidades de conservação.²¹

11.5.3 Reserva da biosfera

O artigo 41 da Lei nº 9.985/2000 incorporou ao Direito interno brasileiro as chamadas “Reservas da Biosfera” como unidades de conservação. O texto do mencionado artigo, entretanto, é confuso, pois o legislador definiu a reserva da biosfera como *um modelo que é “adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações”*.

Os parágrafos do mencionado artigo estabelecem a constituição e outros requisitos das Reservas da Biosfera, constituídas por a) uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza; b) uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; e c) uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

Isso em áreas de domínio público ou privado. Elas podem ser integradas por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. São geridas por Conselho Deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade. E, por fim, são reconhecidas pelo Programa Intergovernamental “O Homem e a Biosfera – MAB”, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. Melhor teria andado o legislador se simplesmente dissesse que são Reservas da Biosfera aquelas assim reconhecidas pela Unesco.

11.5.3.1 Regulamentação

A Reserva da Biosfera, conforme previsto no artigo 41 do Decreto nº 4.340/2002 *é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, que tem por objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. O gerenciamento das Reservas da Biosfera está submetido à coordenação da Comissão Brasileira para o Programa “O Homem e a Biosfera” – Cobramab, de que trata o Decreto de 21 de setembro de 1999.*

À Cobramab, além do estabelecido no decreto de 21 de setembro de 1999, compete apoiar a criação e instalação do sistema de gestão de cada uma das Reservas da Biosfera reconhecidas no Brasil, nas seguintes hipóteses: (i) quando a Reserva da Biosfera abranger o território de apenas um Estado, o sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês regionais; (ii) quando a Reserva da Biosfera abranger o território de mais de um Estado, o sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo e por comitês estaduais.

Compete aos conselhos deliberativos das Reservas da Biosfera: (i) aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua Reserva e coordená-lo; (ii) propor à COBRAMAB macrodiretrizes para a implantação das Reservas da Biosfera; (iii) elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, de acordo com os objetivos básicos enumerados no artigo 41 da Lei nº 9.985, de 2000; (iv) reforçar a implantação da Reserva da Biosfera pela proposição de projetos pilotos em pontos estratégicos de sua área de domínio; e (v) implantar, nas áreas de domínio da Reserva da Biosfera, os princípios básicos constantes do artigo 41 da Lei nº 9.985/2000.

Os comitês regionais e estaduais têm as seguintes incumbências: (i) apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às Reservas da Biosfera; (ii) apontar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das Reservas da Biosfera, bem como para a difusão de seus conceitos e funções.

11.5.3.2 Criação, implantação e gestão das unidades de conservação

11.5.3.2.1 Normas gerais

As unidades de conservação devem ser criadas por ato do Poder Público, conforme o artigo 22 da Lei nº 9.985/2000. A lei não estabelece a natureza do ato instituidor das UCs. Em geral, o vocábulo *ato* tem sido compreendido como “decreto”. Nas hipóteses nas quais as unidades de conservação sejam criadas em áreas públicas, de propriedade do ente federativo que as tenha instituído, não há dúvida de que o decreto é o caminho adequado. Ocorre, porém, que, não raras vezes, as UCs são instituídas em terrenos privados, surgindo daí questões jurídicas que demandam reflexão mais aprofundada. Penso que alguns aspectos importantes devem ser considerados: (i) natureza da unidade de conservação; (ii) titularidade da área na qual a unidade de conservação venha a ser implantada.

As UCs do grupo de proteção integral, conforme foi visto antes, são aquelas nas quais a utilização econômica dos recursos ambientais é zero – ou quase. Evidentemente que, ao serem criadas por ato do Executivo – Decreto, e desde que atingindo áreas de propriedade particular ou de domínio de outro ente federativo

que não o seu instituidor, estas implicam um esvaziamento da propriedade. Faz-se necessário, portanto, que, paralelamente ao ato de criação da unidade de conservação, seja editado decreto, declarando a área de utilidade pública para fins de desapropriação. A Unidade de Conservação somente se aperfeiçoará após ajuizadas as ações expropriatórias e feito o depósito correspondente. Nas unidades de conservação de uso sustentável, em tese, não há o esvaziamento econômico da propriedade, muito embora isso possa ocorrer. Ocorre que, nesses casos, o proprietário deverá dirigir-se ao Poder Judiciário e perante ele demonstrar concretamente o seu prejuízo com vistas à obtenção de indenização pela desapropriação indireta sofrida.

O novo regime legal da criação de unidades de conservação impõe ao Poder Público que estabeleça um procedimento no qual deverão estar previstas a realização de estudos técnicos e de consulta pública, de forma que seja possível identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. A inexistência de tais procedimentos prévios, em minha opinião, torna nulo qualquer ato instituidor de unidade de conservação. Ressalte-se que, por se tratar de norma de natureza processual, o contido no § 2º do artigo 22 da Lei nº 9.985/2000 tem aplicação imediata, mesmo em procedimentos que se encontrem em andamento. É importante ressaltar que, no processo de consulta de que trata o § 2º do artigo 22, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas.

Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica, por se tratarem de unidades de conservação que somente podem ser estabelecidas em terras públicas, não é obrigatória a consulta de que trata o § 2º do artigo 22.

É possível a transformação, total ou parcial, de unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta, estabelecidos no § 2º do artigo 22, e resguardados os direitos de particulares nelas estabelecidos, sob pena de se configurar desapropriação indireta. Na forma do § 6º do artigo 22, a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos em seu § 2º.

A desfetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica, isto é, mediante lei formal, votada e aprovada pelo Poder Legislativo.

a) Gestão

A gestão das unidades de conservação é colegiada, adotando-se o critério da participação organizada da sociedade, Administração Pública e populações das áreas diretamente vinculadas à unidade de conservação. A gestão colegiada e plural materializa-se em conselhos consultivos ou Deliberativos, conforme o caso específico que, seja em um caso, seja em outro, serão presididos pelo chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. O decreto regulamentar define critérios a serem observados quanto à participação de cada um dos diferentes setores interessados em ser representados. Como definido no § 1º do artigo 17 do Decreto nº 4.340, a representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos ambientais dos três níveis da federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas.

Quando se tratar da representação da sociedade civil, ela deverá contemplar, quando couber, a comunidade científica e organizações não governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. O decreto busca estabelecer uma paridade entre a representação social e a governamental, embora não haja qualquer obrigação para que assim seja. O critério a ser adotado é de conveniência e oportunidade. É importante frisar que a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com representação no conselho de uma determinada unidade de conservação, não pode candidatar-se à gestão compartilhada tratada no Capítulo VI do decreto. Os integrantes dos Conselhos fazem jus à denominação conselheiros e têm mandato de dois anos.

Merece destaque a flagrante ilegalidade do § 6º do artigo 17, que determina que *no caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com competências que incluam aquelas especificadas no art. 20 do Decreto, pode ser designado como conselho da unidade de conservação*. Como é curial, falece competência constitucional ao Poder Executivo Federal para se iniscuir em assunto da economia interna do Município, que é a definição de estruturas administrativas próprias da municipalidade. Ao Órgão Executor compete, (i) convocar o conselho com antecedência mínima de sete dias; (ii) prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e devidamente justificado.

Ao Conselho de Unidade de Conservação, na forma do artigo 20, compete: (i) *elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação*; (ii) *acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo*; (iii) *buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno*; (iv) *esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade*; (v) *avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação*; (vi) *opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade*; (vii) *acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada irregularidade*; (viii) *manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos*; e (ix) *propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso*.

a.1) Gestão compartilhada com OSCIP

Um reconhecimento do modelo gerencial participativo é o estabelecimento nos artigos 21 e seguintes do Decreto nº 4.340/2002, *gestão compartilhada de unidade de conservação com OSCIP*. Tal modalidade de gestão deve ser regulada por termo de parceria firmado com o órgão executor, nos termos da Lei nº 9.790/1999. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público elegível para a gestão de unidades de conservação é aquela que atenda aos seguintes requisitos: (i) tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do desenvolvimento sustentável; (ii) comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de conservação ou no mesmo bioma. A escolha da OSCIP que deverá gerir uma unidade de conservação é feita mediante a publicação de edital para seleção de OSCIP, visando à gestão compartilhada, com antecedência mínima de 60 dias da data designada para o certame, em jornal de grande circulação na região da unidade de conservação e no *Diário Oficial*, nos termos da Lei nº 8.666/1993. A escolha a ser feita é diferente da licitação clássica, pois a OSCIP interessada deverá apresentar a sua proposta de gestão em função de um termo de referência elaborado pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade. A OSCIP vencedora deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação do órgão executor e do conselho da unidade.

O decreto deveria ter sido mais claro na estruturação dos contornos legais da gestão compartilhada, pois, na forma em que se encontra – francamente –, muito pouco está esclarecido. É evidente que, em se tratando de gestão pública, as OSCIPs devem oferecer garantias à Administração no sentido de que são dotadas de condições técnicas e econômicas para levarem a bom termo o avençado, inclusive com a eventual responsabilização por danos que possam causar às unidades de conservação que, eventualmente, estejam sob administração de OSCIP. Vejamos as características jurídicas básicas das OSCIPs.

a.2) Natureza jurídica das OSCIPS

A OSCIP organiza-se sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, conforme disposições da Lei nº 9.790/99. Para que uma pessoa jurídica seja caracterizada como OSCIP, é necessário que ela atenda, ao mesmo tempo, aos *critérios*: (i) *não ter fins lucrativos e desenvolver determinados tipos de atividades de interesse geral da sociedade* (arts. 1º e 3º da Lei nº 9.790/99); e (ii) *adotar um determinado regime de funcionamento* – dispor em seus estatutos e

engendrar nas suas ações preceitos da esfera pública que tornem viáveis a transparência e responsabilização pelos atos praticados (art. 4º da Lei nº 9.790/99). A concessão de qualificação como OSCIP é feita pelo Ministério da Justiça.

A OSCIP não é uma mera organização não governamental, pois está submetida a um determinado grau de controle administrativo. A rigidez do controle administrativo decorre da exigência de Termo de Parceria firmado entre o Poder Público e a OSCIP, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas nos artigos 3º e 14 da Lei nº 9.790/99, assim como do artigo 8º do Decreto nº 3.100/99.

A Lei nº 9.790/99, artigo 14, determina que se obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, que são os mesmos princípios que regem a Administração Pública, de acordo com o artigo 37 da CF. Observe-se que o artigo 14 da Lei nº 9.790/1999, e o artigo 21 do Decreto nº 3.100/1999, determinam que as OSCIPs, quando celebrarem um ou mais Termos de Parceria, têm que apresentar ao órgão estatal parceiro, até 30 dias após a assinatura do Termo de Parceria, um Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de Obras e Serviços da OSCIP, publicado na imprensa oficial do Município/Estado/União, dependendo da abrangência do projeto.

No que se refere à prestação de contas, o artigo 4º, VII, *d*, da Lei nº 9.790/99 dispõe que as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão no mínimo: [...] *d*. a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da CF.

As OSCIPs devem observar, no que se refere às normas de *prestação de contas*, de acordo com o artigo 4º da Lei nº 9.790 e o artigo 19 do Decreto nº 3.100, a realização de auditoria, inclusive por auditores externos, independentemente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria, nos casos em que o montante de recursos for maior ou igual a R\$ 600.000,00.

11.5.3.2.2 Normas aplicáveis às unidades de uso sustentável

A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser em regulamento da Lei nº 9.985/2000. O dispositivo do artigo 24, a toda evidência, somente se aplica às unidades de conservação que estejam instaladas em terras públicas. A posse, por ser uma situação de fato, em minha opinião, torna-se difícil de ser regulada por contrato. Em se tratando de terras públicas, penso que o mais indicado seria a utilização do tradicional sistema de aforamento e concessão de uso já existentes, de longa data, em nosso ordenamento jurídico. É evidente que os habitantes das unidades de conservação de uso sustentável obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação. De fato, a figura tratada pela norma legal aproxima-se, em muito, do usufruto.

Para a utilização dos recursos naturais nas unidades de conservação de uso sustentável, são aplicáveis as seguintes normas: (i) proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus *habitats*; (ii) proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas; (iii) demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.

Determina o artigo 24 da Lei nº 9.985/2000 que o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Trata-se de norma de constitucionalidade duvidosa, pois o subsolo, como se sabe, é bem de propriedade da União e a sua propriedade é independente da do solo. Nas unidades de conservação federal, em tese, pode-se admitir a vigência da norma. Quanto à situação das demais, cuja titularidade não seja federal, penso que a matéria deverá ser decidida pelo STF, que deverá decidir se há, ou não, interferência com o regime de propriedade do subsolo, em especial naquilo que diz respeito à exploração de recursos minerais. Isso para não se falar na exploração de águas subterrâneas.

a) Zonas de Amortecimento

O presente item tem por objetivo examinar as repercussões jurídicas da instituição das chamadas ZAs ou ACs das UCs, com ênfase no fato de que as normas jurídicas que disciplinam a matéria são extremamente frágeis, confusas e, portanto, capazes de gerar grave insegurança jurídica, inclusive na esfera penal. As ZAs estão previstas no artigo 25 da Lei do SNUC e devem ser delimitadas em todas as unidades de conservação, com exceção das áreas das APAs e das RPPNs. Juridicamente, as ZAs são definidas como “*o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade*”. A definição é clara e autoexplicativa. A expressão AC apareceu na Resolução nº 13/1990, do Conama, a qual dispôs que os responsáveis pelas UCs, juntamente com os órgãos licenciadores e os órgãos ambientais, deveriam identificar as atividades que potencialmente pudessem causar impactos negativos às unidades de conservação que estivessem situadas em raio de dez quilômetros no entorno, perímetro dentro do qual seria exigido o licenciamento ambiental de “*qualquer atividade que possa afetar a biota*”. Além disso, foi determinado que o licenciamento ambiental somente fosse concedido pelo órgão competente mediante autorização do órgão responsável pela administração da UC.

As AC são uma demonstração bastante clara do precário nível de segurança jurídica do direito ambiental no Brasil. A Lei nº 6.938/1981, que estabeleceu a PNMA, em sua redação original, ostentava o artigo 18, que assim dispunha:

São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal, e os pousos das aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no art. 14 desta Lei.

A lei nada dispôs sobre a existência de “áreas circundantes”, assim como não dispôs a Lei nº 6.902/81. Contudo, a pretexto de regulamentar a norma legal, o Decreto nº 99.274/1990, em seu artigo 27 dispôs que nas ACs das UCs, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama.

Não é necessário muito esforço para que se constate que o regulamento extrapolou dos limites da lei. E mais: o artigo 27 do Decreto está inserido no Título II do Decreto, o qual se denomina assim: “*Das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental*”. Ora, mesmo que, em esforço ímpar, se admitisse que as ACs pudessem ser admitidas como legais, a sua aplicação somente poderia ser relativa às Estações Ecológicas e APAS, pois expressamente previstas no decreto. Contudo, a lei do SNUC (artigo 60) deu novo tratamento à matéria e *ipso iure*, revogou o artigo 18 da Lei nº 6.938/81. Evidentemente que, dada a revogação do artigo da lei, revogado está o artigo do decreto que o regulamentara. Mais grave ainda é o fato de que o Conama editou a Resolução nº 13/90 e manteve o perímetro tratado pelo Decreto. O tema não é uma mera tertúlia jurídica ou literária, ao contrário, cuida-se de matéria de elevada repercussão prática sobre a de indivíduos e empresas. Muitos são os exemplos de consequências gravíssimas da não regulamentação adequada da matéria. Veja-se, exemplificativamente, o caso do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que foi criado pelo Decreto nº 86.060/1981, *sem a definição de Zona de Amortecimento*, a qual não foi definida posteriormente por ato administrativo de igual hierarquia daquele que criou a Unidade de Conservação. Em relação ao mencionado Parque Nacional, o Ibama baixou a Portaria nº 48, de 15/2003, que aprovou o seu plano de manejo do qual, segundo consta da própria Portaria, o “*texto completo [...] é disponibilizado pelo Ibama no Centro Nacional de Informação Ambiental – CNIA/Ibama, bem como na página do Ibama na Internet*”. O sítio internet do ICMbio,²² contudo, não contém o Plano de Manejo tal como determinado pela Portaria (art. 1º), nem qualquer informação de que ele se encontra disponível para consulta, tal como determinado pelo Decreto 4.340/2002. Assim, em tese, há grave violação do princípio da publicidade dos atos administrativos e descumprimento de determinação emanada da própria Administração. Registra-se, no entanto, que o STJ ([...] 2. *Hipótese em que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal – órgão integrante da União – com o objetivo de obstar a construção irregular de empreendimento comercial localizado dentro da Zona de Amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 3. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama é o responsável pela aprovação do Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, conforme se verifica na Portaria Ibama 48, de 15 de setembro de 2003. 4. O Parque Nacional dos Lençóis*

Maranhenses, na qualidade de Unidade de Conservação federal de proteção integral, é administrado pelo Ibama (Autarquia Federal), o que atrai também a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento da presente demanda, nos termos do art. 109, I, da CF. 5. Embora, na perspectiva dos potenciais impactos ambientais negativos, nem todo empreendimento ou atividade que se insira na Zona de Amortecimento (art. 2º, inciso XVIII, da Lei 9.985/2000) ou na Zona Circundante (Resolução Conama 013/1990) de Unidade de Conservação federal seja de interesse da União, não há dúvida de que alguns – ou muitos, dependendo das circunstâncias do caso concreto e da modalidade de área protegida – serão. 6. Compete ao órgão gestor federal zelar não apenas pela salvaguarda direta da Unidade de Conservação e de tudo o que nela se encontra ou se faz, mas também pela sua proteção indireta, pois a ação humana ou antrópica exercida fora das fronteiras da área é capaz, por conta dos chamados efeitos de borda, de ameaçar sua integridade e até mesmo existência. 7. Consoante a Súmula 150 do STJ, [...]”. CC 200601577464, Relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 10/11/2009) tem reconhecido a existência da ZA e mesmo da chamada AC, ainda que estas sejam genéricas e sem expressa previsão legal. Abstraindo-se os problemas referentes à publicidade do plano de manejo das unidades de conservação, fato é que, nos termos da lei, não lhes cabe definir os limites da ZA. De acordo com o § 2º do artigo 25 da Lei do SNUC, repita-se, as ZAs poderão ser definidas no ato da criação da unidade de conservação ou posteriormente. Parece-me que uma leitura coerente do parágrafo indica que a ZA somente pode ser definida por ato de igual hierarquia daquele que criou a unidade de conservação a ser protegida. Assim, o legislador deixou ao administrador duas opções: (i) estabelecer a ZA juntamente com a unidade de conservação ou (ii) examinar a posteriori a criação da ZA e defini-la por instrumento jurídico de igual nível. Aliás, o § 1º do artigo 27 da Lei do SNUC determina que o plano de manejo “deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”, o que implica que ele deve ser **posterior** à instituição da ZA, como inarredável consequência lógica. Chamo a atenção para o fato de que as questões jurídicas suscitadas nas ZAs ou nas ACs acabam, na prática, sendo mais graves do que aquelas que se verificam no interior das próprias unidades de conservação. Isso decorre da imensa imprecisão jurídica que grassa sobre o tema, da enorme quantidade de unidades de conservação constituídas sem a delimitação precisa das ZAs, da divulgação adequada dos planos daquelas já criadas. Um outro bom exemplo é o da *Floresta da Cicuta*, situada no estado do Rio de Janeiro, a qual ostenta a condição jurídica de área de relevante interesse ecológico. Ela é constituída inteiramente por área de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, situada no interior da Fazenda Santa Cecília. Do ponto de vista prático, cuida-se de um parque urbano – ainda que com importância ecológica, tendo em vista os remanescentes de Mata Atlântica que lá se encontram – encravado em uma importante conurbação do Sul Fluminense. No entanto, dada a sua condição jurídica de Unidade de Conservação, os órgãos ambientais têm aplicado a Resolução 13/90 do Conama que, como espero ter demonstrado, não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro. A AC da Floresta da Cicuta atinge o centro da cidade de Barra Mansa, por exemplo.

Com muita frequência, processos criminais são instaurados com base em inobservância das limitações decorrentes da condição jurídica de “área circundante”, como nos dá mostra o seguinte acórdão: *I – Processo penal. Habeas Corpus. II – Crime ambiental. Artigos 48 e 60, ambos da Lei nº 9.605/98. Entorno de área de relevante interesse ecológico. Reserva Florestal da Cicuta. III – Interesse específico da União. Competência da Justiça Federal. IV – Trancamento de ação penal. Não cabimento. V – Liminar revogada. Denegação da ordem. I. [...] II – As Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) podem ser instituídas tanto em propriedade pública quanto em particular (artigo 16, § 2º, da Lei nº 9.985), sendo que, no segundo caso, pode sofrer restrições ao uso. III [...] IV – A previsão de que as unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento, cujas normas deverão ser estabelecidas pelo órgão responsável pela administração da unidade (artigo 25 da Lei nº 9.985/2000), não implica em revogação da Resolução Conama nº 13/90. V – A ARIE Floresta da Cicuta ainda não possui plano de manejo. Aplica-se, como zona de amortecimento, a extensão de 10 km da área de entorno, definida na Resolução Conama nº 13/90, que prevê a necessidade de autorização da administração da ARIE e de licenciamento ambiental para as atividades a serem desenvolvidas em referida área. VI – Mesmo que as condutas narradas na denúncia tenham ocorrido dentro de propriedade particular, na área de entorno de 10 km da ARIE da Reserva Florestal da Cicuta, subsiste o interesse direto e específico da União na causa, posto que se trata de área sujeita à restrição administrativa ao uso da propriedade privada, estabelecida em favor daquela, e também porque a gestão, fiscalização e administração é atribuição do Ibama, autarquia federal [...] VIII – O paciente é administrador da empresa apontada na denúncia e as condutas que lhe são imputadas, foram, supostamente, praticadas no entorno da Floresta da Cicuta e dependiam de autorização prévia e licenciamento ambiental, o que não teria ocorrido. Assim, em tese, subsumem-se às condutas típicas previstas nos artigos 48 e 60, ambos da Lei nº 9.605/98. Não cabível o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. IX – Liminar revogada e ordem denegada (TRF da 2ª Região. HC 200602010068713. Desembargador Federal Abel Gomes. 1ª Turma especializada. DJU 10/10/2006, p. 253). No mesmo sentido vai a seguinte decisão: Administrativo – Mandado de Segurança – meio ambiente – Obra realizada no entorno de Unidade de Conservação – Atividade sujeita à fiscalização do Ibama – Legalidade do ato de embargo. I [...] II – O Decreto nº 99.274/90, que regulamentou a lei supracitada, prevê em seu art. 27 que ‘nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo Conama’, o qual, por sua vez, editou a Resolução nº 13/90, reforçando ainda mais o poder de fiscalização do Ibama sobre as referidas áreas [...]” (TRF da 2ª Região. AMS 200251010222863. Desembargador Federal Sergio Schwaitzer. 2ª Turma. DJU 8/6/2005, p. 248).*

Semelhante à hipótese da Floresta da Cicuta, porém com resultado diverso, é aquela que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região²³, quando o Estado do Ceará impugnou decisão do Juiz Federal da 7ª Vara daquele Estado, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, que determinou a sua atuação direta na proteção ambiental na área de domínio da União, destinada à implantação do Parque do Cocó, em Fortaleza, Ceará. Na oportunidade, o Tribunal, acompanhando voto do desembargador federal relator, Doutor Lázaro Guimarães, proferiu decisão que foi assim ementada: *Ementa Administrativo, Constitucional e Ambiental. Criação de Unidade de Conservação. Omissão do Poder Público. Exegese da Lei 9.985/2000, Lei 6.938/1981 e artigos 23, inciso VI e 225, parágrafo 1º, inciso III da CF. Possibilidade. Zona de amortecimento em área urbana consolidada. Art. 49 da Lei 9.985/2000. Impossibilidade. Manutenção da proibição de concessão de licenciamento restrita à área do ecossistema intocado, preservando a integridade do Parque Ecológico de Cocó, em Fortaleza. Agravo de Instrumento provido em parte.* Do voto condutor merece ser extraído o seguinte trecho: *No entanto, não vejo base legal para a criação de uma zona de amortecimento de 500 (quinhentos) metros no entorno do Parque, porque tais zonas têm como objetivo desestimular ou impedir a ocupação humana no entorno da unidade de conservação [...]. Ora, se a unidade de conservação está sendo demarcada em área de ocupação humana consolidada, com população adensada, residências, edifícios, estabelecimentos comerciais, shopping center, diversos órgãos públicos (entre os quais a Assembleia Legislativa) e demais equipamentos urbanos, não há como criar uma área de desestímulo a esta ocupação, que se deu dentro da própria dinâmica de crescimento do Município de Fortaleza, de forma disciplinada pela legislação urbana própria.*

A fórmula adotada pela decisão acima transcrita, contudo, como já foi visto, não tem sido o padrão prevalente em caso em tudo e por tudo assemelhados. As Cortes, muitas vezes, à falta de informação mais adequada sobre a realidade das ZAs e sem o exame mais minucioso dos termos de criação da unidade de conservação, bem como sem examinar a complexa sucessão de normas sobre o tema, tem admitido a imposição do perímetro de 10 quilômetros disciplinado pela Resolução 13/90 Conama, como uma “regra de ouro”. As consequências sociais e econômicas são relevantes e negativas, muito embora não se possa afirmar com segurança que delas advenham benefícios ambientais tangíveis e que justifiquem os inúmeros incômodos para a sociedade. No meu modo de ver, a decisão merece aplauso.

b) Normas aplicáveis a diferentes unidades de conservação de um mesmo ecossistema

Na existência de um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.

O regulamento da Lei (Decreto nº 4.340/2002) disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades.

b.1) Mosaico de unidades de conservação

O artigo 26 da Lei nº 9.985/2000, criou a figura do “mosaico de unidades de conservação”, que é uma figura jurídica inteiramente nova e sem precedente em nossa legislação sobre unidades de conservação. A ideia do “mosaico” é trazer para o Direito brasileiro a experiência de gestão de unidades de conservação que já é aplicada em diversos países, com destaque para o modelo francês. Evidentemente que a França, por ser um Estado unitário, possui menos problemas institucionais para a gestão de unidades de conservação, pois, de uma forma ou de outra, o poder central é um só. No caso brasileiro, a federação em três níveis implica enormes dificuldades, em função da autonomia política de cada um dos seus componentes. Indiscutível, portanto, que somente pela negociação e cooperação os diferentes entes federativos estabelecerão políticas comuns para unidades de conservação que coexistam em uma mesma área. O mosaico visa possibilitar que os diferentes atores se comuniquem e estabeleçam mecanismos capazes de assegurar uma gestão profissional e positiva para o conjunto das unidades de conservação. A matéria foi regulamentada pelos artigos 8º/11 do Decreto nº 4.340/2002.

A condição de “mosaico” de unidades de conservação depende do reconhecimento do MMA, mediante a expedição de ato próprio, em resposta a requerimento dos órgãos gestores das unidades de conservação interessadas em compatibilizarem as suas formas de gestão. Uma vez reconhecido o “mosaico”, é constituído um conselho de gestão que deverá ser criado segundo os critérios estabelecidos no Capítulo V do decreto regulamentar do SNUC.

A competência do Conselho de Mosaico é a seguinte: (i) elaborar seu regimento interno, no prazo de 90 dias, contados da sua instituição; (ii) propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar: (a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente: (1) os usos na fronteira entre unidades; (2) o acesso às unidades; (3) a fiscalização; (4) o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; (5) a pesquisa científica; e (6) a alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental; (b) a relação com a população residente na área do mosaico; (iii) manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e (iv) manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de conservação ou por outro órgão do Sisnama, sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico.

Por fim, vale ressaltar que, na forma do disposto no artigo 11, os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do MMA, integram os mosaicos para fins de sua gestão, sendo certo que, na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de conservação terá o mesmo tratamento da sua zona de amortecimento.

c) Plano de Manejo

A cada unidade de conservação deve corresponder um Plano de Manejo, que deverá conter as seguintes características mínimas (i) abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas; (ii) a ampla participação da população residente; (iii) deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

O Plano de Manejo das unidades de conservação mereceu regulamentação pelos artigos 12/16 do Decreto nº 4.340/2002. Cada unidade de conservação deve ter o seu próprio Plano de Manejo, que será elaborado pelo seu gestor ou proprietário, conforme o caso. Uma vez elaborado, o Plano de Manejo deve ser aprovado por órgão específico: (i) em portaria do órgão executor, no caso de EE, Rebio, PN, Monumento Natural, RVS, APA, ARIL, Flona, Reserva de Fauna e RPPN; (ii) em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão executor.

Em se tratando de Reservas Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável, o contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com populações tradicionais deve estar de acordo com o Plano de Manejo, *devendo ser revistos, se necessário*. Tal revisão, em minha opinião, somente pode ocorrer se, o que se admite por amor à argumentação, o contrato e o termo de compromisso estiverem em desacordo com a lei ou prejudicando o meio ambiente. Ambas as hipóteses parecem-me distantes. Como regra geral, o Plano de Manejo deve respeitar os usos anteriores – desde que não sejam ilegais ou nocivos ao meio ambiente. Conforme determinação contida no artigo 16, o Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do órgão executor.

É importante observar que o Plano de Manejo é a materialização concreta das unidades de conservação que, sem a sua existência, não passam de meras abstrações. Tal assertiva é especialmente válida para aqueles modelos de unidades de conservação que, sem se apossarem de bens de terceiros, estabelecem restrições para o gozo do direito de propriedade.

Nas UCs são proibidas as: (i) alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. Na inexistência de Plano de manejo e até a sua elaboração, todas as atividades e obras desenvolvidas nas UCs de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais; (ii) introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones, com exceção: a) em se tratando de APAS, Flonas, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, de animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da unidade; b) nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas, considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo.

d) Órgão gestor

Toda UC do grupo de Proteção Integral deve dispor de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2º do artigo 42 da Lei nº 9.985/2000, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão.

e) Recursos econômicos

A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto APA e RPPN, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento. Com a finalidade de auxiliar nos gravíssimos problemas orçamentários das UCs, a lei admite que os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação possam receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que demonstrem interesse em colaborar com a sua conservação. A administração de tais recursos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na implantação, gestão e manutenção da mesma. Embora não haja previsão legal, penso que seria bastante razoável que a lei estabelecesse a previsão de que o doador dos recursos fosse informado sobre a sua utilização e que dela participasse.

Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com critérios legais, que são os seguintes: a) até 50%, e não menos que 25%, na implementação, manutenção e gestão da própria unidade; b) até 50%, e não menos que 25%, na regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo; c) até 50%, e não menos que 15%, na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.

e.1) Exploração de bens e serviços

É passível de autorização a exploração de produtos, subprodutos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo com os objetivos de cada categoria de unidade. Tais produtos, subprodutos ou serviços inerentes à unidade de conservação, conforme o decreto regulamentador, são os seguintes: (i) aqueles destinados

a dar suporte físico e logístico à sua administração e à implementação das atividades de uso comum do público, tais como visitação, recreação e turismo; (ii) a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em UCs de Uso Sustentável, nos limites estabelecidos em lei. Somente se admite a exploração dos produtos, subprodutos ou serviços, conforme previsto no plano de manejo. Os usos anteriores ao decreto, desde que não sejam contrários à lei, permanecem válidos até o encerramento dos respectivos contratos, que não mais poderão ser renovados sem a observância do decreto de regulamentação do SNUC.

Admite-se o uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial, desde que cobrado conforme estabelecido em ato administrativo pelo órgão executor. Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for preponderantemente científica, educativa ou cultural, o uso será gratuito. Isso, contudo, não se aplica ao acesso a conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica e, muito menos, quando se tratar de imagens de comunidades tradicionais que têm direito à repartição de benefícios.

e.2) Utilização de imagens de unidades de conservação

A utilização de imagens de unidades de conservação brasileiras está disciplinada pela IN nº 5/2002, expedida pelo Presidente do IBAMA e que, no momento, deve ser aplicada pelo Instituto Chico Mendes, até que venha a ser substituída. A IN abarca as seguintes atividades: (i) filmagens, (ii) gravações e (iii) fotografias, de caráter educativo/cultural, científico, comercial e publicitário.

Qualquer utilização de imagem das UC, com exceção de APA e RPPN, só é permitida mediante prévia autorização, sujeitando o interessado às normas do artigo 33 da Lei nº 9.985/2000, que institui o SNUC.

A Administração deverá levar em consideração os seguintes critérios para a concessão da autorização pretendida: a) científico: Quando as imagens forem usadas como um instrumento de pesquisa, licenciada pelo IBAMA, conforme IN nº 109/97, que estabelece procedimentos para realização de pesquisa em UC, ou qualquer outro instrumento que venha a substituí-la; b) educativo cultural: Quando o projeto se propuser a divulgar e difundir informações relacionadas à biodiversidade e à gestão dos recursos naturais, vindo a ser um instrumento de transmissão de conhecimento e de interesse coletivo, como: documentários – programas de TV – matérias para revistas – fotografias para ilustração de livros – multimídia – CD-ROM – internet, que abordem aspectos sobre a fauna, flora e recursos hídricos da Unidade de Conservação; aspectos relevantes de natureza geológica, espeleológica, arqueológica e paleontológica da Unidade; registro de atividades de educação ambiental; pesquisas que estejam sendo desenvolvidas na Unidade; trabalhos que estejam sendo desenvolvidos com ou pelas comunidades do entorno; segurança do público; campanhas de utilidade pública desenvolvidas pelo Governo; comercial: Quando a Unidade for utilizada como cenário para difundir e divulgar informações de caráter privado ou comercial, tais como: gravações de programas de TV, anúncios, promoção de marcas, campanhas publicitárias, obras de ficção em qualquer meio ou bitola, promoção de cantores e conjuntos musicais, gravação de cenas para programas de entretenimento, fotos de modelos profissionais e atividades de ecoturismo.

f) Unidades de conservação e compensação por impactos ambientais negativos

Sempre que se tratar de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental negativo, assim considerado pelo órgão ambiental competente, após análise de estudo de impacto ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de UC do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto no artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 e no seu regulamento, observando-se os seguintes critérios: o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para a finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento; o órgão ambiental licenciador definirá as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e, ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas UCs; quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação em questão.

A norma, em minha opinião, só é aplicável quando o projeto a ser licenciado – de alguma forma – causar impacto sobre uma das unidades de conservação da região. Se assim não fosse, seria totalmente destituída de sentido a existência de medidas mitigadoras e compensatórias, pois estas seriam transformadas em verdadeiros impostos sobre a implantação de projetos utilizadores de recursos ambientais.

f.1) Regulamentação

A Compensação por significativo impacto ambiental foi regulamentada pelo Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009.

A lei, de fato, não se refere a um percentual máximo, limitando-se a mencionar um percentual mínimo de 0,5%. A fixação de tais percentuais, evidentemente, deve estar centrada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, se o percentual for excessivo, é sinal de que os danos ambientais a serem compensados são, igualmente, excessivos e, portanto, não licenciável o projeto.

Aliás, é bastante discutível o sentido de compensação estabelecido pela própria lei e pelo decreto, pois compensação ambiental – em minha opinião – deve significar uma melhoria ambiental – jamais uma substituição de tarefas que devem ser realizadas *ex officio* pelo próprio Poder Público. Em realidade, a prioridade estabelecida pelo artigo 33 do decreto está voltada para ações institucionais que devem ser previstas nos orçamentos das unidades de conservação.

11.5.4 Conservação *ex-situ*

A conservação da diversidade biológica não se faz exclusivamente em unidades de conservação, podendo ocorrer também em instituições científicas, o que é denominado como conservação *ex-situ*. Dentre as principais instituições encontram-se os Jardins Botânicos, cujo primeiro foi criado no ano de 1808, como Real Horto, na Cidade do Rio de Janeiro, pelo decreto de 6 de agosto, do Príncipe Regente D. João VI.

O Real Horto tinha por função preparar a aclimação de plantas produtoras de especiarias das Índias. Houve, portanto, na criação do Real Horto, uma finalidade essencialmente econômica e de pesquisa científica aplicada. Atualmente, o Real Horto é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, organizado como fundação. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o mais importante museu vivo do Brasil.

Os jardins botânicos são parques científicos e culturais que integram o conjunto das unidades de conservação brasileiras. São importantes unidades na estratégia de conservação devido ao acervo científico que acumulam, servindo de banco genético para áreas degradadas, bem como para evitar a extinção de espécies. As pesquisas de biodiversidade e de produtos farmacêuticos em geral devem muito aos jardins botânicos e aos seus acervos específicos.

Os jardins botânicos são sítios ecológicos de relevância cultural. Existem muitos Jardins Botânicos e Hortos Florestais no Brasil.²⁴

Os jardins zoológicos estão regulamentados pela Lei nº 7.173/1983. Nos termos do artigo 1º do referido diploma legal, jardim zoológico é qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública. O Poder Público federal, para atender finalidades socioculturais e científicas, poderá manter ou autorizar o funcionamento de jardins zoológicos. Os jardins zoológicos poderão integrar patrimônio público ou privado.

Os animais silvestres que integrem a coleção de um jardim zoológico permanecem de propriedade estatal. Diversas são as categorias nas quais um jardim zoológico pode estar enquadrado. O enquadramento levará em conta critérios técnicos, científicos, de dimensões etc.

11.6 A EXIGIBILIDADE LEGAL DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: DELIMITAÇÃO DOS DANOS

11.6.1 As intervenções aptas a gerar a compensação ambiental

A primeira questão a ser enfrentada quando se fala de compensação ambiental é a definição do tipo de intervenção sobre o meio ambiente e os recursos ambientais que podem dar margem ao surgimento da imposição da medida de compensação ambiental tratada pelo artigo 36 e seus parágrafos²⁵ da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o SNUC.

A CF, ao tratar do EIA, conforme a disciplina contida no inciso IV do § 1º do artigo 225, determinou a sua exigibilidade, *na forma da lei*, para *instalação de obra ou atividade* potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Assim, à lei ficou *reservada* a possibilidade de disposição sobre os EIA, ainda que boa parte da doutrina considere que a Constituição possa ser regulada por simples Resolução administrativa (MACHADO, 2005, p. 217). O fato é que, no que tange à compensação ambiental, a *CF sobre ela não dispôs expressamente e*, portanto, os seus limites são os legais, haja vista que não se lhe aplica diretamente nenhuma norma constitucional. Pois bem, a Lei nº 9.985/2000, *não incluiu* entre as hipóteses de cabimento da compensação ambiental as chamadas *atividades*, limitando-se a mencionar os *empreendimentos*.

Inicialmente, há que se consignar que a Constituição se utiliza de dois vocábulos distintos, a saber: (i) *obra* e (ii) *atividade*. Parece-me que os seus significados não são idênticos, pois do contrário não teria qualquer sentido o Constituinte se utilizar de tais sinônimos. Na verdade, *os termos são distintos* e tal condição tem sido reconhecida pelo poder regulamentar. A lei, como se pode ver, se utilizou do vocábulo *empreendimento* que, no contexto do artigo, tem o inequívoco significado de *obra*. Vejamos:

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. § 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

A *obra* tem sido reconhecida como a implantação física de um empreendimento com caráter de permanência, sendo que a atividade é algo passageiro e que se esgota em si próprio. Admite-se, contudo, que tem havido uma certa mistura dos conceitos em inúmeras Resoluções do Conama. No caso específico da indústria do petróleo, por exemplo, o levantamento de dados sísmicos não pode ser confundido com obra, haja vista que, uma vez feita a atividade, esta não deixará qualquer marca no ambiente, notadamente nos casos da chamada sísmica *off-shore*. Já a implantação de uma refinaria, seguramente, é um conjunto de obras que, certamente foi precedido de inúmeras atividades, tais como levantamento de dados de flora e fauna, da geologia e tantos outros.

As atividades não são suscetíveis de dar azo à compensação ambiental. No caso específico da indústria do petróleo, existe uma definição legal de pesquisa que nos é dada pelo inciso XV do artigo 6º da chamada Lei do Petróleo; nos termos da lei, Pesquisa ou Exploração é o “conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural”. Não me parece que, à luz da Lei do SNUC, a Pesquisa ou a Exploração possa ser compreendida no conceito de “empreendimento”. Empreendimento, no caso, vincula-se mais aos aspectos da produção, tal como definida em lei: “Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação”. Penso que o legislador deixou de fora da exigência da compensação ambiental as meras atividades, limitando-se a torná-la obrigatória para as hipóteses de empreendimentos (*rectius*: obras na linguagem constitucional).

11.6.1.1 A natureza dos danos capazes de gerar compensação ambiental

A Compensação Ambiental é um instrumento legal que se encontra previsto na Lei que instituiu o SNUC, conforme as disposições contidas nos artigos 36 e seus parágrafos. Entretanto, antes de sua instituição *por lei*, o Conama havia baixado a Resolução nº 2/1996, que em seu artigo 2º estabelecia que o valor da compensação não poderia ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais relativos à implantação do empreendimento. Evidentemente que a anterior normação do tema não encontrava amparo em nosso sistema constitucional e legal, motivo pelo qual novo tratamento foi dado ao assunto.

É importante observar que a Lei nº 9.985/2000, em seu artigo 36, determina um dever geral de “*apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral*”, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Penso que, no caso, o legislador estabeleceu uma presunção de que apoiar a implantação de unidade de conservação do grupo de proteção integral é medida apta a compensar determinados danos ambientais, como será visto adiante.

A compensação ambiental é instituto que se liga diretamente à questão referente à possibilidade ou não de *recuperação dos danos ao meio ambiente*. A CF, em seu artigo 225, § 3º, estabelece uma obrigação geral de reparação do dano causado ao meio ambiente. Entretanto, as realidades da vida prática, em não poucas vezes, impedem que haja uma recuperação do dano causado ao meio ambiente. Nas hipóteses em que tal dano é causado por uma atividade lícita, existe uma dificuldade, que é o estabelecimento de um balanço entre as suas diferentes consequências, sejam elas positivas ou negativas. A *compensação* surge quando se verifica que, em um balanço amplo dos diferentes resultados de uma intervenção humana no meio ambiente, a existência de dano ambiental é compensável e socialmente tolerável. Para que o nosso ponto de vista possa ser mais bem explicitado, passo a classificar os danos ambientais.

Os **danos ambientais**, como se sabe, podem ser: (i) **reparáveis**, (ii) **mitigáveis** ou (iii) **compensáveis**.

Reparáveis são aqueles danos que, dadas as suas dimensões, não ostentam um caráter de irreversibilidade; já os **mitigáveis** são aqueles que, mediante a intervenção humana, podem ser reduzidos a níveis desprezíveis, haja vista que intervenções técnicas adequadas são suficientes para mantê-los sob adequado controle. **Compensáveis** são os danos ambientais que, consideradas suas dimensões e características peculiares, **não podem ser reparados ou mitigados**, muito embora, quando sopesados com os *benefícios* que a intervenção venha a ocasionar, se justifiquem ante os termos do artigo 2º da Lei da PNMA. Assim, do ponto de vista teórico, a *compensação ambiental* somente tem sentido quando se está diante de um dano não recuperável ou não mitigável. A compensação não se presta para todo e qualquer dano ambiental. Não há que se falar em compensação ambiental para danos recuperáveis ou para danos mitigáveis.

É importante observar que a definição de grau de impacto é uma definição técnica e não jurídica. Não obstante tal fato, a definição técnica deve se balizar por alguns fatores legais, dentre os quais devem se destacar: (i) somente devem ser considerados os impactos não mitigáveis e não recuperáveis; (ii) tais impactos devem ser cotejados com os benefícios advindos do empreendimento; (iii) a extensão do dano é o elemento central do cálculo do grau de impacto e não os recursos investidos no projeto, como será visto adiante.

A lei do SNUC em seu artigo 36, estabeleceu uma *presunção legal de dano compensável* nos casos de “*licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental*”, com fundamento em EIA, obrigando o empreendedor a “*apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral*”. Parece-me evidente que o legislador, ao determinar o apoio a UC do grupo proteção integral, o fez por entender que **compensáveis** são apenas os danos causados aos chamados recursos ambientais, *verbi gratia*, flora, fauna, recursos hídricos etc.

Chamo a atenção para o fato de que a Lei do SNUC não faz qualquer referência às chamadas compensações sociais, ou socioambientais. No caso de um determinado empreendimento gerar externalidades negativas para terceiros, a hipótese é de ressarcimento de prejuízos causados ou de lucros cessantes, conforme o caso. Não se cuida da compensação estabelecida pelo artigo 36 da Lei nº 9.985/2000.

Observe-se que a aplicação da medida de compensação ambiental ao empreendedor de determinado projeto é um ato administrativo *vinculado às conclusões do EIA*. É o EIA que dirá da existência dos danos, das suas dimensões, da *recuperabilidade*, *mitigabilidade* ou *compensabilidade*. Daí a relevância dos EIAs bem compostos, apurados e tecnicamente bem construídos. A compensação ambiental, penso, não existe como uma medida autônoma cuja única condição de incidência seja a existência de um projeto precedido de EIA. Em nosso ponto de vista, a compensação ambiental se afirma como uma presunção legal *iuris tantum de dano ambiental não recuperável ou mitigável em empreendimento de elevado porte*. Isto é, cuida-se de uma presunção que *admite prova em contrário*. Importante observar que, aqui, *houve a inversão do ônus da prova para o empreendedor; que deverá comprovar que a hipótese de compensação ambiental não se faz presente no*

projeto proposto. Na verdade, parece-me evidente que o legislador determinou ao administrador que todos os empreendimentos que necessitem de estudo prévio de impacto ambiental devem ser examinados como se, *em princípio*, tivessem a capacidade de gerar impactos ambientais ditos compensáveis e não meramente aqueles recuperáveis ou mitigáveis. O que me parece lógico, pois empreendimentos que demandam EIA são, como regra, de grande porte.

Ressalte-se que, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, caso o empreendedor queira produzir prova perante a Administração Ambiental no sentido de que os impactos gerados pelo seu empreendimento são *mitigáveis* ou *recuperáveis*, tal oportunidade não lhe poderá ser sonogada, sob pena de ilegalidade da medida compensatória que venha a ser estabelecida.

Determinou o legislador que o administrador se preocupe com o meio ambiente e com a sua higidez de forma criteriosa. Como sabemos, o papel das presunções jurídicas é o de estabelecer determinadas premissas normativas que podem ser absolutas (*iuris et de jure*) e, portanto, não se derogam de forma alguma, ou podem ser relativas (*iuris tantum*) e podem ser desconstituídas no caso concreto.

É importante ressaltar que, por se tratar de *presunção relativa*, repita-se, cabe ao empreendedor fazer a prova no sentido de que, no caso concreto, não há dano ambiental compensável no processo de licenciamento ambiental. Como nos recorda Venosa (2005, p. 652), “a *presunção faz reverter o ônus da prova*”.

É necessário que se esclareça qual a racionalidade que informa a redação do artigo 225 da CF e a sua inserção no conjunto das normas constitucionais. É indiscutível que o artigo 225 da Constituição estabelece um conjunto de mandamentos constitucionais cuja finalidade última é a adequada utilização dos recursos ambientais, com vistas a assegurar-lhes a sustentabilidade e o correspondente desenvolvimento humano. Daí o constituinte ter tido o cuidado de determinar a elaboração de estudos de impacto ambiental previamente à implantação de obra ou atividade potencialmente ou efetivamente causadora de significativa degradação ambiental, conforme dispõe o inciso IV do § 1º do artigo 225 de nossa CF. Na verdade, partiu o Constituinte do raciocínio de que a *regra geral é a utilização econômica dos bens ambientais*, decorrendo daí a necessidade de que tal utilização se faça com a observância de cautelas constitucionalmente estabelecidas, dentre as quais alcança maior relevo o EIA. O EIA é, em princípio, o instrumento constitucionalmente adequado para prever os danos a serem produzidos por determinado empreendimento, indicar os meios de recuperação ou mitigação e, não havendo tais possibilidades, indicar a necessidade de compensação. Admitem-se os danos compensáveis na medida em que em análise de custo benefício se julgue conveniente suportar danos ao ambiente em troca de benefícios de outra natureza. Vêja-se, contudo, que os danos compensáveis são limitados e não podem ultrapassar um limite razoável, sob pena de, em análise custo/benefício, ser mais conveniente não implantar o empreendimento.

11.6.1.2 O impacto significativo e não mitigável

A matéria é relevante e, na prática, nela reside toda a dificuldade contida na complexa questão da compensação ambiental. Do ponto de vista estritamente legal, há que se considerar que significativo impacto ambiental é um **conceito indeterminado** e, portanto, preenchido em bases casuísticas. Uma possível resposta à questão está relacionada ao conceito de meio ambiente que adotamos. Particularmente, filio-me à corrente que entende que *meio ambiente* é um conceito mais amplo do que ecologia ou recursos naturais. Penso que *meio ambiente* é conceito que tem como centro o indivíduo humano e que tudo aquilo que circunda o indivíduo deve ser tido como meio ambiente; parto do pressuposto de que, em muitas hipóteses, um dano ecológico pode ser um benefício ambiental. Aliás, no regime constitucional brasileiro não é possível outra conclusão, haja vista que o princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais da República. Diante de tal princípio, só tem trânsito constitucional o conceito de proteção do meio ambiente que se funde no Ser Humano como fundamento último de sua proteção. Protege-se o meio ambiente, como forma mediata de proteção da vida humana e de uma vida vivida dignamente.

Os órgãos ambientais, como nos dá exemplo a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA,²⁶ buscam estabelecer alguns critérios que sirvam de orientação para suas equipes técnicas quando se faz necessária a avaliação dos impactos ambientais:

11.6.1.2.1 Interpretação e valoração dos impactos

Ligada à definição da importância dos impactos, esta atividade consiste em duas operações distintas. A primeira, chamada interpretação dos impactos, dedica-se a estabelecer a importância de cada um dos impactos em relação aos fatores ambientais afetados, o que vai depender do projeto que se analisa e de sua localização. A segunda, denominada valoração dos impactos, refere-se à determinação da importância relativa de cada impacto, quando comparada aos demais. A importância de um impacto significa sua resposta social, isto é, o quanto é importante esse impacto para a qualidade de vida do grupo social afetado e para os demais, e depende de um julgamento do valor. O grau de importância determinado pelos técnicos que executam o estudo será certamente diferente dos atribuídos pelos decisores e pelos representantes da comunidade. Daí a necessidade de se criarem condições para o envolvimento, nesta atividade, de todos os participantes do processo de AIA, em especial, dos grupos sociais afetados pelo projeto. Existem inúmeros métodos que permitem o envolvimento do público nas tarefas destinadas a definir graus de importância dos impactos confiáveis e representativos, evitando-se assim que o estudo apresente resultados insatisfatórios para um ou para outro ator do processo de AIA.

Diante do que foi anteriormente exposto, é fácil constatar que não é possível, *a priori*, definir o grau de significância do impacto ambiental apenas e tão somente pelas suas repercussões no *meio natural*, mas, necessariamente, devem ser consideradas as suas repercussões no *ambiente*, que é um conceito bem mais amplo. Foi dentro desse espírito, por exemplo, que o Conama, ao expedir a Resolução nº 1/1986, definiu uma relação exemplificativa de atividades modificadoras do meio ambiente, estabelecendo uma presunção *iuris tantum*, como vem sendo reconhecido por boa parte da doutrina especializada. Milaré (2005, p. 510) afirma com propriedade que:

A presunção relativa (iuris tantum), como se sabe, tem o condão de inverter o ônus da prova, de sorte que o Administrador, à vista de um caso listado, determinará a elaboração do EIA. O empreendedor, querendo, poderá produzir prova no sentido de que a obra ou atividade pretendida não provocará impacto ambiental significativo. Portanto, em vez de o agente público ter que provar a significância do impacto, é o empreendedor quem deve provar sua insignificância.

Outra questão importante é a seguinte: a CF estabelece que o Estudo de Impacto Ambiental deve ser exigido quando se tratar de licenciar uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. O conceito, no entanto, é aberto e somente pode ser preenchido através da edição de atos normativos, sejam legais ou regulamentares. A contrario sensu, se a atividade não se incluir entre aquelas que possam efetiva ou potencialmente ser agentes de poluição ou de degradação, o Estudo do Impacto Ambiental será inexigível. Ocorre que as atividades humanas são múltiplas e, diuturnamente, surgem novos projetos industriais, novos produtos e situações que, dificilmente podem ser antecipadas por atos normativos e legais. Estas questões, de crucial importância, seja para a atividade econômica, seja para a proteção do meio ambiente e da saúde humana, dependem da adequação e definição da natureza jurídica dos Estudos Prévios de Impacto Ambiental. O poder Executivo é o único autorizado a, mediante parâmetros fixados legalmente, definir se uma atividade é ou não causadora de significativo impacto ambiental. É importante observar que as listas de atividades potencialmente poluidoras devem ser examinadas com cuidado, pois não é raro que, em função da tecnologia adotada, uma atividade concreta possa estar aquém ou além do padrão no qual tenha sido classificada. Evidentemente que, em tais casos, a produção de estudos tecnológicos deverá ser levada em consideração para a real classificação da atividade.

A propósito, vale observar que o rigoroso TRF da 4ª Região, em admirável aplicação da análise custo-benefício, ao sopesar a intervenção no meio ambiente e o seu resultado concreto para a sociedade, entendeu desnecessário o EIA quando evidente o benefício decorrente da atividade.

1. Não há necessidade de estudo de impacto ambiental para mera limpeza de canais de escoamento e, in casu, a pretensão de nulidade de todas as autorizações, bem como a paralisação das obras de desassoreamento dos canais, deixa ao desamparo as populações vizinhas, que sofrem riscos de

calamidades decorrentes das cheias, como a proliferação de doenças como a dengue e a leptospirose, além de danos em residências, móveis e utensílios. 2. A aplicação da Resolução nº 237/97 do Conama deve ser feita com razoabilidade à luz do que dispõe o art. 225 da Constituição, sem esquecer que a obra que necessita de estudo de impacto ambiental/ relatório de impacto ambiental, é predicada pela “significativa degradação do meio ambiente”. 3. Verificando a situação concreta, limpeza e desassoreamento de canais vintenarios, operação que deveria ocorrer periodicamente, anualmente quiçá, não se mostra necessário o EIA/ RIMA a cada operação de limpeza, o que seria uma demasia, pelo seu alto custo e complexidade, daí a conclusão de que as autoridades avaliaram bem a situação, ao dispensá-los, neste caso] 4. Não podem, todavia, ser realizadas obras novas, como o canal entre os balneários ST Etienne e Albatroz, no balneário Matinhos, o do Rio da Onça e o ligando o Balneário Monções ao canal do Guaraçu, bem como o próprio alargamento do canal do Guaraçu sem os devidos EIA/RIMAs, no qual se discuta também a opção de “não fazer”. 5. A despeito da função institucional dos órgãos ambientais-réus, IBAMA e IAP, de fiscalizarem tudo o quanto se refira ao meio ambiente, degradação ou restauração, fica mantida a condenação de todos os réus, no que se refere ao cumprimento do Plano de Recuperação Ambiental, inclusive com a promoção da desocupação das áreas invadidas ou irregularmente ocupadas. 6. Parcialmente providos os recursos e a remessa oficial, afastada a condenação em honorários advocatícios, por incabíveis na espécie (Apelação Cível 2003.04.01.014704-5. Relatora: Desembargadora Marga Barth. 3ª Turma. Data de julgamento: 5/8/2003).

Importante realçar que as presunções, em matéria ambiental, operam efeitos tanto no sentido da existência quanto no da inexistência de danos significativos, como é o caso da matéria tratada pela Resolução nº 369/2006, do Conama. Nesse caso, estabeleceu-se *uma presunção em favor do empreendedor* que, conforme o caso concreto, poderá ser desconstituída pelo órgão ambiental mediante prova cabal de que os impactos gerados ultrapassam os benefícios decorrentes do empreendimento. Seria precipitada a interpretação de que a aludida Resolução teria autorizado toda e qualquer intervenção em APP. Tal conclusão não seria razoável, haja vista que implicaria negativa de vigência ao inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF.

A mitigação do impacto é a implementação de medidas técnicas capazes de reduzir a repercussão sobre o meio natural de um determinado empreendimento. É mitigação a exigência de tratamento de efluentes, da colocação de equipamentos aptos a diminuir a emissão de material particulado ou o lançamento de efluentes, barreiras para impedir a propagação de ruídos e outras. A mitigação vincula-se mais à operação do empreendimento do que à sua implantação, ainda que na implantação possa haver medidas mitigadoras, tais como a pavimentação de uma via para a diminuição de material particulado no ar. É mitigação a redução de resíduos sólidos gerados, a maior eficiência no uso da água. O papel da mitigação é reduzir o dano a níveis que o tornem insignificante.

11.6.1.2.2 Definição das medidas mitigadoras e do programa de monitoragem dos impactos²⁷

As medidas mitigadoras são aquelas destinadas a corrigir impactos negativos ou a reduzir sua magnitude. Identificados esses impactos, devem-se pesquisar quais os mecanismos capazes de cumprir esta função, avaliando-se sua eficiência. Os equipamentos para tratamento de despejos e emissões para a atmosfera incluem-se no elenco das medidas mitigadoras das diversas formas de degradação ambiental. Existe, na literatura especializada, uma vasta gama de medidas mitigadoras já utilizadas, o que pode auxiliar a execução desta atividade.

O programa de monitoragem dos impactos deve ser estabelecido como parte do estudo de AIA, de modo que se possam comparar, durante a implantação e operação da proposta, os impactos previstos com os que efetivamente vierem a ocorrer. Deve ser realizado, sempre que possível, para verificar a aplicação e a eficácia das medidas mitigadoras, assegurar que os padrões de qualidade ambiental não sejam ultrapassados, detectar impactos não previstos a tempo de corrigi-los e, também, contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos métodos de AIA e das técnicas de previsão e medição dos impactos, no sentido de melhorar o grau de precisão dos estudos futuros.

Impacto não mitigável, portanto, é aquele que não é passível de adoção de medidas técnicas para que as suas repercussões sobre o meio biótico sejam reduzidas a dimensões desprezíveis.

11.6.1.2.3 Comentários sobre a ADI nº 3.378-6

Faz-se aqui uma análise preliminar do acórdão proferido pelo STF na ADI 3.378-6 DF ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade do artigo 36 e seus parágrafos da lei que criou o SNUC. Como se sabe, desde o seu início a compensação ambiental tem sido muito polêmica e, evidentemente, o seu caminho natural seria passar pela prova da constitucionalidade. A decisão do STF é importantíssima sobre o tema. Contudo, ante a possibilidade da interposição de embargos de declaração pela União, ela ainda não é definitiva e uma análise de seu mérito, nesse momento, seria precipitada. Contudo, ante a densidade da decisão (cerca de 52 páginas), uma análise da concepção dos senhores ministros sobre princípios de Direito Ambiental e como tais princípios foram manejados no caso concreto parece-me bastante relevante.

O relator da ADI foi o **Ministro Carlos Britto**, que em seu voto invocou o princípio da “compensação-compartilhamento” que não se encontra presente nas principais obras doutrinárias sobre direito ambiental até aqui editadas no país. Pelo que se pode compreender do voto, tal princípio implica a obrigação do empreendedor participar do financiamento de unidades de compensação instituídas pelo poder público, sempre que a atividade que vier a ser desenvolvida seja potencial ou efetivamente causadora de significativo impacto ambiental. Um pouco mais adiante, em seu voto (fls. 251), afirma que: “*entendo que o art. 36 da Lei nº 9.985/00 densifica o princípio do usuário-pagador; este a significar um mecanismo de assunção da responsabilidade social (partilhada, insiste-se) pelos custos ambientais derivados da atividade econômica*”. Como se sabe, o chamado princípio do usuário-pagador encontra expressão normativa na Lei da PNRH. Busca o princípio usuário-pagador criar condições para que não ocorra desperdício dos recursos naturais, especialmente a água. Já o princípio poluidor pagador tem por objetivo estabelecer um mecanismo que leve o agente econômico a internalizar os custos ambientais de suas ações, refletindo-os nos preços, com vistas a impedir uma concorrência feita com base em subsídios ambientais não explícitos.

Mais adiante, em seu bem elaborado voto, Sua Excelência afirma que: “nessa ampla moldura, é de se inferir que o fato de, aqui e ali, inexistir efetivo dano ambiental não significa isenção do empreendedor em partilhar os custos das medidas preventivas. Isto porque uma das vertentes do princípio usuário-pagador é a que impõe ao empreendedor o dever de também responder pelas medidas de prevenção de impactos ambientais que possam decorrer, significativamente, da implementação de sua empreitada econômica” (fls. 252). À primeira vista, tem-se a impressão de que a orientação do Ministro-relator é a de que a compensação ambiental é devida pela simples existência da atividade econômica. A compensação, na concepção de Sua Excelência, é uma cláusula econômica geral voltada para a prevenção de possíveis danos ambientais, sejam eles identificados ou não. Aliás, há uma explicitação bastante feliz da opinião do Ministro, como se pode ver do seguinte trecho de seu voto: *Porque a compensação ambiental se revela como instrumento adequado ao fim visado pela Carta Magna: a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, respectivamente [...] não há outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional senão impondo ao empreendedor o dever de arcar; ao menos em parte, com os custos da prevenção, controle e reparação dos impactos negativos ao meio ambiente [...] porque o encargo financeiro imposto (a compensação ambiental) é amplamente compensado pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido na sua higidez.*

Contudo, como se pode ver do texto do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 e do seu decreto regulamentador, a compensação ambiental não está destinada à prevenção de danos ambientais causados por um empreendimento especificamente considerado. Na verdade, a norma legal determina que a compensação seja utilizada como meio de financiamento de unidades de conservação. Sem entrar no mérito de que a obrigação do financiamento das unidades de conservação é do Estado, o fato é que a compensação, tal como concebida pelo legislador, busca criar uma alternativa para os danos não mitigáveis e não recuperáveis e, portanto, compensá-los mediante a adoção de medidas capazes de gerar um valor ambiental positivo superior ao desvalor causado pelo empreendimento do qual foi a compensação cobrada. Parece-me, portanto, que a compensação não guarda qualquer relação com prevenção de danos.

A divergência foi inaugurada pelo Sr. **Ministro Marco Aurélio**, cujo ponto de vista central prendia-se ao fato de que o artigo 225 e seus parágrafos da Constituição Federal estão voltados para a recuperação de danos ambientais já realizados e que não caberia a compensação para danos futuros não adequadamente identificados e não comprovados. *De início, surge o conflito do § 1º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 com o § 2º e o § 3º do artigo 225 da Carta Federal. Enquanto estes versam situações já ocorridas – a circunstância de a atividade desenvolvida pela pessoa natural mostrar-se agressiva ao meio ambiente, contendo o § 3º a alusão até mesmo a infratores, a sanções penais e administrativas, a indenizações por danos causados – a norma atacada despreza, por completo, esses fatos geradores do ônus a ser imposto, que ganha contornos compensatórios. Prevê que o empreendedor, na fase embrionária do planejamento da atividade, visando à obtenção de licença, destinará recursos para implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, sendo o dispêndio realizado segundo preceitos da lei e o regulamento respectivo. Em síntese, há imposição de desembolso para obter-se a licença, sem mesmo saber-se da extensão de danos causados. Mais do que isso, em desprezo total ao princípio da razão suficiente, estabelece, como base de incidência do percentual a ser fixado pelo órgão licenciador, os custos totais previstos para a implantação do empreendimento e não o possível dano verificado.* (fls. 259)

O cerne da intervenção do **Ministro Marco Aurélio**, como se pode ver, está no próprio dano ambiental real e nas formas legais existentes para recuperá-lo ou indenizar quando a recuperação não for possível. De fato, uma leitura dos parágrafos constitucionais voltados para o tratamento dos danos ambientais nos revela que o mandamento primeiro é o de recuperá-los, ou seja, repristiná-los; a *indenização* é uma decorrência da impossibilidade de recuperação. Evidentemente que, em termos ambientais, a indenização não se confunde meramente com pecúnia. *A indenização ambiental é, na verdade, a compensação ambiental.* Ela só cabe nas hipóteses em que o dano não possa ser mitigado ou recuperado. Compensar por meio de mecanismos financeiros danos mitigáveis ou recuperáveis é, de fato, inpor tributos pelo simples fato de que o meio ambiente está sendo utilizado. Entretanto, a medida demanda uma alteração significativa em nosso sistema constitucional tributário. Sua Excelência ressaltou um aspecto muito relevante que é a fixação de um percentual sobre o investimento e não o custo do dano compensável em si, como base de cálculo para a fixação da compensação. Na verdade, parece-me que, da forma como a questão se coloca na lei, criou uma carga pecuniária pelo simples fato de existir um empreendimento a ser precedido de EIA. Isto é, há uma evidente natureza tributária que não consegue se esconder razoavelmente.

No mesmo voto é levantada outra questão bastante interessante, que é a da “presunção” de impacto gerada pela forma como a compensação é imposta aos empreendedores. *Não se pode conceber que, diante da clareza do artigo 225, § 2º e § 3º, da Carta Federal, jungindo a obrigação de indenizar aos danos causados [rectius: reparar] e verificados, dispor mediante – se é que assim se pode considerar – presunção, chegando a verdadeira comissão presentes os custos totais de implantação de certo empreendimento e, o que é pior, sem fixação em lei, ficando o percentual a ser definido pelo órgão ambiental licenciador [...].*

Foi pena que o Tribunal não tivesse se aprofundado no tema da presunção de dano. De fato, as presunções podem e devem ser utilizadas em matéria ambiental. Não é desconhecido que a lista de atividades que demandam estudos de impacto ambiental é uma presunção de danos significativos ao meio ambiente; tal presunção é relativa, pois o EIA poderá demonstrar que a atividade pretendida é licenciável e, portanto, causadora de danos socialmente suportáveis. Por relativa, a presunção admite prova em contrário. Entender a compensação como uma presunção a ser desconstituída (ou não) pelo empreendedor poderia ser um caminho para tornar a questão mais adequada ao contexto jurídico nacional e ambiental. Demonstrando-se, cabalmente, a inexistência de danos não mitigáveis ou não recuperáveis, a compensação – no caso concreto – perderia o sentido. Evidentemente que tal orientação não implicaria o abandono das regras rotineiras da responsabilidade ambiental.

Em aparte, o Sr. **Ministro Ricardo Lewandowski** atribuiu a obrigação de reparação do dano à aplicação concreta do princípio do poluidor pagador (fls. 266) e acrescentou que: *“vigora para o efeito de meio ambiente o princípio da precaução e também da antevisão, esse é um aspecto”.*

O Ministro **Celso de Mello**, aderindo à divergência, avançou na questão – crucial em meu ponto de vista – do elevadíssimo subjetivismo da norma que outorga ao administrador a possibilidade de fixação de valores sem que quaisquer parâmetros legais sejam observados. Eis a manifestação do Ministro: *Portanto, o parágrafo 1º, a meu juízo, com toda a vênia, mostra-se compatível com as exigências estabelecidas na Constituição, inclusive com a proposta feita, agora, pelo eminente Ministro Carlos ALBERTO MENEZES DIREITO e também acolhida pelo eminente Ministro Carlos Britto, mas o de se estabelecer a possibilidade de uma relação causal que permita definir o montante de recursos precisamente de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.*

Merece destaque o fato de que Sua Excelência apontou de forma aguda a contradição entre o estabelecimento de um valor pecuniário e o dano ambiental. *“Eu não concebo que, em se pagando, se possa implementar a degradação do meio ambiente.”* Na verdade, em singelas palavras, foram tocadas as maiores dificuldades da chamada “precificação” do meio ambiente e da economia ecológica, pois os critérios para a identificação de “valor” econômico para o meio ambiente ainda não lograram pacificação entre os estudiosos. Contudo, há um determinado grau de consenso que o direito a “comprar a degradação” não encontra sustentação diante de princípios morais, éticos e mesmo legais. A compensação, tal como concebida na lei – para não falarmos na sua prática concreta –, tem o inconfundível odor de “pedágio ambiental”. Na verdade, parece-me, ela é a filha bastarda da pouca relevância que o meio ambiente tem na Administração brasileira que, ao eximir-se de estipendiar os órgãos ambientais pela via orçamentária, optou por estabelecer a armadilha da compensação que, em sua lógica canhestra, acaba sendo a porta de entrada para projetos ambientalmente mais impactantes e, portanto, com compensações mais alentadas.

Para o **Ministro Menezes Direito**, que, em seu voto, sistematizou as posições anteriormente avançadas pelos seus colegas, um dos pontos relevantes foi a opinião do Ministro Celso de Mello no sentido de que, no caso concreto, *“pode ocorrer que não haja impacto significativo”*. Cuida-se, evidentemente, da inexistência do impacto compensável, conforme se pode inferir pelo conjunto do voto.

No que se refere à natureza jurídica da compensação, Menezes Direito aduziu que ela é *“compensatória porque visa preservar o meio ambiente e eventual empreendimento que possa causar o significativo impacto ambiental”*. Tal como estabelecida pela lei, a compensação somente tem lugar nos casos nos quais sejam exigidos os estudos prévios de impacto ambiental e que, por meio deles, fique demonstrada a existência de impactos significativos que não sejam mitigáveis ou recuperáveis, surgindo daí a categoria dos impactos ditos compensáveis. Contudo, o Ministro Menezes Direito encaminhou o seu voto no sentido de uma interpretação com redução do texto, tendo em vista a controvérsia que se instalara na Corte quanto ao percentual de 0,5% sobre o valor do investimento: *“[...] se assim entender o Pleno, fazemos uma declaração parcial de inconstitucionalidade, com redução do texto, apenas para tirar essas expressões ‘não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento’”. Vale observar, entretanto, que, à base do voto e da sugestão, encontra-se a possibilidade de que o órgão ambiental reconheça que não há dano compensável e, portanto, incabível a imposição do encargo. “E o órgão ambiental, com perícia técnica, e já vimos em várias ocasiões isto ser feito, poderá escalonar ou definir a situação em que se justificará esse pagamento (grifei) do empreendedor para preservar o meio ambiente e garantir a reposição [compensação] do meio ambiente se houver o significativo impacto ambiental.”*

A dificuldade de interpretação da fórmula proposta, contudo, não passou indiferente. Ao esclarecer questionamento formulado pelo **Ministro Joaquim Barbosa**, disse o **Ministro Menezes Direito**: *Se nós tiramos a ideia de percentual poderá ocorrer duas coisas: uma, não haver impacto ambiental significativo e nenhuma proporcionalidade entre o impacto ambiental e a participação do empreendedor na compensação do eventual impacto; a segunda, pode ser estabelecido outro critério que não seja o percentual sobre o empreendimento, porque esse critério, como está fixado no mínimo, pode levar ao máximo, ficando absolutamente descontrolado.*

Sustentando uma interpretação conforme **Joaquim Barbosa** feriu questão crucial que havia passado em segundo plano, que é a da limitação do percentual a ser atribuído ao gravame. Ante a inexistência de um máximo legal, o valor expresso na norma deveria ser o adotado como o maior possível. *Dessa forma, dou interpretação conforme para manter a norma em vigor, entendendo-se que a administração não poderá fixar percentual superior a meio por cento. Se o legislador não fixou patamar superior, penso que o administrador não poderá fazê-lo.* (grifei)

Finalizando o voto do Ministro **Menezes Direito**, surgiram algumas clarificações relevantes à adequada compreensão da compensação: *[...] O que nós estamos fazendo, é o que me parece, é estabelecer que é possível fixar um valor de acordo com o relatório de impacto ambiental {rectius: estudo prévio de impacto ambiental}, como já está previsto na lei, como disse o Ministro Carlos Britto, há perícia; vimos em outros casos que há critérios estabelecidos, e assim sucessivamente, e, ao mesmo tempo, assegurando, como disse o Ministro Celso de Mello, o pleno direito de defesa e do contraditório, nessa fixação. E, ademais, e*

me parece importante, estariam autorizados a que seria possível, sim, fixar um outro meio de compensação para a reposição do meio ambiente. Por exemplo: é possível que, no relatório de impacto ambiental se estabeleça que, para fazer um determinado tipo de empreendimento, seja necessário determinado tipo de repesamento. Pode-se, então, estabelecer não um percentual sobre todo o empreendimento, mas sobre determinada obra que se torne necessária para compatibilizar o empreendimento com a preservação do meio ambiente.

Os trechos anteriores demonstram que o debate ambiental chegou ao STF com força definitiva e que, cada vez mais, a Corte desempenhará um papel decisivo na matéria ambiental, haja vista o *status* constitucional que ela ostenta. Contudo, como se pode perceber dos elementos acima coligidos, o Tribunal ainda demonstra certa oscilação na fixação do conteúdo dos princípios próprios do Direito Ambiental. No entanto, como se pode ver dos votos dos Ministros **Celso de Mello**, **Joaquim Barbosa** e **Menezes Direito**, a principiologia própria do Direito Ambiental não está colocada acima de princípios constitucionais estabilizados como o da legalidade e o da ampla defesa. O tribunal repudiou a compensação ambiental como um valor a ser arbitrado pelo órgão ambiental sem a utilização de contornos claros – ainda que a sua fixação não seja tarefa simples –, bem como deixou claro que a imposição do encargo financeiro não pode ocorrer unilateralmente, sem que se ofereça ao interessado o direito de contestá-la. Certamente, com a interposição dos embargos de declaração, a decisão será mais bem esclarecida. As discussões doutrinárias que se seguirão, certamente, também contribuirão para um melhor entendimento do decidido.

O caso evoluiu no STF com a seguinte decisão: “Compensação ambiental. Decreto que regulamenta o art. 36 da Lei nº 9.985/2000. 1. O art. 31-A do Decreto nº 4.340/2002, acrescido pelo Decreto nº 6.848/2009, não afronta a autoridade do acórdão proferido na ADI nº 3.378, Rel. Min. Ayres Britto. 2. Na vigência do CPC/1973 e da Lei nº 8.038/1990, período em que ajuizado o presente feito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se firmou no sentido de que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a eficácia vinculante dos acórdãos abrange apenas o objeto examinado pela Corte. 4. De toda forma, o ato impugnado não desborda das razões de decidir utilizadas na ADI nº 3.378, não sendo, assim, possível acolher a tese da inicial nos rígidos limites da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rel. AgR 17364, Relator Roberto Barroso, 1ª Turma, Sessão Virtual de 14 a 20.10.2016).

11.7 A EXIGIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS FORMAIS

11.7.1 Termo inicial (*dies a quo*) para a exigência da compensação ambiental

Estabelecido, segundo a argumentação apresentada acima, que a compensação ambiental só é cabível nos casos em que o EIA demonstre a existência de danos ambientais ocasionados *diretamente* pelo empreendimento e que não possam ser classificados como *recuperáveis* ou *mitigáveis*. Como anteriormente explanado, há vinculação legal entre as conclusões do EIA e a imposição administrativa da compensação ambiental. Surge daí a relevante questão da fixação do *dies a quo* para sua exigência por parte do órgão de controle ambiental. Como nos recorda Venosa (2005, p. 516), “*denomina-se termo inicial (ou suspensivo ou ‘dies a quo’) aquele a partir do qual se pode exercer o direito [...]’*”.

Uma leitura do artigo 36 e seus parágrafos, da Lei nº 9.985/2000, não denuncia de forma clara o *dies a quo* para exigibilidade. Relembre-se que o texto legal define que *m os casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto no artigo 36 e seu regulamento (Decreto nº 4.340/2002). Conforme definido pela norma, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. As UCs a serem beneficiadas serão definidas pelo órgão de controle ambiental, considerando as propostas presentes no EIA/RIMA, ouvindo-se o empreendedor e admitindo-se inclusive a criação de novas UCs. Todavia, caso o empreendimento afete UC específica ou sua ZA, o licenciamento a que se refere ambiental só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação a ser custeada pelo empreendedor.*

Da mesma forma, o regulamento da lei em tela é omissivo quanto ao momento em que surge a obrigação de pagamento da chamada compensação ambiental: Efetivamente, o Decreto nº 4.340/2002, em seus artigos 31 e seguintes, *não cuida do tema*. Ante a omissão legal, há que se buscar uma solução por via da interpretação sistemática das diferentes normas envolvidas no tema.

11.7.2 Implantação do empreendimento: conceito

O primeiro aspecto que me chama a atenção é que a exigibilidade da compensação ambiental somente pode ser feita *ipso iure* após a análise do EIA e o reconhecimento de que existem danos ambientais compensáveis, isto é, aqueles não mitigáveis e não recuperáveis. Em geral, a aceitação do EIA ocorre **antes** da emissão da LP. Contudo, não seria razoável a exigência da compensação ambiental na fase da LP, tendo em vista que tal licença não autoriza o início de obras e, portanto, a sua simples concessão não é capaz de gerar qualquer dano ambiental, seja atual, seja potencial.

A licença que, em tese, pode dar margem ao surgimento de danos ambientais compensáveis é a LI, pois ela é aquela que autoriza o início da instalação do empreendimento. Aqui é necessário que se ressalte o fato de que projetos nem sempre são instalados inteiramente de uma só vez. Assim, a fase de implantação se refere apenas àquelas partes do projeto que, efetivamente, venham a ser implantadas, e tal fase se estende, como regra, até o início das operações de cada um dos diferentes segmentos do empreendimento. Ante a inexistência de uma previsão legal explícita quanto ao momento da exigibilidade da compensação, há que se avançar no conceito de implantação do empreendimento.

A resposta inicialmente deve se pautar pela definição semântica do verbo *implantar*; haja vista que é do seu conceito que decorre grande parte das consequências econômicas da compensação ambiental.

Segundo o Dicionário Aurélio:

Implantar. [De *im-1* + *plantar*².] *V. t. d e c. 1. Introduzir; inaugurar; estabelecer: Os colonizadores sempre tentaram implantar seus costumes nas terras conquistadas. 2. Inserir (uma coisa) em outra; plantar; arraigar; fixar: A árvore implanta suas raízes na terra. T. d. 3. Hastear; desfraldar; içar: Implantar uma bandeira. 4. Implantar (1). 5. Arquit. Demarcar no terreno as fundações de (a obra que será construída) [Grifo PBA]. 6. Cir: Fazer implante (2) de. P. 7. Plantar-se, arraigar-se. 8. Fixar-se, estabelecer-se.*

Já para o Michaelis:

Im.plan.tar (*im¹* + *plantar*) *Vtd 1 Plantar (uma coisa) em outra; arraigar; fixar: implantava na alma dos discípulos sódios ensinamentos cristãos. Vtd 2 Estabelecer; introduzir. “Filosofia materialista integral que a Rússia tenta implantar” (Tristão de Ataíde, ap Franc. Fernandes). Vtd 3 Hastear; arvorar: implantou a flâmula da vitória. Vpr 4 Arraigar-se, estar implantado: implantara-se uma parasita no tronco carcomido. Vpr 5 Estabelecer-se, fixar-se: [Grifo PBA] Grande leva de imigrantes ali se implantara.*

De acordo com o acima descrito, a implantação de um projeto pode ser parcial ou completa. Não é pouco usual que os projetos se implantem em fases consecutivas em função da capacidade de investimento do empreendedor, da necessidade de infraestrutura adequada e muitos outros fatores que variam de projeto a projeto. Assim, parece-me que a compensação ambiental, quando devida, somente o será na proporção da parcela do empreendimento que efetivamente estiver sendo implantada e não do empreendimento considerado como planejado, até mesmo porque muitas vezes os planejamentos são abandonados e os empreendimentos não se concretizam tal como outrora idealizados. Igual opinião é sustentada por Machado (2005, p. 789).

Assim, por implantação do empreendimento, deve ser entendida a fase que, efetivamente, estiver sendo construída pelo empreendedor até o início de sua operação efetiva; o mero encerramento das obras civis, em minha opinião, não caracteriza a efetiva implantação de um empreendimento.

11.7.2.1 *Compensação ambiental e empreendimentos já implantados*

Uma curiosa questão é a da possibilidade de exigência de compensação ambiental em empreendimentos já implantados e operando quando se cuidar da renovação da LO. Efetivamente, a norma contida no artigo 36 se refere a “*casos de licenciamento ambiental*” e não especifica qual a etapa do processo de licenciamento ambiental considerada. Contudo, somente uma interpretação de má-fé poderia sugerir que o artigo contempla a renovação de LO – ou outra qualquer que venha a ser concedida com o empreendimento já implantado e operacional –, pois o próprio *caput* do artigo 36 diz, textualmente, “*com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório*”. Ora, tal hipótese, por força do inciso IV do § 1º do artigo 225 da CF, é prévia à instalação e à operação de empreendimento capaz de gerar compensação ambiental.

O Decreto regulamentador da Lei nº 9.985/2000, em seu artigo 34, traz norma que, na minha opinião, não pode ser interpretada como estabelecidora de compensação ambiental retroativa. Vejamos o texto normativo:

Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante licença de operação corretiva ou retificadora.

O que me parece, foi determinado àqueles que operavam antes da edição do Decreto e que não estivessem licenciados que buscassem o órgão ambiental com vistas à obtenção das respectivas licenças ambientais.

O decreto jamais poderia definir uma compensação retroativa, haja vista que a lei não dispôs dessa forma. E mais: mesmo que estivessemos em sede de interpretação da norma, tal interpretação não poderia retroagir, ante expressa vedação legal contida na Lei nº 9.784/99 que, em seu artigo 2º, XIII, estabelece a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação de norma legal.

11.7.2.2 *Extensão da compensação ambiental em relação ao volume de recursos investidos pelo empreendedor*

Como tem sido amplamente examinado no presente parecer, existem falhas relevantes no arcabouço legal da chamada compensação ambiental. Tais falhas, contudo, devem ser minimizadas, com vistas ao aproveitamento da norma jurídica. Portanto, o intérprete se vê diante de tema complexo e que demanda a construção de um raciocínio jurídico que se adapte à presunção de constitucionalidade das leis. Isso impõe a adoção do chamado princípio da *interpretação conforme*. Os notáveis administrativistas ibéricos, Enterría e Fernandez (1990, p. 139), assim definem o mencionado princípio:

A origem do princípio que impõe a interpretação, conforme a Constituição, de todo o ordenamento, está no processo de constitucionalidade das leis: antes de que uma lei seja declarada inconstitucional o juiz que efetua o exame tem o dever de buscar, em via interpretativa, uma concordância da dita lei com a Constituição. A anulação de uma lei é um acontecimento bastante mais grave que a anulação de um ato da Administração, porque cria por si só uma grande insegurança jurídica. [...] É este horror vacui (?) o que determina o princípio formulado assim pelo Tribunal Federal Constitucional alemão: é válido o princípio de que uma lei não deve ser declarada nula quando pode ser interpretada em consonância com a Constituição.

Assim, daremos à compensação ambiental o tratamento de *receita pública*. Como nos recorda Torres (2005, p. 186), ao tratar sobre as receitas do Estado, “*originárias são aquelas que decorrem da exploração do patrimônio do estado, compreendendo os preços públicos, as compensações financeiras e os ingressos comerciais*”. Essa é uma interpretação que, fundando-se no fato de que o meio ambiente é um bem público, cuja defesa compete ao Poder Público. Contudo, há que se observar que a compensação ambiental se reveste de caráter peculiaríssimo, haja vista que *não possui expressa previsão constitucional*, como é o caso da compensação financeira prevista no artigo 20, § 1º, da CF. Entretanto, para que se possa interpretar a norma conforme a Constituição, no caso concreto, há que se temperar alguns de seus comandos, sob pena de uma completa invalidação da norma.

Como compensação financeira, o que se admite para a finalidade de assegurar a constitucionalidade da norma, esta não pode ser exigida do particular sem a fixação de um limite máximo, sob pena de se constituir em verdadeira aberração jurídica. De fato, o legislador, ao redigir o § 1º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, foi extremamente infeliz ao determinar que o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor como compensação ambiental não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Com efeito, *a lei não estabelece um máximo a ser cobrado a título de compensação ambiental e*, como tal, ostenta uma verdadeira natureza confiscatória, pois delega ao administrador a possibilidade de fixar o valor da compensação até o infinito. Aliás, veja-se que mesmo que o administrador fixe um “teto” para a compensação, este seria arbitrário, pois sem expressa e prévia previsão legal. É indiscutível que há que se ter por inconstitucional a expressão “*não pode ser inferior*” e admitir-se que 0,5% é o valor que o legislador entendeu como máximo aplicável. Há particularidade na receita acima descrita, haja vista que, de acordo com o *caput* do artigo 36 da Lei do SNUC, “*o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral*”. Há, portanto, compulsoriedade e, havendo a compulsoriedade, parece-me evidente que o empreendedor tem o direito subjetivo de saber até onde vai o limite legal de sua obrigação. Vale, no caso vertente, a oportuna observação de Saliba (2005, p. 150).

Ressalte-se que, ainda que se diga, bem como se aceite em termos meramente didáticos e não financeiros, que o tipo de receita originária provenha de bens pertencentes ao patrimônio público, ou seja, da sua exploração, não podemos perder de vista que efetivamente quem vai arcar com este custo será sempre um determinado particular.

O legislador, evidentemente, estabelece o valor a ser cobrado pelo administrador, não podendo deixá-lo submetido ao livre-arbítrio do Executivo, ante a prevalência do princípio da legalidade constitucional. Assim, parece-me que o percentual máximo a ser estabelecido pelo administrador é aquele que a lei, equivocadamente, acoimou como mínimo. Essa é a única fórmula que me parece possível e viável para que se tenha como constitucional a norma em questão.

Resta a questão referente ao *valor mínimo da compensação*. Conforme visto acima, o valor da compensação ambiental foi fixado em um *máximo* de 0,5% do valor do investimento. Há uma relevância em se indagar se a lei admitiria uma gradação entre os valores devidos. Entendo que sim. Penso não haver dúvidas quanto ao fato de que o legislador determinou ao administrador que adote uma proporcionalidade entre “o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento” e o valor cobrado como compensação. Cuida-se, em meu modo de ver, de um comando imperativo e que não deixa ao administrador qualquer margem de discricão. Cabe-lhe estabelecer mecanismo capaz de definir valores de compensação proporcionais aos impactos reais, não mitigáveis e não recuperáveis do empreendimento a ser implantado. O próprio Decreto nº 4.340/2002, embora partindo de um pressuposto constitucionalmente equivocado, reconhece a necessidade de proporção entre o valor a ser cobrado a título de compensação e o dano efetivamente causado. Veja-se que o parágrafo único do artigo 31 do Regulamento, os percentuais serão fixados gradualmente. Como já vimos, é possível a inexistência de danos compensáveis na implantação de determinado empreendimento e, portanto, a compensação zero é uma hipótese a ser considerada. Destarte, uma variação entre zero e meio por cento do valor do investimento está compreendida entre os objetivos da lei.

Dessa forma, desde que não implique a dispensa do pagamento da compensação ambiental, o administrador poderá dar-lhe uma dimensão proporcional ao dano e não puramente ao investimento, haja vista a inexistência de uma expressa previsão legal quanto aos valores máximos a serem cobrados. Ainda que em seara de direito privado, mas como apoio ao nosso raciocínio, também podemos nos socorrer do artigo 944 do CC, que pode ser aplicado pelo órgão ambiental sempre que evidente uma desproporção entre o dano e o valor da compensação a ser cobrada.

Como amplamente tratado ao longo do presente, o valor de meio por cento é um valor máximo. Uma vez que o valor devido deve ser calculado em função do impacto ambiental realmente causado, conforme demonstrado no EIA, a cobrança deverá ser proporcional ao impacto. Na inexistência de impacto compensável, o

11.8 AMPLA DEFESA E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Aspecto relevante da questão que está sendo tratada no presente parecer é o que se refere às diferentes concepções sobre a natureza dos impactos ambientais gerados pela implantação de determinado empreendimento. Não será pouco comum que o órgão ambiental considere que o empreendimento é gerador de danos ambientais compensáveis e que o empreendedor considere que os danos são mitigáveis ou recuperáveis e que os compensáveis não têm a dimensão que lhes é atribuída pelo órgão de licenciamento. Como essa questão pode ser resolvida?

Penso que, indiscutivelmente, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo (*rectius*: processo) que trata diretamente de direitos e garantias individuais expressamente tutelados pela CF. Em tal condição, não há como se furtar à aplicação da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Na forma de tal norma, estabelecer-se-á o contraditório administrativo com vistas à produção das provas capazes de demonstrar a veracidade do ponto de vista de uma ou de outra parte, com a aplicação dos artigos 29 e seguintes da lei em tela. Vale observar que não há uma lei disciplinando o processo de licenciamento ambiental, o que seria desejável e necessário.

Além da necessidade do contraditório para a solução das divergências entre as partes e diante do exame que estamos procedendo da matéria, não nos foi possível encontrar qualquer norma que condicione a concessão de qualquer uma das licenças ambientais à quitação dos valores que possam vir a ser exigidos em termos de compensação ambiental. Com efeito, o artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, limita-se a afirmar que:

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/ RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.

Como se sabe, em direito administrativo não se presumem restrições; e mais: a intervenção na esfera privada somente se faz legal mediante expressa autorização de lei.

É importante observar que o legislador, quando entendeu necessário estabelecer algum vínculo de condicionalidade entre o procedimento de licenciamento ambiental e a proteção das unidades de conservação, o fez de forma expressa, como definido no § 3º do artigo 36, que determina a prévia autorização do órgão gestor de unidade de conservação específica ou de sua zona de amortecimento quando estes forem afetados pelo empreendimento, estabelecendo, ainda, que a unidade de conservação em tela deverá ser beneficiada pela compensação. Aqui parece-me evidente que, sem autorização do órgão gestor da unidade de conservação não há que se conceder a licença pleiteada. Trata-se, contudo, de uma exceção. Ressalte-se, por oportuno, que o requisito é a autorização e não o pagamento da compensação.

A Administração Pública, como se sabe, somente pode agir dentro dos estritos e estreitos limites da legalidade, não podendo formular exigências aos empreendedores que não encontrem **base legal**. Tem sido comum o estabelecimento de “condicionantes” nas licenças que se vinculam diretamente ao pagamento da compensação ambiental. Parece-me que, *data venia*, a hipótese é de desvio de finalidade. Efetivamente, cria-se uma “condicionante” não ambiental com o único desiderato de arrecadar o valor correspondente à compensação. O estado dispõe de meio legais para a cobrança dos valores de compensação ambiental que julgue devidos, podendo utilizar-se, inclusive, da execução fiscal, que é forma privilegiada de cobrança de débitos.

A oposição de “condicionante” vinculada ao pagamento da compensação ambiental viola o princípio da ampla defesa constitucional, como já tem sido decidido pelos tribunais superiores em casos que, embora não sejam totalmente assemelhados, servem como base de raciocínio

STJ: “Súmula 127: É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. É evidentemente inconstitucional qualquer tentativa de criar uma obrigatoriedade para a compensação ambiental, vinculando a própria validade da licença ao seu pagamento, visto que a lei não estabelece qualquer indicação nesse sentido (STJ. REsp 633432/MG. Recurso Especial 2004/0030029-4. Ministro Luiz Fux. 1ª Turma. DJ 20/6/2005, p. 141. “Administrativo. Contrato. ECT. Prestação de serviços de transporte. Descumprimento da obrigação de manter a regularidade fiscal. Retenção do pagamento das faturas. Impossibilidade.

1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento licitatório funda-se na CF, que dispõe no § 3º do art. 195 que ‘a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios’, e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei 8.666/93. 2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale assentar que a Administração poderá atuar tão somente de acordo com o que a lei determina. 3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção do pagamento pelos serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a referida sanção à empresa contratada, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a prestação dos serviços. 4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional ‘não significa que a Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A administração poderá comunicar ao órgão competente a existência de crédito em favor do particular para serem adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de segurança’ (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, Editora Dialética, 2002, p. 549). 5. Recurso especial a que se nega provimento”).

Há que se observar que ante o ineditismo do tema, não há uma jurisprudência prévia ou legislação específica que possa nos guiar no tema. Necessário se faz, portanto, que algumas situações assemelhadas sejam vistas.

O CTN, em seu artigo 205 determina que *a lei* poderá exigir a prova da quitação de determinados tributos, mediante a expedição de certidão negativa. Observe-se, contudo, que nas hipóteses em que possa haver a perda do direito, a própria certidão pode ser dispensada, conforme permissivo do artigo 207 do CTN. Assim, no caso da compensação, a expedição das licenças na existência de pendência quanto aos valores em nada obstaculiza o direito de a administração cobrá-la pelas vias próprias e legais.

11.9 EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

A compensação ambiental tem dado margem a muitas polêmicas, em especial no que tange ao seu regime de execução. Com vistas a pacificar a matéria foi editada a Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018 que autorizou o Instituto Chico Mendes a selecionar instituição financeira oficial, dispensada a licitação, para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinados às unidades de conservação instituídas pela União. A possibilidade de nomeação, apenas de instituição oficial merece crítica. Com efeito, o volume de recursos destinados à compensação ambiental é muito elevado e deveria ser levado em consideração a instituição que cobrasse as menores taxas de administração, bem como oferecesse mais eficiência na gestão. Ademais, estimular-se-ia a competição entre as instituições financeiras. Igualmente, não faz sentido estabelecer que a instituição financeira oficial ficará responsável pela “execução, direta ou indireta, e pela gestão centralizada dos recursos de compensação ambiental destinados às unidades de conservação instituídas pela União e poderá, para a execução indireta, firmar contrato com instituições financeiras oficiais regionais.”

A ideia de instituição de um fundo privado para gerir os recursos oriundos da compensação ambiental é boa. Todavia, a ideia não foi levada às suas últimas consequências, pois a gestão foi entregue, na prática para instituições financeiras públicas, com as dificuldades que lhes são inerentes. Como se sabe, instituições

financeiras não são capacitadas para gestão ambiental, muito menos implantação de projetos de recuperação ambiental. Elas deveriam ficar responsáveis apenas pela aplicação dos recursos, pela melhor remuneração para tais aplicações e de repassá-los, conforme decidido pelos órgãos de controle ambiental responsáveis pela aprovação dos projetos de compensação. Igualmente, é despropositada a autorização para que as instituições financeiras promovam as desapropriações dos imóveis privados indicados pelo Instituto Chico Mendes que estejam inseridos na unidade de conservação destinatária dos recursos de compensação ambiental. Também, neste particular, não me parece que seja uma tarefa de instituições financeiras, nem que elas tenham qualquer interesse na tarefa, pois como sabemos, as ações de desapropriação tendem a se prolongar indefinidamente – no caso das desapropriações contenciosas. Por outro lado, quais seriam os critérios adotados para as desapropriações “amigáveis”?

O Fundo Privado terá por objetivo o (i) apoio a projetos de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação, em caráter auxiliar; (ii) apoio à identificação, à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação; e (iii) apoio a ações de uso sustentável, monitoramento, manejo e pesquisa de espécies nativas de interesse econômico, em caráter auxiliar.

Uma importante medida é o fato de que o depósito integral do valor da compensação ambiental no Fundo, pelo obrigado a compensar, o desonera da obrigação.

- ¹ *O desafio do desenvolvimento sustentável – relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento*, Brasília, 1991, p. 78.
- ² Disponível em: <<http://sistemas.mma.gov.br/portalcnuv/index.php?ido=principal.index&idConteudo=6301&idEstrutura=119>>. Acesso em: 14 mar. 2008.
- ³ Lei nº 9.985/2000: Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.
- ⁴ Disponível em: <http://cmsdata.iuc.org/downloads/speaking_common_language.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2010.
- ⁵ Disponível em: <<https://www.valor.com.br/brasil/5099642/entenda-os-objetivos-e-riscos-da-extincao-da-renca-na-amazonia>>. Acesso em: 19 nov. 2018.
- ⁶ Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
- ⁷ Disponível em: <<https://www.seropedicaonline.com/ultimas-noticias/extincao-da-renca-por-meio-de-decreto-e-inconstitucional/>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ⁸ Observa-se que, diante do texto constitucional, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (art. 225, § 1º, IV) é exigível “para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente” e não para “relevante impacto ambiental” conforme consta da Resolução.
- ⁹ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁰ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹¹ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹² Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹³ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁴ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁵ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁶ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁷ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁸ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ¹⁹ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ²⁰ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ²¹ Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc.html>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ²² Disponível em: <<http://www.icmbio.gov.br/brasil/MA/municipios/barreirinhas/parna-lencois-maranhenses>>. Acesso em: 7 jul. 2010.
- ²³ Disponível em: <https://www.trf5.jus.br/revista_jurisprudencia/documentos/Rev_78_27032009.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2010.
- ²⁴ Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/artigo/5743_JARDINS+BOTANICOS+NATUREZA+VALORIZADA>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ²⁵ Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. § 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. § 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. § 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o *caput* deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo. § 4º A obrigação de que trata o *caput* deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal.
- ²⁶ RT – 040-R-2 – Avaliação de Impacto Ambiental – AIA.
- ²⁷ RT – 040-R-2 – Avaliação de Impacto Ambiental – AIA.

A produção e utilização dos OGMs no Brasil encontram-se regidas pela Lei nº 11.105/2005, que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.591/2005, e por muitos outros atos normativos e, em especial, por normas da CTNBio.

12.1 OBJETIVOS, CONCEITOS E PROIBIÇÕES DA LEI DE BIOSSEGURANÇA

A Lei nº 11.105/2005 tem por escopo estabelecer as normas de segurança e mecanismos de fiscalização relativos a construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e o descarte de OGMs e seus derivados. É, ainda, objetivo da norma servir de estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, à proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e à observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Quanto à observância do princípio da precaução, não resta dúvida de que esta se fará, nos termos precisos da Lei de biossegurança, haja vista que tal lei é a expressão normativa da aplicação do mencionado princípio pelo legislador pátrio. A lei não autoriza uma aplicação subjetiva e autônoma do princípio da precaução, sobretudo se considerarmos que a aplicação do princípio está, em sede legal, hierarquizada em mesmo nível que o estímulo ao desenvolvimento científico. Faço tal observação, pois não me parece que o PP possa ser invocado, no caso concreto, como um freio à pesquisa e ao estudo, como tantas vezes acontece.

A atividade de pesquisa tratada pela Lei é aquela que é realizada em laboratório, regime de contenção ou campo, como parte do processo de obtenção de OGM e seus derivados ou de avaliação da biossegurança de OGM e seus derivados. Estão compreendidos em tais atividades, no âmbito experimental, a construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a liberação no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados.

A Lei considera comercial aquela atividade que não se enquadra como de pesquisa e que trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da transferência, da comercialização, da importação, da exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais.

Os agentes das atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial, somente podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas perante a CTNBio, que serão responsáveis pela obediência aos preceitos da Lei e de sua regulamentação e responderão em caso de sua inobservância.

Conceitos da lei: i) organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas; ii) ácido desoxirribonucleico – ADN, ácido ribonucleico – ARN: material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência; iii) moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural; iv) engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante; v) organismo geneticamente modificado – OGM: organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética; vi) derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de OGM.

A utilização de OGMs está proibida (artigo 6º) para: i) implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual; ii) engenharia genética em organismo vivo ou o manejo *in vitro* de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas na lei; iii) destruição ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 e demais da Lei e de sua regulamentação; iv) liberação no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma da lei e de sua regulamentação; v) a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

O artigo 7º determina que são obrigatórias: i) a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área de engenharia genética e o envio de relatório respectivo à autoridade competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data do evento; ii) a notificação imediata à CTNBio e às autoridades da saúde pública, da defesa agropecuária e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminação de OGM e seus derivados; iii) a adoção de meios necessários para plenamente informar à CTNBio, às autoridades da saúde pública, do meio ambiente, da defesa agropecuária, à coletividade e aos demais empregados da instituição ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM.

12.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE BIOSSEGURANÇA

12.2.1 Conselho Nacional de Biossegurança

12.2.1.1 Atribuições e competências

O sistema de Biossegurança no Brasil é estruturado de forma hierárquica, sendo encimada pelo CNBS, que é vinculado organicamente à Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança – PNB. É órgão de natureza política e não técnica. As suas decisões, ainda que levando em consideração as questões técnicas decididas pela CTNBio, não estão adstritas ao parecer técnico emitido pela Comissão. O juízo formulado pelo CNBS é essencialmente de conveniência e oportunidade. Averte-se, contudo, que o juízo discricionário não se afasta do balizamento legal. Logo, uma decisão fundada em juízo de conveniência e oportunidade não significa que os aspectos de legalidade tenham sido desprezados pelo administrador, haja vista que este último está jungido à observância do princípio da legalidade. O que o CNBS faz é examinar se determinada liberação de OGM atende às diferentes necessidades públicas que vão desde o incremento da atividade econômica até a proteção da saúde e o meio ambiente. As suas competências são

as seguintes: i) fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com competência sobre a matéria; ii) analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de OGM e seus derivados; iii) avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no artigo 16 da lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados.

É interessante observar que a natureza política do CNBS se materializa em sua capacidade advocatória, quando julgar necessário. O permissivo está perfeitamente inserido no princípio da hierarquia administrativa que faz com que os órgãos superiores possam exercer controle sobre aqueles que lhes são inferiores, seja quanto à legalidade das ações empreendidas, seja quanto à conveniência e oportunidade da ação de determinados comportamentos por parte dos órgãos inferiores da pública administração. Observe-se que ele pode avocar e decidir, como última instância administrativa, os processos administrativos que tramitam perante a CTNBio. Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente à realização da atividade analisada, encaminhará sua manifestação aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 da Lei. Quando o CNBS deliberar contrariamente à atividade analisada, encaminhará sua manifestação à CTNBio para informação ao requerente. Neste último caso, somente a revisão judicial poderá reverter a decisão do CNBS, alertando-se para o fato de que tal reversão somente poderá ocorrer em função de vícios de legalidade, vez que ao Judiciário é defeso o exame de mérito dos atos administrativos, salvo quando este se confundir com questões de legalidade.

12.2.1.2 Composição

O CNBS é formado por integrantes de alto nível governamental que são os seguintes: i) Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; ii) Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; iii) Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; iv) Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; v) Ministro de Estado da Justiça; vi) Ministro de Estado da Saúde; vii) Ministro de Estado do Meio Ambiente; viii) Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; ix) Ministro de Estado das Relações Exteriores; x) Ministro de Estado da Defesa; xi) Secretário Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República.

12.2.2 A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio

A CTNBio é a base do sistema de biossegurança e dela partem as principais decisões sobre o tema. Ela é um órgão que integra a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo uma instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo cuja finalidade é prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança de OGM e seus derivados, assim como estabelecer normas técnicas de segurança e oferecer pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zootossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. Assim, toda e qualquer questão referente à Biossegurança é decidida administrativamente pela CTNBio, cuja decisão prevalecerá sobre a de qualquer outro órgão administrativo, à exceção do Conselho Nacional de Biossegurança, que lhe é hierarquicamente superior.

12.2.2.1 Composição da CTNBio

A CTNBio é composta por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente. Assim, como se vê de sua composição, em princípio, a principal característica é que ela é técnica. Observe-se que a CTNBio é uma Comissão e não um Conselho. A designação de Comissão tem por finalidade enfatizar o lado técnico das atividades por ela desenvolvidas, em contraposição aos aspectos políticos e sociais que caracterizam, por exemplo, o Conama, sendo: (a) 12 (doze) especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício profissional, dos quais: (i) 3 (três) da área de saúde humana; (ii) 3 (três) da área animal; (iii) 3 (três) da área vegetal; (iv) 3 (três) da área de meio ambiente; (b) um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos titulares: (i) Ministério da Ciência e Tecnologia; (ii) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (iii) Ministério da Saúde; (iv) Ministério do Meio Ambiente; (v) Ministério do Desenvolvimento Agrário; (vi) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (vii) Ministério da Defesa; (viii) Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República; (ix) Ministério das Relações Exteriores; (c) um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça; (d) um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde; (e) um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; (f) um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; (g) um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário; (h) um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego.

O legislador adotou um sistema que garante uma participação moderada da sociedade na composição da CTNBio, haja vista que determina que os integrantes externos à Administração sejam selecionados a partir de listas triplices encaminhadas ao Executivo para que seja escolhido o membro da Comissão. Os conselheiros serão indicados para mandatos de dois anos que, no entanto, não lhes assegura direito ao exercício do tempo integral, pois na realidade os mandatos são meras delegações administrativas, não podendo impedir que o Executivo substitua o conselheiro que não esteja atuando conforme as expectativas da Administração. Na verdade, portanto, os dois anos devem ser entendidos como um período máximo de exercício da função de conselheiro, permitida a recondução por igual período.

12.2.2.2 Funcionamento da CTNBio

O funcionamento da CTNBio tem sido motivo de muita controvérsia e polêmica. Não há a menor dúvida de que a CTNBio, como uma comissão governamental, está plenamente adstrita à observância dos elementos e princípios que regem todo e qualquer órgão da Administração Pública, principalmente os princípios da legalidade e da publicidade dos atos administrativos. Assim, salvo justificativa fundamentada e levada ao conhecimento público, as reuniões da CTNBio devem ser públicas e abertas ao público em geral que, evidentemente, deverá se comportar de forma compatível. Contudo, a CTNBio tem tido muita dificuldade em observar tal circunstância legal, o que tem gerado muitas medidas judiciais sobre o fato. Por força de tais realidades, o TRF 1 reafirmou o caráter público das reuniões da CTNBio, como nos deixa ver o seguinte aresto: *“Constitucional e administrativo. Comissão Técnica de Biossegurança – CTNBio. Reuniões plenárias e das subcomissões setoriais. Restrição genérica e total ao acesso. Ilegitimidade. Princípio constitucional da publicidade. 1. Deve ser assegurado a qualquer pessoa o direito de estar presente às reuniões da CTNBio, na condição de ouvinte, ressalvadas as deliberações sobre questões sigilosas, de interesse comercial, nas quais o seu Presidente ou o colegiado, fundamentadamente, podem determinar o caráter reservado das discussões e votações. 2. A pretensão da CTNBio de, cautelarmente, tornar restrito o acesso a todas as suas reuniões, e sigilosas todas as suas deliberações, independentemente de justificar se o tema em debate exige sigilo, viola o princípio constitucional da publicidade, de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública (CF, art. 37, caput). 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento, mantendo a decisão liminar que garantiu o acesso de qualquer pessoa às reuniões da CTNBio, salvo nos casos de discussão e apreciação de procedimentos com informações sigilosas, decretados previamente em decisão fundamentada”* (TRF 1. AG 2007.01.00.017904-0/DF. Relator: Juiz Federal David Wilson de Abreu Pardo (conv.). 6ª Turma. DJU 26/11/2007, p. 115).

Dentro das normas de publicidade que devem reger as reuniões da CTNBio, órgãos da Administração poderão participar das reuniões para tratar de assuntos de seu interesse, sem direito a voto. Por medida de isonomia e, em observância da proibição de tratamento desigual entre os administrados, nada impede que os interessados em determinado processo sejam chamados à CTNBio para que exponham as suas razões e sustentem suas posições quanto a determinado processo. No caso, é plenamente aplicável o artigo 38 da Lei nº 9.784/99. Admite-se, também, que a CTNBio convide para suas reuniões quaisquer interessados, o que aliás é desnecessário, haja vista que as reuniões são públicas.

A instalação das reuniões da CTNBio somente ocorrerá com a presença de 14 membros que, no entanto, deverá refletir a presença de pelo menos 1 membro de cada uma das diferentes áreas técnicas que compõem o colegiado deliberativo. As deliberações deverão ser tomadas por maioria absoluta. A lei não fala em membros presentes, o que significa que o quórum mínimo de instalação deverá ser exigido para a deliberação, sob pena de nulidade das decisões.

O Decreto nº 5.591/2005, que regulamentou a Lei nº 11.105/2005, sanciona com nulidade a *decisão técnica* que tenha sido proferida com voto decisivo de membro declarado impedido. Há uma certa contradição no dispositivo do § 5º do artigo 14 do decreto. Ora, se o membro foi declarado impedido, não há como ele possa vir a participar do julgamento, haja vista que a declaração de impedimento é uma preliminar ao próprio julgamento. A hipótese é, evidentemente, de declaração superveniente de impedimento. O conceito de voto decisivo, em meu ponto de vista, só pode ser juridicamente válido se ele compuser a maioria absoluta (metade mais 1), pois do contrário estaria sendo posta em julgamento a autonomia dos demais votos que teriam sido contaminados pelo voto impedido. Se o voto do conselheiro impedido estiver na minoria, não há sentido em se falar em anulação, pois não se registrou prejuízo para as partes.

A CTNBio poderá se dividir em subcomissões para apreciar de forma mais minuciosa os diferentes processos que lhe são submetidos.

12.2.2.2.1 Audiência pública

O artigo 15 estabelece a possibilidade de convocação de audiência pública por parte da CTNBio, como forma de obtenção de informações e opiniões da comunidade sobre a matéria em debate. É relevante observar que a audiência não se restringe à comunidade científica, mas está “garantida a participação da sociedade civil”, na forma do regulamento.

12.2.2.2.2 Normas de conduta ética dos conselheiros

A lei (§ 6º do artigo 11) determina que os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo “vedado participar do julgamento de questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal”, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento. Os termos nos quais os impedimentos estão lavrados de forma pouco clara e, até mesmo, abstrata. Mais fácil teria sido a utilização da fórmula geral de impedimento e suspeição contida na Lei nº 9.784/99 (art. 18 e seguintes), o que lamentavelmente não foi feito pelo legislador.

12.2.2.3 Competência da CTNBio

À CTNBio foram atribuídas as seguintes competências: i) estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM; ii) estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus derivados; iii) estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados; iv) proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; v) estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança – CIBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam OGM ou seus derivados; vi) estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas a OGM e seus derivados; vii) relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e seus derivados, em âmbito nacional e internacional; viii) autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, nos termos da legislação em vigor; ix) autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa; x) prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da PNB de OGM e seus derivados; xi) emitir Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para o desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no art. 16 da lei; xii) emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso; xiii) definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação da lei, bem como quanto aos seus derivados; xiv) classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios estabelecidos no regulamento da lei; xv) acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança de OGM e seus derivados; xvi) emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência; xvii) apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de ADN/ARN recombinante; xviii) apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 da Lei, no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; xix) divulgar no *Diário Oficial da União*, previamente à análise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança – SIB a sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio; xx) identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana; xxi) reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do OGM ou derivado, na forma da Lei e seu regulamento; xxii) propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança de OGM e seus derivados; xxiii) apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia.

É importante frisar que, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio vincula os demais órgãos e entidades da administração. Isso significa que a decisão da CTNBio se sobrepõe e prevalece sobre a decisão de qualquer órgão administrativo sobre o tema. Uma questão bastante complexa tem sido a relação da CTNBio com os órgãos de controle ambiental, sobretudo no que se refere ao licenciamento ambiental. A Resolução Conama nº 237/97, em seu anexo 1, determina ser necessário o licenciamento ambiental dos organismos geneticamente modificados. Contudo, tal determinação só tem validade legal nas hipóteses nas quais a CTNBio reconheça que os OGMs, em cada caso concreto, são “efetiva ou potencialmente poluidores”, que é a hipótese legal prevista no artigo 10 da PNMA. Tal declaração não é da alçada dos órgãos ambientais, conforme se pode perceber do § 1º do artigo 14 da Lei nº 11.105/2005. Ainda na vigência da Lei nº 8.974/95, a matéria já estava regulada da mesma forma, tendo obtido reconhecimento judicial, como nos deixa ver o seguinte aresto:

Constitucional e ambiental. Inteligência do artigo 225, § 1º, inciso IV, da CF [...] Eficácia da norma do artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição. Disciplina jurídica do estudo de impacto ambiental na lei 6.398, de 1981, e na Constituição de outubro de 1988. Resoluções nºs 1/86 e 237/97 do Conama. Alterações na Resolução 237/97 do Conama e na Resolução Conama 1/86. Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Conflito aparente de normas: o direito intertemporal aplicável à espécie. Natureza jurídica do parecer técnico conclusivo da CTNBIO [...] 2. A Constituição determinou que o Poder Público (artigo 225, § 1º, inc. IV) tem o dever de exigir, na forma da lei, estudo de impacto ambiental, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. 3. Da dicção do art. 225 da CF ressaí que não há qualquer discricionariedade para a Administração Pública, quanto a exigir ou não o estudo do impacto ambiental, na hipótese de pedido de licenciamento de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, sempre que o administrador se encontrar diante de pedido de licença para atividades ou obras com essas características. 4. O Constituinte de 1988 remeteu ao legislador ordinário a competência para regular essa imposição da obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental nos casos em que ocorrer significativa degradação do meio ambiente [...].

[...] 8. O inciso IV, do § 1º, do artigo 225, da Constituição é uma norma constitucional de eficácia diferida (Paulo Bonavides) ou norma constitucional de eficácia contida (José Afonso da Silva) porque seu real alcance e inteligência só podem ser estabelecidos pelo legislador ordinário a quem a norma constitucional de diretamente se dirigiu [...] 15. O Conama, ao tratar do licenciamento para liberação de organismos geneticamente modificados (OGMs) no meio ambiente, para fins de pesquisa e comércio, nem sempre exige o estudo de impacto ambiental, que pode ser substituído “por outros estudos ambientais”, o que está em conformidade com o inciso II do art. 8º da Lei 6.938/81, na redação da Lei 8.028/90, que facultou ao referido órgão exigir “estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais dos projetos públicos ou privados [...]” apenas quando julgar necessário.

16. A Resolução tem que se adaptar à Constituição e não a Constituição à Resolução. Se a Constituição diz que o estudo de impacto ambiental é obrigatório sempre que houver significativa degradação ambiental, não é possível se aplicar a Resolução que diz que o estudo de impacto ambiental é obrigatório em

qualquer caso.

Mesmo que a Resolução Conama 1/86 não tivesse sido revogada pela Resolução Conama 237, de 19 de dezembro de 1997, não teria validade em face do que dispõe o inciso IV, do § 1º, do artigo 225, da CF de 1988 [...] 18. O Congresso Nacional aprovou a Lei 8.974, de 05 de janeiro de 1995, cuja ementa diz que ela regulamenta o disposto nos incisos II e V, do § 1º, do art. 225, da CF/88. A Lei estabeleceu normas ambientais especiais sobre biossegurança, distintas daquelas destinadas às questões ambientais gerais (Lei 6.938/81). 19. A Lei 8.974/95 não arrolou as obras e atividades, relacionadas com a biossegurança que, por apresentarem potencialmente significativa degradação do meio ambiente, devem ser precedidas de estudo de um impacto ambiental. A questão ficou no âmbito de normas infralegais. Não há norma de lei ordinária detalhando que obras ou atividades são aptas a causarem significativa degradação ambiental, devendo tal especificação se dar em cada caso concreto pelo órgão competente. Essa competência é deferida, em termos gerais, ao Conama, pelo art. 8º, II, da Lei 6.938/81, na redação dada pela Lei 8.028/90, e pela Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, do próprio Conama. *No que diz respeito aos projetos que envolvam biossegurança, tal competência é exclusiva da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, por força do disposto na Lei 8.974/95, alterada pelas Medidas Provisórias 2.137/2000 e 2.191/2001, especificamente em face do seu art. 8º, inciso VI, sendo essa a lei que regulamenta o disposto nos incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da CF, no que pertine ao plantio e comercialização de organismos geneticamente modificados.* 22. A lei especial afasta a aplicabilidade da lei geral que é aplicável para os casos gerais. As regras genéricas da lei genérica sobre meio ambiente foram afastadas pelas normas específicas de lei especial sobre OGMs. As normas da Lei 6.938/81 são gerais em matéria ambiental e as normas da Lei 8.974/95 são especiais, pois dizem respeito apenas a um dos aspectos do meio ambiente (a construção, a manipulação e a liberação de organismos geneticamente modificados). 23. *No conflito aparente de normas, só uma pode prevalecer; pois não é possível que normas de igual hierarquia regulem diferentemente a mesma matéria e ambas incidam concomitantemente. A solução para o conflito aparente de normas está na Lei de introdução ao CC cuja regra é: as normas de lei especial se aplicam aos casos especiais que arrola (art. 2º da LICC – Decreto-lei 4.657, de 1942).*

A regência da Lei 6.938/91 ficou afastada pela aplicação excepcionante das disposições da Lei 8.974/95. A lista constante do Anexo I da Resolução 237/97 do Conama, no ponto onde indica a “introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas”, é ilegal, não podendo ser aplicada validamente, posto que a Lei 8.974/95 é de janeiro de 1995 e não previu mais o licenciamento ambiental, mas sim autorizações pelos órgãos fiscalizadores dos Ministérios que indica. A Resolução, norma administrativa genérica, não pode contrariar a lei e um decreto. A Resolução 237, de 9 de dezembro de 1997, entrando em vigor posteriormente à lei mencionada neste ponto, infringe a Lei 8.974/95, sendo assim ilegal. 24. As Resoluções 01/86 e 237/97, do Conama, não são aplicáveis aos estudos de impacto ambiental que venham a ser exigidos pela **CTNBio** no exercício da competência sobre biossegurança, restando ao Conama sua aplicação nos casos de significativa degradação ambiental e em casos gerais que assim venham a ser considerados pelo órgão federal competente para efeito de licenciamento pelo Ibama.

25. A Resolução 305, do Conama, ao pretender exigir, para toda liberação de OGMs no meio ambiente, realização de estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA) e não avaliação de risco, deve ser interpretada e aplicada de acordo com a CF, com a Lei 8.974, de 1995, e a Medida Provisória 2.137, de 2000, sucedida pela MP 2.191/01, visto que a competência para dizer se os OGMs especificamente considerados causam ou não significativo impacto no meio ambiente foi atribuída legalmente à **CTNBio** [...]

32. *O parágrafo único do artigo 7º da Lei de Biossegurança dispõe que o “parecer técnico conclusivo da CTNBio vincula os demais órgãos da Administração, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM por ela analisados, preservadas as competências dos órgãos de fiscalização de estabelecer exigências e procedimentos adicionais específicos às suas respectivas áreas de competência legal”.* 33. *Como se trata de parecer técnico da área específica de biossegurança, tem eficácia vinculante aos demais órgãos da Administração Federal Pública, porque esses outros órgãos não têm competência científica para discutir o mérito do parecer técnico da CTNBio, que não é órgão consultivo, mas deliberativo quanto à segurança dos produtos que contenham OGM* [...] 53. Não é a Justiça Federal o *locus* para se deliberar, do ponto de vista estritamente científico, sobre a segurança alimentar e ambiental de todos os OGMs que são consumidos no mundo. Os órgãos jurisdicionais não são academias e não foram instituídos para se manifestarem *ex cathedra* sobre teses científicas. O juiz só se pronuncia sobre o fenômeno científico quando ele está implicado com o fato jurídico e dele decorre um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida [...]

89. Apelações providas. Remessa oficial prejudicada” (TRF 1. AC 1998.34.00.027682-0/DF. Relatora: Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida. 5ª Turma. *DJU* 1º/9/2004, p. 14).

12.2.2.3.1 A CTNBio e o licenciamento ambiental

Na forma do artigo 16, § 3º, da lei, a CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Caberá ao Ibama o licenciamento ambiental, sempre que a CTNBio entender seja o caso. Por fim, é de se ressaltar que somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do artigo 8º e do *caput* do artigo 10 da Lei nº 6.938/1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

12.2.2.3.2 Forma das decisões da CTNBio

Como em todo órgão da Administração Pública, as decisões da CTNBio devem ser públicas e fundamentadas, com vistas a poder assegurar a qualquer interessado o direito de revisão, seja judicial, seja administrativa. As decisões técnicas proferidas pela CTNBio devem conter resumo de sua fundamentação técnica, explicitando as medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e, ainda, considerar as particularidades das diferentes regiões do país, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 da Lei, no exercício de suas atribuições.

12.2.3 Comissão Interna de Biossegurança

Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados deve instituir uma Comissão Interna de Biossegurança – CIBio, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto específico, cuja competência será: i) manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; ii) estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela CTNBio; iii) encaminhar à CTNBio os documentos cuja relação será estabelecida na regulamentação da Lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente, quando couber; iv) manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolva OGM ou seus derivados; v) notificar à CTNBio, aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 da lei, e às entidades de trabalhadores, o resultado de avaliações de risco a que estão submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminação de agente biológico; vi) investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionadas a OGM e seus derivados e notificar suas conclusões e providências à CTNBio.

12.2.4 Registro de OGM

Conforme está definido no artigo 16 da Lei nº 11.105/2005, o registro de OGMs é múltiplo, realizando-se em diferentes órgãos administrativos, dependendo do aspecto que se pretenda registrar. Observe-se, contudo, que cabe à CTNBio definir os aspectos referentes à biossegurança, o que na minha opinião quer dizer que os diferentes ministérios e órgãos administrativos devem, apenas e tão somente, exercer a função registrária, sem questionar o mérito do produto licenciando. Quanto ao

particular, deve ser lembrado que na composição da CTNBio estão presentes representantes de diferentes ministérios e órgãos públicos que, dessa forma, já tomaram conhecimento dos aspectos relevantes do produto a ser licenciado. Admitir-se um exame de mérito quanto ao produto a ser registrado é, *ipso iure*, subtrair atribuições da CTNBio.

Assim, na forma do artigo 16 cabe aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do MMA e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, entre outras atribuições, no campo de suas competências, *observadas a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do CNBS e os mecanismos estabelecidos* na Lei e em seu regulamento. Tais atribuições são: i) fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; ii) registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; iii) emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial; iv) manter atualizado no SIB o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; v) tornar públicos, inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; vi) aplicar as penalidades de que trata a lei; vii) subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados.

Assim, é importante que se frise, a atribuição dos órgãos externos à CTNBio é meramente registrária e fiscalizatória e, jamais, autorizativa. Observe-se que a lei expressamente afirma que as autorizações e registros “*estarão vinculados à decisão técnica da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigências técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança*”, cabendo ao CNBS dirimir quaisquer divergências quanto à decisão técnica da CTNBio sobre a liberação comercial de OGM e derivados, os órgãos e entidades de registro e fiscalização, no âmbito de suas competências.

Competência registrária e fiscalizatória

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Saúde	Ministério do Meio Ambiente	Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
Emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins.	Emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins.	Emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados destinados a serem liberados nos ecossistemas naturais, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.	Emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aquicultura.

12.3 RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL

A lei estabeleceu um amplo sistema de responsabilidade civil e administrativa em seus artigos 20 e seguintes. Em primeiro lugar, há que se observar que a lei seguiu o caminho que tem sido o prevalente nas modernas leis que tratam de proteção ao meio ambiente, que é o de se fundar na responsabilidade sem culpa ou objetiva. Também foi estabelecida uma responsabilidade solidária entre aqueles que tenham dado origem ao dano e, diferentemente da PNMA, foi definido que a reparação do dano deve ser integral, não se admitindo, no caso específico, qualquer possibilidade de tarifação. Contudo, há que se observar que o artigo 21 repetiu tendência já encontrada na Lei nº 9.605/98, que é o estabelecimento de tipos administrativos abertos, o que é péssimo. Permito-me lembrar a fórmula geral do artigo 21 da Lei 11.105/2005: “*Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes*”. A punição para a infração administrativa se divide em: i) advertência; ii) multa; iii) apreensão de OGM e seus derivados; iv) suspensão da venda de OGM e seus derivados; v) embargo da atividade; vi) interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; vii) suspensão de registro, licença ou autorização; viii) cancelamento de registro, licença ou autorização; ix) perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo; x) perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito; xi) intervenção no estabelecimento; xii) proibição de contratar com a administração pública, por período de até cinco anos.

As multas, na forma do artigo 22, podem oscilar entre R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração, podendo ser aplicadas cumulativamente e dobradas em caso de reincidência. Na ocorrência de infração continuada, que se caracteriza pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável.

A competência para a aplicação das multas é dos órgãos e entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, referidos no artigo 16 da Lei, de acordo com suas respectivas competências.

Uma importante inovação da lei é que ela estabeleceu uma solidariedade entre os agentes financeiros e os eventuais infratores da lei, sempre que o financiador deixe de exigir o Certificado de Qualidade em Biossegurança. Constituem-se crimes:

Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º (Vetado)

§ 2º Agrava-se a pena:

V – de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se resultar dano à propriedade alheia;

VI – de 1/3 (um terço) até a metade, se resultar dano ao meio ambiente;

VII – da metade até 2/3 (dois terços), se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem;

VIII – de 2/3 (dois terços) até o dobro, se resultar a morte de outrem.

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

13.1 INTRODUÇÃO

Após longuíssima tramitação, o Congresso Nacional editou a Lei nº 12.305/2010, que trata da PNRS, que é *lei geral* voltada para a proteção ambiental, tal como disposto no artigo 24 da CF.

13.2 ABRANGÊNCIA

A lei da PNRS aplica-se a todas as “pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos”, ficando excluídos, expressamente, os rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. Além disso, aplicam-se aos resíduos sólidos as Leis nº 11.445/2007, nº 9.974/2000, e nº 9.966/2000, assim como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

13.3 CONCEITOS NORMATIVOS

O artigo 3º da Lei nº 12.305/2010 estabelece os conceitos normativos que deverão ser utilizados pelos aplicadores do direito, seja na esfera administrativa, seja na judicial, sempre que a PNRS venha a ser empregada. Por se tratarem de conceitos especiais deverão ser aplicados preferencialmente sobre as normas gerais de controle da poluição que, no caso, terão aplicação subsidiária. Eles são os seguintes: i) *acordo setorial*: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; ii) *área contaminada*: local onde há contaminação causada pela disposição, *regular* ou *irregular*, de quaisquer substâncias ou resíduos; iii) *área órfã contaminada*: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis; iv) *ciclo de vida do produto*: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final; v) *coleta seletiva*: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição; vi) *controle social*: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; vii) *destinação final ambientalmente adequada*: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; viii) *disposição final ambientalmente adequada*: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; ix) *geradores de resíduos sólidos*: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo; x) *gerenciamento de resíduos sólidos*: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei; xi) *gestão integrada de resíduos sólidos*: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; xii) *logística reversa*: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada; xiii) *padrões sustentáveis de produção e consumo*: produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras; xiv) *reciclagem*: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; xv) *rejeitos*: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; xvi) *resíduos sólidos*: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; xvii) *responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos*: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos da lei; xviii) *reutilização*: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; xix) *serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos*: conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445/2007.

13.4 CONCEPÇÃO GERAL

A PNRS é política pública que reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações desenvolvidas pelo Governo Federal, por si próprio ou mediante o regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Ela é parte integrante da PNMA, devendo ser implementada de forma articulada com a PNEA, prevista na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a PFSSo, estabelecida pela Lei nº 11.445/2007, e com a Lei nº 11.107/2005, dentre outras.

Os seus *princípios*, bastante amplos, podem ser assim sintetizados: (a) *a prevenção e a precaução*; (b) *o poluidor-pagador e o protetor-recebedor*; (c) *a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública*; (d) *o desenvolvimento*

sustentável; (e) a eficiência ambiental, mediante a compatibilização entre a fornecimento de bens e serviços competitivos, de bens e serviços necessários às necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; (f) a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; (g) a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (h) o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; (i) o respeito às diversidades locais e regionais; (j) o direito da sociedade à informação e ao controle social; (k) a razoabilidade e a proporcionalidade.

A principiologia definida pela Lei nº 12.305/2010 tem por objetivo estabelecer critérios para a sua aplicação e interpretação sempre que o próprio texto normativo não esteja suficientemente claro. Contudo, é preciso reconhecer que, em um conjunto de cerca de 11 princípios, não é tarefa clara estabelecer quais são os prevalentes, notadamente quando tais princípios não são de compreensão unânime e, não raras vezes, são contraditórios entre si. O princípio da precaução, por exemplo, não encontra uma definição tranquila. Por sua vez, o princípio “protetor-recebedor” volta-se para a compensação daqueles que prestam “serviços ambientais” para a coletividade e, por isso, merecem pagamento pela ação desempenhada; é, portanto, o inverso do entendimento brasileiro que tem sido adotado para o princípio do poluidor pagador. O “controle social” é um princípio obscuro. A Constituição brasileira já prevê formas claras de participação do cidadão na gestão da *res publica*, tais como a Ação Popular, a Ação Civil Pública, as Audiências Públicas e outras. O princípio do *controle social*, em meu modo de ver, só pode ser compreendido como albergado em tais previsões constitucionais, não se confundindo com um “controle de assembleia”.

A PNRS busca atingir os seguintes *objetivos*: (a) proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; (b) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; (c) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; (d) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; (e) redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; (f) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; (g) gestão integrada de resíduos sólidos; (h) articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; (i) capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; (j) regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; (k) prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: (i) produtos reciclados e recicláveis; (ii) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; (l) integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (m) estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; (n) incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; (o) estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

O principal objetivo da PNRS é a proteção da saúde pública. A inadequada disposição de resíduos gera inúmeros problemas de saúde pública. Para alcançar tal objetivo foram estabelecidas metas teóricas tais como a redução, o reuso e a reciclagem dos resíduos (3R).

13.5 INSTRUMENTOS

Os instrumentos disponíveis na PNRS são os seguintes: (i) os planos de resíduos sólidos; (ii) os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; (iii) a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (iv) o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; (v) o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; (vi) a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; (vii) a pesquisa científica e tecnológica; (viii) a educação ambiental; (ix) os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; (x) o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; (xi) o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir); (xii) o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa); (xiii) os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; (xiv) os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos; (xv) o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; (xvi) os acordos setoriais; (xvii) no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: (a) os padrões de qualidade ambiental; (b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; (c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; (d) a avaliação de impactos ambientais; (e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); (f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; (xviii) os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; (xix) o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.

Há um amplo rol de instrumentos da PNRS, os quais, seguindo uma tendência bastante marcada em nossa legislação ambiental, tendem a ser vagos, pouco claros e capazes de gerar conflitos interpretativos e de atribuições complexos. Expressões como “*no que couber*”, francamente, não têm qualquer significado inteligível. Já se pode antever, sem a menor sombra de dúvida, graves conflitos interinstitucionais entre os conselhos de meio ambiente e os de saúde, “*no que couber*”. Por outro lado, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos é uma redundância em face do Cadastro Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, uma vez que o primeiro cadastro é um subconjunto do segundo. Dado que a PNRS é subordinada à PNMA, sendo em realidade uma política setorial, faz-se desnecessária qualquer menção aos instrumentos disponíveis na política-mãe, como o licenciamento ambiental, por exemplo.

13.6 DIRETRIZES

Fiel ao propósito basilar da lei que é o estabelecimento de uma *política* para o gerenciamento dos resíduos sólidos, a lei estabeleceu um conjunto de diretrizes a serem aplicadas pelos gestores públicos ou privados de tais resíduos. Em meu ponto de vista, cuida-se de uma medida inteligente e capaz de dar ao administrador a flexibilidade necessária para, em cada caso concreto, optar pela decisão que melhor consulte ao objetivo final da política que se está implementando. Assim, o artigo 9º da lei nº 12.305/2010 definiu uma ordem de prioridade a ser observada na gestão dos resíduos sólidos que é a seguinte: (i) não geração, (ii) redução, (iii) reutilização, (iv) reciclagem, (v) tratamento dos resíduos sólidos e (vi) disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Sabemos que o resíduo é um subproduto de uma determinada atividade e, muitas vezes, processos ineficientes fazem com que a própria matéria-prima possa se transformar em resíduo com perdas econômicas e ambientais significativas. Assim, a ordem de prioridade para o gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos, tal como estabelecida na lei, segue uma lógica econômica e ambiental precisa e que merece aplauso. Note-se que, por ser diretriz, a norma não impede que sejam gerados resíduos, até mesmo porque seria uma norma natimorta. O que a norma busca é que qualquer atividade seja praticada com o mais elevado nível de eficiência econômica e ambiental, o que levará, logicamente, ao menor índice de desperdício que é diretamente proporcional à menor geração de resíduos.

Um elemento importante do artigo 9º é a diretriz contida em seu § 1º, que expressamente reconhece que os resíduos sólidos, se adequadamente aproveitados, podem se constituir em importante fonte de energia complementar, “*desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental*”.

13.7 COMPETÊNCIAS

Como em qualquer aspecto da política ambiental brasileira, a repartição de competências administrativas não é tema trivial; ao contrário, a tônica tem sido a pouca clareza, a obscuridade e, não com pouca frequência, a surpresa. Na forma do artigo 10 da PNRS, “*incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do*

Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos [...]”. Assim, a competência primária em matéria de resíduos sólidos é dos municípios, conforme o artigo 30 da CF, haja vista que a matéria diz respeito ao uso e ocupação do solo, bem como ao predominante interesse local.

Aos Estados foi atribuída a competência de: (i) promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da LC estadual prevista no § 3º do artigo 25 da CF; (ii) controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama. O Estado, portanto, é um indutor que deve “*apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios*”.

13.8 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Extremamente importante é a matéria trazida nos artigos 13 e seguintes da PNRS, que estabelecem a classificação dos resíduos sólidos.

A classificação é a seguinte:

- I – **quanto à origem:** (a) *resíduos domiciliares*: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; (b) *resíduos de limpeza urbana*: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; (c) *resíduos sólidos urbanos*: os englobados nas alíneas a e b; (d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas b, e, g, h e j; (e) *resíduos dos serviços públicos de saneamento básico*: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea c; (f) *resíduos industriais*: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; (g) *resíduos de serviços de saúde*: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; (h) *resíduos da construção civil*: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; (i) *resíduos agrossilvopastoris*: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; (j) *resíduos de serviços de transportes*: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; (k) *resíduos de mineração*: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
- II – **quanto à periculosidade:** (a) *resíduos perigosos*: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; (b) *resíduos não perigosos*: aqueles não enquadrados na alínea a.

13.9 PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os Planos de Resíduos Sólidos podem ser organizados conforme as diferentes competências legais dos diferentes entes federativos e são os seguintes: (i) *Plano Nacional de Resíduos Sólidos*; (ii) *Planos estaduais de resíduos sólidos*; (iii) *Planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas*; (iv) *planos intermunicipais de resíduos sólidos*; (v) os *planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos*; (vi) *planos de gerenciamento de resíduos sólidos*. Os planos devem ser amplamente divulgados no que se refere ao seu conteúdo, bem como submetidos ao “*controle social em sua formulação, implementação e operacionalização*”, observado o disposto na Lei nº 10.650/2003, e no artigo 47 da Lei nº 11.445/2007.

O *Plano Nacional de Resíduos Sólidos* deve ser elaborado pela União, sob a coordenação do MMA, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada quatro anos, tendo como conteúdo mínimo: (i) diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; (ii) proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; (iii) metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; (iv) metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; (v) metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à “*emancipação econômica*” de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; (vi) programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; (vii) normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; (viii) medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; (ix) diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por LC, bem como para as áreas de especial interesse turístico; (x) normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos; (xi) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. O *Plano Nacional de Resíduos Sólidos* deve ser elaborado “*mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas*”.

Os *Planos Estaduais de Resíduos Sólidos* devem ser elaborados como condição prévia para que os Estados possam se candidatar aos recursos econômicos e financeiros federais “*destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade*”. Conforme norma estabelecida pelo artigo 16 da PNRS, a medida é extremamente salutar. Cuida-se, efetivamente, de uma relevante medida de *federalismo cooperativo*, pois permite que a União invista recursos em um projeto previamente definido o qual, necessariamente, estará em conformidade com um Plano Nacional estabelecido e, portanto, evitando-se a dispersão de recursos escassos.

Os recursos da União serão distribuídos prioritariamente aos Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3º do art. 25 da CF, de forma a integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. Regulamento, baixado pelo Executivo, definirá as normas complementares sobre o acesso aos recursos da União.

As microrregiões, respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos da PNRS, abrangem as atividades de: (i) coleta seletiva; (ii) recuperação e reciclagem; (iii) tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos; (iv) gestão de resíduos de construção civil; de (v) serviços de transporte; de (vi) serviços de saúde; (vii) agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.

O *Plano Estadual de Resíduos Sólidos* deverá ser elaborado para vigor por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, pelo período de vinte anos e sendo revisto a cada quatro anos, com o seguinte conteúdo mínimo: (i) diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais; (ii) proposição de cenários; (iii) metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; (iv) metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; (v) metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; (vi) programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; (vii) normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; (viii) medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos; (ix) diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; (x) normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional; (xi) previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de: (a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; (b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental; (xii) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social.

Os Estados poderão, também, elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. A elaboração e a implementação por parte dos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas

ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1º do artigo 17 da PNRS, contarão, obrigatoriamente, com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas na PNRS. Uma vez respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos da PNRS, o plano microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.

13.10 PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, tal como estipulado pela PNRS, é condição para que o Distrito Federal e os Municípios tenham acesso aos recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para que se beneficiem de incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. A União, ao distribuir os recursos em tela, deverá dar prioridade aos Municípios que: (i) optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1º do art. 16 da PNRS; (ii) implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Na elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, será observado o seguinte conteúdo mínimo: (i) diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; (ii) identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da CF e o zoneamento ambiental, se houver; (iii) identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; (iv) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 da PNRS ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33 da PNRS, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; (v) procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445/2007; (vi) indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; (vii) regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da PNRS, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; (viii) definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 da PNRS a cargo do poder público; (ix) programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; (x) programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; (xi) programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; (xii) mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos; (xiii) sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; (xiv) metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; (xv) descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da PNRS, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (xvi) meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da PNRS e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33 da mesma lei; (xvii) ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; (xviii) identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; (xix) periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal.

Admite-se que o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos possa estar inserido no plano de saneamento básico previsto no artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto no artigo 29 da PNRS. Quando se tratar de Municípios com população inferior a 20.000 habitantes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, como definido em regulamento. Contudo, em se tratando de municípios com população inferior a 20.000 habitantes que (art. 19, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.305/2010): (i) sejam integrantes de áreas de especial interesse turístico; estejam (ii) inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional e (iii) cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação, não são aplicáveis as disposições acima.

É importante anotar que a simples existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não é suficiente para elidir a necessidade de que o Município ou o Distrito Federal promovam o licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama, o qual, dependendo do caso concreto, poderá ser o próprio Município ou o Distrito Federal. Acrescente-se ser vedado atribuir-se ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o artigo 20 da PNRS, em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS. Por fim, considere-se que a ausência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não é impeditivo para a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes.

13.11 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é obrigatório para: (i) os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas *e, f, g e k* do inciso I do art. 13 da PNRS; (ii) os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: (a) gerem resíduos perigosos; (b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; (iii) as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; (iv) os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea *j* do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; (v) os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. Os resíduos perigosos serão objeto de normas específicas.

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser elaborado com base no seguinte conteúdo mínimo: (i) descrição do empreendimento ou atividade; (ii) diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; (iii) observância das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: (a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; (b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; (iv) identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; (v) ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentais; (vi) metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem; (vii) se cabível, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31 da PNRS; (viii) medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; (ix) periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.

Regulamento, baixado pelo Executivo, definirá: (i) normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; (ii) critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3º da LC nº 123/2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.

Deverá ser indicado responsável técnico, devidamente habilitado, para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Tais responsáveis técnicos deverão manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, o que será feito mediante sistema declaratório, com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. O artigo 24 da PNRS estabelece que o *“plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama”*. Isso significa que não se concederá licença ambiental sem a existência do mencionado plano. Penso que, na hipótese, há que se exigir o plano para a fase de LI, haja vista que na fase de LP cuida-se apenas de planejamento preliminar do empreendimento. A PNRS determinou, ainda, que *“no processo de licenciamento ambiental”* seja *“assegurada [a] oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos”*.

13.12 RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DOS PODERES PÚBLICOS

O artigo 25 da PNRS estabelece que o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e no seu regulamento. Ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos cabe a responsabilidade pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições da PNRS e seu regulamento. Já, às *“pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 [PNRS] são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24 [PNRS]”*. Considerando que é *res inter alios acta*, (art. 27, § 1º da Lei nº 12.305/2010). *“[a] contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 [PNRS] da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos”*. Evidentemente que contratos entre as partes poderão assegurar que o contratante obtenha da contratada o ressarcimento de prejuízos que venha a ter em função de uma inadequada atuação dessa última; contudo, reafirme-se, tal contrato não é oponível a terceiros. Relevante observar que o § 2º do artigo 27 da PNRS estabeleceu a possibilidade de que os serviços referentes à gestão de resíduos sólidos que tenham sido executados pelo Poder Público *“serão devidamente remunerados pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5º do art. 19”*. Observe-se que, nas hipóteses de geração de resíduos sólidos domiciliares, o seu gerador terá *“cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução”* (art. 28).

A PNRS, em seu artigo 29, estabeleceu a responsabilidade *subsidiária* do poder público no que se refere a *“minimizar ou [fazer] cessar o dano”*, tão logo a Administração *“tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos”*. Os gastos nos quais a administração pública incorra para *“minimizar”* ou fazer cessar os danos causados por terceiros deverão ser ressarcidos integralmente pelo causador das lesões ao meio ambiente.

Importante a determinação contida no artigo 51 da PNRS: *“Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que ‘dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências’, e em seu regulamento.”*

13.12.1 Responsabilidade compartilhada

A PNRS, em seu artigo 30, instituiu a chamada responsabilidade compartilhada *“pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”*. Tal responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem os seguintes objetivos: (i) compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; (ii) promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; (iii) reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; (iv) incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; (v) estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; (vi) propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; (vii) incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.

Além das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: (i) investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos: (a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada; (b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; (ii) divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; (iii) recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33 da PNRS; (iv) compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa.

13.12.2 Embalagens

As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem; cabendo aos respectivos responsáveis assegurar que elas sejam: (i) restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto; (ii) projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém; (iii) recicladas, se a reutilização não for possível. O Regulamento da PNRS deve dispor sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto acima.

A responsabilidade pelo atendimento das determinações supra é de todo aquele que: (i) manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens; (ii) coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.

13.12.3 Logística reversa

Conforme disposição do artigo 33 da PNRS, *“são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes”* de: (i) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; (vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Na forma do que se dispuser em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no *caput* do artigo 33 serão estendidos a produtos comercializados em embalagens

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

A definição dos produtos e embalagens referidos acima deve levar em consideração a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do *caput* e o § 1º (art. 33) tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: (i) implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; (ii) disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; (iii) atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º do artigo 33.

Cabe aos consumidores efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do *caput*, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º, todos do artigo 33. Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 33. Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.

Caso o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere o artigo 33, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. À exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do *caput* do artigo 31 e no § 1º do artigo 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. Sendo certo que os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal. Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1º do artigo 34, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica.

Toda vez que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do artigo 33, os consumidores são obrigados a: (i) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; (ii) disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.

No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: (i) adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; (ii) estabelecer sistema de coleta seletiva; (iii) articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; (iv) realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do artigo 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; (v) implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; (vi) dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do artigo 36, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. A contratação prevista no § 1º do artigo 37 é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

13.13 RESÍDUOS PERIGOSOS

A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, cadastro – parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – este que será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.

As pessoas jurídicas referidas no artigo 38 da PNRS são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 21 da PNRS e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas. A essas mesmas pessoas jurídicas incumbe: (i) manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no *caput*; (ii) informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade; (iii) adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; (iv) informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.

13.13.1 Seguro e áreas órfãs

O órgão de licenciamento ambiental, na forma do artigo 40 da PNRS, pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento.

Cabe ao Governo Federal, sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, a estruturação e manutenção de instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs. Havendo a identificação dos responsáveis pelas áreas órfãs, estes ressarcirão integralmente o valor empregado pelo poder público nos trabalhos de descontaminação.

13.14 INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

O poder público deverá estabelecer políticas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de: (i) prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; (ii) desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida; (iii) implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; (iv) desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, regional, nos termos do inciso I do *caput* do artigo 11; (v) estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; (vi) descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; (vii) desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos; (viii) desenvolvimento de sistemas de gestão

ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.

No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes dessa Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: (i) indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional; (ii) projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; (iii) empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.

Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei nº 11.107/2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.

13.15 PROIBIÇÕES

São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; (ii) lançamento *in natura* a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; (iii) queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; (iv) outras formas vedadas pelo poder público. Sempre que decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa. Uma vez assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do artigo 48.

São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades: (i) utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; (ii) catação, observado o disposto no inciso V do artigo 17 da PNRS; (iii) criação de animais domésticos; (iv) fixação de habitações temporárias ou permanentes; (v) outras atividades vedadas pelo poder público.

É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.

13.16 REGULAMENTAÇÃO: DECRETO Nº 7.404/2010

13.16.1 Introdução

Diferentemente do projeto de lei que deu origem à Lei nº 12.305/2010, a regulamentação da PNRS foi relativamente rápida, haja vista que o Decreto nº 7.404/2010, foi editado cerca de quatro meses após a lei regulamentada. Contudo, devido à complexidade da matéria e à estrutura federativa do estado brasileiro, há necessidade de muitas normas estaduais e municipais, bem como normas técnicas a serem expedidas por órgãos de deliberação coletiva para que a PNRS possa ser plenamente aplicável.

13.16.2 Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos

Sob a coordenação do MMA, o decreto instituiu o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, polo de articulação dos diversos órgãos e entidades governamentais, com vistas a cumprir determinações e metas previstas na PNRS e no próprio decreto, com a seguinte composição: i) MMA; ii) Casa Civil da Presidência da República; iii) Ministério das Cidades; iv) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; v) Ministério da Saúde; vi) Ministério de Minas e Energia; vii) Ministério da Fazenda; viii) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; ix) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; x) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; xi) Ministério da Ciência e Tecnologia; e xii) Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

O Comitê Interministerial é competente para: (i) instituir os procedimentos para elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto no artigo 15 da Lei nº 12.305/2010; (ii) elaborar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto no artigo 15 da Lei nº 12.305/2010; (iii) definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos, conforme o artigo 39 da Lei nº 12.305/2010; (iv) promover estudos e propor medidas visando a desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens fabricados com estes materiais; (v) promover estudos visando a criação, modificação e extinção de condições para a utilização de linhas de financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais; (vi) formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos; (vii) incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem, reaproveitamento e tratamento dos resíduos sólidos; (viii) propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos; (ix) definir e avaliar a implantação de mecanismos específicos voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs, nos termos do artigo 41 da Lei nº 12.305/2010; (x) implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação, execução e revisão dos planos de resíduos sólidos referidos no artigo 14 da Lei nº 12.305/2010; e (xi) contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de mecanismos de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos titulares.

13.16.3 Responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e do poder público

A PNRS e o seu regulamento estabeleceram mecanismos novos de responsabilidade, mediante a instituição de uma cadeia bastante ampla. Houve uma clara evolução em relação ao abstrato conceito de poluidor indireto estabelecido pela PNMA, haja vista que os responsáveis estão claramente definidos, não havendo “surpresas” para nenhuma das partes envolvidas no ciclo de vida dos produtos.

A responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos alcança os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Determina o parágrafo único do artigo 5º que “a responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e encadeada”. Embora os termos da norma deixem margem à interpretação, parece-me que, no caso, dado que a implementação da responsabilidade compartilhada deve ser feita de forma individualizada, uma primeira interpretação seria que, no caso, aplica-se o regime de solidariedade passiva previsto no CC, com os temperamentos que o tempo dirá.

13.16.4 Responsabilidade dos consumidores e coleta seletiva

Havendo o chamado sistema de coleta seletiva, estabelecido por plano municipal, os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Tal obrigação referida não exime os consumidores da observância das regras de acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos previstas na legislação do titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A coleta seletiva é feita pela segregação prévia dos resíduos sólidos, conforme sua constituição ou composição; sua implantação é considerada instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, prevista em lei. A implantação do sistema de coleta seletiva cabe ao titular do

serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, contemplando, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos planos.

Há determinação para que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos valorize a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

13.16.5 Logística reversa

A implantação legal dos instrumentos de logística é uma das maiores inovações da lei da PNRS e de sua regulamentação. A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Não é difícil perceber que é um instrumento que demanda elevados investimentos que, no entanto, se bem praticado, poderá implicar em redução de custos e economia de produtos. A logística reversa de agrotóxicos ano é alcançada pela PNRS.

Os sistemas de logística são postos em prática mediante a utilização dos seguintes instrumentos: (i) acordos setoriais; (ii) regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou (iii) termos de compromisso. O § 1º do artigo 16 do decreto determina que os acordos de maior abrangência geográfica fixam os parâmetros mínimos das medidas de proteção ambiental que somente poderão ser ampliadas pelos acordos de menor abrangência: “podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes dos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica”. Os acordos setoriais, os regulamentos e os termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal, serão submetidos a cada cinco anos ao Comitê para exame da necessidade de revisão.

Os sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens previstos no artigo 33, incisos I a IV, da Lei nº 12.305/2010, cujas medidas de proteção ambiental podem ser ampliadas mas não abrandadas, devem observar as exigências específicas previstas em: (i) lei ou regulamento; (ii) normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS, do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA e em outras normas aplicáveis; ou (iii) acordos setoriais e termos de compromisso. Os sistemas de logística reversa podem ser estendidos, por meio da utilização dos instrumentos previstos no artigo 15 do regulamento, a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. É importante ressaltar que a definição dos produtos e embalagens deve considerar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, a ser aferida pelo Comitê Orientador.

Todos os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos referidos nos incisos II, III, V e VI do artigo 33 da Lei nº 12.305/2010, assim como dos produtos e embalagens referidos nos incisos I e IV e no § 1º do artigo 33 da PNRS, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor. O Dec. 9.177/2017 passou a regulamentar o art. 33 da Lei 12.305/2010.

Na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser adotados procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis.

É relevante considerar que para o cumprimento das normas de logística reversa, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ficam responsáveis pela sua realização **no limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado interno**, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no instrumento que determinar a implementação da logística reversa.

É importante anotar que o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017 estabeleceu o quadro normativo para assegurar a isonomia nas ações fiscalizatórias e na observância das obrigações às quais estão sujeitos os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens aos quais se aplicam as normas da logística reversa obrigatória.

Conforme as disposições contidas no mencionado decreto, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, seus resíduos e suas embalagens tratados no artigo 33 (*caput*) da Lei da PNRS e de demais produtos, seus resíduos ou suas embalagens sujeitos à logística reversa e que não sejam signatários de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com a União, também estão obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, contendo as mesmas obrigações contempladas em acordos setoriais.

13.16.5.1 Acordos setoriais

Acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A iniciativa do acordo setorial pode ser tomada pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens referidos no artigo 18 do decreto.

Os acordos setoriais de iniciativa do poder público deverão ser precedidos de editais convocatórios. Nas hipóteses de iniciativa dos setores produtivos, deverá ser feita proposta formal ao MMA.

Quando se tratar de procedimentos de iniciativa da União, a implantação da logística reversa por meio de acordo setorial terá início com a publicação de editais pelo MMA, que deverão indicar: (i) os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as etapas do ciclo de vida dos produtos e embalagens que estarão inseridas na referida logística; (ii) o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e embalagens referidos em (i); (iii) o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial, observados os requisitos mínimos estabelecidos neste Decreto e no edital; (iv) as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa; (v) a abrangência territorial do acordo setorial; e (vi) outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial, conforme as especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística reversa.

É importante observar que os editais a serem publicados pelo MMA deverão ser precedidos de aprovação pelo Comitê Orientador, da avaliação da viabilidade técnica e econômica da implantação da logística reversa, promovida pelo grupo técnico previsto no § 3º do artigo 33 do decreto. Quando se tratar de procedimentos de iniciativa dos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, as propostas de acordo setorial serão avaliadas pelo MMA, consoante os critérios previstos no artigo 28, que as enviará ao Comitê Orientador para as providências previstas no artigo 29, ambos do regulamento da PNRS.

Os acordos setoriais visando à implementação da logística reversa deverão conter, no mínimo: (i) indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial; (ii) descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se insere, observado o disposto no inciso IV do artigo 3º da Lei nº 12.305/2010; (iii) descrição da forma de operacionalização da logística reversa; (iv) possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações propostas no sistema a ser implantado; (v) participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se encarregarem de alguma etapa da logística a ser implantada; (vi) definição das formas de participação do consumidor; (vii) mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos e embalagens; (viii) metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser implantado; (ix) cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de evolução até o cumprimento da meta final estabelecida; (x) informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio; (xi) identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e impactos à saúde humana e ao meio ambiente; (xii) avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa; (xiii) descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas

ou pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, devendo incluir: (a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive pelos consumidores e recicladores; (b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e respectivas responsabilidades; (c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de responsabilidades pelos pontos de coleta; (d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes, identificando as responsabilidades; e (e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de tratamento, inclusive triagem, dos resíduos, bem como pela disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e (xiv) cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das obrigações previstas no acordo.

O acordo setorial, antes de ser firmado, deverá ter a proposta submetida à audiência pública, cabendo ao MMA: (i) receber e analisar as contribuições e documentos apresentados pelos órgãos e entidades públicas e privadas; e (ii) sistematizar as contribuições recebidas, assegurando-lhes a máxima publicidade. Determina o artigo 28 do decreto que o MMA deverá levar em consideração os seguintes pontos para a avaliação da proposta: (i) adequação da proposta à legislação e às normas aplicáveis; (ii) atendimento ao edital de chamamento, no caso dos processos iniciados pelo Poder Público, e apresentação dos documentos que devem acompanhar a proposta, em qualquer caso; (iii) contribuição da proposta e das metas apresentadas para a melhoria da gestão integrada e do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e para a redução dos impactos à saúde humana e ao meio ambiente; (iv) observância do disposto no artigo 9º da Lei nº 12.305, de 2010, quanto à ordem de prioridade da aplicação da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos propostos; (v) representatividade das entidades signatárias em relação à participação de seus membros no mercado dos produtos e embalagens envolvidos; e (vi) contribuição das ações propostas para a inclusão social e geração de emprego e renda dos integrantes de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

O MMA, concluída a avaliação, remeterá o seu parecer ao Comitê Orientador, que poderá: (i) aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial para assinatura do acordo setorial; (ii) solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação da proposta de estabelecimento de acordo setorial; ou (iii) determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na negociação do acordo. Em norma, inócuo, do ponto de vista jurídico, o artigo 30 do Regulamento dispõe que *“a logística reversa poderá ser implantada diretamente por regulamento, veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo”*. Observe-se, entretanto, que o parágrafo único estabeleceu uma relevante autolimitação do Executivo ao determinar que *“antes da edição do regulamento, o Comitê Orientador deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa”*, o que significa que o Executivo não poderá estabelecer mecanismos de logística reversa sem que o Comitê Orientador tenha emitido parecer sobre os aspectos técnicos e econômicos da proposta, concluindo pela sua viabilidade.

13.16.5.2 Termos de compromisso

O Regulamento da PNRS admite que o poder público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando ao estabelecimento de sistema de logística reversa: (i) nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou regulamento específico; (ii) para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento. Determina o parágrafo único do artigo 32 que os *“termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão ambiental competente do Sisnama, conforme sua abrangência territorial”*. Tal disposição é ilegal, pois os atos administrativos, da repercussão do ora examinado, somente adquirem validade e se tornam obrigatórios para terceiros após a sua publicação. Importante observar que o Termo de Compromisso ora examinado não tem a característica de título executivo extrajudicial, como tem sido comum em termos de compromisso e outras formas de acordos ambientais, instituídos por expressa previsão legal. É relevante consignar que títulos executivos extrajudiciais necessitam ser expressamente criados por lei, o que não é o caso.

13.16.5.3 Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa

O Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística Reversa – Comitê Orientador tem a seguinte composição: (i) Ministro de Estado do Meio Ambiente; (ii) Ministro de Estado da Saúde; (iii) Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (iv) Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e (v) Ministro de Estado da Fazenda, sob a presidência do Ministro de Estado do Meio Ambiente. Não há previsão de participação de todos os interessados nos problemas referentes aos resíduos sólidos, salvo na condição de convidados *ad hoc*, para a composição de grupo técnico. Cuida-se de uma orientação de política pública inteiramente superada, pois alheia aos principais interessados que, em última análise, deverão arcar com os custos da implementação do sistema.

Ao Comitê Orientador competem as seguintes atribuições: (i) estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de logística reversa instituídos nos termos da Lei nº 12.305/10 e do regulamento; (ii) definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de chamamento de propostas de acordo setorial para a implantação de sistemas de logística reversa de iniciativa da União; (iii) fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa; (iv) aprovar os estudos de viabilidade técnica e econômica; (v) definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos dos sistemas de logística reversa; (vi) avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal; (vii) definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica ou econômica, da obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem a reutilização e reciclagem; (viii) definir a forma de realização da consulta pública relativa a proposta de implementação de sistemas de logística reversa; (ix) promover estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias produtivas sujeitas à logística reversa e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa; e (x) propor medidas visando incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e embalagens adquiridos diretamente de empresas não estabelecidas no país, inclusive por meio de comércio eletrônico.

13.16.5.4 Diretrizes aplicáveis à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos

O tratamento adequado dos resíduos sólidos impõe medidas de gestão e gerenciamento que devem se pautar por uma lógica que se inicie com a não geração, seguindo diferentes etapas que possam implicar na diminuição do tamanho do problema, como medida mais eficiente para solucioná-lo, ou torná-lo administrável. Assim, o artigo 35 do Regulamento determina que: *“Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”*. Um importante elemento para a redução dos resíduos sólidos é a sua utilização como matéria-prima para processos de geração de energia – o que vem ocorrendo cada vez mais –, em casos tais que compete aos órgãos reguladores do setor elétrico dispor as normas que se façam necessárias para a adoção da medida, do ponto de vista da geração de energia, sem descuidar das competências das demais agências envolvidas no processo. Aqui existe um fortíssimo potencial de negócios e, igualmente, um barateamento do custo da coleta dos resíduos sólidos, pois a sua utilização como fonte geradora de energia é um forte incentivo econômico para a atividade e sua expansão. Segundo estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica:¹

Das fontes para produção de energia, o biogás é uma das mais favoráveis ao meio ambiente. Sua aplicação permite a redução dos gases causadores do efeito estufa e contribui com o combate à poluição do solo e dos lençóis freáticos. Isto porque o biogás é obtido da biomassa contida em dejetos (urbanos, industriais e agropecuários) e em esgotos. Essa biomassa passa naturalmente do estado sólido para o gasoso por meio da ação de micro-organismos que decompõem a matéria orgânica em um ambiente anaeróbico (sem ar). Neste caso, o biogás também é lançado à atmosfera e passa a contribuir para o aquecimento global, uma vez que é composto por metano (CH₄), dióxido de carbono (CO₂), nitrogênio (N₂), hidrogênio (H₂), oxigênio (O₂) e gás sulfídrico (H₂S). A utilização do lixo para produção de energia permite o direcionamento e utilização deste gás e a redução do volume dos dejetos em estado sólido. Segundo o Key World Energy Statistics 2008 da IEA, a biomassa e o lixo (urbano e industrial) responderam por 10,1% da produção energética mundial em 2006. Na matriz da geração mundial de eletricidade, o biogás é incluído no grupo “Outras Fontes”, cuja participação foi de 2,3% da produção total em 2006. Já o estudo Renewables 2007 Global Status Report, da REN21, informa que, apesar de pequena, a aplicação comercial de usinas a biogás nos

últimos anos tem apresentado significativo crescimento nos países em desenvolvimento, particularmente na China e Índia. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, também têm utilizado o lixo urbano e industrial para a produção de energia.

Na verdade, existem três rotas tecnológicas para a utilização do lixo como energético. Uma delas, a mais simples e disseminada, é a combustão direta dos resíduos sólidos. Outra é a gaseificação por meio da termoquímica (produção de calor por meio de reações químicas). Finalmente, a terceira (mais utilizada para a produção do biogás) é a reprodução artificial do processo natural em que a ação de micro-organismos em um ambiente anaeróbico produz a decomposição da matéria orgânica e, em consequência, a emissão do biogás.

De acordo com dados da IEA, em 2005 o lixo urbano deu origem a uma produção mundial de 870.578 terajoules (TJ), o industrial a 428.645 TJ e o biogás a 520.918 TJ. Na produção de energia elétrica, a participação de cada um deles foi de, respectivamente, 50,9 TWh, 13,3 TWh e 21,8 TWh. Estes volumes só não foram inferiores ao da energia produzida por outras novas fontes renováveis, como solar e dos oceanos.

Os gases oriundos do processo de biodigestão e de decomposição de matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos não dependem de regulamentação conjunta dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e das Cidades. Há determinação regulamentar para que os geradores de resíduos sólidos adotem medidas que promovam a redução da geração dos resíduos, principalmente os resíduos perigosos, conforme o estabelecido nos respectivos planos de resíduos sólidos e nas demais normas aplicáveis.

13.16.5.5 Participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis

O artigo 40 do Regulamento determina que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa deverão prioritariamente contar com a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda, devendo os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definir programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Cabe à União criar, por meio de regulamento específico, programa com a finalidade de melhorar as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, sendo certo que as políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis deverão observar: (i) a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; (ii) o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e (iii) a melhoria das condições de trabalho dos catadores.

No que se refere à implementação da melhoria das condições dos catadores e recicladores, relevante se observar que qualquer matéria ao tema relacionada, refoge à competência da Justiça do Trabalho.

Competência da Justiça do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer consistente na celebração de convênio/termo de parceria entre a empresa ré e organizações de catadores de materiais recicláveis [...]. Conquanto o inc. X do art. 114 da Constituição da República disponha que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei –, é basilar para a fixação da competência da Justiça do Trabalho que – as outras controvérsias – sejam de alguma forma decorrentes da relação de trabalho. No caso, consoante exposto pelo Tribunal Regional, a pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública é de obrigar a empresa a celebrar convênio ou termo de parceria com as organizações de catadores para a formalização da entrega de todo o resíduo sólido reciclável gerado em suas unidades e departamentos (onde deverá constar o necessário protocolo contemplando o volume e tipo do resíduo sólido reciclável produzido diariamente, a tabela dos dias e horários de quando deverá ocorrer a coleta pela organização dos catadores, facilitando a estes o acesso e desenvolvimento do seu trabalho) e a afixar no quadro de editais do seu estabelecimento, em local visível e acessível a todos os empregados cópia da decisão, liminar ou definitiva, que vier a ser proferida. Não se verificam, na hipótese, as figuras de empregado e empregador nem de relação de trabalho entre a empresa – uma indústria de derivados de plásticos – e as organizações de catadores. Note-se que a causa de pedir fixada na ação não tem natureza trabalhista nem tampouco revela, sob enfoque algum ou mesmo em potencial, uma relação de trabalho entre os catadores e a reclamada. Por mais que se possa pensar nas benesses que poderiam advir para os catadores de material reciclável e para a sociedade com a formalização de convênios ou termos de parceria como o que pretende o Ministério Público, e na louvável atuação do *Parquet*, o fato é que não pode a Justiça do Trabalho obrigar a empresa à sua formalização, justamente porque à margem de uma relação de trabalho. Recurso de Revista de que não se conhece (Tribunal Superior do Trabalho. RR 6603520105090594 660-35.2010.5.09.0594, 5ª Turma, *DEJT* 31/8/2012, Ministro João Batista Brito Pereira).

13.16.6 Planos de resíduos sólidos

Os planos de resíduos sólidos podem ser: (i) o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; (ii) os planos estaduais de resíduos sólidos; (iii) os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; (iv) os planos intermunicipais de resíduos sólidos; (v) os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e (vi) os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Os planos de resíduos sólidos deverão ser amplamente divulgados, por todos os meios possíveis, inclusive as suas propostas preliminares, estudos que as fundamentaram, de forma a assegurar “o controle social” na sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, e na Lei nº 11.445, de 2007.

13.16.6.1 Planos de resíduos sólidos elaborados pelo poder público

13.16.6.1.1 Plano Nacional de Resíduos Sólidos

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos é aquele elaborado pela União, sob a coordenação do MMA, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, devendo ser atualizado a cada quatro anos, conforme disposição constante do artigo 46 do Regulamento. A formulação do artigo é confusa, pois determina que o Plano Nacional terá prazo de validade indeterminado, com “horizonte” de 20 anos, havendo obrigatoriedade de revisão a cada quatro anos. Mais fácil teria sido atribuir ao Plano a validade de 20 anos, com atualizações e revisões a cada quatro anos.

O Regulamento estabeleceu o procedimento padrão para a elaboração do Plano Nacional que é o seguinte: (i) formulação e divulgação da proposta preliminar em até 180 dias, contados a partir da publicação deste Decreto, acompanhada dos estudos que a fundamentam; (ii) submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de 60 dias, contados da data da sua divulgação; (iii) realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do país e uma audiência pública de âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública referido no próprio Regulamento; (iv) apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas da consulta e das audiências públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola; e (v) encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da República da proposta de decreto que aprova aquele Plano.

13.16.6.1.2 Planos estaduais e planos regionais de resíduos sólidos

O Regulamento estabeleceu o mesmo prazo de validade do Plano Nacional para os Planos estaduais, os quais deverão abranger todo o território do respectivo Estado e atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 17 da Lei nº 12.305/2010. Os Estados poderão estabelecer, além dos planos estaduais, planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, sendo assegurada a participação em sua implementação e elaboração, a

participação de todos os Municípios que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana.

13.16.6.1.3 Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão elaborados de acordo com o determinado no art. 19 da Lei nº 12.305/2010. Tais planos deverão passar por revisão ou atualização, preferencialmente, em sincronia com a elaboração dos planos plurianuais municipais.

Há determinação relevante do Regulamento (Decreto nº 7.404/2010) no sentido de que os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos identifiquem e indiquem medidas de recuperação para os passivos ambientais originados, entre outros, de: (i) áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados; e (ii) empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Infelizmente, o Regulamento não previu a fonte de recursos para a adoção das medidas preconizadas, o que certamente torna difícil o cumprimento da norma.

Os municípios com pequenas populações, “*total inferior a vinte mil habitantes, apurada com base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE,*” poderão adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos, os quais deverão conter: (i) diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; (ii) identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver; (iii) identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; (iv) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº 12.305/2010, observadas as disposições do Regulamento e as normas editadas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; (v) procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; (vi) regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na legislação federal e estadual; (vii) definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos; (viii) programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos; (ix) programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando houver; (x) sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445/2007; (xi) metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos; (xii) descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305/2010, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; (xiii) identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e (xiv) periodicidade de sua revisão.

O disposto no § 2º artigo 51 do regulamento não se aplica aos Municípios: (i) integrantes de áreas de especial interesse turístico; (ii) inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; ou (iii) cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação.

Nas hipóteses nas quais os municípios integrem consórcios para o tratamento da questão dos resíduos sólidos, há dispensa da elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010.

13.16.6.1.4 Relação entre os planos de resíduos sólidos e os planos de saneamento básico no que tange ao componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos

Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, compostos pelas atividades mencionadas no artigo 3º, inciso I, alínea c, e no artigo 7º da Lei nº 11.445/2007, deverão ser prestados em conformidade com os planos de saneamento básico previstos na referida lei e no Decreto nº 7.217/2010. Quando se tratar de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, os planos de resíduos sólidos deverão ser compatíveis com os planos de saneamento básico previstos na Lei nº 11.445/2007, e no Decreto nº 7.217/2010, sendo que: (i) o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no artigo 52, inciso I, da Lei nº 11.445/2007, e no artigo 15 da Lei nº 12.305/2010; e (ii) o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, e no artigo 19 da Lei nº 12.305/2010.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado de forma articulada entre o MMAe os demais órgãos e entidades federais competentes, contando com a participação obrigatória do Ministério das Cidades na avaliação da compatibilidade do referido Plano com o Plano Nacional de Saneamento Básico. Admite-se que o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos esteja inserido nos planos de saneamento básico previstos no artigo 19 da Lei nº 11.445/2007, desde que seja respeitado o conteúdo mínimo referido no artigo 19 da Lei nº 12.305/2010, ou o disposto no artigo 51 do Regulamento, conforme o caso.

13.16.6.2 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos

Aqueles empreendimentos ou atividades sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos que estejam localizados em um mesmo condomínio, Município, microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, que exerçam atividades características de um mesmo setor produtivo e que possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum, poderão optar pela apresentação do referido plano de forma coletiva e integrada, individualizando as atividades e os resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores.

Todos os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverão fornecer ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e às demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, consoante as regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, por meio magnético.

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos listados no artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010, poderá prever a participação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, quando (art. 58 do Decreto nº 7.404/2010): (i) houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica e operacionalmente de realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos; (ii) a utilização de cooperativas e associações de catadores no gerenciamento dos resíduos sólidos for economicamente viável; e (iii) não houver conflito com a segurança operacional do empreendimento.

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as tratadas pelos incisos I e II do artigo 3º da LC nº 123/2006, que gerem *apenas* resíduos sólidos domiciliares ou equiparados pelo poder público municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 12.305/2010, estão dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Observe-se que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de pequeno porte, quando exigível, poderá ser inserido no plano de gerenciamento de empresas com as quais operam de forma integrada, desde que estejam localizadas na área de abrangência da mesma autoridade responsável pelo licenciamento ambiental.

Contudo, não se aplicam as disposições acima às microempresas e empresas de pequeno porte geradoras de resíduos perigosos.

13.16.7 Resíduos Perigosos

São geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades (art. 64 do Decreto nº 7.404/2010): (i) cujo processo produtivo gere resíduos perigosos; (ii) cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental; (iii) que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental; (iv) que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou (v) que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do Sisnama, SNVS ou Suasa como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos.

As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, quando couber, do SNVS e do Suasa, observadas as exigências previstas no Regulamento ou em normas técnicas específicas.

O artigo 66 do Regulamento determina que a instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente serão autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. A comprovação da capacidade técnica e econômica se faz pelo preenchimento dos seguintes requisitos: (i) existência de meios técnicos e operacionais adequados para o atendimento da respectiva etapa do processo de gerenciamento dos resíduos sob sua responsabilidade, observadas as normas e outros critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e (ii) apresentação, quando da concessão ou renovação do licenciamento ambiental, das demonstrações financeiras do último exercício social, da certidão negativa de falência, bem como da estimativa de custos anuais para o gerenciamento dos resíduos perigosos, ficando resguardado o sigilo das informações apresentadas. A determinação de apresentação de demonstrações financeiras parece-me que exorbita do marco legal, até mesmo porque o órgão licenciador poderá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

13.16.7.1 Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos

A lei da PNRS instituiu o chamado Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, disciplinado pelo Regulamento. Assim, todas as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento, são obrigadas a nele se cadastrar, indicando o responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. O responsável técnico deverá ser profissional de profissão regulamentada que o autorize ao exercício da atividade. O cadastro será implantado e coordenado Ibama, contando com o auxílio das autoridades federais, estaduais e municipais. Compete ao Ibama, no particular (art. 69 do Decreto nº 7.404/2010): (i) adotar medidas visando a assegurar a disponibilidade e a publicidade do cadastro aos órgãos e entidades interessados; (ii) promover a integração do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e com o Sinir.

A base de dados para a composição do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será composta por: (i) informações constantes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos; (ii) relatório específico anual do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; e (iii) informações sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob responsabilidade da respectiva pessoa jurídica, além de outras fontes que se façam necessárias.

13.16.7.2 Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR

O regulamento instituiu o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, sob a coordenação e articulação do MMA, com os objetivos de: (i) coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; (ii) promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, sistematização, compartilhamento, acesso e disseminação dos dados e informações; (iii) classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e confidencialidade, em conformidade com a legislação vigente; (iv) disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, inclusive visando à caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; (v) permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; (vi) possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o acompanhamento das metas dos planos e das ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; (vii) informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos; (viii) disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no país, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e (ix) agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Regulamento estabeleceu o prazo máximo de dois anos, contados de sua publicação, para a implementação do Sinir. O mesmo Regulamento determinou que a estruturação do SINIR deverá ser feita de molde a conter as informações que lhe forem fornecidas: (i) pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; (ii) pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; (iii) pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; (iv) pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de resíduos sólidos referidos no artigo 14 da Lei nº 12.305, de 2010; (v) pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente – SINIMA; e (vi) pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA, no que se refere aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Quanto à sua implementação, determina o Regulamento que ela se dê pela: (i) articulação com o Sinima e com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SNIRH; (ii) articulação com os órgãos integrantes do Sisnama, para interoperabilidade entre os diversos sistemas de informação existentes e para o estabelecimento de padrões e ontologias para as unidades de informação componentes do SINIR; (iii) integração ao Sinisa no tocante aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos; e (iv) sistematização de dados, disponibilização de estatísticas e indicadores referentes à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.

Cabe ao MMA apoiar os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os respectivos órgãos executores do Sisnama na organização das informações, no desenvolvimento dos instrumentos e no financiamento das ações voltadas à implantação e manutenção do Sinir, cabendo-lhe, ainda, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, organizar e manter a infraestrutura necessária para receber, analisar, classificar, sistematizar, consolidar e divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos.

13.16.8 Educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos

A educação ambiental para a adequada gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. As atividades de educação ambiental para a gestão dos resíduos sólidos deverão obedecer às diretrizes gerais fixadas na Lei nº 9.795/1999, e no Decreto nº 4.281/2002, bem como às regras específicas estabelecidas na Lei nº 12.305/2010, e em seu Regulamento. Para a implantação da Educação Ambiental na gestão dos resíduos sólidos o Poder Público deverá adotar, no mínimo, as seguintes medidas (art. 77, § 2º, do Decreto nº 7.404/2010): (i) incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada; (ii) promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a Política Nacional de Educação Ambiental; (iii) realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa; (iv) desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da

responsabilidades compartilhadas de que trata a Lei nº 12.305/2010; (v) apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por organizações não governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações sobre o comportamento do consumidor brasileiro; (vi) elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável; (vii) promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos sólidos; e (viii) divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo consciente e com a minimização da geração de resíduos sólidos.

O regulamento, no § 3º do artigo 77, expressamente, dispõe que: “*As ações de educação ambiental previstas neste artigo não excluem as responsabilidades dos fornecedores referentes ao dever de informar o consumidor para o cumprimento dos sistemas de logística reversa e coleta seletiva instituídos*”.

Por fim, não se pode esquecer as disposições da Lei nº 13.186, de 11 de novembro de 2015 que estabelece a Política de Educação para o Consumo Sustentável que em seu artigo 2º estabelece como um de seus objetivos a promoção da redução do acúmulo de resíduos sólidos, pelo retorno pós-consumo de embalagens, pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e outros produtos considerados perigosos ou de difícil decomposição e, ainda, o estímulo a reutilização e a reciclagem dos produtos e embalagens.

13.16.9 Condições de acesso a recursos técnicos, econômicos e financeiros

Determina o artigo 78 do Regulamento que: “a elaboração dos planos de resíduos sólidos previstos no art. 45 é condição, nos termos do art. 55 da Lei nº 12.305/2010, para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tenham acesso a recursos da União ou por ela controlados, bem como para que sejam beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento destinados, no âmbito de suas respectivas competências”: (i) a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos; ou (ii) à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Acresce à relação acima a necessidade de “*comprovação da regularidade fiscal perante a União*”. Faz-se necessário anotar que o Regulamento não fez qualquer menção aos valores dos recursos disponíveis, muito menos estabeleceu qualquer obrigatoriedade de que os “recursos” sejam definidos no orçamento da União, nem excepcionou a possibilidade de contingenciamento. Limitou-se o Regulamento, na forma do artigo 79, a estabelecer uma prioridade de acesso aos recursos: (i) aos Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3º do art. 25 da Constituição, para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos; (ii) ao Distrito Federal e aos Municípios que: (a) optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no art. 16 da Lei nº 12.305, de 2010; ou (b) implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; e (iii) aos consórcios públicos, constituídos na forma da Lei nº 11.105/2005.

Ademais, os critérios de prioridade no acesso aos recursos previstos no artigo 79 não excluem outros critérios definidos em programas específicos instituídos pelo Poder Público Federal, o que não é claro. Qual deverá prevalecer? Existe, ainda, uma relação de medidas que deverão ser adotadas para que a prioridade possa ser aplicável, a saber: (i) adotar, de forma efetiva, soluções regionalizadas para a organização, planejamento e execução das ações na gestão dos resíduos sólidos, no que concerne aos incisos I, II, alínea *a*, e III, do *caput*, do artigo 79; e (ii) manter os dados e informações atualizadas no SINIR, o que será comprovado mediante a apresentação de certidão de regularidade emitida pelo órgão coordenador do referido sistema.

13.16.10 Instrumentos econômicos

Estabelece o artigo 80 do Regulamento que: as iniciativas previstas no artigo 42 da Lei nº 12.305/2010, serão fomentadas por meio de medidas indutoras, a saber: (i) incentivos fiscais, financeiros e creditícios; (ii) cessão de terrenos públicos; (iii) destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos do Decreto nº 5.940/2006; (iv) subvenções econômicas; (v) fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas; (vi) pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; e (vii) apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL ou quaisquer outros mecanismos decorrentes da Convenção – Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas.

Ainda no âmbito das medidas de incentivo econômico, determina o artigo 81 do Regulamento que as instituições financeiras federais *poderão* também criar linhas especiais de financiamento para: (i) cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com o objetivo de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos; (ii) atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos sólidos, bem como atividades de inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos; e (iii) atendimento a projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos. Não há, portanto, uma obrigatoriedade para a instituição de linhas especiais de financiamento, muito menos a definição de um valor, ainda que estimativo, para tais financiamentos. Assim, a instituição dos incentivos financeiros é uma declaração de intenções, necessitando ser concretizada.

13.16.11 Infrações administrativas

Os artigos 84 e 85 do Regulamento determinaram fosse alterado o Decreto nº 6.514/2008, como se segue:

Art. 84. O art. 62 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62. [...]

IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos;

X – lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

XI – queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade;

XII – descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;

XIII – deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

XIV – destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;

XV – deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade; XVI – não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e

XVII – deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2º do art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010.

§ 1º As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação.

§ 2º Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência.

§ 3º No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2º, poderá ser aplicada a penalidade de multa, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 4º A multa simples a que se refere o § 3º pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito de corpos d'água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.

§ 6º As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX” (NR).

Art. 85. O Decreto nº 6.514, de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

“Art. 71-A. Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”.

¹ Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par2_cap5.pdf>. Acesso em: 4 set. 2011.

SANEAMENTO BÁSICO

14.1 INTRODUÇÃO

A inclusão de capítulo referente ao saneamento básico neste livro se justifica na medida em que inúmeras questões referentes à poluição e à degradação da qualidade ambiental estão diretamente ligadas à *falta* de saneamento básico em boa parte do território nacional. A ausência de saneamento é, na minha opinião, o maior problema ambiental do País, haja vista que a maior parte de nossa população é urbana e os níveis de cobertura do saneamento básico ainda deixa muito a desejar. Para que se possa ter uma pálida ideia da dimensão do problema, veja-se o seguinte quadro:

Déficit na oferta de saneamento básico no Brasil (2013)¹

Área	Nº de domicílios (unidades)	Domicílios não atendidos por Rede Geral de Água		Domicílios não atendidos com Coleta de Esgoto Sanitário	
		Unidades	%	Unidades	%
Urbana	42.107.183	3.368.575	8,0	18.821.911	44,7
Rural	7.034.988	5.231.305	74,4	6.754.491	96,0
Total	49.142.171	8.599.880	17,5	25.576.402	52,0

(1) Na área rural, o déficit em esgoto é determinado pela inexistência de rede coletora e fossa séptica.

(2) Os dados não incluem os domicílios da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Fonte: PNAD 2003, IBGE.

Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2013, segundo região geográfica e Brasil

Região	Índice de atendimento com rede (%)				Índice de tratamento dos esgotos (%)	
	Água		Coleta de Esgotos		Esgotos gerados	Esgotos coletados
	Total	Urbano	Total	Urbano	Total	Total
	(IN055)	(IN023)	(IN056)	(IN024)	(IN046)	(IN016)
Norte	52,4	62,4	6,5	8,2	14,7	85,3
Nordeste	72,1	89,8	22,1	29,3	28,8	78,1
Sudeste	91,7	96,8	77,3	82,2	43,9	64,3
Sul	87,4	97,4	38,0	44,2	35,1	78,9
Centro-Oeste	88,2	96,3	42,2	48,6	45,9	91,6
Brasil	82,5	93,0	48,6	56,3	39,0	69,4

Nota: para o cálculo do índice de tratamento dos esgotos gerados (IN046) estima-se o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume de água consumido.

Houve um grande avanço na distribuição do Saneamento Básico no Brasil, conforme se pode ver do seguinte mapa produzido pelo IBGE:²



Apesar das melhorias, o número de residências e municípios com boas condições de saneamento Básico, ainda está além do desejável:

Brasil e Grandes Regiões	Total de Municípios		Tipo de Serviço							
			Rede geral de distribuição de água		Rede coletora de esgoto		Manejo de resíduos sólidos		Manejo de águas pluviais	
	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008
			Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número
Brasil	5.507	5.564	5.391	5.531	2.877	3.069	5.475	5.562	4.327	5.256
Norte	449	449	422	442	32	60	445	449	222	403
Nordeste	1.787	1.793	1.722	1.772	767	819	1.769	1.792	1.227	1.615
Sudeste	1.666	1.668	1.666	1.668	1.547	1.586	1.666	1.667	1.468	1.643
Sul	1.159	1.118	1.142	1.185	451	472	1.149	1.188	1.094	1.172
Centro-Oeste	446	466	439	464	804	132	446	466	316	423

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 veio tentar normatizar a questão, em especial quanto à titularidade dos serviços de saneamento básico, cuja indefinição legal estava contribuindo de forma decisiva para que o problema não fosse enfrentado. Todavia, é necessário que se ressalte que a norma jurídica é impotente para solucionar os problemas decorrentes da inexistência de recursos financeiros para a implementação das medidas urgentes e necessárias em matéria de saneamento básico, decorrentes de uma enorme dificuldade de investimento por parte do Estado e uma resistência nem sempre justificada de conceder o serviço.

14.2 DIRETRIZES E POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Em primeiro lugar, há que se consignar que a denominação da Lei merece aplauso, pois diferentemente do que ocorre com invulgar frequência em matéria de direito ambiental, não se criou uma “política nacional”, mas federal, haja vista as competências tipificadas na CF.

Os recursos hídricos foram excluídos do conceito de saneamento básico por expressa determinação legal, contida no artigo 4º da Lei, devendo a sua utilização na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, ser sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433/1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais aplicáveis.

Determina o artigo 2º da Lei nº 11.445/2007 que os serviços públicos de saneamento básico deverão ser prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: (i) universalização do acesso; (ii) integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; (iii) abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; (iv) disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (v) adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; (vi) articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; (vii) eficiência e sustentabilidade econômica; (viii) utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; (ix) transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; (x) controle social; (xi) segurança, qualidade e regularidade; (xii) integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; e (xiii) adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: (a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; (b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; (c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; (d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (ii) gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da CF; (iii) universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico; (iv) controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; (v) prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares; (v) subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; (vi) localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A composição dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, para efeitos de aplicação da lei, é composto pelas seguintes atividades: (i) coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do *caput* do artigo 2º da Lei; (ii) triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do *caput* do artigo 2º da Lei; (iii) varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

Não integra o conceito de serviço público de saneamento a ação executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.

14.3 TITULARIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Esse talvez seja o tema mais complexo da Lei em exame, pois sempre houve intensa controvérsia entre estados e municípios sobre a matéria, sobretudo em função do elevadíssimo potencial arrecadatório dos serviços de saneamento. Entendeu a Lei que os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do artigo 241 da CF e da Lei nº 11.107/2005; com isso estabeleceu-se, claramente, a possibilidade de investimentos privados no setor, como forma de obtenção dos recursos necessários à implementação das diretrizes legalmente estabelecidas sobretudo à tão almejada universalização. Assim, determinou a norma competir ao titular dos serviços a formulação da respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto: (i) elaborar os planos de saneamento básico; (ii) prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; (iii) adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo *per capita* de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água; (iv) fixar os direitos e os deveres dos usuários; (v) estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do *caput* do artigo 3º da Lei; (vi) estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; (vii) intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.

Dessa forma, o titular deverá instituir uma agência reguladora dos serviços de saneamento básico, criar um marco legal para a regulação da atividade, especificando direitos e garantias das partes, com ênfase para os direitos dos usuários do serviço. Determinou-se ainda que, na hipótese da prestação do serviço por particular, deverá ser celebrado contrato, sendo expressamente vedada “a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”. Objetivou o legislador criar um quadro jurídico estável, de forma que o investimento feito pelo particular fique longe de variações políticas de ocasião e, em última análise, o usuário do serviço seja prejudicado, com a interrupção ou má prestação do serviço. Há exceção legal para: (I) os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a: (a) determinado condomínio; (b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; (II) os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005.

O contrato de prestação de serviço de saneamento básico é modalidade de contrato administrativo, o qual terá como condição de validade: (i) a existência de plano de saneamento básico; (ii) a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico; (iii) a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; (iv) a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. Por se tratar de condições de validade, o contrato firmado sem a observância das condições acima não produzirá efeito jurídico.

Há, também, a necessidade de que os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato sejam compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico, sem o que não se justificaria a concessão. Na hipótese que entre o particular e a Administração existam contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso III do § 2º do artigo 11 da Lei deverão prever: (i) a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida; (ii) a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; (iii) as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; (iv) as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: (a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; (b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; (c) a política de subsídios; (v) mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; (vi) as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

Tais cláusulas são obrigatórias e, portanto, condições de validade do contrato; caso inexistentes, o contrato padece de vício grave, sendo juridicamente ineficaz. O legislador não se limitou a estipular cláusulas obrigatórias, estabelecendo, igualmente, uma proibição de inclusão de cláusulas contratuais que “prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados”. Mesmo que a proibição de tais cláusulas seja uma decorrência lógica do sistema jurídico adotado no país, justifica-se a menção diante do grande número de municípios existente no país e o seu baixo grau de institucionalização.

Nas hipóteses em que os serviços públicos de saneamento básico sejam da responsabilidade de mais de um prestador, havendo interdependência entre eles, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato, sendo a regulação e a fiscalização exercidas por uma única entidade, a qual definirá, no mínimo: (i) as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; (ii) as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; (iii) a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços; (iv) os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; (v) o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município.

São cláusulas obrigatórias entre os diferentes prestadores de serviço: (i) as atividades ou insumos contratados; (ii) as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos; (iii) o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; (iv) os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades; (v) as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato; (vi) as condições e garantias de pagamento; (vii) os direitos e deveres sub-rogados ou os que

autorizam a sub-rogação; (viii) as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais; (ix) as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; (x) a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados.

Com vistas à implantação da universalização dos serviços, os entes Federados, isoladamente ou em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico. Admite-se que os recursos de tais fundos possam ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

14.3.1 Prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico

Ocorre a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico quando: (i) há um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; (ii) há uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração; (iii) compatibilidade de planejamento. Tal prestação poderá ser exercida por: (i) órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação; (ii) empresa a que se tenham concedido os serviços.

Quanto às atividades de fiscalização e regulação nas hipóteses de prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, elas poderão ser exercidas: (i) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, obedecido o disposto no artigo 241 da CF; (ii) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

14.3.1.1 Decisão do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a Suspensão de Liminar 1.143 interposta pelo Município de Mata de São João (BA) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia que declarara inconstitucional a Lei Municipal 656/2017, que cria empresa municipal de água e saneamento básico. À base da decisão da relatora, Ministra Carmem Lúcia estava o argumento de que a norma local não observou os limites formais e materiais estipulados na Constituição estadual, por tratar de questões que dizem respeito diretamente aos interesses de outros municípios integrantes da região metropolitana de Salvador. A Ministra argumentou que:

Há possibilidade de confirmação da decisão cautelar impugnada quando do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. A autorização precária de funcionamento de empresa municipal cujos custos iniciais são elevados e seriam suportados por toda a população de São João da Mata é fator inegável de insegurança jurídica que, acrescido da incerteza de validade dos atos que poderão ser praticados, impedem o atendimento do que pleiteado pelo requerente.

14.4 PLANEJAMENTO

A prestação de serviços públicos de saneamento básico pressupõe a existência de planejamento, consubstanciado em um plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: (i) diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; (ii) objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; (iii) programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, *identificando possíveis fontes de financiamento*; (iv) ações para emergências e contingências; (v) mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Os planos de saneamento básico são de responsabilidade dos titulares dos serviços públicos de saneamento, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. Tais planos deverão ser consolidados e compatibilizados pelo titular do serviço, observando-se os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.

14.5 REGULAÇÃO

Regulação é a atividade administrativa mediante a qual são estabelecidas normas para a prestação de serviços públicos concedidos, estabelecendo as regras a serem observadas pelos prestadores, com vistas a garantir boa qualidade dos serviços e modicidade das tarifas. No caso específico dos serviços públicos de saneamento básico, o exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: (i) independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora; (ii) transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. Tal como exposto acima, são objetivos da regulação: (i) o estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; (ii) a garantia do cumprimento das condições e metas estabelecidas; (iii) a prevenção e a repressão ao abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; (iv) a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Compete à entidade reguladora editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, as quais deverão contemplar, pelo menos, os seguintes aspectos: (i) padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; (ii) requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; (iii) as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; (iv) regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; (v) medição, faturamento e cobrança de serviços; (vi) monitoramento dos custos; (vii) avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; (viii) plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; (ix) subsídios tarifários e não tarifários; (x) padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; (xi) medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.

O titular do serviço público de saneamento básico, por motivo de conveniência e oportunidade, poderá delegar a fiscalização e a regulação da atividade a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Caso se trate de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação, sendo portanto mais conveniente a delegação da regulação a uma entidade única, com vistas a assegurar a uniformidade do controle.

Os usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, têm direito a: (i) amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; (ii) prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos; (iii) acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; (iv) acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Como atividade econômica é necessário que os serviços públicos de saneamento básico tenham a chamada sustentabilidade econômico-financeira, que deverá ser assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: (i) de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; (ii) de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; (iii) de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. Acresce que a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico deverá observar ainda: (i) prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; (ii) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; (iii) geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; (iv) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; (v) recuperação dos

custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; (vi) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; (vii) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; (viii) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

O prestador de serviço poderá interromper a prestação nas seguintes hipóteses: (i) situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; (ii) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas; (iii) negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; (iv) manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário; e (v) inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

14.5.1 Aspectos técnicos e ambientais

A prestação dos serviços deverá atender a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais. No que se refere especificamente aos padrões de potabilidade da água, deverão ser observados os padrões federais, salvo nas hipóteses em que os Estados definam padrões mais estritos. Em tal caso, deverá ser considerada a repercussão do padrão local nas tarifas, de forma a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A lei determina que os órgãos ambientais, quando do licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água, deverão considerar etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários. Isso se faz pela definição de metas a serem alcançadas em determinado período de tempo. Penso que, no particular, seria bastante conveniente que as metas ambientais fossem incluídas nos contratos, como cláusulas contratuais a serem observadas, haja vista que, em tese, a ação da agência reguladora é mais rápida e eficiente do que a ação dos órgãos ambientais. As metas, igualmente, são aplicáveis à qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários que atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.

14.5.2 Participação de órgãos colegiados no controle social

O “controle social” dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de *caráter consultivo*, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: (i) dos titulares dos serviços; (ii) de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; (iii) dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; (iv) dos usuários de serviços de saneamento básico; (v) de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

14.6 POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A União, ao estabelecer sua política de saneamento básico, deverá observar as seguintes diretrizes (art. 48 da Lei nº 11.445/2007): (i) prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico; (ii) aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia; (iii) estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; (iv) utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; (v) melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; (vi) colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; (vii) garantia de meios adequados para o atendimento da população rural, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares; (viii) fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; (ix) adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, considerados fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; (x) adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações; (xi) estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados; (xii) combate à perda de água e racionalização de seu consumo pelos usuários; (xiii) estímulo ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água e (xiv) estímulo à integração das bases de dados do setor.

A PFSB objetiva (art. 49 da Lei nº 11.445/2007): (i) contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda, a inclusão social e a promoção da saúde pública; (ii) priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda; (iii) proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais; (iv) proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; (v) assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social; (vi) incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico; (vii) promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa; (viii) promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais; (ix) fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico; (x) minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde; (xi) incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água; (xii) promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários; e (xiii) promover a capacitação técnica do setor.

A alocação de recursos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União deverão ser feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos artigos 48 e 49 da Lei e com os planos de saneamento básico, estando condicionados a: (I) alcance de índices mínimos de: (a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; (b) eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saneamento básico; (II) à operação adequada e à manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos federais.

Os chamados recursos a fundo perdido serão alocados prioritariamente às ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou Municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços, não se admitindo a sua aplicação a empreendimentos contratados de forma onerosa. É prerrogativa da União instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico com participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. Todavia, é proibida a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente, situação que deverá ser devidamente documentada e justificada.

No âmbito da PFSB, compete à União, sob a coordenação do Ministério das Cidades, elaborar: (i) o PNSB, que conterá: (a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; (b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos; (c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da PFSB, com identificação das fontes de

financiamento, de forma a ampliar os investimentos públicos e privados no setor; (d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico; (e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas; (ii) planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas em que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico.

O PNSB deverá: (i) abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais com limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes de drenagem, além de outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda; (ii) tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas.

Com vistas a catalogar a informação disponível sobre saneamento básico, foi instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – Sinisa, com os objetivos de: (i) coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; (ii) disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; (iii) permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.

Todas as informações constantes do Sistema são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas por meio da internet. Os titulares dos serviços serão apoiados pela União na organização de sistemas locais de informação.

14.7 REGULAMENTO DA LEI (DECRETO Nº 7.217/2010): ASPECTOS AMBIENTAIS

O Regulamento estabeleceu os seguintes conceitos normativos aplicáveis às questões de saneamento básico: (i) planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada; (ii) regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos; (iii) fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; (iv) entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora, consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos serviços regulados; (v) prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou não de execução de obra, com o objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço público de saneamento básico com características e padrões de qualidade determinados pela legislação, planejamento ou regulação; (vi) controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; (vii) titular: o ente da Federação que possua por competência a prestação de serviço público de saneamento básico; (viii) prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa: (a) do titular, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; ou (b) ao qual o titular tenha delegado a prestação dos serviços, observado o disposto no artigo 10 da Lei nº 11.445/2007; (ix) gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da Constituição; (x) prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a dois ou mais titulares, com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração, e com compatibilidade de planejamento; (xi) serviços públicos de saneamento básico: conjunto dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais, bem como infraestruturas destinadas exclusivamente a cada um destes serviços; (xii) universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico; (xiii) subsídios: instrumento econômico de política social para viabilizar manutenção e continuidade de serviço público com objetivo de universalizar acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; (xiv) subsídios diretos: quando destinados a determinados usuários; (xv) subsídios indiretos: quando destinados a prestador de serviços públicos; (xvi) subsídios internos: aqueles concedidos no âmbito territorial de cada titular; (xvii) subsídios entre localidades: aqueles concedidos nas hipóteses de gestão associada e prestação regional; (xviii) subsídios tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária; (xix) subsídios fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; (xx) localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; (xxi) aviso: informação dirigida a usuário pelo prestador dos serviços, com comprovação de recebimento, que tenha como objetivo notificar a interrupção da prestação dos serviços; (xxii) comunicação: informação dirigida a usuários e ao regulador, inclusive por meio de veiculação em mídia impressa ou eletrônica; (xxiii) água potável: *água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos e químicos atendam ao padrão de potabilidade estabelecido pelas normas do Ministério da Saúde*; (xxiv) sistema de abastecimento de água: instalação composta por conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do Poder Público; (xxv) soluções individuais: todas e quaisquer soluções alternativas de saneamento básico que atendam a apenas uma unidade de consumo; (xxvi) edificação permanente urbana: construção de caráter não transitório, destinada a abrigar atividade humana; (xxvii) ligação predial: derivação da água da rede de distribuição ou interligação com o sistema de coleta de esgotos por meio de instalações assentadas na via pública ou em propriedade privada até a instalação predial; (xxviii) etapas de eficiência: parâmetros de qualidade de efluentes, a fim de se alcançar progressivamente, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas e processos de tratamento, o atendimento às classes dos corpos hídricos; e (xxix) metas progressivas de corpos hídricos: desdobramento do enquadramento em objetivos de qualidade de água intermediários para corpos receptores, com cronograma preestabelecido, a fim de atingir a meta final de enquadramento.

Conforme o regulamento, cabe ao Ministério da Saúde definir os parâmetros e padrões de potabilidade da água, bem como estabelecerá os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. A responsabilidade pelo controle da qualidade da água é do prestador do serviço, não se incluindo a vigilância da qualidade da água para consumo humano por parte da autoridade de saúde pública.

14.7.1 Esgotamento sanitário

Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: (i) coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários; (ii) transporte dos esgotos sanitários; (iii) tratamento dos esgotos sanitários; e (iv) disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas.

Admite-se que a lei, decreto ou normas de regulação possam considerar como esgotos sanitários os efluentes industriais com características semelhantes às do esgoto doméstico. Há previsão de que as normas de regulação possam prever penalidades no caso de lançamentos de águas pluviais ou de esgotos não compatíveis com a rede de esgotamento sanitário.

14.7.2 Resíduos sólidos

Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos: (i) resíduos domésticos; (ii) resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e (iii) resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como: (a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos; (b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; (c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas

águas pluviais em logradouros públicos; (d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e (e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público.

No particular há que se considerar as interfaces com a Lei nº 12.305/10, que trata da PNRS.

14.7.3 Águas pluviais urbanas

Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas os constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: (i) drenagem urbana; (ii) transporte de águas pluviais urbanas; (iii) detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias; e (iv) tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas.

14.7.4 Serviços públicos de saneamento básico e recursos hídricos

Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, o qual, no entanto, deverá ser prestado com base no uso sustentável dos recursos hídricos, sendo certo que os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas em que os Municípios estiverem inseridos. De qualquer forma, a utilização de recursos hídricos para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, está sujeita ao regime de outorga de direito de uso.

14.7.5 Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões definidos pela legislação ambiental e os das classes dos corpos hídricos receptores. Isso implica que o órgão ambiental, responsável pelo licenciamento da atividade, deverá definir um programa de metas ambientais e eficiência a ser alcançado em determinado espaço de tempo, em função de um programa de investimentos previamente acordado entre as partes envolvidas no procedimento de licenciamento ambiental.

A questão da implantação das etapas de eficiência é complexa, pois a norma determina que elas deverão levar em consideração “a capacidade de pagamento dos usuários”, ou seja, adotou-se o princípio da melhor tecnologia sem custos excessivos. Logicamente, os custos da tecnologia utilizada serão arcados pelos usuários do serviço e, ao mesmo tempo, deverá ser respeitada a equação econômico-financeira do contrato de concessão. Assim, em tais casos se faz necessária a consulta dos usuários, os quais deverão ser informados dos custos referentes às metas adotadas. Penso que a matéria deveria constar do contrato de concessão de forma clara, com vistas a que se evitem impasses prejudiciais às partes envolvidas. Por outro lado, a inclusão da matéria nos contratos de concessão torna-a mais facilmente executável e, portanto, mais viável de ser atendida. Quanto ao particular, o Regulamento determinou que o Conama e o CNRH elaborem, no âmbito de suas respectivas competências, normas para o cumprimento do dispositivo.

É importante realçar que na estrutura da remuneração dos serviços está previsto que ela deverá levar em consideração, além da capacidade de pagamento dos usuários, os “padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação” (Regulamento, artigo 47, VI, do Decreto nº 7.217/2010).

-
- ¹ Disponível em: <<http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2013>>. Acesso em: 24 out. 2015.
 - ² Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1998&id_pagina=1>. Acesso em: 12 out. 2012.

REGIME JURÍDICO DOS RECURSOS HÍDRICOS

§ 1º DIREITO DOS RECURSOS HÍDRICOS

15.1 A IMPORTÂNCIA DAS ÁGUAS

A água é um elemento indispensável a toda e qualquer forma de vida. Essa afirmação, absolutamente óbvia e elementar, por incrível que pareça, é incapaz de sensibilizar muitas pessoas e comunidades, de forma que estas possam proteger e preservar as águas, pois o desperdício dos recursos hídricos é um fato que se repete muitas vezes. O valioso estudo *Cuidando do Planeta Terra – Uma estratégia para o futuro da vida*, indica que:

O nosso uso da água está criando uma crise em grande parte do mundo. Estima-se que as retiradas totais de água tenham aumentado mais de 35 vezes durante os últimos três séculos, e que devem aumentar 30-35% até o ano 2000. Os níveis atuais de uso de água doce não poderão ser mantidos se a população humana atingir 10 bilhões em 2050.

A denominação Terra para o nosso planeta é claramente equívoca. Mais adequado seria se o seu nome fosse *Água*, haja vista que da superfície global da Terra, mais de 2/3 pertencem aos oceanos. É, também, nos oceanos que se localiza mais de 94% de toda a água existente no planeta. A manutenção da boa qualidade das águas é problema que está assumindo dimensões preocupantes.

Da água doce existente no mundo são utilizados 73% na agricultura, 21% na indústria e 6% como água potável (ALLAIS, 1992, p. 250). A água utilizada na agricultura é grandemente desperdiçada, pois quase 60% de seu volume total se perde antes de atingir a planta. A água potável é de qualidade precária, pois, nos países pobres mais de 80% das doenças e mais de um terço da taxa de mortalidade são decorrência da má qualidade da água (ALLAIS, 1992) utilizada pela população para o atendimento de suas necessidades.

Em média, a quantidade de água consumida por um cidadão europeu é 70 vezes maior do que a de um habitante de Gana. Um norte-americano consome 300 vezes mais água que um ganense.

Merece ser mencionado o fato de que, ainda na década de 90 do século passado, quase 1,5 bilhão de pessoas não tinham água potável e quase 2 bilhões não dispunham de instalações sanitárias, dos quais 330 milhões habitam países da OCDE (BARRÈRE, 1992, p. 250). Ocorre que o problema é ainda mais grave do que a simples análise quantitativa do consumo de água pode demonstrar. É de se observar que o consumo de água tem o perfil da estrutura social. As distorções sociais refletem-se e se reproduzem no consumo de água individualmente considerado.

O acesso à água já começa a ser uma das principais fontes de conflitos internacionais, sobretudo nas regiões semiáridas e áridas. A ONU reconhece a existência de, pelo menos, 15 (TROLLDALEN, 1992, p. 62) grandes disputas internacionais envolvendo a utilização de recursos hídricos.

A convocação da CNUMAD – Rio 92, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, levou em consideração os graves problemas que afetam os recursos hídricos em todo o mundo. Conforme anota o Embaixador G. E. do Nascimento e Silva (1995, p. 75):

A Assembleia Geral das Nações Unidas, ao convocar a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, enumerou, dentre os principais tópicos a serem abordados, “a proteção da qualidade e do suprimento de água potável”, tendo em vista a sua importância na manutenção da qualidade do meio ambiente da Terra.

A proteção do meio ambiente é um dos setores do Direito Internacional que, nos últimos anos, tem alcançado o maior desenvolvimento. Ainda que, segundo Nascimento e Silva (1995, p. 75) e boa parte da doutrina autorizada, não se possa falar em Direito Internacional do Meio Ambiente, o fato é que a proteção ambiental tem sido um dos setores do Direito Internacional que mais tem se desenvolvido e influenciado o Direito interno de diversas nações. Quanto à proteção das águas pelo Direito Internacional, pelo menos duas grandes divisões podem ser estabelecidas, a saber: a) a proteção do meio marinho; e b) a proteção das águas continentais, nelas incluídas as áreas úmidas e alagadas.

Tanto as águas marinhas quanto as águas doces mereceram menção de destaque na *Agenda 21* que, como se sabe, foi o principal documento elaborado pela CNUMAD – Rio 92.

O documento mais importante adotado no decorrer da Conferência do Rio é a Agenda 21, onde a comunidade internacional apresenta, em longo documento, um planejamento destinado a solucionar até o ano 2000 os principais problemas ambientais que, conforme a denominação indica, deverá entrar pelo século 21.

Os capítulos 17 e 18 da *Agenda 21* estão diretamente direcionados para a proteção das águas. O capítulo 17 tem por objetivo a proteção dos oceanos e mares, inclusive os mediterrâneos ou semimediterrâneos, das áreas costeiras e o desenvolvimento e uso racional de seus recursos vivos; já o capítulo 18 tem por objetivo a proteção da qualidade e do suprimento das fontes de água potável.

Inúmeros são os tratados e convenções internacionais voltados para a proteção do meio ambiente aquático. O Brasil é signatário de inúmeros documentos internacionais que foram estabelecidos com a finalidade de proteção dos recursos marítimos.

Os graves problemas que afetam as águas em todo o mundo levaram a comunidade internacional a afirmar alguns princípios fundamentais para o uso sustentável das águas e sua conservação para as futuras gerações: a) a água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; b) o desenvolvimento e a administração da água devem estar baseados em uma abordagem participativa, envolvendo os usuários, planejadores e elaboradores de políticas públicas, em todos os níveis; c) a mulher desempenha um papel central na administração, na proteção e na provisão da água; d) a água tem valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem econômico.

A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada tendo como objetivo atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os homens, tendo esta Declaração constantemente no espírito, se esforcem, através da educação e do ensino, em desenvolver o respeito aos direitos e obrigações anunciados e assomam, com medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação efetiva.

Art. 1º A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

Art. 2º A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.

Art. 3º Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia.

Art. 4º O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

Art. 5º A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.

Art. 6º A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.

Art. 7º A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.

Art. 8º A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.

Art. 9º A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social.

Art. 10º O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.

15.2 A ÁGUA NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

15.2.1 As águas nas Constituições anteriores a 1988

Examinar como as águas foram tratadas nas Constituições anteriores à de 1988 é importante para que se possa entender as mudanças propiciadas pela atual Carta Política quanto ao tema.

15.2.1.1 *Constituição imperial*

A Constituição de 1824 não cuidou do tema. Entretanto, a Lei de 1º de outubro de 1828, que disciplinou as obrigações das Câmaras Municipais, atribuiu-lhes competência legislativa sobre as águas, conforme disposto no artigo 66, o qual dotava os vereadores de competência para deliberar sobre: a) aquedutos, chafarizes, poços, tanques; b) esgotamento de pântanos e qualquer estagnação de águas infectas.

Ainda sob o regime político imperial foi promulgado o Ato Adicional, Lei nº 16/1834, que estabeleceu a competência das Assembleias Legislativas provinciais para legislar sobre obras públicas, estradas e navegação no interior de seus respectivos territórios, o que, evidentemente, tinha reflexos claros sobre a política a ser adotada quanto às águas.

15.2.1.2 *Período republicano*

15.2.1.2.1 Constituição de 1891

A CF de 1891 não tratou do tema, limitando-se a definir a competência federal para legislar sobre Direito Civil, no qual se podem incluir as águas. O CC brasileiro de 1916, elaborado sob aquela ordem constitucional, era dotado de um vasto número de artigos dedicados às águas.

15.2.1.2.2 Constituição de 1934

A Constituição Brasileira de 1934 foi a primeira a enfrentar o tema de forma clara e considerando os aspectos econômicos e de desenvolvimento que nele se incluem. Acrescente-se que o artigo 20, II, da Constituição de 1934 determinava ser de domínio da União os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro.

Em razão do profundo cunho intervencionista que marcava a Carta de 1934, foi nela incluído um título referente à ordem econômica e social que, em nosso Direito Constitucional, se constituiu em grande novidade. Os artigos 118 e 119 da CF, expressando de forma bastante clara as tendências constitucionais, determinavam que as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial e que o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei. E mais: o aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso exclusivo do proprietário, independe de autorização ou concessão, sendo que a lei deveria regular a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do país.

A água, portanto, foi enfocada sob o ponto de vista de que se constituía em elemento essencial para a produção de riquezas econômicas e desenvolvimento, especialmente como fonte geradora de energia elétrica.

15.2.1.2.3 *Constituição de 1937*

A Constituição de 1937, em seu artigo 16, XIV, atribuiu competência privativa à União para legislar sobre os bens de domínio federal, águas e energia hidráulica. Acrescente-se que o artigo 143 determinava que as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta da propriedade do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. O aproveitamento industrial de minas e jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização federal.

15.2.1.2.4 Constituição de 1946

A CF de 18 de setembro de 1946, em seu artigo 5º, inciso XV, alínea I, determinava ser da competência da União legislar sobre riquezas do solo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, caça e pesca. Tal competência, nos termos do artigo 6º, não excluía a legislação estadual supletiva ou complementar.

Dentre os bens pertencentes à União, conforme estabelecido pelo artigo 34 da Constituição de 1946, “os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países”. Na relação dos bens pertencentes aos Estados, incluíam-se os lagos e rios em terrenos de seu domínio e os que têm nascente e foz no território estadual.

A Constituição de 1946 manteve a existência de um título voltado para a disciplina da ordem econômica e social. Em tal capítulo, o constituinte não deixou de tratar das águas e o fez nos artigos 152 e 153. O artigo 152 manteve as quedas d’água sob o regime de propriedade distinta da do solo para o efeito de aproveitamento industrial ou de exploração. O artigo 153 determinava que o aproveitamento de recursos minerais e de energia hidráulica dependia de autorização ou concessão, conforme definido em lei. O aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida não dependia de autorização ou concessão. As concessões ou autorizações de que tratava o artigo 153 somente poderiam ser dadas a brasileiros ou a empresas organizadas no país.

15.2.1.2.5 Constituições de 1967 e 1969

As Constituições de 1967 e de 1969 não possuem grandes diferenças, entre si, quanto ao particular. Assim sendo, dentre os bens pertencentes à União estavam incluídos *os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, constituam limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro; as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países.*

Dentre os bens dos Estados e Territórios estavam incluídos os lagos em território de seu domínio, bem como os rios que neles têm nascentes e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreendidas no domínio federal.

A competência legislativa federal sobre águas foi mantida, afastando-se a competência supletiva dos Estados quanto ao particular.

A Constituição de 1969, em seu artigo 168, determinava que: as jazidas, minas e os demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para o efeito de exploração e aproveitamento industrial. Todavia, a exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica dependerão de autorização ou concessão federal, na forma da lei, dadas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País. Naquele regime, não dependia de autorização ou concessão o aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida.

15.2.2 As águas na Constituição de 1988

15.2.2.1 Domínio da União

A CF de 1988, assim como diversas Cartas anteriores, também dispôs sobre as águas. Assim é que o artigo 20, III, determina pertencem a União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Por outro lado, domínio da União, na forma do determinado pelos incisos IV, V, VI, VII, VIII do artigo 20, também é integrado pelas Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; pelas praias marítimas; pelas ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II; pelos recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e, ainda, pelo mar territorial, terrenos de marinha e seus acrescidos e, igualmente, pelos potenciais de energia hidráulica.

O inciso III do artigo 20 da Constituição trouxe algumas inovações em relação ao direito anterior, ao mesmo tempo em que consolidou algumas situações que se mostravam controversas. As inovações ficam por parte da introdução dos *terrenos marginais e das praias fluviais* que no direito anterior não integravam o rol de bens da União. A consolidação do direito pretérito ficou por conta da reafirmação do domínio federal sobre lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado da Federação, ou se estendam a território estrangeiro ou dele sejam provenientes.

O artigo 176 da CF, integrante do capítulo que estabelece os princípios gerais da atividade econômica, determina que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Conforme o § 4º não dependem de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

15.2.2.2 Domínio dos Estados

O artigo 26, em seus incisos I, II e III, arrola entre os bens pertencentes aos Estados os seguintes:

- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
- as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
- as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

15.2.2.3 Competência legislativa

A competência legislativa sobre águas é exercida privativamente pela União; conforme determinado pelo artigo 22, IV, da CF, tal competência deve ser compreendida em conjugação com a competência federal para legislar sobre energia, que é estabelecida na mesma norma constitucional. Observe-se, contudo, que o parágrafo único do artigo 22 prevê a possibilidade de que LC, obviamente federal, possa autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas relacionadas no artigo 22.

Quanto às competências administrativas, o artigo 23 da Constituição determina que o combate à poluição, em qualquer de suas formas, e a defesa do meio ambiente integram a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ora, é evidente que, para exercitar tais atribuições, existe a necessidade de que sejam elaboradas normas e regulamentos. Portanto, cabe, sem dúvida, uma produção legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios sobre águas, desde que voltada para o combate à poluição e para a proteção do meio ambiente.

15.2.2.4 Mudança de concepção

A CF de 1988 trouxe uma profunda alteração em relação às Constituições anteriores no que tange ao tratamento da água. Utilizando-se de aspectos que eram apenas insinuados, a Carta atual caracterizou a água como um recurso econômico de forma clara.

Um outro elemento que deve ser observado é que a concepção subjacente ao modelo constitucional de 1988 prevê o fim da privatização dos recursos hídricos. De fato, dado que a água é um bem público de livre apropriação, os grandes usuários de recursos hídricos apropriam-se das águas para as suas finalidades privadas, transferindo os custos decorrentes da poluição ou escassez para a coletividade.

15.3 O REGIME JURÍDICO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O regime jurídico aplicável aos recursos hídricos foi profundamente alterado pela Constituição de 1988 que, na prática, extinguiu o regime privado de águas, o qual remanesce sem maior importância,

Dentre os chamados recursos ambientais, a água é, provavelmente, aquele que vem sendo tutelado pelo Direito Positivo há mais tempo. Conforme anota Afrânio de Carvalho (1986, p. V):

O CC de 1916 dedicou uma das seções à água e fê-lo com inegável acerto, mantendo a tradição de nosso direito (*Ordenações do Reino*; *Resolução de 17/8/1775*; *Alvará de 27/11/1804*; *Consolidação das Leis Cíveis de Teixeira de Freitas*). Após o CC, quando este já vigorava há muitos anos, veio o Código de Águas de 1934 (Dec. nº 24.643, de 17/1/1934).

Não é recente a preocupação do Direito brasileiro com as águas. A legislação colonial, sobretudo as Ordenações Filipinas, decretadas em 11 de janeiro de 1603 e vigentes por quase três séculos, já tratava da proteção das águas. Assim é que no Livro V, Título LXXXVIII, foi estabelecida a proibição de poluição das águas, conforme nos lembra Ann Helen Wainer (1991, p. 20):

O conceito de poluição das águas nos é fornecido no parágrafo sétimo do referido título, que expressamente proíbia a qualquer pessoa jogar material que pudesse matar os peixes e sua criação ou sujar a água dos rios e lagoas.

No sistema republicano, o CC de 1916 dedicou espaço ao trato de questões referentes à utilização e ao regime das águas. Dessa forma, foi estabelecido, em seus artigos 563 a 568, um regime geral das águas, submetido a normas de Direito comum. O novo CC instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, também é dotado de dispositivos voltados para a proteção das águas, ainda que sob uma ótica mais privatista, conforme artigo 1.288 e seguintes, constituindo-se em setor do direito de vizinhança.

A legislação brasileira, ainda vigente, de proteção aos recursos hídricos é bastante ampla. O principal instrumento é o Decreto nº 24.643, de 17 de julho de 1934 (Código de Águas). O Código, ainda que baixado com o principal objetivo de regulamentar o uso das águas como fonte geradora de energia elétrica, possuía mecanismos capazes de assegurar a utilização sustentável dos recursos hídricos, bem como garantir o acesso público às águas. O CC, igualmente, possui várias normas referentes à proteção da qualidade da água. Podem, ainda, ser apontadas as seguintes leis: (i) Lei nº 4.466/1964, (ii) Lei nº 6.050/1974, (iii) Lei nº 6.938/1981, (iv) Lei nº 9.966/2000 e (v) Lei nº 12.787/2013.

O aspecto que, hodiernamente, se pode considerar superado na legislação mencionada é aquele que estabelece o acesso *não oneroso* às águas. Pela legislação atualmente em vigor, salvo em alguns Estados, *não há um preço para a água em estado bruto*. Isso faz com que o desperdício e descaso com a proteção e qualidade dos recursos hídricos seja, em geral, muito grande.

O Código Penal também possui normas destinadas à proteção dos recursos hídricos.

15.3.1 Água: sua definição

A água é um daqueles elementos que nos cercam, cuja definição parece ser demasiadamente óbvia e, em razão disso, dificilmente a encontramos.

O Dicionário Aurélio Eletrônico registra a seguinte definição para o vocábulo *água*:

Verbetes: água [Do lat. aqua.] S. f. 1. Quím. Óxido de di-hidrogênio, líquido, incolor, essencial à vida. [Fórm.: H₂O.] 2. A parte líquida do globo terrestre.

O Dicionário Geológico-Geomorfológico de Antônio Teixeira Guerra (1993, p. 8) assim define a água:

É um composto químico formado de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio (H₂O). A água constitui uma unidade de medida de densidade e a escala termométrica centesimal (Celsius) se baseia no seu ponto de solidificação 0° e de ebulição 100°C [...] As águas estão em constante circulação, estando presentes tanto na atmosfera sob a forma de vapor quanto na superfície do solo sob a forma líquida, ou mesmo no interior do subsolo, constituindo lençóis aquíferos. Três são as partes que integram o ciclo hidrológico: 1 – Água de evaporação; 2 – Água de infiltração; 3 – Água de escoamento superficial.

15.3.2 Conceitos básicos do Código de Águas

O Código de Águas instituído pelo Decreto nº 24.643/1934 – em grande parte revogado –, significou uma profunda alteração nos dispositivos legais do CC brasileiro, que se destinavam à regulamentação do regime dominial e de uso das águas no Brasil. Explica-se o fato na medida em que o CC limitava-se a uma regulamentação cujo fundamento básico era o direito de vizinhança e a utilização das águas como bem essencialmente privado e de valor econômico limitado. O Código de Águas foi construído a partir de uma concepção inteiramente diversa. Para o Código de Águas, as águas são um dos elementos básicos do desenvolvimento, pois a eletricidade é um subproduto essencial para a industrialização do país. Ao mesmo tempo, a lei das águas estabelece um mecanismo de intervenção governamental com vistas a garantir a qualidade e a salubridade dos recursos hídricos. Aliás, a diferença fundamental entre a normatividade estabelecida pelo CC brasileiro e pelo Código de Águas está, exatamente, no fato de que o Código de Águas enfoca as águas como *recursos* dotados de valor econômico para a coletividade e, por isso, merecedores de atenção especial do Estado.

Observe-se que as *consideranda* do Código de Águas são bastante explícitas.

Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido até hoje por uma legislação obsoleta, em desacordo com as necessidades e interesses da coletividade nacional; considerando que se torna necessário modificar este estado de coisas, dotando o País de uma legislação adequada que, de acordo com a tendência atual, permita ao Poder Público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas; considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem e garantam seu aproveitamento racional [...].

Merecem destaque, também, os artigos 32 e 33 do Código de Águas, que estabelecem a possibilidade de desapropriação das águas em razão de necessidade ou utilidade pública.

Dignas de destaque, igualmente, são as disposições contidas nos artigos 109/116, que tratam das águas nocivas, e que são bastante atualizadas, ainda hoje.

É, portanto, a partir de uma ótica intervencionista que devem ser compreendidos os institutos jurídicos estabelecidos pelo Código de Águas.

O Código de Águas define uma série de conceitos jurídicos que são fundamentais para o estudo do Direito e, em especial, para o Direito Ambiental. A importância dos mencionados conceitos decorre do fato de que toda a regulamentação administrativa referente à qualidade dos recursos hídricos deverá levar em consideração o regime dominial ao qual estão submetidas as águas.

Inicialmente, cumpre considerar que o Código de Águas divide as águas em três categorias básicas, a saber: a) públicas; b) comuns; e c) particulares.

As águas públicas foram divididas pelo Código em duas categorias, que são: a) de uso comum; e b) dominicais. Vale observar que para que as águas ostentem a condição jurídica de águas públicas é indispensável que as mesmas sejam perenes. As águas públicas de uso comum (art. 2º do Decreto nº 24.643/1934 – Código de Águas) são as seguintes: a) mar territorial, nos mesmos incluídos os golfos, baías, enseadas e portos; b) correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou fluviáveis; c) as correntes de que se façam estas águas; d) as fontes e reservatórios públicos; e) as nascentes, quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam o *caput fluminis*; f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade ou fluviabilidade; g) as situadas em zonas periodicamente assoladas pela seca, nos termos e de acordo com a legislação especial sobre a matéria.

As *águas públicas dominicais* são todas aquelas situadas em terrenos que ostentem a condição de domínio público dominial, quando não forem do domínio público de uso comum, ou não forem comuns. São *particulares* as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns.

Em relação aos seus proprietários, águas públicas podem se classificar em federais, estaduais e municipais. São águas públicas federais quando: a) sejam marítimas; b) estejam situadas em territórios federais; c) sirvam de limites da República com as nações vizinhas ou se estendam a território estrangeiro; d) quando situadas na zona de 100 km contígua aos limites da República; e) quando sirvam de limites entre dois ou mais Estados; f) quando percorrerem parte do território de

dois ou mais Estados (art. 29, I).

São estaduais quando: a) sirvam de limites a dois ou mais municípios; e b) quando percorram parte dos territórios de dois ou mais municípios. As águas públicas são municipais quando exclusivamente situadas em seu território, respeitadas as restrições que possam legalmente ser impostas.

Águas comuns são as correntes não navegáveis ou fluviáveis.

Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto (art. 9º). Em sentido comum, o álveo é o leito do rio, conforme a definição que nos é fornecida pelo Dicionário Aurélio Eletrônico: *Verbetes: álveo [Do lat. alveu.] S. m. 1. Leito (5). 2. Sulco, escavação. O álveo poderá ser público, de uso comum ou dominical, conforme a propriedade respectiva das águas. Será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares (art. 10).*

Nascentes são as águas que surgem naturalmente ou por indústria humana e que correm dentro de um mesmo prédio particular e, ainda que o transponham, quando elas não tenham sido abandonadas pelo proprietário do mesmo (art. 89).

Águas pluviais são aquelas que procedem diretamente das chuvas (art. 102).

15.3.2.1 Outros conceitos importantes

Alguns conceitos são importantes para a compreensão do âmbito de aplicação do Código de Águas, embora o próprio Código de Águas não nos forneça a sua definição normativa. Doravante, passarei a apresentar aqueles que julgo serem essenciais.

15.3.2.1.1 Rio

Rio é um conceito essencial no que diz respeito à aplicação do Código de Águas. O rio é uma das classificações em que se dividem as águas correntes naturais. Na sua acepção semântica, rio tem o seguinte significado:¹

Verbetes: rio [Do lat. rivu (riu no lat. vulg.).] S. m. 1. Curso de água natural, de extensão mais ou menos considerável, que se desloca de um nível mais elevado para outro mais baixo, aumentando progressivamente seu volume até desaguar no mar, num lago, ou noutro rio, e cujas características dependem do relevo, do regime de águas, etc. [V. afluentes (4), curso (3), foz, leito (5), margem (3) e nascente (5)].

Juridicamente, conforme observa Antônio de Pádua Nunes (s.d., p. 3), o conceito difere daquele que é fornecido pela linguagem comum:

Podemos considerar rio o curso de água que é apto para navegação ou flutuação, bastando que essa aptidão exista em algum trecho nos termos do art. 6º do Decreto-lei nº 2.281, de 5/9/1940. Se assim não for, a corrente deverá denominar-se córrego, ribeirão, riacho, arroio etc.

Afrânio de Carvalho (1986, p. 121) ensina-nos que:

O rio, no seu todo, compõe-se de três elementos, água, leito e margem, dos quais a água é o principal, servindo o leito e a margem para contê-la. Ao passo que a água é um elemento autônomo, o leito e a margem se completam e solidarizam na função de continente dela. A margem, como prolongamento lateral ascendente do leito ou álveo, chega até a orla saliente da calha do rio, onde serve para lindar a contenção da água no seu curso normal. Na parte mais baixa, também é chamada de praia, e na mais alta, de ribanceira, ou barranca, pois costuma haver uma gradação, maior ou menor, de uma para outra, embora seja por vezes quase repentina a mudança, como nos “canhões” do rio. Assim como o leito, a margem é parte integrante do rio, mas, ao mesmo tempo, ambos não passam realmente de extremidades do solo ribeirinho, dada a homogeneidade de sua composição.

Bacia hidrográfica – o Vocabulário Básico de Meio Ambiente apresenta os seguintes significados para o conceito de bacia hidrográfica:

Área cujo escoamento das águas superficiais contribui para um único exutório [...] Área de drenagem de um curso d'água ou lago [...] Área total drenada por um rio e seus afluentes [...] Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes [...] São grandes superfícies limitadas por divisores de águas e drenadas por um rio e seus tributários [...] (MOREIRA, 1992, p. 35).

15.3.2.1.2 Lago e lagoa

Lago e lagoa são duas definições extremamente importantes para a legislação protetora dos recursos hídricos. Em sua acepção comum, o vocábulo *lago*, originado do latim *lacus*, é sinônimo de *extensão de água cercada de terras*. Já *lagoa* é vocábulo que também tem a sua origem no latim, provindo de *lacona*, segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico, é um *lago pouco extenso*. No Brasil, é corrente chamar *lagoa* a qualquer *lago*.

15.3.2.1.3 Corrente

Corrente é vocábulo cujos significados dicionarizados por Aurélio Buarque são extremamente amplos, em sendo assim, passarei a apresentar, apenas, aqueles que guardam referência direta com o nosso tema:

Corrente [Do lat. currente. [...] Diz-se das águas que correm, que não se acham estagnadas; corrediço, corredio [...] O curso das águas de um rio, de um ribeiro, de um regato; correnteza [...].

15.3.3 Legislação extravagante de proteção aos recursos hídricos

Além do Código de Águas, existem outras normas legais, no Direito brasileiro, que se prestam à proteção dos recursos hídricos. Cid Tomanik de Pompeu (s.d., p. 105), em excelente trabalho, arrolou o conjunto de normas legais que, mesmo antes do estabelecimento da PNMA – PNMA, mediante a edição da Lei nº 6.938/81, eram perfeitamente aptas à proteção da qualidade das águas públicas e particulares. Tal legislação, antecedente à concepção jurídica que dá base à existência do Direito Ambiental, está fundada na defesa da saúde pública que, como se sabe, é a concepção jurídica que primeiro serviu para a proteção legal do meio ambiente. Tal legislação guarda uma relação direta com o processo de industrialização vivido pelo país a partir da década de 30 e, sobretudo, a partir dos anos 50. Atualmente, existindo a legislação específica de Direito Ambiental, com vistas ao combate da poluição dos recursos hídricos, a legislação mencionada pelo professor Tomanik Pompeu é importante pelo seu valor histórico e retrospectivo. Citarei, doravante, algumas das normas referidas pelo ilustre autor.

Em primeiro lugar, deve ser citado o revogado Decreto nº 23.777/1934, que “já estabelecia a obrigatoriedade do lançamento dos resíduos industriais das usinas açucareiras nos rios principais, longe das margens, em lugar fundo e correntoso, devendo, quando não fosse possível, ser adotados tanques de depuração” (POMPEU, s.d., p. 106). Como se observa, não existe uma preocupação evidente com o tratamento dos rejeitos ou mesmo com a sua eliminação. Entretanto, o que é bastante louvável, considerando-se a época, é que existe a preocupação de que seja evitada a contaminação das águas imediatamente utilizáveis pelos ribeirinhos.

Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que estabelece a possibilidade de desapropriação por utilidade pública, na qual se compreende a *salubridade pública*.

As leis posteriores aos anos 50 não foram referidas, pois, de maneira geral, encontram-se analisadas ao longo de todo o presente trabalho, em diversos capítulos e tópicos.

15.4 O VALOR ECONÔMICO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Como já foi visto antes, a legislação brasileira é pródiga em normas cujo objetivo é a proteção dos recursos hídricos. A legislação anterior à Lei nº 6.938/81 tinha como escopo básico a proteção da saúde humana. O importante da legislação brasileira de proteção aos recursos hídricos é que, mesmo antes da Lei nº 6.938/81, o Código de Águas e as demais normas jurídicas voltadas para a proteção dos recursos hídricos já estavam fundamentados em concepção jurídica que contemplava, simultaneamente, a proteção da saúde humana, com a proteção da qualidade ambiental das águas e com a proteção e manutenção do valor que as mesmas ostentam para o desenvolvimento econômico e social. O combate à poluição dos recursos hídricos se faz, portanto, a partir do reconhecimento do multifacético valor assumido pelas águas no Direito brasileiro.

O reconhecimento do valor econômico tem sido assumido desde a vigência do Código de Águas e ganhou nível constitucional desde a Carta de 34.

15.4.1 Desapropriação de recursos hídricos

O Código de Águas, em seus artigos 32 e 33, reconhece a possibilidade de desapropriação dos recursos hídricos. A desapropriação das águas públicas de uso comum ou patrimoniais dos Estados ou dos Municípios, bem como as águas comuns ou particulares, ainda como os seus respectivos álveos e margens, o podem ser em razão de necessidade ou utilidade pública. A declaração de necessidade ou utilidade pública somente é possível, contudo, quando se tratar da hipótese de algum serviço público a ser instalado e que esteja previsto na legislação brasileira.

Em assim sendo, são aplicáveis as hipóteses do artigos 2º, §§ 2º e 5º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, que tratam das desapropriações por utilidade pública. São aplicáveis, igualmente, as disposições contidas na Lei nº 4.132/1962, que dispõe sobre a desapropriação por interesse social. Na lei em tela são consideradas como de interesse social, por força dos incisos VI e VII: As terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte, eletrificação, armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas (art. 2º, VI) e, ainda, a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais (art. 2º, VII)

A desapropriação de recursos hídricos, dado o novo regime constitucional, em minha opinião, perdeu o sentido.

15.4.2 Obrigação de conservação da qualidade das águas

Antecipando-se aos modernos conceitos de responsabilização por danos ambientais, o Código de Águas, em seus artigos 109/118, estabelece um sistema pelo qual aquele que “conspurcar ou contaminar as águas que não consome em prejuízo de terceiros” deve arcar com o ressarcimento dos prejuízos e com os custos da recuperação da qualidade das águas. Hodiernamente, estaríamos diante da obrigação de repristinar o meio ambiente agredido pelo inquinamento.

Estabelecida a proibição geral de conspurcação ou contaminação das águas em prejuízo de terceiros, conforme as determinações legais contidas no artigo 109, o próprio Código de Águas passa a definir quais os mecanismos que deverão ser utilizados para a reparação dos danos ambientais, independentemente da responsabilidade civil, penal e administrativa. Com efeito, determina o artigo 110 do Código de Águas que os trabalhos para a salubridade das águas serão executados à custa dos infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos administrativos.

Verifica-se que, pelo que está disposto na norma, compete ao poluidor todo o pagamento pelos *trabalhos para a salubridade*, isto é, pelos trabalhos para a recomposição da biota agredida, bem como a indenização pelos danos causados a terceiros ou às propriedades públicas ou privadas que, eventualmente, tenham sido prejudicadas pela poluição causada. O poluidor, igualmente, sujeita-se às sanções administrativas resultantes da inobservância de regulamentos administrativos e, por fim, caso o dano ambiental tenha sido provocado por um comportamento criminalmente reprovável, o poluidor deve responder pelos seus atos perante o juízo do crime.

15.4.2.1 A regulamentação administrativa das águas

15.4.2.1.1 Estabelecimento das classes de águas

O estabelecimento de um sistema de classificação das águas é essencial para que se possa organizar o sistema administrativo destinado a exercer a fiscalização do controle de qualidade das águas interiores. A primeira classificação das águas realizadas no Brasil foi estabelecida pela Portaria nº 13/76 do Ministério do Interior que, na época, era o órgão ao qual estava vinculada a antiga SEMA.

Atualmente, a matéria está regida por resoluções do Conama. A água é um dos componentes do meio ambiente natural que tem merecido as maiores atenções administrativas por parte do Conama. Diversas têm sido as resoluções voltadas para a proteção dos recursos hídricos. A atividade administrativa do Conama dirige-se seja para a proteção das águas marinhas, seja para a proteção das águas doces. O principal instrumento regulamentar é a resolução Conama nº 357/2005.

Classificação das águas conforme o uso preponderante

Classificação	Classe	Destinação das Águas
Águas doces	Classe Especial	Águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, e a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.
	Classe 1	Águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução Conama no 274, de 2000; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
	Classe 2	Águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução Conama no 274, de 2000; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca.
	Classe 3	Águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento

		convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais.
	Classe 4	Águas destinadas à navegação; à harmonia paisagística.
Águas salinas	Classe Especial	Águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; e à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
	Classe 1	Águas destinadas à recreação de contato primário, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000; à proteção das comunidades aquáticas e à aquicultura e a atividade de pesca.
	Classe 2	Águas destinadas à pesca amadora; e à recreação de contato secundário.
	Classe 3	Águas destinadas à navegação; à harmonia paisagística.
Águas salobras	Classe Especial	Águas destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.
	Classe 1	Águas destinadas à recreação de contato primário, conforme Resolução Conama nº 274, de 2000; à proteção das comunidades aquáticas; à aquicultura e à atividade de pesca; ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.
	Classe 2	Águas destinadas à pesca amadora; e à recreação de contato secundário.
	Classe 3	Águas destinadas à navegação; à harmonia paisagística.

A Resolução Conama nº 430/2011, complementou a Resolução Conama nº 357/2005 acrescentando novas definições e conceitos:

- **Capacidade de suporte do corpo receptor:** valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento;
- **Concentração de Efeito Não Observado – CENO:** maior concentração do efluente que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, em um determinado tempo de exposição, nas condições de ensaio;
- **Concentração do Efluente no Corpo Receptor – CECR,** expressa em porcentagem: a) para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos etc.): $CECR = [(vazão\ do\ efluente) / (vazão\ do\ efluente + vazão\ de\ referência\ do\ corpo\ receptor)] \times 100$, para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo órgão ambiental;
- **Concentração Letal Mediana – CL50 ou Concentração Efetiva Mediana – CE50:** é a concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado período de exposição, nas condições de ensaio;
- **Efluente:** é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos;
- **Emissário submarino:** tubulação provida de sistemas difusores destinada ao lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o limite do mar territorial brasileiro;
- **Esgotos sanitários:** denominação genérica para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes não domésticos;
- **Fator de Toxicidade – FT:** número adimensional que expressa a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição, nas condições de ensaio;
- **Lançamento direto:** quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor;
- **Lançamento indireto:** quando ocorre a condução do efluente, submetido ou não a tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor;
- **Nível trófico:** posição de um organismo na cadeia trófica;
- **Parâmetro de qualidade do efluente:** substâncias ou outros indicadores representativos dos contaminantes toxicológica e ambientalmente relevantes do efluente;
- **Testes de ecotoxicidade:** métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica; e
- **Zona de mistura:** região do corpo receptor, estimada com base em modelos teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro.

15.4.2.1.2 Possibilidade de ultrapassagem dos parâmetros

A norma admite que, em condições excepcionais, os parâmetros fixados possam ser ultrapassados, conferindo ao corpo receptor características de qualidade “em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento” (art. 5º da Res. Conama 430/2011). São circunstâncias excepcionais e obrigatoriamente transitórias, devendo haver autorização prévia e específica por parte do órgão ambiental responsável pela fiscalização da atividade “mediante análise técnica fundamentada”, observando-se alguns requisitos, tais como (art. 6º da Resolução Conama nº 430/2011): a) comprovação de relevante

interesse público, devido ao quadro no enquadramento do corpo receptor e às metas intermediárias e finais, progressivas e obrigatórias; c) realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento; d) estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e) fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma; e f) estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do lançamento excepcional.

Dada a importância do tema e a criticidade da proteção aos recursos hídricos, parece-me razoável que tal hipótese deve ser amplamente divulgada e tornada pública mediante a edição de resolução ou deliberação específica por parte do órgão de controle ambiental.

15.5 AS ÁGUAS SUBMETIDAS AO REGIME JURÍDICO DE UTILIZAÇÃO “PRIVADA”

Muito embora a Lei nº 9.433/1997 tenha estabelecido no inciso I do artigo 1º que “a água é um bem de domínio público”, subsistem em relação à água determinados direitos de uso “privados”, sobretudo no que diz respeito às relações de vizinhança.

15.5.1 Normas gerais estabelecidas pelo CC brasileiro

Apesar da existência do Código de Águas, que regulamentou a utilização das águas, remanescem as normas do CC brasileiro quanto ao particular. O Código de Águas não significou uma revogação pura e simples das normas contidas no CC brasileiro sobre o regime jurídico das águas. Conforme afirma Afrânio de Carvalho (1986, p. 114):

O Código de Águas de 1934 cobriu interstícios deixados pelo CC, de sorte que os dois diplomas, embora se repitam em certo tanto, noutro tanto se completam.

O CC trata do assunto nos artigos 1.288 e seguintes que complementam as normas do Código de Águas, sobretudo no que se refere aos aspectos de vizinhança. Conforme observa Silvio Rodrigues (1980, 140):

Quando dentro do campo da vizinhança, fala-se em regime de águas legalmente estabelecido, tem-se em vista o complexo das normas reguladoras das relações entre vizinhos, referentes às águas de nascente e pluviais, que, com o escopo de harmonizar interesses e compor conflitos, criam direitos e obrigações recíprocos.

Os direitos e obrigações recíprocos que são estabelecidos pelo CC dizem respeito à garantia do livre fluxo das águas do prédio superior para o prédio inferior, da obrigação de receber as águas que fluem normalmente etc. A matéria encontra-se também no Código de Águas, em seus artigos 68/138.

Os principais direitos e obrigações concernentes à utilização das águas são os seguintes (GOMES, 1989, p. 181-182): Principais direitos: a) o que tem o dono do prédio superior de facilitar o escoamento das águas mediante abertura de sulcos e drenos; b) o que tem o proprietário do prédio inferior de facilitar o escoamento natural das águas com a abertura de canais e valetas; c) o de captar as águas de que se serve; d) o que tem o dono do prédio superior de utilizar-se livremente das águas de fonte não captada para satisfazer suas necessidades; e) o que tem o proprietário do prédio inferior sobre as sobras de fonte não captada pelo prédio superior; f) o de captar água de fonte; g) o de utilizar-se das águas pluviais; h) o de aproveitar águas de rios públicos; i) o de canalizar, através de prédios alheios, as águas a que tenha direito; j) o de captar águas dos rios que banhem ou atravessem seu terreno; k) o de alterar o álveo da corrente que atravessa seu imóvel, desde que mantendo o mesmo ponto de saída para o prédio inferior.

Quanto às principais obrigações, estas são as seguintes: a) a que tem o dono do prédio inferior de receber as águas que correm naturalmente do superior, isto é, as águas correntes por obra da natureza e as águas pluviais; b) a que tem o dono do prédio superior de não aumentar o ímpeto das águas, reunindo-as num só curso; c) a que tem o dono do prédio inferior de consentir que o proprietário do prédio superior penetre seu terreno para a execução de trabalhos de conservação e limpeza; d) a do dono do prédio superior de não impedir o curso natural das águas pelos prédios inferiores; e) a de permitir, através de seus prédios, o aqueduto; f) a de não captar toda a água da corrente que atravessa ou banha seu terreno, para não privar o dono do prédio vizinho da parte que lhe toca; g) a que tem o dono do prédio superior de não piorar a situação do prédio inferior, com as obras que fizer para facilitar o escoamento das águas.

É importante observar que não se cuida de regime de propriedade das águas, mas única e exclusivamente de um regime de convivência entre partes que se utilizam de um mesmo recurso hídrico.

15.5.1.1 Regime de prescrição

Sendo certo que a água é um bem juridicamente apropriável, o regime de prescrição incidente sobre o mesmo é muito importante. Como se sabe, através da aplicação do regime de prescrição são possíveis a perda e a aquisição de bens. A matéria está regulada pelo artigo 79 do Código de Águas, que estabelece:

É imprescritível o direito de uso sobre as águas das correntes, o qual só poderá ser alienado por título ou instrumento público, permitida não sendo, entretanto, a alienação em benefício de prédios não marginais, nem com prejuízo de outros prédios, aos quais pelos artigos anteriores é atribuída a preferência no uso das mesmas águas. Parágrafo único. Respeitam-se os direitos adquiridos até a data da promulgação deste Código, por título legítimo ou prescrição que recaia sobre oposição não seguida, ou sobre a construção de obras no prédio superior, de que se possa inferir abandono do primitivo direito.

15.5.2 Normas do Código de Águas referentes ao aproveitamento de águas comuns e particulares

A disposição mais importante do Código de Águas sobre as águas particulares é aquela que está contida no artigo 68, que estabelece o regime de inspeção e autorização administrativa para as águas comuns e as particulares, no interesse da saúde e da segurança pública; e para as águas comuns, no interesse dos direitos de terceiros ou da qualidade, curso ou altura das águas públicas. Note-se que, aqui, está estabelecida uma norma de grande alcance ambiental, pois considera a água como um *interesse público*, independentemente de seu regime de domínio.

15.6 A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – PNRH

A CF de 1988, como já foi exaustivamente dito ao longo de todo o presente trabalho, é um marco significativo na mudança de concepção sobre o meio ambiente e de sua proteção legal. Infelizmente, muitos aspectos verdadeiramente inovadores da Carta ainda não passaram pela necessária densificação legislativa. Felizmente, naquilo que diz respeito aos recursos hídricos, o legislador federal estabeleceu uma nova normação que possibilitou o estabelecimento da PNRH que, como se verá adiante, não é antagônica à PNMA, ao contrário, ambas são complementares. A PNRH está estabelecida pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

15.6.1 Princípios gerais da PNRH

Os princípios basilares da PNRH – PNRH estão estabelecidos no artigo 1º e seus incisos, da Lei nº 9.433/97. Eles são os seguintes: a) a água é um bem de domínio público; b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos animais; d) a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas; e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos; f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

O principal aspecto que pode ser compreendido desses princípios é que a nova concepção legal busca encerrar com a verdadeira apropriação privada e graciosa

dos recursos hídricos. Com efeito, sabemos que a indústria e a agricultura são os grandes usuários dos recursos hídricos. Normalmente, a água é captada, utilizada e devolvida para o seu local de origem, sem que aqueles que auferem vantagens e dividendos com a sua utilização paguem qualquer quantia pela atividade. E mais, a recuperação e manutenção das boas condições sanitárias e ambientais dos recursos hídricos, conspurcados pelas diversas atividades econômicas que deles dependem, é um encargo de toda a sociedade que, com seus impostos, subsidia de forma inaceitável diversas atividades privadas.

A PNRH, em seus princípios, rompe com a antiga e errônea concepção de que os problemas referentes aos recursos hídricos podem ser enfrentados em descon sideração das realidades geográficas. A adoção da gestão por bacias é um passo fundamental para que se consiga um padrão ambientalmente aceitável para os nossos recursos hídricos. Igualmente relevante é a adoção do critério de que a gestão dos recursos hídricos é um elemento de interesse de toda a sociedade e que, portanto, somente em ações conjuntas é que se conseguirá obter resultados favoráveis.

15.6.1.1 Objetivos

A PNRH tem os seguintes objetivos: a) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; e d) incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.

15.6.2 Instrumentos

A PNRH possui os instrumentos capazes de torná-la exequível. Esses instrumentos são os seguintes: a) os planos de recursos hídricos; b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; c) a outorga de direitos de uso de recursos hídricos; d) a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e) a compensação a municípios; f) o sistema de informação sobre os recursos hídricos.

Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores cujo objetivo é fundamentar e orientar a implantação da PNRH, bem como o gerenciamento dos recursos hídricos. Os Planos de Recursos Hídricos caracterizam-se por serem planos de longo termo. O plano deverá ter o seguinte conteúdo mínimo: a) diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; b) análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução das atividades produtivas e da modificação dos padrões de ocupação do solo; c) balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; d) metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; e) medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento de metas previstas; f) prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; g) diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; h) propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos.

Os planos poderão ser criados em nível local, regional e nacional.

O enquadramento dos corpos de água em classes, já existentes anteriormente, conforme já foi visto, tem por objetivo atingir os seguintes resultados: a) assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; b) diminuir os custos do combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.

15.6.2.1 Outorga de direito de uso de recursos hídricos

Juntamente com o estabelecimento da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, este é um dos fatores mais importantes nas modificações trazidas pela nova legislação. Com efeito, através da outorga, o Estado passa a ter controle sobre a captação e o lançamento de efluentes nos corpos de água. A inexistência de tais controles, como se sabe, acarretou consequências extremamente negativas. De fato, antes da legislação atual, o bem público água era apropriado privadamente, gerando lucro e riqueza para os seus usuários e transferindo os ônus da manutenção de sua qualidade para a sociedade como um todo. Essa prática, é desnecessário dizer, era extremamente antissocial.

A outorga do direito de uso é um instituto jurídico administrativo cujos contornos ainda não estão muito bem definidos, em razão de sua novidade em nosso sistema jurídico. O artigo 11 da Lei nº 9.433/1997, estabelece que o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

A própria lei estabeleceu, em seu artigo 12, quais são os direitos que se encontram submetidos ao regime de outorga. São os seguintes os direitos recém-mencionados: a) derivação ou captação de parcela de água existente em corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; c) lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; d) aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e) outros usos que alteram o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.

Bem se vê que o grande número de atividades sujeitas ao regime de outorga, necessariamente, acarretará um maior controle das atividades que, de alguma forma, utilizam os corpos hídricos. A outorga deverá ser solicitada à entidade de direito público que tenha a titularidade do corpo hídrico, ou a quem lhe faça as vezes.

A outorga deve ser tida como um instituto jurídico administrativo intermédio entre a autorização e a licença administrativa. Embora não seja concedida em caráter precário, igualmente não o é, de forma definitiva. Há que se observar, entretanto, que, na forma do artigo 15, existe uma expressa previsão legal das diversas hipóteses nas quais se poderá registrar a suspensão da outorga. A suspensão da outorga de recursos hídricos poderá ser: (a) parcial e (b) total. Ou ainda: (a) definitiva ou (b) por tempo limitado. Os motivos legais que podem acarretar a suspensão da outorga são os seguintes: a) não cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga; b) ausência de uso por três anos consecutivos; c) necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; d) necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental; e) necessidade de atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fonte alternativa; f) necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo hídrico.

Todas as hipóteses previstas em lei estão bastante evidentes e são voltadas para o atendimento de um interesse público relevante. Mesmo o não cumprimento dos termos da outorga significa uma violação de interesse público, pois a outorga, quando concedida, visa uma exploração sustentável do recurso, dentro de um planejamento mais abrangente.

A outorga, concedida pelo prazo de 35 anos, renováveis, não implica alienação das águas, mas, apenas e tão somente, a autorização para a sua adequada utilização. “*Processual civil – Administrativo – Mandado de Segurança – Captação de recursos hídricos – Outorga – Não comprovação – Falta de prova pré-constituída – Atribuição do poder executivo – Dilação probatória – Descabimento. 1. A Lei 9.433/97, que institui a PNRH, estipula que a exploração de recursos hídricos está sujeita a outorga pelo Poder Público (art. 12), de modo que somente se legitima a questionar judicialmente, em mandado de segurança, ato da autoridade pública que visa impedir a captação de água, quem é detentor de outorga do Poder Público para a referida exploração. 2. A inexistência de comprovação, no ato da impetração, da referida outorga impede o exame de eventual direito líquido e certo do impetrante à captação de recursos hídricos, uma vez que o mandado de segurança pressupõe a juntada aos autos de prova pré-constituída do direito alegado, não podendo haver dilação probatória, nessa via. 3. A concessão da outorga não pode ser conferida pelo Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, pois, nos termos do art. 14 da citada Lei, a competência de tal ato é atribuída exclusivamente a autoridade do Poder Executivo Federal, Estadual ou Distrital. Ademais, os requisitos para essa concessão não podem ser aferidos nesta seara processual, que sequer admite dilação probatória. 4. Recurso especial improvido” (STJ. ROMS 200501594346. Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. DJU 20/6/2007, p. 226).*

15.6.2.2 Cobrança pela utilização dos recursos hídricos

A cobrança pelo uso da água está inserida em um princípio geral do Direito Ambiental que impõe, àquele que, potencialmente, auferirá os lucros com a utilização dos recursos ambientais, o pagamento dos custos. A cobrança, portanto, está plenamente inserida no contexto das mais modernas técnicas do Direito Ambiental e é socialmente justa. A cobrança pela utilização do uso dos recursos hídricos não é um fim em si mesmo, mas, ao contrário, um instrumento utilizado para o alcance de finalidades precisas. A cobrança não tem a natureza de tributo. São objetivos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos: a) reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; b) incentivar a racionalização do uso da água; c) obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e interações contemplados nos planos de recursos hídricos.

A cobrança pela utilização dos recursos hídricos deve ser realizada tendo por base os critérios legais fixados na lei, sendo certo que a sua utilização prioritária deve ocorrer na bacia hidrográfica que tenha gerado o recurso financeiro. A aplicação dos recursos poderá ser feita a *fundo perdido*, ou seja, o dinheiro retorna à sua origem com vistas ao financiamento de projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, à qualidade, à quantidade e ao regime de vazão dos corpos de água.

15.6.2.3 Administração dos recursos hídricos

A administração dos recursos hídricos é feita em três níveis: a) CNRH; b) Comitês de Bacias Hidrográficas; c) Agências de água.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi constituído tendo por base os seguintes objetivos: a) coordenar a gestão integrada das águas; b) implementar a PNRH; c) arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os Recursos Hídricos; d) planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos Recursos Hídricos; e) promover a cobrança pela utilização dos Recursos Hídricos.

O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos é integrado por: a) CNRH; b) a Agência Nacional de Águas; c) Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; d) Comitês de Bacias Hidrográficas; e) os órgãos dos poderes públicos federais, estaduais e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos; f) as Agências de Água.

15.6.2.3.1 Constituição e competências do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos

O CNRH tem a seguinte composição, conforme estabelecido pelo Decreto nº 4.613/2003 (art. 2º): (i) um representante de cada um dos seguintes Ministérios: a) da Fazenda; b) do Planejamento, Orçamento e Gestão; c) das Relações Exteriores; d) dos Transportes; e) da Educação; f) da Justiça; g) da Saúde; h) da Cultura; i) do Desenvolvimento Agrário; j) do Turismo; e k) das Cidades; (ii) dois representantes de cada um dos seguintes Ministérios: a) da Integração Nacional; b) da Defesa; c) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; d) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e e) da Ciência e Tecnologia; (iii) três representantes de cada um dos seguintes Ministérios: a) MMA; e b) de Minas e Energia; (iv) um representante de cada uma das seguintes Secretarias Especiais da Presidência da República: a) de Aquicultura e Pesca; e b) de Políticas para as Mulheres; (v) dez representantes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; (vi) – doze representantes de usuários de recursos hídricos; e VII – seis representantes de organizações civis de recursos hídricos.

Ao Conselho compete (art. 1º do Decreto nº 4.613/2003): (i) promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários; (ii) arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; (iii) deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos, cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; (iv) deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica; (v) analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à PNRH; (vi) estabelecer diretrizes complementares para implementação da PNRH, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; (vii) aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacias Hidrográficas e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; (viii) deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem interpostos; (ix) acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; (x) estabelecer critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso; (xi) aprovar o enquadramento dos corpos de água em classes, em consonância com as diretrizes do Conama e de acordo com a classificação estabelecida na legislação ambiental; (xii) formular a PNRH nos termos da Lei nº 9.433/1997, e do art. 2º da Lei nº 9.984/2000; (xiii) manifestar-se sobre propostas encaminhadas pela Agência Nacional de Águas – ANA, relativas ao estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei nº 9.984/2000; (xiv) definir os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, nos termos do inciso VI do art. 4º da Lei nº 9.984/2000; (xv) definir, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, as prioridades de aplicação dos recursos a que se refere o *caput* do art. 22 da Lei nº 9.433/1997, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei nº 9.984/2000; (xvi) autorizar a criação das Agências de Água, nos termos do parágrafo único do art. 42 e do art. 43 da Lei nº 9.433/1997; (xvii) deliberar sobre as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos de domínio da União, nos termos do inciso V do art. 38 da Lei nº 9.433/1997; (xviii) manifestar-se sobre os pedidos de ampliação dos prazos para as outorgas de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, estabelecidos nos incisos I e II do art. 5º e seu § 2º da Lei nº 9.984/2000; (xix) delegar, quando couber, por prazo determinado, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.433/1997, aos consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, com autonomia administrativa e financeira, o exercício de funções de competência das Agências de Água, enquanto estas não estiverem constituídas.

15.6.2.3.2 Comitês de Bacia Hidrográfica

Os Comitês de Bacia Hidrográfica poderão ter como áreas de atuação: (i) a totalidade de uma bacia hidrográfica; (ii) sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou (iii) grupo de bacias ou sub-bacias contíguas.

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação (Lei nº 9.433/97, art. 38): (i) promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; (ii) *arbitrar*, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; (iii) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia (iv) acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; (v) propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; (vi) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; (vii) estabelecer critérios e promover o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

É a seguinte a composição dos Comitês de Bacia: (i) representante da União; (ii) representante do Estado e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; (iii) representantes dos Municípios situados, no todo ou em parte, em suas áreas de atuação; (iv) representantes dos usuários das águas em sua área de atuação; (v) das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

Nas hipóteses em que os Comitês estejam constituídos em áreas que envolvam Terras Indígenas, deverão ser integrados por representantes da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e das comunidades indígenas da região.

15.6.3 Infrações e penalidades

São infrações às normas de utilização dos Recursos Hídricos: (i) derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso; (ii) iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que impliquem alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; (iii) utilizar-se dos recursos hídricos

ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; (iv) perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; (v) fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos; (vi) infringir normas estabelecidas em regulamento, compreendendo as normas administrativas emanadas dos órgãos competentes; (vii) obstar ou dificultar as ações da fiscalização competente.

As penalidades aplicáveis são as seguintes: (i) advertência por escrito, na qual será fixado o prazo para a correção da irregularidade; (ii) multa simples ou diária, proporcional à gravidade da infração; (iii) embargo provisório, por prazo determinado, para a execução de serviços e obras necessárias para o cumprimento das normas legais referentes aos recursos hídricos; (iv) embargo definitivo, com revogação da outorga.

15.7 AGÊNCIA DE ÁGUA

As Agências de Água têm por função o desempenho das atividades técnicas necessárias para que os Comitês de Bacia Hidrográfica possam ver aplicadas as suas deliberações. As Agências de Água podem prestar serviços para mais de um Comitê. As Agências de Água deverão ter a sua constituição autorizada pelos Comitês ou pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

São condições legais necessárias à constituição de Agências de Água: (i) prévia existência do Comitê ou dos Comitês de Bacia Hidrográfica que as tenham instituído; (ii) viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação.

Incumbe à Agência de Bacia, na sua área de atuação: (i) manter balanços atualizados da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; (ii) manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; (iii) efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; (iv) analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos; (v) acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua área de atuação; (vi) gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação; (vii) celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências; (viii) elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; (ix) promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação; (x) elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica; (xi) propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Compete, ainda, às Agências de Água propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: (i) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo conselho nacional ou conselhos estaduais de recursos hídricos, de acordo com o domínio destes; (ii) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; (iii) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; (iv) o rateio do custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

15.7.1 Organizações civis de recursos hídricos

Nos termos da Lei nº 9.433/1997, artigo 47, são consideradas organizações civis de recursos hídricos, (i) consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; (ii) associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; (iii) organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos; (iv) organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; (v) outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

15.7.2 Agência Nacional de Águas – ANA

15.7.2.1 Apresentação

A edição da Lei Federal nº 9.984/2000 foi um poderoso instrumento legal para a complementação do novo modelo de gestão dos recursos hídricos estabelecido pela Lei Federal nº 9.433/1997.

O Brasil é um país, como se sabe, extremamente bem aquinhado com recursos hídricos que, no entanto, necessita que eles sejam geridos de forma racional e capaz de conservá-los para o futuro. Assim como a renda, a distribuição de recursos hídricos em nosso território é bastante desigual e, portanto, carecedora de uma intervenção que possa promover o equilíbrio e as necessárias compensações entre as regiões e os diferentes usuários do recurso. Em última análise, a ANA tem o papel de ser a entidade encarregada de dar execução às decisões políticas capazes de definir usos adequados para os recursos hídricos brasileiros, atendendo às diferentes necessidades nacionais de forma equilibrada e contemplando todos os usos e velando para que uns não se sobreponham aos outros, assegurando o equilíbrio entre as diferentes demandas dos diferentes usuários.

15.7.2.2 Competências da ANA

De acordo com o determinado na Lei Federal nº 9.433/1997, compete ao CNRH promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a PNRH. O mencionado Conselho, entretanto, não possui competências executivas; estas pertencem à ANA. É importante observar, entretanto, que a ANA não está organizada administrativamente como as demais agências criadas após o processo de concessões e privatizações que vem sendo implantado pela administração pública brasileira desde a década de 90 do século XX. A ANA, diferentemente da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel e ANP, não possui autonomia administrativa frente à Administração, pois é organizada sob a forma de autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, *vinculada* ao MMA, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a PNRH, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No desempenho de suas funções, a ANA deverá observar os fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da PNRH, articulando-se com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A competência da ANA é a seguinte (Lei nº 9.984/2000, art. 4º): i) supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; ii) disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da PNRH; iii) outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º da lei que instituiu a ANA; iv) fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; v) elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo CNRH, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do artigo 38 da Lei nº 9.433/1997; vi) estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica; vii) implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União; viii) arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no artigo 22 da Lei nº 9.433/1997; ix) planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios; x) promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos; xi) definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas; xii) promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicos ou privados que a integram, ou que dela sejam usuários; xiii) organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos; xiv) estimular a pesquisa e a capacitação de recursos

humanos para a gestão de recursos hídricos; xv) prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos; xvi) propor ao CNRH o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos; xvii) participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação; xviii) regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d'água de domínio da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão, e adução de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditoria de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes; xix) organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); xx) promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens; xxi) coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma consolidada; xxii) declarar a situação crítica de escassez quantitativa ou qualitativa de recursos hídricos nos corpos hídricos que impactem o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União; e xxiii) estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água a fim de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos a que se refere o inciso XXIII.

Em se tratando de bacias hidrográficas compartilhadas com países vizinhos, evidentemente que a ANA não poderá ultrapassar ou deixar de observar os limites estabelecidos em tratados internacionais ou multilaterais.

15.7.2.2.1 Exceções às atribuições da ANA

As atribuições da ANA são marcadas por algumas exceções bastante claras e que, de certa forma, são bastante razoáveis, pois implicam a utilização do Poder Regulamentar em níveis superiores aos de uma simples agência administrativa. Refiro-me, por exemplo, às restrições à utilização normal e regular dos recursos hídricos quando envolverem a aplicação de racionamentos preventivos, que somente poderão ser promovidas mediante a observância de critérios a serem definidos em decreto do Presidente da República.

Sempre que se tratar da definição das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos, esta será efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Em salutar medida de descentralização administrativa, a ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do artigo 44 da Lei nº 9.433/1997, e demais dispositivos legais aplicáveis.

15.7.2.2.2 A outorga administrativa como instrumento de gestão de recursos hídricos

Não é demais lembrar que a água, quando apropriável com finalidades econômicas, é tratada pela moderna legislação ambiental brasileira como recurso hídrico. Esse é um elemento extremamente importante e necessário para a adequada compreensão do novo tratamento dispensado às águas pelo direito brasileiro, especialmente naquilo que diz respeito à apropriação de águas públicas com a finalidade de gerar riquezas econômicas, sejam públicas ou privadas. Entendeu o legislador brasileiro, acertadamente, em meu ponto de vista, que a natureza comunitária da titularidade dos recursos hídricos impede que os mesmos sejam utilizados como instrumento para produzir riqueza apenas para um indivíduo ou grupo de indivíduos, sem que se estabeleça um mecanismo de compensação para a coletividade.

A outorga é o instrumento jurídico administrativo que foi instituído pelo legislador ordinário para definir as condições pelas quais o usuário dos recursos hídricos poderá captá-lo ou nele lançar efluentes, dentro de critérios técnicos que assegurem a sustentabilidade do recurso.

a) Limites e condições da outorga

O artigo 5º da lei de regência (nº 9.984/2000) estabeleceu os seguintes prazos: (i) até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga; (ii) até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado; (iii) até 35 anos, para vigência da outorga de direito de uso.

Na fixação dos prazos mencionados, a autoridade administrativa deverá levar em conta a natureza e o porte do empreendimento, bem como, quando for o caso, o período de retorno do investimento. Em consequência disso, os prazos estabelecidos nas letras (a) e (b) poderão ser ampliados, quando o porte e a importância social e econômica do empreendimento justificarem a ampliação, desde que ouvido o CNRH. Quanto ao prazo estabelecido na letra (c), o mesmo poderá ser prorrogado pela ANA, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos.

É importante assinalar que as outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os dos correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de autorização. A medida justifica-se em função dos elevadíssimos investimentos necessários e do evidente interesse público envolvido na matéria.

b) Outorga preventiva e declaração de reserva de disponibilidade hídrica

A lei estabeleceu a figura da “outorga preventiva” de uso de recursos hídricos. Tal outorga tem por finalidade declarar a disponibilidade de água para os usos requeridos, observado o disposto no artigo 13 da Lei nº 9.433/1997. A expressão “outorga preventiva”, em minha opinião, é incorreta e não deveria ser utilizada. Em primeiro lugar, porque não é, efetivamente, uma outorga, pois a outorga é um consentimento administrativo, para que uma determinada quantidade de recursos hídricos possa ser apropriada economicamente, como parte de um processo produtivo ou como corpo receptor de efluentes. Ela, como se sabe, estabelece prazos e condições para que um bem público possa ser momentaneamente utilizado privadamente (desde que tenha utilidade para a coletividade). Como se passará a ver, a “outorga preventiva” não exerce qualquer função similar.

Em segundo lugar, há que se considerar que a outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos. O seu único objetivo é o de reservar a vazão passível de outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. Em verdade, o que existe é uma declaração feita pelo poder público dirigida a um determinado empreendedor, no sentido de que, em tese, há vazão suficiente para o empreendimento projetado. Existe, no particular, um certo grau de similaridade com a LP prevista na legislação de licenciamento ambiental. Entretanto, diferentemente do que ocorre com a LP, a concessão da “outorga preventiva” não cria uma vinculação da administração para com as razões nela estabelecidas. Em primeiro lugar porque a lei, expressamente, afasta a incidência do direito adquirido para a hipótese. Por outro lado, a administração, ao concedê-la, gera para o particular uma expectativa de direito bastante relevante, pois o planejamento é feito com base em custos projetados desde uma determinada carga de vazão. Uma alteração nesse particular, não se desconhece, pode ser bastante negativa para as atividades que se pretende desenvolver. Penso que a administração, portanto, deverá fundamentar jurídica e tecnicamente toda decisão que implique modificação dos termos da outorga. A fundamentação, portanto, passa a ser o motivo determinante do ato administrativo. Caso a fundamentação mostre-se em desconformidade com a realidade técnica, o particular poderá, judicialmente, pleitear o restabelecimento da vazão que originariamente lhe fora acenada.

É também de se considerar que a classificação de “preventiva” para a declaração feita pela administração é bastante inadequada, pois ela não tem a pretensão de evitar coisa alguma. Tenho a sensação de que o legislador desejava utilizar-se do termo “cautelar” ou “prévio” e, inadvertidamente, lançou mão da palavra “preventiva”.

As outorgas preventivas, assim como a outorga propriamente dita, são concedidas com prazos definidos. Estes serão fixados levando-se em conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de três anos, findo o qual será considerado o disposto nos incisos I e II do artigo 5º. O prazo, assim como a vazão, em minha opinião, poderá ser alterado pela Administração, mediante a edição de ato jurídico devidamente fundamentado, desde que o interesse público, definido em lei, assim o exija e justifique.

Uma figura assemelhada à da outorga preventiva é a “declaração de reserva de disponibilidade hídrica”. Trata-se de documento essencial sempre que a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel for promover licitação com o objetivo de autorizar ou conceder o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de água de

domínio da União.

O § 2º do artigo 7º assegura a transformação automática da declaração de reserva de disponibilidade hídrica, pelo respectivo poder outorgante (*rectius*: que estabeleceu a reserva, pois outorga ainda não existe), em outorga de direito de uso de recursos hídricos à instituição ou empresa que receber da Aneel a concessão ou a autorização de uso do potencial de energia hidráulica. A medida é inteligente e de caráter prático, pois assegura maior celeridade processual e evita a repetição de procedimentos administrativos desnecessários. Por medida de isonomia e de economia processual e administrativa, entendo que o mesmo deva ocorrer com a outorga preventiva, que poderia ser, automaticamente, transformada em outorga, desde que presentes as condições para a operação do empreendimento planejado. Na hipótese em que o corpo de água for de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica será obtida em articulação com a respectiva unidade gestora de recursos hídricos.

Desnecessário dizer que os pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, bem como os atos administrativos que deles resultarem, devem ser tornados públicos por meio de publicação na imprensa oficial e em pelo menos um jornal de grande circulação na respectiva região da outorga requerida.

15.7.3 Estrutura administrativa da Agência Nacional de Águas – ANA

15.7.3.1 Diretoria: composição

A ANA é dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução consecutiva, e contará com uma Procuradoria. O Diretor-Presidente da ANA é escolhido diretamente pelo Presidente da República entre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro anos ou pelo prazo que restar de seu mandato.

O artigo 10 da Lei nº 9.984/2000 estabelece uma estranha estabilidade para os membros da diretoria da ANA, pois a mesma não encontra qualquer amparo constitucional. Em primeiro lugar, é utilizada a expressão “exoneração imotivada”, o que, em termos de direito administrativo, é totalmente incongruente. A demissão do servidor deve ser motivada, a exoneração do exercente de cargo comissionado, assim como a nomeação, é feita *ad nutum*. Parece-me, portanto, inconstitucional a norma contida no artigo 10, que determina, *in verbis*:

Art. 10. A exoneração imotivada de dirigentes da ANA só poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos. § 1º Após o prazo a que se refere o caput, os dirigentes da ANA somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.

Além dessa hipótese, inconstitucional, repita-se, de perda de cargo, os dirigentes da ANA estão submetidos aos §§ 2º e 3º do artigo 10. A preocupação demonstrada pelo texto legal com a estabilidade funcional dos dirigentes da ANA é saudável, pois revela a necessidade de que as agências ambientais possam ter uma direção profissional e não meramente política, como infelizmente tem sido a prática administrativa. Isso, entretanto, não é suficiente para que sejam subtraídos poderes legítimos do Chefe do Executivo, sem que haja expressa previsão constitucional.

15.7.3.2 Atividades vedadas aos dirigentes

O artigo 11 da Lei nº 9.984/2000 estabeleceu um rol de atividades vedadas aos dirigentes da ANA, enquanto eles estiverem no desempenho do mandato. São proibições amplas, pois se estendem ao exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. Existe, ainda, a proibição de que o detentor de cargo de direção da autarquia, conforme dispuser o seu regimento interno, tenha interesse direto ou indireto em empresa relacionada com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A lei, no § 2º do artigo 11, estabeleceu uma derrogação parcial da proibição, ao não a aplicar “*aos casos de atividades profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa*”. A exceção, em meu ponto de vista, não se justifica, pois a cada dia é maior o número de instituições de ensino e pesquisa que, por meios próprios ou mediante a contratação por fundações, oferecem serviços no mercado como qualquer empresa, utilizando inclusive a dispensa de licitação favorecida pela lei de licitações.

15.7.3.3 Atribuições da diretoria

Na forma do artigo 12 da Lei nº 9.984/2000, é da competência da Diretoria da ANA: (i) exercer a administração da ANA; (ii) editar normas sobre matérias de competência da ANA; (iii) aprovar o regimento interno da ANA, a organização, a estrutura e o âmbito decisório de cada diretoria; (iv) cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; (v) examinar e decidir sobre pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União; (vi) elaborar e divulgar relatórios sobre as atividades da ANA; (vii) encaminhar os demonstrativos contábeis da ANA aos órgãos competentes; (viii) decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio da ANA; (ix) conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da Diretoria da ANA. Ao Diretor-Presidente compete: (x) exercer a representação legal da ANA; (xi) presidir as reuniões da Diretoria Colegiada; (xii) cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada; (xiii) decidir, *ad referendum* da Diretoria Colegiada, as questões de urgência; (xiv) decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada; (xv) nomear e exonerar servidores, provendo os cargos em comissão e as funções de confiança; (xvi) admitir, requisitar e demitir servidores, preenchendo os empregos públicos; (xvii) encaminhar ao CNRH os relatórios elaborados pela Diretoria Colegiada e demais assuntos de competência daquele Conselho; (xviii) assinar contratos e convênios e ordenar despesas; (xix) exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor e (xx) encaminhar ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico os relatórios analisados pela Diretoria Colegiada e os demais assuntos do interesse desse órgão.

Compete à Procuradoria da ANA, que se vincula à Advocacia Geral da União para fins de orientação normativa e supervisão técnica: (i) representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de Fazenda Pública; (ii) representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de direção, inclusive após a cessação do respectivo exercício, com referência a atos praticados em decorrência de suas atribuições legais ou institucionais, adotando, inclusive, as medidas judiciais cabíveis, em nome e em defesa dos representados; (iii) apurar a liquidez e certeza de créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da ANA, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial; e (iv) executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.

A atribuição contemplada em (ii) em minha opinião, é absurda e não pode ser tida como constitucional. Com efeito, cabe à Advocacia da União e aos seus órgãos vinculados a atuação em defesa do Estado e do Erário Público, defesas estas que não se confundem com a defesa judicial dos dirigentes de órgãos públicos – quaisquer que sejam os níveis hierárquicos ostentados pelos mesmos. Imagine-se que um determinado dirigente da ANA esteja respondendo aos termos de uma ação popular, em função da prática de ato, em tese, lesivo à autarquia. Como poderão os procuradores da ANA defender a autarquia e o dirigente concomitantemente? O mesmo ocorre para as hipóteses de improbidade administrativa etc.

§ 2º POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

15.8 ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES

O governo federal, mediante a edição da Lei nº 12.334/2010, estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de

Barragens. A Lei ora comentada é aplicável “a barragens destinadas à acumulação de água para diversos usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes características: (i) altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15 m (quinze metros); (ii) capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³ (três milhões de metros cúbicos); (iii) reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; (iv) categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6º da Lei”.

O artigo 2º da lei estabelece as seguintes definições normativas: (i) *barragem*: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas; (ii) *reservatório*: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou de mistura de líquidos e sólidos; (iii) *segurança de barragem*: condição que vise a manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente; (iv) *empreendedor*: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade; (v) *órgão fiscalizador*: autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalização da segurança da barragem de sua competência; (vi) *gestão de risco*: ações de caráter normativo, bem como aplicação de medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos; (vii) *dano potencial associado à barragem*: dano que pode ocorrer devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem.

O caso do rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, no Município de Mariana (MG), é um exemplo eloquente do que se fala.²

15.9 OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

O artigo 3º da PNSB estabelece os seguintes objetivos: (i) garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências; (ii) regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o território nacional; (iii) promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens; (iv) criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança; (v) coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de barragens pelos governos; (vi) estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; (vii) fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos.

15.10 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS – PNSB

A PNSB se fundamenta nos seguintes princípios: (i) *Princípio da Prevenção*: a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros; a segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais; (ii) *Princípio da Participação*: a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indiretamente, das ações preventivas e emergenciais; (iii) *Princípio da Responsabilidade*: o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la.

15.11 PODER DE POLÍCIA

O Poder de Polícia administrativa sobre as barragens é bastante complexo, sendo da titularidade de diferentes órgãos da administração pública. Desdobrando-se da seguinte forma: (i) entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico; (ii) entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; (iii) entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou temporária de rejeitos; (iv) entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins de disposição de resíduos industriais.

Conforme disposto no artigo 16 da PNSB, o órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a: (i) manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação dos empreendedores, para fins de incorporação ao SNISB; (ii) exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por profissional habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea)/Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, construção, fiscalização e demais relatórios exigidos pela PNSB; (iii) exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança; (iv) articular-se com outros órgãos envolvidos com a implantação e a operação de barragens no âmbito da bacia hidrográfica; (v) exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações relativas à barragem no SNISB.

Cabe ao órgão fiscalizador informar à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) qualquer não conformidade que implique risco imediato à segurança ou qualquer acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdição. Por sua vez, o empreendedor da barragem obriga-se a: (i) prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem; (ii) providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto final como construído; (iii) organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a documentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando couber, à desativação da barragem; (iv) informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança; (v) manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme estabelecido no Plano de Segurança da Barragem; (vi) permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do Sindec ao local da barragem e à sua documentação de segurança; (vii) providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da Barragem, observadas as recomendações das inspeções e as revisões periódicas de segurança; (viii) realizar as inspeções de segurança; (ix) elaborar as revisões periódicas de segurança; (x) elaborar o PAE, quando exigido; (xi) manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência em volume armazenado, bem como das características químicas e físicas do fluido armazenado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador; (xii) manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do reservatório, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador; (xiii) cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB.

15.12 INSTRUMENTOS DA PNSB

A PNSB é dotada dos seguintes instrumentos: (i) sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano potencial associado; (ii) Plano de Segurança de Barragem; (iii) Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); (iv) Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima); (v) Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; (vi) Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; (vii) Relatório de Segurança de Barragens. É importante notar que os itens iv, v, vi e vii também são instrumentos da PNMA. O que denota uma tentativa do legislador em promover a integração da PNSB com a PNMA, o que é saudável. Para o exercício do poder de polícia, a Lei da PNSB prevê uma classificação das barragens segundo o grau de risco de cada uma delas, de acordo com o dano potencial e pelo volume, conforme critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). As categorias de risco são: (i) alto, (ii) médio ou (iii) baixo e é feita conforme as (i) características técnicas, o (ii) estado de conservação do empreendimento e o (iii) atendimento ao Plano de Segurança da Barragem. Para a classificação do grau de risco (dano potencial), a Administração deverá levar em conta o (i) potencial de perdas de vidas humanas e dos (ii) impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.

15.12.1 Plano de Segurança da Barragem

As barragens devem adotar o Plano de Segurança da Barragem, o qual deverá conter: (i) a identificação do empreendedor; (ii) os dados técnicos referentes à

implantação do empreendimento, inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a promulgação da PNSB, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem; (iii) a estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem; (iv) os manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem; (v) regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; (vi) a indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem; (vii) o Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido; (viii) relatórios das inspeções de segurança; (ix) a previsão de revisões periódicas de segurança.

É da atribuição do órgão fiscalizador definir a periodicidade dentro da qual será feita a atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança. Uma vez realizadas as inspeções periódicas da barragem, deverá o empreendedor contemplar as exigências formuladas pelo órgão de fiscalização nas atualizações do Plano de Segurança. Em tal contexto é importante observar que as inspeções de segurança, as quais se dividem em (i) regular e (ii) especial, terão a sua periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem. Cabe à própria equipe de segurança da barragem a realização da inspeção de segurança regular, cujo relatório deverá ficar disponível ao órgão fiscalizador e à sociedade civil. Por sua vez, a inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações das condições a montante e a jusante da barragem, sendo certo que os relatórios das inspeções de segurança deverão indicar as ações a serem adotadas pelo empreendedor com vistas à manutenção da segurança da barragem. Além do mais, deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragem cujo objetivo é a verificação do estado geral de segurança da barragem, considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusante da barragem. A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deverá indicar as ações a serem tomadas pelo empreendedor. Compete ao órgão de fiscalização estabelecer (i) a periodicidade; (ii) a qualificação técnica da equipe responsável; (iii) o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem.

Um dos principais, senão o principal, objetivos da Revisão Periódica de Segurança de Barragem é indicar as ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da barragem, devendo contemplar: (i) o exame de toda a documentação da barragem, em especial dos relatórios de inspeção; (ii) o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo empreendedor; (iii) a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às revisões efetuadas anteriormente.

As barragens classificadas na categoria de dano potencial alto poderão ser exigidas a elaborar PAE, o qual estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, contemplando, no mínimo: (i) a identificação e análise das possíveis situações de emergência; (ii) os procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições potenciais de ruptura da barragem; (iii) os procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; (iv) a estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência. O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil.

15.12.2 Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)

A PNSB, em seu artigo 13, criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), para fins de registro informatizado das condições de segurança de barragens em todo o território nacional. Tal SNISB compreende sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de suas informações sobre barragens em construção, em operação e desativadas. O SNISB é estruturado com base nos seguintes princípios: (i) descentralização da obtenção e produção de dados e informações; (ii) coordenação unificada do sistema; (iii) acesso a dados e informações garantido a toda a sociedade.

A PNSB, em seu artigo 15, deu especial atenção à educação e à comunicação sobre a segurança de barragens, sendo certo que deverá ser estabelecido *programa de educação e de comunicação sobre segurança de barragem*, com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância da segurança de barragens, o qual deverá conter as seguintes medidas: (i) apoio e promoção de ações descentralizadas para conscientização e desenvolvimento de conhecimento sobre segurança de barragens; (ii) elaboração de material didático; (iii) manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens sob sua jurisdição; (iv) promoção de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e associações técnicas relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins; (v) disponibilização anual do Relatório de Segurança de Barragens.

A barragem que não estiver conforme os requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, o qual deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas. A recuperação ou a desativação (descomissionamento) da barragem deverá ser objeto de projeto específico. Nos casos de omissão ou inação do empreendedor, o órgão fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de danos potenciais associados à segurança da barragem, *devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor*.

15.13 SANÇÕES

O artigo 22 da PNSB estabelece que “*o descumprimento dos dispositivos desta Lei sujeita os infratores às penalidades estabelecidas na legislação pertinente*”. Cuida-se de uma cláusula geral a qual expressa uma péssima orientação normativa que, seguidamente, vem sendo adotada na legislação de proteção ao meio ambiente, deixando obscuras as normas aplicáveis. Melhor teria andado o legislador se tivesse estabelecido na própria PNSB as sanções aplicáveis em caso de sua inobservância.

15.14 POLÍTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

15.14.1 A Política Nacional de Irrigação – aspectos gerais

A Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013 instituiu a Política Nacional de Irrigação a ser implementada em todo o território nacional. A referida política é regida pelos seguintes princípios (i) uso e manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à irrigação; (ii) integração com as políticas setoriais de recursos hídricos, de meio ambiente, de energia, de saneamento ambiental, de crédito e seguro rural e seus respectivos planos, com prioridade para projetos cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos; (iii) articulação entre as ações em irrigação das diferentes instâncias e esferas de governo e entre estas e as ações do setor privado; (iv) gestão democrática e participativa dos Projetos Públicos de Irrigação com infraestrutura de irrigação de uso comum, por meio de mecanismos a serem definidos em regulamento e, (v) prevenção de endemias rurais de veiculação hídrica. Cuida-se, portanto, de inserir a irrigação no conjunto das políticas públicas ambientais existentes no País, sendo portanto um elemento a ser considerado no planejamento nacional.

A Política tem por objetivos (i) incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases ambientalmente sustentáveis; (ii) reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas; (iii) promover o desenvolvimento local e regional, com prioridade para as regiões com baixos indicadores sociais e econômicos; (iv) concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; (v) contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para exportação; (vi) capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de tecnologias relacionadas a irrigação; (vii) incentivar projetos privados de irrigação, conforme definição em regulamento.

15.14.2 Licenciamento ambiental

Os projetos de irrigação devem ser submetidos ao licenciamento ambiental que observará as regras de competência aplicáveis em cada caso concreto. Há que se observar, entretanto, que o órgão encarregado do licenciamento deverá indicar “o prazo máximo necessário para deliberação, a partir das datas de recebimento e avaliação prévia dos estudos e informações requeridos, podendo a licença ambiental ser concedida para etapas do projeto de irrigação, conforme os módulos produtivos operacionais”, ou seja, a lei expressamente isenta a obrigatoriedade de licenciamento do projeto como um todo.

O parágrafo segundo do artigo 22 da Lei nº 12.787/2013 admite que as obras de infraestrutura de irrigação, nelas compreendidos os barramentos de cursos d’água que necessitem de intervenção ou supressão em áreas de preservação permanente poderão (*rectius*: serão na hipótese de inexistência de alternativa locacional ou de custo excessivo) ser tidas como de utilidade pública para efeito de licenciamento ambiental, quando declaradas pelo poder público federal essenciais para o desenvolvimento social e econômico. Parece-me que a hipótese de declaração de utilidade pública é, também, da competência de Governadores e Prefeitos se o licenciamento for efetivada por Estados ou Municípios e o projeto conste dos respectivos planos de irrigação, em harmonia com o plano nacional de irrigação, pois admitir-se apenas a competência do Executivo federal é, de fato, burocratizar-se uma ação que, em sua essência, necessita de velocidade.

Os projetos de irrigação deverão observar o sistema de outorga de recursos hídricos que deverá ser concedida por órgão federal, estadual ou distrital, conforme o caso. Assim como no licenciamento ambiental, o órgão responsável pela outorga da utilização dos recursos hídricos deverá indicarão prazo máximo necessário para deliberação, a partir das datas de recebimento e avaliação prévia das informações requeridas.

É importante observar que as instituições integrantes do sistema nacional de crédito rural (Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965) somente financiarão a implantação, a ampliação e o custeio de projetos de irrigação que

15.15 POLUIÇÃO HÍDRICA POR ÓLEOS

A partir da edição da Lei nº 9.478/1997, conhecida como Lei do Petróleo, houve um aumento significativo das atividades petrolíferas e, particularmente, o incremento da atividade *offshore*, ou seja, a exploração e produção de petróleo no mar. Indiscutivelmente, quanto maior o volume de atividades com óleo, maior a possibilidade de que acidentes ocorram. Para que se tenha uma pálida ideia do papel desempenhado pelo petróleo na economia brasileira e, sobretudo, do seu crescente papel, confira-se a informação de Haroldo Lima (2008, p. 27-28):

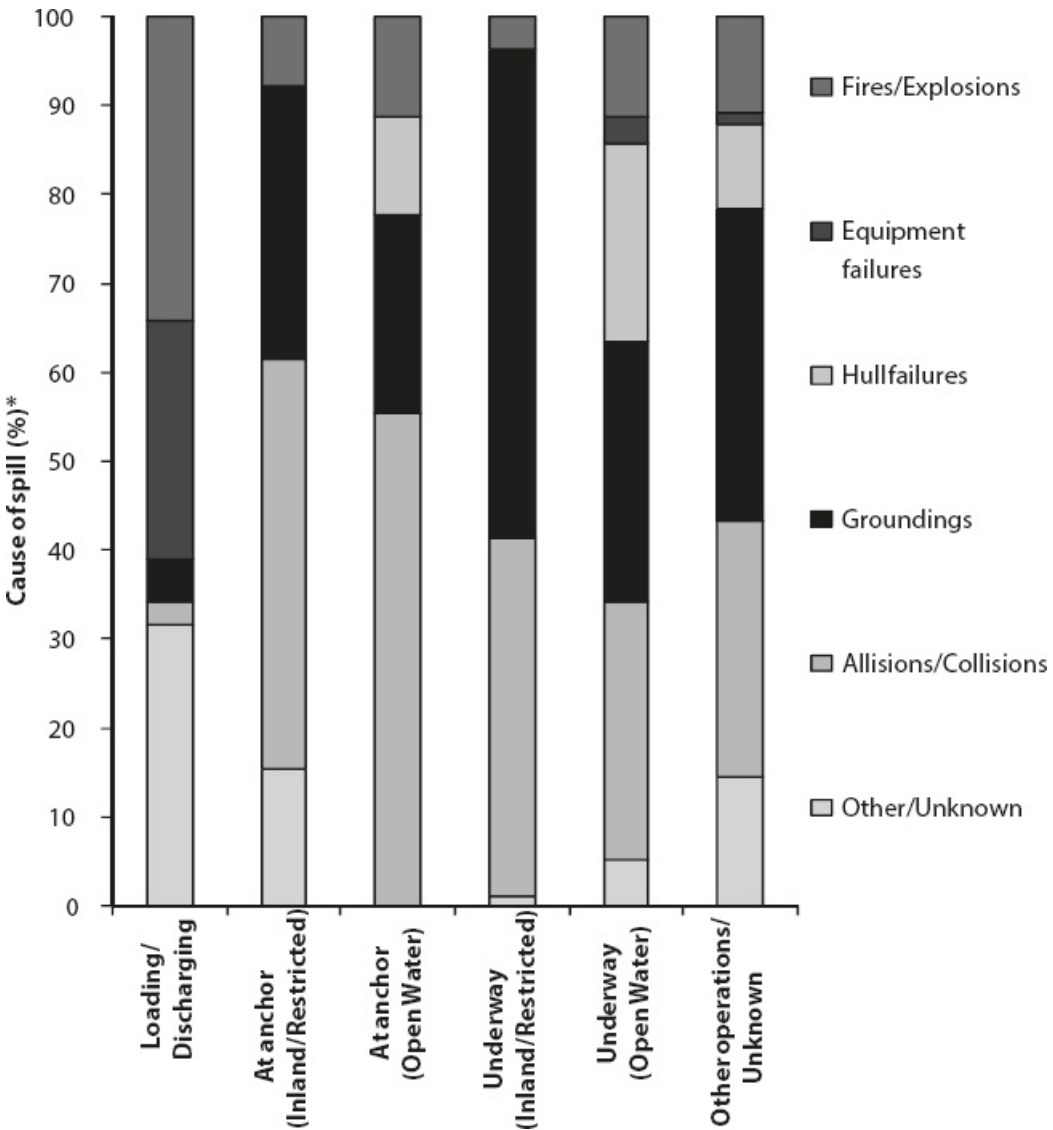
A participação do setor petróleo no PIB brasileiro é acompanhada pela ANP desde 2002. Dados anteriores mostram que, em 1955, pouco depois do surgimento da Petrobras, o setor participava com 0,24% do PIB, em valores referidos a preços de mercado e corrigidos para 2003. Nos anos 60, o valor médio agregado pelo setor ao PIB foi de 2,44%, passando para 2,79% nos anos 70 e 4,2% nos anos 80. A partir de 2002, a ANP passou a estimar a participação do setor petróleo e gás no PIB do país. Para tal foi desenvolvida uma metodologia específica, que resultou em uma evolução de 2,7% para 10,5% entre 1997 e 2005, a preços básicos [...] Para nos fixarmos em período computado a partir do aparecimento da Agência Nacional do Petróleo, constata-se que, entre 1998 e 2004, enquanto o conjunto da economia claudicou, com crescimento de 14,22% em sete anos, o setor petróleo, incluindo a petroquímica, cresceu 318%.

Os números acima mencionados tiveram repercussão direta na produção de petróleo que “entre 1996 e 2006 mais do que dobrou, passando de 252 para 268 milhões de barris/ano”. Certamente, o incremento da atividade petrolífera, sobretudo *offshore*, gera externalidades tais como o aumento da poluição. O quadro abaixo demonstra que os acidentes referentes ao lançamento de petróleo no mar que ocorreram no Brasil podem ser classificados como pequenos ou de baixa relevância.

Quadro – Derramamento de óleo no mar (Brasil)³

Antes da Lei nº 9.478/97	Depois da Lei nº 9.478/97
Março de 1975 – Um cargueiro derrama 6 mil toneladas de óleo na Baía de Guanabara.	18 de janeiro de 2000 – O rompimento de duto que liga a Refinaria Duque de Caxias ao terminal da Ilha d’Água: vazamento de 1,3 milhão de óleo combustível na Baía de Guanabara.
Outubro de 1983 – 3 milhões de litros de óleo vazam de um oleoduto em Bertioga.	11 de março de 2000 – Vazamento de 18 mil litros de óleo cru em Tramandaí (RS).
Agosto de 1984 – vazamento de gás em poço <i>offshore</i> . 37 mortos e 19 feridos.	16 de março de 2000 – Derramamento de 7.250 litros de óleo no canal de São Sebastião (SP).
Maiο de 1994 – 2,7 milhões de litros de óleo em 18 praias do litoral norte paulista.	26 de junho de 2000 – Derramamento de 380 litros de óleo combustível.
10 de março de 1997 – Rompimento de duto entre a Refinaria de Duque de Caxias (RJ) e o terminal DSTE-Ilha: vazamento de 2,8 milhões de óleo combustível em manguezais na Baía de Guanabara (RJ).	Novembro de 2000 – 86 mil litros de óleo vazaram de um cargueiro da Petrobras poluindo praias de São Sebastião e de Ilhabela (SP).
16 de agosto de 1997 – Vazamento de 2 mil litros de óleo combustível atinge cinco praias na Ilha do Governador (RJ).	11 de agosto de 2001 – Vazamento de óleo atinge 30 km de praias do litoral norte baiano.
	15 de agosto de 2001 – Vazamento de 715 litros de petróleo na Baía de Ilha de Grande (RJ).
	5 de outubro de 2001 – Vazamento de 150 litros de óleo em monoboia, a 8 km da costa de São Francisco do Sul (SC).
	18 de outubro de 2001 – Vazamento de 392 mil litros de óleo. Morte de 1 pessoa.
	23 de fevereiro de 2002 – Vazamento de 50 mil litros de óleo combustível no Píer da Praça Mauá (RJ).
	13 de maio de 2002 – Vazamento de 16 mil litros na baía de Ilha Grande (RJ).
	25 de junho de 2002 Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), deixando vazar 15 mil litros óleo
	10 de agosto de 2002 – Vazamento de 3 mil litros de petróleo em São

	Sebastião (SP).
	Novembro de 2004 – Porto de Paranaguá (PR) um milhão de litros de metanol e 5 milhões de litros de óleo combustível vazaram no mar.
	Novembro de 2011 – Bacia de Campos, Macaé (RJ) – vazamento de 3,7 mil barris de petróleo, o equivalente a 588 mil litros de óleo no mar.



*Incidence of spills > 700 tonnes by operation at time of incident and primary cause of spill, 1970-2011. (One bunkering incident occurred in this size category but has not been included in the graph).

No caso do petróleo, diferentes fatores contribuem para que o tema seja bastante discutido e, com segurança, desempenhe um importante papel no imaginário ambiental. De fato, acidentes e incidentes ocorrem diariamente na indústria do petróleo, sobretudo naquela porção da atividade que é exercida no mar. Conforme se verá mais adiante, a grande maioria dos acidentes e incidentes é de pequena monta e não atrai a atenção das cadeias de mídia e, consequentemente, não empolga a opinião pública. Por outro lado, acidentes pontuais com navios petroleiros e dutos atraem a atenção internacional cada vez com mais força; especialmente se tais acidentes ocorrerem em regiões situadas ou próximas a países desenvolvidos. Pode-se afirmar que o acidente com o navio tanque *Torey Cannynon*, em 1967, foi o início das medidas internacionais adotadas contra a poluição marítima. Alvo de diferentes pressões, a atividade petrolífera tem dado margem ao aparecimento de soluções inovadoras para os riscos ambientais dela decorrentes e, principalmente, na elaboração de mecanismos financeiros capazes de garantir indenizações para os afetados por danos por ela causados.

Maiores derramamentos de óleo

Posição	Nome do navio	Ano	Local	Dimensão (toneladas)
1	Atlantic Empress	1979	Costa de Tobago, Índias Ocidentais	287.000
2	ABT Summer	1991	700 milhas náuticas de Angola	260.000
3	Castillo de Bellver	1983	Baía Saldanha, África do Sul	252.000
4	Amoco Cadiz	1978	Costa da Bretanha, França	223.000
5	Haven	1991	Genova, Itália	144.000
6	Odyssey	1988	700 milhas náuticas da Nova Escócia, Canadá	132.000
7	Torrey Canyon	1967	Ilhas Scilly, Reino Unido	119.000

8	Sea Star	1972	Golfo de Omã	115.000
9	Irenes Serenade	1980	Baía Navarino, Grécia	100.000
10	Urquiola	1976	La Coruña, Espana	100.000
11	Hawaiian Patriot	1977	300 milhas náuticas de Honolulu	95.000
12	Independenta	1979	Bósforo, Turquia	95.000
13	Jakob Maersk	1975	Porto, Portugal	88.000
14	Braer	1993	Ilhas Shetland, Reino Unido	85.000
15	Khark 5	1989	120 milhas náuticas da costa atlântica do Marrocos	80.000
16	Aegean Sea	1992	La Coruña, Espanha	74.000
17	Sea Empress	1996	Milford Haven, Reino Unido	72.000
18	Nova	1985	Ilha Kharg, Golfo do Iran	70.000
19	Katina P	1992	Costa de Maputo, Moçambique	66.700
20	Prestige	2002	Costa da Galícia, Espanha	63.000
35	Exxon Valdez	1989	Estreito Príncipe William, Alasca, EUA	37.000

Fonte: <<http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/#major>>. Acesso em: 5 fev. 2012.

O derramamento de óleo provocado pelo navio Torey Cayon, repita-se, em 1967 (ANTUNES, 2012), levou à criação, em 1968, da *International Tanker Owners Pollution Federation* (ITOPF), que reúne os principais proprietários de navios petroleiros. Uma das funções básicas da ITOPF foi gerir um fundo voluntário e transitório estabelecido pelos armadores com a finalidade de assegurar indenizações para os afetados por derramamento de óleo no mar. Tal fundo, denominado Tovalap (*Tankers Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution*), foi, posteriormente, reconstituído e organizado com o nome de Cristal (*Contract Regarding and Interim Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution*). Ambos os fundos foram extintos em 1997.

Os fundos mencionados foram capazes de assegurar indenizações para os prejudicados, de forma que as vítimas não ficassem desamparadas, assim como o meio ambiente. Muitas são as Convenções existentes hoje, destacando-se as 1992 *Civil Liability Convention* (1992 CLC) e a 1992 *Fund Convention* (1992 FC), que entraram em vigor em 30 de maio de 1996. A 1992 CLC estabelece o regime de responsabilidade civil objetiva e determina a existência de seguros compulsórios, levando em consideração a tonelagem da embarcação, para cobrir os danos causados pela atividade. O regime de compensação pela existência de um fundo é bastante interessante, pois assegura mais velocidade para a reparação dos danos e indenização das vítimas. Não se trata, obviamente, de uma solução miraculosa para os graves problemas decorrentes da poluição marinha por óleo, porém das soluções atualmente existentes é a mais eficiente. O quadro abaixo apresenta os valores máximos das compensações pagas pelos mecanismos acima descritos.

Valor Máximo de compensação (CLC e Fund Convention) (Milhões de dólares americanos, dezembro 2011)

Tonelagem Bruta	1969 CLC	1992 CLC (após nov. 2003)	1992 FUND (após nov. 2003)	Fundo suplementar
5.000	1	6,9	311,7	1151,5
25.000	5,1	26,3	311,7	1151,5
50.000	10,2	50,5	311,7	1151,5
100.000	20,4	98,6	311,7	1151,5
140.000	21,5	137,9	311,7	1151,5

Nota: Os limites de responsabilidade sob os vários regimes são baseados em Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Right – SDR). Na Tabela, foi considerada a taxa de 1 SDR = US\$ 1,54 (dezembro, 2011 – Fundo Monetário Internacional).

O Brasil não é parte em nenhuma das duas convenções, limitando-se à condição de observador. O quadro a seguir demonstra as Convenções ratificadas pelo Brasil e as não ratificadas.

Convenções Internacionais (adaptado de PALMA, 2011, p. 143-144)	
Ratificadas	Não ratificadas
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC-1969)	Prevenção da Poluição do Mar por Óleo (Oilpol)
Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol – 1973-78)	Estabelecimento de um Fundo Internacional para Reparação de Danos por Poluição por Óleo (<i>Fund Convention</i>)
Direito do Mar (Unclos)	Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes da Poluição por Óleo, Resultante da Exploração de Recursos Minerais do Subsolo Marinho
Preparo, Resposta e Cooperação em Casos de	
Poluição por Óleo (OPRC – 1990)	

Muito embora o foco primordial do presente trabalho seja o direito interno referente à poluição por óleo, é indiscutível que o Direito Internacional, no particular, exerce uma influência decisiva, pois é imperiosa a necessidade de harmonização de normas, tendo em vista que (i) a circulação do petróleo é internacional; (ii) o mar

é um interesse comum de toda a humanidade; (iii) a poluição marítima não respeita fronteiras políticas. Em função disso, como foi muito bem assinalado por Guido Fernando Silva Soares (2001, p. 120):

Diferentemente das águas doces continentais, os espaços marítimos e oceânicos, mesmo sendo mais extenso o número de tratados e convenções internacionais multilaterais sobre o assunto permitem certa sistematização de suas inúmeras normas, em parte devido à força dos usos e costumes internacionais de há muito aceitos pelos Estados, em particular em termos de Direito Marítimo, que acabou por contaminar o Direito do Mar com seus princípios já estabelecidos (sobretudo em matéria de segurança da navegação e da responsabilidade civil. Por outro lado, as catástrofes dos derramamentos de óleo e suas sequelas sobre importantes setores da sociedade já tinham deixado os Estados alertados sobre sua necessidade urgente de regulamentar a poluição das águas marinhas...).

15.16 A CONVENÇÃO MARPOL

A Convenção Marpol (*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*) é a mais importante convenção internacional voltada para a prevenção e repressão da poluição dos ambientes marinhos, causada por navios. Na verdade, a Marpol é a denominação pela qual ficou conhecida a Convenção de 1973, com a adição do tratado de 1978, a qual possui ainda dois protocolos (1978/1997). Atualmente são seis os anexos, os quais serão brevemente noticiados abaixo.

O organismo internacional responsável pela gestão da Marpol é a IMO (*International Maritime Organization*), integrante do sistema das Nações Unidas. Está incluída entre os elementos regulamentados pela Marpol a poluição decorrente de lançamento de óleo, produtos químicos, substâncias perigosas empacotadas, esgoto e lixo. O Protocolo de 1978 referente à Convenção Internacional de 1973 (Marpol 1978 Protocol) foi aprovado em Conferência sobre a segurança dos petroleiros e Prevenção da Poluição em fevereiro de 1978, realizada como resposta internacional a toda uma série de acidentes com petroleiros ocorridos nos anos 1976/1977. Dado que a Convenção Marpol 1973 ainda não tinha entrado em vigor, o Protocolo Marpol 1978 absorveu a Convenção-mãe, gerando uma norma que é um “somatório” de ambas. A combinação dos documentos é conhecida como Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marinha por Navios, de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978 (Marpol 73/78), cuja entrada em vigor se deu aos 2 de outubro de 1983 (anexos I e II). Em 1997, um novo protocolo foi adotado para adicionar mais um anexo, o anexo VI.

A Convenção possui dispositivos voltados para a minimização e prevenção da poluição causada por navios, seja a acidental, seja a atribuída às operações rotineiras, contando com seis anexos técnicos:

Marpol		
Anexo	Regras	
I	Prevenção da poluição por óleo (entrou em vigor em 2 de outubro de 1983)	
II	Controle da Poluição por substâncias líquidas nocivas transportadas a granel (entrou em vigor em 2 de outubro de 1983)	
III	Prevenção da Poluição por Substâncias Nocivas transportadas por mar em embalagens (que entrou em vigor em 1º de julho de 1992)	
IV	Prevenção da Poluição por esgotos sanitários dos navios (em vigor desde 27 de setembro de 2003)	
V	Prevenção da Poluição por Lixo por Navios (entrou em vigor em 31 de dezembro de 1988)	
VI	Prevenção da Poluição Atmosférica por Navios (entrou em vigor em 19 de maio, 2005)	
Emendas à Marpol		
	Resolução	Entrada em Vigor
Emendas 2010	Resolução MEPC.193(61)	1º/1/2014
	Resolução MEPC.194(61)	1º/2/2012
Emendas 2011	Resolução MEPC.200(62)	1º/1/2013
	Resolução MEPC.201(62)	1º/1/2013
	Resolução MEPC.202(62)	1º/1/2013
	Resolução MEPC.203(62)	1º/1/2013

Fonte: <https://www.ccaimo.mar.mil.br/convencoes_e_codigos/convencoes/prevencao_da_poluicao_marinha/marpol#>.

A Marpol 73/78, consolidada com as emendas que entraram em vigor internacionalmente até 1º/4/2004, incluindo o Protocolo de 1997 (anexo VI), foi aprovada no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 499/09. Para a conclusão do processo de internalização do Protocolo de 1997 falta a sua promulgação por Decreto Presidencial. Emendas à Convenção Marpol em tramitação:

Aguardando sanção de Presidente da República: (a) o Decreto Legislativo nº 499/2009 [Convenção consolidada, seus Protocolos 1978 e 1997 e emendas constantes das Resoluções MEPC.111(50), MEPC.115(51) e MEPC.116(51)]; (b) o Decreto Legislativo nº 985 de 22/12/2009 (emendas constantes das Resoluções MEPC.117(52), MEPC.118(52), MEPC.132(53), MEPC.141(54), MEPC.143(54), MEPC.154(55) e MEPC.164(56)). O Anexo II revisado da Marpol, adotado pela Resolução MEPC.118(52), em sua Regra 6, alterou a classificação e listagem de Substâncias Líquidas Nocivas e de outras substâncias para as categorias X, Y, X e Outras substâncias, em função dos riscos que representam aos recursos marinhos ou à saúde humana. Em função desta alteração, e considerando que a Lei nº 9.966/2000 refere-se em seu artigo 3º à classificação A, B, C e D constante da Regra 3, do Anexo II anterior à revisão, o Comandante da Marinha, pelo Ofício nº 30-709/2009, de 21/12/2009, apresentou ao Ministro de Estado da Defesa uma minuta de projeto de alteração da mencionada Lei.

Enviadas pela CCA-IMO para o MRE: (a) Resolução MEPC.176(58)

– Anexo VI revisado, pelo ofício nº 10-17/EMA, de 8/3/2010; (b) Resolução MEPC.186(59) – Emendas ao Anexo I, pelo Ofício 10-37/EMA, de 8/3/2010; (c) Resolução MEPC.187(59) – Emendas ao Anexo I, pelo Ofício 10-37/EMA, de 8/3/2010.

III) **Em processo de internalização pela Sec-IMO:** (a) Resolução MEPC.189(60); emendas ao Anexo I (b) Resolução MEPC.190(60); emendas ao Anexo VI (c) Resolução MEPC.193(61); emendas ao Anexo III (d) Resolução MEPC.194(61); emendas ao Anexo VI (e) Resolução MEPC.200(62); emendas ao Anexo IV (f) Resolução MEPC.201(62); emendas ao Anexo V (g) Resolução MEPC.202(62); emendas ao Anexo VI (h) Resolução MEPC.203(62); emendas ao Anexo VI.

15.16.1 Conteúdo dos Anexos

O Anexo I diz respeito à prevenção da poluição por óleo originada (i) por rotinas operacionais ou (ii) por descargas acidentais; desde 1992, é obrigatório que os navios petroleiros novos possuam casco duplo, adotando-se prazo para que os navios que estivessem em uso passassem a adotar os cascos duplos. Houve revisão em 2001 e 2003.

O Anexo II estabelece os critérios e as medidas a serem adotadas para o controle da poluição causada por substâncias líquidas nocivas transportadas a granel. Houve a avaliação de aproximadamente 250 substâncias para a inclusão na lista anexa à Convenção. Somente se admite descarga de resíduos de instalações de recepção, observadas concentrações e condições, as quais variam de acordo com a categoria de substâncias lançadas. De qualquer forma, há que se observar a distância de 12 milhas marítimas da costa mais próxima.

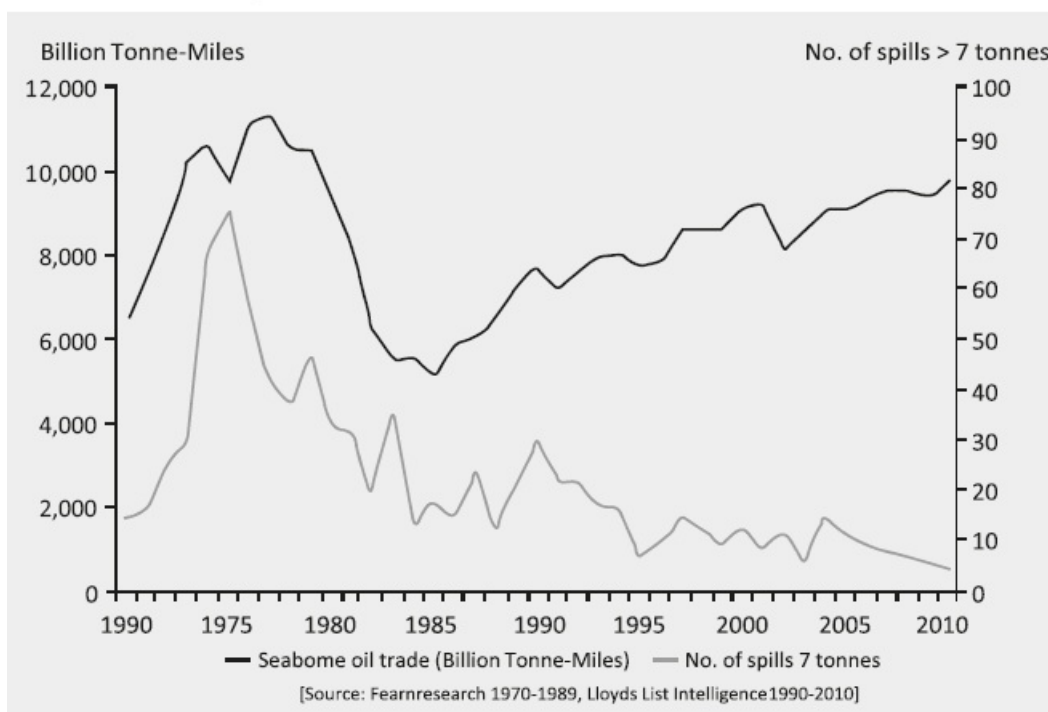
No Anexo III estão contemplados os requisitos gerais para a edição de normas detalhadas sobre embalagem, marcação, rotulagem, documentação, estiva, limitações de quantidade, exceções e notificações com vistas a evitar a poluição por substâncias nocivas.

Os requisitos para controlar a poluição do mar por lançamento de efluentes sanitários estão relacionados no Anexo IV; já o anexo V cuida dos diversos tipos de lixo, fixando as distâncias da terra, bem como a forma pelo qual eles podem ser eliminados. Os requisitos variam dependendo da fragilidade da área marítima. É relevante notar a proibição de *dumping* de plásticos no mar.

O Anexo VI está inserido no contexto de prevenção das mudanças climáticas globais, sobretudo o “aquecimento global”. Pelo Anexo VI são estabelecidos limites para a emissão de Nox e Sox por navios, bem como foi proibida a emissão de elementos que contribuam para a depleção da camada de ozônio.

Em 2011, a IMO adotou medidas obrigatórias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) gerados pelo transporte marítimo internacional, com um novo capítulo adicionado ao Anexo VI. Os navios, após 1º de janeiro de 2013 deverão adotar mecanismos e procedimentos de eficiência energética.

Transporte Marítimo de Petróleo × Derramamentos



15.17 A LEI Nº 9.966, DE 28 DE ABRIL DE 2000

15.17.1 Objetivos e definições da lei

A Lei nº 9.966/2000, “estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional”, aplicando-se (i) nas hipóteses em que “ausentes os pressupostos para aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol 73/78)”, (ii) “às embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias, dutos, plataformas e suas instalações de apoio, em caráter complementar à Marpol 73/78”; bem como (iii) “às embarcações, plataformas e instalações de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou não de país contratante da Marpol 73/78, quando em águas sob jurisdição nacional”; e, por fim, (iv) “às instalações portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares.”

O primeiro ponto que se destaca na análise do campo de aplicação da Lei nº 9.966/2000 é que ela tem como um dos objetivos cobrir as lacunas em relação à aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição por Navios (Marpol). Na verdade, a lei nacional é consistente com a Marpol e, na prática, é a incorporação ao direito interno do contido na norma internacional.

15.17.1.1 Glossário da Lei nº 9.966/2000

A lei estabeleceu um glossário, em seu artigo 2º, no qual constam as definições de diferentes termos que são por ela utilizados frequentemente. Observe-se que vários dos termos que serão abaixo transcritos também são definidos por outras leis e normas jurídicas; por conseguinte, os termos abaixo deverão ser, para a aplicação da Lei nº 9.966/2000, compreendidos pelo intérprete tal como definidos pelo glossário, salvo se do contexto resultar significado diferente.

Marpol 73/78: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de novembro de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, e emendas posteriores, ratificadas pelo Brasil;

CLC/69: Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969, ratificada pelo Brasil;

OPRC/90: Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, de 1990, ratificada pelo Brasil;

Áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou interiores, definidas por ato do Poder Público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação do meio ambiente, *com relação à passagem de navios*;

Navio: embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, inclusive hidrofólios, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros engenhos flutuantes;

Plataformas: instalação ou estrutura, fixa ou móvel, localizada em águas sob jurisdição nacional, destinada a atividade direta ou indiretamente relacionada com a pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar, da plataforma continental ou de seu subsolo;

Instalações de apoio: quaisquer instalações ou equipamentos de apoio à execução das atividades das plataformas ou instalações portuárias de movimentação de cargas a granel, tais como dutos, monoboias, quadro de boias para amarração de navios e outras;

Óleo: qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados;

Mistura oleosa: mistura de água e óleo, em qualquer proporção;

Substância nociva ou perigosa: qualquer substância que, se descarregada nas águas, é capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno;

Descarga: qualquer despejo, escape, derrame, vazamento, esvaziamento, lançamento para fora ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigosas, em qualquer quantidade, a partir de um navio, porto organizado, instalação portuária, duto, plataforma ou suas instalações de apoio;

Porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária;

Instalação portuária ou terminal: instalação explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto organizado, utilizada na movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;

Incidente: qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação intencional ou acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana;

Lixo: todo tipo de sobra de víveres e resíduos resultantes de faxinas e trabalhos rotineiros nos navios, portos organizados, instalações portuárias, plataformas e suas instalações de apoio;

Alijamento: todo despejo deliberado de resíduos e outras substâncias efetuado por embarcações, plataformas, aeronaves e outras instalações, inclusive seu afundamento intencional em águas sob jurisdição nacional;

Lastro limpo: água de lastro contida em um tanque que, desde que transportou óleo pela última vez, foi submetido a limpeza em nível tal que, se esse lastro fosse descarregado pelo navio parado em águas limpas e tranquilas, em dia claro, não produziria traços visíveis de óleo na superfície da água ou no litoral adjacente, nem produziria borra ou emulsão sob a superfície da água ou sobre o litoral adjacente;

Tanque de resíduos: qualquer tanque destinado especificamente a depósito provisório dos líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras misturas e resíduos;

Plano de emergência: conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas;

Plano de contingência: conjunto de procedimentos e ações que visam à integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate da poluição das águas;

Órgão ambiental ou órgão de meio ambiente: órgão do poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sinama), responsável pela fiscalização, o controle e proteção ao meio ambiente no âmbito de suas competências;

Autoridade marítima: autoridade exercida diretamente pelo Comandante da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio, além de outros cometimentos a ela conferidos;

Autoridade portuária: autoridade responsável pela administração do porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;

Órgão regulador da indústria do petróleo: órgão do poder executivo federal, responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas da indústria do petróleo, sendo tais atribuições exercidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A lei, em função do princípio da soberania dos Estados, aplica-se, em princípio, somente nas áreas submetidas ao poder de império do Estado brasileiro. Também nesse particular, a Lei nº 9.966/2000 adotou uma definição das águas cuja higidez é tutelada pela Lei que foram divididas em grandes grupos: (i) águas interiores e (ii) água marítimas. As (i) águas interiores são (a) as compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial; (b) as dos portos; (c) as das baías; (d) as dos rios e de suas desembocaduras; (e) as dos lagos, das lagoas e dos canais; (f) as dos arquipélagos; (g) as águas entre os baixios a descoberta e a costa. Por sua vez, as águas marítimas, são todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam interiores. Como se pode perceber sem grande esforço, a Lei nº 9.966/2000 não se dirige apenas ao combate da poluição por óleo causada nas águas marítimas, *mas nas águas sob jurisdição nacional*. Assim, *ausentes os pressupostos para aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol 73/78)*”, (ii) “às embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias, dutos, plataformas e suas instalações de apoio, em caráter complementar à Marpol 73/78”; bem como (iii) “às embarcações, plataformas e instalações de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou não de país contratante da Marpol 73/78, quando em águas sob jurisdição nacional”; e, por fim, (iv) “às instalações portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, e aos estaleiros, marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares.”, mesmo que em água doce, aplicáveis as normas da lei ora examinada.

O quadro a seguir mostra a relação entre as diferentes águas sob jurisdição nacional.

Lei nº 9.966/2000	Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993
I – águas interiores;	Mar territorial brasileiro: faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil.
a) as compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial;	Nos locais em que a costa apresente recorte profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de base retas, ligando pontos apropriados, para o traçado da linha de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial.
b) as dos portos;	A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo.
c) as das baías;	A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às vinte e
d) as dos rios e de suas desembocaduras;	
e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;	
f) as dos arquipélagos;	

g) as águas entre os baixios a descoberta e a costa;	quatro milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial.
II – águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam interiores.	Na zona contígua, o Brasil poderá tomar as medidas de fiscalização necessárias para: (i) evitar as infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, no seu território, ou no seu mar territorial; (ii) reprimir as infrações às leis e aos regulamentos, no seu território ou no seu mar territorial. A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos. Art. 8º Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marítimo, bem como a construção, operação e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. Parágrafo único. A investigação científica marinha na zona econômica exclusiva só poderá ser conduzida por outros Estados com o consentimento prévio do Governo brasileiro, nos termos da legislação em vigor que regula a matéria. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. O limite exterior da plataforma continental será fixado de conformidade com os critérios estabelecidos no art. 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, celebrada em Montego Bay, em 10 de dezembro de 1982. Art. 12. O Brasil exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental, para efeitos de exploração dos recursos naturais. Parágrafo único. Os recursos naturais a que se refere o <i>caput</i> são os recursos minerais e outros não vivos do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, àquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo, ou que só podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo. Art. 13. Na plataforma continental, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marinho, bem como a construção, operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. § 1º A investigação científica marinha, na plataforma continental, só poderá ser conduzida por outros Estados com o consentimento prévio do Governo brasileiro, nos termos da legislação em vigor que regula a matéria. § 2º O Governo brasileiro tem o direito exclusivo de autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma continental, quaisquer que sejam os seus fins.

O Mar Territorial confunde-se com o conceito de águas marítimas, dele excluindo-se as águas interiores, mesmo que não sejam doces. Este é um conceito fundamental para o estudo, por exemplo, das competências para o licenciamento ambiental.

15.17.2 Classificação das substâncias quanto ao perigo ou nocividade

A Lei determina que o órgão federal de meio ambiente, no caso o Ibama, deverá divulgar e manter atualizada a lista de substâncias classificadas conforme o disposto no artigo 4º, sendo certo que ela deverá ser “*no mínimo, tão completa e rigorosa quanto a estabelecida pela Marpol 73/78*”. A classificação diz respeito aos riscos produzidos quando as substâncias são descarregadas na água.

Classificação quanto ao perigo ou nocividade	
Categoria A	alto risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático;
Categoria B	médio risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático;

Categoria C	risco moderado tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático;
Categoria D	baixo risco tanto para a saúde humana como para o ecossistema aquático.

O tema merece atenção, pois a norma e a relação de substâncias nocivas e perigosas estabelecem uma presunção relativa quanto ao nível de risco causado pelo seu lançamento. Uma vez ocorrido o lançamento e estabelecida a presunção, ocorre como consequência jurídica a inversão do ônus da prova. Assim, fundamental para que existam as definições mencionadas na lei, bem como que a aplicação de qualquer penalidade referente ao lançamento de óleo em águas jurisdicionais brasileiras seja precedida de laudo pericial capaz de identificar a substância lançada às águas, conforme o grau de risco e periculosidade administrativamente definido, sem o que a aplicação de penalidade terá desatendido aos ditames da legalidade.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, mediante a edição da IN nº 6, de 6 de julho de 2011 baixou, em seu Anexo, a lista de substâncias nocivas e perigosas.

Importante observar que, na forma do disposto na Portaria nº 24, de 4 de abril de 2007 do Ibama, foi autorizado o credenciamento da Marinha do Brasil, por meio de suas organizações militares subordinadas – Diretoria de Portos e Costas (DPC) e Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), para “emissão de laudos técnicos ambientais nos incidentes de derramamento de óleos e derivados em águas sob jurisdição nacional, nos termos das sanções especificadas no Decreto nº 4.136, de 2002”. Curiosamente, o Parágrafo único do artigo 1º da Portaria afirma que: *O credenciamento consiste na autorização à DPC e ao IEAPM para a elaboração dos laudos técnicos ambientais, dentro das competências da Autoridade Marítima para aplicação de penalidades descritas no Decreto nº 4.136, de 2002.*

Parece mais do que óbvio que se a autorização ocorre “dentro das competências da autoridade marítima”, ela é inteiramente desnecessária, só se explicando por resistência corporativa do Ibama em reconhecer as atribuições da autoridade marítima no particular.

AIN nº 6/2011 do Ibama tem sido criticada;

Causa espanto observar que somente para 12 das quase duas centenas de substâncias apresentadas na IN-6-Ibama são indicadas as concentrações residuais e, assim mesmo, adota-se um mesmo valor para todas elas, de 0,1% m/m, para locais fora de áreas ecologicamente sensíveis, e de 0,05% m/m, para locais dentro de áreas ecologicamente sensíveis, independentemente da toxicidade que apresentam ou até mesmo sem levar em consideração se as substâncias são solúveis nestas concentrações, o que torna a instrução um documento inócuo. Entre as 12 substâncias destacadas, citam-se: (a) creosoto, uma mistura complexa praticamente insolúvel em água, usada para preservação de madeira, considerada um óleo carcinogênico; (b) naftaleno: insolúvel em água; (c) tetraetilchumbo: praticamente insolúvel em água, substância extremamente venenosa. Nenhuma das três substâncias destacadas, como exemplos, conseguem atingir os limites máximos de concentração estabelecidos na IN-6-IBAMA, o que faz dela um documento inócuo, pois nunca haverá transgressão legal nestes casos. Além do mais, para as outras substâncias sequer são estabelecidos tais limites máximos...⁴

15.17.2.1 Sistemas de prevenção, controle e combate da poluição

Não se admite mais que as atividades utilizadoras de recursos ambientais, notadamente os hídricos, não tenham planos, projetos, equipamentos e pessoal especializados voltados para a prevenção, o controle e o combate da poluição. Na verdade, segundo a disciplina estabelecida pelo artigo 5º da Lei nº 9.966/2000, “todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição, observadas as normas e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente”. Como matéria submetida ao poder de polícia do Estado, cabe ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento do porto organizado, instalação portuária e plataforma e suas instalações de apoio definir as características das aludidas instalações e meios destinados ao recebimento e tratamento de resíduos e ao combate da poluição. Este procedimento deve ser feito durante o licenciamento ambiental, considerando-se as fases que estão sendo submetidas ao procedimento de licenciamento ambiental, devendo ser embasado em estudo técnico, que, na forma da lei, deverá estabelecer, no mínimo: (i) as dimensões das instalações; (ii) a localização apropriada das instalações; (iii) a capacidade das instalações de recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos, padrões de qualidade e locais de descarga de seus efluentes; (iv) os parâmetros e a metodologia de controle operacional; (v) a quantidade e o tipo de equipamentos, materiais e meios de transporte destinados a atender situações emergenciais de poluição; (vi) a quantidade e a qualificação do pessoal a ser empregado; (vii) o cronograma de implantação e o início de operação das instalações. A norma legal estabelece alguns parâmetros a serem observados pelo estudo técnico, a saber: (i) o porte, (ii) o tipo de carga manuseada ou movimentada e (iii) outras características do porto organizado, instalação portuária ou plataforma e suas instalações de apoio.

O legislador, ainda que com excesso de zelo, buscou evitar que a autoridade licenciante abrandasse o limite do estudo técnico, como forma de burlar a proteção ambiental, gerando limites muito fluidos para o licenciamento.

O legislador, no § 3º do artigo 5º, atribui à discricionariedade administrativa dos órgãos ambientais que, no caso de “instalações ou meios destinados ao recebimento e tratamento de resíduos e ao combate da poluição” poderão exigir “das instalações portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, bem como dos estaleiros, marinas, clubes náuticos e similares” as medidas de proteção adequadas, mediante a implantação de sistemas de prevenção, controle e combate da poluição. Contudo, do meu ponto de vista, não se cuida de hipótese discricionária, pois a CF determina que a Administração bem como o particular devem contribuir para a proteção ambiental. Parece-me bastante claro que todas as atividades que possam, comprovadamente, contribuir para a poluição do mar, devem ser dotadas dos mecanismos capazes de evitar ou minimizar os riscos causados, na exata medida de sua dimensão, conforme definido pelo licenciamento ambiental.

As medidas de prevenção, controle e combate da poluição devem estar organizadas e disponíveis sob a forma de manual de procedimentos internos para o gerenciamento de riscos da poluição, bem como para a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas, o qual deverá ser aprovado pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento da atividade, em conformidade com a legislação, normas e diretrizes técnicas vigentes, sendo a sua elaboração responsabilidade das entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias, proprietários ou operadores de plataformas.

15.17.2.1.1 Os planos de emergência

Uma vez ocorrida a poluição, o que resta a fazer é tentar minimizar-lhe os efeitos. É para a ação em tais contextos de acidente que a norma prevê a existência dos planos de emergências individuais que são obrigatórios para os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como suas instalações de apoio. Os planos de emergência, elaborados pelo exercente da atividade de risco, ou por terceiro a seu mando, devem ser aprovados, do ponto de vista ambiental, pelo órgão responsável pelo procedimento de licenciamento ambiental.

O plano de emergência individual não deve ser entendido como um plano a ser implementado por uma única empresa responsável por atividades que possam ter efeitos nocivos sobre o ambiente marinho. Se assim fosse, dadas as dimensões de portos organizados, instalações portuárias e plataformas, a dificuldade de coordenação entre os diversos planos de emergência individual seria praticamente insuperável. Com o fito de evitar o desperdício de esforços, a descoordenação e, na prática, a inaplicabilidade dos planos de emergência, determina a lei que “no caso de áreas onde se concentrem portos organizados, instalações portuárias ou plataformas, os planos de emergência individuais serão consolidados na forma de um único plano de emergência para toda a área sujeita ao risco de poluição, o qual deverá estabelecer os mecanismos de ação conjunta a serem implementados”, observado o disposto nesta Lei e nas demais normas e diretrizes vigentes.

A Lei, no § 2º do artigo 7º, determina que “a responsabilidade pela consolidação dos planos de emergência individuais em um único plano de emergência para a

área envolvida cabe às entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias, e aos proprietários ou operadores de plataformas, sob a coordenação do órgão ambiental competente” (rectius: licenciante). Quando se tratar de planos de emergências individuais para atividades ou áreas de grande porte, o órgão ambiental fará a consolidação sob a forma de planos de contingência locais ou regionais, em articulação com os órgãos de defesa civil. Cabe ao órgão federal de controle ambiental, no caso o Ibama, consolidar os planos de contingência locais e regionais, na forma de um Plano Nacional de Contingência, articulando-se com a defesa civil, observado o disposto na *Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em caso de Poluição por Óleo, assinada em Londres em 30 de novembro de 1990*, promulgada pelo Decreto nº 2.870/1998.

15.17.2.1.2 Auditorias

As auditorias independentes e bianuais deverão ser realizadas pelas entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e os proprietários ou operadores de plataformas e suas instalações de apoio, com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental em suas unidades, sob pena de imposição de multa, conforme disposto no artigo 25, II da Lei. É importante consignar que o STF entendeu perfeitamente constitucional a exigência de auditorias ambientais periódicas, como dá mostra a seguinte decisão.

O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – Medida Liminar – Lei Estadual que instituiu auditoria ambiental compulsória – Diploma que, em primeira análise, coaduna-se com o sistema constitucional de proteção do meio ambiente equilibrado – Plausibilidade – Ausência – Grande lapso temporal entre a edição do ato e a propositura da ação – Urgência não caracterizada – Insurgência meramente quanto à interesses subjetivos dos associados da entidade autora – Caráter objetivo do controle de constitucionalidade abstrato – Circunstâncias que não afetam o julgamento da ação direta – Indeferimento da liminar” (fl. 307). Tem-se no voto condutor do julgado recorrido: “Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão de liminar, indefere-se o pedido, devendo o feito prosseguir ao fim de requisitarem-se as informações necessárias à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná” (fl. 315). 3. No recurso extraordinário, a Agravante afirma que o Tribunal a quo teria contrariado o art. 24, inc. XI, da Constituição da República. 4. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal (fls. 491-492). Apreciada a matéria trazida na espécie, **Decido**. 5. Razão jurídica não assiste à Agravante. 6. As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito da controvérsia, devem ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela sentença que julgar o mérito da causa, podendo, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu. Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não viabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares. [...] 7. Incide na espécie vertente a Súmula nº 735 do Supremo Tribunal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 8. Nada há a prover quanto às alegações da Agravante. 9. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, *caput*, do CPC/73 e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF) (AI 736734/PR. Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 27/3/2011, *DJe*-067).

15.17.3 Descarga em águas jurisdicionais nacionais de óleo, substâncias nocivas ou perigosas e lixo

Os artigos 15 e ss. da Lei nº 9.966/2000 estabelecem uma proibição genérica de descarga em águas sob a jurisdição nacional das substâncias classificadas conforme o artigo 4º, criando exceções específicas.

A proibição de descarga de substâncias nocivas ou perigosas classificadas na categoria “A”, mesmo daquelas provisoriamente assim classificadas como tal, além de água de lastro, resíduos de lavagem de tanques ou outras misturas que contenham tais substâncias. A descarga da água subsequentemente adicionada ao tanque lavado em quantidade superior a cinco por cento do seu volume total somente será admitida se atendidas cumulativamente as seguintes condições: (i) a situação em que ocorrer o lançamento enquadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73/78; (ii) o navio não se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensível; (iii) os procedimentos para descarga sejam devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente. É proibido descarregar água subsequentemente adicionada ao tanque lavado em quantidade inferior a cinco por cento do seu volume total.

No que tange à descarga, em águas sob jurisdição nacional, de substâncias classificadas nas categorias “B”, “C”, e “D”, mesmo aquelas provisoriamente assim classificadas, além de água de lastro, resíduos de lavagem de tanques e outras misturas que as contenham, há proibição, salvo se observado, cumulativamente, o seguinte: (i) a situação em que ocorrer o lançamento enquadre-se nos casos permitidos pela Marpol 73/78; (ii) o navio não se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensível; (iii) os procedimentos para descarga sejam devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente. Para efeito de descarga, os efluentes de esgotos sanitários e águas servidas de navios, plataformas e suas instalações de apoio são equiparáveis às substâncias incluídas na categoria “C” e deverão observar, também, as condições e os regulamentos de vigilância sanitária.

Com exceção das situações permitidas pela Marpol 73/78, **é proibida a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em águas sob jurisdição nacional**, desde que o navio, plataforma ou similar não se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensível, devendo os procedimentos para descarga ser devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente. A água de processo, que seja continuamente descartada, será regida pelas normas de controle ambiental vigentes ao tempo do descarte. Os plásticos, de qualquer tipo, inclusive cabos sintéticos, redes sintéticas de pesca e sacos plásticos estão proibidos de ser descarregados ou descartados em águas jurisdicionais nacionais.

A descarga de lixo, água de lastro, resíduos de lavagem de tanques e porões ou outras misturas que contenham óleo ou substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria só poderá ser efetuada em instalações de recebimento e tratamento de resíduos, conforme previsto no art. 5º da Lei, salvo nos casos expressamente previstos na Lei nº 9.966/2000. Admite-se, contudo, que a descarga de óleo, misturas oleosas, substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria, e lixo, em águas sob jurisdição nacional, possa ser excepcionalmente tolerada com vistas a salvaguarda de vidas humanas, pesquisa ou segurança de navio, tal como definido em regulamento.

Na hipótese de realização de pesquisa, é necessário que se observe o seguinte: (i) a descarga seja autorizada pelo órgão ambiental competente, após análise e aprovação do programa de pesquisa; (ii) esteja presente, no local e hora da descarga, pelo menos um representante do órgão ambiental que a houver autorizado; (iii) o responsável pela descarga coloque à disposição, no local e hora em que ela ocorrer, pessoal especializado, equipamentos e materiais de eficiência comprovada na contenção e eliminação dos efeitos esperados.

A descarga de resíduos sólidos das operações de perfuração de poços de petróleo será objeto de regulamentação específica pelo órgão federal de meio ambiente.

15.17.3.1 Ressarcimento de custos de combate à poluição

A sociedade não deve arcar com os custos do combate à poluição, sob pena de que poluir se torne economicamente lucrativo; desta forma, determina o princípio do poluidor pagador – claramente incorporado no artigo 23 da Lei nº 9.966/2000 – que o responsável pela poluição arque com os custos da limpeza. Observe-se que aqui não se cuida de responsabilidade, pois não se está tratando da aplicação de multas ou outras penalidades. Assim, determina o artigo 23:

A entidade exploradora de porto organizado ou de instalação portuária, o proprietário ou operador de plataforma ou de navio, e o concessionário ou empresa autorizada a exercer atividade pertinente à indústria do petróleo, responsáveis pela descarga de material poluente em águas sob jurisdição nacional, são obrigados a ressarcir os órgãos competentes pelas despesas por eles efetuadas para o controle ou minimização da poluição causada, independentemente de prévia autorização e de pagamento de multa.

As operações de combate à poluição, bem como o recolhimento de óleo descarregado, resgate de animais e tantas outras atividades que normalmente ocorrem em vazamentos de óleo, dadas as dimensões e urgência, implicam o envolvimento de várias partes e, consequentemente, custos. As partes privadas que, por convocação da autoridade pública, participarem das Ações de combate à poluição devem ter os seus custos ressarcidos pelo responsável pela descarga, na condição de terceiros prejudicados, tal como disposto no § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/1981.

A obrigação de ressarcimento dos custos relativos ao combate à poluição tem sido reconhecida por nossas cortes judiciais há bastante tempo: “*Dano ecológico. Reparação. Rompimento de duto. Poluição ambiental. Artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/1981. Cobrança das despesas feitas pela Companhia de Saneamento. Procedência. É o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros por sua atividade. Tendo a Companhia de Saneamento, encarregada de zelar pelo meio ambiente e guardiã de um interesse difuso da comunidade, tomado as medidas necessárias para o combate à poluição ocasionada pelo rompimento de um duto, deve ser ressarcida, como terceira das despesas correspondentes*” (STJ. REsp 20401. Ministro Hélio Mosimann. 2ª Turma. Decisão: 10/12/1993).

O parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 9.966/2000 estabeleceu um direito de retenção nos casos em que a descarga tenha origem em navio que ano possua o certificado exigido pela CLC/69; em tais hipóteses, a liberação do navio somente ocorrerá após a oferta de caução idônea para cobrir o “*pagamento das despesas decorrentes da poluição*”. A propósito, veja-se: “*Ação civil pública. Transbordo e liberação de mistura ácida em navio. Danos ambientais. Medidas de precaução. – Determinados o transbordo e a liberação de mistura ácida – transportada pelo navio Bahamas – para águas internacionais, além da prestação de caução, capaz de suportar a operação, a fim de afastar perigo ambiental decorrente de vazamento da referida substância em águas territoriais, brasileiras*”. (TRF da 4ª Região. Apelação Cível 200304010474378. Desembargador Federal Edgard Antônio Lippmann Júnior. 4ª Turma. DJU 27/7/2005, p. 714).

15.17.4 Poder de polícia em matéria de poluição por óleo

A definição normativa de poder de polícia é aquela contida no artigo 78 do CTN que o define como a “*atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos*”, sendo exercido regularmente quando “*desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder*”. A proteção do meio ambiente e o exercício de atividades econômicas no mar são altamente fiscalizados e, portanto, submetidos ao poder de polícia do Estado brasileiro. O poder de polícia sobre o meio ambiente, como se sabe, é atividade administrativa e, portanto, integrante da competência comum estabelecida pela CF em seu artigo 23. O artigo 23 de nossa CF foi regulamentado pela LC nº 140/2011 que “*fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da CF, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981*”. Em tal texto legal, atribui-se ampla competência à União em matéria de poluição marítima.

15.17.4.1 Repartição das atribuições de polícia

O artigo 27 da Lei de combate à poluição por óleo estabelece a repartição das atribuições dos diferentes órgãos da Administração Pública, seja da federal, seja da estadual no que diz respeito à implementação das normas de combate à poluição marinha por óleo:

Autoridade Marítima	Ibama	OEMA	OMMA	ANP
a) fiscalizar navios, plataformas e suas instalações de apoio, e as cargas embarcadas, de natureza nociva ou perigosa, autuando os infratores na esfera de sua competência;	a) realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos organizados, das instalações portuárias, das cargas movimentadas, de natureza nociva ou perigosa, e das plataformas e suas instalações de apoio, quanto às exigências previstas no licenciamento ambiental, autuando os infratores na esfera de sua competência;	a) realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos organizados, instalações portuárias, estaleiros, navios, plataformas e suas instalações de apoio, avaliar os danos ambientais causados por incidentes ocorridos nessas unidades e elaborar relatório circunstanciado, encaminhando-o ao órgão federal de meio ambiente;	a) avaliar os danos ambientais causados por incidentes nas marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações similares, e elaborar relatório circunstanciado, encaminhando-o ao órgão estadual de meio ambiente;	a) fiscalizar diretamente, ou mediante convênio, as plataformas e suas instalações de apoio, os dutos e as instalações portuárias, no que diz respeito às atividades de pesquisa, perfuração, produção, tratamento, armazenamento e movimentação de petróleo e seus derivados e gás natural;
b) levantar dados e informações e apurar responsabilidades sobre os incidentes com navios, plataformas e suas instalações de apoio que tenham provocado danos ambientais;		b) dar início, na alçada estadual, aos procedimentos judiciais cabíveis a cada caso;	b) dar início, na alçada municipal, aos procedimentos judiciais cabíveis a cada caso;	b) levantar os dados e informações e apurar responsabilidades sobre incidentes operacionais que, ocorridos em plataformas e suas instalações de apoio, instalações portuárias ou dutos, tenham causado danos ambientais;
c) encaminhar os dados, informações e resultados de apuração de responsabilidades ao órgão federal de meio ambiente, para avaliação dos danos ambientais e início das medidas judiciais cabíveis;	b) avaliar os danos ambientais causados por incidentes nos portos organizados, dutos, instalações portuárias, navios, plataformas e suas instalações de apoio;	c) comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas	c) autuar os infratores na esfera de sua competência.	c) encaminhar os dados, informações e
d) comunicar ao órgão	c) encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório circunstanciado sobre			

regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio, quando atinentes à indústria do petróleo.	os incidentes causadores de dano ambiental para a propositura das medidas judiciais necessárias; d) comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio, quando atinentes à indústria do petróleo.	instalações de apoio, quando atinentes à indústria do petróleo; d) autuar os infratores na esfera de sua competência.		resultados da apuração de responsabilidades ao órgão federal de meio ambiente; d) comunicar à autoridade marítima e ao órgão federal de meio ambiente as irregularidades encontradas durante a fiscalização de instalações portuárias, dutos, plataformas e suas instalações de apoio; e) autuar os infratores na esfera de sua competência.
---	---	--	--	--

Pelo que se pode ver do quadro acima, parece bastante claro que as principais competências para a proteção do meio ambiente marinho, em razão de poluição por óleo, remanesçam com a autoridade naval, dentro de uma linha de coerência com todo um conjunto de normas que rege as relações jurídicas estabelecidas no ambiente marinho. O texto da lei, aliás, é bastante claro ao atribuir à autoridade marítima o dever de “*apurar responsabilidades sobre os incidentes com navios, plataformas e suas instalações de apoio que tenham provocado danos ambientais*”, (artigo 27, I, *b*). Contudo, o que se vê, é que o órgão de controle ambiental, no caso o Ibama, tem se arvorado a competência para multar diversos agentes econômicos em razão de poluição do mar por óleo. Inobstante, a clara determinação legal que atribui ao Ibama, o controle do que foi determinado pelo licenciamento ambiental:

realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos organizados, das instalações portuárias, das cargas movimentadas, de natureza nociva ou perigosa, e das plataformas e suas instalações de apoio, quanto às exigências previstas no licenciamento ambiental, autuando os infratores na esfera de sua competência (art. 27, II, *a*).

É interessante notar que a revogada Lei nº 5.357/1967, que estabelecia “penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras” determinava que:

As embarcações ou terminais marítimos ou fluviais de qualquer natureza, estrangeiros ou nacionais, que lançarem detritos ou óleo nas águas que se encontrem dentro, de uma faixa de 6 (seis) milhas marítimas do litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas e outros tratos de água ficarão sujeitos às seguintes penalidades: (a) as embarcações, à multa de 2% (dois por cento) do maior salário mínimo vigente no território nacional, por tonelada de arqueação ou fração; (b) os terminais marítimos ou fluviais, à multa de 200 (duzentos) vezes o maior salário mínimo vigente no território nacional. Parágrafo único. Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro.

A Lei da PNMA, bem como a criação de diferentes órgãos ambientais e a publicação da Lei nº 9.605/98 fizeram com que matéria que, em meu ponto de vista era bastante clara, passasse por período de questionamentos e incertezas, no que se refere seja a apuração, seja à aplicação de sanções pela poluição do mar por óleo. A este respeito é interessante o exame da ementa do Recurso Especial nº 673765, o qual sintetiza a orientação do STJ quanto à aplicação da Lei nº 5.357/67 após a entrada em vigor da legislação especificamente voltada para a proteção do meio ambiente. Entendeu o Tribunal, pelo voto condutor do Ministro Luiz Fux, hoje Ministro do STF, que “*a competência da Capitania dos Portos não exclui, mas complementa, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente*”. Divirjo da posição adotada pelo STJ, conforme as razões que passo a expor.

A PNMA é uma lei geral cuja principal finalidade é estabelecer um sistema de cooperação administrativa interinstitucional, conhecido como PNMA, com vistas a coordenar as medidas de proteção ambiental, mediante a criação de instrumentos e princípios a serem observados.

15.17.4.1.1 Poder de Polícia da Marinha do Brasil em matéria ambiental

A Marinha do Brasil exerce o poder de polícia nas águas jurisdicionais nacionais mediante a atuação da Capitania dos Portos que, na forma do Decreto Imperial nº 358/1845, poderia ser estabelecida em cada uma das províncias marítimas do Império do Brasil. As primeiras capitânicas dos portos foram efetivamente criadas pelo Decreto nº 447/1846. Quando se trata do exercício do poder de polícia em matéria ambiental, notadamente quando se trata de poluição do mar, existe uma tendência – encontrável inclusive na jurisprudência – de se considerar que o Ibama e os Estados podem exercer o controle ambiental em conjunto com a Marinha do Brasil, em razão de que: “*a competência da Capitania dos Portos não exclui, mas complementa, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente*” (REsp 200401090312, Relator: Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJU 26/9/2005, p. 214).

a) Capitânicas dos Portos: evolução normativa

A atuação da Marinha do Brasil na proteção do meio ambiente marinho é mais do que centenária e não há qualquer norma vigente em nosso ordenamento jurídico que tenha alterado tal circunstância. De fato, como lembrado por Valdir Andrade Santos (2010, p. 33):

A primeira notícia que se tem no Brasil acerca da prevenção e repressão à poluição do meio marinho nos vem do Decreto nº 447, de 19 de maio de 1846 [...] Mandando pôr em execução o Regulamento para as Capitânicas dos Portos. Esse Regulamento, em seu art. 52, assim dispunha: Art. 52. É proibido embarcar, ou desembarcar lastro durante a noite, e igualmente lançá-lo ao mar no mesmo lugar do ancoradouro, e da mesma forma a varredura do porão em ocasião de limpeza; o contraventor no primeiro caso será sujeito a uma multa de cinquenta mil réis e, no segundo, além da multa de cem mil réis a um conto de réis, será preso de um até trinta dias, conforme a gravidade do caso.

Na verdade, o regulamento para as Capitânicas dos Portos aprovado pelo Decreto nº 3.334/1899, continha várias normas que modernamente poderiam ser compreendidas como normas de combate à poluição marinha. As capitânicas dos portos, segundo o Regulamento ora examinado, “*como instituição federal, exercem no domínio marítimo e fluvial da União a jurisdição compatível com a natureza de seus serviços, e dentro dos limites dessa jurisdição independem de quaisquer outras repartições*” (art. 7º) na forma do artigo 16 eram atribuições das capitânicas “*os serviços relativos a polícia marítima, regime e conservação dos portos e rios*

navegáveis... e que fazem o principal objeto da instituição das capitâneas”. Ao longo do Regulamento, podem ser identificados vários artigos cuja boa observância teria repercussões importantes sobre a qualidade ambiental, tais como: artigo 167 (licença para construção de viveiros, cercados ou currais para peixes); artigo 169 (extração de areia das praias e escavações no litoral); artigo 173 (lançamento de entulhos, cinzas, varreduras ou quaisquer imundices nos cais ou praias dos portos, fora dos lugares para isso destinados pelas câmaras municipais, de acordo com as capitâneas); artigo 176 (proibição de lançamento ao mar ou rio, de bordo dos navios ou de quaisquer embarcações de lixo, cinzas, varreduras do porão etc.); artigo 203 (desmanche de navios); artigo 204 (proibição de derretimento de breu ou piche nas lanchas quando do calafate na fabricação de navios); artigo 236 (licença para meter, aliviar ou descarregar lastro); artigo 237 (carga e descarga de pedras, tijolos ou areia para lastro); artigo 238 (lastro durante a noite); artigo 241 (queda de pedras, tijolos, telhas, ladrilhos e outros objetos no mar ou rio); artigo 453 (pesca com explosivos, substâncias tóxicas, eletricidade, aparelhos ou instrumentos destinados à destruição do peixe); artigo 457 (atração de peixes com de fogos, emprego de buzinas, ou turbação de águas com o fim de atordoar os peixes); artigo 462 (proibição de fábricas ou estabelecimentos industriais lançarem efluentes e detritos nocivos nos portos, rios, lagoas). Existiam, também, inúmeras normas sobre a criação de peixe confinado.

Posteriormente, houve aprovação de novo Regulamento da Capitania dos Portos, conforme o Decreto nº 3.929/1901. Do ponto de vista do nosso estudo, não foram trazidas alterações significativas em relação às regras anteriormente existentes. Pelo artigo 1º competia à capitania dos portos ter “*a seu cargo a polícia, regime e conservação da costa, portos, rios e lagoas navegáveis da República*”, exercendo “*a jurisdição compatível com a natureza de serviços, e dentro dos limites dessa jurisdição independem de quaisquer outras repartições*”. Da mesma forma que no Regulamento revogado, havia várias disposições “ambientais”, como por exemplo: artigo 113 (proibição de obras, aterros e construções sobre o mar, rios navegáveis e seus braços, terrenos de marinha e reservados para servidão pública sem autorização); artigo 121 (proibição de extração de areia das praias e realização de escavações do litoral, interior dos portos e suas enseadas); artigo 125 (proibição de lançamento de entulhos, cinzas, varreduras ou quaisquer imundices nos cais ou praias dos portos, fora dos lugares para isso destinados pelas câmaras municipais, de acordo com as capitâneas); artigo 126 (proibição de depósito de madeiras nas praias, sem licença); artigo 128 (proibição de lançamento ao mar ou rio, de bordo dos navios ou de quaisquer embarcações, de lixo, cinzas, varreduras do porão); artigo 155 (desmanche de navio); artigo 156 (proibição dirigida aos calafates, por ocasião do fabrico dos navios, de acender fogo nas lanchas ou pranchas do calafete, para derreter breu ou piche, sem as terem em distância delas pelo menos o comprimento de uma amarra); artigo 188 (proibição de meter, aliviar ou descarregar lastro sem licença); artigo 190 (proibição de embarque ou desembarque noturno de lastro); artigo 193 (proibição de lançamento de pedras, tijolos, telhas, ladrilhos e outros objetos submersíveis); artigo 400 (proibição de com dinamite ou qualquer outro explosivo, bem como do emprego de substâncias tóxicas, aparelhos ou instrumentos destinados à destruição do peixe); artigo 404 (proibição de pesca mediante a utilização de fogos que atraíam o peixe, emprego de buzinas, ou turvação das águas com o fim de atordoar o peixe); artigo 409 (proibição de que as fábricas ou estabelecimentos industriais despejem nos portos, rios, lagoas etc. os detritos deles provenientes, ainda que não sejam nocivos à conservação do peixe).

Os Regulamentos que sucederam aos acima examinados, em linhas gerais, mantiveram as mesmas normas já apontadas.

b) Capitania dos Portos e poluição por óleo

A mudança do combustível utilizado pela navegação da força dos ventos para o carvão e, posteriormente para o petróleo, repercutiu na legislação referente ao exercício do poder de polícia sobre o mar. Assim, o regulamento das capitâneas dos portos, aprovado pelo Decreto nº 16.197/1923, pela primeira vez, fez uma proibição expressa de lançamento de óleo nos corpos hídricos, como se verá mais abaixo. É importante ressaltar que o regulamento de 1923, em seu artigo 8º, I, claramente mencionava como um dos serviços das capitâneas dos portos “*a conservação da costa, portos, rios e lagoas da República*”. De fato, o artigo 226 do Regulamento de 1923 dispunha que:

Art. 226. É proibido lançar entulhos, cinzas, óleos, varreduras ou quaisquer imundices nos cais ou praias dos portos, fora dos lugares para isso destinados pelas câmaras municipais, de acordo com as capitâneas. Os infratores serão obrigados, além da multa de 100\$, a remover o entulho, se for possível fazê-lo; mas quando não o seja ou se ignore quem praticou o despejo, a Capitania solicitará da municipalidade ou repartição dela dependente para que seja efetuada imediatamente a remoção.

Também no artigo 229 foi tratada a proibição de lançamento de óleo:

Art. 229. É proibido lançar nos portos, canais, rios ou qualquer ancoradouro, lixo, cinzas, óleos, objetos lastro ou quaisquer varreduras dos porões. Os infratores pagarão multa de 500\$000 a 5:000\$000 e na reincidência o dobro. Parágrafo único. Toda embarcação que tiver de descarregar cinzas é obrigada a requerer licença à Capitania. Tal licença para as embarcações de longo curso ou de cabotagem, durará o tempo indispensável para o desembarque; e para as embarcações de tráfego do porto será mensal. Se os proprietários das cinzas desejarem depositá-las em lugares por eles indicados, as capitâneas concederão licenças especiais, depois de verificarem que não ocorre algum inconveniente. Neste caso a licença durará todo o exercício findo o qual será renovada, sob pena de 20\$000 a 60\$000 de multa.

Normas semelhantes foram mantidas nas atualizações do Regulamento das Capitâneas dos Portos, tais como aprovadas pelos Decretos nº 17.096/1925; nº 24.288/1934 e nº 220-A/1935. Em sequência ao conjunto de normas acima apontadas, foi editada a Lei nº 5.357/1967 – já mencionada acima – que dispôs especificamente sobre a poluição do mar por óleo que assim determinava:

Art. 1ª As embarcações ou terminais marítimos ou fluviais de qualquer natureza, estrangeiros ou nacionais, que lançarem detritos ou óleo nas águas que se encontrem dentro, de uma faixa de 6 (seis) milhas marítimas do litoral brasileiro, ou nos rios, lagoas e outros tratos de água ficarão sujeitos às seguintes penalidades: (a) as embarcações, à multa de 2% (dois por cento) do maior salário mínimo vigente no território nacional, por tonelada de arqueação ou fração; (b) os terminais marítimos ou fluviais, à multa de 200 (duzentos) vezes o maior salário mínimo vigente no território nacional. Parágrafo único. Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro. Art. 2ª A fiscalização desta Lei fica a cargo da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, em estreita cooperação com os diversos órgãos federais ou estaduais interessados. Art. 3ª A aplicação da penalidade prevista no art. 1ª e a contabilidade da receita dela decorrente far-se-ão de acordo com o estabelecido no Regulamento para as Capitâneas de Portos.

c) Autoridade Marítima e combate à poluição no mar

Até a edição da Lei nº 6.938/1981, não havia a menor dúvida de que competia à Marinha do Brasil o exercício do poder de polícia em matéria de poluição marinha causada por óleo. Tal atribuição foi expressamente mantida pela Lei da PNMA, conforme o § 4º do artigo 14 da redação original da Lei.

Art. 14. [...] § 4ª Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, prevalecer o disposto na Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967.

Autoridade Marítima	
LEI Nº 9.966/2000	LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Art. 2º; XXII – autoridade marítima: autoridade exercida diretamente pelo Comandante da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental	Art. 3º Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta Lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de

causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio, além de outros cometimentos a ela conferidos por esta Lei.	embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio. [...] Art. 39. A autoridade marítima é exercida pelo Ministério da Marinha.
---	--

15.17.5 **Infrações administrativas**

A Lei nº 9.966/2000 em seu artigo 25 e ss. estabeleceu um rol de infrações administrativas atribuindo-lhes sanções específicas. Não me parece que se possa admitir como legal a criação de tipos administrativos por decreto, sobretudo em função de que a **Lei** possui claramente delineadas as condutas que o legislador entendeu deveriam ser tipificadas como infracionais. Observe-se que o artigo 33 da Lei nº 9.966/2000 determina que: “*O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de trezentos e sessenta dias da data de sua publicação*”. Do meu ponto de vista, a regulamentação não pode chegar ao ponto de criar tipos administrativos além daqueles constantes na própria lei. Observe-se que, no caso, a Lei nº 9.966/2000 sequer é dotada de um dispositivo aberto como aquele constante na Lei nº 9.605/98. Contudo, inexplicavelmente, o regulamento baixado pelo Decreto nº 4.136/2002 estabelece em seu artigo 1º que “*constitui infração às regras sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional a inobservância a qualquer preceito constante da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e a instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil*”. Parece-me que o legislador não deixou espaço para que o Executivo “crie” infrações administrativas, vez que a lei estabeleceu, de forma cabal, nos artigos 25 e 26, quais são as infrações administrativas puníveis, deixando ao poder regulamentar a possibilidade de dispor sobre os valores da multa aplicável conforme as circunstâncias concretas. Assim, em princípio, sou de entendimento que as sanções administrativas introduzidas *ex novo* no ordenamento jurídico pelo Decreto nº 4.136/2002 carecem de base legal, ante os termos dos artigos 25, 26 e 33 da Lei nº 9.966/2000.

Art. 25. São infrações, punidas na forma desta Lei:
I – descumprir o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º:
Pena – multa diária;
II – descumprir o disposto nos arts. 9º e 22:
Pena – multa;
III – descumprir o disposto nos arts. 10, 11 e 12:
Pena – multa e retenção do navio até que a situação seja regularizada;
IV – descumprir o disposto no art. 24:
Pena – multa e suspensão imediata das atividades da empresa transportadora em situação irregular.
§ 1º Respondem pelas infrações previstas neste artigo, na medida de sua ação ou omissão:
I – o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o represente;
II – o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou operado pelo proprietário;
III – o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo;
IV – o comandante ou tripulante do navio;
V – a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar;
VI – o proprietário da carga.
§ 2º O valor da multa de que trata este artigo será fixado no regulamento desta Lei, sendo o mínimo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
§ 3º A aplicação das penas previstas neste artigo não isenta o agente de outras sanções administrativas e penais previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em outras normas específicas que tratem da matéria, nem da responsabilidade civil pelas perdas e danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado.

A lei determina que os artigos 5º, 6º e 7º são de cumprimento obrigatório, sob pena de multa diária. Multa diária é aquela renovada diariamente enquanto persistir a prática da infração. Os valores deverão ser fixados em regulamento, observados os parâmetros fixados pelo § 2º do artigo 25. A multa diária começa a correr do dia em que foi constatada a infração até o efetivo cumprimento da norma violada. É importante observar que, nos termos do artigo 17 da LC nº 140/2011, cabem a fiscalização e a consequente imposição da sanção à entidade responsável pelo licenciamento ambiental.

No que tange ao inciso II do artigo 25, descumprimento dos artigos 9º e 22, a lei considerou a infração menos grave do que a do inciso I, tanto assim que determinou a imposição de multa. As infrações são omissivas, pois ambas dizem respeito à não realização de (I) auditorias bianuais e (ii) falta de comunicação aos órgãos ambientais, à Capitânia dos Portos e à ANP de incidentes que possam implicar poluição do mar. Muito embora os artigos 9º e 22 sejam bastante claros em seus termos, há necessidade de regulamentação do tipo de auditoria bianual que deverá ser entregue ao órgão de controle ambiental responsável pelo licenciamento.

No âmbito federal, as auditorias ambientais tratadas pela Lei nº 9.966/2000 foram disciplinadas pela Resolução Conama nº 306/2002, subsidiariamente na Resolução Conama nº 265/2000. Para que se possa ter como cumprido o determinado pelo artigo 9º, a Auditoria deve preencher os requisitos dispostos na Resolução do Conama específica. Caso o licenciamento ambiental da facilidade industrial seja estadual, será exigível a auditoria tal como tratada na norma estadual ou como determinar o órgão ambiental. Penso que não há exigência cumulativa; isto é, não se podem exigir, concomitantemente, uma auditoria para apresentação no órgão federal, uma para o estadual e outra para o municipal. Como afirmado acima, a LC nº 140/2011 disciplinou a questão, definindo claramente a competência para a fiscalização e, evidentemente, para a exigência de elementos a serem fiscalizados.

Quanto à comunicação tratada pelo artigo 22, há que se considerar que “*imediatamente*” é um conceito aberto que necessita ser preenchido por norma administrativa. Assim, a comunicação imediata deverá ser examinada à luz da regulamentação específica de cada um dos órgãos para os quais a comunicação é obrigatória.

Fica estabelecido, através da presente Resolução, o procedimento para comunicação de incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas autorizadas pela ANP a exercer as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como distribuição e revenda.

O inciso III do artigo 25 da Lei nº 9.966/2000 diz respeito ao descumprimento dos artigos 10, 11 e 12, cominando as penas de multa e retenção do navio até que a situação seja regularizada. Retenção, no caso, não se confunde com o direito de retenção que o credor possui sobre bem móvel com vistas a garantir o seu crédito. Até porque, na hipótese, os bens são imóveis por determinação legal. Na verdade, o navio não poderá deixar o porto enquanto persistir o descumprimento das normas contidas nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 9.966/2000. A multa é aplicada na modalidade simples, haja vista que a lei não se referiu à “multa diária”.

A infração tipificada no inciso IV do artigo 25 é: “*descumprir o disposto no art. 24*”, cominando-se as penas de (i) multa e (ii) suspensão imediata das atividades da empresa transportadora em situação irregular. As penas são cumulativas. A pena cominada é curiosa, pois o artigo 24 é destinado ao administrador público ou privado, no sentido de que ele somente contrate empresa transportadora regularmente licenciada para as atividades de transporte. O ilícito praticado pela transportadora, certamente, é não possuir o licenciamento necessário para o exercício de suas atividades; não tendo qualquer sentido penalizá-la por ter firmado um contrato. Por outro lado, a norma não penaliza aquele que contratou o serviço de empresa irregular. Observe-se que, dadas as dimensões da atividade regulada pela Lei nº 9.966/2000, não se está falando de empresas de “fundo de quintal”, mas de empresas de porte e cuja regularidade pode ser muito bem pesquisada pelos contratantes, sem maiores dificuldades.

Quando a contratação for feita por entidade submetida ao regime das licitações públicas, aplicáveis os artigos 84 e 85 da Lei nº 8.666/86. No caso de licitações realizadas pela Petrobras aplica-se o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A., aprovado pelo Decreto nº 2.745/1998. O STF já se manifestou sobre o decreto em tela (Ação cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido no STJ. 3. Plausibilidade jurídica do pedido. Licitações realizadas pela Petrobras com base no Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado [Decreto nº 2.745/98 e Lei nº 9.478/97]. 4. Perigo de dano irreparável. A suspensão das licitações pode inviabilizar a própria atividade da Petrobras e comprometer o processo de exploração e distribuição de petróleo em todo o País, com reflexos imediatos para a indústria, comércio e, enfim, para toda a população. 5. Medida cautelar deferida para conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário. [AC 1193 MC-QO. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento: 9/5/2006. 2ª Turma. DJU 30/6/2006]).

15.17.5.1 Responsabilidade

O artigo 25, em seu § 1º, estabelece a relação de pessoas passivamente responsáveis pela observância das normas da Lei nº 9.966/2000. É importante observar que o § 1º determina que a responsabilidade existe “*na medida de sua ação ou omissão*” para (i) o proprietário do navio, pessoa física ou jurídica, ou quem legalmente o represente; (ii) o armador ou operador do navio, caso este não esteja sendo armado ou operado pelo proprietário; (iii) o concessionário ou a empresa autorizada a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo; (iv) o comandante ou tripulante do navio; (v) a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar; (vi) o proprietário da carga.

“*Na medida de sua ação ou omissão*”, implica juízo de culpabilidade, matéria típica da responsabilidade subjetiva. Assim, três são as hipóteses que devem ser examinadas, ainda que sucintamente: (i) a responsabilidade civil; (ii) a responsabilidade administrativa; e (iii) a responsabilidade penal.

A responsabilidade civil é objetiva, pois assim estabelecido na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (artigo 14, § 1º) e confirmada pelo CC de 2002 (artigo 927). A responsabilidade penal em matéria de proteção ao meio ambiente é subjetiva; quanto à responsabilidade administrativa, há muita controvérsia a respeito do tema, pois a Lei nº 9.605/98 (artigo 72, § 3º), ao dispor sobre a imposição de penalidade pertinente à aplicação da pena de multa, é clara ao determinar a aplicação de multa simples em caso de negligência ou dolo. Contudo, tem se firmado orientação no sentido de considerar-se objetiva a responsabilidade administrativa. Ora, ao se considerar objetiva a responsabilidade administrativa, em meu ponto de vista, perde o sentido tentar-se aferir a “*medida da ação ou omissão*”, pois ação ou omissão implicam conduta subjetiva. Dada a relação de potenciais responsáveis pela observância das normas legais constantes do § 1º do artigo 25, da Lei nº 9.966/2000 não há como se excluir a subjetividade da conduta, pois punir-se o proprietário da carga, por exemplo, quando o incidente foi relativo a vazamento de óleo quando o navio estava sendo abastecido, parece ser excessivo. Entendo que o § 1º estabeleceu uma ordem de preferência para a imposição de sanções administrativas que deve ser observada, conforme as circunstâncias do caso concreto.

[...] 1. Danos causados ao meio ambiente, na forma de derramamento de óleo pesado em águas marinhas por navio ancorado no cais do Porto de Santos. 2. O dano é inquestionável, posto que cabalmente comprovado por fotografias e documentos oriundos da Capitania dos Portos. 3. O fato de ser impossível detectar a exata extensão dos danos ao meio ambiente não leva a considerá-los inócuos. 4. É irrelevante que a apelante tenha pago (*sic*) multa pelos atos praticados, visto que ela tem caráter punitivo e natureza administrativa, enquanto a reparação de danos tem natureza constitucional-civil, sendo devida independentemente das sanções de caráter penal e administrativo, nos termos do art. 225, 3º, da CF. 5. Não se pode pretender que a apuração dos danos ambientais, em casos como os destes autos, fique restrita ao âmbito da Capitania dos Portos, posto que sua atuação é de caráter administrativo, não impedindo que o Ministério Público Federal exerça as atribuições que lhe foram expressamente conferidas pelo art. 129, inciso III, da CF, notadamente no que diz respeito à proteção do meio ambiente. 6. A r. sentença de primeiro grau escudou-se em parâmetros fornecidos pelo laudo pericial, encontrando, no caso, o valor de US\$ 125.892,54 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e dois dólares americanos, cinquenta e quatro centavos), os quais, convertidos em moeda nacional, foram definidos em R\$ 119.597,91 (cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). 7. Trata-se, sem dúvida, de valor significativo, mas adequado ao caso, em se considerando a dimensão que têm os derramamentos de óleo nas águas marinhas, exigindo rigor das autoridades constituídas para que, sobretudo, se evite a repetição de acontecimentos como os tratados nestes autos. 8. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios a 10% do valor da condenação (TRF da 3ª Região. AC 96030142670. AC 304590. Juiz Convocado Rubens Calixto. 3ª Turma. DJU 5/9/2007. p. 154).

[...] 1. O Ministro da Marinha delegou competência ao Diretor de Portos e Costas para elaborar normas e executar ações previstas no art. 4º da Lei 9.537/97, que regula a segurança em transporte aquaviário, também conhecida como Lesta, através da Portaria Ministerial nº 67/1998, razão pela qual as normas são válidas. 2. Somente há que se falar em contraditório e em ampla defesa quando existe processo judicial ou administrativo em desfavor do interessado. O inquérito não constitui processo, mas mero procedimento de caráter investigatório, com o fim de se apurar a existência e circunstâncias de determinado fato que servirá de base para posterior fase processual. 3. A teor da Lei 2.180/54, o Tribunal Marítimo é o órgão técnico competente para processar e julgar o acidente marítimo, através de processo administrativo em que é assegurado ao interessado todas as garantias inerentes ao devido processo legal, inclusive contraditório e ampla defesa. 4. A ressalva feita pela parte final do parágrafo único do art. 33 da Lei 9.537/1997 (Lesta) vai de encontro ao devido processo legal quando confere imediata exigibilidade à multa relativa à poluição das águas antes de decisão final do Tribunal Marítimo. 5. Inexiste qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na expedição de Normas de Autoridade Marítima pelo Diretor de Portos e Costas. É certo que o Decreto-lei nº 200/67, regulamentado pelo Decreto nº 83.937/79, prevê o instituto da delegação de competência como forma de garantir maior celeridade e objetividade às funções administrativas do Estado, de modo a atender aos anseios sociais com maior efetividade. Tal conduta da Administração constitui desconcentração administrativa, na qual o órgão delegante pode, a qualquer tempo, avocar para si as atribuições do órgão delegado, com o fim de preservar o princípio da legalidade e da hierarquia funcional. 5. Remessa Necessária e apelações das partes litigantes improvidas (TRF da 5ª Região. APELREEX 200881000121946. APELREEX 10978. Desembargador Federal Francisco Barros Dias. 2ª Turma. DJe 17/2/2011, p. 358).

15.18 ALIJAMENTO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL

o artigo 30 da Lei nº 9.966/2000 determina que o alijamento em águas sob jurisdição nacional deverá observar as condições previstas na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, de 1972, promulgada pelo Decreto nº 87.566/1982, e suas alterações. Nos termos do artigo I da Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, ficou o Brasil obrigado a promover “*o controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio marinho e se comprometem, especialmente, a adotar todas as medidas possíveis para impedir a contaminação do mar pelo alijamento de resíduos e outras substâncias que possam gerar perigos para a saúde humana, prejudicar os recursos biológicos e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir em outras aplicações legítimas do mar*”. Tal obrigação deverá ser cumprida conforme o disposto na própria Convenção e “*segundo suas possibilidades científicas, técnicas e econômicas, medidas eficazes, individuais e coletivamente, para impedir a contaminação do mar causada pelo alijamento*” e harmonizarão suas políticas a respeito.

15.18.1 Definições

O artigo III da Convenção define **alijamento** como: (i) todo despejo deliberado, no mar, de resíduos e outras substâncias efetuado por embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar; (ii) todo afundamento deliberado, no mar, de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar.

Estão excluídas da definição de alijamento contidas na Convenção as seguintes Ações: (i) o despejo no mar de resíduos e outras substâncias, que sejam acidentais, em operações normais de embarcações, aeronaves, plataformas e outras construções no mar, e de seus equipamentos, ou que delas se derivem, exceto os resíduos ou outras substâncias transportadas por ou para embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar, que operem com o propósito de eliminar as ditas substâncias ou que se derivem do tratamento dos citados resíduos ou outras substâncias nas ditas embarcações, aeronaves, plataformas ou construções; (ii) a colocação de substâncias para fins diferentes do seu próprio despejo, sempre que a dita colocação não seja contrária aos objetivos da Convenção. (iii) o despejo de resíduos ou outras substâncias diretamente derivadas de prospecção, exploração e tratamentos afins dos recursos minerais do leito do mar, fora da costa, ou com os mesmos relacionadas, não estará compreendido nas disposições da Convenção.

Embarcações e aeronaves: os veículos que se movem na água ou no ar, quaisquer que sejam seus tipos, inclusive os veículos que se deslocam sobre um colchão de ar e os flutuantes, sejam ou não autopropeulsados.

Mar: as águas marinhas que não sejam águas interiores dos Estados.

Resíduos ou outras substâncias: os materiais e substâncias de qualquer classe, forma ou natureza.

Permissão especial: permissão concedida especificamente por meio de solicitação prévia e de acordo com os Anexos II e III da Convenção.

Permissão geral: permissão concedida previamente e de acordo com o Anexo III da Convenção.

Organização: a organização designada pelas Partes Contratantes de acordo com o artigo XIV-2.

15.18.2 Proibição de alijamento

De acordo com o disposto na Convenção deve ser proibido o alijamento de quaisquer resíduos ou outras substâncias em qualquer forma ou condição, exceto nos seguintes casos: (i) proíbe-se o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeradas no Anexo I; (ii) o alijamento de resíduos ou outras substâncias enumeradas no Anexo II requer uma permissão especial prévia; e (iii) o alijamento de todos os demais resíduos ou substâncias requer uma permissão geral prévia. Somente deverá ser concedida uma permissão para alijamento após uma consideração cuidadosa de todos os fatores que figuram no Anexo III, incluindo estudos prévios das características do local de lançamento, conforme estipulado nas seções B e C do citado Anexo. Isto significa que, nos termos do direito brasileiro, devem ser realizados estudos ambientais prévios, antes da emissão da permissão de alijamento (*rectius*: licença). Importante observar que os estudos ambientais, independentemente de seus resultados: “*Nada disposto na presente Convenção pode ser interpretado no sentido de impedir que uma Parte proíba, no que lhe concerne, o alijamento de resíduos ou outras substâncias não mencionadas no Anexo I*”.

A Parte em questão notificará tais medidas à Organização. O artigo V excepciona as disposições do Artigo IV as quais *não se aplicarão quando for necessário salvar a segurança da vida humana ou de embarcações, aeronaves, plataformas e outras construções no mar; em casos de força maior devidos às inclemências do tempo ou em qualquer outro caso que constitua perigo para a vida humana ou uma real ameaça para as embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar; se o alijamento configurar o único meio de se evitar a ameaça e se existir toda probabilidade de que os danos oriundos do dito alijamento venham a ser menores do que os que de outro modo ocorreriam. Tal alijamento será levado a cabo de forma que se reduza ao mínimo a probabilidade de que venha a ocasionar danos a seres humanos ou à vida marinha, e será comunicado imediatamente à Organização.*

Admite a Convenção ainda que: *Uma Parte Contratante poderá expedir uma permissão especial como exceção do disposto no item 1, parágrafo a, do Artigo IV, nos casos de emergência que provoquem riscos inaceitáveis para a saúde humana e desde que não se encontre outra solução exequível. Antes de expedir a, a Parte fará consultas a qualquer outro país ou países que possam vir a ser afetados, bem como à Organização, a qual, após consultar as outras Partes e as organizações internacionais que julgue pertinente, recomendará à Parte, sem demora, de conformidade com o artigo XIV, os procedimentos mais adequados, que devam ser adotados. A Parte seguirá estas recomendações, dentro do máximo de suas possibilidades, de acordo com o prazo dentro do qual deve tomar as medidas e com a obrigação de evitar danos do meio marinho, informando à Organização sobre as medidas adotadas. As Partes se comprometem a ajudar-se mutuamente em tais situações.*

Na forma do artigo VI da Convenção: *1. Cada Parte Contratante designará uma autoridade ou autoridades apropriadas para: (a) expedir as permissões especiais, que forem requeridas previamente, para o alijamento de substâncias enumeradas no Anexo II e nas circunstâncias previstas no item 2 do artigo V; (b) expedir as permissões gerais, que forem requeridas previamente, para o alijamento de todas as demais substâncias; (c) manter registros da natureza e das quantidades de todas as substâncias que se permita alijar, assim como do local, data e método de alijamento; e (d) vigiar e controlar, individualmente ou em colaboração com outras Partes e com as organizações internacionais competem competentes, as condições dos mares para os fins desta Convenção. 2. A autoridade ou autoridades de uma Parte Contratante expedirão permissões especiais ou gerais, de conformidade com o item 1, a respeito das substâncias destinadas a serem alijadas: (a) que sejam transportadas em seus territórios; (b) que sejam transportadas em uma embarcação ou aeronave registrada ou com bandeira de seu território, quando o transporte tenha lugar em território de um Estado que não seja Parte desta Convenção. 3. Na expedição de permissões especiais ou gerais, de acordo com os parágrafos a e b do item 1, a autoridade ou autoridades apropriadas observarão as disposições do anexo III, assim como os critérios, medidas e requisitos adicionais considerados pertinentes. 4. Cada Parte Contratante comunicará à Organização e, quando for o caso, às demais Partes, diretamente através de uma Secretaria estabelecida com base em um acordo regional, a informação especificada nos parágrafos c e d do item 1 e os critérios, medidas e requisitos adotados de conformidade com o item 3. O procedimento a seguir e a natureza dos ditos informes serão combinados pelas Partes mediante consulta.*

O artigo VII da Convenção determina que: *1. Cada Parte Contratante adotará as medidas necessárias para a aplicação da presente Convenção a todas as: (a) embarcações e aeronaves matriculadas em seu território ou que arvoem seu pavilhão; (b) embarcações e aeronaves que transportem, em seus territórios ou em suas águas territoriais, substâncias destinadas a serem alijadas; e (c) embarcações, aeronaves e plataformas fixas ou flutuantes em zonas sob sua jurisdição, que se supõe dedicarem-se a operações de alijamento. 2. Cada Parte tomará em seu território as medidas apropriadas para prevenir e punir condutas que constituam contravenções à presente Convenção.*

O número 4 do artigo VII determina que: *A presente Convenção não se aplicará às embarcações e aeronaves que tenham direito à imunidade soberana, de acordo com o direito internacional. Não obstante, cada Parte assegurar-se-á, mediante adoção de medidas apropriadas, de que as embarcações e aeronaves de sua propriedade ou que esteja explorando, operem de forma compatível com o objetivo e fins da presente Convenção e informará a organização a respeito.*

Desde a incorporação da Convenção ao direito brasileiro, o Brasil se comprometeu a fomentar, dentro dos competentes organismos especializados e de outros

órgãos internacionais, a adoção de medidas para proteção do meio marinho contra a contaminação causada por: (i) hidrocarburetos, incluindo o petróleo e seus resíduos; (ii) outras substâncias nocivas ou perigosas, transportadas por embarcações para fins que não seja o alimento; (iii) resíduos perigosos produzidos durante operações de embarcações, aeronaves, plataformas e outras estruturas construídas no mar pelo homem; (iv) contaminadores radioativos de todas as procedências, inclusive embarcações; (v) agentes de guerra química e biológica; e (vi) resíduos ou outras substâncias que sejam consequência direta de ou relacionados com prospecção, exploração e tratamentos afins, ao largo da costa, dos recursos minerais do leito do mar; obrigações que, dentro das condições nacionais, vêm sendo cumpridas.

15.18.2.1 Bens alijados no mar

A Lei nº 7.542/1986, embora não seja destinada ao combate à poluição marinha, merece ser examinada, haja vista que suas disposições, de certa forma, guardam relação com o nosso tema. Com efeito, a norma tem por objeto “*as coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar*”, cabendo “*ao Ministério da Marinha a coordenação, o controle e a fiscalização das operações e atividades de pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar*”. Os serviços podem ser delegados para outras entidades públicas ou concedidos a particulares, “*em áreas definidas de jurisdição*”.

Uma coisa ou bem será considerado perdido, para fins de aplicação do artigo 1º da Lei nº 7.542/1986, quando o seu responsável (*rectius*: proprietário ou possuidor): (i) declarar à Autoridade Naval que o considera perdido; (ii) não for conhecido, estiver ausente ou não manifestar sua disposição de providenciar, de imediato, a flutuação ou recuperação da coisa ou bem, mediante operação de assistência e salvamento.

O proprietário ou possuidor da coisa submersa, afundada, encalhada ou perdida pode requerer a Autoridade Naval licença para (i) pesquisa, (ii) exploração, (iii) remoção ou (iv) demolição. A pesquisa, exploração, remoção ou demolição poderá ser total ou parcial. A licença concedida determinará o início e o término das atividades licenciadas. A Autoridade Naval, de ofício, poderá determinar que o “responsável” por coisas ou bens submersos, encalhados ou perdidos que possam ser considerados como perigosos para a navegação ou para o meio ambiente e para terceiros, promova-lhes a remoção ou a demolição, ainda que parcial.

Prazo Prescricional:

Prescreve em 5 (cinco) anos o direito de requerer a licença tratada pelo art. 4º da Lei nº 7.542/1986, contando-se o prazo a partir da data do sinistro, alijamento ou fortuna do mar. Suspende-se o prazo prescricional quando: (i) o responsável iniciar a remoção ou demolição; (ii) a Autoridade Naval determinar a remoção ou demolição; (iii) a remoção ou demolição for interrompida mediante protesto judicial, o qual deverá ser promovido perante a Justiça Federal. Encerrado o prazo prescricional sem que o proprietário ou possuidor tenha manifestado interesse no bem, mediante o requerimento de licença tratado no artigo 4º, a lei estabelece a presunção de renúncia à propriedade, incorporando-se o bem ao patrimônio da União. Sobre a matéria veja-se a interessante decisão:

[...] 1 – Os dispositivos do Código Comercial foram revogados textualmente pelo art. 38, da Lei nº 7.542, de 26/9/1986, não deixando margem a interpretações. 2 – Insubsistência da tese da apelante acerca da inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 28 e 32, e do caput do artigo 38, todos da Lei nº 7.542/1986, frente à Carta de 1967, posto que cuidam, tão somente, de disciplinar os bens acessórios, já necessariamente vinculados aos bens principais, quais sejam, o Mar Territorial e a plataforma continental, ambos propriedade da União. 3 – Localizando-se os destroços em mar territorial, de propriedade da União e, havendo a descoberta sido realizada sem prévia autorização da mesma, não há que se invocar o disposto no art. 607 do CC/1916, em função do propalado no dispositivo seguinte, o 608, cuja dicção foi mantida no art. 1.265, da Lei nº 10.406/2002, o novo CC. 4 – No escopo de proteger o Patrimônio Histórico Nacional buscou-se incluir tais descobertas como propriedade da União e, com o mesmo propósito a Lei nº 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, impingiu a obrigação de comunicá-las ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, revelando-se, pois, iniludível que os bens em questão devem ser entregues à tutela do mesmo. 5 – Sentença mantida. Apelação improvida (TRF da 5ª Região. Apelação Cível 305269. Desembargador Federal Geraldo Apoliano. 3ª Turma. DJU 22/8/2003, p. 903).

15.18.2.1.1 Remoção ou demolição: responsabilidade

Do ponto de vista do combate à poluição do mar, relevante observar as disposições dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 7.542/1986. As coisas afundadas, encalhadas, submersas ou perdidas, como qualquer bem com valor econômico, poderão ser legalmente transferidas a terceiros, mediante todas as formas contratuais admitidas pelo direito brasileiro. Nos termos do artigo 8º “*o responsável pelas coisas ou pelos bens referidos no art. 1º desta lei poderá ceder a terceiros seus direitos de disposição sobre os mesmos*”. Em tal hipótese, “*o cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelos riscos ou danos à segurança da navegação, a terceiros e ao meio ambiente, decorrentes da existência das coisas ou dos bens referidos no art. 1º ou consequentes das operações de sua remoção ou demolição*”. Exige a norma, sob pena de anulabilidade do ato, a comunicação à autoridade naval.

A Autoridade naval, como já foi visto acima, pode determinar ao “responsável” seja efetuada a remoção ou demolição dos bens afundados, submersos, perdidos ou encalhados, mediante: (i) intimação pessoal, quando o responsável tiver paradeiro conhecido no País; (ii) por edital, quando o responsável tiver paradeiro ignorado, incerto ou desconhecido, quando não estiver no País, quando se furtar à intimação pessoal ou quando for desconhecido. Por se tratar de matéria referente a direitos e garantias individuais, recomenda-se que as intimações sejam feitas na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, artigo 26, no que for cabível, ante a inexistência de norma própria na Lei nº 7.542/1986. No que diz respeito à intimação por edital, a lei traz algumas disposições determinando que: (i) a intimação de responsável estrangeiro deverá ser feita através de edital, enviando-se cópia à Embaixada ou ao Consulado de seu país de origem, ou, caso seu paradeiro seja conhecido, à Embaixada ou Consulado do país em que residir e (ii) o edital, com prazo de 15 (quinze) dias, será publicado, uma vez, no *Diário Oficial da União*, em jornal de grande circulação da capital da Unidade da Federação onde se encontrem as coisas ou os bens, em jornal da cidade portuária mais próxima ou de maior importância do Estado e em jornal do Rio de Janeiro, caso as coisas ou os bens se encontrem afastados da costa ou nas proximidades de ilhas oceânicas.

Nas hipóteses em que os responsáveis pela remoção ou demolição dos bens tratados pela Lei nº 7.542/1986 não seja providenciada pelos legalmente obrigados, a Autoridade Naval poderá assumir as operações de pesquisa, exploração, remoção ou demolição das coisas ou bens, por conta e risco de seu responsável. Isto significa que os custos serão cobrados do responsável. Caso da atividade resultem danos ao meio ambiente e a terceiros, o responsável é solidariamente responsável.

O responsável, antes de dar início à pesquisa, exploração, remoção ou demolição solicitadas ou determinadas, das coisas ou dos bens referidos no art. 1º da Lei, deverá adotar providências imediatas e preliminares para prevenir, reduzir ou controlar os riscos ou danos à segurança da navegação, a terceiros e ao meio ambiente, tal como estabelecido pela autoridade naval, necessariamente com: (i) manutenção, se possível, a bordo, ou em local próximo à embarcação, de seu Comandante ou de um Oficial ou um Tripulante; e (ii) demarcação ou sinalização das coisas ou dos bens. Importante observar que, na inobservância das medidas mencionadas, a Autoridade Naval atuará de imediatamente, por conta e risco do responsável.

Assim, a Autoridade Naval, agindo de ofício e dentro de seu poder de polícia, poderá empregar seus próprios meios ou, ainda, autorizar que terceiros executem as operações de pesquisa, exploração, remoção ou demolição de coisas ou bens referidos no art. 1º da Lei. Os contratos a serem celebrados entre a Autoridade Naval, de natureza pública, poderá ter “*cláusula determinando o pagamento no todo ou em parte, com as coisas ou os bens recuperados, ou removidos, ressalvado o direito do responsável de reaver a posse até 30 (trinta) dias após a recuperação, mediante pagamento do valor da fatura, do seguro ou de mercado, o que for maior, da mesma coisa ou bem, além do pagamento do que faltar para reembolso integral das despesas havidas ou contratadas para a operação executada*”. Não havendo “*disposição em contrário no contrato ou autorização ou sendo a recuperação feita pela Autoridade Naval, as coisas ou os bens resgatados, nacionais ou nacionalizados, serão imediatamente vendidos em licitação ou hasta pública, dando-se preferência na arrematação àquele que efetuou a remoção ou recuperação, ressalvado o direito do responsável de reaver sua posse, na forma e no prazo estabelecidos*” no § 2º do artigo 12.

O responsável pelas coisas ou bens referidos no art. 1º da lei, seu cessionário e o segurador, que tenham coberto especificamente os riscos de pesquisa, exploração, remoção ou demolição das coisas ou bens, permanecerão solidariamente responsáveis: (i) pelos danos que venham provocar, direta ou indiretamente, à segurança da navegação, a terceiros ou ao meio ambiente, até que as coisas ou os bens sejam removidos ou demolidos, ou até que sejam incorporados ao domínio da União pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar do sinistro; e (ii) pelo que faltar para reembolsar ou indenizar a União, quando a Autoridade Naval tiver atuado conforme disposto no art. 10 e no § 2º do art. 11 da Lei. Em se tratando de embarcação, o seu responsável responderá, solidariamente, com o responsável pela carga, pelos danos que ela cause à segurança da navegação, a terceiros e ao meio ambiente. Quando uma embarcação contenha carga e, em decorrência de sinistro ou fortuna do mar, se encontre em qualquer das situações previstas no art. 1º da Lei, deverá ser adotado o seguinte procedimento: (i) não havendo manifestação de interesse por parte do responsável pela carga, o responsável pela embarcação poderá solicitar autorização para remoção ou recuperação da carga ou ser intimado pela Autoridade Naval a remover a carga, juntamente com a embarcação ou separadamente dela; (ii) o responsável pela carga poderá solicitar à Autoridade Naval autorização para sua remoção ou recuperação, independente de pedido por parte do responsável pela embarcação.

A remoção da carga poderá ser exigida tanto do responsável pela embarcação, como do responsável pela carga, em conjunto ou separadamente, dada a existência da solidariedade. De qualquer forma, a autorização para a remoção da carga, fica a critério da Autoridade Naval a qual deverá levar em consideração as repercussões da remoção para a própria embarcação e consequências para terceiros e o meio ambiente, bem como para a segurança da navegação.

-
- ¹ *Dicionário Aurélio Eletrônico*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
 - ² Disponível em: <<https://www.fundacaorenova.org/>>. Acesso em: 17 nov. 2018.
 - ³ Pesquisa do autor.
 - ⁴ Roberto Santos Barbiéri, Magda Aparecida de Carvalho Schmaltz, Tenisoy Bragança de Araujo, Fernando Teodoro Martins Peixoto e Christiane Bastos Tinoco de Carvalho. Avaliação da IN nº 6 do IBAMA (6/7/2001), sobre substâncias nocivas ou perigosas, sob a ótica da química. Disponível em: <www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/senior/resumos/resumo_2532.htm>. Acesso em: 9 fev. 2012.

16.1 A MINERAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

A mineração é atividade econômica de grande importância, com amplas repercussões sobre o meio ambiente. A implementação de técnicas adequadas, controles e fiscalização podem reduzir o impacto por ela causado ao ambiente. Infelizmente, a mineração causou um dos maiores acidentes ambientais já registrados no Brasil, na cidade de Mariana, estado de Minas Gerais, no qual o rompimento de uma barragem de rejeitos causou inúmeras vítimas fatais, poluição em toda a calha do rio Doce, prejuízos econômicos de grande monta, danos ambientais, pessoais e patrimoniais. Apesar disso, é indiscutível que, no patamar tecnológico em que a humanidade se encontra, é absolutamente impossível a vida humana sem as atividades minerárias. Esse fato, evidente por si mesmo, fez com que o constituinte de 1988 dedicasse diversos tópicos da Carta promulgada em 1988 à mineração.

Dadas as condições em que o Brasil foi colonizado por Portugal, a mineração sempre desempenhou papel relevante na economia nacional. O extrativismo de riquezas naturais, durante muitos anos, foi a principal atividade econômica do país, e, no interior da atividade extrativista, a mineração sempre se destacou.

Com o descobrimento do Brasil, a Coroa portuguesa passou a ser senhora e proprietária de todo o território brasileiro. Estabelecidos os mecanismos para a concessão de terras para aqueles que se dispusessem a financiar a colonização, através das Cartas de Doação, a Coroa reservava-se o direito de reter a quinta parte das riquezas minerais que fossem encontradas e lavradas na colônia. Os minerais, portanto, eram de propriedade do Estado, que outorgava o direito de lavra aos particulares que, em contrapartida, ficavam obrigados ao pagamento do *quinto*.

16.1.1 Constituições anteriores

O Regime Imperial não deu tratamento constitucional ao tema na Constituição de 1824. Na República, todas as Constituições dispuseram sobre a matéria. Na Constituição Republicana de 1891, as minas foram contempladas pelo artigo 72, § 17 que determinava que “o direito de propriedade mantém-se em toda a plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia, sem que as minas pertencem aos proprietários do solo, salvo as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria”.

Com a reforma constitucional promovida pela Emenda de 3 de setembro de 1926, o dispositivo foi alterado determinando que o direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. E mais que as minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas, acrescentando que as minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa nacionais e as terras onde existirem não podem ser transferidas a estrangeiros.

A Constituição de 1934 dispunha, em seu artigo 118, que: “as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial”. Aqui foi feita uma grande inovação, pois foram separadas as propriedades do solo e do subsolo. A atividade minerária, bem como a utilização dos potenciais hídricos continuaram dependendo de autorização ou concessão federal (artigo 119), sendo outorgadas apenas a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil. As minas, jazidas minerais e quedas d’água deveriam ser nacionalizadas progressivamente. A CF de 1937 dispôs sobre a matéria no artigo 143 e seus parágrafos. Não houve grandes mudanças em relação ao Texto Magno de 1934. A Constituição de 1946 manteve o regime anterior, sem modificações mais profundas, o mesmo ocorrendo com a Carta Constitucional de 1967.

16.1.2 A mineração na Constituição de 1988

16.1.2.1 Disposições constitucionais

A CF estabelece em seu artigo 20, IX, que os recursos minerais, inclusive os do subsolo são bens de domínio da União. Por sua vez, o artigo 21, XXV, da CF determina competir à União “estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.” Coerentemente com o que foi estabelecido pelo artigo 20, IX, da Constituição de 1988, o artigo 22, XII, determina que “compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia”. Não se pode esquecer de que o artigo 91, § 1º, inciso III, da CF também está ligado ao tema. Tanto é assim que, na forma do artigo mencionado, compete ao Conselho de Defesa Nacional “propor os critérios e condições de utilização das terras indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo”.

O artigo 174, por seus §§ 3º e 4º, determina que o “Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros” e que tais cooperativas “terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei”.

As competências estaduais e municipais específicas de proteção ambiental, necessariamente, terão repercussões na atividade minerária, ainda que não caiba aos Estados e aos Municípios legislar *diretamente* sobre tais atividades. Mais à frente, o artigo 176 da CF voltou-se, especificamente, para disciplinar a atividade minerária dispondo: que “as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.” Já os §§ 1º, 2º e 3º do mencionado artigo determinam que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o *caput* deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem na faixa de fronteira ou terras indígenas. Aos proprietários do solo é assegurada participação nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Todavia, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

No capítulo constitucional (art. 225) voltado para a proteção do meio ambiente, encontra-se o § 2º que destaca o regime de responsabilidade ambiental da atividade minerária, determinando que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.”

Por fim, acrescente-se a norma contida no § 3º do artigo 231 da CF que, embora voltada para os povos indígenas, impacta a atividade minerária, assim, o

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. STJ. ADI-MC 3352. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Plenário. *I. Ação direta de inconstitucionalidade: ato normativo (MPr 225/04) susceptível de controle abstrato de constitucionalidade, não obstante a limitação numérica dos seus destinatários e a breve duração de sua vigência. II. Mineração em terras indígenas: alegação de inconstitucionalidade da MPr 225/04, por alegada violação dos arts. 231, § 3º, e 49, XVI, da Constituição: carência de plausibilidade da arguição: medida cautelar indeferida. 1. É do Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas (CF, arts. 49, XVI, e 231, § 3º), mediante decreto-legislativo, que não é dado substituir por medida provisória [...].*

Fora do corpo permanente da CF, também, existem normas voltadas para a disciplina da atividade minerária. Assim é que no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, os artigos 43 e 44 dispuseram sobre a matéria, estabelecendo que “na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de um ano, a contar da promulgação da Constituição, tornar-se-ão sem efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos”.

16.1.2.2 Breve análise das disposições constitucionais à luz do artigo 225, § 2º

Os recursos minerais e as atividades de exploração, lavra e pesquisa mineral, como se viu, foram amplamente tratados pela CF. A atividade de garimpagem sempre se constituiu em um dos graves problemas nacionais, seja pelos aspectos ambientais, seja pelos aspectos sociais. É de se estranhar, portanto, que a garimpagem tenha merecido incentivos explícitos por parte do legislador constituinte. Tal fato somente se pode explicar pela presença de grupos de pressão e de políticos interessados na continuidade de uma atividade econômica que é altamente degradadora do meio ambiente e que é extremamente nociva à saúde dos próprios garimpeiros e de inúmeros grupos indígenas. Sendo uma atividade econômica que é grande utilizadora de mão de obra desqualificada, a garimpagem é, evidentemente, um bom celeiro de votos para aqueles que se dedicam a “ajudar” os garimpeiros. Várias são as implicações das atividades garimpeiras, merecendo destaque as condições subumanas em que vivem os homens dos garimpos, a destruição dos povos indígenas, o contrabando do minério garimpado, a devastação ecológica de flora e fauna nas regiões de garimpo, a poluição de rios, a contaminação por mercúrio etc. Acrescente-se a essa lista a violência e a corrupção. Diante de um quadro caótico, a norma contida no artigo 225, § 2º, serve de verdadeiro marco a indicar um caminho que deve ser percorrido pela sociedade e pelas autoridades, com o objetivo de estabelecer um ordenamento razoável para o grave problema.

Devo observar que o Estado brasileiro chamou a si a responsabilidade de organizar a garimpagem que, como se sabe, é uma prática de alto impacto ambiental. E mais, além de organizar a atividade garimpeira, o Estado brasileiro atribuiu prioridade à autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas em que os garimpeiros estejam atuando, e mesmo em áreas que, posteriormente, venham a ser demarcadas.

A garimpagem é exercida por homens e mulheres que, por motivos econômicos em sua maioria, foram expulsos de suas cidades ou terras e que se dirigiram para as áreas de fronteira até chegarem aos garimpos, às “serras peladas”, em busca de um eldorado que jamais encontrarão. São pessoas com precárias condições de saúde, de cultura etc. que se tornam presas fáceis para grupos de especuladores que os utilizam como mão de obra semiescrava com a finalidade de produzirem a maior quantidade possível de mineral e metais preciosos. A vida desses indivíduos torna-se cada vez mais curta e menos valiosa para aqueles que promovem a exploração dos garimpos. É curioso observar que, apesar da imensa quantidade de pessoas envolvidas no garimpo, sobretudo de ouro, a produção oficial de ouro nos garimpos é pequena. E assim é em razão do grande contrabando que é praticado serenamente.

A CF, em seu artigo 91, § 1º, III, não deixa dúvida de que compete ao Conselho de Defesa Nacional “*propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo*”. A garimpagem, portanto, é constitucionalmente uma questão de segurança nacional e, em consequência, cabe ao Conselho de Defesa Nacional dispor sobre a sua prática nas áreas de fronteira.

16.2 O CÓDIGO DE MINERAÇÃO

O Código de Minas, estabelecido pelo Decreto-lei nº 227/1967, é o principal diploma legal brasileiro, em âmbito infraconstitucional, que regulamenta a atividade de extração mineral em nosso país. Uma vez que a propriedade dos recursos minerais independe da propriedade do solo, o Código tem por função básica o regramento da atividade do Poder Público como administrador dos recursos minerais. A matéria, evidentemente, é da maior repercussão econômica e ambiental. Ao analisarem a importância do ordenamento jurídico da atividade minerária, Lauro Lacerda Rocha e Carlos Alberto M. Lacerda (LACERDA, 1983, p. 3) assim se pronunciaram: “*Realidade de maior preponderância econômica, política e estratégica do Estado, o direito sobre as minas e jazidas é aqui objetivado [no Código] sob o ponto de vista constitucional da intervenção do poder público no conceito moderno da propriedade territorial [...]*”.

O Código foi fortemente modificado pela Lei nº 9.314/1996, que alterou a redação de vários de seus principais artigos.

É no Código de Minas que estão os padrões básicos para o licenciamento das atividades utilizadoras de recursos ambientais minerários. Os conceitos básicos que devem ser apreendidos por aqueles que buscam compreender as repercussões da atividade minerária no meio ambiente são os de:

- *Jazida* – que do ponto de vista técnico-científico tem a sua melhor definição como “*ocorrência anormal de minerais constituindo um depósito natural que existe concentrado em certos pontos da superfície do globo terrestre. Consideram-se assim todas as substâncias minerais de origem natural, mesmo as de origem orgânica, como: carvão, petróleo, calcário etc.*” (GUERRA, 1993, p. 4).

O artigo 4º do Código de Minas dispõe que: “*Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa*”.

- *Mina* – é o depósito mineral (jazida) em exploração pelo homem. Um pegmatito decomposto e inexplorado é uma jazida; o mesmo em estado de exploração, com galerias, escavadeiras etc., é uma mina” (GUERRA, 1993, p. 290). Do ponto de vista jurídico, as minas foram definidas pelo artigo 4º do Código de Minas, conforme foi visto na letra precedente. Na concepção de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1992, p. 340), é uma *universitas iuris* que abrange a jazida, a concessão e as diversas servidões administrativas que forem instituídas para a construção de edifícios, instalações e vias necessárias ao bom êxito dos trabalhos de lavra. De acordo com a nova redação dada ao artigo 6º do Código, as minas podem ser assim classificadas em: (a) mina manifestada, a em lavra, ainda que transitoriamente suspensa a 16 de julho de 1934 e que tenha sido manifestada na conformidade do artigo 10 do Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei nº 94, de 10 de dezembro de 1935; (b) mina concedida, quando o direito de lavra é concedido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.
- *Lavra* – é tecnicamente definida como “*lugar onde se realiza a exploração de mina, geralmente de ouro ou diamante. Lavra significa, por conseguinte, exploração econômica da jazida*” (GUERRA, 1993, p. 261). Normativamente, o conceito foi fixado pelo artigo 36 do Código de Minas, cujo teor é o seguinte: “*entende-se por lavra, o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas*”.
- *Garimpo* – é um verbete definido pelo Dicionário Aurélio Eletrônico como: “[*Der. regress. de garimpeiro.*] S. m. Bras. 1. Mina de diamantes ou carbonados. 2. Lugar onde se encontram tais minas. 3. Lugar onde existem explorações diamantinas e auríferas. 4. Ant. Mineração ou exploração clandestina de diamante e de ouro. 5. Bras., GO. Povoação fundada e habitada pelos garimpeiros”.
- *Pesquisa mineral* – é a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade do seu aproveitamento econômico. Na pesquisa estão compreendidos os seguintes trabalhos de campo e de laboratório: levantamentos geológicos detalhados da área a ser

pesquisada, estudos de afloramentos e suas correlações; levantamentos de natureza geofísica e geoquímica; abertura de escavações visitáveis e realização de sondagens no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; ensaios de beneficiamento de minérios ou das substâncias minerais para a obtenção de concentrados, de acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial (FREIRE, 1995, p. 43).

- *Permissão de lavra garimpeira* – é o aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

Vale notar que, por força das modificações introduzidas no artigo 3º, estão afastados da incidência das normas do Código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais *in natura* necessários para a abertura de vias de transporte, obras de terraplenagem e de edificações, desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos trabalhos, ficando seu aproveitamento restrito à própria obra.

16.2.1 Classificação das jazidas minerais

A classificação das jazidas minerais, conforme estava estabelecido pelo artigo 5º do Código de Mineração, foi totalmente extinta por força do artigo 3º da Lei nº 9.314/96. A antiga classificação, entretanto, ainda pode ter repercussão jurídica em atividades que estejam se desenvolvendo, motivo pelo qual não a retiramos deste trabalho. O revogado artigo 5º do Código indicava as seguintes categorias de jazidas:

- Classe I – jazidas de substâncias minerais metalíferas;
- Classe II – jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil;
- Classe III – jazidas de fertilizantes;
- Classe IV – jazidas de combustíveis fósseis sólidos;
- Classe V – jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas;
- Classe VI – jazidas de gemas e pedras ornamentais;
- Classe VII – jazidas de minerais industriais, não incluídas nas classes precedentes;
- Classe VIII – jazidas de águas minerais;
- Classe IX – jazidas de águas subterrâneas.

Conforme a observação de William Freire (1995, p. 28):

Essa classificação não abrange as jazidas de combustíveis líquidos, gases naturais e jazidas de substâncias minerais de uso na energia nuclear.

Uma vez estabelecidas as classes de jazidas minerais, foi definida uma divisão técnica dos minerais mais conhecidos dentro de cada uma das classes. Os casos omissos ficaram submetidos à classificação pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Tal divisão dos minerais por classes é a seguinte (conforme Regulamento do Código de Mineração – Capítulo II):

- Classe I – alumínio, antimônio, arsênico, berílio, bismuto, cádmio, cério, césio, cobalto, cromo, chumbo, cobre, escândio, estanho, ferro, germânio, gálio, háfnio, índio, irídio, ítrio, lítio, magnésio, manganês, mercúrio, molibdênio, nióbio, níquel, ósmio, ouro, paládio, platina, prata, rádio, rênio, ródio, rubídio, rutênio, selênio, tálio, tântalo, telúrio, titânio, tungstênio, vanádio, xenotímio, zinco, zircônio.
- Classe II – ardósias, areias, cascalhos, quartzitos e saibros, quando utilizados *in natura* para o preparo de agregados, argamassa ou como pedra de talhe, e não se destinem, como matéria-prima, à indústria de transformação.
- Classe III – fosfatos, guano, sais de potássio e salitre.
- Classe IV – carvão, linhito, turfa e sapropelitos.
- Classe V – rochas betuminosas e pirobetuminosas.
- Classe VI – gemas e pedras ornamentais.
- Classe VII – substâncias minerais industriais, não incluídas nas classes precedentes;
 - a) anfibólios, areias de fundição, argilas, argilas refratárias, andaluzita, agalmatolitos, asbestos, ardósias, anidrita, andofilita, bentonitas, barita, boratos, calcários, calcários coralíneos, calcita, caulim, celestita, cianita, conchas calcárias, córidon, crisotila,¹ diatomitos, dolomitos, diamantes industriais, dumortirita, enxofre, estroncianita, esteatitos, feldspatos, filitos, fluorita, gipso, grafita, granada, hidrargilita, leucita, lofilita, magnesita, mármore, micas, ocre, pinguita, pirlita, pirofilita, quartzo, quartzito, silimanita, sais de bromo, sais de iodo, sal-gema, saponito, sílex, talco, tremolita, tripolito, vermiculita, wollastonita;
 - b) basalto, gnaisses, granitos, quaisquer outras substâncias minerais, quando utilizadas para produção de brita ou sujeitas a outros processos industriais de beneficiamento.
- Classe VIII – águas minerais.
- A Classe IX foi excluída pelo regulamento do Código.

16.2.2 O Código de Minas e a proteção do meio ambiente

O próprio Código de Minas contém dispositivos legais que podem ser utilizados na proteção do meio ambiente. É certo que tais dispositivos são tímidos, que estavam a demandar normas mais explícitas em sua substituição. Assim é que o artigo 47 do Código determina:

Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: [...] V – Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares; [...] VII – Não dificultar ou impossibilitar por lavra ambiciosa, o aproveitamento ulterior da jazida; VIII – Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou indiretamente da lavra; IX – Promover a segurança e a salubridade das habitações existentes no local; X – Evitar o extravio de águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; XI – Evitar a poluição do ar ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração; XII – Proteger e conservar as fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos, quando se tratar de lavra de jazida da classe VIII; [...].

As disposições ambientais contidas no Código de Minas não foram revogadas com o advento da novel legislação de proteção ambiental, mas, pelo contrário, devem ser interpretadas de acordo com o sistema instituído pela PNMA.

16.3 MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS

Dentre todos os temas polêmicos que dizem respeito às atividades minerárias, certamente, o mais polêmico é o referente à mineração em terras indígenas. Veja-se

que, no tocante à mineração, o § 3º do artigo 231 da CF estabelece uma exceção ao regime de usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas, conforme definido pelo § 2º do artigo 231. Nos resultados da utilização econômica dos recursos minerais eventualmente existentes no interior de terras indígenas, a CF determinou que, na forma da lei, seja assegurada aos índios a *participação nos resultados da lavra*. A Constituição de 1988 determinou, igualmente, fossem ouvidas as comunidades afetadas pela atividade minerária.

Pelo que se constata dos termos contidos na CF, *a mineração em terras indígenas não está proibida no Brasil*. O que a Constituição determinou foi, apenas e tão somente, que o Congresso Nacional autorizasse a atividade e que a comunidade indígena afetada fosse ouvida, assegurando-se à mesma a percepção de *royalties*. A participação dos indígenas no produto da lavra é, apenas e tão somente, uma extensão dos direitos, previstos no § 2º do artigo 176, aos povos aborígenes.

Infelizmente, ainda hoje, o Congresso Nacional não aprovou as leis necessárias para que as atividades minerárias possam se desenvolver normalmente, e para que as próprias comunidades indígenas possam obter uma melhor situação econômica, a partir da exploração racional das riquezas existentes em seus territórios. A inércia que vem sendo a marca do Congresso Nacional, no particular, é extremamente nociva para todas as partes envolvidas no problema. A não regulamentação da matéria, em minha opinião, serve como um incentivo para a invasão de terras indígenas por garimpeiros e outros aventureiros.

16.4 MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE

É indiscutível que, em princípio, a mineração é uma atividade causadora de alto impacto ambiental e que, nessa condição, necessário se faz que ela esteja rigorosamente submetida a controles de qualidade ambiental, de monitoramento e auditoria constantes. Tais circunstâncias, contudo, não fazem com que a mineração seja uma atividade proscribida ou ilegal em nosso país. Ao contrário, a mineração é uma atividade lícita e que tem gerado muitos recursos para o Brasil. É dentro dessa perspectiva que as relações entre as atividades minerárias e o meio ambiente devem ser observadas. Aliás, não é demais que se recorde os termos do artigo 2º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, que são os seguintes:

A PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições de desenvolvimento econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...].

A própria CF, ao dispor amplamente sobre as atividades de mineração, reconheceu a importância das mesmas. As únicas restrições que podem ser opostas às atividades minerárias, do ponto de vista ambiental, são aquelas com imediato assento constitucional. Tais restrições são:

- ser praticada em áreas definidas como intocáveis; e
- ser realizada em áreas indígenas sem autorização do Congresso Nacional e sem que as comunidades indígenas sejam consultadas.

Excetuando-se as duas vedações apresentadas, a atividade minerária será permitida, desde que, precedida de Estudo de Impacto Ambiental, conforme determinação constitucional contida no artigo 225, § 1º, inciso IV, e que sejam atendidas as condições contidas no § 2º do mesmo artigo 225, cujo teor é o seguinte:

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

16.4.1 Licenciamento das atividades de mineração

A mineração, assim como as demais atividades utilizadoras de recursos ambientais, está submetida à necessidade de licenciamento, para que possa ser exercida licitamente e de conformidade com a lei brasileira. Assim é em razão do artigo 10 da Lei nº 6.938/81. Há, entretanto, direito especial quanto ao regime jurídico do licenciamento das atividades minerárias, estabelecido pela Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, que altera o Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de matrículas e dá outras providências. Tanto a permissão de lavra garimpeira, tratada no artigo 3º da Lei nº 7.805/89, quanto a concessão de lavra, tratada no artigo 16, dependem de prévio licenciamento pelo órgão ambiental integrante do Sisnama.

Mandado de Segurança. Garimpo de Serra Pelada. Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada. Trabalhos de garimpagem e sua extensão. A Lei nº 7.194, de 11/6/1984, retirou 100 hectares da concessão da Companhia Vale do Rio Doce, localizados no Município de Marabá, PA, e os destinou a trabalhos exclusivamente por garimpagem, estabelecidos o prazo de três anos e a cota limite de 190 metros acima do nível do mar; para o exercício dessa atividade. A Lei nº 7.599, de 15/5/1987, no art. 3º, permitiu a garimpagem, no local, até 31 de dezembro de 1988, podendo esse prazo ser prorrogado por ato do poder executivo, alterando, ainda, o § 2º do art. 2º, da Lei nº 7.194/1984, para estipular que a garimpagem não se admitirá além da profundidade em que seja possível garantir o trabalho dos garimpeiros em condições de segurança, cabendo a grupo de trabalho, instituído nesse diploma, avaliar tais condições. A Lei nº 7.805, de 18/7/1989, que alterou o Decreto-lei nº 227/1967, criou o regime de permissão de lavra garimpeira, estabelecendo, em seu art. 3º, a necessidade de prévio licenciamento ambiental e estipulando, no art. 18, que os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão temporária ou definitiva, de acordo com parecer do órgão ambiental competente. o Decreto nº 99.385, de 12/7/1990, prorrogou, até 11 de março de 1991, o prazo para o término dos trabalhos exclusivamente por garimpagem, em Serra Pelada, prevendo que a cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada – Coomigasp – deveria apresentar, até 11 de janeiro de 1991, projeto demonstrando a viabilidade do prosseguimento das atividades de garimpagem no tocante ao aproveitamento racional do depósito, à segurança do trabalho, ao adequado atendimento das normas ambientais e à disponibilidade de recursos técnicos e financeiros para implantação das diretrizes nele preconizadas, observada a promoção econômica e social dos garimpeiros cooperativados. Prorrogação do término dos trabalhos de garimpagem, em Serra Pelada, ainda, por Decreto de 13/3/1991, até 11/6/1991, e, por fim, pelo Decreto de 12/6/1991, até 11/2/1992, explicitando-se, todavia, neste último diploma, que a prorrogação se aplica, exclusivamente, aos trabalhos desenvolvidos por garimpagem nos rejeitos oriundos da cava principal do garimpo. Legitimidade ativa da cooperativa impetrante para requerer mandado de segurança contra as restrições indicadas. Não aplicação à espécie da Súmula 266. Inexistência, entretanto, de direito certo e líquido ao prosseguimento de trabalhos de garimpagem, na área, sem as limitações do decreto impugnado. Pronunciamento da comissão interministerial, criada pelo Decreto nº 99.385, de 12/07/1990, desfavoravelmente ao projeto encaminhado pela impetrante, nos termos em que se formulou. Análise do parecer. Não cabe, na via eleita, a margem da discussão de fatos e provas, afastar, desde logo, as conclusões da comissão interministerial, para reconhecer, ao contrário, o direito da impetrante ao prosseguimento, puro e simplesmente, das atividades de garimpagem, na área anterior de cem hectares e na própria cava principal do garimpo. A limitação posta no decreto impugnado, quanto ao âmbito de atuação da garimpagem, no local, não é desautorizada pela Constituição (arts. 174, § 4º, e 21, XXV), ou pela legislação em vigor; e evidencia a possibilidade, ainda, de uma transição entre a situação anterior e outra que venha a definir-se. Não há dúvida de que graves problemas sociais e ambientais, no local, estão presentes, devendo encontrar a administração e a impetrante caminhos para sua solução. Exato é, porém, que não existe direito certo e líquido da impetrante ao que pretende, o que configura, por si só, a impossibilidade de conceder a segurança. Mandado de segurança indeferido (STJ. MS 21401. Relator: Ministro Néri da Silveira).

O artigo 17 da lei nº 7.805/1989 estabelece a possibilidade de que a pesquisa e a lavra possam ser realizadas em unidades de conservação, desde que haja prévia autorização do órgão ambiental responsável pela administração da unidade de conservação. O que a lei pretende é que, nas unidades de conservação nas quais sejam admitidas atividades econômicas, destas, a princípio, não se poderá excluir a atividade minerária. A exclusão da mineração somente poderá ser concebida se, no estudo de impacto ambiental, resultar demonstrado que os efeitos nocivos das atividades de mineração, na unidade específica, não podem ser mitigados adequadamente. A matéria deverá ser examinada, portanto, caso a caso, considerando-se os objetivos legais da unidade de conservação, a intangibilidade ou não de seu território e os efeitos concretos, previstos na avaliação dos impactos ambientais, da atividade pretendida. Conforme observa Marcelo Gomes de Souza: “O

16.4.2 Estudos de impacto ambiental e atividades de mineração

A mineração, obviamente, está submetida ao regime geral estabelecido pelo artigo 225, § 1º, IV, da Constituição, que determina a obrigatoriedade da realização de estudos de impacto ambiental para a atividade. Coloca-se a questão: toda atividade minerária deve ser submetida a estudo de impacto ambiental? Essa não é uma questão pacífica, pois autores há que entendem ser inconstitucional a exigência de estudos de impacto ambiental para toda e qualquer atividade de mineração, vez que é necessário “*seja levado em consideração se o aproveitamento do recurso mineral específico é ou não potencialmente causador de expressivo impacto ambiental*” (SOUZA, 1995, p. 133). A Resolução Conama nº 1, de 23 de janeiro de 1986, determina que:

Art. 2º Dependará de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do Ibama em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como [...] IX – extração de minério, inclusive os da classe II, definida no Código de Mineração [...].

Posteriormente, o próprio Conama fez editar a Resolução Conama nº 9, de 6 de dezembro de 1990, com o objetivo de definir mais claramente as normas pertinentes ao licenciamento ambiental das atividades de extração mineral das classes I, III, IV, VI, VII, VIII e IX do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967.

O licenciamento ambiental da atividade minerária é, prioritariamente, realizado pelos órgãos estaduais integrantes do Sisnama. O Ibama somente tem atuação supletiva, isto é, caso o órgão estadual deixe de realizar a sua tarefa. Não há que se falar em embargos administrativos promovidos pelo Ibama em razão de discordância com os termos do licenciamento estadual. Na hipótese em que a atividade minerária a ser desenvolvida tenha repercussão ambiental em mais de um Estado-Membro da federação, competirá ao Ibama a coordenação dos trabalhos de licenciamento.

O estudo de impacto ambiental deverá ser apresentado ao órgão fiscalizador juntamente com o requerimento de concessão da Licença Prévia (LP). Na fase posterior do processo de licenciamento, isto é, quando do requerimento da Licença de Instalação (LI), o empreendedor deverá apresentar o Plano de Controle Ambiental (PCA), o qual deverá conter os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais, analisados quando do requerimento de concessão da licença prévia (LP).

Observe-se que, nos termos em que está redigido o § 2º do artigo 5º da Resolução Conama nº 9/90, a concessão da licença de instalação (LI) é um direito do requerente, desde que o PCA tenha sido aprovado: *o órgão ambiental competente, após a aprovação do PCA do empreendimento, concederá a licença de instalação*. A licença de operação, igualmente, se constitui em direito do empreendedor, desde que tenham sido implantados os projetos previstos no PCA e que os mesmos estejam tendo desempenho satisfatório.

Art. 7º Após a obtenção da portaria de lavra e a implantação dos projetos constantes do PCA, aprovados quando da concessão da Licença de Instalação, o empreendedor deverá requerer a Licença de Operação, apresentando a documentação necessária [...] § 2º O órgão ambiental competente, após a comprovação da implantação dos projetos do PCA, concederá a Licença de Operação.

A Resolução Conama nº 1/86 menciona expressamente a Classe II como uma das categorias de atividades minerárias para as quais são exigidos estudos prévios de impacto ambiental. Ocorre que o próprio Conama, através da Resolução Conama nº 10, de 6 de dezembro de 1990, entendeu que nem sempre as atividades minerárias são *potencialmente causadora(s) de significativa degradação do meio ambiente*. Assim é que o artigo 3º da recém-mencionada resolução estabelece a possibilidade de dispensa da apresentação de estudo prévio de impacto ambiental. De fato, dispõe o artigo 3º do diploma legal:

A critério do órgão ambiental competente, o empreendimento, em função de sua natureza, localização, porte e demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

A expressão “a critério” deve ser entendida como: “não havendo impacto ambiental significativo”, haja vista que, caso exista o impacto significativo, o EIA não poderá ser dispensado.

Foi determinado ao empreendedor que, na hipótese de inexigibilidade de apresentação do EIA/RIMA, o mesmo deverá apresentar um Relatório de Controle Ambiental – RCA, elaborado segundo diretrizes fixadas pelo órgão ambiental.

As Licenças de Instalação (LI) e de Operação (LO), desde que o empreendedor tenha atendido às exigências legais, se constituem em direito do requerente. Como se vê, a Resolução Conama nº 10/90 derogou a Resolução Conama nº 1/86, no que se refere às atividades minerárias relativas aos minerais compreendidos na Classe II.

16.4.2.1 Ilegalidades existentes na Resolução nº 9/90 do Conama

O Conama, no uso de seu poder regulamentar, baixou as Resoluções nºs 9 e 10/90, com o objetivo de disciplinar o licenciamento e as exigências de estudos de impacto ambiental para as atividades de mineração. Do ponto de vista legal e regulamentar, a matéria está contida no Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e no Decreto nº 98.812, de 9 de janeiro de 1990.

A Resolução Conama nº 9, de 6 de dezembro de 1990, estabelece em seu artigo 1º que:

A realização de pesquisa mineral, quando envolver o emprego de guia de utilização, fica sujeita a prévio licenciamento ambiental pelo órgão competente.

Inicialmente, há que ser dito que o Código de Minas (Decreto-lei nº 227/1967), nos artigos 14/35, não faz qualquer menção à necessidade de licenciamento ambiental para a obtenção de autorização de pesquisa. Explica-se a circunstância em razão de que o Código é muito anterior à legislação ambiental. Evidentemente que o titular da autorização de pesquisa não pode se esquivar ao cumprimento das determinações legais contidas no artigo 47, especialmente naquilo que diz respeito à proteção ambiental. Ora, inexistindo norma no Código de Minas, a matéria deve ser examinada à luz dos demais dispositivos legais referentes às atividades minerárias. Dessa forma, é necessário que se examinem as disposições contidas na Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989. Tal lei tem por finalidade básica a disciplina da atividade de lavra garimpeira. Nos artigos 16, 17 e 18 estão os elementos básicos para que se possa examinar se o legislador objetivou a exigência de licenciamento ambiental para as atividades de pesquisa minerária. O artigo 16 estabelece que a concessão de lavra depende de prévio licenciamento ambiental. Não há qualquer menção à pesquisa mineral. Pelo artigo 17 verifica-se que as atividades de pesquisa e lavra em “*áreas de conservação*” (sic) dependem de prévia autorização do órgão ambiental que as administre. Nessa hipótese, embora não seja utilizada a expressão “licença ambiental”, na prática, o que ocorrerá é que o órgão ambiental responsável pela unidade de conservação realizará determinadas exigências ao empreendedor. Observe-se, contudo, que, uma vez que o licenciamento ambiental é, eminentemente, estadual, se a unidade de conservação for federal ou municipal, a pesquisa poderá ser realizada sem a licença estadual; já a lavra não. Assim é porque o artigo 16 exige o licenciamento ambiental para a lavra.

Pelo artigo 18, observa-se que o órgão ambiental, ainda que não tendo concedido licença para a pesquisa mineral, tem poderes para suspender os trabalhos, caso estes estejam sendo nocivos ao meio ambiente. Repetem-se, no artigo 19, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva daqueles que, exercentes de atividades minerárias, vierem a causar danos ao meio ambiente.

Observe-se que no Decreto nº 98.812, de 9 de janeiro de 1990, igualmente, e acertadamente, exige a licença ambiental para os trabalhos de pesquisa minerária. Merece ser ressaltado que, nas áreas de conservação (*rectius*: unidades de conservação), conforme estabelecido em lei, o artigo 19 do decreto condiciona a concessão de autorização para a pesquisa e a lavra ao consentimento do órgão gestor da unidade.

Parece-me, portanto, que há uma evidente ilegalidade na exigência de licenciamento ambiental para as atividades de pesquisa mineral, pois, nos termos da legislação vigente, a pesquisa mineral só depende do licenciamento exclusivamente mineral.

16.4.2.2 A extinção das classes minerais e os estudos de impacto ambiental

A extinção das classes minerais estabelecidas pelo Código tem enormes repercussões em tudo o que diz respeito à exigência de estudos de impacto ambiental. De fato, as resoluções do Conama pertinentes à matéria estão fundadas em uma exigência genérica vinculada às classes minerais. Ora, inexistentes as classes, como se deve aplicar a exigência dos estudos de impacto ambiental? Em minha opinião, enquanto não for editada uma nova resolução Conama, o assunto deve ser examinado casuisticamente. Isto é, em cada caso o órgão ambiental deverá verificar, concretamente, as possibilidades de impacto ambiental negativo e justificar o requerimento de que sejam realizados os estudos de impacto ambiental.

16.4.2.3 Atividades com repercussões ambientais em áreas indígenas

Como já foi dito em diversas oportunidades deste livro, muitas vezes, as atividades minerárias têm repercussão em áreas indígenas. Observe-se que, aqui, não se está a falar de atividades no *interior* de áreas indígenas, mas de atividades realizadas *fora* de áreas indígenas e que, eventualmente, poderão gerar consequências em terras indígenas. Tal matéria está submetida à regulamentação do Decreto nº 7.747/2012². O Serviço do Meio Ambiente das Terras Indígenas,³ vinculado à Coordenadoria de Patrimônio Indígena da Fundação Nacional do Índio – Funai, é o órgão responsável pela aprovação de projetos de órgãos públicos ou privados que possam acarretar impactos diretos ou indiretos ao meio ambiente das terras indígenas. Dentre as atribuições do mencionado Serviço do Meio Ambiente das Terras Indígenas (Semat), incluem-se as atribuições de elaborar e acompanhar os projetos de recuperação de áreas indígenas que tenham sofrido degradação ambiental e de acompanhar a execução de projetos que provoquem alterações do meio ambiente das terras indígenas. Situação diferente é a de atividades realizadas *no interior* de terras indígenas, pois, como foi visto, estas necessitam de autorização do Congresso Nacional.

16.4.3 Obrigação de recuperação ambiental da área degradada

Como se sabe, o Direito Ambiental consagra o princípio geral da responsabilização dos causadores de danos ambientais. Dentre os elementos fundamentais que constituem a obrigação de reparação do dano, encontra-se a *repristinação do meio ambiente* como um dos mais importantes aspectos a serem observados pelos utilizadores de recursos ambientais. A CF, contudo, no que diz respeito às atividades minerárias, foi redundante, pois, no § 2º do artigo 225, estabelece que:

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Sendo certo que no § 3º está determinado que: *As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.*

*Recurso Especial. Ação civil pública. Poluição ambiental. Empresas mineradoras. Carvão mineral. Estado de Santa Catarina. Reparação. Responsabilidade do Estado por omissão. Responsabilidade solidária. Responsabilidade subsidiária. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, mesmo em se tratando de responsabilidade por dano ao meio **ambiente**, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a lei. [...] 3. Condenada a União a reparação de **danos** ambientais, é certo que a sociedade imediatamente estará arcando com os custos de tal reparação, como se fora autoindenização. [...] 4. Havendo mais de um causador de um mesmo dano ambiental, todos respondem solidariamente pela reparação, na forma do art. 942 do CC. De outro lado, se diversos forem os causadores da degradação ocorrida em diferentes locais, ainda que contíguos, não há como atribuir-se a responsabilidade solidária adotando-se apenas o critério geográfico, por falta de nexo causal entre o dano ocorrido em um determinado lugar por atividade poluidora realizada em outro local. 5. [...] Portanto, (i) na falta do elemento “abuso de direito”; (ii) não se constituindo a personalização social obstáculo ao cumprimento da obrigação de reparação ambiental; e (iii) nem comprovando-se que os sócios ou administradores têm maior poder de solvência que as sociedades, a aplicação da disregard doctrine não tem lugar e pode constituir, na última hipótese, obstáculo ao cumprimento da obrigação. 6. Segundo o que dispõe o art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, os sócios/administradores respondem pelo cumprimento da obrigação de reparação ambiental na qualidade de responsáveis em nome próprio. A responsabilidade será solidária com os entes administrados, na modalidade subsidiária. 7. A ação de reparação/recuperação ambiental é imprescritível. [...] (STJ. REsp 200400327854. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. 2ª Turma. DJU 22/10/2007, p. 233).*

Obviamente que a reparação dos danos estabelecidos pelo § 3º somente pode ser considerada tecnicamente correta se feita de acordo com a orientação do órgão público competente. Admite-se, contudo, que o constituinte tenha buscado dar um relevo às atividades minerárias e aos danos que estas possam ter causado ao meio ambiente.

Após a promulgação da Constituição de 1988, foi baixado o Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989, com o objetivo de regulamentar o artigo 2º, inciso VIII, da Lei nº 6.938/81. O qual estabelece e que um dos princípios da PNMA é a recuperação das áreas degradadas. A degradação da qualidade ambiental é, nos termos da lei, *a alteração adversa das características do meio ambiente*.

É evidente que a degradação ambiental não decorre, apenas, das atividades minerárias. Entretanto, o Decreto nº 97.632/89 limitou-se a tratar de recuperação de áreas degradadas por atividades minerárias. Observe-se, ademais, que o decreto estabeleceu uma definição para degradação. Assim determina o artigo 2º:

Para efeito deste decreto são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas das suas propriedades, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.

O Código de Mineração, conforme o disposto em seu artigo 48, define a *lavra ambiciosa* como aquela “conduzida sem observância do plano preestabelecido, ou efetuado de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida.” Decorre daí que o Código tem duas preocupações básicas, a primeira que é a de assegurar que a lavra seja efetuada dentro de padrões técnicos que garantam a salubridade da atividade, e a segunda, com o objetivo de manter um determinado grau de sustentabilidade da atividade minerária. Sabemos, entretanto, que os recursos minerais não são renováveis e que, para a sua extração, não raro, são necessárias atividades que criam modificações ambientais irreversíveis. Tais modificações, durante a realização das atividades de extração mineral, não podem ser impedidas. Como exemplo é possível apresentar o desmonte de um morro para a extração de determinado minério. Dificilmente o morro poderá ser reconstituído e, em seu lugar, poderá surgir uma cratera. Bem se vê que, no caso, não se poderá falar em *repristinação ambiental* ante a total impossibilidade, pelo menos em nível de nossa melhor tecnologia atualmente existente.

Penso que a situação que está colocada é interessante, pois, de fato, não se poderia adotar a designação *degradação* para as atividades minerárias, regularmente realizadas e praticadas segundo os ditames dos licenciamentos, inclusive o ambiental. Assim é porque, nos termos da lei, a degradação é uma alteração adversa do meio ambiente e, portanto, proibida. Analisando-se a questão sob outro prisma, observa-se que o legislador, diante das importantes repercussões econômicas e sociais das atividades minerárias, estabeleceu um critério diferenciado para a prática de tais atividades. Embora tenha exigido que as mesmas se façam com respeito à legislação de proteção do meio ambiente e mediante critérios bastante rígidos de segurança, admitiu que, durante a fase de extração, são inevitáveis os resultados negativos sobre o meio ambiente.

A recuperação dos danos ambientais causados pela mineração é, precipuamente, uma atividade de *compensação*, pois raramente é possível o retorno, ao *status quo ante*, de um local que tenha sido submetido a atividades de mineração.

a) Alíquotas das substâncias minerais:

ALÍQUOTA	SUBSTÂNCIA MINERAL
(VETADO)	(VETADO)
1% (um por cento)	Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias minerais quando destinadas ao uso imediato na construção civil; rochas ornamentais; águas minerais e termais
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)	Ouro
2% (dois por cento)	Diamante e demais substâncias minerais
3% (três por cento)	Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema
3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento)	Ferro, observadas as letras <i>b</i> e <i>c</i> deste Anexo

- b) Decreto do Presidente da República, a ser publicado em até noventa dias a partir da promulgação desta Lei, estabelecerá critérios para que a entidade reguladora do setor de mineração, mediante demanda devidamente justificada, possa reduzir, excepcionalmente, a alíquota da CFEM do ferro de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para até 2% (dois por cento), com objetivo de não prejudicar a viabilidade econômica de jazidas com baixos desempenho e rentabilidade em razão do teor de ferro, da escala de produção, do pagamento de tributos e do número de empregados.
- c) A decisão e o parecer técnico da entidade reguladora do setor de mineração relativos à redução da alíquota da CFEM, de que trata a letra *b* deste Anexo, serão divulgados em seu sítio oficial na internet, e a redução somente entrará em vigor sessenta dias a partir da divulgação.

16.4.4 Cavernas

As cavernas são cavidades subterrâneas que integram o patrimônio da União, conforme expressa previsão constitucional. As chamadas cavernas são elementos muito importantes do ponto de vista ambiental e do ponto de vista turístico. É desnecessário dizer que as atividades econômicas de grande impacto ambiental e, em especial a mineração, podem causar importantes repercussões sobre as cavidades naturais, muito embora o tema ainda não tenha merecido a devida atenção por parte da doutrina, da jurisprudência e mesmo da legislação. Há, contudo, uma tendência à valorização das cavidades subterrâneas, com repercussões judiciais. Em nível federal a matéria está regulada por decreto. (Decreto nº 99.556, de 1ª de outubro de 1990) *Penal e ambiental. Arts. 55 e 62, I, da Lei nº 9.605/98. Supressão parcial de gruta. Reconhecimento legal como patrimônio cultural nacional. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Extração de minério sem autorização do DNPM. Excesso no exercício da atividade de pesquisa. I. Apelações dos réus (pessoa natural e pessoa jurídica) e do Ministério Público Federal em ação relativa à prática dos crimes previstos nos arts. 55 e 62, I da Lei nº 9.605/98. II. O reconhecimento da gruta parcialmente suprimida pela ação dos réus como patrimônio cultural nacional, de acordo com os meios normativos previstos, é suficiente para a configuração objetiva do delito do art. 62, I, da Lei de Crimes Ambientais, sendo impertinente a alegação de ser a proteção ao local (“Gruta do Vitor”, em São Rafael/RN) baseada em credences sem fundamentação fática. III. “Em regra, não cabe a aplicação do princípio da insignificância jurídica em delitos ambientais, porquanto a ofensa ao bem jurídico tutelado não pode ser mensurada por critérios quantitativos, pois a potencialidade do ato atinge diretamente a higidez do meio ambiente, cuja preservação é salvaguardada pelo poder público para a presente e futuras gerações” (TRF/4ª Região, ACR nº 2005.71.00.016071-6, Oitava Turma, Rel. Elcio Pinheiro de Castro, DJ 28/2/2007). IV. Redução do quantum da multa, para adequá-lo ao patamar de razoabilidade em virtude do tamanho da empresa e da manutenção de sua viabilidade econômica. V. Ainda que os autores detenham alvará de pesquisa da lavra expedido pelo DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, a atividade que extrapole o limite imposto pela Administração e configure extração intensiva do minério da área configura a hipótese do art. 55 da Lei nº 9.605/98, não sendo o mencionado ato administrativo um salvo-conduto genérico para a atuação econômica dos particulares. VI. Apelação dos réus parcialmente provida, apenas para a redução da multa imposta. Apelação do MPF provida (TRF da 5ª Região. ACR 200684020000400. Relator Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho. 4ª Turma. DJU 28/5/2009, p. 306).*

16.4.4.1 Proteção ao patrimônio espeleológico

O MMA, mediante a expedição da Portaria MMA nº 358, de 30 de setembro de 2009 instituiu o “Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico”, o qual a estratégia nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico se fundamenta nos seguintes princípios: (i) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações; (ii) onde exista evidência científica de dano irreversível à diversidade biológica, o Poder Público determinará medidas eficazes para evitar a degradação ambiental; (iii) a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente deverá ser precedida de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; e (iv) o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco, incluindo os valores ecológico, geológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético.

As diretrizes gerais a serem adotadas pelo Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico são: (i) valorização do Patrimônio Espeleológico, bem da sociedade brasileira; (ii) integração de ações setoriais, por meio da descentralização de ações, do fortalecimento da ação governamental, do estabelecimento de parcerias e envolvimento dos setores interessados na implementação do Programa; (iii) abordagem ecossistêmica para a gestão do Patrimônio Espeleológico, avaliando problemas, identificando soluções e propondo medidas adequadas de conservação, uso sustentável e recuperação dos recursos da geodiversidade.

16.4.4.1.1 Atribuições do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes

Para a implementação do Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico, cabe ao Instituto Chico Mendes propor ao MMA: (i) articulação das ações do Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama e junto aos demais setores do governo e da sociedade; (ii) projetos em apoio às ações previstas no Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico, buscando recursos financeiros; (iii) articulação com os Ministérios afetos aos temas tratados para a elaboração e encaminhamento de propostas de criação ou modificação de instrumentos legais necessários à execução do Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico; (iv) integração de políticas setoriais visando à implementação de ações direcionadas à gestão sustentável do Patrimônio Espeleológico (conservação, utilização sustentável, avaliação de impactos); e (v) estímulo à cooperação interinstitucional e internacional para a melhoria da implementação das ações de gestão do Patrimônio Espeleológico.

Competindo-lhe ainda: (i) coordenar a elaboração do Programa, definindo as metas a serem alcançadas, o arranjo de implementação do Programa, as parcerias necessárias e os indicadores para alcance do objetivo do Programa; (ii) acompanhar e avaliar a execução dos componentes do Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico; (iii) monitorar, inclusive com indicadores, a execução das ações previstas do Programa Nacional do Patrimônio Espeleológico; (iv) coordenar a elaboração de Planos de Ação para o patrimônio espeleológico, decorrentes das metas estabelecidas no Programa; e (v) acompanhar, monitorar e avaliar a execução de Planos de Ação, decorrentes do detalhamento das metas do Programa.

Determina o Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 6.640/08, que as cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. Para os fins de aplicação da norma, cavidade natural subterrânea é *“todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, fuma ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante”*.

As cavidades naturais subterrâneas deverão ser classificadas conforme o grau de relevância, que é dividido em (i) máximo, (ii) alto, (iii) médio ou (iv) baixo. A classificação é feita de acordo com análise dos atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local, ou seja, as cavidades não são consideradas em relação ao conjunto de cavidades subterrâneas existentes em todo o território nacional, mas apenas e tão somente em relação aos níveis regional e local. Isso quer dizer que há uma valorização efetiva das cavidades, pois regional ou localmente elas podem ter uma relevância que não teriam se examinadas dentro de um contexto mais amplo.

A análise dos diferentes atributos deverá ser assim procedida: i) geológicos: comparando cavidades da mesma litologia; ii) enfoque local: a unidade espacial que engloba a cavidade e sua área de influência; iii) enfoque regional: a unidade espacial que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente no qual se insere.

Conforme a importância, os atributos deverão ser classificados em (i) acentuados, (ii) significativos ou (iii) baixos. Para que se caracterize o grau de relevância máxima, a cavidade natural deverá ter pelo menos um dos seguintes atributos: (i) gênese única ou rara; (ii) morfologia única; (iii) dimensões notáveis em extensão, área ou volume; (iv) espeleotemas únicos; (v) isolamento geográfico; (vi) abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais; (vii) *habitat* essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos; (viii) *habitat* de troglóbio raro; (ix) interações ecológicas únicas; (x) cavidade testemunho; ou (xi) destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.

O atributo de isolamento geográfico só é considerado no caso de cavidades com grau de relevância alto e médio. A administração deverá baixar “ato normativo” enquadrando as cavidades nos respectivos graus de relevância. A cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto é aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que trata o artigo 5º do Decreto: (i) acentuada sob enfoque local e regional; ou (ii) acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. A cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio é aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que trata o artigo 5º do decreto: (i) acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou (ii) significativa sob enfoque local e regional. A cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo é aquela cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que trata o artigo 5º do decreto: (i) significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou (ii) baixa sob enfoque local e regional.

Pelo que se pode perceber do artigo 2º, § 9º, do decreto, a classificação das cavidades deverá ser feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pois *“diante de fatos novos, comprovados por estudos técnico-científicos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes poderá rever a classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, tanto para nível superior quanto inferior”*. A metodologia a ser observada para a classificação do grau de relevância das cavidades naturais subterrâneas, considerando o disposto no artigo 2º do decreto, é definida *“em ato normativo”* do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama e demais setores governamentais afetos ao tema.

a) Impacto nas cavidades subterrâneas

A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área de influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, somente se admitindo sua utilização dentro de condições que assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico. *“Mandado de Segurança – Cavidade natural subterrânea denominada “Grutas de São Miguel” no município de Bonito/MS I – Desprovida a impetrante de autorização da autoridade competente (Ibama) a fim de permitir a exploração turística e econômica de cavidade natural subterrânea denominada “Grutas de São Miguel”, revela-se conforme as normas legais e regulamentares a interdição do empreendimento promovida pela autoridade coatora. II – Estudo encomendado pela impetrante que não tem o condão de suprir as exigências da legislação que rege a exploração turística e econômica do patrimônio ambiental em comento, sendo imprescindível aguardar-se a autorização da autoridade ambiental competente (Ibama) para então iniciar-se a exploração do local, mediante o atendimento das condições a serem impostas pelo agente fiscalizador, a fim de resguardar o bem explorado de qualquer possibilidade de poluição ou degradação pelo uso predatório.”* (TRF da 3ª Região. AMS 200060000048366. Relatora: Juíza Cecília Marcondes. 3ª Turma. DJU 23/8/2006, p. 575).

Curiosamente, o decreto admite que as cavidades naturais subterrâneas com graus de relevância alto, médio ou baixo possam ser objetos de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental. O decreto estabeleceu um tipo de compensação ao impacto ambiental irreversível sofrido pela cavidade, mediante o estabelecimento, no processo de licenciamento ambiental, de *“medidas e ações para assegurar a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho”*. A medida, do ponto de vista puramente numérico, é boa, vez que estabelece uma proporção de 2:1 e garantia da conservação da cavidade subterrânea testemunho, contudo, parece-me que uma medida adicional necessária seria a de que, ao longo do processo de licenciamento ambiental, fosse estabelecido um mecanismo claro de análise custo-benefício, inclusive do ponto de vista econômico, relacionado aos benefícios do projeto em relação à destruição da cavidade subterrânea natural. O § 3º do artigo 4º estabelece que: *“não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades representativas que possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto Chico Mendes poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de compensação”*. Aqui, do ponto de vista legal, existe um problema complexo, pois a compensação ambiental, tal como hoje vigente no país, se faz de acordo com os termos do artigo 36 da Lei do SNUC, sendo certo que nas hipóteses de licenciamento ambiental mediante Estudo Prévio de Impacto Ambiental, será devido um percentual correspondente ao grau de impacto, tal como calculado pelo EIA. Ora, havendo a destruição total de uma cavidade subterrânea natural, sem a possibilidade de manutenção de uma cavidade “testemunho”, tal impacto será necessariamente negativo e significativo, até mesmo porque o decreto os define como “irreversíveis”.

Está claro que os impactos ambientais negativos e irreversíveis são admitidos pelo direito ambiental brasileiro, contudo, é necessário que eles sejam menores do que os benefícios advindos da implantação da atividade impactantes. Dessa forma, penso ser absolutamente necessária, repito, a elaboração de análise econômica da relação custo-benefício resultante da implantação do empreendimento.

Nas hipóteses de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo e alto. Quando se tratar de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo, o empreendedor não estará obrigado a adotar medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades naturais subterrâneas.

b) Licenciamento ambiental

O decreto, de forma redundante, determina em seu artigo 5º-A que *“a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente”*. Contudo, os demais parágrafos do artigo 5º-A e o próprio artigo 5º-B criaram um

quadro normativo bastante confuso e, até mesmo, gerador de insegurança jurídica.

Vejamos o § 1º do artigo 5º-A, que determina que: *“O órgão ambiental competente, no âmbito do processo de licenciamento ambiental, deverá classificar o grau de relevância da cavidade natural subterrânea, observando os critérios estabelecidos pelo MMA.”* Tal parágrafo é contraditório com o § 9º do artigo 2º, o qual determina que o ICMBio deverá reclassificar as categorias das cavidades subterrâneas diante de fatos novos. É ilícito imaginar que a classificação deva ser feita pelo ICMBio e não pelos órgãos ambientais estaduais ou municipais, até mesmo porque, do ponto de vista jurídico, um órgão estadual ou municipal jamais poderia autorizar a destruição de um bem da União, como são as cavidades subterrâneas, igualmente, por não serem titulares do bem, não poderiam autorizar-lhes a utilização. Fato é que as cavernas são bens imóveis da União e os estados e municípios, por mais que autorizem a sua utilização, do ponto de vista ambiental, não podem fazê-lo do ponto de vista patrimonial e o decreto deveria ter cuidado de tal peculiaridade.

Determinou o decreto que os estudos para a definição do grau de relevância das cavidades subterrâneas *“impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável pelo empreendimento ou atividade”*. Os empreendimentos ou atividades *“já instalados ou iniciados terão prazo de noventa dias, após a publicação do ato normativo de que trata o art. 5º, para protocolar junto ao órgão ambiental competente solicitação de adequação”* ao decreto.

-
- 1 Ver item relativo aos asbestos em produtos perigosos.
 - 2 Ver Capitulo relativo às Terras Indígenas.
 - 3 Instituído pela Portaria nº 422, de 25/4/1989, da Presidência da Funai.
 - 4 Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990.

CONTROLE DE PRODUTOS TÓXICOS

§ 1º PRODUTOS TÓXICOS EM GERAL

17.1 INTRODUÇÃO

O controle das substâncias tóxicas encontra o seu fundamento constitucional no inciso V do § 1º do artigo 225 combinado com o artigo 200 da Lei Fundamental. Além disso, tais substâncias estão submetidas ao poder de polícia. É necessário estruturar um sistema de controle de substâncias tóxicas capaz de diminuir o risco que elas representam para a vida humana. Embora não haja maior dificuldade na compreensão dessa necessidade, a sua concretização não é muito simples. A preocupação com os produtos tóxicos é recente. Foi somente com o aparecimento do livro *Silent Spring*, da escritora Rachel Carson, que o problema ganhou dimensão planetária. Isso ocorreu no ano de 1962, nos Estados Unidos da América. O livro foi o primeiro libelo contra a poluição causada por produtos químicos, notadamente pelos pesticidas. *Silent spring* alcançou a notável marca de meio milhão de exemplares vendidos, tendo permanecido por 31 semanas na lista de *best-sellers* do *New York Times* (McCORNICK, 1992, p. 63).

É importante observar que antes da publicação de *Silent Spring* os “acidentes” com produtos tóxicos não mereciam maior atenção das autoridades ou mesmo da opinião pública: A inquietação difundida pelos efeitos da precipitação nuclear e pelas advertências de *Silent Spring* se combinou no período de 1966-1972 com uma série de “desastres ambientais” – acontecimentos que figuraram em manchetes de jornal e tiveram um efeito catalisador sobre os temores ambientais. Houve desastres ambientais comparáveis antes, alguns deles em passado muito recente. Em 1948, por exemplo, vinte pessoas morreram e 43% da população de Donora, Pensilvânia, caíram doentes em consequência de um nevoeiro sulfuroso. Uma mistura de nevoeiro e fumaça (o smog) típica do inverno desceu sobre Londres entre 5 e 10 de dezembro de 1952, tendo sido responsável, segundo o Conselho do Condado de Londres, pela morte imediata de 445 pessoas; ao todo, mais de quatro mil pessoas morreram, a maioria por condições circulatórias e respiratórias de longo prazo provocadas pelo nevoeiro. O acontecimento foi diretamente responsável pela aprovação na Grã-Bretanha da Lei do Ar Limpo, em 1956 (McCORNICK, 1992, p. 71).

Infelizmente, não temos, no Brasil, um diagnóstico adequado dos problemas causados por produtos químicos e outras formas de poluição. O caso de poluição mais notório do Brasil é, sem dúvida, o da cidade de Cubatão, no Estado de São Paulo. O relatório apresentado pelo Governo brasileiro à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, contém alguns elementos elucidativos, ainda que tímidos, da tragédia que se desenrolou e ainda se desenrola naquela cidade, *in verbis*: “A presença de zonas habitadas sobre áreas de passagens de dutos para o transporte de produtos perigosos, sujeitando milhares de pessoas a acidentes de grandes proporções, provocou, nesse mesmo ano de 1984, a tragédia da Vila Socó. A explosão e incêndio de 700 mil litros de gasolina mataram mais de 100 pessoas” (BRASIL, 1991, p. 50).

Convém, no entanto, que não sejam esquecidas as palavras de Jean Dorst (1973, p. 205): “Trata-se, na realidade, de um assunto extraordinariamente complexo, e é muito difícil ter atualmente uma visão serena e objetiva. Demasiados interesses materiais e financeiros – indústria química, produção agrícola – e demasiados sentimentalismos e conclusões apressadas complicaram um problema sobre o qual, no entanto, já possuímos atualmente uma série de informações provenientes de um número crescente de experiências e observações. As conclusões conduziram, frequentemente, a posições extremadas em que a impulsividade de uns se opunha aos interesses materiais de outros”.

17.2 CONTROLE DE PRODUTOS PERIGOSOS

17.2.1 Convenções internacionais

17.2.1.1 Convenção de Basileia

É uma importantíssima norma internacional que foi incorporada ao Direito brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 34, de 1992. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 463, de 21 de novembro de 2001, que “aprova os textos da Emenda ao Anexo I e dos dois novos Anexos (VIII e IX) à Convenção de Basileia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito, adotados durante a IV Reunião da Conferência das Partes, realizada na Malásia, em 27 de fevereiro de 1998”. O texto original da Convenção foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993, publicado em 20 de julho de 1993.

A Convenção tem por objetivo reduzir a circulação internacional de resíduos perigosos, tendo em vista que as Partes consideram “que a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos perigos que esses resíduos representam é a redução ao mínimo da sua geração em termos de quantidade e/ou potencial de seus riscos”. A Convenção definiu que são resíduos perigosos: (a) Resíduos que se enquadram em qualquer categoria contida no Anexo I, a menos que não possuam quaisquer das características descritas no Anexo III; e (b) Resíduos não cobertos pelo parágrafo (a) mas definidos ou considerados resíduos perigosos pela legislação interna da Parte que seja Estado de exportação, de importação ou de trânsito; (c) Os resíduos que se enquadram em qualquer categoria contida no Anexo II e que sejam objeto de movimentos transfronteiriços serão considerados “outros resíduos” para os fins da Convenção; (d) Os resíduos que, por serem radioativos, estiverem sujeitos a outros sistemas internacionais de controle, inclusive instrumentos internacionais que se apliquem especificamente a materiais radioativos, ficam excluídos do âmbito da Convenção; (e) Os resíduos derivados de operações normais de um navio, cuja descarga esteja coberta por um outro instrumento internacional, ficam excluídos do âmbito da Convenção.

A Convenção determina que cada Parte deve informar às demais, por meio do Secretariado, como define em sua legislação local os resíduos perigosos. Pelo artigo 4 da Convenção foram estipuladas obrigações gerais para as Partes quanto à informação às demais sobre a implementação do direito de proibir ou não permitir importação de resíduos perigosos, bem como de proibir ou não permitir a exportação de resíduos perigosos; sem a concordância por escrito do estado importador, considera-se crime internacional a movimentação internacional de resíduos perigosos fora dos termos da Convenção.

17.2.1.2 Convenção de Roterdã

A Convenção de Roterdã foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 197, de 7 de maio de 2004, e promulgada pelo Decreto nº 5.360, de 31 de janeiro de 2005, tendo entrado em vigor aos 24 de fevereiro de 2004.

A Convenção de Roterdã visa a estabelecer os mecanismos para que as populações envolvidas possam ter uma informação adequada sobre a movimentação internacional de substâncias químicas perigosas e agrotóxicos. A Convenção objetiva promover a responsabilidade compartilhada e esforços cooperativos entre as Partes no comércio internacional de certas substâncias químicas perigosas, visando à proteção da saúde humana e do meio ambiente contra danos potenciais e contribuir para o uso ambientalmente correto desses produtos, facilitando o intercâmbio de informações sobre suas características, estabelecendo um processo decisório nacional para sua importação e exportação e divulgando as decisões resultantes às Partes. Tal Convenção é de grande importância, por exemplo, para a agricultura, visto que trata de agrotóxicos, dentre outros produtos.

17.2.1.3 Convenção de Estocolmo

É a mais recente das Convenções internacionais destinadas a tratar de produtos químicos perigosos. No caso, ela é voltada especificamente para os chamados poluentes orgânicos persistentes (POPs). Ela foi promulgada pelo decreto nº 5.472, de 20 de junho de 2005.

Um dos objetivos fundamentais da Convenção é fazer com que cada uma das Partes adote medidas para reduzir ou eliminar as liberações decorrentes de produção e uso intencionais dos poluentes orgânicos persistentes que, em essência, são os chamados organoclorados. Assim, é lícito aos Estados que proíbam e/ou adotem medidas jurídicas e administrativas que sejam necessárias para eliminar a produção e utilização das substâncias químicas relacionadas no Anexo A da Convenção, de acordo com as disposições especificadas naquele Anexo; e também a importação e exportação das substâncias químicas relacionadas no Anexo A, de acordo com as disposições do parágrafo 2 da Convenção; e restringir a produção e utilização das substâncias químicas relacionadas no Anexo B, de acordo com as disposições especificadas naquele Anexo.

17.2.2 Normas internas

17.2.2.1 Asbestos (amianto)¹

Amianto é denominação de origem latina (*amianthus*): “incorrutível, sem mácula”. Existem dois importantes grupos de rochas amiantíferas: as *serpentin*as e os *anfíbólios*. As variedades de amianto desses dois grupos são distintas tanto nas aplicações como nos riscos que podem causar à saúde humana. A principal variedade de serpentina é a crisotila ou amianto branco, correspondendo a quase 98,5% de todo o amianto utilizado no mundo. Os anfíbólios são fibras duras, retas e pontiagudas. Agrupam-se em cinco variedades principais: *amosita* (amianto marrom), *crocidolita* (amianto azul), *antofilita*, *tremolita* e *actinolita*. Do ponto de vista econômico, os dois primeiros são os mais importantes. Muito utilizados até os anos de 1970, atualmente estão em desuso, por causa de seus efeitos sobre a saúde.

Foram os anfíbólios que produziram a má fama do amianto. Atualmente, o amianto marrom e o amianto azul representam menos de 1,5% do consumo mundial, estando localizados os seus centros produtivos na África do Sul, e seu uso é cada dia mais insignificante.

17.2.2.1.1 Utilização do amianto

O amianto é um produto que se presta a inúmeras utilizações comerciais e industriais. Estima-se que mais da metade das construções realizadas nos Estados Unidos entre 1950 e 1970 possuam algum tipo de asbesto em sua composição. “Literalmente, milhões de casas, escolas, edifícios públicos estaduais e federais, e estruturas comerciais e industriais beneficiaram-se de suas propriedades de resistência ao fogo” (EBLEN e EBLEN, 1994, p. 39).

Em razão de suas múltiplas propriedades físico-químicas, o amianto tem tido, ao longo da história, milhares de aplicações. Entretanto, ultimamente, tais aplicações estão reduzidas a cerca de uma centena. Passo a expor as principais utilizações do amianto:

- i) Cimento-amianto: mais de 80% do consumo mundial de amianto é realizado por esse segmento. Anualmente, produzem-se, mundialmente, cerca de 30 milhões de toneladas de telhas onduladas, placas de revestimento, painéis divisórios, tubos, caixas d’água e outros artigos necessários para a construção civil. No Brasil, o cimento-amianto responde por quase 90% do amianto consumido. Registre-se que mais de 50% dos telhados no Brasil são de cimento-amianto.
- ii) Produtos de fricção: utilização na indústria automobilística e ferroviária para a confecção de pastilhas, lonas de freio e discos de embreagem.
- iii) Indústria têxtil: é utilizado para a confecção de mantas para isolamento térmico de caldeiras, motores, automóveis, tubulações e equipamentos diversos, em particular para as indústrias química e petrolífera, e também na produção de roupas especiais (macacões, aventais e luvas) e biombos de proteção contra fogo.
- iv) Produção de filtros: serve para a produção de filtros especiais que são utilizados nas indústrias farmacêutica e de bebidas (cervejas e vinhos) e na fabricação de soda cáustica, dentre outros.
- v) Indústria de papéis e papelões: laminados de papel ou papelão utilizados como isolante térmico e elétrico de fornos, caldeiras, estufas, tubulações de transporte marítimo e embalagens especiais.
- vi) Material de vedação: é utilizado em combinação com outros produtos para a produção de juntas de revestimento e vedação, guarnições diversas, além de mástiques e massas especiais, usadas em setores como a indústria automotiva e a de extração de petróleo.
- vii) Isolantes térmicos para as indústrias aeronáutica e aeroespacial.
- viii) Revestimentos de piso.

17.2.2.1.2 Amianto e a saúde humana

Os principais problemas relacionados com os asbestos dizem respeito à sua presença no ar atmosférico e consequente inalação. As suas microfibras penetram nas vias respiratórias e podem acarretar doenças graves. De fato, as repercussões do amianto sobre a saúde humana são a principal discussão sobre o produto, pois ninguém desconhece a sua importância econômica. Toda a polêmica teve início na década de 1960, quando veio a público um estudo de casos de doenças em uma mina de amianto anfíbólio na África do Sul. O amianto vem sendo estudado há muitos anos e, sem dúvida alguma, já existe um nível de conhecimento científico bastante importante sobre o mesmo. O amianto pode estar relacionado com três doenças principais: a asbestose, o câncer do pulmão e o mesotelioma. As doenças eram decorrentes de uma intensa exposição dos operários à poeira do amianto, sobretudo nas minas e quando da aplicação por jateamento (*spray*) de isolantes térmicos em navios, casas e prédios.

Algumas conclusões científicas podem ser adiantadas:

- i) O amianto é nocivo apenas aos pulmões.
- ii) A asbestose, o câncer do pulmão e o mesotelioma são males que demoram cerca de 15 a 40 anos para se manifestar e só estão sob risco os trabalhadores expostos, durante longos períodos, a altas concentrações de fibras.

Asbestose. Doença pulmonar relacionada com a prolongada inalação de poeira contendo alta concentração de fibras de amianto. As fibras alojam-se nos alvéolos pulmonares, e, para se defender, o organismo deposita sobre elas uma proteína semelhante a um cimento, que cicatriza o alvéolo, impedindo que se encha de ar. Esse processo, repetindo-se intensamente ao longo dos anos, pode tornar o pulmão fibrosado e sem elasticidade, com dificuldades respiratórias. O período médio de aparecimento da doença é de 15 anos.

Câncer do pulmão. É semelhante ao câncer causado pelo fumo. Do início da exposição às fibras de amianto até o aparecimento do câncer passam-se em média 20 anos.

Mesotelioma. Forma muito rara de tumor maligno que se desenvolve no mesotélio, a membrana que envolve o pulmão (pleura), o abdômen e seus órgãos (peritônio). O período médio de aparecimento da doença, desde o início da exposição, é de 30 a 40 anos.

17.2.2.2 Quadro legal sobre a matéria

17.2.2.2.1 Regulamentação do Conama

A primeira regulamentação da utilização de asbestos no Brasil, em termos ambientais, foi feita pelo Conama que, mediante a Resolução nº 5, de 24 de janeiro de 1986, constituiu uma comissão especial, com a finalidade de estudar os problemas ambientais relacionados com a utilização de Amianto/Asbestos.² Posteriormente, o próprio Conama, através da Resolução nº 7, de 16 de setembro de 1987,³ fixou normas regulamentadoras do uso do amianto.

O artigo 3º da Resolução Conama nº 7, de 16 de setembro de 1987, determina que: *O não cumprimento do disposto nesta Resolução acarretará aos infratores multa de 10 a 1.000 OTNs, aplicável em dobro nas reincidências, na forma do art. 14 e alíneas, da Lei nº 6.938 e do Decreto nº 88.351, artigo 37 e alíneas, complementado pelo Decreto nº 89.532/84.*

A Resolução em tela limita-se a estabelecer alguns mecanismos de identificação do produto, que deverão ser observados, sob pena da aplicação de multas e sanções administrativas. Não se estabeleceu nenhum mecanismo com a finalidade de promover estudos visando substituir a utilização do amianto por produtos inofensivos, ou menos agressivos. Deve ser observado que a política de “controle” estabelecida pelo Conama não logrou produzir nenhum resultado significativo. Em verdade, a produção de asbestos aumentou, apesar da crise econômica e da recessão que há muito atingem o país, como apontam dados do próprio IBGE:⁴

A produção de asbesto [...] apresentava tendência crescente já no ano de 1989, quando a atividade de indústria como um todo declinava.

17.2.2.2.2 Portaria nº 1, de 28 de maio de 1991 (Secretaria Nacional do Trabalho)

A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que *trata da utilização do asbesto em condições de segurança* – 1986, foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991. A aplicação do documento internacional no país foi regulamentada pela Portaria nº 1, de 28 de maio de 1991, baixada pelo diretor do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

O mencionado diploma legal estabeleceu os limites de tolerância para as poeiras minerais-asbesto, limites estes que são aplicáveis a quaisquer atividades nas quais os trabalhadores estejam expostos ao asbesto no exercício de trabalho. A exposição ao asbesto foi definida como:

A exposição no trabalho às fibras de asbesto respiráveis ou poeira em suspensão no ar originada pelo asbesto ou por minerais, materiais ou produtos que contenham asbesto.

A mencionada portaria proibiu a pulverização (*spray*) de toda e qualquer forma de asbesto. Foi estabelecido, igualmente, um cadastro de todas as empresas que utilizam asbestos.

Providências ambientais

Elaboração de plano prévio aos trabalhos de remoção ou desmonte, em conjunto entre os trabalhadores e a empresa, com vistas a:

- i) proporcionar toda proteção necessária aos trabalhadores;
- ii) limitar o desprendimento de poeira de asbesto no ar;
- iii) prever a eliminação dos resíduos que contenham asbesto.

Avaliação ambiental da poeira de asbesto em períodos não superiores a seis meses.

Manutenção dos registros pelo prazo mínimo de 30 anos.

Participação dos trabalhadores no processo de avaliação ambiental.

Direito dos trabalhadores de solicitar avaliação ambiental complementar ou impugnar o resultado daquela realizada.

Fixação de padrões de qualidade do ar (fibras respiráveis).

Responsabilidade do empregador quanto à eliminação dos resíduos de asbesto sem prejuízo para o meio ambiente e para a população em geral.

17.2.2.2.3 Lei nº 9.055, de 19 de junho de 1995 e Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997

Após as normas legais mencionadas, com natureza hierárquica inferior, o país atingiu um novo patamar legal sobre a matéria com a edição da Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, que:

disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras providências.

Essa lei, em termos gerais, segue e mantém os compromissos que a nação assumiu no âmbito internacional ao firmar e ratificar a Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho – OIT.

Na forma do artigo 1º da Lei nº 9.055/95, ficou vedada em todo o território nacional:

I – a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização da actinolita, amosita (amianto marrom), antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais pertencentes ao grupo dos anfíbios, bem como dos produtos que contenham estas substâncias minerais;

II – a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei;

III – a venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º da norma que ora está sendo analisada.

O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco), do grupo dos minerais das serpentinhas, e as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim, somente podem ser extraídos, industrializados, utilizados e comercializados em consonância com as disposições contidas na lei. Para os

efeitos da norma, são consideradas fibras naturais e artificiais as fibras naturais e artificiais referidas no artigo 2º, contidas na legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, nos acordos internacionais ratificados pela Constituição da República Federativa do Brasil e nos acordos assinados entre os sindicatos de trabalhadores e os seus empregadores, atualizadas sempre que necessário.

Os órgãos competentes de controle de segurança, higiene e medicina do trabalho foram incumbidos do desenvolvimento de programas sistemáticos de fiscalização, monitoramento e controle dos riscos de exposição ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais tratadas no artigo 2º da lei. Tal atribuição pode ser exercida diretamente ou através de convênios com instituições públicas ou privadas credenciadas para tal fim pelo Poder Executivo.

O legislador determinou às empresas que manipulem ou que utilizem materiais contendo asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras naturais e artificiais que enviassem, anualmente, ao Sistema Único de Saúde e aos sindicatos representativos dos trabalhadores, uma relação dos seus empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante. Determinou, ainda, que todos os trabalhadores das empresas que lidam com o asbesto/amianto da variedade crisotila e com as fibras naturais e artificiais fossem registrados e acompanhados por serviços do Sistema Único de Saúde, devidamente qualificados para esse fim, sem prejuízo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde interna, de responsabilidade das empresas.

O artigo 7º estabeleceu determinação de que em todos os locais de trabalho onde os trabalhadores estejam expostos ao asbesto/amianto da variedade crisotila ou das fibras naturais ou artificiais devem ser observados os limites de tolerância fixados na legislação pertinente e, na sua ausência, estes serão fixados com base nos critérios de controle de exposição recomendados por organismos nacionais ou internacionais, reconhecidos cientificamente. Os limites fixados devem ser reavaliados anualmente, com vistas a que se reduza a exposição dos trabalhadores ao nível mais baixo que seja razoavelmente exequível.

O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais e artificiais é considerado de alto risco e, no caso de acidente, a área deve ser isolada e todo o material deve ser reembalado dentro de normas de segurança, sob a responsabilidade da empresa transportadora.

Todas as infrações à Lei nº 9.055/91, desde que constatadas, devem ser encaminhadas pelos órgãos fiscalizadores, no prazo máximo de 72 horas, ao Ministério Público Federal, através de comunicação circunstanciada, para as devidas providências. Conclui-se, daí, ser federal a competência para processar e julgar ações decorrentes da norma examinanda.

A Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, foi regulamentada pelo Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997, nos seguintes termos:

A extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte de asbesto/amianto, no território nacional, foram limitados à variedade crisotila. A importação de asbesto/amianto da variedade crisotila, em qualquer de suas formas, somente pode ser realizada após autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM do Ministério de Minas e Energia, e atendidas as seguintes exigências:

I – cadastramento junto ao DNPM das empresas importadoras de asbesto/amianto da variedade crisotila, em qualquer de suas formas, condicionado à apresentação, pela empresa importadora, de licença ambiental e registro no cadastro de usuário do Ministério do Trabalho;

II – apresentação, até 30 de novembro de cada ano, ao DNPM, de previsão de importação, para o ano seguinte, de asbesto/amianto da variedade crisotila;

III – cumprimento das condições estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal de controle ambiental, de saúde e segurança no trabalho e de saúde pública, pertinentes a armazenagem, manipulação, utilização e processamento do asbesto/amianto, bem como de eventuais resíduos gerados nessa operação, inclusive quanto à sua disposição final (artigo 2º).

O cadastramento da empresa importadora de asbesto/amianto no órgão competente de que trata o inciso I do artigo 2º é válido apenas por 12 meses, ao término dos quais, inexistindo a renovação, deve ser cancelado.

A comercialização dos produtos que contenham asbesto/amianto da variedade crisotila, importados ou de produção nacional, somente poderá ser feita se estes apresentarem marca de conformidade do Sistema Brasileiro de Certificação. As fibras naturais e artificiais que já estejam sendo comercializadas ou que venham a ser fabricadas deverão ter a comprovação do nível de agravo à saúde humana avaliada e certificada pelo Ministério da Saúde.

O monitoramento e controle dos riscos de exposição ao asbesto/amianto da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais, nos termos do artigo 4º da Lei nº 9.055, de 1995, poderão ser executados por intermédio de instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério do Trabalho. O credenciamento de instituições públicas ou privadas especializadas no monitoramento e controle dos riscos de exposição dos trabalhadores ao asbesto/amianto deve ser feito conforme critérios estabelecidos pelos Ministérios do Trabalho, de Minas e Energia e da Saúde.

Na forma do artigo 13, os Ministérios do Trabalho e da Saúde determinarão aos produtores de asbesto/amianto da variedade crisotila, bem como das fibras naturais e artificiais referidas no artigo 2º da Lei nº 9.055, de 1995, a paralisação do fornecimento de materiais às empresas que descumprirem obrigação estabelecida naquela lei, dando ciência, ao mesmo tempo, ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo para as providências necessárias.

O Decreto, em seu artigo 14, criou a Comissão Nacional Permanente do Amianto – CNPA, vinculada ao Ministério do Trabalho, de caráter consultivo, com o objetivo de propor medidas relacionadas ao asbesto/amianto da variedade crisotila, e das demais fibras naturais e artificiais, visando à segurança do trabalhador.

São integrantes da CNPA: I – dois representantes do Ministério do Trabalho, um dos quais a presidirá; II – dois representantes do Ministério da Saúde; III – dois representantes do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; IV – um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; V – um representante do Ministério de Minas e Energia; VI – quatro representantes de entidades de classe representativas de empregados e quatro de empregadores.

17.2.2.3 Competência concorrente e amianto

O tema Amianto tem suscitado importante discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que alguns Estados editaram leis que proíbem a proibição e circulação de produtos contendo Amianto em seus territórios. À base da proibição estão argumentos que variam da proteção ao meio ambiente até a proteção da saúde, todos eles considerados de forma autônoma. Normalmente, o questionamento das Leis Estaduais é feito pelo Estado de Goiás que, atualmente, é o único produtor de Amianto no país. O argumento básico apresentado por Goiás é o de que a matéria está regulada por lei federal e que os estados não podem ir além do que o que foi estabelecido pela lei federal. Assim, o argumento básico do estado goiano é limitativo de sua própria autonomia como membro da federação, haja vista que em nome dos interesses econômicos de uma única atividade – mineração de amianto – admite a centralização dos poderes em favor da União.

O STF proferiu uma importante decisão em matéria ambiental; refiro-me à ADI nº 2.396-9, Relatora a Senhora Ministra Ellen Gracie. A hipótese era a seguinte: o Senhor Governador do Estado de Goiás ajuizou Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, sendo requerida a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, com vistas a suscitar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei Estadual (Mato Grosso do Sul) nº 2.210, de 5 de janeiro de 2001: artigo 1º e §§ 1º, 2º e 3º; artigo 2º; artigo 3º e §§ 1º e 2º; e parágrafo único do artigo 5º. A matéria tratava da proibição da utilização de amianto no Estado do Mato Grosso do Sul. A decisão foi assim ementada:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 2.210/01, do Estado de Mato Grosso do Sul. Ofensa aos artigos 22, I e XII; 25, § 1º; 170, caput, II e IV; 1º; 18 e 5º caput, II e LIV. Inexistência. afronta à competência legislativa concorrente da União para editar normas gerais referentes à produção e consumo, à proteção do meio ambiente e controle da poluição e à proteção e defesa da saúde. Artigo 24, V, VI e XII e §§ 1º e 2º da Constituição Federal. Não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população. Os estudos nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear as ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. Sendo possível a este Supremo

Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que não os indicados na inicial, verifica-se que ao determinar a proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e comercialização do amianto crisotila. A legislação impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses de competência legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MG-MC e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo (STF. ADI 2396/MS – ADI. Ministra Ellen Gracie. Julgamento: 8/5/2003. Tribunal Pleno).

Posteriormente, a matéria voltou a ser debatida em função da edição de lei sobre a matéria, pelo Estado de São Paulo. Refiro-me à ADI nº 2.656 (Tribunal Pleno, DJU 1º/8/2003, p. 117):

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Paulista. Proibição de importação, extração, beneficiamento, comercialização, fabricação e instalação de produtos contendo qualquer tipo de amianto. Governador do Estado de Goiás. Legitimidade ativa. Invasão de competência da União. 1. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua comercialização imposta pela legislação paulista, com evidentes reflexos na economia de Goiás, Estado onde está localizada a maior reserva natural do minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar o processo de controle concentrado de constitucionalidade e pertinência temática. 2. Comercialização e extração de amianto. Vedação prevista na legislação do Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e recursos minerais. Legislação. Matéria de competência da União (CF, artigo 22, VIII e XIII). Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de produtos que utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 9055/95). Consequência. Vício formal da lei paulista, por ser apenas de natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de interesse nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5. Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto. Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF, artigo 22, VIII). Extrapolação da competência concorrente prevista no inciso V do artigo 24 da Carta da República, por haver norma federal regulando a questão. (Ministro Maurício Correa).

O tema é da maior importância, pois o instrumento de busca *Yahoo* registra 24.800 entradas para a palavra *amianto*. A própria Organização Mundial do Comércio – OMC anunciou, em 25 de julho de 2000, a autorização para que os países-membros bloqueiem importações de amianto, sob a alegação de defesa da saúde pública. Tal decisão foi apelada, tendo sido mantida pelo Painel encarregado de julgar o caso em 2001.⁵ Entendeu o Painel serem legítimas as restrições estabelecidas pela União Europeia no que se refere às importações de produtos contendo qualquer tipo de amianto. O Brasil, como 4º produtor mundial do mineral, protestou contra a decisão da OMC, pois a exportação do produto gera divisas de cerca de 30 milhões de dólares. Muito embora em números absolutos 30 milhões de dólares seja um importante valor, ele é pequeno diante do valor total das exportações brasileiras. Parece evidente que do ponto de vista custo-benefício internacional, não faz mais qualquer sentido econômico manter a produção brasileira de amianto. Deveriam ser adotadas medidas para que o Município de Minaçu, único produtor de amianto, fosse compensado pela paralisação da atividade e reorganizada a sua atividade produtiva.

A lei do Estado do Mato Grosso do Sul, ao banir o amianto daquele Estado, nada mais fez do que seguir uma tendência legislativa que vem se verificando em vários estados e municípios, os quais têm rejeitado o amianto. A questão que se coloca, claramente, é a da importante indagação quanto à constitucionalidade das inúmeras normas legais estaduais em face do artigo 24, VI, da Constituição Federal, que determina ser competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre, dentre outras coisas, “*proteção do meio ambiente e controle da poluição*”.

Fato é que se encontram em plena vigência as leis federais que tratam da matéria. Tais leis são: (i) Lei nº 9.055, de 1 de junho de 1966; (ii) Lei nº 9.976, de 3 de julho de 2000; (iii) Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991, que “Promulga a Convenção nº 162, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre a Utilização do Asbesto com Segurança”; (iv) Decreto nº 2.350, de 15 de outubro 1997, que regulamenta a Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995. O conjunto normativo consagra a “*utilização controlada*” do amianto e não o seu banimento.

O debate ganhou novos contornos, tendo em vista que o Estado de São Paulo editou novas normas relativas à proibição do amianto, as quais também foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal.

A questão jurídica relevante que foi ventilada pela concessão da liminar é a que diz respeito ao correto entendimento do que é a competência concorrente. Há uma tendência, quase unânime, de se considerar que a legislação estadual sobre meio ambiente pode – para alguns, deve – ser mais restritiva que a federal. Dentro de tal compreensão, a lei do Estado do Mato Grosso deveria ser tida por constitucional. O Tribunal, em princípio, está com entendimento contrário.

Caso o STF prossiga na linha de raciocínio que prevaleceu para a concessão da Medida Liminar, estará definitivamente estabelecendo que o limite da competência concorrente é muito claro: os Estados não podem desnaturar o comando estabelecido na norma federal. Aos estados está reservada a possibilidade de, nos limites da lei federal, criar adaptações para as suas peculiaridades regionais. A decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade interessa diretamente a todos aqueles que se preocupam com a proteção jurídica do meio ambiente.

17.2.2.4 Doença ocupacional e indenização

O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu devida indenização em função de doença ocupacional adquirida por exposição ao amianto, aplicando norma contida no Código Civil, considerando que a doença ocupacional que nasceu quando do seu conhecimento em abril de 2004, quando já vigente o referido diploma legal. O Tribunal entendeu que demonstrado que há nexo causal entre a doença e as atividades desempenhadas pelo empregado por força contratual, para a empresa, e o diagnóstico da doença ocupacional, asbestose, ocorrendo somente depois da demissão, quando da vigência do Código Civil de 2002, não há se falar na limitação da pretensão relacionada com a data da vigência do Código Civil, eis que não se limitou o julgado a firmar a responsabilidade objetiva, em razão de atividade de risco, como também a culpa subjetiva, na medida em que remete à culpa do empregador pela doença ocupacional, porque não comprovada a eficiência do Equipamento de Proteção Individual do ex-empregado, no controle de absorção de asbesto, pois o laudo declarou que o reclamante usava “máscara 3M simples sem filtro”. A presunção de culpa, igualmente, decorre do fato incontestável de que se trata de um dos males do século XX, reconhecido como poeira assassina. Acrescentou a Corte “*Deste modo, torna-se irrelevante o fato de tratar o eg. TRT da responsabilidade objetiva, em relação à atividade que gerou a doença ocupacional [...]*” (TST. RR 521900-41.2006.5.09.0892. Ministro Aloysio Correa da Veiga. Julgamento: 1º/6/2011. 6ª Turma. DEJT 10/6/2011).

17.2.2.5 Conclusão

A legislação brasileira optou por permitir a sua utilização controlada no território brasileiro. Contudo, há uma forte tendência internacional pelo banimento do amianto, com consequências econômicas relevantes e desgaste da imagem internacional dos países produtores. Considerando-se que o volume econômico da produção brasileira de amianto não é fundamental para a nossa economia e que é capaz de gerar graves prejuízos à imagem e à saúde das pessoas, seria conveniente que se fizessem estudos capazes de apontar os melhores caminhos para a proibição do produto em um espaço de tempo razoável, como por exemplo cinco ou dez anos. Contudo, a experiência nos mostra que é necessária muita fiscalização, pois casos como o do Ascarel, cuja proibição já existe há décadas, ainda não foram

resolvidos.

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional⁶ a utilização do Amianto no Brasil, em decisão complexa e polêmica.

17.2.3 Ascarel

O fluido dielétrico conhecido pelo nome comercial de Ascarel, dentre outros, é um organoclorado de grande teor tóxico. As bifenilas policloradas (PCBs) podem assumir diversas formas. Em realidade, estas são distintos compostos químicos, cuja composição difere somente quanto ao número e à posição dos átomos de cloro substituídos na molécula da bifenila. Quanto às bifenilas policloradas, ainda se pode acrescentar que são substâncias que consistem em uma molécula bifenila, com ou sem substituintes alquila ou arila, na qual mais de um átomo de cloro é substituído no núcleo bifenila. Os produtos comerciais são misturas de compostos clorados em vários graus, de acordo com o uso pretendido, também podendo conter baixos teores de impurezas altamente tóxicas, como clorobenzotioxinas e policlorodibenzofuranos. Os óleos que contêm PCBs são conhecidos sob denominações comerciais, como Ascarel, Aroclor, Clorophen, Phenoclor, Kaneclor, Pyroclor, Ineerten, Pyranol, Pyralene e outros. São óleos que apresentam PCBs em sua composição química, combinados com solventes orgânicos [...]. Os PCBs podem se apresentar como óleo ou sólido branco cristalino, tendendo a sedimentar-se quando em mistura com água, em função do seu maior peso específico [...]. Os efeitos tóxicos dos PCBs nos seres humanos, a partir da ingestão ou contato, passaram a ser observados através do acompanhamento de inúmeros acidentes, o pior deles ocorrido em 1968, no Japão, quando mais de 1.500 pessoas foram afetadas com óleo de arroz contaminado (FEEMA) (MOREIRA, 1992, p. 40).

17.2.3.1 Portaria Interministerial nº 19, de 29 de janeiro de 1981 (Ministério do Interior, da Indústria e do Comércio e das Minas e Energia)

O Ascarel é utilizado, em larga escala, para a refrigeração de sistemas elétricos. Os seus impressionantes efeitos levaram à proibição de seu uso, pela administração federal, por ato consistente na Portaria Interministerial nº 19, de 29 de janeiro de 1981, que afirma:

Considerando ser urgente e indispensável evitar a contaminação do ambiente por bifenil policlorados – PCBs (comercialmente conhecidos como Askarel, Aroclor, Clophen, Phenoclor, Kanechlor e outros), devido aos efeitos nocivos que esses compostos causam no homem e animais; considerando que os mencionados compostos provocam males, como lesões dermatológicas acentuadas, alterações no fígado e rins, alterações morfológicas nos dentes, alterações psíquicas, perda da libido, efeitos teratogênicos e cancerígenos; considerando, ainda, os efeitos nefastos sobre o homem e animais, de acordo com estudos realizados, por ocasião da contaminação acidental de alimentos com PCBs em alguns países [...].

Desde a publicação da referida portaria, está proibida a instalação de qualquer equipamento que utilize o Ascarel ou qualquer elemento congênere. Ficou, também, proibida a produção do referido produto químico em território nacional. Pelo mesmo ato foram proibidos o uso e a comercialização de PCBs, em todo estado, puro ou em mistura, em qualquer concentração ou estado físico, conforme prazos estabelecidos na própria portaria. Foi, ainda, proibido “terminantemente” o despejo de PCBs, direta ou indiretamente, nos cursos e coleções de água ou em locais expostos a intempéries.

Engana-se quem pensa que a Portaria Interministerial nº 19/81 significou a solução para o problema dos PCBs. Ao contrário, ela própria foi uma complicadora para toda a questão, como se verá. Em primeiro lugar, deve ser adiantado que a Portaria nº 19/81 não proibiu a utilização dos PCBs, pois pelo item III da mesma foi determinado que:

Os equipamentos de sistema elétrico, em operação, que usam bifenil policlorados PCBs, como fluido dielétrico, poderão continuar com este dielétrico, até que seja necessário o seu esvaziamento, após o que somente poderão ser preenchidos com outro que não contenha PCBs.

A vida útil de um equipamento de sistema elétrico é de 20 anos ou mais; dessa forma, nos termos da portaria, somente a partir de 2001 iniciou-se um processo de substituição em massa dos equipamentos supracitados.

Ademais, o item IV da Portaria é bastante claro ao demonstrar o caráter puramente indicativo da mesma, senão vejamos:

IV – as empresas usuárias de equipamentos elétricos deverão considerar, nas especificações de novos capacitores de potências, a aquisição de equipamentos que não utilizem PCBs.

Isso implica que a movimentação entre empresas de equipamentos que sejam utilizadores de PCB é legal.

É de se considerar, ainda, que a Portaria não estabeleceu uma solução final para o lixo contaminado que resulta não só do próprio Ascarel, como dos diversos equipamentos que, gradativamente, vão sendo postos fora de uso. O fato é que, hoje, existem milhares de toneladas de equipamentos infectados e que não têm qualquer solução para as suas destinações. A própria destruição é problemática, pois a incineração só recentemente começou a ser realizada no Brasil e, mesmo assim, a queima dos organoclorados é um tema polêmico entre os químicos e outros técnicos que têm se dedicado ao tema. Alega-se que a referida queima gera dioxina, que é uma substância altamente nociva à saúde, além de contribuir para a depleção da camada de ozônio ao liberar cloro para atmosfera. Um grave acidente envolvendo o óleo Ascarel aconteceu no rio Paraíba do Sul, no mês de agosto de 1988. O fato ocorreu nas instalações de grande indústria siderúrgica sediada em Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Um derramamento de óleo no rio, após a ocorrência de um incêndio, paralisou o abastecimento de água de uma população de cinco milhões de pessoas durante três dias. Foram despejados 300 litros do óleo e, embora diversas ações judiciais tenham sido propostas tão logo o acidente se verificou, houve uma do Ministério Público Federal em que o julgamento demorou muito. No ano de 2010, as Ações foram julgadas em primeira instância, com a condenação da empresa ao pagamento da quantia de R\$ 3,7 milhões a serem revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e para o Fecam (Fundo ambiental do Estado do Rio de Janeiro).

Igualmente, o Ministério Público Federal ajuizou diversas ações, tendo por finalidade fosse determinada judicialmente a destruição do Ascarel estocado por diversas empresas na cidade do Rio de Janeiro. As ações quanto à destruição do Ascarel, assim como aquela acima mencionada, passaram por longa tramitação e, a partir do meio da primeira década de 2000, começaram a ser decididas favoravelmente ao Ministério Público.

17.2.3.2 Resolução Conama nº 6, de 15 de junho de 1988

O Conama, através da Resolução Conama nº 6, de 15 de junho de 1988, de forma explícita reconheceu as precárias condições e a total falta de informação quanto à estocagem e à armazenagem dos PCBs. Tais circunstâncias fizeram com que, no processo de licenciamento, fossem determinadas medidas especiais quanto às bifenilas policloradas.

A referida resolução determinou prazo para que as indústrias geradoras de resíduos, nos quais a presença dos PCBs fosse notada, apresentassem ao órgão de controle ambiental as informações sobre geração, características e destino final de seus resíduos. O referido conjunto de informações deve ser prestado ao órgão ambiental estadual e, supletivamente, ao órgão federal. A resolução estabeleceu um critério definidor das empresas que, na forma do artigo 2º, deveriam apresentar o referido relatório. A relação é constituída por:

- a) indústrias siderúrgicas com mais de 100 funcionários;
- b) indústrias químicas com mais de 50 funcionários;
- c) indústrias de qualquer tipo (grupo 00 a 30) com mais de 500 funcionários;
- d) indústrias que possuem sistema de tratamento de águas residuais do processo industrial;

e) indústrias que gerem resíduos perigosos definidos como tais pelos órgãos ambientais competentes.

Foi feita uma determinação especial para as empresas concessionárias de energia elétrica, pois tais empresas, em razão de sua peculiar atividade, são grandes utilizadoras de aparelhos que são refrigerados por óleos em cuja composição os PCBs são muito importantes. O mencionado destaque, entretanto, limitou-se a exigir, no prazo de 60 dias da publicação da resolução, que as concessionárias de energia elétrica apresentassem relatório, contendo inventário de seus estoques, ao órgão de controle ambiental.

Foi estabelecida a aplicação de uma multa cujo valor era de 10 a 1.000 OTNs, caso as determinações da resolução não fossem observadas. O órgão aplicador da penalidade é o órgão estadual de controle ambiental. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama está destinada a atuação supletiva.

Em caso de terceirização da gestão dos resíduos, o agente terceirizado deverá obter um licenciamento específico.

Os anexos da Resolução Conama nº 6/88 trazem uma enorme quantidade de dados técnicos que devem ser informados quando da feitura do mencionado inventário.

É importante observar que a resolução do Conama que se vem de mencionar é basicamente voltada para o objetivo de conhecer os estoques de PCBs e outros produtos tóxicos e determinar algumas medidas para o seu armazenamento que, na maioria das vezes, ocorre *in situ* e, o que é pior, em condições bastante precárias.

17.2.4 Ascarel em juízo

No ano de 1991, enquanto o autor ainda exercia as funções de procurador da República em primeira instância no Estado do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ajuizar diversas ações civis públicas em face de pessoas jurídicas que mantinham armazenado ou ainda se utilizavam de óleo ascarel em seus equipamentos, buscando que o ascarel fosse destruído de forma adequada. No ano de 2010, foram proferidas algumas decisões pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Todas diziam respeito a recursos oriundos do Tribunal Regional Federal da 2ª região, responsável pelo exame do tema em grau de apelação (RE 630542/RJ. Relator(a): Min. Cármen Lúcia. Julgamento: 14/12/2010. *DJe*-024, divulg. 4/2/2011, public. 7/2/2011). A decisão foi assim lavrada:

Decisão recurso extraordinário. Direito ambiental. Proibição de utilização de substâncias tóxicas: PCBs. Portaria interministerial nº 19/81. Matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Recurso ao qual se nega seguimento. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea *a*, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: “Ambiental. Ação Civil Pública. Portaria Interministerial nº 19/81. PCBs. Combustão incompleta. Resíduos tóxicos. Utilização do ascarel como fluido dielétrico. Impossibilidade. I – Os interesses econômicos particulares devem ceder frente à importância de se preservar o equilíbrio do meio ambiente. II – Ainda que não o tenha referido expressamente, a Portaria Interministerial nº 19/81 proibiu a utilização dos PCBs, tendo em vista que reconheceu os efeitos nocivos que os últimos causam aos homens e aos animais. Eis a interpretação mais adequada do aludido ato normativo, diante da necessidade de harmonizá-lo à Constituição Federal. III – A combustão incompleta do PCB gera produtos ainda mais nocivos. Daí, não ser a imediata incineração dos compostos químicos e dos equipamentos contaminados a solução mais adequada à tutela do meio ambiente, e sim a eliminação gradual e segura. IV – A dificuldade prática que inviabiliza a célere eliminação não beneficia a ré, que não pode aproveitar essa situação para manter o maquinário contaminado em atividade. V – A utilização do ascarel como fluido dielétrico há de cessar de imediato. Por mínimo que seja, não se justifica o risco a que está sujeito o meio ambiente em função da indevida exploração econômica dos PCBs. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 50). 2. A Recorrente alega que o Tribunal *a quo* teria contrariado os arts. 5º, inc. II, e 225 da Constituição da República. Argumenta que “a harmonização da Portaria 19/81 à Constituição Federal, levada a efeito pelas instâncias ordinárias a pretexto de compatibilizá-la com o art. 225 do texto magno, na verdade implica em violação de tal dispositivo constitucional, e ainda, em ofensa ao art. 5º, inciso II da Lei Fundamental da República” (fl. 591). Sustenta que “desde que cumpridas as normas técnicas e de segurança – o que é inequivocamente reconhecido que a CSN faz – não pode falar em contrariedade entre as exigências da Constituição e o uso, até esvaziamento, dos PCBs já instalados, com arrimo no inciso III da Portaria Interministerial 19/81” (fl. 607). Apreciada a matéria trazida na espécie, *Decido*. 3. Razão jurídica não assiste à Recorrente. 4. O Tribunal *a quo* assentou que: “Com efeito, os interesses econômicos particulares devem ceder frente à importância de se preservar o equilíbrio do meio ambiente. Assim, ainda que não o tenha referido expressamente, a Portaria Interministerial nº 19/81 proibiu a utilização dos PCBs, tendo em vista que reconheceu os efeitos nocivos que os últimos causam aos homens e aos animais. Eis a interpretação mais adequada do aludido ato normativo, diante da necessidade de harmonizá-lo à Constituição Federal” (fl. 527). Concluir de forma diversa do que foi decidido pelas instâncias originárias demandaria a análise prévia de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria Interministerial nº 19/81). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. [...] 5. Ademais, a alegada contrariedade ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nada há, pois, a prover quanto às alegações da Recorrente. 6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, *caput*, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Ministra Cármen Lúcia)

Houve decisão anterior, em hipótese idêntica, envolvendo o Jornal do Brasil, na qual o Ministro Joaquim Barbosa (STF. RE 430274/RJ. *DJe*-045, divulg. 11/3/2010, public. 12/3/2010) negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

O Superior Tribunal de Justiça negou medida cautelar para atribuir efeito suspensivo a Recurso Especial interposto pela mesma Companhia Siderúrgica Nacional, da forma que segue:

*Processual Civil. Medida cautelar. Efeito suspensivo. Recurso Especial admitido pelo tribunal de origem. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar. Precedentes do STJ. Negativa de seguimento da medida cautelar. 1. Trata-se de medida cautelar proposta pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, com pedido liminar, objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial admitido, interposto contra acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 595): “Ambiental. Ação Civil Pública. Portaria interministerial nº 19/81. PCBs. Combustão incompleta. Resíduos tóxicos. Utilização do **ascarel** como fluido dielétrico. Impossibilidade. I – Os interesses econômicos particulares devem ceder frente à importância de se preservar o equilíbrio do **meio ambiente**. II – Ainda que não o tenha referido expressamente, a Portaria Interministerial nº 19/81 proibiu a utilização dos PCBs, tendo em vista que reconheceu os efeitos nocivos que os últimos causam aos homens e aos animais. Eis a interpretação mais adequada do aludido ato normativo, diante da necessidade de harmonizá-lo à Constituição Federal. III – A combustão incompleta do PCB gera produtos ainda mais nocivos. Daí, não ser a imediata incineração dos compostos químicos e dos equipamentos contaminados a solução mais adequada à tutela do **meio ambiente**, e sim a eliminação gradual e segura. IV – A dificuldade prática que inviabiliza a célere eliminação não beneficia a ré, que não pode aproveitar essa situação para manter o maquinário contaminado em atividade. V – A utilização do **ascarel** como fluido dielétrico há de cessar de imediato. Por mínimo que seja, não se justifica o risco a que está sujeito o **meio ambiente** em função da indevida exploração econômica dos PCBs. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido”. Sustenta, em síntese, a presença dos pressupostos para o conhecimento da medida cautelar, especificamente a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de risco de dano jurídico irreversível. Alega que interpôs recurso especial com fundamento na alínea *a* do permissivo constitucional, por negativa de vigência dos arts. 2º, IV e V, da Lei 6.938/81, e 460, 461 e 515, do Código de Processo Civil. Assevera que o fumus boni iuris consiste na violação dos dispositivos legais apontados como violados, especialmente por desrespeito ao princípio da precaução, impossibilidade de fixação de astreinte de ofício pelo Tribunal de origem e pela “imperiosa necessidade de superação da multa, ou ao menos de sua redução, e de ampliação para incineração total dos materiais” (fl. 25). Defende a presença do periculum in mora, o qual estaria configurado na*

determinação contida no acórdão recorrido, pois “ao fixar um prazo contado da sua própria prolação, para cumprimento definitivo do julgado, sob pena de multa, visa a compelir a Requerente a uma providência a qual terá não só caráter plenamente satisfativo, como, também, será ‘irreversível’, uma vez que, se por hipótese, vier a ser executada a incineração, esta jamais poderá ser desfeita” (fls. 28/29). Requer a concessão do pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. É o relatório. 2. A propositura de medidas cautelares no Superior Tribunal de Justiça tem sido admitida apenas em casos excepcionais, para o fim de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, em sede de recurso especial, tendo por finalidade a “proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa” (art. 34, V, do RISTJ). Consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, perseguida em cautelar incidental, deve satisfazer cumulativamente os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, além da prévia admissão do recurso especial pela Corte de origem. A ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a pretensão cautelar. [...] Na hipótese examinada, não obstante o recurso especial tenha sido admitido pelo Tribunal de origem, é consolidado o entendimento no sentido de que a plausibilidade do direito invocado relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do apelo excepcional. Assim, apesar dos argumentos expostos pela requerente, verifica-se que o acórdão impugnado pelo recurso especial, ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo, foi fundado em elementos fáticos e probatórios contidos nos autos. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou (fls. 592/593): “O Ministério Público Federal ajuizou a presente ação civil pública no intuito de obrigar a CSN a incinerar os PCBs – substâncias altamente tóxicas e proibidas por ato infralegal – que utiliza e todos os materiais contaminados. O juízo a quo acolheu in totum os pedidos formulados pela parte autora. Com efeito, os interesses econômicos particulares devem ceder frente à importância de se preservar o equilíbrio do **meio ambiente**. Assim, ainda que não o tenha referido expressamente, a Portaria Interministerial nº19/81 proibiu a utilização dos PCBs, tendo em vista que reconheceu os efeitos nocivos que os últimos causam aos homens e aos animais. Eis a interpretação mais adequada do aludido ato normativo, diante da necessidade de harmonizá-lo à Constituição Federal. Em suma, são acertadas as premissas sobre as quais o juízo a quo assentou suas conclusões. Apesar disso, a sentença merece parcial reforma. Na verdade, a imediata incineração dos compostos químicos e dos equipamentos contaminados não é a solução mais adequada à tutela do **meio ambiente**. É o que evidenciam os seguintes trechos extraídos do laudo pericial: A incineração dos PCBs deverá ser feita em incineradores especiais para esta finalidade, equipados com dispositivos de controle da poluição atmosférica e rigorosamente observados os parâmetros de processo. [...] A combustão incompleta gera produtos cuja toxicidade é maior que a dos próprios PCBs (fls. 98). No Brasil, os incineradores habilitados e autorizados à incineração dos PCBs são o da Bayer do Brasil em Belford Roxo e o da Central de Tratamento de Efluentes do Polo de Camaçari-Cetrel na Bahia (fls. 98). A Bayer coloca 50% da capacidade nominal de seu incinerador (aproximadamente 1.500 toneladas/ano) para atendimento ao mercado na forma de prestação de serviços (fls. 99). Podemos verificar que existe o firme propósito de solucionar o problema causado pelo **ascarel**, eliminando os estoques existentes ou substituindo os equipamentos que usam o **ascarel**. Existe no local uma empresa contratada pela CSN em horário integral, para preparar os resíduos sólidos e líquidos para incineração, além da substituição do **ascarel** pelo líquido isolante RTEMP (fls. 105). Ou seja, condenar a CSN a incinerar de imediato todo o **ascarel** que mantém estocado pode provocar um desastre ambiental de graves proporções. Isso porque a apelante se veria compelida a fazê-lo por conta própria, apesar de não ter condições para tanto. O resultado seria a combustão incompleta do PCB, o que, como alertou o perito judicial, gera produtos ainda mais nocivos. A melhor solução parece ser a incineração gradual e segura do material tóxico. Nesse sentido, é suficiente o prazo de um ano para a eliminação completa do estoque, uma vez que, de acordo com cronograma estipulado pela CSN, havia condições para que isso tivesse ocorrido há aproximadamente três anos. No entanto, deve ser mantida a sentença na parte em que se determinou a substituição dos equipamentos que se utilizam do **ascarel**. Com efeito, a dificuldade prática que inviabiliza a célere eliminação não beneficia a apelante, que não pode aproveitar essa situação para manter o maquinário contaminado em atividade, como pretende. Assim, a utilização do **ascarel** como fluido dielétrico há de cessar de imediato. Por mínimo que seja, não se justifica o risco a que está sujeito o **meio ambiente** em função da indevida exploração econômica dos PCBs”. Portanto, ainda que em juízo perfunctório, verifica-se que a análise da pretensão cautelar pleiteada pela requerente, com a consequente inversão da conclusão exposta pelo Tribunal a quo, exige o reexame de matéria fático-probatória presente na hipótese, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 7/STJ, o que afasta a plausibilidade do direito invocado e, consequentemente, a viabilidade da própria medida cautelar. Nesse sentido, os seguintes precedentes: “Processual civil. Medida cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635 do STF. Necessária análise de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula nº 7, do STJ. [...] 3. A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial exige, como pressupostos, a necessária demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar que quando do provimento final não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo, bem como, a caracterização do *fumus boni iuris*, ou seja, que haja plausibilidade do direito alegado. 4. Incumbe, portanto, ao requerente da medida demonstrar a verossimilhança do que alega, bem como a possibilidade de acolhimento do Recurso Especial a que pretende dar efeito suspensivo. 5. In casu, o requerente pretende demonstrar o periculum in mora em razão da impossibilidade de se promover atividade econômica no dia de sábado, o que gera segundo a sua ótica prejuízos, inaferríveis pelo STJ (Súmula 07). 6. Ademais, se em sede de apelo extremo dirigido a esta Corte Superior não se admite a análise de matéria fático-probatória, com muito mais razão se lhe veda esse ângulo cognitivo na via acessória cautelar, ante o verbete sumular nº 07, do STJ. 7. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg na MC 10.546/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 21/11/2005, p. 123) “Administrativo. Agravo Regimental. Medida cautelar. Decisão agravada. Fundamentos em princípios constitucionais. Possibilidade. Criação de nova linha. Licitação anterior. Súmula 7/STJ. Periculum in mora. Ausência. 1. Não é da competência deste Tribunal Superior a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, consoante dispõem os arts. 102, III, a, c/c com o 105, III, a, ambos da CF. É certo, contudo, que todos os órgãos judicantes do país devem analisar as situações e interpretar os diplomas normativos de acordo com os princípios, direitos e garantias dispostos na Constituição Federal. 2. A Corte regional, em nenhum momento, fixou a premissa fática de que teria sido criada linha nova em trajeto anteriormente licitado à ora agravante e, por outro lado, entendeu ser indispensável a continuidade da prestação do serviço de transporte coletivo mesmo após a decretação de nulidade do ato administrativo de permissão. Solução em contrário demandaria o revolvimento das circunstâncias fático-probatórias, o que é vedado nos termos da Súmula 7 desta Corte. 3. A agravante afasta o periculum in mora ao aduzir ‘como se sabe, não é bem visto o ajuizamento de Medida Cautelar no recesso forense, a não ser que o direito esteja de fato perecendo e/ou que o recurso especial tenha sido protocolizado no referido período [...]’ (fl. 172). 4. Agravo regimental improvido” (AgRg na MC 10.418/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 7/11/2005, p. 165). Ademais, a análise da controvérsia também exigiria a interpretação da Portaria Interministerial 19/81, o que não seria permitido em recurso especial, pois não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘lei federal’, constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Outrossim, a proximidade do término do prazo para cumprimento da determinação contida no aresto recorrido, bem como a alegação de eventual perda do objeto do recurso especial não representam, por si só, risco de dano jurídico irreparável apto a ensejar a concessão da tutela cautelar. Tais considerações decorrem da efetiva necessidade do cumprimento do acórdão recorrido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e nego seguimento à própria cautelar, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ” (Ministra Denise Arruda).

O próprio Recurso Especial (REsp 1099103, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 4/2/2010) teve o seu seguimento negado pela Ministra Denise Arruda:

Processual civil. Recurso Especial. Análise de portaria. Impossibilidade. Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. Multa diária. Fixação de ofício. Legalidade. Precedentes do STJ. Negativa de seguimento do recurso especial. 1. Trata-se de recurso especial interposto pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 530): “Ambiental. Ação civil pública. Portaria Interministerial nº 19/81. PCBs. Combustão incompleta. Resíduos tóxicos. Utilização do **ascarel** como fluido dielétrico. Impossibilidade. I – Os interesses econômicos particulares devem ceder frente à importância de se preservar o equilíbrio do meio ambiente. II – Ainda que não o tenha referido expressamente, a Portaria Interministerial nº 19/81 proibiu a utilização dos PCBs, tendo em vista que reconheceu os efeitos nocivos que os últimos causam aos homens e aos animais. Eis a interpretação mais adequada do aludido ato normativo,

diante da necessidade de harmonizá-la à Constituição Federal. III – A combustão incompleta do PCB gera produtos ainda mais nocivos. Daí, não ser a imediata incineração dos compostos químicos e dos equipamentos contaminados a solução mais adequada à tutela do meio ambiente, e sim a eliminação gradual e segura. IV – A dificuldade prática que inviabiliza a célere eliminação não beneficia a ré, que não pode aproveitar essa situação para manter o maquinário contaminado em atividade. V – A utilização do **ascarel** como fluido dielétrico há de cessar de imediato. Por mínimo que seja, não se justifica o risco a que está sujeito o meio ambiente em função da indevida exploração econômica dos PCBs. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido”. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal de origem, nos termos da seguinte ementa (fls. 548/549): “Processo civil e constitucional. Embargos de declaração. Astreintes. Cominação de ofício. Possibilidade. Prequestionamento. Ponderação de interesses. Portaria Interministerial nº 19/81. Interpretação. Regulamentação da Lei nº 6.938/81. I – A cominação de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer independe de iniciativa da parte. Portanto, não há falar em reformatio in pejus ou em provimento extra petita em razão da imposição de astreintes pelo órgão ad quem, sobretudo porque isso poderia ser feito a qualquer tempo e de ofício. Inteligência do art. 461, §§ 3º e 4º do CPC. II – Mesmo os embargos de declaração com fins de prequestionamento devem suscitar questão que deveria ter sido enfrentada no acórdão embargado, a teor do art. 535, I e II do CPC. III – Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional (TRF – 2ª Região, AGT 72437, Rel. Juiz Federal Conv. José Neiva, DJ 29/8/2007). IV – Quanto à harmonização da Portaria Interministerial nº 19/81 à Constituição, é de se esclarecer que houve uma ponderação entre o interesse econômico particular e o direito difuso à higidez do meio ambiente, prevalecendo o último, consubstanciado no art. 225 da Lei Maior. V – Não custa lembrar que o objeto da Portaria Interministerial nº 19/81 foi erradicar o uso dos PCBs o que inviabiliza a interpretação de que as máquinas que trabalham movidas por esses compostos poderiam funcionar para sempre, enquanto não sobreviesse o esvaziamento. VI – Ao determinar que a utilização do ascarel como fluido dielétrico deveria cessar de imediato, o julgado apenas supriu a lacuna da norma infralegal, interpretando-a de modo a maximizar sua eficácia. VII – Não se poderia exigir que houvesse uma lei para cada substância química nociva cujo uso fosse proibido. A Lei nº 6.938/81 transferiu a competência para tanto ao Governo Federal, que, observando os limites de delegação, regulamentou a lei através da Portaria Interministerial nº 19/81. Não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da legalidade. VIII – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos”. Sustenta a recorrente que o aresto recorrido negou vigência aos arts. 2º, IV e V, da Lei 6.938/81, 460, 461 e 515 do Código de Processo Civil. Alega, em síntese, que: a) “não existe norma que proíba a utilização dos PCBs em equipamentos que já o usavam quando da edição da Portaria Ministerial nº 19/81” (fl. 562); b) o prazo de um ano fixado pelo acórdão recorrido não é suficiente para cumprimento da obrigação; c) é inadmissível a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial, quando não houve pedido da parte para tanto. Requer o provimento do recurso especial para reformar o aresto recorrido. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 619/631). Admitido o recurso na origem, subiram os autos. Nesta Corte, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 657/663). É o relatório. 2. A pretensão recursal não merece acolhimento. Inicialmente, a análise da controvérsia demandaria a interpretação da Portaria Interministerial 19/81, o que não é permitido em recurso especial, pois este não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘lei federal’, constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. [...] Ademais, o Tribunal de origem, consignou que “é suficiente o prazo de um ano para a eliminação completa do estoque, uma vez que, de acordo com cronograma estipulado pela CSN, havia condições para que isso tivesse ocorrido há aproximadamente três anos” (fl. 528). Assim, a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar se o prazo fixado pelo acórdão recorrido é ou não suficiente para o cumprimento da obrigação, exigiria, necessariamente, o reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. [...] Quanto à fixação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é legal a imposição da multa de ofício, sendo desnecessário o pedido da parte. Sobre o tema, a orientação deste Tribunal Superior: “Processual civil. Obrigação de fazer. Art. 461 do CPC. Astreintes. Aplicação para a Fazenda Pública. Possibilidade. Revisão do quantum estipulado. Matéria fática. Súmula 7/STJ. 1. É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. 2. A revisão do valor da multa demanda, como regra, o reexame de matéria fática, vedado a esta Corte nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental provido” (AgRg no Ag 1.040.411/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19/12/2008). [...] 3. Ante o exposto, nego seguimento (Recurso Especial 1.099.103/RJ (2008/0230060-7), Relatora: Ministra Denise Arruda).

No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a maior parte das apelações interpostas pelas empresas foi negada, mantendo-se as condenações de primeira instância que determinavam a destruição do Ascarel. Hipótese interessante, a qual implicou na rejeição dos argumentos *ad terrorem* apresentados pela empresa Light Serviços de Eletricidade S.A., a qual, condenada em primeira instância, apresentou apelação recebida somente no efeito devolutivo. Sustentava a empresa que a imediata execução da sentença poderia implicar na paralisação do fornecimento de eletricidade para a cidade do Rio de Janeiro e outras atendidas pela companhia.

A execução provisória do julgado, para imediata desativação dos equipamentos ainda utilizantes do PCBs, traria evidente prejuízo às suas atividades e aos seus consumidores, além de contrariar os termos de como vem sendo feita a desativação, de acordo com o estabelecido na Portaria Ministerial 19/81.

A rejeição das razões da empresa foi assim fundamentada: O presente recurso visa a obstar a execução da sentença que julgou procedente o pedido:

para condenar a Ré a incinerar todo o PCB (Bifenila Policlorada) que mantém estocado, bem como todos os capacitores e transformadores infectados pelos PCB, além de todo o material e equipamento que esteja infectado pelo PCB, e determinar que a Ré proceda à substituição de todos os equipamentos que ainda se utilizem de PCB, incinerando-os. O ponto aqui suscitado, refere-se, em especial, a determinação contida no decisum relativo à substituição imediata dos equipamentos que ainda se utilizem de PCB, uma vez que não há discordância quanto a sua nocividade, verbis: “Como se verá adiante, a recorrente não questiona a necessidade de cumprir as determinações da Portaria Interministerial citada, muito menos quer se exonerar do compromisso de, bem e fielmente, eliminar o óleo, ascarel que acumulou no passado, antes de se conhecer os efeitos efetivamente nocivos desse material. Hoje não há dúvida em relação a este último aspecto”. Considerando-se que a aludida Portaria Ministerial data de 1994, e ainda, que a empresa já vem desenvolvendo um cronograma de descarte, incineração e substituição dos transformadores e capacitores utilizadores de ascarel desde o ano de 2001, dentro do cronograma apresentado pelo FEEMA, não há que se falar em prejuízo à normalidade de suas atividades, como bem salientou o Ministério Público Federal. E ainda, por se tratar de substância de considerável risco e periculosidade ao meio ambiente e à saúde pública, deve ser confirmada a decisão agravada (TRF da 2ª Região, AG 200202010439199, Agravo de Instrumento 104086, Desembargador Federal Paulo Espírito Santo).

17.2.5 Mercúrio

O mercúrio é, dentre os metais pesados, aquele que se tornou mais conhecido pelos resultados trágicos causados pela sua disseminação irresponsável e aleatória pelo ambiente. O episódio envolvendo poluição causada por mercúrio que obteve a maior repercussão internacional ocorreu no Japão, durante as décadas de 50 e 60, e ficou conhecido como a doença de Minamata. Os casos reconhecidos e notórios de poluição por mercúrio (símbolo químico Hg) são pelo menos 33 e espalham-se por todo o mundo.

No Brasil, os principais focos de poluição por mercúrio situam-se nas regiões de garimpo, sobretudo na Amazônia, em regiões de alta concentração industrial, sendo um bom exemplo o Polo Petroquímico de Camaçari, situado no Estado da Bahia.

Vários foram os casos englobados na chamada doença de Minamata. Passemos a examinar alguns deles (VIEIRA, 1990, p. 37-39):

O primeiro destes casos (Nigata Minamata) fundamentou-se no envenenamento de algumas pessoas por metil mercúrio orgânico registrado inicialmente a partir de 1964 nas águas ao longo do rio Aganogama, no Distrito de Nigata. Setenta e sete pacientes ingressaram em juízo demonstrando este fato e

exigindo da empresa Showa Denko Ltd. – e sua fábrica em Knose – indenização por danos no valor aproximado de 530 milhões de ienes. A fábrica está localizada a montante do rio Aganogama, que abastece o distrito. A sentença foi prolatada em setembro de 1971 e reconheceu a culpa da empresa pelo dano, que segundo o tribunal, resultara da negligência da companhia. A Corte definiu que a acusada havia causado prejuízo à saúde de pessoas como resultado do contínuo lançamento de águas residuais que praticava, sem prévio tratamento, e que este fato era capaz de caracterizar a imprudência da empresa. A companhia foi, além disso, acusada de ter cometido erros grosseiros, porque havia se descuidado de investigar se suas águas residuais continham substâncias perigosas, muito embora tivesse conhecimento de que uma outra fábrica de produtos químicos, de Chisso, que produzia componentes químicos similares, estava sob suspeita de que as águas utilizadas para processamento teriam sido causadoras de doenças em Kumamoto Minamata. O tribunal condenou a empresa a pagar a indenização solicitada.

O segundo caso, conhecido como a doença de Itai-itai originou-se de uma enfermidade que ocorria com grande frequência, dentre os residentes, ao longo do rio Kintu no Distrito de Toyama. Dor intolerável e fraqueza nos ossos foram registradas como sintomas mais comuns da estranha patologia – a dor extrema fazia com que os pacientes gritassem “itai-itai” (o equivalente do “ai” em língua portuguesa, como reação de sofrimento). Trinta e uma vítimas ajuizaram petição requerendo indenizações da empresa Mitsui Kinzoku Ltd., tida como responsável pelas enfermidades, no montante aproximado de 62 milhões de ienes. A empresa mantinha uma companhia de mineração a montante do rio Kintu, chamada de Minas de Kamioka. A essa ação a Corte emitiu decisão final, em junho de 1971, reconhecendo a existência da relação causal entre a doença e o mineral cádmio (Cd) que era emitido pela mencionada fábrica. O tribunal determinou que a acusada honrasse a indenização pelo dano; insatisfeita, a empresa ingressou com recurso para uma Corte superior. Em prosseguimento, os demandantes promoveram o aumento para 151,3 milhões de ienes. O recurso foi indeferido e a companhia teve que pagar o novo valor.

O último caso, talvez o mais referido de todos, cuida do que se conheceu, a partir de então, como doença de Kumamoto Minamata. Nas áreas circunvizinhas à baía de Minamata, no Distrito de Kumamoto, foram registrados casos de envenenamentos frequentes, identificados como resultado da contaminação por mercúrio orgânico, substância que provocava, nos pacientes, distúrbios da fala e da visão, dentre outros efeitos. Os fenômenos tiveram início por volta de 1953, e 138 pessoas apresentaram ação contra a companhia Chisso e sua fábrica de Minamata, reclamando o total de aproximadamente 1.470 milhões de ienes, como compensação pelos danos. O tribunal reconheceu a alegação dos autores de que havia, de fato, correlação entre a ocorrência das doenças e a substância metil mercúrio emitida pela fábrica da Chisso, bem como negligência da empresa e concluiu pela condenação dos acusados. A sentença reconheceu, ainda, que a doença era provocada pela ingestão de alimentos marinhos pescados na baía de Minamata e nas suas proximidades, os quais estavam contaminados com compostos de mercúrio. Esses alimentos, que vinham sendo consumidos ao longo de muitos anos, depositaram grandes quantidades de mercúrio no organismo das pessoas, gerando a doença então diagnosticada como Encefalopatia Tóxica. Em acréscimo, o tribunal também concluiu que a empresa havia negligenciado, quanto ao seu importante dever de prevenir o perigo que suas operações representavam à vida e à saúde das pessoas, particularmente da comunidade local, havendo cometido imprudência adicional quando, muito embora já tivesse sido determinado que a água residual que liberava na baía era perigosa, ou pelo menos sobre ela já se havia estabelecido dúvida quanto à ameaça, que tais dejetos poderiam representar, ainda assim deixara de adotar as medidas possíveis ao seu dispor; tal como a imediata suspensão das operações da fábrica [...].

O governo japonês, contudo, tem resistido a reconhecer a totalidade das vítimas da doença de Minamata, e existem ainda aproximadamente 2.000 ações judiciais em curso com a finalidade de obtenção de indenização pelos danos causados pelo mercúrio. Até o ano de 1992, a administração japonesa reconheceu que 2.900 pessoas eram portadoras da doença de Minamata.

A limpeza da baía de Minamata já consumiu bilhões de ienes e, se for feito um cálculo entre as diversas indenizações pagas, não será difícil alcançar-se a cifra de 140 bilhões de ienes (NAMU, 1992).

17.2.5.1 O controle dos metais pesados no Brasil

O garimpo é uma das atividades que responde pela maior parcela da contaminação por mercúrio dos rios brasileiros.

“Ação civil pública. Garimpagem com a utilização de mercúrio. Inadmissibilidade. 1. Legitimidade passiva do Estado do Amazonas, uma vez que a preservação do meio ambiente constitui competência comum da União e dos Estados (Carta Magna, art. 23, VI e VII). 2. A garimpagem, com a utilização de mercúrio, constitui atividade que implica a degradação do meio ambiente e risco para a saúde das populações ribeirinhas, indígenas ou não, bem como para os próprios garimpeiros, uma vez que o metal em questão é absorvido pelos peixes, que é uma das principais fontes de alimento na região amazônica (Carta Magna, art. 225, *caput*; e § 4º). 3. Inadmissibilidade da exploração de riquezas minerais em reserva indígena sem autorização do Congresso Nacional (Carta Magna, art. 231, §§ 2º e 3º). 4. Remessa a que se nega provimento”. Apesar disso, o mercúrio é proibido nessa atividade desde 1989, conforme determinação do Decreto nº 97.507, de 13 de fevereiro de 1989, “que dispõe sobre licenciamento de atividade mineral, o uso do mercúrio metálico e do cianeto em áreas de extração de ouro, e dá outras providências”. (TRF 1ª Região. Remessa *Ex Officio* 199901000923997/AM. Relator Juiz Federal LEÃO APARECIDO ALVES (CONV.). 3ª Turma Suplementar. DJU 27/5/2004, p. 55.

Assim é que o artigo 2º do mencionado decreto determina:

Art. 2º É vedado o uso de mercúrio na atividade de extração de ouro, exceto em atividade licenciada pelo órgão ambiental competente.

É curiosa a redação do artigo, pois fica proibida a utilização de mercúrio no garimpo não licenciado e autorizada nos garimpos que tenham sido regularmente licenciados. Parece-me impossível que qualquer proibição de uma atividade que esteja sendo realizada clandestinamente possa ter resultado prático. Por outro lado, permitir a atividade licenciada é, na prática, criar uma autorização expressa para a utilização do mercúrio. É, portanto, inexistente a aludida “proibição”.

As consequências da utilização do mercúrio no garimpo são bastante conhecidas por todos. De fato, o mercúrio tem causado danos extraordinários às populações ribeirinhas e, especialmente, aos povos que habitam a Floresta Amazônica, onde o garimpo e o mercúrio espalham-se como ervas daninhas.

Administrativo. Responsabilidade civil. Agentes de saúde contaminados por produtos tóxicos no exercício de suas funções. Custeio do tratamento médico pela Funasa. Tutela antecipada. Cabimento. 1. Incensurável a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ao determinar à Funasa que assumisse o custeio do tratamento médico de seus funcionários, acometidos de intoxicação por agentes químicos (DDT e mercúrio), no exercício de suas atividades profissionais, tendo em vista a verossimilhança da alegação e por estar comprovada a possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito dos autores. 2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo de instrumento improvido. 4. Agravo regimental prejudicado. (TRF 1ª Região. AGA 200001000894664/PA. 5ª Turma. DJU 26/9/2003, p. 204. Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus.)

Um estudo piloto foi realizado, em novembro de 1987, por uma equipe de médicos do Departamento de Epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em duas áreas garimpeiras do Pará: Cachoeiro e Cumaru, esta última na reserva Gorotire dos índios Kayapó. O estudo visava medir a intoxicação mercurial proveniente de “mercúrio inorgânico em estado líquido agregado na fase de concentração e amalgamação” do ouro. A conclusão a que chegaram os pesquisadores é que a intoxicação mercurial incide “sobre os garimpeiros, assim como os outros grupos sociais envolvidos: índios, comprador de ouro”, Tc: (Rosa C. de S. Couto, Volney M. Câmara, Paulo C. Barboza 1988 p. 314) (RIBEIRO, 1992, p. 226).

17.2.5.2 Limite legal de concentração de mercúrio na água

A matéria está tratada na Resolução Conama nº 357, de 17 de março de 2005, que estabelece novos critérios para a classificação das águas doces, salobras e salinas no território nacional, conforme complementação feita pela Resolução Conama nº 430, de 13/5/2011.

17.2.6 Benzeno

A fabricação de produtos que contenham benzeno em território nacional está proibida desde 28 de abril de 1982, conforme determinação contida na Portaria Interministerial (MS/MTE) nº 3, de 28 de abril de 1982. Admite-se, contudo, a presença de 1% da referida substância, como agente contaminante.

17.2.7 Cloro

17.2.7.1 Importância do Cloro

O cloro é dos diferentes produtos químicos que mereceu regulamentação legal de sua produção e utilização. É precisamente essa a função desempenhada pela Lei nº 9.976, de 3 de julho de 2000, que *“dispõe sobre a produção de cloro e dá outras providências”*. Tal lei enquadra-se em um amplo movimento internacional que tem como um de seus objetivos um controle mais eficiente dos diversos produtos químicos que, atualmente, se encontram em utilização. O cloro (Cl) certamente é um dos produtos químicos mais importantes e que, em tal condição, é responsável por importantes impactos ambientais e sobre a saúde humana. É relevante a observação de McGinn (2000, p. 84), no sentido de que *“dos 1.000 contaminadores ambientais conhecidos, cerca da metade contém cloro, que tende a proporcionar estabilidade à molécula e torná-la mais propensa a bioacumular”*. A importância do cloro para a indústria química é extraordinária, motivo pelo qual a sua substituição encontra enorme dificuldade econômica, e, mais do que isso, o seu valor para a vida de cada um de nós, ainda, é de uma relevância tal que dificilmente se poderia imaginar a vida moderna dissociada do cloro e de todas as suas consequências, sejam as positivas, sejam as negativas. Já existem estudos e pesquisas que buscam substituir o cloro como elemento de tratamento de água por outras substâncias potencialmente menos danosas. *“Experimentos realizados na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP comprovaram que a utilização de ozônio, ácido peracético, ou um processo combinado envolvendo ozônio e cloro, podem ser alternativas ao uso do cloro na desinfecção de água para consumo humano.”*⁷ A utilização do cloro para o tratamento de água teve início no começo do século XX, nos Estados Unidos. A experiência pioneira realizada naquele país rapidamente começou a se expandir pelos mais diferentes recantos do mundo. Os resultados alcançados pela utilização do cloro para a purificação de água podem ser classificados como espetaculares, pois o número de casos de febre tifoide por veiculação hídrica decaiu de 25.000 em 1900 para apenas 20 em 1960.⁸ No Brasil, desde 1925 – em São Paulo – é obrigatória a utilização do cloro como elemento purificador da água utilizada para o abastecimento público. Em outros setores da medicina, igualmente, o cloro é um produto da maior importância: “Dos mais de 400 novos compostos aprovados para o uso terapêutico em pessoas, desde 1984, mais de 60 são compostos clorados e muitos outros usam cloro como intermediário em sua fabricação. Mais de 2 mil compostos orgânicos clorados ocorrem também na natureza. Esses compostos são produzidos como parte do ciclo de vida de plantas, organismos marinhos, insetos, bactérias e fungos, assim como nas atividades atmosférica e geológica”.

17.2.7.2 A Regulamentação legal da produção de cloro no Brasil

A Lei nº 9.976, de 3 de julho de 2000, tem como objetivo precípuo o estabelecimento de normas para a produção de cloro pelo processo de eletrólise em todo o território nacional. Em primeiro lugar, há que considerar que a lei em comento não estabeleceu uma proibição das tecnologias de produção de cloro pelo processo de eletrólise utilizadas no país até a data de sua edição. Como se verá, a norma legal estabeleceu uma proibição *ex nunc* e criou critérios rígidos de controle para as empresas já instaladas no território nacional. A medida legal adotada pelo legislador é razoável e de bom-senso, pois não desativa o parque industrial do setor e exige padrões tecnológicos, ambientais e de segurança do trabalho mais rígidos para as empresas que venham a se instalar em território nacional. Há, portanto, uma transição tecnológica contemplada na lei. As indústrias que estavam operando na data da edição da lei e que utilizavam o processo de eletrólise para a produção de cloro podem continuar a fazê-lo, desde que observem o seguinte:

- i) cumprimento da legislação de segurança, saúde no trabalho e meio ambiente vigente;
- ii) análise de riscos com base em regulamentos e normas legais vigentes;
- iii) plano interno de proteção à comunidade interna e externa em situações de emergência;
- iv) plano de proteção ambiental que inclua o registro das emissões.

17.2.7.2.1 Controle da presença de mercúrio no processo produtivo

Especial ênfase foi dada ao controle do mercúrio, tendo sido estabelecidas as seguintes obrigações para as indústrias:

- a) sistema de reciclagem e/ou tratamento de todos os efluentes, emissões e resíduos mercuriais;
- b) paredes, pisos e demais instalações construídas de forma a minimizar perdas de mercúrio;
- c) operações de manuseio, recuperação, manutenção e armazenagem de mercúrio que evitem a contaminação dos locais de trabalho e do meio ambiente;
- d) avaliações ambientais conforme normas específicas para esse agente.

Ainda quanto à presença do mercúrio, faz-se necessária a existência de um programa de prevenção da exposição ao mercúrio que inclua:

- a) avaliação de risco para a saúde do trabalhador;
- b) adoção de medidas de controle de engenharia, operações administrativas e equipamentos de proteção individual – EPIs;
- c) monitoramento da exposição e gerenciamento do risco;
- d) ação de vigilância à saúde dos trabalhadores próprios e de terceiros;
- e) procedimentos operacionais, de manutenção e de atividades de apoio.

17.2.7.2.2 Controle da presença de amianto

Da mesma forma que para o mercúrio, a lei estabeleceu critérios bastante estritos para o controle do amianto no processo produtivo. Assim, é necessário que a empresa tenha um sistema gerencial de controle de amianto que obrigatoriamente contemple o seguinte:

- a) utilização de amianto somente do tipo crisotila;
- b) ambiente fechado com filtração de ar para o manuseio do amianto seco;
- c) locais controlados nas operações de preparação e remoção de diafragmas de amianto;
- d) segregação de resíduos do amianto, tratamentos e destinações adequadas, com registro interno de todas as etapas;
- e) vestiários adequados para o acesso às áreas do amianto por pessoas designadas;
- f) vigilância da saúde na prevenção de exposição ocupacional ao amianto com procedimentos bem definidos de toda ação de controle; e
- g) disponibilidade de equipamento de proteção individual e uniformes específicos para operações nessa área.

17.2.7.2.3 Aspectos de segurança e saúde do trabalhador

Sempre que os dados originários do sistema de monitoramento ambiental indiquem a ultrapassagem dos padrões legalmente obrigatórios, deverá ser providenciado o afastamento temporário, do trabalhador, do local de risco, até que medidas de controle sejam adotadas e o indicador biológico normalizado. É indiscutível que tal afastamento deverá ser suportado financeiramente pela indústria, não podendo haver, em decorrência dele, qualquer redução salarial do empregado.

Em função do elevado potencial de danos ao meio ambiente e à saúde humana, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs têm o dever legal de estabelecer mecanismos aptos a propiciar a adequada discussão dos riscos para a saúde e para o meio ambiente em decorrência do uso do mercúrio e do amianto.

17.2.7.2.4 Monitoramento

As indústrias são obrigadas a possuir planos de automonitoramento, isto é, elas próprias são obrigadas a manter registros e documentos capazes de informar os padrões de efluentes e de emissões de suas instalações, de forma clara e insofismável, sempre que solicitados pelo órgão ambiental. Nos mencionados planos deverá estar especificado, no mínimo, o seguinte:

- a) forma e metodologia do monitoramento;
- b) estratégia de amostragem;
- c) registro e disponibilização dos resultados médios de monitoramento.

17.2.7.3 Ampliação e modificação de indústrias já instaladas

A lei proibiu a instalação de novas indústrias de produção de cloro à base da eletrólise, mas não proibiu a chamada “*modificação substancial*” naquelas atualmente existentes que utilizam processos a mercúrio ou diafragma de amianto; condicionou-as, entretanto, ao registro, prévio, mediante comunicação formal aos órgãos públicos competentes, sem prejuízo das exigências legais pertinentes. A própria lei definiu as *modificações substanciais* como aquelas alterações de processo, instalações, equipamentos e área envolvida diretamente no processo de eletrólise que:

- i) aumentem a capacidade nominal de produção da fábrica;
- ii) modifiquem a área utilizada;
- iii) alterem o tipo de célula;
- iv) aumentem o número de células existentes;
- v) possam resultar em impactos ambientais em função de:
 - a) mudança de matérias-primas e insumos;
 - b) aumento de geração de poluentes nas águas, ar e resíduos sólidos;
 - c) alterações nas formas e quantidades de energias utilizadas; e
 - d) aumento no consumo de água;
- vi) possam resultar em alterações nos riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e das instalações.

Penso que, da forma que a lei tratou a matéria, não se pode deixar de considerar que as chamadas modificações substanciais, sub-repticiamente, são um prolongamento “branco” do processo já proibido por lei. Tendo em vista que a lei expressamente refere-se a modificações cujos impactos ambientais são negativos, pois admite o aumento de geração de efluentes nas águas, ar e ampliação dos resíduos sólidos; bem como contempla alteração nas quantidades e formas de energia e, principalmente, admite a possível existência de riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e das instalações, o que indiretamente pressupõe riscos para os vizinhos da instalação, é evidente que a mera comunicação ao órgão ambiental não é suficiente para dar tintas de legalidade ao procedimento. *O § 1º do artigo 4º não pode ser interpretado como uma cláusula permissiva para a elisão de obrigações ambientais.* A sua interpretação deve ser feita em harmonia com o conjunto das normas de proteção ambiental previstas na Constituição Federal, na legislação ordinária e na própria lei que o contempla. Em assim sendo, a *comunicação formal* de que trata a lei *somente pode ser entendida como o requerimento formal de novo licenciamento ambiental, submetido a todas as regras a ele pertinentes.* Em princípio, inclusive, não deve ser descartada a exigência de novo estudo de impacto ambiental, pois a própria lei menciona alterações ambientais adversas que, se autorizadas, necessitam da realização, prévia, de estudo de impacto. Outra não pode ser a conclusão, pois a atividade impactante está submetida ao poder de polícia ambiental e, em tais condições, somente pode ser exercida após licenciada. O empreendedor não goza do direito potestativo de meramente comunicar – ainda que formalmente – ao órgão ambiental as modificações que pretende implantar em seu estabelecimento. Pelo § 2º do artigo 4º, “*ficam vedadas ampliações desses processos que configurem construções de novas salas de células ou circuitos completos adicionais aos já existentes*”. A vedação da ampliação é coerente com a proibição da implantação de novas indústrias, pois muitas ampliações são verdadeiramente novas instalações industriais.

É importante notar que, sempre que se falar em novas tecnologias, estas somente poderão ser implantadas se precedidas de análise de risco, conforme preceitua o artigo 5º da lei.

17.2.7.4 Penalidades

A não observância das normas e determinações contempladas na lei que ora se examina sujeitam os infratores às seguintes penalidades:

- i) advertência;
- ii) multa;
- iii) suspensão temporária da atividade industrial; e iv) suspensão definitiva da atividade industrial.

De observar, no entanto, que as penalidades previstas na Lei nº 9.605 são aplicáveis às hipóteses de violação da norma específica sobre a produção de cloro.

17.2.8 Pilhas e baterias

17.2.8.1 Aspectos gerais

Um dos mais graves problemas gerados pelos resíduos sólidos é aquele causado pela disposição final de pilhas e baterias. Essa situação se deve ao fato de que grande parte desses produtos possui em sua composição química diferentes espécies de metais pesados. A questão é extremamente grave, pois, como não se desconhece, o consumo de tais mercadorias é crescente e não parece estar próximo de se deter, ao contrário, constantemente aparecem novos equipamentos e aparelhos que demandam fontes autônomas de energia, cada vez mais poderosas. A matéria cuja importância é óbvia por si própria, evidentemente, necessita de um urgente tratamento legal.

O Conama, desconhecendo a extensão do problema, buscou estabelecer uma disciplina para a matéria, e o fez através da edição da Resolução Conama 257, de 30 de junho de 1999. Quando da edição da norma pelo Conama, certamente, havia inúmeras controvérsias acerca da legalidade da Resolução nº 257/99; contudo, com o advento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 33, II), a matéria foi pacificada, haja vista que existe, em princípio, compatibilidade da Resolução com o Texto legal.

17.2.8.2 Definição de pilhas e baterias

O artigo inaugural da Resolução Conama nº 257/99 estabelece que:

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

A resolução estabeleceu cinco categorias distintas de obrigações (i) para os usuários das pilhas e baterias: obrigação de entregar aquelas que já se tenham esgotado aos revendedores; (ii) para os comerciantes e assistência técnica autorizada: receber as pilhas e baterias usadas e repassá-las aos fabricantes ou importadores; (iii) para os fabricantes e importadores: receber os produtos já utilizados e dar-lhes destino final adequado. O mesmo procedimento deve ser adotado quando se tratar de baterias industriais, guardadas as peculiaridades próprias.

É imperioso registrar que foi somente em seu artigo 2º que a Resolução estabeleceu os conceitos normativos de pilhas e baterias – elemento absolutamente indispensável para que se possa saber qual é o alcance da norma legal. Dessa forma, foram adotadas as seguintes definições:

I – bateria: conjunto de pilhas ou acumuladores recarregáveis interligados convenientemente (NBR 7039/87); II – pilha: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante conversão geralmente irreversível de energia química (NBR 7039/87); III – acumulador chumbo-ácido: acumulador no qual o material ativo das placas positivas é constituído por compostos de chumbo, e os das placas negativas essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido sulfúrico (NBR 7039/87); IV – acumulador (elétrico): dispositivo eletroquímico constituído de um elemento, eletrólito e caixa, que armazena, sob forma de energia química, a energia elétrica que lhe seja fornecida e que a restitui quando ligado a um circuito consumidor (NBR 7039/87); V – baterias industriais: são consideradas baterias de aplicação industrial, aquelas que se destinam a aplicações estacionárias, tais como telecomunicações, usinas elétricas, sistemas ininterruptos de fornecimento de energia, alarme e segurança, uso geral industrial e para partidas de motores diesel, ou ainda tracionárias, tais como as utilizadas para movimentação de cargas ou pessoas e carros elétricos; VI – baterias veiculares: são consideradas baterias de aplicação veicular aquelas utilizadas para partidas de sistemas propulsores e/ou como principal fonte de energia em veículos automotores de locomoção em meio terrestre, aquático e aéreo, inclusive de tratores, equipamentos de construção, cadeiras de roda e assemelhados; VII – pilhas e baterias portáteis: são consideradas pilhas e baterias portáteis aquelas utilizadas em telefonia, e equipamentos eletroeletrônicos, tais como jogos, brinquedos, ferramentas elétricas portáteis, informática, lanternas, equipamentos fotográficos, rádios, aparelhos de som, relógios, agendas eletrônicas, barbeadores, instrumentos de medição, de aferição, equipamentos médicos e outros; VIII – pilhas e baterias de aplicação especial: são consideradas pilhas e baterias de aplicação especial aquelas utilizadas em aplicações específicas de caráter científico, médico ou militar e aquelas que sejam parte integrante de circuitos eletroeletrônicos para exercer funções que requeiram energia elétrica ininterrupta em caso de fonte de energia primária sofrer alguma falha ou flutuação momentânea.

17.2.8.3 Obrigações

Pelos artigos 3º e 4º, foi estabelecida a obrigatoriedade de que os estabelecimentos que comercializem os produtos tratados pelo artigo 1º da resolução, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores de tais produtos, aceitem dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas características sejam similares àquelas comercializadas, com vistas aos procedimentos referidos no artigo 1º. As pilhas e baterias recebidas devem ser acondicionadas adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas as normas ambientais e de saúde pública, bem como as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu repasse a estes últimos. Em primeiro lugar, há que se observar que a obrigação de receber pilhas e baterias não se restringe àquelas que sejam comercializadas pelo receptor. Quaisquer pilhas e baterias que sejam similares às comercializadas devem ser recebidas.⁹

Pelo artigo 5º da resolução, foram fixados prazos para o estabelecimento de novos padrões técnicos a serem adotados pelas pilhas e baterias a serem importadas, fabricadas e comercializadas no Brasil. Os padrões técnicos e os prazos definidos pelo Conama são os seguintes:

A partir de 1º de janeiro de 2000, a fabricação, importação e comercialização de pilhas e baterias deverão atender aos limites estabelecidos a seguir: I – com até 0,025% em peso de mercúrio, quando forem do tipo zinco-manganês e alcalina-manganês; II – com até 0,025% em peso de cádmio, quando forem do tipo zinco-manganês e alcalina-manganês; III – com até 0,400% em peso de chumbo, quando forem do tipo zinco-manganês e alcalina-manganês; IV – com até 25 mg de mercúrio por elemento, quando forem do tipo pilhas miniaturas e botão.

Para o ano de 2001, foram estabelecidas as seguintes normas, conforme determinação contida no artigo 6º:

A partir de 1º de janeiro de 2001, a fabricação, importação e comercialização de pilhas e baterias deverão atender aos limites estabelecidos a seguir: I – com até 0,010% em peso de mercúrio, quando forem do tipo zinco-manganês e alcalina-manganês; II – com até 0,015% em peso de cádmio, quando forem dos tipos alcalina-manganês e zinco-manganês; III – com até 0,200% em peso de chumbo, quando forem dos tipos alcalina-manganês e zinco-manganês.

A disposição final das pilhas e baterias somente pode ser feita dentro de padrões técnicos capazes de assegurar que elas não venham a causar danos ecológicos ou à saúde humana, restando proibidos, pelo artigo 8º da norma em comento, os seguintes tipos de destinação final de pilhas e baterias usadas, de quaisquer tipos ou características:

I – lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais; II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme legislação vigente; III – lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

Desde que atendam às exigências estipuladas pelo artigo 6º, as pilhas e baterias poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros sanitários licenciados; vale observar, todavia, que os fabricantes e importadores devem identificar os produtos, pela aposição nas embalagens e, quando couber, nos produtos, de símbolo que permita ao usuário distingui-los dos demais tipos de pilhas e baterias comercializados.

Medida cautelar. Dano ao meio ambiente. Despejo de pilhas e baterias em aterros sanitários. Ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da medida. Improcedência. 1. Cuida-se de medida cautelar interposta por Energizer do Brasil Ltda. para emprestar efeito suspensivo a recurso especial interposto de acórdão prolatado em sede de agravo de instrumento que manteve decisão concessiva de tutela antecipada que compeliu a requerente a proceder à destinação que entendesse mais adequada às pilhas e baterias que importa e comercializa não podendo mais despejá-las nos aterros sanitários, sob pena de multa diária por dano ao meio ambiente. Revolta-se a recorrente quanto ao fato de que, tendo sido interpostos agravos de instrumentos individualmente, por cada uma das empresas, estas lograram provimento, enquanto que o mesmo não lhe sucedeu. Sustenta a presença do fumus boni iuris,

na medida em que cumprindo a legislação aplicável ao caso da lide, e do periculum in mora, pois o procedimento do recurso especial sem o efeito concessivo requerido acarretará a obrigatoriedade de a requerente, sozinha, cumprir a determinação do Juízo de 1ª Instância sob pena de pagamento de multa diária em valor elevado. 2. Para atribuição do efeito suspensivo ora postulado, faz-se necessário um mínimo de aparência de bom direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora), que estão direta e simultaneamente ligados à possibilidade de êxito do recurso especial e à necessidade de urgência da prestação recursal. (MC 11.632/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros) 3. O artigo 13 da Resolução 257/99 do Conama invocado pela requerente para configurar o fumus boni iuris alegado, encontra-se com a sua legalidade questionada, não servindo, pois, para configuração do requisito da fumaça do bom direito. Por outro lado, o acórdão impugnado mediante o recurso especial, ao qual se pretende emprestar efeito suspensivo, desproveu o agravo da requerente por entender insuficientes as provas apresentadas para solução da controvérsia, comprometendo o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. Não está patenteado o perigo da demora alegado pela parte interessada, até mesmo porque o julgamento prolatado em relação às outras não vincula a Câmara Cível que o proferiu à requerente. 4. Medida cautelar improcedente. Agravo regimental prejudicado (STJ, Medida Cautelar 200700411297, Ministro José Delgado, 1ª Turma, DJU: 19/11/2007, p. 184).

A reutilização, reciclagem, tratamento ou a disposição final das pilhas e baterias abrangidas por esta resolução, realizados diretamente pelo fabricante ou por terceiros, deverão ser processados de forma tecnicamente segura e adequada, com vistas a evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, principalmente no que tange ao manuseio dos resíduos pelos seres humanos, filtragem do ar, tratamento de efluentes e cuidados com o solo, observadas as normas ambientais, especialmente no que se refere ao licenciamento da atividade, conforme determinado pelo artigo 14. Caso não seja possível a reutilização ou reciclagem das pilhas e baterias, a destinação final por destruição térmica deverá obedecer às condições técnicas previstas na NBR – 11175 – Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos – e os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução Conama nº 3, de 28 de junho de 1990.

17.3 TRANSPORTE DE PRODUTOS TÓXICOS

A importância do exame da regulamentação jurídica do transporte rodoviário de produtos perigosos é imensa, pois, no Brasil, é por meio do transporte rodoviário que circula a imensa maioria de nossas mercadorias. Logo, os produtos perigosos, igualmente, são, em grande parte, transportados por via terrestre, mediante a utilização de caminhões e outros veículos automotores. O regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos foi aprovado pelo Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988. O referido regulamento é aplicável, apenas, ao transporte civil de produtos perigosos; o transporte militar obedece à regulamentação própria.

Observe-se, entretanto, que não é apenas o Ministério do Transporte o órgão dotado de atribuições para definir o ordenamento aplicável ao transporte de produtos perigosos. Quando se tratar de produtos explosivos, o transporte rodoviário deverá observar, também, as normas emanadas do Ministério do Exército. Na hipótese de transporte de produtos radioativos, deverá ser observada, também, a regulamentação originária da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. A definição jurídica de produto perigoso é aquela fixada pelo Ministro de Estado dos Transportes, em ato próprio.

O regulamento busca estabelecer medidas que sejam capazes de disciplinar o transporte rodoviário de produtos perigosos em seu ciclo completo. Em assim sendo, a regulamentação se estende desde as condições de transporte, nelas compreendidos os veículos e equipamentos; a carga e a sua maneira de ser acondicionada; o itinerário; o estacionamento etc.

17.3.1 Condições de transporte

Somente poderão proceder ao transporte de produtos perigosos os veículos que se enquadrem em padrões de segurança estabelecidos por normas brasileiras especialmente voltadas para o setor. Tais veículos deverão possuir um atestado de qualidade fornecido pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou por órgão por ele credenciado. Tais veículos, ademais, estão sujeitos à vistoria em lapso de tempo não superior a três anos. Há, ainda, a necessidade de que, em caso de acidente com os veículos, os mesmos somente retornem à atividade após serem vistoriados e periciados pelo Inmetro ou órgão legalmente credenciado.

Os veículos destinados ao transporte de produtos perigosos deverão portar rótulos de risco e painéis de segurança especificados de acordo com normas técnicas. Todos os veículos deverão ser equipados com tacógrafos, cujos discos deverão permanecer à disposição do expedidor, do contratante, do destinatário e do órgão fiscalizador pelo período de três meses, excepcionando-se os casos de acidente, quando deverão permanecer acautelados por um ano.

Toda a carga deverá ficar acondicionada de forma segura e identificada, acusando a classificação do produto e o seu risco. A responsabilidade pelo acondicionamento e as consequências pela sua inexata realização pertencem ao expedidor. Em se tratando de produto importado, tal responsabilidade é do importador.

Os produtos perigosos não podem ser transportados juntamente com animais, alimentos ou outro tipo de carga que não tenha, com os mesmos, compatibilidade.

Os veículos transportadores de produtos perigosos devem procurar observar itinerários adequados, evitando as áreas densamente povoadas, as de proteção de mananciais, reservatórios de água ou reservas florestais e ecológicas. O estacionamento de tais veículos somente poderá ocorrer em áreas previamente determinadas e, na inexistência destas, deverá ser evitado estacionamento em locais que possam importar risco para a coletividade.

17.4 TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS ENTRE BRASIL, ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI

A matéria foi tratada pelo Decreto nº 1.797, de 25 de janeiro de 1996, que “*dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994*”. Os quatro países integrantes do chamado “cone sul” firmaram, em 30 de dezembro de 1994, em Montevideu, o Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na forma do Decreto nº 1.797/96, artigo 1º, “*o Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência*”.

Administrativo. Transporte rodoviário de produtos perigosos no território nacional. Autorização, pelo DNER, de utilização de rodotrens (combinações de veículos de carga – CVCs). Decreto 96.044/88, Código Brasileiro de Trânsito e Resolução 68/98 do Contran. Proibição prevista no acordo de alcance para facilitação de transporte internacional de produtos perigosos celebrado pelos países membros do Mercosul (Decreto 1.797/96). Inaplicabilidade. 1. O Acordo Internacional, nacionalizado pelo Decreto 1.797/96, tem força de lei ordinária nos limites da norma. 2. Consecutivamente, no concurso com as normas internas, aplica-se a regra da Lei de Introdução ao Código Civil, constante do art. 2º, § 2º, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica a lei anterior” [...]. 3. *In casu*, o Acordo regula o transporte internacional de produtos perigosos realizado entre os Estados Partes do Mercosul e o Código Brasileiro de Trânsito, o transporte interno. As condições do transporte dos produtos perigosos restaram estipuladas no Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto 96.044/88. 4. O Contran, com base no artigo 97, do CBT, expediu a Resolução 68/98, que estabeleceu os requisitos de segurança necessários à circulação de Combinações de Veículos de Carga – CVC. 5. À luz das referidas premissas, a instância *a quo* assentou que: “Administrativo. Autorização especial de trânsito de produtos perigosos. Deferimento relativo a trechos rodoviários internos que não é afetado pelo Acordo de Alcance para Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos celebrado pelos países do Mercosul. [...]” 6. Deveras, “[...] não há conflito com a Lei nº 9.503/97, que fixou a competência do Contran para estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito e as diretrizes da política nacional de trânsito. A Resolução nº 68 do Contran, com fulcro no CNT, além de posterior ao Decreto nº 1.797/96, regulamenta matéria específica, ditando os requisitos de segurança necessários à circulação de CVC. Aliás, o Decreto nº 1.797/96, por tratar de **transporte** internacional de produtos perigosos, não revogou o Decreto-lei nº 96.044/88, que regulamenta o transporte rodoviário dos mesmos produtos no âmbito interno, eis que desarrazoado imaginar que a legislação pátria teria aplicação fora do território brasileiro. Descabe invocar,

portanto, o critério temporal no afã de defender tese contrária. Como o âmbito de aplicação das normas é diverso, embora cuidem da mesma matéria, não há o suposto conflito. Com efeito, a Autorização Especial de Trânsito especifica o itinerário a ser percorrido pelos veículos – limitando-o a estradas brasileiras. Então não há falar em relação de transporte internacional, nem de aplicação do Decreto nº 1.797/96. Óbvio que a AET não vingaria diante da pretensão de transpor a raia nacional. Seria mesmo teratológico que a Polícia Rodoviária obstaculizasse o tráfego dos veículos, inobstante especialmente autorizados a circular no território nacional, sob a invocação de um Decreto que fiscaliza o transporte entre os países do Mercosul. Tal mister deve ser exercido na fronteira com os países vizinhos, sob pena de tornar-se inócua a Autorização fornecida pelo DNER” (fl. 154). 7”. (STJ, REsp 200500135957, Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJU: 27/3/2006, p. 186).

17.4.1 Acordo de alcance parcial para a facilitação do transporte de produtos perigosos

Todo o transporte dos produtos das classes 1 e 7 dos Anexos do Acordo, e dos resíduos perigosos, é regido pelas disposições do Acordo de “*Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos*” e pelas normas específicas estabelecidas por organismos competentes de cada um dos Estados-Partes. Cada um dos Estados-Partes poderá, mediante prévia comunicação aos demais membros do acordo, proibir a entrada de qualquer produto perigoso em seu território.

As entradas e saídas de produtos perigosos realizadas de acordo com as exigências estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (OMI) e pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI) devem ser aceitas pelos Estados-Partes. A circulação das unidades de transporte com produtos perigosos é regida pelas normas gerais estabelecidas no acordo e pelas disposições particulares de cada um dos Estados-Partes.

17.4.1.1 Embalagens

O transporte de produtos perigosos deverá ser feito colocando-os em embalagens ou equipamentos que:

- i) sejam capazes de atender aos requisitos estabelecidos nas Recomendações das Nações Unidas para o Transporte de Produtos Perigosos;
- ii) estejam marcados e identificados;
- iii) estejam em conformidade com as práticas nacionais que atendam a tais requisitos.

17.4.1.2 Veículos

O transporte de produtos perigosos somente pode ser realizado por veículos cujas características técnicas e estado de conservação assegurem segurança compatível com o risco correspondente aos produtos transportados. Durante as operações de carga, transporte, descarga e transbordo de produtos perigosos ou de limpeza e descontaminação, os veículos deverão ostentar os rótulos de risco e painéis de segurança identificadores dos produtos e dos riscos a eles associados. Na documentação utilizada para o transporte de produtos perigosos devem estar incluídas informações capazes de identificar, de forma clara, o material transportado e indicar todos os procedimentos que devem ser adotados em caso de emergência.

A equipe responsável pelo transporte e manuseio de produtos perigosos deve possuir treinamento específico para as suas atribuições, bem como possuir o equipamento de proteção adequado. É importante observar que, na forma do artigo 10, “*os certificados e os relatórios de ensaios expedidos em um Estado-Parte serão aceitos pelos demais, quando exigidos no contexto deste acordo*”. Isso significa que a legislação aplicável quanto à documentação é a do país no qual o veículo de transporte esteja registrado.

17.4.2 Normas técnicas

As normas técnicas para o transporte de produtos perigosos foram definidas pela Portaria nº 22, de 19 de janeiro de 2001, publicada no *Diário Oficial da União* em 24 de janeiro de 2001.

17.5 TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Embora sem a importância estatística que mereceria, o transporte ferroviário de produtos perigosos é muito importante, pois alivia a pressão sobre as rodovias e, conseqüentemente, desempenha papel de reduzir o risco de impactos ambientais altamente negativos, que são os causados pelos acidentes rodoviários com produtos perigosos. A matéria foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 98.973, de 21 de fevereiro de 1990, que “*aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos*”.¹⁰

17.5.1 Aplicabilidade do regulamento

O regulamento aprovado pelo Decreto nº 98.973/90 aplica-se ao transporte ferroviário de produtos perigosos, excluído o realizado pelas Forças Armadas, que é disciplinado por legislação específica.

O regulamento do transporte, por via férrea, de produtos que, por suas características, sejam perigosos ou representem riscos para a vida e a saúde das pessoas, para a segurança pública, assim como para o meio ambiente ou para a própria ferrovia, não impede a aplicação do disposto na legislação peculiar a cada produto perigoso, nem da legislação geral de proteção ao meio ambiente. Produtos perigosos, para efeito de transporte, são aqueles relacionados em portaria baixada pelo Ministério dos Transportes. Quando se tratar de transporte de produtos explosivos e de substâncias radioativas, aplicam-se, também, as normas próprias do Ministério da Defesa, bem como da Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme o caso.

Outras normas aplicáveis:

Portaria MT 349, de 4 de junho de 2002 – Aprova as Instruções para a Fiscalização do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional.

Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 – Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

Resolução ANTT nº 701, de 25 de agosto de 2004 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo.

Resolução ANTT nº 1.644, de 26 de novembro de 2006 – Altera o Anexo à Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

Portaria Denatran/MJ nº 1, de 5 de fevereiro de 1998 – Baixa as instruções a serem adotadas quando da elaboração e do preenchimento do Auto de Infração, anexo I, conforme Resolução nº 1/98, de 23/1/1998, do Conselho Nacional de Trânsito.

Portaria Denatran/MJ nº 38, de 10 de dezembro de 1998 – Acrescenta ao Anexo IV da Portaria nº 01/98 – DENATRAN, os códigos das infrações referentes ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

Portaria INMETRO nº 8, de 16 de janeiro de 2001 – Publica a proposta do texto de Portaria para a Regulamentação Técnica de Cilindros de Liga Leve para Armazenamento de Gás Metano Veicular.

Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001 – Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser

destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.

Decreto nº 4.262, de 10 de junho de 2002 – Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.

Portaria MJ nº 1274, de 26 de agosto de 2003 – Exerce o controle e a fiscalização de precursores e outros produtos químicos essenciais empregados na fabricação clandestina de drogas, como estratégia fundamental para prevenir e reprimir o tráfico ilícito e o uso indevido de entorpecentes e substâncias psicotrópicas.

Resolução CONTRAN/MJ nº 168, de 14 de dezembro de 2004 – Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências.

§ 2º AGROTÓXICOS

O Brasil é o único País do mundo que adota o termo agrotóxico para designar os produtos químicos utilizados na agricultura para o combate de pragas. Como sabemos, tóxico é algo ruim, capaz de fazer mal.¹¹ Por sua vez, o termo defensivo agrícola “consiste em produtos, que servem não para intoxicar a lavoura ou o consumidor, mas sim para defender a plantação de pragas, insetos e parasitas, garantindo a alimentação de milhares de pessoas.”¹² Assim, parece claro que o legislador Brasileiro privilegiou os aspectos negativos dos produtos químicos utilizados na agricultura em detrimento de seus aspectos positivos. Utilizaremos o termo agrotóxico por ser o legal.

A inadequada utilização dos agrotóxicos representam um dos mais graves problemas de poluição causada por produtos químicos. As suas implicações são muito graves, pois abrangem área que oscila desde a produção de alimentos e da sua qualidade até a saúde humana afetada, seja pelos próprios agrotóxicos, seja pelo consumo de alimentos contaminados.

Agrotóxicos são produtos químicos destinados à utilização pela agricultura com a finalidade de combate às pragas ou destinados a aumentar a produtividade de determinadas culturas. Inicialmente, foram denominados como *fertilizantes* ou *defensivos agrícolas*, denominações estas que caíram em desuso, tendo em vista a adoção de nova denominação pela lei brasileira.

A aplicação dos agrotóxicos por lavradores com baixo nível de escolaridade e cultura formal tem gerado um explosivo coquetel de agrotóxicos e doenças causadas por intoxicação.

A problemática dos agrotóxicos é complexa, pois implica, inclusive, questões referentes à economia nacional, autossuficiência de alimentos, pauta de exportações e saúde pública. Deve ser observado que, ainda hoje, a agricultura sem produtos químicos é apenas uma esperança, haja vista que se logrou, até aqui, uma produção agrícola de grande escala que seja isenta de produtos químicos; mesmo a agricultura transgênica demanda certo grau de utilização de produtos químicos.

17.6 REGIME LEGAL DOS AGROTÓXICOS

A Constituição Federal, em seu capítulo dedicado ao meio ambiente, não deixou passar em branco o tema relativo ao controle de agrotóxicos (art. 225, § 1º, V). A norma constitucional teve um efeito multiplicador junto aos legisladores constituintes estaduais.

17.6.1 Antecedentes legislativos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989

17.6.1.1 Decreto nº 24.414, de 12 de abril de 1934

A primeira norma federal a tratar do tema foi o Decreto Federal nº 24.414, de 12 de abril de 1934. O objetivo do Decreto foi o de colaborar com a modernização da agricultura que, à época, era a principal atividade econômica brasileira. O decreto ainda se encontra em vigor, com pequenas alterações feitas pelo Decreto-lei nº 5.478, de 12 de maio de 1943, e Decreto nº 6.946, de 2009, no que diz respeito a aspectos da defesa sanitária, excluídos os aspectos referentes aos agrotóxicos.

Na legislação estadual, foi o Estado do Rio Grande do Sul um dos que primeiro tratou do assunto, mediante a promulgação de uma lei bastante completa. Tal lei, contudo, foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal: “*o Poder de Polícia do Estado pode manter e atualizar a utilização de agrotóxicos e outros biocidas, respeitando a classificação toxicológica da União*” (STF, REsp nº 1.153/RS, 27/11/1985). Tal decisão foi proferida na vigência da Carta Constitucional anterior, muito embora o Supremo Tribunal Federal (RE 286789/RS, julgamento 8/3/2005, 2ª Turma, DJU: 8/4/2005, p. 138-141) tenha entendido que diante da Carta de 1988 não houve alteração significativa das competências em matéria de agrotóxicos, contudo, a evolução da jurisprudência da Corte caminhou no sentido de entender que, além de agrotóxicos, a norma dispunha sobre saúde pública. “1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e apartou as normas desta lei que superavam os limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde. 3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88). 4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Ministra Ellen Gracie).

17.7 A LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989

A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, com nova redação dada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000 é o instrumento normativo que se encontra vigente com a finalidade de disciplinar a matéria em âmbito federal.

A competência legislativa em matéria de agrotóxicos, seus componentes e afins é aquela definida na Constituição Federal e na própria Lei nº 7.802/89. Paralelamente à competência administrativa, existe, como se sabe, a competência legislativa da qual cada um dos integrantes da Federação possui uma parcela definida. Em sede legal, o artigo 9º da Lei nº 7.802/89 determinou que a *União*, no exercício de sua competência, adotasse as seguintes medidas:

- legislar sobre produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;
- controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação;
- analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados; e
- controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.

Em conformidade com os artigos 23 e 24 da Constituição Federal, compete aos *Estados* e ao *Distrito Federal* legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o

comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Aos Municípios cabe, supletivamente, legislar sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins.

Constitucional. Meio ambiente. Legislação municipal supletiva. Possibilidade. Atribuindo, a CF, a competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, cabe, aos municípios, legislar supletivamente sobre a proteção ambiental, na esfera do interesse estritamente local. A legislação municipal, contudo, deve se restringir a atender às características próprias do território em que as questões ambientais, por suas particularidades, não contem com o disciplinamento consignado na lei federal ou estadual. A legislação supletiva, como é cediço, não pode ineficacizar os efeitos da lei que pretende complementar, uma vez autorizada pela União a produção e deferido o registro do produto, perante o ministério competente, é defeso aos municípios vedar, nos respectivos territórios, o uso e o armazenamento de substâncias agrotóxicas, extrapolando o poder de complementar, em desobediência à lei federal. A proibição de uso e armazenamento, por decreto e em todo o município, constitui desafeição à lei federal e ao princípio da livre iniciativa, campo em que as limitações administrativas hão de corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva, sem o aniquilamento das atividades reguladas. Recurso conhecido e improvido. Decisão indiscrepante (STJ. REsp 29299/RS. Relator: Ministro Demócrito Reinaldo. 1ª Turma. *DJU* 17/10/1994, p. 27861).

E mais:

Processual civil e ambiental. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Uso de herbicida. Lei municipal proibitiva. Ofensa ao art. 18 da Lei nº 1.533/51. Não caracterização. Direito supletivo dos **municípios** de legislar em matéria de seu peculiar interesse. Matéria constitucional. Decisão. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com fundamento na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fls. 358/359): Reexame necessário – Mandado de Segurança preventivo – Cabimento – Lei municipal que proíbe o uso do herbicida 2.4-D E comina sanções – Ilegalidade – Matéria regulamentada por lei federal – Produto devidamente registrado nas esferas federal e estadual – Ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo – Incompetência do município para legislar sobre a matéria – Segurança concedida – Decisão mantida. A possibilidade de aplicação de sanção em virtude do uso do herbicida fabricado e comercializado, em completa conformidade com as legislações federal e estadual que disciplinam a matéria, pelo órgão de fiscalização municipal, representa efetiva ameaça de violação a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança. Ao Município não cabe legislar sobre a matéria de meio ambiente já disciplinada em lei federal. Nesta área a competência legislativa do Município é complementar, não podendo invadir a esfera de competência da União e dos Estados, consoante estabelece o artigo 24, inciso IV, da Constituição Federal. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em efeitos infringentes (fl. 442). Em suas razões recursais (fls. 410/423 e 448), sustenta o recorrente que o referido acórdão violou os arts. 535 do Código de Processo Civil – CPC, 18 da Lei nº 1.533/51 e 11 da Lei nº 7.802/89. Nas contrarrazões (fls. 459/479), defende a recorrida a manutenção do acórdão combatido. O recurso especial foi admitido na instância ordinária (fls. 498/503) e os autos subiram a esta Corte Superior. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, é de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. [...] Em segundo lugar, no que tange à suposta ofensa ao art. 18 da Lei nº 1.533/51, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que tal dispositivo não é aplicável aos casos de mandado de segurança preventivo. Confira-se um exemplo emblemático para o presente caso: Processual civil. Administrativo. Lei municipal que restringe a utilização e comercialização de herbicida 2.4-D. Mandado de Segurança. Caráter preventivo. Prazo decadencial. Inaplicabilidade do art. 18 da Lei 1533/51. Precedentes jurisprudenciais. 1. O mandado de segurança que objetiva impedir eventual imposição de multa decorrente da aplicação da Lei Municipal nº 159/98, que proibiu a utilização dos herbicidas 2.4-D, a toda evidência, revela feição eminentemente preventiva, posto que não se volta contra lesão de direito já concretizada, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 18 da Lei 1.533/51. [...] Em terceiro e último lugar, a controvérsia instaurada nos autos diz respeito à existência de interesse local que justifique a restrição legal imposta pela municipalidade interessada para o uso de herbicidas, em atenção ao que dispõem os arts. 24, inc. VI, e 30, inc. I, da Constituição da República e à Lei nº 7.802/89. Embora o recorrente fundamente sua pretensão recursal no art. 11 da referida lei federal (segundo o qual “cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins”), é fácil visualizar que a demanda tem contornos constitucionais, pois envolve a interpretação sistemática de dois dispositivos da Lei Maior e a delimitação da competência legislativa dos entes federados, fato que desloca a atribuição para apreciação e julgamento da causa para o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o próprio dispositivo infraconstitucional antes mencionado nada mais é do que mera repetição da disposição de competências constitucionais dos Municípios, cabendo à Corte Suprema definir a extensão da expressão ‘interesse local’ em matéria ambiental. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do art. 557, *caput*, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (STJ. REsp 985910. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. *DJU* 17/3/2009).

17.7.1 Repartições de Competências Administrativas no Interior da Administração Federal

Os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, estabeleceram as competências administrativas de cada um dos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, naquilo que diz respeito ao processo de fiscalização e inspeção de todo o ciclo dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Tais competências foram repartidas conforme demonstra o seguinte quadro:

17.7.1.1 Competências dos Ministérios da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente

Conforme estabelecido pelo artigo 2º do Regulamento (Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002), as competências são as seguintes, de acordo com a atribuição de cada um:

- i) estabelecer as diretrizes e exigências relativas a dados e informações a serem apresentados pelo requerente para registro e reavaliação de registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
- ii) estabelecer diretrizes e exigências objetivando minimizar os riscos apresentados por agrotóxicos, seus componentes e afins;
- iii) estabelecer o limite máximo de resíduos e o intervalo de segurança dos agrotóxicos e afins;
- iv) estabelecer os parâmetros para rótulos e bulas de agrotóxicos e afins;
- v) estabelecer metodologias oficiais de amostragem e de análise para determinação de resíduos de agrotóxicos e afins em produtos de origem vegetal, animal, na água e no solo;
- vi) promover a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for alertado nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos;
- vii) avaliar pedidos de cancelamento ou de impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins;
- viii) autorizar o fracionamento e a embalagem dos agrotóxicos e afins;
- ix) controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como os respectivos estabelecimentos;
- x) controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins frente às características do produto registrado;

- xi) desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento sobre o uso correto e eficaz dos agrotóxicos e afins;
- xii) prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
- xiii) indicar e manter representantes no Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos de que trata o art. 95 do Regulamento;
- xiv) manter o Sistema de Informações sobre Agrotóxicos – SIA, referido no art. 94 do Regulamento; e
- xv) publicar no Diário Oficial da União o resumo dos pedidos e das concessões de registro.

17.7.1.2 Competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Na forma do artigo 5º do Regulamento, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

- i) avaliar a eficiência agronômica dos agrotóxicos e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens; e
- ii) conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

17.7.1.3 Competências do Ministério da Saúde

Na forma do artigo 6º do Regulamento, compete ao Ministério da Saúde:

- i) avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, seus componentes, e afins;
- ii) avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública, quanto à eficiência do produto;
- iii) realizar avaliação toxicológica preliminar dos agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins, destinados à pesquisa e à experimentação;
- iv) estabelecer intervalo de reentrada em ambiente tratado com agrotóxicos e afins;
- v) conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente; e
- vi) monitorar os resíduos de agrotóxicos e afins em produtos de origem animal.

17.7.1.4 Competências do Ministério do Meio Ambiente

De acordo com a determinação regulamentar, compete ao Ministério do Meio Ambiente (art. 7º do Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002):

- i) avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas, quanto à eficiência do produto;
- ii) realizar a avaliação ambiental, dos agrotóxicos, seus componentes e afins, estabelecendo suas classificações quanto ao potencial de periculosidade ambiental;
- iii) realizar a avaliação ambiental preliminar de agrotóxicos, produto técnico, pré-mistura e afins destinados à pesquisa e à experimentação;
- iv) conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos e pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes hídricos, na proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas, atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Saúde.

17.7.1.5 Competências do Ministério do Trabalho e Emprego

Ainda que não haja uma menção explícita no Regulamento, não há como desconsiderar que o Ministério do Trabalho e Emprego tem importantes atribuições no que se refere aos agrotóxicos. Não são atribuições quanto ao produto em si mesmo, mas dizem respeito à utilização dos agrotóxicos em suas finalidades precípuas, ou seja, na agricultura. Tais atribuições, do ponto de vista regulamentar, são exercidas pela elaboração de Normas Regulamentadoras. Atualmente está vigendo a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura – NR 31, aprovada pela Portaria nº 86, de 3 de março de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 4 de março de 2005.

17.7.2 Definição legal de agrotóxico, seus componentes e afins

De conformidade com a norma legal, são considerados agrotóxicos e afins (art. 2º da Lei nº 7.802/1989):

- i) agrotóxicos e afins:
 - a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
 - b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
- ii) componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.

17.7.3 Controle de qualidade, inspeção e fiscalização dos agrotóxicos

Do ponto de vista legal, existe um sistema de amplo monitoramento dos agrotóxicos. Tal monitoramento abrange todos os aspectos da vida do produto. A lei estabelece um mecanismo de controle sobre toda exportação, produção, importação, comercialização e utilização dos agrotóxicos. Assim é que os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências formuladas dos órgãos responsáveis pelos setores de saúde, do meio ambiente e da agricultura.

O aludido monitoramento divide-se em *controle de qualidade, inspeção e fiscalização*. O *Controle de qualidade*, a inspeção e a fiscalização são realizados com vistas ao controle dos agrotóxicos, seus componentes e afins em tudo aquilo que diga respeito à sua produção, aos veículos destinados ao transporte, ao seu armazenamento, à sua comercialização e utilização, à propaganda comercial, à rotulagem e à disposição final de resíduos e embalagens.

17.7.3.1 Controle de qualidade

O artigo 68 do Regulamento determina que os órgãos federais encarregados dos setores de agricultura, saúde e meio ambiente mantenham atualizados e aperfeiçoados mecanismos capazes de assegurar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins, tendo em vista a identidade, pureza e eficácia dos produtos. Isso deverá ser efetuado mediante mecanismos de controle de qualidade. O Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, exerce o controle de qualidade, entretanto, isso não desobriga que o estabelecimento destinado à produção e importação de agrotóxicos, seus componentes e afins disponha de unidade de controle de qualidade próprio, com a finalidade de verificar a qualidade do processo produtivo, das matérias-primas e substâncias empregadas, quando couber, e dos produtos finais. Admite-se que as empresas produtoras de agrotóxicos, seus componentes e afins realizem os controles previstos no Regulamento em institutos ou laboratórios oficiais ou privados, de acordo com a legislação vigente.

17.7.3.2 Inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins

Segundo determinação contida no artigo 70 do Regulamento, todo o ciclo de vida dos agrotóxicos, seus componentes e afins será submetido à fiscalização. No ciclo de vida estão compreendidos: (i) sua produção, (ii) manipulação, (iii) importação, (iv) exportação, (v) transporte, (vi) armazenamento, (vii) comercialização, (viii) utilização, (ix) rotulagem e a (x) destinação final de suas sobras, resíduos e embalagens.

Considerando a natureza federal do Estado brasileiro e a existência de um regime de federalismo cooperativo, o artigo 71 do Regulamento estabeleceu a seguinte estrutura para a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins:

17.7.3.2.1 Competência federal (art. 71, I, do Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002)

- i) estabelecimentos de produção, importação e exportação;
- ii) produção, importação e exportação;
- iii) coleta de amostras para análise de controle ou de fiscalização;
- iv) resíduos de agrotóxicos e afins em produtos agrícolas e de seus subprodutos; e
- v) quando se tratar do uso de agrotóxicos e afins em tratamentos quarentenários e fitossanitários realizados no trânsito internacional de vegetais e suas partes.

17.7.3.2.2 Competência dos Estados e Distrito Federal (art. 71, II, do Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002)

Os órgãos estaduais e do Distrito Federal são encarregados dos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, dentro de suas respectivas esferas de competência, ressalvadas aquelas específicas dos órgãos federais relacionados,¹³ quando se tratar de:

- i) uso e consumo dos produtos agrotóxicos, seus componentes e afins na sua jurisdição;
- ii) estabelecimentos de comercialização, de armazenamento e de prestação de serviços;
- iii) devolução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso;
- iv) transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, por qualquer via ou meio, em sua jurisdição;
- v) coleta de amostras para análise de fiscalização;
- vi) armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias e dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; e
- vii) resíduos de agrotóxicos e afins em produtos agrícolas e seus subprodutos.

Admite-se a delegação de atribuições da União para os Estados.

17.7.3.3 Atribuições da fiscalização

A fiscalização é atividade rotineira e de caráter permanente, somente podendo ser desenvolvida por agentes devidamente credenciados e com a formação profissional que o habilite devidamente para tal. Os fiscalizados devem, sob pena de aplicação de sanções, prestar informações ou proceder à entrega de documentos nos prazos estabelecidos pelos órgãos competentes, a fim de não obstar as ações de inspeção e fiscalização e a adoção das medidas que se fizerem necessárias.

A fiscalização tem livre acesso, no desempenho de suas atividades, aos locais onde se processem, em qualquer fase, a industrialização, o comércio, a armazenagem e a aplicação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, competindo-lhes, quando se fizer necessário (art. 74 do Decreto nº 4.074/2002):

- i) coletar as amostras necessárias às análises de controle ou fiscalização;
- ii) executar visitas rotineiras de inspeções e vistorias para apuração de infrações ou eventos que tornem os produtos passíveis de alteração e lavrar os respectivos termos;
- iii) verificar o cumprimento das condições de preservação da qualidade ambiental;
- iv) verificar a procedência e as condições dos produtos, quando expostos à venda;
- v) interditar, parcial ou totalmente, os estabelecimentos ou atividades quando constatado o descumprimento do estabelecido na Lei nº 7.802, de 1989, neste Decreto e em normas complementares e apreender lotes ou partidas de produtos, lavrando os respectivos termos;
- vi) proceder à imediata inutilização da unidade do produto cuja adulteração ou deterioração seja flagrante, e à apreensão e interdição do restante do lote ou partida para análise de fiscalização; e
- vii) lavrar termos e autos de infração.

A inspeção se faz por meio de exames e vistorias sobre (art. 75 do Decreto nº 4.074/2002): (i) matéria-prima, qualquer que seja a sua origem ou natureza; (ii) a manipulação, transformação, elaboração, conservação, embalagem e rotulagem dos produtos; (iii) os equipamentos e as instalações do estabelecimento; (iv) o laboratório de controle de qualidade dos produtos; e (v) a documentação de controle da produção, importação, exportação e comercialização.

A fiscalização será exercida sobre os produtos nos estabelecimentos produtores e comerciais, nos depósitos e nas propriedades rurais. Caso seja constatada qualquer irregularidade, o estabelecimento poderá ser interditado e o produto ou alimento poderão ser apreendidos e submetidos à análise de fiscalização.

17.7.3.3.1 Produção de prova

A análise de fiscalização será realizada mediante coleta de amostra representativa do produto ou alimento pela autoridade fiscalizadora. A coleta de amostra deverá ser realizada em três partes, conforme técnica e metodologia indicada em ato normativo próprio. A amostra deve ser acondicionada de forma que se torne inviolável em presença do interessado e, caso ele não se encontre presente ao ato, ou se recuse a acompanhá-lo, faz-se necessária a presença de duas testemunhas. A produção de prova será feita da seguinte maneira (art. 77): (i) uma parte da amostra será utilizada pelo laboratório oficial ou devidamente credenciado; (ii) outra permanecerá

no órgão fiscalizador; e (iii) outra ficará em poder de perícia de contraprova. Resguardado o emprego de metodologia oficial, a análise de fiscalização poderá ser realizada por laboratório oficial ou credenciado (art. 78).

Em prazo máximo de 45 dias, contados da data da coleta da amostra, o interessado deve ser comunicado dos resultados da análise de fiscalização (art. 79). Havendo discordância quanto ao resultado, poderá a parte requerer seja periciada a contraprova, em dez dias contados da ciência do resultado da análise de fiscalização. Cabe ao interessado: (i) arcar com os ônus da contraprova e (ii) indicar perito habilitado.

Assim como a análise de fiscalização, a perícia de contraprova deve ser realizada em laboratório oficial, ou credenciado, asseguradas a presença de peritos do interessado e do órgão fiscalizador e a assistência técnica do responsável pela análise contestada. A contraprova será realizada no prazo máximo de 15 dias (art. 80, § 1º), contados da data de seu requerimento, salvo quando condições técnicas exigirem a sua prorrogação, o que deverá ser informado ao interessado de forma fundamentada, em obediência ao princípio constitucional da ampla defesa. Somente será admitida a realização da contraprova em parte da amostra que não tenha sido violada, fato que será, obrigatoriamente, atestado pelos peritos (art. 80, § 2º).

A autoridade não realizará a contraprova quando for verificada a violação da amostra, oportunidade em que será finalizado o processo de fiscalização e instaurada sindicância para apuração de responsabilidades (art. 80, § 3º). Nessa hipótese se estabelece uma situação complexa, visto que a contraprova se encontra em poder da autoridade e, ante a impossibilidade de examiná-la, em tese, não se poderiam validar os resultados da análise impugnada. Recomenda a cautela que se suspenda a aplicação de qualquer penalidade ao interessado, até que a Comissão de sindicância apure os fatos e, caso reste provado que a violação não foi praticada com o concurso do interessado, ou feita de forma a beneficiá-lo, não me parece cabível a aplicação de penalidade com base na primitiva análise. Evidentemente que a parte da amostra que se encontra em poder do interessado não poderá ser utilizada na controvérsia.

Com vistas a assegurar a ampla defesa e o contraditório, ao perito da parte interessada deverá ser dado conhecimento da análise de fiscalização e prestadas as informações que ele solicitar, assim como exibidos os documentos necessários ao desempenho de sua tarefa.

Todo o ato de perícia de contraprova deve ser reduzido a termo, com a lavratura de laudos e ata que serão assinados pelos peritos e arquivados no laboratório oficial ou credenciado, após a entrega de cópias à autoridade fiscalizadora e ao requerente (art. 80, § 5º). Havendo divergência entre o laudo de contraprova e o da análise de fiscalização, proceder-se-á a nova análise, em terceiro laboratório, oficial ou credenciado, cujo resultado será irrecorrível, conforme a dicção do decreto (art. 80, § 6º), utilizando-se a parte da amostra em poder do órgão fiscalizador, facultada a assistência dos peritos anteriormente nomeados, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 80.

Evidentemente que a irrecorribilidade é meramente administrativa, visto que no Brasil vigora o princípio do juízo universal e toda e qualquer lesão, ou ameaça de lesão a direito, pode ser objeto de apreciação judicial.

17.7.4 Registro de pessoas física e jurídica

Com vistas à obtenção de registro nos órgãos competentes do Estado, do Distrito Federal ou do Município, as pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, formulem, manipulem, exportem, importem ou comercializem, deverão apresentar, dentre outros documentos, requerimento solicitando o registro, onde constem, no mínimo, as informações contidas no Anexo V do Regulamento. Não obstante a existência do registro, o funcionamento somente poderá se iniciar sob a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado. As pessoas físicas ou jurídicas serão cadastradas no sistema de informação de agrotóxicos (cadastro geral de estabelecimentos produtores, manipuladores, importadores, exportadores e de instituições dedicadas à pesquisa e experimentação).

Até 30 dias após o Registro na Junta Comercial, quaisquer alterações estatutárias ou contratuais deverão ser comunicadas aos órgãos federais registrantes e fiscalizadores. “Art. 40. As empresas importadoras, exportadoras, produtoras ou formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins passarão a adotar, para cada partida importada, exportada, produzida ou formulada, codificação em conformidade com o Anexo VI do Regulamento, que deverá constar de todas as embalagens dela originadas, não podendo ser usado o mesmo código para partidas diferentes.”

O artigo 41 determina às empresas importadoras, exportadoras, produtoras e formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e afins que forneçam aos órgãos federais e estaduais competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, todos os dados relacionados às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados de acordo com o modelo de relatório semestral do Anexo VII do Regulamento.

Há obrigação de que as pessoas físicas ou jurídicas que produzam, comercializem, importem, exportem ou que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, mantenham à disposição dos órgãos de fiscalização de que trata o artigo 71 o livro de registro ou outro sistema de controle, que deve conter:

- i) Para o produtor de agrotóxicos, componentes e afins:
 - a) relação detalhada do estoque existente; e
 - b) nome comercial dos produtos e quantidades produzidas e comercializadas.
- ii) Para os estabelecimentos que comercializem agrotóxicos e afins no mercado interno:
 - a) relação detalhada do estoque existente; e
 - b) nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas, acompanhados dos respectivos receiptuários.
- iii) Para os estabelecimentos que importem ou exportem agrotóxicos, seus componentes e afins:
 - a) relação detalhada do estoque existente;
 - b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas ou exportadas; e
 - c) cópia das respectivas autorizações emitidas pelo órgão federal competente.
- iv) Para as pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e afins:
 - a) relação detalhada do estoque existente;
 - b) programa de treinamento de seus aplicadores de agrotóxicos e afins;
 - c) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos receiptuários e guia de aplicação; e
 - d) guia de aplicação.

17.7.5 Alerta de organizações internacionais e seus reflexos no Brasil

A lei revela uma salutar preocupação com o *estado da arte* das pesquisas sobre agrotóxicos, de molde a manter o país atualizado e apto a enfrentar os desafios constantes que surgem em tão complexa área. Dessa forma, o artigo 3º, § 4º, da lei de agrotóxicos (Lei nº 7.802/1989) determina:

Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar as imediatas providências, sob pena de responsabilidade.

Aqui existem algumas questões importantes que necessitam ficar bem esclarecidas. Há uma evidente diferença entre Tratados e Convenções internacionais que

determinem a proibição de determinados produtos e das quais o Brasil seja Parte. Uma vez que a Convenção ou o Tratado entrem em vigor, mediante os mecanismos de ratificação, tais medidas se tornam obrigatórias para nós. Diferente é a posição de hipótese na qual uma entidade internacional tenha patrocinado um estudo e chegado a conclusões definitivas quanto à nocividade de um determinado produto. Caso não haja uma norma internacional, obrigatória, que proíba a utilização do mencionado elemento, o Brasil não estará obrigado a proibi-lo. A correta interpretação do parágrafo é no sentido de que o Brasil, por suas autoridades, deverá levar em conta os estudos internacionais e examinar a sua procedência para a nossa realidade. Manda o bom-senso que medidas preventivas sejam adotadas, com vistas ao esclarecimento das questões suscitadas pelo documento do organismo internacional.

Para os fins de aplicação da norma em questão, deve-se compreender por Organização Internacional aquela que possa ser qualificada dentro do conceito vigente no Direito Internacional Público (MELLO, 1974, p. 314): *“As organizações internacionais, apesar de serem uma realidade na sociedade internacional, não possuem uma definição fornecida por uma norma internacional. As definições de organizações internacionais são dadas pela doutrina. A que nos parece ser mais exata é a dada por Angelo Piero Sereni: ‘organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional, constituída por ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de direito internacional, que se realiza em um ente de aspecto estável, que possui um ordenamento jurídico interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios, por meio dos quais realiza as finalidades comuns de seus membros mediante funções particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos’. Esta definição é um pouco longa, mas tem, entretanto, a vantagem de enunciar as principais características das organizações internacionais”*.

Observe-se que a norma legal não definiu uma proibição ou uma prescrição ditada por organismo internacional, mas limitou-se a falar em desaconselhamento ou alerta quanto à nocividade do produto. Qual a providência que deverá ser adotada pela autoridade brasileira? Parece-nos que, nos termos em que a legislação está colocada, a única medida que pode ser tomada pela autoridade brasileira é a determinação de que se realizem estudos quanto ao produto que tenha sido objeto de investigação da organização internacional. Tais estudos deverão, é certo, levar em consideração as análises realizadas no exterior; contudo, não poderão deixar de ter em mente que o que se quer é investigar as consequências do produto no Brasil. Se o produto estiver registrado segundo as leis brasileiras, somente após a completa realização de novos estudos é que o registro poderá vir, em tese, a ser colocado em questão.

O artigo 19 do Regulamento (Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002) estabelece que: “Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá aos órgãos federais de agricultura, saúde e meio ambiente, avaliar imediatamente os problemas e as informações apresentadas. Parágrafo único. O órgão federal registrante, ao adotar as medidas necessárias ao atendimento das exigências decorrentes da avaliação, poderá: I – manter o registro sem alterações; II – manter o registro, mediante a necessária adequação; III – propor a mudança da formulação, dose ou método de aplicação; IV – restringir a comercialização; V – proibir, suspender ou restringir a produção ou importação; VI – proibir, suspender ou restringir o uso; e VII – cancelar ou suspender o registro”.

17.7.6 Registro do produto

Devido aos riscos envolvidos com o ciclo de vida dos agrotóxicos, seus componentes e afins, eles somente serão produzidos, manipulados, importados, exportados, comercializados e utilizados no território nacional mediante prévio registro no órgão federal competente, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente. Para que o registro seja efetivado, cabe aos requerentes e titulares de registro fornecer, obrigatoriamente, aos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, as inovações concernentes aos dados apresentados para registro e reavaliação de registro dos seus produtos.

É condição indispensável à obtenção do registro ou à reavaliação de registro de produtos técnicos, pré-misturas, agrotóxicos e afins, que o interessado apresente, em prazo não superior a cinco dias úteis, a contar da data do primeiro protocolo do pedido, a cada um dos órgãos responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, requerimento em duas vias, conforme Anexo II do Regulamento, acompanhado dos respectivos relatórios e de dados e informações exigidos, por aqueles órgãos, em normas complementares.

O registro de produto equivalente será realizado com observância dos dados e documentos exigidos no Anexo II, itens 1 a 11, 15 e 16.1 a 16.6.

Quando se tratar do registro ou RET (Registro Especial Temporário) de produtos e agentes de processos biológicos geneticamente modificados que se caracterizem como agrotóxicos e afins, este deverá ser ultimado na forma dos critérios e exigências estabelecidos na legislação específica. Quanto aos produtos de baixa toxicidade e periculosidade, deverá ser-lhes dada tramitação prioritária, sempre que requerido, conforme definido pelos órgãos competentes.

Conforme determina o artigo 13 do Decreto nº 4.074/2002, os agrotóxicos, seus componentes e afins poderão ter os seus registros reavaliados, suspensos ou cancelados administrativamente caso apresentem indícios de redução de eficiência agronômica, alteração dos riscos à saúde humana ou ao meio ambiente. Logicamente que isso somente poderá ocorrer com a observância do devido processo legal e da ampla defesa.

O registro de agrotóxico é feito sob ampla publicidade, devendo ser publicado no Diário Oficial da União, em prazo de até 30 dias da data do protocolo do pedido e da data da concessão ou indeferimento do registro, resumo o qual conterá: (i) o pedido com o nome do requerente; a marca comercial do produto; o nome químico e comum do ingrediente ativo; o nome científico, no caso de agente biológico; o motivo da solicitação; e a indicação de uso pretendido; (ii) a concessão ou indeferimento do registro, com o nome do requerente ou titular; a marca comercial do produto; o resultado do pedido e, se indeferido, o motivo; o fabricante e o formulador; o nome químico e comum do ingrediente ativo; nome científico, no caso de agente biológico; indicação de uso aprovada; classificação toxicológica; e classificação do potencial de periculosidade ambiental.

Cabe aos órgãos federais realizarem a avaliação técnico-científica, para fins de registro ou reavaliação de registro, no prazo de até 120 dias, contados a partir da data do respectivo protocolo. A contagem do prazo será suspensa caso qualquer dos órgãos avaliadores solicite por escrito, e fundamentadamente, documentos ou informações adicionais, reiniciando a partir do atendimento da exigência, acrescidos 30 dias. Havendo o não atendimento de pedidos complementares no prazo de 30 dias, arquivar-se-á o processo, com o indeferimento do requerimento pelo órgão encarregado do registro, salvo se apresentada, formalmente, justificativa técnica considerada procedente pelo órgão solicitante, que a seu juízo poderá conceder prazo adicional, seguido, obrigatoriamente, de comunicação aos demais órgãos para as providências cabíveis. O requerimento será decidido em até 30 dias, após a divulgação dos resultados das avaliações dos órgãos federais envolvidos.

É importante ressaltar que, na forma do artigo 20 do Regulamento, somente será concedido registro de novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for, comprovadamente, igual ou menor do que a daqueles já registrados para o mesmo fim. Compete aos órgãos competentes estabelecer os padrões a serem considerados para a avaliação tratada no artigo 20, sendo certo que eles deverão considerar prioritariamente o seguinte: (i) toxicidade; (ii) presença de problemas toxicológicos especiais, tais como: neurotoxicidade, fetotoxicidade, ação hormonal e comportamental e ação reprodutiva; (iii) persistência no ambiente; (iv) bioacumulação; (v) forma de apresentação; e (vi) método de aplicação.

Proceder-se-á ao cancelamento do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins sempre que for verificada modificação não autorizada pelos órgãos federais dos setores de agricultura, saúde e meio ambiente em fórmula, dose, condições de fabricação, indicação de aplicação e especificações enunciadas em rótulo e bula, ou outras modificações em desacordo com o registro concedido.

17.7.6.1 Produtos para exportação

Os produtos destinados exclusivamente à exportação prescindem da apresentação dos estudos relativos à eficiência agronômica, à determinação de resíduos em produtos vegetais e outros que venham a ser estabelecidos em normas complementares pelos órgãos responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente.

O registro para exportação deve ser concedido, no prazo de 60 dias da entrega do pedido, certificado de registro para exportação de agrotóxicos, seus

componentes e afins para os produtos que já tenham sido registrados com nome comercial diferente daquele com o qual será exportado, desde que o interessado apresente cópia do certificado de registro e de requerimento contendo as seguintes informações: (i) destino final do produto; e (ii) marca comercial no país de destino.

17.8 RESPONSABILIDADE

Como já foi exaustivamente analisado ao longo de todo o presente livro, as violações às normas de proteção ambiental implicam a imputação de responsabilidade àquele que tenha dado causa à ruptura da ordem pública do meio ambiente. A responsabilidade, como se sabe, reveste-se de múltiplos aspectos. A imputação de responsabilidade, nos termos da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, está normatizada nos artigos 14 e seguintes do mencionado diploma legal. A regulamentação da aplicação das sanções administrativas está contemplada pelo Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 5.549/2005.

As responsabilidades penal, civil e administrativa, pelo não cumprimento da lei, são imputáveis:

- a) ao profissional, quando comprovada a prescrição de receita errada;
- b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;
- c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita;
- d) ao registrante que, por dolo ou culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas;
- e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente;
- f) ao empregador, quando não fornecer e não fazer manutenção dos equipamentos necessários à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos utilizados ou destinados à produção, distribuição e aplicação dos produtos.

17.8.1 Responsabilidade criminal

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa de 50 (cinquenta) a 500 (quinhentos) MVR.

17.8.2 Responsabilidade administrativa

Os artigos 17 e 18 da lei ora em exame estabelecem as penalidades administrativas que devem ser aplicadas àqueles que, eventualmente, burlem as normas aplicáveis à manipulação e utilização dos agrotóxicos. As penalidades às quais nos referimos são “*independentes das medidas cautelares de embargo de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados*” (art. 17, *caput*). Tais medidas são as seguintes:

- a) advertência;
- b) multa de até 1.000 vezes o Maior Valor de Referência – MVR, aplicável em dobro em caso de reincidência;
- c) condenação do produto;
- d) inutilização do produto;
- e) suspensão da autorização, registro ou licença;
- f) interdição temporária ou definitiva do estabelecimento;
- g) cancelamento da autorização, registro ou licença;
- h) destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de agrotóxico de uso não autorizado, a critério do órgão competente;
- i) destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido.

A título de pena administrativa acessória, deverá ser dada ampla divulgação das sanções aplicadas pela autoridade administrativa aos infratores das normas legais e regulamentos referentes aos agrotóxicos. Ademais, todo e qualquer custo em que tenha incorrido o Estado para a aplicação das penalidades e para a apuração das responsabilidades decorrentes de infração aos dispositivos legais e regulamentares que vêm sendo examinados ao longo do presente capítulo deverá ser suportado pelo infrator.

A incidência da responsabilidade é bastante abrangente, pois deverá responder pela infração todo aquele que cometer, incentivar ou se beneficiar da prática da infração. A ação e a omissão devem ser entendidas como qualquer causa sem a qual a infração não teria ocorrido. Admite-se, no entanto, as excludentes decorrentes de força maior ou de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis. Eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis devem ser tidos como cientificamente imprevisíveis, ou de possibilidade desprezível. A imprevisibilidade para o homem comum do povo, aqui, não pode ser tida como excludente de responsabilidade. Como já foi visto antes, os agrotóxicos têm a sua utilização altamente regulamentada e, sem dúvida alguma, todos os passos de sua utilização estão vinculados a conhecimentos técnicos, receituários etc. Há, portanto, uma presunção de que a utilização dos agrotóxicos está sendo feita dentro de uma moderna metodologia científica.

17.8.2.1 Infrações

Utilizando-se de uma cláusula aberta que, seguidamente, vem se tornando mais corriqueira no direito ambiental, o Regulamento, em seu artigo 82 (Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002), estabelece que:

Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância do disposto na Lei nº 7.802, de 1989, neste Decreto ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes.

A responsabilidade decorrente da utilização de agrotóxicos se estende às pessoas físicas e jurídicas que serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nas **Leis nºs 7.802, de 1989, e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998**, e ainda nos regulamentos pertinentes, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, pessoa individual ou órgão colegiado, no interesse ou em benefício da sua entidade, conforme previsto no artigo 83 do Regulamento. Aqui, permito-me observar que não vejo como aplicável o artigo 2º da Lei nº 9.605/98, visto que ele próprio se restringe aos casos decorrentes da própria aplicação da lei de crimes ambientais e não de outras normas, pois tal função caberia ao Código Penal e não a uma lei extravagante. Por igual,

o artigo 84 estabelece que as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, em função do descumprimento do disposto na legislação pertinente a agrotóxicos, seus componentes e afins, recairão sobre: (i) o registrante que omitir informações ou fornecê-las incorretamente; (ii) o produtor, quando produzir agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as especificações constantes do registro; (iii) o produtor, o comerciante, o usuário, o profissional responsável e o prestador de serviços que opuser embaraço à fiscalização dos órgãos competentes ou que não der destinação às embalagens vazias de acordo com a legislação; (iv) o profissional que prescrever a utilização de agrotóxicos e afins em desacordo com as especificações técnicas; (v) o comerciante, quando efetuar a venda sem o respectivo receituário, em desacordo com sua prescrição ou com as recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (vi) o comerciante, o empregador, o profissional responsável ou prestador de serviços que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde ou ao meio ambiente; (vii) o usuário ou o prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou com as recomendações do fabricante ou dos órgãos sanitário-ambientais; e (viii) as entidades públicas ou privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa, que promoverem atividades de experimentação ou pesquisa de agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as normas de proteção da saúde pública e do meio ambiente. Confesso a minha imensa dificuldade em enquadrar no esquema teórico do ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade penal definida em decreto.

A cláusula genérica contida na Lei foi transformada na relação do artigo 85 do decreto, que estabeleceu as seguintes infrações administrativas:

- i) pesquisar, experimentar, produzir, prescrever, fracionar, embalar e rotular, armazenar, comercializar, transportar, fazer propaganda comercial, utilizar, manipular, importar, exportar, aplicar, prestar serviço, dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com o previsto na **Lei nº 7.802, de 1989**, e legislação pertinente;
- ii) rotular os agrotóxicos, seus componentes e afins, sem prévia autorização do órgão registrante ou em desacordo com a autorização concedida; e
- iii) omitir informações ou prestá-las de forma incorreta às autoridades registrantes e fiscalizadoras.

17.8.2.1.1 Sanções administrativas e sua aplicação

Determina o artigo 86 do Regulamento que: “sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposições legais acarretará, isolada ou cumulativamente, independentemente da medida cautelar de interdição de estabelecimento, a apreensão do produto ou alimentos contaminados e a aplicação das sanções previstas no **art. 17 da Lei nº 7.802, de 1989**. § 1º A advertência será aplicada quando constatada inobservância das disposições deste Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. § 2º A multa será aplicada sempre que o agente: I – notificado, deixar de sanar, no prazo assinalado pelo órgão competente, as irregularidades praticadas; ou II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos competentes. § 3º A inutilização será aplicada nos casos de produto sem registro ou naqueles em que ficar constatada a impossibilidade de lhes ser dada outra destinação ou reaproveitamento. § 4º A suspensão de autorização de uso ou de registro de produto será aplicada nos casos em que sejam constatadas irregularidades reparáveis. § 5º O cancelamento da autorização de uso ou de registro de produto será aplicado nos casos de impossibilidade de serem sanadas as irregularidades ou quando constatada fraude. § 6º O cancelamento de registro, licença, ou autorização de funcionamento de estabelecimento será aplicado nos casos de impossibilidade de serem sanadas as irregularidades ou quando constatada fraude. § 7º A interdição temporária ou definitiva de estabelecimento ocorrerá sempre que constatada irregularidade ou quando se verificar, mediante inspeção técnica ou fiscalização, condições sanitárias ou ambientais inadequadas para o funcionamento do estabelecimento. § 8º A destruição ou inutilização de vegetais, parte de vegetais e alimentos será determinada pela autoridade sanitária competente, sempre que apresentarem resíduos acima dos níveis permitidos ou quando tenha havido aplicação de agrotóxicos e afins de uso não autorizado. § 9º A suspensão do registro será aplicada quando a solicitação de adequação de informações ou documentos não for atendida no prazo de trinta dias, salvo justificativa técnica procedente”.

Os autos de infração deverão conter a descrição do fato, a capitulação do ilícito administrativo e a informação das penalidades aplicáveis, sob pena de nulidade. O artigo 88 do Regulamento determina que a autoridade competente, ao analisar o processo administrativo, observará, no que couber, o disposto nos **arts. 14 e 15 da Lei nº 9.605, de 1998**. A norma é claramente além do que foi disposto na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000, visto que a Lei nº 7.702 não trata do assunto. O artigo é, portanto, ilegal e inaplicável.

Seguindo uma orientação que vem se consolidando no sentido de que apenas uma autoridade federada aplique multa em função de um mesmo fato, o artigo 89 determina que: “A aplicação de multa pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios exclui a aplicação de igual penalidade por órgão federal competente, em decorrência do mesmo fato.” Merece ser chamada a atenção para o fato de que a dimensão dos valores é irrelevante no caso. O Poder Público, em caso de destruição ou inutilização de agrotóxicos, seus componentes e afins, nocivos à saúde humana ou animal ou ao meio ambiente, determinará ao infrator que arque com os custos.

Em qualquer caso, o procedimento a ser adotado será com base na **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

17.9 COMERCIALIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS

Os agrotóxicos, assim como quaisquer outros produtos, têm um ciclo de vida que começa na sua produção e se encerra na sua destinação final. Nesta altura do presente trabalho, necessário se faz examinar os elementos indispensáveis para que os agrotóxicos e afins possam ser legalmente comercializados no território brasileiro. O primeiro elemento a ser examinado, portanto, é o receituário agrônomo, sem o qual nenhum agrotóxico poderá ser comercializado legalmente no Brasil. Quanto à necessidade de profissional habilitado para a venda de agrotóxicos:

17.9.1 Receituário agrônomo

A receita ou receituário é a prescrição e orientação técnica necessárias para a utilização de agrotóxico ou afim, por profissional legalmente habilitado. Sem tal documento não pode haver comercialização de agrotóxicos. Observe-se que não há necessidade legal de que o profissional seja engenheiro agrônomo, bastando a qualificação de técnico agrícola com formação de segundo grau. O receituário é um documento formal que deve obedecer a determinados parâmetros técnicos especiais. Em primeiro lugar ele deve ser expedido em, pelo menos, duas vias, a primeira para o usuário e a segunda para o estabelecimento comercial que deverá mantê-la à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo prazo de dois anos, contados da data de sua emissão. A receita deverá conter as seguintes informações (art. 66 do Decreto nº 4.074/2002): (i) nome do usuário, da propriedade e sua localização; (ii) diagnóstico; (iii) recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto; recomendação técnica com as seguintes informações: nome do(s) produto(s) comercial(ais) que deverá(ão) ser utilizado(s) e de eventual(ais) produto(s) equivalente(s), cultura e áreas onde serão aplicados; doses de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas; modalidade de aplicação, com anotação de instruções específicas, quando necessário, e, obrigatoriamente, nos casos de aplicação aérea, época de aplicação; intervalo de segurança; orientações quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência; precauções de uso; orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de EPI; data, nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu, além do seu registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.

Produtos de baixa periculosidade poderão ser dispensados de receituário, conforme for definido pelas autoridades administrativas.

17.9.2 Embalagem, fracionamento e rotulagem

Um dos problemas relevantes com os agrotóxicos é o referente às embalagens e, sobretudo, ao seu destino final. O ordenamento jurídico brasileiro não dispõe, até o momento, de uma norma que disponha amplamente sobre a destinação final dos resíduos sólidos. Isso tem feito com que o Conama, indo além de suas atribuições, busque disciplinar a matéria pela via das resoluções, o que, evidentemente, é excessivo, pois aquele Conselho não tem atribuição legal para criar

obrigações para terceiros. As embalagens de agrotóxicos, devido ao seu elevado grau de contaminação, ocupam papel de destaque na problemática dos resíduos sólidos.

As embalagens, os rótulos e as bulas de agrotóxicos e afins devem obedecer às especificações e dizeres aprovados pelos órgãos federais dos setores da agricultura, da saúde e do meio ambiente, em suas respectivas áreas de competência, por ocasião do registro do produto ou, posteriormente, quando da autorização para sua alteração, sendo que a inobservância dessas disposições acarretará a suspensão do registro do produto, ou seja, o fabricante não é inteiramente livre para definir como será a apresentação comercial do produto.

Art. 43, § 3º, Decreto 4.074/2002. As alterações que se fizerem necessárias em rótulos e bulas decorrentes de restrições, estabelecidas por órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão:

- i) ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização, reciclagem e destinação final adequada;
- ii) ser imunes à ação de seu conteúdo ou insuscetíveis de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
- iii) ser resistentes em todas as suas partes e satisfazer adequadamente às exigências de sua normal conservação;
- iv) ser providas de lacre ou outro dispositivo, externo, que assegure plena condição de verificação visual da inviolabilidade da embalagem;
- v) as embalagens rígidas deverão apresentar, de forma indelével e irremovível, em local de fácil visualização, exceto na tampa, o nome da empresa titular do registro e advertência quanto ao não reaproveitamento da embalagem.

Admite-se o fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo de comercialização desde que realizados pela empresa produtora ou por manipulador, sob responsabilidade daquela, em locais e condições previamente autorizados pelos órgãos estaduais, do Distrito Federal e municipais competentes.

17.9.3 Destinação final dos agrotóxicos

A destinação final de agrotóxicos é uma medida que necessita ser definida em lei. A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, não dispôs sobre a matéria, motivo pelo qual o decreto regulamentador não poderia enfrentar o tema. Reconhece-se que a relevância é óbvia e que a necessidade de disciplinar o assunto é inquestionável. Entretanto, a observância da ordem jurídica é igualmente fundamental. Não se pode *despir um santo para vestir outro*. O que é necessário é que o Poder Público promova a edição da lei necessária para regular a matéria.

Em medida salutar, o Poder Público admite a reutilização de embalagens, mediante aprovação dos órgãos federais intervenientes no processo de registro. Quanto à destinação final, o artigo 52 do Decreto 4.074/2002 estabelece que: “A destinação de embalagens vazias e de sobras de agrotóxicos e afins deverá atender às recomendações técnicas apresentadas na bula ou folheto complementar”.

Cabe aos usuários de agrotóxicos e afins devolver as embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua compra. Findo o prazo anterior, havendo ainda produto na embalagem, dentro do prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até seis meses após o término do prazo de validade. Faculta-se ao usuário a devolução de embalagens vazias a qualquer posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado por órgão ambiental competente e credenciado por estabelecimento comercial.

Os usuários devem manter à disposição dos órgãos fiscalizadores os comprovantes de devolução de embalagens vazias, fornecidas pelos estabelecimentos comerciais, postos de recebimento ou centros de recolhimento, pelo prazo de, no mínimo, um ano, após a devolução da embalagem. Na hipótese de embalagens contendo produtos impróprios para utilização ou em desuso, o usuário observará as orientações contidas nas respectivas bulas, cabendo às empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras, promover o recolhimento e a destinação admitidos pelo órgão ambiental competente. As embalagens rígidas, que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, deverão ser submetidas pelo usuário à operação de triplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme orientação constante de seus rótulos, bulas ou folheto complementar. Os usuários devolverão as embalagens vazias aos estabelecimentos nos quais compraram os produtos, quando se tratar de produto adquirido diretamente do exterior. Os estabelecimentos comerciais disporão de instalações adequadas para recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas pelos usuários, até que sejam recolhidas pelas respectivas empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras, responsáveis pela destinação final dessas embalagens; caso eles não tenham condições de receber ou armazenar embalagens vazias no mesmo local onde são realizadas as vendas dos produtos, os estabelecimentos comerciais credenciarão posto de recebimento ou centro de recolhimento, previamente licenciados, cujas condições de funcionamento e acesso não venham a dificultar a devolução pelos usuários. Nas notas fiscais deverá constar o endereço de devolução.

Os estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de atividades que envolvam embalagens vazias de agrotóxicos, componentes ou afins, bem como produtos em desuso ou impróprios para utilização, deverão obter licenciamento ambiental.

O artigo 57 do Decreto dispõe que: *As empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pelo recolhimento, pelo transporte e pela destinação final das embalagens vazias, devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos comerciais ou aos postos de recebimento, bem como dos produtos por elas fabricados e comercializados; I – apreendidos pela ação fiscalizatória; e II – impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reciclagem ou inutilização, de acordo com normas e instruções dos órgãos registrante e sanitário-ambientais competentes. § 1º As empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras de agrotóxicos e afins, podem instalar e manter centro de recolhimento de embalagens usadas e vazias. § 2º O prazo máximo para recolhimento e destinação final das embalagens pelas empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras, é de um ano, a contar da data de devolução pelos usuários. § 3º Os responsáveis por centros de recolhimento de embalagens vazias deverão manter à disposição dos órgãos de fiscalização sistema de controle das quantidades e dos tipos de embalagens, recolhidas e encaminhadas à destinação final, com as respectivas datas.*

Quando o produto for importado, o importador arcará com a responsabilidade pela destinação:

- i) das embalagens vazias dos produtos importados e comercializados, após a devolução pelos usuários; e
- ii) dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso.

- 1 Informação técnica colhida em: <<http://www.abra-amianto.org.br>>. Acesso em: 7 set. 2011.
- 2 Publicada no *DOU* de 17/2/1986.
- 3 Publicada no *DOU* de 22/10/1987.
- 4 ACSELRAD Henry. *Uma Luta pelo Controle dos Recursos Naturais*. Rio de Janeiro: Políticas Governamentais, nº 78, v. VIII, p. 24.
- 5 Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis09_e.htm>. Acesso em: 28 jun. 2011.
- 6 O Supremo Tribunal Federal banuiu nesta quarta-feira (29/11) o uso do amianto em todo o País. Mais do que reafirmar a inconstitucionalidade de normas que permitiam a extração de amianto crisotila, a Corte fez algo que, na palavra de alguns ministros, é inédito: declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da lei com efeito vinculante e eficácia erga omnes (vale para todos).
- A questão começou a ser enfrentada pelos ministros nas ações diretas de inconstitucionalidade 3.470 e 3.406, que tratavam da lei do Rio de Janeiro proibindo a comercialização e a extração da substância.
- Em agosto, o tribunal já havia apreciado o tema e decidido pela manutenção de lei paulista, questionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), que vetava o “uso” naquele estado de “produtos, materiais, artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto”
- Naquela data, por um problema de quórum na análise da Ação Direita de Inconstitucionalidade 3937, os ministros tiveram que acabar declarando “incidentalmente” a partir da lei estadual a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9055/1995, que permitia o “uso controlado” do amianto crisotila, utilizado principalmente na produção de telhados.
- A decisão, porém, deixou uma série de dúvidas sobre seu real efeito. Os próprios ministros do Supremo divergiram. Alguns ministros sustentavam que o uso do minério já estava proibido porque a declaração incidental valia para todo país, outros entendiam que a decisão só tinha validade para o estado de São Paulo.
- Na sessão desta quarta, na discussão sobre as leis do Rio, a dúvida sobre a abrangência do julgamento foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes. “A pergunta que se fez desde o julgamento passado é se pode ou não pode a crisotila”, afirmou.
- Moraes ressaltou que a avaliação era que o Supremo tinha criado um vácuo jurídico para estados que não tinham lei proibindo a fibra, uma vez que não têm lei regulamentando a exploração. Para alguns ministros, os estados sem norma a respeito poderiam – por terem competência concorrente para legislar sobre meio ambiente – aprovar regras sobre o tema.
- Com isso, a principal discussão entre os ministros não foi nem o mérito da lei sobre o amianto, mas os efeitos da decisão que se estava tomando. Além de declararem, por 7 votos a 2, improcedentes as ações contra a proibição do uso do amianto no Rio, os ministros decidiram que o resultado do julgamento da lei fluminense tem efeito erga omnes e vinculante e estenderam esses efeitos também para a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2 da lei federal que trata do amianto.
- O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que o STF estava caminhando para algo inédito: declarar a inconstitucionalidade de matéria, e não do dispositivo legal específico. A presidente da corte, ministra Cármen Lúcia, também afirmou que o Supremo seguia para uma inovação na jurisprudência do Supremo ao não analisar a constitucionalidade da lei, mas da matéria contida nela.
- O ministro Dias Toffoli argumentou que o controle difuso pode dar efeito erga omnes e vinculante à decisão para todo Brasil. “Se a decisão do controle abstrato tem uma consequência, no controle concreto teria outro?”.
- O ministro Marco Aurélio divergiu dos colegas e demonstrou forte incômodo com a saída encontrada pelos colegas. O ministro disse que, apesar de o STF ter direito à palavra final sobre o direito positivo, isso deve ser considerado dentro das balizas definidas pela Constituição e que o entendimento adotado pela Corte impediria o Congresso de aprovar uma nova lei sobre amianto.
- O advogado Thomaz Pereira, professor da FGV Direito Rio, afirmou que o fato de uma declaração incidental em lei estadual repercutir em uma lei federal é uma inovação no STF. Além disso, ele afirma que os ministros “abstrativizaram o controle abstrato”, pois julgaram matéria, e não a lei em si.
- Amianto**
- A relatora das ADIs 3.406 e 3.470, ministra Rosa Weber, ao votar pela improcedência das ações, observou que a lei estadual não viola a competência da União para definir normas gerais sobre comércio, consumo e meio ambiente. Segundo ela, a opção de editar normas específicas, mais restritivas que a lei federal, foi uma escolha legítima do legislador estadual, no âmbito de sua competência concorrente suplementar. A ministra explicou que não é possível a norma estadual confrontar a diretriz geral federal, mas não há impedimento em adotar uma postura mais cautelosa.
- A ministra considera que lei federal e a lei do Rio de Janeiro orientam-se na mesma direção, mas a lei estadual resolveu avançar onde a federal parou. “Ao impor nível de proteção mínima, a ser observada em todos os estados da federação, a lei federal não pode ser apontada como um obstáculo à maximização dessa proteção”, afirmou a ministra.
- Ao final, o julgamento acabou em 7 a 2. Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Celso de Mello, Dias Toffoli e a presidente Cármen Lúcia seguiram a relatora. O ministro Alexandre de Moraes inaugurou a divergência e foi seguido pelo ministro Marco Aurélio.
- Os dois que divergiram, no entanto, apresentaram argumentos diferentes. Enquanto Marco Aurélio protestou contra a forma, Moraes criticou o conteúdo da lei paulista. Para ele, o artigo 2º da lei federal é constitucional e se adequa às convenções internacionais.
- A relatora, por sua vez, defendeu que há consenso na comunidade científica em relação à nocividade do amianto. Segundo ela, estudos apontam que a substância provoca câncer e é dever estatal regulamentar a utilização de substâncias comprovadamente nocivas.
- 7 Disponível em: <<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125060524>>. Acesso em: 28 jun. 2011.
- 8 Informação disponível em: <<http://www.clorosur.org.br>>. Acesso em: 7 set. 2011.
- 9 Política Nacional de Resíduos Sólidos: “Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que ‘dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências’, e em seu regulamento.”
- 10 Publicado no *Diário Oficial da União* de 22/2/1990.
- 11 Adjetivo com propriedade de envenenar; que contém veneno: substância tóxica capaz de entorpecer por afetar o sistema nervoso; droga cujas propriedades fazem mal ao organismo. Substantivo masculino. Nome genérico dos venenos; substância venenosa; veneno. Etimologia (origem da palavra *tóxico*). Do latim toxicum.i. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/toxico/>>. Acesso em: 17 nov. 2018.
- 12 Disponível em: <<http://ibrahort.org.br/index.php/16-canal-do-consumidor/73-defensivos-agricolas-x-agrotoxicos-por-que-o-brasil-e-o-unico-pais-que-utiliza-o-termo-agrotoxico-para-se-referir-aos-defensivos-agricolas>>. Acesso aos 17 nov. 2018.
- 13 STF – STF. AI-AgR – AG. Reg. no Agravo de Instrumento – RS – *DJU*: 26/4/1996, p. 13120. Relator Ministro Maurício Corrêa. “Ementa: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Nulidade da decisão agravada: alegação de invasão de competência ao argumento de que em sede de agravo de instrumento somente é cabível emissão de juízo de admissibilidade, e não apreciação do mérito. Improcedência. Art. 1. da Lei nº 7.747/82, do Rio Grande do Sul. Inconstitucionalidade rejeitada pelo Plenário desta Corte. Agravo improvido. 1. A teor do disposto no art. 21, par. 1º, do RISTF, poderá o relator arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal. Nulidade: invasão de competência. Improcedente. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar a Representação nº 1.153-RS, não julgou inconstitucional o art. 1º da Lei 7.742/82, que condiciona a prévio cadastramento do produto agrotóxico e outros biocidas no Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio Ambiente a comercialização no território do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo regimental improvido.”

POLÍTICA ENERGÉTICA E MEIO AMBIENTE

18.1 INTRODUÇÃO

O ano de 2001 marcou uma importantíssima alteração nos hábitos de consumo de energia dos brasileiros, pois nele ocorreu o fenômeno que ficou conhecido como apagão. O apagão foi o nome popular de um grave problema de abastecimento de energia elétrica, consequência de vários e diferentes fatores políticos, sociais, econômicos e climatológicos. A produção e o consumo de energia são das questões ambientais mais relevantes e, qualquer que seja a configuração da matriz energética de um país, as suas repercussões sobre o meio ambiente serão sempre importantes e significativas.

18.2 POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, é a principal norma jurídica nacional que dispõe sobre política energética. É preciso que se diga, entretanto, que a lei está voltada fundamentalmente para o setor de petróleo do grande complexo energético que compõe a nossa matriz energética brasileira. A mencionada lei *dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo*.

18.2.1 Princípios e objetivos da política energética nacional

A lei estabelece em seu artigo 1º que as políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia devem buscar atender aos seguintes objetivos:

- i) preservar o interesse nacional;
- ii) promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos;
- iii) proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
- iv) proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;
- v) garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do artigo 177 da Constituição Federal;
- vi) incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;
- vii) identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do país;
- viii) utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
- ix) promover a livre concorrência;
- x) atrair investimentos na produção de energia;
- xi) ampliar a competitividade do país no mercado internacional;
- xii) incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional;
- xiii) garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional;
- xiv) incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica;
- xv) promover a competitividade do País no mercado internacional de biocombustíveis;
- xvi) atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis;
- xvii) fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável;
- xviii) mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis.

18.2.2 Conselho Nacional de Política Energética

A lei instituiu o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, que é um órgão vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas específicas destinadas a:

- i) promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país, em conformidade com os princípios enumerados no capítulo anterior e com o disposto na legislação aplicável;
- ii) assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do país, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios;
- iii) rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do país, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
- iv) estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas;
- v) estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o artigo 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
- vi) incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;

- vii) identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País;
- viii) utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
- ix) promover a livre concorrência;
- x) atrair investimentos na produção de energia;
- xi) ampliar a competitividade do País no mercado internacional;
- xii) incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005)
- xiii) garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)
- xiv) incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)
- xv) promover a competitividade do País no mercado internacional de biocombustíveis; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)
- xvi) atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)
- xvii) fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)
- xviii) mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores de

Tal órgão de assessoramento pessoal do Sr. Presidente da República é apoiado em suas atividades e atribuições pelas Agências Reguladoras do Setor Energético.

O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE foi regulamentado pelo Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000, com nova redação dada pelo Decreto nº 5.793, de 29 de maio de 2006, que dispõe sobre a sua estrutura e o seu funcionamento.

18.2.2.1 Finalidade e composição

Na forma do artigo 1º do decreto, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, criado pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, é órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia, destinadas a (artigo 1º do Decreto nº 3.520/2000):

- I – promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com o disposto na legislação aplicável e com os seguintes princípios:
 - a) preservação do interesse nacional;
 - b) promoção do desenvolvimento sustentado, ampliação do mercado de trabalho e valorização dos recursos energéticos;
 - c) proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
 - d) proteção do meio ambiente e promoção da conservação de energia;
 - e) garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do artigo 177 da Constituição Federal;
 - f) incremento da utilização do gás natural;
 - g) identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País;
 - h) utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
 - i) promoção da livre concorrência;
 - j) atração de investimentos na produção de energia;
 - l) ampliação da competitividade do País no mercado internacional;
 - m) incremento da participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional;
 - n) garantia de suprimento de biocombustíveis em todo o território nacional;
- II – assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios, observado o disposto no parágrafo único do artigo 73 da Lei nº 9.478, de 1997;
- III – rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
- IV – estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia proveniente de outras fontes alternativas;
- V – estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o artigo 4º da Lei nº 8.176 de 8 de fevereiro de 1991.

O CNPE, se entender necessário, poderá constituir comitês técnicos para analisar e opinar sobre matérias específicas sob sua apreciação, inclusive com a participação de representantes da sociedade civil, dos setores de produção e de distribuição e dos consumidores, quando a matéria analisada lhes disser respeito.

O Conselho Nacional de Política Energética é integrado pelas seguintes autoridades públicas (artigo 2º do Decreto nº 3.520/2000): I – o Ministro de Estado de Minas e Energia, que o presidirá; II – o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; III – o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; IV – o Ministro de Estado da Fazenda; V – o Ministro de Estado do Meio Ambiente; VI – o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; VII – o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República; VIII – o Ministro de Estado da Integração Nacional; IX – o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; X – um representante dos Estados e do Distrito Federal; XI – um representante da sociedade civil especialista em matéria de energia; e XII – um representante de universidade brasileira, especialista em matéria de energia; XIII – o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE; e XIV – o Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia.

Os Ministros de Estado, nos seus impedimentos, serão representados pelos respectivos Secretários-Executivos. Os membros referidos nos incisos X, XI e XII serão designados pelo Presidente da República para mandatos de dois anos, renováveis por mais um período, sendo o representante dos Estados e do Distrito Federal indicado pelos respectivos Secretários de Governo a que estejam afetos os assuntos de energia, e os demais pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.

O CNPE, na forma de seu Regimento Interno, tem a seguinte organização administrativa: i) Plenário; ii) Secretaria-Executiva; iii) Assessoria Técnica; e iv) Comitês Técnicos que venham a ser constituídos.

18.2.2.1.1 Atribuições do Presidente do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE

- i) convocar e presidir as reuniões do colegiado;

- ii) manifestar voto próprio e de qualidade, em caso de empate, na deliberação de proposições a serem encaminhadas ao Presidente da República;
- iii) encaminhar ao Presidente da República as propostas aprovadas pelo Conselho.

O Presidente do CNPE, considerando a matéria que será submetida à apreciação do Colegiado, poderá convocar para participar das reuniões do Conselho os Presidentes da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, bem como os dirigentes máximos de outros órgãos ou entidades.

18.2.2.1.2 Plenário

O Plenário do CNPE é composto pelos Conselheiros nomeados na forma da lei. As suas reuniões somente podem ser instaladas com o *quorum* mínimo de metade mais um do total de seus integrantes, titulares ou representantes indicados especificamente para a reunião. As recomendações e resoluções do CNPE são aprovadas por metade mais um dos membros do Conselho presentes à reunião. O Presidente do CNPE pode, em casos de necessidade, decidir questões *ad referendum* do Plenário do Conselho.

18.2.2.1.3 Secretaria-Executiva

O CNPE contará com uma Secretaria-Executiva, com as seguintes atribuições:

- i) emitir os convites e organizar as pautas das reuniões;
- ii) acompanhar a execução das propostas aprovadas pelo Presidente da República;
- ii) coordenar os trabalhos dos comitês técnicos; e
- iv) cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas.

18.2.2.1.4 Assessoria Técnica

A Assessoria Técnica, de caráter permanente, tem a função de apoiar tecnicamente o funcionamento do CNPE, sendo composta pelo Secretário de Energia, na função de coordenador, por um representante da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por um representante da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural – ANP e por representantes indicados pelos Ministros de Estado, que integram o CNPE. Ele deve se reunir, no mínimo, 20 dias antes de cada reunião ordinária do CNPE, com o objetivo de preparar a pauta de trabalho do plenário. Ela, se convocada, poderá participar das reuniões do Plenário.

O apoio técnico ao Conselho e a estrutura de funcionamento correspondente devem ser providenciados pela Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia e por técnicos indicados pelos Diretores Gerais da ANEEL e da ANP, com ou sem o auxílio de outros profissionais de entidades vinculadas aos Ministérios que integram o CNPE. O Secretário-Executivo do CNPE poderá, mediante aprovação do Presidente, contratar consultores por atividade específica e por tempo determinado, para participar de estudos relacionados a assuntos em análise pelos Comitês Técnicos, assim como poderá convidar, a critério do Presidente do Conselho, técnicos e especialistas de outras áreas da administração pública direta ou indireta, bem como da iniciativa privada, para participar de estudos e análises a serem levados à consideração do Plenário do Conselho ou de seus Comitês Técnicos.

Comitês Técnicos

Os Comitês Técnicos serão criados pelo Plenário do CNPE, em número não superior a oito, e terão por função analisar e emitir parecer sobre matérias específicas ligadas à área de energia a serem apreciadas pelo Conselho. É obrigatório que deles participem representantes dos seguintes setores: i) produtor; ii) distribuidor; iii) consumidores, e ainda; iv) técnicos da administração pública; e v) de entidades de classe, quando a matéria a ser analisada lhes disser respeito.

A coordenação dos Comitês Técnicos será exercida pelo Secretário-Executivo do CNPE, ou por outro profissional de sua indicação. Os seus membros serão indicados pelo Secretário-Executivo e nomeados pelo Presidente do CNPE. Os Comitês serão constituídos por prazo limitado, que não será superior a 12 meses, contados a partir da reunião do plenário que os instituir, podendo ser prorrogados a critério do plenário.

As normas para funcionamento e os programas de atividades dos Comitês Técnicos serão aprovados pelo Presidente do CNPE. A conclusão dos trabalhos realizados pelos Comitês Técnicos será encaminhada ao Presidente do CNPE, que a submeterá à consideração do plenário.

A Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia deve prover os recursos necessários e o apoio administrativo para a operação dos Comitês Técnicos.

18.2.2.2 Funcionamento do CNPE

Conforme determina o artigo 11 de seu Regimento Interno, o CNPE deve se reunir ordinariamente a cada seis meses, mediante convocação de seu Presidente. Havendo ausência ou impedimento de seu Presidente, os demais conselheiros escolherão um dos Ministros de Estado presentes à reunião para presidir os trabalhos.

O CNPE pode se reunir, extraordinariamente, por convocação do Presidente, nas seguintes hipóteses: i) por sua exclusiva iniciativa; e ii) quando solicitado por quaisquer dos integrantes efetivos do CNPE, desde que apoiado por mais dois integrantes titulares.

Cabe ao Presidente comunicar aos demais integrantes do plenário do CNPE, com antecedência mínima de 15 dias, a data, horário e local das reuniões ordinárias, bem como a pauta dos assuntos a serem tratados. Para cada assunto da pauta, o Secretário-Executivo elaborará um relatório, o qual será encaminhado aos integrantes do Conselho juntamente com a pauta da reunião. Os assuntos que os integrantes do plenário desejarem discutir nas reuniões ordinárias deverão ser previamente encaminhados ao Secretário-Executivo do CNPE, observada a antecedência mínima de 20 dias, a fim de serem instruídos e encaminhados aos demais membros do Conselho.

18.3 O PETRÓLEO NA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

18.3.1 A Exploração e Produção (E&P) de petróleo no Brasil

A atividade de exploração e produção de petróleo no Brasil, em linhas gerais, pode ser assim resumida:¹

- i) Até 1938, com as explorações sob o regime da livre-iniciativa. A primeira sondagem profunda foi realizada entre 1892 e 1896, no Município de Bofete, Estado de São Paulo, por Eugênio Ferreira Camargo.
- ii) Regime de propriedade estatal do subsolo. Criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938.
- iii) Regime de monopólio estatal, com a criação da Petrobras, em 3 de outubro de 1953, promulgou a Lei nº 2.004.
- iv) Flexibilização do Monopólio, conforme a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, decorrente de reforma constitucional.

No ano de 1931, o escritor nacionalista Monteiro Lobato fundou a Companhia de Petróleo do Brasil e passou a se dedicar a uma campanha para extração do produto. A primeira descoberta de petróleo no Brasil ocorreu no Estado da Bahia, na localidade de Lobato, no ano de 1953. A primeira tentativa de atração de

investimentos estrangeiros na indústria nacional de petróleo foi feita em 1975, com os contratos de risco que, no entanto, não obtiveram muito sucesso.

A exploração comercial do petróleo na Bacia de Campos (RJ) ocorreu no ano de 1977. Em 1985, tem início a produção em águas profundas. No ano de 1997, foi atingida a produção de mais de 1 milhão de barris por dia, meta só alcançada por 16 países.

18.3.2 Regime legal do petróleo no Brasil

18.3.2.1 Dispositivos constitucionais

A Constituição Federal de 1988, conforme a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, modificou inteiramente o regime do monopólio do Petróleo que, por muitos anos, prevaleceu no Brasil. O monopólio da atividade de exploração e produção de petróleo continua a existir, porém, é exercido pelo regime de concessão do serviço. Estabeleceu a norma constitucional a abertura do mercado para a iniciativa privada que, desde então, passa a competir com a Petrobras, que é a empresa de economia mista, organizada sob o regime jurídico de Sociedade Anônima, que era a única responsável pela exploração e a produção de petróleo no Brasil até então.

Na forma do artigo 177 da Lei Fundamental da República, o monopólio da União abrange as seguintes atividades: i) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; ii) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; iii) a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; iv) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; v) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas *b e c* do inciso XXIII do *caput* do art. 21 da Constituição Federal.

A União pode contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV do artigo 177, observadas as condições estabelecidas em lei. Tal lei, de acordo com o mandamento constitucional, deve tratar dos seguintes temas: i) a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; ii) as condições de contratação; iii) a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União.

18.3.2.1.1 Exercício do monopólio

São de propriedade da União todos os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva.

18.3.2.2 Glossário da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997

- I – Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e condensado;
- II – Gás Natural ou Gás: todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros;
- III – Derivados de Petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo;
- IV – Derivados Básicos: principais derivados de petróleo, referidos no art. 177 da Constituição Federal, a serem classificados pela Agência Nacional do Petróleo;
- V – Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em derivados de petróleo;
- VI – Tratamento ou Processamento de Gás Natural: conjunto de operações destinadas a permitir o seu transporte, distribuição e utilização;
- VII – Transporte: movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso considerado de interesse geral;
- VIII – Transferência: movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural em meio ou percurso considerado de interesse específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades;
- IX – Bacia Sedimentar: depressão da crosta terrestre onde se acumulam rochas sedimentares que podem ser portadoras de petróleo ou gás, associados ou não;
- X – Reservatório ou Depósito: configuração geológica dotada de propriedades específicas, armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não;
- XI – Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em produção;
- XII – Prospecto: feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e de interpretação geológica, que justificam a perfuração de poços exploratórios para a localização de petróleo ou gás natural;
- XIII – Bloco: parte de uma bacia sedimentar, formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices, onde são desenvolvidas atividades de exploração ou produção de petróleo e gás natural;
- XIV – Campo de Petróleo ou de Gás Natural: área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção;
- XV – Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural;
- XVI – Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação;
- XVII – Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar as atividades de produção de um campo de petróleo ou gás;
- XVIII – Descoberta Comercial: descoberta de petróleo ou gás natural em condições que, a preços de mercado, tornem possível o retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção;
- XIX – Indústria do Petróleo: conjunto de atividades econômicas relacionadas com a exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação e exportação de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados;
- XX – Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede varejista ou com grandes consumidores de combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
- XXI – Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, exercida por postos de serviços ou revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis;
- XXII – Distribuição de Gás Canalizado: serviços locais de comercialização de gás canalizado, junto aos usuários finais, explorados com exclusividade pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos do § 2º do art. 25 da Constituição Federal;
- XXIII – Estocagem de Gás Natural: armazenamento de gás natural em reservatórios próprios, formações naturais ou artificiais;
- XXIV – Biocombustível: substância derivada de biomassa renovável, tal como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da

ANP, que pode ser empregada diretamente ou mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;

- XXV – Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;
- XXVI – Indústria Petroquímica de Primeira e Segunda Geração: conjunto de indústrias que fornecem produtos petroquímicos básicos, a exemplo do eteno, do propeno e de resinas termoplásticas;
- XXVII – cadeia produtiva do petróleo: sistema de produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e a estocagem, bem como o seu consumo;
- XXVIII – Indústria de Biocombustível: conjunto de atividades econômicas relacionadas com produção, importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem, comercialização, distribuição, avaliação de conformidade e certificação de qualidade de biocombustíveis;
- XXIX – Produção de Biocombustível: conjunto de operações industriais para a transformação de biomassa renovável, de origem vegetal ou animal, em combustível;
- XXX – Etanol: biocombustível líquido derivado de biomassa renovável, que tem como principal componente o álcool etílico, que pode ser utilizado, diretamente ou mediante alterações, em motores a combustão interna com ignição por centelha, em outras formas de geração de energia ou em indústria petroquímica, podendo ser obtido por rotas tecnológicas distintas, conforme especificado em regulamento;
- XXXI – Bioquerosene de Aviação: substância derivada de biomassa renovável que pode ser usada em turborreatores e turbopropulsores aeronáuticos ou, conforme regulamento, em outro tipo de aplicação que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil.

18.3.2.3 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tem origem na própria Constituição Federal, que, por força do artigo 177, § 2º, III, determinou a constituição de um órgão regulador para as atividades das diversas facetas da indústria petrolífera. Tal agência foi instituída pelo artigo 7º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Ela é integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Sua sede e foro situam-se em Brasília, com escritórios centrais na cidade do Rio de Janeiro, podendo instalar unidades administrativas regionais. Justifica-se a situação geográfica de seus escritórios centrais, na medida em que o Estado do Rio de Janeiro é, de longe, o maior produtor de petróleo no Brasil.

Os objetivos institucionais da ANP são os de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:

- I – implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;
- II – promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão ou contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produção;
- III – regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas;
- IV – elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução;
- V – autorizar a prática das atividades de refinação, liquefação, regaseificação, carregamento, processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento;
- VI – estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos nesta Lei;
- VII – fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
- VIII – instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de dutos e de terminais;
- IX – fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente;
- X – estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento;
- XI – organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis;
- XII – consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua divulgação;
- XIII – fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
- XIV – articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE;
- XV – regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;
- XVI – regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;
- XVII – exigir dos agentes regulados o envio de informações relativas às operações de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de produtos sujeitos à sua regulação;
- XVIII – especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis;
- XIX – regular e fiscalizar o acesso à capacidade dos gasodutos;
- XX – promover, direta ou indiretamente, as chamadas públicas para a contratação de capacidade de transporte de gás natural, conforme as diretrizes do Ministério de Minas e Energia;

- XXI – registrar os contratos de transporte e de interconexão entre instalações de transporte, inclusive as procedentes do exterior, e os contratos de comercialização, celebrados entre os agentes de mercado;
- XXII – informar a origem ou a caracterização das reservas do gás natural contratado e a ser contratado entre os agentes de mercado;
- XXIII – regular e fiscalizar o exercício da atividade de estocagem de gás natural, inclusive no que se refere ao direito de acesso de terceiros às instalações concedidas;
- XXIV – elaborar os editais e promover as licitações destinadas à contratação de concessionários para a exploração das atividades de transporte e de estocagem de gás natural;
- XXV – celebrar, mediante delegação do Ministério de Minas e Energia, os contratos de concessão para a exploração das atividades de transporte e estocagem de gás natural sujeitas ao regime de concessão;
- XXVI – autorizar a prática da atividade de comercialização de gás natural, dentro da esfera de competência da União;
- XXVII – estabelecer critérios para a aferição da capacidade dos gasodutos de transporte e de transferência;
- XXVIII – articular-se com órgãos reguladores estaduais e ambientais, objetivando compatibilizar e uniformizar as normas aplicáveis à indústria e aos mercados de gás natural.

Parágrafo único. No exercício das atribuições de que trata este artigo, com ênfase na garantia do abastecimento nacional de combustíveis, desde que em bases econômicas sustentáveis, a ANP poderá exigir dos agentes regulados, conforme disposto em regulamento:

- I – a manutenção de estoques mínimos de combustíveis e de biocombustíveis, em instalação própria ou de terceiro;
- II – garantias e comprovação de capacidade para atendimento ao mercado de combustíveis e biocombustíveis, mediante a apresentação de, entre outros mecanismos, contratos de fornecimento entre os agentes regulados.

Art. 8º-A. Caberá à ANP supervisionar a movimentação de gás natural na rede de transporte e coordená-la em situações caracterizadas como de contingência.

§ 1º O Comitê de Contingenciamento definirá as diretrizes para a coordenação das operações da rede de movimentação de gás natural em situações caracterizadas como de contingência, reconhecidas pelo Presidente da República, por meio de decreto

§ 2º No exercício das atribuições referidas no **caput** deste artigo, caberá à ANP, sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas na regulamentação

- I – supervisionar os dados e as informações dos centros de controle dos gasodutos de transporte;
- II – manter banco de informações relativo ao sistema de movimentação de gás natural permanentemente atualizado, subsidiando o Ministério de Minas e Energia com as informações sobre necessidades de reforço ao sistema;
- III – monitorar as entradas e saídas de gás natural das redes de transporte, confrontando os volumes movimentados com os contratos de transporte vigentes;
- IV – dar publicidade às capacidades de movimentação existentes que não estejam sendo utilizadas e às modalidades possíveis para sua contratação; e
- V – estabelecer padrões e parâmetros para a operação e manutenção eficientes do sistema de transporte e estocagem de gás natural.

O conjunto de atribuições da ANP, *embora relacionado diretamente com a qualidade da operação das atividades de petróleo*, indiscutivelmente, guarda muita proximidade com o controle ambiental. Efetivamente, a má operação quase sempre implica o lançamento de petróleo no ambiente. Observa-se, portanto, que um derramamento de óleo com efeitos negativos sobre o ambiente repercute, do ponto de vista jurídico, na esfera administrativa própria da atividade de petróleo, bem como nas diferentes esferas tuteladas pelo Direito Ambiental. É importante, portanto, que a ANP, o IBAMA e as Agências Ambientais dos Estados estabeleçam um mecanismo de colaboração e consulta, a fim de que a proteção ambiental seja considerada de forma concreta e razoável.

18.3.2.3.1 Caso concreto de conflito entre autoridades ambientais em matéria de petróleo

As disputas entre os diferentes atores da proteção ambiental em matéria de petróleo atingiram o paroxismo com o vazamento de petróleo ocorrido no dia 16 de julho de 2000, no Estado do Paraná,² quando ocorreu o maior acidente com derramamento de óleo/petróleo em recursos hídricos (arroyo Saldanha, rio Barigui e rio Iguaçu) brasileiros. No dia seguinte ao fato, o Instituto Ambiental do Paraná – IAP autuou a Petrobras/Repar, impondo-lhe uma multa administrativa no valor de R\$ 50.000.000,00, pelo atingimento de corpos hídricos estaduais, conforme determina a Lei Federal nº 9.605/98. Passados cerca de 15 dias, o IBAMA autuou a Petrobras/Repar, aplicando-lhe três multas pelos danos ao rio federal, à flora e à fauna silvestre e à ictiofauna, isso tudo no valor de R\$ 168.000.000,00.

O surpreendente é que, após a aplicação da multa realizada pelo IAP, o órgão ambiental paranaense viu-se na condição de requerido em uma medida cautelar,^{3,4} na qual eram requerentes os Ministérios Públicos Federal, Estadual e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com o objetivo de que a multa ambiental aplicada pelo IAP fosse declarada nula, sob o argumento da incompetência do órgão estadual para aplicar sanções administrativas de defesa do meio ambiente, no caso concreto. O feito foi julgado extinto, sem apreciação do mérito.⁵ O Poder Judiciário, na hipótese, restabeleceu a racionalidade.

A grande pergunta que surge do caso anteriormente narrado é: quem é o beneficiário da ação? O meio ambiente?

18.3.2.4 Exploração e produção (aspectos ambientais)

As atividades de exploração e produção de petróleo estão submetidas ao poder de polícia ambiental exercido na forma da lei pelos órgãos competentes.

Em primeiro lugar, há que se considerar que *todos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP*. Isso implica que a União e a ANP, tendo em vista a titularidade dos recursos minerais relacionados ao petróleo e ao gás natural, na condição de poder concedente, são *subsidiariamente responsáveis* por danos ambientais decorrentes das atividades de exploração e produção de petróleo. Ou seja, o Estado somente poderá ser acionado por danos ambientais advindos da atividade de exploração e produção de petróleo se, e somente se, o capital das empresas diretamente responsáveis pelo dano tiver se esgotado e a concessão tiver retornado ao Poder concedente, sem a reparação dos danos causados. A responsabilidade do Estado é uma matéria que, em Direito Ambiental, deve ser aplicada com parcimônia, pois, ante a vigência do princípio poluidor pagador, não é razoável que se impute à coletividade os custos com a reparação de danos ambientais que foram causados por atividades privadas e com lucros privados.

18.3.2.4.1 Informações técnicas

As atividades de exploração e produção de petróleo são intrinsecamente causadoras de impactos ambientais que, no entanto, podem ser diminuídos se as informações técnicas existentes sobre as reservas, o estado do ambiente no qual as atividades serão desenvolvidas, forem em nível suficiente – qualitativa e quantitativamente – para permitir que as atividades se desenvolvam com o menor risco possível. É por isso que o artigo 22 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, determina que: *o acervo técnico constituído pelos dados e informações sobre as bacias sedimentares brasileiras é também considerado parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua coleta, manutenção e administração*. A lei, realisticamente, reconheceu que o maior banco de dados existente no país sobre exploração e produção de petróleo é de propriedade da Petrobras que, desde 1953, vinha exercendo o monopólio do petróleo, em todas as suas fases.

Com vistas a dotar o órgão regulador com as informações técnicas essenciais para o desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo e, igualmente, com vistas a garantir um mínimo de igualdade no mercado entre as empresas que ingressam na atividade, foi determinado à Petrobras que transferisse para a ANP as informações e dados de que dispusesse sobre as bacias sedimentares brasileiras, assim como sobre as atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo ou gás natural, desenvolvidas em função da exclusividade do exercício do monopólio. Tal transferência, remunerada, deve ser feita com critérios estabelecidos pela própria ANP.

18.3.2.4.2 Contratos de concessão

As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural somente podem ser exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, cujos termos essenciais são definidos na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Os blocos a serem concedidos são definidos pela ANP, mediante a adoção de procedimento próprio, e obrigatoriamente deverão contemplar duas fases: (i) exploração e (ii) produção.

Na fase de exploração, estão compreendidas as atividades de avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de seu nível potencial de comercialização. Na fase de produção, devem estar incluídas, também, as atividades de desenvolvimento. Somente podem se candidatar à concessão para a exploração e produção de petróleo ou gás natural as empresas que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP.

a) Cláusulas cogentes dos contratos de concessão

O contrato de concessão, como qualquer contrato de concessão, deve reproduzir as condições do edital e da proposta vencedora, tendo as seguintes cláusulas essenciais:

- i) definição do bloco objeto da concessão;
- ii) prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua prorrogação;
- iii) programa de trabalho e o volume do investimento previsto;
- iv) obrigações do concessionário quanto às participações, conforme o disposto na Seção VI da Lei do Petróleo;
- v) indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados para cada fase;
- vi) especificação das regras sobre devolução e desocupação de áreas, inclusive retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens;
- vii) procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato;
- viii) obrigatoriedade de o concessionário fornecer à ANP relatórios, dados e informações relativos às atividades desenvolvidas;
- ix) procedimentos relacionados com a transferência do contrato, conforme o disposto no artigo 29 da Lei do Petróleo;
- x) regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional;
- xi) casos de rescisão e extinção do contrato;
- xii) penalidades aplicáveis na hipótese de descumprimento, pelo concessionário, das obrigações contratuais.

Na forma do artigo 44, o contrato deve estabelecer, ainda, as seguintes obrigações para o concessionário:

- i) adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio ambiente;
- ii) comunicar à ANP, imediatamente, a descoberta de qualquer jazida de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos ou de outros minerais;
- iii) realizar a avaliação da descoberta nos termos do programa submetido à ANP, apresentando relatório de comercialidade e declarando seu interesse no desenvolvimento do campo;
- iv) submeter à ANP o plano de desenvolvimento de campo declarado comercial, contendo o cronograma e a estimativa de investimento;
- v) responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a suportar em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário;
- vi) adotar as melhores práticas da indústria internacional do petróleo e obedecer às normas e aos procedimentos técnicos e científicos pertinentes, inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a racionalização da produção e o controle do declínio das reservas.

Não é ocioso observar que o contrato de concessão pode ser um poderoso instrumento de proteção e conservação ambiental, pois, por cláusulas bem definidas e claras, é possível determinar medidas concretas de defesa do meio ambiente. Esse é um mecanismo que, parece-me, tem sido pouco explorado e desenvolvido. Se considerarmos as dificuldades inerentes aos processos legislativo e regulamentar, torna-se bastante simples perceber que há uma enorme margem de manobra para que o controle ambiental possa ser parcialmente exercido por cláusulas do próprio contrato de concessão.

b) Direitos e obrigações do concessionário

A concessão é exercida pelo concessionário, às suas próprias expensas, com a obrigação de explorar e, na hipótese de obter sucesso, produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, cabendo-lhe a propriedade do produto de sua atividade, sobre eles incidindo os encargos relativos ao pagamento dos tributos aplicáveis e das participações legais ou contratuais correspondentes. Caracterizado o sucesso da exploração, cabe à ANP aprovar os planos e projetos de desenvolvimento e produção. O órgão regulador tem o prazo legal de 180 dias para aprovar ou não os planos. Em minha opinião, sendo a produção viável, ambiental e economicamente, à ANP só resta aprová-lo. Se assim não o fizer, penso que o concessionário pode exigir judicialmente tal aprovação.

O artigo 44 da Lei nº 9.478 estabelece algumas regras de responsabilidade e cuidados ambientais que merecem menção. Assim, o concessionário está obrigado a (i) adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos equipamentos e para a proteção do meio ambiente; (ii) responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar todos e quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a suportar em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário; (iii) adotar as melhores práticas da indústria internacional do petróleo e obedecer às normas e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, inclusive quanto às técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a racionalização da produção e o controle do declínio das reservas.

c) Extinção das concessões

São causas de extinção das concessões: i) vencimento do prazo contratual; ii) acordo entre as partes; iii) motivos de rescisão previstos em contrato; iv) término da fase de exploração, sem que tenha sido feita qualquer descoberta comercial, conforme definido no contrato; v) na fase de exploração, se o concessionário exercer a opção de desistência e de devolução das áreas que, a seu critério, não justifiquem investimentos em desenvolvimento.

c.1) Descomissionamento

O descomissionamento é o abandono organizado de uma atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural. Trata-se de uma atividade cuja repercussão ambiental é de transcendental importância, pois como a E&P é feita com significativo impacto ambiental, necessário se faz que o encerramento de tais processos seja feito dentro de normas ambientais que assegurem o máximo de recuperação da área degradada, bem como dos aparelhos e equipamentos utilizados. Daí a relevância do § 2º do artigo 28, que determina: “em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades e praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes”.

Ainda que exista uma previsão legal para o descomissionamento e a recuperação ambiental, com a remoção de equipamentos e bens que não sejam revertidos para o poder concedente, *verbi gratia*, plataformas de produção, armazenamento etc., persiste uma necessidade muito grande de aprofundamento do quadro regulatório da matéria.

c.2) Abandono de poço

A ANP vem buscando, no âmbito de suas competências, estabelecer um marco regulatório para as diferentes atividades referentes ao descomissionamento das variadas fases da E&P de petróleo. Exemplo disso é a Portaria nº 25 de 06 de março de 2002⁶, que *aprova o Regulamento de Abandono de Poços perfurados com vistas à exploração ou produção de petróleo e/ou gás*.

O objetivo do regulamento em questão é estabelecer procedimentos a serem adotados no abandono de poços de petróleo e/ou gás, de maneira a assegurar o perfeito isolamento das zonas de petróleo e/ou gás e também dos aquíferos existentes, prevenindo:

- a migração dos fluidos entre as formações, quer pelo poço, quer pelo espaço anular entre o poço e o revestimento; e
- a migração de fluidos até a superfície do terreno ou o fundo do mar.

O abandono do poço, no transcorrer da Fase de Exploração, poderá ser feito, desde que de acordo com o disposto no Regulamento próprio e mediante notificação prévia à ANP. Quando se tratar da Fase de Produção, excetuando-se a Etapa de Desenvolvimento, todo poço produtor de petróleo e/ou gás, ou injetor, somente poderá ser abandonado mediante autorização da ANP. Na primeira etapa, é necessária uma mera notificação ao Órgão Regulador; já na fase de Produção faz-se necessária a autorização da ANP, ou seja, o seu consentimento formal.

É proibido o abandono de poço enquanto as operações de abandono puderem causar prejuízo de alguma forma a quaisquer operações em poços vizinhos, salvo se o poço em questão, por algum motivo, representar ameaça de dano à segurança e/ou ao meio ambiente. O Regulamento estabelece os mecanismos para a cimentação do poço que, por seu caráter extremamente técnico, não vejo necessidade de mencionar.

O abandono pode ser dividido em: (i) permanente e (ii) temporário e deve ser realizado conforme determinado pelos capítulos II e III do Regulamento.

18.3.2.4.3 Aspectos ambientais da licitação

A licitação é a forma constitucional e legal para a concessão de serviços públicos e foi o método adotado pelo nosso regime legal para a concessão das atividades de E&P. A fórmula adotada tem sido criticada pelos estudiosos do assunto, pois não segue a tendência mundial dos Contratos de Produção Partilhada. Houve uma retomada do modelo vigente no Código de Mineração de 1934, que perdurou até o advento da Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, que criou o Conselho Nacional de Petróleo. Não pretendo, aqui, discutir os aspectos de direito administrativo do processo licitatório de blocos para a E&P, pois esse não é o objetivo deste trabalho. Entretanto, julgo oportuno estabelecer algumas observações sobre as repercussões ambientais do processo licitatório e, principalmente, das repercussões ambientais na execução do contrato de concessão.

O edital de licitação, conforme determina o artigo 37 da Lei do Petróleo, deverá vir acompanhado da minuta básica do contrato de concessão e, obrigatoriamente, deverá indicar:

- i) o bloco objeto da concessão, o prazo estimado para a duração da fase de exploração, os investimentos e programas exploratórios mínimos;
- ii) os requisitos exigidos dos concorrentes, nos termos do artigo 25, e os critérios de pré-qualificação, quando este procedimento for adotado;
- iii) as participações governamentais mínimas, na forma do disposto no artigo 45, e a participação dos superficiários prevista no artigo 52;
- iv) a relação de documentos exigidos e os critérios a serem seguidos para aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica dos interessados, bem como para o julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
- v) a expressa indicação de que caberá ao concessionário o pagamento das indenizações devidas por desapropriações ou servidões necessárias ao cumprimento do contrato;
- vi) o prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e demais elementos e informações necessários à elaboração das propostas, bem como o custo de sua aquisição.

Na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio, o edital conterá as seguintes exigências:

- i) comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas;
- ii) indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio e pela condução das operações, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas;
- iii) apresentação, por parte de cada uma das empresas consorciadas, dos documentos exigidos para efeito de avaliação da qualificação técnica e econômico-financeira do consórcio;
- iv) proibição de participação de uma mesma empresa em outro consórcio, ou isoladamente, na licitação de um mesmo bloco;
- v) outorga de concessão ao consórcio vencedor da licitação condicionada ao registro do instrumento constitutivo do consórcio, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

O edital deverá conter a exigência de que a empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou em consórcio apresente, juntamente com sua proposta e em envelope separado:

- i) prova de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, nos termos da regulamentação a ser editada pela ANP;
- ii) inteiro teor dos atos constitutivos e prova de encontrar-se organizada e em funcionamento regular, conforme a lei de seu país;
- iii) designação de um representante legal junto à ANP, com poderes especiais para a prática de atos e assunção de responsabilidades relativamente à licitação e à proposta apresentada;
- iv) compromisso de, caso vencedora, constituir empresa segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil.

Como se pode ver das regras básicas para o procedimento licitatório, *não* há qualquer preocupação com a *caracterização ambiental da área a ser submetida ao*

certame. Tal fato, em minha opinião, é extremamente preocupante, pois as licitações dos blocos, como têm sido feitas até agora, têm se limitado aos exames geofísicos das bacias sedimentares nas quais os diferentes blocos são oferecidos. Penso que seria extremamente conveniente que os instrumentos convocatórios do certame fossem oferecidos ao público interessado com uma descrição detalhada das áreas ambientalmente sensíveis, indicando as áreas de exclusão, unidades de conservação existentes e outras informações ambientais relevantes. Parece-me que a inexistência de dados ambientais, em especial sobre o meio ambiente marinho, está criando uma situação de difícil administração, pois são exigidos das empresas vencedoras das licitações estudos de impacto ambiental que, em minha opinião, ultrapassam, em muito, o razoável.

O ideal é que, antes do oferecimento do bloco à licitação pública, sejam realizados os estudos ambientais necessários para a exploração da área – por contratação da ANP. Uma vez concedido o bloco para exploração, os estudos ambientais seriam meros aprofundamentos de dados já existentes.

18.4 POLÍTICA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Uma norma diretamente advinda da crise energética e da ameaça de apagão é a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que “*Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providências.*” Tal lei, é desnecessário dizer, possui uma enorme repercussão ambiental, pois, pela conservação e uso racional de energia, diminui-se a pressão sobre os diferentes recursos ambientais. Infelizmente, o Brasil só passou a desenvolver uma política consistente de conservação de energia com a crise do ano 2001. Porém, é imperioso dizer que os resultados que vêm sendo alcançados têm sido bastante expressivos e a colaboração espontânea dos diferentes consumidores de energia tem servido de importante lição para as autoridades públicas, que necessitam fazer planejamentos mais profundos e realistas.

É relevante assinalar que o artigo 1º da lei dispõe, expressamente, que a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia (PNCURE) *visa à alocação eficiente de recursos energéticos e à preservação do meio ambiente*. Esse é um reconhecimento formal de que o desperdício de energia é um fator de degradação ambiental.

O principal ponto enfocado pela PNCURE é o estabelecimento de níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no país, com base em indicadores técnicos pertinentes. A lei, portanto, busca alcançar a eficiência energética com aparelhos menos intensivos na utilização de energia. Isso implicará, sem dúvida, uma modernização dos aparelhos utilizados no país, com uma repercussão ambiental imediata.

A fixação de parâmetros racionais de consumo de energia e eficiência energética deve ser feita de forma que utilize valores técnica e economicamente viáveis, considerando a vida útil das máquinas e aparelhos consumidores de energia. A implantação será feita de maneira gradual, tendo início em até um ano a partir da publicação dos referidos níveis, conforme um Programa de Metas para sua progressiva evolução.

Os níveis máximos de consumo de energia e mínimo de eficiência energética, conforme forem definidos pelas autoridades públicas, são obrigatórios para os fabricantes e os importadores de máquinas e aparelhos consumidores de energia que, para alcançá-los, devem adotar as medidas necessárias. É importante observar que, diferentemente de diversos padrões, proibições e limites ambientais, no caso da PNCURE, eles têm base diretamente legal e não em resoluções ou outros atos administrativos de menor hierarquia.

Compete aos importadores comprovar o atendimento aos níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, durante o processo de importação.

18.4.1 Penalidades

Os aparelhos consumidores de energia encontrados no mercado sem atender às especificações legais, quando da vigência da regulamentação específica, serão recolhidos, no prazo máximo de 30 dias, pelos respectivos fabricantes e importadores. Uma vez ultrapassado o prazo anteriormente mencionado (artigo 3º, § 2º), os fabricantes e importadores estarão sujeitos às multas por unidade, a serem estabelecidas em regulamento, de até 100% do preço de venda por eles praticados.

A lei buscou aplicar um mecanismo democrático para a fixação dos limites máximos de consumo de energia e mínimo de eficiência energética, por mais de um mecanismo de consultas prévias realizado mediante audiências públicas, com divulgação antecipada das propostas formuladas pelo Governo, nas quais deverão participar entidades representativas de fabricantes e importadores de máquinas e aparelhos consumidores de energia, projetistas e construtores de edificações, consumidores, instituições de ensino e pesquisa e demais entidades interessadas.

18.4.2 Regulamentação da Política Nacional de Conservação de Energia

A Política Nacional de Conservação de Energia foi regulamentada pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001. O artigo 1º do decreto estabelece que os níveis máximos de consumo de energia, mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados, bem como as edificações construídas, serão estabelecidos com base em indicadores técnicos e regulamentação a ser baixada pelo Ministério das Minas e Energia.

18.4.2.1 Composição e atribuições do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE

O Decreto instituiu o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE, cuja formação é a seguinte: i) Ministério das Minas e Energia; ii) Ministério da Ciência e Tecnologia; iii) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; iv) Agência Nacional de Energia Elétrica; v) Agência Nacional do Petróleo; vi) Um representante de universidade brasileira e um cidadão brasileiro, ambos especialistas em matéria de energia, designados pelo Ministro de Estado das Minas e Energia, com mandato de dois anos, podendo ser renovado por mais um período.

Atribuições do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE:

- i) elaborar plano de trabalho e cronograma para a implementação da Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001;
- ii) elaborar regulamentação específica para cada tipo de aparelho e máquina consumidores de energia;
- iii) estabelecer Programa de Metas com indicação da evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento regulamentado;
- iv) instituir Comitês Técnicos para analisar e opinar sobre matérias específicas que estejam sendo apreciadas pelo CGIEE, assegurada a participação de representantes da sociedade civil;
- v) acompanhar e avaliar sistematicamente o processo de regulamentação e propor plano de fiscalização; e
- vi) deliberar sobre as proposições do Grupo Técnico para maior eficiência de energia em edificações.

18.4.2.1.1 Audiências Públicas

As Audiências Públicas são previstas como parte do procedimento para a aprovação dos níveis máximos de consumo e mínimos de eficiência energética.

18.4.3 Energia renovável: iniciativa energética

Uma importante medida em favor da proteção ambiental e da maior sustentabilidade da matriz energética nacional é a representada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, com nova redação dada pela Lei nº 12.212/10, que “*dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária*

extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências”.

Tal lei, em seu artigo 3º, institui o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa, cujo objetivo é aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, cuja concepção seja baseada em fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional.

18.5 POLÍTICA NACIONAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

18.5.1 Introdução

Como tenho sustentado ao longo de todo este livro, há uma forte tendência centralizadora na legislação ambiental federal, com o abuso de criação das chamadas “políticas nacionais”, sem que haja uma previsão expressa na Constituição Federal. A grande maioria das “políticas nacionais” não se sustenta, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista de sua implementação prática. Não é o caso da Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), haja vista as interferências humanas no que diz respeito ao clima, pois as condições atmosféricas gerais não dizem respeito a uma única localidade ou mesmo estado da federação, necessitando de medidas mais abrangentes que, em grande parte das vezes, devem ser adotadas pela comunidade internacional. Sob forte pressão internacional, o Brasil, que ocupa lugar de destaque no rol dos grandes emissores de gases de efeito estufa (GEE), viu-se obrigado a adotar medidas legais e administrativas com o objetivo de dar início a uma redução na emissão de GEE.

O Protocolo de Quioto e as emissões de carbono estão no centro do atual debate internacional, sendo dos mais importantes temas do Direito Ambiental Internacional. É relevante observar que todas as questões envolvidas na discussão dizem respeito ao volume de emissões de cada um dos países signatários e até mesmo dos Estados Unidos, até aqui, que não aceita as obrigações estabelecidas no documento internacional. Como se sabe, a ordem jurídica internacional tem uma grave fragilidade, que é a capacidade de executar as decisões tomadas e acordadas nos tratados e convenções internacionais. Se aquele que se nega a dar cumprimento ao tratado ou à convenção é suficientemente forte militar ou economicamente, a comunidade internacional tem pouca chance de penalizá-lo. Aqui existe um problema moral relevante, pois a norma de direito internacional tende a se transformar em uma ficção para os mais fortes, demonstrando que ainda estamos distantes de uma verdadeira civilização. O acatamento à lei internacional é uma prova de nossa maturidade ou imaturidade. No particular, muito embora a humanidade tenha avançado, o fato objetivo e concreto é que ainda há muito por ser feito.

O Protocolo de Quioto estabeleceu metas para os países do Anexo I, definindo que os países do *não anexo* estão isentos de metas. A lógica do Protocolo, assim como a lógica subjacente aos tratados e convenções internacionais, é que eles são firmados pelos sujeitos de direito internacional, que, em tese, ao manifestarem sua vontade perante a sociedade internacional, obrigam-se juridicamente diante dessa mesma comunidade. A realidade desse início de segunda década do século XXI é, contudo, mais complexa e necessitaria de uma reflexão profunda sobre os novos sujeitos de direito internacional. É fato que a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e outras já admitem que várias organizações civis participem das reuniões na condição de observadores; citem-se como exemplo os Médicos Sem Fronteira, Greenpeace e tantos mais.

No caso específico das emissões de carbono (GEE), podemos verificar que, há cerca de três ou quatro décadas, teve início um processo muito forte de transferência de atividades emissoras de carbono para os países do então chamado terceiro mundo, com destaque para a China. O processo de transferência da base industrial emissora de carbono para a periferia do sistema econômico internacional foi enormemente facilitado com o enrijecimento das leis de proteção de propriedade intelectual que, sem emissão de uma única molécula de carbono, asseguram a supremacia econômica daqueles que detêm a patente. A criação da Organização Mundial de Comércio (OMC) e o tratado TRIPS (Tratado de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio) impulsionaram a tendência. Imagine-se que o Brasil, a China e a Índia adotassem metas obrigatórias de redução de emissões e não apenas de redução do futuro aumento de emissões; nada impediria, por exemplo, que as emissões fossem transferidas para o Congo, Bangladesh e o Paraguai, por exemplo. Não só a propriedade das indústrias, de suas patentes, bem como o mercado consumidor permitiriam que a migração ocorresse sem, em tese, qualquer violação do Protocolo, haja vista que os países do não anexo estão dispensados de dar cumprimento a qualquer meta.

Assim, em meu ponto de vista, parece bastante evidente que há uma lacuna legal muito importante e que merece ser examinada pelos especialistas na matéria. Seria de todo conveniente que, no âmbito da sociedade internacional, as organizações industriais fossem reconhecidas como sujeitos de direito internacional e que se estabelecessem metas específicas no setor, independentemente dos países nos quais as indústrias estivessem instaladas. Tento fazer-me claro: determinado setor industrial teria que atingir determinada meta mundial de redução, independentemente do país no qual a atividade estivesse instalada. Utopicamente, seria conveniente que um organismo internacional estabelecesse padrões de eficiência para novas plantas industriais quaisquer que fossem os locais de sua futura instalação. A harmonização, por cima, de padrões de emissões seria uma forma de impedir uma competição industrial baseada em padrões ambientais mais lenientes, como tem sido a prática recente.

Por fim, cogitar-se de uma organização internacional voltada especificamente para dirimir questões ambientais, à semelhança dos painéis da OMC, talvez fosse uma forma superior para o enfrentamento de problemas que são cada vez mais reais e relevantes.

18.5.2 A Política Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC

O governo federal, mediante a edição da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC, estabelecendo-lhe os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos e adotando o seguinte glossário, para os fins específicos da norma: (i) *adaptação*: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima; (ii) *efeitos adversos da mudança do clima*: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; (iii) *emissões*: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado; (iv) *fonte*: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; (v) *gases de efeito estufa*: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha; (vi) *impacto*: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais; (vii) *mitigação*: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; (viii) *mudança do clima*: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis; (ix) *sumidouro*: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e (x) *vulnerabilidade*: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.

O artigo 3º da PNMC estabelece que a “PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução”. Não é difícil perceber que o artigo 3º é extremamente genérico, valendo-se de princípios que não estão claramente definidos, seja no nível doutrinário, no legal ou mesmo jurisprudencial e, inclusive, valendo-se de um princípio de direito internacional que pouco sentido faz em norma de direito interno. Parece-me que, salvo melhor juízo, os princípios invocados deveriam estar contemplados em normas positivadas que exprimissem um determinado nível de compreensão desses mesmos princípios. Parece-me que a simples menção aos

princípios no corpo da norma, sem identificar-lhes um conteúdo é a outorga de uma “*carte blanche*” para uma aplicação administrativa sem critérios e, até mesmo, aleatória.

A aplicação da PNMC deverá ser feita, segundo os termos da própria lei, considerando o seguinte: (i) todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático; (ii) serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, *sobre as quais haja razoável consenso* por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; (iii) as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima; (iv) o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no território nacional; (v) as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas.

Ça *va sans dire* que os conceitos que devem ser levados em consideração para a aplicação da PNMC são extremamente abstratos e, até mesmo, contraditórios entre si. Parece-me que, no particular, o legislador adotou o conceito de “*dar uma no cravo, outra na ferradura*”, evitando o comprometimento com uma conduta mais consistente e coerente. De fato, conceitos como “desenvolvimento sustentável”, “razoável consenso” são ambíguos, pouco esclarecedores e, efetivamente, podem significar qualquer coisa, dependendo do “*mood*” do intérprete. Sustentar uma *política nacional* em tais conceitos é, perdoem-me a franqueza, não ter política alguma. Em que pese a indefinição conceitual, a PNMC, conforme o artigo 4º da Lei, tem os seguintes objetivos: (i) compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático; (ii) redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes; (iii) fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional; (iv) implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; (v) preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;⁷ (vi) consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas; (vii) estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE. Tais objetivos devem “*estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais*” (artigo 4º, parágrafo único).

A PNMC será implementada com base nas seguintes diretrizes: (i) compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário; (ii) ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação *a posteriori*; (iii) medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; (iv) estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos local, regional e nacional; (v) estímulo e apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima; (vi) promoção e desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a: (a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; (b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima; (c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; (vii) utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no artigo 6º da PNMC; (viii) identificação, e sua articulação, com a PNMC, de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático; (ix) apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa; (x) promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de informações; (xi) aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas; (xii) promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a conscientização pública sobre mudança do clima; (xiii) estímulo e apoio à manutenção e à promoção: (a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa; (b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Os instrumentos da PNMC são os seguintes: (i) Plano Nacional sobre Mudança do Clima; (ii) Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; (iii) Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas; (iv) Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas Conferências das Partes; (v) resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; (vi) medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica; (vii) linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e privados; (viii) desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento; (ix) dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União; (x) mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto; (xi) mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima; (xii) medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; (xiii) os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas; (xiv) medidas de divulgação, educação e conscientização; (xv) monitoramento climático nacional; (xvi) indicadores de sustentabilidade; (xvii) estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; (xviii) avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.

Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança do Clima incluem: (i) o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima; (ii) a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; (iii) o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima; (iv) a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima; (v) a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.

Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PNMC. O Poder Executivo, mediante a edição de Decreto, deverá estabelecer, em conformidade com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas – NAMAs.

Mecanismo os financeiros: As instituições financeiras oficiais instituirão linhas de crédito e financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos da PNMC e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e

responsabilidades sociais.

O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de GEE.

18.5.2.1 Redução de emissões de GEE?

A PNMC determina em seu artigo 12 que o “País adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020”. E, em complemento, estabelece que: “A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput [artigo 20] serão dispostos por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010.” Na verdade, o que a PNMC determina é uma “redução do aumento” da emissão de GEE, pois não foi definido um retorno ao nível de emissões passadas, tal como disposto no Protocolo de Quioto; o que foi feito, foi “voluntariamente”, isto é, sem qualquer obrigação, estabelecer que o aumento projetado para as emissões seja reduzido nos percentuais mencionados na norma; ou seja, a PNMC autoriza um aumento de emissão de GEE até o ano 2020.

-
- ¹ Disponível em: <<http://www.cepet.unicamp.br>>.
 - ² Disponível em: <<http://www.pr.gov.br/iap/petro01.html>>.
 - ³ Processo 2000.70.00.019229.8, 4ª Vara Federal de Curitiba.
 - ⁴ Deu origem à Ação Civil Pública 2001.70.582.0.
 - ⁵ Disponível em: <<http://www.jfpr.gov.br/consultas/asp>>.
 - ⁶ Disponível em: <<http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/portarias-anp/tecnicas/2002,/marco&item=panp-25—2002>>. Acesso em: 17 nov. 2018.
 - ⁷ Artigo 225 da Constituição Federal.

ENERGIA NUCLEAR

§ 1º A ENERGIA NUCLEAR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 1988 contém inúmeros dispositivos relativos à utilização da energia nuclear, os quais estão contidos em vários pontos da nossa Carta Política. São tratados temas que variam desde o uso de radioisótopos com objetivos medicinais até a proibição de utilização da energia nuclear com finalidades agressivas. É, portanto, um espectro bastante amplo.

Como não é difícil perceber, há uma enorme margem de discussão e dúvidas suscitadas pelas normas constitucionais concernentes à atividade nuclear no Brasil. Essas dificuldades surgem em função da organização federativa do Estado brasileiro e de uma normatização da energia nuclear muito imprecisa em nossa Constituição. A própria novidade da matéria enfocada não deixa oportunidade para que se possa recorrer a fontes doutrinárias e/ou jurisprudenciais capazes de apontar uma tradição jurídica plenamente consolidada sobre o tema. Dessa forma, resta fazer uma tentativa de abordagem teórica sobre o assunto, visando extrair da Lei Fundamental e da legislação ordinária um mínimo de coerência e harmonia para que a legislação nuclear possa ser compreendida como uma legislação de tutela do meio ambiente e da saúde pública, e não como uma legislação voltada para a defesa da indústria da energia nuclear, puramente.

A Agência Internacional de Energia vem desenvolvendo intenso trabalho no estímulo à produção do Direito Nuclear, o qual vem incorporando cada vez mais diretrizes de proteção ao meio ambiente em face das radiações ionizantes e dos danos que podem por elas serem causados. O direito nuclear se funda sobre os seguintes princípios:¹ (i) princípio da segurança, (a) das instalações e das pessoas, bens e ambiente, (b) segurança internacional; (ii) princípio da responsabilidade; (iii) princípio da atividade permitida; (iv) princípio do controle contínuo; (v) princípio da compensação; (vi) princípio do desenvolvimento sustentado; (vii) princípio da obediência; (viii) princípio da independência; (ix) princípio da transparência; (x) princípio da cooperação internacional. Muitos dos princípios aqui mencionados foram incorporados ao texto da Constituição Federal de 1988.

Em brevíssima análise topológica dos artigos constitucionais referentes à energia nuclear, é possível se constatar que a matéria diz respeito, simultaneamente, à organização administrativa (artigo 21, XXIII, e artigo 22, XXVI), à organização dos Poderes (artigos 48 e 49, XIV) e à ordem econômica e financeira (artigos 177, V, e 225, § 6º). Vale ressaltar que, no título da Ordem Econômica e Financeira, inclui-se a defesa do meio ambiente (artigo 170, VI).

A energia nuclear, independentemente do juízo de valor que se possa fazer de sua utilização, tem evidentes implicações ambientais. Dessa forma, obviamente, é preciso que se examine a inserção do meio ambiente na Lei Fundamental. Feito isso, será possível chegar-se a um completo quadro legal sobre o tema.

19.1 COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA NUCLEAR

19.1.1 Competências da União

19.1.1.1 Administrativa

Estão no artigo 21, inciso XXIII, da Constituição Federal as primeiras referências constitucionais à energia nuclear. Como se sabe, o artigo 21 da Constituição de 1988 é o que estabelece as *competências da União*. Ao longo das três alíneas do inciso XXIII, o legislador constituinte definiu princípios a serem observados pela Administração Pública quando ela estiver exercitando as suas atribuições relativas à energia nuclear. Determina o artigo 21, inciso XXIII, da Lei Fundamental da República: “*Compete à União: explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, [...]*.” Estabelecidas as competências administrativas, o próprio texto constitucional definiu um rol de princípios a ser obrigatoriamente observado no trato da questão; tais princípios são os seguintes:²

- toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;
- sob o regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas;
- a responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa.

19.1.1.2 Legislativa

Ao estabelecer as competências constitucionais *privativas da União*, a Constituição Federal determinou que nelas se inclui a de legislar sobre atividades nucleares *de qualquer natureza*, contida no artigo 22, inciso XXVI, da Carta Política vigente. Observe-se, entretanto, que o parágrafo único do referido artigo dispõe: “*Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*”

Essas são as repartições básicas da competência federal em matéria de energia nuclear. É desnecessária qualquer análise mais fundamentada acerca das competências e de suas divisões, pois ela já foi feita ao longo deste livro.

19.1.1.2.1 Papel do Congresso Nacional

O Congresso Nacional tem competência exclusiva para *aprovar iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares* (CF, artigo 49, inciso XIV), independentemente de sanção do Chefe do Poder Executivo (CF, artigo 48, *caput*).

19.1.2 As competências dos Estados e dos Municípios em matéria nuclear

A competência estabelecida pelo artigo 21 da Constituição Federal dá à União um amplo campo de atuação em matéria nuclear. Já o artigo 23 da Constituição de 1988, que trata da competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dispõe em seu inciso VI que aos referidos entes políticos compete “*proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas*”. É certo, ainda, que, no campo legislativo, o artigo 24 determina: “*Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição*”. Ademais, o inciso VIII do mesmo artigo constitucional determina que aos mesmos entes políticos cabe a competência legislativa concorrente em matéria relativa a danos ao meio ambiente.

Por derradeiro, registre-se que os quatro parágrafos do artigo 24 determinam que, em se tratando de *legislação* concorrente, a competência da *União limita-se a estabelecer normas gerais*. Ocorre que a competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Na inexistência de lei federal que disponha sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades regionais. Na hipótese de superveniência de lei federal disciplinadora daquilo que deve ser entendido como norma geral em cada uma das hipóteses definidas constitucionalmente, suspender-se-á a eficácia da lei estadual, naquilo que implique violação das normas gerais estabelecidas pelo Poder Legislativo da federação.

Quanto aos municípios, é de se observar que as suas competências constitucionais foram estabelecidas pelo artigo 30 da Lei Fundamental da República. Em assim sendo, aos municípios, por força do artigo 30, VIII, compete: “*promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano*”.

19.1.3 Análise da estrutura de competências

Como já foi dito, é indiscutível a repercussão da utilização da energia nuclear sobre o meio ambiente. Tal repercussão encontra reconhecimento nas próprias normas constitucionais. A questão que se coloca ante o analista é a de saber se é possível aos Estados-Membros e aos Municípios legislar sobre meio ambiente quando se tratar das repercussões ambientais da utilização de material radioativo. É importante observar que, ao se falar em repercussões ambientais da energia nuclear, a situação vem se alterando dramaticamente e, sem dúvida alguma, é crescente o número de cientistas altamente respeitados que entendem que a energia nuclear pode desempenhar relevante papel no combate às mudanças climáticas globais. “*Todas as pesquisas detalhadas concordam, entretanto, que a energia nuclear é uma fonte de baixo carbono e portanto um bom candidato para o novo mix energético. Em especial trata-se de uma das poucas tecnologias que estão prontas para serem utilizadas Não é renovável, já que o minério de urânio tem de ser escavado e um dia vai se esgotar. Mas as reservas atuais devem durar várias décadas, até mesmo se a indústria se expandir significativamente – e desenvolvimento tecnológico na área da reciclagem de combustível nuclear poderiam estender isso a vários milhares de anos. [...] Em parte a hostilidade à energia nuclear é um resquício de projetos antigos que refletiam uma menor consciência quanto à necessidade de segurança e que geravam mais lixo radioativo do que os modelos agora disponíveis.*”³

James Lovelock é bastante categórico ao afirmar: “*Acho que não consideramos a energia nuclear uma fonte boa e confiável de energia porque fomos cruelmente induzidos ao erro por um conjunto de mentiras. O erro foi erguido sobre um erro e repetido pela mídia de forma insensata até que a crença no mal essencial de todas as coisas nucleares se tornou parte de uma resposta instintiva.*”⁴

Deve ser observado que a energia nuclear e os elementos radioativos, de um modo geral, estão tratados nos itens que definem a competência legislativa *privativa* da União (CF, artigo 22, XXVI). Relembre-se que o texto Constitucional fala em “*atividades nucleares de qualquer natureza*”. Parece-me que o inciso diz respeito não só à produção de radiação mas, também, a toda e qualquer repercussão que a “*atividade nuclear*” possa vir a causar nos diversos aspectos da vida humana. É de se verificar que a matéria nuclear é uma exceção dentre os múltiplos aspectos normatizados pelo Direito Ambiental. Com efeito, o ordenamento jurídico peculiar à atividade nuclear e suas repercussões no mundo fático tem merecido tratamento específico e destacado por parte da legislação brasileira que, no particular, não se afasta das principais ordens jurídicas da comunidade internacional.

A norma constitucional que ora está sendo examinada estabelece uma exceção dentre as diversas normas ambientais. Trata-se, repita-se, de uma norma particular que, como tal, sobrepõe-se às gerais. Esse é um princípio tradicional de interpretação das normas de Direito, cuja validade é aceita por todos os juristas que versaram sobre o tema.⁵ Ademais, não se pode deixar de considerar que o objetivo da norma contida no inciso XXVI do artigo 22 da Constituição Federal diz respeito à atividade nuclear-fim, motivo pelo qual as inúmeras atividades-meio que lhe dão suporte devem estar subordinadas ao mesmo poder legiferante. Trata-se de uma conclusão lógica e irrefutável. Veja-se que, na Constituição de 1969 (artigo 8º, XV, *b*, e XVII, *i*), já havia norma semelhante àquelas que hoje se contêm nos artigos 21, inciso XXIII, e 22, inciso XXVI, da Constituição de 1988. Ocorre que o quadro normativo da Constituição de 1988 é muito mais complexo do que aquele existente nas duas Constituições anteriores, devido ao fato de que, diferentemente das cartas anteriores, o poder constituinte democrático exprimiou-se de maneira mais ambígua, em razão do conflito de interesses e do peso das diversas forças políticas que integraram a Assembleia Nacional Constituinte.

Diante das circunstâncias apontadas, como é possível que, constitucionalmente, os Estados-Membros da Federação possam atuar em matéria nuclear? O tema é relevante, pois os Estados dispuseram, amplamente, sobre energia nuclear em suas Constituições.

Sabemos que o objeto do Direito Ambiental é extremamente vasto e que o conceito de meio ambiente é suficientemente largo para que, em seu interior, possam ser incluídas matérias muito distantes umas das outras. A princípio, penso, não se pode confundir energia nuclear ou qualquer outra atividade que implique a utilização de radioisótopos radioativos com meio ambiente. A relação necessária entre o nuclear e o meio ambiente é que o nuclear, potencialmente, pode causar graves danos ambientais, seja no momento da mineração do mineral radioativo, seja no momento da utilização do radioisótopo ou, finalmente, no momento em que se deva dar um destino final aos rejeitos radioativos. Portanto, embora mantenham relações fundamentais, não se pode confundir meio ambiente e nuclear. Evidentemente que, em uma conceituação lata de Direito Ambiental e de proteção da natureza, as atividades nucleares, em geral, estão compreendidas entre aquelas que podem e devem ser normatizadas por regras de Direito Ambiental. Ocorre que, no presente caso, a própria Lei Fundamental da República estabeleceu uma *exceção* definida e precisa. Isto é, a *atividade nuclear* está diretamente ligada ao Poder Federal naquilo que diz respeito à competência legislativa, sendo certo que, na hipótese, trata-se de competência privativa e, portanto, indelegável.

Entretanto, há um elemento complicador que é estabelecido pelo § 6º do artigo 225 da Norma Fundamental. Determina o referido parágrafo: “*as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas*”. Ora, em realidade, o próprio parágrafo reforçou a necessidade de lei federal para a definição de locais para a instalação das usinas que operem com reatores nuclear. Isso se deve ao fato de que a matéria ambiental é de competência da União, dos Estados e dos Municípios. O reconhecimento explícito de que o nuclear tem repercussões ambientais – daí a sua inserção parcial no capítulo constitucional referente ao meio ambiente – implica delegação de determinadas competências, tanto aos Estados quanto aos Municípios; definir os limites de tal competência é que é o problema importante.

A Constituição Federal de 1988 possui elementos capazes de alterar a jurisprudência do STF sobre o assunto? Penso que sim. Em primeiro lugar, deve ser observado que a Constituição de 1988 é muito mais abrangente naquilo que diz respeito à utilização da energia nuclear e às disposições sobre o meio ambiente. Em segundo lugar, ainda que buscando afastar o tema nuclear do tema meio ambiente, estabelecendo a norma *excepcional* quanto à energia nuclear e meio ambiente, a Constituição, em seu artigo 225, § 6º, assume, claramente, a forte vinculação entre ambos. Pelo menos no que diz respeito às instalações nucleares, a Lei Fundamental entende que a matéria é relativa ao meio ambiente.

Observe-se, ainda, que a grande maioria dos Estados fez introduzir em suas Constituições normas que limitam as atividades nucleares. Tais limitações têm por essência a preocupação com a segurança das instalações e com o destino das diversas formas de rejeitos radioativos. Alguns Estados, inclusive, chegaram a determinar uma proibição pura e simples da energia nuclear em seus territórios. Há uma evidente manifestação daquilo que é conhecido no Direito Ambiental como *síndrome de NIMB* (*Not in my backyard*), ou seja, não no meu quintal. Contudo, a realidade é que grande parte da legislação estadual sobre energia nuclear corresponde muito mais a uma tendência antinuclear – seriamente questionada em função do chamado aquecimento global – do que propriamente a uma realidade.⁶

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal⁷ reafirmou a sua jurisprudência, como nos dá mostra a seguinte decisão:

“**ENERGIA NUCLEAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.** É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre atividades relacionadas ao setor nuclear no âmbito regional, por violação da competência da União para legislar sobre atividades nucleares, na qual se inclui a competência para fiscalizar a execução dessas atividades e legislar sobre a referida fiscalização. Ação direta julgada procedente.” (Ministro Joaquim Barbosa)

É importante ressaltar o seguinte trecho do voto do Sr. Ministro Joaquim Barbosa:

“Tem nítido caráter de proteção da comunidade, tanto no que concerne à população como no que tange ao meio ambiente. Trata-se de norma elaborada com o intuito de impedir eventual exercício irregular ou perigoso de atividades nucleares que possam vir a causar danos à sociedade. Noto que houve preocupação do legislador estadual com a realização da pesquisa e outras atividades relacionadas com o setor nuclear no Estado de São Paulo.

Contudo, não obstante a justa preocupação do legislador estadual, o fato é que a Constituição de 1988 determina expressamente, no art. 22, XXVI, que compete privativamente à União legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza.”

No caso concreto, vale ser mencionado que a ADI foi ajuizada pelo Sr. Governador do Estado de São Paulo, o que está a indicar que os Executivos estaduais não têm interesse em aprofundar, no particular, a discussão sobre os limites de sua competência.

19.1.4 Inserção da atividade nuclear na ordem econômica

O artigo 177 da Constituição Federal, integrante do título da Ordem Econômica e Financeira, em seu inciso V, determina que constituem monopólio da União: “a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas *b e c* do inciso XXIII do *caput* do art. 21 desta Constituição Federal”. Dispõe, ainda, o referido artigo em seu § 3º que: “a lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional”.

O texto constitucional é suficientemente claro e, portanto, não demanda qualquer análise mais aprofundada.

19.2 TRATAMENTO DEMOCRÁTICO DO PROBLEMA NUCLEAR NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Penso que os aspectos mais importantes quanto ao tratamento democrático conferido pela Constituição Federal de 1988 ao complexo problema nuclear encontram-se nos artigos 49, XIV, 177, § 2º, e 225, § 6º. Por tais disposições constitucionais, verifica-se que o Congresso Nacional e a lei são os dois pilares fundamentais sobre os quais deve se alicerçar a atividade nuclear no Brasil. Há uma evidentíssima mudança em relação ao sistema anterior. Veja-se que, embora mantendo a competência federal para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, o que a nosso ver está correto, a Lei Fundamental determinou que tal competência é restrita a setores da atividade nuclear e que é o povo que deve definir os rumos de tal legislação.

O artigo 49, XIV, estabelece que compete ao Poder Legislativo *aprovar iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares*, sendo certo que, por força do artigo 48, a aprovação congressual não depende de sanção do Chefe do Executivo. Quais seriam tais iniciativas? Seriam os projetos de lei originados do Executivo? O termo utilizado pela Constituição não é técnico. Aliás, a Constituição não tem obrigação de ser técnica, pois não é feita por técnicos nem para técnicos. Cabe ao jurista buscar o sentido técnico-jurídico dos termos utilizados na Constituição, em harmonia com os princípios fundamentais que dão fisionomia e caráter à Lei Fundamental.

Pelo artigo 84, III, da Constituição Federal, cabe ao Chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo nos casos e na forma previstos na própria Constituição. O inciso III do mesmo artigo atribui ao Presidente da República prerrogativas para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ora, não se pode perder de vista que o artigo 21, inciso XXIII, alínea *a*, determina que “*toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional*”. Ao que nos é dado compreender, a Constituição Federal não autorizou o Presidente da República a expedir decretos e regulamentos em matéria nuclear sem que estes sejam aprovados pelo próprio Congresso; dito de outra maneira, o Presidente pode dispor sobre matéria nuclear, mas, nos estritos termos da Lei Fundamental da República, *as iniciativas do Executivo somente poderão produzir efeitos jurídicos após a aprovação pelo Congresso Nacional*. Trata-se de uma restrição imposta pelo Constituinte ao Executivo. Para nós, trata-se de uma situação peculiar, porém real: o Congresso aprova uma lei, sem sanção presidencial, e o Presidente a regulamenta; tal regulamento, contudo, só entra em vigor após a aprovação pelo próprio Congresso. É um duplo controle exercido pelo Legislativo sobre o Executivo: inicial e final.

O parágrafo único do artigo 22 admite: “*lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo*”. É preciso que se harmonize a competência da União definida no artigo 21 com aquela prevista no artigo 22. Tal harmonização só pode ser analisada à luz daquilo que dispõe o artigo 49, XIV, da Constituição. As “*questões específicas*” tratadas no parágrafo se referem a incisos que não encontrem, em outros locais da Lei Fundamental da República, obstáculos à delegação. Ora, em sendo competência exclusiva do Congresso Nacional *aprovar iniciativas do Poder Executivo relativas a atividades nucleares*, essa competência não pode ser delegada, por força do § 1º do artigo 68. A matéria nuclear é indelegável, por via de lei complementar, para os Estados. Em verdade, o inciso XXVI do artigo 22 da Constituição de 1988 cuida de competência exclusiva e não privativa.

19.3 O BRASIL NA COMUNIDADE NUCLEAR INTERNACIONAL

O Brasil, como país-membro da comunidade internacional, participa de diversos acordos multilaterais sobre energia nuclear, sendo que diversos foram ratificados. Os documentos internacionais de que o Brasil é signatário são os seguintes:

- Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica, ratificado aos 25 de julho de 1957;
- Emenda aos artigos VI (13/10/1971), VI A I (19/2/1985 aceitação) e VI A 3 (13/2/1985) da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA);
- Tratado para a proscrição das armas nucleares na América Latina e no Caribe – Tratado de Tlateloco (29/1/1968);
- Tratado para a proscrição das experiências com armas nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e sob a água (4/3/1965);
- Tratado sobre a proibição da colocação de armas nucleares e outras armas de destruição em massa do leito do mar, no fundo do oceano e em seu subsolo (15/3/1988);
- Convenção sobre a proteção física de materiais nucleares (17/10/1985);
- Convenção sobre a pronta notificação de acidente nuclear (5/12/1990);
- Convenção sobre assistência no caso de acidente nuclear ou emergência radiológica (5/12/1990).

§ 2º OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR

A utilização da energia nuclear para fins pacíficos não aconteceu de forma simples, sobretudo devido ao fato de a utilização militar das fontes nucleares ter tido

uma enorme repercussão negativa em todo o ciclo nuclear e que perdura até os dias de hoje.

A energia nuclear é responsável pela geração de cerca de 14% da energia elétrica no mundo, Os Estados Unidos possuem 104 usinas em operação e estão promovendo a ampliação de sua capacidade de geração. A França, possuindo 58 reatores, e Japão, com 50, também são grandes produtores de energia nuclear, seguidos por Rússia (33) e Coreia do Sul (21).⁸

19.4 ACIDENTES NUCLEARES NA UTILIZAÇÃO PACÍFICA DA ENERGIA NUCLEAR

19.4.1 Three Mile Island

O “acidente” nuclear de *Three Mile Island* foi o maior acidente nuclear em instalações civis e não submetidas ao regime de segredo até os acontecimentos de Chernobyl e Fukushima. Aos 28 de março de 1979, registrou-se o vazamento em uma das válvulas do sistema de resfriamento do reator nº 2 da central nuclear de *Three Mile Island*, localizada no Estado da Pensilvânia, EUA. O acidente obrigou a evacuação de 3.170 famílias da região e acarretou a perda do emprego de 636 pessoas. Foi paga uma indenização de 33 milhões de dólares àqueles que foram prejudicados pelo vazamento. Na ocasião do vazamento, não se registraram vítimas fatais.⁹

19.4.2 Chernobyl

A central nuclear de Chernobyl foi a causadora do acidente nuclear mais grave jamais verificado na história humana. O volume total dos custos financeiros decorrentes do acidente ainda não pode ser completamente contabilizado. O número total de vítimas, igualmente, ainda não pode ser avaliado.¹⁰ A 25 de abril de 1986, incendiou-se o reator nº 4 da central nuclear. O incêndio foi devido ao resultado negativo de uma experiência que estava sendo realizada.

O número inicial de mortos foi de 32, sendo certo que o número de pessoas hospitalizadas chegou a 299. Inicialmente, foram evacuadas 12.000 pessoas. Um total de 20.000 pessoas foi submetido a processos de descontaminação. Os resultados se espalharam pelo mundo inteiro.¹¹

19.4.3 Goiânia

O Brasil, lamentavelmente, ocupa um lugar de destaque na *ranking* internacional dos acidentes nucleares. Em Goiânia, no ano de 1987, ocorreu um acidente cujas consequências negativas somente foram superadas pelas decorrentes do acidente de Chernobyl e Fukushima. Os fatos relacionados ao acidente demonstram uma triste realidade de pobreza, descumprimento da lei, irresponsabilidade e ignorância, que foram absolutamente essenciais para que o acidente com a cápsula de Césio 137 tivesse as consequências que, efetivamente, teve.

Um grupo de apanhadores de lixo encontrou um objeto metálico em um depósito de lixo e resolveu abri-lo para verificar o que havia dentro dele. Foi encontrada uma estranha pedra azul brilhante que encantou os seus desafortunados descobridores.

A referida pedra era o mineral radioativo Césio 137. Além da pedra, havia um pó azul que foi espalhado pelos três apanhadores de papel em seus corpos. A pedra e o pó foram retirados do local e exibidos pelos seus descobridores a diversos amigos e vizinhos.

Em poucos dias, os três homens estavam mortos. A causa foi uma aguda intoxicação nuclear. Também, em poucos dias, algumas partes da cidade de Goiânia foram fortemente contaminadas. O número de vítimas do acidente nuclear foi extremamente alto. A Comissão Nacional de Energia Nuclear fez monitoramento em aproximadamente 112 mil pessoas, tendo encontrado 249 contaminadas. A experiência com outros acidentes nucleares demonstra que não se pode ter certeza de que o número de vítimas permanecerá aquele atualmente conhecido.

Até o ano de 1995, as vítimas do acidente ainda não tinham sido indenizadas e algumas ações judiciais arrastam-se sem que cheguem a qualquer solução, apesar do clamor público gerado pelos acontecimentos. No campo penal, houve a condenação por homicídio culposos dos donos da clínica que, criminosamente, deixaram abandonado o aparelho que utilizava o césio 137. A pena aplicada pela Justiça foi de três anos de detenção, passível de conversão em prestação de serviços à comunidade. A pena foi rigorosa, dentro da fragilidade da legislação vigente.¹² A condenação, no entanto, somente ocorreu em 1992.¹³ As apelações¹⁴ interpostas pelos réus, fatalmente, acarretaram a prescrição, em concreto, do direito de punir os criminosos.

Penso que a decisão criminal de Goiânia nos traz alguns importantes pontos para reflexão. O primeiro deles é aquele que diz respeito à total insuficiência da legislação penal ordinária como instrumento de repressão a delitos produzidos com material radiativo. A lesão causada foi imensa e a lei tratou-a como se fosse um simples homicídio culposos.¹⁵

19.5 FUKUSHIMA¹⁶

Aos 11 de março de 2011, houve um grande terremoto acompanhado de tsunami no Japão, os quais alcançaram 9,0 na escala Richter em profundidade de aproximadamente 25 quilômetros. Tal terremoto obrigou ao imediato fechamento de 11 reatores nucleares japoneses (Onagawa 1, 2 e 3; Fukushima Dai-ichi 1, 2 e 3; Fukushima Dai-ni 1, 2, 3 e 4; e Tokai 2). O tsunami gerou ondas de mais de 14 metros de altura na planta nuclear de Dai-ichi. O terremoto e o tsunami produziram devastação que se espalhou pelo nordeste japonês, resultando em aproximadamente 25.000 pessoas mortas ou desaparecidas, desalojando dezenas de milhares de pessoas, e impactou significativamente na infraestrutura e a indústria costeiras do Japão.¹⁷

19.5.1 Jurisprudência

O acidente com o césio 137 gerou enorme debate judicial e uma farta jurisprudência sobre o tema.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIA RADIOATIVA (CÉSIO 137) – LEGITIMIDADE DA UNIÃO – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – REALIZAÇÃO POR PERITO JUDICIAL – INVALIDADE. 1. A União é parte passiva legítima na demanda que objetiva a construção de depósito de substância radioativa (césio 137) em vista da atribuição que lhe foi outorgada pelo artigo 21, inciso XXIII, da Constituição Federal, para ‘explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza’. Precedente. 2. O relatório de impacto ambiental – RIMA – configura indiscutível trabalho técnico atribuído à Administração. Por isso, não pode o julgador determinar sua realização por perito, mesmo porque não configura prova que deva ser produzida para instrução da causa, mas documento de interesse da lide que deve ser elaborado por quem legitimamente investido da atribuição (órgão municipal, estadual ou federal). 3. Agravo provido.”¹⁸

“CONSTITUCIONAL¹⁹ E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ACIDENTE RADIOLÓGICO EM GOIÂNIA COM BOMBA DE CÉSIO 137. DANO AMBIENTAL E PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PODER DE POLÍCIA, FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM APARELHOS RADIOATIVOS. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. ABANDONO DE MATERIAL RADIOATIVO POR PROPRIETÁRIO DA CLÍNICA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS), OBRIGAÇÃO DE DAR (PAGAMENTO AO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS). 1. Embora o acidente com os radioisótopos de utilização médica tenham sido expressamente excluídos da disciplina da Lei 6.453/77, que dispõe sobre a responsabilidade civil sobre danos nucleares, o dano ambiental por ser de ordem pública é indisponível e insuscetível de prescrição enquanto seus efeitos nefastos continuam a produzir lesão. 2. A configuração do dano ambiental causado pelo maior acidente radiológico do mundo com a destruição da bomba de césio 137, na cidade de Goiânia, no ano de 1987, é fato público e notório e também fartamente documentado nos autos. 3. O direito à reparação

do dano (actio nata) não surge em o acidente, mas com a lesão por ele causada, isto é, com o conhecimento pela vítima da lesão sofrida. Se após o dano ambiental inicial decorrente do acidente radiológico com a bomba de césio 137, anos depois, o efeito do dano ambiental continua provocando lesão nas vítimas e fazendo novas vítimas, não há se falar em prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. 4. A pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica. A responsabilidade pela reparação do dano é atribuível a quem explora a atividade que teria dado ensejo ao acidente. Se o dano é resultante de ato ilícito, todos os que concorrem para o resultado são responsáveis na reparação dos efeitos lesivos. 5. O acidente radiológico com o césio 137, em setembro de 1987 na cidade de Goiânia, insere-se no conceito legal de dano ambiental, eis que implicou em lançar na atmosfera e no solo substância química desencadeadora de processo de radiação que atingiu pessoas e animais. 6. O acidente radiológico gerou a contaminação de vários locais naquela cidade e ocasionou a coleta de quatorze toneladas de material radioativo. O desastre ambiental produziu dano no passado, está a produzi-los no presente e poderá continuar a produzi-los no futuro, pois diversas consequências físicas poderão atingir pessoas que tiveram contato com a radiação ou que a recebeu indiretamente pela ascensão à atmosfera de átomos que se desintegraram no ar. 7. O dano ambiental decorrente da exposição radiológica provocou danos físicos que causaram a morte de quatro pessoas e atingiu, direta ou indiretamente, outras centenas, das quais foram assim distribuídas: a) Grupo I – 57 pessoas envolvidas diretamente no acidente, com maior grau de contaminação interna e externa, com queimaduras na pele e radiodermites; Grupo II – 50 pessoas também contaminadas, porém sem queimaduras de pele ou radiodermites; e Grupo III – outras 514 pessoas acompanhadas anualmente com dosimetria baixa ou não detectada (familiares das vítimas dos Grupos I e II, profissionais que trabalharam no acidente e funcionários da Vigilância Sanitária Estadual). 8. O césio não é substância nuclear e sim um radioisótopo e, em consequência, o acidente ocorrido em Goiânia não foi um acidente nuclear, mas radiológico em proporção gigantesca. 9. Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade de degradação ambiental (art. 3º, IV da Lei 6.938/81). 10. A identificação do nexa causal requer que se verifique em cada caso concreto quem ou o que é a causa imediata ou mediata do dano e que teve condições de impedi-lo para que o resultado não ocorresse. 11. Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade é subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três modalidades – negligência, imperícia e imprudência, não sendo necessário individualizá-la, dada que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 12. A falta do serviço (faute du service) não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer o nexa de causalidade entre a omissão atribuída ao Poder Público e o dano causado. 13. Não é da competência da União manter a fiscalização das clínicas radiológicas, sendo parte ilegítima ad causam. 14. O Decreto nº 77.052, de 19.01.76, dispõe sobre a fiscalização sanitária e seu art. 1º estabelece que a verificação das condições de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde compete às Secretarias de Saúde dos Estados (adequação das condições do ambiente, o estado de funcionamento de equipamentos e aparelhos e meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos circunstantes). 15. Compete à Secretaria de Saúde dos Estados a fiscalização de serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raio X, substâncias radioativas ou radiações ionizantes. 16. Constitui infração sanitária a utilização de serviço que utilizem aparelhos de raio X e outras substâncias radioativas fora dos parâmetros legais (art. 10, inciso III, do Decreto 77.052/76). Constatada a infração sanitária praticado pelo Instituto Goiano de Radiologia (IGR), deveria a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás comunicar o fato à autoridade policial. 17. Agiu com negligência a autoridade sanitária estadual que não fiscalizou o IGR nos termos do decreto regulamentar e da Lei 6.437/77 (art. 10). O caso sub iudice não diz respeito ao monopólio de comércio radioisótopos artificiais e substâncias radioativas, mas de uso indevido (abandono) de um aparelho radiológico em local de acesso a transeuntes. 18. É dever do Estado de Goiás prestar assistência médica especializada às vítimas da radiação do césio 137, vez que os problemas de saúde a elas cometidos são graves e sinistros exigindo atendimento especial. 19. Se uma ou mais pessoas concorreram culposamente para que se produzisse o resultado, respondem solidariamente pelos danos. E responsabilidade solidária, significa que todos são responsáveis pela dívida, conforme se encontra expresso no parágrafo único do art. 896 do Código Civil. A sentença atenta ao fato ao dispor que ‘a imputação da responsabilidade aos figurantes do polo passivo deu-se na forma solidária (CC art. 1.518)’. 20. Como consequência na natureza solidária das atribuições resultantes do ato ilícito é possível a atribuição ao Estado de Goiás prestar assistência médica às suas vítimas e: (a) fazer atendimento especial médico-hospitalar, técnico-científico, odontológico, psicológico às vítimas diretas e indiretas, reconhecidamente atingidas, até a 3ª geração, como estava sendo feito pela extinta Fundação Leide Neves; (b) fazer o transporte das vítimas em estado mais grave (do Grupo I) para realização dos exames, caso necessário, em ambulâncias; (c) prosseguir o acompanhamento médico da população de Abadia de Goiás – GO, vizinha ao depósito de rejeitos radioativos, bem como prestar eventual atendimento médico, em caso de contaminação; (d) efetivar sistema de notificação epidemiológica sobre câncer; (e) fazer o trabalho de monitoramento epidemiológico na população de Goiânia; (f) manter na cidade de Goiânia centro de atendimento específico para as vítimas do césio 137, com médicos especializados como era feito pela extinta FUNLEIDE; (g) desenvolver um programa de saúde especial para crianças vítimas diretas ou indiretas da radiação. 21. A competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, nos termos do art. 2º da Lei 6.189/74, vigente à época dos fatos, era fiscalizar o reconhecimento e o levantamento geológico de minerais nucleares; a pesquisa; a lavra e a industrialização de minérios nucleares; a produção e o comércio de materiais; a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento nuclear. A CNEN não possui atribuição legal de fiscalizar a utilização de aparelhos de radioisótopos artificiais ou de hospitais que utilizem substâncias radioativas. 22. Segundo legislação vigente ao tempo do acidente com a bomba de césio 137, a competência da CNEN era circunscrita a expedir normas referentes ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos (art. 2º da Lei 6.189/74). Os rejeitos radioativos precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente, se for o caso. O acidente de Goiânia envolveu uma contaminação radioativa, isto é, a existência de material radioativo onde não deveria estar presente. 23. Compete à CNEN expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativos ao tratamento e a eliminação de rejeitos radioativos e não há demonstração de que a autarquia tenha feito o trabalho de esclarecimento necessário. 24. Não se houve a CNEN com a diligência necessária após o acidente no sentido de prevenir e esclarecer aos bombeiros que fizeram a limpeza do local que deveriam usar roupas apropriadas. 25. O IPASGO, mesmo não sendo o responsável pelo abandono da bomba de césio em seu imóvel, tinha o dever de zelar para que ele não desse causa a transtornos a saúde e segurança da vizinhança (art. 554 do CC). O art. 1.528 do CC também estabelece a responsabilidade do dano pelos danos decorrentes da ruína do imóvel. Ainda que não tenha sido o IPASGO quem demoliu o prédio, ao tornar-se seu proprietário e possuidor, deveria cuidar de repará-lo, pois o alojamento da substância radiológica assim o exigia. 26. Amaurillo Monteiro de Oliveira, ex-sócio do IGR, agiu com imprudência ao demolir parte do imóvel e nele deixar abandonada a bomba de césio 137 que foi objeto de subtração e depois destruída a marteladas, dando início ao desastre. 27. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida para declarar a legitimidade passiva ad causam dos médicos Carlos de Figueiredo Bezerril e Criseide Castro Dourado e condenar os réus ao pagamento individual de R\$ 100.000,00 em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e para condenar o Estado de Goiás ao pagamento de R\$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e as seguintes obrigações de fazer: (a) fazer atendimento especial médico-hospitalar, técnico-científico, odontológico, psicológico às vítimas diretas e indiretas, reconhecidamente atingidas, até a 3ª geração, como estava sendo feita pela extinta Fundação Leide Neves; (b) fazer o transporte das vítimas em estado mais grave (do Grupo I) para realização dos exames, caso necessário, em ambulâncias; (c) prosseguir o acompanhamento médico da população de Abadia de Goiás – GO, vizinha ao depósito de rejeitos radioativos, bem como prestar eventual atendimento médico, em caso de contaminação; (d) efetivar sistema de notificação epidemiológica sobre câncer; (e) fazer o trabalho de monitoramento epidemiológico na população de Goiânia; (f) manter na cidade de Goiânia centro de atendimento específico para as vítimas do césio 137, com médicos especializados como era feito pela extinta FUNLEIDE; (g) desenvolver um programa de saúde especial para crianças vítimas diretas ou indiretas da radiação. 28. Apelação da CNEN parcialmente provida para diminuir para R\$ 100.000,00 a condenação ao pagamento ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e isentá-la da obrigação de prestar assistência médico-hospitalar e epidemiológica da competência do Estado de Goiás. 29. Apelação do médico Amaurillo Monteiro de Oliveira improvida. Mantida a sentença que o condenou ao pagamento de R\$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 30. Apelação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás improvida. Mantida a sentença que condenou o IPASGO ao pagamento de R\$ 100.000,00 ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 31. Remessa oficial prejudicada.”

19.6 OS REJEITOS NUCLEARES: BREVE DEFINIÇÃO

Rejeito nuclear ou lixo nuclear é todo material contaminado cuja produção seja resultado da atividade desenvolvida em uma instalação nuclear. Atualmente, o rejeito produzido pelos reatores nucleares em atividade em todo o mundo é equivalente a algumas centenas de toneladas e cresce constantemente, sendo o seu armazenamento e descarte extremamente problemáticos. Os rejeitos nucleares podem se revestir de várias formas e cada uma delas possui características bastante diversas das demais modalidades. Os rejeitos radioativos podem ser classificados como de:

- baixa;
- média; ou
- alta radioatividade.

No Brasil, atualmente, somente a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto produz rejeitos de alta radioatividade, a matéria está regulada pela Lei nº 10.308/2001.

19.7 ALGUNS ASPECTOS INTERNACIONAIS DO PROBLEMA

Quaisquer que sejam os argumentos em favor da utilização da energia nuclear, nenhum deles consegue apresentar uma solução adequada para o descarte definitivo dos rejeitos nucleares de alta radioatividade. Anualmente, toneladas de rejeitos radioativos são estocadas no mundo inteiro e, enquanto isso, ainda não se logrou chegar a uma conclusão definitiva sobre o destino que deve ser dado a essas verdadeiras montanhas de lixo letal. Com efeito, o nível atual de conhecimento científico demonstra que somente o processo natural de desintegração é capaz de destruir os materiais radioativos. Isso implica que, em nível da melhor tecnologia disponível, não há nada a fazer que não seja esperar pacientemente pela perda de letalidade dos materiais radioativos.

A incerteza é a única certeza em matéria de radioatividade e de seus efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Como afirma Nicholas Lensen,²⁰ “*até hoje não se sabe ao certo quais são os efeitos da radiação*”. Ante uma realidade extremamente complexa que é o manejo do lixo radioativo, os diversos países têm encontrado inúmeras dificuldades para conseguir localizar os rejeitos nucleares de forma segura. As dificuldades são de natureza técnica e política. As dificuldades técnicas derivam das condições científicas que foram genericamente mencionadas; as dificuldades políticas derivam do fato de que nenhuma comunidade deseja ter o depósito de rejeitos nucleares em seu território.²¹

A solução que tem sido adotada pela maioria dos países para o grave problema do lixo atômico é o enterramento do material em aterros especificamente preparados. Entretanto, mesmo essa solução não tem conseguido obter consenso público e social ou facilidade na sua implementação. O consagrado físico Anselmo Paschoa entende que a melhor solução para o problema talvez seja o depósito no subsolo submarino, nas planícies abissais.²²

Os EUA, que, inicialmente, pretendiam ter obtido uma solução definitiva para o problema em 1985, não conseguiram realizar o seu intento e, no momento, a solução está prevista para ser implementada somente em 2010.²³ Na Alemanha, ocorreu o mesmo retardamento, a previsão atual é que o depósito somente estará pronto no ano 2020.

Na Inglaterra, foi construída uma central para reprocessamento de rejeitos de baixa e média radioatividade na cidade de *Sellafield*.²⁴ Esse mencionado depósito tem causado bastante controvérsia, pois, recentemente, foi descoberto que um relatório elaborado para o Ministério do Meio Ambiente constataria a existência de perigo de explosões subterrâneas em decorrência do acúmulo de gases no depósito. As explosões poderiam vir a romper as proteções blindadas do depósito.²⁵

Os custos econômicos envolvidos na construção dos aterros para os rejeitos nucleares atingem valores que são realmente extraordinários. Estima-se que o custo para a construção de um único local capaz de armazenar 96.000 toneladas de combustível irradiado e os rejeitos de alto nível de radioatividade seja de 36 bilhões de dólares americanos.²⁶ Como se vê, a energia nuclear representa uma quantidade de investimentos que quase sempre precisam ser reavaliados. Para começar ou para encerrar a atividade nuclear gastam-se milhares de milhões de dólares.

19.8 O PROBLEMA NO BRASIL

Como já tivemos oportunidade de ver, no Brasil inexistente legislação federal capaz de fornecer diretrizes para solucionar os graves problemas ocasionados pela destinação final dos rejeitos nucleares. Mais uma vez, não se trata de uma particularidade brasileira, pois no mundo inteiro a questão tem se caracterizado pela inércia e pela desconfiança generalizadas.

A energia nuclear, independentemente do juízo de valor que dela se faça, traz consigo um inequívoco problema, que é o gerado pelo rejeito radioativo que se alastra diariamente em grande proporção. Esse é um problema que acompanha todos os equipamentos que utilizam a radiação ionizante em qualquer de suas formas conhecidas até hoje.

Os problemas mais significativos existentes no Brasil referentes aos rejeitos radioativos são aqueles causados pelo Césio 137, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás; pelos rejeitos da usina nuclear de Angra dos Reis e por mineradoras que trabalham com material radioativo na extração mineral e, simplesmente, deixam o rejeito decorrente de sua atividade para que a sociedade e o Poder Público o tratem.²⁷

19.8.1 O Césio 137

O rejeito nuclear não pode ser examinado apenas naquilo que tange às instalações nucleares; o problema é muito mais grave. Fato é que existem centenas, senão milhares, de equipamentos que utilizam material radioativo em nosso país e não há uma lei federal regulamentando a disposição final desses rejeitos.

O acidente com o Césio 137, que é o maior acidente nuclear brasileiro, muito embora não tenha sido causado por uma instalação nuclear, é um caso exemplar. Mais uma vez, pode ser citado o caso do rejeito radioativo resultante do acidente com o Césio 137 que, até hoje, continua “*guardado*” em tonéis, de segurança discutível.

A lentidão administrativa para a solução do gravíssimo problema do rejeito nuclear é absolutamente espantosa. Vejamos as repercussões do acidente com o Césio 137, ocorrido em Goiânia, no ano de 1987, nas atitudes da Administração Pública. No ano de 1987, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional mensagem contendo projeto de lei sobre depósito intermediário de rejeitos radioativos. Aos 19 de novembro de 1987, foi aprovada a urgência para a tramitação de tal mensagem. A urgência foi retirada aos 16 de maio de 1990.²⁸ Em abril de 1992, foi anunciada a abertura de uma concorrência para a realização do Estudo de Impacto Ambiental que deveria anteceder à construção do depósito definitivo do lixo nuclear resultante do acidente acontecido em Goiânia.

O depósito foi previsto para armazenar cinco mil toneladas de rejeito radioativo e somente ficou pronto em 1994, isto é, sete anos após o acidente.²⁹

19.8.2 Destinação final de rejeitos radioativos

A importante questão da destinação final dos rejeitos radioativos, como foi demonstrado nas edições anteriores do presente trabalho, passou muitos anos sem que qualquer medida legislativa fosse adotada para enfrentá-la. Finalmente, o Congresso Nacional saiu de sua inércia e aprovou a Lei nº 10.308, de 20 de novembro de 2001, que “*dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências*”. É desnecessário dizer que se trata de uma lei de importância extraordinária que,

até aqui, ainda não foi regulamentada. Esse fato, como se sabe, impede a aplicação concreta da norma legal que ora se pretende examinar.

O objetivo da lei é estabelecer normas para o destino final dos rejeitos radioativos produzidos no território nacional, bem para a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos radioativos. Ou seja, buscou-se cobrir todo o espectro do problema. Conforme foi definido pelo parágrafo único do artigo 1º da lei em questão, a nomenclatura a ser adotada para a implementação da norma legal é aquela estabelecida nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

19.8.2.1 Responsabilidade pelos rejeitos radioativos

Conforme definido pelo artigo 2º da Lei nº 10.308/2001, compete à União, com base nos artigos 21, inciso XXIII, e 22, inciso XXVI, da Constituição Federal, por meio da CNEN, no exercício das competências que lhe são atribuídas pela Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974, modificada pela Lei nº 7.781, de 27 de junho de 1989, a responsabilidade pelo destino final dos rejeitos radioativos produzidos em território nacional.

19.8.2.2 Tipos de depósitos de rejeitos radioativos

O artigo 3º da lei admite a instalação e a operação dos seguintes tipos de depósitos de rejeitos radioativos: I – depósitos iniciais; II – depósitos intermediários; III – depósitos finais.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN tem o dever legal de estabelecer normas para a construção, licenciamento, administração e procedimentos diversos dos depósitos iniciais, intermediários e finais, vedado o recebimento nos depósitos finais de rejeitos radioativos na forma líquida ou gasosa. É admissível que os depósitos iniciais utilizados para o armazenamento de rejeitos nas instalações de extração ou de beneficiamento de minério sejam convertidos em depósitos finais, mediante expressa autorização da CNEN. Nas hipóteses de ocorrência de acidentes radiológicos ou nucleares, excepcionalmente poderão ser construídos depósitos provisórios, que serão desativados, com a transferência total dos rejeitos para depósito intermediário ou depósito final, segundo critérios, procedimentos e normas especialmente estabelecidos pela CNEN.

19.8.2.2.1 Seleção de locais para depósitos de rejeitos radioativos

A seleção de locais para depósitos iniciais deve ser feita dentro de critérios estabelecidos pela CNEN para a localização das atividades produtoras de rejeitos radioativos. Tal seleção de locais para instalação de depósitos intermediários e finais deve obedecer a critérios, procedimentos e normas estabelecidos pela CNEN. Os terrenos escolhidos como adequados para depósitos finais deverão ser declarados de utilidade pública e desapropriados pela União, quando já não forem de sua propriedade. Não se admite o depósito de rejeitos de quaisquer naturezas nas ilhas oceânicas, na plataforma continental e nas águas territoriais brasileiras.

O operador das instalações nas quais são gerados os rejeitos deve responsabilizar-se pelo projeto, construção e instalações dos depósitos iniciais de rejeitos radioativos. Quanto aos depósitos intermediários e finais, o seu projeto, construção e instalação são da responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

19.8.2.2.2 Licenciamento e fiscalização dos depósitos

Cabe à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN a responsabilidade pelo licenciamento de depósitos iniciais, intermediários e finais de rejeitos nucleares. Especialmente quanto aos aspectos referentes ao transporte, manuseio e armazenamento de rejeitos radioativos e à segurança e proteção radiológica das instalações, sem prejuízo da licença ambiental e das demais licenças legalmente exigíveis, a fiscalização dos depósitos iniciais, intermediários e finais será exercida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, no campo de sua competência específica, sem prejuízo do exercício por outros órgãos de atividade de fiscalização prevista em lei.

19.8.2.2.3 Administração e operação dos depósitos

O titular da autorização para operar a atividade geradora dos rejeitos é o responsável pela administração e operação de depósitos iniciais, competindo à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN a administração e a operação de depósitos intermediários e finais.

19.8.2.2.4 Depósitos provisórios

Quando ocorrerem acidentes nucleares ou radiológicos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, a seu exclusivo critério, considerada a emergência enfrentada, poderá determinar a construção de depósitos provisórios para o armazenamento dos rejeitos radioativos resultantes, sendo da sua exclusiva responsabilidade a seleção do local, o projeto, a construção, a operação e a administração dos depósitos provisórios, ainda que executados por terceiros devidamente autorizados. A fiscalização de tais depósitos é exercida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, no campo de sua competência específica, sem prejuízo do exercício por outros órgãos de atividade de fiscalização prevista em lei. Todos os custos relativos aos depósitos provisórios, inclusive os de remoção de rejeitos e descomissionamento, são de responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. No que tange à segurança “física” dos mencionados depósitos, esta fica à guarda das autoridades estaduais, cabendo, no entanto, a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos nos depósitos provisórios ou durante o transporte do local do acidente para o depósito provisório e deste para o depósito à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

19.8.2.2.5 Remoção dos rejeitos

A remoção de rejeitos de depósitos iniciais para depósitos intermediários ou de depósitos iniciais para depósitos finais é da responsabilidade do titular da autorização para operação da instalação geradora dos rejeitos, que arcará com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da atividade. Tais remoções somente podem ser feitas com prévia autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Compete ao titular da autorização para a operação da instalação geradora de rejeitos arcar integralmente com os custos relativos à seleção de locais, projeto, construção, instalação, licenciamento, administração, operação e segurança física dos depósitos iniciais. À Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN compete arcar com os custos relativos à seleção de locais, projeto, construção, instalação, licenciamento, administração, operação e segurança física dos depósitos intermediários e finais.

19.8.2.3 Responsabilidade civil

Em se tratando de depósitos iniciais, a responsabilidade por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos neles depositados, independentemente de culpa ou dolo, é do titular da autorização para operação da instalação; já nos depósitos intermediários e finais, a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos neles depositados, independentemente de culpa ou dolo, é da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Quando se tratar do transporte de rejeitos dos depósitos iniciais para os depósitos intermediários ou de depósitos iniciais para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos é do titular da autorização para operação da instalação que contém o depósito inicial. Já no transporte de rejeitos dos depósitos intermediários para os depósitos finais, a responsabilidade civil por danos

radiológicos pessoais, patrimoniais e ambientais causados por rejeitos radioativos é da CNEN. Ainda que exista a possibilidade de delegação, a terceiros, da atividade de transporte do material dos depósitos intermediários para os depósitos finais, a responsabilidade civil remanesce afetada à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Somente mediante a prestação de garantias, previstas no artigo 13 da Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 1977,³⁰ serão concedidas autorizações para a operação de depósitos iniciais, intermediários ou finais. O titular da autorização para a operação da instalação, quando se tratar de operação ou descomissionamento de depósitos iniciais e de intermediários ou finais, na hipótese de estarem sendo operados por terceiros, deverá apresentar garantia suficiente para fazer frente às indenizações por danos radiológicos causados por rejeitos radioativos. Na forma do artigo 25, “*nos depósitos intermediários e finais, caso sejam operados por terceiros, consoante o art. 13 desta Lei, o prestador de serviços deverá oferecer garantia para cobrir as indenizações por danos radiológicos*”.

Os direitos eventualmente existentes sobre os rejeitos radiativos são transferidos para a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, mediante a sua simples entrega para armazenamento nos depósitos intermediários ou finais.

§ 4º RESPONSABILIDADE CRIMINAL EM MATÉRIA NUCLEAR

19.9 A RESPONSABILIDADE CRIMINAL EM MATÉRIA NUCLEAR

A responsabilidade criminal em matéria nuclear está prevista na Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 1977, embora a lei não esgote todas as hipóteses de crimes que possam ser praticados com a utilização de material nuclear ou relacionados com a atividade nuclear em todas as suas múltiplas possibilidades. O potencial de agressão dos delitos nucleares é imenso e, no entanto, eles não mereceram até hoje uma legislação que não diga respeito, apenas, às instalações nucleares. O que acontece é que crimes de imensas repercussões sociais são punidos pela legislação penal comum que, como se sabe, não é vocacionada para a delinquência tecnológica. No Brasil, infelizmente, existe um exemplo claro dessa situação que nos é dado pelo processo criminal contra os causadores da catástrofe de Goiânia, afinal condenados por homicídio culposo (art. 101, § 3º, do Código Penal).

19.9.1 Os crimes previstos na Lei nº 6.453/77

Os *crimes nucleares* estão relacionados nos artigos 20/27 da Lei nº 6.453/77, sendo que o artigo 19 limita-se a fazer uma exposição genérica dos preceitos nos quais estão previstos os crimes cometidos na exploração e utilização da energia nuclear.

A primeira constatação a ser feita é que, ao longo dos artigos 20/27, encontra-se, apenas, um crime de exposição da vida, da saúde e do patrimônio a perigo causado pela não observação de regras de segurança ou proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material nuclear, que é o descrito no artigo 26.

O dano propriamente dito não foi objeto de tutela específica, pois a lei optou por permanecer no mero perigo. Qualquer ato ou omissão que implique dano efetivo causado contra a pessoa humana, contra a vida humana, contra a saúde pública, contra o meio ambiente, ou mesmo contra o patrimônio público ou privado, deverá ser punido pela legislação penal comum. Tanto o Código Penal como a legislação extravagante poderão vir a ser utilizados, conforme o caso concreto.

19.9.1.1 Os tipos legais previstos na Lei nº 6.453/77

Os crimes previstos na lei de responsabilidade pela utilização de energia nuclear dizem respeito, muito mais, a atos praticados contra as instalações nucleares ou contra a Administração Pública, pela inobservância de normas técnicas, do que a atos ilícitos praticados durante a operação da instalação nuclear e que possam ter atingido a vida humana ou o patrimônio dos indivíduos, ou mesmo o meio ambiente.

O artigo 19 é bem demonstrativo da filosofia adotada pela lei em tela, *in verbis*:

Constituem crimes na exploração e utilização da energia nuclear os descritos neste capítulo, além dos tipificados na legislação de segurança nacional [...]

a) Artigo 20. Produzir, processar, fornecer ou usar material nuclear sem a necessária autorização ou para fim diverso do permitido em lei: Pena: reclusão, de quatro a dez anos.

O crime é praticado por qualquer pessoa física ou jurídica que se destine a produzir, processar, fornecer ou usar material nuclear sem a autorização do Poder Público. O objeto jurídico tutelado é o poder de polícia da Administração Pública. A utilização de material nuclear, a sua produção, processamento e comércio somente podem ser feitos mediante autorização específica de órgão do Poder Público, no caso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. A autorização vencida é equiparável à autorização inexistente.

b) Artigo 21. Permitir o responsável pela instalação nuclear sua operação sem a necessária autorização. Pena: reclusão, de dois a seis anos.

É a primeira vez que a lei utiliza o termo *responsável* e não o termo *operador*. Parece-me que a norma se destina à direção da empresa ou instituição operadora da instalação nuclear. O *operador* da instalação nuclear, nos termos da lei, é sempre a “pessoa jurídica devidamente autorizada para operar instalação nuclear”. Trata-se de uma responsabilidade pessoal.

O objeto jurídico tutelado é o poder de polícia da Administração Pública.

c) Artigo 22. Possuir, adquirir, transferir, transportar, guardar ou trazer consigo material nuclear, sem a necessária autorização. Pena: reclusão, de dois a seis anos.

A definição de material nuclear é a constante da própria lei (art. 1º, inciso IV). O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O objeto jurídico tutelado é o poder de polícia da Administração Pública.

d) Artigo 23. Transmitir ilicitamente informações sigilosas, concernentes à energia nuclear. Pena: reclusão, de quatro a oito anos.

Trata-se de um artigo curioso. As informações referentes ao ciclo nuclear estão amplamente disseminadas pelo mundo, seja na comunidade científica, seja na sociedade em geral. Diversas centrais nucleares são negociadas entre empresas e governos e, de fato, a utilização civil da energia nuclear não conhece mais segredos. Eventualmente podem existir segredos *industriais e não nucleares*, como pretende a lei. O segredo nuclear, tal como está estipulado no tipo, parece-me ser de natureza militar e, portanto, incabível em lei destinada às atividades civis.

O próprio plano de evacuação em caso de acidente nuclear em Angra dos Reis permaneceu sigiloso durante muitos anos. Observe-se a contradição, pois, se a população tiver que ser retirada da região, *necessariamente*, terá que ter conhecimento do plano de evacuação. A finalidade do artigo ora examinado é obscura. O objeto jurídico tutelado é o sigilo das informações sobre energia nuclear. Ora, em sendo a energia nuclear um monopólio federal, o princípio da publicidade da Administração Pública (CF, art. 37) impede a existência de sigilo, salvo expressa previsão legal.

Uma questão bastante interessante que é suscitada pelo artigo é a referente ao sigilo em relação a uma atividade que se encontra sob regime de monopólio. Como se sabe, o sigilo industrial tem por finalidade impedir que uma empresa aproprie-se de técnicas e pesquisas de outra e passe a fazer uma concorrência desleal. No

regime de monopólio, a referida situação não existe, pois não há concorrência entre empresas. Ademais, as instalações nucleares brasileiras foram adquiridas no exterior e, portanto, não há qualquer segredo industrial em relação a elas, pois são produzidas em série e com tecnologia conhecida.

e) Artigo 24. Extrair, beneficiar ou comerciar ilegalmente minério nuclear. Pena: reclusão, de dois a seis anos.

O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública e o seu interesse em controlar a circulação econômica dos minérios nucleares. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O crime só admite a forma dolosa.

f) Artigo 25. Exportar ou importar, sem a necessária licença, material nuclear, minérios nucleares e seus concentrados, minérios de interesse para a energia nuclear e minérios e concentrados que contenham elementos nucleares. Pena: reclusão, de dois a oito anos.

O objeto jurídico tutelado é o poder de polícia da Administração Pública e, em especial, o seu interesse em manter o controle da entrada e saída de material radioativo do território nacional. O sujeito ativo do crime é qualquer indivíduo. Ante a natureza do presente tipo, as questões suscitadas em relação ao artigo 334 do Código Penal guardam uma relevante pertinência. Observe-se que a pena cominada para o artigo da lei penal comum é inferior àquelas da lei de responsabilidade nuclear.

g) Artigo 26. Deixar de observar as normas de segurança ou de proteção relativas à instalação nuclear ou ao uso, transporte, posse e guarda de material nuclear, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena: reclusão, de dois a oito anos.

É o único crime, previsto na legislação nuclear, que não diz respeito à Administração Pública ou a circunstâncias inerentes ao próprio processo de produção nuclear. É um tipo penal bastante insuficiente para penalizar qualquer dano gerado por qualquer falha, ação ou omissão, culposa ou dolosa cuja fonte seja a instalação nuclear.

O tipo limita-se a falar em um genérico *outrem*, tal qual os tipos penais voltados para a repressão de delitos individuais praticados contra indivíduos. O dano nuclear é *sempre coletivo*, a história não registra um único caso em que um dano nuclear tenha sido sofrido por um único indivíduo.

A exposição a perigo causada por instalação nuclear será sempre coletiva e a lei deveria contemplar essa hipótese. Em verdade, o tipo do artigo 26 é uma deliberada redução, para efeitos penais, das consequências do perigo nuclear. Tendo em vista o monopólio da energia nuclear existente no Brasil, percebe-se que está voltado para a proteção da camada tecnoburocrática responsável pela operação das instalações nucleares.

O tipo não contempla, ainda, o dano ambiental que somente poderá ser punido como crime de poluição, previsto na Lei nº 6.938/81. O tipo não contempla casos de morte em decorrência de ilícitos nucleares que, dessa forma, deverão ser enquadrados no Código Penal como homicídio; a qualificação de culposos ou dolosos deverá ser feita diante do caso concreto, não sendo aceitável que se adote a posição de considerá-los culposos *a priori*.

h) Artigo 27. Impedir ou dificultar o funcionamento de instalação nuclear ou o transporte de material nuclear. Pena: reclusão, de quatro a dez anos.

É interessante constatar que o crime apenado com maior rigor é o tipificado no artigo 27. A sua pena supera, inclusive, a prevista no artigo 26 que, como se viu, é o único que guarda alguma relação com a vida dos cidadãos. O artigo é aquele que mais profundamente assume o caráter de defesa das instalações nucleares e não da comunidade, contido na lei que está sob exame. Tanto do ponto de vista penal como do ponto de vista civil, a Lei nº 6.453 é muito mais uma lei de defesa da energia nuclear do que uma lei de defesa dos cidadãos contra a energia nuclear.

19.9.2 A utilização do Código Penal

Ante a inexistência de uma legislação nuclear especificamente voltada para o aspecto penal que possa ser usada eficientemente pela sociedade em sua própria defesa, faz-se necessário que se examine quais artigos do Código Penal vigente poderão ser aplicáveis aos casos concretos. O exame não se pretende exaustivo, pois há a possibilidade de toda uma cumulação de crimes em concurso formal ou material que, praticamente, tornam impossível uma previsão de casos concretos.

A deficiência da utilização do Código Penal para as hipóteses em que o bem jurídico atingido é o meio ambiente já foi percebida por vários juristas em todo o mundo. As dificuldades são internas e externas ao Direito. Internamente, é possível verificar a incapacidade de os tipos penais existentes atenderem a demandas inteiramente diversas daquelas do tempo em que foram criados. A subjetividade, a pessoalidade e demais critérios centrados no indivíduo são absolutamente impotentes para lidar com problemas de sociedades altamente tecnológicas. Externamente, o problema mais grave é a inexistência de uma consciência social que aceite o ilícito ecológico como ilícito criminal e que veja o delinquente ecológico como verdadeiro criminoso. Infelizmente, a tendência social é considerar os ilícitos ecológicos como “acidentes”.

i) Artigo 121. Matar alguém.

Trata-se do crime de homicídio. A sua utilização em matéria nuclear, lamentavelmente, já foi experimentada pela Justiça brasileira, no tristemente célebre caso do Césio 137, em Goiânia. Os donos e o técnico responsável pela cápsula de Césio 137, que se encontrava abandonada, foram processados por homicídio culposos, tendo em vista a morte de três pessoas, que encontraram o equipamento abandonado e se “pintaram” com o pó que se desprendia do mesmo.

A pena aplicada pela Justiça foi de três anos de detenção, passível de conversão em prestação de serviços à comunidade. A pena aplicada foi rigorosa, dentro da fragilidade da legislação vigente. A condenação, no entanto, somente ocorreu em 1992 (O GLOBO, 1992). As apelações interpostas pelos réus, fatalmente, acarretarão a prescrição, em concreto, da pretensão punitiva.

j) Outros artigos do Código Penal

Embora reconhecendo uma certa dificuldade em suas aplicações, penso que os artigos 252 (exposição da vida ou da saúde pelo emprego de gases tóxicos ou asfixiantes) e 270 (envenenar água potável ou substância alimentícia) podem ter uma utilidade considerável na repressão aos crimes causados por meio da energia nuclear. Na hipótese, os eventuais resultados danosos, morte e lesão corporal grave, importam agravamento da pena.

Como leciona Fernando Fragoso (1992, p. 110),

além das consequências mais agravadas, o evento morte, resultante [...] de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia, implica para o criminoso uma série de outros gravames, impostos pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990, a saber: não são passíveis de anistia, graça ou indulto; o réu preso em flagrante responderá à ação penal preso, pois está proibida a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; a pena será cumprida integralmente em regime fechado; e o livramento condicional somente poderá ser apreciado após o cumprimento de, no mínimo, dois terços da pena.

19.9.3 Lei de Crimes Ambientais

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) deu nova redação ao artigo 56 da Lei nº 9.605/1998, muito influenciada pelos problemas decorrentes do caso do Césio 137 (Goiânia), tipificando mais um crime nuclear:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – abandona os produtos ou substâncias referidos no *caput* ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;

II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

§ 3º Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

- 1 Disponível em: <http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160_web.pdf>. Acesso em: 12 set. 2011.
- 2 CF, artigo 21, inciso XXIII, alíneas *a, b e c*.
- 3 WALKER, Gabrielle; KING, Sir David, *O Tema Quente* – como combater o aquecimento global e manter as luzes acesas. Trad. Caroline Chang. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. p. 134.
- 4 LOVELOCK, James. *Gaia: Alerta Final*. Trad. Jesus de Paula Assis e Vera de Paula Assis. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010. p. 106.
- 5 MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Rio de Janeiro: Forense, 1981. *passim*.
- 6 STF ADI 329/SC – Santa Catarina – Julgamento: 1º/4/2004. Tribunal Pleno.
- 7 Supremo Tribunal Federal – ADI 1575/SP – São Paulo. Julgamento: 7/4/2010, Tribunal Pleno. *DJe*-105, Divulg. 10/6/2010, Public. 11/6/2010.
- 8 Disponível em: <<http://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/Energia-Nuclear.aspx>>. Acesso em: 17 nov. 2018
- 9 RÉMOND-GOUILLOUD, Martine. *Du Droit de Détruire*. Paris: PUF, 1989. p. 77-78.
- 10 “O acidente fez crescer preocupações sobre a segurança da indústria nuclear soviética, diminuindo sua expansão por muitos anos, e forçando o governo soviético a ser menos secreto. Os agora separados países de Rússia, Ucrânia e Bielorrússia (Belarus) têm suportado um contínuo e substancial custo de descontaminação e cuidados de saúde devidos ao acidente de Chernobyl. É difícil dizer com precisão o número de mortos causados pelos eventos de Chernobyl, devido às mortes esperadas por câncer, que ainda não ocorreram e são difíceis de atribuir especificamente ao acidente. Um relatório da ONU de 2005 atribuiu 56 mortes até aquela data – 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças com câncer de tireoide – e estimou que cerca de 4.000 pessoas morrerão de doenças relacionadas ao acidente. O Greenpeace, entre outros, contesta as conclusões do estudo.” Disponível em: <http://www.achetudoeregiao.com.br/rj/usina_nuclear4.htm>. Acesso em: 26/9/2011.
- 11 RÉMOND-GOUILLOUD, Martine. Op. cit., p. 79.
- 12 Artigo 121, § 3º, do Código Penal.
- 13 *O Globo*, 6/8/1992.
- 14 O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 1995, confirmou a decisão de primeira instância. Há grande possibilidade de que sejam interpostos recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o STF.
- 15 Cujo tratamento, aliás, é excessivamente brando.
- 16 Disponível em: <<http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1118/ML111861807.pdf>>. Acesso em: 13 set. 2011.
- 17 Disponível em: <<http://www.nrc.gov/japan/japan-info.html>>. Acesso em: 26 set. 2011.
- 18 TRF 1 – Relator: Juiz Evandro Reimão dos Reis (Conv.). Julgamento: 2/10/2002. Órgão Julgador: Terceira Turma Suplementar, Publicação: 10/7/2003, *DJ*, p. 194.
- 19 TRF1 – Apelação Cível: AC 14371 – GO 2001.01.00.014371-2 – Relator(a): Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida – Julgamento: 27/7/2005 – Órgão Julgador: Quinta Turma – Publicação: 15/8/2005, *DJ*, p. 4.
- 20 LENSEN, Nicholas. Desafiando o lixo nuclear. In: BROWN, Lester. *Qualidade de Vida 1992* – Salve o Planeta!, São Paulo: Globo, 1992. p. 75.
- 21 Trata-se do fenômeno conhecido como *not in my backyard*.
- 22 *Jornal do Brasil*, 19/8/1991, Ecologia.
- 23 LENSEN, Nicholas. Op. cit., p. 82.
- 24 Disponível em: <<http://www.sellafieldsites.com/>>. Acesso em: 25 set. 2011.
- 25 *Jornal do Brasil*, 4/4/1992.
- 26 LENSEN, Nicholas. Op. cit., p. 84.
- 27 PASCHOA, Anselmo. *Jornal do Brasil*, 4/4/1992.
- 28 *Ecologia e Desenvolvimento*, nº 9, ano 1, p. 41.
- 29 *O Estado de S. Paulo*, 13/4/1992.
- 30 “Artigo 13. O operador da instalação nuclear é obrigado a manter seguro ou outra garantia financeira que cubra a sua responsabilidade pelas indenizações por danos nucleares. § 1º A natureza da garantia e a fixação de seu valor serão determinadas, em cada caso, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, no ato da licença de construção ou da autorização para a operação. § 2º Ocorrendo alteração na instalação, poderão ser modificados a natureza e o valor da garantia. 3º Para a determinação da natureza e do valor da garantia, levar-se-ão em conta o tipo, a capacidade, a finalidade, a localização de cada instalação, bem como os demais fatores previsíveis. 4º O não cumprimento, por parte do operador, da obrigação prevista neste artigo acarretará a cassação da autorização. 5º A Comissão Nacional de Energia Nuclear poderá dispensar o operador da obrigação a que se refere o *caput* deste artigo, em razão dos reduzidos riscos decorrentes de determinados materiais ou instalações nucleares.”

TERRAS INDÍGENAS

§ 1º LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

TERRAS INDÍGENAS – INTRODUÇÃO

A inserção de um capítulo constitucional, versando sobre os índios e o direito dos povos indígenas, abriu uma nova perspectiva em nosso sistema jurídico quanto à garantia do respeito aos direitos dos povos indígenas. Lamentavelmente, a simples existência de um capítulo constitucional dedicado aos índios não é suficiente para assegurar a efetividade de suas normas. A realidade indígena, como se sabe, não será modificada apenas pela força dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal.

Os estudos jurídicos voltados exclusivamente para os índios e sua realidade são muito poucos em nossa literatura especializada. Raras são as obras jurídicas voltadas para o exame legal das questões indigenistas. Infelizmente, essa lacuna em nosso universo jurídico ainda está longe de ser superada e, em realidade, os cursos jurídicos e os estudiosos do Direito não têm demonstrado muito interesse, seja pela vida dos indígenas, seja pelo Direito Indigenista; é lamentável, pois as questões indígenas vêm crescendo em relevância inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A importância do estudo do Direito Indigenista é, em nossa opinião, fundamental, pois, no estudo da condição jurídica dos povos indígenas, diversas e candentes questões têm sido suscitadas ao longo de séculos. Em primeiro lugar, parece-me que o reconhecimento à diferença e à identidade são os pontos cruciais de todo o Direito Indigenista. Os obstáculos ao exercício do direito à diferença têm diversas origens. Existem os obstáculos de natureza ideológica, que se fundamentam em um forte componente racista. Existem, ainda, obstáculos de natureza econômica, pois não é segredo para ninguém que a localização geográfica e espacial dos povos indígenas está em áreas potencialmente ricas em minérios e outras riquezas naturais. Acrescente-se, ademais, a fortíssima vinculação dos temas indigenistas com a geração de energia elétrica através da construção de usinas hidrelétricas e outras formas de utilização de recursos naturais.

Os graves problemas fundiários existentes no Brasil, igualmente, não podem ser solucionados sem que se resolvam os problemas relativos às terras indígenas. Assim é, na medida em que a expansão da fronteira agrícola verificada na década de 70 do século XX e a construção de diversas rodovias, tais como a Transamazônica, implicaram o deslocamento de inúmeros povos indígenas das terras que tradicionalmente ocupavam, ou mesmo a invasão das terras indígenas por colonos originários das mais diferentes regiões do país.

Outro aspecto extremamente importante a ser observado é o da íntima relação entre os povos indígenas e a conservação do meio ambiente e a ecologia. Os povos indígenas são, dentre todos, aqueles cujas formas de vida guardam maior proximidade com a natureza e o meio ambiente. A conservação do meio ambiente é uma condição fundamental para a reprodução da vida, nos moldes tradicionais, nas comunidades indígenas. Em um país como o Brasil, no qual a presença de imensas áreas florestais é significativa, não se pode deixar de examinar a repercussão que o Direito possui na vida dos povos e gentes que encontram na floresta o seu *habitat*.

Os povos indígenas e os demais povos que habitam as florestas brasileiras, desde que compreendidos em suas diferenças em relação à sociedade envolvente, têm um papel fundamental a desempenhar em toda a complexa marcha para o perfeito conhecimento da biodiversidade existente nas florestas, em especial na Floresta Amazônica. É de se observar que a própria Lei Fundamental Brasileira reconhece a importância dos índios para a conservação do meio ambiente, assim como reconhece a importância do meio ambiente para a conservação e sobrevivência dos índios (art. 231, § 1º).

Há uma nova compreensão do papel a ser desempenhado pelos povos aborígenes na conservação ambiental. Lentamente, está sendo modificada a antiga, e errônea, compreensão de que a proteção ambiental deveria ser feita mediante a adoção de políticas que implicassem o isolamento da área a ser protegida.

É necessário, e fundamental, que os povos indígenas possam conservar suas identidades e peculiaridades como parte integrante que são da riqueza e diversidade cultural brasileira. É de se observar que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – Convenção relativa aos povos indígenas e tribais em países independentes. O artigo 4.1 da referida convenção determina que:

Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.

Não se pode deixar de mencionar, ademais, toda a problemática suscitada pela presença indígena em diversas regiões da fronteira brasileira e de suas implicações em temas extremamente sensíveis, tais como soberania e defesa nacionais. Em suma, embora extremamente marginalizados pela sociedade brasileira, não resta dúvida de que os índios estão colocados em uma posição estratégica no que se refere à construção do Brasil como Nação e, principalmente, como Nação e Estado democráticos. Está, portanto, plenamente justificada a inclusão de toda uma seção dedicada ao Direito Indigenista no interior de um livro voltado para o estudo do Direito Ambiental.

20.1 OS PRIMEIROS CONTATOS COM O COLONIZADOR

O colonizador, quando aportou nas terras brasileiras, já encontrou uma grande população plenamente estabelecida. Essa população era de aproximadamente cinco milhões de indivíduos e composta por muitos e muitos povos extremamente diferentes entre si. Os povos nativos que aqui estavam passaram a ser conhecidos como índios. Desnecessário dizer da superficialidade da generalização. Tal designação, como se sabe, é bastante equívoca, pois não se pode afirmar qualquer semelhança entre os originários habitantes de nossa terra e as populações do subcontinente indiano. Esta, no entanto, foi a designação que se adotou para todos os povos nativos do “Novo Mundo”.

Os “índios”, em realidade, eram, e são constituídos por diversos povos e nações com costumes e peculiaridades específicas. Não se pode agrupá-los em uma única categoria. Pouco se sabe sobre os povos que habitavam o Brasil quando da época da chegada dos colonizadores. Os tupis formam o grupo mais bem conhecido, pois, em razão dos combates e guerras que travaram com os portugueses, estes passaram a anotar-lhes as características mais importantes etc.

Diferentemente do que é pregado pela história oficial, a colonização não se fez sem sangue e sem luta. A disparidade entre a força das armas, o nível organizacional e outras circunstâncias levaram os povos nativos à derrota ante o colonizador. Convém acentuar, contudo, que: *nos limites de suas possibilidades, foram inimigos duros e terríveis, que lutaram ardorosamente pelas terras, pela segurança e pela liberdade, que lhes eram arrebatadas conjuntamente* (HOLANDA, 1985, p. 72). Não há, contudo, uma história da resistência indígena. O movimento historiográfico voltado para o “outro” lado da História é recente e minoritário. Os indígenas dedicavam-se à caça, à pesca, à silvicultura e à colheita. Os instrumentos utilizados para as suas atividades eram, em geral, construídos de pedras ou de madeira. O ferro ou o bronze eram desconhecidos entre os primitivos habitantes do Brasil.

Os brasileiros nativos, desde o começo, sofreram a escravização por parte dos colonizadores que aqui aportavam. De fato, a escravização dos “gentios” caminhou lado a lado com a ocupação do território brasileiro e dela não pode ser separada. Conforme anota Rodolfo Garcia (1975, p. 63):

Desde o primeiro contato com a terra do Brasil, como veio a chamar-se logo depois, e com a população aborígene começaram os descobridores a praticar a escravidão.

20.1.1 O Regimento de Tomé de Souza

O Regimento do Governador Geral Tomé de Souza continha determinações extremamente precisas para que a mais alta autoridade colonial buscasse explorar as eventuais rivalidades entre os diversos povos nativos, em proveito da empreitada da colonização. E, igualmente, trazia ordens para que o exército colonizador destruísse, sem qualquer piedade, aqueles que se opusessem à atividade da colonização. Vale ressaltar que a palavra “paz” está muito presente no documento que ora se comenta. Mas, sem dúvida, trata-se da paz conseguida à custa do silêncio e da submissão dos povos que já se encontravam nas terras brasileiras no momento da chegada dos portugueses. Os termos contidos no Regimento são assustadores:

E tanto que a dita cerca for reparada e estiverdes provido do necessário, e o tempo vos parecer disposto para isso, praticareis, com pessoas que o bem entendam, a maneira que tereis para poder castigar os culpados, a mais a vosso salvo, e com menos risco da gente que puder ser, e como assim tiverdes praticado, o poreis em ordem, destruindo-lhes suas aldeias e povoações, e matando e cativando aquela parte deles, que vos parecer que basta para seu castigo e exemplo de todos, e daí em diante, pedindo-vos paz, lha concedais, dando-lhes perdão; e isso, porém, será com eles ficarem reconhecendo sujeição e vassalagem, e com encargo de darem em cada ano alguns mantimentos para a gente da povoação; e no tempo que vos pedirem paz, trabalhareis por haver a vosso poder alguns dos principais que foram no dito alevantamento, e estes mandareis, por justiça, enforcar na aldeia donde eram principais (MENDONÇA, 1972, p. 37).

Não obstante as ordens extremamente cruéis e duras contidas no Regimento, toda a atividade colonizadora, conforme se pode ler no documento comentado, foi praticada no intuito de trazer a fé católica aos indígenas: “*Porque a principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse à nossa Santa Fé Católica*” (MENDONÇA, 1972, p. 37).

A nobre missão de levar a fé aos gentios, contudo, não impediu que as autoridades coloniais simplesmente ignorassem todos os mandamentos religiosos e eclesiásticos que proibiam a escravização dos povos indígenas. Em realidade, ao longo de todo o período colonial, houve uma legislação extremamente vacilante e contraditória que jamais conseguiu, efetivamente, impedir e proibir o cativeiro dos índios.

Izidoro Martins Jr. (1979, p. 133) destaca a seguinte passagem do Regimento de 1548: “[...] *Destruir-lhes as aldeias e povoações, matando, cativando e expulsando o número que lhe parecesse bastante para castigo e exemplo.*”

No projeto da colonização, como se pode perceber, não havia qualquer espaço para a complacência ou tolerância para com os primitivos ocupantes de nossas terras brasileiras. A guerra travada contra os indígenas possuía dois *fronts* bastante claros e definidos: o ataque físico às populações indígenas e o ataque cultural. Pelo ataque físico tentava-se a destruição militar dos indígenas; pelo ataque cultural o objetivo era a “integração” dos indígenas à ideologia e à sociedade colonial. Essas características que marcaram o início do processo de colonização são as principais características que regeram, por cinco séculos, as relações entre brancos e índios, entre “civilizados” e “selvagens”.

20.1.2 A escravização dos indígenas

Uma das primeiras manifestações do colonizador para com os índios foi a tentativa de escravizá-los. Já no ano de 1511, cerca de 30 índios cativos foram levados para Lisboa. Os Senhores e Donatários das capitanias hereditárias recebiam, através das próprias Cartas de Doação e Forais, o direito de escravizar indígenas. Os senhores tinham o direito de escravizar quantos índios quisessem e podiam levar até 39 para a capital da colônia. Buscava, o colonizador, assegurar o suprimento de mão de obra barata e abundante, sem que precisasse, para tanto, comprar escravos negros no mercado africano.

O início oficial e legal do cativeiro indígena, contudo, ocorreu no ano de 1537, quando foi expedida uma Carta Régia pela qual foi permitida a escravização dos caetés.

Ao longo do período colonial foram feitas inúmeras leis e outros documentos legais que tinham por finalidade tratar da “liberdade” dos povos indígenas. Esse era o eufemismo utilizado para estabelecer as condições mediante as quais era permitida a escravização dos indígenas. Em que pese a alegada fé cristã e católica da Coroa Portuguesa, a Corte jamais deu muita importância aos mandamentos da Igreja quanto ao delicado problema da escravização dos índios. Sendo certo, igualmente, que a própria concepção eclesiástica acerca do problema da escravização dos indígenas, por muito tempo, foi vacilante e contraditória. Observe-se que, no ano de 1537, isto é, no mesmo ano em que foi permitida a escravização dos caetés, o papa Paulo III expediu uma Bula pela qual eram excomungados todos aqueles que mantivessem índios em cativeiro. Segundo Eduardo Galeano (1986, p. 155): “*Uma nova Bula sai do Vaticano. Se chama sublimis Deus e descobre que os índios são seres humanos, dotados de plena razão*”.

Tal Bula foi confirmada, em 1639, por Urbano VIII.

A legislação acerca dos direitos, deveres e escravização dos indígenas sempre foi muito confusa, embora tivesse um núcleo comum que era o de, no mínimo, submeter os índios à religião católica. Tanto é assim que no Regimento de Tomé de Souza constava que o principal fim por que se povoava o Brasil era o de reduzir “o gentio à fé católica” (MARTINS JR., 1979, p. 133). Reduzir o gentio à fé católica, evidentemente, significava impor a religião católica aos índios. Pela lei de 30 de julho de 1609, os índios foram declarados livres *conforme o Direito e seu nascimento natural*. Por força dessa nova legislação, os índios tiveram restabelecidos os seus direitos de liberdade. Tal liberdade, contudo, não teve maior duração, pois a lei de 10 de setembro de 1611 restabeleceu o regime de escravidão indígena. Pela referida lei “*será reputado legítimo o cativeiro não só dos aprisionados em guerra justa, mas, também, dos índios resgatados quando cativos de outros índios*” (MARTINS JR., 1979, p. 137).

Embora seja indiscutível a forte influência da Igreja Católica em todo o processo de colonização do território brasileiro, ela não conseguiu impedir a legislação que permitia a escravidão indígena. Somente em 1647 é que foi revogada a lei de 13 de outubro de 1611, a qual estabeleceu condições para a “liberdade dos gentios”. Com efeito, os Alvarás de 10 de novembro de 1647 e dos dias 5 e 29 de setembro de 1649 restabeleceram o regime de liberdade dos povos nativos. É de se observar, contudo, que, pela provisão de 17 de outubro de 1653, voltada especialmente para o Pará e para o Maranhão, foram restabelecidos os antigos casos de cativeiro e instituídos outros novos. Já aos 9 de abril de 1655 foram abolidos os novos casos de escravidão.

A incoerência e vacilação da legislação, contudo, levaram a que leis dos anos 1663, 1667 e 1673 voltassem a determinar hipóteses de escravidão indígena. A escravidão indígena foi abolida pela lei de 1º de abril de 1680, que reprimou a lei de 30 de julho de 1609; pela lei em tela foi determinado: “*se não pudesse cativar índio algum em nenhum caso, nem ainda nos executados nas leis anteriores, sendo livres os que fossem prisioneiros nas guerras ofensivas ou defensivas que com os colonos fizessem, como se usa nas da Europa; podendo somente ser entregues nas aldeias de índios livres católicos, para que se pudessem reduzir à fé e servir ao*

estado” (MARTINS JR., 1979, p. 138).

Em 1684, pela lei de 2 de setembro, novamente, foi restabelecida a escravidão indígena. Para o grande estudioso da escravidão no Brasil, Perdigão Malheiros, a lei de 2 de setembro, contudo, não passava de uma “escravidão disfarçada”. A revogação definitiva da escravidão indígena no Brasil só veio a ocorrer com a carta Régia de 27 de outubro de 1831.

J. F. Lisboa, citado por Izidoro Martins Jr. (1979, 135-136), fez uma síntese extremamente feliz de todas as ambiguidades e contradições que marcaram a escravização dos povos indígenas:

Em relação aos índios a dominação portuguesa foi uma série nunca interrompida de hesitações e contradições até o ministério do marquês de Pombal. Decretava-se hoje o cativo sem restrições, amanhã a liberdade absoluta, depois um meio-termo entre os dois extremos. Promulgava-se, revogava-se, transigia-se, ao sabor das paixões e interesses em voga, e, quando enfim se supunham as ideias assentadas por uma vez, recomeçava-se com novo ardor a teia interminável. Foi aquele ministro enérgico e poderoso quem rompeu sem regresso com o princípio funesto da escravidão. Os índios, é certo, ainda depois das famosas leis de 1755, foram não poucas vezes vítimas da opressão; porém o mal nestes casos tinha um caráter meramente accidental e transitório e nunca mais adquiriu os foros de doutrina corrente, que legitimando os seus resultados, os tornava por isso mesmo mais intensos e duradouros. As experiências que em sentido contrário tentou o governo do príncipe regente em 1808 nem foram bem aceitas pela opinião pública, nem vingaram contra o princípio da liberdade já radicado [...] Um curioso espécime dessa legislação casuística e vacilante é a provisão de 9 de março de 1718, que, ela só, resume em poucas linhas quanto se encontra disperso em difusas páginas durante mais de dois séculos [...] É fácil conceber todo o partido que executores ávidos e cruéis podiam tirar dessas leis contraditórias e confusas, que multiplicando-os casos e as exceções davam estímulos poderosos à cavilação e ao arbítrio [...] Uma vez reduzidos ao cativo, índios e africanos eram em tudo e por tudo iguais em condição e miséria. As leis portuguesas, equiparando-os frequentemente às bestas e a animais, e considerando-os antes coisas que pessoas, tratavam-nos consequentemente de um modo estranho a todos os sentimentos de humanidade. Os escravos chamavam-se peças. Como fôlegos vivos e bem perituos, acautelava-se o perigo da sua perda. Como gado ou mercadoria, marcavam-se e carimbavam-se para se não confundirem uns com os outros, em prejuízo dos respectivos senhores. Se cometiam crimes, e um dos mais graves era tentarem fugir do cativo, julgavam-se em voz, sem forma nem estrépito de juízo, e a mutilação e a marca de ferro em brasa, já instrumentos de boa arrumação mercantil e sinais distintivos da propriedade, passavam a figurar entre as disposições da política e justiça real [...] Nem os seus folguedos rudes e simples, nem os ornatos das suas mulheres escapavam a implacável regulamentação da Corte! [...] A exploração destas peças desvalidas nunca ficou circunscrita dentro dos limites da escravidão, aliás tão fáceis de transpor e sempre tão pouco respeitados pela cobiça infrene dos exploradores. Quanto aos remorsos ou à hipocrisia da Corte forçaram-na a decretar o princípio da liberdade, ficava-lhe o recurso dos descimentos dos índios livres para prover os colonos ociosos de braços para o trabalho [...] Com o suor de seu rosto, e a força de seus braços, edificavam-se as igrejas, os conventos, os hospitais, os palácios, as fortalezas e os armazéns reais. Eles abriram as estradas, lavraram a terra, colhiam os frutos, beneficiavam os engenhos, tripulavam as canoas, iam à pesca e à caça, apanhavam o gado, e eram nos açougues as ajudas dos açougueiros. Os índios finalmente faziam a guerra ofensiva e defensiva no interesse dos seus opressores, e iam com eles às expedições do sertão para matarem, cativarem e descerem por seu turno outros índios.

O grande historiador do Direito brasileiro, Izidoro Martins Jr. (1979, p. 139), com maestria, resumiu o significado da legislação portuguesa acerca da escravização dos indígenas:

Foi esta que aí fica, na sua simplíssima feição de labirinto, de caos, de Proteu administrativo, a extravagante legislação portuguesa sobre os índios da colônia brasileira.

A escravização do índio, no Brasil, não é mais permitida, assim como não é permitida a escravização de nenhum ser humano. Contudo, muitas denúncias referentes à existência de escravidão indígena têm sido feitas.

20.2 O ÍNDIO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

Conforme ensina José Afonso da Silva (2004, p. 772), “[...] a Constituição de 1988 revela um grande esforço da Constituinte no sentido de preordenar um sistema de normas que pudesse efetivamente proteger os Direitos e interesses dos índios.” É indiscutível que a Carta Política de 1988 foi a que mais extensamente abordou o assunto e o fez de maneira mais favorável aos índios. O tratamento foi bastante abrangente, mas é preciso que se diga que a simples presença, ainda que ampla, das questões indígenas em nossa Lei Fundamental não é suficiente para equacionar os gravíssimos problemas enfrentados pelos diversos povos nativos em nosso país.

As Cartas de Doação e Forais expedidas pelos Reis de Portugal em favor dos donatários das Capitanias Hereditárias e os próprios Regulamentos dos Gerais foram os primeiros textos legais vigentes no Brasil e, guardadas as devidas proporções, podem ser considerados como as Constituições primitivas do Brasil. Em tais documentos constavam normas acerca dos indígenas. Tais normas eram destinadas à “pacificação” e determinavam a conduta a ser seguida pelos portugueses em relação aos indígenas.

A Constituição Brasileira de 1824 não dedicou qualquer de seus itens ao tratamento dos problemas indígenas. Foi totalmente omissa. A omissão constitucional redundou, provavelmente, do fato de a Carta ter sido outorgada e do pouco interesse que a sorte dos índios sempre despertou nas classes dirigentes brasileiras, imperiais e republicanas. É curioso que a Assembleia Constituinte não deixou de debater os assuntos indígenas. O resultado dos debates, contudo, foi classificado por Manuela Carneiro da Cunha (1987, p. 65) como “decepcionante”.

A Carta Republicana de 1891 não se dedicou aos assuntos indigenistas. É importante observar, contudo, que o debate acerca dos aborígenes esteve presente na Assembleia Constituinte. O Apostolado Positivista, na sua proposta constitucional, elaborou um texto que reconhecia cabalmente os índios e seus direitos originários.

Mais uma vez, a Professora Manuela Carneiro da Cunha (1987, p. 65) fornece-nos uma indicação segura a ser seguida:

Em 1890, o Apostolado Positivista apresenta à Constituinte uma proposta que contém o mais explícito reconhecimento da soberania indígena. Art. 1º A República dos Estados Unidos do Brasil é constituída pela livre federação dos povos circunscritos dentro dos limites do extinto Império do Brasil. Compõem-se de duas sortes de estados confederados, cujas autonomias são igualmente reconhecidas e respeitadas segundo as fórmulas convenientes a cada caso, a saber: I – Os Estados Ocidentais brasileiros sistematicamente confederados e que provêm da fusão do elemento europeu com o elemento africano e o elemento aborígene. II – Os Estados Americanos brasileiros empiricamente confederados, constituídos pelas hordas fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A federação deles limita-se à manutenção das relações amistosas hoje reconhecidas como um dever entre nações distintas e simpáticas, por um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a proteção do Governo Federal contra qualquer violência, quer em suas pessoas, quer em seus territórios. Estes não poderão jamais ser atravessados sem o seu prévio consentimento pacificamente solicitado e só pacificamente obtido.

A primeira Constituição brasileira a dispor sobre a situação jurídica dos indígenas foi a de 1934. A Constituição de 1934 dedicou dois tópicos ao tema ora examinado. A menção inicial se encontrava presente no artigo 5º, inciso XIX, alínea m. Tratava-se ali da competência legislativa privativa da União. Dentre as competências legislativas privativas da União estava incluída a de legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. O artigo 129 manteve e elevou em nível constitucional a tradição do Direito brasileiro em reconhecer e respeitar os direitos originários dos indígenas sobre as suas terras. Assim é que o artigo mencionado dispunha:

Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedada a alienação das mesmas.

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.

O fim da Ditadura Vargas foi consolidado pela Constituição de 1946, que, também, fez menção aos silvícolas e suas terras. O artigo 5º, ao tratar das competências legislativas da União, determinou ser de sua competência legislar sobre a *incorporação dos silvícolas à comunhão nacional*. Já o artigo 216 dispunha que:

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não as transferirem.

Já a Constituição de 1967 incluiu entre os bens da União *as terras ocupadas pelos silvícolas* (art. 4º, IV). O artigo 8º daquela Constituição, em seu inciso XVII, incluiu entre as competências da União a de legislar sobre *nacionalidade, cidadania e naturalização; incorporação dos silvícolas à comunhão nacional*. O regime jurídico constitucional das terras ocupadas pelos indígenas, em suas linhas básicas, foi estabelecido pelo artigo 186, cujo teor era o seguinte:

É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes.

A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, estabeleceu a competência legislativa da União no que se refere à *incorporação dos silvícolas à comunhão nacional* (art. 8º, XVII, alínea o). A mesma Emenda, por seu artigo 198, dispôs sobre as terras indígenas. De todas as Constituições que o país tivera até aquele momento, foi a E.C. nº 1 a que dedicou maior espaço à questão.

O artigo 198 estabeleceu que:

As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar; a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes.

Por força do mandamento constitucional, foram declarados nulos e extintos todos os efeitos jurídicos, quaisquer que fossem as suas naturezas, de atos que tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas (art. 198, § 1º). A declaração de nulidade constitucionalmente estabelecida foi determinada sem que o usurpador das terras indígenas tivesse direito a qualquer indenização (art. 198, § 2º).

Do ponto de vista cultural, a Constituição de 1988 foi a mais abrangente.

O traço comum entre as diversas Cartas Políticas anteriores à atual é o de buscar “integrar” o índio à comunidade nacional. Parece-nos que nos dispositivos constitucionais anteriores está presente a ideia de que o índio é um ser estranho à chamada comunidade nacional, pois não compartilha dos elementos julgados basilares pelos *nacionais*, tais como a religião, a língua, os costumes, a maneira de ver o mundo etc. A diferença existente entre os índios e a “comunidade nacional” é vista como algo a ser eliminado, através da progressiva transformação do indígena em “branco”, ou seja, à medida que o indígena abra mão de sua diferença cultural e assuma a plena identificação com a sociedade envolvente. A integração, portanto, se faria através da dissolução do elemento cultural e existencial dos povos indígenas nos elementos da “comunhão nacional”.

O índio é visto, em nossa tradição constitucional, como um coabitante do país, mas, efetivamente, não é um *nacional*. Pior, não é sequer estrangeiro, pois aos estrangeiros residentes sempre foram reconhecidos todos os direitos fundamentais do homem. Jamais se exigiu que um estrangeiro se “aculturasse”, para ter direitos sobre os seus filhos ou bens, por exemplo. Paternalisticamente, as Constituições reconheceram a existência dos índios para negar-lhes o direito à diferença e aniquilá-los em suas identidades fundamentais.

As Constituições que precederam à atual não reconheceram aos povos indígenas o direito à manutenção de seu modo particular de vida. O que foi reconhecido, pelas Cartas anteriores, é que os índios se constituíam em uma parcela da população brasileira que, ainda, não havia se agregado às demais. Esse afastamento dos indígenas da “comunhão nacional” se fazia em razão do “atraso cultural” destes povos em relação aos demais brasileiros. O índio e a sua cultura, nos regimes anteriores, jamais passaram do âmbito da “curiosidade folclórica”, isto é, expressavam formas de vida e de pensar que, devido à sua ingenuidade, deveriam ser substituídos por uma expressão cultural mais consistente, mais amadurecida, mais perene, a cultura ocidental manifestada na “comunhão nacional”.

20.2.1 Dispositivos da Constituição de 1988

A Constituição Federal de 1988 contém diversas menções implícitas e explícitas aos índios. Os artigos constitucionais voltados para os povos indígenas são os seguintes: artigos 20, XI; 22, XIV; 109, XI; 129, V; 210, § 2º; 215, § 1º; 231 e 232.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas integram o conjunto de bens da União (art. 20, XI), sendo sua competência legislar sobre as populações indígenas (art. 22, XIV). Ao Congresso Nacional compete dispor sobre a autorização, a exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais nas terras indígenas (art. 49, XVI). É importante observar que, no caso, o Congresso Nacional exerce a atribuição sem a sanção do Presidente da República (art. 48).

O processamento e o julgamento de ações judiciais versando sobre direitos indígenas cabe à Justiça Federal (art. 109, XI), sendo atribuição do Ministério Público Federal a tutela judicial dos interesses e direitos das populações indígenas (art. 129, V).

A educação dos povos indígenas também foi motivo de preocupação da Assembleia Nacional Constituinte. O artigo 210, em seu § 2º, determinou fossem asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Garantiu a Lei Fundamental que os povos indígenas possam se desenvolver em seus próprios idiomas e, mais que isso, possam garantir a perpetuação de um dos elementos mais fundamentais para a construção de uma identidade, que é a língua.

Ainda no campo cultural, o constituinte desejou fossem garantidas as peculiaridades da cultura indígena. Em assim sendo, foi assegurada aos índios a proteção de seus valores e manifestações culturais (art. 215 e §§). Não se pode deixar de anotar que as tradições, modos e maneiras de viver, pensar e produzir, indígenas, por força da norma contida no artigo 216, são parte integrante do patrimônio cultural brasileiro.

Existem, ademais, artigos constitucionais que, mediatamente, dizem respeito à problemática vivenciada pelos povos pré-colombianos. Tais artigos podem ser encontrados nos capítulos destinados aos direitos e garantias individuais, aos direitos sociais e coletivos, à ordem econômica e social etc. Por questões óbvias por si mesmas, deve ser ressaltado que os tópicos constitucionais voltados para a atividade garimpeira e para a extração de riquezas minerais e naturais têm grande relevância para os povos indígenas.

20.2.1.1 Dispositivos específicos

A Constituição de 1988, como já foi visto, é a que dedicou maior atenção aos indígenas. Os índios e o seu modo de ser foram cabalmente reconhecidos pela Constituição Federal, tendo sido imposta à União a obrigação de proteger os índios, suas terras, sua cultura, suas línguas, bens etc. É importante frisar que os direitos dos índios sobre suas terras foram considerados *direitos originários*. A reconhecida especialista Manuela Carneiro da Cunha (CEDI, 1991, p. 29) afirma que a categoria direitos originários é importante pois [...] *tais direitos derivam de um fato histórico – o de terem sido os índios os primeiros ocupantes do Brasil – e não, como erroneamente muitas vezes se pensa, da situação de fragilidade e desproteção em que se encontram*. Os direitos originários dos indígenas sobre as suas terras são preexistentes a qualquer um outro, de quem quer que seja. São, portanto, oponíveis *erga omnes*.

A própria Lei Fundamental definiu o conceito de *terras tradicionalmente ocupadas pelos índios*. Tais terras são aquelas por eles habitadas em caráter permanente,

as utilizadas com vistas às suas atividades produtivas, culturais, religiosas etc.

É nos artigos 231 e 232 que se encontram os elementos essenciais para a definição jurídico-constitucional de tudo aquilo que diz respeito aos indígenas e seus direitos coletivos e individuais.

20.2.2 Conclusão

O Texto Constitucional de 1988 é bastante abrangente e pode, efetivamente, fornecer um quadro institucional bastante adequado para a proteção jurídica, física e cultural dos povos indígenas. É exatamente em razão dos aspectos claramente favoráveis aos índios e seus direitos que, por ocasião da natimorta revisão constitucional de 1994, muitas propostas têm sido feitas visando à modificação dos dispositivos constitucionais referentes aos povos indígenas.

§ 2º AS TERRAS INDÍGENAS, A EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E O CONSENTIMENTO PRÉVIO LIVRE E INFORMADO

O principal problema dos diversos grupos indígenas que integram o povo brasileiro é, sem dúvida, o que diz respeito à preservação e manutenção de suas terras. A própria inserção da matéria em diversos textos constitucionais, desde 1934, é uma prova bastante evidente da sensibilidade do assunto. O interesse da literatura jurídica nacional sobre a matéria tem sido escasso. A bem da verdade, contudo, deve ser assinalado que, nos últimos anos, vêm sendo produzidas algumas obras especialmente voltadas ao tema.

É preciso não olvidar que a própria existência do tema terras indígenas é, com efeito, um triste reconhecimento de que os povos indígenas, de há muito, não são mais os senhores de seus tradicionais territórios. A discussão acerca das terras indígenas não é uma simples polêmica entre juristas ou entre indianistas. O tema, efetivamente, é o mais importante dentre todos os temas vinculados ao Direito Indigenista. O tema é, claramente, antropológico e, como é evidente, falece competência ao autor para enfrentá-lo com a necessária profundidade. Dessa forma, permito-me a transcrição de algumas palavras da consagrada antropóloga Alcida Rita Ramos (1986, p. 13) em relação à matéria:

No passado, quando não havia grandes pressões de fora sobre a quantidade de terra a ser utilizada para cada sociedade indígena, a questão da manutenção de fronteiras territoriais não chegava a se colocar de maneira categórica. Todos tinham o direito de utilizar os recursos do meio ambiente na forma de caça, pesca, coleta e agricultura, sem que divisas rígidas fossem mantidas entre aldeias, mesmo sociedades vizinhas.

A demarcação das terras indígenas, embora seja, contraditoriamente, uma reivindicação histórica dos indígenas, serve de demarcação dos espaços nos quais os indígenas estarão “confinados,” sem que possam exercer a sua “indigenidade” fora de tais limites territoriais.

A terra, entretanto, tem diversas outras funções importantes. A terra é o local no qual se desenvolvem as relações culturais, religiosas e econômicas. Conforme anotou a Professora Alcida Ramos, com propriedade: “*Não é apenas um recurso natural, mas – e tão importante quanto este – um recurso sociocultural.*”

Entre os indígenas nunca se verificou uma fronteira rígida entre os territórios pertencentes a cada uma das diversas sociedades. Havia uma certa tolerância que grupos diferentes utilizassem um mesmo território. As limitações estabelecidas tinham por base uma ética peculiar entre os aborígenes.

Os conceitos de casa ou até mesmo de aldeia não possuem maior importância para os indígenas. O elemento fundamental é o seu território, o seu mundo. É dentro desse universo que todas as suas principais relações são desenvolvidas, e fora dele, dificilmente, a sociedade consegue sobreviver e prosperar.

20.3 HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO

20.3.1 Do período colonial até o século XIX

Logo no início do século XVII é possível constatar-se que a legislação colonial reconhecia a existência de terras indígenas, isto é, de terras de posse e domínio exclusivamente indígenas. Manuela Carneiro da Cunha (1987, 58) informa-nos que as Cartas Régias de 30 de julho de 1609, bem como a de 10 de setembro de 1611, expedidas por Felipe III, reconheciam o *pleno domínio dos índios sobre seus territórios e sobre as terras que lhes são alocadas nos aldeamentos*. Ainda no século XVII, surgiram outros alvarás e atos governamentais que dispunham sobre o direito dos índios às suas terras. Esse tipo de legislação, indiscutivelmente, pressupunha que as terras do Brasil não eram dos índios e que, ao contrário, dentro do território nacional, deveriam ser reservadas áreas específicas para os índios; reconheciam igualmente, a existência de um estado de beligerância entre nações diversas. Nesse sentido, é interessante observar a própria redação do Alvará Régio de 1º de abril de 1680, pelo qual foi estabelecido que os povos indígenas *foram os primeiros ocupantes e donos naturais destas terras*. Ou seja, não o são mais. Em razão desse reconhecimento, o Estado passa a estabelecer áreas exclusivas para os índios, buscando compensar as enormes perdas sofridas pelos índios e manter sobre um determinado grau de controle a expansão da colonização. A principal dessas compensações é a indicação e o reconhecimento de áreas que serão dedicadas à posse exclusiva dos indígenas.

O Alvará de 1º de abril de 1680 foi destinado ao tratamento das questões relativas aos povos indígenas do Grão-Pará mas, apesar disso, pode ser apresentado como um marco para a legislação dedicada aos problemas indigenistas em geral, pois, pelo Alvará de 8 de maio de 1758, foi determinada a extensão das determinações ora examinadas para todos os povos indígenas do Brasil. O § 4º do Alvará de 1680 determinou fossem destinadas terras aos índios que descessem do sertão. Havia a proibição explícita de que os silvícolas fossem mudados das terras a eles destinadas, sem que assim o consentissem. Os índios não estavam obrigados ao pagamento de qualquer tributo por suas terras.

Evidentemente que a distância entre a norma legal e a sua aplicação concreta sempre foi muito grande em nosso país. Imagine-se quão descumpridas deveriam ser as regras citadas. Fato é que a legislação colonial reconhecia aos índios o direito exclusivo das terras necessárias à sua sobrevivência. Observe-se que a Carta Régia de 9 de março de 1718 reconheceu que os índios *são livres, e isentos de minha jurisdição que os não podem obrigar a saírem de suas terras, para tomarem um modo de vida que se não agradarão*. É importante observar que, se foi estabelecida uma proibição legal, isso se deveu ao fato de que, evidentemente, a situação proibida, de fato, ocorria. Do contrário, não haveria a necessidade da proibição.

A “*guerra justa*”, movida contra os povos indígenas, permitia que as terras indígenas fossem subtraídas de seu domínio. As terras passavam a assumir a condição de terras devolutas. A definição legal de terras devolutas, contudo, somente foi estabelecida de forma definitiva pela Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. As terras devolutas, dentre outras destinações, podiam ser afetadas à colonização dos indígenas. Elas eram concedidas a sesmeiros que, por caírem em comisso, retornavam ao domínio do Poder Público.

José Afonso da Silva (SILVA, XXX, p. 728) aponta que os dispositivos legais referentes às terras indígenas constituíam o instituto jurídico do *indigenato*, que é fonte primária de Direito e não se confunde com a simples posse. Esse instituto jurídico extrapola os limites do Direito Civil. Não é Direito comum, mas Direito especializado. Trata-se de um direito à própria sobrevivência das comunidades indígenas.

O século XIX é considerado pelos especialistas como um período no qual houve um grande retrocesso no reconhecimento dos direitos dos povos nativos. Tal fato se deu, em grande parte, em razão do Ato Adicional de 1834, que atribuiu competência às Assembleias Provinciais para legislar, concorrentemente, com o Governo Geral e a Assembleia Nacional sobre assuntos indígenas. Obviamente que as oligarquias locais passaram a ter mais poder jurídico e, portanto, foram

dotadas dos instrumentos necessários para a usuração das terras indígenas.

20.3.2 O período republicano

Somente com o Estatuto do Índio é que as peculiaridades da posse indígena sobre as suas terras foram reconhecidas. A Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, em seu artigo 23, dispõe:

Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detêm e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil.

20.4 AS TERRAS INDÍGENAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

20.4.1 Antecedentes

Os direitos dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam no Brasil é constitucional desde a Constituição de 1934. Pela Carta de 1934, à União competia promover a interação dos aborígenes à *comunidade nacional* (art. 5º, XIX, *m*). Da mesma forma, aquela Carta Política determinava fosse respeitada a posse dos indígenas (silvícolas: denominação da época) sobre as terras que *ocupassem permanentemente*, sendo-lhes vedada a alienação (art. 129). O notável Pontes de Miranda(s/d, p. 348) assim tratou do artigo 129: “[...] *respeita-se a “posse” do silvícola, posse a que ainda se exige a localização permanente [...]. Desde que há a posse e a localização permanente [grifamos], a terra é do nativo, porque assim o quis a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte de silvícolas, ou em que se achem permanentemente localizados [grifamos] e com posse os silvícolas, é nula*”. Aquela Constituição inaugurou uma tradição constitucional que, de modo geral, consolidou o reconhecimento da posse indígena. A própria “Constituição de 1937”, notoriamente autoritária, reconheceu a posse dos “silvícolas” sobre as terras que ocupavam em caráter permanente.¹

Com a redemocratização, a Constituição de 1946 tratou da matéria com grande vigor. Manteve-se a competência privativa da União para legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunidade nacional (art. 5º, XV, *r*),² persistindo-se no respeito à posse das terras que *ocupassem permanentemente* (art. 216).³ Quanto à interpretação do artigo 216 da carta de 1946, o Supremo Tribunal Federal, por voto do saudoso Ministro Vítor Nunes Leal, examinou a questão em profundidade no Recurso Extraordinário nº 44.485: “*Aqui não se trata do direito de propriedade comum; o que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena, sob a guarda e administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes não têm disponibilidade de terras. O objetivo da Constituição Federal é que ali permanecem os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a sobrevivência dessa tribo, como para estudo dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual. Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos: trata-se do habitat de um povo. Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam, era necessária à sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior; se o Estado a diminuiu de dez mil hectares, amanhã a reduzirá em outros dez, depois mais dez, e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato, até o território da aldeia, porque ali é que a ‘posse’ estaria materializada nas malocas.*” Sobre o tema, Pontes de Miranda (1953, p. 335-336) assim comentou o dispositivo constitucional de 1946: “*O texto respeita a ‘posse’ do silvícola, posse a que ainda se exige o pressuposto da localização permanente. O juiz que conhecer de alguma questão de terras deve aplicar o art. 216, desde que os pressupostos estejam provados pelos silvícolas, ou constem dos autos, ainda que algumas das partes ou terceiro exiba título de domínio. Desde que há posse e a localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o diz a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte de silvícolas, ou em que se achem permanentemente localizados e com posse, os silvícolas, é nula, por infração da Constituição. Aquelas mesmas que forem em virtude do art. 216 reconhecidas como de posse de tais gentes, não podem se alienadas. Os juízes não podem expedir mandados contra silvícolas que tenham posse, e nas terras, de que se trata, se localizaram com permanência. A proibição de alienação tem como consequências: a) a nulidade de qualquer ato de disposição incluídos aqueles que só se referem a elementos do direito de propriedade ou da posse (usufruto, garantia real, locação); b) não há usucapião contra silvícola ainda que trintenali; c) as sentenças que adjudiquem tais terras a outrem são suscetíveis de rescisão, dentro do prazo de preclusão, por infringirem texto constitucional.*”

Com o debacle do regime de 46, a Constituição de 1967 manteve o reconhecimento da posse das terras ocupadas em caráter permanente pelos silvícolas, outorgando-lhes, ainda, o usufruto permanente dos recursos naturais e das utilidades nelas existentes (art. 186).⁴ A instituição do usufruto indígena implicou no reconhecimento de que as terras ocupadas pelos aborígenes eram de propriedade da União (art. 4º, IV).⁵ O recrudescimento do regime autoritário expresso pela redação dada à Carta de 1967 pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, outorgada à Nação pela força do Ato Institucional nº 5, manteve a tradição de reconhecimento da posse dos indígenas em relação às terras por eles ocupadas e, sob pressão internacional, declarou nulos todos os atos jurídicos que tivessem por objeto a posse, o domínio ou a mera ocupação das terras habitadas pelos silvícolas (art. 198, §§ 1º e 2º).⁶ O “constituinte” foi mais adiante e determinou que a extinção e nulidade dos atos jurídicos passados e que versassem sobre terras ocupadas pelos indígenas não daria margem à indenização. Medida extrema que refletia o regime político da época. Vale ressaltar que as terras ocupadas pelos indígenas continuaram guardando a natureza jurídica de terras públicas federais,⁷ assim como já ocorria anteriormente.

A constitucionalização do tema estabeleceu o dies a quo para o reconhecimento da posse indígena que é o da promulgação da Constituição de 1934 (16 de julho de 1934). Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 646.933: “*como a proteção constitucional aos índios iniciou-se com a promulgação da Constituição Federal de 1934, e, nessa data, as terras já estavam há muito sendo ocupadas pelos antepassados dos recorridos, mediante justo título, não há qualquer direito a socorrer a pretensão da FUNAI*”. (Ministro Uyeda)

No regime Constitucional de 88 o leading case do Supremo Tribunal Federal é o da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que definiu como dies a quo a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) que, por isso, serve como marco temporal da ocupação da terra pelos indígenas e a tradicionalidade da sua ocupação, como se depreende do seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Carlos Ayres de Brito: “*I – o marco temporal da ocupação. Aqui, é preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) como insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios, ‘dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam’. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988. Marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de área indígena. Mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição anterior. É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro [destaque no original]. Com o que se evita, a um só tempo: a) a fraude da subtânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da demarcação [grifamos]; b) a violência da expulsão de índios para descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras, à data da vigente Constituição. Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica [destaque no original] da questão indígena nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígene. Exclusivo uso e fruição [destaque no original] (usufruto é isso, conforme Pontes de Miranda) quanto às ‘riquezas do solo, dos rios e dos lagos’ existentes na área objeto de precisa demarcação (§ 2º do art. 231), devido a que ‘os recursos minerais, inclusive os do subsolo’, já fazem parte de uma outra categoria de ‘bens da União’ (inciso IX do art. 20 da CF); II – o marco da tradicionalidade da ocupação [destaque no original]. Não basta, porém, constatar uma ocupação fundiária coincidente com o dia e ano da promulgação do nosso Texto Magno. É preciso ainda que esse estar coletivamente situado em certo espaço fundiário se revista do caráter da perdurabilidade. Mas um tipo qualificadamente tradicional [destaque no original] de perdurabilidade da ocupação indígena, no sentido entre anímico e psíquico de que viver em*

determinadas terras é tanto pertencer a elas quanto elas pertencerem a eles, os índios (‘Anna Pata, Anna Yan’: ‘Nossa Terra, Nossa Mãe’).”⁸

A importância do tema é tanta que a Constituição Federal dedica diversos tópicos ao problema. As terras indígenas são, inclusive, tratadas no dispositivo constitucional voltado para a ordem econômica e social. Veja-se o § 2º do artigo 176, que exige lei específica para o desenvolvimento da atividade garimpeira em terras indígenas. Esta não é, contudo, a única referência constitucional à garimpagem em áreas indígenas. A relevância da matéria é extraordinariamente grande e o próprio ato das disposições constitucionais transitórias estabeleceu um prazo para a demarcação de todas as terras indígenas. Por força do artigo 67 do ADCT, a demarcação deveria estar concluída em prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal. Desnecessário dizer que a determinação constitucional não foi cumprida.

Foi reconhecido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. À União Federal foi atribuída a tarefa de demarcação de todas as áreas indígenas. Houve, como já foi visto, a fixação de período fixo para que a demarcação fosse concluída.

O conceito jurídico de *terra tradicionalmente ocupada* pelos índios tem os seus alicerces no próprio corpo da Constituição:

- são as terras utilizadas para atividades produtivas; as imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar dos índios e as necessárias à reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (art. 231, § 1º);
- são destinadas à posse permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 2º).

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, portanto, não são terras que “imemorialmente” tenham sido ocupadas pelos indígenas. Podem ou não estar nesta condição. O fundamental do conceito é que as terras sejam essenciais ao modo indígena de viver, nada mais. Não se cogita da temporalidade do conceito, observado o dia 5 de outubro de 1988.

As terras indígenas são terras federais e pertencentes ao domínio exclusivo da União. A própria União, entretanto, sofreu limitação de seus direitos de proprietária. O constituinte instituiu um *usufruto exclusivo* dos índios sobre as riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. E mais: determinou a inalienabilidade e a indisponibilidade das terras indígenas, sendo imprescritíveis os direitos sobre as mesmas.

A inalienabilidade e a imprescritibilidade que gravam as terras indígenas opõem-se à União e às próprias comunidades indígenas, que, elas também, não poderão efetuar qualquer negócio jurídico que implique qualquer tipo de disposição ou alienação de seus direitos sobre as terras.

A importância das terras indígenas para as diferentes nações indígenas é tão grande que a Lei Fundamental estabeleceu uma *inamovibilidade indígena*. Os índios foram constitucionalmente vinculados, na condição de povos, ao seu torrão. A remoção temporária de um povo indígena de suas terras somente pode ser feita em casos de epidemia ou catástrofe que ponha em risco a própria sobrevivência da população indígena. Em ocorrendo a hipótese mencionada, a remoção deverá ser referendada pelo Congresso Nacional. Admite-se, ainda, que, mediante deliberação do Congresso Nacional, possam os índios ser removidos de suas terras, quando em risco a soberania nacional. Cessados os riscos, deverá haver a mediata realocação dos índios em suas terras de origem.

A própria Constituição determina a absoluta nulidade e extinção de qualquer ato jurídico que tenha por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas. Igualmente nulos e extintos são quaisquer atos que tenham por objeto a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas, sem aprovação do Congresso Nacional. A Lei Maior ressaltou o interesse público da União, tal qual definido em lei complementar. As nulidades tratadas no § 6º do artigo 231 não ensejam qualquer indenização, excetuadas as benfeitorias realizadas de boa-fé.

20.4.2 Direitos adquiridos sobre as terras indígenas

Um problema importante e que não pode deixar de ser abordado neste trabalho é o que diz respeito a pretensos direitos adquiridos por terceiros sobre as terras indígenas. Como estabelecido pelo § 6º do artigo 231 da Lei Fundamental, não é devida qualquer indenização em razão de atos ou negócios jurídicos praticados por terceiros e que envolvam terras indígenas. A única exceção é para as benfeitorias feitas por terceiros de boa-fé. A Constituição de 1988 *não criou novas áreas indígenas*. Ao contrário, limitou-se a reconhecer as já existentes. Tal reconhecimento, contudo, não se cingiu às terras indígenas já demarcadas. As áreas demarcadas, evidentemente, não necessitavam do reconhecimento constitucional, pois, em nível da legislação infraconstitucional, já se encontravam afetadas aos povos indígenas. O que foi feito pela Constituição foi o reconhecimento de situações fáticas, isto é, a Lei Fundamental, independentemente de qualquer norma de menor hierarquia, fixou critérios capazes de possibilitar o reconhecimento jurídico das terras indígenas. Não se criou direito novo.

É preciso estar atento ao fato de que as terras indígenas foram reconhecidas como afetadas aos diversos grupos étnicos de origem pré-colombiana, em razão do expresso reconhecimento da incidência de *direito originário*, isto é, direito precedente e superior a qualquer outro que, eventualmente, se possa ter constituído sobre o território dos índios. A demarcação das terras tem única e exclusivamente a função de criar uma delimitação espacial da titularidade indígena e de opô-la a terceiros. A demarcação não é constitutiva. O que constitui o direito indígena sobre as suas terras é a própria presença indígena e a vinculação dos índios à terra, desde que anterior a 5 de outubro de 1988. Ora, qualquer construção, qualquer empreendimento encontrado no interior das áreas indígenas, sem expressa previsão legal ou, ainda, por autorização contratual firmada entre as partes, deve ser tido, a partir da Constituição de 1988, como violador dos direitos originários dos indígenas sobre as suas terras. É não indenizável, a menos que o terceiro interessado comprove, judicialmente, desconhecer o caráter indígena do território no qual tenha realizado o empreendimento em tela. Observe-se que, aqui, o terceiro não poderá invocar em sua defesa a norma contida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, pois houve *expressa exclusão de quaisquer direitos adquiridos*. A única exceção é em relação às benfeitorias de boa-fé.

20.4.3 Classificação das terras indígenas pelo Estatuto do Índio

O Estatuto do Índio, como não poderia deixar de ser, possui uma lista de artigos voltados unicamente para o trato das questões referentes às terras indígenas. Em qualquer parte do território nacional, a União pode demarcar e destinar áreas para a utilização exclusiva dos povos indígenas. Tais áreas podem ser adquiridas por compra, por desapropriação ou por qualquer outro modo de transmissão de domínio.

Nos termos do Estatuto, as terras indígenas podem ser classificadas em:

- *reserva indígena* – área destinada a servir de *habitat* a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência;
- *parque indígena* – área contida em terra na posse dos índios, cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região;
- *colônia agrícola indígena* – área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional;⁹
- *território federal indígena* – é a unidade administrativa subordinada à União, instituída em região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios.

20.4.4 A extração de madeira nas terras indígenas

Esse é mais um dos pontos extremamente polêmicos dentro de um tema que é essencialmente polêmico. É indiscutível que a maior parte das terras indígenas é altamente rica em diversas madeiras nobres e raras. Penso que o problema cuja abordagem ora se inicia tem duas vertentes distintas, ainda que ambas tenham uma origem comum, que é o descaso e abandono com que são tratados os índios brasileiros. Refiro-me à exploração clandestina de madeira nas áreas indígenas e à exploração realizada pelos próprios índios. Desta última o exemplo mais eloquente é a extração de mogno no território Kaiapó.

a) *Exploração clandestina* – As dimensões necessárias para que uma exploração de área madeireira seja comercialmente viável demonstram cabalmente que, de fato, estas não possam existir sem a mais ampla convivência daqueles que deveriam ser responsáveis pela proibição da atividade. A “clandestinidade” da extração de madeira em áreas indígenas é economicamente extremamente importante, sendo responsável pela maior parte do mogno exportado pela América Latina. (DURNING, 1993, p. 123) O que se sabe a respeito da exploração “clandestina” de madeira é que esta encontra, não raras vezes, um ambiente favorável, na medida em que é uma atividade de “desenvolvimento econômico”. A partir do momento em que “constata” a existência de uma atividade “clandestina” de exploração de madeira e, diante de uma realidade irreversível, começa todo um processo com vistas à “regularização” da exploração. Muitos são os argumentos apresentados em favor de tais “regularizações”. O mais forte é sempre o de que os índios serão “beneficiados” com os enormes recursos de que passarão a dispor.

A total falta de recursos destinados às aldeias indígenas serve de armadilha para que os índios fiquem em uma situação embaraçosa, pois, diante da falta de recursos para a assistência médica, educacional, sanitária etc., busca-se criar uma situação que tem por objetivo forçá-los a admitir a exploração desenfreada de madeiras nobres em suas áreas.

b) *Exploração realizada pelos índios ou com autorização destes* – A invasão das terras indígenas pelos mais diversos tipos de invasores e a omissão, quase que reiterada, das autoridades públicas em assegurar que as áreas indígenas permaneçam na posse exclusiva dos índios têm gerado situações paradoxais e bastante graves. Não poucas vezes, ante situações de fato, praticamente irreversíveis, os próprios índios, mediante “contratos”, autorizam a exploração de madeira e mesmo de garimpo em suas terras.

A complexidade do problema é muito grande, pois suscita questões referentes à autonomia dos povos indígenas acerca do grau de liberdade que é dado aos índios para a exploração dos recursos econômicos eventualmente existentes em suas terras.

Em primeiro lugar, penso que deve ser examinado qual o fundamento jurídico que serve de base para que *terras públicas federais* sejam afetadas diretamente às diversas nações indígenas em *usufruto permanente*. Ora, conforme o mandamento constitucional contido no artigo 231, § 1º, tais terras são aquelas “*imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural*”; desnecessário dizer, portanto, que a terra foi tida pela Lei Fundamental como um elemento essencial à própria sobrevivência dos povos indígenas como grupos étnicos e culturais plenamente diferenciados. O legislador constituinte entendeu, acertadamente, que qualquer risco que as terras indígenas possam sofrer significa risco aos próprios índios.

Dando mais consistência ao *caput* do artigo 231, o § 4º dispõe que: “*as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis*”. Evidentemente que no conceito de terras indígenas não está incluindo, apenas, o chão, mas, ao contrário, todo o conjunto de bens que nelas existem e, em especial, o patrimônio ecológico nelas abrigado. É, aliás, um princípio elementar de direito o de que os bens móveis se vinculam aos bens imóveis nos quais estão inseridos. Ora, se as terras indígenas são inalienáveis, parece-me que os seus acessórios (riquezas minerais, madeiras etc.) também o são. Não se pretende que tais recursos sejam tidos como intocáveis, mas necessário se faz que a utilização dos mesmos não se faça de forma predatória e potencialmente causadora de riscos para a própria sobrevivência das comunidades indígenas. Essa concepção antropológica e legal já foi objeto de confirmação judicial, durante o regime da Carta de 69, pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, conforme decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 31.078 – Mato Grosso, relator o Ministro Adhemar Raymundo, em cuja ementa se pode ler o seguinte:

[...] O objetivo da norma Constitucional, ao transformar as áreas ocupadas pelos índios em terras inalienáveis, foi o de preservar o habitat de uma gente, sem cogitar de defender a sua posse, mas dentro do sadio propósito de preservar um patrimônio territorial, que é a razão de ser da própria existência dos índios [...]. (GUIMARÃES, 1993, p. 35)

O reconhecimento da autonomia cultural dos povos indígenas se faz no âmbito do Estado brasileiro e implica, evidentemente, a construção de *direitos e deveres*, tanto para a chamada sociedade envolvente quanto para os próprios povos indígenas que, também eles, possuem obrigações para com os outros setores e etnias de nossa sociedade multiétnica. O dever de conservação do meio ambiente, tal qual estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, é imposição feita a todos os brasileiros, sem qualquer distinção racial ou étnica.

É de se observar que a extração de madeira por grupos indígenas, quase sempre, é duplamente um mau negócio, pelo menos para os índios. É um mau negócio porque, comercialmente, o preço da madeira que é pago para os índios pelas madeireiras é *sempre abaixo do real preço de mercado*. Em segundo lugar, é um mau negócio, pois as explorações, em geral, são feitas sem qualquer critério de sustentabilidade e, em médio e longo prazos, acarretarão gravíssimos riscos para a própria sobrevivência da comunidade envolvida.

Em algumas comunidades indígenas, a extração de madeira já chegou a atingir proporções alarmantes, tal é o caso da extração de mogno pelos índios Kaiapó. Permito-me transcrever o seguinte texto sobre o particular:

O mogno extraído das reservas kaiapós representa parte significativa do total das exportações brasileiras. Para se ter uma ideia basta dizer que do total das exportações dessa madeira em 1987, 163.271m3 segundo dados da Cacex, cerca de 69% foram extraídos das áreas dos grupos kaiapós das aldeias A'Ukre, Gorotire, Kikretum, Kokraimoro e Kuben-Kran-Ken. O ano de 1987 parece ter sido um ano extremamente produtivo para as atividades das madeireiras nas áreas Kaiapó, como indica o declínio da atividade no ano seguinte, 1988, quando se retirou “apenas” 69.421,736m3, ou seja, pouco mais da metade do ano anterior. Especulativamente pode-se inferir que a queda na atividade se deva ao esgotamento das reservas pela exploração. Ainda assim, esse total de mogno extraído das reservas kaiapó, em 1988, ficou acima do total das exportações brasileiras dessa madeira nos anos de 1985 e 1986 somados.¹⁰

Esse fato tem causado, inclusive, divisões entre os kaiapós, pois muitos dos caciques são frontalmente contra a política de extração de madeira que vem sendo desenvolvida de forma bastante agressiva por determinados setores do povo kaiapós. Em realidade, o que se constata é que os kaiapós chegaram a uma situação limite. As suas terras, situadas na região Sul do Estado do Pará, sempre foram alvo de grande pressão, seja por parte de garimpeiros, seja por parte de madeireiras, e mesmo pressão agropecuária. A inércia e incapacidade do governo em realizar a demarcação plena da terra kaiapó serviram de base para a consolidação de situação fática cuja irreversibilidade a curto prazo é bastante evidente. A pressão internacional por madeiras nobres, conjugada à indiferença dos órgãos governamentais, está fazendo com que uma boa parcela de um importante grupo indígena, em nome de ganhos fáceis, esteja alienando o seu futuro enquanto povo. De certa forma, a própria Funai é interessada na devastação que se vem verificando, pois, como se sabe, é a administradora da chamada “renda indígena”. Veja-se que a Lei nº 6.001/73, por seu artigo 46, condiciona a autorização de corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de preservação permanente, à existência de “programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento”. É evidente por si mesmo que nenhuma das atividades mencionadas guarda qualquer relação com o modo indígena de viver.

É importante observar que o tipo de exploração em tela é nula de pleno direito, em razão do § 6º do artigo 231 da Lei Fundamental, que determina a nulidade de qualquer contrato que tenha por objeto a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e lagos existentes em terras indígenas, ressalvado o interesse público da União, conforme definido em lei complementar. Tal nulidade, como é evidente, abrange contratos firmados por índios ou por brancos.

20.4.5 Terras indígenas e soberania nacional

A quantidade de interesses que estão envolvidos em toda a problemática referente às terras indígenas tem possibilitado o surgimento de pontos de vista completamente distorcidos sobre o assunto. Penso que, ainda que não se trate de novidade, deve ser ressaltado o fato de que *as terras indígenas são terras de propriedade da União Federal*, isto é, pertencem ao Estado brasileiro. A partir dessa inquestionável realidade jurídica, não só de direito interno, mas, sobretudo, de direito internacional, é que se deve examinar toda a complexa situação das fronteiras e da soberania.

Fala-se, atualmente, em uma profunda mudança no conceito de soberania nacional. Tal mudança seria decorrente de alterações estruturais na ordem econômica internacional, com um aprofundamento cada vez mais presente da internacionalização da economia.

A importância que a Amazônia dentro do atual contexto internacional é, sem dúvida, crescente. Sabe-se que as riquezas escondidas na Amazônia são incalculáveis. Não se fala, aqui, de riquezas minerais, pois estas são perfeitamente detectáveis pelos modernos sistemas de satélite e já foram levantadas, em grande parte, pelo Projeto Radam. A principal riqueza da Amazônia está na sua biodiversidade. É indiscutível que, com o atual nível de conhecimento, não se pode ter a real dimensão de todas as substâncias químicas que poderão vir a ser sintetizadas a partir da flora amazônica. A proteção dessas riquezas é um imperativo. Evidentemente que, em razão dessas e de outras questões extremamente graves, como o tráfico internacional de entorpecentes e armas, existe a necessidade real e concreta da proteção das áreas de fronteiras do país. O domínio das terras nas regiões fronteiriças sempre foi motivo de divergência jurídica, vez que, por muitos anos, não existiu uma lei capaz de definir categoricamente os direitos em relação a tais terras.¹¹ Pela Constituição vigente, não há a menor dúvida de que as terras situadas na faixa de fronteira pertencem à União Federal. No caso das terras indígenas que estejam situadas na faixa de fronteira, é indiscutível que estas pertencem à União por dupla afetação: por estarem na faixa de fronteira e por serem terras indígenas.

Há quem pretenda ver uma incompatibilidade entre a presença dos índios na faixa de fronteira e a preservação da segurança nacional. Há, também, quem pretenda ver uma impossibilidade da presença do Estado em suas fronteiras, se estas estiverem afetadas aos povos indígenas, em razão de que tal presença seria nociva aos índios. Penso que ambas as posições são extremadas e não consultam ao interesse nacional. Não falo de um interesse nacional abstrato, mas, muito pelo contrário, de um interesse que se faz sentir na possibilidade de cada brasileiro viver dignamente e de acordo com os seus hábitos, tradições e características culturais mais profundas. É óbvio que a preservação física, cultural e espiritual dos povos indígenas é do interesse nacional, assim como a preservação da integridade das fronteiras. Os dois bens jurídicos são igualmente relevantes e não conflitantes, pois ambos possuem previsão constitucional.

O que tem sido conflitante é o conjunto de políticas adotadas, o despreparo e, não raras vezes, a má-fé com que o assunto é encarado, independentemente de quem sejam os atores. A ótica integracionista e a sua contraposição, isto é, aquela que julga terem os índios direitos superiores aos dos demais brasileiros, são nocivas aos legítimos interesses brasileiros, de todos os brasileiros. Se é indiscutível a necessidade de proteção de nossas fronteiras, é igualmente indiscutível que projetos como o *Calha Norte* mostraram-se equivocados e incapazes de gerar frutos socialmente úteis. O problema, contudo, é um dos mais graves enfrentados pelo país e deve ser discutido por toda a sociedade brasileira, de forma ampla e leal. A omissão em tal debate, penso, é o pior mal que se pode fazer ao país e, evidentemente, aos próprios índios.

20.5 A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS

A Constituição Federal determina, em seu artigo 67, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que: “*a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição*”. A norma jurídica, em si, não constitui novidade em nosso Direito Positivo, pois representa repetição e elevação em nível constitucional de norma existente no artigo 65 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Portanto, há mais de 40 anos, existe um prazo legal para que as terras indígenas fossem demarcadas *dentro de cinco anos*. Tanto a norma legal como a constitucional restaram letras mortas. As razões para que isso ocorra são inúmeras e não precisam ser examinadas neste trabalho.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens de propriedade da União (CF, art. 20, XI). Tais terras são destinadas à posse permanente dos indígenas e a eles cabe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em seu interior (CF, art. 231, § 2º). À União compete demarcar, proteger e fazer respeitar as terras indígenas (CF, art. 231, *caput*).

Terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são aquelas:

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (CF, art. 231, § 1º).

O Poder Executivo, em iniciativa, com o objetivo de agilizar a demarcação das terras indígenas, baixou o Decreto nº 22, de 4 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre o *processo administrativo* de demarcação das terras indígenas e dá outras providências.

Vale ressaltar que o Decreto nº 22/91 admite que os interessados não indígenas possam intervir no processo de demarcação. Visando a assegurar-lhes a defesa de eventuais direitos de terceiros, o § 7º do art. 2º do Decreto determina a publicação do relatório que caracteriza a terra indígena a ser demarcada. As impugnações ao relatório podem ser feitas no prazo de 30 dias (art. 2º, § 8º). Somente após o prazo do § 8º é que o Ministro da Justiça determinará a demarcação da terra indígena. Releva notar que, mesmo após terem sido demarcadas, as terras indígenas ainda dependem da homologação do Presidente da República. Existem, portanto, três momentos nos quais os eventuais interessados podem opor sua irrisignação ao processo de demarcação.

Por fim, é importante verificar uma lição do Direito Comparado, em matéria de tutela dos direitos indígenas:

Para compensar a desvantagem em que o processo de feitura de tratados colocou as tribos e para ajudar a implementar a responsabilidade federal, a Suprema Corte estabeleceu normas simpáticas aos interesses dos índios. A interpretação dos tratados deve ser construída, tal como eles eram compreendidos, pelos representantes tribais que participaram de sua negociação. (CANBY Jr., 1994, p. 88)

20.5.1 O Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996

Com a revogação do Decreto nº 22/91, foi baixado o Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996. Esse Decreto suscitou muita polêmica. O debate estava centrado, muito mais, na revogação do Decreto nº 22 do que propriamente na elaboração de um novo diploma legal.

O que o Decreto nº 1.775/96 fez foi estabelecer, de forma clara, os princípios de índole constitucional que já se encontravam presentes na norma anterior. O contraditório, já existente, por força de mandamento constitucional, tornou-se mais meridiano, mais límpido. Foi expressamente estabelecido que todos aqueles que se julgassem prejudicados com o reconhecimento administrativo de terras indígenas teriam um prazo para impugnar o reconhecimento. Das centenas de impugnações apresentadas, a sua imensa maioria era completamente destituída de sentido e foi rechaçada pela Fundação Nacional do Índio – Funai. O Ministro da Justiça, ao analisar as impugnações, sustentou a imensa maioria das decisões da Funai, solicitando diligências em alguns poucos casos.

O Decreto nº 1.775/96 busca fazer com que a caracterização das terras indígenas seja feita, única e exclusivamente, dentro das determinações constitucionais; isto é, que a Fundação Nacional do Índio – Funai, ao declarar uma área como terra indígena, verifique, efetivamente, se as terras cumprem as funções determinadas pelo artigo 231 da Lei Fundamental da República. O que se pode constatar é que o Decreto nº 1.775/96 criou uma obrigação técnico-profissional extremamente complexa e que deve ser bem desempenhada pelo órgão de proteção aos índios. Por outro lado, não se pode olvidar de que o maior rigor técnico exigido para a demarcação fará com que os procedimentos sejam mais seguros, gerando maior tranquilidade para a sociedade e para os próprios indígenas.

20.6 DIREITO DE PROPRIEDADE, TERRAS INDÍGENAS E ETNOGÊNESE

A Constituição de 1988 estabeleceu regras bastante abrangentes e, até mesmo, claras, para a definição dos direitos das populações indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ao mesmo tempo, o renascer democrático propiciado pela Lei Fundamental de 88 deu uma nova perspectiva para a defesa judicial dos direitos, em quaisquer de suas dimensões, sejam os individuais, sejam os difusos. O debate sobre a demarcação de Terras Indígenas não poderia, por óbvio, ser subtraído da apreciação judicial.

Muito embora seja de uma obviedade que beira o absurdo, não se pode pensar em Terras Indígenas sem a necessária presença do Índio. Contudo, definir quem é Índio é uma questão complexa e que, nem sempre, tem sido adequadamente considerada. As fortes desigualdades que marcam a sociedade brasileira tem dado base a que medidas compensatórias sejam adotadas pelas autoridades administrativas que tendem a assumir como único critério para o reconhecimento de uma população indígena a chamada *autoidentificação*. Como se verá, a autoidentificação é condição necessária mas não suficiente para que se declare uma população como

indígena. Para que se possa avançar na questão, veja-se a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, firmada pelo Brasil. Começemos pelas considerações da referida Convenção: “*Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram; Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm sofrido erosão frequentemente.*”

Penso que o acordo internacional está voltado basicamente para os povos coloniais que guardam relativo grau de alteridade em relação à sociedade nacional, dela se distinguindo por usos, costumes e tradições e que, em função de suas particularidades em relação às diferentes comunidades nacionais, sofrem ataques constantes e decisivos aos seus modos peculiares de vida. É conveniente que se examine o artigo 1º da Convenção: “*Artigo 1º 1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.*”

Assim, a Convenção se aplica aos povos que vivam em tribos e que (i) *as condições culturais, sociais e econômicas os distingam da comunidade nacional e que (ii) estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial.* Aplica-se, também, àqueles que reconhecidos como descendentes dos povos que habitavam os países coloniais quando do encontro de civilizações que *conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.* Logo, muito embora a autoidentificação seja um critério fundamental, ela não é o único critério.

A legislação brasileira específica não discrepa da Convenção, assim é que dispõe o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), em seu artigo 3º, inciso I: “*Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: I – Índio ou Silvícola – É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional.*” O item 2 da Convenção 161 da OIT, autoidentificação, é, critério que somente é, aplicável em conjunto com os demais, conforme o caso, e deve ser considerado fundamental, apenas e tão somente, como elemento capaz de dirimir dúvidas quanto ao reconhecimento ou não de uma etnia.

Conforme a dicção de Luiz Fernando Villares (2009, p. 33-34), um dos mais respeitados juristas em matéria de direito dos povos indígenas e ex-Procurador Geral da FUNAI entre 2005 e 2007: “*Tanto a Convenção 169 da OIT como o Estatuto do Índio definem que a origem histórica, a autoidentificação, a identificação, a identificação pela comunidade e a conservação de determinadas características culturais e institucionais são necessárias para definir o índio. Não parece que a Convenção 169 estabeleça autoidentificação como o único critério prescrito. Para a Convenção, ‘a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos’. Ora, se é um critério fundamental, é o critério imprescindível, sem o qual uma pessoa não pode ser considerada como índio, então existem outros não fundamentais, mas que são válidos. Por prever e permitir a existência de outros critérios, a Lei 6.001/73 não foi revogada.*”

Por outro lado, a Convenção, com essa norma, proíbe que alguém seja identificado como índio, independentemente de sua vontade e de seu autorreconhecimento. É a proibição de rotular alguém numa qualificação em que o indivíduo mesmo não se reconheça, em algumas oportunidades utilizada para segregar e discriminar a pessoa, impingindo-lhe um status renegado por ela.”

Está claro que o reconhecimento de Terras Indígenas somente pode ser feito após o reconhecimento da etnia indígena. A propósito, veja-se atualíssima decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo que a existência de título de propriedade que demonstre longa cadeia dominial gera a presunção da inexistência da presença indígena na área em data anterior a 5 de outubro de 1988.¹² “**Proprietários de fazenda na Terra Indígena Arroio-Korá obtêm liminar suspendendo demarcação.** O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, suspendeu os efeitos de decreto presidencial do último dia 21, que homologou a demarcação da Terra Indígena denominada Arroio-Korá, no município de Paranhos (MS). Gilmar Mendes concedeu liminar em Mandado de Segurança (MS 28541) impetrado pelos proprietários da Fazenda Iporã, até decisão final de mérito. A terra indígena tem 7.175 hectares, dos quais 184 hectares são ocupados pela fazenda. A decisão alcança apenas esta área. Em sua decisão, o presidente do STF afirma que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar. Segundo ele, ‘são plausíveis os argumentos quanto à violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório’. Além disso, documentos atestam que o registro do imóvel é de 1924, data muito anterior; portanto, a 5 de outubro de 1988 (data da promulgação da Constituição Federal), marco fixado pelo STF no caso Raposa Serra do Sol para o reconhecimento, aos índios, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O ministro verificou que há documento comprovando a transferência da propriedade do imóvel a particulares e ratificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). ‘O periculum in mora parece evidente. O decreto homologatório foi publicado no último dia 21 de dezembro de 2009 e, a qualquer momento, poderá a União proceder ao registro no cartório imobiliário, com a consequente transferência definitiva de propriedade’, afirmou o presidente do STF. Outra circunstância considerada pelo ministro Gilmar Mendes foi a notícia de que a publicação do decreto homologatório gerou a movimentação de lideranças indígenas para, nos próximos dias, perpetrarem atos de ocupação das terras demarcadas. ‘Esses motivos são suficientes para o acolhimento do pedido de medida liminar’, concluiu. **Argumentos dos proprietários.** No mandado de segurança, os donos do imóvel rural – Maxionilio Machado Dias e Hayde Castelani Dias – afirmam que adquiriram a fazenda há décadas e, desde então, a utilizam de forma produtiva, com atividade agropastoril para seu sustento. Relatam ainda que integram uma ação que tramita na Justiça Federal em Ponta Porã (MS) pelos demais proprietários das áreas abrangidas pelo procedimento demarcatório. Entretanto, o presidente da República teria desconsiderado o fato de que a questão está sendo analisada no Judiciário. Os proprietários alegam ainda que o decreto seria ilegal diante da ilegitimidade do presidente para demarcar terras indígenas; competência, no entender dos impetrantes, exclusiva do Congresso Nacional. Para os proprietários, houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois não lhes foi conferida a oportunidade de se manifestarem previamente à edição do decreto. Foi invocado o Decreto 1.775/1996 que garante a participação dos interessados em todas as fases do processo administrativo. Os impetrantes afirmam que sequer foram notificados de sua deflagração. Os donos da Fazenda Iporã alegam que, se existiu alguma aldeia indígena na área em que está localizada a propriedade, trata-se de aldeamento extinto porque os índios que hoje estão no local o teriam invadido em 2001 e, desde então, estão dificultando o acesso às terras. O estudo antropológico realizado pela FUNAI seria falho, na opinião da defesa dos fazendeiros, na medida em que teria se baseado exclusivamente em entrevistas com os índios. Por fim, sustentam que a Fazenda Iporã foi transferida pelo estado do Mato Grosso ao domínio privado no ano de 1924, tendo sido ocupada apenas por não índios.”

20.7 GESTÃO TERRITORIAL DE TERRAS INDÍGENAS

O Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Na verdade, cuida-se de uma política federal haja vista que as terras indígenas estão compreendidas no rol dos bens públicos federais, não havendo que se falar em competências estaduais ou municipais sobre o tema. A PNGATI foi criada com “o objetivo de garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente”.

APNGATI se alicerça sobre duas “ferramentas” fundamentais para a gestão ambiental e territorial, a saber: (i) *Etnomapeamento* que é o mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas; e (ii) o *Etnozoneamento* que é o instrumento de planejamento participativo que visa à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento.

As diretrizes da PNGATI são as seguintes: (i) reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, tradições e especificidades de cada povo indígena; (ii) reconhecimento e valorização das organizações sociais e políticas dos povos indígenas e garantia das suas expressões, dentro e fora das terras indígenas; (iii) protagonismo e autonomia sociocultural dos povos indígenas, inclusive pelo fortalecimento de suas organizações, assegurando a participação indígena na governança da PNGATI, respeitadas as instâncias de representação indígenas e as perspectivas de gênero e geracional; (iv) reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres indígenas e do uso de seus conhecimentos e práticas para a proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais imprescindíveis para o bem-estar e para a reprodução física e cultural dos povos indígenas; (v) contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos biomas das terras indígenas por meio da proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações dos povos indígenas; (vi) proteção territorial, ambiental e melhoria da qualidade de vida nas áreas reservadas a povos indígenas e nas terras indígenas; (vii) proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por povos indígenas isolados e de recente contato; (viii) implementação da PNGATI para povos e comunidades indígenas, cujas terras se localizam em área urbana, naquilo que seja compatível, e de acordo com suas especificidades e realidades locais; (ix) proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conhecimentos dos povos indígenas e de seus sistemas de manejo e conservação dos recursos naturais; (x) reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão ambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições ambientais necessárias à reprodução física, cultural e ao bem-estar dos povos e comunidades indígenas; (xi) garantia do direito à consulta dos povos indígenas, nos termos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004; (xii) reconhecimento dos direitos dos povos indígenas relativos a serviços ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais que promovem em suas terras, nos termos da legislação vigente; e (xiii) promoção de parcerias com os governos estaduais, distrital e municipais para compatibilizar políticas públicas regionais e locais e a PNGATI.

20.7.1 Objetivos da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas

A política ambiental das terras indígenas possui objetivos específicos que buscam implementar a Política Nacional do Meio Ambiente especialmente para o interior das terras indígenas. Os objetivos específicos se dividem em 7 (sete) “eixos”, isto é, em diretrizes a serem implantadas pelos órgãos encarregados da gestão.

O eixo 1 – proteção territorial e dos recursos naturais, tem os seguintes objetivos:

- promover a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites;
- promover a participação dos povos, comunidades e organizações indígenas nas ações de proteção ambiental e territorial das terras indígenas, respeitado o exercício de poder de polícia dos órgãos e entidades públicos competentes;
- contribuir para a proteção dos recursos naturais das terras indígenas em processo de delimitação, por meio de ações de prevenção e de defesa ambiental pelos órgãos e entidades públicos competentes, em conjunto com os povos, comunidades e organizações indígenas;
- promover a elaboração, sistematização e divulgação de informações sobre a situação ambiental das terras indígenas, com a participação dos povos indígenas;
- apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam localizados fora dos limites de suas terras;
- promover ações de proteção e recuperação das nascentes, cursos d’água e mananciais essenciais aos povos indígenas;
- apoiar o monitoramento das transformações nos ecossistemas das terras indígenas e a adoção de medidas de recuperação ambiental;
- assegurar, sempre que possível, que bens apreendidos em decorrência de ilícitos ambientais praticados em terras indígenas sejam revertidos em benefício dos povos e comunidades indígenas afetados, na forma da legislação vigente;
- promover o etnozoneamento de terras indígenas como instrumento de planejamento e gestão territorial e ambiental, com participação dos povos indígenas; e
- promover e garantir a integridade ambiental e territorial das terras indígenas situadas nas áreas de fronteira, por meio de ações internas e de acordos binacionais e multilaterais, a fim de combater e controlar os ilícitos transfronteiriços, com especial atenção à proteção da vida de mulheres e homens indígenas, de todas as gerações.

O eixo 2 – governança e participação indígena, está voltado para os seguintes objetivos:

- promover a participação de homens e mulheres indígenas na governança, nos processos de tomada de decisão e na implementação da PNGATI;
- promover a participação dos povos indígenas e da FUNAI nos processos de zoneamento ecológico-econômico que afetem diretamente as terras indígenas;
- promover o monitoramento da qualidade da água das terras indígenas, assegurada a participação dos povos indígenas e o seu acesso a informações a respeito dos resultados do monitoramento;
- apoiar a participação indígena nos comitês e subcomitês de bacias hidrográficas e promover a criação de novos comitês em regiões hidrográficas essenciais aos povos indígenas;
- promover a participação dos povos indígenas nos fóruns de discussão sobre mudanças climáticas; e
- realizar consulta aos povos indígenas no processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que afetem diretamente povos e terras indígenas, nos termos de ato conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente.

O eixo 3 – áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, têm os seguintes objetivos:

- realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas no processo de criação de unidades de conservação em áreas que os afetem diretamente;
- elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das áreas de sobreposição das terras indígenas com unidades de conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos, costumes e tradições dos povos indígenas;
- promover a participação indígena nos conselhos gestores das unidades de conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas; e
- assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das unidades de conservação contíguas às terras com presença de índios isolados ou de recente contato.

O eixo 4 – prevenção e recuperação de danos ambientais, estrutura-se em torno dos seguintes objetivos:

- promover ações com vistas a recuperar e restaurar áreas degradadas nas terras indígenas;
- promover ações de prevenção e controle de desastres, danos, catástrofes e emergências ambientais nas terras indígenas e entornos;
- promover ações de prevenção e controle da contaminação por poluição e resíduos sólidos e de outras formas de degradação de recursos naturais das terras indígenas;
- identificar as espécies nativas de importância sociocultural em terras indígenas e priorizar seu uso em sistemas agroflorestais e na recuperação de paisagens em áreas degradadas;
- promover a recuperação e conservação da agrobiodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à segurança alimentar e nutricional dos povos

indígenas, com vistas a valorizar e resgatar as sementes e cultivos tradicionais de cada povo indígena;

- promover ações para a recuperação de áreas degradadas e a restauração das condições ambientais das terras indígenas, em especial as de prevenção e combate à desertificação;
- promover a regularização ambiental de atividades e empreendimentos instalados no interior de terras indígenas, incentivando a adoção de medidas compensatórias e mitigatórias; e
- promover medidas de reparação dos passivos socioambientais causados por atividades e empreendimentos inativos no interior de terras indígenas, observada a legislação específica.

O eixo 5 – uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas, está assim dividido:

- garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas;
- fortalecer e promover as iniciativas produtivas indígenas, com o apoio à utilização e ao desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis;
- promover e apoiar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais usados na cultura indígena, inclusive no artesanato para fins comerciais;
- apoiar a substituição de atividades produtivas não sustentáveis em terras indígenas por atividades sustentáveis;
- apoiar estudos de impacto socioambiental de atividades econômicas e produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas;
- desestimular o uso de agrotóxicos em terras indígenas e monitorar o cumprimento da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007, que veda o cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas;
- apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas atividades;
- promover a sustentabilidade ambiental das iniciativas indígenas de criação de animais de médio e grande porte;
- promover a regulamentação da certificação dos produtos provenientes dos povos e comunidades indígenas, com identificação da procedência étnica e territorial e da condição de produto orgânico, em conformidade com a legislação ambiental; e
- promover assistência técnica de qualidade, continuada e adequada às especificidades dos povos indígenas e das diferentes regiões e biomas.

O eixo 6 – propriedade intelectual e patrimônio genético, tem os seguintes objetivos:

- reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos indígenas sobre conhecimentos, práticas, usos tradicionais, costumes, crenças e tradições associados à biodiversidade e ao patrimônio genético existente nas suas terras, de forma a preservar seu direito na repartição dos benefícios, na forma da legislação vigente; e
- apoiar e valorizar as iniciativas indígenas de desenvolvimento de pesquisa, criação e produção etnociência e tecnológica, para possibilitar inovação e fortalecimento de base econômica, social e ambiental.

O eixo 7 – capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental, tem os seguintes objetivos:

- promover a formação de quadros técnicos, estruturar e fortalecer os órgãos públicos e parceiros executores da PNGATI;
- qualificar, capacitar e prover a formação continuada das comunidades e organizações indígenas sobre a PNGATI;
- fortalecer e capacitar as comunidades e organizações indígenas para participarem na governança da PNGATI;
- promover ações de educação ambiental e indigenista no entorno das terras indígenas;
- promover ações voltadas ao reconhecimento profissional, à capacitação e à formação de indígenas para a gestão territorial e ambiental no ensino médio, no ensino superior e na educação profissional e continuada;
- capacitar, equipar e conscientizar os povos indígenas para a prevenção e o controle de queimadas e incêndios florestais; e
- promover e estimular intercâmbios nacionais e internacionais entre povos indígenas para a troca de experiências sobre gestão territorial e ambiental, proteção da agrobiodiversidade e outros temas pertinentes à PNGATI.

A governança da PNGATI é promovida pelos seguintes órgãos: (i) o Comitê Gestor da PNGATI; (ii) **os Comitês Regionais da FUNAI**; e (iii) a Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI).

O Comitê Gestor da PNGATI, responsável pela coordenação da execução da política, será integrado por representantes governamentais e representantes indígenas, conforme ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e do Meio Ambiente editado nos termos do art. 8º da PNGATI.

É também da competência do Comitê Gestor: (i) promover articulações para a implementação da PNGATI; (ii) **acompanhar e monitorar as ações da PNGATI**; (iii) propor ações, programas e recursos necessários à implementação da PNGATI no âmbito do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.

A coordenação do Comitê Gestor da PNGATI será exercida de forma alternada entre as representações do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas, cabendo a Secretaria-Executiva do Comitê Gestor da PNGATI à FUNAI.

20.8 A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS EM TERRAS INDÍGENAS: O CONSENTIMENTO PRÉVIO LIVRE E INFORMADO

Passada a primeira década do Século 21, a nova forma de apropriação dos recursos naturais existentes nas florestas tropicais e nas demais áreas habitadas por povos indígenas e populações tradicionais é uma realidade, dado que paulatinamente foi construído um marco legal, tanto a nível local como internacional, o qual determina que as intervenções com vistas à utilização econômica dos recursos naturais, bem como dos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica, sejam feitas *após* a obtenção do consentimento prévio livre e informado das populações que habitam as áreas potencial ou efetivamente impactadas e provedoras dos recursos naturais. Trata-se de uma realidade legal complexa, com diferentes origens econômicas, sociais, éticas e morais e, sobretudo, porque reintroduz, de alguma forma, a questão do pluralismo jurídico no direito contemporâneo, vez que o Consentimento Prévio Livre e Informado deve ser manifestado conforme os costumes dos povos tradicionais. Do ponto de vista econômico das empresas parece mais do que evidente que a ampliação dos protestos e demandas judiciais feitos pelos povos indígenas e comunidades tradicionais, não raras vezes implica em paralisações de atividades, intensa publicidade negativa e tantos outros abalos econômicos e de imagem que demonstram que intervenções feitas à revelia dos detentores de direitos territoriais são altamente arriscadas e com grande grau de insegurança jurídica, gerando custos indesejáveis e até mesmo insuportáveis. Do ponto de vista legal, há uma crescente legislação garantidora dos direitos de participação das populações indígenas e tradicionais na gestão de seus territórios, bem como de uma remuneração “justa e equitativa” pelos rendimentos auferidos por terceiros a partir da utilização dos recursos naturais existentes nesses territórios.

Assim, o Consentimento Prévio Livre e Informado expressa uma forma inteiramente nova de relacionamento entre os agentes econômicos – muitas vezes

internacionais – e comunidades que ao longo de séculos têm visto os seus locais de vida, trabalho e identificação serem somados ao processo econômico mundial, sem que elas tenham, qualquer possibilidade de interferência ou obtenham remuneração, direta ou indireta, pela utilização dos recursos naturais.

A incorporação das comunidades locais e das populações indígenas no processo decisório relativo à extração dos recursos naturais tem sua origem jurídica mais imediata na Carta das Nações Unidas que estabeleceu a prevalência dos Direitos Humanos e da autodeterminação dos povos, dando base ao posterior desenvolvimento de normas jurídicas aptas a estabelecer mecanismos de consultas às comunidades afetadas por projetos de grande impacto social e ambiental. Em relação ao hemisfério, não se pode esquecer a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o Protocolo Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador).

No âmbito do sistema das Nações Unidas existe a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho [OIT] sobre povos indígenas e tribais que tem sido considerada como “o mais completo instrumento de direito internacional com caráter vinculante sobre povos indígenas e tribais no mundo”¹³, a qual claramente reconhece o direito dos povos indígenas a serem ouvidos, de forma adequada, sobre todos os projetos capazes de impactar-lhes os territórios, o modo de vida e que possa acarretar o seu deslocamento de suas terras. Posteriormente a Convenção sobre Diversidade Biológica dispôs que a utilização dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade só fosse permitida mediante concessão de consentimento prévio livre e informado por parte das populações detentoras de tais conhecimentos, assegurada a repartição justa e equitativa dos benefícios. À lista acima deve ser acrescentada a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas aprovada na 107ª Sessão Plenária da Assembleia Geral realizada aos 13 de setembro de 2007 que, assim como as Convenções mencionadas, dispõe sobre o Consentimento Prévio Livre e Informado.

A necessidade de concessão de consentimento prévio para o desempenho de certas atividades tem sido adotada para além do acesso aos recursos naturais, No Brasil, por exemplo, vigem a (i) Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito [Convenção de Basileia], a (ii) Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacional – CPI, e (iii) a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, por exemplo.

É importante observar que as principais instituições financeiras internacionais tais como o Fundo Monetário Internacional e o grupo Banco Mundial têm estabelecido em seus programas de financiamento para grandes empreendimentos, no que se refere à utilização de recursos naturais, a necessidade da concessão do Consentimento Prévio Livre e Informado. Da mesma forma têm agido as instituições bancárias privadas, mediante a adoção dos Princípios do Equador. Dessa forma, está claro que o Consentimento Prévio Livre e Informado é uma realidade que veio para ficar e que a extração de recursos naturais está merecendo uma nova abordagem a qual, necessariamente, deve incluir aqueles que são mais diretamente impactados como elementos fundamentais do processo. No que se refere ao Brasil deve-se observar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em suas políticas socioambientais e de responsabilidade social não faz referência expressa ao Consentimento Prévio Livre e Informado, limitando-se a, em seu artigo 2º, estabelecer, o “respeito aos direitos humanos e combate e repúdio a toda prática de atos que importem em qualquer tipo de discriminação ou violação de direitos”,¹⁴ todavia, ao longo deste artigo ficará claro que o conjunto de compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro impõe que o BNDES siga o padrão atualmente vigente em nível global.

20.8.1 Bases legais do Consentimento Prévio Livre e Informado

20.8.1.1 Em nível internacional

Até o estabelecimento do Consentimento Prévio Livre e Informado como uma exigência legal para projetos de exploração de recursos naturais uma longa rota foi percorrida. Após vários séculos de conflitos e disputas foi somente no início do século 20 que uma delegação indígena se apresentou autonomamente no cenário internacional, representada por um grupo de iroqueses canadenses (seis nações) solicitando audiência à Liga das Nações, sem sucesso (ANAYA, 2009, p.4). Foi especialmente na década de 60 do século 20 que os indígenas e as comunidades tradicionais começaram a surgir no cenário internacional como força política. Essa situação foi favorecida por vários fatores dentre os quais merecem destaque (i) a descolonização efetivada após a 2ª Guerra Mundial, (ii) os conflitos internos nos países originários da descolonização, com predominância de determinados grupos étnicos sobre outros, (iii) o movimento de direitos civis nos Estados Unidos com a incorporação de questões étnicas por parte de uma classe média com raízes indígenas. É importante ressaltar que os movimentos indígenas, não poucas vezes, conflitaram com o ambientalismo. As reivindicações indígenas estão mais próximas do discurso da justiça ambiental, *environmental justice*, que surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século 20 e, como ressaltado por John Hannigan (2014, p; 84), que diferia inteiramente das interpretações prevalecentes sobre os principais problemas e prioridades ambientais. Segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009, p. 17), “O Movimento de Justiça Ambiental constitui-se nos EUA nos anos 1980, a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis” que desde os anos 1960 começaram a incluir as questões relativas às más condições de saneamento, a contaminação química de bairros residenciais e outras questões assemelhadas. Como se sabe, as principais questões ambientais naquela época, e de certa forma ainda hoje, estavam relacionadas aos temas de conservação da vida silvestre e planejamento rural. Todavia, deve ser ressaltado que, no Brasil, já na década de 70 do século 20, havia o movimento liderado por Chico Mendes que tinha como um dos seus principais focos a compatibilização entre a proteção do meio ambiente e o respeito ao estilo de vida dos povos tradicionais (ANTUNES, 2014, p. 55), custando a vida do líder seringueiro. Anote-se que a maioria das questões suscitadas pelas populações indígenas e tradicionais eram relativas à posse e uso dos recursos naturais existentes em seus territórios, bem como relativas ao seu reconhecimento como grupo étnico e respeito humano e cultural, pois “para um povo colonizado o valor mais essencial, porque mais concreto, é primeiro e principalmente a terra: a terra que lhes trará pão e, sobretudo, dignidade”(FANON, 1963, p. 80).

A Carta das Nações Unidas, com seu espírito igualitário, em seu artigo 55 (a) estabelece que um dos princípios da cooperação entre os estados é favorecer que se atinja, “níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social”, a cooperação econômica, igualmente, deve favorecer, “o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” (art. 55 (c)), por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que “[t]odos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” (Artigo 1º), podendo invocá-los “sem distinção alguma” (Artigo 2º), destacando-se os direitos “à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (Artigo 3º), bem como a igualdade “perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei.” Os povos indígenas e populações tradicionais passaram a se compreenderem como destinatários de tais direitos universais e, desde então, buscam a sua implementação, utilizando-se de todos os diferentes meios disponíveis para tal.

20.8.1.1.1 Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho

A Organização Internacional do Trabalho [OIT], em sua 79ª Conferência aprovou a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes [C 169] que é um dos principais, senão o principal, instrumentos obrigatório em nível internacional que trata especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais no mundo. A Convenção foi incorporada ao Direito Brasileiro pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Conforme o disposto no artigo 1º (a) e (b) ela se aplica “aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial”, bem como

“aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas”.

Já o artigo 1º (2) estabelece que “[a] consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção” Do ponto de vista normativo, parece claro que a C169 tutela as (i) populações tribais que devidos

às suas condições sociais, culturais e econômicas se distinguem de outros setores da comunidade de país ou nação e que se (ii) autogovernem em sua vida cotidiana por costumes e tradições próprias ou (iii) sejam destinatárias de legislação especial em função de suas peculiaridades étnicas. Em relação aos povos indígenas a C169 estabelece o critério de (i) “descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais” e que, “seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas”. A norma estabelece critérios complexos para a identificação de populações tradicionais e indígenas, sendo que a aplicação concreta da norma, em diversas vezes tem priorizado a “consciência de sua origem indígena ou tribal” para a caracterização de uma população como beneficiária da Convenção, o que não parece ser o objetivo do texto legal. No Brasil, por exemplo, a Fundação nacional do Índio – FUNAI¹⁵ tem se posicionado no sentido de que a “consciência” é o elemento determinante, “[d]essa forma, os critérios utilizados consistem: a) na autodeclaração e consciência de sua identidade indígena; b) no reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.” Parece claro que a forma como a FUNAI vem interpretando a C169 implica na extensão da proteção concedida pela Convenção a setores populacionais que, rigorosamente, nela não se enquadram. A “consciência de sua origem indígena ou tribal” é um “critério fundamental, mas não único, como parece fazer crer a declaração da FUNAI. Logo, a Convenção estipulou algumas condições objetivas para o reconhecimento dos povos indígenas ou tribais – com vistas ao reconhecimento de direitos específicos – e, igualmente, estipulou alguns critérios interpretativos para a aplicação dos critérios objetivos, ou seja, havendo dúvidas no que se refere à aplicação ou não da Convenção a uma determinada situação concreta, o intérprete se socorrerá do disposto no número 2 do artigo 1º, “[a] consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”. Veja-se que a Convenção fala em *critério fundamental, mas não em critério único*, o mero autorreconhecimento de um indivíduo ou de uma comunidade como indígena não é suficiente para que ela passe a fazer jus aos benefícios da Convenção, ou de um tratamento legalmente privilegiado se ele ou ela não ostentarem “condições sociais, culturais e econômicas [que] os distingam de outros setores da coletividade nacional” ou estiverem “regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial”, ou mesmo que conservem “todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas”. A norma estabelece critérios complexos para a identificação de populações tradicionais e indígenas, sendo que a eles devem ser somados ao auto-reconhecimento de uma identidade própria. Mesmo uma interpretação liberal não pode dispensar a caracterização de peculiaridades culturais e étnicas, capazes de destacar a comunidade examinada dentro de uma determinada sociedade nacional, sob pena de uma ampliação excessiva dos destinatários o que, certamente, não é o objetivo da C 169.

O Consentimento Prévio Livre e Informado de acordo com a C169 se molda em um conjunto de regras legais – cogentes – explícitas e implícitas. O Artigo 2º (2) assegura aos povos indígenas e às comunidades tradicionais “o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população”, portanto, os direitos conferidos pela Convenção são complementares aos direitos assegurados a todo e qualquer cidadão. A manifestação do consentimento das populações indígenas e tradicionais começa a se concretizar no artigo 4º (1) e (2) que estabelecem que mesmo as medidas adotadas com vistas a salvaguardar pessoas, instituições, bens, cultura e meio ambiente das populações beneficiárias da C 169 não “deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados”, ou seja, só devem ser precedidas do Consentimento Prévio Livre e Informado. O artigo 6º (a) determina uma obrigação de consulta aos “povos interessados, mediante a utilização de mecanismos apropriados”, em especial por intermédio das instituições representativas e legítimas de tais povos, “cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente.” Em conformidade com o artigo 6º (b) cabe aos estados estabelecer “os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes”. Logo, cabe aos Estados estabelecerem os mecanismos de consulta – o procedimento – levando em conta as peculiaridades culturais dos povos a serem consultados. Em países como o Brasil, por exemplo, dado o grande número de comunidades, não haverá um modelo único, ou se existente, ele deverá ser dotado de flexibilidade suficiente para acomodar múltiplas culturas.

As consultas a serem realizadas deverão ser efetuadas “com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.” Logo, o Consentimento Prévio Livre e Informado não se confunde com um poder de veto, mas com uma obrigação de acomodação de interesses. Em complemento, o artigo 7º (1) reconhece que os destinatários da C 169 têm o “direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural.”

20.8.1.2 Convenção Sobre Diversidade Biológica – Decreto legislativo nº 2/1994

O acesso aos Conhecimentos Tradicionais associados à diversidade biológica e a sua utilização econômica é uma das questões mais controvertidas da atualidade, pois ele suscita questões de natureza ética, cultural e histórica. A CDB tem como objetivos a (i) conservação da diversidade biológica, a (ii) utilização sustentável de seus componentes e a (iii) repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, aplicando-se um critério de justiça. Reconhece a Convenção, portanto, a desigualdade econômica entre os provedores de recursos genéticos e aqueles que, dotados de tecnologia, têm capacidade de utilizá-los em escala comercial, dessa forma o artigo 8 (j) dispõe que, de acordo com a sua legislação interna, os Estados deverão “respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”. O artigo destaca algumas questões importantes, tais como o (i) *reconhecimento* das comunidades locais e populações indígenas como realidade social e cultural específicas e, por isso mesmo, “relevantes à conservação” da diversidade biológica. Note-se o abandono da ideia de incompatibilidade entre proteção ambiental e presença humana, – muito significativo no pensamento ambientalista majoritário (ANTUNES, 2015); a (ii) aprovação e a participação das comunidades locais e populações indígenas para a utilização por terceiros dos Conhecimentos Tradicionais associados à diversidade biológica, ou seja a necessidade de *procedimentos* claros para a utilização legal de tais conhecimentos e, por fim, a (iii) distribuição dos benefícios econômicos – mas não se limitando a eles – de forma justa entre as comunidades locais e populações indígenas.

O *procedimento*, ou seja, o mecanismo mediante o qual as comunidades locais e populações indígenas darão – ou não – o seu consentimento ao acesso aos Conhecimentos Tradicionais associados é tratado no artigo 15 (5), devendo ser (i) *prévio* e (ii) *fundamentado* (informado), a menos que o Estado Parte da Convenção, em sua legislação interna tenha estabelecido de outra forma. Acrescente-se que o artigo 15 (7) determina a obrigação de que as Partes Contratantes adotem medidas “legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso” com vistas a estabelecer mecanismos para “compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza”, devendo a partilha ocorrer de comum acordo.

No âmbito da CDB, foram adotadas as Diretrizes de Bonn para o acesso aos recursos genéticos e a justa e equitativa repartição dos benefícios associados foram adotadas na COP VI [conferência das partes], Decisão VI/24, as quais estabeleceram as linhas gerais a serem seguidas pelas Partes em relação às políticas, normas e procedimentos internos que adotarem. As diretrizes em seu item “C” indica as medidas para a aplicação do artigo 15 (5) da CDB, resguardando os direitos soberanos das Partes sobre os seus recursos naturais. Conforme o número 3 (18) das Diretrizes, os “stakeholders” relevantes devem ser consultados e os seus pontos de vista “levados em consideração” em cada etapa do processo. É muito importante observar que deve ser facilitado o envolvimento dos “stakeholders” relevantes, incluídos neles as populações indígenas e as comunidades tradicionais, mediante o (i) fornecimento de informações científicas e aconselhamento jurídico de forma que eles possam estar aptos a “participar efetivamente”. Desde que seja do interesse da comunidade envolvida, ela poderá buscar o apoio de mediadores ou facilitadores quando da negociação de acordos para a concessão do acesso aos Conhecimentos Tradicionais e à repartição de benefícios. Há, também, o Protocolo de Nagoya, ainda não ratificado pelo Brasil, o qual estabelece em seu artigo 6 (2) que cada uma das partes deve adotar as medidas administrativas e legislativas com vista a assegurar que “seja obtido o consentimento prévio informado ou a aprovação e o envolvimento de comunidades indígenas e locais para acesso aos recursos genéticos, quando o direito de conceder acesso a tais recursos lhes tenha sido estabelecido.” E mais, determina o artigo 6 (3) a necessidade das partes assegurarem meios para “(a) conceder segurança jurídica, clareza e transparência sobre sua legislação ou requisitos regulatórios domésticos sobre acesso e repartição de

benefícios; (b) prover regras e procedimentos para acesso a recursos genéticos justos e não arbitrários; (c) oferecer informação sobre como solicitar o consentimento prévio informado; (d) apresentar decisão escrita clara e transparente, tomada por uma autoridade nacional competente, de maneira custo-efetiva e dentro de um período de tempo razoável; (e) Providenciar a emissão, no momento do acesso, de uma autorização ou seu equivalente como evidência da decisão de conceder consentimento prévio informado e do estabelecimento de termos mutuamente acordados e notificar sobre essa providência a Base de Dados sobre Acesso e Repartição de Benefícios; (f) onde for aplicável e sujeito à legislação nacional, estabelecer critérios e/ou processos para obtenção do consentimento prévio informado ou da aprovação e envolvimento de comunidades indígenas e locais para acesso a recursos genéticos; e (g) estabelecer regras claras para requisição e estabelecimento de termos mutuamente acordados, os quais devem ser celebrados por escrito, podendo incluir, por exemplo: (i) cláusula de resolução de disputas; (ii) termos sobre repartição de benefícios, inclusive com relação a direitos de propriedade intelectual; (iii) termos sobre direito de uso por terceiros, se for o caso; e (iv) condições para alteração de cláusulas, onde for aplicável, o mesmo em relação ao acesso aos Conhecimentos Tradicionais, conforme estipulado pelo artigo 7.

20.8.1.3 Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou aos 7 de setembro de 2007 a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas – 2007 que dispõe amplamente sobre o Consentimento Prévio Livre e Informado. O seu artigo 3 determina que os “povos indígenas têm direito à livre determinação” e, em consequência de tal direito “determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.” Especificamente no que se refere ao deslocamento dos povos indígenas de seus territórios, a Declaração estipula, no artigo 10 que “[n]ão se procederá a nenhuma mudança de local sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados, nem sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e equitativa e, sempre que seja possível, a opção de regresso.”

A Declaração segue a mesma linha da C 169 no que diz respeito ao dever de colaboração entre o Estado e os povos indígenas e as comunidades tradicionais, estabelecendo que a adoção, por parte dos Estados, de medidas administrativas e legislativas que afetem os povos indígenas deverão ser efetivas mediante consultas e cooperação “de boa-fé com os povos indígenas interessados por meio de suas instituições representativas” com vistas à obtenção de “seu consentimento livre, prévio e informado” (artigo 19). Os projetos que possam afetar as terras indígenas deverão ser submetidos à consulta de boa-fé às instituições indígenas, com o objetivo de obter o Consentimento Prévio Livre e Informado (artigo 32).

20.8.2 Brasil

O Direito nacional também assegura amplamente a necessidade de que o Consentimento Prévio Livre e Informado seja concedido antes da utilização de recursos naturais existentes em territórios indígenas e de comunidades tradicionais, seja pela incorporação de normas internacionais, seja por disposições constitucionais e legais, todavia, a sua utilização – ou não utilização – prática é ainda muito discricionária, pois faltantes as necessárias regulamentações. Todas as Convenções internacionais mencionadas no item precedente foram devidamente integrados ao ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, estão plenamente vigentes, sendo obrigatórios tanto para a União como para estados e municípios.

A Constituição Brasileira de 1988 protege amplamente os povos indígenas e as comunidades tradicionais, em especial aquelas remanescentes de quilombos. Na Constituição, constam disposições de proteção à cultura, o reconhecimento explícito da diversidade cultural do País (artigo 216), a definição de direitos dos povos indígenas (artigo 231) e o reconhecimento das terras comunais dos remanescentes de quilombos (Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 68), tais dispositivos vêm sendo observados e implantados. Atualmente existem 548 diferentes áreas destinadas aos povos indígenas, sob diferentes denominações, totalizando 113.518.234,9197 hectares;¹⁶ em relação aos remanescentes de quilombos, segundo dados oficiais já foram identificadas oficialmente 2007 comunidades¹⁷, reconhecidas quarenta e duas e, tituladas vinte e nove. Tais comunidades são compostas por cerca de dois milhões de pessoas. Dando cumprimento aos ditames implícitos da Constituição Federal, o Executivo editou uma série de Decretos lidando com o tema, sendo o último deles o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, conforme o estipulado no Decreto, povos e comunidades tradicionais são

“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.”

A identificação e reconhecimento, também nesse caso, não se limita à auto declaração ou autorreconhecimento. Os povos e comunidades tradicionais podem ocupar Territórios Tradicionais que são “os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações,” Para fins de aplicação da política, o desenvolvimento sustentável foi definido como “o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.” As populações indígenas, por exemplo, em função dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, bem como do desenvolvimento de algumas políticas públicas específicas vem crescendo em ritmo superior à média nacional, muito em função de um processo de etnogênese e de recuperação do orgulho indígena, fenômeno semelhante ocorre com outros grupos étnicos.

“[...] O contingente de brasileiros que se considerava indígena cresceu 150% na década de 90. O ritmo de crescimento foi quase seis vezes maior que o da população em geral. O percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou de 0,2% em 1991 para 0,4% em 2000, totalizando 734 mil pessoas. Houve um aumento anual de 10,8% da população, a maior taxa de crescimento dentre todas as categorias, quando a média total de crescimento foi de 1,6%.”

É ainda relevante notar que, segundo o IBGE e a FUNAI, há importante parcela da população indígena vivendo em áreas urbanas, cerca de 315 mil indivíduos. Além das 305 etnias indígenas, falantes de 274 diferentes línguas, reconhecidas pelo IBGE em seu censo de 2010, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais [CNPCT], reconhece a existência de 27 povos e comunidades tradicionais, tal como descritas pelo Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Assim, a CNPCT reconhece oficialmente as seguintes comunidades: (i) Indígenas, (ii) Caiçaras, (iii) Pomeranos, (iv) Quebradeiras de coco de babaçu, (v) Veredeiros, (vi) Apanhadores de sempre-viva, (vii) Andirobeiras, (viii) Catingueiros, (ix) Castanheiras, (x) Catadores de Mangaba, (xi) Ciganos, (xii) Cipozeiros, (xiii) Extrativistas, (xiv) Faxinalenses, (xv) Fundo de Pasto, (xvi) Geraizeiros, (xvii) Ilhéus, (xviii) Isqueiros, (xix) Morroquianos, (xx) Pantaneiros, (xxi) Pescadores Artesanais, (xxii) Piaçaveiros, (xxiii) Povos de Terreiro, (xxiv) Quilombolas, (xxv) Retireiros, (xxvi) Ribeirinhos, (xxvii) Seringueiros.

O Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016 instituiu o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, cuja natureza é consultiva e integra a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. O Conselho é composto por 44 membros titulares, com maioria da sociedade civil e dois membros convidados com direito a voz.

Já, a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 que trata da repartição de benefícios referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica, em seu artigo 2º, VI, define o conceito normativo de consentimento prévio informado, determinando que ele é condição para o acesso aos conhecimentos tradicionais (artigo 8º). Acrescente-se que os países latino-americanos têm adotado legislações integrando o Consentimento Prévio Livre e Informado em seu direito interno de forma explícita, no Chile o procedimento de consulta está decepcionado pelo Decreto Supremo nº 66 de 2013; no Peru a matéria é contemplada pela Lei de Consulta Prévia os Povos Indígenas de 2011, havendo ainda outros exemplos.

20.8.3.1 O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos

O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos tem como suas principais bases (i) uma estrutura legal e (ii) uma estrutura administrativa. A estrutura legal é formada, segundo Fergus Mackay (MACKAY, 2002, p. 24), por dois quadros legais inter-relacionados, o primeiro constituído pela (i) Carta da Organização dos Estados Americanos [OEA] de 1948 e pela (ii) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aplicáveis a todos os membros da OEA e o segundo grupo é composto pela (i) Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e pelo (ii) Protocolo Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)¹⁸ cuja obrigatoriedade restringe-se aos seus signatários.

A estrutura encarregada da implementação da proteção aos direitos humanos é formada pela (i) Comissão Interamericana de Direitos Humanos e (ii) pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cada uma delas desempenhando funções próprias. A Comissão é um, órgão da OEA, conforme estabelecido no artigo 53 (e) de sua Carta de criação, com atividades administrativas com vistas a “promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da Organização em tal matéria” (artigo 106). Conforme disposto no Pacto de San José da Costa Rica, a Comissão dentre suas funções e atribuições, entre outras, “atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 (41 f).” O acesso à Comissão, para a apresentação de denúncias, é simplificado, sendo amplamente facilitado para indivíduos, grupo de indivíduos ou organizações não governamentais regularmente constituídas de acordo com as leis de seus países de origem.

Por sua vez, a Corte, estabelecida pelo Pacto de San José da Costa Rica, é um dos órgãos competentes para conhecer dos temas relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados Partes relacionados ao Pacto de San José, artigo 33(b). O acesso à Corte só é permitido aos Estados Partes ou à Comissão, artigo 61 (1). Após esgotados os procedimentos estipulados pelos artigos 48/50, ou seja as instâncias nacionais. Uma vez que ela considere violados direitos ou liberdades protegidos pelo Pacto de San José cabe-lhe determinar que o Estado adote as medidas necessárias para o restabelecimento o direito violado, ou quando for o caso, que sejam adotadas medidas reparatórias adequadas, inclusive mediante o pagamento de indenização justa (artigo 63(1). A Corte possui, ainda, uma importante função consultiva relativa à interpretação do Pacto de San José e/ou outros tratados sobre direitos humanos adotados no sistema interamericano. As sentenças emitidas pela Corte são definitivas e inapeláveis, sendo de observância obrigatórias para os Estados partes, podendo a execução financeira ser efetivada no país no qual se originou a demanda, sob as leis próprias para execução judicial do Estado, artigo 68 (1) e (2). Como se vire mais à frente, a Corte tem desempenhado papel bastante ativo e significativo na matéria.

20.8.3.2 Decisões do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos

O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos tem dado resposta às diferentes questões apresentadas por povos indígenas e comunidades tradicionais relativas à proteção dos direitos humanos, com a explicitação do conteúdo do Consentimento Prévio Livre e Informado de forma bastante clara e indiscutível. É importante registrar que tanto a Comissão como a Corte têm convergido no sentido de definições relativas ao tema e mais: os diferentes tribunais nacionais dos países do Hemisfério, da mesma forma, têm enfrentado às questões, resultando evidente que o Consentimento Prévio Livre e Informado é uma realidade jurídica cogente e essencial para a utilização legal dos recursos naturais existentes em territórios indígenas e de comunidades tradicionais.

20.8.3.2.1 O caso Saramaka

A Corte tem decidido vários casos sobre o tema de direitos indígenas e de populações tradicionais¹⁹. Dada amplitude e profundidade com que lidou com a matéria, optamos por apresentar o chamado caso Saramaka que nos fornece um excelente panorama da atuação do tribunal.

O Caso Saramaka vs. Suriname tem origem em uma demanda submetida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos – 23/06/2006 – a partir da denúncia 12.338 (27/10/2000) apresentada pela Associação de Autoridades Saramaka [AAS] e doze capitães Saramaka em seus nomes pessoais e, também, em nome do povo Saramaka. Aos 2 de março de 2006, a Comissão aprovou os Relatórios de Admissibilidade e de Mérito (nº 9/06) com recomendações para o Suriname. Aos 19 de junho de 2006, entendendo que a questão permanecia insolúvel, ante a inércia do Suriname, a Comissão submeteu a questão à Corte Interamericana que a decidiu. Conforme consta da decisão:

A Comissão requereu que a Corte declarasse a responsabilidade do Suriname pela violação aos artigos 21 (Direito à Propriedade) e 25 (Direito à Proteção Judicial) do Pacto de San José. O primeiro aspecto que merece destaque na decisão foi o reconhecimento do Povo Saramaka como uma comunidade tribal passível de proteção pela C 169, aplicável ao caso. A Corte²⁰ assim dispôs sobre o tema do reconhecimento de “sociedades tribais” e de sua elegibilidade para a proteção internacional de direitos humanos:

“78. A Comissão e os representantes alegaram que o povo Saramaka constitui uma unidade tribal e que o Direito Internacional dos Direitos Humanos impõe ao Estado a obrigação de adotar medidas especiais para garantir o reconhecimento dos direitos dos povos tribais, incluindo o direito à posse coletiva da propriedade. [...]”

79. [...] Portanto, estão fazendo valer seus direitos na qualidade de suposto povo tribal, isto é, um povo que não é nativo da região, mas que compartilha características similares com os povos indígenas, como ter tradições sociais, culturais e econômicas diferentes de outras partes da comunidade nacional, identificar-se com seus territórios ancestrais e estar regulados, ao menos de forma parcial, por suas próprias normas, costumes ou tradições.”

A Corte entendeu necessário que as peculiaridades do Povo Saramaka, isto é, a sua diferenciação em relação à comunidade nacional do Suriname estavam comprovadas.

“80. De acordo com as evidências apresentadas pelas partes, o povo Saramaka é um dos seis distintos grupos marrons do Suriname, cujos ancestrais foram escravos africanos levados à força ao Suriname durante a colonização europeia no século XVII. Seus ancestrais escaparam para as regiões do interior do país onde estabeleceram comunidades autônomas. O povo Saramaka está organizado em doze clãs de linhagem materna (lös) e se estima que o número atual da população Saramaka seja de 25.000 a 34.000 membros, que se dividem em 63 comunidades situadas na região superior do Rio Suriname e em algumas comunidades deslocadas que estão localizadas ao norte e ao oeste desta região.

81. Sua estrutura social é diferente à de outros setores da sociedade, pois o povo Saramaka está organizado em clãs de linhagem materna (lös) e se regem, ao menos de forma parcial, por seus próprios costumes e tradições. Cada clã (lô) reconhece a autoridade política de vários líderes locais, incluindo os que eles chamam de Capitães e Capitães Chefes, assim como um Gaa'man, que é o oficial de mais alta posição dentro da comunidade.

82. Sua cultura é também muito parecida com a dos povos tribais, já que os integrantes do povo Saramaka mantêm uma forte relação espiritual com o território ancestral que tradicionalmente usaram e ocuparam. A terra significa mais do que meramente uma fonte de subsistência para eles; também é uma fonte necessária para a continuidade da vida e da identidade cultural dos membros do povo Saramaka. As terras e os recursos do povo Saramaka formam parte de sua essência social, ancestral e espiritual. Neste território, o povo Saramaka caça, pesca e colhe, e coleta água, plantas para fins medicinais, óleos, minerais e madeira. Os sítios sagrados estão distribuídos em todo o território, toda vez que o território em si tem um valor sagrado para eles. Em especial, a identidade dos integrantes do povo com a terra está intrinsecamente relacionada à luta histórica pela liberdade contra a escravidão, chamada a sagrada “primeira vez”.

84. Por isso, de acordo com o exposto, a Corte considera que os membros do povo Saramaka constituem uma comunidade tribal cujas características sociais, culturais e econômicas são diferentes de outras partes da comunidade nacional, particularmente graças à relação especial existente com seus

Consentimento Prévio Livre e Informado: conteúdo

A Corte, no Caso Saramaka, dispôs longamente sobre o Consentimento Prévio Livre e Informado, valendo notar o recurso à C169 da OIT, já que Pacto de San José não trata da matéria. A Corte considerou que a Consulta com vistas à obtenção do Consentimento Prévio Livre e Informado deve ser realizada ainda na fase preliminar ou de planejamento da atividade pretendida, com antecedência razoável, de forma que o grupo afetado possa compreender a natureza da intervenção proposta e, a partir disso estar capacitado para emitir o seu juízo adequadamente.

O Caso Saramaka deixou assentado, igualmente, que a Consulta prévia não é uma atividade meramente burocrática e protocolar, efetivada apenas para cumprir formalmente a necessidade de atender à obrigação de obtenção do consentimento da comunidade envolvida. Em todos os casos, a Consulta deve ser realizada de acordo com os mecanismos tradicionalmente utilizados pelas comunidades indígenas ou tribais para deliberar, ou seja a Consulta deve ser *culturalmente adequada*, isto é, consistente com os costumes da comunidade envolvida, apurando-se a legitimidade dos representantes comunitários, segundo os mecanismos reconhecidos pelos membros da comunidade em questão. Logo, o conceito da adequação cultural é essencial para a validade da Consulta e do Consentimento Prévio Livre e Informado dela emanado. A informação a ser debatida na consulta há de ser cabal e apta a indicar toda a natureza e conteúdo da intervenção pretendida, com as vantagens e desvantagens, riscos e benefícios ambientais, de saúde pública e outros para a comunidade indígena, de forma a propiciar à comunidade os elementos necessários para emitir o seu consentimento de forma voluntária e informada. Portanto, a Consulta deve ser efetivada de boa fé, buscando alcançar um acordo entre as partes.

“133. [...] Este dever requer que o Estado aceite e ofereça informação e implica numa comunicação constante entre as partes. As consultas devem realizar-se de boa fé, através de procedimentos culturalmente adequados e devem ter como objetivo alcançar um acordo. Além disso, o povo Saramaka deve ser consultado, de acordo com suas próprias tradições, nas primeiras etapas do projeto de desenvolvimento ou investimento e não unicamente quando surja a necessidade de obter a aprovação da comunidade, se for o caso. O aviso com antecedência proporciona um tempo para a discussão interna dentro das comunidades e para oferecer uma adequada resposta ao Estado. O Estado, além disso, deve assegurar-se de que os membros do povo Saramaka tenham conhecimento dos possíveis riscos, incluindo os riscos ambientais e de salubridade, a fim de que aceitem o projeto de desenvolvimento ou investimento proposto com conhecimento e de forma voluntária. Por último, a consulta deveria levar em consideração os métodos tradicionais do povo Saramaka para a tomada de decisões.

134. Ademais, a Corte considera que, quando se trate de projetos de desenvolvimento ou de investimento de grande escala que teriam um impacto maior dentro do território Saramaka, o Estado tem a obrigação não apenas de consultar os Saramaka, mas também deve obter seu consentimento livre, prévio e informado, segundo seus costumes e tradições. A Corte considera que a diferença entre “consulta” e “consentimento” neste contexto requer maior análise [...].

137. [...] A Corte concorda com o Estado e, além disso, considera que além da consulta requerida, sempre que se apresente um projeto de desenvolvimento ou de investimento dentro do território tradicional Saramaka, a garantia de participação efetiva requerida quando se trate de grandes projetos de desenvolvimento ou investimento que possam ter um impacto profundo nos direitos de propriedade dos membros do povo Saramaka em grande parte de seu território, deve entender-se como requisito adicional à obrigação de obter o consentimento livre, prévio e informado do povo Saramaka, segundo seus costumes e tradições.

154. [...] Ademais, o Estado não permitiu a participação efetiva do povo Saramaka, de acordo com suas tradições e costumes, no processo de tomada de decisões a respeito das concessões madeireiras [...]”.

E por fim, a Corte determinou que o Suriname deveria “adotar, *em sua legislação interna e através de consultas prévias, efetivas e plenamente informadas* com o povo Saramaka, medidas legislativas ou de outra natureza necessárias a fim de reconhecer, proteger, garantir e efetivar o direito de titularidade de direitos de forma coletiva sobre o território que tradicionalmente ocuparam e utilizaram ao povo Saramaka”. A decisão acima comentada não é isolada e, de certa forma, tem sido reproduzida por várias Cortes nacionais de países integrantes da Organização dos Estados Americanos e de outros continentes²¹.

20.8.3.3 Decisões Judiciais

Os tribunais federais brasileiros vêm aplicando, com frequência cada vez maior, a C 169 e decidindo questões com base no Consentimento Prévio Livre e Informado. O Superior Tribunal de Justiça, na maioria dos casos tem decidido sobre cassações de medidas liminares concedidas ao Ministério Público Federal em defesa de direitos indígenas. Na Reclamação nº 17.224/PA, relatada pelo Presidente do STJ, a tribunal entendeu que a Consulta prévia demanda regulamentação, e que “a par de inexistir a necessária regulamentação legal, não é tarefa singela”.

Em outra decisão,²² relativa ao mesmo empreendimento, o tribunal, pela decisão de seu presidente, entendeu que: “não vislumbro como meros estudos preliminares, atinentes tão-somente à viabilidade do empreendimento, possam afetar, diretamente, as comunidades envolvidas.” Acrescentando:

“O que não se mostra possível, no meu entender, é dar início à execução do empreendimento sem que as comunidades envolvidas se manifestem e componham o processo participativo com suas considerações a respeito de empreendimento que poderá afetá-las diretamente. Em outras palavras, não poderá o Poder Público finalizar o processo de licenciamento ambiental sem cumprir os requisitos previstos na Convenção nº 169 da OIT, em especial a realização de consultas prévias às comunidades indígenas e tribais eventualmente afetadas pelo empreendimento.

Além disso, não há uma regulamentação específica que exija que a consulta deverá se dar antes mesmo do início dos estudos de viabilidade do empreendimento, decorrendo daí a possibilidade de, obedecido o princípio de preservação dos direitos fundamentais dessas comunidades, a consulta se dar concomitante às avaliação e estudos, pois, nesse caso, ao meu sentir, não haverá “medida administrativa” tendente a afetar diretamente as comunidades envolvidas.”

Leitura atenta do artigo 6º do C 169 demonstra que, de fato, há necessidade de mecanismos estáveis e previamente definidos para a realização da Consulta prévia dos povos indígenas e populações tradicionais. De fato, o artigo 6º (1)(a) estabelece que a consulta deverá ser procedida “mediante procedimentos apropriados”, o que significa a existência de normas regulamentadoras reconhecendo as “instituições representativas” dos indígenas e comunidades tradicionais. Tal compreensão é fortalecida pelo disposto no artigo 6º (1) (b) que determina a obrigação dos estados estabelecerem “os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente”, ou os procedimentos a serem adotados e reconhecidos pela administração para que o consentimento prévio livre e informado possa ser manifestado. Aliás, há que se acrescentar que o mesmo artigo 6º, 1 em seu item (c) determina a obrigação dos estados forneceremos meios para “o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.”

Os tribunais dos países da América Latina têm aplicado a C 169 da OIT, com frequência cada vez maior, cite-se como exemplo as seguintes decisões do Chile e da Colômbia.

Chile: O Poder Judiciário chileno tem aplicado a C169 da OIT e a Declaração da Organização das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas em diversos casos relacionados aos Mapuche; em grande parte dos casos os tribunais judiciais têm anulado decisões administrativas que afetam desfavoravelmente direitos indígenas, ao negar-lhes o direito de participação efetiva em consultas com vistas à obtenção do Consentimento Prévio Livre e Informado, em especial quando se trata de questões de meio ambiente e avaliação de impacto ambiental. A Corte de Apelação de Valdivia, anulou por ilegalidade a Resolução Isenta nº 041, de 5 de abril de 2010 do CONAMA que foi favorável à declaração de impacto ambiental de uma projeto de estação de transferência de resíduos sólidos do Município de Lanco.

Colômbia. Na Colômbia, há a importante Sentença C-030 de 2008 proferida pela Sala Plena da Corte Constitucional que decidiu a demanda de inconstitucionalidade da Lei 1021 de 2006 (Lei Geral Florestal). A matéria debatida pela Corte Constitucional colombiana dizia respeito à obrigatoriedade da consulta aos povos indígenas previamente à tomada de medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-los. A Corte julgou a Lei Geral Florestal inaplicável, baseada nos seguintes argumentos: “e, essa consulta, que tem características especiais, não foi feita neste caso, e a mesma não pode ser substituída pelo processo participativo que, de maneira geral, foi feito para o projeto de lei.” E acrescentou: “Para que se tivesse cumprido com o requisito da consulta teria sido necessário, levar ao conhecimento das comunidades, por intermédio de instâncias suficientemente representativas, o projeto de lei.”

20.8.4 Instituições de Fomento Econômico e o Consentimento Prévio Livre e Informado

As instituições financeiras internacionais após severas críticas que lhes foram feitas por diversas organizações não governamentais e, igualmente, com vistas a terem um grau maior de certeza em relação aos elevados investimentos necessários para os projetos de utilização de recursos naturais em territórios indígenas ou de comunidades tradicionais – por elas financiados – passaram a ter no Consentimento Prévio Livre e Informado um elemento fundamental para a concessão de créditos e financiamentos.

Vale notar que estudos realizados pelo Fundo Monetário Internacional – FMI demonstram que os povos indígenas estão arrolados entre as comunidades mais pobres da América Latina (HALL e PATRINOS, 2005). A partir da década de 70 do século XX, teve início um processo de crítica aos financiamentos concedidos pelos Bancos de Desenvolvimento, pois segundo os críticos, tais empréstimos contribuíam para a implantação de projetos social e ambientalmente desastrosos, gerando consequências gravosas para as populações por eles afetadas. No centro de tais críticas estavam os processos financiados pelo Banco Mundial, dentre os quais se tornou icônico o Polonoroeste, criado pelo Decreto nº 86.029, de 27 de maio de 1981. O Banco Mundial contribuiu com o US\$ 346,4 milhões em financiamento. Conforme informa Phillip Fearnside (1987, p. 51), cerca de US\$ 1,55 bilhões foram destinados à reconstrução e pavimentação do trecho de 1.500 km da rodovia Marechal Rondon ou BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, aproximadamente 57 % do projeto, sendo que apenas 3% dos recursos foi “destinad[o] para a proteção das reservas, inclusive das reservas indígenas.” Apesar de seus objetivos de “assegurar o crescimento da produção em harmonia com as preocupações de preservação do sistema ecológico e de proteção às comunidades indígenas”, o projeto enfrentou forte resistência indígena, tendo em vista a invasão de seus territórios. A Associação Cultural Survival, em matéria contemporânea aos fatos indicou que entre os anos de 1984 e 1985 ocorreram vários conflitos nas áreas indígenas impactadas pelo Polonoroeste, sendo o primeiro registrado na Área Indígena do Igarapé Lourdes, habitada pelos Gavião, Arara e Zoró, com a tomada de reféns pelos indígenas. Diversos outros conflitos com características similares ocorreram, com outras etnias.²³

Este e outros casos fizeram com que o Grupo Banco Mundial passasse a adotar critérios ambientais mais rígidos e, inclusive, passasse a exigir o Consentimento Prévio Livre e Informado (GOODLAND, 2004, p. 66) das comunidades afetadas, dando sequência a procedimentos já adotados desde a década de 80 do século 20 quando foi introduzido o conceito de “consulta significativa” para os projetos por ele financiados e, em 1992, com a participação obrigatória dos *stakeholders*. O mesmo critério foi adotado pela Corporação Financeira Internacional [IFC da sigla em Inglês]. Com a adoção do Consentimento Prévio Livre e Informado como um dos pressupostos legais para a aprovação de projetos de exploração de recursos naturais, há um novo requisito que é compatível com um novo modelo jurídico internacional para a utilização de recursos naturais em territórios indígenas e tradicionais. Como uma das instituições integrantes do grupo do Banco Mundial a IFC desenvolveu mecanismos para gerir os riscos sociais e ambientais dos projetos por ela financiados – natureza privada –, assim como o Banco Mundial – projetos públicos – fez para os seus. Dentre os padrões de performance adotados pela IFC, o de nº 7 é voltado para as comunidades indígenas e tradicionais.

A orientação adotada pelo Grupo Banco Mundial impactou as instituições financeiras privadas internacionais que passaram a ser agrupar sob a bandeira dos Princípios do Equador que é um conjunto de diretrizes e normas a serem observadas pela indústria financeira quando da concessão de financiamentos a projetos que impactem povos indígenas e comunidades tradicionais. Os Princípios do Equador contam com a adesão de 80 instituições financeiras de todos os continentes e exprimem um compromisso voluntário dessas instituições de os utilizarem como um instrumento para gestão e mitigação de riscos sociais e ambientais para os financiamentos de projetos. Fica claro, portanto, que o Consentimento Prévio Livre e Informado é uma condição necessária para a estabilidade financeira de grandes empreendimentos, pois em ele o risco de paralisações e questionamentos que podem gerar prejuízos significativos é muito elevado.

Relativamente ao relacionamento com as comunidades tradicionais e populações indígenas os Princípios do Equador expressamente estabelecem que no caso de Projetos das Categorias A e B, os clientes deverão demonstrar o “[e]ngajamento efetivo de Partes Interessadas, como um processo contínuo, estruturado e culturalmente apropriado, junto às comunidades afetadas e, quando pertinente, junto a outras partes interessadas.” (Princípio 5) E mais: “Quando o Projeto tiver potencial de gerar impactos adversos significativos sobre as Comunidades Afetadas, o cliente deverá promover um processo de Consulta e Participação Informada.” No particular, parece ser desnecessário dizer que os termos da C 169 e de sua interpretação judicial devem ser tomados como o padrão a ser implantado.

As Consultas a serem promovidas pelos clientes das instituições participantes dos PE deverão estar adequadas aos seguintes fatores: (i) os riscos e impactos do Projeto; (ii) a fase de desenvolvimento em que o Projeto se encontra; (iii) as preferências de idioma das Comunidades Afetadas e seus processos de tomada de decisões; e (iv) as necessidades de grupos vulneráveis ou em desvantagem. O processo deve ser consistente com as diretrizes emanadas dos tratados e convenções internacionais relativos às comunidades e populações indígenas, bem como com a farta jurisprudência sobre o tema e, portanto, deve ser livre de manipulação externa, interferências, coerção ou intimidação. A documentação a ser fornecida às Comunidades Afetadas deve estar “prontamente disponível” sendo relevante observar que ela deve ser “culturalmente adequada” e “no idioma local”.

20.8.5 Conclusões

O Consentimento Prévio Livre e Informado é um instrumento jurídico que determina a busca de um acordo entre governos, empreendedores e os povos indígenas e comunidades tradicionais sempre que se cuide da implantação de projetos, empreendimentos e atividades que possam afetar não só os territórios indígenas e de comunidades tradicionais, bem como a sua cultura, modo de vida e organização social. Pelo que foi demonstrado no artigo, o tema é cada vez mais relevante e presente nas relações econômicas internacionais, bem como nos diferentes *fora* que tratam de questões relativas aos direitos humanos. Parece bastante claro que, sob o regime jurídico internacional de proteção aos direitos humanos, a exploração de recursos naturais em terras habitadas por povos indígenas e populações tradicionais, necessariamente, deve ser precedida de Consultas realizadas com vistas à obtenção do Consentimento Prévio Livre e Informado. Dado que as principais instituições financeiras internacionais estão comprometidas com a exigência do Consentimento Prévio Livre e Informado para a concessão de financiamentos, um novo modelo legal e econômico está se afirmando, com repercussões diretas na forma de apropriação de recursos naturais.

O novo modelo em implantação é um reconhecimento, por parte da comunidade internacional, do protagonismo desempenhado pelos povos indígenas e populações tradicionais na conservação dos recursos naturais, bem como o fruto de justas reivindicações feitas por comunidades desde há muito marginalizadas, como foi muito bem observado por Robert Goodland (2004, p. 66), ex-servidor do Banco Mundial, dado que “dar atenção aos afetados pelo desenvolvimento é um processo relativamente novo”. Este processo novo é hoje uma exigência legal, com mecanismos bastante eficientes para o seu cumprimento.

§ 3º A LEGISLAÇÃO PENAL E OS INDÍGENAS

20.9 ASPECTOS GERAIS

O Direito Penal é um campo do Direito que tem grande importância para os assuntos legais voltados para a tutela dos índios. Em primeiro lugar, deve ser

consignado que é bastante vultoso e aspecto histórico da legislação penal e a sua incidência sobre os povos indígenas que habitam o território brasileiro. Como já foi visto em outros pontos do presente livro, diversas foram as leis do período colonial que determinavam o aprisionamento de índios, a imposição de penas diversas etc. Modernamente, a questão tem sido apresentada sob um outro ângulo, que é o da relação que deve haver entre uma legislação com tendências à generalização e à universalização, como é o caso da legislação penal, e o direito à diferença e à especificidade cultural que têm sido reconhecidos como direitos básicos das minorias étnicas.

20.10 LEGISLAÇÃO PENAL ESPECÍFICA (LEI Nº 6.001/73)

20.10.1 Principiologia em relação ao agente indígena

A legislação penal específica encontra-se arrolada no Estatuto do Índio. Assim é que os artigos 58/59 tipificam infrações penais próprias. É importante consignar que a especificidade, no caso, se encontra em uma principiologia particular naquilo que diz respeito ao sistema de imputação penal dos indígenas. Ademais, o sistema penal brasileiro admite a possibilidade de que os próprios indígenas possam aplicar sanções penais àqueles que tenham praticado atos que sejam contrários aos usos e costumes indígenas. Ficam, no entanto, excluídas as penas cuja natureza seja infamante e a pena de morte.

A Lei nº 6.001/73 admite a possibilidade de que o direito indígena seja aplicado para a solução de conflitos ocorridos dentro de uma comunidade indígena. Parece-me, entretanto, que a norma indígena somente poderá ser aplicada para a solução de conflitos ocorridos no interior de uma mesma tribo indígena. O espírito da legislação brasileira não alcança a aplicação das regras de um determinado ordenamento indígena quando o agente do delito não pertencer à comunidade cuja ordem social foi violada. Nesse caso, parece-me, deverá ser aplicado o direito brasileiro. Não se trata, contudo, de uma questão simples, pois, com toda razão, a nação cujo direito tenha sido violado deverá reivindicar a aplicação de seu ordenamento. Penso, entretanto, que ante a imensa pluralidade de ordens jurídicas indígenas, é necessário que o estranho tenha um parâmetro de comportamento que, no caso, é fornecido pela legislação indigenista brasileira. De qualquer forma, a questão permanece em aberto e somente a prática concreta poderá apresentar soluções satisfatórias.

Muitas questões, entretanto, serão suscitadas pela norma de direito indigenista. Em primeiro lugar há que se observar que o Direito Indígena deverá ser provado, isto é, a comunidade, ao optar pelo julgamento perante a Justiça Federal, deverá proceder tal qual a hipótese capitulada no artigo 376 do CPC.²⁴ Obviamente que, em sendo consuetudinário, tal direito deverá ser provado, no caso, mediante laudo antropológico que confirme a vigência da prática legal entre a comunidade indígena. Outra questão importante que é suscitada pela norma contida no projeto é a referente às garantias individuais. Como se sabe, o artigo 5º da Lei Fundamental está inspirado nas concepções jurídicas oriundas do liberalismo europeu e ocidental. Dessa forma, são assegurados aos acusados os direitos e garantias processuais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência etc. Tais princípios, como se sabe, são histórica e culturalmente determinados e, portanto, podem inexistir no contexto de um dado Direito Indígena. Pensamos, contudo, que, na hipótese de aplicação do Direito Indígena pelo Juiz Federal, o magistrado não poderá deixar de realizar uma adaptação entre o Direito Indígena e o artigo 5º da CRFB. De fato, o que ocorrerá será a aplicação do Direito Indígena mesclado com o sistema de garantias constitucionais brasileiro.

Com efeito, a norma comentada abre um imenso universo exegético e, sem dúvida, estabelece um novo parâmetro de observação do fenômeno jurídico, enriquecendo extraordinariamente o Direito brasileiro.

O artigo 56 da Lei nº 6.001/73 determina que:

No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.

Quanto à execução da pena, igualmente, existem princípios particulares a serem observados pelo magistrado competente. Dispõe o parágrafo único do artigo 56:

As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado.

O princípio geral é que as penas aplicadas aos indígenas deverão ser atenuadas, em razão de o agente ser indígena e, como parâmetro de dosimetria, deverá ser considerado o nível de integração do indígena na sociedade nacional. A atenuante será tanto maior quanto menor for o grau de integração do índio. Quanto à matéria ora ventilada, vale trazer à colação o seguinte acórdão do STF:

Habeas Corpus: Indígena. Se o índio já é aculturado e tem desenvolvimento mental que lhe permite compreender a ilicitude de seus atos, é plenamente imputável. Recurso desprovido (RHC 64.476-7/MG, Rel. Min. Carlos Madeira, DJU: 31/1/1986).

Ocorre que tal atenuante tem sido tratada pela doutrina jurídica de uma forma extremamente preconceituosa e nefasta. De fato, os doutrinadores em Direito Penal têm, sistematicamente, entendido que a atenuante em tela, isto é, o fato de o agente ser índio, não é aplicável. Ademais, o nível de integração vem sendo considerado como sinônimo de *desenvolvimento mental incompleto e/ou retardado*. Consagrados autores se pronunciaram, assim como Nelson Hungria, um dos autores do Código Penal de 1940 e Ex-Ministro do STF, sobre os índios e o Direito Penal:

O artigo 22 fala em “desenvolvimento incompleto ou retardado”. Sob este título se agrupam não só os deficitários congênitos do desenvolvimento psíquico ou oligofrênicos (idiotas, imbecis, débeis mentais), como os que são por carência de certos sentidos (surdos-mudos) e até mesmo os silvícolas inadaptados [...] assim não há dúvida que entre os deficientes mentais é de se incluir também o Homo sylvester, inteiramente desprovido das aquisições éticas do civilizado Homo medius que a lei penal declara responsável (SOUZA FILHO, s.d., p. 162).

Décadas após, o pensamento jurídico não se modificou em grande coisa. Damásio de Jesus (1998, p. 441), assim como a imensa maioria da doutrina penal, entende que os indígenas não integrados devem ser incluídos, para fins de inimputabilidade, na cláusula do desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

A segunda cláusula de inimputabilidade é o desenvolvimento mental incompleto, i. e., o desenvolvimento mental que ainda não se concluiu. É o caso dos menores de 18 anos (art. 27) e dos silvícolas inadaptados.

Outro autor de nomeada, como é o caso de Delmanto (1991, p. 48), refere-se ao assunto desta forma: “A lei se refere a desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Como exemplo, os silvícolas não totalmente integrados, os mudos por surdez sem aprendizado [...]”

Evidentemente que o grau de integração do indígena na sociedade nacional e o desenvolvimento mental são dois conceitos que não guardam a menor relação entre si. Para que um índio ou qualquer pessoa tenha o seu desenvolvimento mental completo não há a menor necessidade de que este esteja integrado na sociedade brasileira. As diferenças culturais não podem, de forma nenhuma, servir de base para julgamentos relativos à sanidade ou ao desenvolvimento mental de qualquer pessoa. Tratar-se diferenças culturais como retardamento mental é extremamente perigoso, pois, à semelhança do nazismo e do estalinismo, todo aquele que não estiver “integrado” em um determinado padrão de organização social passa a ser tratado como retardado mental, intelectualmente pouco desenvolvido ou louco.

Uma das vozes mais lúcidas a enfrentar o tema foi o falecido professor Heleno Cláudio Fragoso, que, ao discorrer sobre a matéria em tela, aponta para o fato de que se deve fazer uma distinção precisa entre a inimputabilidade decorrente de uma situação peculiar, do ponto de vista sociocultural, e a cláusula de desenvolvimento mental incompleto. É importante relembrar as palavras do professor Heleno Fragoso (1977, p. 14):

Nem sempre a questão estará bem posta pelo prisma da imputabilidade. Imputabilidade é capacidade de culpa, vale dizer, capacidade de governar a própria

conduta, segundo as exigências do ordenamento jurídico. Parece-nos terem razão os que afirmam não haver fundamento válido para formular, como princípio geral, o da inimizabilidade do indígena [...] trata-se de atribuir relevância jurídica ao déficit social dos silvícolas, enquanto estranhos e alheios ao nosso estilo de civilização.

O conhecido e respeitado especialista em Direito Indigenista brasileiro, prof. Carlos Frederico Marés de Souza Filho (SOUZA F^o, s.d., p. 164), examinou o tema da seguinte forma:

A leitura simples e direta do dispositivo legal nos remete à vontade do legislador de dar aos índios um tratamento diferenciado no julgamento da ação ou omissão criminosa dos índios, que, só pelo fato de sê-lo, deverão ter pena atenuada. Na aplicação da pena atenuada, deverá o juiz atender ao grau de integração. Quer dizer, em qualquer hipótese, o índio terá sua pena atenuada, conforme expressamente determina o texto legal, e de acordo com o seu grau de integração a aplicação será minorada.

A vontade do legislador, contudo, permanece presa a estereótipos e preconceitos em desfavor dos indígenas. A jurisprudência mais moderna vem se desenvolvendo no sentido de fazer uma clara distinção entre o desenvolvimento mental incompleto e/ou retardado e o grau de aculturação do indígena. Assim é que Delmanto (1991, p. 49) apresenta ementa que merece transcrição: “*É necessária perícia médica que comprove o desenvolvimento incompleto ou retardado, não bastando a só condição de silvícola*” (TJSC, RT 544/390; TJPR, RT 621/1339).

As causas de inimizabilidade, retardamento mental e baixo nível de aculturação, portanto, são totalmente diversas e não podem ser confundidas. O retardamento mental, não só para os índios, mas também para todo e qualquer acusado, deve ser comprovado por perícia médico-psiquiátrica. Já o grau de integração do índio somente pode ser comprovado pela perícia antropológica que a modalidade técnica específica. Não pode o magistrado, baseado em impressões pessoais, determinar se o indígena já se encontra em nível de compreensão plena do ordenamento jurídico da sociedade nacional e em gozo da capacidade de se auto-ordenar, em consonância com tal entendimento. A inexistência do laudo antropológico, no caso de condenação do indígena, parece-me acarretar a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e falta de prova técnica. Aliás, é importante ressaltar que os conceitos de índio integrado ou em vias de integração são conceitos técnico-normativos previstos nos incisos II e III do artigo 4º da Lei nº 6.001/73.

Quanto aos chamados *índios isolados*, ou seja, aqueles que “*vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional*”, eles são totalmente inimizáveis em razão da total incapacidade de compreensão do sistema jurídico nacional.

20.10.2 Crimes praticados contra os indígenas e suas comunidades

Inicialmente é na própria Lei Fundamental da República que deve ser encontrada a fonte normativa dos tipos penais que incriminam atos praticados contra os indígenas e as suas comunidades. Assim é que o artigo 3º, inciso IV, da Constituição determina que:

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Mais adiante, a Lei Máxima da República, no artigo 5º, incisos XLI e XLII, estabelece que:

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

XLII – a prática do racismo constitui crime inimizável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Os termos insculpidos em nossa Constituição são um importante fator de promoção social dos indígenas, bem como de outras minorias étnicas discriminadas. Entretanto, como se sabe, a simples existência do preceito constitucional não é suficiente para impedir a discriminação racial nas suas mais diversas manifestações.

A primeira imputação penal referente ao racismo tipificada pela legislação brasileira ocorreu com a chamada Lei Afonso Arinos, atualmente vige a chamada Lei Caó (Carlos Alberto de Oliveira, Deputado Federal autor do projeto, Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989).

20.10.2.1 Crimes previstos no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73)

O vigente Estatuto do Índio tem a previsão de diversos tipos penais voltados especialmente para a tutela dos indígenas e de seus valores fundamentais. Os três incisos do artigo 58 da Lei nº 6.001/73 definem como crime as seguintes figuras:

Artigo 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena: I – escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas; vilipendia-los ou perturbar; de qualquer modo, a sua prática: pena – detenção de um a três meses; II – utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos: pena – detenção de dois a seis meses; III – propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integrados: pena – detenção de seis meses a dois anos.

Todas as penas mencionadas são agravadas de um terço quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.

O primeiro crime tipificado tem como núcleos os verbos *escarnecer*, *vilipendiar* ou *perturbar* cerimônia, rito, uso, costume ou tradições culturais indígenas. O Dicionário Aurélio Eletrônico assim define o verbo *escarnecer*:

Verbete: escarnecer [Incoativo de escarnir.] V. t. d. 1. Fazer escárnio de; trocar de; zombar de; ludibriar. V. t. i. 2. Zombar; mofar: [Sin.: escarnir. Conjug.: v. aquecer.]

Já vilipendiar tem o significado de:

Verbete: vilipendiar V. t. d. 1. Tratar com vilipêndio. 2. Ter ou considerar como vil; desprezar; repelir. [Pres. ind.: vilipêndio, etc. Cf. vilipêndio.]

O crime, como é fácil perceber, se constitui de diferentes ações. O agente, parece-nos, somente pode ser indivíduo não índio ou, pelo menos, índio “integrado”. Na realidade, o objeto jurídico tutelado é o respeito aos usos e práticas de uma cultura *vis-à-vis* às demais. A proteção que a lei busca atribuir é, sem dúvida, uma proteção contra os elementos externos às diversas culturas indígenas. Pretende-se assegurar, coercitivamente, o respeito por parte dos integrantes da sociedade brasileira aos valores indígenas mais profundos. O crime admite tentativa.

O segundo crime, previsto no inciso II, diz respeito à preservação da imagem indígena. O objetivo da lei é evitar que a imagem indígena seja utilizada como atração turística ou “folclórica”, ou seja, foi proibida a exploração do elemento indígena como “curiosidade”, capaz de gerar lucro para aqueles que o façam. Evidentemente que a lei não proibiu a utilização de fotos, imagens ou qualquer outro instrumento audiovisual como fator de divulgação e fortalecimento da cultura indígena. O objeto jurídico tutelado é a integridade da imagem pública dos índios e de suas comunidades.

O terceiro tipo penal está vinculado a um duplice elemento, que é a integridade da saúde física e mental dos indígenas e, ao mesmo tempo, a integridade cultural das nações indígenas. Trata-se de incriminar todos aqueles que, por quaisquer meios, facilitem aos indígenas a utilização de bebidas alcoólicas. É desnecessário dizer do grande mal que se constituiu a bebida alcoólica no meio dos povos indígenas.

É de se observar que, ao teor do que dispõe o artigo 59 da Lei nº 6.001/73, a prática de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes de índio não integrado ou de comunidade indígena implica agravamento de um terço da pena aplicada.

Os crimes descritos, se praticados no interior de área indígena, serão processados e julgados perante a Justiça Federal (HC 65.912 – 8/MG, relator, o Ministro

20.10.2.2 Genocídio (Lei nº 2.889/56)

A Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, que define o crime de genocídio, embora não seja especificamente voltada para a defesa das populações indígenas, evidentemente, guarda grande importância para a defesa das populações indígenas como etnias. A lei, como se sabe, surgiu como uma reação internacional contra os crimes praticados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial contra minorias étnicas, tais como os judeus e os ciganos.

Lamentavelmente, a lei ora referida já teve oportunidade de ser utilizada pelo Ministério Público Federal quando da chacina cometida contra os ianomâmis.

Nos termos da lei, pratica o crime de genocídio:

Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal:

- a) matar membros do grupo;*
- b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;*
- c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial;*
- d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo (art. 1º).*

A incitação à prática do genocídio, em qualquer das modalidades previstas na lei, direta e publicamente, implica pena correspondente à metade das penas cominadas no artigo 1º. Havendo a consumação do genocídio, em razão da incitação, a pena aplicada ao incitador será igual à do crime consumado. Caso a incitação seja praticada pela imprensa, a pena será aumentada de um terço.

A associação de mais de três pessoas para a prática do genocídio implica agravamento em metade das penas aplicadas, conforme determinação legal contida no artigo 2º. Haverá agravamento em um terço da pena, caso o crime seja praticado por governante ou funcionário público.

Ponto importante da lei é que o crime de genocídio não é considerado crime político para os fins de extradição (art. 6º).

Por força do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, o crime de genocídio foi considerado como crime hediondo e, portanto, submetido a um regime jurídico particular²⁵. Em assim sendo, o genocídio, tentado ou consumado, é insuscetível de anistia, graça ou indulto, fiança (art. 2º, I e II).²⁶ Há, ainda, a previsão legal de um regime próprio de execução penal que retira do âmbito da Lei de Execuções Penais a execução das penas aplicadas aos genocidas.

Em primeiro lugar, deve ser apontado que o genocida deverá cumprir a pena integralmente em regime fechado. O réu somente poderá apelar em liberdade se o magistrado, fundamentadamente, assim o decidir.

20.10.2.3 Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716/89)

Em substituição à antiga Lei Afonso Arinos, que estabelecia a contravenção resultante de preconceito racial ou de cor, o Congresso Nacional decretou e foi sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Na aludida lei são tipificadas diversas condutas criminosas que, evidentemente, são praticadas em detrimento não apenas dos índios, mas de todo e qualquer grupo étnico e racial. A lei é bem mais abrangente que a antiga Lei Afonso Arinos e cobre um universo mais amplo.

O primeiro crime tipificado pela lei é o de “impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviço público” (art. 3º). A prática é apenada com reclusão de dois a cinco anos. Também é considerado crime o ato de “negar ou obstar emprego em empresa privada” (art. 4º), bem como impedir o ingresso nas forças armadas (art. 13). “Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador” (art. 5º). O bloqueio ao acesso às instituições de ensino, públicas ou privadas, de qualquer grau, em razão da raça ou da cor do indivíduo, é o crime previsto no artigo 6º. A pena cominada é de reclusão de três meses a cinco anos, agravando-se de um terço, caso o crime seja praticado contra menor de 18 anos.

Os serviços de hotelaria, estalagem e pensões, restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público não podem negar atendimento ou acesso aos indivíduos, sob pena da prática dos crimes previstos nos artigos 8º e 9º.

Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público (art. 10), bem como impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades (art. 11), são crimes previstos na lei em tela.

O livre acesso a todos os meios de transporte é o bem jurídico tutelado pela norma contida no artigo 13.

Por fim, é considerado crime o ato de impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social; a pena para o crime previsto no artigo 14 é de reclusão de dois a quatro anos.

No caso em que os crimes previstos na lei ora examinada tenham sido praticados por servidor público, haverá a pena acessória de perda do cargo. Os estabelecimentos comerciais, nos quais tenha sido praticado o crime de racismo, terão o seu funcionamento suspenso por prazo que não excederá três meses.

20.10.2.4 Lavra garimpeira (Lei nº 7.805/89)

A Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, instituiu o chamado regime de permissão de lavra garimpeira. O regime de lavra garimpeira, como se sabe, é o aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A matéria é de grande relevância para o Direito Indigenista, pois, é notório, as áreas indígenas são extremamente ricas em minerais.

O crime previsto no artigo 21 da lei em questão determina que: “a realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa”. É decretado, também, o perdimento de todos os utensílios que tenham sido utilizados na extração ilegal do minério.

A permissão de lavra garimpeira, instituída na lei em tela, não se aplica às áreas indígenas. A conduta típica punível, contudo, pode ser praticada no interior de áreas indígenas.

20.10.2.5 Crimes praticados pelos índios

A imputabilidade penal plena somente é reconhecida aos indígenas que se encontrem “integrados” à sociedade envolvente. Em razão disso, o Estatuto do Índio determina que, no caso de condenação de índio por infração penal, deverá ser atenuada a pena, e o juiz deverá estar atento ao grau de integração do silvícola (art. 56). A Lei nº 6.001/73 determina, ademais, que as penas de reclusão e detenção deverão ser cumpridas, *se possível*, em regime de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado.

- 1 Constituição de 1937: “Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.”
- 2 Constituição de 1946: “Art. 5º Compete à União: [...] XV – legislar sobre: [...] r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional.”
- 3 Constituição de 1946: “Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.”
- 4 Constituição de 1967: “Art. 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes.”
- 5 Constituição de 1967: “Art. 4º Incluem-se entre os bens da União: [...] IV – as terras ocupadas pelos silvícolas.”
- 6 Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969: “Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. § 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. § 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio.”
- 7 Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969: “Art. 4º Incluem-se entre os bens da União: [...] IV – as terras ocupadas pelos silvícolas.”
- 8 STF, Pet. 3388, Voto do Ministro Carlos Ayres de Brito. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/dl/Voto_Brito_Pet3388.pdf>.
- 9 Pela redação do Estatuto, verifica-se que o índio não é considerado membro da comunidade nacional.
- 10 *O Mogno Kaiapó*, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, op. cit., p. 312.
- 11 Para maiores detalhes, v. Aurélio Veiga Rios. Os Direitos Constitucionais dos Índios nas Faixas de Fronteiras. In: SANTILLI, Juliana (Org.). Op. cit., p. 51 ss.
- 12 Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=118284>>. Acesso em: 31 dez. 2009.
- 13 Disponível em: <http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=o-que-e#consulta>. Acesso em: 26 jun. 2015.
- 14 Disponível em <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/-BNDES_Transparente/Responsabilidade_Social_e_Ambiental/politica_de_responsabilidade.html>. Acesso em: 6 ago. 2015.
- 15 Disponível em: <<http://www.funai.gov.br/index.php/todos-ouvidoria/23-perguntas-frequentes/97-pergunta-3>>. Acesso em: 27 fev. 2015.
- 16 Disponível em: <<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>>. Acesso em: 15 ago. 2015.
- 17 Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?page_id=88>. Acesso em: 2 mar. 2015.
- 18 Ver relação dos signatários disponível em: <http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/f.Protocolo_de_San_Salvador_Ratif.htm>. Acesso em: 7 ago. 2015.
- 19 Disponível em: <<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/por7.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2015.
- 20 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, CASO DO POVO SARAKAMA VS. SURINAME, SENTENÇA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007 (**Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas**), in, Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos/Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tradução da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, p. 273-4. Notas suprimidas.
- 21 Disponível em: <<http://www.amnestyusa.org/news/news-item/india-landmark-supreme-court-ruling-a-great-victory-for-indigenous-rights>>. Acesso em: 17 ago. 2015.
- 22 Superior Tribunal de Justiça. SLS 001745, Relator Ministro Félix Fischer. Publicação: 24/04/2013.
- 23 Cultural Survival, Quarterly, 10.2 (Summer 1986) Land Rights: Strategies for Survival, i Disponível em: <<http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/brazil/warfare-polonoeste>>. Acesso em: 2 jul. 2015.
- 24 Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.
- 25 Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados [...]. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.
- 26 Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I – anistia, graça e indulto; II – fiança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral e BEZERRA, Gustavo das Neves. (2009) *O que é Justiça Ambiental*. Rio de Janeiro: Garamon.
- AGUIAR, Roberto Armando Ramos. (1994) *Direito do Meio ambiente e Participação Popular*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal/Ibama.
- ALBERT, Bruce. (1993) *O massacre dos Yanomami de Haximu*. Brasília, datilografado, relatório apresentado à Procuradoria Geral da República.
- ALLAIS, Catherine. (1992) O estado do planeta em alguns números. In: BARRÈRE, Martine (Org.). *Terra, patrimônio comum*. São Paulo: Nobel.
- ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. (2005) *Competências na Constituição de 1988*. 3. ed. São Paulo: Atlas.
- ALMEIDA, João Batista de. (1991) *Comentários ao Código de Proteção do Consumidor*. São Paulo: Saraiva, 1991.
- _____. (2001) *Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública – Doutrina e Jurisprudência*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- ALTMAN, Daniel. (2011) *O Futuro da Economia: as 12 tendências que vão transformar a economia global*. (Trad. Afonso Celso da Cunha Serra) Rio de Janeiro: Elsevier.
- ÁLVARES, Walter T. (1976) *Curso de Direito da Energia*. Rio de Janeiro: Forense.
- ALVES, Vilson Rodrigues. (1992) *Uso nocivo da propriedade*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- ANAYA, S. James. (2009) *International Human Rights and Indigenous Peoples*. Austin: Wolters Kluwer.
- ANDERSON, Perry. (1992) *O fim da história – de Hegel a Fukuyama*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- ANDRADE, Manuel A. Domingues. (1983) *Teoria Geral da Relação Jurídica*. Coimbra: Almedina, v. I.
- _____. (2014) *Direito Ambiental*, São Paulo: Atlas, 16. ed.
- ANTUNES, Paulo de Bessa. (1992) *Curso de Direito Ambiental*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar.
- _____. *Uma nova introdução ao Direito*. Rio de Janeiro: Renovar.
- _____. (2015) *Dano Ambiental: uma abordagem conceitual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas.
- _____. *Diversidade Biológica e Conhecimentos Tradicionais Associados*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- _____. (1995) *Jurisprudência Ambiental Brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- _____. (1995a) Polícia tem que ficar fora de área indígena. *Jornal do Comércio*, 18 ago. 1995.
- _____. (1992a) Princípios constitucionais de utilização da energia nuclear. *Revista da Procuradoria Geral da República*. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 1, out./nov./dez.
- _____. (1994) A justiça e o direito a água limpa. In: CAUBET, Guy (Org.). *Manejo alternativo de recursos hídricos*. Florianópolis: UFSC, 1994.
- _____. (2005) A necessária proteção do conhecimento tradicional, *Gazeta Mercantil*.
- _____. (2005a) Vale o mais restritivo? Disponível em: <www.oeco.com.br>. Acesso em: 28/8/2005.
- _____. (2005b) Omissões inconstitucionais. Disponível em: <www.oeco.com.br>. Acesso em: 11/9/2005.
- _____. (2005c) Correr atrás de baleia é crime. Disponível em: <www.oeco.com.br>. Acesso em: 18/9/2005.
- AQUINO, Sandra Cilce de. (s/d) *Parecer sobre OCIP*. Inédito. Informações básicas sobre ao assunto.
- ARGENTINA, Política Ambiental Nacional. Ley 25.675.
- ARNT, Ricardo. (2001) Tesouro Verde. *Exame*, ano 35, nº 9, maio.
- AYLWARD, Bruce. (1998) *The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care*. In: SWANSON, Timothy M. *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation – An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*. Cambridge: Cambridge.
- AZEVEDO, Álvaro Villaça. (1997) *Teoria Geral das Obrigações*. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- BALEEIRO, Aliomar. (1985) *Direito Tributário Brasileiro*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense.
- BANCO MUNDIAL. (1992) *Le Secteur Forestier*. Washington.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. (1992) *Curso de Direito Administrativo*. 4. ed. São Paulo: Malheiros.
- _____. (1991) *Elementos de Direito Administrativo*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- BANQUE MONDIALE. (1992a) *Le secteur Forestier*. Washington.
- BARDET, Gaston. (1990) *O urbanismo*. Campinas: Papirus.
- BARRÈRE, Martine. (1992) *Terra – Patrimônio Comum – A ciência a serviço do meio ambiente e do desenvolvimento*. São Paulo: Nobel.
- BARROSO, Luis Roberto. (2004) *Interpretação e Aplicação da Constituição*. 6. ed. São Paulo: Saraiva.
- BASTOS JR., Luiz Magno Pinto. (2001) A Convenção sobre Diversidade Biológica e os Instrumentos de Controle das Atividades Ilegais de Bioprospecção, *Revista de Direito Ambiental*. Revista dos Tribunais, ano 6, jul./set. 2001, nº 23.
- BECK, Ulrich. (2013) Sociedade de risco – rumo a uma outra modernidade (Trad. Sebastião Nascimento), São Paulo: Editora 34.
- BENJAMIM, Antônio Hermann. (1992) Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites da discricionariedade administrativa, *Revista Forense*, nº 317, jan./mar.
- _____. *Visão Geral da lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação*. In: MILANO, Miguel Sereidiuk; THEULEN (Org.). (2000) *II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais*, v. III. Campo Grande.
- _____. (2001) Introdução à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. In: BENJAMIN, Antônio Hermann (Coord.). *Direito Ambiental das Áreas protegidas*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- _____. (Org.). (2001a) *Direito Ambiental das Áreas Protegidas*. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
- BERGERON, Yves et al. (1992) A floresta ameaçada. In: BARRÈRE, Martine. *Terra. Patrimônio comum – a ciência a serviço do meio ambiente e do desenvolvimento*. Nobel.
- BITTAR, Carlos Alberto. (1989) *Responsabilidade civil – teoria e prática*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- _____. (1985) *Responsabilidade civil nas atividades nucleares*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.
- _____. (1990) *Direito das Obrigações*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.
- Black's law dictionary*. (1991) St. Paul: West.
- BLAKENEY, Michael. (s/d) Bioprospecting and the Protection of Traditional Medical Knowledge of Indigenous People: an Australian Perspective, *European Industrial Property Review*, v. 19, issue 6.
- _____. (1995) Protecting Expressions of Australian Aboriginal Folklore under Copyright Law, *European Intellectual Property Review*, 9.
- BOBBIO, Norberto. (1992) *A era dos direitos*. Rio de Janeiro: Campus.
- BORÉM, Aluizio. (2001) *Escape Gênico & Transgênicos*. Viçosa: UFV.
- BOSQUET, Michel. (1978) *Ecologia e liberdade*. Lisboa: Vega.
- BOXER, Charles R. (2000) *A idade de ouro do Brasil – dores de crescimento de uma sociedade colonial*. (Trad. Nair de Lacerda) Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- BRAÑES, Raúl. (2000) *Manual de Derecho Ambiental Mexicano*. 2. ed. México DF: Fondo de Cultura Económica.

- BRASIL. (1941) Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
- BRASIL. (1992) Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 1992, seção I, suplemento ao nº 33.
- BRASIL. (1965) Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965.
- BRASIL, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
- BRASIL, Constituição Federal.
- BRASIL, Decreto n. 2.681, de 7 de dezembro de 1912.
- BRASIL, Lei nº 12.846, de 1ª de agosto de 2013. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AREsp 476067, Relator Min. Humberto Martins.
- BRASIL, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1071741/SP, Relator Min. Herman Benjamin.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1373788/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 1381211/TO, Relator Min. Marco Buzzi.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, REsp 160051/RJ, Relator Min. Antônio de Pádua Ribeiro.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1412664/SP, Relator Min. Raul Araújo.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.421.027 – RJ (2012/0218893-7) Relator Min. Raul Araújo.
- BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AREsp 414617, Relator Min. Sérgio Kukina.
- BRASIL, Constituição Federal.
- _____. Decreto nº 86.029, de 27 de maio de 1981.
- _____. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
- _____. Decreto de 27 de dezembro de 2004.
- _____. Decreto de 13 de julho de 2006.
- _____. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
- _____. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.
- BREEN, Barry. (1993) *Environmental Law from resource to recovery*. In: CAMPBELL-MOHN, Celia; BREEN, Barrey; FUTRELL, J. William. *Environmental law from resources to recovery*. St. Paul: West.
- BROWN, Lester R. (1992) O início da revolução ambiental. In: BROWN, Lester R. *Qualidade de vida 1992 – Salve o planeta!* Globo.
- _____; RENNERT, Michael; HALWEIL, Brian. (2000) *Sinais Vitais 2000 – As tendências ambientais que determinarão nosso futuro*. (Trad. Henry J. Mallet) Salvador: UMA.
- CABALLERO, Francis. (1981) *Essai Juridique sur la notion de nuisance*. Paris: LGDJ.
- CAETANO, Marcello. (1986) *Manual de Direito Administrativo*. 10. ed. Coimbra: Almedina.
- CÂMARA LEAL. (1982) *Da prescrição e da decadência*. Rio de Janeiro: Forense.
- CANBY JR., William. (1994) *American Indian Law*. St. Paul: West, 1994.
- CAPOBIANCO, João Paulo R. (2001) Situação e perspectivas para a conservação da Mata Atlântica. In: LIMA, André (Org.). *Aspectos jurídicos da proteção da Mata Atlântica*. São Paulo: Instituto Sócio Ambiental.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. (1983) *Jurisdição e competência*. São Paulo: Saraiva, CARSON, Rachel. (2010) *Primavera Silenciosa* (Trad. Cláudia Sant’Anna Martins), São Paulo: Editora Gaia
- CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. (1991) O drama dos Yanomamis, *Ciência Hoje*, Amazônia, dez.
- CARSON, Rachel (1994) *Silent Spring* (with an introduction of Vice President Al Gore). Boston-New York, Houghton Mifflin.
- CARVALHO, Afrânio. (1986) *Águas interiores*. São Paulo: Saraiva.
- CARVALHO, Carlos Gomes. (1990) *Introdução ao Direito Ambiental*. Cuiabá: Verde-Pantanal.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. (1999) *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- CASSIER, Ernst. (2001) *Ensaio sobre o Homem – Introdução a uma Filosofia da Cultura Humana*. (Trad. Tomás Rosa Bueno) São Paulo: Martins Fontes
- CASTRO, José Nilo. (1999) *Direito Municipal Positivo*. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
- CHADE, Jamil. (2001) País quer defender conhecimento indígena, *O Estado de S. Paulo*, 18 dez., Geral.
- CHILE. Decreto Supremo nº 66 de 2013.
- _____, Ley nº 19.300
- CIRNCROSS, Frances. (1992) *Meio Ambiente – custos e benefícios*. São Paulo: Nobel.
- CLARK, Brian. (1994) A Aia e o Banco Mundial. In: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário; JESUS, Júlio de. *Avaliação do Impacto Ambiental*. Lisboa: CEPGA.
- _____. (1994) O Processo de AIA: Conceitos básicos. In: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário; JESUS, Júlio de (Org.). *Avaliação do Impacto Ambiental*. Lisboa: Centro de Estudos de Planeamento e Gestão Ambiental – CEPGA.
- COLL, Josefina Oliva de. (1986) *A resistência indígena – do México à Patagônia, a história da luta dos índios contra os conquistadores*. 2. ed. (Trad. Jurandir Soares dos Santos) Porto Alegre: LPM.
- COLÔMBIA – Corte Constitucional Sentença C-030 de 2008.
- _____. – Decreto 6837 78.
- COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. (1988) *Nosso Futuro Comum*. Rio de Janeiro: FGV.
- CONTADOR, Cláudio Roberto. (1988) *Avaliação social de projetos*. 2. ed. São Paulo: Atlas.
- CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. (2014) Caso do povo Saramaka vs. Suriname. Sentença de 28 de novembro de 2007 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos/Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia, Corte Interamericana de Direitos Humanos. (Trad. Corte Interamericana de Direitos Humanos) Brasília: Ministério da Justiça.
- CORREA, Carlos M. (s/d) *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPS Agreement and Policy Options*. New York/Pennag: ZED/Third World Network, s/d.
- COTTERELL, Arthur. Introdução. In: SPENCE, Lewis. (1993) *Mitologia Norte-Americana*. Guia Ilustrado. Lisboa: Editorial Estampa/Círculo dos leitores.
- COUGHLIN JR., M. D. (s/d) *Using the Merck – INbio agreement to clarify the Convention on Biological Diversity*, *Columbia Journal of Transnational Law* 31(2).
- COUSILLAS, Marcelo J. (1994) *Evaluación del impacto ambiental*. Montevideo: IEEM.
- CRETILLA JR., José. (1989) *Comentários à Constituição de 1988* (artigos 1ª a 5ª LXVII). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- _____. *Comentários à Constituição de 1988*. (1991) Rio de Janeiro: Forense Universitária. v. IV.
- _____. (1980) *O Estado e a obrigação de indenizar*. São Paulo: Saraiva.
- CRICK, Francis. (1996) *The Astonishing Hypothesis – the scientific search for the soul*. New York: Simon and Schuster.
- CULTURAL SURVIVAL, Quarterly, 10.2 (Summer 1986) Land Rights: Strategies for Survival.
- CUNHA, Manuela Carneiro da. (1985) Definições de Índios e comunidades indígenas nos textos legais. *Sociedades indígenas e o direito, uma questão de direitos humanos*. Florianópolis: UFSC.

_____. (1987) *Os direitos do índio*. São Paulo: Brasiliense.

DAJOZ, Roger. (1983) *Ecologia Geral*. 4. ed. Petrópolis.

D'AMATO, Claudio; TORRES, João P. M.; MALM, Olaf. DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane): toxicity and environmental contamination – a review. *Quím. Nova*. São Paulo, v. 25, n. 6a, 2002. Disponível em: <<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S010040422002000600017&lng=en&nrm=iso>>.

DARWIN, Charles. (s/d) *The origin of species* – by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. New York: Bantam Books.

Déclaration de Limoges, de 16 de novembro de 1990.

DELMANTO, Celso. (1989) *Código Penal comentado*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar.

_____. (1981) *Código Penal Comentado*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar.

DESPAX, Michel. (1980) *Droit de L'environnement*. Paris: Litec.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. (1990) *Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas.

_____. (1996) *Parcerias na Administração Pública*. São Paulo: Atlas.

DIAMOND, Jared. (2000) *De l'inégalité parmi les sociétés* – Essai sur L'Homme et L'Environnement dans L'Histoire. Paris: Galimard.

_____. (2005) *Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso*. (Trad. Alexandre Raposo) Rio de Janeiro: Record.

DICK, Phillip K. (2002) *Minority Report: a nova lei* (Trad. Ana Luiza Borges). Rio de Janeiro: Record.

DIEGUES, Antônio Carlos. (2002) *Aspectos sociais e culturais do uso dos recursos florestais da Mata Atlântica*. São Paulo: Senac.

_____; ARRUDA, Renato S. V. (Org.). (2001) *Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil*. Brasília: MMA.

DINIZ, Maria Helena. (1989) *Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito das Coisas*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, v. IV.

_____. (1989) *Norma Constitucional e seus efeitos*. São Paulo: Saraiva.

_____. (1998) *Lei de introdução ao CC Brasileiro interpretada*. 4. ed. São Paulo: Saraiva.

DOAS, Margaret. (1995) Intellectual Property Law. Indigenous Peoples Concerns. In: *Canadian Intellectual Property Review*, v. 12, nº 1, oct.

DORST, Jean. (1973) *Antes que a natureza morra*. São Paulo: Edgar Blücher.

DOUGLAS, Mary. (1994) *Risk and Blame – Essays on Cultural Theory*, London and New York: Routledge.

DUPUY, Pierre-Marie. (1976) *La responsabilité internationale des états pour le dommage d'origine technologique et industrielle*. Paris: Pedonne.

DURNING, Alan Thein. (1993) Prestando apoio aos povos indígenas. In: BROWN, Lester. *Qualidade de vida – 1993 – salve o planeta!*

DURNING, Allan B. (1990) Acabando com a pobreza, *Salve o Planeta! Qualidade de vida* 1990. São Paulo: Globo.

DUTILED, Grahlan. (2000) *Intellectual property rights, trade and biodiversity*. London: IUCN/Earthscan.

DWORKIN, Ronald. (2002) *Levando os Direitos a Sério*. (Trad. Nélson Boderá) São Paulo: Martins Fontes.

_____. (2000) *Uma questão de princípio*. (Trad. Luís Carlos Borges) São Paulo: Martins Fontes,

EDELMAN, Margalit. (2001) Os beneficiários da propriedade intelectual, *Gazeta Mercantil*, 16, 17 e 18 nov.

EHRlich, Paul R. (2000) *Human Natures: genes, cultures, and the human prospect*. Washington: Island Press/Shearwater Book.

ENGISCH, Karl. (1979) *Introdução ao pensamento jurídico*. 5. ed. (Trad. Prefácio de J. Baptista Machado). Lisboa: Calouste Gulbenkian.

ENTERRÍA, Eduardo Garcia de; FERNANDEZ, Tomás Ramón. (1990) *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

ENZENSBERGER, Hans Magnus. (1995) *Guerra Civil*. São Paulo: Cia das Letras.

ERRIGNON, Judith. (1992) Les Vêrts: Changer la société in *Tout sur les écologistes*. Collection Libération, nº 9, mar.

ESTADO DE MINAS GERAIS. TJMG, AC 10439110065125001 MG, Relator Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível. publ. 02/12/2013.

ESTADO DE SÃO PAULO. TJSP. APL 90933507420098260000 SP, Relator Desembargador Ricardo Dip, 1ª Câmara extraordinária de Direito Público, publ. 16/05/201.

EUGUI, David Vivas. (s/d) *El régimen legal y la experiencia venezolana en materia de acceso a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual*.

EWALD, François. (1993) *Foucault – A norma e o Direito*. Lisboa: Vega, 1993.

_____. (s/d) *L'État providence*. Paris: Grasset.

_____. (s/d) La Faute Civile, Droit et Philosophie. In: *Fin de la faute?* Paris: PUF, Droits, nº 5.

FANON, Frantz, (1963) *The Wretched of the Earth*, Preface by Jean-Paul Sartre, Translated by Constance Farrington Grove Weidenfeld, New York.

FARIAS, Talden. (2007) *Licenciamento Ambiental – Aspectos Teóricos e Práticos*. Belo Horizonte: Fórum.

FAURE, Michael, (2007) *L'analyse économique du droit de l'environnement*, Bruxelles: Bruylant.

FERRAZ, Sérgio. (1972) Direito Ecológico, perspectivas e sugestões, Porto Alegre. *Revista da Consultoria-Geral do Estado*, v. 2, nº 4.

FINDLEY, Roger; FARBER, Daniel. (1988) *Environmental Law*. St. Paul: West.

FISCHOFF, Baruch; LICHTENSTEIN, Sarah; SLOVIC, Paul; DERBY, Stephen Le KEENEY, Ralph. (1981) *Acceptable risk*, Cambridge: Cambridge University Press, 1.

FLAVIN, Christopher. (2000) *Planeta rico, planeta pobre*. In: BROWN, Lester R. *Estado do Mundo 2001*. Salvador: UMA.

FRAGOSO, Fernando. (1992) Os crimes contra o meio ambiente no Brasil, *Revista Forense*, nº 317, jan./mar.

FRAGOSO, Heleno Cláudio. (1977) *Direito Penal e Direitos Humanos*. Rio de Janeiro: Forense.

FREIRE, William. (1995) *Comentários ao Código de Mineração*. Rio de Janeiro: Aide.

FREITAS, Vladimir Passos de. (1993) *Direito Administrativo e meio ambiente*. Curitiba: Juruá, 1.

_____. (2000) *A CF e a Efetividade das Normas Ambientais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2.

_____; FREITAS, Gilberto Passos de. (1990) *Crimes contra a natureza*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

FUNARI, Pedro Paulo; NOELLI, Francisco Silva. (2002) *Pré-História do Brasil*. São Paulo: Contexto.

FURLAN, Anderson; FRACALOSS, William. (2010) *Direito Ambiental*. Rio de Janeiro: Forense.

FUTRELL, J. William. (1993) *The History of environmental law*. In: CAMPBELL-MOHN, Celia; BREEN, Barry; FUTRELL, J. William. *Environmental law from resources to recovery*. St. Paul: West.

GALEANO, Eduardo. (1986) *Nascimentos – Memória do Fogo* (1). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

GARCIA, Rodolfo. (1975) *Ensaio sobre a História Política e Administrativa do Brasil (1500-1810)*. Rio de Janeiro: José Olympio-MEC.

GASPARINI, Diógenes. (1989) *Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva.

GASSEN, Hans Günther. (2000) *Biotechnologia para Países em Desenvolvimento*. In: GASSEN, Hans Günther et al. *Biotechnologia em Discussão*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.

GAZETA MERCANTIL, (2002) Vegetação natural em SP aumenta após trinta anos, 3 out.

GLISSEN, John. (1988) *Introdução histórica ao Direito*. Lisboa: Calouste Gulbenkian.

GOLDBERGER, José; DESSUS, Benjamim. (1992) Energia: inventar novas solidariedades, *Terra patrimônio comum – A ciência a serviço do meio ambiente e desenvolvimento*. Nobel.

GOMES, Orlando. (1998) *Obrigações*. Rio de Janeiro: Forense. 8. ed., 1986, 12. ed.

GONÇALVES, Carlos Roberto. (1988) *Responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva.

- GOODLAND, Robert. (2004) Free, Prior and Informed Consent and the World Bank Group. Sustainable Development Law and Policy, Summer.
- GOULD, Stephan Jay. (1993) *Dedo mindinho e seus vizinhos* – Ensaios de história natural. (Trad. Sérgio Flaksman) São Paulo: Companhia das Letras.
- GRANZIERA, Maria Luiza Machado. (1993) *Direito de águas e meio ambiente*. São Paulo: Ícone,
- _____. (2009) *Direito Ambiental*, São Paulo: Atlas.
- GRAU, Eros Roberto. (1991) *A ordem econômica na Constituição de 1988* (interpretação e crítica). 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- _____. (1983) *Direito Urbano*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- GRECO FILHO, Vicente. (1991) *Comentários ao Código de Proteção do Consumidor*. São Paulo: Saraiva.
- GREENPEACE INTERNATIONAL, jan. 1992.
- GUATARI, Felix. (1990) *As três ecologias*. Campinas: Papirus.
- GUERRA, Antonio Teixeira. (1993) *Dicionário Geológico – Geomorfológico*. 8. ed. Rio de Janeiro: IBGE.
- GUIMARÃES, Paulo Machado. (1993) *Ementário de jurisprudência indigenista*. Brasília: CIMI.
- HAIGH, Nigel. (1994) *Direito Comunitário do Ambiente. Direito do Ambiente*. Lisboa: INA.
- HALL, Gilbert e PATRINOS, Anthony, (2005) Latin America's Indigenous Peoples, Finance and Development, dez. v. 42, nº 4.
- HANNIGAN, John. (2014) *Environmental Sociology*, London and New York: Routledge, 3. ed.
- HAWKING, Stephen W. (1989) *A brief history of time from the big bang to black holes*. New York: Bantam.
- HÉMER, Daniel; DEBIER, Jean-Claude; DELÉAGE, Jean-Paul. (1993) *Uma história da energia*. Brasília: Ed. da UnB.
- HERTSGAARD, Mark. (1992) Les Catastrophes secrètes de Tcheliabinsk, *L'évenement du jeudi*, nº 376, 16 au 22 janvier.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. (1985) *História Geral da Civilização Brasileira, I – A época colonial (do descobrimento à expansão territorial)*. São Paulo: DIFEL.
- HOLANDA, Aurélio Buarque de (s/d) *Dicionário Aurélio eletrônico*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- ILNUOVO ZINGARELLI. Vocabulário della lingua (1988) italiana. Milano: Zanichelli, undicesima edizione,
- INSTITUTO ACENDE BRASIL (2013). Povos Indígenas e o Setor Elétrico: do Conflito ao Consenso. White Paper 12, São Paulo.
- JAPIASSU, H.; MARCONDES, D. (1990) *Dicionário Básico de Filosofia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
- JATAHY, Carlos Roberto de Castro. (2008) *Curso de Princípios Institucionais do Ministério Público*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- JESUS, Damásio E. de. (1988) *Direito Penal – Parte Geral*. 13. ed. São Paulo: Saraiva.
- JUSTEN FILHO, Marçal. (2005) *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva.
- KADE, Gerhard et al. (1975) *O homem e seu ambiente*. Rio de Janeiro: FGV.
- KEEPIN, Bill. (1992) Energia nuclear e aquecimento global, *Aquecimento Global* – o relatório do Greenpeace. Rio de Janeiro: FGV.
- KELSEN, Hans. (1979) *Teoria Pura do Direito*. Coimbra: Armênio Amado Editor.
- KHALIL, Mohamed. (1998) Biodiversity and the Conservation of Medicinal Plants: issues from the perspective of the developing world. In: SWANSON, Timothy M. (Ed.). *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation – an interdisciplinary analysis of the values of medicinal plants*. Cambridge: Cambridge.
- KISS, Alexandre. (1989) *Droit International de L'environnement*. Paris: Pedonne.
- _____. (2004) Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. In KRINSKY, Sheldon. (1991) *Biotechics and Society – The rise of industrial genetics*. Westport: Praeger.
- LACERDA, Galeno. (1986) Ação Civil Pública, *Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, edição especial, nº 19.
- LAITOS, Jan G.; TOMAIN, Joseph P. (1992) *Energy and natural resources law*. St. Paul: West.
- LARENZ, Karl. (1987) *Derecho Civil* – parte general. Madri: Reunidas.
- _____. (1985) *Derecho justo* – Fundamento de la ética jurídica. (Trad. Luis Díez-Picazo) Madrid: Civitas.
- LAS CASAS, Bartolomé. (1997) *Brevíssima Relação da destruição das Índias*. (Trad. Júlio Henriques) Lisboa: Antígona.
- LAUGHTON, M. A. Power To The People. Future-proofing the security of UK power supplies. Disponível em: <http://www.viewsofscotland.org/library/docs/ASI_Power_to_the_People_03.pdf>.
- LEAKEY, Richard; LEWIN, Roger. (1999) *La sixième extinction – évolution et catastrophes*. (Trad. Vincent Fleury) Paris: Flammarion.
- LEAL, Vítor Nunes. (1945) Ato discricionários e as funções quase judiciais da administração. Rio de Janeiro: DASP, *RDA*, nº 2.
- LEGGET, Jeremy (Org.) (1992) *Aquecimento Global* – o relatório do Greenpeace. Rio de Janeiro: FGV.
- LEITÃO, Ana Valéria Nascimento Araújo. (1993) Direitos culturais dos povos indígenas – aspectos do seu reconhecimento. In: SANTILLI, Juliana. *Os Direitos Indígenas e a Constituição*. Porto Alegre: Sérgio Fabris.
- LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. (2010) *Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial*. 3. ed. São Paulo: RT.
- _____; FERREIRA, Maria Leonor Paes Cavalcanti. Estado de Direito Ambiental no Brasil: Uma Visão Evolutiva. In: FARIAS, Talden; COUTINHO, Francisco Seráfico da Nóbrega (Org.). (2010) *Direito Ambiental: O Meio Ambiente e os Desafios Contemporâneos*. Belo Horizonte: Fórum.
- _____; BELCHIOR, Germana Parente Neiva, Dano ambiental na sociedade de risco: uma visão introdutória. In: Leite, José Rubens Morato (Coord.). (2012) *Dano Ambiental na Sociedade de Risco*, São Paulo: Saraiva.
- LEITE, Marcelo. (2000) *Os alimentos transgênicos*. São Paulo: Publifolha.
- LENSEN, Nicholas. (1992) Desafiando o lixo nuclear. In: BROWN, Lester. *Qualidade de vida 1992* – Salve o planeta! São Paulo: Globo.
- LEONARD, H. Jeffrey. Meio Ambiente e pobreza: estratégias de desenvolvimento para uma agenda comum. In: LEONARD, H. Jeffrey (Org.). (1992) *Meio ambiente e pobreza: estratégias de desenvolvimento para uma agenda comum*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- LEUZINGER, Márcia Dieguez. (2009) *Natureza e Cultura* – Unidades de Conservação de Proteção Integral e Populações Tradicionais Residentes. Curitiba: Letra de Lei.
- LIMA, André (Org.). (2001) *Aspectos jurídicos da proteção da Mata Atlântica*. São Paulo: Instituto Sócio Ambiental.
- LIMA, Haroldo. (2008) *Petróleo no Brasil: a situação, o modelo e a política atual*. Rio de Janeiro: Synergia.
- LIMA, Ruy Cime. (1954) *Pequena História Territorial do Brasil (Sesmarias e Terras Devolutas)*. Porto Alegre: Sulina.
- LOMBORG, Bjorn. (2001) *The Skeptical Environmentalist* – measuring the real state of the world. Cambridge: Cambridge University Press.
- LOVELOCK, James. (2010) *Gaia: Alerta Final*. (Trad. Jesus de Paula Assis e Vera de Paula Assis) Rio de Janeiro: Intrínseca.
- LUTZEMBERGER, José. (1976) *Fim do Futuro?* Porto Alegre: Movimento.
- MACHADO, Paulo Affonso Leme. (s/d) Biodiversidade aspectos jurídicos, *Revista de Direitos Difusos*. São Paulo: ADCOAS/IBAP, ano I, v. I, p. 11-17.
- _____. (1991) *Direito Ambiental Brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.
- _____. (2005) *Direito Ambiental Brasileiro*. 13. ed. São Paulo: Malheiros
- _____. (2012) *Direito Ambiental Brasileiro*. 20. ed. São Paulo: Malheiros.
- MACKAY, Fergus. (2002) *A Guide to Indigenous Peoples Rights in The Inter-American Human Rights System*, Copenhagen: IWGIA.
- MACKINNON, John. (1998) *Bornéu*. 3. ed. Rio de Janeiro: Cidade.
- MADDALENA, Paolo. (1990) *Danno Pubblico Ambientale*. Rimini: Maggioli.
- MAIA, Luciano Mariz (Org.). (1993) *Legislação Indigenista*. Brasília: Senado Federal.

MALHEIROS, Tânia; WAMBIER Telmo. (1992) TCU vê perda de dinheiro público em Angra, *O Estado de S. Paulo*, 2/8/1992.

MAMELUQUE, Leopoldo. (1995) *Privatização: Modernismo e Ideologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

MARMORI, Margareth. (1991) A história do conflito, *Ciência Hoje*, Amazônia, dez.

MARTIN, Claude. (1993) Introduction. In: KEMF, Elizabeth (Ed.). *Protecting indigenous peoples in protected areas*. San Francisco: Sierra Club Books.

MARTINEZ, Atecio López (s/d) *Sistemas Sui Genris para la Protección del Conocimiento Tradicional*. Disponível em: <<http://www.comunidadandina.org/taller4/pdf>>.

MARTINS JR., Izidoro. (1979) *História do Direito Nacional*. Brasília: Ministério da Justiça.

MARTINS, Edilson. (1978) *Nossos índios, nossos mortos*. Rio de Janeiro: Codecri.

MAXIMILIANO, Carlos. (1981) *Hermenêutica e aplicação do Direito*. Rio de Janeiro: Forense.

MAYR, Ernst. (1998) *O desenvolvimento do pensamento biológico*. (Trad. Ivo Martinazzo. Revisão técnica de José Maria G. de Almeida Jr) Brasília: UnB.

MAZZILLI, Hugo Nigro. (1998) *A defesa dos interesses difusos*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

_____. (1998) *Introdução ao Ministério Público*. 2. ed. São Paulo: Saraiva.

McCORMICK, John. (1992) *Rumo ao paraíso – a história do movimento ambientalista*. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

McGINN, Anne Platt. (2000) Eliminando gradualmente os poluentes orgânicos persistentes. In: BROWN, Lester R.; FLAVIN, Christopher; FRENCH, Hilary F. *Estado do Mundo 2000*. Salvador: UMA.

MEDAUAR, Odete. (1996) *Direito Administrativo Moderno*. São Paulo: Revista dos Tribunais.

MEIRELLES, Hely Lopes. (2000) *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 18. ed., 1993, 25. ed. atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et al.

_____. Proteção ambiental e ação civil pública. Rio de Janeiro: FGV, *Revista de Direito Administrativo*, 165.

MELATTI, Júlio Cezar. (1993) *Índios do Brasil*. 7. ed. Brasília: Edunb-Hucitec.

MELLO, Celso Albuquerque. (1974) *Curso de Direito Internacional Público*. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, v. 2.

MENCHÚ, Rigoberta (Forward). (1994) In: Davidson, Art. *Endangered Peoples*. (photographs by Art Wolfe, John Isaac), San Francisco: Sierra Club Books.

MENDONÇA, Marcos Cameiro de. (1972) *Raízes da Formação Administrativa do Brasil*. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro/Conselho Federal de Cultura, t. I.

MESGRAVIS, Laina; PINSKY, Carla Bassanazi. (2002) *O Brasil que os europeus encontraram*. São Paulo: Contexto.

MICRO ROBERT – plus. Paris: Robert, 1988.

MIKSELL, Raymond; WILLIAMS, Lawrence. (1992) *International Banks and the Environment – from growth to sustainability: an unfinished agenda*. San Francisco: Sierra Club Books, 1992.

MILARÉ, Édís. (2001) *Direito do Ambiente*. São Paulo: Revista dos Tribunais,

_____. (2005) *Direito do Ambiente*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais

_____. (2009) *Direito do Ambiente*, São Paulo: RT, 6. ed.

MILLER, Peter. (1991) A come back for nuclear power? Our electric future. In: *National Geographic*, v. 180, nº 2, aug.

MONCADA, Luís Cabral. (1988) *Direito Econômico*. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora.

MONTEIRO, Antônio Pinto. (1985) *Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade de indenizar*. Coimbra: Almedina.

MOONSEM, Frans; MAIA, Luciano Mariz (Org.). *Etno-história dos índios Potiguara*. João Pessoa: PRPB/SECPB, 1992.

MORAES, Luís Carlos Silva de. (1999) *Código Florestal comentado – com as alterações da lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605/98*. São Paulo: Atlas.

_____. (2006) *Curso de Direito Ambiental*. 2. ed. São Paulo: Atlas.

MORAES, Rinaldo. (2002) Os grandes projetos na Amazônia. *Gazeta Mercantil*, 28 mar. 2002, edição especial 4º aniversário.

MOREIRA, Iara Vêrocai Dias. (1997) *Vocabulário Básico de Meio Ambiente*. Rio de Janeiro: Petrobras/FEEMA. MOTTA, Ronaldo Seroa. Desafios ambientais da economia brasileira. IPEA: textos para discussão nº 509. Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br/pub/td/t.pdf>>.

MOREIRA NETO, Carlos Araújo. (1988) *Índios da Amazônia – de maioria a minoria (1750 – 1850)*. Petrópolis: Vozes,

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. (1992) *Curso de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Forense.

_____. (1977) *Introdução ao direito ecológico e ao direito urbanístico*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. _____. (2007) *Mutações do Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Renovar.

MYERS, Norman. (1992) Florestas Tropicais. In: LEGGET, Jeremy. *Aquecimento Global. O Relatório do Greenpeace*. Rio de Janeiro: FGV.

NASCIMENTO E SILVA, G. E. do. (1995) *Direito Ambiental Internacional*. Rio de Janeiro: Thex.

NEGRET, Rafael. (1982) *Ecossistema – unidade básica para o planejamento da ocupação territorial*. Rio de Janeiro: FGV.

NIMUENDAJU, Curt. *Mapa Etno-histórico*. Rio de Janeiro: IBGE/Pró-memória, 1987.

NO RECOURSE – *A guide to compensation in the event of a nuclear disaster*. Greenpeace.

NUNES, Antônio de Pádua. *Código de Águas*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1.

O desafio do desenvolvimento sustentável – Relatório do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brasília, 1991.

O GLOBO (2001) Favela já tem 17% da população. *O Globo*, 28 abr. 2001.

O MOGNO KAIAPÓ, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, *Aconteceu*, Não anni. (1987) La responsabilità dell' esercente nucleare. In: GENTILE, Giovanni G. *Lezioni di Diritto dell' energia*. Milano: Giuffrè.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas.

_____. Convenção Sobre Diversidade Biológica.

_____. Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas.

_____. Diretrizes de Bonn.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta da Organização dos Estados Americanos.

_____. Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

_____. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.

_____. Protocolo Adicional à Convenção sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador).

_____. Protocolo de Nagoya.

PERU, Lei Geral do Ambiente Ley nº 28611.

POMPEU, Cid Tomanik. (s/d) Regime Jurídico das Águas Públicas – 1 – *Polícia da Qualidade*. São Paulo: Cetesb.

PONTES DE MIRANDA. (s/d) *Comentários à Constituição da República dos E.U. do Brasil*. Rio de Janeiro: Guanabara Waissmann, Koogan, t. II.

_____. (1953) *Comentários à Constituição de 1946*, v. V.

_____. (1987) *Comentários à Constituição de 1967* (com a emenda nº 1 de 1969). Rio de Janeiro: Forense, t. II.

PONTIFÍCIO CONSELHO DE “JUSTIÇA E PAZ”. *Compêndio de Doutrina Social da Igreja*. São Paulo: Paulinas, 2005.

POPPER, Karl. R. (2006) Em Busca de um mundo melhor, (Trad. Milton Camargo Mota), São Paulo: Martins Fontes.

- POSNER, Richard A. (2004) *Animal Rights. Legal, Philosophical, and Pragmatic Perspectives*, in, Cass R. Sunstein and Martha C. Nussbaum (edited by), *Animal Rights – Current Debates and new Directions*, New York: Oxford University Press.
- PRAKASH, Siddhartha. (1999) Towards a Synergy between Biodiversity and Intellectual Property Rights, *The Journal of World Intellectual Property Rights*, v. 2, nº 5, set.
- PRIEUR, Michel. (1991) *Droit de L'Environnement*. Paris: Dalloz.
- RAMOS, Alcida Rita (1986). *Sociedades indígenas*. São Paulo: Ática,
- Rapport de la Commission des Communautés Européennes à la Conférence des Nations unies sur L'environnement et le développement, Bruxelles, 1992.
- REALE, Miguel. (1993) *Filosofia do Direito*. 15. ed. São Paulo: Saraiva.
- REINACH, Fernando. (2010) *A longa marcha dos grilos canibais, e outras crônicas sobre a vida no planeta terra*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Relatório da Reunião da Comissão Binacional *ad hoc* Brasil – Venezuela. Brasília, datilografado, 1993.
- RÉMOND-GOUILLOUD, Martine. (1989) *Du droit de détruire*. Paris: PUF.
- REZEK, José Francisco. (1984) *Direito dos tratados*. Rio de Janeiro: Forense.
- RIBEIRO, Darcy. (1982) Nosotros Latino-Americanos, *Encontros com a Civilização Brasileira*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. III, nº 11, nº 29.
- RIFKIN, Jeremy. (1999) *O século da biotecnologia – a valorização dos genes e a reconstrução do mundo*. (Trad. Arão Sapiro). São Paulo: Makron Books.
- RIOS, Aurélio Veiga. A situação das terras indígenas no Brasil. Brasília, mimeografado, s/d.
- RIVERO, Jean. (1981) *Direito Administrativo*. Coimbra: Almedina.
- ROBBINS, Paul; HINTZ, John e MOORE, Sarah A. (2014) *Environment and Society – a critical introduction*. Oxford: Wiley Blackwell, 2nd edition.
- ROCHA, Alex Pires. (2010) Comentários aos crimes contra a flora previstos nos artigos 38, 39, 40, 41 e 48 da Lei nº 9.605/98. In: BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo; SILVA, Fernando Quadros. *Crimes Ambientais – Estudos em Homenagem ao Des. Vladimir Passos de Freitas*. Porto Alegre: Verbo Jurídico.
- ROCHA, Lauro L.; LACERDA, Carlos Alberto M. (1983) *Comentários ao Código de Mineração do Brasil*. Rio de Janeiro: Forense.
- RODGERS JR., William H. (1977) *Environmental Law*. St. Paul: West.
- RODOTÁ, Stefano. (1986) *El Terrible Derecho – estudios sobre la propiedad privada*. (Trad. Luis Díez-Picazo). Madrid: Civitas.
- RODRIGUES, Sílvio. (1980) *Direito Civil – Direito das Coisas*. São Paulo: Saraiva, v. 5.
- _____. (2002) *Direito Civil: Parte Geral*. 32. ed. São Paulo: Saraiva, v. 1.
- ROSA, Luiz Pinguelli. (1992) As alternativas energéticas e o novo estilo de desenvolvimento, *O ambiente inteiro – a contribuição crítica da universidade à questão ambiental*. Rio de Janeiro: UFRJ.
- _____; BARROS, Fernando de Souza; BARREIROS, Suzana Ribeiro. (1991) *A Política Nuclear no Brasil*. São Paulo: Greenpeace.
- RYAN, John C. (1992) Conservando a diversidade biológica. In: BROWN, Lester R. *Qualidade de vida 1882 – salve o planeta*. São Paulo: Globo.
- _____. (1992) Conservando a diversidade biológica. In: BROWN, Lester R. *Qualidade de vida 1992 – salve o planeta*. São Paulo.
- SALGAR, Ana Maria Hernández. (2010) *Conocimiento tradicional y bionegocios: la experiencia de Colombia*.
- SALOMON, Marta. (2011) *TCU: apenas 3,7% das multas aplicadas são pagas*. Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/25448_TCU+APENAS+37+DAS+MULTAS+APLICADAS+SAO+PAGAS>.
- SAMPAIO, José Adércio Leite. (2010) Responsabilidade Ambiental e ação civil pública. In: SOARES Jr., Jarbas e ALVARENGA, Luciano José. *Direito Ambiental no STJ*. Belo Horizonte: Del Rey.
- SANTILLI, Juliana. (2005) *Socioambientalismo e novos direitos – proteção jurídica da diversidade biológica e cultural*. São Paulo: Peirópolis.
- SANTILLI, Márcio. (2000) Vitória do Usufruto Indígena. *Os Brasileiros e os Índios*. São Paulo: Senac.
- _____. (1992) Os Direitos indígenas na Constituição Brasileira, Centro Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI, Povos indígenas no Brasil 1987/88/89/90, *Aconteceu Especial*, nº 18, São Paulo.
- SANTOS, Edmilson Moutinho dos; CORREIA, Carlos Augusto de Almeida. Deve a Agência Nacional de Petróleo Explorar Novas Fórmulas Contratuais? Disponível em: <<http://www.ibp.org.br>>.
- SANTOS, Valdir Andrade. (2010) *Poluição Marinha: uma questão de competência, aspectos da Lei nº 9.966, de 28/4/2000*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2. ed.
- SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. (2014) *Princípios do direito ambiental*, São Paulo: Saraiva.
- SCHIERA, Pietro. (1984) Sociedade de “Estados”, de “ordens” ou “corporativas”. In: HESPANHA, Antônio. *Poder e Instituições na Europa do antigo regime*. Lisboa: Calouste Gulbenkian.
- SCHMIDHEINY, Stephan. (1992). *Mudando o Rumo – uma perspectiva empresarial global sobre desenvolvimento e meio ambiente* Rio de Janeiro: FGV.
- SCHOLTEN, Jules. (1994) Revisão independente em AIA nos Países Baixos. In: PARTIDÁRIO, Maria do Rosário; JESUS, Júlio de (Org.). *Avaliação do impacto ambiental*. Lisboa: Centro de Estudos de Planeamento e Gestão Ambiental – CEPGA.
- Selected Environmental Law Statutes – 1991-92*. Educational Edition. St. Paul: West, 1991.
- SHELDON, Jennie Wood; BALICK, Michael. (1998) Ethnobotany and the Search for Balance between Use and Conservation. In: SWANSON, Timothy M. *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation – An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*. Cambridge: Cambridge.
- SHIVA, Vandana. (2001) *Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento*. (Trad. Laura Cardellini Barroso de Oliveira). Petrópolis: Vozes.
- SHOUMATOFF, Alex. (1991) *Qui a tué Chico Mendes?* Paris: Payot.
- SILVA, José Afonso da. (1994) *Direito Ambiental Constitucional*. São Paulo: Malheiros.
- _____. *Direito Ambiental Constitucional*. 5. ed. São Paulo: Malheiros. 2004.
- _____. *Direito urbanístico brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
- SILVA, Orlando Sampaio. O índio perante o direito. In: SANTOS, Sílvio Coelho dos (Org.). *O índio perante o direito – ensaios*. Florianópolis: Ed. UFSC.
- SINGER, Peter (2004) *Libertação Animal* (Trad. de Marly Winckler). Edição revista. Porto Alegre/São Paulo: Lugano Editora.
- SKIDMORE, Thomas E. (1998) *Uma História do Brasil*. (Trad. Raul Fiker). 2. ed. São Paulo: Paz e Terra.
- SMITH, Fraser D. M.; DAILY, Gretchen C.; EHRLICH, Paul R. Human population dynamics and biodiversity loss. In: SWANSON, Timothy M. (Ed.). *The economic and ecology of biodiversity decline – the forces driving global change*. Cambridge: Cambridge University, 1998.
- SOARES, Guido Fernando Silva (2001). *Direito Internacional do Meio Ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades*. São Paulo: Atlas.
- SOARES Jr., Jarbas; ALVARENGA, Luciano José. (2010) *Direito Ambiental no STJ*, Belo Horizonte: Del Rey.
- SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean, (2014) *Imposturas Intelectuais – o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos* (Trad. Max Altman) Rio de Janeiro: Best Bolso.
- SOUZA, Marcelo Gomes de. (1995) *Direito Minerário e meio ambiente*. Belo Horizonte: Del Rey.
- SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. (s/d) O direito envergonhado: o direito e os índios no Brasil. In: GRUPIONI, L. D. Benzi (Org.). *Índios no Brasil*. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura.
- STEIGLEDER, Annelise Monteiro. (2004) Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado.
- STERN, Paul L.; YOUNG Oraw R.; Druckman. Daniel (Coord.). (1993) *Mudanças e agressões ao meio ambiente*. (Trad. José Carlos B. Santos) São Paulo: Makron.
- STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3.652 RR, j. 18/12/2006, Tribunal Pleno, *DJU* 16/3/2007, p. 377.
- STF – RE 300244/SC. Julgamento: 20/11/2001. 1ª Turma. *DJU* 19/12/2001, p. 27.

STF – MS 24184/DF. Tribunal Pleno. *DJU* 27/2/2004, p. 22.

STF – 27623 MC/DF. *DJe*-210, divulg. 5/11/2008, public. 6/11/2008.

STF – MS 24665/DF. Relator p/ acórdão: Min. Cezar Peluso. Tribunal Pleno. *DJU* 6/10/2006, p. 33.

STF – MS 22164/SP – Julgamento: 30/10/1995. Tribunal Pleno. *DJU* 17/11/1995, p. 39206.

STJ. Reclamação nº 17.224/PA.

STJ. SLS 001745.

TÁCITO, Caio. (1986) Poder de polícia e polícia do poder, *Direito Administrativo da Ordem Pública*, Rio de Janeiro: Forense.

TAYLOR, G. Rattray. (1978) *A ameaça ecológica*. São Paulo: Verbo-Edusp.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. (1984) *Processo de conhecimento*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. THOMAS, Keith. (1988) *O Homem e o mundo natural*. São Paulo: Cia. das Letras, 1ª reimpressão.

THOREAU, Henry David. *Life without principle*. Disponível em: <<http://thoreau.eserver.org/life1.html>>. Acesso em: 15 ago. 2007.

THORNTON, Justine; BECKWITH, Silas. (1997) *Environmental Law*. London: Sweet & Maxwell.

TORRES, Ricardo Lobo. (2005) *Curso de direito financeiro e tributário*. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. *Auditoria Operacional em Áreas de Proteção Ambiental*. Rio de Janeiro: TCMRJ, 2010.

TRIGGER, Bruce G. (1992) *Les Indiens, la Fourrure et les Blancs* – Français et Amerindiens en Amérique du Nord. (Trad. Georges Khal) Québec: Boréal/Seuil.

TRINDADE, Gustavo. Parecer nº 312/Conjur/MMA/2004.

TROLLDALEN, Jon Martin. (1992) *International Environmental Conflict Resolution, the role of the United Nations*. Washington: WFED/UNITAR/NIDR.

UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza, PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e WWF – Fundo Mundial para a Natureza. (1991) *Cuidando do Planeta Terra*. São Paulo.

UICN. (1991) *Cuidando do Planeta Terra – Uma Estratégia para o Futuro da Vida*. São Paulo.

UNESCO (2005) The Precautionary Principle World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (Comest), Paris.

VARELLA, Marcelo Dias; FONTES, Eliana; ROCHA, Fernando Galvão. (1999) *Biossegurança & Biodiversidade* – contexto científico e regulamentar. Belo Horizonte: Del Rey.

_____; PLAUTAU, Ana Flávia Barros. *Princípio da precaução*. ESMPU/Del Rey: Belo Horizonte.

VENOSA, Sílvio de Salvo. (2005) *Direito Civil – Responsabilidade Civil*. 5. ed. São Paulo: Atlas, v. 4.

VIEIRA, Roberto Santos. (1990) *Direito ambiental Brasileiro*. Manaus: inédito.

VILLARES, Luiz Fernando. (2009) *Direito e Povos Indígenas*. Curitiba: Juruá.

WAINER, Ann Helen. (1991) *Legislação ambiental do Brasil* (subsídios para a história do Direito Ambiental). Rio de Janeiro: Forense.

WALKER, Gabrielle; KING, Sir David. (2008) *O Tema Quente* – como combater o aquecimento global e manter as luzes acesas. (Trad. Caroline Chang) Rio de Janeiro: Objetiva.

WATSON, James D. (2005) *DNA – O segredo da vida*. (Trad. Carlos Afonso Malferrari) São Paulo: Companhia das Letras.

Webster's unabridged dictionary unabridged edition. 2. ed. Nova York.

WHITEHEAD, Alfred North. (1994) *O conceito de Natureza*. (Trad. Júlio B. Fischer) São Paulo: Martins Fontes.

WIEACKER, Franz. (1980) *História do Direito privado moderno*. Lisboa: Calouste Gulbenkian.

WOLFF, Maria Thereza. A Biodiversidade na Propriedade Industrial, *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, nº 52, maio/jun. 2001.

PERIÓDICOS

CEDI – Centro Ecumênico de Documentação e Informação – Povos indígenas no Brasil – 1987/88/89/90, *Aconteceu especial* nº 18, São Paulo.

Comissão pró-índio de S.P. – Departamento Jurídico – *Informe jurídico*, ano IV, set. 1992, nºs 21 e 22.

Ecologia, *Jornal do Brasil*. Rio de Janeiro, 22 jul. 1991.

Ecologia e desenvolvimento, nº 9, ano 1, p. 41.

Época, 25 dez. 2000.

FUNAI. *Brasil Indígena*. Brasília, ano 1, nº 1, dez. 1993.

A reserva do futuro. *Gazeta Mercantil*, 13 e 14 maio 2000.

Vegetação Natural em SP aumenta após trinta anos, *Gazeta Mercantil*, 3 out. 2002.

Vértice Mondiale su Ambiente e sviluppo, *Il Manifesto del mese*, nº 4, 1992, Roma.

Informativo da Associação dos Juizes Federais – AJUFE, maio 1995.

Ecologia, *Jornal do Brasil*, 19/8/1991.

Jornal do Brasil, 4/4/1992.

Jornal do Commercio, 1/9/1994.

Justiça suspende construção de estradas em aldeias, *Globo*, 3/1/1994.

O Estado de S. Paulo, 2/9/1994.

O Estado de S. Paulo, 13/4/1992.

O Globo, 9/3/1992.

O Globo, 9/3/1992.

O Globo, 10/7/1992.

O Globo, 6/8/1992.

Omissão gera conflitos, *Porantim*, ano XVII, nº 168, set. 1994.

Revista da Procuradoria Geral da República, nº 1, out./nov. 1992.

Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, nº 44, 1992.

Tout sur les écologistes, Libération – collection, Mars 1992, nº 9.

PROCESSOS JUDICIAIS

Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em face de Furnas Centrais Elétricas S/A, Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e União Federal, na 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Proc. 91.297400).

Ação Civil Pública nº 90 – 114 – 5, 7ª Vara Federal de Brasília, Juiz Novély Vilanova da Silva Reis.

ADI 1086 MC/SC – Santa Catarina – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator Min. Ilmar Galvão – j. 1º/8/1994 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno.

ADI 1245/RS – Rio Grande do Sul. Relator Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. *DJU* 26/8/2005, p. 5.

ADI 1245/RS – Rio Grande do Sul. Relator Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. *DJU* 26/8/2005.

ADI 1278 MC/SC – Santa Catarina. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator Min. Marco Aurélio.

ADI 2.068, Relator Min. Celso de Mello, *DJU* 16/5/2003.

ADI 2432/RN – Rio Grande do Norte. Relator Min. Eros Grau Tribunal Pleno. *DJU* 26/8/2005, p. 5. Republ. *DJU* 23/9/2005, p. 7.

ADI 2544 MC/RS. Relator Min. Sepúlveda Pertence Julgamento: 12/6/2002, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. *DJU* 8/11/2002, p. 21.

Agravo de Instrumento nº 94. 01. 06666 – 3/TO TRF da 1ª Região.

Apelação Cível nº 31.078 – MT, Relator Min. Adhemar Raymundo, *DJU* 21/5/1981.

Ministério Público Federal, Inquérito policial nº 78/93, Livro 5; Processo 93.0000501 – 4 (Procuradores da República Carlos Frederico Santos, Franklin Rodrigues da Costa e Luciano Mariz Maia).

MS 21239/DF. Relator Min. Sepúlveda Pertence. Tribunal Pleno. *DJ* 23/4/1993, p. 6920.

Processo no TC – 016.440/91-9, Decisão nº 197/92 – 2ª Câmara, Relator Min. Luciano Brandão Alves de Souza.

RE 286789/RS. Recurso Extraordinário. Relatora Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. *DJ* 8/4/2005, p. 38.

REsp 591948/SP; Recurso Especial. 2003/0176435-1. Relator Min. Luiz Fux. 1ª Turma. *DJU* 29/11/2004.

REsp 628588/SP; Recurso Especial. 2004/0004702-7. Relator Min. Luiz Fux; Relator p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki.

RHC nº 64.476-7-MG, Relator Min. Carlos Madeira, *DJU* 31/1/1986.

STF – RE: 92845/SP – São Paulo. *DJU* 19/9/1980, p. 7206. Relator Min. Cunha Peixoto.

STF – RE-embargos – Embargos no Recurso Extraordinário. 51972. *ADJ*: 14/11/1963, p. 1165. Relator Min. Cândido Motta.

STF, Pet. 3388. Voto do Min. Carlos Ayres de Britto.

STF: HC 82424 QO/RS – Questão de Ordem no *Habeas Corpus*. Relator Min. Moreira Alves; Rel. Acórdão Min. Mauricio Corrêa. Tribunal Pleno. *DJU* 19/3/2004, p. 17.

STJ – REsp – 235773/RJ. 1ª Turma. *DJU* 27/3/2000, p. 76. Relator Min. José Delgado.

TRF – 2ª Região – AG – 118162/ RJ. 1ª Turma. *DJU* 4/10/2004, p. 271. Relator Juiz Carreira Alvim.

TRF da 5ª Região, AC nº 20.978-AL, Relator Juiz Lázaro Guimarães, *DJU* 2/4/1993.

ENDEREÇOS NA INTERNET

<<http://6ccr.pgt.mpf.br/atuacao-do-mpf/acao-civil-publiva/aplicacao-da-convencao-169-na-america-latina>>.

<<http://6ccr.pgt.mpf.br/atuacao-do-mpf/acao-civil-publiva/jurisprudencia-da-cidh-1>>.

<<http://cwanderson.org/wp-content/uploads/2011/11/Philip-K-Dick-The-Minority-Report.pdf>>.

<http://dplf.org/sites/default/files/informe_consulta_previa_2015_web-2.pdf>.

<<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0035&from=PT>>.

<<http://olca.cl/oca/justicia/justicia096.htm>>.

<http://publique.rdc.union.br/revistaalceu/media/alceu_n4_Leopoldi.pdf>.

<<http://redesustentabilidade.org.br/regional/sp/emissoes-de-carbono-no-brasil-atingem-o-maior-valor-desde-2008/>>.

<http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HTM_GMP_2011_eng.pdf?ua=1>.

<<http://www.american.edu/ted/merck.htm>>.

<<http://www.amnestyusa.org/news/news-item/india-landmark-supreme-court-ruling-a-great-victory-for-indigenous-rights>>.

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/02/100216_eua_reatores_ac_np.shtm>

<<http://www.bioamazonia.org.br>>.

<<http://www.biodiversidadla.org/documentos/7788.html>>.

<<http://www.biodiversidadla.org/documentos5.html>>.

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Responsabilidade_Social_e_Ambiental/politica_de_responsabilidade.html>.

<<http://www.brasiloeste.com.br/noticia/1149/soja-transgenica-na-safra-gaucha>>.

<<http://www.cepet.unicamp.br>>.

<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif.htm>.

<http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/f.Protocolo_de_San_Salvador_Ratif.htm>.

<<http://www.comciencia.br/reportagens/transgenicos/trans07.htm>>.

<<http://www.comunidadandina.org/normatva/dec/d391.htm>>.

<<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-030-08.htm>>.

<<http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/por7.pdf>>.

<<http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/brazil/warfare-polonoroeste>>.

<<http://www.dicionarioweb.com.br/dendroclasta/>>.

<<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Povos-Ind%C3%A9genas/declaracao-das-nacoes-unidas-sobre-os-direitos-dos-povos-indigenas.html>>.

<<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5257778,00.html>>.

<<http://www.eletronuclear.gov.br/tecnologia/index.php?idSecao=2>>.

<<http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting>>.

<http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_portuguese_2013.pdf>.

<<http://www.estadao.com.br/ext/ciencia/arquivo/mata>>.

<http://www.fedcourt.gov.au/judgments/judgments_decis02.html>.

<<http://www.foundingdocs.gov.au/places/>>.

<<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao>>.

<<http://www.funai.gov.br/index.php/todos-ouvidoria/23-perguntas-frequentes/97-pergunta-3>>.

<<http://www.genéricos.med.br/faq.html#10>>.

<<http://www.georgetown.edu/pdba/constitutions/bolivia/bol95.html>>.

<<http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/colombia.html>>.

<<http://www.georgetown.edu/pdba/constitutions/venezuela/ven1999htm>>.

<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title-42/html/USCODE-2011-title-42-chap103.htm>>.

<<http://www.humboldt.org.co/biocomercio/html/dpi-biodiv.htm>>.

<http://www.iadb.org/sds/ind/ley/bolivia/bolivia_var1.htm>.

<http://www.iadb.org/sds/ind/ley/ecuador/ecuador_var1.htm>.

<http://www.iadb.org/sds/ley/peru/peru_var14.htm>.

<<http://www.icip.lawnet.com.au/html/part2.htm>>.

<<http://www.icmbio.gov.br/brasil/MA/municipios/barreirinhas/pama-lencois-maranhenses>>.

<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES>.

<<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/hall.htm#author>>.

<<http://www.inbio.ac.cr/es/pdb>>.

<http://www.ipcc.ch/publications_and_data/>.

<<http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3267>>.

<<http://www.jfpr.gov.br/consultas/asp>>.

<<http://www.kraho.org/projetos.html>>.

<<http://www.mma.gov.br/port/se/PESQUISA/valores.html>>.

<<http://www.mre.gov.br>>.

<http://www.palmares.gov.br/?page_id=88>.

<<http://www.pr.gov.br/iap/petro01.html>>.

<http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=o-que-e#consulta>.

<<http://www.unicamp.br/~jmarques/cursos/1998-hg-022/politica.doc>>.

<<http://www.wipo.int/globalissues/tk/report/final/pdf/part2.pdf>>.

<http://www2.uol.com.br/linguaportuguesa/valeoescrito/ve_paubrasil.htm>.

<<http://ypade.org/portal/index.php/2014-07-27-18-22-09>>.

<<http://zeroanthropology.net/2009/03/12/frantz-fanon-concerning-violence/>>.

<<https://www.cbd.int/abs/bonn>>.

<www.knowledge-basket.co.nz/waitangi/about/about.html>.

<www.law.unionn.edu>.

VER

Ação Ordinária. Procedimento comum ordin. nº 2007.70.05.002039-8/PR.

Apelação Cível nº 2007.70.05.002039-8/PR. TRF 4. Processo AC 200770050024999.

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Processo AG 200904000028300AG.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região. RSE-200903990413835. Relator Juiz Henrique Herkenhoff. *DJF* 3, CJ1: 13/5/2010, p. 172.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ACR 200334000196408. Relator Juiz Federal Saulo José Casali Bahia (conv.). 3ª Turma. *DJ*: 18/8/2006, p. 30.